MARMARA HUKUK YORUMU

EŞYA HUKUKU

CİLT: IV/1

GİRİŞ, TEMEL KAVRAM VE İLKELER

Yazar: Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA

ZİLYETLİK

Yazar:
Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA

TAPU SİCİLİ

Yazarlar:
Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA Doç. Dr. Murat TOPUZ

Editör:
Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA

Genişletilmiş 3. Baskı

SEÇKİN | Hukuk
Ankara 2019

3. Baskıya Önsöz

Medeni Hukukun yeni dönemde, yeni bilimsel gelişimler ve bakışlar ışığında incelenmesine ve bilimsel olarak yorumlanmasına yönelik, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku C. I, II ve III ve Medeni Hukuka Giriş, Temel Kavramlar ve Başlangıç Hükümleri kitaplarını yayımlamıştık. Bu yayınlarımızı "Marmara Hukuk Yorumu" başlığı altında toplayıp, tamamlamayı ve genişleterek yenilemeyi amaçlamaktayız.

Türk Eşya Hukuku'nun, Eşya Hukuku'nun temel kavramları ve ilkeleri ile zilyetliği ele alan temel eserlerin azlığı ve bazılarının yenilenmiş olsa da eserlerin 4721 sayılı TMK öncesi dönemde yazılmış olması, özellikle zilyetliğin özel ve güncel bilimsel görüşler kapsamında yeni bir bakış açısıyla incelenmesi gereği, Türk Medeni Kanunu'nun dördüncü kitabının yeniden yorumlanması zorunluluğunu doğmuştur.

Bu kitap, bir yandan öğrencilerin kaynak ve kitap ihtiyacını karşılamayı diğer yandan doktrin ve uygulama için TMK m.1 son fıkrada ifade edilen bilimsel yardımcı kaynak oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Eşya Hukuku C. I, II ve III kitaplarını yayımlamıştık. Şimdi ise söz konusu üç ciltlik kitabı daha da genişleterek tek cilt halinde, Marmara Hukuk Yorumu'nun IV/1 cildi olarak yayımlıyoruz.

Bu eserimizi Marmara Hukuk Yorumu'nun IV/2 cilti olarak "Mülkiyet Hukuku" isimli eserimiz takip edecek olup, kısa bir süre sonra yayımlamayı hedeflemekteyiz.

Eşya Hukuku Cilt IV/1 olarak yayımladığımız bu eserde, gerek İsviçre gerek Alman gerekse Türk hukuk literatüründe yeni yayımlanan eserlere atıflar yapılmış; zilyetlik ve tapu siciline ilişkin olarak yeni Yargıtay içtihatları eklenmiş, en önemlisi de tapu sicil hukuku, bu kapsamda elektronik tapu sicili kitabımıza işlenmiştir.

Belirtelim ki, teknolojik ve elektronik gelişmelerin, hukuka, hukukun temel kurumlarına ve ilkelerine, bu kapsamda taşınmaz hukukunun ve onu düzenleyen tapu sicil sistemine yansıması, onların yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Eserimizde, Türk tapu sicil sisteminin elektronik tapu sicil sistemine geçişine ilişkin hukuki ve diğer altyapıyı sağlayabilmesi için Kıta Avrupası hukuk sistemi içinde yer alan mehaz İsviçre, Almanya ve

Avusturya elektronik tapu sicil hukukunun, Türk tapu sicili ile mukayeseli olarak incelenmesi, değerlendirilmesi ve Türk tapu sicil hukuku için öneriler getirilmesi de amaçlanmıştır. Bu bölümde "Elektronik Tapu Sicil Hukuku" (İstanbul 2019) kitabındaki açıklamalar temel alınmıştır. Elektronik tapu sicilinin mukayeseli hukuktaki gelişimi ve hukuki düzenlemeleri için bu kitaba başvurulabilecektir.

Bu kitabın yayına hazırlanmasına katkıda bulunan Dr. Öğr. Üyesi İpek ÇEVİK'e, Arş. Gör. Pelin ÇAVDAR'a ve Arş. Gör. İsmail DEDE'ye teşekkür ederiz.

Ayrıca kitabı yayınlayan Seçkin Yayıncılık sahibi Koray SEÇKİN'e teşekkür ederiz. Bu vesile ile Av. Mutlu DİNÇ başta olmak üzere yayınevi çalışanları Murat ÇETİNKAYA, Ahmet ATAMAN, Akif ÇALIŞICI ve kitabın dizgisini gerçekleştiren İlhan EROĞLU'na da teşekkür ederiz.

Şile, 29 Ekim 2019

Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA

İçindekiler

3. Baskıya Önsöz 7

Kısaltmalar 39

Birinci Bölüm
GİRİŞ - TEMEL KAVRAM VE İLKELER

§ 1. EŞYA HUKUKUNUN YERİ, KAYNAKLARI VE KONUSU

I. EŞYA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE ÖZEL HUKUKTAKİ YERİ 47

A. Genel Olarak 47

B. Eşya Hukukunun Kayrakları 47

1. Temel Kaynaklar 47

a. Anayasa ve Diğer Kamu Kuralları 47

b. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu 48

c. Özel Kanunlar 48

d. Tüzük ve Yönetmelikler 49

e. Temel Kavramlar ve Eşya Hukukunun Genel İlkeleri 49

2. Tamamlayıcı Kaynaklar 50

a. Örf ve Adet Kuralları 50

b. Hâkimin Yarattığı Hukuk Kuralları 50

3. Yardımcı Kaynaklar 50

a. Doktrin 50

b. Yargı Kararları 51

C. Eşya Hukukunun Malvarlığı Hukukunun Bir Bölümünü Oluşturması 52

D. Eşya Hukukunun Sınırlı Olarak İrade Özerkliğine İmkân Tanıması 53

II. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU 53

A. Kişinin Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyetini Düzenlemesi 54

B. Eşya Hukukunun, Eşya Üzerindeki Hakkın Kurulmasını ve Sona Ermesini Düzenlemesi 54

C. Eşya Hukukunun, Eşya Üzerinde Kurulan Hakları ve Bu Hakların Sınırlarını Belirlemesi 55

D. Eşya Hukukunun, Eşya Üzerinde Birden Fazla Hak Sahibi Olan Kişilerin Eşyadan Yararlanmasını ve Onu Yönetimini Düzenlemesi 55

1. Eşya Hukukunun Kişilerin Birlikte Mülkiyetinde Bulunan Eşyadan Yararlanılmasını ve Yönetimini Düzenlemesi 55

2. Eşya Hukukunun Sınırlı Ayni Hak Sahibinin Yükümlenen Eşya Üzerindeki Yararlanmasını Düzenlemesi 56

§ 2. EŞYA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

I. EŞYA 57
A. Kavram 57
B. Unsurları 58
1. Kişilik Değerleri Dışında Varlık Olması (Kişilik Dışılık) 58
a. Gerçek Kişinin Bedeni ve Uzuvları 58
b. Bedenden Ayrılan Uzuvlar (Organlar) 58
c. İnsan Cesedi ve Parçası 59
d. Protez 60
e. Üreme Hücreleri veya Embriyo 60
f. Hayvan 63
2. Ekonomik Bir Değeri Olan Tanımlanabilir Belirli Bir Maddi Varlık Olması 64
a. Belirli Maddi Bir Varlık (Belirlilik) 64
aa. Kural 64
bb. İstisnalar 68
aaa. Enerji ve Doğal Güçler 68
bbb. Kanunla Belirlenmiş Bazı Haklar 69
(1). Bağımsız ve Sürekli Haklar 69
(2). Bağımsız Bölümler 69
(3). Başkasına Devredilebilen Hak ve Alacaklar 69
b. Tanımlanabilir Maddi Bir Varlık (Tanımlanabilirlik) 70
aa. Basit Eşya 71
bb. Birleşik Eşya 72
cc. Birlikte Eşya 72
dd. Eşya Topluluğu 72
aaa. Malvarlığı (Hukuki Eşya Birliği) 72
bbb. Fiili Eşya Birliği 74
ccc. Ekonomik Eşya Birliği: Eklenti 74
c. Ekonomik Bir Değeri Olan Maddi Bir Varlık (Ekonomik Değerlilik) 74
3. Maddi Varlık Üzerinde Hukuki Olarak Hâkimiyete Elverişli Olmalı (Edinmeye Elverişlilik) 75
C. Çeşitleri 76
1. Özel Mülkiyete Konu Eşya - Kamu Mülkiyetine Konu Eşya 76
a. Kamu Malları 76
aa. İdarenin Kamu Malları 78
bb. Genel Mallar 79
cc. Kamu Finans Malları 79
b. Diğer Kamu Mülkiyetine Tabi Mallar 80
aa. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi 80

bb. Yabancı Ticari Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi 81
cc. Yabancı Sermayeli Ticari Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi 82
2. Taşınır Eşya – Taşınmaz Eşya 84
3. Misli Eşya - Misli Olmayan Eşya 86
4. Parça Eşya – Çeşit (Cins) Eşya 87
5. Tüketilebilen Eşya – Tüketilemez Eşya 87
6. Bölünebilen Eşya – Bölünemeyen Eşya 89
7. Sahipsiz Eşya 90
II. AYNİ HAK 90
A. Kavram 90
1. Ayni Hak ve Ayni İşlem Tanımı 90
2. Ayni Hakkı Açıklayan Görüşler 91
a. Hâkimiyet Görüşü 91
b. Kişici (Şahısçı) <*erga omnes*> Görüş 91
c. Karma Görüş 92
d. Düzenleme Görüşü 92
3. Ayni Hakkın Çifte Yapısal Olgusu 92
a. Eşya Üzerinde Doğ-udan Hâkimiyet Vermesi (Amaçsal Olgu) 93
b. Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi (Mutlak Hak – Normatif Olgu) 94
B. Niteliği 95
1. Ayni Hakkın Bir – Subjektif- Hak Olması 95
2. Mutlak Hak Niteliğinde Olması (Mutlaklık İlkesi) 95
a. Genel Olarak 95
b. Diğer Haklardan Ayrılması 96
aa. Diğer Mutlak Haklardan 96
bb. Nispi Haktan, Özellikle Alacak Hakkından 97
aaa. Genel Olarak 97
bbb. Ayni Hakkın Alacak Hakkından Farkları 97
ccc. Ayni Hakkı ile Alacak Hakkı Ayrımının Sonuçları 98
(1). Unsurları ve Hakka Etkileri Yönünden 98
(2). Korunması Yönünden 99
(3). İcra-İflas Hukuku Yönünden 99
c. Eşyaya Bağlı Haktan Ayrılması 100
aa. Kavram 100
bb. Niteliği 101
cc. Karakteristik Olguları ve Bunlar Arasındaki İlişki 102
aaa. Genel Olarak 102
bbb. Eşyaya Bağlı Borcun Nispi Niteliği 103

ccc. Eşyaya Bağlı Hakkın Nispi Niteliği 104
(1). Eşya Hukukunun Genel İlkelerinin Uygulanması 104
(2). Eşyaya Bağlı Borcun Konusunu Olumlu Edim Oluşturması 104
dd. Çeşitleri 104
aaa. Kanundan Doğan Eşyaya Bağlı Borç 104
bbb. Hukuki İşlemden Doğan Eşyaya Bağlı Borç 106
d. Zilyetlikten Ayrılması 107
3. Eşya Üzerindeki Hak Olan Ayni Hakkın Diğer Nitelikleri 107
a. Eşya Üzerindeki Hakkın Tipik Yapısını Yansıtması 107
b. Malvarlığı Hakkı Niteliği 107
c. Asli Hak Niteliği 108
d. Ayni Hakkın Tekelci (İnhisari) Niteliği 108
4. Çeşitleri: Ayni Hakkın Kapsamına Göre: Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Haklar 108
a. Genel Olarak 109
b. Mülkiyet Hakkı ile Sınırlı Ayni Hak Hakları Arasındaki İlişkiye İlişkin Görüşler 109
aa. Bölünme Görüşü 109
bb. Yükleme Görüşü 109
c. Tam Hâkimiyet Veren Hak: Mülkiyet 110
d. Sınırlı Hâkimiyet Veren Haklar: Sınırlı Ayni Haklar 111
aa. Genel Olarak 111
bb. Ayni Hakkın Konusuna Göre 111
cc. Eşya Üzerindeki Yetkiye Göre 112
aaa. İrtifak Hakları 112
(1). Yararlanma Yetkisinin Kapsamı Açısından 112
(2). Yararlanma Yetkisinin Tarzı Açısından 113
(3). Hak Sahibinin Tayini Açısından 114
(a). Kişiye Bağlı İrtifaklar 114
(b). Eşyaya Bağlı İrtifaklar 117
(c). Diğer İrtifaklar 118
bbb. Rehin Hakları 118
(1). Taşınmaz Rehni 119
(a). İpotek 120
(b). İpotekli Borç Senedi 121
(c). İrat Senedi 122
(2). Taşınır Rehni 122
(a). Teslime Bağlı Rehin 123
(b). Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Rehin 124
(c). Hapis Hakkı 124
ccc. Taşınmaz Yükü 126
dd. Sınırlı Ayni Hakların İçeriğine Göre Çeşitleri: Yararlanma Hakları – Ayni Teminat (Paraya Çevirme) Hakları 126
aaa. Yararlanma Hakkı 127

bbb. Ayni Teminat (Paraya Çevirme) Hakkı 127
(1). Eşya Sahibinin Tayinine Göre 127
(2). Hak Sahibini Belirlemeye Göre 128
(a). Eşyaya Bağlı Ayni Haklar 128
(b). Kişiye Bağlı Ayni Haklar 128
(c). Eşyaya veya Kişiye Bağlı Sınırlı Ayni Haklar 129
(d). Alacağa Bağlı Ayni Haklar 129

§ 3. EŞYA HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ

I. GENEL OLARAK 131

II. ALENİYET İLKESİ 132

A. Aleniyet İlkesi (Kamuya Açıklık İlkesi) 132

B. Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları 133

1. Genel Olarak 133

2. Taşınırlarda Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları: Zilyetlik, Siciller 134

a. Zilyetlik 134

b. Siciller 134

aa. Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Devir Sözleşmesi Sicili 135

bb. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Sicili 135

cc. Hayvan Rehni Sicili 135

dd. Gemi Sicili 136

ee. Uçak Sicili 137

ff. Maden Sicili 137

gg. Kamuya Açık Yerlerin İşletilmesinden Doğan Kamu Borçları İçin Bu Yerlerdeki Eşya Üzerindeki Rehin 137

3. Taşınmazlarda Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları: Tapu Sicili, Kat Mülkiyeti Sicili 137

a. Genel Olarak 137

b. Tapu Sicilinin Etkisi 138

aa. Tapu Sicilinin Olumsuz (Kurucu) Etkisi 138

bb. Tapu Sicilinin Olumlu (Maddi) Etkisi 138

C. Aleniyet İlkesinin Etkisi 139

1. Genel Olarak 139

2. Hak Karinesi Etkisi 139

3. Taşınmazlarda Aleniyet İlkesinin Yansımaları ve Etkileri 140

a. Taşınmazlarda Sınırlı Açıklık İlkesi 140

aa. Genel Olarak 140

bb. İnceleme ve Örnek Alma Hakkı 140

cc. Elektronik Ortamda Verilere Erişim Hakkı 142

dd. Kaydın Herkesçe Bilindiği İlkesi 142

ee. Kaydın İçeriğinin Doğru Olduğuna Kanıt Oluşturması İlkesi 142
b. Taşınmazların Tapu Siciline Kayıt İlkesi 142
c. Ayni Hakların Tescili İlkesi 143
aa. Tescille Kazanım İlkesi 143
aaa. Mutlak Tescil İlkesi 143
bbb. Nispi Tescil İlkesi 144
bb. Tescil İçin Talep Zorunluluğu 144
d. Sebebe Bağlılık İlkesi 145
aa. Genel Olarak 145
bb. Sebepte Şekil Zorunluluğu 146
e. Tescilde Öncelik İlkesi 148
f. Tescilin Hakkın Sahibini ve İçeriğini Belirlemesi Etkisi (Tescilin Hakkın İçeriğini Belirleme İlkesi) 148
g. Tapu Siciline Güven (Maddi Aleniyet) İlkesi 148
4. Taşınırlarda Aleniyet İlkesinin Yansımaları ve Etkileri 149
a. Zilyetliğin Olumsuz (Kurucu) Etkisi ve Olumlu (Maddi) Etkisi 149
aa. Zilyetliğin Olumsuz (Kurucu) Etkisi 149
bb. Zilyetliğin Olumlu (Maddi) Etkisi 149
b. Taşınırlarda Teslim İlkesi 149

III. İYİNİYETLİ KAZANIMLARIN KORUNMASI İLKESİ 150

A. Genel Olarak 150
B. Taşınmazlarda 151
C. Taşınırlarda 151

IV. TİPE BAĞLILIK (*NUMERUS CLAUSUS*) İLKESİ VE TİPİN KAPSAMININ BELİRLİLİĞİ İLKESİ 152

A. Genel Olarak 152
B. Tipe Bağlılık (*Numerus Clausus*) İlkesi 153
1. Genel Olarak 153
2. Tipe Bağlılık İlkesine Aykırılık 154
C. Tipin Kapsamının Belirliliği İlkesi 155
1. Genel Olarak 155
2. Tipin Kapsamının Belirlenmesi İlkesine Aykırılık 156

V. BELİRLİLİK (MUAYYENLİK) İLKESİ 157

A. Kural 157
B. Rehinde Belirlilik İlkesi 158

VI. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ 159

A. Genel Olarak 159

B. Kazandırma ve Kazandırma İşlemi 159
C. Kazandırma İlkesi (Sistemi): Teslim ve Tescil İlkesi (Sistemi) 161
D. Kazandırmanın Hukuki Sebebi 161
1. Hukuki Sebep (Causa) Kavramı 161
2. Hukuki Sebep Çeşitleri 162
3. Kazandırma İşlemin Sebebe Bağlılığı (İlliliği) veya Soyutluğu 162
E. Borçlandırıcı İşlem ve Tasarruf İşlemi 163
1. Borçlandırıcı İşlem 163
2. Tasarruf İşlemi 164
a. Kavram 164
b. Tasarruf İşlemlerinde Tasarruf Yetkisi Olgusunun Zorunluluğu 165
c. Tasarruf İşlemlerinin Hukuki Olguları 165
aa. Tasarruf İşleminden Önce Mevcut Bir Malvarlığı Hakkının Olması 165
bb. Tasarruf İşleminden Sonra Hakta Meydana Gelmiş Bir Sonuç (Etki) Gerçekleşmesi 165
3. Borçlandırıcı İşlemin Tasarruf İşleminden Farkları 166
4. Borçlandırıcı İşlemlerin ve Tasarruf İşlemlerinin Etkisi 166
a. Genel Olarak 166
b. Sözleşmenin Hakka Etkisinde Sistemler: Ayrılık İlkesi (Sistemi) 166
aa. Birlik İlkesi (Sistemi) 167
bb. Ayrılık İlkesi (Sistemi) 167
F. Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı veya Soyutluğu 168
1. Genel Olarak 168
2. Tasarruf İlkesinin Sebebe Bağlılığının Uygulama Alanları 170
a. Taşınmaz Mülkiyetini Geçiren Tasarruf İşlemleri 170
b. Taşınır Mülkiyetini Geçiren Tasarruf İşlemleri 170
c. Diğer Uygulama Alanları 171
d. Ayrımın Sonuçları: Bağlayıcı Temel (Borçlandırıcı) İşlem Olmadan Geçerli Tasarrufun Olmadığı 172
aa. Hukuki İşlemin (Sebebin) Geçersizliğinde Uygulanması 172
aaa. Genel Olarak 172
bbb. Hukuki Sonuçları 172
bb. Hukuki İşlemin Sona Erdirilmesinde Uygulanması 173
cc. Soyutluk İlkesi ile Hukuki Sonuçlarının Karşılaştırılması 173
VII. KATILMA (İLTİHAK) VEYA BAĞLANMA İLKESİ 174
A. Kural: Asıl Şeye Katılanın veya Bağlı Kılınan Şeyler Asıl Şeyin Hukuki Rejimine Tabi Olması 174
1. Genel Olarak 174

2. Katılma İlişkisi: Bütünleyici Parça 174
3. Bağlanma İlişkisi: Eklenti 175
B. Hukuki Sonuçları 175
1. Mülkiyet Hakkının Kapsamı Bakımından 176
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı Bakımından 176
3. Rehnin Kapsamı Bakımından 176
C. İstisnaları 176
VIII. ZAMAN İTİBARI İLE ÖNCELİK İLKESİ 176
A. Kural: Zaman İtibarı ile Öncelik İlkesi 176
B. Uygulama Alanı 177
1. Genel Olarak 177
2. Rehin Hakkında Uygulanması 177
3. Taşınırlarda Zaman tibarı ile Öncelik İlkesi 179
4. Taşınmazlarda Zaman İtibarı ile Öncelik İlkesi 179
C. İstisna: Derece Sistemi 180

İkinci Bölüm
ZİLYETLİK

§ 4. GENEL OLARAK ZİLYETLİK

I. ZİLYETLİĞİN HUKUKİ OLGU OLARAK YERİ VE FONKSİYONU 183
II. YASAL DÜZENLENMESİ 185
III. İNCELEME SİSTEMATİĞİMİZ 185

§ 5. ZİLYETLİK KAVRAMI

I. GİRİŞ 187
A. Genel Olarak 187
B. Terim 187
C. Tarihi Gelişimi 187
II. TANIM 188
III. KONUSU 190
IV. HUKUKİ NİTELİĞİ 191
A. Hak Görüşü 192
1. Ayni Hak Görüşü 192

2. Nispi Hak Görüşü 192
B. Hukuki Durum Görüşü 193
V. UNSURLARI 194
A. Temel Görünüm Şekli: Eşya Zilyetliği 194
1. Fiili Hakimiyet 194
a. Genel Olarak 194
b. Fiili (Maddi) Etki 195
c. Mekansal Fiili (Maddi) İlişki 195
d. Maddi (Fiili) Mekansal İlişkinin Sürekliliği 196
e. Fiili Hakimiyetin Görünürlüğü 197
2. Hâkimiyet İradesi 198
3. Niteliği 200
a. Doğal İrade 200
b. Genel İrade 200
c. Özel Durumlar 201
B. İstisnai Görünüm Şekilleri 201
1. Hak Zilyetliği 201
a. Kavram 201
b. Hukuki Olguları 202
aa. Taşınmaz Üzerine İrtifak Hakkı veya Taşınmaz Yükünden Doğan Bir Hak Olmalı 202
bb. Hak Fiilen Kullanılmalı 203
2. Hukuki Sonucu 204
3. Fiktif (Sanal) Zilyetlik 204
a. Mirasçıların Zilyetliği 204
b. Bulunmuş Eşyanın Teslim Edildiği Kişilerin Zilyetliği 205
C. Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi 205
1. Mülkiyetten 205
2. Hayvan Bulunduran ve İşletenden 206
3. Hizmet Zilyedinden 206
a. Genel Olarak 206
b. Zilyet Sahibine Yardım İlişkisinde Talimata Bağlılık 207
c. Talimata Bağlılık İlişkisinin Görünürlüğü 208
d. Kavram 209
e. Zilyetlikten Ayırt Edilmesi 209
f. Organın Zilyetliği ve Hizmet Zilyetliği 211
g. Banka Kasa Sözleşmesinde 212
VI. FONKSİYONLARI 213
A. Toplumsal Düzeni ve Güvenliği (Huzuru) Sağlama Fonksiyonu 213
1. Huzur Fonksiyonu 213

2. Huzur Fonksiyonunu Açıklayan Görüşler 214
a. Huzur Teorisi 214
b. Süreklilik Teorisi 214
c. Görüşümüz 214
3. Hukuki Koruma Fonksiyonu 215
B. Aleniyeti Sağlama Fonksiyonu 215
1. Hakkı Kurma Etkisi 216
2. Hakkı Zamanaşımı ile Kazandırma Etkisi 216
3. Karine Etkisi 216
4. Güvenin Korunması Etkisi 216

§ 6. ZİLYETLİK ÇEŞİTLERİ

I. GİRİŞ 217
II. DOLAYLI ZİLYETLİK - DOLAYSIZ ZİLYETLİK 217
A. Genel Olarak 217
B. Çeşitleri 218
1. Dolaysız Zilyetlik 218
2. Dolaylı Zilyetlik 219
C. Hukuki Sonuçları 220
1. Zilyetliğin Korunmasında 220
2. Taşınır Mülkiyetinin Zamanaşımı ile Kazanımında 220
3. Kaybedilen Eşyada 221
III. BASİT ZİLYETLİK - KADEMELİ ZİLYETLİK 221
A. Basit (Yalın) Zilyetlik 221
B. Kademeli Zilyetlik 222
1. Genel Olarak 222
2. Kademeli Geçerli Katılım İlişkisi ve Zilyetliğe Katılım İradesi 223
3. İkili Kademenin Çeşitleri 225
a. Asli Zilyetlik 225
b. Fer'i Zilyetlik 225
c. Başkası İçin Zilyet 226
4. Hukuki Sonuçları 227
a. Temel Sonuç: Asli Zilyedin Fiili Hakimiyeti Sona Erse Bile Fer'i Zilyetle Birlikte Zilyet Olması (Fiksiyon Ziyet) 227
b. Eşler Arasında 227
c. Ön Mirasçı - Art Mirasçı 228
d. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinde 228

IV. KENDİSİ İÇİN ZİLYET - BAŞKASI İÇİN ZİLYET 228
A. Kendisi İçin Zilyet 228
1. Genel Olarak 228
2. Ayni Hak (Malik) Sahibi Sıfatıyla Zilyet - Başka Sıfatla Zilyet 229
B. Başkası İçin Zilyet 229
V. BÜTÜN (TAM) ZİLYET – KISMİ ZİLYET 229
VI. HAKKA DAYANAN ZİLYET – HAKSIZ ZİLYET 230
A. Hakka Dayanan Zilyet 230
B. Haksız Zilyet 231
1. Genel Olarak 231
2. Çeşitleri 231
a. İyiniyetli Haksız Zilyet 232
b. Kötüniyetli Haksız Zilyet 232
VII. TEK BAŞINA ZİLYETLİK – BİRLİKTE ZİLYETLİK 232
A. Tek Başına Zilyetlik 232
B. Birlikte Zilyetlik 232
1. Genel Olarak 232
2. Ayrılması ve Mülkiyet Çeşitleriyle Olan İlişkisi 233
3. Çeşitleri 234
a. Elbirliği (İştirak Halinde) Zilyetlik 234
b. Paylı (Müşterek) Zilyetlik 234
c. Yan Zilyet 235
4. Hukuki Sonuçları 235

§ 7. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ

I. GENEL OLARAK 237
II. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 238
A. Zilyetliği Kazanma Yolları 238
1. Genel Olarak 238
2. Aslen Kazanma 240
a. Kavram 240
b. Hukuki Olguları 240
aa. Objektif Unsur 241
bb. Subjektif Unsur: Aslen Kazanma (Hâkimiyet) İradesi 241
c. Zilyetliği Haklı Aslen Kazanma – Zilyetliği Haksız Aslen Kazanma 242

3. Devren Kazanma 242
a. Kavram 242
b. Zilyetliğin Devri ile Mülkiyetin Devri Arasındaki İlişki 243
c. Çeşitleri 245
aa. Genel Olarak 245
bb. Eşyanın Teslim ile Zilyetliğin Kazanımı 246
aaa. Genel Olarak 246
bbb. Çeşitleri 246
(1). Hazırlar Arasında Devir 246
(a). Eşyanın Teslimi 247
(b). Eşyada Hâkimiyeti Sağlayacak Araçların Teslimi 247
(2). Tarafların Zilyetliğin Teslimle Devrinde Uzlaşması 248
(a). Zilyetliğin Teslimle Devrinde Anlaşma 248
(b). Zilyetlik Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 250
(c). Üçüncü Kişi Yararına Bağışta Bağışlananın Zilyetliği 250
(3). Hazır Olmayanlar Arasında Devir (Temsilciye Teslim) 250
(a). Genel Olarak 250
(b). Nitaliği 251
ccc. Hukuki Sonucu 253
(1). Zilyet Temsilcisi Doğrudan Temsilci İse 254
(2). Zilyet Temsilcisi Dolaylı Temsilci İse 254
(3). Yetkisiz Zilyet Temsilcisi 255
(4). Vekaletsiz İşgörenin Temsili 255
cc. Eşyanın Teslimi Olmaksızın Zilyetliğin Kazanımı (Zilyetlik Sözleşmesi ile Zilyetliğin Kazanımı) 255
aaa. Genel Olarak 255
bbb. Zilyetlik Sözleşmesi 257
(1). Genel Olarak 257
(2). Sözleşme Niteliği 257
(3). Tarafların İradi Temsili 258
(4). Zilyetlik Sözleşmesinin Sebep İşlemden Soyutluğu 259
(5). Çeşitleri 260
(a.). Zilyetliğe Açık Durumunun Devri 260
(aa). Kavram 260
(bb). Hukuki Olguları 262
(aaa). Devredenin Eşya Üzerinde Doğrudan Zilyet Olması 262
(bbb). Üzerinde Zilyetlik Kurulabilmeye Elverişli Açık Eşya Olmalı 262
(ccc). Zilyetlik Sözleşmesi 262
(cc). Hukuki Sonucu 263
(b). Kısa Elden Zilyetliğin Devri 264
(aa). Kavram 264
(bb). Hukuki Olguları 265
(aaa). Zilyetliği Kazanacak Olanın Hâlihazırca Zilyet Olması 265
(bbb). Kısal Elden Zilyetliğin Devri Sözleşmesi 265
(cc). Hukuki Sonuçları 265

dd. Hükmen Teslim ... 266
aaa. Genel Olarak ... 266
bbb. Kavram ... 267
ccc. Hukuki Olguları ... 268
(1). Devrecenin Dolaysız Zilyet Kalması ... 268
(2). Özel Hukuki İlişki ... 268
(3). Somut Hükmen Teslim ... 270
(4). Uygulama Alanı ... 270
(5). İspatı ... 271
ddd. Hükmen Teslim Sözleşmesi ... 271
(1). Genel Olarak ... 271
(2). Zilyetliğin Devredilmesine İlişkin Sözleşme: Zilyetliğin Hükmen Teslimi Sözleşmesi ... 272
eee. Hukuki Sonuçları ... 273
fff. Özel Durumlar ... 273
(1). Elden Bağışlama ... 273
(2). Teslim Şartlı Rehin ... 274
(a). Genel Olarak ... 274
(b). Hükmen Teslimle Kanuna Karşı Hile ... 274
ee. Zilyetliğin Havalesi ... 275
aaa. Genel Olarak ... 275
bbb. Kavram ... 276
ccc. Hukuki Olguları ... 277
(1). Dolaylı Zilyet Olunan Bir Eşyanın Devri Söz Konusu Olmalı ... 277
(2). Üçüncü Kişinin Özel Bir Hukuki İlişkiye Dayanarak Eşyaya Dolaysız Zilyet Olması ... 277
(a). Genel Olarak ... 277
(b). İstihkak Hakkından Talebin Ayrılmasında Hükmen Teslim ... 278
(3). Zilyetliğin Havalesi Sözleşmesi ... 279
ddd. Hukuki Sonuçları ... 280
(1). Zilyetliğin Havalesi Sözleşmesinin Tarafları Arasındaki İlişki ... 281
(2). Zilyetliğin Havalesi Sözleşmesi Tarafları ile Üçüncü Kişi (Dolaysız Zilyet) Arasındaki İlişki ... 281
(a). Genel Olarak ... 281
(b). Niteliği ... 282
(c). Bildirimin Şekli ... 283
(d). Bildirimin Hukuki Sonuçları ... 283
(aa). Bildirimden Önce ... 283
(bb). Bildirimden Sonra ... 283
(e). Dolaysız Zilyedin Eşyayı Geri Vermekten Kaçınması ... 284
eee. Özel Durumlar ... 286
ff. Emtiayı Temsil Eden Evrakların Teslimi ... 287
aaa. Genel Olarak ... 287
bbb. Hukuki Olguları ... 287
(1). Emtia Taşıyıcıya ya da Ardiyeciye veya Umumi Mağazaya Bırakılmış Olmalı ... 288

(2). Emtiay (Eşyayı) Temsil Eden Kıymetli Evrak Teslim Edilmeli 288
ccc. Hukuki Sonucu 290
(1). Emtianın Teslim Edilmiş Sayılması 290
(2). Verme Yükümlülüğünde Hapis Hakkı 292
(3). İyiniyetli Emtiayı Teslim Alanın Korunması 293
III. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ 293
A. Genel Olarak 293
B. Fiili Hâkimiyetinin Sürekli Kaybedilmesi 294
1. Fiili Hâkimiyetin Geçici Kaybı veya Sürekli Kaybı Kavramı 294
2. Fiili Hâkimiyetin Sürekli Kaybıyla Zilyetliğin Kaybedilmesi 296
a. Zilyedin Rızası ile Zilyetliğin Kaybedilmesi 296
b. Zilyedin Rızası Dışında Zilyetliğin Kaybedilmesi 298

§ 8. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI

I. ZİLYETLİĞİN KORUNMASININ AMACI VE FONKSİYONU 299
A. Genel Olarak 299
B. Zilyetliğin Korunmasının Sebebi 299
1. Genel Olarak 299
2. Eşya Üzerindeki Haklardan Bağımsızlığı ve Bunlarla İlişkisi 300
3. Konusu 300
C. Hukuki Olguları 301
1. Zilyetliği İhlal (El Atma) 301
2. Zilyetliğin Hukuka Aykırı Olarak İhlali: Zilyetliğe Yasak El Atma 302
a. Genel Olarak 302
b. Görünüm Şekilleri: Zilyetliğin Gaspı (Elinden Alınması) ve Zilyetliğe Saldırı 303
aa. Zilyetliğin Gaspı (Elinden Alınması) 303
bb. Zilyetliğe Saldırı 303
3. Hukuka Uygunluk Sebebinin Bulunmaması 305
a. Özel Hukuktan Kaynaklanan Hukuka Uygunluk Sebepleri 305
aa. Genel Olarak 305
bb. Zilyedin Rızası 306
b. Kamu Hukukundar Kaynaklanan Hukuka Uygunluk Sebepleri 306
D. Zilyetliği Korunan Kişi: Zilyet 307
1. Genel Olarak 307
2. Hak Zilyetinin Durumu 307
3. Kademeli Zilyetlikte 308
a. Asli Zilyet ve Fer'i Zilyet İlişkisinde 308
b. Dolaylı Zilyet ve Dolaysız Zilyet İlişkisinde 309

4. Hizmet Zilyetinin Durumu 309
5. Birlikte Zilyetlik ve Elbirliği ile Zilyetlik 310
E. Zilyetliğin Korunması Talepleri ile Haklardan Doğan Davalar Arasındaki İlişki 311
F. Hukuki Sonucu 311
1. Genel Olarak 311
2. Zilyedin Kuvvet Kullanarak Zilyetliğini Koruması 312
a. Genel Olarak 312
b. Zilyedin Savunma Yetkisinin (Kuvvet Kullanma Hakkının) Hukuki Olguları 313
aa. Zilyetliğe Olan Hukuka Aykırı İhlalin Başlamış ve Halen Devam Ediyor Olması 313
bb. Sınır: Durumun Haklı Gösterdiği Derece Kuvvet Kullanılması 314
aaa. Kuvvet Kullanmanın Saldırıyla Orantılı Olması İlkesi 314
bbb. Savunma Hakkının Sınırının Aşılması (Orantısız Kuvvet Kullanma) 315
cc. Zilyetliğe Aykırılığın Hukuka Aykırı Olması 316
c. Savunma Yetkisinin Tarafları 316
aa. Savunma Yetkisinin Aktif Tarafı: Zilyet 316
bb. Savunma Yetkisinin Pasif Tarafı: Gasp veya Saldırgan 318
d. Savunma Yetkisi 318
aa. Zilyetliği İhlal Eden Saldırıya Karşı Kuvvet Kullanarak Defetme Yetkisi 318
aaa. Zilyetliği İhlal Eden Saldırıya Karşı Savunma Yetkisi 318
bbb. Meşru Müdafaa İçin Kuvvet Kullanarak İhlali Defetme Yetkisi 319
bb. Zilyetliğin Elinden Alınmasına Karşı Kuvvet Kullanarak Zilyetliği Geri Alma Yetkisi 319
aaa. Zilyetliğin Elinden Alınmasına Karşı Savunma 319
bbb. Kuvvet Kullanarak Zilyetliği Geri Alma Hakkı 319
(1). Taşınmazlarda El Koyanı Kovma Hakkı 319
(2). Taşınırlarda Elinden Alma Hakkı 320
3. Dava Yoluyla Zilyetliğin Savunulması 320
a. Genel Olarak 320
b. Zilyetlik Davalarının Özelliği 320
c. Zilyetlik Davalarında Yargılama 323
d. Zilyetliğin Gaspında Zilyedin Dava Hakkı: Geri Verme (Alma) Davası 323
aa. Terim 323
bb. Hukuki Olguları 323
cc. Korunan Kişi (Davacı Sıfatı/Aktif Dava Tarafı: Davacı): Zilyet 324
aaa. Haksız Zilyedin Davacı Sıfatı 324
bbb. Dolaylı Zilyedin Davacı Sıfatı 325
ccc. Birlikte Zilyedin–El Birliği ile Zilyetlerin Davacı Sıfatı(ları) 326
dd. Karşı Taraf (Davalı Sıfatı/Pasif Dava Tarafı: Davalı): Gaspçı 327
ee. Hukuki Sonucu 328
aaa. Zilyetliğin Geri Verilmesi Talebi 328
(1). Genel Olarak 328
(2). Davalının Üstün Hakkı Savunması (Geri Vermekten Kaçınma Hakkı) 328

bbb. Zilyetliğin Gaspından Dolayı Uğradığı Zararın Tazminini Talep 330
e. Zilyetliğe Saldırıda Dava Hakkı 332
aa. Terim 332
bb. Hukuki Olgular 333
cc. Konusu 334
dd. Davacı Sıfatı ve Davalı Sıfatı 334
ee. Hukuki Sonucu 335
aaa. Zilyetliğe Saldırı Fiilinin veya Saldırı Sebebinin Önlenmesi Davası 336
bbb. Saldırının Sona Erdirilmesi Davası 337
ccc. Zilyetliğe Saldırıdan Dolayı Uğradığı Zararın Tazmini Talep 338
f. Dava Hakkının Düşmesi 339
aa. Genel Olarak 339
bb. Hak Düşürücü Sürenin Niteliği 340
cc. Dava Hakkının Düşme Süresi 340
aaa. Dava Hakkının Düşeceği Kısa Süre 341
bbb. Dava Hakkının Düşeceği Uzun Süre 341
II. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI 341
A. 3091 Sayılı Kanunun Uygulama Alanı: Taşınmazlar 341
B. Korumanın Amacı 343
C. Taşınmaz Zilyetliğine Tecavüz ve Müdahaleye Karşı İdari Korunma 343
1. Tecavüz ve Müdahale Kavramları 343
2. Tecavüz ve Müdahale Sayılan Haller 344
3. Damlı Yapının Fuzuli İşgaline Koruma 344
D. Korumaya Yetkili İdari Makamın Yetki ve Görevi 344
E. İdari Makama Başvuru 345
1. Genel Olarak 345
2. Başvuruda Bulunma Süresi 345
3. Soruşturma ve İnfaz Giderleri 346
4. Başvuru Sahibinin Başvurusundan Vazgeçmesi 346
F. Soruşturma 346
1. Soruşturmacı Tayini 346
2. İlgililere Tebligat 347
3. Soruşturma 348
4. Şahitlerin Dinlenmesi ve Karar 348
5. Kroki Çizilmesi 349
6. Soruşturma Süresi 349
7. Tarafların Anlaşması 349
8. Soruşturma Evrakı ile Fezlekenin Yetkili Makama Verilmes 349

G. Karar 350
H. Anlaşmazlığın Dava Konusu Olması 350
I. Kararın Uygulanması: İnfaz 351
1. Genel Olarak 351
2. İnfaz 352
3. İnfazın Ertelenemeyeceği 353
4. Taşınmaz Mal Üzerindeki Ekim, Tesis ve Değişiklikler 353
5. İkinci ve Daha Sonraki Tecavüzler 353

§ 9. ZİLYETLİĞİN HAKKIN OLGUSU OLARAK KORUNMASI

I. GENEL OLARAK 355
A. Yasal Düzenleme 355
B. Zilyetliğin Hakkın Olgusu Olarak Korunmasının Amacı 355
C. Zilyetlik Olgusuna Dayanarak Zilyetliğin Korunmasından Farkı 356
D. Zilyetlik Olgusuna Dayanılarak Hakkın Korunması Araçları 357
II. ZİLYETLİK OLGUSUNA BAĞLANAN KARİNELER 357
A. Taşınırlarda Zilyetliğe Bağlanan Karineler 359
1. Genel Olarak 359
a. Zilyetliğin Haksız Olduğunun Görünüşten Anlaşılamaması 360
b. Karine Sonucu Hakkın Taşınır Üzerinde Zilyetlik Yetkisi Vermesi 361
2. Asli Zilyetlikten Kaynaklanan Karine: Mülkiyet Karinesi 361
a. Taşının Halihazır Zilyedinin Mülkiyet Karinesi 362
aa. Karine Olgusu 362
bb. Karine Sonucu 363
b. Taşının Önceki Zilyedinin Mülkiyet Karinesi 364
aa. Karine Olgusu 364
bb. Karine Sonucu 364
3. Fer'i Zilyetlikten Kaynaklanan Karine 364
a. İyiniyetli Malik Sıfatıyla Asli Zilyedin Mülkiyet Karinesine Dayanılabilmesi 365
b. Sınırlı Ayni Hak Karinesi veya Nispi Hak Karinesi 367
B. Taşınmazlarda Zilyetliğe Bağlanan Karineler 368
1. Tapuya Kayıtlı Taşınmazlar 369
2. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar 370
III. DAVADA ZİLYETLİK OLGUSUNA DAYANAN HAK KARİNESİNE DAYANARAK TALEP VEYA SAVUNMA, HAKKA DAYANABİLME 371
A. Davalının, Davada Zilyetlik Olgusunun Dayandırdığı Hakka Dayalı Savunması 371

B. Davacının, Zilyetlik Olgusunun Dayandığı Hak Karinesi veya Hakla Korunması, Özelikle Taşınır Davası 372
1. Davacının Zilyetlik Olgusunun Dayandığı Hak Karinesi veya Hakka Dayanarak Korunması 372
2. Tarihi Kökleri 372
3. Haksız Zilyetlik Kazanımı Kavramı 373
4. Haksız Zilyetlik Kazanımında Eşyanın İadesi 373
a. Genel Olarak 373
b. Taşınır Davası 375
aa. Terim 375
bb. Kavram 375
cc. Hukuki Niteliği 377
aaa. Taşınır Davasının Hukuki Dayanağının Niteliği 377
bbb. Taşınır Davasının Niteliği 378
ccc. Kararın Kesinliği 378
dd. Konusu 379
ee. Tarafları 380
aaa. Davacı Sıfatı 380
(1). Genel Olarak 380
(2). Asli Zilyet ve Fer'i Zilyet 380
(3). Dolaysız Zilyet ve Dolaylı Zilyet 380
(4). Birlikte Zilyet 381
(5). Hizmet Zilyedi 381
bbb. Davalı Sıfatı 382
ff. Haksız Kazanımın İadesinde Temel Kriter Olarak: İyiniyetli Kazanım ve Kötüniyetli Kazanım 383
aaa. Genel Olarak 383
bbb. İyiniyetle Kazanım 383
ccc. İyiniyetin Karine Olması 385
gg. Hukuki Olguları 386
aaa. Genel Olarak 386
bbb. Önceki Zilyedin (Davacının) Kazanımının İyiniyetli Olması 386
ccc. Hâlihazır Zilyedin (Davalının) Üstün Hak İddiasının Çürütülmesi 387
(1). Hâlihazır Zilyedin (Davalının) Zilyetliği Kötüniyetli Kazanmış Olması 387
(2). Taşınırın Önceki Zilyedinin (Davacının) Elinden Zilyetliğin Rıza Dışı Çıkmış Olması 388
(a). Hukuki Olguları 388
(b). Rıza Dışı Elden Çıkma Halleri 390
(c). Dava Süresi 391
(aa). Rıza Dışı Elden Çıkmış Eşyada 391
(bb). Kötüniyetle Kazanımlara Karşı 392
(aaa). Hukuki Sonucu 392
(bbb). İyiniyetin Korunması 392

IV. TAŞINIR DAVASININ DİĞER DAVALARLA OLAN İLİŞKİSİ VE KARŞILAŞTIRILMASI..399
A. Zilyetliği Koruyan Davalarla 399
1. Nitelikleri Bakımından 399
2. Konusu Bakımından 400
3. Hukuki Olguları Bakımından 400
4. Dava Süreleri Bakımından 400
5. Kararın Niteliği Bakımından 401
B. Mülkiyet Hakkına Dayanan İstihkak Davası ile 402
1. Konu Bakımından 403
2. Nitelikleri Bakımından 403
3. Hukuki Olguları Bakımından 403
4. İspat Bakımından 403
5. Süreleri Bakımından 404
V. İYİNİYETLİ ZİLYETLİK OLGUSUNUN HAKKI KAZANDIRMASI 404
A. Genel Olarak 404
B. Emin Sıfatıyla Zilyetten İyiniyetli Edinim 405
1. Genel Olarak 405
2. Hukuki Olguları 407
a. Eşyayı Emin Sıfatıyla Zilyetten Kazanım 407
aa. Konusu 407
bb. Emin Sıfatıyla Zilyet Kavramı 407
cc. Zilyetlik Çeşitlerinde 410
dd. İrade Sakatlıklarının Zilyetliğin Devrine Etkisi 411
b. Yeni Zilyedin İyiniyetli Olarak Ayni Bir Hak Kazanımı 412
aa. Ayni Hak Kazanımı 412
bb. İyiniyetle Ayni Hak Kazanımı 413
c. Zilyedin Ayni Hak Kazandırma Yetkisinin Olmaması 416
3. Taşınır Rehninin İyiniyetli Kazanımı 417
4. Hukuki Sonucu 417

§ 10. HAKSIZ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU

I. GİRİŞ 419
A. Yasal Düzenleme 419
B. Niteliği 419
1. Sebep Sorumluluğu Olması 419
2. Zilyetliğin İadesine İlişkin Yan Hukuki Sonuçları (Talepleri) Düzenlemesi 420

3. Hükümlerin Özel Hüküm (Leges Speciales) Niteliği 420
a. Genel Olarak 420
b. Diğer Geri Verme Sebepleri ile Olan İlişkisi 421
aa. Sebepsiz Zenginleşme ile Olan İlişkisi 421
bb. Taleplerin Yarışması (Zilyetlik Hükümlerinin Mutlak Önceliği) 422
4. Eşyanın İadesi Erteleyici Şartına Bağlı Talep Niteliği 423
II. HUKUKİ OLGULARI 425
A. Haksız Zilyetliğin Söz Konusu Olması 425
1. Genel Olarak 425
2. Sınırlı Ayni Hakta Haksız Talep 425
3. Alacak Hakkında Haksız Talep 426
4. Haksız İade Talebini Konu Alan Davalar 428
a. Taşınır Davası ve İstihkak Davası 428
b. Zilyetliğin Gaspı Davasında Uygulanmaması 428
c. Taşınmazlarda Hak Karinesinden Yararlanılarak Açılan Davalarda 428
d. Haksız Zilyetliğe Yapılan Atıflar 428
e. Sözleşmeden Doğan İade Yükümlülüklerinde 429
aa. Sözleşmenin Geçersiz Olması 430
bb. Sözleşmenin Sona Ermesi 431
B. Haksız Zilyetliğin Hak Sahibinin Zararına Sebep Olması 433
III. HUKUKİ SONUÇLARI 434
A. Genel Olarak 434
B. İyiniyet Kavramı 434
C. Zamanaşımı 436
IV. İYİNİYETLİ HAKSIZ ZİLYEDİN (İADE SORUMLULUĞU) 438
A. Genel Olarak 438
B. İyiniyetli Haksız Zilyedin Eşyanın Varlığından veya Eşyayı Alıkoymadan Sorumlu Olmaması 438
1. Var Olan Haliyle Eşyanın İadesi 438
2. Varlığına İnanılan Hakkın Sınırları İçinde Kayıptan, Yok Olmadan ve Hasardan Sorumlu Olmama 439
3. Elden Çıkarmadan Sorumlu Olmama 439
a. Genel Olarak 439
b. Malvarlığına Giren Karşılıktan Sorumlu Olma 439
C. İyiniyetli Haksız Zilyedin Ürünlerden ve Kullanma Çıkarından Sorumlu Olmaması 441
1. Genel Olarak 441
2. Yasal Kazanım Sebebi Oluşturması 441

3. Ürünlerin Mülkiyetinin Kazanımı 442
4. Üründen Sorumsuzluğun Sınırı: Haksız Zilyedin Varlığına İnandığı Hak 443
D. Zorunlu ve Yararlı Giderlerin Tazminini Talep Hakkı 444
1. Genel Olarak 444
a. Gider Kavramı 444
aa. Gider Yabancı Bir Eşyaya Yönelik Yapılmalı 445
bb. Gideri Oluşturan Ekonomik Kayıp Kesin Olmalı 445
cc. Gider Objektif Açıdan Sonuç Doğurmaya Elverişli Olmalı 445
dd. Gider Yapılan Malvarlığına İradi Olarak Bir Yük Getirme i veya Eksilmeye Sebep Olmalı 446
ee. Giderin Özel Bir Amaca Dayalı Olması 446
b. Gider Çeşitleri 447
aa. Genel Olarak 447
bb. Ayrım Ölçütü 447
cc. Zorunlu Gider 448
aaa. Kavram 448
bbb. Kıstas: Objektif Değerlendirme 448
dd. Yararlı Gider 449
aaa. Kavram 449
bbb. Gerçek Hak Sahibine Yarar Sağlamasının Gerekli O maması ve Eşyanın Değerini Arttırması 449
ccc. Yararlı Gider Miktarının Belirlenmesi 451
ee. Diğer Giderler 451
c. İspat Yükü 452
d. Zorunlu ve Yararlı Giderlerin Tazmini 452
e. Zorunlu ve Yararlı Giderleri Dışındaki (Lüks) Giderlerin Tazmin Edilememesi 455
aa. İade Yapılacak Kişinin Ayrılacak Şeyin Giderlerini Ödeme Teklifinde Bulunmaması 455
f. Giderlerin Tazmini 456
aa. Genel Olarak 456
bb. Zilyedin Elde Ettiği Ürünlerin Mahsubu 456
2. Eşyayı Geri Vermekten Kaçınma (Alıkoyma Hakkı) 457
V. KÖTÜNİYETLİ HAKSIZ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU 459
A. Genel Olarak 459
B. Kötüniyetli Haksız Zilyedin Eşyanın Varlığından ve Alıkoymadan Sorumluluğu 459
1. Genel Olarak 459
2. Sorumluluğun Kapsamı ve Kapsamının Belirlenmesi 460
a. Eşyanın Varlığının Uğradığı Zarardan 460
b. Eşyanın Devrinden veya Hakla Sınırlandırılmasından Doğan Zarardan 460
c. Alıkoymaktan Doğan Zarardan 461

C. Kötüniyetli Haksız Zilyedin Ürünlerden ve Kullanma Çıkarından Sorumluluğu 461
1. Genel Olarak 461
2. Elde Edilen Ürünlerden Sorumluluk 461
3. Elde Edilmesi İhmal Edilen Ürünlerden Sorumluluk 464
a. Kavram 464
aa. Subjektif Görüş 464
bb. Objektif Görüş 464
b. İhmal Edilen Ürünün Değeri ve Tazmini 465
4. Kullanım Yararından Sorumluluk (Ecrimisil) 465
a. Hukuki Dayanağı 465
b. Kullanma Yararının (Ecrimisilin) Belirlenmesi 467
D. Zorunlu Giderler Tazminatının Hak Sahibi İçin Zorunlu Olanlarla Sınırlandırılması .468
E. Özel Durum: Eşyanın Kime İade Edileceğinin Bilinmemesi 469

Üçüncü Bölüm
TAPU SİCİLİ

§ 11. TAPU SİCİLİNİN ANLAMI, TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ YERİ, TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN ALENİYETİ SAĞLAYAN SİSTEMLER İLE MODERN HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER

I. GENEL AÇIKLAMALAR 473
II. İNCELEMEDEKİ YERİ 475
III. ZİLYETLİĞİN TAŞINMAZLARDA KAMUYA AÇIKLIK SAĞLAMADA YETERSİZLİĞİ 476
IV. TAŞINMAZLARDA KAMUYA AÇIKLIĞI SAĞLAYAN SİSTEMLER 478
A. Tarihi Gelişim 478
B. Taşınmazlarda Kamuya Açıklık Araçlarına İlişkin Sistemler 479
1. Kayıt/Tespit Sistemi 479
a. Genel Açıklamalar 479
b. Kayıt Sistemini Uygulayan Ülkeler 482
aa. Kıta Avrupası Ülkelerinde 482
aaa. Fransa 482
bbb. İtalya 483
bb. Anglo-Amerikan Ülkelerinde 483
aaa. Deed Kayıt Sistemi 484
bbb. Title Kayıt Sistemi 485
2. Tasdik Sistemi 486

3. Tapu Sicili Sistemi 488
a. Almanya 488
b. Avusturya 494
V. TAPU SİCİLİ İLE AYNİ HAK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ 496

§ 12. TAPU SİCİLİNİN YASAL DÜZENLEMESİ

I. TARİHİ GELİŞİMİ 497
II. TAPU SİCİLİNİN YASAL KAYNAKLARI 498
A. Temel Hukuki Kaynak 499
1. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu 499
2. Tapu Sicil Tüzüğü 499
B. Diğer Hukuki Kaynaklar 500
1. Tapu Kanunu 500
2. Kadastro Kanunu 505
3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 506

§ 13. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI SİSTEMLERİ

I. GENEL OLARAK 509
II. ELEKTRONİK TAPU SİCİL KAVRAMI VE UNSURLARI 509
III. DEFTER (KLASİK) TAPU SİCİLİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAPU SİCİLİ 511
A. Defter (Klasik) Tapu Sicil Tutma Sistemi 511
B. Bilgisayar Destekli Defter (Kağıt) Tapu Sicil Sistemi 512
1. Genel Olarak 512
2. Yararları 514
3. Türk Tapu Sicilin Düzenlenmesi Sistemi 514
a. Genel Olarak 514
b. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi: TAKBİS 516
c. Taşınmaz Verilerinin TAKBİS'e Kayıt Edilmesi 517
4. Tapu Sicili Tüzüğü'ne Göre Elektronik Tapu Verilerine Erişim 519
a. Sınırlı Aleniyet (Açıklık) İlkesine Göre Elektronik Tapu Verilerine Erişim 519
aa. Sınırlı Aleniyet İlkesi 519
bb. Tapu Bilgilerine İlişkin Bilgi ve Belge İstemi 523
b. Elektronik Tapu Verilerine Erişim 525
aa. Türk Tapu Sicillerinin Elektronik Ortamda Tutulması 525
bb. Resmi Şekle Tabi Olmayan Belge ve Kayıt Örneği Talepleri 526
cc. Elektronik Ortamda Verilere Erişim Hakkı 526

c. Veri Paylaşımı Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Tapu ve Kadastro (TAKPAS) Verisinin Paylaşımı 527
d. Yetki Alanı Dışı Taşınmazla İlgili Tapu İşlemi Yapılması 528
e. TAKPAS Verisi Paylaşımı 528
f. TAKPAS Üzerinden Veriye Erişim (Sorgulama) Yetkisi Olanlar 530
g. TAKPAS Üzerinden Veriye Erişim (Sorgulama) Yöntem ve İlkeleri 531
h. TAKBİS'te Sorgulama 532
i. TAKBİS'ten Örnek Edinme 532
ı. Kurum ve Kişilerin Yükümlülükleri 533
j. Veri Paylaşımı İlkelerinin İhlali ve Hukuki Sorumluluk 534

§ 14. ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ

I. KAVRAM 535

II. ELEKTRONİK TAPU SİCİL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 536

A. Amacı 536
B. Olumlu ve Olumsuz Yönleri 537
1. Olumlu Yönleri 537
2. Olumsuz Yönleri 538
C. Elektronik Tapu Sicil Sisteminin Bütünlüğü 539
D. Elektronik Tapu Sicilire Hakim İlkeler 539
E. Elektronik Tapu Sicilinin Etkisi 540
F. Elektronik Tapu Sicil Verilerinin Güvenliği 540
G. Kayıt (Tescil) İşlemlerine Uygunluğun Sağlanması 541
H. Tapu Kütüğündeki Elektronik Kişisel Verilerin Korunması 541

III. İSVİÇRE HUKUKUNDA ELEKTRONİK TAPU SİCİL SİSTEMİNİN UYGULANMASI 542

A. Genel Olarak 542
B. Elektronik Tapu Sicilinin Tutulması 544
1. Elektronik Tapu Sicilinin Tutulması 544
a. Kayıt (Tescil) Verilerinin İşlenmesi (Tetkik Usulü) 544
b. Tapu Sicil Müdürlüğü ile Yapılan Elektronik Hukuki İşlemler 545
c. Tapu Sicil Verilerine Erişim 548

§ 15. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA TAPU SİCİLİ

I. TAPU SİCİLİ KAVRAMI 551

II. TAPU SİCİLİNİN BAŞLICA FONKSİYONLARI 552

A. Yapısı İtibariyle Taşınmaz Olan Şeylere Hukuki Olarak Taşınmaz Niteliği Kazandırması 552

B. Taşınmazlar Üzerindeki Hakları Kamuya Açık Hale Getirmesi 553
C. Ayni Hakların Kazanılması, Devredilmesi veya Ortadan Kaldırılmasını Sağlama 553
III. TAPU SİCİLİNİ MEYDANA GETİREN UNSURLAR 553
A. Genel Olarak 553
B. Tapu Kütüğü (Ana Kütük) 556
C. Kat Mülkiyeti Kütüğü 556
D. Yevmiye Defteri 558
E. Tapu Planı 559
F. Resmi Belgeler 560
G. Yardımcı Siciller 561
1. Aziller Sicili 561
2. Düzeltmeler (Tashih) Sicili 562
3. Kamu Orta Malları Sicili 562
4. Tapu Envanter Defteri 564

§ 16. TAPU SİCİLİNDE GEÇERLİ OLAN TEMEL İLKELER

I. GENEL AÇIKLAMALAR 565
II. HER TAŞINMAZA AYRI BİR SAYFA AÇILMASI İLKESİ (AYNİLİK İLKESİ) 566
III. TESCİL İLKESİ 567
IV. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ 567
A. Genel Olarak 567
B. Kazandırma Kavramı ve İşlemler 568
C. Eşyanın Devri Sistemleri 569
D. Hukuki İşlemin Sebebi 570
E. Kazandırmanın Sebebe Bağlılığı 570
IV. İSTEM (BAŞVURU) İLKESİ 573
V. ALENİYET (KAMUYA AÇIKLIK) İLKESİ 574
VI. TAPUYA GÜVEN (İTİMAT) İLKESİ 581
VII. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLU OLMASI İLKESİ 589
A. Genel Açıklamalar 589
B. Sorumluluğun Niteliği 590
C. Sorumluluk Koşulları 590
1. Tapu Sicili Hukuka Aykırı Olarak Tutulmuş Olmalı 590
2. Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması Sonucu Bir Zarar Doğmalı 591
3. Zarar, Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğmuş Olmalı (İlliyet Bağı) 592

§ 17. TAPU SİCİLİNDE YAPILAN TEMEL İŞLEMLERİ

I. KAYIT 595
A. Genel Açıklamalar 595
B. Tapuya Taşınmaz Olarak Kaydedilecek Şeyler 597
1. Genel Açıklamalar 597
2. Arazi 603
3. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler 603
4. Bağımsız ve Sürekli Haklar 605
C. Kaydın Yapılış Şekli 606
D. Tapulamanın (Kadastronun) Yapılışı 607
1. Genel Olarak 607
2. Kadastronun Amacı ve Yapılışı 609
a. Kadastronun Amacı 609
b. Kadastro Bölgesinin ve Çalışma Alanın Belirlenmesi 610
aa. Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı 610
bb. Kadastro Ekibi ve Komisyonun Kuruluşu 610
c. Kadastro Komisyonu 611
aa. Genel Olarak 611
bb. Kadastro Çalışma Alanında Ormanın Bulunması 611
cc. Kadastro Çalışma Alanında Kamu Orta Malı Bulunması 612
d. Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtiraz 612
aa. Genel Olarak 612
bb. Dava Listesi ve Diğer Belgelerin Alınması 613
aaa. Dava Listelerinin Alınması 613
bbb. Tapu Kayıt Örneklerinin Çıkarılması 614
ccc. Vergi Kayıtlarının Çıkarılması 615
ddd. Zilyetliği Tevsik Edici Vergi Kayıtları 615
eee. Diğer Kuruluşlarca Yaptırılmış Haritaların Alınması 616
cc. Kadastro Tespit Tutanağı ve Tutanağa İtiraz 616
aaa. Kadastro İncelemesi, Tespitler ve Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi 616
bbb. Kat İrtifakına Konu Taşınmazların Tespiti 620
ccc. Kat Mülkiyetine Konu Taşınmazların Tespiti 621
ddd. Davalı Taşınmazların Sınırlandırma ve Tespiti ile Tutanakların Mahkemeye Devri 621
eee. Kadastro Tutanağının Kontrolü 624
fff. Kadastro Komisyonlarının Görevleri 624
ggg. Kadastro Tespitine İtiraz 625
hhh. Kadastro Komisyonu İncelemesi 627
iii. Kadastro Sonuçlarının İlanı 627

dd. Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve Hak Düşürücü Süre 628
ee. Kadastro Başladıktan Sonraki Akit ve Tescil İşlemleri 630
ff. Kadastro Kanunun Uygulanacağı Diğer Haller 631
e. Kadastro Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi 632
aa. Görev ve Yetki 632
bb. Kadastro Davalarında Yargılama 634
cc. Yargılama Usulü 634
dd. Deliller ve Hakimin Takdiri 635
ee. Karar ve Kararın Yerine Getirilmesi 635
ff. Kararın Kesinliği 636
f. Kadastro Uyuşmazlıklarına Uygulanacak Maddi Hukuk Kuralları 636
aa. Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar 636
aaa. Kayıt Sahibi veya Mirasçıları Zilyet Bulunuyorsa 636
bbb. Kayıt Sahibi veya Mirasçılarından Başkası Zilyet Bulunuyorsa 638
ccc. Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Zilyet Bulunan Kişi Adına Tespiti 639
(1) Kayıt Malikinin Ölmüş Hallerde 639
(2) Kayıt Malikinin Gaipliğine Karar Verildiği Hallerde 640
(3) Tapu Kaydında Yazılı Malikin Kim Olduğunun Tespit Edilemediği Hallerde 640
bb. Haricen Satışın Dikkate Alınamayacağı Durumlar 640
cc. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti 641
dd. Harici Taksimin Kabul Edilmeyeceği Haller 643
ee. Taksim ve Kısmi İktisap Hali 643
ff. Tanım Arazilerinde 645
gg. Miktar Fazlasının İfrazı 647
hh. Takyitler, Sınırlı Ayni Haklar ve Muhdesat 647
ii. Kayıt ve Belgelerin Kapsamını Tayin 647
jj. Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerler 648
kk. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 649
g. Ormanın Kadastrosu 649
h. İhya Edilen Taşınmaz Mallar 650
i. Hazine Adına Tespit ve Kazandırıcı Zamanaşımı Kazanım Yasağı 651
j. Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Haller 651

II. TESCİL 651

A. Genel Açıklamalar 651

B. Tescilin Yapılabilmesinin Şartları 653

1. Geçerli Bir Hukuki Sebebin Bulunması 653

2. Tescil Talebinin Yetkili Kişi Tarafından Yapılması 656

C. Tescilin Gerçekleştirilmesi 658

D. Tescilin Hükümleri 658
1. Tescilin Olumsuz Hükmü 658
2. Tescilin Olumlu Hükmü 659
III. TERKİN 660
A. Genel Açıklamalar 660
B. Terkinin Yapılabilmesinin Şartları 661
C. Terkinin Hükmü 662
IV. ŞERH 662
A. Genel Açıklamalar 662
B. Tapu Siciline Şerh Edilebilecek Hususlar 663
1. Kişisel Haklar 663
a. Tapuya Şerh Edilebilecek Başlıca Kişisel Haklar 664
aa. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Alıcının Hakkı 665
bb. Sözleşmeden Doğan Önalım (Şufa) Hakkı (TMK m. 1009/1; TMK m. 735) 665
cc. Alım (İştira) Hakkı 666
dd. Geri Alım (Vefa) Hakkı (TMK m. 1009/1; TMK m.736) 667
ee. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Haklar 667
ff. Kiracının Alacak Hakkı 668
gg. Tapuya Şerh Edilebilen Diğer Nispi Haklar 669
aaa. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamalarda, Bağışlayanın Hakkı (TBK m. 292) 669
bbb. Taşınmaz Rehninde Sonraki Sırada Yer Alan Rehinli Alacaklının Boşalan Dereceye Geçme Hakkı (TMK m. 871/III) 669
ccc. Paylaşmalı Mal Ayrılığında, Evliliğin İptali veya Boşanma Durumunda, Eşit Olarak Paylaşma Konusu Olan Aile Konutunda Kalma Hakkı (TMK m. 254/I-III) 670
ddd. Üst Hakkı Sona Erdiğinde, Üst Hakkı Sahibine Ödenmesi Kararlaştırılan Bedele İlişkin Anlaşmadan Doğan Haklar (TMK m. 830) 670
b. Kişisel Hakların Şerhinin Gerçekleştirilmesi 670
2. Tasarruf Yetkisini Kısıtlayan veya Yasaklayan Şerh 672
a. Şerh Edilebilecek Haller 672
b. Şerhin Yapılması ve Etkisi 674
3. Geçici Tescil Şerhi 675
a. Geçici Tescil Şerhi Yapılabilecek Haller 675
b. Geçici Tescil Şerhinin Yapılması ve Etkisi 677
V. BEYAN 678
A. Genel Açıklamalar 678
B. Beyanlar Sütununa Yazılacak Hususlar 678
1. Heyelan Bölgesi 678

2. Kanundan Kaynaklanan Geçit Hakları 679
3. Toprağın İyileştirilmesi 679
4. Eklentiler 679
5. Kurulmaları Artık Mümkün Olmayan Ayni Hakların Yazımı 680
6. Vesayet Kararlarının Yazımı 680
7. Zanaatkârlar veya Yüklenicilerin İşe Başlama Tarihinin Yazımı 680
8. Yararlanan ve Yüklü Taşınmazın Bölünmesi 680
9. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili 680
C. Beyanın Yapılması 681
D. Beyanın Hukuki Etkisi 681
VI. DÜZELTME 682
A. Genel Açıklamalar 682
B. Tapu Sicilini Düzeltme Yöntemleri 683
1. İstem Üzerine Düzeltme 683
2. Re'sen Düzeltme 684
3. Mahkeme Kararı ile Düzeltme 685

Kaynakça 691
Kavramlar Dizini 707

Kısaltmalar

ABGB	: Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für Österreich
Abs.	: Absatz
Art.	: Artikel
Aufl.	: Auflage
AÜHFD	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
AÜSBE	: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
AYM	: Anayasa Mahkemesi
b.	: Bend
Bd.	: Band
BeckRS	: Beck-Rechtsprechung
BGB	: Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.	: Bundesgesetzblatt
BGE	: Entscheidungen des Schweizerishen Bundesgerichts
BGer	: Bundesgericht
BGH	: Bundesgerichtshof
BGHZ	: Entscheidungen des deutschen Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
BK	: Berner Kommentar
bkz.	: bakınız
BN	: Der Bernische Notar
BNotO	: Bundesnotarordnung
BSK	: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht
BT-Dr.	: Bundestag - Drucksache
BWNotZ	: Zeitschrift fur das Notariat in Baden-Württemberg
c.	: cümle
C.	: Cilt
CBS	: Coğrafi Bilgi Sistemi
CCfr	: Code civil français vom 21. März 1804

CCit : Codice civile italiano vom 16. März 1942

CHK : Handkommentar zum Schweizer Privatrecht

DaBaGG : Gesetz zur Einführung eines Datenbankgrundbuchs

dn. : dipnot

DNotZ : Deutsche Notar-Zeitschrift

DSG : Datenschutzgesetz

DStR : Deutsches Steuerrecht

DtZ : Deutsch-Deutsche Rechts-Zeitschrift

E. : Esas

EDV : Elektronische Datenverarbeitung

EGBA : Eidgenössisches Amt für Grundbuch- und Bodenrecht

Einl. : Einleitung

EJPD : Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement

ERV : elektronischer Rechtsverkehr

ERVGBG : Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und elektronischen Akte im Grundbuchverfahren

eTMK : 743 sayılı Medeni Kanun

f/ff. : und nachstfolgende Seite(n) bzw. und nächstfol

f/ff. : und nächstfolgende Seite(n) bzw. und nächstfolgende(r) Artikel

ff. : (und) folgende

FGPrax : Praxis der Freiwilligen Gerichtsbarkeit

FS : Festschrift

FSEK : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

GBG : Allgemeines Grundbuchsgesetz

GBO : Grundbuchordnung

GBV : Grundbuchverordnung

GBVG : Tapu Sicili Uygulama Talimatı

GDB : Grundstücksdatenbank

GG : Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

GIS : Geographical Information System

GUG	: Grundbuchsumstellungsgesetz
HD	: Hukuk Dairesi
HGK	: Hukuk Genel Kurulu
Hk.	: Hakkında
HMK	: Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Hrsg.	: Herausgeber
HRT	: Hayvan Rehni Tüzüğü
ITRF96	: Uluslararası Yersel Referans Koordinat Sistemi
İBD	: İstanbul Barosu Dergisi
İBK	: İçtihadı Birleştirme Kararı
JuS	: Juristische Schulung
JZ	: Juristen Zeitung
K.	: Karar
Kars.	: Karşılaştırınız
KAYSİS	: Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi
KİB	: Kazancı İçtihat Bankası
KK	: Kadastro Kanunu
KMK	: Kat Mülkiyeti Kanunu
KMK	: Kat Mülkiyeti Kanunu
KVK	: Kadastro Veri Konsolidasyonu
LAN	: Local Area Network
LIS	: Arazi Bilgi Sistemi
m.	: madde
MDR	: Monatsschrift für Deutsches Recht
MEGSİS	: Mekansal Gayrimenkul Sistemi
MittBayNot	: Mitteilungen des Bay. Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern
MÜHF-HAD	: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
MünchK	: Münchener Kommentar
N.	: Note

N.	: Nummer
NCI	: non codierte Informationen
NJW	: Neue Juristische Wochenschrift
NotBZ	: Zeitschrift f. d. notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis
Nr.	: Number
OFK	: Orell Füssli Kommentar
OLG	: Oberlandesgericht
OR	: Schweizerische Obligationenrecht
ORF	: Ordonnance sur le registre foncier
PARIS	: Parzellen Information System
R.G.	: Resmi Gazete
Rd.	: Randziffer(n)
RG	: Resmi Gazete
Rn.	: Randnummer
Rpfleger	: Der Deutsche Rechtspfleger
Rz.	: Randziffer(n)
Rz.	: Randziffer(n)
s.	: sayfa
sa.	: sayı
SchkG	: BG betreffend Schuldbetreibung und Konkurs
SMK	: Sınai Mülkiyet Kanunu
SPR	: Schweizerisches Privatrecht
StGB	: Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
SWZ	: Schweizerische Zeitschrift fur Wirtschafts
Syst. Teil	: Systematischer Teil
T.	: Tarih
TAKBİS	: Tapu Kadastro Bilgi Sistemi
TAKPAS	: Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi
TARES	: Taşınır Rehin Sicil Sistemi
TBK	: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

TCK	: Türk Ceza Kanunu
TGBV	: Technische Verordnung zum Grundbuch
TierSchG	: Tierschutzgesetz (Deutschland)
TKGM	: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
TKMP	: Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi
TMK	: Türk Medeni Kan
TRK	: Taşınır Rehni Kanunu
TschG	: Tierschutzgesetz vom 9. März 1978
TST	: Tapu Sicili Tüzüğü
TSY	: Tapu Sicil Yönetmeliği
TSY	: Tapu Sicil Yönetmeliği
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
vb.	: ve benzeri
VBS	: Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
vd.	: ve devamı
VIZ	: Zeitschrift für Vermögens- und Immobilienrecht vom 1. Juni 1811
Vorbem.	: Vorbemerkungen
WiRO	: Wirtschaft und Recht in Osteuropa
WM	: Zeitschrift für Wirtschafts und Bankrecht
WORM	: Write One- Read Multiple
XML	: Extensible Markup Language
Yarg.	: Yargıtay
YKD	: Yargıtay Kararları Dergisi
ZBGR	: Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und
ZBGR	: Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht
ZBJV	: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins
ZertES	: Bundesgesetz über die elektronische Signatur
ZfIR	: Zeitschrift für Immobilienrecht

ZGB	: Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGBS	: Zentrale Grundbuchspeicherstelle fur Bayern
ZHR	: Zeitschrift fur das gesamte Handels urd Wirtsc-
ZIP	: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
Ziff.	: Ziffer
ZK	: Zürcher Kommentar
ZPO	: Zivilprozessordnung
ZSR	: Zeitschrift für Schweizerisches Recht
ZSR	: Zeitschrift für Schweizerisches Recht
ZSR	: Zeitschrift für Schweizerisches Recht
ZWE	: Zeitschrift für Wohnungseigentumsrecht

Birinci Bölüm
GİRİŞ - TEMEL KAVRAM VE İLKELER

Yazar: Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA

§ 1. EŞYA HUKUKUNUN YERİ, KAYNAKLARI VE KONUSU

I. EŞYA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE ÖZEL HUKUKTAKİ YERİ

A. Genel Olarak

1 Hukuk, ekonomik değere sahip varlıklar olan ve kişilerin hâkimiyet altına almak istediği eşya ile ilişkilerini düzenler. Kişinin eşya üzerinde hâkimiyet kazanması, hâkimiyeti kaybetmesi, bu hâkimiyetin el değiştirmesi ve korunması hukuk bakımından büyük öneme sahiptir. Özellikle liberal hukuk sisteminin temel taşı olan mülkiyet hakkının taşıdığı önem, bu hakkın düzenlemesini ve korunmasını gerekli kılmaktadır.

2 Özel hukuk sistemi, önemli bir parasal değer olarak eşyanın kullanım ve yararlanma değerini de düzenleme gereği duymuştur. Söz konusu düzenlemeler para ekonomisi sisteminin zorunlu bir sonucudur[1].

B. Eşya Hukukunun Kaynakları

1. Temel Kaynaklar

a. Anayasa ve Diğer Kamu Kuralları

3 Anayasa m.35'te "*Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.*" düzenlemesi yer almaktadır.

4 Anayasa'nın yanında idare hukuku, özellikle tapu ve kadastro teşkilatı ve tapu sicilinin tutulmasına ilişkin hükümleri konu almaktadır. Örneğin, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu. İlaveten, zilyetliğin idari yönden korunmasına ilişkin olarak getirilmiş olan 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun da idare hukukunun konusu içindedir.

---

[1] HUBER, SGPR III, s.21 ff; SGPR IV, s. 308, 901 ff.

b. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu

5 Eşya hukuku; TMK'da düzenlenen kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku kitaplarını takip eder. TMK, dördüncü kitap olarak 683'üncü ile 1030'uncu maddeleri arasında eşya hukukunu düzenleyen hükümlere yer vermiştir. TMK'nın Eşya Hukuku kitabı; birinci kısmında "Mülkiyet"i 683 ile 778'inci maddeler arasında, ikinci kısmında "Sınırlı Ayni Haklar"ı 779 ile 972'nci maddeler arasında, üçüncü kısmında "Zilyetlik ve Tapu Sicili" 973 ile 1026'ncı maddeler arasında düzenlemiştir[1].

6 Genel hüküm niteliği taşıyan başlangıç hükümlerinin, özellikle dürüstlük kuralının (TMK m.2) eşya hukukunda uygulanması da doğaldır. TBK'nın genel nitelikteki hükümleri eşya hukuku ilişkilerine uygulanırken; TMK'nın eşya hukukunda düzenlendiği genel nitelikteki hükümleri, borçlar hukuku ilişkilerinde kıyasen uygulanacaktır (TMK m.5)[2]. Kişiler hukuku, ilaveten aile ve miras hukuku da fonksiyonel bir bütünlük içinde eşya hukuku ile bağlantılıdır. Örneğin; kişiler hukukunda düzenlenen hak ve fiil ehliyeti kurallarının[4], mal rejimlerine göre eşlerin mal edinmelerinde[5], miras hukukunda vasiyeti tenfiz memurunun tasarrufunda[6] veya taşınmazı taksim sözleşmesinde tasarrufun alım veya geri alım hakkı ile sınırlandırılmasında[7] bu türden bağlantıya rastlanılmaktadır. Yine eşya hukuku sorunlarının çözümünde, borçlar hukukunun borç ilişkisini düzenleyen hükümlerinin uygulanması söz konusu olur. Tasarruf işleminin sebep yönünden bağlı olduğu borçlandırıcı işlemin, örneğin satış sözleşmesinin geçerliliği gibi hususlarda TBK uygulama alanı bulur.

c. Özel Kanunlar

7 Eşya Hukukunu ilgilendiren çok sayıda ilgili kanunlardan başlıcaları şunlardır: 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 634 sayılı

---

1 Eşya hukuku, ayrı bir kanun olarak düzenlenen, ancak TMK'nın ayrılmaz bir parçası olduğu ve TMK'nun beşinci kitabını oluşturduğu 646. maddesinde vurgulanan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri ile mavarlığı hukuku düzenlemeleri yönünden yakın ilişki içindedir. Bu ilişki, özel hukukun bütünlüğü (yeknesaklığı) içinde TMK m.5 hükmünün bir gereğidir. Bkz. **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §2. IV.

2 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.23 ff.; **DOMEJ**, KurzKommentar, vor Art 641-654a, N.1.

4 Bkz. Tescil talebinde bulunanın fiil ehliyeti konusunda BGE 124 II 341 ff. 344.

5 Bkz. Mal rejimi sözleşmesine göre ortak mülkiyet kazanımında mülkiyetin tapu siciline tescilinde BGE 111 II 1132 ff. 117. Ayrıca bkz. BGE 119 II 323 ff.

6 Bkz. BGE 112 II 206, E.2.

7 BGE 118 II 395 ff. 397. Ayrıca bkz. yüklü (külfetli) vasiyet için BGE 120 II 182, 185.

Kat Mülkiyeti Kanunu, 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu[5], 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 6292 sayılı Orman Kanunu, 3572 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2981 ve 3290 sayılı İmar Affı Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu), 1512 sayılı Noterlik Kanunu.

d. Tüzük ve Yönetmelikler

8 Eşya Hukukunu ilgilendiren çok sayıda ilgil: mevzuattan başlıcaları şunlardır: Tapu Sicil Tüzüğü, Ticari İşlemlerce Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik, Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği, Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik.

e. Temel Kavramlar ve Eşya Hukukunun Genel İlkeleri

9 Eşya hukukuna ilişkin temel kavramlar, uygulanacak kuralın belirlenmesinde, örneğin bir şeyin hukuki süje olarak eşya olarak nitelenmesinde önemli bir yol göstericidir. TMK bu konuda kavramsal tanımdan kaçındığı için bu konuda yardımcı kaynaklardan, özellikle doktrinden yararlanacaktır. Eşya hukuku alanında doktrinde geliştirilen ve uygulamada vücut bulan genel ilkelerin eşya hukuku uygulanmasında, özellikle eşya hukuku kuralının belirlenmesinde ve yorumunca önemli bir yardımcı kaynak olduğu tartışmasızdır.

10 Eşya hukukunun genel ilkelerinin TMK m.1 II'ye göre boşluk doldurma yanında, genel – toplu – kıyas olarak uyuşmazlık konusuna TMK m.1 I'e göre doğrudan uygulanması söz konusudur. Eşya hukukunun genel ilkelerinin uygulaması esnasında, hukuk kuralındaki yarar dengesi ve korunan hukuki değerin genel ilkeye uygun olması, yani çatışmaması gerekir; kanun koyucu ilgili hükümde genel ilkeye istisna getirmeyi amaçlamış olabilir[6].

---

[5] Ayrıntılı bilgi için bkz. **ANTALYA O. G./ACAR, F.**, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde İlk Tespitler), İstanbul, 2017.

[6] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.56.

2. Tamamlayıcı Kaynaklar

a. Örf ve Adet Kuralları

11 TMK m.1 II ilk tamamlayıcı kaynak olarak örf ve adet hukukunu[c] öngörmüş olmasına karşın uygulamada, eşya hukukuna ilişkin kanun boşluğunun örf ve adet kuralı ile doldurulduğu bir örneğe rastlamamaktayız.

b. Hâkimin Yarattığı Hukuk Kuralları

12 TMK m.1 II eşya hukukundaki boşluğun örf ve adet kuralı ile doldurulamaması halinde, hâkimin bizzat kendisinin kanun koyucu gibi hareket ederek söz konusu boşluğu doldurmasını öngörmüştür[cc]. Türk hukukunda Yargıtay kararlarına ve içtihatlarına konu olan bu türden boşluk doldurma örneklerine rastlamaktayız.

3. Yardımcı Kaynaklar

13 Eşya hukuku alanındaki uyuşmazlıklara ilişkin olarak kanun hükmünün yorumlanmasında ve tamamlanmasında, hukuk kaynakları ve yardımcı kaynaklardan yararlanılması gerekir[2]. Hukuk kaynaklarının başında ise kanun koyucunun yorumu olan genel gerekçe ve madde gerekçesi gelir. TMK madde gerekçeleri, Komisyon üyesi öğretim üyelerince yazıldığından Türk hukukunda ayrı bir önem taşır.

a. Doktrin

14 Doktrin, yargı uygulamasına dair oluşturduğu bilimsel yorum ile kanun hükmünün yorumlanmasında, tamamlanmasında ve gelişiminde yol gösterici olan bir yardımcı kaynaktır[3]. Türk doktrinin yanı sıra kaynak ZGB'ye ilişkin İsviçre doktrini tarafından ortaya konmuş bilimsel yorum da önem arz etmektedir. Türk ve İsviçre Eşya hukuku doktrinine, bu kitabın kaynakçasında yer verilmiştir.

15 Yine liberal hukuk sistemini benimsemiş, Roma-Cermen hukuk sistemine dâhil ülkelerin doktrini de yardımcı kaynak olarak yol gösterici-dir. Bu çerçevede özellikle Alman Medeni Kanunu'nda yer eşya hukuku

---

[c] ANTALYA/TOPUZ, MH, § 8, II, B.

[cc] ANTALYA/TOPUZ, MH, § 8, II, C, 2, b.

[2] MEIER-HAYOZ, BK Syst. Teil, N.54 f. 106 f. REY, I, N. 60 f.

[3] MEIER-HAYOZ, BK ZGB Art.1, N.359.

düzenlemeleri ve bu düzenlemelere ilişkin olarak ortaya konmuş bilimsel yorumlar da yardımcı kaynak olarak değerlendirilmelidir. Konuyla ilgili Avrupa Birliği Yönergeleri de yol gösterici, hatta bazen de üst norm olarak açıklayıcı rol oynar. Doktrinde savunulan görüşler, kanun koyucunun yeni düzenlemeleri oluşturması esnasında etkili olmaktadır. Gerçekten, TMK m.713 beşinci fıkrasında, taşınmazın olağanüstü zamanaşımı ile mülkiyeti kazanma anı olarak, doktrinde savunulan bir görüşe uygun olarak birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleşme anı esas alınmıştır.

b. Yargı Kararları

16 Türk yargı uygulaması, Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yaptığı yorumlar ve verdiği kararlarla yerleşmiş içtihatlar oluşturmuştur. Bu yönüyle Yargıtay'ın yerleşmiş kararları, huzuruna intikal edecek benzeri uyuşmazlıklar hakkında hâkime sınırlı uyma yükümlüğü getirmektedir[4]. Yargıtay Kanunu m.45 uyarınca hâkim, zaten Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararlarına uymak zorundadır. Örneğin TMK m. 683'te düzenlenen istihkak ve el atmanın önlenmesi davalarına ilişkin olarak çok sayıda Y.İBK kararı söz konusudur[5].

17 Yargıtay 1.10.1982 T., 3/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı'nda, mirastan doğan elbirliğiyle mülkiyette, ortaklardan birinin ya da birkaçının kendi adına el atmanın önlenmesi davası açtığı durumlarda diğer ortakların muvafakatinin alınması gerektiğine ya da MK'nın 581. maddesi uyarınca bir temsilci tayin edilmesi gerektiğine karar vermiştir. MK m.581'i karşılayan TMK m.640 düzenlemesi yapılırken, karara konu MK m.581'in son fıkrası TMK'ya alınmamıştır. Böylece uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için maddeye ilave edilen dördüncü fıkra, mirasçıların her birinin hakkını korumak için tek başına dava açmasına imkân tanımış ve açılan dava sonucunda elde edilen karardan, mirasçıların hepsinin yararlanmasını sağlamıştır. Bu hüküm kayrak ZGB düzenlemesinden farklı bir yaklaşımı bünyesinde barındırmaktadır.

18 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hazırlanırken de bazı hükümlere yargı uygulamasına uygun eklemeler yapılırken; bazı hükümlerde değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, TMK m.1091'de arsa payı karşılığı inşaat

---

[4] **ANTALYA/TOPUZ**, MF, §8, III, B. 2.

[5] Yarg. İBK 14.04.1943 T., 48/15 sayılı Kararı, 28.02.1945 T. 23/5 sayılı Kararı, 04.03.1953 T. 1/2 sayılı Kararı, 16.05.1956 T. 1/6 sayılı Kararı, 16.05.1956 T. 1/7 sayılı Kararı, 11.02.1959 T. 17/15 sayılı Kararı, 11.10.1982 T. 3/2 sayılı Kararı, 26.03.1984 T. 10/4 sayılı Kararı.

sözleşmelerinin doğan kişisel hakkın şerh edilebileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Yine TMK m.713'te düzenlenen olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasına ilişkin düzenlenme, kaynak ZGB Art. 662'den ayrışması ve mahallî yargı uygulamasına yer vermesi yönünden özellikle değerlendirilmelidir. Yargı uygulamaları, uygulamacılar tarafından Türk hukukunda şerhlerde derlenmektedir. Bu şerhlere kaynakçamızda yer verilmiştir.

19 Kaynak yasanın ZGB olması sebebiyle eşya hukuku alanında da, İsviçre yargı uygulamasından, İsviçre Federal Mahkeme kararlarından yardımcı kaynak olarak yargı uygulamasında yararlanılması gerekir. Dikkat etmek gerekir ki, eşya hukuku alanında Türk yargı uygulaması İsviçre yargı uygulamasından çokça noktada ayrılmış; farklı uygulamalara yer vermiştir[16].

C. Eşya Hukukunun Malvarlığı Hukukunun Bir Bölümünü Oluşturması

20 Eşya hukuku, borçlar hukuku ile birlikte malvarlığı hukukunun temel alanlarını oluşturur[17]. Doktrinde, malvarlığı hukuku içindeki eşya hukuku alanı "**hâkimiyet hukuku**" (*Herrschaftsrechte*); borçlar hukuku alanı "**edim hukuku**" (*Leistungsrechte*) olarak ifade edilmiştir[18].

21 Eşya hukuku ile borçlar hukuku birbiriyle yoğun ve özel ilişki içindedir. Her iki hukuk alanı da ortak bir temel fonksiyonun yerine getirilmesine hizmet eder[19]. Borçlar hukuku, kişinin eşya ile olan ilişkisinin toplumsal ilişkide güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlar. Kısaca işlem güvenliğini sağlar. Eşya hukuku, kişinin eşya (mal) üzerindeki hâkimiyetini; borçlar hukuku ise eşyanın (malın) devrini düzenler. *Merz*, bu ayrımı "**mala hâkimiyet**" ve "**malın değişimi**" şeklinde açıklamaktadır[20].

22 Taşıdıkları ortak temel fonksiyona rağmen; eşya hukuku, kişinin eşya ile olan ilişkisinde özellikle "şeye kimin sahip olacağı"nı düzenlediği

---

16 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 36; AKİPEK/AKINTÜRK, s.90; ÜNAL/ BAŞPINAR, Giriş, IV, C.

17 MERZ, SPR VI/1, s.36. Bkz. Fikir ve sanat eserleri hukukunun da malvarlığı hukukuna dâhil olduğu unutulmamalıdır.

18 TUOR/SCHNYDER/SCHMID, s. 836 f.

19 REY, I, N. 15 f.

20 MERZ, SPR VI/1, s.36

halde, borçlar hukuku bunun tam aksine "şeyin kime devredileceği"ni düzenlemektedir.

23 Malvarlığının -bazen karşılığı olacak şekilde- devrini konu alan hukukî işlemlerde, iltanın konusu edimin eşya olduğu durumlarda, borçlandırıcı işleme (hukuki sebebe, causa) dayanarak, tasarruf işlemiyle hakkın konusu devredilir. Eşyanın devrinde ve bir eşyaya katılımı konu olan işlemlerde ayni hak, borçlandırıcı işlemin (causa) sebebi olduğundan borçlar hukukunun *sebep fonksiyonundan*; tasarruf işleminin devrinin geçerliliği borçlandırıcı işleme bağlı olduğundan eşya hukukunun *genetik fonksiyonundan* bahsedilir[21].

24 *Kramer*, borçlandırıcı işlemi "**planlama aşaması**" (*Planungsphase*), tasarruf işlemini "*planın yerine getirilmesi*" (Planererfüllung) olarak açıklamaktadır[22].

D. Eşya Hukukunun Sınırlı Olarak İrade Özerkliğine İmkân Tanıması

25 Türk-İsviçre eşya hukuku sistemi, emredici kurallarla düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler içerisinde, kişinin veya kişilerin irade özerkliği ilkesi uyarınca yeni bir ayni hak tipini, çeşidini belirleme imkânı yoktur. Düzenlenen ayni hakkın konusu ve kapsamını da belirleme imkânı sadece kanunun verdiği yetki kadardır. Bu sebeple eşya hukuku detaylı kural düzenlemelerini gerekli kılar.

II. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU

26 Eşya hukuku, kişinin eşya üzerindeki özel hukuk ilişkisini düzenler[23]. Kişi ile eşya arasındaki hukukî ilişkide, kişinin eşya üzerindeki doğrudan ve sınırlı olarak belirlenmiş hakkını konu alır[24]. Eşya hukuku, bu yönleriyle borçlar hukukunda borcun konusunu oluşturan eşya ve eşyayı talep hakkından farklıdır[25]. Eşya hukuku, kişinin eşya üzerindeki ayni hakkını konu alır. Ayni hak, sahibine geniş yetkiler vermektedir: tasarruf yetkisi, kullanma yetkisi, yararlanma yetkisi, para çevirme yetkisi vb. Bu yönüy-

---

21 **REY**, I, N.17.

22 **KRAMER**, Allg. Einl. vor OR Art.1, N.48.

23 **WIEGAND**, BSK ZGB II, vor Art.641 ff. N.4.

24 Karş. **WIEGAND**, BSK ZGB II, vor Art.641, N.4.

25 **TOUR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO**, s.813 ff.

le, kişinin eşya üzerindeki aynî hakkı, özellikle mülkiyet hakkı, en geniş şekliyle kişiliğe dayandırılmaktadır[26]. Eşya hukuku kişinin eşya üzerinde doğrudan sınırlandırılarak belirlenmiş hakkını aşağıdaki şekilde düzenler:

A. Kişinin Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hâkimiyetini Düzenlemesi

27 Eşya hukuku, kişinin eşya yani taşınır veya taşınmaz üzerindeki doğrudan hâkimiyetini düzenleyen hakları konu alır. Bu sebeple, bu kurallar eşya üzerinde kişinin hâkimiyet kurmasına elverişli olmalıdır[27]. Kişinin hâkimiyet kuracağı eşyanın niteliğine ve özelliğine göre, yani taşınır veya taşınmaz olmasına göre de hukuki durumu farklı olacaktır[28]. Bu sebeple TMK'nın eşya hukuku kitabında bu iki eşya grubunu farklı hükümlere tabi tutulmuştur[29].

28 Kişinin eşya üzerindeki hâkimiyeti, hakka dayansın dayanmasın eşya üzerindeki doğrudan hâkimiyettir; dolaylı hâkimiyet eşya hukukunun konusu dışında kalır. Kişinin eşya üzerindeki hâkimiyetinin dış dünyaya yansıması, eşya üzerindeki tasarruf olarak karşımıza çıkar. Taşınır eşya üzerindeki doğrudan hâkimiyet, yani fiili tasarruf zilyetlik olarak karşımıza çıkar. Zilyetlik eşya üzerindeki doğrudan hâkimiyeti ortaya koyabilirken, taşınmazlarda zilyetlik aynı fonksiyonu yüklenmekte yetersiz kalır. Bu yetersizlik sebebiyle, taşınmazlarda bu fonksiyon TMK'da düzenlenen tapu sicili sistemi ile giderilmeye çalışılmıştır. Kişinin eşya üzerindeki hâkimiyeti; eşya üzerindeki aynî hakkı alenileştirdiği gibi, aynî hakkın kurulmasına, özellikle devrini de sağlamaya hizmet eder.

B. Eşya Hukukunun, Eşya Üzerindeki Hakkın Kurulmasını ve Sona Ermesini Düzenlemesi

29 Eşya hukuku, eşya üzerindeki hakkın kurulmasını ve sona ermesini düzenler. Eşya hukuku, toplumsal yaşam ilişkilerinin güvenliği gereği ve tarafların menfaatini sağlamak amacıyla, aynî hakların ve reel borç ilişkisinin hukukî durumunun kurulmasını ve sona ermesini emredici nitelikte düzenler. Eşya hukuku, eşyayı konusuna göre taşınır ve taşınmaz olarak

---

[26] MEIER-HAYOZ, Wesen, s.171.

[27] BAUR/STÜRNER, § 1. N.1.

[28] REY, I, N.1.

[29] PALANDT/BASSENGE, BGB Einl. vor § 854 N.1; BAUR/STÜRNER, § 2. N.15; WESTERMANN, § 6 I 2, s. 40.

ikiye ayırarak incelediğinden, ayni hakkı, özellikle mülkiyet hakkının kurulmasını (ve sona ermesini); taşınmaz mülkiyeti olarak TMK m. 557 vd. hükümlerinde düzenlemiş, taşınır mülkiyetini ise TMK m. 762 vd. hükümlerinde düzenlemiştir.

C. Eşya Hukukunun, Eşya Üzerinde Kurulan Hakları ve Bu Hakların Sınırlarını Belirlemesi

30 Eşya hukuku, eşya üzerinde kurulan hakları ve bu hakların sınırlarını belirler. Eşya hukuku, kişinin eşya ile olan hukuki ilişkilerini belirleyen hakların hangi haklar olduğunu sınırlı sayı (*numerus clausus*) ilkesine göre belirler; belirlediği hakkın kapsamının sınırlarını da emredici olarak düzenler. Bu sebeple eşya hukukundan tipe bağlılık ve tipin kapsamının belirliliği ilkesi söz konusudur. TMK'da ve özel bir kanunun hükmü ile belirlenen mülkiyet ve sınırlı ayni hak çeşitleri dışında, yeni bir ayni hak yaratılamamasına **tipe bağlılık ilkesi** denir.

31 Eşya hukuku kuralları, kurulmasına imkân verdiği ayni hakkın kapsamını da önceden belirlediğinden, ayni hakkın konusu ve kapsamının taraflarca veya hak sahibince sonradan değiştirilmesi söz konusu değildir. Buna da **tipin kapsamının belirliliği ilkesi** denilir. Kanun koyucu, ayni hak olarak belirlediği hakkın kapsamının ve yapısının herkesçe önceden bilinebilir olmasını sağlamış; sınırlarını belirlemiştir. Örneğin, TMK m.779'da taşınmaz lehine irtifak hakkında, yüklü taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınması veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanılmasına katlanması hakkın konusu olarak belirlenmiştir.

D. Eşya Hukukunun, Eşya Üzerinde Birden Fazla Hak Sahibi Olan Kişilerin Eşyadan Yararlanmasını ve Onu Yönetimini Düzenlemesi

1. Eşya Hukukunun Kişilerin Birlikte Mülkiyetinde Bulunan Eşyadan Yararlanılmasını ve Yönetimini Düzenlemesi

32 Eşya hukuku, birlikte mülkiyet çeşitlerini tipe bağlılık ilkesine göre belirlemiş; kurulmasını ve sona ermesini düzenlemiş ve de belirlediği birlikte mülkiyet çeşitlerinde hak sahibinin yönetim ve yararlanma haklarını düzenlemiştir (paylı mülkiyet TMK'nın m. 688 vd., elbirliği ile mülkiyet ise TMK'nın m. 701 vd., bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyeti ise Kat Mülkiyeti Kanunu'nda).

2. Eşya Hukukunun Sınırlı Ayni Hak Sahibinin Yükümlenen Eşya Üzerindeki Yararlanmasını Düzenlemesi

33 Eşya hukuku, sınırlı ayni hak sahibinin yükümlenen eşya üzerindeki yararlanmasını düzenler. Aynı eşya üzerinde ayni hak sahibi kendi yetkilerini yarar dengesini dikkate alarak, sınırlı ayni hakka ilişkin kapsam ve konuda sınırlayarak, bu kapsam ve konu ile sınırlı olmak üzere eşyanın üzerindeki hakkını başka bir kişiye bırakmasını düzenler. Sınırlı ayni hakla, sadece **yararlanma yetkisinin**, bazen daha sınırlı **kullanma yetkisi** yanında, **yönetme yetkisini**, hatta belirli bir borca ayni garanti teşkil etmesi şeklindeki **paraya çevirme yetkisini** düzenlenmektedir.

§ 2. EŞYA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

I. EŞYA

A. Kavram

34 Eşya kavramı kanunda tanımlanmamıştır. TMK taşınmaz mülkiyetinin konusu eşyaları TMK m.704'te üç bent halinde saymış; taşınır mülkiyetinin konusunu ise, nitelikleri itibarı ile taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen taşınır maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan şeyler olarak belirlemiştir.

35 Eşya kavramı farklı hukuk sistemlerinde farklı olarak tanımlanmıştır. ZGB ve TMK'da, ortak hukukun etkisiyle -Alman hukukunda BGB § 90'da tanımlandığı üzere maddi varlığa sahip şeyler olarak belirlenirken; Avusturya hukukunda ABGB § 285'te kişiden farklı, insanın kullanımına hizmet edilen şey olarak ifade edilmiştir[1].

36 Roma hukukundaki eşya kavramını takip eden Fransız hukukunda ise eşya *'biens corporels'* olarak değil de *'biens incorporels'* olarak belirlenmektedir. Yani ekonomik değeri olan, mülk edinmeye elverişli bulunan her şey eşya sayılmaktadır[2].

37 Türk-İsviçre hukuku eşya tanımı vermeyerek, bu kavramın ne anlama geldiğinin belirlenmesi hususunu doktrin ve uygulamaya bırakmıştır[3]. Bu durum, kavramın statik değil dinamik olmasını, günün ekonomik ve sosyal şartlarına uygun anlaşılmasını ve fonksiyonel olmasını sağlamıştır.

38 Eşya kavramı sadece fiziksel özellik ile izah edilmemelidir. Şeyin amaçsal yaklaşımla özellikle ekonomik fonksiyonu, toplumsal yaşam ilişkileri ve etik düşünce kapsamındaki yeri dikkate alınarak, hukuk düzeninin o şeyi eşya olarak tanıyıp tanımadığını belirlemek gerekir[4]. Doktrinde genel olarak kabul edildiği üzere eşya kavramını, kişilik değeri oluşturmayan üzerinde hukuki olarak hâkimiyet kurulabilen, ekonomik

---

1 Ayrıca bkz. ABGB § 353.

2 **FERID/SONNENBERGER**, Bd.2 N. 3 A 22 ff.

3 **ÜNAL/BAŞPINAR**, § 3. II, A. 1.

4 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.116 ff.

değeri olan belirli bir maddi varlık olarak tanımlayabiliriz[4]. Eşya ayni hakkın konusunu oluşturur.

B. Unsurları

1. Kişilik Değerleri Dışında Varlık Olması (Kişilik Dışılık)

39 İsviçre-Türk hukuku kabul ettiği dar kavramsal eşya yaklaşımına bağlı olarak, aşağıda incelenecek eşyanın üç boyutlu yaklaşımın yanında, olumsuz bir unsur olarak kişiliği ve bunu oluşturan kişilik değerlerini eşya kavramı dışında bırakmıştır. Kışılığın eşya kavramı dışında değerlendirmesi, ahlak ve etik kuralı gereğidir[5].

40 Kişilik unsurlarının eşya kavramı dışında bırakılması; onun, haktan, fikri haklardan, malvarlığından, enerjiden ve de eşya topluluğu ile hak topluluğundan, aşağıda inceleyeceğimiz üzere ayrılmasında rol oynar[6].

a. Gerçek Kişinin Bedeni ve Uzuvları

41 Gerçek kişi, yani insan ve onun bedeni eşya kavramına değil, TMK m. 23 vd.'da düzenlenen kişilik değerlerine dâhildir[7]. İnsanın uzuvları; örneğin saçı, organları bedenle bağlılığını devam ettirdiği sürece eşya niteliği kazanamaz.

42 TBK m. 19-20'ye uygun olarak TMK m. 27 III c.1'de düzenlendiği üzere kişinin yazılı rızası ile insan kökenli biyolojik maddelerin bedenden alınması, bedene aşılanması ve başka bir bedene nakli mümkündür[8].

b. Bedenden Ayrılan Uzuvlar (Organlar)

43 Bedenden ayrılan organlar, kural olarak eşya özelliğine sahip olur ve böylelikle ayni hakkın konusunu teşkil edebilir. Örneğin kesilen saçtan oluşturulan peruk, çekilen diş eşya niteliğine sahiptir.

---

4 **TUOR/SCHNYDER/SCHMID**, s.817; **REY**, BK Syst. Teil, N.147; **REY**, I. N.66; **STEINAUER** I. N.60; **LIVER**, SPR V/1, s.11; **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.55; **HAAB**, ZK Einl. N.21 ff; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.4. Bkz. **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.8; **ÜNAL/BAŞPINAR**, Giriş, II. A. 1. d.

5 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.130; **LIVER**, SPR V/1, s.11; **REY**, I. N. 100.

6 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.117 f; **REY**, I. N.81; **STEINAUER**, I. N.61.

7 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.131; **LIVER**, SPR V/1, s.11; **HAAB**, ZK Einl. N.22 ff.; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.5; **REY**, I. N.101; **ÜNAL/BAŞPINAR**, § 2. II 2 d; **AKINCI**, s.172 vd.

8 Aynı maddenin ikinci cümlesinde, biyolojik madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirilmesi istenemez, maddi ve manevi tazminat isteminde bulunamaz hükmü getirilmiştir. Bu hükümle biyolojik madde verme borcu, eksik borç olarak düzenlenmektedir.

53 Üreme hücreleri nitelik ve özellik itibarı ile eşya niteliği ve özelliği taşımazlar; eşya olarak fonksiyon görmezler. Ancak üreme hücreleri sınırlı olarak yaşam ilişkilerine, hukuk kurallarının izin verdiği ve onun sınırları içinde konu olabilir. Üreme hücreleri tıbbi gereklilik sonucu yaşam ilişkilerini karşılıksız olarak konu olabilir. Görüşümüze göre kişinin üreme hücreleri, ürediği kişiden ayrılsa bile onun kişiliğinin bir parçası olarak kişilik değeri varlığını devam ettirir. Kişilik değeri olarak işlem görür ve korunur.

54 **Embriyo** ise[22], görüşümüze göre ceninin ilk oluşumu olarak, oluşumu sonrasında sağ ve tam çocuk olarak doğması halinde hak ehliyetine sahip olacağından, doğacak çocuğun bedenin oluşumunun ilk başlangıcı olarak kişilik değeridir ve kişilik olarak korunmalıdır[23].

55 Türk hukuku yönünden de embriyonun eşya olduğu söylemez[24]. İsviçre hukukunda embriyonun anne dışında gelişimi eşya olarak değil de özel hukuk rejimine tabi cenin şeklindedir[25]. Ancak embriyo; sınırlı olarak, yaşam ilişkilerine hukuk kurallarının izin verdiği ölçüde ve onun sınırları içinde konu olabilir. Embriyonun yaşam ilişkilerine konu olabilmesi ise tıbbı gereklilik sonucu, karşılıksız edinilmesine bağlıdır.

56 Avrupa Birliği'nin 4 Nisan 1997 tarihli Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi, 5013 sayılı İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun olarak kabul edilmiştir[26]. Bu sözleşmenin 18. Maddesi imzacı devletin tüpte (*in vitro*) *embriyo* üzerinde araştırmaya izin vermesi halinde, imzacı devlete embriyo için yeterli korumayı sağlama yükümlülüğünü getirmiş ve aynı zamanda araştırma amaçlarıyla insan embriyolarının oluşturulmasını yasaklamıştır[27].

57 Ayrıca bu Sözleşme; insan vücudu ve parçalarının, bu nitelikleri dolayısıyla, ticari kazanç sağlanmasına konu olmayacağını (m.21) ve bir

---

[22] **KALIN**, s. 140 ff. **REY**, , N.118 ff. **STEINAUER**, N.67a.

[23] Bkz. **GUGENBÜHL/NÄGELI**, BSK ZGB I, Art.31, N.19 ff.

[24] **AKINCI**, s.10 vd., 17 vd.

[25] **ÜNAL/BAŞPINAR**, § 3, II, d.

[26] Bu sözleşme, 20 Nisan 2004 tarih ve 25439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

[27] İsviçre Federal Anayasası m.119/II yumurtanın kadın bünyesi dışında spermle birleştirmesini yani embriyonun kadının yumurtalı

müdahale sırasında insan vücudunun herhangi bir parçası alındığında, bu parçanın, yalnızca uygun bilgilendirme ve muvafakat alma işlemlerine uyulduğu takdirde, çıkarılma amacından başka bir amaç için saklanamayacağı ve kullanılamayacağını, başka şekilde insan vücudu ve parçaları üzerinde tasarruf edilemeyeceğini düzenlemiştir (m.22).

58 Türk hukukunda, Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik[24], üremeye yardımcı tedavi (ÜYTE) olarak, yani anne adayının yumurtası ile kocasının sperminin çeşitli yöntemlerle döllenmeye daha elverişli hale getirilerek, gerektiğinde vücut dışında döllenmesini sağlayıp, gametlerin veya embriyonun anne adayına transferini de kapsayan ve modern tıpta bir tıbbi tedavi yöntemi olarak kabul edilen uygulamaları düzenlemiştir.

59 Bu Yönetmeliğin 20'nci maddesi birinci fıkrası, ikinci fıkrada[25] ve üçüncü fıkralarda[26] belirtilen tıbbi zorunluluk halleri dışında üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanması yasaktır.

60 Zorunlu hallerde alınan üreme hücreleri ve gonad dokuları, verici adaya ait EDTA'lı kan örneği ile birlikte bir merkezde uygun şartlarda en fazla beş yıl süreyle saklanır. Adaylardan fazla embriyo elde edilmesi durumunda eşlerden her ikisinin rızası alınarak embriyolar dondurulmak suretiyle saklanır.

61 Saklama süresinin bir yılı aşması halinde her yıl embriyonun saklanması için çiftler mutlaka başvuruda bulunarak taleplerinin devam ettiğini ifade eden imzalı dilekçe vermelidir. Eşlerin birlikte talebi, eşlerden birinin ölümü, boşanmanın hükmen sabit olması halinde ya da belirlenen süre son bulduğunda saklanan embriyolar kurulacak bir komisyon tarafından tutanak altına alınarak imha edilir.

---

[24] Resmî Gazete Tarihi: 30.09.2014, Sayısı: 29135.

[25] Yönetmelik m. 10 fıkra (2): "*Erkeklerde üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbbî zorunluluk halleri şunlardır: a) Cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi halinde. b) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde. c) Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (testislerin alınması ve benzeri) öncesinde. ç) Çok az sayıda sperm olması (kriptozoospermi durumunda.*"

[26] Yönetmelik m. 20 fıkra (3): "*Kadınlarda üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbbî zorunluluk halleri şunlardır: a) Kemoterapi ve radyoterapi gibi gonad hücrelerine zarar veren tedaviler öncesinde. b) Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak olan ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi operasyonlar) öncesinde. c) Düşük over rezervi olup henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikâyesinin üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda.*"

f. Hayvan

62 Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabulü sonrası, hayvanın eşya olup olmadığı konusu tartışılmaktadır. Bu Bildirgede, bütün hayvanların hak sahibi olduğu, var olma ve insanlarla birlikte yaşama, saygı görme, bakım ve korunma hakkına sahip olduğu ifade edilmektedir[31]. Bu bildirgenin kabulü sonrası ZGB Art. 641a, BGB § 90a[32] ve ABGB § 285a hayvanın hukuki durumuna ilişin düzenlemeler getirilmiştir[33].

63 ZGB Art.641a hükmünde, hayvanların eşya olmadığı vurgulanmış ve hayvanların hukuki durumu konusunda özel hüküm bulunmadığı sürece eşyaya ilişkin hükümlerin uygulanacağını düzenlenmiştir.

64 Bu düzenlemeler sonrasında, hayvanın hukuki durumu ve hak sahibi ile hak konusu dışında üçüncü bir kategori oluşturup oluşturmadığı tartışılmaktadır:

65 Bir görüş, kanun koyucunun amacının yeni bir kategori yaratmak olmadığını, hayvanın eşya statüsü içinde değerlendirilmesi gerektiğini savunurken[34]; diğer görüş eşya benzeri varlık olarak kabul etmektedir[35]. Başka bir görüş ise, kendisine özgü statüsü olan (sui generis) bir eşya niteliğinde olduğunu[36], farklı bir görüş ise getirilen düzenlemelerle hayvanların eşya dışında özel bir cismani varlık saymaktadır[37].

66 Bildirge sonrası hayvanın hukuki durumunu düzenleme amacıyla mukayeseli hukukta özel kanunlar çıkarılmıştır[38]. Türk hukukunda da 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu (HKK) çıkarılmıştır[39]. 5199 sayı-

---

31 **SUNGURBEY**, s. 41 vd.

32 BGB § 90'ın dâhil olduğu bölümün başlığı da eskiden sadece eşya iken eşya ve hayvanlar olarak değiştirilmiştir.

33 İsviçre hukukunda yapılan düzenlemeler için bkz. ZGB Art. 482 Abs 4, 651a, 720a, 722 Abs. bis und 1 ter, 728 Abs. 1 bis ve 924 Abs 1; OR Art.42 Abs.3 ve 43b Abs Ibis ilaveten İsviçre Ceza Kanunu'nda (StGB Art.110 Ziff.4 und Art 332 ve İsviçre İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklikler (SchKG Art 92 Abs.1 Zff.1a) yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. **ARIDEMİR**, s. 327 vd.; **AKSOY DURSUN**, s.182.

34 **WIEGAND**, BSK ZGB Art.641a, N.2-4; **BELSER**, CHK ZGB Art 641a, N.2; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N 6; **AKSOY DURSUN**, s. 185.

35 **AKSOY DURSUN**, s. 188.

36 **ÜNAL/BAŞPINAR**, Giriş, II, A. 1, d.

37 BGE 115 IV 248.

38 **ERTAŞ**, EH. s.7; **GÜRPINAR**, s.174.

39 Alman hukukunda Tierschutzgesetz (TierSchG); İsviçre hukukunda Tierschutzgesetz (TschG – SR 455).

lı HHK, hayvanın bakımı (m.5), korunması ve yaşamaları (m.4), sahiplenilmesi (m.10) ile haczine dair (m.5.V) hükümlere yer vermiştir.

67 Gerçekten, TMK'da hayvanla ilgili değişiklik getirilerek hayvanın hukuki durumu ayrıca düzenlememişse de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu düzenlemesi ile birlikte eşya - hayvan- kişi, kavramsal ayrımı getirilmiş; hayvanın hukuki durumu özel olarak düzenlenmiş ve hayvanlar artık eşya olmaktan çıkmıştır[40].

68 Hayvanın bu düzenleme sonrasında eşya olarak nitelendirilmesinin kabulü mümkün değilse de hayvan olarak yeni bir hukuki –süjesi- kategorinin getirildiğinin kabulü de mümkün değildir[41]. *Hayvan yine hukuk objesi, insan da onun hukuk süjesini oluşturur.* Hayvan yine hukuki işleme konu olur, mülkiyetin konusunu oluşturur. Yani satış sözleşmesinin konusunu oluşturmakta, üzerlerinde de mülkiyet veya diğer bir sınırlı hak kurulabilir.

2. Ekonomik Bir Değeri Olan Tanımlanabilir Belirli Bir Maddi Varlık Olması

a. Belirli Maddi Bir Varlık (Belirlilik)

aa. Kural

69 Eşya, varlık özelliği olarak *somut olarak evrende üç boyutlu maddi bir kapsama* sahip olmalıdır. Eşya, evrende *somut* yer almalıdır. Bu sebeple, kural olarak, haklar (alacak hakkı, fikri ve sınai haklar), malvarlığı, eşya veya hak toplulukları, enerji eşya değildir[42]. TMK m.762 taşınır mülkiyetinin konusu olarak taşınabilir nitelikteki "*maddi şeyler*", demek suretiyle eşyanın maddi niteliğini vurgulamıştır.

70 Varlığın maddi bir varlık olduğu onun doğal niteliğinden; örneğin, taş kum gibi doğal niteliklerinden ya da örneğin kumaş veya plastik gibi insani bir faaliyet sonucu yaratılmasıyla ona verilen niteliklerden anlaşılır. Böylelikle o şey diğer maddi varlıklardan nitelik ve yapısal olarak fark edilebilir biçimde ayrışır. Maddi varlık ayrışabilir olduğundan ve kendine özgü yeknesaklığa sahip olduğunda eşya niteliğine sahip olur[43].

---

40 Aynı yaklaşım bkz. **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.10.

41 **REY**, I, N.239h.

42 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.220 ff; **REY**, I, N.81 ff; **ARNET/BELSER**, CHK ZGB Art.641, N.10; **STEINAUER**, N.61.

43 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.195.

71 Eşyanın olguları içinde yer alan maddi varlığın belirli olması unsuru, onu haklardan özellikle de fikri ve sınai hakların konusu eserden ayırır. Kişilerin düşüncesi, zekâsı, bilgi birikimi ve hisleri vasıtasıyla sanat, edebiyat veya bilim alanlarında ortaya koyduğu ürünlere "*fikri ürünler*" denir. Kişilerin bu fikri ürünler üzerinde sahip olduğu haklara da *fikri mülkiyet hakları* denir[44].

72 Geniş anlamda fikri mülkiyet hakkı kavramının hem sınai hakları hem de fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları kapsadığı kabul edilmektedir[45]. *Sınai haklar*, fikri çabası sonucu ortaya koyduğu, sanayi, ticaret ve endüstride kullanılmak üzere meydana getirilen ürünler üzerindeki hakları ifade ederken; *fikri haklar*, fikir ve sanat eserleri üzerinde eser sahibi ile bağlantılı hak sahiplerine tanınmış olan mal varlığı değerleri arasında gösterilen, eserinden ekonomik yararlanma sağlayan mali haklar ile kişilik değerleri kapsamında değerlendirilen manevi haklardır[46].

73 Fikri mülkiyet hakkı ibaresinde yer alan "mülkiyet" kelimesi, eşya hukukunun temel kavramlarından biri olan mülkiyet kavramı ile karıştırılmaktadır. Bu karışıklık fikri ürünlerin eşya sayılıp sayılmayacağı tartışmasını da beraberinde getirmektedir. Fikri mülkiyetteki mülkiyet kelimesi ile fikri ürünün eseri meydana getiren kişiye olan aitliği, bir başka deyişle eser sahibinin o eser üzerinde hak sahibi olduğu ifade edilmek istenmektedir[47].

74 Fikri bir çaba sonucunda ortaya konulan şey maddi bir varlık olan eşya üzerinde cisimlenmiş olabilir. Bu gibi durumlarda sahiplikten kaynaklı iki farklı hak türü ortaya çıkar. Bunlardan biri eşya üzerindeki mülkiyet hakkı iken diğeri fikri eserin meydana getirilmesinden kaynaklı fikri mülkiyet hakkıdır.

75 Eşyaya ilişkin mülkiyet hakkı fikri eseri meydana getiren eser sahibine ait ise iki hak tek kişide toplanmış olur. Ancak eşyaya ilişkin mülkiyetin başka bir kimseye ait olması durumunda iki hak sahibi söz konusu olur. İşte bu gibi durumlarda, eşya üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan

---

[44] **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §4, II, C, 1.

[45] **YARSUVAT**, s. 3; **TEKİNALP**, s. 1; **ÖZTRAK**, s. 5.

[46] **TEKİNALP**, s. 2; **ATAR**, s. 5.

[47] 'Fikri mülkiyet hakkı' ibaresindeki 'mülkiyet' kelimesinin rolüne ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. **IŞIK**, s. 89 vd.

kimse, sahibi olduğu mülkiyet hakkının kendisine vermiş olduğu kullanma, yararlanma ve tasarruf edebilme yetkileri bazı konularda sınırlandırılmıştır[43].

76 Fikri haklar, birçok uluslararası sözleşmenin[45] yanı sıra ulusal mevzuatımız olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunur[46]. Sınai haklar, yani marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin haklar ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile korunur[47].

77 Fikri eserler cisimleştikleri eşyadan bağımsız olarak ayrı bir korumaya tabi olur. Bir ressamın yapmış olduğu resimde, maddi varlığı teşkil eden bez tuval, eşya hukukunun konusunu teşkil ederken tuvalin üzerinde yer alan resme ilişkin düşünce, fikri mülkiyet hukuku kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısıyla fikri hakların konusu olan eser kavramı[48], eşya kavramı dışındadır. Ancak bunların taşındığı, saklandığı veya bu hakların kullanımını ve bu haklardan yararlanılmasını

---

[43] FSEK özelinde bu sınırlandırmalara FSEK m. 16'da yer alan eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı, m. 17'de yer alan eser sahibinin esere ulaşma hakkı ve m. 45'te yer alan eser sahibinin satış bedelinden pay talep etme hakkı örnek gösterilebilir.

[45] Fikri hak sahibinin hakları uluslararası düzlemde o denli korunmaktadır ki ulusal mevzuatlarda dahi eser sahibinin haklarının sınırlandırılması ancak öğretide üç aşamalı test olarak adlandırılan belirli kurallar dahilinde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. **HELVACIATAR**, s. 1289 vd.

[46] Fikri hakkı tecavüze u

sağlayan formlar (kitap, veri taşıyıcısı, film makarası vb.) eşya niteliğindedir[53].

78 Fikri haklar gibi, sınai haklar için de benzer bir durum söz konusudur. Sınai haklardan olan marka hakkı ve patent hakkı bakımından konu ele alındığında, marka hakkının konusunu oluşturan marka ile patent hakkının konusunu oluşturan patentin eşya kavramının bir parçası olup olmadığı sorunu ortaya çıkar.

79 Marka, bir eşya üzerinde cisimleşmekle birlikte soyuttur[54]. Markanın bir eşya üzerinde cisimleşerek, bir mal veya hizmetle ilgili olarak kullanılması, markayı somut hale getirmez[55]. Dolayısıyla marka, maddi varlığa sahip olmayan, başka bir ifadeyle gayri maddi bir malvarlığı değeridir[56]. Türk-İsviçre hukukunda eşya olarak nitelendirilebilmenin birinci koşulu, maddi bir varlığa sahip olma olduğundan, markanın eşya olarak değerlendirilmesi de mümkün değildir[57]. Bu sebepledir ki marka, 6769 sayılı SMK'nın korumasından yararlanırken, markanın tecessüm ettiği eşya, eşya hukuku kurallarına tabidir[58].

80 6769 sayılı SMK m. 82'de patent verilebilmesi için gereken şartlara yer verilmiştir. Söz konusu madde uyarınca "Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir". Patent gayri maddi malvarlığına dâhil bir değerdir. Patentin konusunu buluş oluşturur. Buluş bir varlık üzerinde cisimleşebilir, işte buluşun cisimleştiği bu varlık eşya hukuku kurallarına tabi olurken bu durum buluş üzerinde var olan patent hakkını somutlaştırarak maddi bir malvarlığı değeri haline getirmez. Yine SMK m. 82 de bazı buluşlara patent verilmeyeceği belirtilmiştir. İnsan vücudu ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi

---

[53] Bilgisayar programları, ilim eseri olarak FSEK kapsamında korunmaktadır (m.2 b.1). Fikri hak kapsamında olan kitabın yazılı kaynakçası veya bilgisayar programını taşıyan veri taşıyıcısının konu alan hukuki işlemlere konu olduğundan borçlar hukuku ve eşya hukuku kurallarının uygulanması gerektiği kabul edilebilir. Alman hukukunda özellikle bilgisayar programlarının satışında ayıp konusunda ayıba karşı tekeffül hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususu tartışılmaktadır. Bkz. **BYDLINSKI**, s. 304.

[54] **YASAMAN**, s. 174.

[55] **YASAMAN**, s. 174.

[56] **IŞIK**, s. 90; **SEROZAN**, Genel Bolüm, II § 4 N. 3; **KAYA**, s. 34; **OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 575; **KARAN/KILIÇ**, § 6.2; **ÇOLAK**, s. 9.

[57] **IŞIK**, s. 89.

[58] Marka hakkının mülkiyet hakkıyla olan ilişkisi hakkında ayrıntılı açıklamalar için bkz. **IŞIK**, s. 95.

ekonomik bakış açısıyla hukuki olarak da tanımlanabilir olmasını gerekli kılar[72].

97 *Sıvı ve gaz* ancak nitelik ve özelliğine uygun tanımlanabildiğinde eşya vasfını kazanır. Örneğin, süt şişeye, yağ teneke ye konulduğunda, doğal gaz tüpe, saç spreyi kutusuna doldurulduğunda eşya vasfını kazanır. Bioteknoloji ve gen teknolojisinde, *mikro organizmalar* örneğin klinik mikro organizmalar gibi eğer kontrol altında sınırlanabilirse, maddi varlık olarak eşya hükümlerine tabi tutulmalıdır[73].

98 Sanatsal faaliyet sonucu veya üretim aşamalarından geçen birbirinden bağımsız olan eşyalar fonksiyonel birliktelik sebebi ile başka bir eşyayı oluşturabilir veya başka bir eşya ile birlikteliğe bürünebilir. Bu fonksiyonel birliktelik, birlikte eşya, birleşik eşya, eşya topluluğu olarak karşımıza çıkar.

99 Aynı haklara ilişkin kurallar, belirlilik ilkesi gereği, kural olarak, eşya birlikteliklerine uygulanmaz. Eşyaların ekonomik amaçla bir araya gelmeleri durumunda, bir araya gelen eşyalar borçlar hukuku hukuki işlemlerini, özellikle konusunu teşkil edebilir. Örneğin, bir konteyner eşyanın satışı; bir hisseler grubunun satışı. Ancak bunların ifası bu birlikteliği oluşturan eşyaların her birinin mülkiyetinin ayrı ayrı devri ile tek tek gerçekleşir[74].

aa. Basit Eşya

Eşyanın fonksiyonel birlikteliğini incelemeden önce basit eşya kavramı üzerinde duralım.

100 *Basit eşya*, dışarıdan başka bir eşya ile fonksiyonel bağlantıya veya birlikteliğe girmeksizin tek başına eşya kavramının unsurlarını taşıyan eşyadır. Bir miktar eşya; tek başına eşya niteliğine sahip olmamasına karşın, belli bir miktara veya sayıya ulaştığında eşya niteliğine oluşabilen şeylerdir. Örneğin, bir küfe kömür, bir kasa tuz, bir çuval kum bir miktar eşya kavramına örnek olarak gösterilebilir.

---

72 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.69. **REY**, I. N.69. Syst. Teil. N.227; **STEINAUER**, I, N.64.

73 **HALLMANN/BURKARD**, s.50; **REY**, I. N.84, 116. Aynı yönde bkz. **ERLÜLE**, s. 102 vd.

74 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.142; **REY**, I. N.125; **STEINAUER**, I. N.79 f; **LIVER**, SPR V/1, s.14. BGE 112 II 406 ff. 410.

bb. Birleşik Eşya

101 *Birleşik eşya* ise, birden fazla basit eşyanın fonksiyonel olarak birbiriyle ayrılmaz birliktelik oluşturarak bir araya gelenlerden ayrı ve onlardan bağımsız bir şekilde eşya niteliğine sahip ayrı bir varlıktır. Motor, kasa, şase, tekerlikler, koltuklar ve diğer eşyalar motorlu aracı oluşturur.

102 Birleşik eşyayı oluşturan eşyalar onun *tamamlayıcı eşyası*dır. Tamamlayıcı eşya o şeyi oluşturarak onun tamamlayıcısı olduğundan bağımsız eşya olma niteliğini kaybederler, ayrıldıklarında da tekrar kendiliğinden eşya haline dönüşürler. Birleşik eşya oluşturan basit eşya, birleştiği eşyanın bütünleyici parçası olur. TMK m.684 I'e göre asıl eşya üzerindeki ayni haklar bütünleyici parça üzerinde de geçerli olur.

cc. Birlikte Eşya

103 *Eşya birliği veya birlikte eşya* kavramının ise hem basit hem de birleşik eşyadan ayrılması gerekir. Birden fazla eşya, niteliklerini kaybetmeksizin aralarında kurulmuş olan ortak amacı yerine getirmek için bir araya getirilmiştir.

104 Ekonomik bütünlük arz eden eşya birlikteliğinde, birlikte olan her eşya diğerlerinden bağımsız eşya niteliğini korur; diğerleri ile arasında aslilik ve ferilik ilişkisi bulunmadığı gibi, birinin kaderi diğerinin kaderine bağlı değildir[75].

dd. Eşya Topluluğu

105 Birden fazla eşyadan oluşan eşya topluluğu, oluşumun niteliği ve aralarındaki ilişki bakımından üçe ayrılır: malvarlığı (hukuki eşya birliği), eklenti (teferruat) ve fiili eşya birliği (*universitas factis*). Eşya birlikteliğinin, örneğin resim veya pul koleksiyonun ya da hak birlikteliğinin kural olarak eşya olmadığını ifade etmiş idik.

aaa. Malvarlığı (Hukuki Eşya Birliği)

106 Malvarlığı, bir kişinin mamelekinden, yani o kişinin ekonomik değeri olan mallarının, hak ve borçlarının tamamından oluşur[76]. Örneğin kişinin beklenen hakları, alacak hakları, aynı hakları, fikri hakları, malvarlığına dâhildir.

---

[75] ÜNAL/BAŞPINAR, Giriş, II. A. 4. b.

[76] MEIER-HAYOZ, BK Syst. Teil N.151; REY, I, N.131; STEINAUER, I, N.84.

Malvarlığına hakim ilkelere değinirsek:

- Parayla ölçülebilen haklar malvarlığının aktifini, borç ve yükümlülükler ise malvarlığının pasifini oluşturur. Malvarlığı aktif ve pasifiyle bir bütündür *(Bütünlük İlkesi)*.
- Malvarlığını oluşturan aktif ve pasif kalemlerinin hak sahibi süjesi veya borçlusu aynı tek kişidir *(Sahiplik İlkesi)*.
- Herkes mutlaka bir malvarlığına sahiptir (*Zorunluluk İlkesi*).

107 Kişi varlığını oluşturan kişisel değerler, malvarlığının dışındadır[71]. Malvarlığını oluşturan kalemlerin mutlaka ölümle intikal etmesi gerekmediği gibi sağlar arası tasarrufla üzerinde intikale elverişli olması zorunlu değildir. Örneğin, intifa ve oturma hakları sağlar arası tasarrufla başkalarına devredilemediği gibi gerçek kişinin ölümüyle sona erer ve buna karşın bu haklar o gerçek kişinin malvarlığına dâhildir. Malvarlığında, eşyalar arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Bağlantı bunlar üzerindeki hak sahipliği süjesi bakımından, hepsinin aynı süjenin hak sahipliğinde olmasında yatmaktadır. Malvarlığı kavramı, tereke kavramından farklıdır[72].

108 Malvarlığı, hukuki anlamda eşya kavramının unsurlarını taşımadığından, özellikle hakkın belirli objesi olamayacağından bir ayni hakkın konusunu oluşturmaz[73]. TMK m.794 I ve 814 hükümlerinde malvarlığında intifayı düzenlenmesi bu hakkın teknik anlamada sınırlı bir ayni hak olduğu anlamına gelmez; bunun malvarlığından toplu olarak yararlanma hakkı olarak kabul edilmesi gerekir[74].

109 Özel malvarlığı kavramına örnek olarak çocuğun malları, eşlerin edinilmiş veya ortak malları gösterilebilir. Özel malvarlığı, ayni malvarlığı gibi belirli olmadığından bir bütün olarak eşya olarak değerlendirilemez. Bu özel malvarlığındaki şeyler her biri, ayrı ayrı eşya niteliğinde olabilir. Özel malvarlığı, kanun koyucunun öngördüğü amaca uygun olarak, kişinin veya birbiriyle ilişki içinde olan kişilerin malvarlığına dâhil bazı şeylerin belirlenen amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle, kanunun kural-

---

71 **ANTALYA**, Manevi Tazminat, s. 49 vd.

72 **ANTALYA/SAĞLAM**, s. 34 vd.

73 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N. 152 ff.; **HAAB**, ZK Einl. N.49; **STEINAUER**, I, N.86 f.; **AYİTER**, Mamelek, s. 20 vd., 27.

74 **PIOTET**, SPR V/1, s. 638; BGE 86 II 451 ff., 460.

larıyla oluşur. Bu özel malvarlığını kanun, birtakım özel hükümlere tabi tutmuştur[21].

bbb. Fiili Eşya Birliği

110 Fiili eşya birliği, birden fazla eşyanın ortak ekonomik amacı gerçekleştirmek üzere birlik teşkil etmesidir. Örneğin; kütüphane, hayvan sürüsü, pul koleksiyonu, makyaj çantası vb. Bu koordinasyon birlikteliği onu oluşturan eşyaların bağımsızlığını ortadan kaldırmaz.

111 Fiili birlikteliğe dâhil olan eşyalar tek başlarına tasarrufa konu olmaya devam ederler. Fiili eşya birliğinde, birliğe dâhil olan basit eşyalar ortak amaç için ayrı ayrı eşit olarak işbirlığı içindedir. Örneğin, bir çift saban öküzü, bir çift koşum atı gibi.

ccc. Ekonomik Eşya Birliği: Eklenti

112 Eşya birliği, içerisinde yer alan basit eşyalardan birinin asıl eşya olarak diğeri veya diğerlerinin ona tabi olacak şekilde ekonomik bütünlük arz etmek üzere bir araya gelmeleridir. Örneğin, ayakkabı, ayakkabı kutusu veya bağı; gözlük ve gözlük kabı; fotoğraf makinası ve kılıfı, flaşı; lens ve filtre gibi. İşte eşya birliği içinde ekonomik bakımdan asıl eşyaya bağlı olan eşya, eklentidir.

113 TMK m. 686 I eklenti kavramını şu şekilde tanımlamıştır: *"Eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır."*

114 Eklenti, asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu nitelığını kaybetmez. Eklenti asıl şeyden ayrı bir eşyadır; ancak asıl şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar.

c. Ekonomik Bir Değeri Olan Maddi Bir Varlık (Ekonomik Değerlilik)

115 Maddi varlığın hukuki anlamada eşya sayılabilmesi için ekonomik değeri olması gerekir[22]. Zira hakkın tanımında yer aldığı üzere, eşyada hak sahibi olan kişinin o şeyden hukuki menfaati olması gerekir. Ekono-

---

[21] **MEIER-HAYOZ,** BK Syst. Teil N.156.

[22] Aksi görüş bkz. **AKİPEK/AKINTÜRK,** s.28; **ÜNAL/BAŞPINAR.** Giriş, II. A. 1. d.

mik değeri olmayan şeyler örneğin tane deniz kumu, bir taş parçası, bir ağaç dalı eşya hukuku yönünden eşya sayılmamalıdır[83].

116 Hukuki menfaatin, mutlaka malvarlığına ilişkin menfaat olması gerekli değildir; şahıs varlığına giren kişisel değerlerde, örneğin hatıra mektubu, fotoğraf gibi varlıkların eşya sayılması için de menfaat unsuru gerçekleşmiştir[84].

3. Maddi Varlık Üzerinde Hukuki Olarak Hâkimiyete Elverişli Olmalı (Edinmeye Elverişlilik)

117 Bir şeyin hukuki olarak eşya olarak kabul edilmesi için, onun maddi varlığının fiili ve hukuki olarak üzerinde hâkimiyet kurmaya elverişli olması gerekir[85]. Eşya üzerindeki hâkimiyet kurmaya elverişlilik iki yönde değerlendirilmelidir:

- Fiili hâkimiyet kurulabilirlik ve
- Hukuki hâkimiyet kurulabilirlik[86].

118 Fiili hâkimiyet kurulabilirliği örnekleyecek olursak, güneşin insan için halen daha ulaşılmaz olması, hâkimiyet altına alınamaz ve sınırlandırılamaz olmasından hareketle, eşya olarak kabul edilemez olduğunu söyleyebiliriz.

119 Gökyüzü veya açık deniz, nehir, akarsu[87] vb. niteliğindeki varlıklar, genel mallar *(res communes omnium)* olarak adlandırılmaktadır. Genel mallar da kural olarak eşya niteliğinde değildir. Ancak genel mallar, mekan ve zaman olarak belirli sınırlamalarla hâkimiyet altına alınarak, yararlanmaya elverişli hale getirilebilir. Genel mallar sınırlandırılmış şekliyle veya kapsamıyla hukuki olarak eşya olarak kabul edilebilir.

---

[83] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 6; **AYİTER**, s. 4; **AYAN**, I. Giriş, II.A.

[84] Menfaat kavramı hakkında geniş açıklamalar için bkz. **TOPUZ, M.** İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, İstanbul 2011, s. 133 vd.

[85] **LIVER**, SPR V/1, s.11; **REY**, I, N.77; **STEINAUER**, I, N.86 f.

[86] **WIEGAND**, BSK ZGB Vorb. Art.641 N.11.

[87] Nehir, akarsu ve derenin bir taşınmazın sınırları içinde akması halinde, bu suyun eşya niteliği tartışmalıdır. Bkz. **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.127; **HUBER**, ZSR 1900, s.519 ff; **WIEGAND**, ZGB Art.641, N.2a. Bize göre akan sular ve yeraltı suları hâkimiyete elverişli olmadığından eşya niteliğine sahip değildir (Hakim görüş için bkz. **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.125 f; **LIVER**, SPR V/1, s.11 f; **WIEGAND**, BSK ZGB Vorb. Art.641 N.12).

120 Eşya üzerinde hâkimiyet sadece fiili değil, hukuki olarak imkânsız olmamalı ve yasal olmalıdır[64]. Roma hukukunda bazı nesneler -*res sacre*- hukuki olarak eşya nitelığı dışında değerlendirilmiştir. Günümüzde kamusal malları buna örnek olarak verebiliriz.

C. Çeşitleri

121 Eşya, çeşitli açılardan ayrıma tabi tutulur. Bu ayrımlardan biri olan basit eşya- birleşik eşya ve bu kapsamda bir miktar eşya ve eşya topluluğu incelenmiştir. Aşağıda ise eşyanın diğer ayrımlara göre çeşitleri incelenecektir:

1. Özel Mülkiyete Konu Eşya - Kamu Mülkiyetine Konu Eşya

122 Özel hukuka tabi tüm eşyalar, toplumsal yaşam ilişkilerine konu olabilir. Başka bir deyişle özel eşya hakkın konusu (objesi) olabilir; özel hukuk işlemine konu olabilir ve üzerinde tasarruf edilebilir. Kamu mülkiyetine tabi eşyalar ise, üzerinde ya hiç toplumsal yaşam ilişkilerine konu olmaz ya da sınırlı olarak bu türden ilişkilere konu olur.

123 TMK m. 715 I hükmü, "*...yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.*" düzenlemesi ile TMK m. 715 II hükmü ise, "*Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, özel hukuk kişisinin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz.*" düzenlemesi ile genel mallarla ilgili karine yer vermektedir.

124 TMK m.715 III ise, yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tabi olduğu ifade etmiştir. Kamu mülkiyetine tabi eşyaları, kamusal mallar ve diğer kamu mülkiyetine tabi eşyalar başlığı altında inceleyebiliriz:

a. Kamu Malları

125 Kamu malları, kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal amaçlarının yerine getirilmesine hizmet eden ya da kamunun kamusal ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan maddi varlıklardır[65].

---

[64] **WIEGAND**, BSK ZGB Vorb. Art 641 N.13.

[65] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.177 f; **HAAB**, ZGB Art 654 N. 4 ff; **REY**, I, N.177; **REY/STREBEL**, BSK ZGB Art. 664, N.7 ff; **WIEGAND**, BSK ZGB Vorb. Art.641 N.39

126 Bir malın kamu malı olup olmadığı, mülkiyet ilişkisine, özellikle ilişkinin tarafına bakarak belirlenmez; maddî varlığın amacının belirlenmesiyle tespit edilir[50]. Maddî varlık kamusal bir amacının yerine getirilmesine, kamusal bir fonksiyonun veya görevin yerine getirilmesine hizmet ediyorsa, kamu malı niteliği söz konusudur[51].

127 *Dar anlamıyla* kamu malları ikiye ayrılır:

- İdarenin kamusal malları ve
- İdarenin genel malları[52].

Geniş anlamıyla kamu malları içine bu ikisine ilaveten kamu finans malları da ilave edilmektedir.

128 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Taşınır ve Taşınmaz Satışı" başlıklı 46'ncı maddesinde "*Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir...*" hükmü yer almaktadır.

129 Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsisin kaldırılması ve satışı, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la düzenlenmiştir.

130 Özel kanunlarla verilen yetkiler dışında, kamu (hazine) malları konusunda genel yetkili kuruluş Milli Emlak Genel Müdürlüğü'dür. Bu kapsamda örneğin, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik[53] çıkarılmıştır.

---

[50] **RENTCH**, ZBGR 1980, 339.

[51] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.178.

[52] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.1177 f; **HAAB**, ZGB Art.664, N. 4 ff; **REY**, I. N.177; **WIEGAND**, BSK ZGB Vorb. Art.641 N.39. İsviçre hukukunda kamu mallarının dualist yapısı için Bkz. **HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN**, N. 1847 ff.

[53] R.G. 19.06.2007.

131 Kamu malları üzerindeki tasarruf, kamu hukuku kurallarına tabidir. Kamu malları, kamu hukukuna dair mülkiyet kurallarına tabidir. Kamu hukuku kuralları, malı kullanma yetkisini ve kullanma amacını belirler. Ancak kamu malları tasarrufu konusunda bir kamu kuralı bulunmaması durumunda, özel hukuk kuralları, özellikle TMK nın eşya hukuku kuralları, niteliğine uygun olduğu ölçüde kıyasen uygulanır. Kamu mallarının mülkiyetinin kapsamı da kamu kuralları tarafından belirlenir. Bu kurallar, kamu malının hizmet ettiği amacın ve kamu ödevinin yerine getirmesi kapsamına göre kamu mallarının kapsamını belirler ve yine bu kurallar şekilde yorumlanır[54].

132 İdarenin özel mülkiyete tabi eşyası da söz konusu olabilir. İdarenin kamu malı dışındaki eşyaları özel hukuk hükümlerine tabidir. Buna ilaveten kamu malı maliki olan idare, malik sıfatıyla TMK m. 730 hükmü uyarınca sorumludur[55]; TBK m. 69 OR Art. 58 uyarınca yapı maliki olarak sorumludur[56]. Özel hukuka tabi bir taşınmazın kamulaştırma ile kazanımı (TMK m.705) veya kamu taşınmazı üzerindeki bir hakkın tapuda devri sözleşmesi de özel hukuk şekil kurallarına tabidir (TMK m.706)[57].

aa. İdarenin Kamu Malları

133 İdarenin yani kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş ve hizmet amacının yerine getirilmesine hizmet eden kamu mallarıdır. Bunlara 'kamu yönetim malları' da denmektedir.

134 Kamu mallarına taşınmaz eşya örneği olarak; valilik gibi yönetim binaları, hastane binaları, okul gibi hizmet binaları veya taşınır eşya örneği olarak araç, büro masası, ameliyat malzemesi veya ilaç, sıra ya da kitap olabilir. Bu kamu mallarının kullanım kapsamı da amaçları ve amaçta belirlenen ödevleri yerine getirmeyle sınırlıdır. Kamu malları, kamu finans mallarından farklı olarak, özel hukuka konu olamaz. Örneğin kamu malları rehin edilemez; üzerlerinde inşaatçı ipoteği kurulamaz[58].

135 Dini yerlerden idarenin ibadete tahsis ettiği yerlerden örneğin cami, şadırvan, abdesthane, mescit vb. idarenin kamu mallarıdır. Buna karşın

---

54 **LIVER.** SPR V/1. s.131 REY. I. N.179.

55 **ANTALYA,** EH I, N. 155 vd.

56 **ANTALYA,** BH GH II, s 307 vd.

57 **MEIER-HAYOZ,** BK ZGB Art 644. N.83. **HAAB.** ZK ZGB Art.664. N.27.

58 BGE 108 II 305 ff; 124 III 337 f.

dini vakıfların, özel hukuk kişilerinin ibadete tahsis ettiği yerler ise, özel hukuk hükümlerine tabidir.

bb. Genel Mallar

136 Genel mallar kamu amaçlı olarak herkesin kullanımına ve yararlanmasına açık olan mallardır. Kamunun yararlanması, yararlananın onun maddesel varlığına müdahale hakkı vermez. Bu yararlanma, kamusal yararlanma kapsamından ve onun belirlediği sınırlar içinde gerçekleşir.

137 Genel maldan herkesin yararlanması kamu idaresinin rıza veya iznine bağlı olmadığı gibi, bedelsizdir[59]. Özel ve genel nitelikli ortak mal kullanımı idare tarafından ücretlendirilebilir[60].

138 Genel malların bir kısmını, kamuda herkesin kullanımı söz konusudur. Örneğin cadeler, köprüler, meydanların herkes tarafından kullanılması gibi. Diğer kısmı ise *tabiat varlıklarıdır*; örneğin dağ, tepe ova, plato, orman, buzullar, bunlardan çıkan kaynaklar vb. veya *kamu sularıdır*, örneğin göller, nehirler, akarsular, dereler, yeraltı suları vb.[61].

139 Genel mallar mülkiyet konusu olmasa da tabiat varlığı olan araziden tarıma elverişli olan yerlerin mülkiyete konu olması mümkündür[62]. TMK m.715 II hükmü tarıma elverişli olmayı, arazilerin mülkiyete konu olabilmesi noktasında bir istisna olarak düzenlemiştir.

cc. Kamu Finans Malları

140 Kamu malları içinde değerlendirilen kamu finans malları ise sermaye değeri veya onun getirisi olarak kamusal amacın yerine getirilmesine hizmet eden kamu mallarıdır.

Kamu finans malları sermaye, değişim getirisi olarak umuma açık olan ve doğrudan kamusal amaç ve bu amaçta belirtilen ödevin yerine getirilmesine hizmet etmeyen mallardır. Devlet tahvilleri, hazine bonoları, tasarruf bonoları, gelir ortaklığı senetleri gibi kamu menkul değerleri, kamu finans mallarına örnek olarak gösterilebilir.

---

[59] **HAAB**, ZK ZGB Art 664, N.7; **HEBERLEIN/BREITSCHMID/BELSER/RIEDER**, CHK ZGB Art 664, N.8.

[60] **HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN**, N.2392.

[61] **REY**, BSK ZGB Art 664, N.11 f.

[62] Bkz. **MEIER-HAYOZ**, BK ZGB Art 664, N.148 f.

141 Bu kamu finans malları dış ilişkide, özel hukuk hükümlerine tabidir[C3]. Bu mallar üzerinde sınırsız olarak tasarruf edilebilir[C4]. Buna karşın idarenin özel hukuk alanındaki faaliyetleri, örneğin bankacılık faaliyetleri, kanunla kurulsa veya ondan kaynaklansa da doğrudan kamusal bir ödeve ve amaca hizmet etmediğinden özel hukuk hükümlerine tabidir.

142 Mülkiyeti özel hukuk tüzel kişisinde olan bir eşya, kamusal amaçlı olarak bir kamusal ödevin ifasında kullanılsa bile, örneğin üniversite vakıflarının malları, dini vakfın malları, özel hukuk hükümlerine tabidir.

b. Diğer Kamu Mülkiyetine Tabi Mallar

143 Kamu yararı amacıyla bir eşyanın üzerindeki tasarruf ya da yararlanma, sınırlanabilir veya kaldırılabilir[C5]. Bu sınırlama savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi olağanüstü kamu düzeni sebeplerine dayanabilir; askeri savunma ve güvenlik amaçlı olabilir. Yine ormanların, meraların, çevrenin, kültür ve tabiat varlıkları vb. korunması amacına yönelik olabilir. İmar, inşaat ve şehircilik amaçlı olabilir.

144 Yabancıların, özellikle ülke sınırları içinde taşınmaz devralması sınırlandırılmıştır[C6]. Bu konu üzerinde kısaca durursak:

aa. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi

145 2644 satılı Tapu Kanunu'nda 6302 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca m.35 I'de aranan 'mütekabiliyet (karşılıklılık) şartı' kaldırılarak, "*Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen – 183 - ülke- vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye'de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilecekleri; ancak yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu*

[C3] **LIVER**, SPR V/1, s.128; **REY**, I. N.182; **HEBERLEIN/BREITSCHMID/BELSER /RIEDER**, CHK ZGB Art.664, N.7. Ayrıca bkz. **HAFELIN/MÜLLER/UHLMANN**, N.1843.

[C4] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.83; **REY**, Syst. Teil. N.207.

[C5] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.212; **HAAB**, ZK Einl. N.34 f; **REY**, I. N.194 ff.

[C6] 2012 yılı Bakanlar Kurulu kararına göre, sit alanlarında, sit alarını belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğünden izin alınması gerekir. Adalardaki taşınmazlarda, çişleri Bakanlığından izin alınması için talep yazısı yazılmaktadır. Tarım arazi vasfı için 2013/15 sayılı genelge eki taahhütname ile Tarım İl Müdürlüğü'ne sorulmaktadır.

ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı..." geçemeyeceği sınırlaması getirilmiştir[107].

bb. Yabancı Ticari Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi

146 Tapu Kanunu m.35 II'ye göre, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketler, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde, örneğin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu[108], 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu[109], 6326 sayılı Petrol Kanunu[110] çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler[111]. Bu ticaret şirketleri dışındakiler taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu ticaret şirketleri ile yabancı uyruklu gerçek kişiler lehine taşınmaz rehni tesisinde bu maddede yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Ayrıca askeri bölgelerde taşınmaz edinimleri Genelkurmay Başkan-

---

[107] Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçüm ve miktar olarak belirleme, sınırlandırma, kısmen veya tamamen durdurma veya yasaklayabilme yetkisine sahiptir (Tapu Kanunu m.35/IV).

[108] 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 8/E maddesi uyarınca, imar planında turizm kullanımına ayrılmış alanlarda turizm sektöründe faaliyette bulunmak kaydıyla 2644 sayılı tapu kanununun 35 ve köy kanununun 87'nci maddelerinde yer alan koşul ve sınırlamalardan Bakanlar Kurulu Kararı ile istisna edilebilmekte, dolayısıyla bu alanlarda bu amaçlarla taşınmaz mal edinebilmektedirler. Yine aynı kanunun 8/D maddesi uyarınca, turizm yatırım belgesine sahip yabancı uyruklu ticaret şirketlerine Turizm Bakanlığınca bu alanlardaki taşınmaz mallarda TMK uyarınca taşınmaz mal niteliğindeki bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı ve irtifak hakkı tesis edilebilmektedir. Ancak bu taşınmaz malların imar planlarında turizm kullanımına ayrılmış alanlar içerisinde yer alması ya da turizm yatırımının gerçekleşmesini sağlayacak imar planının yapılması (mevzii imar planı) gerekmektedir.

[109] 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa göre kurulan üretim bölgeleri içindeki taşınmaz mallar üzerinde yasanın 4. maddesi gereğince Yabancı Ticaret Şirketleri lehine irtifak hakkı tesis edinebilmektedir.

[110] Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, 6326 Sayılı Petrol Kanununun 12/2 maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla petrol çıkarmak için gerekli taşınmaz mal ve sınırlı ayni hak edinebilmektedirler. Bu Kanundaki esaslara uygun olmak şartıyla, sermayelerinde kamu payı bulunanlar da dâhil, sermaye şirketlerine veya yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzelkişilerine müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi verilebilir (m.6/2). Kanunun 87. maddesi gereği, "*Bir petrol hakkı sahibi; arama işletme veya belge sahasında veya civarında petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazinin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaşma veya kamulaştırma yolu ile; arazi sahipsiz ise arama ruhsatnamesine işletme ruhsatnamesine veya belgeye kaydedilmek suretiyle iktisap edebilir.*"

[111] Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır. İlgili Bakanlıkça başlama ve bitirilme süresi belirlenerek onaylanan proje tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilir. Onaylanan projenin süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgili Bakanlıkça takip edilir (Tapu Kanunu m.35/IV).

lığı'nın ya da yetkilendireceği komutanlıkların; özel güvenlik bölgesinde ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliklerin iznine bağlı tutulmuştur.

147 Tapu Kanunu m.35 hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyenler ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınırlamalar dışında miras yoluyla edinilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek bir yılı geçmeyen süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde, tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.

148 Satış vaadi sözleşmelerinin şerhi, yabancıların başvurularında kanuni sınırlama ve prosedürlere bakılmaksızın uygulanmaksızın şerh verilebilir. Finansal kiralama işlemleri, banka ve kredi işlemi olması sebebiyle örneğin X Katılım Bankası A.Ş tarafından, Y Varlık Kiralama A.Ş'ye taşınmaz satış işlemi veya Y Varlık Kiralama A.Ş tarafından X Katılım Bankası A.Ş'ye taşınmaz satış işlemi idari sürece tabi değildir.

149 Tapu Kanunu'nun 3. maddesine göre, "*Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tanınmış olan yabancılara ait dini, ilmi, hayrı müesseselerin fermanlara ve Hükümet kararlarına müsteniden sahiplendikleri gayrimenkuller bu belgelerin sınırları dışına çıkmamak ve Hükümetin izni alınmak şart ile müesseselerin hükmi şahsiyetleri namına tescil olunabilir*".

cc. Yabancı Sermayeli Ticari Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi

150 Tapu Kanunu m.36'ya göre; yabancı uyruklu gerçek kişilerin (Türk vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamındaki kişiler hariç), yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin, uluslararası kuruluşların, %50'si veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkına haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye'de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere Türkiye'de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler[12].

[12] 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 36. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığı'nın 16.08.2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 36. maddesi kapsamındaki şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı

151 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu şirketlerin, askeri yasak bölgeler ile askeri güvenlik bölgeleri ve aynı Kanunun 28. maddesi çerçevesinde belirlenen (Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde) bölgelerdeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığı'nın ya da yetkilendireceği komutanlıkların veya özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir.

152 Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler, gibi yatırım bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimlerinde belli sürede elden çıkarma zorunluluğunun devam etmesi kaydıyla bankaların, Bankacılık Kanunu çerçevesinde kredi veya alacaklarını tahsil amacıyla edinmiş oldukları taşınmazlarda bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu kapsamdaki edinilen taşınmazların kullanımı Valiliklerce belli aralıklarla takip edilir.

153 Tapu Kanunu 36 madde kapsamındaki yabancı sermayeli şirketlerin 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında kiracı olması ve finansal kiralama konusunun taşınmaz mal olması halinde bu sözleşme yazılı şekilde yapılır ve söz konusu sözleşme kütüğün şerhler hanesine kaydedilir. Sözleşme süresi sonunda taşınmazın kiracı adına devri öngörülmüşse kira süresi sonunda taşınmazın devri talep edildiğinde, idari – valilik- süreç işletilecektir[3].

Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik" çıkarılmış ve taşınmaz ya da sınırlı ayni hak edinim süreçleri belirlenmiştir. Bu Yonetmelik hükümlerine gore, 36. maddenin yeni hükmüne istinaden, Yabancı yatırımcıların şirketteki ortaklık oranlarının birlikte veya ayrı ayrı %50 veya daha fazla olması veya şirket yoneticilerinin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulunduğu tespit edilen yabancı sermayeli şirketlere ilişkin Yetki Belgesinde "2644 sayılı Tapu Kanununun 36. maddesi kapsamındaki Yabancı Sermayeli Şirkettir" ibaresine yer verilmesi gerekmektedir. Söz konusu yetki belgesinde bu ibarenin bulunduğu yabancı sermayeli şirketlerin ilgili yönetmelik gereğince gerekli evraklar ile Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Valilik şirket başvurusundan sonra 3 iş günü içerisinde edinilmek istenen taşınmazın Askeri Yasak Bölge, Askeri Güvenlik Bölgesi veya 2565 sayılı kanunun 28. maddesi kapsamında kalıp kalmadığını, Genel Kurmay Başkanlığına veya yetkilendireceği Komutanlıklara, Özel Güvenlik Bölgesi içinde kalıp kalmadığını İl Emniyet Müdürlüğünden veya İl Jandarma Komutanlığından sorar. İlgili komutanlığın, İl Emniyet Müdürlüğünün veya İl Jandarma Komutanlığının 15 gün içinde cevap vermesi gerekmektedir. Aksi halde soz konusu taşınmazın belirtilen alanlar içinde kalmadığına hükmedilerek işlem yapılır. Edinilmek istenen taşınmaz yukarıda belirtilen bölgeler dışında kaldığının tespit edilmesi halinde tescil işleminin yapılması için Valilik tarafından şirket veya iştirak ile Tapu Müdürlüğüne 3 iş günü içinde yazılı bilgi verir. Yazılı bilginin şirket veya iştirake tebliğinden itibaren 6 ay içinde tescil talebinde bulunulması gerekmektedir. Bu konuda bkz. Tapu ve Sicil Genel Müdürlüğü'nün 17.09.2012 tarihinde 2012/13 sayılı Genelgesi.

[3] TOPUZ, M., Finansal Kralama (Leasing) Sozleşmesi, İstanbul 2017, s. 261 vd.

2. Taşınır Eşya – Taşınmaz Eşya

154 Eşyanın taşınır ve taşınmaz olarak ayrımının Roma hukukunda fazla önemi olmamasına karşın, Pandekt hukukunun eşya yaklaşımında temel rol oynamaktadır. İsviçre-Türk eşya hukuku da Pandekt hukukundaki bu temel ayrımı esas alarak eşya hukuku kurallarını düzenlemiştir[114].

155 TMK'nın dördüncü kitabı olan Eşya Hukuku taşınır ve taşınmaz ayrımına uygun olarak, birinci kısmının ikinci bölümü taşınmaz mülkiyeti (m.704-761) ve taşınır mülkiyeti (m.762 -778) ayrımıyla, ikinci kısım olan sınırlı ayni haklar ikinci bölüm taşınmaz rehni (850-938), üçüncü bölüm taşınır rehni (m.939-972) ayrımıyla, üçüncü kısmı genellikle taşınırları ilgilendiren zilyetlik (m. 973-996) taşınmazlarla ilgili tapu sicili (m.997-1026) şeklinde düzenlenmiştir. Zira bu ayrım eşyanın dış dünyadaki görünümüne ve fonksiyonelliğine uygun bir ayrımdır.

156 Eşyanın taşınır ve taşınmaz şeklindeki ikili ayrımı sadece eşya hukukunda değil, diğer özel hukuk alanlarında etkili olmaktadır. Örneğin, TBK'nın satış sözleşmesi hükümleri, bu ayrıma uygun olarak, taşınmaz satışı (m. 213 vd.) ve taşınır satışı (m.184 vd.) olarak düzenlenmektedir[115].

157 Bir eşya, taşınmaz mülkiyeti konusuna girmiyorsa ve bulunduğu arazi ile sıkı surette bağımlı bulunmuyorsa, konusu ve nitelikleri bakımından özüne zarar gelmeden başka bir yere nakledilebiliyorsa veya hukuk kurallarınca taşınır olarak belirlenmişse bu eşya, taşınır eşyadır. TMK m. 762'de taşınırın konusunu belirleyen hükmünde taşınır kavramını tanımlamıştır.

158 Taşınmaz mülkiyetinin konusu ise TMK m.704 hükmünde tek tek sayılmıştır. Ayrıca TMK m.998 taşınmaz mülkiyeti konusu olabilen taşınmaz eşyaları, tapu kütüğüne kaydedilebilecek taşınmaz olarak tekrar saymıştır:

- Arazi,
- Tapu sicilinde ayrı bir sayfaya kaydedilebilen taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar,
- Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.

---

[114] **HAAB**, ZK ZGB Einl. N.26. vor N.1 ff. **WIEGAND**, BSK Vor Art.641. N.21; **REY**, I. N.153.

[115] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.168; **WIEGAND**, BSK Vor Art.641. N.21; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 25; **ACAR, F.**, Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, Tıpkı 2. Basım. İstanbul 2017, s. 1 vd.

159 Yukarıda sayılanlar arasında arazi, taşınmazın tipik konusunu oluşturur[116].

160 Taşınmaz eşya olarak sayılan eşyalardan hareketle, taşınmaz eşya ise, konusu ve nitelikleri bakımından özüne zarar gelmeden başka bir yere nakledilemeyen, hukuk kurallarının taşınmaz olarak belirlediği eşyalardır. Taşınır ile taşınmaz ayrımının temelini, eşyanın bir yerden diğer bir yere taşınması (nakledilmesi) oluşturmaktadır.

161 Taşınır eşyanın bir yerden başka yere naklı, onun doğal niteliği sonucu gerçekleşebileceği gibi bir dış güç marifetiyle de gerçekleşebilir; bu farklılık taşınır-taşınmaz ayrımı yönünden önemli değildir. Bazı taşınırlar da taşınmazla olan ilişkileri sebebiyle taşınmaz hükümlerine tabi kılınmıştır[117]. Örneğin araziye sahip olan o şeyin bütünleyici parçası olan taşınırlarında maliki olur (TMK m.684).

162 Aynı şekilde, TMK 685 III'e göre doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır. Eşyanın nakledilmesi veya nakledilememesi temel kriteri yanında, örneğin TMK m.762, edinmeye elverişli şeyleri örneğin, doğal güç ve enerjiyi de taşınır olarak belirlemiştir.

163 Benzer şekilde TMK m.704 daimi ve süreklı hakkı tapu kütüğüne kaydedildiğinde taşınmaz olarak kabul etmiştir.

164 Yine niteliği tartışmalı olan kat mülkiyetine kayıtlı bağımsız bölüm, taşınmaz olarak kabul edilmiştir.

165 Öyleyse, nakledilebilme kriteri yanında eşyaya, onun fonksiyonuna uygun olarak, kanun koyucunun yüklediği nitelik de önemlidir. Kanun koyucunun nitelemesi de eşyanın nitelik ve özeliğine en yakın veya kapsam itibarıyla da düzenlemenin temel -taşınır veya taşınmaz- ayrımına uygun nitelemedir. Bu niteleme toplumsal ilişkilerin sosyal ve ekonomik dinamiğine de uygundur.

166 Diğer özel kanunlarda da, örneğin İİK m.23 ve 136 hükmünde niteliği taşınır olan gemiyi, taşınmaz hükmüne tabi tutmuşken, 6103 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası İİK m. 23 son fıkrasında gemi bu kanun yönünden taşınır hükümlerini tabi tutmuştur. TTK m. 954 ve devamında

---

[116] MEIER-HAYOZ, BK Syst. Teil N.170.

[117] HAAB, ZK Einl. N.27.

gemiler taşınmaz hükümlerine benzer (örneğin özel bir gemi sicilinin varlığı) şekilde düzerlemiştir.

3. Misli Eşya - Misli Olmayan Eşya

167 **Misli eşya**, hakim görüşe göre, genel yaşam ve ticaret ilişkilerine göre her bir parçasının tek başına özel ayrı bir özelliği bulunmayan ve bu sebeple biri aynı özellikteki diğeri yerine ikame edilen eşyalardır[18]. Örneğin, para, fabrikanın endüstriyel seri üretimleri, doğal ürünler[19].

168 Başka bir deyişle, misli eşyalar, BGB § 91'de ifade edildiği üzere; sayı, ağırlık ve uzunluk gibi bir ölçü esasına göre aynı nitelikteki şeylerin hep birlikte bir araya geldiği ve birbiri yerine ikame edilebilen şeylerdir[20]. Örneğin, bir kasa turunç, on adet yumurta, on metre şile bezi, kırk litre motorin.

169 Eşyanın mislliliğinin, tarafların – biri veya her ikisinin- veya malikin –veya zilyedin- iradesinden değil; eşyanın objektif nitelığından ve özelliğinden kaynaklanması gerekir[21]. Eşya hukuku bakımından misli eşya, belirli bir miktara veya kapsama geldiğinde bir bütün olarak eşya niteliğine kavuşur ve bu şekliyle bağımsız bir eşyadır.

170 Misli eşyanın karışması TMK m.727'de düzenlenmiştir.

171 **Misli olmayan eşya** ise, misli eşya kavramının tam tersidir. Örneğin; arazi, 24 numaralı apartman dairesi, 34 GA 349 plakalı motorlu araç, "Mavi" isimli tekne, sanat eseri, özel üretim mobilya, özel üretim araçları, özel dikim takım elbise[22].

172 Misli olan eşya - misli olmayan eşya ayrımı eşya hukuku dışında da özellikle borçlar hukuku alanında önem taşır[23]. Satış sözleşmesinin konusunu oluşturan misli eşya ayıplı ise, alıcı TBK m.227/I'deki seçimlik hakka sahiptir; bu imkân misli olmayan eşya bakımından tanınmamıştır. Bazı sözleşmelerin, örneğin tüketim sözleşmesi (TBK m.386) veya havalenin (TBK m.555) konusu ise sadece misli şeylerdir.

---

[18] **REY**, I, N.153.

[19] Diğer örnekler için bkz. **MEIER- HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.175 f.

[20] **WIEGAND**, BSK Vor Art.641, N.25; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 26; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.9; **ÜNAL/BAŞPINAR**, Giriş, II. A. 4. c.

[21] **HAAB**, ZK ZGB Einl. N.29; **ÜNAL/BAŞPINAR**, Giriş, II. A. 4. c. Ekz. **ANTALYA**, BH GH I. s. 57.

[22] Diğer örnekler için bkz. **MEIER- HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.176 f.

[23] **ANTALYA**, BH GH. I. s. 57.

4. Parça Eşya – Çeşit (Cins) Eşya

173 Misli eşya ve misli olmayan eşya kavramı, parça eşya ve çeşit (cins) eşya ayrımından farklıdır. Ancak misli eşya her zaman çeşit (cins) borcunu oluşturduğu halde, tam tersi söz konusu değildir.

Misli eşya ve misli olmayan eşya, eşyanın niteliği ve özelliğinin objektif değerlendirmeyle belirlenirken; parça eşya ve çeşit (cins) eşya ayrımı ise eşyayı borcun konusu haline getiren, tarafların iradesinden hareketle yapılacak irade yorumu ile belirlenir[24].

174 Parça borcu ve çeşit (cins) borcu ayrımı eşya hukuku yönünden önemsizdir. Bu ayrımın, borçlar hukuku yönünden özel bir önemi vardır[25]. TBK bu ayrımdan hareketle, çeşit borcunu TBK m.86'da düzenlemiştir: "*Çeşit borçlarında hukuki ilişkiden ve işin özelliğinden aksi anlaşılmadıkça, edimin seçimi borçluya aittir. Ancak borçlunun seçeceği edim, ortalama nitelikten daha düşük olamaz*".

5. Tüketilebilen Eşya – Tüketilemez Eşya

175 **Tüketilebilen eşya**, eşyanın niteliği veya özelliği onun amacına uygun şekilde bir kere – belirli bir ölçüde - kullanımıyla yok olan, maddi varlığı ortadan kalkan- eşyadır. Örneğin; ekmek, tuz, şeker, meyve, sebze gibi gıdalar, krem gibi kozmetik maddeler, kömür, odun, motorin gibi yakıtlar.

176 **Tüketilemez eşya** ise, tüketilebilenin tam tersi kavramı ifade eden, örneğin buzdolabı, bulaşık makinası, buzdolabı, cep telefonu vb. eşyalardır. Taşınmazlar, tüketilmez eşyadır[26].

177 Mübadele araçları örneğin para ve elden çıkarmak üzere istifade edilen eşya da, örnek vermek gerekirse kitapçıya satılmak üzere bırakılmış kitap da tüketebilir eşya niteliğindedir. Para örneğinden devam edersek, parayı bankaya olan kredi borcunu ödediğini sanarak bankaya yatıran müşteri, paranın bankadan iadesini mülkiyete ilişkin istihkak davası ile isteyemez; sebepsiz zenginleşme ile talep edebilir. Zira paranın mülkiyeti bankaya geçmiş, müşterinin parası diğer paralarla karışmış durumdadır[27].

---

[24] BGE 121 III 453 ff. 456.

[25] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.180. Borçlar hukukunda parça borcu–çeşit (cins) borcu ayrımı ve bu ayrımın önemi konusunda bkz. **ANTALYA**, BH GH I. s. 56 vd.

[26] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.183; **STEINAUER**, I. N.104.

[27] **EREN**, Mülkiyet, s.513; **ÜNAL/BAŞPINAR**, Giriş, II. A. 4. d. Aksi görüş için bkz: **BURCUOĞLU**, Para, s.93 vd.

178 Tükenmez ve tüketilebilen eşya, misli eşya ile misli olmayan eşya ayrımında olduğu üzere, objektif olarak eşyanın arzulanan kullanım amacına göre ayrılır. Bu konuda ilk olarak belirleyici olan eşyanın yaşam ve ticari ilişkisine göre kullanımıdır[28].

179 Tüketilmez eşya ve tüketilebilen eşya ayrımı eşya hukukunda aşağıdaki noktalarda önemlidir[29]:

180 İntifa hakkının sona ermesi üzerine intifa hakkı sahibi, hakkın konusunu malike geri vermekle yükümlüdür (TMK m.799). Eğer geri vermekle yükümlü olunan mal tüketilmez eşya ise aynen geri verilmelidir; buna karşın tüketilebilir nitelikte eşya söz konusu ise, bu eşya misli nitelikte ise aynı miktar ve nitelikte eşya geri verilmelidir; gayri misli eşya söz konusu ise iade yükümlülüğü ikinci tazminat yükümlülüğüne dönüşür.

181 TMK m.808 II uyarınca, intifa hakkının konusu tüketilebilen eşya malik tehlikenin ispatına gerek olmaksızın teslimden önce güvence isteyebilir.

182 TMK m.819 I hükmüne göre tüketilebilen şeyin mülkiyeti, aksi kararlaştırılmadıkça, intifa hakkı sahibine geçer. İntifa hakkı sahibi geri verme esnasında, tüketilen şeyin iade günündeki değerini ödemekle yükümlüdür.

183 Tüketilmesi için özgülenen şeyler, eklenti sayılmaz (TMK m.687).

184 Bu ayrım borçlar hukuku yönünden de önem taşımaktadır. Ödünç sözleşmesinin iki çeşidi olan kullanım ödüncü ile tüketim ödüncü ayrımına temel olan ölçüt, ödünç konusunun tüketilebilir olup olmamasından ileri gelir.

185 Kullanım ödüncünün konusu tüketilmez eşyadır (TBK m.379).

186 Tüketim ödüncünü tanımlayan TMK m.386 hükmü sözleşmenin konusunu "*bir miktar para ya da tüketilebilen bir şey*" olarak belirlemiştir[30].

187 İlaveten, TMK m.570 mislen iadesi kararlaştırılan paranın saklanmasını, özel olarak düzenlemiştir: Bırakılan paranın yararı ve hasarı saklayana ait olur.

---

[28] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.184; **HAAB**, ZK ZGB Einl. N.30.

[29] **REY**, I, N.165 f.

[30] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.184.

6. Bölünebilen Eşya – Bölünemeyen Eşya

188 **Bölünebilen eşya**, maddi varlığın değerini kaybetmeksizin birden fazla parçaya bölünebilen ve bölündüğünde de ekonomik olarak daha küçük, fakat taşıdığı çeşit (cins) niteliğinin özelliğini koruduğu birden fazla eşyalara ayrılabilen eşyadır[131]. Bölünebilen eşya, genellikle cins (çeşit) eşyadır. Para, ekonomik bir değişim aracı olarak kağıt veya madeni paraya bölünebilen bir eşyadır.

189 **Bölünemeyen eşya** ise, bölündüğünde ekonomik değeri önemli ölçüde azalan veya ortadan kalkan eşyadır[132]. Örneğin resim, motorlu taşıt, bilgisayar vb.

190 Bölünebilir eşya ve bölünemez eşya ayrımı, eşyanın fizikı niteliği yanında hukuki bölünebilirliği ile de gerçekleşmelidir. Bölünebilirlik de belirli bir kapsamla sınırlandırılabilir[133]. Kısmi bölünebilirlik de söz konusu olabilir. Örneğin bir TIR araç bölümü, kasası ve konteynerden oluşur. Bu üç aşamaya kadar bölünme söz konusu olabilir.

191 Bölünebilir eşya ile bölünemez eşya ayrımı, elbirliği ile mülkiyetin sona ermesi sonrasında paylaşmanın nasıl yapılacağına ilişkin paylı mülkiyete yapılan atfı düzenleyen TMK m.703 II hükmünün uygulanmasında ve paylı mülkiyetin sona ermesinde paylaşmayı düzenleyen TMK m.699 III hükmünün uygulanmasında önem taşır. Bu hükme göre eşya bölünebiliyorsa aynen paylaşma; bölünemiyorsa açık artırmaya çıkması sonrasındaki satış bedelinin paylaşılması şeklinde gerçekleşir. Tereke mallarının paylaşımında TMK m.651 hükmü, değerinde önemli azalma olmadan bölünemeyen tereke malı, bütün olarak bir mirasçıya özgülenir; bölünemez eşyanın kime tahsis edileceği hususunda mirasçılar anlaşamazlarsa, o bölünemez mal satılır ve bedeli bölüşülür[134].

192 Borçlar hukukunda, borcun konusu yönünden, bölünemeyen eşyanın ifası, TMK m.85'te düzenlenmiştir:

"Bölünemeyen bir borcun birden çok alacaklısı varsa, alacaklılardan her biri, borcun alacaklıların tamamına ifasını isteyebilir (f.1). Borçlu, edimini alacaklıların hepsine birden ifa etmek zorundadır (f.2). Bölü-

---

[131] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.189; **REY**, I. N.167.

[132] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.189; **REY**, I. N.169.

[133] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 10; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 32; **AYAN**, s. 48.

[134] **ANTALYA/SAĞLAM**, s. 440 vd.; **AVCI**, s. 172 vd.

nemeyen borcun birden çok borçlusu varsa, borçlulardan her biri borcun tamamını ifa etmekle yükümlüdür. Durumun gereğinden aksi anlaşılmadıkça, ifada bulunan borçlu, alacaklıya halef olur ve diğer borçlulardan payları oranında alacağını isteyebilir (f.3)".

7. Sahipsiz Eşya

193 Sahipsiz eşya, taşınır ya da taşınmaz olsun, tasarruf edilebilir olmasına karşın üzerinde mülkiyet kurulmamış eşyadır[35]. Sahipsiz eşya üzerinde, örneğin yaban balı, deniz veya nehir balıkları, doğa hayvanlarında olduğu gibi ya hiç mülkiyet kurulmamıştır ya da kurulmakla birlikte takip eden zamanda sona erdirilmiş, örneğin terk edilmiş, tekrar mülkiyet kurulmamış eşyadır. Sahipsiz taşınmazla ilgili olarak TMK m.707 (işgal) ve m.717 (terkin ve yok olma) hükümleri; sahipsiz taşınırlarla ilgili olarak TMK m.767 (sahipsiz şeyler), m.768 (sahipsiz duruma gelen hayvanlar), m.772 (define), m.773 (bilimsel değeri olan eşya) ve m.778 (kaybedilmesi) hükümleri konuyu düzenlemektedir.

194 Bir eşyanın sonradan sahipsiz hale gelmesi durumunda, onun üzerindeki sınırlı ayni hak bundan etkilenmez; varlığını devam ettirir[36]. Taşınmazlar yönünden, TMK m.715.I'e göre, sahipsiz yerler, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Sahipsiz yerlerin kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tabidir (TMK m.715 II). Sahipli eşya devren iktisapla veya zamanaşımı ile kazanılabilirken, sahipsiz eşya aslen kazanılır.

II. AYNİ HAK

A. Kavram

1. Ayni Hak ve Ayni İşlem Tanımı

195 Ayni hak, hakim görüşe göre, hak sahibine eşyanın üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet yetkisi veren ve ihlal eden herkese –üçüncü kişiye- karşı ileri sürülmesi yetkisi veren bir – sübjektif- bir haktır[37]. Farklı

---

[35] **MEIER-HAYOZ,** BK Syst. Teil N.217; **HAAB,** ZK ZGB Einl. N.22. **WIEGAND,** BSK Vor Art 641. N.40; **LIVER,** SPR V/1. s.143; **REY,** Syst. Teil. 173.

[36] **MEIER-HAYOZ,** BK Syst. Teil N.217; **HAAB,** ZK ZGB Einl. N.32. **WIEGAND,** BSK Vor Art 641. N.40.

[37] **MEIER-HAYOZ,** BK Syst. Teil N.235 f. **REY,** I. N.200, Syst. Teil. N.20; **RIEMER,** II. § 3 N.2; **PIOTET,** SPR V/1, s.608 f; **WIEGAND,** BSK Vor Art.641. N.45; **SCHMID/HURLIMANN-KAUP,**

bir görüş ise, ayni hakkı düzenleme fonksiyonu ile açıklamaktadır[38]. Ayni haktan doğan talep de ayni taleptir.

196 Ayni hakkın kurulması, içeriğinin değiştirilmesi, devri, ortadan kaldırılması veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin sözleşme, *ayni hukuki işlem*dir. Ayni hukuki işlem karşımıza *ayni sözleşme* veya *ayni tek taraflı işlem* olarak çıkar. Ayni işlemelere ilişkin olarak, niteliklerine uygun olduğu ölçüde, TBK'nın sözleşmelere ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

2. Ayni Hakkı Açıklayan Görüşler

197 Ayni hak kavramının ve bunun hukuki olgularının ne olduğu konusunda, tarihsel gelişim içinde iki temel görüş savunulmuştur: "klasik görüş" ve "kişisel (şahısçı) görüş". Bu iki görüşe de yönelen eleştiriler sonrasında günümüzde ağırlıklı olarak kabul gören görüş, bu iki görüşü telif eden "karma görüştür". Bu görüşleri aşağıda kısaca inceleyeceğiz[39]:

a. Hâkimiyet Görüşü

198 Klasik görüşü ifade eden doğrudan hâkimiyet görüşü (Unmittelbarkeitstheorie)[40], hakkın iç kapsamından hareketle, ayni hakkı hak sahibine eşya üzerinde tanınan yetkiden hareketle tanımlamaktadır: Ayni hak, kişilere eşya üzerinde doğrudan doğruya verilmiş en geniş olarak sınırsız şekilde tanımış haktır. Bu görüş, ayni hakkın mutlak hak niteliğine ilişkin olguya yer vermektedir. Bu görüş, aşağıda inceleyeceğimiz üzere, ayni hakkın amaçsal olgusunu ihmal etmektedir.

b. Kişisel (Şahısçı) <*erga omnes*> Görüş

199 Kişisel (şahısçı) görüş (<*erga omnes*> Theorie) ise[41], ayni hakkın dış kapsamından hareketle, hak sahibinin diğer kişilere karşı sahip olduğu haktan hareketle ayni hakkı tanımlamaktadır: Ayni hak, bir eşya üzerin-

---

N.18 f; **İMRE**, Ayni, s.333 vd.; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 3-4; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.7 vd; **AYAN**, s. 32; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.13. Alman hukukunda bkz. **SEILER**, Staudinger, Rn. 17 ff.; **STADLER**, Soergel, Rn. 24.

[38] Bkz. **SEILER**, Staudinger, Rn. 17 ff.; **STADLER**, Soergel, Rn. 24.

[39] Bu görüşler için bkz. **İMRE**, Ayni, s.328 vd.; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 3-4; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s.6 vd.; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.3 vd.; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.1' vd.; **AYAN**, s. 29 vd.

[40] Bkz. **LIVER**, SPR V/I, s.9; Einl. zu ZGB Art.730-792, N.2 f. Alman hukuku için bkz. **PALANDT/BASSENGE**, Einl. Vr § BGB, N.2. BGE 104 II 170 ff. 177.

[41] Bkz. **STEINAUER**, I N.15, ZSR II, s.213 ff. **KRAMER**, Allg. Einl. vor OR Art.1, N.46. Alman hukuku için bkz. **WINDSCHEID/KIPP**, Bd.I, § 38; **AICHER**, s.63.

deki haktır ki, hak sahibi bu hakkını ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir. Bu görüş, aşağıda inceleyeceğimiz üzere, ayni hakkın -normatif olgusunu ihmal etmektedir.

c. Karma Görüş

200 Karma görüş, hâkimiyet görüşü ile şahısçı görüşü telif ederek, ayni hakkın hem iç, hem de dış kapsamını ortaya koyacak şekilde, amaçsal olgu ile birlikte normatif olguya yer verecek şekilde ayni hak kavramını tanımlamaktadır. Katıldığımız görüş uyarınca yukarıda ayni hak kavramı, bu şekliyle tanımlanmış ve hukuki olguları incelenmiştir.

d. Düzenleme Görüşü

201 Almanya hukuk doktrininde düzenleme görüşünü (Zuordnungslehre) savunan bazı yazarlar, ayni hakkın herkese karşı olan mutlak etkisinin ve bununla birlikte geri isteme ve kaçınma taleplerinin, kısaca eşya üzerindeki doğrudan hâkimiyetin, başka bir deyişle *ayni hakkın fonksiyonu* olarak eşyayı düzenlemesinin sonucudur[42].

202 Aynılığın varlığı, onun düzenlediği fonksiyonla belirlenir. Eşya ile olan doğrudan ilişki, davadaki korumanın soyutluğu ve hak sahibinin hukuk alanına dâhil konuların kapsamı, ayni fonksiyonun sonucu olarak düzenlenmiştir[43].

203 Bu görüşten hareketle *Zobl*, sınırlı ayni hakkın konusunun zorunlu olarak eşya olmasını gerekli görmemektedir. Yazar, alacaklar ve diğer haklar sınırlı ayni hakkın konusu olarak kanun tarafından açıkça düzenlenmesi yeterli görmüştür[44].

3. Ayni Hakkın Çifte Yapısal Olgusu

204 Ayni hak, tanımında yer aldığı üzere, iki temel hukuki olgunun birlikteliği halinde oluşur[45]: Birinci hukuki olgu: amaçsal olgu olarak, eşya üzerinde hak sahibine doğrudan hâkimiyet verme olgusu. İkinci hukuki olgu: normatif olgu yani ona mutlak hak niteliği veren yani hakkın herkese karşı ileri sürülebilmesi olgusu (yasak kuralı).

---

[42] **WESTERMANN.** § 2. II s.9.

[43] **WESTERMANN.** § 2. IV, s.15.

[44] **ZOBL,** Syst. Teil. N.153c.

[45] **REY,** Syst.Teil. N.20 ff. I. N.208 ff. **SIMONIUS/SUTTER.** I. N.3: **BAUR/STÜRNER.** § 2. N.2: **SOERGEL,** Münchkomm., Einl Vor § 854 BGB.

205 *Rey*, ayni hakkın bu çifte hukuki olguların kombinasyonundan, oluştuğunu ifade etmektedir[145].

Portmann'a göre, ayni hakkın bu çifte yapılı kombinasyonu, aynı zamanda ayni hakkın tipini de belirlemektedir. Yazara göre bu yapı, mülkiyet ve *olumlu irtifak* ilişkisi, temel hak ve buna yasaklama hakkı ile bu sınırlı ayni hakkın konusunda yetkili olma arasındaki ilişkiyi; mülkiyet ile olumsuz irtifak ilişkisinde, temel hak ve buna ilişkin yasaklama hakkı ile bu sınırlı ayni hakkın konusunda kaçınma talebi arasındaki ilişkiyi; son olarak da mülkiyet ile rehin arasındaki ilişki temel hak ve bu hakka ilişkin yasaklama hakkı ve yararlanma hakkı (Genussrecht) ile yapabilme hakkı (tasarruf hakkı) (Verfugungsrecht) ilişkiyi izah etmektedir[147].

a. Eşya Üzerinde Doğrudan Hâkimiyet Vermesi (Amaçsal Olgu)

206 Ayni hak, tarımında da yer aldığı üzere kümülatif olarak iki temel hukuki olgudan oluşur: birinci hukuki olgusu, amaçsal olgu olarak adlandırılan, eşya üzerinde hak sahibine doğrudan hâkimiyet verme olgusudur. Ayni hak, nispi hakkın özellikle alacak hakkının aksine, konusu eşya üzerinde direkt, üçüncü bir kişinin aracılığı olmaksızın etkili olur. Bu doğrudan hâkimiyet, mülkiyet hakkında söz konusu olduğu gibi, sınırlı ayni hakta da söz konusudur.

207 Eşya üzerindeki hâkimiyet, hak sahibinin eşya üzerindeki hakkının ihlalini yasaklar ve ona eşyanın doğal ve hukuki semerelerinden yararlanmaya ilişkin ayni hak verdiği gibi; eşyanın maddi varlığını bozma, hatta yok etme hakkını da hak sahibine verir[148].

208 Ayni hak, malikine konusu olan eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet hakkı verdiği halde; alacak hakkı, sadece alacaklıya borcun konusu olan edimi talep yetkisi verir. Bu etki, eşyayı hâkimiyet altına almak için dolaylı bir yetkidir.

Alacak talep edilse bile, talep eşya üzerinde hâkimiyeti sağlamaya yetmez. Borçlu talep üzerine, borcu olan eşyayı devretmeyebilir. Bu takdirde, alacaklı şartları varsa mahkeme kararı ile borçluyu takip edebilir

---

[145] **REY**, I, N.208.

[147] **PORTMANN**, N.387 ff.

[148] **MEIER-HAYOZ**, Syst.Teil. N.242 ff; **LIVER**, SPR V/1, s.9; Einl. zu ZGB Art.730-792, N.3; **REY**, Syst. Teil, N.31 ff; I, N.212; **RIEMER**, II, § 3, N.2

veya aleyhine aynen ifa davası açabilir. Açılan davada alınacak ifa kararı ile cebri icra ile eşyaya teslim alabilir.[145]

209 Doktrinde bir kısım yazarlar hâkimiyetin sadece maddi varlığı olan eşya üzerinde kurulabileceğini ileri sürerek, hak- alacak hakkı- üzerinde intifayı veya rehni (TMK m.794, 820 vd.) sınırlı ayni hak olarak kabul etmemekte, mutlak hak olarak nitelememektedir[151]. Bu görüşe katılmamız söz konusu değildir[152].

210 Dar anlamda eşya sayılmayan, ancak eşya olarak kabul edilen doğal güç ve enerjinin, yine hamiyet kurulabilmeye elverişli eşya olduğunu yukarıda incelemiş idik[153].

b. Herkese Karşı İleri Sürülebilmesi (Mutlak Hak – Normatif Olgu)

211 Ayni hak, tanımında yer aldığı üzere, birinci hukuki olgusu olan amaçsal olguya kümülatif olarak ilaveten ikinci hukuki olgu olan normatif olgu, yani ona mutlak hak niteliği veren olgu olarak herkese karşı ileri sürülebilme olgusundan oluşur.

212 Borçlandırıcı ilişkiden doğan hak, sadece ilişkinin tarafı olan borçluya karşı ileri sürülebilirken (*nispi etki*); ayni hak, herkese karşı ileri sürülür (*ayni etki*). Roma hukukunda bu etki *erga omnes* olarak ifade edilmiştir.

213 Ayni hak, mutlak hak niteliğine sahip olduğundan *erga omnes* etkiye sahiptir. Ayni hakkın konusu sadece eşya olduğundan diğer mutlak haklardan bu yönüyle ayrılır. Ayni hakkın herkese karşı olan etkisi, ihlal eden kişi tarafından ayni hakkı bilinebilir olması şartına bağlıdır. Ayni hakkın bilinebilir olması, *alenilik ilkesi*nin sonucudur.

214 Alenilik ilkesi yanında, ayni hakkın görünüm şekli ve görünen şeklinin kapsamının da belirli olması gerekir. Bu sebeple kanun hak sahibinin sahip olunabilecek ayni hakların sayısını sınırlı -*numerus clausus*- olarak belirlemiştir. Bu ilke *tipe bağlılık* ilkesi olarak ifade edilmektedir. Yine

---

[145] **MEIER-HAYOZ,** Syst Teil. N.40; **LIVER,** SPR V/1, s.9; Einl. zu ZGB Art.730-792, N.2; **REY,** Syst. Teil. N.27; I. N.210. BGE 1342 II 155 ff. 164.

[150] Karş. **MEIER-HAYOZ,** Syst Teil. N.229 ff. 245; **LIVER,** SPR V/1, s.24; Einl. zu ZGB Art.730-792, N.21; **REY,** Syst. Teil. N.28, 227 ff; I, N.211.

[151] **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP,** N.20; **STEINAUER,** I. N.15.

[152] **ANTALYA,** EH I, N. 103, 104, 105.

kanun, ayni hak sahibinin ayni hakkın kapsamını düzenleme yetkisini sınırlamıştır; bu ilke de *tipin belirliliği ilkesi* olarak ifade edilmektedir.

B. Niteliği

1. Ayni Hakkın Bir – Subjektif- Hak Olması

215 Hak, kişiye hakkın konusundan yararlanmak üzere bir yetki verir. Hak sahibinin bu yetkisi, kişinin irade özerkliği ile ilgili olan kural koyma yetkisi ile yakından ilgilidir. Kural koyma yetkisi, hak sahibi olan kişiye karşı, diğer hukuk süjelerinin hakkın konusuna uygun olarak davranmalarını veya aykırı davranmamalarını gerekli kılar[53]. Yani üçüncü kişi hak sahibinin hukuki yetkisine uygun davranmakla yüklenmektedir.

216 Kişi, hakkına ilişkin kural koyma yetkisini hukuk kurallarına uygun kullanmalıdır. Örneğin dürüstlük kuralına uygun olmalıdır (TMK m.2)[54]. Yine, ayni haklar, hak olarak özel hukukun genel kurallarındaki hükümlere örneğin, ehliyet, kamu düzenine uygun kullanılmalıdır.

217 Yine ayni hak kullanımı, örneğin ateşli silahlar 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un özel hükümlerindeki veya ilaç, reçete ile ilgili sağlık mevzuatındaki özel hükümlerindeki devir ve tasarruf sınırlamalarına ve yasaklarına tabidir[55].

218 Haklar, nispi haklar (özellikle alacak hakları) ve mutlak haklar diye ayrılır.

2. Mutlak Hak Niteliğinde Olması (Mutlaklık İlkesi)

a. Genel Olarak

219 Mutlak haklar, herkese karşı ileri sürülebilen ve bu sebeple hak sahibi dışında herkesin uymakla yükümlü olduğu haklardır[56]. Ayni haklar da mutlak hak olduğundan mutlaklık (Absoultheit) ilkesi geçerlidir[57].

---

[53] **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §3. I vd.

[54] Bkz. **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §11. I vd.

[55] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.237; **REY**, I. N.202. Syst. Teil, N.4.

[56] **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.17.

[57] Alman hukukunda hakim olan bu ilke için bkz. **SEILER**, Staudinger BGB Einl. SachenR, Rn. 37; **STADLER**, Soergel BGB Einl. SachenR. Rn. 27; **JOOST**, MünchK BGB Einl. SachenR, Rn. 10; Ayrıca bkz. **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §4. II, C. 1.

220 Mutlak haklar; ayni haklar yanında, kişilik hakkı[54] ve fikri ve sınai haklar (marka hakkı, patent hakkı, tasarım hakkı, model hakkı vb.) olmak üzere üç temel gruba ayrılır.

221 Ayni haklar, mutlak haklar grubuna dâhildir. Ayni hakkın tanımında yer alan herkese karşı ileri sürülebilme yetkisi, hakkın mutlak hak niteliğini ortaya koyar. Herkes ayni hakka uygun davranmakla yükümlüdür. Ayni hak sahibi, hakkını ihlal eden her kimse, bu kişiye karşı hukuki korunma talep etme hakkına sahiptir.

222 TMK m.683 II mülkiyet hakkının korunmasına ilişkin istihkak davasında, "*malikin, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı*" mülkiyet hakkının korunmasını talep edebileceğini ifade etmiştir.

Bu sebeple, öncelikle ayni hakkı diğer mutlak haklardan ayırt etmemiz gerekir; sonra mutlak hak ile nispi hak ayrımına, mutlak hakkın nispi haklardan özellikle alacak hakkından ayrımına değinmemiz gerekir.

b. Diğer Haklardan Ayrılması

aa. Diğer Mutlak Haklardan

223 Mutlak haklar ayni hak olarak sadece eşya hukukunda düzenlenmiş değildir. Mutlak haklar aynı zamanda kişiler hukuku, aile hukuku ve fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında da düzenlenmişlerdir.

224 Ayni hakları diğer haklardan ayıran nitelik ve özellik farkları kısaca aşağıda belirtilmiştir[55]:

225 Ayni hak sadece eşyayı konu aldığı halde, diğerlerinin konuları, örneğin kişilik değeri beden bütünlüğü, ad, fikir ve sanat eserleri, sır, marka, patent gibi farklıdır.

226 Ayni hakların konusu malvarlığına dâhil olduğu halde, diğer haklar ise genellikle kişi varlığına dâhildir. Bu sebeple, ayni hak konusu eşya, sağlar arası ve ölüme bağlı borçlandırıcı, kazandırıcı ve tasarruf işlemlere konu olur. Buna karşın kişi varlığı hakları bakımından ise kural olarak tam tersi kural geçerlidir, örneğin TMK m.25 IV hükmü uyarınca bunlardan doğan manevi tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmedikçe dev-

[54] Kişilik hakkı ve kişilik değerleri için bkz. **ANTALYA**, Manevi Tazminat, s. 49 vd.

[55] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.10; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s.6; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.11; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.43.

ıedilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmedikçe mirasçılara geçmez[60].

bb. Nispi Haktan, Özellikle Alacak Hakkından

aaa. Genel Olarak

227 Nispi haklar, özellikle alacak hakkı, iki taraf arasındaki borç ilişkisinden kaynaklanır. Alacaklı, bu hakkını üçüncü kişiye karşı değil; kural olarak sadece borç ilişkisinin tarafı olan borçluya karşı ileri sürebilir; ondan borcun konusu olan edimi yerine getirmesi (verme, yapma, yapmama) talep edilir[61].

bbb. Ayni Hakkın Alacak Hakkından Farkları

228 Ayni hak ile alacak hakkının farklarını şu şekilde sıralayabiliriz[62]:

- Ayni hakların konusu sadece eşyadır; alacak hakkının konusu eşya olabilir, ancak onun dışında belirlenebilir.

- Ayni hakkın konusu olan eşya belirli, en azından belirlenebilir olmalıdır; alacak hakkı gelecekteki beklenen hak ya da bekleme durumundan, mirasçılık beklentisinden doğan hakka da konu alabilir.

- Ayni hakkın konusu hak sahibinde mevcut, yani var olan eşyayı konu olabildiği halde; alacak, borçlusunda bulunmayan edimi de konu alabilir.

- Ayni haklar sürekli, alacak hakları geçicidir.

- Ayni hak, malikine konusu olan eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet hakkı verdiği halde; alacak hakkı, sadece alacaklıya borcun konusu olan edimi talep yetkisi verir. Bu etki, eşyayı hâkimiyet altına almak için dolaylı bir yetkidir. Alacak talep edilse bile, talep eşya üzerinde hâkimiyeti sağlamaya yetmez. Borçlu talep edilse dahi, borcu olan eşyayı devretmeyebilir. Bu takdirde, alacaklı şartları varsa mahkeme kararı ile borçluyu takip edebilir veya aleyhine aynen ifa davası açabilir. Açılan davada alınacak ifa kararı ile cebri icra marifeti ile eşyayı teslim alabilir.

---

[60] Bkz. **ANTALYA**, BH GH II, s. 160; **ANTALYA**, Manevi Tazminat, s. 67 vd.

[61] **KRAMER**, BK Allg. Einl. OR vor Art.1, N.43 ff. Bkz. **ANTALYA**, EH GH I, s. 21.

[62] **İMRE**, Ayni, s.325 vd.; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s.10 vd.; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.4, 16 vd.; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 44, 51 vd.; **AYAN**, s.34 vd.

- Ayni hak, mutlak hakların ortak olgusu gereği herkese karşı ileri sürülebilirken; alacak hakkı, kural olarak borç ilişkisinin borçlusuna karşı ileri sürülebilir.

- Borcun kaynakları farklıdır. Alacak hakkı; hukuki işlem, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve diğer borç ilişkilerinden kaynaklanır. Ayni hak ise kaynağını, kanunda belirlenen hukuki olguların gerçekleşmesinde bulur. Örneğin, taşınmaz mülkiyetinde, mülkiyet hakkının tapu sicilinde tescil edilmiş olması gerekir.

- Ayni haklar tipiklik yani sınırlı sayı ilkesine tabi olup, tıpık olarak ayni hakların kapsamları da belirlenmiştir. Alacak hakkı ve bu hakkın kapsamının belirlenmesinde ise, irade muhtariyeti (özgürlüğü) prensibi geçerlidir.

- Yenilik doğuran haklar kanunda öngörülen süre içerisinde kullanılmazsa sona erer. Muaccel alacaklar ise, yine kanunun öngördüğü sürede talep edilmezse zamanaşımına uğrar. Dolayısıyla, nispi haklar hak düşürücü süre ile zamanaşımı süresine tabidirler. Buna karşılık ayni hakların hak düşürücü süre veya zamanaşımına uğraması mümkün değildir. Dolayısıyla üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, ayni hakka konu eşyanın fiilen kullanılmaması ayni hakkı sona erdirmediği gibi; bir başkasının eşyadan sırf fiilen uzun süre istifade etmesi de aynı hak sahibinin ona karşı talep ve dava hakkını ortadan kaldırmaz[63]. Örneğin Bay (A) köydeki tapulu tarlasını 50 yıl kullanmamış olsa bile, tarla yine Bay (A)'nın mülkiyetindedir. Ayni hak olan mülkiyet hakkı zamanın geçmesiyle ortadan kalkmaz.

ccc. Ayni Hakkı ile Alacak Hakkı Ayrımının Sonuçları

(1). Unsurları ve Hakka Etkileri Yönünden

229 Her ikisinin de eşyayı konu alması durumunda; ayni hak bakımından ayni hakkın konusu eşyanın kendisi, malvarlığının aktifine dâhildir. Alacak hakkında ise, ifanın konusu eşya değil; eşyayı talep yetkisi veren alacak hakkı malvarlığının aktifinde yer alır. Alacak hakkı, eşya üzerinde bir hâkimiyet ve yaralanma hakkı vermez; ifanın konusu eşyanın aynen ifasını talep hakkı verir[64].

---

[63] Ayrıntılı bilgi için bkz. **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 112 vd.; **AYAN**, s. 36; **ESENER/GÜVEN**, s. 52. Hak düşürücü süre ile zamanaşımı süresi hakkında geniş bilgi ve farkları için bkz. **ERDEM**, s. 5 vd., özellikle s. 25-33.

[64] Aynen ifa için bkz. **ANTALYA**, BH GH III, s. 170.

230 Aynı haklar eşyanın hukuki aidiyetini kime ait olduğunu belirlerken; alacak hakları ise eşyanın hukuki aidiyeti üzerinde etkili olmazlar, bir değişiklik yaratmazlar. Alacak hakları, hukuki aidiyetin değiştirilmesine ilişkin talep hakkı verirler[65].

(2). Korunması Yönünden

231 Aynı hak ile alacak hakkı arasındaki temel ayrım hukuki sonuçlarda etkisini gösterir.

232 İlk olarak alacak hakkının ihlali borç ilişkisinin tarafı olan borçlu tarafından gerçekleşebilir; kural olarak üçüncü kişilerin alacaklı ile borçlu arasındaki, borç ilişkisini ihlalleri söz konusu olmaz. Alacaklının kural olarak, alacak hakkının üçüncü kişinin ihlallerinden dolayı hukuki korunması söz konusu değildir. Üçüncü kişinin borçlunun davranışından sorumluluğu istisnadır[66]. Örneğin, üçüncü kişinin davranışı ahlaka aykırı davranış teşkil edebilir[67].

233 Buna karşın ayni haklar, hakkı ihlal eden herkese karşı ileri sürülür. Ayni hakkın muhatabı sadece borç ilişkisinin tarafı değil; herkestir. Ayni hak sahibi hakkın korunmasını, hakkını ihlal edene ileri sürme hakkına sahiptir; hatta malik rızası dışı elinden çıkan eşyasını, bazı istisnalar dışında, kimin elinde olursa olsun geri alabilme yetkisine sahiptir (TMK m.683, 689).

(3). İcra-İflas Hukuku Yönünden

234 Aynı haklarla alacak hakkı ayrımının, gerek icra hukukunda gerekse iflas hukukunda, ayrı bir önemi vardır.

235 İlamsız takipte para ve teminat alacağı takibi (İİK m.42) ile ipotek ve rehinle teminat altına alınmış alacaklar (İİK m.45) ayrı olarak, taşınır ve taşınmazların haczi, neticeleri ve muhafaza tedbirleri özel olarak (İİK m.86 vd.) düzenlenmiştir. Alacakların haczi ise İİK m.89'da farklı olarak düzenlenmiştir.

236 Borçlunun elinde bulunan hacze konu bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği itirazı (İİK m.96) sonrasında ve direkt olarak, üçüncü bir kişi tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkına ilişkin istih-

---

[65] UNAL/BAŞPINAR, s. 52.

[66] ANTALYA, BH GH I, s. 23.

[67] ANTALYA, BH GH I, s. 23.

kak iddiası İİK m.97'de özel olarak düzenlenmiştir. Bu istihkak davalarında mülkiyet karinesine ilişkin özel bir hüküm bir getirilmiştir (İİK m.97/a).

237 Taşınırların satışı (İİK m.112 vd.) ve taşınmazların satışı (İİK m.123 vd.) özel olarak düzenlenmiştir.

238 Taşınır rehninin paraya çevrilmesi (İİK m.145 vd.) ve ipoteğin paraya çevrilmesi (İİK m.148 vd.) özel takip yolu olarak düzenlenmiştir.

239 İflas hukukunda da bu ayrımın özel önemi vardır. Örneğin, İİK m.190 hükmüne göre alacak hakkı olan alacağını iflas masasına alacak olarak kaydettirme imkânına sahipken, ayni hak sahibi, iflas halinde müflisteki bulunan eşyasının iflas masasından ayrılıp (ayırma hakkı), kendisine verilmesini masadan isteyebilir.

c. Eşyaya Bağlı Haktan Ayrılması

aa. Kavram

240 Alacak haklarının sadece borç ilişkisinin tarafı olan borçluya karşı ileri sürülmesinin kural olmasına karşın; kime ileri sürüleceği bakımından, alacak hakkının ayni hakkın bazı özellikliklerine yaklaştığı durumlardan birisi de eşyaya bağlı borç haktır.

241 Eşyaya bağlı borç, en dar anlamıyla, bir kimseyi bir mala malik olduğu için yükümlülük altına sokan borçtur.

242 Eşyaya bağlı hak, en dar anlamıyla, bir kimseyi bir mala malik olduğu için talep yetkisi veren haktır. Bu benzerlik eşyaya bağlı hakkın, ayni haktan ve alacak hakkından ayrılmasını zorlaştırmaktadır.

243 Eşyaya bağlı hak terimi, İsviçre hukukunda "obligation dite reelle", "obligation propter rem", "sübjektive dingliche Rechte" olarak yeknesak bir terminoloji kullanılmış olsa da "Realobligation" terimi ile yerleşmiştir. Türk hukukunda ise, *Oğuzman* ilk defa "sübjektif ayni hak" anlamına gelen bu terim karşılığında "eşyaya bağlı hak" terimini kullanmış[66] ve bu terim doktrinde benimsenmiştir[65].

---

[66] **OĞUZMAN**, Eşyaya Bağlı Haklar, s. 209 vd. Ayrıca bkz. **OĞUZMAN**, Hakim Olan Esaslar, s. 107 vd.; Eşyaya Bağlı Borçlar, 225 vd.

[65] **EREL**, Eşyaya Bağlı Borç, s.4; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.16; **AYİTER**, s.3; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s.39; **HATEMİ/SEROZAN/ARPACI**, s.384; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 45; AYAN, s. 37.

244 Eşyaya bağlı borç veya hak, durum borçlarının (Zustandobligation) bir çeşididir. Durum borçları, tarafların içinde bulundukları hukuki durum veya ilişkiyi düzenleyen hukuki statü dolayısıyla tarafların alacaklı veya borçlu sıfatına sahip olduğu ilişkidir[170].

245 Eşya bağlı borç (veya hak) kavramını, bir borç ilişkisine konusu olan olumlu bir edimi yerine getirilmesi yükümlülüğünün (veya hak sahipliğinin), kısaca borçlunun (veya alacaklının), eşya üzerindeki hak sahipliği ile bazı durumlarda zilyetlikle somutlaşarak belirlendiği hukuki ilişki olarak tanımlayabiliriz[171]. Başka bir deyişle, eşyaya bağlı borç (veya hak), bir kimsenin bir şey üzerinde sahip bulunduğu ayni hak ve zilyetlik dolayısıyla borcun (veya hakkın) konusu olumlu edimin alacaklı veya borçlu olmasıdır. Bu ilişkiyi *eşyaya bağlı borç ilişkisi* olarak isimlendirmekteyiz.

246 *Eşyaya bağlı hak* sadece alacaklı tarafı, *eşyaya bağlı borç* ise sadece borçlu tarafı ifade eder. Eşya bağlı hakla birlikte borçluluğun ayni hak sahipliği ya da zilyetliğe bağlandığı *karşılıklı eşyaya bağlı hak ve veya borç* da söz konusu olabilir[172].

247 Eşyaya bağlı borç *Meier-Hayoz*'un belirttiği üzere iki temel özelliğe sahiptir[173]: Merkezde yine *borçlandırıcı ilişki* ve bu ilişkide borçlunun edimine (yapma, yapmama ve kaçınma) ilişkin yükümlülük (hak veya alacak) yer almaktadır. Sadece olumlu edimler eşyaya bağlı borcun konusu olabilir[174].

Borçlandırıcı ilişkide, edimi ifa edecek borçlu (edimi talep edecek alacaklı), ifanın konusu olan eşya üzerinde ayni hak sahipliği belirlemektedir. Kısaca, *ayni (reel) olgu* ise, borç ilişkisinin de borçlu veya alacaklı sıfatını belirlemektedir.

bb. Niteliği

248 Eşyaya bağlı haklar İsviçre hukukunda Almanca dilinde eser veren yazarlarca genellikle nispi hakkın kuvvetlendirilmesi olarak kabul edil-

---

[170] **EREL**, Eşyaya Bağlı Borç, s. 5; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 45.

[171] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.271; **REY**, Syst. Teil. N.85; I, N.240; **LIVER**, Einl. zu ZGB Art.730-792, N.148; **STEINAUER**, I, N.53.

[172] **REY**, Syst. Teil. N.85; I, N.240.

[173] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.71. Aynı yaklaşım: BGE 116 II 667 ff. 682.

[174] BGE 116 II 677; REY, I, N.247 f.

mekteyken[75]; Fransızca dilinde eser veren yazarlarca ise, "droits personnels renforcés" olarak ayrı bir kategoride değerlendirmektedir[76].

cc. Karakteristik Olguları ve Bunlar Arasındaki İlişki

aaa. Genel Olarak

249 Eşyaya bağlı borç ilişkisindeki hakta, nispilik niteliği değişmeksizin, aynı ve nispi element birbirine bağlanmakta, nispi nitelikteki alacak hakkı aynı bir elementi kapsamına almaktadır[77].

250 Eşyaya bağlı borç ilişkisi, nispilik ilkesinin istisnasını teşkil eder, ancak ilişkinin nispilik niteliği değişmez. Kişi borç ilişkisinin tarafı olmasa bile, hatta bu konuda bir iradesi dahi bulunmasa da, sırf o şey üzerinde sahip olduğu aynî hak sebebiyle o ilişkinin tarafı olarak borçlu veya alacaklı sıfatına sahip olmaktadır. Diğer borç ilişkisinden farkı, sözleşme tarafının hak ve borçluluğu doğrudan değil, dolaylı olarak belirlenir.

251 Eşyaya bağlı borç ilişkisinin eşya üzerinde aynî hak sahibi ile olanla kurulması, ilişkiyi aynî ilişki haline getirmez. Eşya bağlı borç ilişkisinden doğan hak, aynî hak değildir. Eşyaya bağlı haklar, hak sahibine ne hakkın konusu eşya üzerinde doğrudan hâkimiyet verir, ne de herkese karşı dermeyan edilebilir[78].

252 Eşyaya bağlı borç ilişkisinden doğan hakkın niteliği yine nispi hak niteliğindeki alacak hakkı ve borçtur. Hakkın veya borcun süjesinin eşyaya bağlı olarak değişmesi, hakkın nispi niteliğini dönüştürmez. Eşyaya bağlı borç ilişkisi yine tarafları arasında hüküm ve sonuç doğurur (*res inter alias acta*). Örneğin, tapuya şerh edilmiş kira ve ödünç sözleşmesinin tapuya şerhi halinde, borç ilişkisi eşyaya bağlı borca dönüşür. Taşınmazın devri halinde, yeni malik, kira sözleşmesinin tarafı haline gelir[79]. Aynı şekilde, tapuya şerh edilmiş sözleşmeden doğan onalım hakkı (TMK m.735), sözleşmeden doğan alım ve geri alım hakkı (TMK m.736) eşyaya bağlı haktır.

---

[75] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.279 ff. **LIVER**, SPR V/1, s.209. **SCHMID/HÜRLIMANN**, N.23.

[76] **STEINAUER**, I. N.55.

[77] **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.21.

[78] **LIVER**, ZGB Art.730, N.225. **REY**, Syst. Teil. N.88; I, N.245.

[79] Aksi görüş sözleşmeden veya kanundan doğan onalım hakkı ve alım ve geri alım haklarını eşyaya bağlı hak olarak değil de *eşyaya bağlı hakka benzer hukuki ilişki* olarak nitelemektedir. **SİMONIUS/SUTTER**, I. § 2. N.1 ff; **WIEGAND**, BSK Vorbem. Art.641 ff. N.50.

253 Eşya bağlı borca aykırılığa TBK'nın temerrüt ve akde aykırılık hükümleri uygulanır (TMK m.112 vd.).

254 Eşyaya bağlı borç veya hakkın sona ermesi yine eşyaya bağlı borç ilişkisinin (sözleşmenin) sona ermesi borçlar hukuku kurallarına tabidir; ancak bazı eşyaya bağlı hakkın bazı özellikleri de dikkate alınmalıdır[85]. Bu kapsamda, ayni hakkın ortadan kalktığı, örneğin eşyanın yok olduğu, sınırlı ayni haktan vazgeçildiğinde, zilyetliğe bağlı ise zilyetliğin sona erdiği durumlarda ayni eşyaya bağlı niteliği de onunla sona erer; borç ilişkisi olarak devam edip etmediği borçlar hukuku kurallarına göre belirlenir[86].

255 Yine, eşyaya bağlı borcun konusu para ise, borçlanılan edim istisnai olarak zamanaşımına uğrar. Ancak kanun bazı eşyaya bağlı hakların kullanılmasını, opsiyon hakkının veya yenilik doğurucu hakkın kullanılmasına veya dava açılmasına bağlamışsa, bu hakkın kullanımını veya dava açılmasını hak düşürücü süreye tabi tutabilir. Örneğin, sözleşmeden doğan onalım hakkını kullanmak isteyen hak sahibi, bu hakkın veya işlemin kendisine bildirilmesinden başlayan üç ay ve her halde satışın yapılmasından başlayarak iki yıl içinde dava açarak kullanmak zorundadır (TBK m.242).

256 İlaveten belirtelim ki kanun, eşyaya bağlanan hakkın ayni etkisini sözleşmede belirtilen süre veya kanunda belirtiler üst sürenin geçmesiyle sona ereceğini düzenleyebilir. Hukuki işlemle kurulabilen eşyaya bağlı haklardan tapuya şerh edilmiş sözleşmeden doğan onalım hakkı (TMK m.735), alım ve geri alım hakkı (TMK m.736); eşya bağlı etkisi şerhte belirtilen süre sonunda, belirtilmemişse on yılın sonunda sona erer.

bbb. Eşyaya Bağlı Borcun Nispi Niteliği

257 Eşya bağlı borç ilişkisinde, sadece borçlu sıfatı eşyanın sahipliği ile borcun nakline ve başka bir işleme gerek olmaksızın değişmektedir. Borcun nispiliği ilkesi ve buna bağlanan sonuçlar, eşyaya bağlı borç ilişkisine uygulanır.

258 Eşyaya bağlı borç, evvelki ayni hak sahibinin borçları yeni malike devredilmez; her ayni hak sahibinin sorumluluğu eşyayı sahip olduğu dönemle sınırlıdır.

---

[85] MEIER-HAYOZ, BK. Syst. Teil. N.299. REY, I. N.261.

[86] REY, I, N.262.

ccc. Eşyaya Bağlı Hakkın Nispi Niteliği

259 Eşyaya bağlı hak da TBK'nın tanıdığı yetkileri verir. Alacağın nispiliği ilkesi ve buna bağlanan sonuçlar eşyaya bağlı borç ilişkisine uygulanır.

260 Eşyaya bağlı borç ilişkisinde, eşya bağlı hak sahibi de alacağın temliki ve başka bir işlemine gerek olmaksızın eşya sahipliği ile değişmektedir.

(1). Eşya Hukukunun Genel İlkelerinin Uygulanması

261 Eşyaya bağlı hak veya borçlar, ayni haklara ilişkin genel ilkelere tabidir. Bu kapsamda, özellikle tıpıklık ilkesi, kapsamın tipikliği ilkesine tabidir. Tipiklik ilkesi gereği eşyaya bağlı hak ve borçlar sadece kanunun tarafından düzenlendiği veya kanun taraflara düzenleme imkânı verdiği takdirde ve kanunun belirlediği kapsamda söz konusu olabilir[82].

(2). Eşyaya Bağlı Borcun Konusunu Olumlu Edim Oluşturması

262 Eşyaya bağlı borcun konusu sadece olumlu edimlerdir[83]. Bu niteliğiyle olumlu ile birlikte olumsuz edimleri de konu alabilen diğer alacak haklarından ve konusunu sadece olumsuz edim olan irtifaklardan ayrılır[84].

dd. Çeşitleri

263 Eşyaya bağlı haklar, kanundan veya hukuki işlemden doğarlar[85]:

aaa. Kanundan Doğan Eşyaya Bağlı Borç

264 TMK'nın Eşya Hukuku kitabında düzenlenen eşyaya bağlı borçları sıralarsak[86];

- Arazi maliklerinin birlikte taşınmazın sınırları belirleme yükümlülüğü (TMK m.720);

- Paydaşların yasal ön alım hakkı (TMK m.735 III);

---

[82] **REY**, I, N.242; **EREL**, Eşyaya Bağlı Borçlar, s. 37 vd; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 49-50.

[83] **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 49.

[84] **REY**, Syst. Teil. N.82 f; I, N.247 f.

[85] **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 46 vd.; **EREL**, Eşyaya Bağlı Borçlar, s. 88 vd.

[86] **REY**, I, N.255 ff.

- Taşınmaz malikinin üst taraftaki araziden taşınmazına doğal olarak akan suların akışına katlanma (TMK m.742 I);

- Üst taraftaki araziden kendi arazisine akan doğal suların boşaltılmasını engellememe, zarar görmesi halinde yapılacak mecrayla suyun akıtılmasını isteme (TMK m.743);

- Arazi maliklerin taşınmazın sınırlıklarını çevrilmesi için yapılan gideri karşılama yükümü (TMK m.749 I);

- Komşuluk hukukundan doğan yetkilerin kullanılması için gerekli olan işlere ve bunların giderlerine kendi yararlanması oranında katılma yükümlülüğü (TMK m.750);

- Malikin inşaatın arazisine taşan kısmının mülkiyetini iyiniyetli komşu arazi malikine devretme yükümlülüğü (TMK m.725 III);

- Taşınmazın malikinin kendi arazisi üzerinde talepte bulunan kişi lehine zorunlu mecra (TMK m.744 I),

- Zorunlu geçit (TMK m.747) ve zorunlu su hakkı (TMK m.761 I) tanıma yükümlülüğü;

- Kaybolmuş eşyayı bulanın ilgili kişilere bildirme ve onu özenle muhafaza yükümlülüğü (TMK m.760, 770 I);

- İrtifak hakkının kullanılması için yapılan tesislerin yüklü taşınmaz malikine de faydalı olması halinde, yüklü taşınmaz malikinin bakım masraflarına katılma yükümlülüğü (TMK m.790 II);

- Malikin üst –yapı- hakkı sahibine karşı üst hakkının karşılığı olan ve irat şeklindeki gelirin teminatı olarak ipotek talep hakkı (TMK m.834, 835);

- Yapı alacaklısının tescile tabı kanuni ipotek hakkı (TMK m. 893 I b.3)187;

- Üst hakkı sahibinin, taşınmaz malikine kalan malzemeler için tazminat talep hakkı (TMK m.829).

265 Özel kanunlarda eşyaya bağlı hak ve borçlar düzenlenmiştir. Örneğin, 3083 sayılı Kanuna göre, dağıtılan toprağı işde eden çiftçinin zaruri

[187] Hakim görüş için bkz. **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.25-25; 1726 ff. BGE 92 II 227 ff. 229

ve faydalı masrafları talep hakkı (m.11 III); 5403 sayılı Kanun tarım arazilerinin belirli miktarların altındaki parsellere bölünmesi yasakları (m.8)[88].

266 Kat Mülkiyet Kanunu da çok sayıda eşyaya bağlı hak ve borcu düzenlemiştir[89]. Örneğin, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm malikinin aidat ödeme yükümlülüğü.

bbb. Hukuki İşlemden Doğan Eşyaya Bağlı Borç

267 Kanun öncelikle eşya bağlı borç ve hakkın taraflarca hukuki işlemle, özellikle sözleşmeyle belirlenmesini öngörmelidir[90]. Sözleşmedeki edimin konusu eşya, özellikle taşınmazdaki ayni hakka ilişkin olmalıdır.

268 Eşyaya bağlı hak, tapu siciline kaydedilebilen ayni hakla irtibatlı veya bazı durumlarda ayrıca tek başına *eşya bağlı sözleşme* olarak düzenlenebilir veya sözleşmeden doğan eşyaya bağlanabilecek hak, tapu siciline şerh edilebilmelidir. Borçlandırıcı işlemdeki hak tapu sicilinde yer aldığı andan itibaren eşyaya bağlı hak niteliğine kavuşur.

269 Sözleşme ve sözleşmeden doğan eşyaya bağlı hak kanunda belirlenen tipe uygun ve kapsama uygun olmalıdır. Örneğin, taşınmaz irtifakının konusu yapma borçları oluşturmaz; sadece yan edim olarak bağlanması (TMK m. 779 II); bakım giderlerinin irtifaktan yararlanan taşınmaz malikine olması veya irtifakla yüklü taşınmazın malikine yararına olan bakım giderlerine katılması (TMK m.741); TMK m.838 düzenlenen taşınmaz yükü olarak; taşınmaz yükü olarak belirlenen eşyaya bağlı borç, taşınmaz enerji veya su temin yükü yüklenebilir.

270 TMK m.1009'da dayılan tapuya şerh edilerek kuvvetlendirilmiş kişisel haklar ise:

- Tapuya şerh edilmiş sözleşmeden doğan onalım hakkı (TMK m.735),

- Sözleşmeden doğan alım ve geri alım hakkı (TMK m.736);

- Rehinde boş dereceye ilerleme hakkı (TMK m.871 III);

---

[88] ÜNAL/BAŞPINAR, s. 48.

[89] İsviçre hukuku için bkz. MEIER-HAYOZ, BK Syst. Teil. N 227 ff.

[90] LIVER, SPR V/1, s 559; REY, ZGB Art.730. N.148; I. N 260; RIEMER, Sachenrecht. II. § 8. N.5; SCHMID/HÜRLIMANN, N.29.

- Tapuya şerh edilmiş kira ve ürün sözleşmesi (TBK m.312, Ürün kirası TMK m.358 atfıyla);

- Ayni hak bağışlayanın dönme hakkının tapu kütüğüne şerhi (TBK m.247 II).

d. Zilyetlikten Ayrılması

271 TMK zilyetlik kavramını tanımlamamıştır. TMK hükümlerine bakılınca zilyetlik kavramının farklı anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz. Zilyetlik kavramı ve kavramın kullanıldığı anlamlar üzerinde aşağıda ayrıca durulacaktır[51]. Burada kısaca zilyetliğin niteliği üzerinde incelemede bulunursak, bize göre, zilyetlik bir ayni hak değildir. Zilyetliği, ayni hakkın özel şekli olarak savunan yazarlar da bulunmaktadır[52].

272 Bize göre, zilyetlik bir hak değildir; hele ayni hak hiç değildir; belirli bir maddi olgu, genellikle eşya üzerindeki hukuki ilişkidir.

3. Eşya Üzerindeki Hak Olan Ayni Hakkın Diğer Nitelikleri

a. Eşya Üzerindeki Hakkın Tipik Yapısını Yansıtması

273 Ayni hak, özellikle mülkiyet, özel hukuk tanımlarında yer aldığı şekliyle *"tipik" yapısına*[53] (Strukturtypus) uygun fonksiyonu yerine getirir; bu sebeple sadece ayni hakkın kendisi sınırlı sayı ile değil, kapsamı da tipik yapısına uygun TMK'nın Eşya Hukuku kitabında düzenlemiştir[54].

b. Malvarlığı Hakkı Niteliği

274 Ayni haklar para ile ölçülebilen ekonomik bir değere sahip olduğundan malvarlığı hakları içinde, malvarlığının aktifinde yer alırlar[55]. Malvarlığı niteliği sebebiyle üzerinde sağlar arası ve ölüme bağlı tasarrufa konu edilebilir ve devredilebilir; mirasçılara intikal edebilir.

---

[51] **ANTALYA,** EH II, N. 26 vd.

[52] **HINDERLING,** SPR V/1, s.407; **STEINAUER,** I, N.169.

[53] **REY,** I, N.199.

[54] Tipiklik doktrini (Typenlehre) için bkz. **LARENZ,** s.461; **LARENZ/CANARIS,** s.90; **MEIER-HAYOZ/SCHLUEP/OTT,** ZSR 1971, s.294 ff; **SCHLUEP,** Wirksamer Wettbewerb, s.25.

[55] **AKİPEK,** I, s.13.

c. Asli Hak Niteliği

275 Özel hukukta haklar,

- Asli haklar ve
- Yetki veren haklar[96] olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

276 Asli hak kavramı, yararlanma hakkı terimiyle de ifade edilmektedir. Asli hak, hâkimiyet hakkı olarak da isimlendirilmektedir[97]. Günümüzün çağdaş yaklaşımına uygun olarak, bir kişinin şahsi malvarlığı üzerinde hâkimiyet hakkın alabildiğince serbestçe kullanılması görüşünden vazgeçildiğinden hâkimiyet hakkı teriminin kullanılmasından günümüzde vazgeçilmiştir. Biz de hâkimiyet hakkı yerine, "asli hak" terimini kullanmayı tercih etmekteyiz. Ayni hakları, yararlanma hakları- paraya çevirme hakları diye ikiye ayırmaktayız[98].

277 Asli haklar, sahibine hakkın konusu olan maddi veya gayri maddi değerden yararlanma ve paraya çevirme hakkı veren haklardır[99]. Asli hak, katılım hakları, nispi (alacak) hakları ve mutlak haklar diye ayrılmaktadır. Ayni haklarda mutlak hakların alt başlığında yer alır. Kişilik hakları, kişi üzerindeki yetki hakları ve fikri ve sınai haklar mutlak hakların diğer alt grubunu oluşturur[100].

d. Ayni Hakkın Tekelci (İnhisari) Niteliği

278 Ayni hak sahibine eşya üzerinde inhisari olarak o şeyden tek başına yararlanma hakkı verir[101]. Bir diğer kişi, hak sahibinin iradesi olmaksızın, hakkın konusu eşyadan kanuni istisnalar hariç yararlanamaz.

4. Çeşitleri: Ayni Hakkın Kapsamına Göre: Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Haklar

279 Ayni haklar, tipe bağlılık ilkesi gereği, TMK'da mülkiyet, irtifak hakkı, rehin ve taşınmaz yükü olarak düzenlemiştir. Bu dört hak kapsamına ve verdiği yetkiye, konusuna, hak sahibi tayinine ve hak sahibin be-

---

[96] Yetki veren haklar üçe ayrılır: Yenilik doğuran haklar, defi hakları ve yönetim ve temsil hakları. Yönetim ve temsil hakkı yerine 'ehliyet' ve 'temsil hakları' ayrımı da yapılmaktadır. Bkz. **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 41-42.

[97] **EREN**, BH GH, s. 47; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 40.

[98] **ANTALYA**, EH I, N. 433-436.

[99] **EREN**, BH GH, s. 47.

[100] **EREN**, BH GH, s. 47 vd.; **ANTALYA**, BH GH I, s. 30; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 40 vd.

[101] **AKİPEK**, I, s.14.

lirleniş şekline göre tasniflere tabi tutulmaktadır. Aşağıda ayni haklar bu ayrım kriterlerine göre incelenecektir.

a. Genel Olarak

280 Ayni hakların, mülkiyet ve sınırlı ayni hakların hepsi, aynilik niteliğinden hareketle, nicelik bakımından; mülkiyeti tam bir hâkimiyet hakkı; sınırlı ayni haklar ise sınırlı bir ayni hâkimiyet hakkı vermektedir. Nitelik bakımından; sınırlı ayni haklar, mülkiyet hakkının bir bölümünü oluşturmaksızın, onu sınırlayan ve ona yük yükleyen haklardır.

281 Aynîliğin amaçsal olgusu, hak sahibine eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet verir. İşte aynîliğin hâkimiyetinin kapsamına göre, ayni haklar tam hâkimiyet yani mülkiyet; sınırlı hâkimiyet yani sınırlı ayni haklar olmak üzere ikiye ayrılır.

b. Mülkiyet Hakkı ile Sınırlı Ayni Hak Hakları Arasındaki İlişkiye İlişkin Görüşler

aa. Bölünme Görüşü

282 Bölünme görüşüne göre[201], sınırlı ayni haklar, mülkiyetin sağladığı yetkilerden bazılarının ondan ayrılıp bağımsızlaştırılması ve ayrı bir hak olarak özgülenmesi yoluyla kurulurlar. Sınırlı ayni hakların mülkiyetin kapsamındaki kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkilerinden biri veya birkaçından oluştuğu kabul edilir. Bu görüş, malikin yetkilerin parçalanması ve bir kısmının sınırlı ayni hak sahibine verilmesi düşüncesine dayanır.

283 Sınırlı ayni hak varlığını koruduğu sürece malikin yetkileri de bu oranda sınırlanır. Söz konusu yetkilerin sınırlandırılması geçicidir. Sınırlı ayni hakkın sona ermesiyle birlikte malikin yetkisi geri döner ve malik tekrar eski hukuki durumuna kavuşur.

bb. Yükleme Görüşü

284 Yükleme görüşü, Türk hukukunun aksine İsviçre hukuk doktrininde hakim görüştür[202]. Eşya üzerinde sahip olunan yetkilerden hareket eden

---

[201] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s 611; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s 612 vd.; **SEROZAN**, s.39; **HATEMİ/AYBAY**, s 243; **AYAN**, s 3; **KÖPRÜLÜ/KANETİ**, genel olarak sınırlı ayni hakların nitelikçe mülkiyetten farklı olmadıklarını kabul ederek bölünme görüşünü benimsemekle birlikte, yükleme görüşünün mülkiyet ve sınırlı ayni haklar arasındaki ilişkilerle uyum içinde olduğunu belirterek yükleme görüşüne taraftar gözükmektedir. Bkz. s 4, 5.

[202] **LIVER**, ZK Art. 730-744, Einl., s. 8; **DUERR**, ZK, Syst. Teil und Art.793-804, s 53; **HAAB**, Art 641, s 45; **SCHMID/HURLIMANN-KAUP**, s 242.

bölünme görüşünün aksine, yükleme görüşü ise eşya üzerinde sağlanan hâkimiyeti esas alır.

285 Eşya üzerinde kurulabilecek en geniş kapsamlı hâkimiyet hakkı olan mülkiyetin ayrıca kapsamındaki yetkilerin sayılmasına gerek yoktur.

286 Mülkiyet, eşya üzerindeki hâkimiyetin bütününü ifade ederken, sınırlı ayni haklar belirli bir hâkimiyet kesitini ifade ederler. Sınırlı ayni hakkın varlığı mülkiyet üzerinde bir kısıtlama oluşturur. Sınırlı ayni hak mülkiyetten ayrılmış bir parça olmayıp, mülkiyet üzerine getirilmiş bir yük veya yetki sınırlamasıdır.

287 Sınırlı ayni hakta, mülkiyetin sağladığı hâkimiyet, sınırlı ayni hakkın sahibine sağladığı yetki veya ödev oranında sınırlanır. Bu sınırlamanın yarattığı durum yine de geçicidir. Sınırlı ayni hakkın son bulmasıyla birlikte mülkiyet üzerindeki sınırlama da son bulur; mülkiyetin hâkimiyeti tamlaşır. Mülkiyet ile sınırlı ayni haklar arasında sadece nicelik farkı gözeten bölünme görüşünün aksine, yükleme görüşü gereğince nicelik farkı yanında nitelik farkını da dikkate alır.

c. Tam Hâkimiyet Veren Hak: Mülkiyet

288 Ayni haklardan, eşya üzerinde en geniş anlamıyla sınırsız hâkimiyet veren hak, mülkiyettir. Mülkiyet, kanuni sınırları içinde, sahibine eşya üzerinde her türlü tasarruf ve yararlanma yetkisi verir. Mülkiyetin verdiği yetkilerin, kamu ve özel hukuk sınırları aşağıda ayrıca incelenecektir.

289 Roma hukukundan beri, kabul gören mülkiyetten doğan yetkiler,

- Kullanma yetkisi (*usus*),
- Yararlanma yetkisi (*fructus*) ve
- Tasarruf yetkisidir (*abusus*). Mülkiyet bu yetkileri kapsamında toplayan yegane ayni haktır. Mülkiyet sadece yetkiler içermez; ona yüklenmiş ödevler de söz konudur. Mülkiyetin sağladığı yetkiler ve ödevler aşağıda ayrıca incelenecektir.

290 TMK mülkiyeti, taşınır ve taşınmaz mülkiyeti ayrımını temel alarak düzenlemiştir. Bu ayrımın hukuki sonuçlar yönünden farkları üzerinde kısaca durursak[204];

[204] **AYAN**, s. 54 vd.

- **Aleniyet bakımından**: Taşınırlarda aleniyeti zilyetlik sağlarken, taşınmazlarda tapu sicili yerine getirir.
- **Şekil bakımından**: Kural olarak, taşınırlarda ayni hakkı kuran borçlandırıcı işlemler şekle tabi olmamasına karşın, taşınmazlar resmi şekle tabıdır (TMK m.706, 781, TBK m.237 ve Tapu K. m.26).
- **Ayni hakkın kazanılması ve devri bakımından**: Taşınırlarda zilyetlikle ayni hak kurulur; zilyetliğin el değiştirmesi ile taşınır mülkiyeti devredilir. Taşınmazlarda, ayni hakkın kazanımı ve devri, kural olarak, tapu sicilinde tescille gerçekleşir (TMK m.705, 1008).
- **Karine olgusu bakımından**: Taşınırlarda zilyetlik, taşınmazlarda tapu sicili ayni haklara karine teşkil eder (TMK m.985, 992).
- **Ayni hak konusu olabilme bakımından**: Bazı ayni haklar sadece taşınırların, teslime bağlı rehin, hapis; bazıları ise sadece taşınmazın örneğin irtifak hakkı, taşınmaz yükü, ipotek konusunu oluşturur. Her ikisinin konusu olan ayni haklarda örneğin intifa bulunmaktadır (TMK m.838, 850, 959).
- **Taşınır davası açma bakımından**: Taşınır davası sadece taşınırlarda hukuki koruma sağlar; taşınmazlar için bu davanın açılması söz konusu olmaz.

d. Sınırlı Hâkimiyet Veren Haklar: Sınırlı Ayni Haklar

aa. Genel Olarak

291 Sınırlı ayni haklar ise, sahibine eşya üzerinde sınırlı hâkimiyet veren – yetki veren haklardır. Sınırlı ayni haklarda, mülkiyette belirli bir fonksiyonu yerine getiren bir yetki, ondan alınıp, yine ayni bir hak olarak tanımlanan başka bir hakka verilmekte veya ona yük olarak yüklenmektedir. Mülkiyet hakkının konusu olabilen taşınır ve taşınmaz eşya, sınırlı ayni hakların da konusu olabilir. Bunun yanında kanun, sınırlı ayni haklardan intifa ve rehin hakkının, eşya dışında haklar üzerinde de kurulabileceğini kabul etmiştir (TMK m. 794, 820, 954).

bb. Ayni Hakkın Konusuna Göre

292 Ayni haklar konusu eşya ve eşya olmamasına göre ikiye ayrılırlar: Konusu eşya olan ayni haklar ve konusu eşya olmayan ayni haklar. Ayni hakkın asli konusu elbette eşyadır. TMK eşyayı taşınmaz ve taşınır ayrımı altında düzenlemiştir.

293 TMK eşya dışında bazı hakların ayni hak konusu olarak düzenlemiştir. Alacak hakkı üzerindeki rehin, tereke üzerinde kurulan intifa ve enerjiyi örnek verebiliriz (TMK m.839, 850 ve 950). Bu hususu yukarıda incelemiş idik[205].

cc. Eşya Üzerindeki Yetkiye Göre

294 Sınırlı ayni haklar, eşya üzerinde sağladıkları yetki açısından üç ana gruba ayrılırlar: İrtifak hakları, Rehin hakları ve Taşınmaz yükü[206].

aaa. İrtifak Hakları

295 Hak sahibine, bir eşya üzerinde, o eşyadan yararlanma veya o eşyayı doğrudan doğruya kullanma yetkisi veren ve böylece, söz konusu eşyanın malikine, mülkiyet hakkına ait bazı yetkileri kullanmama veya bu yetkilerin sınırlı ayni hak sahibi tarafından kullanılmasına katlanma yükümlülüğü yükleyen haklara irtifak hakları denir. Burada mülkiyetin içeriğini oluşturan yetkilerden bazılarının bağımsızlaştırılarak bir hak olarak özgülenmesi söz konusudur[207].

296 TMK'da düzenlenen irtifak türleri, taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı ve diğer irtifaklardır. TMK'da düzenlenen irtifaklar, sınırlı sayıda olup; bunlar dışında irtifak türü yaratılması mümkün değildir. İrtifak hakları da kendi içlerinde, yararlanma yetkisinin kapsamı, yararlanma yetkisinin tarzı ve hak sahibinin tayini açısından çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadır:

(1). Yararlanma Yetkisinin Kapsamı Açısından

297 Bu bağlamda irtifak hakları, tam veya sınırlı yararlanma yetkisi sağlamasına göre ikiye ayrılmaktadır.

298 İrtifak haklarından bazıları eşya üzerinde tam yararlanma yetkisi vermektedir. Eşya üzerinde tam yararlanma yetkisi veren irtifak hakkı, intifa hakkıdır. İrtifa hakkı, hak sahibine, eşyayı kullanma ve eşyanın ürünlerinden yararlanma yetkisi verir[208].

---

205 **ANTALYA**, EH I, N. 102 vd.

206 **TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO**, s. 813 vd.; **HATEMİ/SEROZAN/ARPACI**, s. 24 vd.; **AYAN**, Sınırlı Ayni Haklar, s. 3 vd.

207 **TEKİNAY**, Menkul Mülkiyeti, s.28; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 611; **ERTAŞ**, s.477; **AYAN**, Sınırlı Ayni Haklar, 21 vd.

208 **ÖZEN**, İntifa Hakkı, s. 19 vd.; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 644.

299 İntifa dışındaki irtifaklarda yararlanma yetkisi sınırlıdır. Sınırlı yararlanma, örneğin oturma hakkında, bir binada oturma; üst hakkında, inşaat yapma ve buna sahip olma; kaynak hakkında, bir taşınmazdaki kaynaktan su alma; geçit irtifakında, bir taşınmaz üzerinden geçme şeklinde kendisini göstermektedir.

(2). Yararlanma Yetkisinin Tarzı Açısından

300 Bu ayrımın temelinde, irtifak hakkı sahibinin hakkından yararlanma şekli bulunur. İrtifak hakları bu bakımdan olumlu ve olumsuz irtifaklar olmak üzere ikiye ayrılır:

301 *Olumlu irtifaklarda* hak sahibi eşyayı kullanarak yararlanma yetkisine sahiptir[208]. Demek ki, olumlu irtifaklarda irtifak hakkı sahibi yararlanma yetkisini eşyayı kullanarak gerçekleştirecektir. Bu irtifaklarda hak sahibi ile eşya arasında kullanma dolayısıyla doğrudan doğruya bir ilişki söz konusudur. Hak sahibinin eşya üzerinde sahip olduğu kullanmanın kapsamı, tanınan irtifak hakkına ve sözleşmenin içeriğine göre belirlenir. Olumlu irtifaklarda taşınmaz maliki, irtifak hakkı sahibinin eşyayı kullanmasına katlanma yükümlülüğü altındadır[209].

302 *Olumsuz irtifaklar* ise eşyayı belirli bir tarzda kullanmayı malike yasaklamak suretiyle irtifak hakkı sahibine bir menfaat sağlar[210]. Diğer bir ifadeyle, eşyadan yararlanma, eşyayı belirli bir tarzda kullanmayı malike yasaklama biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu irtifaklarda, malikin eşyayı belirli bir şekilde kullanmamasında irtifak hakkı sahibinin menfaati bulunmaktadır. Şu halde bu irtifaklar malikin taşınmaz üzerindeki bazı yetkilerini ortadan kaldırmaktadır. Olumsuz irtifakın içeriği TMK m. 779 I'de, "*mülkiyetin sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınma*" şeklinde ifade edilmiştir. Örneğin manzara kapatmama irtifakında taşınmaz maliki, irtifak hakkı sahibinin manzarasını kapatmamakla yükümlüdür. Dolayısıyla manzara kapatmama irtifakı, malike irtifak hakkı sahibi lehine taşınmazını belirli bir tarzda kullanmama borcu yükler. Bu borç manzarayı kapatmama şeklinde yerine getirilecektir.

---

[208] AKİPEK/AKINTÜRK, s. 642

[209] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 777-778

[210] AKİPEK/AKINTÜRK, s. 642

(3). Hak Sahibinin Tayini Açısından

303 Bu ayrımın temelinde hak sahibinin belirleniş tarzı bulunur. TMK, hak sahibinin tayini yönünden irtifakları: Kişiye bağlı irtifaklar, Eşyaya bağlı irtifaklar, Diğer irtifaklar olmak üzere üçe ayırmaktadır. Şimdi bu ayrımdan hareketle söz konusu hakları açıklayalım:

(a). Kişiye Bağlı İrtifaklar

304 Bazı irtifaklarda kişiler önem taşır ve hak doğrudan doğruya belirli bir kişiye bağlıdır. Bu irtifaklara kişiye bağlı irtifaklar ismini vermekteyiz.

305 Kişisel irtifaklardan bir kısmı, zorunlu olarak sadece kişiye bağlı kurulabilir. Bu hakların özelliği kişiye ayrılmaz biçimde bağlı olmalarıdır. Bu irtifaklar, başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Zorunlu olarak kişiye bağlı irtifaklar, intifa ve oturma hakkıdır.

306 İntifa ve oturma dışındaki irtifak hakları, kişiye bağlı olarak kurulabilecekleri gibi; devredilebilir ve mirasçılara geçebilir tarzda da kurulabilir. Bu irtifaklar düzensiz kişisel irtifaklar olarak isimlendirilmektedir. Üst hakkı ve kaynak hakkı, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, devredilebilir ve mirasçılara geçebilir. TMK m. 838'de düzenlenen "diğer irtifaklar"da ise durum farklıdır. Bu irtifaklarda asıl olan kişiye bağlı kurulmalarıdır. Ancak taraflar, sözleşmede aksini kararlaştırarak, bu irtifakları da devredilebilir ve mirasçılara geçebilir şekilde kurabilirler[212].

Şimdi zorunlu kişiye bağlı irtifak çeşitlerini kısaca inceleyelim:

307 Zorunlu olarak kişiye bağlı olan irtifak hakları, intifa hakkı ve oturma hakkı olmak üzere iki tanedir.

308 Öncelikle kişiye zorunlu olarak bağlı irtifaklardan olan **intifa hakkı** üzerinde duralım. İntifa hakkı, hak sahibine, başkasına ait bir eşya, hak veya malvarlığı üzerinde tam bir yararlanma yetkisi sağlayan irtifak hakkıdır[213-214] (TMK m. 794 II).

---

[212] **LARENZ/WOLF**, § 15. Nr. 7; **ÖZEN**, İntifa Hakkı, s. 19 vd.

[213] " ... *İntifa hakkı sahibinin hakkın konusu maldan tam olarak yararlanma yetkisi, eşyanın intifanın amacına uygun olarak fiilen kullanılması olanağını sağlar. Bu hak kullanılırken malın öz değere zararlı olabilecek tarzda kullanımı söz konusu olamayacağı gibi eşyada önemli değişiklikler yapılamayacak ve ayrıca da, eşyanın özgülendiği ekonomik amacı malike önemli derecede zarar verecek biçimde değiştirilemeyecektir* ..." (Y. 14 HD., 13.03.2008 T., 1826 E., 3216 K.)

[214] **TEKİNAY**, Menkul Mülkiyeti, s. 39; **ERTAŞ**, s. 486; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 674; **ÖZEN**, İntifa Hakkı, s. 19 vd.

309 İntifa hakkı, zorunlu olarak kişiye bağlı kurulması gereken bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkının bağlandığı kişinin gerçek veya tüzel kişi olması mümkündür. Bu hakkın devredilmesi veya mirasçılara geçmesi söz konusu olmaz. Ancak hak sahibi, intifa hakkını bizzat kullanmaya mecbur değildir. İntifa hakkının kullanılmasına ilişkin yetkilerin üçüncü kişilere devredilmesi mümkündür (TMK m. 806)[215].

310 Zorunlu olarak kişiye bağlı hakların bir diğeri oturma (sükna) hakkıdır. **Oturma hakkı** belirli bir kişiye bir binadan veya binanın bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren irtifak hakkıdır (TMK m. 823)[216].

311 Oturma hakkı, zorunlu olarak kişiye bağlı kurulması gereken irtifaklardandır. Bu hak devredilemez ve mirasçılara geçmez (TMK m. 823 II). Oturma hakkı yalnızca gerçek kişiler lehine kurulabilir[217]. Oturma hakkı, bir binanın tamamında veya bir kısmında oturma yetkisi verir. Oturma, ancak hak sahibinin kişisel ihtiyacının karşılanmasına yönelik olabilir ve bu hakkın başkasına bırakılması mümkün değildir (TMK m. 824 I). Oturma hakkı sahibi, hakkın şahsına özgülendiği açıkça belirtilmedikçe, bina veya onun bir bölümünde ailesi ve ev halkı ile birlikte oturabilir (TMK m. 824 II). Binanın bir bölümü üzerinde oturma hakkına sahip olan kimse, ortak kullanıma özgülenen yerlerden de yararlanabilir.

312 Kişiye bağlı olması zorunlu olmayan irtifaklar üst ve kaynak haklarıdır:

313 Öncelikle **üst hakkı** üzerinde duralım. Üst hakkı, sahibine, arazinin altında veya üstünde bir inşaat yaparak yahut hakkın kurulmasından önce arazide mevcut bulunan bir inşaatı muhafaza ederek ona malik olma yetkisi veren sınırlı ayni haktır (TMK m. 726, 826)[218].

314 Üst hakkı kuran taşınmaz malikinin arazi üzerindeki mülkiyet hakkı devam eder. Malik, araziyi satıp devredebilir, rehnedebilir. Arazi malikinin yükümlülüğü, irtifakı kuran resmi senette yer alan hükümlere uygun olarak, üst hakkı sahibinin inşaat yapmasına ve yaptığı inşaatı muhafaza etmesine katlanmaktır. Üst hakkının bir gerçek kişi veya tüzel kişi lehine kurulması mümkün olduğu gibi, bir diğer taşınmaz lehine eşyaya bağlı

---

[215] ÖZEN, İntifa Hakkı, s. 293 vd.

[216] TEKİNAY, Menkul Mülkiyeti, s. 54-55.

[217] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 853.

[218] DURAL/SARI, s. 155; OĞUZMAN/BARLAS, s. 146; GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 8.

olarak da kurulması mümkündür[219]. Üst hakkı bağımsız ve daimi nitelikte ise bu hak için tapuda ayrı bir sayfa açılması mümkündür[220]. Üst hakkının tapuda ayrı bir sayfaya kayıt edilebilmesi için iki temel özelliğe sahip olması gerekir. Bunlar, bağımsızlık ve süreklilikiir. Bu iki özellik bir arada bulunduğunda, üst hakkı sahibi, irtifak hakkının tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilmesini isteyebilir. Bir üst hakkının bağımsız ve sürekli nitelikte olması, tapuda bu hak için ayrı bir sayfa açılmasını kendiliğinden sağlamaz. Bunun için irtifak hakkı sahibinin talebi gerekli ve yeterlidir (TST m. 11); irtifak hakkının yükletildiği taşınmaz malikinin veya bu taşınmaz üzerindeki diğer hak sahiplerinin rızasına gerek yoktur[221].

315 İrtifak hakkının bağımsız olmasından kasıt, hakkın devir ve intikale elverişli nitelikte olmasıdır. İrtifak hakkının sürekli olmasından kasıt ise irtifak hakkının süresiz olarak veya en az otuz yıl süreyle kurulmuş olmasıdır (TMK m. 826, 998 III)[222]. Buna göre süresiz olarak veya en az otuz yıl süreyle kurulan irtifak hakkı bağımsız niteliktedir. Üst hakkı, bağımsız bir hak olarak en çok yüz yıl için kurulabilir (TMK m. 836 I). Üst hakkı, süresinin dörtte üçü dolduktan sonra, kurulması için öngörülen şekle uyularak uzatılabilir. Ancak bu uzatma süresi, yüz yılı aşamaz. Uzatma konusunda önceden yapılan taahhüt bağlayıcı değildir. Üst hakkı bağımsız ve sürekli olarak tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedildiğinde, hakkın konusu olan inşaat mevcut olsun olmasın, bir taşınmaz gibi işlem görür. Üst hakkının içerik ve kapsamıyla ilgili olarak resmi senette yer alan, özellikle yapının konumuna, şekline, niteliğine, boyutlarına, özgülenme amacına ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ilişkin sözleşme kayıtları herkes için bağlayıcıdır (TMK m. 827). Üst hakkının ivazlı veya ivazsız olarak kurulması mümkündür. Taraflar bir ivaz kararlaştırmışlarsa, bu ivaz, üst hakkı sahibinin kişisel borcu olarak değerlendirilir.

316 Kişiye bağlı olması zorunlu olmayan hakların bir diğeri **kaynak hakkıdır**. Kaynak hakkı, hak sahibine bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak yetkisini sağlayan bir irtifak hakkıdır (TMK m. 837)[223].

---

219 **ERTAŞ**, s. 497; **AYAN**, Sınırlı Ayni Haklar, s. 69-70.

220 Üst hakkının bağımsız ve sürekli hak niteliğine sahip olması halinde tapuya taşınmaz olarak kaydedilebileceğine ilişkin bkz. Y. 14. HD., 17.04.2000 T., 2430 E., 2573 K.

221 **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 858 vd.; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 459.

222 **AYAN**, Sınırlı Ayni Haklar, s. 69 vd.; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 459; **SAYMEN/ELBİR**, s. 300.

223 **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, Eşya, s. 246-247; **SAYMEN/ELBİR**, s. 539; **ERTAŞ**, s. 509; **TEKİNAY**, Menkul Mülkiyeti, s. 62-64.

Kaynak hakkının eşyaya veya kişiye bağlı olarak kurulması mümkündür. Kaynak hakkı, kural olarak, devredilebilir ve mirasçılara geçer. Kaynak hakkının bağımsız nitelikte ve en az otuz yıl süre için kurulmuş olduğu hallerde, tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya taşınmaz olarak kaydedilmesi mümkündür. Kaynak hakkının kazanılması konusunda özel hüküm olmadığından, eşyaya bağlı irtifakların kazanılmasına ilişkin hükümler, kıyasen, kaynak hakkının kazanılmasında da uygulanır. Kaynak hakkı, hak sahibine, malikin müdahalesine gerek olmadan kaynak suyunu tutarak alma ve kendi arazisine akıtma yetkisi sağlar (TMK m. 827/I). İrtifak sözleşmesinde, tarafların haklarını daha ayrıntılı olarak düzenlemeleri mümkündür. Kaynak hakkı sahibi, suyun alınması, tesislerin bakım onarım ve kontrolü için kaynağın bulunduğu araziye girebilir; taşınmaz maliki bu duruma katlanmak zorundadır[224].

(b). Eşyaya Bağlı İrtifaklar

317 Kişiye bağlı irtifaklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi de eşyaya bağlı irtifakları kısaca açıklayalım:

318 Bazı irtifaklar taşınmaz lehine kurulurlar; böyle bir durumda irtifak hakkının sahibi belirlenirken söz konusu taşınmazın maliki esas alınır. Hak sahipliği, bir taşınmaza malik bulunma olgusuna bağlıdır. Bu halde, irtifak hakkının kurulmasında malikin kişiliği önemli değildir. Bu nedenle bazı irtifaklar eşyaya bağlıdırlar[225]. Kanunda zorunlu olarak kişiye bağlı olarak kurulmaları öngörülenler haricindeki irtifak haklarının eşyaya bağlı olarak kurulması mümkündür. Bu halde iki taşınmaz söz konusu olur. İrtifakın yükletildiği taşınmaza "yüklü taşınmaz" (TMK m. 784), diğer taşınmaza ise "yararlanan taşınmaz" denir (TMK m. 784).

319 Eşyaya bağlı irtifaklarda yararlanan taşınmaza kim malikse, irtifak hakkının sahibi de o olur. Eşyaya bağlı irtifak, bir taşınmaz üzerine bir başka taşınmaz lehine yükletilmiş bir yük olup; yüklü taşınmaz malikini, mülkiyetin içeriğindeki bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya irtifak hakkı sahibinin bu taşınmazı hakkına uygun biçimde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar (TMK m. 779)[226]. Örneğin, birbirine komşu olan (A) ve (B) taşınmazları arasında, (A) taşınmazının lehine ve (B) taşınma-

[224] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 872-873.

[225] **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 643-644; **AYAN**, Sınırlı Ayni Haklar, s. 33 vd.

[226] **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 648 vd.; **TEKİNAY**, Menkul Mülkiyeti, s. 30 vd.

zının aleyhine bir geçit irtifakı tanındığını varsayalım. Geçit irtifakı, sahibine, yükümlü taşınmazı geçiş alanı olarak kullanma hakkı verir. Bu örnekte, bir eşyaya bağlı irtifak söz konusu olduğuna göre, bu hak, (A) taşınmazının maliki kim ise ona tanınmış demektir. Yani, geçit hakkının sözleşmede kararlaştırılan süresi boyunca, (A) taşınmazı üzerinde mülkiyet hakkını haiz olan kişiler, geçit hakkına da sahip olacaklardır. (A) taşınmazının malikinin değişmesi hakkı sona erdirmez.

(c). Diğer İrtifaklar

320 TMK m. 838'de, malikin, taşınmazı üzerinde herhangi bir kişi veya topluluk lehine atış eğitimi veya spor alanı ya da geçit olarak kullanılmak gibi belirli bir yararlanmaya hizmet etmek üzere başka irtifak hakları da kurabileceği düzenlenmiştir.

321 Diğer irtifakların içeriği, eşyaya bağlı irtifakların içeriği ile aynı olup; hak sahibine taşınmazdan sınırlı bir yararlanma yetkisi sağlar. TMK m. 838'de diğer irtifaklara örnek olarak, atış eğitimi veya spor alanı ya da geçit olarak kullanılmak yetkisi gösterilmiştir. Diğer irtifaklar, kural olarak devredilemez ve mirasçılara geçmez (TMK m. 838 II). Ancak taraflar aksini kararlaştırabilirler. Bu irtifaklar devredilebilir şekilde kurulmuşsa ve sürekli hak niteliğindeyse (en az otuz yıl için kurulmuşsa), tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya taşınmaz olarak kaydedilebilir. Diğer irtifakların kişiye veya eşyaya bağlı olarak kurulabilmesi mümkündür. Ancak TMK m. 838'de, bu irtifakların bir topluluk lehine de kurulabileceği düzenlenmiştir. Bu hâlde irtifak hakkı toplulukta bulunan belirsiz kişiler yararına kurulmuş olmaktadır[227]. Topluluğa dâhil olan herkes irtifak hakkından yararlanabilir.

322 Diğer irtifakların kapsamı, hak sahibinin olağan ihtiyaçlarına göre belirlenir (TMK m. 838). Olağan ihtiyaçların neler olduğu ise irtifakın kurulduğu tarihe göre tespit edilir. Sonradan ihtiyaçların değişmesine dayanarak yüklü taşınmaz üzerindeki yük arttırılamaz.

bbb. Rehin Hakları

323 Rehin hakları, hak sahibinin bir alacağını teminat altına alan ve alacak tahsil edilmediği takdirde alacaklıya, rehin konusu malın satılması suretiyle elde edilecek paradan alacağını karşılama yetkisi sağlayan hak-

[227] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 874-875

lardır[228]. Rehin hakkı sahibi, rehinle teminat altına alınan borç kendisine ifa edilmediğinde, rehin konusunu icra organları vasıtasıyla paraya çevirterek alacağını elde etme yetkisine sahip olur. Bununla beraber, rehin hakkı, hak sahibine doğrudan doğruya bizzat rehin konusunu satarak paraya çevirme yetkisi vermez[229].

324 Rehin hakkında, tüm ayni haklarda bulunan "doğrudan doğruya hâkimiyet" unsuru, rehin hakkı sahibinin rehin konusu eşyanın paraya çevrilmesini malikin aracılığına ihtiyaç duymaksızın tek başına talep edebilmesi noktasında kendisini gösterir[230]. Bu talep yetkisi nedeniyle, rehin hakkı bir ayni hak olarak nitelendirilir. Rehin hakkı, belirli bir alacağı teminat altına almak amacıyla kurulduğundan, bu hakkın doğuşu ve sona ermesi teminat altına alınan alacağa bağlıdır. Başka bir deyişle, rehin hakları, teminat altına aldıkları alacak hakkının sahibine tanınırlar ve teminat altına alınan alacağın kaderine tabi olurlar. Dolayısıyla alacak hakkı ortadan kalkarsa rehin hakkı da ortadan kalkar. Bu nedenle rehin haklarına "feri ayni haklar" da denir[231].

325 Rehin hakları, hakkın konusu olan malın türüne göre taşınır rehni ve taşınmaz rehni olmak üzere ikiye ayrılır.

(1). Taşınmaz Rehni

326 Taşınmaz rehni, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi olmak üzere üç şekilde tesis edilebilir.

327 İpotek, sadece teminat fonksiyonuna sahip bir rehin şekli iken; ipotekli borç senedi ve irat senedinde, teminat altına alınan alacak kıymetli evrak niteliğinde bir senede bağlanır. Bu senet sayesinde taşınmazın değerinin tedavülü imkânı da sağlanmış olur. Uygulamada yaygın olan teminat türü ipotek olup, ipotekli borç senedi ve irat senedine pek rastlanmamaktadır[232].

Şimdi kısaca taşınmaz rehninin türleri üzerinde duralım:

---

[228] Ayrıntılı bilgi için bkz. **KÜHL/REICHOLD/RONELLENFITSCH**, §11, Nr. 45; **LARENZ/VOLF**, § 15, Nr. 7; **DURAL/SARI**, s. 157; **OĞUZMAN/BARLAS**, s. 147; **ACAR**, Rehin, s. 57 vd.

[229] Taşınır rehninde lex commissoria yasağı için bkz. Y. 8 HD., 13.02.2007 T., 7967 E., 692 K.

[230] **AYAN**, Sınırlı Ayni Haklar, s. 153 vd.; **DURAL/SARI**, s. 158; **ACAR**, Rehin, s. 57 vd.

[231] **OĞUZMAN/BARLAS**, s. 147; **ACAR**, Rehin, s. 57 vd.

[232] Ayrıntılı bilgi için bkz. **BERGER**, § 6, Nr. 588; **LARENZ/VOLF**, § 15, Nr. 67; **İMRE**, s. 254; **SEROZAN**, s. 224.

(a). İpotek

328 İpotek, halen mevcut veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası olan herhangi bir alacağın bir taşınmaz teminat gösterilerek güvence altına alınmasıdır (TMK m. 881)[223,224].

329 İpotek, bir kimsenin herhangi bir kişisel alacağını, borçlunun kişisel sorumluluğuna bir etkide bulunmadan, bir taşınmazın değeri veya değer parçası ile teminat altına alır[225]. İpoteğin amacı, borcun ödenmemesi ihtimaline karşı alacaklıya ayni bir teminat sağlayarak onu korumaktır. Bundan dolayı ipotek, teminat altına aldığı alacağa bağlı fer'i bir haktır[226]. İpoteğin doğması için kural olarak tapu kütüğüne tescil yapılması gerekir (TMK m. 856).

330 Geçerli bir tescil için ise taşınmaz malikinin yazılı beyanı ile geçerli bir kazanma sebebinin varlığı aranır. İpotek asıl alacağa bağlı bir hak olduğundan, ipoteğin geçerli olması için, kazanma sebebinin yanı sıra asıl alacağı doğuran bağımsız bir borç ilişkisinin varlığı da zorunludur[227]. Temel ilişkinin geçersiz olmasından dolayı alacak hakkı doğmamışsa, ipotek de doğmaz. İpoteğin doğumu için yapılan tescilin, alacaklı ile borçlu arasındaki borç ilişkisine herhangi bir etkisi yoktur. Tescil alacağı doğurmaz, ipotek hakkı alacağın varlığına bağlı olarak tescille doğar.

331 Rehinli alacağın devriyle birlikte ipotek de yeni alacaklıya kendiliğinden geçer (TBK m. 189).

332 Asıl alacağın sona ermesi, ipoteğin de sona ermesi sonucunu doğurur. TMK m. 883'e göre, asıl alacak sona erince ipoteklı taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir. Alacaklının bu talebe uymaması halinde açılacak dava, TMK m. 1025 uyarınca, yolsuz ipoteğin terkinine yönelik bir davadır[228].

---

223 **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 786; **TEKİNAY**, Menkul Mülkiyeti, s. 106; **ACAR**, Rehin, s. 57 vd.

224 "... *İpotek kişisel bir alacağın teminat altına alınması amacını güden ve bir taşınmaz değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan sınırlı bir aynı haktır. İpotek tesisi için rehin edilecek taşınmaz maliki ile alacaklı arasındaki anlaşmanın (rehin sözleşmesi) Türk Medeni Kanunu'nun 856. maddesi uyarınca tapu siciline tescil edilmesi gerekir. ...*" (Y. 14. HD., 06.10.2008 T., 10087 E., 11028 K.)

225 **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 787; **ACAR**, Rehin, s. 57 vd.

226 **TEKİNAY**, Menkul Mülkiyeti, s. 107; **ACAR**, Rehin, s. 57 vd.

227 **TEKİNAY**, Menkul Mülkiyeti, s. 107; **ACAR**, Rehin, s. 57 vd.

228 **ACAR**, Rehin, s. 57 vd.

333 İcra ve İflas Kanunu'na göre, ipotekle güvence altına alınmış bir alacağın borçlusu borcunu ödemezse, rehinli alacaklının, öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapması gerekir. Rehinli alacaklı, rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen meblağla alacağını alamazsa, kalan kısım için borçlunun diğer malvarlığı değerlerine başvurabilir. İpotekte, kişisel sorumlu olan borçlu ile taşınmaz malikinin aynı kişi olması zorunlu değildir (TMK m. 881 II).

334 İpotekli taşınmaz maliki, ipotek dolayısıyla kişisel borçlu haline gelmez. Fakat borçlunun borcunu ödememesi halinde taşınmazın paraya çevrilmesine katlanmak zorundadır. Taşınmazın paraya çevrilmesi sonucu elde edilen miktar alacağı karşılamıyorsa, kalan kısım için sadece esas borçluya başvurulabilir; rehinli taşınmaz malikı üçüncü kişinin kişisel sorumluluğuna gidilemez. İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir değişiklik meydana getirmez (TMK m. 888 I).

(b). İpotekli Borç Senedi

335 İpotekli borç senedi, hem kişisel sorumluluğun sürdüğü hem de taşınmaz değerinin tedavül ettiği bir taşınmaz rehnidir[235].

336 Taşınmazın değeri bağımsızlaştırılmış ve ipotekli borç senedi adı verilen kıymetli evraka bağlanarak tedavülü sağlanmıştır. Senedin düzenlenmesiyle soyut (mücerret) bir alacak doğar ve teminat altına alınmak istenen temel bir alacak varsa, bu alacak senedin yenileme etkisiyle sona erer (TMK m. 910).

337 İpotekli borç senedinden doğan borçtan dolayı, borçlunun hem kişisel sorumluluğu hem de taşınmazı ile sorumluluğu söz konusu olur. Borçlu borcunu ödemezse taşınmaz paraya çevrilir. Elde edilen miktar alacağı karşılamazsa, alacaklı borçlunun diğer malvarlığı değerlerine başvurabilir. İpotekli borç senedi yoluyla rehin kurulması için tapu idaresince taşınmaza resmen değer biçilir (TMK m. 899). Bu resmi değer biçmenin amacı, senedin piyasada tedavülünden ötürü üçüncü kişilerin zarar görmesini engellemektir[240].

---

[235] **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.817 vd.; **TEKİNAY**, Menkul Mülkiyeti, s.122-123 vd.; **ACAR**, Rehin, s.57 vd.

[240] **ERTAŞ**, s.548; **ACAR**, Rehin, s.57 vd.

(c). İrat Senedi

338 İrat senedi, taşınmazın değerini tedavül ettirmek amacına yönelmiştir[241]. Bununla taşınmazın değeri bağımsızlaştırılmakta, bu değer taşınmazdan ödenmesi gereklı bir para borcu biçiminde bir mükellefiyet olarak taşınmaza yükletilmektedir. Bu para borcunun ifası ve borcun ifasının taşınmazın değeri ile teminat altına alınması, yükün içeriğini oluşturmaktadır. Bu değeri temsil etmek için irat senedi düzenlenmektedir.

339 İrat senedinin düzenlenmesi ile soyut bir alacak doğmaktadır. İrat senedinde borçlunun borçtan dolayı sorumluluğu, taşınmazla sınırlı ayni sorumluluk olup; borçlunun kişisel sorumluluğu yoktur.

340 Kıymetli evrakta mündemiç borç ifa edilmezse, rehinli alacaklı ancak teminat teşkil eden taşınmazın paraya çevrilmesini isteyebilir. Taşınmazın paraya çevrilmesinden elde edilen miktar alacağı karşılamazsa, alacaklı, karşılanmayan kısım için borçlunun diğer malvarlığı değerlerine başvuramaz.

341 İrat senediyle birleşmiş olan borç, eşyaya bağlı bir borç olup; borçlu, teminat teşkil eden taşınmazın malikine göre belirlenir. İrat senedi borçlusu, taşınmazın malikidir (TMK m. 907 I). Yüklü taşınmazı edinen kimse irat senedinin borçlusu olur ve eski malik başka bir işleme gerek kalmaksızın borcundan kurtulur (TMK m. 907 II).

342 Ancak faiz borçları, taşınmazla güvence altında olmaktan çıktığı tarihten başlayarak, malikin kişisel borcu olur. İrat senedinin güvencesini ancak tarım arazisi, konutlar ve üzerinde bina yapılabilecek arsalar oluşturabilir (TMK m. 903).

(2). Taşınır Rehni

343 Taşınır rehni, bir alacağı teminat altına almak için bir menkul eşya, hak veya alacak üzerinde tesis edilen bir yük olup, rehinli alacaklıya borcun yerine getirilmemesi halinde teminat konusunu paraya çevirterek alacağını tahsil etme yetkisi verir[242]. Alacaklı, rehinli mal paraya çevrilince, satış bedelinden alacağını tahsil eder.

344 Alacaklının rehinli mal üzerinde başka bir tasarruf yetkisi yoktur. Rehinli maldan, paraya çevrilme dışında yararlanması mümkün değildir.

---

[241] AKİPEK/AKINTÜRK, s.819 vd.; ACAR, Rehin, s.57 vd.

[242] ERTAŞ, s.551; AKİPEK/AKINTÜRK, s.832; ACAR, Rehin, s.57 vd.

Taşınmaz rehninde olduğu gibi, borcun ödenmemesi halinde taşınırın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine ilişkin anlaşmalar hükümsüzdür (TMK m. 949). Taşınır rehni, teminat altına aldığı alacağa bağlı fer'i bir haktır[243]. Varlığı, teminat altına aldığı alacağın varlığına bağlıdır.

345 Medeni Kanun *"Taşınır rehni"* başlığı altında taşınmaz rehni dışındaki çeşitli rehin türlerini düzenlemiştir. Bunlar, *"teslime bağlı rehin ve hapis hakkı"* (MK m. 939-953), *"hayvan rehni"* (MK m. 940), *"alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin"* (MK m. 954-961)dir. *"Rehin karşılığı ödünç verme işi ile uğraşanlarla yapılan rehin"* (MK m. 962-969) ile *"rehinli tahvil"* (MK m. 970-972) ise özel olarak düzenlenmiştir. Rehin bahsinde ayrıntısıyla inceleneceği için, burada kısaca teslime bağlı rehin, bir sicile kaydı gerekli rehin ve hapis hakkından bahsedilecektir.

(a). Teslime Bağlı Rehin

346 Kanunda öngörülen istisnalar hariç olmak üzere, taşınır bir mal üzerinde rehin kurulması için, dolaysız) zilyetliğin rehin alana sağlanması gerekmektedir (TMK m. 939 I). Bu bağlamda, rehin veren ve rehin alanın dolaysız zilyetliğin devri konusunda anlaşmaları aranır.

347 Rehnin kurulmasıyla alacaklı, rehinli mal üzerinde sınırlı bir ayni hak elde eder. Bu hak, borç ödenmediği takdirde rehinli alacaklıya rehni paraya çevirterek alacağını elde etme yetkisi verir (TMK m. 946).

348 Rehin verenin mutlaka şahsen borçlu olması gerekmez. Bir kimse, başkasının borcu için de kendi malı üzerinde alacaklıya rehin hakkı tanıyabilir. Rehnin paraya çevrilmesi, İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca gerçekleşir. Rehin hakkı, asıl alacağın yanı sıra sözleşme faizlerinin, takip giderlerinin ve gecikme faizinin de güvence altına alınmasını sağlar (TMK m. 946 II).

349 Rehinli alacaklının taşınır mal üzerinde tasarruf yetkisi yoktur (TMK m. 939 II). Ancak rehin konusu taşınıra iyiniyetle zilyet olan kimse, zilyetlik hükümlerine göre edinimi korunduğu ölçüde rehin hakkı kazanır. Alacaklı, rehinli taşınırı ancak rehnedenin rızasıyla bir başkasına rehnedebilir (TMK m. 942). Rehin, taşınırı eklentileriyle birlikte kapsar. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça alacaklı, rehinli taşınırın doğal ürünlerini, ürünler rehin konusunun bütünleyici parçası olmaktan çıkınca malike

[243] **TEKİNAY**, Menkul Mülkiyeti, s. 135.

vermekle yükümlüdür. Diğer yandan, rehin, paraya çevirme sırasında bütünleyici parça niteliğinde olan doğal ürünleri de kapsar.

350 Aynı taşınır üzerinde birden çok rehin kurulması mümkündür. Aynı taşınır üzerinde birden çok rehin hakkı bulunduğu takdirde, alacaklılara rehin haklarının sırasına göre ödeme yapılır. Rehin hakkının sırası kuruluş tarihine göre belirlenir. Teslime bağlı taşınır rehni alacağa bağlı bir hak olduğundan, alacak herhangi bir sebeple sona erince, rehin hakkı da sona erer.

(b). Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Rehin

351 TMK m. 940'ta düzenlenen teslime bağlı olmayan rehin türlerinden biri hayvan rehnidir. Bu kurum sayesinde hayvan sahibinin hem hayvanını rehnedip kredi temin etmesi, hem de hayvanı kullanmaya devam etmesi mümkün kılınmıştır.

352 Hayvan rehninin kurulması için rehin konusunun zilyetliğinin devrine gerek olmayıp, özel bir sicile tescil gerekmektedir. Hayvan rehninin esasları Hayvan Rehni Tüzüğü ile düzenlenmiştir.

353 Hayvan rehni sicili icra dairelerinde tutulur. Yetkili icra dairesi, rehnedilen hayvanın mutat olarak bulunduğu yerdeki dairelerdir. Hayvanın mutat olarak bulunduğu yer, sahibinin isteği ile devamlı şekilde bakılıp tutulduğu yerdir. Rehin konusu hayvanlar, dört ayaklı, ehil, sürü veya çiftlik hayvanı olabilir[244]. Buna karşılık kedi, köpek gibi hayvanlar hayvan rehninin konusu olamaz.

354 TMK m.940 II'de, hayvan rehninden başka tescili zorunlu rehinlerin kurulmasına da olanak tanınmıştır. Bu şekilde kurulabilen taşınır rehinleri motorlu araç rehni, ticari işletme rehni[245], gemi ipoteği, hava aracı ipoteğidir. Bu rehinlerin kurulması, rehin konusu malın zilyetliğinin devri gerekmeksizin, sicile tescil ile gerçekleşir.

(c). Hapis Hakkı

355 Hapis hakkı, alacaklının borçlunun rızasıyla zilyet bulunduğu ve borçluya iade etmekle yükümlü bulunduğu bir eşyayı veya kıymetli evrakı, borç ödeninceye kadar zilyetliği altında tutma ve borç ödenmediği ve-

---

[244] ERTAŞ, s.556.

[245] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ANTALYA/ ACAR, s.1 vd.

ya teminat gösterilmediği takdirde paraya çevirtme hususunda alacaklıya yetki veren ayni bir haktır[246].

356 Hapis hakkının konusu, taşınır eşya ve kıymetli evrak olabilir (TMK m. 950 I). Üzerinde hapis hakkı kullanılacak taşınırlar, paraya çevrilecek nitelikte olmalıdır. Paraya çevrilme imkânı olmayan, fotoğraf, mektup, diploma gibi taşınırlar üzerinde hapis hakkının kurulması mümkün değildir (TMK m. 951).

357 Taşınmazlar üzerinde de hapis hakkı söz konusu olmaz.

358 Hapis hakkının kurulması için ayni bir sözleşmeye gerek yoktur. Kanuni şartların gerçekleşmesi ile hapis hakkı kendiliğinden doğar. Hapis hakkı, alıkonulan eşyalardan alacağı karşılamaya yetecek kadarı üzerinde kullanılabilir; eşyaların değeri alacağı aşan kısmının borçluya geri verilmesi gerekir[247].

359 Hapis hakkı kanunda gösterilen şartların gerçekleşmesiyle doğar. Bu şartlar şunlardır: *Borçlunun rızası ile zilyetlik kurulmalıdır. Alacaklının hapis hakkına esas teşkil eden alacağı muaccel olmalıdır*[248]. *Borçluya ait eşya ile alacak arasında bağlantı bulunmalıdır* (TMK m. 950 II). *Hapis hakkının kullanılması taraflar veya kanun tarafından engellenmemiş olmalıdır* (TMK m. 951 II)

360 Hapis hakkı, alacaklıya, malı borçluya geri vermekten kaçınma ve paraya çevirme hakkı verir. Hapis hakkının kullanılmasına yol açan borç ödenmediği sürece, alacaklı, paraya çevirme yoluna gitmeksizin, zilyet olduğu malları borçluya geri vermekten kaçınarak zilyetliğinde bulundurmaya devam edebilir. Böylelikle, alacaklı hapis hakkını bir def'i tarzında kullanmış olur[249]. Alacaklı, borçlunun ödemeden acze düşmesi halinde, alacağı henüz muaccel olmasa bile hapis hakkını kullanabilir.

361 Borç yerine getirilmez ve yeterli güvence de gösterilmezse, alacaklı, borçluya önceden bildirimde bulunarak, hapsettiği şeylerin teslime bağlı rehin hükümleri uyarınca paraya çevrilmesini isteyebilir (TMK m. 953 I). Bu hükme göre, paraya çevirmenin iki şartı bulunmaktadır: borçluya ih-

[246] **ERTAŞ**, s.566; **TEKİNAY**, Menkul Mülkiyeti, s.142.

[247] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.1029 vd.

[248] **ERTAŞ**, s.567.

[249] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 836.

tarda bulunulması ve borçlunun bu ihtara rağmen yeterli teminat göstermemesi. Bu şartlar gerçekleşince alacaklı, hapsettiği şeylerin paraya çevrilmesini isteyebilir.

ccc. Taşınmaz Yükü

362 Bir taşınmaz malikinin, maliki bulunduğu taşınmaz dolayısıyla ve bu taşınmaz teminat olmak üzere, bir başka kişi lehine bir şey yapmaya veya vermeye mecbur tutulmasına taşınmaz yükü denir. Bu yükümlülük, herhangi bir taşınmazın maliki kim ise onun lehine olmak üzere de kurulabilir.

363 Taşınmaz yükü, eşyaya bağlı hak niteliğindedir[250]. İrtifak haklarından farklı olarak, burada, taşınmazın maliki bir şey yapmak ya da vermek borcu altına girer. Örneğin, bir buğday tarlasının maliki (A), bir ekmek fabrikasını işleten (B)'ye, her hasat zamanı belli miktarda buğday gönderme borcu altına girmişse, taraflar, (A)'nın bu borcunun bir taşınmaz yükü şeklinde düzenlenmesine karar verebilirler. Böylece, buğday tarlasına külfet yüklemek üzere ve (B) lehine bir taşınmaz yükü kurulursa, artık (A) ile (B) arasındaki kişisel borç ilişkisi, eşyaya bağlı bir borç ilişkisine dönüşmüş olur. Bu tarla, söz konusu borcun teminatını oluşturur. Yani bu borç yerine getirilmezse, (B), tarlayı paraya çevirterek zararlarını karşılayabilir.

364 İşte taşınmaz yükünün bu teminat fonksiyonu cephesinde, alacaklı açısından tıpkı rehindeki gibi, sınırlı bir ayni hak söz konusudur[251]. Taşınmaz yükünde, taşınmaz malikinin sorumluluğu ve alacaklının hakları, taşınmazın değeri ile sınırlıdır[252].

dd. Sınırlı Ayni Hakların İçeriğine Göre Çeşitleri: Yararlanma Hakları – Ayni Teminat (Paraya Çevirme) Hakları

365 Sınırlı ayni hakkın içeriğine göre, yararlanma hakkı (Nutzungsrecht) ve paraya çevirme hakkı (Verwertungsrechte) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım TMK'nın sistematiğinde de yer almaktadır[253].

---

250 MEIER-HAYOZ, BK Syst. Teil. N.262. REY, I. N.233. SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N.41.

251 SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N.42.

252 Ayrıntılı bilgi için bkz. DURAL/SARI, s.159. OĞUZMAN/BARLAS, s.148. İMRE, s.253. ERTAŞ, s.61. GÜRSOY/EREN/CANSEL, s.745. SEROZAN, s.223.

253 MEIER-HAYOZ, BK Syst. Teil. N.262. REY, I. N.228 ff; Syst. Teil N.69.

aaa. Yararlanma Hakkı

366 Yararlanma hakları, eşya üzerinde doğrudan yararlanma hakkı veren ayni haklardır. Yararlanma hakkı, kullanma hakkını, maddi diğer faydalarından yararlanmayı da kapsar. Yukarıda kısaca üzerinde durduğumuz irtifak hakları, örneğin olumlu taşınmaz irtifakları, intifa, üst hakkı vb. bu niteliktedir.

367 Taşınmaz yükünü yukarıda incelediğimiz özellikleri yönünden değerlendirirsek, bu ayrımda, yararlanma hakları arasında yer alır. Ancak ilk olarak belirtelim ki yararlanma hakkı ayni nitelikte değildir; eşyaya bağlı hak niteliğindedir[254]. İkinci olarak, taşınmaz yükü paraya çevirme yetkisi de verir ki bu yönüyle ayni niteliktedir.

bbb. Ayni Teminat (Paraya Çevirme) Hakkı

368 Ayni teminat hakları, hak sahibine alacağını elde edememesi halinde, ayni teminatın konusu eşyayı paraya çevirerek alacağını elde etme imkânı veren ayni haklardır.

Bu haklara *ayni teminat hakları* (dingliche Sicherungsrechte) veya *paraya çevirme hakları* (Verwertungsrechte) ismi verilmektedir. Yukarıda incelediğimiz taşınmaz ve taşınır rehin hakları bu niteliktedir.

(1). Eşya Sahibinin Tayinine Göre

369 Sınırlı ayni haklar, kural olarak, başkalarının mülkiyetinde olan eşya üzerinde kurulur. Roma hukukunda bu kural değil, ilke olarak kabul edilmekteydi. Bu ayni haklara, başkasının mülkü üzerinde haklar (*Jus in re aliena*) denmektedir.

370 Pandekt hukukunun etkisiyle malikin kendi eşyası üzerinde kendi lehine sınırlı ayni hak kurulabileceği kabul edilmektedir. Malikin kendi lehine sınırlı ayni hak sahibi olması sadece taşınmazlarda söz konusu olur. Örnek olarak malik rehni, malik irtifakı.

371 Malik lehine kurulabilecek ayni haklarda, tüm ayni haklarda olduğu üzere, tipiklik ilkesi geçerlidir: Bunları sayarsak, taşınmaz lehine irtifak (TMK m. 782, 784), örneğin komşu taşınmazın yararına sınırı olan taşınmaza yüklenen geçit hakkı veya kaynak hakkı ve rehin hakkı, örneğin

[254] MEIER-HAYOZ, BK Syst. Teil. N.262. REY, I. N.233. SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N.41.

kendi taşınmazı üzerinde kendi lehine ipotekli borç senedi ve irat senedi kurmasıdır (TMK m. 884, 898, 914, 918).

(2). Hak Sahibini Belirlemeye Göre

372 Sınırlı ayni haklar yani hakkı yetkilerine göre çeşitlerini incelerken her ayni hakta işaret ettiğimiz üzere, hak sahibini belirleme bakımından kişi (şahıs) lehine (Personalrechte) ve eşya lehine (Realrecht) olmak üzere ve her ikisinden biri lehine kurulabilen ve alacak lehine kurulabilen sınırlı ayni haklar söz konusudur[355].

(a). Eşyaya Bağlı Ayni Haklar

373 Sadece eşya lehine kurulabilen sınırlı ayni haklara, eşyaya bağlı ayni hak denmektedir. Örneğin, eşya lehine kurulabilen sınırlı ayni haklara, eşyaya bağlı ayni hak ismi de verilmektedir.

Kişinin şahsına değil, onun sahibi olduğu taşınmaz lehine ayni hak kurulur. Kim ki lehine irtifak kurulan taşınmazın malıki ise o irtifak hakkının sahibi olur (TMK m.779, 839 II).

374 Eşyaya bağlı ayni hakların kaderi, lehine kurulduğu yararlanan taşınmazın hukuki kaderine bağlıdır. Bu sebeple de, taşınmazın devrinden bağımsız olarak sağlar arası tasarrufla ondan ayrı devredilemez; ölüme bağlı tasarrufa konu olmaz. İrtifakın lehine kurulduğu taşınmaza "*yararlanan* (veya "hakım") *taşınmaz*"; irtifakla yüklü taşınmaza "*yüklü* (veya "hadim") *taşınmaz*" ismi verilmektedir. Sınırlı ayni haklardan irtifak hakkı eşyaya bağlı ise, eşyaya (ayni veya arzi) bağlı irtifak olarak adlandırılmaktadır.

(b). Kişiye Bağlı Ayni Haklar

375 Sadece kişi lehine kurulabilen sınırlı ayni haklar, kişiye bağlı ayni hak olarak isimlendirilmektedir. Örneğin, kişi lehine kurulabilen sınırlı ayni haklara, kişiye bağlı ayni hak ismi de verilmektedir.

376 Kişiye bağlı ayni haklar, irtifaklar ve taşınmaz yüküdür. Sınırlı ayni haklardan irtifak hakkı, kişiye bağlı ise, kişiye bağlı irtifak olarak adlandırılmaktadır. Kişiye bağlı irtifakların bir kısmı, belirli süreli veya lehine kurulduğu kişinin ömrü ile sınırlıdır; mirasçılara intikal etmez.

---

[355] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.263 f. **REY**, I. N.234 f. Syst. Teil. N.76 ff.

377 Doktrinde bu nitelikteki irtifaklara "şahısla kaim ayni haklar[255]", "*el değiştirmeyen kişiye bağlı irtifaklar*[256]" terimi kullanılmaktadır; biz ise "*düzenli kişiye bağlı irtifaklar*[257]" olarak adlandırmaktayız.

378 Kişiye bağlı irtifakların diğer kısmı ise sağlar arası ve ölüme bağlı tasarrufla üçüncü kişilere devredilebilir; hak sahibinin mirasçılarına intikal eder. Kişiye bağlı irtifakların bazılarının üçüncü kişiye devri kanundan kaynaklanabilir, örneğin üst hakkı ve yapı hakkı veya hukuki işlemden, üst ve kaynak hakkı dışında kalan diğer irtifaklar kaynaklanır. Bunlara da "*düzensiz kişiye bağlı irtifaklar*" olarak isimlendirilmekteyiz. Bu nitelikteki kişiye bağlı irtifakların üçüncü kişiye devredilebilmesinin aksi sözleşmeyle kararlaştırılabilir.

(c). Eşyaya veya Kişiye Bağlı Sınırlı Ayni Haklar

379 Bazı sınırlı ayni haklar, hem eşya lehine hem de kişi lehine kurulabilir. Örneğin geçit irtifakı kişinin ihtiyacını karşılamak üzere kişiye bağlı olarak veya komşu taşınmazın ihtiyacını karşılamak üzere eşyaya bağlı olarak kurulabilir[258].

(d). Alacağa Bağlı Ayni Haklar

380 Sadece alacak lehine kurulabilen sınırlı ayni haklara, alacağa bağlı ayni hak olarak isimlendirilmektedir. Bunlar "fer'i ayni haklar[259]" olarak da isimlendirilmektedir. Bunlar ne kişiye bağlı ne de eşyaya bağlı olarak kurulabilir. Örneğin, rehin hakları alacağın hukuki kaderine bağlı ayni haktır. Alacağın sahibi kim ise rehin hakkının sahibidir; alacağın sahibi değiştikçe rehin hakkının sahibi de değişir.

---

[255] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 819.

[256] KÖPRÜLÜ/KANETİ, s. 44.

[257] AKİPEK/AKINTÜRK, s. 28; GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 789, 796; ÜNAL/BAŞPINAR, s. 61.

[258] KOCABAŞ, s. 35 vd.

[259] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 25.

§ 3. EŞYA HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ

I. GENEL OLARAK

381 Eşya hukukuna hakim olan genel ilkeler TMK'da tek tek sayılmamıştır. Zira, TMK eşya hukuku kurum ve hükümlerini soyut olarak düzenlemiştir. Eşya Hukuku kitabının hükümleri bir bütün olarak incelendiğinde, eşya hukukuna hakim olan genel ilkelerin belirlenmesi söz konusu olabilmektedir.

382 Eşya hukukuna hakim olan genel ilkeler, TMK m.1 I anlamında, TMK'nın eşya hukuku hükümlerinin özüne dâhil olarak ilgili maddenin uygulanmasında, yorumlanmasında rol oynar.

383 Tıpıklık ilkesi geçerli olsa da eşya hukuku hükümlerindeki kanun boşluğunun doldurulmasında da eşya hukukunun genel ilkeleri rol oynar[1].

Hatta kanuni -toplu- kıyas olarak, uyuşmazlığa kanun hükmü olarak uygulanması gerektiği de savunulabilir[2].

Diğer yandan, doktrin ve uygulama tarafından geliştirilen genel ilkeler uygulanacak hukukun belirlenmesinde, yardımcı kaynaktır[3].

384 Eşya hukukuna hakim olan genel ilkeleri şu şekilde belirleyebiliriz[4]:

- *Mutlaklık İlkesi:* Bu ilke ayni hakkın mutlak hak olması dolayısıyla söz konusu olan ilkedir. Mutlaklık ilkesi, bir ilkeden ziyade, hakkın niteliğinin ve bu nitelikten doğan özelliği olarak görmek gerekir. Ayni hakkın mutlak hak olması ve buna ilişkin özellik ve bu özelliğe ilişkin sonuçları yukarıda incelemiş idik[5].
- *Aleniyet İlkesi;*

---

1 **MEIER-HAYOZ,** BK ZGB Art. 1-10, I, N.405 ff, 410.

2 Hukukun genel ilkelerinin rolü konusunda bkz. **ANTALYA/TOPUZ,** MH, §8, II, C, 3, b.

3 **REY,** I, N.270.

4 **TUOR/SCHNYDER/SCHMID,** § 87 N. 8 f. **MEIER-HAYOZ,** BK Syst. Teil. N.56 ff; **REY,** I, N.270 ff; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP,** N.61 ff. **SIMONIUS/SUTTER,** I, s.100 ff. **STEINAUER,** I, N.120 ff. Alman hukuku için bkz. **SCHREIBER,** s.272 ff; Mukayeseli hukuk için bkz. **STADLER,** JZ 65/2010, s.380 ff.

5 **ANTALYA,** EH I, N. 264.

- *Tipe Bağlılık İlkesi (Sınırlı Sayı İlkesi),*
- *Belirlilik İlkesi*[6],
- *Sebebe Bağlılık İlkesi*[7],
- *Katılma (İltihak) İlkesi*[8].
- *Zaman İtibarı ile Öncelik İlkesi*[9].

385 Eşya hukukunun tamamına hakim olan bu ilkeler yanında, bazı sınırlı aynî haklara özel aşağıdaki genel ilkeler de söz konusudur[10]:

- Taşınmaz ve taşınır rehninde, fer'i hakların bağımlılığı ilkesi[11],
- Taşınır rehninde, rehin sorumluluğunun bölünmezliği ilkesi[12],
- Taşınmaz hukukunda, ayni görünüm ilkesi ve talep ilkesi geçerlidir[13]. Bu ilkeleri tapu sicilinin şekli kamuya açıklığı olarak TMK m.1020 düzenlemiştir. Taşınmazlara ilişkin bu ilkeler, belirlilik ilkesine bağlı alt ilkeler olarak değerlendirilebilir.

II. ALENİYET İLKESİ

A. Aleniyet İlkesi (Kamuya Açıklık İlkesi)

386 Aynî hakların, mutlak hak niteliği gereği, ihlal eden herkese karşı ileri sürülebildiğini ifade etmiştik. Şu halde, aynî hakkı ihlal etmemesi istenen kimselere karşı, aynî hukukî durumun dışa yansıtan bir tezahür şekline ihtiyaç vardır.

387 Aleniyet ilkesi (*Publizitätsprinzip, Offenkundigkeit*), eşya üzerinde var olan aynî hakkın herkes tarafından varlığını ve bu hakkın süjesinin

---

[6] **AYBAY/HATEMİ**, belirli konu – bireysel işlem ilkesi olarak ifade etmiştir (s.22 vd.).

[7] "... *Medeni Yasa, aynî hakkın kazanılmasında tescilin haklı ve geçerli bir hukuksal sebebe dayanmasını zorunlu kılmıştır* ..." (Y. 1. HD. 09.06.1989 T., 6084 E., 7468 K.).

[8] **AYBAY/HATEMİ**, yan nesnelerin aynî haklar bakımından asla bağımlı olması olarak ifade etmiştir (s.22 vd.).

[9] **ERTAŞ**, ilaveten 'mutlak olma ilkesi', 'devredebilirlik ilkesi' ve 'mülkilik ilkesi'ni genel ilke olarak saymaktadır (s. 22 vd.).

[10] **REY**, I, N.271

[11] **RIEMER**, Sachenrecht, II, § 22 N.10, § 31, N.16.

[12] **ZOBL**, Syst. Teil, N.309 ff.

[13] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.100 ff.

kim olduğunun tanınabilir ve bununla birlikte belirlenebilir olmasını ifade eden ilkedir[74].

388 Aleniyet ilkesi eşyadaki hakkın hukuki durumunu kamuya bildirir. Bu sebeple aleniyet ilkesine, kamuya açıklık ilkesi (Offenlegungsprizip) ismi de verilmektedir. Bu ilke Roma hukukunun aksine, Pandekt hukukunun Türk-İsviçre hukukundaki etkisi ile düzenlenmiştir.

389 Aleniyet ilkesi eşyanın toplumsal ve ticari ilişkilerde tedavülünde hukuk güvenliği sağlar. Aleniyet prensibinin, özellikle taşınmaz hukukunda ilke olarak kabul edilmesi, bazı durumlarda eşyanın tedavülünde engelleyici rol oynadığı söylenebilir.

390 Nispi haklar, alacak hakları, nispilik ilkesi gereği aleniyete ihtiyaç duymazlar; hatta ticari hayatta sözleşmelerin ve bunlardan doğan alacak haklarının ve borçların gizliliği özel hükümlerle korunmaktadır.

B. Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları

1. Genel Olarak

391 Kamuya açıklığı sağlayacak araçları (Publizitätsmittel), eşya hukukunun temel ayrımı olan taşınır ve taşınmaz ayrımına göre, TMK'da ve özel kanun hükümlerinde düzenlenmiştir[75].

392 Aynı hakta aleniyetin sağlanabilmesi için, kamuya açıklık araçlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ya fiili bir olgu ya da sicil olgusu olabilir. Sicil olgusu taşınmazlarda, fiili olgu olan zilyetlik aleniyetin kamuya açıklık aracıdır.

393 Kısaca belirtirsek, taşınır eşyalarda ayni hakkı alenileştiren kamuya açıklık aracı zilyetlik olduğu halde, taşınmazlarda tapu sicilidir[76].

394 Şimdi meseleyi bir örnekle somutlaştıralım: (A)'nın elinde bir cep telefonu vardır ve (A) telefonu kullanmaktadır. Dış görünüş itibarıyla başkaları o cep telefonunun yani cep telefonu üzerindeki mülkiyet hakkının

---

[74] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.100 ff; **WIEGAND**, BSK vor Art.641, N.53 ff; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.63 ff; **DOMEJ**, KurzKomm vor Art.641-654a, N.20; **ARNET/BELSER**, HK ZGB Art.641, N.22.

[75] Geniş bilgi için bkz. **ŞENGÜL**, s.7; **HEDDINGER**, s.41 ff.

[76] **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.20; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.65; **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.56 ff; **REY**, I, N.270 ff.; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.63.

(A)'ya ait olduğunu düşünürler. Mülkiyet hakkı ise en geniş yetkileri sağlayan ayni haktır. Buna göre, bir kimsenin bir taşınır mal üzerinde ayni hak sahibi olduğu hususunu, söz konusu eşyanın o kişinin zilyetliğinde bulunmasından anlarız. Taşınır eşyalar üzerindeki ayni hakları başkaları nazarında alenileştirip bilinebilir hale getiren husus eşyaya zilyet olmaktır. Taşınmazlara geldiğimizde ise, (A)'nın bir arazinin malıki olduğu hususunu ancak tapu sicilinden anlayabiliriz. Zira bir taşınmaz üzerinde ayni hak (örnekte mülkiyet hakkı) tapuya tescil ile kazanılır. Tapu herkese açık olduğu için oradaki kayıtların bilinmediği de ileri sürülemeyecektir.

395 Aleniyet ilkesinin kamuya açıklığı sağlayan araçlarıyla, taraflar arasındaki eşya hukuku ilişkini görünür hale getirir, böylelikle kişi ile eşya arasındaki ilişki ne olduğu, ilişkinin kapsamı, bu ilişkide kimin hak sahibi olduğunu belirler[17].

2. Taşınırlarda Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları: Zilyetlik, Siciller

a. Zilyetlik

396 Taşınır mallarda ayni hakkın varlığını ve sahibinin kim olduğunu anlamaya yarayan araç, zilyetliktir[18]. Zilyetlik, bir taşınırın iradi olarak fiili hâkimiyet altında bulundurulması halidir. Zilyetliği aşağıda detaylı olarak inceleyeceğiz[19].

b. Siciller

397 Hukuk düzeni içinde hukuk güvenliğini sağlamaya yönelik olmak üzere, bazı taşınırların aleniyet fonksiyonu sağlayan sicillerde söz konusudur. TMK m. 940 II hükmü, gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarının güvence altına alınması için, kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşınır mallar üzerinde, zilyetlik devredilmeden de, taşınır malın kayıtlı bulunduğu sicile yazılmak suretiyle rehin kurulabilmesine imkân vermiştir. Rehnin kurulmasına ilişkin diğer hususlar tüzükle belirlenecektir. Diğer sicillere örnek olarak aşağıdaki sicilleri gösterebiliriz:

---

[17] **WIEGAND**, BSK ZGB vor Art.641 ff. N. 55.

[18] **NOMER/ERGÜNE**, s.94 vd.; Ayrıntılı bilgi için bkz. **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.107 vd.; **AYAN**, s.35; **ESENER/GÜVEN**, s.52.

[19] **ANTALYA**, EH II, N. 65 vd.

aa. Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Devir Sözleşmesi Sicili

398 TMK m.764 hükmüne göre, taraflar arasında yapılan mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi, alıcının yerleşim yeri noterince resmi şekilde yapılır ve noter tarafından tutulan özel sicile kayıt edilir. Hayvan satışları bu sözleşmenin konusunu oluşturmaz.

bb. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Sicili

399 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu'nu yürürlükten kaldıran Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TRK), düzenlediği taşınır varlıklarda ve ticari işletme üzerinde rehin hakkı tesisi (m. 4), rehinli taşınır sicilini (m.8), tarafları (m.3), üzerinde rehin kurulabilecek taşınır varlıkları (m.5), rehin hakkının üçüncü kişiye olan etkisini (m.9), rehin sözleşmesin tarafların hak ve yükümlülüklerini (m.12) ve rehinli işletmelere ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemiştir[=].

400 Taraflarını (TRK m.3) kanunda belirtilen kişilerin oluşturduğu ve yine kanunun belirlediği taşınır varlıklar ve ticari işletme üzerinde (m.5) rehin hakkı, rehin sözleşmesinin (m. 3(6) ve 12)) sicile tescili ile kurulur (m. 4 (1)); sicile tescil kurucudur.

401 Rehin hakkının tesisi ve üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesi, rehinli alacaklılar arasında öncelik hakkının belirlenmesi, rehinli taşınır varlık ile alacağın devrinin tescili amacıyla Rehinli Taşınır Sicili (TARES) kurulur (m.8 (1)). Sicilin kuruluş ve işleyişi ile bu sicille diğer kanunlar uyarınca tutulan taşınır sicillerinin verilerinin paylaşımına yönelik usul ve esaslar Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Sicil hizmetlerinin ifası amacıyla Ticaret Sicil Sistemi (TARES) kurulmuştur ((RTSY m. (1) k, 15 vd.). TRK m. 9 (1)'e göre, rehin hakkı, rehin sözleşmesinin sicile tescil edilmesiyle üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder.

cc. Hayvan Rehni Sicili

402 TMK m. 940 IIüncü maddesi gereğince, hayvan üzerinde teslimsiz rehin tesisi imkânı tanınmış olup, bu hayvan rehni, Hayvan Rehni Tüzüğünde (HRT) düzenlenmiştir. Rehin hakkının tesisi için bu sicile kayıt yeterlidir (HRT m.9 son fıkra). Buradaki tescil kurucudur.

= Ayrıntılı bilgi için bkz. **ANTALYA/ACAR**, s.14 vd.

403 Sicilin aleniliği, HRT m. 8'de "Hayvan rehni sicili alenidir. Menfaati bulunan herkes sicilde bir kayıt bulunup bulunmadığı ve varsa mahiyeti hakkında sözlü veya yazılı bilgi verilmesini sicili tutan memurdan isteyebilir." şeklinde düzenlenmiştir. TRK m.5 d hükmü uygulama kapsamında ticari işletmede taşınır rehnine konu varlık olarak hayvanların rehin verilmesini düzenlediğinden, TMK m.940 ve HRT uygulanmayacaktır[21]. TRK'nın gerek kapsam (TRK m.1) gerekse tarafları (TRK m.3) yönünden hayvan rehni kurulamadığı hallerde TMK m.940 atfiyla HRT hükümleri uygulanabilecektir. Ancak TRK'nın yürürlüğe girmesi sonrasında uygulama alanı oldukça daralmıştır.

dd. Gemi Sicili

404 6102 sayılı TTK m.875-877, 954 ile 995'inci maddeler arasında gemi sicilini düzenlemiştir. TMK m.973 hükmünde gemi sicilinin aleniliği ilkesi düzenlenmiştir[22]. Ayrıca gemi sicilinin karine olduğu TTK m.974 hükmünde[23] ve sicile güven ilkesinin geçerli olduğu TTK m.983 hükmünde[24] düzenlenmiştir. Şerh verilebilecek haklar ve bunların etkisi ayrıca hüküm altına alınmıştır[25]. Tescil edilmiş aynî haklardan doğan istem

---

[21] ANTALYA/ACAR, s.69-79.

[22] TTK m. 973'e göre, *"(1) Gemi sicili açıktır. Herkes sicil kayıtlarını inceleyebilir ve giderini ödemek şartıyla onaylı veya onaysız örneklerini alabilir. (2) Haklı bir menfaatinin olduğunu inandırıcı bir şekilde ortaya koyar bir kişi, sicil dosyalarını, bir kaydın tamamlanabilmesi için gemi sicilinde kendilerine gönderme yapılan belgeleri ve henüz sonuçlanmamış tescil istemlerini de incelemeye ve onların örneklerini almaya yetkilidir."*

[23] TTK m. 974'e göre, *"(1) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, geminin maliki sayılır. (2) Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteği veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir intifa hakkı tescil edilmiş olan kişi o hakkın sahibi sayılır. (3) Tescil olunmuş bir hak siciden silinirse o hakkın artık var olmadığı kabul edilir. (4) Türk Medenî Kanununun 992'nci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklıdır."*

[24] TTK m. 983'e göre, *"(1) Hukuki bir işlem ile bir geminin mülkiyetini, intifa hakkını, gemi ipoteğini veya ipotek üzerindeki bir hakkı iktisap eden kişi lehine gemi sicilinin içeriği, bu haklarla ilgili olduğu ölçüde doğru sayılır; meğerki, iktisap eden kişi kaydın doğru olmadığını bilmiş veya bilmesi gerekmiş olsun. Hak sahibinin kayıtlı bir hak üzerindeki tasarruf yetkisi belli bir kişi lehine sınırlanmış ise, bu sınırlama iktisap eden hakkında ancak gemi sicilinde yazılı olması veya onun sicil kaydının doğru olmadığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi şartıyla hüküm ifade eder. (2) Hakkın iktisabı için tescil şart olan hâllerde, kaydın doğru olmadığının bilinmesi bakımından tescili istem tarihi asıldır. (3) Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiş olan bir kişiye bu hakkı sebebiyle bir edimde bulunulması veya bu kişinin üçüncü bir kişi ile, sicile kayıtlı bir hak üzerinde birinci fıkrada yazılı olanlar dışında bir tasarruf işlemi yapılması hâllerinde de birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır."*

[25] TTK m. 977'ye göre, *"(1) Bir gemi veya gemi ipoteği üzerinde bir hakkın kurulmasını veya kaldırılmasını yahut böyle bir hakkın içeriği veya derecesinin değiştirilmesini isteyebilmek hakkını teminat altına almak için gemi siciline şerh verilebilir. Gelecekte doğacak veya şarta bağlı bir istem hakkının teminat altına alınması amacıyla gemi siciline şerh verilmesi mümkündür. (2) Şerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapılacak tasarruflar, şerh ile teminat altına alınan hakkı ihlal ettiği ölçüde geçerli değildir. Tasarrufun cebrî icra veya ihtiyati haciz yoluyla yahut iflas idaresi tarafından yapılması hâllerinde de hüküm böyledir. (3) Şerh ile teminat altına alınan hakkın derecesini belirlemede şerh tarihi esas tutulur. (4) Hak, şerh verilmek suretiyle teminat altına alındığı ölçüde yükümlünün mirasçısı, sorumluluğunun sınırlı olduğunu ileri süremez."*

hakları, tescil devam ettiği sürece zamanaşımına tabi değildir (TTK m.984-(1)).

ee. Uçak Sicili

405 Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca *"Türk sivil hava araçlarının tescili için Ulaştırma Bakanlığınca bir sicil tutulur. Bu sicile "Uçak Sicili" adı verilir."*

406 Uçak sicili hava araçlarının kaydedildiği özel bir sicil olup, bunlara ait bilgilerin ve hukukî ilişkilerinin alenileştirilmesine hizmet eder. Hava aracının tamamı veya bir payının üzerinde mülkiyet ve diğer ayni hakların tesisi, devri ve temlik için yazılı sözleşme yapılması lazım ve kafidir.

407 Temlike ilişkin sözleşmeler yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli değildir. Sözleşmeler uçak siciline tescil edilmeden üçüncü şahıslar bakımından hüküm ifade etmez (m.66).

408 Türk Sivil Havacılık Kanunu, hava araçlarının teslime gerek kalmaksızın rehnedilebilmelerine imkân tanımıştır. Bu Kanunun 69 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan ayni hak türü "hava aracı ipoteği"dir[25].

ff. Maden Sicili

409 Maden sicili ve işletme haklarının ve maden cevherinin rehni 3213 sayılı Maden Kanunu m. 39, 108'de düzenlenmiştir.

gg. Kamuya Açık Yerlerin İşletilmesinden Doğan Kamu Borçları İçin Bu Yerlerdeki Eşya Üzerindeki Rehin

410 Kamuya açık yerlerin işletilmesinden doğan kamu borçları için bu yerlerdeki eşya üzerindeki rehin 6183 sayılı Amme Alacaklılarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun m. 12'de düzenlenmiştir.

3. Taşınmazlarda Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları: Tapu Sicili, Kat Mülkiyeti Sicili

a. Genel Olarak

411 Zilyetlik taşınır mallarda ayni hakkın varlığı ve sahibi hususunda kural olarak yeterli aleniyeti sağlamakta ise de, taşınmazlar bakımından ay-

[25] Bkz. HIZIR/TURUEV, s.371-404. Hava aracı ipoteğine ilişkin ayrıca bkz. AKÇURA KARAMAN, s. 32 vd.

nı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira bir çalışma masasında ve çantasında taşıdığı bilgisayar kişinin maliki olduğu kabul edilirken, bir evde oturan ya da bir araziyi işleyen kimse her durumda onun malıkı sayılmayabilir. Bu nedenle taşınmaz mallarda ayni hakkın varlığını kamuya açıklamaya yarayan vasıta, o hakkın tapu siciline tescil edilmiş olmasıdır. Zira taşınmazları konu alan tüm ayni haklar kural olarak tapu siciline tescil ile kurulur (TMK m.1021).

412 Tescil varsa ayni hak kazanılmıştır, tescil yoksa ayni hak kazanılmamıştır. Ayrıca tapu sicili herkese açıktır. Kimse tapudaki kaydı bilmediğini ileri süremez (TMK m. 1020). Tapu sicili veya kat mülkiyeti sicili, ayni hakların, eşyaya bağlı borçlar da dâhil olmak üzere, kamuya açıklık araçlarıdır[27].

b. Tapu Sicilinin Etkisi

aa. Tapu Sicilinin Olumsuz (Kurucu) Etkisi

413 Kaydın olumsuz etkisi olarak ifade edilebilen tapu sicilinin etkisi, taşınmazlar üzerinde ayni hak kazanımı için kural olarak ayni hakkın tapu siciline kaydı (tescili, şerhi) şart olduğunu ifade eder. Başka bir ifadeyle taşınmazlar üzerinde bir ayni hakkın kazanımı, değişimi için tescil şarttır. Tapu siciline tescille ayni hak doğar (TMK m.1022 I).

414 Aynı hakkı devrini konu alan tasarruf işlemi yapılsa da, tescil yapılmadıkça ayni hak kazanılmaz. Tasarruf işlemi, tamamlayıcı olgu olan tescille tamamlanır. Tescilin bu olumsuz etki, TMK m.1020'de genel kural olarak ifade edilmekle yetinilmemiş; mülkiyet (TMK m.705 I) ve sınırlı ayni hak kazanımı için (TMK m.780 I, 795, 840 I, 856 I) kanunda özel olarak düzenlenmiştir. Bu hallerde, tescilin *kurucu* etkisi söz konusudur. Bu etkiye *tescilin olumsuz hükmü* ismi de verilmektedir.

415 Tescilsiz ayni hak kazanımı sonrasında yapılan tescilde ise, *açıklayıcı* etki söz konusudur. Tescilsiz ayni hak kazanımında yine o hakkın tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır (TMK m.705 II c.2; m.780 II).

bb. Tapu Sicilinin Olumlu (Maddi) Etkisi

416 Tasarruf yetkisi eksikliğine rağmen, yapılan tasarruf işlemi sonucunda iyiniyetli üçüncü kişinin ayni hak kazanımı korunması tapu sicilinin

---

[27] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.58; **HAAB**, ZK Einl. N.63; **LIVER**, SPR V/1, s. 311; **REY**, I. N.280 ff.

olumlu maddi etkisidir. Bu etkiye tescilin (madcî) olumlu etkisi hükmü ismi de denilmektedir.

417 TMK m. 1023 hükmü, tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan üçünü kişinin bu kazanımı korunur[28].

C. Aleniyet İlkesinin Etkisi

1. Genel Olarak

418 Aleniyet ilkesinin kamuya açıklığı sağlayan, taşınmazlarda tapu sicili, taşınırlarda zilyetlik araçlarıyla, taraflar arasındaki eşya hukuku ilişkindeki hakkın ne olduğu, hakkın kapsamı ve bu ilişkide kimin hak sahibi olduğunu belirlenir[29].

2. Hak Karinesi Etkisi

419 Aleniyetin ayni hakkı görünür hale getirerek belirleme etkisi, zilyetlikte tam olarak ortaya konulmasa da, kanun koyucu zilyedin, zilyetliğinde bulundurduğu taşınır üzerinde iddia ettiği hakkın varlığına karine teşkil ettiğini düzenlemiştir. TMK m.985 hükmü taşınırın zilyedi onun maliki sayılır[30].

420 Zilyetliğin hak karinesi özelliği taşınmazlarda BGB § 891 aksine düzenlenmemesine karşın, TMK'nın m.1020 ile 1024 hükümleri incelendiğinde, tapu siciline kayıtlı taşınmazlar bakımından, -tapu sicilinin olumlu etkisi olarak – söz konusu hak karinesinin tapu sicilinde kayıtlı haklar bakımından olduğunu söyleyebiliriz[31]. TMK m.7 resmi sicil olan tapu sicilinin belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturduğuna ilişkin kari-

---

[28] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.57; **HAAB**, ZK Einl. ZGB, N.62; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.27 vd.; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.94 vd.; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.66.

[29] **WIEGAND**, BSK vor Art.641 ff ZGB, N. 55.

[30] YİBK., T.09.10.1946, E.1946/6, K.1946/12. "*Medeni Kanunun 898. maddesi menkul malda asli zilyetliğin mülkiyet karinesi olduğunu bildirir. 899. maddesi yine menkul malda fer'i zilyedin dayanabileceği mülkiyet karinelerini göstermekle beraber bu maddenin ikinci fıkrası zilyedin, menkul şeyi kendisine vermiş olan kimseye karşı bu karineyi dermeyan edemeyeceğini beyan eder. Bu maddeler hükümlerinin menkul mallar hakkında olduğu açıktır. Gayrimenkul mallarda zilyedlik mülkiyet karinesi değildir. Bu karineyi ancak tapu sicilindeki kayıt teşkil eder. Bu halde 899. maddenin ikinci fıkrasına dayanılarak ikinci zilyedin, kendisinden gayrimenkul malı aldığı birinci zilyede karşı mülkiyet karinesine dayanamayacağı ve bu malı birinci zilyede geri vermesi gerektiği yolunda ileri sürülen mütala da yersiz bulunur.*"

[31] Karş. **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.59; **HAAB**, ZK Einl. N.62; **LIVER**, SPR V/1, s. 311; **REY**, I, N.287.

neyi düzenlemiştir[32]. Tapu sicilinin ve zilyetliğin hak karinesi olması, hukuk yargılamasında ispat yükünü tersine çevirir[33].

3. Taşınmazlarda Aleniyet İlkesinin Yansımaları ve Etkileri

a. Taşınmazlarda Sınırlı Açıklık İlkesi

aa. Genel Olarak

421 Tapu sicilinin açıklık ilkesi TMK m.1020 I'de "Tapu sicili herkese açıktır" şeklinde ifade edilmiştir. Tapu sicilinin herkese açıklığı sınırsız değildir. Tapu sicilinin aleniyeti, *"ilgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilmesi" (TMK m.1020 II)* ile sağlanır[34].

422 Herkesten kast edilen her üçüncü kişi değil, tapudaki kayıtla ilgisini inanılır kılan üçüncü kişiler, sadece tapu sicilinin ilgisi olduğu kaydı inceleyebilir.

423 Tapu sicilinde aynî veya eşya bağlı hak sahibi olan veya hakkın yükümlüsü olanların inceleme ve örnek alma hakkı olduğu tabiidir.

Bu konu aşağıda elektronik tapu sicili kapsamında tekrar incelenecektir.

bb. İnceleme ve Örnek Alma Hakkı

424 Tapu sicilleri, Tapu Müdürlüğü dışına çıkarılamaz; ancak, mahkemeler veya yetkili resmî merciler tarafından sicil veya belgelerin aslı istenildiği takdirde, örnekleri müdür tarafından tasdik edilip, iade edilmek üzere imza karşılığında asılları verilir. Onaylı örnek belgeler, asılları iade edilene kadar özenle saklanır (TST m.84).

425 TMK m.1020 II'e paralel olarak, ama daha dar olarak TST m.84 (2) hükmü, kamu tüzel kişisine (Devlete), özel hukuk kişilerine bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, tapu kayıtlarının onaylı örneğinin verileceğini düzenlemiştir. Mahkemeler, Cumhuriyet

---

[32] ANTALYA/TOPUZ, MF. §13. VI.

[33] ANTALYA/TOPUZ, MF. §13. VI. D.

[34] BÄNZIGER-COMPAGNONI, s.75 ff; 89 ff.; ETTER-STREBER, recht 1988, s.35 ff; REY, ZBGR 1984, s.73 f; HAUSHEER, ZBGR 1988, s.1 ff.

Başsavcıları ile özel kanunları ve tüzükleri gereği görevli ve yetkili kişilerin suç araştırma veya soruşturma kapsamında yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerinin verilmesi mümkündür. Tapu işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen istem belgesi, resmî senet, tapu senedi ve ipotek belgelerinin birer örneği, Tapu Müdürlükleri tarafından hak sahiplerine verilir (TST m. 85 (1)). İlgilisinin istemi hâlinde, tapu sicilini oluşturan diğer bilgi ve belgelerin örneği verilir (TST m. 85 (2)).

426 Tapu sicili kayıtlarının incelenmesi ve örnek alınması, bir ilginin varlığı ile sınırlandırılmıştır; bu ilginin hukuken korunmaya değer bir menfaate dayalı olması gerekir. Ancak, korunmaya değer menfaati daha az olan bazı durumlarda örneğin, hangi taşınmazda, hangi tarihten itibaren, hangi hukuki sebebe dayanarak, kimin ayni hak sahibi olduğu, hak sahipliğinin mülkiyet mi yoksa başka bir sınırlı ayni hak olduğunu öğrenmekte ilgisi var olduğu kabul edilmelidir[35].

427 Kamu düzeni ve tapu siciline güvenin gereği olarak, gerek özel hukuk tüzel kişilerinin, gerekse kamu hukuku tüzel kişilerinin münferit isteklerinde de ilginin varlığının ispatı aranmalıdır. Örneğin, uygulamada, bankaların kredi aşamasında, kişilerin taşınmazlarına ait araştırma ve inceleme kapsamında bilgi istemlerinde, banka müdürlüklerince yazılı talepte bulunmaları halinde, incelenmesi talep edilen taşınmazın tapu senedi fotokopisinin ibrazı ile ilgisi ispatlanması istenmekte, belge örneği istemlerinde ise malikin veya yetkili vekilinin yazılı talebi aranmaktadır.

428 4667 sayılı Kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2.II. maddesi "*Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır...*" hükmünü getirmiştir.

429 Tapu sicilindeki kaydın süjesine ilişkin kişilik değeri oluşturan kişisel verilerin korunması için de tapu müdürlükleri özen göstermekle yükümlüdür. Nüfus kimlik bilgileri ile yerleşim paylaşımında, talep edenin kamu ve özel ayrımı yapmaksızın kayıtla ilgisinin varlığına dikkat etmelidir.

---

[35] ZGB Art. 790 (2).

cc. Elektronik Ortamda Verilere Erişim Hakkı

430 Tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulması halinde, ana ve yardımcı siciller TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) içerisinde saklanır ve yönetilir (TST m. 12 (1)).

431 Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek sağlanabilir (TST m. 14 (1)). Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilirler (TST m.14 (2)). Protokolde, TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, erişimin türü ve şekli, erişim kontrolü, verilerin kullanım amacı, üçüncü kişilere kullandırılmasına ilişkin sınırlamalar ve amacı dışında kullanımın sonuçları yer alır (TST m.14 (3)). Erişim hakkına sahip kuruluşlar, taşınmaz ile ilgili verileri TAKBİS üzerinden alırlar. Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, düzenlenecek sözleşme şartları dâhilinde verilere erişebilirler (TST m.14 (4)). Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilir (TST m.14 (5)).

dd. Kaydın Herkesçe Bilindiği İlkesi

432 Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez (TMK m.1020 III). Kaydın herkes tarafından bilindiği olgusunun fiksiyon olduğu; bu sebeple aksinin ispat edilemediği kabul edilmektedir. Bu olgu tapu sicilinin (tescilin) olumlu etkisi yani tapuya güven ilkesi ile yakından ilgilidir[56].

ee. Kaydın İçeriğinin Doğru Olduğuna Kanıt Oluşturması İlkesi

433 Tapu sicilindeki kayıtlar, tapu sicili kaydın yani kayıttaki hak sahipliğinin, hakların ve hakların niteliğinin ve kapsamının doğru olduğuna kanıt teşkil eder (TMK m. 7).

b. Taşınmazların Tapu Siciline Kayıt İlkesi

434 Her taşınmaz için tapu kütüğünde, her bağımsız bölüm için kat mülkiyeti kütüğünde ayrı sayfa açılır (TMK m.1000 I ve KMK m.13 II). Bu

[56] SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 459 ff; REY, I, N 296a; ZOBL, Grundbuchrecht, N.106 ff.

kütüklere ancak tıpıklık ilkesi gereği hukuk düzeninin belirlediği haklar, hukuk düzeninin belirlediği kapsamda kaydedilebilir (TMK m.1000 III ve 1008 vd.). Bu ilke, ayni hakların belirlilik ilkesi ile de yakından ilişki içindedir.

c. Ayni Hakların Tescili İlkesi

aa. Tescille Kazanım İlkesi

435 Tapu kütüğüne kayıtlı taşınmazda mülkiyetin veya başka bir sınırlı ayni hakkın kazanımı veya kaybı, kural olarak, tapu siciline kayıtla gerçekleşir. Bu ilke ayni hakkın kazanımı bakımından TMK m.1021'de "*kurulması kanunen tescile tâbi ayni haklar, tescil edilmedikçe varlık kazanamaz*" şeklinde ifade edilmiştir. Tescil ilkesi, taşınmazlarda aleniyet ilkesinin, ticarî yaşamda tapu sicili ile somutlaşmasını hizmet eder. Aynı ilke, mülkiyetin kazanımı bakımından TMK m.705 hükmünde, "*taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur*" denmek suretiyle kural ortaya konmuştur. İstisna olarak, "*Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâller*"de mülkiyetin tescilden önce kazanılacağı belirtilmiştir.

436 Ayni hakların tescille kazanımı ilkesi "*taşınmazlarda tescil ilkesi*" olarak da ifade edilebilir. Taşınmazlarda tescil ilkesi, taşınmazların ayni hakkın tescil edilmesi kuralını ve tescil zorunluluğunu ifade eder. Taşınmazlardaki ayni hakkın tescili ticari yaşam ilişkilerine uygun olarak hukuk güvenliğini sağlar. İrtifak hakkının kurulması bakımından TMK m.780 I, intifa bakımından TMK m.785, taşınmaz yükü bakımından ve TMK m.840 I, rehin bakımından TMK m.856 I c.1 ayni hak kazanımı için tescil şartı aramaktadır.

437 Doktrinde *tescilin olumsuz hükmü* olarak incelenen ayni hakların tescille kazanımı ilkesi aynı zamanda *tapu sicilinin olumsuz etkisini* de ortaya koymaktadır. Mülkiyetin kaybı bakımından da, TMK m. 717 I'de ayni hakların tapu sicilinde sona ereceği düzenlenmiştir. Tescil ilkesinin mutlak tescil ilkesi ve nispi tescil ilkesi olarak ikiye ayırarak incelememiz gerekir:

aaa. Mutlak Tescil İlkesi

438 Mutlak tescil ilkesi (absulute Wirkungsprinzip), ayni hakların devrini veya yararlanmasını konu alan hukukî işlemler (sözleşmeler) tescil olmaksızın, tek başına ayni hakkı oluşturmaya yeterli değildir; taşınmaz

üzerine ayni hak kazanımı için *tescil kurucu olgudur*. Mutlak tescil ilkesi, tescilin *kurucu (ihdasi) hukuki etkisini* (konstituve, rechtsbegründende Wirkung) ifade eder.

439 Bu kuralın birinci istisnası, TMK m.727 III'te düzenlenen dışarıdan görülebilen mecra irtifakının tescille değil, noterde düzenlenen sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğmasıdır. Bu durumda aleniyet doğal olarak sağlanmıştır; yani *doğal aleniyet* söz konusudur.

440 Diğer bir istisnası da, mecra geçirme hakkının, hak sahibinin istemi üzerine giderleri karşılandığında tapu kütüğüne tescil edilmesidir.

bbb. Nispi Tescil İlkesi

441 Nispi tescil ilkesi (retalive Eintragungsprinzip) ise, ayni hakkın sadece hukuki işleme (sözleşmeye) dayalı tescil olgusuyla değil, kanunda özel olarak düzenlenmiş diğer ayni hak kazandırıcı –tescilsiz iktisap- olguların gerçekleşmesi ile, örneğin, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma, mirasın intikali gibi olguların gerçekleşmesi ile tescil olgusu olmaksızın kazanılabileceğini ifade etmektedir. TMK m. 705 II'de sayılan bu haller *tescilsiz kurucu olgular*dır.

442 Tescilsiz ayni hak kazanım olguları ile kişi taşınmaz üzerinde olgunun gerçekleşmesiyle ayni hak sahibi olsa da, hak sahibinin ayni hak üzerindeki tasarruf edebilmesi, mülkiyetin tapu sicilinde tescil edilmiş olmasına bağlıdır. Buradaki tescil ayni hakkı kurucu değil, *açıklayıcı tescil*dir.

bb. Tescil İçin Talep Zorunluluğu

443 Taşınmazlardaki ayni hak kazanımı, değişimi ve sona ermesi, kural olarak taleple gerçekleşir. TSY m.16 I hükmü "*kanunlarda ve bu Tüzükte belirlenen istisnalar dışında yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamaya*cağını belirtmiştir. Örneğin, bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen değişiklikler, eşlerden birinin istemiyle tapu kütüğüne doğrudan tescil olunur (m.716 III).

444 Tescil, kural olarak tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılır (TMK m.1013 I). Edinen kimse, kanun hükmüne, kesinleşmiş mahkeme kararına veya buna eşdeğer bir belgeye dayanıyorsa, bu beyana gerek yoktur.

445 Bir aynî hakkı tescilden önce kazanan kimse, gereklı belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir. Bir ayni hakka ilişkin tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı üzerine yapılabilir (TMK m.1014 I).

446 Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukuki sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır (TMK m.1015 I). Hukukî sebebin belgelenmesi, şekil zorunluluğu ilkesi gereği, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur.

447 Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, hukuki sebebe ilaveten tasarruf yetkisini de belgelemiş olması gerekir (TMK m.1015 I).

448 İstemde bulunan kimse, kendisinin, aleniyet ilkesi gereği, tapu sicilinde hak sahibi görünen kişi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş olur (TMK m.1015 II).

d. Sebebe Bağlılık İlkesi

aa. Genel Olarak

449 Tapu sicilindeki kayıtların hüküm doğurması sebebe bağlıdır. Türk borçlar ve eşya hukuku işlemlerde birlik değil, ayrılma sistemini benimseyerek, borçlandırıcı işlemle tasarruf işleminin birbirinden ayrı olarak düzenlediği halde, her iki işlemin birbirine sebebe bağlılık ilkesi ile ilişkilendirmiştir[37].

450 Tasarruf işlemin geçerliliği, borçlandırıcı sebep işleminin varlığına ve onun geçerliliğine bağlıdır. Bu bağlılık *sebebe bağlılık ilkesi* olarak ifade edilmektedir.

451 Her iki işlemin tek işlemde birleştiği veya bütünleştiği hallerde (Geschäftseinheit) pek ayrıştırılamazsa da, mevcuttur. Geçersizlik, olgu eksikliği aynılığı her iki sözleşmeyi ayrı ayrı etkiler.

---

[37] Alman hukukunda hakim olan soyutluk ilkesi (Abstraktionsprinzip), BGB'nin benimsediği ayrılık prensibinin/sisteminin (Trennungsprinzip) sonucudur bkz. **STADLER**, Soergel Einl. SachenR. Rn. 28; tasarruf işlemlerinde şekil sorunu hakkında bkz. **TOPUZ. M.**, Ticari İşletmenin Devrinde Tasarruf İşlemlerine İlişkin Şekil Sorunu (İsviçre Birleşme Kanunu (Fusionsgesetz FusG) ve Alman Hukuku Perspektifinde). Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 18 (2), 19 vd.

452 Borçlandırıcı (sebep) işlemin geçersizliğine neden olan geçersizlik sebebi tasarruf işlemine de sirayet ederek tasarruf işlemini de geçersiz kılar. Bunun aksine, tasarruf işleminin geçersizliğine neden olan geçersizlik sebebi ile borçlandırıcı işlemin geçersizliğine neden olan sebepte ayniyet (Fehleridentität) söz konusu ise borçlandırıcı işlem, bu geçersizlikten etkilenir. Örneğin ayırt etme gücünün olmaması sebebiyle ehliyetsizlik, borçlandırıcı işlemi etkiler.

453 TMK m.1015 I hükmünde taşınmazların devrinin sebebe bağlı olduğunu açık olarak düzenlemiştir: "*Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, ... hukukî sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır.*"

454 Sağlar arası işlemlerde, tescilin hukuki sebebi esas itibarı ile taşınmaz devrini konu alan borçlandırıcı işlemlerdir. Konusu yönünden taşınmaz mülkiyeti devreden borçlandırıcı sözleşmeler, örneğin satış sözleşmesini, bağışlama sözleşmesini hukuki sebebi oluşturur.

455 Ölüme bağlı tasarruflarda, örneğin, vasiyetname, miras sözleşmesi taşınmaz devrinin sebebini oluşturabilirler. Hukuki sebebin belgelenmesi de, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur (TMK m.1015 III). Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur (TMK m.1024 II).

456 Bir ayni hak tapu sicilime yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir (TMK m.1025 I). İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemleri korunur (TMK m.1023). Katıldığımız hakim görüş uyarınca, taşınırlarda da geçerli olan bu ilkeyi aşağıda ayrıca inceleyeceğiz.

bb. Sebepte Şekil Zorunluluğu

457 Taşınmazlarda şekil zorunluluğu önemli bir rol oynar. Taşınmazdaki bir ayni hak kazanımı, değişimi ve terkini belirli bir şekil zorunluluğu içinde gerçekleşmesi, aleniyetin doğrudan sonuçlarından biridir.

458 Taşınırlarda ise, tam tersine, kural olarak, sebebi belirleyen borçlandırıcı işlemlerde şekil serbestisi (özgürlüğü) geçerlidir. Taşınır mülkiyetinin naklinin zilyetliğin devri olacağı belirtilmiş; ancak zilyetliğin devrinin şekline ilişkin bir hüküm getirilmemiştir (TMK m.763 I). TMK

m.939 hükmü, teslime bağlı rehnin kurulmasında aynı ilkeyi benimsemiştir.

459 Ancak istisnai olarak kanun taşınır üzerindeki ayni haklar şekle tabi tutabilir. Örneğin, 6570 sayılı TRK m.4 taşınır rehni sözleşmesinin noter tarafından tanzim edileceğini veya güvenli imza ile onanmış elektronik ortamda veya imzaları noterde onanmış yazılı şekilde yapılacağını düzenlemiştir[28].

460 Şekil zorunluluğunun temel gerekçesini, eşya üzerindeki ayni hakkın görünebilir ve bilinebilir olması oluşturmaktadır. Ancak yazılı şekil içinde ortaya konulan bir sebep, ayni hakkın sahibini ve ayni hakkın niteliğini ve kapsamını açık olarak ortaya koyar. Sebebin resmi senette yer alması hakkın aleniyetini ve onunla birlikte hukuk güvenliğini sağlamaya da hizmet eder.

461 Taşınmaza ilişkin ayni hakkın hukuki sebebin belgelenmesi, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur (TMK m.1015 III). Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmesine bağlanmıştır.

462 Ölüme bağlı tasarruflar ve mal rejimleri sözleşmeleri kendilerine özgü şekillere tabidir (TMK m.706 vd.).

463 Taşınmazın devrinin şekli bazen borçlandırıcı işlemin şekline bağlanabilir. Örneğin, TBK m. 237 hükmü, taşınmaz satış sözleşmesinin geçerli olabilmesini, sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesine bağlamıştır.

464 Kanun şekil koruma amacına uygun olarak şekil zorunluluğunda, bazen yazılı şekli bazen de resmi şekli öngörmüştür. Örneğin, taşınmaz mülkiyetinin devri (TMK m.706 I), intifa hakkının kurulması (TMK m.725 II atfıyla m.706 I), rehin sözleşmesi (TMK m.856 I) resmi şekle tabi tutulmuştur. Yine TMK m.781 hükmü taşınmaz irtifak hakkının kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerli olması resmi şekle bağlanmıştır.

465 Tapu Kanunu m. 26'ya göre, resmi şekli yapacak resmi makam, tapu memurudur.

---

[28] ANTALYA/ACAR, s. 34 vd.

e. Tescilde Öncelik İlkesi

466 Aynı haklar tescille doğdukları an itibarı ile sıralarını ve tarihlerini alırlar (TMK m.1022 I). Önce yapılan tescil veya şerh kaydı, sonrakilere nazaran önceliklidir.

467 Öncelik bakımından yevmiye defterine kayıt tarihi esas alınır (TMK m.2022 II; TST m.23 II c.2).

f. Tescilin Hakkın Sahibini ve İçeriğini Belirlemesi Etkisi (Tescilin Hakkın İçeriğini Belirleme İlkesi)

468 Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi için, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini de belgelemiş olması gerekir (TMK m.1015 I).

469 İstemde bulunan kimse, kendisinin, aleniyet ilkesi gereği, tapu sicilinde hak sahibi görünen kişi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş olur (TMK m.1015 II).

470 Tapu sicilinde kayıtlı olan ayni hakkın niteliği, içeriği, kapsamı ve sınırları yine tapu sicilindeki kayıtla anlaşılır. Tapu sicilinde kayıtlı ayni hakkın içeriğini belirlemesi, tapu sicilinin kendisinde kayıtlı hakkın herkesçe bilindiği ilkesi ve tapu sicilindeki kayıtların doğruluğuna kanıt oluşturduğu ilkesi ile ilişkilidir.

g. Tapu Siciline Güven (Maddi Aleniyet) İlkesi

471 Tapu siciline güven ilkesi, tapu siciline güvenilerek yapılan iyiniyetli kazanımların korunmasını ifade eder (TMK m.1023)[39]. Başka bir deyişle, kamusal tapu sicilinde ayni hakkın aleniyet bulmuş maddi olgularına güvenerek üçüncü kişilerin iyiniyetli kazanımları istisnasız korunur[40].

472 TMK m.3 II'e göre durumun gereklerine göre kendinden beklenen göstermeyen kişi iyiniyet iddiasında bulunamaz[41].

473 Burada tapu sicilinin ortaya koyduğu hukuki görünüme olan güven korunur[42]. Doktrinde *tescilin olumlu hükmü* olarak da incelenen tapuya

---

[39] BGE 109 II 102 E.2; 93 II 290, 298.

[40] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.60, 64; **HAAB**, ZK Einl. ZGB, N.62; **REY**, I, N.291; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.69; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR** s. 27 vd.; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 94 vd.; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 66.

[41] BGer 5C.301/2005 vom 17.02.2005; **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §10. V. B.

[42] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.65; **LIVER**, SPR V/1, s. 311; **REY**, I, N.291.

güven ilkesi aynı zamanda *tapu sicilinin olumlu etkisini* de ortaya koymaktadır. Bu ilkeye maddi aleniyet ilkesi ismi de verilmektedir[43]. Aleniyet ilkesinin hukuki sonucu olarak, taşınırlarda da söz konusu kısmen daha sınırlı olan koruma aşağıda incelenecektir.

4. Taşınırlarda Aleniyet İlkesinin Yansımaları ve Etkileri

a. Zilyetliğin Olumsuz (Kurucu) Etkisi ve Olumlu (Maddi) Etkisi

474 Zilyetlik ayni haklarda kamuya açıklığı sağlar ve buna bağlı olarak ayni hakkın varlığına karine teşkil eder (TMK m.985, 986). Zilyetliğin aleniyet ilkesinin yansıması olarak olumsuz ve olumlu (maddi) etkisinden bahsedilir:

aa. Zilyetliğin Olumsuz (Kurucu) Etkisi

475 Taşınırdaki mülkiyetin devri, kural olarak, zilyetliğin devrini gerektirmektedir (TMK m.763 I). Yine taşınır üzerinde intifa hakkın kurulması, zilyetliğin devrine bağlıdır (TMK m.795 I). TMK m.939 I kanundaki istisnalar dışında taşınırların ancak alacaklıya devri suretiyle kurulabileceğini düzenlemiştir. Taşınır mülkiyetinin sahiplenme (TMK m.767) veya zamanaşımı (TMK m.777) ile kazanımı, kanunda öngördüğü şartlarla birlikte zilyetlikle gerçekleşmektedir.

bb. Zilyetliğin Olumlu (Maddi) Etkisi

476 Hak sahibi olmayan zilyetten, iyiniyetle ayni hak kazanımı belirli şartlarla tamamen veya kısmen korunmuştur (TMK m.788-990). İyiniyetli taşınır kazanımlarının korunması aşağıda incelenecektir.

b. Taşınırlarda Teslim İlkesi

477 Taşınır ayni hakkın kazanımında kural, geçerli bir hukuki işlemle birlikte, taşınırın veya taşınır üzerindeki hâkimiyet sağlayacak araçların zilyetlik edinene teslimidir (TMK m.977)[44]. Toplumsal ve ticari yaşamın gereği olarak da, TMK teslim ilkesinin değişik ikameleri yoluyla ayni hakkın (zilyetliğin) devrini çeşitlerini düzenlemiştir[45]. Örneğin TMK m.979'da düzenlenen haller: Hükmen teslim. Taşınırın teslimi, onun dev-

---

[43] **REY**, I, s.291.

[44] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.69. **LIVER.** SPR V/1. s. 315; **REY,** I. N.304.

[45] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.69. **LIVER.** SPR V/1. s. 317.

rin aracı olarak o şey üzerindeki ayni hakkın kurulduğunu ve bir başkasına devredildiğini ortaya koyar.

478 Taşınırlarda geçerli teslim ilkesi, taşınır rehninde de istisnası uygulama alanı bulur (TMK m.939). Bu ilke taşınır rehin hukukunda "teslimli rehin ilkesi" (*Faustpfandprinzip*) olarak isimlendirilmektedir[45].

III. İYİNİYETLİ KAZANIMLARIN KORUNMASI İLKESİ

A. Genel Olarak

479 İyiniyetli hak kazanımlarının korunması, ilkesi aleniyet ilkesinin yansıması olan aleniyeti sağlayan araçların (tapu sicilinin, zilyetliğin) olumsuz etkisi olarak bu araçların maddi olgusunun hukuki sonuçlarıyla da yakından bağlantılıdır.

480 Ayni hakların aleniyeti, taşınırlarda zilyetlik ve taşınmazlarda tapuya tescil ile temin edilmektedir. Şu halde doğal olan, bir taşınırı devralırken zilyedinin, taşınmazı devralırken de taşınmaz tapuda adına tescil edilmiş kimsenin ayni hak sahibi olduğunun kabul edilmesidir. İfade ettiğimiz hususlar gerçeği yansıtmakta ise sorun yoktur. Ancak taşınırı devreden kimse zilyet olsa dahi gerçekte ayni hak sahibi olmayan ya da devir yetkisi bulunmayan bir kimse, örneğin bir hırsız olabilir. Aynı şekilde, taşınmazı devraldığımız kimsenin de tapuda adına tescil bulunsa dahi gerçekte mülkiyet hakkı olmayabilir.

481 Acaba taşınırlarda fiili duruma, taşınmazlarda ise tapu sicilindeki mevcut tescile güvenen kimsenin bu *iyiniyeti* korunacak mıdır? Türk Medeni Kanunu taşınmazlarda iyiniyeti mutlak olarak korumuş (TMK m.1023), taşınırlarda ise elden rıza dışı veya rıza ile çıkma bakımından bir ayrım yaparak iyiniyetin korunmasında sınırlı bir koruma kabul etmiştir (TMK m.988-990).

482 Sonuç olarak bir ayni hakkın kazanılmasında, hakkın kazanılmasına engel olacak hukuki sakatlık veya eksikliği bilmeyen kişinin iyiniyeti bazı koşullarda korunur. Böylece ayni hak iyiniyet sayesinde hukuken kazanılmış olur. O halde ayni hakların kazanılmasında iyiniyet önemli bir role sahiptir.

---

[45] **RIEMER.** Sachenrecht I. § 31. N.7.

B. Taşınmazlarda

483 Kamusal nitelikteki tapu sicilinde ayni hakkın aleniyet bulmuş maddi olgularına olan güvenerek üçüncü kişilerin iyiniyetli kazanımları istisnasız korunur (TMK m.1023)[47].

484 TMK m.3 II'e göre durumun gereklerine göre kendinden beklenen göstermeyen kişi iyiniyet iddiasında bulunamaz[48]. Burada tapu sicilinin ortaya koyduğu hukuki görünüme olan güven korunur[49-50].

C. Taşınırlarda

485 Bir yanda taşınırdaki devralanın menfaatinin korunması ve hukuk güvenliğinin sağlanması amacı ve diğer yanda taşınır malikinin yararı, Roma hukukundaki "hiç kimse sahip olduğu haktan fazlasını devredemez" (*nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*) şeklindeki hukuki yaklaşımı, Pandekt hukukunda esaslı olarak benimsemiştir[51].

486 TMK, taşınırlarda, üçüncü kişilerin taşınırla ilişki içinde olan zilyetten olan hak kazanımlarını kısmen veya tamamen korumuştur (TMK m. 988-990). Görüldüğü üzere, üçünü kişinin taşınmazlardaki koruması mutlak olduğu halde, taşınırlardaki tam koruma zilyedin emin sıfatıyla zilyet olup olmamasına veya ticari hayatta tedavül eden para veya hamiline senetlere bağlanmışır.

487 TMK m.988'e göre üçüncü kişi ile bir taşınır konu alan tasarruf işlemi yapan kişi, ancak o taşınırın emin sıfatıyla zilyedi ise tam olarak korunur. Emin sıfatıyla zilyet, malikin rızası ile taşınırın zilyetliğini kazanmış kişidir. Para ve hamiline yazılı senetleri de iyiniyetle edinmiş olan kişinin kazanımı ise kazananın zilyetliğinin malikin rızası ile kazanılmış olmasa da örneğin senetler çalınmış olsa da korunur (TMK m.990).

488 İyiniyetli hak kazanmanın kısmi korunması çalınma dâhil irade dışında elden çıkan taşınır, açık arttırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyiniyetle edinilmiş ise, zilyet taşınırın iadesini talep

---

47 BGE 109 II 102 E.2; 93 II 290, 298.

48 BGer 5C.301/2005 vom 17.02.2005. **ANTALYA/TOPUZ**, MH, §10, V.

49 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.65; **LIVER**, SPR V/1, s. 311; **REY**, I, N.291.

50 *Üçüncü kişinin iyiniyeti sadece tapu kütüğündeki tescil yönünden korunmakta olup, sicil dışı unsurlar bu maddenin koruma kapsamı dışındadır* (Y. 1. HD., 24.02.2009 T., 11502 E., 2327 K.).

51 **STARK**, Vorbem. zu 930-937, N.5 ff., 21 f.

edebilir; ancak iyiniyetli zilyet taşınıra ödediği bedelin kendisine verilmesini isteyebilir (TMK m. 989 II). Hatta bedel ödeninceye kadar, eşyaya üzerinde alıkoyma hakkını kullanarak eşyayı geri vermekten kaçınabilir[52].

IV. TİPE BAĞLILIK (*NUMERUS CLAUSUS*) İLKESİ VE TİPİN KAPSAMININ BELİRLİLİĞİ İLKESİ

A. Genel Olarak

489 Ayni hakkın tipe bağlılığı ve tipin kapsamının belirliliği hukuk politikası sorunudur. Hukuk doktrininde tipe bağlılık ve tipin kapsamının belirliliği ilkesinin nispileştirme konusunda yeni yaklaşım söz konusudur[53].

490 Yeni yaklaşımlar sınırlı sayı (*numerus clausus*) ilkesini ticari yaşam ilişkilerindeki ihtiyaçlar sebebiyle aşmaya çalışmaktadırlar. Özellikle teminat hukukunda ve bekleme durumunda[54] sınırlı sayı ilkesini aşma girişimlerini uygulama ve doktrinde gözlemekteyiz. Bu gayretlere, özellikle –teminat amaçlı- inançlı işlemler[55] ve kademeli birlikte mülkiyeti[56] örnek verebiliriz[57].

491 Bunlara ilaveten, taraflar nispi etki doğuran borç ilişkisi, genellikle sözleşme kapsamında, kendilerini bağlayacak şekilde ayni hakkın tipiklik ilkesinin sınırlarını aşmalarında engel bulunamamaktadır. Özellikle, tapuya şerh edilebilen kişisel haklar, örneğin arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, onalım ve geri alım gibi haklardan hangilerinin tapuya şerh edilebileceğinde tipe bağlılık geçerli iken, kapsamını taraflar serbestçe belirleyebilirler.

492 Sınırlı sayı dışında ayni teminat gerçekleştirmede, taşınmazlarda teminat amaçlı inançlı işlemlerle aşma girişimleri söz konusudur. Yine tes-

---

52 **SARI**, s. 38 vd.

53 Bu konuda bkz. **WIEGAND**, BSK OR Art.18; N.144; Vorbem. zu ZGB Art.641 ff. N.64 f.

54 Alman yargı uygulamasında, bekleme durumundan doğan hak tam mülkiyetle nitelik olarak benzer, fakat ondan yapısal olarak eksik ("wesensgleiches minus"), fakat ticari ilişkilerde mülkiyetin ön aşaması olarak kendisine özgü nitelikte görülmektedir. Bkz. BGHZ 28, 16 (21) = NJW 1958, 1133; BGHZ 83, 395 (399) = NJW 1982, 1639; BGHZ 114, 161 (164) = NJW 1991, 2019.

55 Bkz. **WALTER**, özellikle s.246 ve 251; **ANTALYA**, BH GH I, s. 296-297.

56 **REY**, I. N.1054C.

57 İsviçre'de uygulamada geliştirilen ipotekli borç (Hypothekarobligation) kurumu için bkz. BGE 100 III 319 ff; **RIEMER**, Sachenrecht, II, § 22, N 209.

limsiz taşınır rehni ile ilgili uygulamada değişik özel hukuk yolları geliştirilmektedir. Ayni hakların tipe bağlılığı, diğer ilkelerle birlikte eşyanın ticarî yaşamda hukuken güvenli dolaşımına hizmet eder. Sadece eşya hukukunda değil, TMK'dan doğan tüm ayni haklarda, mal rejimlerinde, ticarî şirketlerde hâkim genel ilkedir[58].

B. Tipe Bağlılık (*Numerus Clausus*) İlkesi

1. Genel Olarak

493 Borçlar hukukunda irade muhtariyeti ilkesi gereğince, tarafların sözleşme tipini ve kapsamını belirleme özgürlüğü söz konusudur. Borçlar hukuku sözleşmeleri bakımından taraflar mutlaka kanunda öngörülen sözleşme tiplerinden birini seçmek zorunda değildir. Bu çerçevede, taraflar, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik hakkına aykırılık teşkil etmediği sürece aralarında anlaşarak, kanunda düzenlenmiş sözleşme tiplerinin bir ya da birkaç unsurunu bir araya getirip yeni bir sözleme tipi meydana getirebilecekleri gibi; kanunda hiç düzenlenmemiş bir sözleşme de kurabilirler. Dolayısıyla borçlar hukukunda, sözleşmelerin sınırlı sayı ve tipte olma ilkesinden söz edilemez. Buna bağlı olarak nispî haklar sınırlı sayıda değildir ve kanunda belirtilen tipte olma zorunluluğu da yoktur[59]. Eşya hukukunda ise tipe bağlılık ilkesi geçerlidir[60].

494 Tipe bağlılık (Typengebundenheit) ilkesinin amacı, toplumsal ve de ticarî yaşamın güvenliğini sağlamaktır. Tipe bağlılık ilkesi, aleniyet ilkesi ve onun açıklık araçları ile yakından ilgilidir[61].

495 Türk Medeni Kanunu'nun kabul ettiği ayni hak tiplerinin taşınmazlarda, mülkiyet, irtifak, taşınmaz yükü ve rehin olduğunu ifade etmiştik. İşte kişiler, sadece kanunda öngörülen bu ayni hak tiplerini kurabilirler[62]. Taşınırda da mülkiyet ve kanunun belirlediği sınırlı ayni haklar kurulabilir. Taraflar veya kişi kanunda belirtilen ayni hak tipinden farklı bir ayni

---

58 **WIEGAND**, Numerus Clausus, s. 623 ff.

59 **ANTALYA**, BH GH I, s. 30.

60 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.78; **HAAB**, ZK Einl. ZGB, N. 59; **REY**, I, N.315 ff; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 71; **WIEGAND**, BSK vor Art.641, N.61 ff; **DOMEJ**, KurzKomm vor Art 641-654a, N.21; **ARNET/BELSER**, HK, ZGB Art.641, N.20.

61 Bkz. **WIEGAND**, Numerus Clausus, s.623 f.

62 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.80; **REY**, I, N.315; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.71.

hak yaratıp kuramazlar[63]. Şu halde ayni haklarda ve tipe bağlılık (sınırlı sayı: *numerus clausus*) ilkesi geçerlidir[64]. Örneğin, taraflar mülkiyeti alt veya birinci derece mülkiyet ve üst veya ikinci derecede mülkiyet veya olumlu temel edim yükümü konu alan irtifak hakkı olarak düzenleyemez.

496 Tipe bağlılık ilkesine ilişkin hükümler emredici niteliktedir. Kanun bir hakka ayni hak niteliği veren kurucu hukuki olguları kanunda düzenlemiştir. Bu kurucu olguların taraflarca değiştirilmesi, ilave olgular yapılması mümkün değildir. Taraflar kanun belirlediği ayni hakların tipik kurucu olgularını karma biçimde bir araya getirerek yeni bir ayni hak yaratamazlar; kanundaki tipik ayni haklar dışında, kanunda düzenlensin ya da düzenlemesin, farklı olguları kararlaştırarak, kendine özgü - *sui generis* – bir ayni hak yaratamaz.

497 Kanunu ayni hak olarak belirlediği hakkın ve bu hakkın kanunda belirtilen hukuki olgularını taşımayan bir hak, ayni hak değildir. Nispi bir hak olarak geçerliliği söz konusu olabilir. Belirtelim ki, kanunun izin verdiği tipte bir ayni hakkın içeriği ve kapsamına yine kanunun çizdiği sınırlar çerçevesinde taraflarca serbestçe tayin edilebilirse de, bunlar dışında bir ayni hak tesis edilmesi veya hakkın içeriğinin kanunun uygun görmediği bir biçimde belirlenmesi söz konusu işlemleri geçersiz (kesin hükümsüz) kılar.

2. Tipe Bağlılık İlkesine Aykırılık

498 Tipe bağlılık (*numerus clausus*) ilkesine aykırılık halinde, aynı hakka vücut veren hukuki olgu gerçekleşmediğinden, bir ayni hak doğmamış olduğundan ayni hak yok hükmündedir.

499 Başka bir görüş, tipe bağlılık ilkesi ile tipin kapsamının belirliliği ilkesini aynı yaptırıma tabi tutmaktadır. Bu görüşe göre, tapu kütüğüne tipikliğe aykırı bir hakkın kaydolması durumunda, emredici hukuk kurallarına aykırı bu kayıt, imkânsız ve kanuna aykırı olduğundan kesin hükümsüzdür[65].

---

[63] BGE 116 II 275, 277 E 3b.

[64] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.78; **HAAB**, ZK Einl. N.59; **REY**, I. N.318; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 71-74. **WIEGAND**, BSK vor Art.641. N.61; **DOMEJ**, KurzKomm vor Art.341-654a, N.20; **ARNET/BELSER**, HK, ZGB Art.641. N.21; **ESENER/GÜVEN**, s.50; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.109 vd.; **AYAN**, s.36.

[65] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.81; **REY**, I, N.326 f. 327.

500 Görüşümüze göre, bir hakka ayni hak niteliği veren kurucu hukuki olgular kanunda düzenlenmiştir. Bu kurucu olguların taraflarca değiştirilmesi, ilave olgular yapılması mümkün değildir. Taraflar kanunun belirlediği ayni hakların tipik kurucu olgularını karma biçimde bir araya getirerek yeni bir ayn: hak yaratamazlar; kanundaki tipik ayni haklar dışında, kanunda düzenlensin ya da düzenlenmesin, farklı olguları kararlaştırarak, kendine özgü - *sui generis* – bir ayni hak yaratamaz.

501 Kanunun ayni hak olarak belirlediği hak ve bu hakkın kanunda belirtilen hukuki olgularını taşımayan bir hak, ayni hak değildir. Nispi bir hak olarak geçerlilik söz konusu olabilir. Bu hakkın ve bu hakkı düzenleyen hukuki ilişkinin, genellikle sözleşmenin, ayni hakkın kurucu olgularına aykırı olduğu ve bu nedenle hukuken imkânsız ve hukuka aykırı olduğu iddia edilemez; sadece bu borçlandırıcı işleme dayanılarak hakkın tapu siciline yazılımı talep edilemez. Ancak hak nispi hak olarak borç ilişkisi taraflarını bağlamaya devam eder; hakka aykırılık halinde borçlar hukuku hükümleri uygulanır (TBK m.112)[66].

502 Tapu siciline tescil edilmiş olsa bile kaydedilebilme imkânı olmayan bir yok hükmünde bir ayni haktır; bu hakkın ayni hak olarak tapu siciline kaydedilmiş olması, ona ayni hak koruması vermez; gelecekte bir ayni hakkın zamanaşımı ile kazanımı sağlamaz. Her zaman tapu kütüğüne kaydedilemeyecek olan hakkın, yok hükmünde olduğu davada tespit konusu yapılabilir. Bir davaya konu uyuşmazlıkta her zaman hakkın tapu kütüğüne kaydedilemeyen bir hak olduğu – ayni hak olmadığı- itiraz olarak savunması yapılabilir; hâkim bu kurucu hukuki olgu yokluğunu taraflar ileri sürmemiş olsa da, kendiliğinden dikkate alır.

503 Aynı hakkın kurucu olgularının bulunmadığı itirazı, hakkın kötüye kullanılması (TMK m.2 II) olgularıyla düzeltilemez; tahvile konu olamaz.

C. Tipin Kapsamının Belirliliği İlkesi

1. Genel Olarak

504 Tipe bağlılık ilkesi, tipin belirliliği (Typenfixierung) ilkesi ile ilgili ve onunla yakından irtibatlıdır.

[66] ANTALYA, BH GH III, s. 193 vd.

505 Tipin belirliliği ilkesine göre, taraflar ancak kanunun düzenlediği ayni hakkı, kanunun düzenlediği içerik ve kapsamda düzenleyebilirler; taraflar kanunun belirlediği hakkın bu kapsamı değiştirmeye yetkili değildir[67]. Örneğin, TMK m.823 II oturma hakkının başkasına devredilmez ve mirasçılara geçmeyeceğini düzenlemiştir. Taraflar oturma hakkının içeriğini, başkasına devredilebilir ve mirasçıya intikal edebilir şekilde düzenlenemez.

506 TMK tipini belirlediği bazı ayni hakların kapsamını düzenleme yetkisini taraflara bıraktığı istisnai durumlarda söz konusudur. Başka bir deyişle, kanun tipik olarak öngördüğü ayni hakkın içeriğini serbestçe düzenleme imkânı vermişse, taraflar ayni hakkın kapsamını TBK'nın sözleşme özgürlüğüne ilişkin genel sınırlarda serbestçe belirleyebilir. Örneğin, TMK m.779 II hükmü yapma borçlarının irtifaka yan edim olarak tarafların belirledikleri kapsamda ilavesine imkân tanımıştır. Diğer bir örnek olarak, TMK m. 827'de üst hakkı sözleşmesinin kapsamını belirleme özgürlüğü ve bağlayıcılığı düzenlenmiştir (Ayrıca bkz. TMK m. 794 II, 838 II, 844, 852 I, 871 III).

2. Tipin Kapsamının Belirlenmesi İlkesine Aykırılık

507 Öncelikle belirtelim ki, tipin kapsamının belirliliği ilkesini düzenleyen kanun hükümleri emredici nitelikte hükümlerdir[68]. Kanunun ayni hakkının kapsamını belirlediği tipik kapsama hükümlerine aykırı bir düzenleme, imkânsızlık ve kanuna aykırılık sebebiyle *kesin hükümsüzdür*[69]. Kanunun tıpık kapsamına aykırı hükümler yasal düzenlemeye şeklinde uygulanması söz konusu olabilir.

508 Tarafların tipin kapsamına aykırı düzenlemeleri yerine kanun emredici olarak getirdiği kapsam ve içerik hükümleri taraflar arasındaki ilişkide doğrudan uygulanır. Ayni hakkın kapsamına uyulmadığı itirazı, hakkın kötüye kullanılması (TMK m.2 II) olgularıyla, örneğin ihtilafsız uygulanırken çok sonra itiraz olarak ileri sürülmesi[70], hukuken korunmaya-

---

[67] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.86 f; **HAAB**, ZK Einl. ZGB, N.60; **STEINAUER**, I, N.123; **REY**, I, N.320; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.73. BGE 103 II 176, 182 EW.2; 116 II 275 ff. 276. Bu yaklaşıma eleştirel bakış için bkz. **WIEGAND**, BSK vor Art.641 ff ZGB, N. 62.

[68] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.96; **HAAB**, ZK Einl. ZGB, N.690; **REY**, I, N.320. Farklı fikir **WIEGAND**, BSK Vorbem. zu Art.6451 ff ZGB, N.62.

[69] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.81; **REY**, I, N.326 f. 327. Bkz. EGE 11 II 134 ff. 141.

[70] BGE 111 II 134 ff. 142 E.5.

bilir[71]. Yine tipik ayni hakkın kapsamına ilişkin aykırı hükümlerin tahvili söz konusu olabilir. Örneğin su temin yükümlülüğü ve buna ilişkin tesisleri bakım yükümlüğüne ilişkin olumlu edim borcunu irtifak hakkı olarak kararlaştırmışlarsa da, taşınmaz yükü olarak tapuya yazılımı[72].

509 Kanununun tipik kapsamına aykırı hükümler, ayni ilişki kapsamında geçersiz iken, borç ilişkisi bakımından nispi etkili olarak geçerlidir. Borç ilişkisi taraflara ayni hakkın korumasını sağlamaz; tarafların belirlediği kapsamda ayni hakkın kurulmasına imkân vermese de bir alacak olarak varlığını sürdürür; uyulmaması halinde borca aykırılığın hükümleri uygulanır (TBK m.112).

V. BELİRLİLİK (MUAYYENLİK) İLKESİ

A. Kural

510 Hukuki hâkimiyete elverişli olan, sınırlanabilir niteliği bulunan ve kişisel olmayan cismani şeylerin eşya sayılacağını daha önce belirtmiştik. İşte ayni hakkın konusunu, taşınır veya taşınmaz olmak üzere "belirli ve bireysel bir eşya" teşkil edebilir. Bir bütün teşkil eden parçalar, ayrılarak ayrı bir eşya niteliği kazanmadıkça, ayrı bir ayni hak konusu oluşturamazlar. Örneğin, bir ineğin baş tarafının ayrı ve diğer uzuvlarının ayrı ayni hak konusu teşkil etmesi; buna bağlı olarak da her birine ayrı kimselerin malik olması mümkün değildir[73].

511 İşte ayni hakların, bireysel olarak ayrı bir bağımsız maddi varlık teşkil edebilen, sınırları belirli eşyalar üzerinde kurulabileceği ilkesi, belirlilik (muayyenlik) ilkesini ifade eder (Spezialitätsprinzip, Individuallitätsprinzip, Bestimmtheitsgrundsatz)[74].

512 Belirlilik ilkesi, eşya üzerindeki tasarrufun konusunun belirliliğinin sağlanması anlamına gelir. Gerçekten tasarruf, etkilediği hakkın belirli olmasını gerekli kılar[75]. Yine belirlilik ilkesi, aleniyet ilkesi ile birlikte

---

[71] **REY**, I. N. 327.

[72] BGE 93 II 290 ff; 108 II 39 ff.

[73] **ESENER/GÜVEN**, s. 5[1]; **AYAN**, s. 34; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 105 vd.

[74] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.75; **REY**, I. N.333 ff.; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 70; **WIEGAND**, BSK vor Art.641, N.60; **DOMEJ**, KurzKomm vor Art.641-654a, N21; **ARNET/BELSER**, HK. ZGB Art.641, N.22.

[75] Bkz. **WIEGAND**, Akzessorietät, s. 1 vd.

eşyaların, ticari yaşamda, dolaşım ve değişiminin görünebilir, net ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesine hizmet eder.

513 Belirlilik ilkesi, ayni hakkın konusu olan eşyanın maddi belirliliğinin sonucudur. Bu olgu ayni hak konusu olabilen eşyayı, eşya birlikteliğinden (örneğin, depo, hisse senetleri portföyü) malvarlığı ve hukuki eşya birlikteliğinden (örneğin ticari işletme) ayırır[76]. Bu hususu yukarıda incelemiş idik[77].

514 Ayni haklar ferden belirli şeyler üzerinde kurulabilir; cins (çeşit) olarak belirlenebilen şeyler üzerinde ayni hak kurulabilmesi için onların cinste ayrılarak belirli ve bağımsız hale gelmesi gerekir[78]. Fakat ayni hakkı konu alan eşya üzerindeki mülkiyeti sınırlayan birden fazla birbiriyle çatışmamak kaydıyla ayni hak kurulabilir. Tapu sicil sistemi içinde, her taşınmaz, kütüğün ayrı bir sayfasında ayrı bir numara ile kayıt altına alındığından (TMK m.1000 I), taşınmazlarda belirlilik ilkesi, zaten taşınmazın niteliğinde yer almaktadır.

515 İlerleyen bölümlerde görüleceği üzere, bütünleyici parçanın söz konusu olduğu durumlarda da asıl şeyin ve bütünleyici parçanın ayrı ayrı kimselere ait olması mümkün değildir (TMK m.684 I). Örneğin bir otomobil (A)'ya ait ise otomobilin motoru da (A)'nın mülkiyetindedir. Otomobil başkasına, motor başkasına ait olamaz. Zira, bütünleyici parçalar bağımsızlıklarını yitirdikleri ve asıl şeyin hukuki kaderine bağlı oldukları için, örneğin otomobilin motorunun ve iskeletinin ayrı ayrı ayni haklara konu edilmesi mümkün değildir. Asıl şey ile teferruat kural olarak ayrı eşya olma niteliğini korurlar; fakat teferruat asıl şeyin hukuki kaderine tabi olur (TMK m.686 I).

B. Rehinde Belirlilik İlkesi

516 Taşınmaz rehninde rehin kurulurken, rehin konusu olan taşınmazın belirlenmesi gerektiğini düzenleyen TMK m. 854 I taşınmaz rehninde belirlilik ilkesini düzenlemiştir. Bölünebilen taşınmazın parselleri tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydedilmedikçe rehne konu olamaz (TMK m.854). Taşınmaz rehninde, belirlilik ilkesi açıkça belirtilmişse de, sicil sistemi gereği zaten, taşınmaz tapu kütüğünün ayrı bir sayfasında ayrı bir numara

---

[76] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.75; **REY**, I. N.333 ff.; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 70

[77] **ANTALYA**, EH I, N. 127 vd.

[78] **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 20; **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.75; **HAAB**, ZK Einl. ZGB. N.690

ile kayıtlıdır (TMK m.1000 I). Taşınmaz rehni de, rehne konu taşınmazın bu sayfasının özel sütununa (TMK m.1000 III b.3) tescil edilir.

517 Taşınır rehninde, TMK m.854 hükmünde olduğu şeklinde açıkça ifade edilmemişse ce, doktrin ve uygulama, belirlilik prensibinin taşınır rehninde de geçerli olduğunu kabul etmektedir[75]. Gerçekten, teslimli rehin ilkesi, rehin konu taşınırın teslimini öngördüğünden, belirlilik ilkesini gerçekleşmesine hizmet eder[76].

VI. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ

A. Genel Olarak

518 Türk-İsviçre eşya hukukunda tüm ayni hakkı konu alan tasarruf işlemlerinin geçerliliği hukuki sebebe bağlıdır. Geçerli bir hukuki tasarruf işlemi ancak ona konu olan ayni hakkı kurabilir, sona erdirebilir veya değiştirebilir. Başka bir deyişle, sebebe bağlılık ilkesi, eşya hukukundaki tasarruf işlemlerinin geçerliliğinin, onun temelini oluşturan borçlandırıcı işlemdeki sebebe bağlı olduğunu (Kausalitätsprinzip) ifade eder. Örneklersek, bir ayni hakkın devrinin geçerliliği, onun devri borcunu (tasarrufunu) konu alan borçlandırıcı işlem olan, örneğin satış sözleşmesinin veya bağışlama sözleşmesinin geçerliliğine bağlıdır. Borçlandırıcı işlem bir benzetmeyle[77], tasarruf işlemin ön aşaması olarak, borcun ifası olarak karşımıza çıkmaktadır.

519 Konunun anlaşılabilmesi için kazandırma kavramı ve bununla bağlantı tasarruf işlemi ile tasarruf işlemleri ve borçlandırıcı işlem kavram ve ilişkileri üzerinde durmamız ve bu kapsamda sebebe bağlılık ilkesini açıklamamız gerekir ki konu anlaşılabilsin.

B. Kazandırma ve Kazandırma İşlemi

520 *Kazandırma*, bir kişinin malvarlığından diğerinin malvarlığı yararına bir malvarlığı değerinin sağlanması fiilidir. Bu işleme de *kazandırma işlemi* adı verilir.

---

[75] **RIEMER**, Sachenrecht I, § 31, N. 1, 6; **REY**, I, 345.

[76] Henüz doğmamış olmakla birlikte, doğacak alacakların da rehin hakkının konusunu oluşturabileceği yönünde bkz. Y. 3. HD., 30.04.2015 T., 2704 E., 9785 K.

[77] Bkz. von **TUHR/PETER**, s. 195 f.

521 Kazandırma üçüncü kişinin borcunu ödemede, üçüncü kişi lehine sözleşmede olduğu üzere dolaylı ya da taşınmaz mülkiyenin devrinde olduğu üzere doğrudan gerçekleşebilir. Kazandırma ile kazananın malvarlığında bir artış meydana gelir. Artış kazanın aktifinde çoğalma şeklinde olabileceği gibi; pasifinin azalması şeklinde de gerçekleşebilir[82].

522 Malvarlığındaki değere etkileri açısından hukuki işlemler dörde ayrılır[83]:

1. Kazandırma (iktisap) işlemleri[84],
2. Borçtan kurtarma işlemleri[85],
3. Borçlandırıcı işlemler (borçlanma işlemi),
4. Tasarruf işlemleri.

Borçtan kurtarma işlemleri de aslında borçlandırıcı işlemdir; ancak konu aldığı hakka etkisi yönünden ayrı bir kategori olarak ifade edilmiştir. Diğer yandan borçlandırıcı işlemleri ve tasarruf işlemleri ve ikisi arasındaki ilişki de kazandırmaya olan etkileri yönündendir. Gerek borçlanma işlemleri, gerekse tasarruf işlemleri ile bir kişinin, başkasına ait malvarlığına yeni bir kazandırma fiilinde bulunması halinde kazandırıcı işlemden bahsedilir.

523 Borçlandırıcı işlem ile tasarruf işleminin ortak noktası, her ikisinin de malvarlığında azalmaya sebebiyet vermesidir. Borçlandırıcı işlem, işlemi yapanın malvarlığının pasifini çoğaltırken, tasarruf işlemi aktif kısmını azaltmaktadır. Kazandırma kavramı, hukuki işlemler dışında maddi fiillerle de gerçekleşebilir. Örneğin TMK. m.755'te işleme halinde işleyen, maddi bir fiille şeyin malikine kazandırmada bulunmuştur[86].

---

[82] **FLUME**, s.152; **FEYZİOĞLU**, I, s.45; **EREN**, BH GH, § 17, I, 1; **KOCAYUSUFPAŞAOĞLU**, BH GH, § 11, III, 1, a; **ANTALYA**, BH GH I, s.107; **ANTALYA/TOPUZ**, MH, §7, V, C, 3, a.

[83] **ANTALYA**, BH GH I, s. 107.

[84] Kazandırma işlemleri, kazananın hak kazandırmasını sağlayan, malvarlığının aktifini arttıran işlemlerdir.

[85] Borçtan kurtarma işlemleri ise, borcun ifası, ibra, yenileme örneklerinde olduğu üzere bunu yapanın veya karşı tarafın malvarlığının pasifini azaltan işlemlerdir.

[86] Karışma ve birleşme için bkz. TMK m. 776.

C. Kazandırma İlkesi (Sistemi): Teslim ve Tescil İlkesi (Sistemi)

524 Malvarlığını oluşturan her hakkın devrinde, kural olarak o hakkın devrine ilişkin kurallar uygulanır[43]. Hak, örneğin alacak hakkı ise alacak hakkı, ayni hak ise ayni hak kuralları uygulanacaktır.

525 Malvarlığı değerleri olarak eşyanın devri konusunda benimsenen iki temel ilke ve bu yaklaşıma bağlı iki sistem söz konusudur[44]:

1. İrade (sözleşme) ilkesi (Konsensprinzip Vertragprinzip),

2. Teslim ve Tescil ilkesi (Traditionsprinzip Übergabeprinzip)

526 İki ilke (sistem) arasındaki fark, malvarlığı değerinin ne zaman el değiştirdiği noktasındadır. İrade ilkesini kabul eden sistemlerde, devreden ile devralan arasındaki irade uyuşmasıyla, örneğin sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmasıyla birlikte hak devredilmekte; teslim tescil ilkesinde ise, irade uyuşmasına ilaveten eşyanın teslimi (*traditio*) ya da ayni hakkın devrinin ya da kurulmasının veyahut sınırlandırılmasının tapu siciline tescilinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin devrinde bir sicile kaydı gereken ayni hakkının devri söz konusu ise, teslim, yerini tapu siciline tescile bırakmaktadır.

527 Türk Hukuku'nda taşınır mülkiyetinin devri için, zilyetliğin devri (TMK. m. 705 I)[45]; taşınmaz mülkiyetinin devri için, devreden ile devralan arasındaki irade uyuşması (sözleşme) yanında, tasarruf işlemin kurucu unsuru tescil aranmaktadır[46]. Bu yaklaşımla mutlak malvarlığı haklarının, örneğin ayni hakların intikali teslim tescil ilkesine bağlanmıştır. Buna karşın nispi hak niteliğindeki alacağın devrinde ise irade ilkesi geçerlidir.

D. Kazandırmanın Hukuki Sebebi

1. Hukuki Sebep (Causa) Kavramı

528 Her hukuki işlemin bir sebebi, bunu takip eden her kazandırmanın da bir sebebi vardır. Hukuki sebep (*causa*) taraf veya tarafların kazandırma

---

43 **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 324; **SEROZAN**, Taşınır Eşya, s. 63.

44 İrade sistemi Fransa, İtalya, Belçika, İngiliz ve ABD hukuklarında, teslim ilkesi de Almanya, İsviçre, İspanya, Yunan ve Hollanda hukuklarında benimsenmiştir. **UTKU**, s. 87 dn. 325.

45 Başka bir görüş zilyediğin nakli ile birlikte tasarruf sözleşmesinin varlığını aramaktadır. Bkz. **KOCAYUSUFPAŞAOĞLU**, § 11, II, 2, a, aa, 1.

46 **UTKU**, s. 88 dn. 329'daki yazarlar.

ile doğrudan doğruya asli olarak istedikleri, temel ve kazandırmaya hukuki niteliğini veren amaçtır[50].

529 Tarafların her birinin ayrı ayrı arzuladıkları amaçları değil, tarafların üzerinde uzlaştıkları, *ortak amaç* dikkate alınır. Ortak amaç, kazandırmanın amacına ilişkin *sebep anlaşmasında* yer alır. Ortak amaç dışında tarafların saikleri de önemli değildir. Hukuki işlemin amacını *saiklerden* (*etken*lerden) ayırmak gerekir[51].

2. Hukuki Sebep Çeşitleri

530 Roma Hukuku'ndan günümüze kadar yapılan ifa sebebi (*causa solvendi*), alacak sebebi *(causa credendi veya acquirendi)*, bağışlama sebebi (*causa donandi*) şeklinde yapılan üçlü ayrımın yanında, garanti (teminat) sebebi, yenileme sebebi (*causa novandi*) gibi diğer sebeplerin de varlığını dikkate alarak hukuki sebepleri beşli ayrıma tabi tutulmaktadır.

531 Kazandırma birden çok sebebe dayanıyorsa, karma sebep söz konusudur. Örneğin karma bağışlamalar, hem bağışlama, hem de alacak sebebine dayanır.

3. Kazandırma İşlemin Sebebe Bağlılığı (İlliliği) veya Soyutluğu

532 Taraflarca istenen ortak hukuki sebep (amaç) kazandırıcı işlemi oluşturan işlemin onsuz olmaz bir unsuru haline gelmişse kazandırma *sebebe bağlıdır, illidir*[52]. Bu kazandırmanın geçerli olarak hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için, geçerli bir hukuki işlemin bulunması gerekir.

533 Buna karşın hukuki sebebin hukuki işlemin olgusunu teşkil etmemesi, kazandırmanın hukuki sebepten soyutlandığı ihtimallerde söz konusu olabilir. Yine hukuki sebebi göstermeyen, ondan ayrılmış hukuki işlemlerle yapılan kazandırmalar da *sebebe bağlı değildir, soyuttur.* Bu tür kazandırmalara (soyut) işlemler denir.

534 Bu durumda hukuki sebep bulunmadan veya geçerli olmadan da kazandırma geçerli olur ve hukuki sonuçlarını doğurur. Unutulmamalıdır ki,

---

[50] **ANTALYA**, BH GH I, s. 109; **TÜREL**, s. 382.

[51] Saik, kişinin amacının oluşmasına etken olan, kişiyi bu sebebin bulunduğu hukuki işlemi yapmaya sevk eden kişisel düşünce ve diğer iç ve dış etkenlerdir. Kural olarak hukuk düzeni istisnalar dışında saikleri değil, hukuki sebebi esas almıştır. Saiklerin hukuken dikkate alındığı hukuk kuralları için bkz. **ANTALYA**, BH GH I, s. 110; **TÜREL**, s. 382.

[52] **FLUME**, s.153; **SCHWARZ**, s.284; **FEYZİOĞLU**, I, s. 43; **EREN**, BH GH, § 17, III; **KOCAYUSUFPAŞAOĞLU**, BH GH, § 11, III,, 2, b aa; **ANTALYA/TOPUZ**, MH, §7, V, D.

kazandırmayı soyut işlemle elde eden kişinin kazandırması bir sebebe dayanmıyorsa "sebepsizdir" ve kazandırmanın sebepsiz zenginleşme kurallarıyla iadesi talep edilebilir.

535 Borçlandırıcı işlem kural olarak sebebe bağlıdır. Hukuki işlemin zorunlu unsuru olarak kazandırmada belirtilir; taraflar bu unsurda uzlaşır. Borçlandırıcı işlemlerde hukuki sebebin kendisi, hukuki işlemin kendisidir[54]. Kazandırmanın sebebini hukuki işlem oluşturur. Örneğin, alıcının satış bedelini ödeme borcu karşı edim alacağına karşılık alacak sebebi olarak borçlanılmıştır. Kazandırıcı işlemde ise, kural olarak hukuki sebep, borçlandırıcı işlemdir. Tasarruf işlemleri, borçlandırıcı işlemin ifasına hizmet eder.

E. Borçlandırıcı İşlem ve Tasarruf İşlemi

1. Borçlandırıcı İşlem

536 Kişi, malvarlığının aktif kısmında yer alan kalemlere dokunmaksızın sadece pasifini yani borçlarını arttıran bir işlem yaparsa buna *borçlandırıcı işlem* (Verpflichtungsgeschäft) denir.

537 Borçlandırıcı işlemler genellikle karşımıza *borçlandırıcı sözleşme* olarak çıkarlar. Örneğin (A) özellikleri belirlenen bir bilgisayarı (B)'ye 1.000 TL. karşılığı satmayı teklif etmiş, (B) de bu teklifi kabul etmiştir. (A) ile (B) arasında yapılan bu borçlandırıcı sözleşme ile bilgisayar üzerindeki mülkiyet hakkı (A)'dan (B)'ye geçmez. Borçlandırıcı işlemler malvarlığının aktifini ve orada mevcut bir hakkı doğrudan etkilemezler; söz konusu işlemlerin dolaylı etkileri vardır. Borçlandırıcı işlem, örnekte satış sözleşmesi, sadece (A)'ya bilgisayar üzerindeki mülkiyeti (B)'ye devretme borcunu yükler. Bir başka deyişle, borçlandırıcı işlemler borçlanılan edim konusu hakkı devir, sınırlama, değiştirme veya ortadan kaldırma taahhüdünü içerirler.

538 Satış sözleşmesi (A)'ya ait malvarlığının sadece pasifi üzerinde etki yapmış ve ona bir borç yüklemiştir. Oysa aktifi üzerinde bir etkide bulunmamaktadır; (A) bilgisayarın mülkiyetinde hak sahibidir. Ama (A), (B)'ye sattığı bilgisayar üzerindeki mülkiyeti devir borcunu yerine getirir, yani bilgisayarı (B)'ye teslim ederse, artık (A)'nın bilgisayar üzerindeki mülkiyet hakkı sona erer. Bu da (A)'nın malvarlığının aktifi üzerinde bir etki yapar.

---

[54] **FLUME**, s.169; **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §7. V. D.

539 Bir sözleşme veya tek taraflı hukuki işlemle borç altına giren kişi için bu işlem bir borçlandırıcı işlem iken alacak hakkı elde eden kişi yönünden ise *kazandırma işlemi* (Erwerbsgeschäft) söz konusudur.

540 Borçlandırıcı işlemin, konusunu teşkil eden edim konusu şeyin mülkiyetine etkisi olmadığından, malikin tasarruf hak ve yetkisini sınırlamadığından, aynı şey birden fazla işlemin konusunu teşkil edebilir. Edim konusu şeyin, borçlanıldığı anda borçlunun malvarlığında bulunmasına da gerek yoktur. Aynı şeyi konu alan sözleşmeler, doğum tarihleri yönünden de bir öncelik hakkına sahip değildir.

2. Tasarruf İşlemi

a. Kavram

541 Tasarruf pek çok yönü itibarı ile karmaşık bir kavram olsa da, tasarruf, hukuki sonucu itibarı ile, bir hakkın kapsamında, onu azaltan (sınırlayan) veya ortadan kaldıran etkidir[55].

542 *von Tuhr*, her tasarrufun malvarlığının aktifini azalttığını vurgulamaktadır[56].

543 Tasarruf işlemi de, tasarrufta bulunanın malvarlığının aktifinin eksilmesine etkili olan işlemdir[57]. Bir kişi malvarlığının aktifinde mevcut olan hakka etki yaparak bu hakkı başkası yararına devreden, değiştiren, hakkı sınırlayan veya onu sona erdiren bir hukuki işlem yaparsa, bu işlemin *tasarruf işlemi* olacağını ifade etmiştik[58]. Kişi, malvarlığının aktifindeki ayni hakkı doğrudan ya da dolayı azaltıyor veya kaldırılıyorsa, *ayni tasarruf işlemi söz* konudur. Örneğin, bir malın başkasına rehin olarak verilmesi ya da başkası lehine bir irtifak hakkı tesis edilmesi o mal üzerindeki mülkiyet hakkını kayıtlayan bir işlem olarak malvarlığının aktifinde azalmaya sebep olduğundan ayni tasarruf işlemidir. Tasarruf işlemi tek taraflı hukuki işlem, örneğin alacağın temliki, ayni talep veya sözleşme, örneğin ayni (tasarruf) sözleşme, ibra sözleşmesi vb. şeklinde karşımıza çıkabilir. Ayni tasarruf işlemleri (Verfügungsgeschaft), *tasarruf*

---

55 **WIEGAND**, Eigentumserverb, 17 f.

56 von **TUHR/PETER**, s.195.

57 **GAUCH/SCHLUEP/REY**, N.3306.

58 **ANTALYA**, BH GH I, s. 114.

(ayni) sözleşmesi ya da tek taraflı işlem ise *tasarruf talebi* olarak isimlenmektedir[55].

b. Tasarruf İşlemlerinde Tasarruf Yetkisi Olgusunun Zorunluluğu

544 Tasarruf işlemi yapanın **tasarruf yetkisine** sahip olması gerekir. Tasarruf yetkisi tasarrufa konu hakkın bir parçasıdır. Tasarruf yetkisi borçlandırıcı işlemin yapıldığı anda değil, tasarruf işleminin yapıldığı anda bulunmalıdır. Tasarruf yetkisi hukuki işlemle sınırlanabilir; bu sınırlama borçlandırıcı etkiye sahiptir.

c. Tasarruf İşlemlerinin Hukuki Olguları

545 Bir hukuki işlemin tasarruf işlemi olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki iki unsur bulunmalıdır:

aa. Tasarruf İşleminden Önce Mevcut Bir Malvarlığı Hakkının Olması

546 Tasarruf işleminin konusu, tasarrufa elverişli bir hak olmalıdır. İş görme edimleri, örneğin hizmet iş edimi tasarrufa elverişli olmadığından tasarruf işleminin konusunu oluşturmazlar. Tasarruf işleminin konusunu kural olarak haklar oluşturur. Tasarruf işleminin konusunu sadece hak değil, hakkın yanında zilyetlik[56] ve hukuki ilişkiler[57] oluşturmaktadır. Hukuki ilişkiyi değiştiren veya sona erdiren tasarruf işlemleri de söz konusudur. Yenilik doğurucu hakların, hakkın yanında hukuki işleme de etkisi söz konusuysa, örneğin sözleşmenin feshi veya dönmede olduğu üzere, teknik anlamda değil, fakat geniş anlamda tasarruf işleminin konusunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

bb. Tasarruf İşleminden Sonra Hakta Meydana Gelmiş Bir Sonuç (Etki) Gerçekleşmesi

547 Tasarruf işlemin sonucu dört şekilde karşımıza çıkar; Hakkın devri, Hakkın sınırlandırılması, Hakkın içeriğinin değişmesi, Hakkın sona ermesi.

---

[55] DURAL/SARI, 18. 4. HATEMİ, §10. N.29; FLUME, s.140. ANTALYA/TOPUZ, MH. §7. V, C. 2

[56] von TUHR/PETER, § 25 I. s.194. AYİTER, K., s.18.

[57] von TUHR/PETER, § 25 I. s.194. AYİTER, K., s.18.

548 Hukuki sonuç malvarlığında yer alan iktisadi değerler üzerinde değil, bu iktisadi değere ilişkin menfaati koruyan hak üzerinde doğar[152]. Bir başka deyişle tasarruf işlemi eşyayı değil, o eşya üzerindeki hakkı konu alır[153].

3. Borçlandırıcı İşlemin Tasarruf İşleminden Farkları

549 Borçlandırıcı işlemle tasarruf işlemi aşağıda belirtilen temel noktalarda birbirinden farklılık gösterir[154]:

- Tasarruf işlemi, genelde borçlandırıcı işlemi ifa eden işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasarruf işlemi borçlandırıcı işlemden sonra yapılır. Borçlandırıcı işlemle tasarruf işleminin aynı anda yapıldığı elden işlemleri de, örneğin elden satış, elden bağışlamada olduğu üzere söz konusu olabilir.
- Her iki işlemin ayrılık prensibi uyarınca geçerlilik unsurları, özellikle şekli farklı olabilir.
- Tasarruf işleminde, tasarruf anında tasarruf edenin tasarruf yetkisine sahip olması gerekirken, borçlandırıcı işlemde böyle bir yetkinin bulunmasına gerek yoktur.
- Son olarak da belirlilik ve aleniyet ilkesi tasarruf işlemlerini borçlandırıcı işlemlerden ayırır.

4. Borçlandırıcı İşlemlerin ve Tasarruf İşlemlerinin Etkisi

a. Genel Olarak

550 Yukarıda açıklandığı üzere, irade ilkesi tasarrufun gerçekleşmesi için irade uyuşmasını yeterli görürken, teslim tescil ilkesi bu irade uyuşması yanında teslim ya da tescil olgusunu aramaktadır. Her iki ilkede de irade uyuşması kural olarak aranmaktadır.

b. Sözleşmenin Hakka Etkisinde Sistemler: Ayrılık İlkesi (Sistemi)

551 Sözleşmenin hakka etkisinin ne olduğu hususunda iki ilke (sistem) geçerlidir: Birlik ilkesi (sistemi) ve ayrılık ilkesi (sistemi).

---

[152] AYİTER, K., s.17.

[153] ANTALYA, Gelecektek Hakta Tasarruf, s. 547.

[154] EREN, BH GH. § 16. V.3.

aa. Birlik İlkesi (Sistemi)

552 İşlemde birlik ilkesinde (Einheitsprinzip), devredenle devralan arasındaki irade uyuşması borçlandırıcı etki yanında tasarrufi etki de göstermektedir. Tek bir hukuki işlem iki etkiyi de kendi içeriğinde taşımaktadır; başka bir deyişle aynı sözleşme hem borçlandırıcı, hem de tasarrufi sonuç doğurmaktadır.

bb. Ayrılık İlkesi (Sistemi)

553 Ayrılık ilkesinde (Trennungsprinzip) ise, borçlandırıcı etki gösteren irade uyuşması, tasarrufun sonuçlarını göstermemekte, tasarrufun gerçekleşebilmesi için *ayni sözleşme* olarak ifade edebileceğimiz, borçlandırıcı işlemden sonra, tasarrufi etki gösterecek ikinci bir hukuki işlemin yapılması gerekli görülmektedir. İşlemde ayrılık görüşünde, taşınmazlarda ikinci tasarruf işleminin bir tasarruf sözleşmesi mi yoksa tek taraflı hukuki işlem mi olduğu tartışılmaktadır.

554 Ayrılık ilkesinin hakim olduğu hukuk sisteminde tasarruf sözleşmesi çoğu kez karşımıza borçlanma işleminden doğan bir borcun yerine getirilmesi için (ifa sebebiyle) yapılır[105].

555 Bu sebeple borçlanma işlemi, tasarruf işleminin hukuki sebebini oluşturan temel işlemdir. Türk-İsviçre hukukunda taşınmaz mülkiyetine ilişkin tasarrufta, işlemde birlik ilkesinin mi yoksa işlemde aykırılık ilkesinin mi geçerli olduğu tartışmalıdır:

556 Bir görüşe göre, teslim tescil ilkesinin tek sözleşme ilkesi ile birlikte uygulanması gerektiği savunulmaktadır. Bu görüşe göre, tescile eklenerek tasarrufu gerçekleştirecek olan irade uyuşması borçlandırıcı işlemin içinde yer almaktadır. Tescil, hakta tasarruf edenin tek başına başvurarak gerçekleştirebileceği işlemdir. Bu sebeple bu görüşe göre tescil ve tescil talebi ***usuli resmi bir işlem*** niteliğindedir[106].

557 Diğer görüş ise, tescilin bir ***ayni sözleşme*** niteliğinde olduğunu ve ayni hak kazanan kişi ikinci bir irade beyanında bulunmasa da bu beyanın (farazi olarak) varlığının bulunduğunu savunmaktadır[107].

---

[105] von TUHR/PETER, §25 III. s.195; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, BH GH, §11, N.40.

[106] von TUHR, s.49; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s.26; ACEMOĞLU, K., s. 5; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, EH, s.329.

[107] WIEGAND, Art.963, N.2; AKİPEK, s.359; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s.490.

558 Katıldığımız çoğunluk görüşü ise, tescil talebinin usuli işlem olmasının yanında aynı zamanda ***tek taraflı tasarruf işlemi*** de olduğunu kabul etmektedir[128]. Elden işlemlerde, borçlandırıcı işlemle tasarruf işlemi birlikte aynı anda gerçekleşmektedir. Ancak düşünsel de olsa ayrılık ilkesinin bu halde de mevcut olduğu söylenebilir.

F. Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı veya Soyutluğu

1. Genel Olarak

559 Tasarrufta sebebe bağlılık (illilik) ve soyutluk (mücerretlik) tartışmaları, tasarrufun sonuç doğurabilmesi için mutlaka geçerli bir tasarruf sebebinin bulunmasına gerek olup olmadığına ilişkindir; *causa* tartışmaları Roma Hukukuna dayanır[129].

560 Sebebe bağlılık görüşüne göre, tasarrufun sonuç doğurabilmesi için varlığı ve geçerli bir tasarruf sebebi zorunludur.

561 Soyutluk görüşüne göre ise, tasarruf sebebini oluşturacak işlemin kurulamadığı veya geçerli olmadığı hallerde dahi tarafların tasarruf yönelmiş iradelerine hukuki sonuç bağlanır[130]. Bu nitelikteki hukuki işlemlere *soyut hukuki işlem* (Abstraktgeschäft) denmektedir.

562 Tasarruf işlemi sebebe bağlı ise, o işlemin geçerliliği ve hükümlerini doğurması bağlı olduğu borçlandırıcı işlemin geçerliliğine paralel olarak gerçekleşecektir. Tasarruf işleminin bağlı olduğu borçlandırıcı işlemin geçerliliğine tabi olması halinde, sebebe bağlı (illi) işlemden (Kausalgeschäft) bahsedilir.

563 Buna karşın tasarruf işlemi soyut ise, temel ilişki geçerli olmasa bile (sebepsiz zenginleşmeden doğan geri alma hakkı saklı olmak üzere) tasarruf işlemi geçerli olarak hükümlerini doğuracaktır.

564 Türk-İsviçre eşya hukuku, taşınır mülkiyetindeki tartışmalar bir yana bırakılırsa, kural olarak sebebe bağlılık ilkesini benimsemiştir[131].

---

[128] POSTACIOĞLU, s.197; SCHWARZ, s.162; CANSEL, s.44; MEIER-HAYOZ, BK ZGB Art.656, N.12.

[129] Maddi mallar alanında "iusta causa traditionis" tartışmalardaki (D.Ulpianus, 12.1.18; D.Iulianus, 41.1.36) causaya ilişkin görüş ayrılığına dayanmaktadır. EDİS, s. 283; FLUME, s.174; ANTALYA/TOPUZ, MH, §7, V, D.

[130] EDİS, Mülkiyetin İntikali, s.286; CANSEL, s.333; ÖZ, s.184; GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 15.

[131] BGE 55 II 306; 93 II 375. Alacağın temliki işleminde soyutluk ilkesi geçerlidir. Alacağın temlikini sebebe bağlılık kuralına bağlamaya ilişkin tartışmalar için bkz. EREN, BH GH, § 44, I, 3; JÄGGI,

565 Fransız hukukunda (CCfr Art.771, 1138al.2, 1583) ve İtalyan hukukunda (CCit. Art.1376) sebebe bağlılık ilkesi hakimdir. Ancak Türk-İsviçre hukukundan farklı olarak borçlandırıcı işlem ve tasarruf işlemi ayrımı olmaksızın taşınmazın hukuki işlemle kazanımı, işlemin yapılmasıyla gerçekleşmektedir.

566 Alman Hukuku ise tasarruf işlemlerinde soyutluk ilkesini benimsemiştir. Tasarruf işlemi sebep amaçlı değildir; ayni hakkın temelinde yatan işlemden örneğin satış işleminin ifası amacından (*içerikte soyutluk*) ve borçlandırıcı işlemin geçerliliğinden veya tasarruf yetkisinden soyuttur (*dışa soyutluk*)[112]. Bu yaklaşım, Pandekt hukukunun hak sahibinden iyiniyetle derhal kazanımını sağlayarak, ticari yaşamda hukuki güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. Alman hukukunda -TMK m.988, 1023'e benzer şekilde- sicile güvenle üçüncü kişilerin kazanımı korunmaktadır (BGB § 932). Alman hukukunda soyutluk ilkesinin kabulü, borçlandırıcı işlem – tasarruf işlemi ayrımının yapılmadığı anlamına gelmemektedir[113].

567 Türk-İsviçre mülkiyet kazanımı sisteminden farklı olarak Alman ayni hukuk doktrininde; iradi olgu olarak ayni uzlaşma (dingliche Einigung) olgusu ve taşınırlarda teslim, taşınmazlarda tescil şeklinde gerçekleşen görünebilir bilinilebilir (Kundmachung) olgusu ayrımı yapılmakta ve ayni uzlaşma olgusu ve görünebilir olma olgusu, tasarruf işleminde kombine edilmiş şekilde, aynı değerde ve kendine özgü birbirini tamamlayan iki olgudur[114].

568 Ayni uzlaşma sebepten bağımsız olup, borçlandırıcı işlemin geçerliliğine bağlı değilcir[115]. Borçlandırıcı işlem ve tasarruf işlemindeki soyutluk ilkesinin üç durumda ortadan kalktığı kabul edilmektedir[116]:

569 Borçlandırıcı işlem ve tasarruf işleminin ayrı sebepten iptali ve düzeltilebilir geçersizliği sebebinin iki işlem için de söz konusu olması. Her iki işlemin birbirine şartla bağlanması, örneğin satılanın intikalinin

---

s.6 vd. Kıymetli evrak hukukunda da (çek, bono ve poliçe) soyutluk ilkesi geçerlidir. Türk hukukunda sebebe bağlılık prensibinin yürürlüğüne ilişkin doktrin incelemesi hakkında bkz. **BURCUOĞLU**, Sebebe Bağlılık, s. 59 vd.

[112] **JUERNIG**, JuS 1994, s.772.

[113] **JUERNIG**, JuS 1994, s.71 f; **STADLER**, s. 7.

[114] Geniş bilgi için bkz. **BAUR/STÜRNER**, § 5, N. 1 ff. 30, § 19 N.8 ff. 51, N. 5 ff.

[115] **LARENZ**, SR II/1, S.10

[116] **BAUR/STÜRNER**, § 5, N. 50 ff; **JUERNIG**, JuS 1994, s.723 ff f; **STADLER**, s. 82 ff.

satım bedeline ödenmesi bozucu şartına bağlanması (BGB § 455). Tartışmalı olmakla birlikte her iki işlemin bir tek işlem içinde yapılması (BGB § 139).

2. Tasarruf İlkesinin Sebebe Bağlılığının Uygulama Alanları

570 Türk-İsviçre eşya hukuku, taşınır mülkiyetindeki tartışmalar bir yana bırakılırsa, kural olarak sebebe bağlılık ilkesini benimsemiştir[117]. Geçersiz bir borçlandırıcı işleme dayanan taşınır zilyetlik devirleri **haksız**; tapu kütüğüne yapılan tesciller ise **yolsuz tescildir**.

a. Taşınmaz Mülkiyetini Geçiren Tasarruf İşlemleri

571 Taşınmaz hukukunda, tescilin mutlak (kurucu) etkide olduğu ve tasarrufun tapu siciline tescil talebi şeklinde olacağı kabul edilmiştir[118]. Taşınmazlar üzerindeki aynı hakların, mülkiyetin devri için TMK m.1024 II hükümleri açıkça sebebe bağlılık ilkesini kabul etmiştir: "*Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur*". Yolsuz tescil sebebiyle hakkı zedelenen kişi tapu sicilinin düzeltilmesi davası açma hakkına sahiptir (TMK m.1025).

b. Taşınır Mülkiyetini Geçiren Tasarruf İşlemleri

572 Taşınır hukukunda, söz konusu tasarruf işlemi, zilyetliğin geçirilmesi (TMK m.977 vd.) şeklinde gerçekleşir. TMK'da taşınır mülkiyetini geçiren işlemlerin sebebe bağlılık ilkesine mi yoksa soyutluk ilkesine mi tabi olduğu hususunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Doktrinde konu tartışmalı olmakla birlikte, hakim görüş[119], İsviçre Federal Mahkemesi[120] ve Yargıtay[121] da sebebe bağlılık ilkesini kabul etmiştir[122].

---

117 BGE 55 II 306; 93 II 375. Alacağın temliki işleminde soyutluk ilkesi geçerlidir. Alacağın temlikini sebebe bağlılık kuralına bağlamaya ilişkin tartışmalar için bkz. **EREN**, BH GH, § 44, I, 3; **JÄGGI**, s.6 vd. Kıymetli evrak hukukunda da (çek, bono ve poliçe) soyutluk ilkesi geçerlidir.

118 BGE II 221, 229, 111 II 42 ff, 46, 110 II 128 ff, 130. Bkz. REY, recht 1986, N.128.

119 Ayrıntılı bilgi için bkz. **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.88 ff; **LIVER**, SPR V/1, N.317 f; **REY**, I, N.353 ff; **WIEGAND**, BSK vor Art.641 ff, N. 67; **SCHWANDER**, BSK ZGB Art.714, N.3 ff; **ARNET/BELSER**, CHK, ZGB Art.641, N.23; **TEKİNAY**, Menkul, s. 5, 447; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 325; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.739; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 71; **BURCUOĞLU**, Sebebe Bağlılık, s.79. Eleştiri için bkz. **HONSELL**, FS Wiegand, s.353. Bu konuda özellikle bkz. **HARTMANN**, N.132 ff.

120 BGE 55 II 302 ff kararından bu yana bkz. BGE 126 IV 161, N.3c, 121 III 345 ff, 347.

121 Y.HGK, 12.10.1968 T. 967/1-2- 687 (YKD, 1968, II/1, s. 264); Y.1. HD., 24.01.1978 T., 12524/658 (YKD., 1978/12, s.1942).

122 Bu tartışmalar için bkz. **HAAB**, ZK Art.714, N.21; **HONSELL**, Tradition, s.349 ff.

573 Örneğin, taşınır satış sözleşmesi bir *borç sözleşmesi*dir. Taraflar arasında kurduğu borç ilişkisi uyarınca, satıcı satılanın zilyetliğini devretme ve mülkiyeti geçirme borcu altındadır. Satıcının borcunu yerine getirmesi ikinci bir işleminin yapılmasını zorunlu kılar. Satıcının satılanın zilyetliğini alıcıya devretmesi yeterlidir. Zilyetliğin naklinin alıcıya mülkiyetin devri amacıyla yapıldığı hususunda anlaşmalarına, yani *tasarruf sözleşmesini yapmalarına gerek olup olmadığı tartışmalıdır*[22].

574 Katıldığımız hakim görüşe göre, taşınır mülkiyetinin geçmesi sadece tasarrufi sözleşmeyle değil, ayni sözleşmeye eklenecek ve hukuken maddi fiil olan şey üzerindeki fiili hâkimiyetin sağlanması (zilyetliğin devri) ile tamamlanacaktır.

c. Diğer Uygulama Alanları

575 Tüm sınırlı ayni haklarda da, taşınır veya taşınmaz ayrımı yapmaksızın, örneğin irtifak haklarında sebebe bağlılık ilkesi geçerlidir[24].

576 Sebebe bağlılık ilkesi taşınır rehninde de geçerlidir, yani rehin hakkının geçerliliğinin rehin sözleşmesinin geçerlilığine yani bağlayıcılığına bağlıdır[25]. TMK m.1024 II hükmünün, açık düzenleme yoksa, ayni hakkın kamuya açıklık aracı olduğu sicile tescil edilen taşınırlara da kıyasen uygulanması gerektiği kabul edilmektedir[26]. Hakkın aleniyeti sağlayan ve hakkı kuran sona erdiren sicillerin sebebe bağlı olması doğaldır. Bu konuda aksine bir düzenleme yoksa, bu sicillere ilişkin olarak TMK m.1024 II hükmünün kıyasen uygulanması ve sebebe bağlılık ilkesinin kabul edilmesi gerekir[27].

577 Taşınırlar üzerindeki rehin haklarının tescili için bir sicil düzeni (TARES) öngören 6750 sayılı TRK m.4 rehin hakkının rehin sözleşmesinin sicile tescil edilmesiyle kurulacağını ve m.8 (1) ve 9 hükmü rehin hakkının üçüncü kişilere karşı hüküm ifade edeceğini düzenlemiştir. Yine TRK m.5 rehin alacaklısının, alacağının son bulduğu tarihten itibaren terkin için başvuracağını ve RTS Yönetmeliğinin m.21 (3) hükmü taraflardan birinin talebe bağlı tescil sistemini benimsemiştir. TRK yönünden de,

---

[22] **ANTALYA**, BH GH I, s. 120.

[24] **MEIER-HAYOZ**, ZGB Art 656, N.4; **LIVER**, ZGB Art.731, N.2; **REY**, ZGB Art.731, N.6

[25] **OFTINGER/BÄR**, ZGB Art.731, N.6; **MAKARACI BAŞAK**, s. 5 vd.

[26] İsviçre'de gemi sicilinin sebebe bağlılığında kıyasen uygulama için bkz. BGE 110 II 427, 429.

[27] **REY**, I, N.323

TMK rehin hukukunun sebebe bağlılık ilkesine uygun olarak, rehin hakkını kuran ve aleniyeti sağlayan araç sicil sistemi için de TMK m.1024 II hükmünü kıyasen uygulayarak, sebebe bağlılık ilkesinin geçerli olduğunu kabul etmemiz gerekir[228].

d. Ayrımın Sonuçları: Bağlayıcı Temel (Borçlandırıcı) İşlem Olmadan Geçerli Tasarrufun Olmadığı

aa. Hukuki İşlemin (Sebebin) Geçersizliğinde Uygulanması

aaa. Genel Olarak

578 Tasarruf işleminin sebebe bağlı olduğu kabul edilirse, borçlandırıcı işlemde yer alan geçersizlik tasarruf işlemine etki ederek, onu geçersiz kılacaktır. Hiç kurulmamış sayılan, örneğin irade uygunsuzluğu; yazılmamış sayılan, örneğin genel işlem koşullarında kapsam denetimine aykırılık[229]; kesin hükümsüz olan örneğin ehliyet, şekle aykırılık[230], kanuna ve ahlaka aykırılık veya düzeltilebilirliği ortadan kalkarak geçersiz hale gelen örneğin irade sakatlığı hallerinde, ayni hakkı konu alan borçlandırıcı sözleşmeye dayanılarak yapılan tasarruf geçersizdir. Örneğin satış sözleşmesinin geçersizlik unsurlarından biri ile (şekle aykırılık, ehliyetsizlik gibi) kesin hükümsüz olması durumunda, yapılan tasarruf işlemi geçersiz olacağından, alıcıya mülkiyetin geçirilmesi engellenecek, alıcı satılanı teslim aldığı halde malik olamayacaktır.

bbb. Hukuki Sonuçları

579 Borçlandırıcı işlem geçersiz olduğundan tasarruf işlemi haksız olduğunda, taşınırda tasarrufta bulunarak zilyetliğini devreden, verdiğini *istihkak davası* açarak (TMK. m. 683 II) geri alma imkânına sahip olacaktır. Örneklersek; satıcı, verdiği taşınırın mülkiyet hakkı kendinde olduğundan istihkak davası ile geri alacaktır. Bağlayıcı olmayan veya sebepsiz hukuki işleme dayanan ve Tapuda alıcı adına yapılan tescil yolsuz tescil olduğundan, ayni hakkı zedelenen kişi *tapu sicilinin düzeltilmesini* (TMK m. 1025) dava edebilir[231].

---

[228] Bkz. **ANTALYA/ACAR**, s. 53.

[229] **TOPUZ, M.** 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi, Prof.Dr. Mustafa DURAL'a Armağan, İstanbul 2013, s. 1138 vd.

[230] Borçlandırıcı işlemdeki şekil eksikliğinin dürüstlük kuralı ile düzeltilmesi söz konusudur. Bkz. **ANTALYA**, BH GH I, s. 481 vd., **ANTALYA/TOPUZ**, MH, s. 373 vd.

[231] **REY**, ZGB Art.731, N.79; I, N.368

bb. Hukuki İşlemin Sona Erdirilmesinde Uygulanması

580 Buna karşın, katıldığımız dönüşüm görüşüne göre borçlandırıcı işlem; geri alma, iptal, cayma, dönme[132] veya fesih[133] sebepleri ile sona erdirilmişse borçlandırıcı işlem aynı nitelikte *tasfiye (geri verme) ilişkisine* (Rückabwicklungverhältnis) dönüşür; ayni hakkı kazanmaya neden olan tasarruf işlemi varlığını ve geçerliliğini devam ettirir[134].

581 Geri verme (dönüşüm) ilişkisinden doğan talep, tasfiye ilişkisinden doğan sözleşmesel taleptir. Sona erdirilen borçlandırıcı işleme dayanarak taşınmazı devreden, geri verme ilişkisinden doğan *kişisel talebe dayanarak, devrettiği taşınmazın kendisi adına tescilini* TMK m.716 hükmüne dayanarak talep edecektir. Taşınırlarda ise geri verme ilişkisine dayanarak taşınır *zilyetliğinin devrini* (teslimini) talep edecektir (TMK m. 763 I).

582 TBK m.173 bozucu koşula bağlanmış sözleşme hükümlerinin koşul gerçekleştiğinde ortadan kalktığını düzenlemiştir. Bu durumda da yine sözleşmeden doğan geri verme ilişkisine dayanan talep söz konusudur[135].

cc. Soyutluk İlkesi ile Hukuki Sonuçlarının Karşılaştırılması

583 Soyutluk ilkesinin kabul edildiği durumlarda ise, borçlandırıcı işlemin geçersizliğine rağmen tasarruf işlemi geçerliliğini koruyacaktır. Yukarıdaki örneğin aksi olarak, satış sözleşmesinin kesin geçersizliğine rağmen satılanın mülkiyeti alıcıya geçecek, fakat alıcının bu kazanımı sebepten yoksun olacaktır. Satıcı da sebepsiz zenginleşme kurallarına dayanarak satılanın geri verilmesini talep edebilecektir. Bu durumda da borçlandırıcı işlem (sözleşme) cayma, dönme veya fesih ya da başka bir şekilde sona erdirilmişse, borçlandırıcı işlem geri verme ilişkisine, bir başka deyişle tasfiye ilişkisine (sözleşmesine) dönüşecek, verilen şey bu sözleşmeye dayanılarak geri istenecektir.

584 Bu iki ilkenin sonuçlarındaki en önemli fark, kendisini hakkın niteliğinde gösterir. Soyutluk ilkesinin sonucu olarak, meydana gelen sebepsiz zenginleşme veya geri verilmesini isteme, borç ilişkisi doğuran bir nispi

---

[132] Dönmenin sözleşmeye etkisi konusunda üç görüş savunulmaktadır. Klasik (sebepsiz zenginleşme) görüş, ayni etkili dönme görüşü ve dönüşüm görüşü. Dönmenin hukuki sonuçları için bkz. **ANTALYA**, BH GH III, s.510 vd.

[133] Feshin hukuki sonuçları için bkz. **ANTALYA**, BH GH III, s.540 vd.

[134] **ANTALYA**, BH GH, III, s. 512.

[135] **GAUCH/SCHLUEP/REY**, N.4239. Aksi fikir için bkz. **KELLER/SCHÖBI**, s.109; **MERZ**, SPR VIII, s.163.

hak olduğundan, sadece kazandırmada bulunulan tarafa karşı ileri sürülebilecektir.

585 Halbuki sebebe bağlılık ilkesinde ayni hak sahibi olan devreden, mülkiyeti üçüncü kişiye devredilmiş olsa bile, ilişkinin geri verme ilişkisine dönüştüğü hallerde, -geri verme talebi hariç- üçüncü kişinin iyiniyetli olduğu haller saklı olmak üzere, üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilir. Üçüncü kişinin iyiniyetli olması halinde ise, kazandırma sebepsiz olması nedeniyle geçersiz olacağından, kazandırmada bulunan karşı tarafa sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre başvurabilecektir.

586 Sebebe bağlılık ilkesinde tasarrufta bulunan malik, geçersiz sözleşmeye rağmen malik sıfatını tapu sicilinde şeklen kaybetse de gerçek malik sıfatını kendisinde saklı tutar; bu sebeple ayni hak sahibi gibi korunur, yararlara ve haklara sahip olur.

VII. KATILMA (İLTİHAK) VEYA BAĞLANMA İLKESİ

A. Kural: Asıl Şeye Katılanın veya Bağlı Kılınan Şeyler Asıl Şeyin Hukuki Rejimine Tabi Olması

1. Genel Olarak

587 Mülkiyetin kapsamında inceleyeceğimiz üzere, katılma (ilhak) ilkesi (Akzessionsprinzip) veya bağlanma ilkesi, bir asıl (esas) şeye katılarak ya da bağlı kılınarak onun bir parçasını oluşturan şeylerin, asıl şeyin hukuki rejimine tabi olmasını ifade eden ilkelerdir. Katılma ilkesi, asıl şeye katılan veya bağlı kılınan şeylerin, asıl şeyin hukuki rejimine tabi olmasını ifade eder[136].

588 Katılma ve bağlanma ilkesi, eşya kavramının sınırlarını belirleyerek ve eşya üzerindeki mülkiyetin kapsamını çizerek, eşyanın ticari yaşamda değişim ve hukuk güvenliğinin sağlanmasına hizmet eder. Asıl şeyle ona katılan şey arasındaki ilişki iki farklı şekilde gerçekleşebilir; katılma ilişkisi: Bütünleyici parça ve bağlanma ilişkisi: Eklenti

2. Katılma İlişkisi: Bütünleyici Parça

589 Katılma ilişkisinde, esas şeyle ona katılan arasında, yoğun maddi bütünleşme söz konusudur. Katılma ilişkisiyle, iki şey ekonomik anlamda bütünleşmekte, onunla yeknesaklaşmaktadır. Esas şeye katılan şey, bütünleyici

[136] MEIER-HAYOZ, BK Syst.Teil. N.98; REY, I N.392 ff. SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N.79-80.

parça (mütemmim cüz) olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda, bir şey, asıl şeyin temel unsuru haline gelerek; o şey yok edilmedikçe, zarara uğramadıkça, veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak olmayacak şekilde ona katılmışsa, bütünleyici parça halıne gelmiştir (TMK m.684 II).

590 Katılan şeyle asıl şey arasındakı katılma yoğun bir şekilde gerçekleşmekte, katılan şey esas şeyin temel unsuru haline gelmektedir. Bütünleyici parça da, esas şeye katılma, yerel adete göre belirlenmektedir.

591 Bır şey asıl şeyle, ticari yaşam ilişkilerine göre, objektif olarak sıkı bir ekonomik bütünlük oluşturmuşsa, hukuki mukadderatı da aynı eşya yeknesaklığında olduğu üzere asıl şeyin mukadderatına tabi olur.

3. Bağlanma İlişkisi: Eklenti

592 Bir şeyin esas şeye bağlanmasında ikı şey arasında ekonomik bütünleşme değil, ekonomik olarak esas şeyın fonksiyonelliğini sağlamak için nitelikli bir yakınlaşma söz konusu olur. Bağlanma ilişkisinde, katılmadan daha zayıf bır şekilde asıl şeye özgülenme ve bağlı kılınma gerçekleşmektedir. Asıl şeyin işletılmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli özgülenen ve kullanılmasında birleşme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan şeyler, eklentidir (teferruat) (TMK m.686 II). Bağlanma ilişkisi malikin anlaşılan rızası ve yerel adete göre belirlenir.

B. Hukuki Sonuçları

593 Öncelikle belırtelim ki, katılan bütünleyici parça ve bağlanan eklenti, kendıleri tek başına ayni hakkın konusunu oluşturmazlar; bu sebeple de mülkiyetin konusunu yanı tek başlarına ayni hakkı konu alan tasarruf işleminin konusunu oluşturmazlar[37]. Esas şeyden sürekli ayrılabilen şeyler (eklentiler), gelecekte ifa edilebilir taşınır eşya olarak bir borçlandırıcı işlemin, örneğin satışın konusunu oluşturabilir[38]. Böylelikle, katılma veya bağlılık ilkesi, aynı zamanda eşya kavramının ve belirlilik ilkesinin sınırlarını çizer[39]. Katılma (ilhak) veya bağlılık ilkesine, TMK ayni hakkın kapsamı bakımından aşağıdakı sonuçları bağlamıştır[40].

---

[37] **HAAB**, Art.642, N.19 ff. **LIVER**, SPR V/1, s.36; **REY**, I, N. 407 ff.

[38] **OSER/SCHÖNENBERGER**, OR Art.187, N.8; **MEIER-HAYOZ**, ZGB Art.642, N.69; **KOLLER**, BSK OR Art.184, N.16; **REY**, I, N.409.

[39] **REY**, I, N.413-415.

[40] **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 79.

1. Mülkiyet Hakkının Kapsamı Bakımından

594 Esas şeye malik olan, o şeye katılan bütünleyici parçanın da maliki olur (TMK m.684). Yine esas şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe, ona bağlanan eklentiyi de kapsar (TMK m.686).

2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı Bakımından

595 Arazi üzerindeki mülkiyet, üstündekileri (örneğin: yapılar, bitki ve kaynaklar) ve altındaki arz katmanlarını kapsar (TMK m.718). Arazi ve yapı ilişkisi TMK m.722'de düzenlenmiştir.

3. Rehnin Kapsamı Bakımından

596 Rehin, taşınmazı bütünleyici parçaları ve eklentileriyle birlikte yükümlü kılar (TMK m.862/I). Taşınır rehni, taşınırı eklentileriyle birlikte kapsar. Rehin, paraya çevirme sırasında bütünleyici parça niteliğindeki doğal ürünleri de kapsar; aksi kararlaştırılmış olmadıkça alacaklı, rehinli taşınırın doğal ürünlerini, bütünleyici parçası olmaktan çıkınca malike vermekle yükümlüdür. (TMK m. 947)

C. İstisnaları

597 TMK, katılma ve bağlanma ilkesinin istisnalarını da düzenlemiştir:

- Üst hakkı (TMK m. 726, 826 vd.),
- Mecraların işletmenin eklentisi olması ve işletme malikinin malı sayılması (TMK m. 727),
- Bağımsız bölüm üzerindeki kat mülkiyeti veya kat irtifakı (KMK),
- Ağaçlar ve ormanların üst hakkının konusu oluşturmaması (TMK m.729/II).

VIII. ZAMAN İTİBARI İLE ÖNCELİK İLKESİ

A. Kural: Zaman İtibarı ile Öncelik İlkesi

598 Bir eşya üzerinde birden fazla mülkiyet hakkı kurulamaz, ama birden fazla kişi birlikte o mülkiyet hakkına sahip olabilir. Bir eşya üzerinde tek bir mülkiyet hakkının kurulmasına *mülkiyet hakkının inhisariliği ilkesi* ismi verilmektedir[4].

[4] ÜNAL/BAŞPINAR, s.7.

599 Mülkiyet hakkını sınırlayan ona ilave birden fazla sınırlı ayni hak kurulabilir. Hatta aynı sınırlı ayni haktan, örneğinden rehin hakkından birden fazla kurulabilir. İşte sınırlı ayni hakların mülkiyetle ve birbiriyle olan ilişkisi ve kendi içlerindeki ilişkisinin ve bu ilişkilerde hangisinin diğerine göre önceliğinin olduğunun ve bu önceliğin hangi sıraya göre oluşturulması gerektiğinin belirlenmesi gerekir.

B. Uygulama Alanı

1. Genel Olarak

600 Mülkiyet ile sınırlı ayni hak arasındaki ilişki aşağıda ayrıca incelenecekse de sınırlı ayni hak mülkiyeti sınırladığından, mülkiyet hakkı sahibi, sınırlı ayni hak sahibinin sahip olduğu hak ve yetkilere katlanmak, ona karşı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmak durumundadır. Bu sebeple mülkiyet hakkı ile sınırlı ayni hak arasında öncelik veya sıra sorunu bulunmamaktadır.

601 Sınırlı ayni hakların aralarındaki öncelik sırası, kuruluş tarihindeki önceliğe göre belirlenir. Buna hakların çatışmasında *zaman itibari ile öncelik (Alterspriotat) ilkesi* ismini vermekteyiz. Bu kurala, sözleşme (TMK m.871) veya kanunla (TMK m.842, 870, 892) istisna getirilebilir.

602 Zaman itibarı ile öncelik ilkesi, tüm ayni hakların çatışması ilişkisinde, örneğin irtifak hakları ile diğer irtifak hakları, taşınmaz yükü, rehin hakları arasındaki çatışma ilişkisinde uygulanır[42]. Şerh verilen kişisel haklarda da şerh ediliş, tarihe göre öncelliğe sahiptir[43].

2. Rehin Hakkında Uygulanması

603 Zaman itibarı ile öncelik ilkesi sınırlı ayni haklarda, özellikle önceden kurulmuş rehin hakkının sonra kurulan irtifak hakları veya eşyaya bağlı borç haline getirilmiş kişisel haklarla çatışmasında özel önem taşır. Böyle bir hak çatışması halinde TMK m.869 hükmü taşınmaz rehni hakkı sahibini korumaktadır. Şöyle ki, alacaklının taşınmaz üzerindeki rehin hakkı, o taşınmaz üzerinde rızası olmaksızın sonradan tesis edilen bütün irtifak haklarından ve gayrimenkul yüklerinden önce gelir. Sonradan kurulan ve rehnin paraya çevrilmesi sırasında daha eski tarihli rehin alacak-

[42] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst.Teil. N.85 ff. **LIVER**, Einl. zu ZGB Art.730-792, N.35, Art.737, N.97; **REY**, Syst. Teil, N.239.

[43] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst.Teil, N.97; **REY**, I. N. 550.

lılarına zarar veren bu haklar, terkin olunur. Önceki rehinli alacaklının istemiyle irtifak hakları veya taşınmaz yükleri terkin edilen kimselerin, rehinli taşınmazın paraya çevrilmesinde, hakları sonradan tescil edilenlere karşı, satış bedelinden haklarının değerini karşılayan miktarı almak hususunda öncelikleri vardır.

604 TBK m. 310 hükmü çatılı konut ve işyerlerinde, kiracının korunması amacıyla, kiralanan taşınmaz el değiştirirse, yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı olduğunu düzenlemiştir. Yine bu hüküm üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması durumunda da uygulanacaktır (TMK m.311). İlaveten TMK m.312 hükmü taşınmaz kiralarında, kiracının kiracılık hakkının sözleşmeyle şerhinin kararlaştırılabileceğini düzenlemektedir.

605 Önce konut ve çatılı işyeri yeni malikinin, şerh edilmemiş olsa da eski kira sözleşmesinin tarafı haline gelmesi halinde, konut ve çatılı kira sözleşmesinden doğan hak ile ipotek alacaklısının hakkının çatışmasını değerlendirmemiz gerekir. Bu durum, TMK'da ve TBK'nda düzenlenmemiştir. İİK m. 135 hükmü, taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş, bir sözleşmeye dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edileceğini; bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur. İİK m.135 taşınmazın paraya çevrilerek satışından sonra kiracının korunmasını, kira sözleşmesinin resmi belge olarak düzenlenmesine bağlamaktadır. Halbuki TBK m.310 hükmü ile EBK m.254'te benimsenen satış kirayı sona erdirir ilkesinden vazgeçmiştir. Bu hükümle, taşınmazın el değiştirmesinde cebri icrayı ayırt etmeksizin, "*herhangi bir sebep*"le el değiştirmesini yeterli görülmüştür; bu sebeple de çatılı konut ve işyeri niteliğindeki taşınmazlarda uygulama alanı bulacaktır. Çatılı konut ve işyeri kira sözleşmesi resmi belge şeklinde yapılmışsa veya zaten bu şekle uyularak şerh edilmişse, taşınmazın cebri icra ile el değiştirmesi İİK m.135 hükmü de kiracının haklarını korumaktadır. Yeni malikin gereksinim hakkına dayanarak dava yoluyla sözleşmeyi sona erdirilmesini talep hakkı saklıdır (TMK m.350).

606 Peki rehin hakkı ile özellikle çatılı konut ve işyeri dışındaki uzun süreli kira sözleşmeleri –hatta ödünç sözleşmeleri- arasındaki çatışma nasıl çözülecektir.

607 Kira sözleşmesi şerh edilmemişse, bu takdirde, bir açık kanun boşluğu bulunduğu kabul edilmeli, bu boşluk TMK m.869 hükmü ile doldurulmalıdır[144]. Önce tarihi eski olan rehin hakkı sahibinin izin verip vermediğine bakılacaktır. İzin alınmadan kira sözleşmesi şerh edilmişse, sonradan kurulan ve rehnin paraya çevrilmesi sırasında daha eski tarihli rehinli alacaklıya zarar veren şerh edilmiş kiracılık hakkı terkin edilecektir.

608 TBK m.312'e göre, rehinden önce şerh edilmiş ise, çatılı konut ve işyerine konu olanlar dâhil kira sözleşmesinden doğan kiracının hakkı korunacaktır. İİK m. 135 hükmü saklıdır.

609 TMK'nın kabul ettiği bu ilkeyi taşınır ve taşınmaz ayrımına göre aşağıda inceleyelim:

3. Taşınırlarda Zaman İtibarı ile Öncelik İlkesi

610 Taşınırlarda öncelik sırası, **kuruluş tarihine göre** belirlenir[145]. Başka bir deyişle, "zamanda öncelik, hakta öncelik (*prior tempore, potior jure*) kuralı" uyarınca, önce kurulan sonra kurulandan önce gelir ilkesi geçerlidir.

4. Taşınmazlarda Zaman İtibarı ile Öncelik İlkesi

611 Taşınmazlarda kurulan birden fazla sınırlı ayni haklarda öncelik sırası daha önem taşır. Taşınmazlarda kurulan farklı sınırlı ayni hak tiplerinin, önce kapsamlarının birbiriyle çatışıp çatışmadığının belirlenmesi gerekir. Örneğin, bir geçit hakkı ile kaynak hakkının verdiği kullanım veya yararlanma yetkilerinin kapsamı birbiriyle çatışmayabilir. Ama aynı taşınmaz üzerinde kurulan oturma hakkı ile intifa hakkı birbiriyle çatışır. Belirtmek gerekir ki, farklı sınırlı ayni hak tipleri arasında sıra itibarıyla öncelik sorunu veya birinin diğerine üstünlüğü yoktur; tüm sınırlı ayni hak tipleri birbiriyle eşittir. Buna *sınırlı ayni hak tiplerinin eşitliği ilkesi* diyebiliriz. Taşınmazlarda, zamanda öncelik, hakta öncelik kuralı mutlak değildir; taraflar bunun aksine öncelik zamanını kendileri belirleyebilirler[146].

---

[144] REY, I, N.553 a.

[145] MEIER-HAYOZ, BK Syst.Teil. N.95; REY, I. N. 556; OFTINGER/BÄR, ZGB Art.893. N.11 ff; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N. 77.

[146] GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 779.

612 Sınırlı ayni hakların taşınmazdan yararlanma veya garanti teşkil etmesi bakımından muhtevalarının çatışması söz konusu olduğunda, öncelik sırasının belirlenmesi gerekir. Sınırlı ayni hakların verdiği yetkilerin kapsamının çatışması halinde, zamanda öncelik, hakta öncelik kuralı uygulanır: zaman itibarı önce kurulan sınırlı ayni hak, diğerine göre öncelikli sıradadır. TMK kuruluş tarihindeki önceliklidir ilkesini TMK m.1022 I hükmünde, taşınmaz üzerinde hangi sınırlı ayni hak önce kurulmuşsa, o daha sonra kurulanlardan önce gelir şeklinde ifade etmiştir.

C. İstisna: Derece Sistemi

613 Zaman itibarı ile öncelik ilkesinin istisnası, taşınmaz rehninde TMK'nın kabul ettiği sabit dereceler sistemidir[147]. Taşınmaz rehninin önceliği, kurulma zamanına göre değil, bulunduğu derecenin sırasına göre belirlenir (TMK m.870)[148]. 6750 sayılı TRK, ticari işlemlerde taşınır rehninde derece sistemine imkân tanımıştır[149].

---

[147] **REY**, I, N.557 ff.

[148] **EREL**, Rehinde Sıra, s. 1 vd.; **BAŞPINAR**, Sıra, s. 50.

[149] Bkz. **ANTALYA/ACAR**, s. 106 vd.

İkinci Bölüm

ZİLYETLİK

Yazar: Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA

§ 4. GENEL OLARAK ZİLYETLİK

I. ZİLYETLİĞİN HUKUKİ OLGU OLARAK YERİ VE FONKSİYONU

614 Hiçbir hukuk düzeni, kişinin eşya üzerinde bulunan fiili hakimiyetinin bir başkası tarafından ihlalini ve bu hakimiyetin toplum düzeni bakımından korunmasının önemini görmezlikten gelemez. Bu sebeple, her hukuk düzeni, zilyetliği olgu olarak dikkate alıp, bu olgudan hareketle hakimiyetin sınırlarını ve bu olgunun korunmasının yasal araçlarını hukuk kuralları ile düzenlemiştir.

615 TMK m.973 ve devamında düzenlenen zilyetlik ve TMK m.997 ve devamında düzenlenen tapu sicili doktrinde genellikle sistematik olarak, kanun sistematiğinden farklı olarak, TMK m.683 ve devamında düzenlenen mülkiyet ve sınırlı ayni haklardan önce incelenir. Bunun sebebi bu iki kurumun da ayni hakkın aleniyetini sağlayan kamuya açıklık aracı olmasındandır. Eşya üzerindeki hak kendini dışarıya zilyetlik ve tapu sicili ile görünür kılmaktadır. Bir kişinin ayni hak sahibi olduğu eşya ile olan ilişkisi taşınmazlarda tapu sicili, taşınırlarda zilyetlik şeklinde dışa yansıyan bir görünümle anlaşılır.

616 Özellikle zilyetlik ile taşınmaz mülkiyeti arasında yoğun ilişki ve bu ilişkiye bağlanan sonuçlar söz konusu ise de, zilyetliğin tüm ayni haklarla ilişkisi ve buna bağlanan hukuki sonuçları söz konusudur. Bunlardan zilyetliğin ayni hakkın kurulmasına, hatta kazanılmasına sebep olan bir hukuki olgu olmasına kısaca göz atarsak;

- Zilyetlik taşınırlarda mülkiyet karinesidir (TMK m.985 I),
- Taşınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğinin devri gerekir (TMK m.764 I),
- İyiniyetli malik sıfatıyla zilyetlik, taşınır mülkiyetini zamanaşımı ile kazandırır (TMK m.777),
- İntifa hakkının kurulması, taşınırlarda zilyetliğinde devri ile gerçekleşir (TMK m.795 I),
- Teslime bağlı rehin, zilyetliğin alacaklıya devri suretiyle kurulur (TMK m. 939 I).

Zilyetliğin ayni haklarda aleniyeti sağlaması ve buna bağlanan sonuçları yukarıda incelemiş idik[1].

617 Bilindiği üzere, TMK Eşya Hukuku kitabını, taşınır hukuku ve taşınmaz hukuku ayrımına göre düzenlemiştir. Bu ayrım içinde zilyetlik, aleniyeti sağlayıcı açıklık aracı olması ve buna bağlanan hukuki sonuçları itibarı ile önemli bir olgudur. Buna karşın, zilyetliğe ilişkin hukuki hükümler genel hükümlerdir yani hem taşınırlara hem de taşınmazlara uygulanır. Özellikle zilyetliğin korunmasına ilişkin TMK m. 981-984, zilyetliğin geri verme borcunun kapsamına ilişkin TMK m.993-995, zilyetliğin zamanaşımı ile kazanımındaki rolüne ilişkin TMK m. 707, 712, 713, 996 hükümleri taşınmazlar bakımından da önem taşımaktadır.

618 Taşınmazın, zamanaşımı ile kazanımı (TMK m.712, 713) işgalle iktisabı (TMK m.707); Kadastro Kanunu'na göre imar ve ihya ile kazanımı (Kad.K.m.17) ve diğer özel Kanunlardaki taşınmaz kazanımında zilyetlik olgusu kurucu olgudur. Örneğin, TMK m. 973 I hükmü taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yükünde hak zilyetliğini; TMK m.981-984, 992 hükümleri ise taşınmazlardaki hak karinesinden kimin yararlanacağını, gasp ve saldırı halinde kimin dava açacağını düzenleyerek taşınmaz malikine özel koruma imkânı sağlar. İlaveten belirtelim ki, yargı kararlarında da kabul edildiği üzere, taşınmazların devrinde şekle aykırılığın TMK m.2'e göre düzeltilmesinde önemli bir rol oynar[2].

619 Zilyetliğe, özelikle iyiniyetli veya iyiniyetli olmayan zilyedin zilyetliğinin iadesine ilişkin hükümlere, madde veya kurum olarak atıfta bulunan çok sayıda, TMK hükmü bulunmaktadır. Örneğin; TMK m.552 II b.2, 585 I, 599 II ve III, 638 I, 646 III, 687, 712, 713 I ve II, 763, 795 I, 803 I, 810, 918 II, 923 I, 939.

620 TMK'nın yanı sıra TBK'da da zilyetliğe, özelikle iyiniyetli veya iyiniyetli olmayan zilyedin zilyetliği iadesi hükümlerine atıfta bulunulduğunu görmekteyiz. Örneğin, TBK m.208 I ve II, 210, 212 II, 234 I, 235 III, 250 II, 282, 574 III.

---

1 **ANTALYA**, EH I, N. 466.

2 **ANTALYA/TOPUZ**, MHG, s. 381; **ANTALYA**, BH GH, I, s. 132 vd.

II. YASAL DÜZENLENMESİ

621 TMK'nın "Eşya Hukuku" kitabının üçüncü kısmında "Zilyetlik ve Tapu Sicili" düzenlenmiştir. Üçüncü kısmın birinci bölümü "Zilyetlik", ikinci bölümü "Tapu Sicili"dir. Aşağıda "Zilyetlik" başlığının TMK sistematiği verilmiştir:

BİRİNCİ BÖLÜM: ZİLYETLİK

A. Zilyetlik Kavramı ve Türleri: TMK m.973-976
   I. Kavram: TMK m.973
   II. Türleri: TMK m.974-975
   III. Geçici Olarak Kesilme: TMK m. 976
B. Zilyetliğin Devri: TMK m.977- 980
   I. Hazırlar Arasında: TMK m.977
   II. Hazırlar Olmayanlar Arasında: TMK m.978
   III. Teslimsiz Devir: TMK m.979
   IV. Emtiayı Temsil eden Senetlerin Teslimi: TMK m.980
C. Zilyetliğin Hükümleri: TMK m.981-996
   I. Korunması: TMK m.981-984
   II. Zilyetlik Dolayısıyla Hakkın Korunması: TMK m.985-992
   III. Sorumluluk: TMK 993-995
   IV. Kazandırıcı Zamanaşımından Yararlanma: TMK m.996

III. İNCELEME SİSTEMATİĞİMİZ

622 Bir şey üzerindeki hukuki hakimiyet mülkiyet, fiili hakimiyet ise zilyetliktir[3]. Biz de TMK Eşya Hukuku sistematiğini takip etmeyerek, öncelikle zilyetliğe ilişkin açıklamalarda bulunacağız. İlerleyen bölümlerde ise TMK sistematiğine uygun olarak önce mülkiyeti, daha sonra sınırlı ayni hakları inceleyeceğiz[4].

---

[3] ÜNAL/BAŞPINAR, s. 81.

[4] TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s 33 vd; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s 49 vd.; AKİPEK/AKINTÜRK, s. 5; NOMER/ERGÜNE, s 1 vd.; AYAN, s. 68 vd.

Bu incelememizde, zilyetliğin ve tapu sicilinin aleniyeti sağlama aracı olarak sadece şekli değil, maddi hükümlerde de düzenlenmesinden; özellikle şekli eşya hukuku ve maddi eşya hukuku ayrımı yapmayacağız[5].

Yine zilyetliğe ve tapu siciline sadece mülkiyetin içinde yer veren bir sistematikten[6] de kaçınacağız.

[5] ÜNAL/BAŞPINAR, s. 78.

[6] REY, I, 1319ff, 1693 ff.

§ 5. ZİLYETLİK KAVRAMI

I. GİRİŞ

A. Genel Olarak

623 Eşya hukukundaki zilyetlik genellikle bir hukuki ilişki sebebiyle gerçekleşir; ama zorunlu değildir. Şeyi fiili hakimiyetinde tutan zilyedin başka hukuki ilişkiden doğan sıfatları ve bu sıfatlarını veren hukuki ilişkiden doğan başka hakları ve bu hakların verdiği koruma da söz konusudur. Örneğin, malik mülkiyet hakkından doğan ayni hak yetkisi ve korunmasına; vekil, vekalet sözleşmesinden doğan nispi hak yetkisi ve korunmasına sahiptir. Bu hakları zilyetlikten doğan hak ve koruma yanında saklıdır. Belirtelim ki zilyedin zilyetliğini sağlayan başka bir hukuki ilişkide bulunması zorunlu değildir. Örnek; hırsız, bulan.

624 Öncelikle belirtelim ki, Anayasa hukuku bakımından zilyetlik, mülkiyeti teminat altına alan Anayasa'nın m. 35 hükmü garantisi altındadır[1].

B. Terim

625 Arapça kökende "sahip" anlamına gelen "zi" ile "el" anlamına gelen "yed" kelimeleri zilyetlik kavramını oluşturmaktadır. Kökeninden hareket edersek, zilyetliğin kelime anlamı eşya üzerindeki "elsahipliği"dir[2].

C. Tarihi Gelişimi

626 Zilyetliğe tarihi kökeni yönünden baktığımızda, günümüzde zilyetliğin, Alman ve Roma hukuku esas alınarak onun geliştirilmiş şeklinin kurallaştırıldığını görmekteyiz[3].

627 Alman hukukunun[4] zilyetliğin kapsam ve çeşitlerinde, hukuki korumasında; Roma hukukunun[5] ise zilyetliğin özellikle irade unsurunda ve

---

1 BGE 128 I 327 ff. 337; 129 I 129 ff. 133. 120 Ia 120 ff. 121.

2 **UNAL/BAŞPINAR**, s. 79.

3 Roma ve ortak hukukta zilyetlik kavramı için bkz. **HERMANN**, Cautio damni, s.203 ff; Roma hukukunda *possessio* kavramı ve Roma hukukundaki zilyetlik teorileri **NIGGLI**, s. 94 ff.

4 Alman hukukunda zilyetlik ve zilyetliğin giydiği elbise olarak "die Gewere" kavramı için bkz. **STARK**, BK ZGB Einl. N.24 ff; **STINTZING**, 435 ff; **OGRIS**, 1658 ff.

5 Roma hukukunda zilyetlik için bkz. **STARK**, BK ZGB Einl. N.8 f; **KAISER**, s.140 f; **KAISER**, s. 1 vd.

kazanılmasında rol oynadığını gözlemleyebiliriz. Bu sebeple TMK ve ZGB'nin zilyetlik sisteminin, Pandekt hukukundaki[6] gelişim sonrasında, Pandekt ve Roma hukuku kombinasyonu olduğunu söyleyebiliriz[7].

628 *Huber*, Alman Eşya hukukundaki 'Gewere' kavramının aleniyet fonksiyonuna dikkat çekmektedir[8]. BGB tarihsel gelişiminde ilk tasarıda "Inhabung", yani önceki yaklaşımla maddi hakimiyet ile "zilyetlik" yani *animus domini* iradesiyle eşya ile olan ilişki ayrımı yapıldığı halde, bu öneri ikinci komisyonda kabul edilmeyerek ikisi arasında özel bir fark olmadan düzenlemeye gidilmiştir[9].

629 Mukayeseli hukukta, Alman hukukunda Roma ve Alman düşüncesindeki birliktelik; Avusturya hukukunda tabi hukuk görüşünün Roma ve Alman unsurları; Fransız hukukunda *corpus* ve *animus* unsurlarındaki ayrım kabul edilmiştir[10].

II. TANIM

630 Zilyetlikle ilgili TMK hükümlerinin soyut olması, kanun kuyucunun TMK'da zilyetliği yeknesak olarak düzenlememesi ve ona farklı fonksiyonlar yüklemesi ve de birbirinden farklı sonuçlar bağlaması, zilyetlik kavramının tartışmasız bir biçimde ortaya konulmasını zorlaştırmaktadır[11]. Bu sebeple doktrinde zilyetlik kavramının izafiliğinden (*Relativität des Besitzesbegriffes)* bahsedilmektedir[12]. Kavramın zilyetliğin izafiliği onun fonksiyonun çeşitliliğine uygun kabule göre, ona yüklenen fonksiyona göre az ya da çok kapsamına göre farklılık göstermesinden kaynaklanır. Gerçekten, zilyetlik, dalgalı ve değişken bir kavramdır. Zilyetliğin izafi kavram olmasından hareket eden görüşler, ona fonksiyonuna uygun bir tanım vermektedirler[13].

---

[6] Pandekt hukukunda zilyetlik için bkz. **STARK**, BK ZGB Einl. N.38 f; **HERMANN**, Cautio damni, s.203 ff.

[7] **HINDERLING**, SPR VI/1, s. 409.

[8] Bkz. **HUBER**, s. 1 vd.

[9] **JOOST**, MünchKom BGB vor § 854 N. 2; **ERNST**, s. 3 ff; **FÜLLER**, s. 273; **HERMANN**, Cautio damni, s. 208 ff.

[10] **HECK**, Grundriss, s.22; **STARK**, BK ZGB Einl. N.53.

[11] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.52; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s.79; **NOMER/ERGÜNE**, s. 3.

[12] **PFISTER**, 160; **WINKLER**, 18; **STARK**, BK Art.919, N.1; **ERNST**, s. 25 ff; **OFTINGER/ BÄR**, ZK Art.884, N.187; **TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO**, s.739.

[13] Bu yaklaşımlar için bkz. **NIGGLI**, s. 10 ff.

631 Diğer yandan, hukuki kavram olarak zilyetlikle, ekonomik kavram olarak zilyetlik kavramları da tam olarak yakınlaşmamaktadır.

632 Zilyetliği sosyal bir toplumsal kavram olarak ele alan görüşler ise, toplumsal yaşam ilişkilerinde fiili hakimiyetten hareket etmekte, sosyal grup içinde fiili hakimiyeti sağlamaya yetecek hakimiyet ilişkisi olarak zilyetliği ifade etmektedirler[14]. Zilyetlik olgularının ekonomik olarak hangi olgulardan oluşması gerektiği konusunda uzlaşılmamıştır; bu yönüyle zilyetlik tartışmalı bir kavramdır[15].

633 TMK m.973 I zilyetlik kavramını tanımlamamış, kazanılması yoluyla açıklamaya çalışmıştır. Bu hükme göre "*bir şey üzerinde hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedi sayılır*".

634 Zilyetliğin, fonksiyonel olarak, ona zilyet olana hakta maddi bir yetki vermediği söylenemez[16].

635 Doktrinde zilyetliğe verilen anlamda uzlaşamamaktadır[17]. Yeni zamanda zilyetlik kavramının belirlenmesine yönelik tanım denemeleri de yapılmaktadır[18]. Bu kapsamda *Westermann*, zilyetliği kişinin eşya üzerindeki fiili hakimiyetine, eşya ile olan diğer hukuki ilişkiden ayrı olarak, hukuk düzenin olgu olarak tanıması ve sonuç bağlaması olarak tanımlamaktadır[19]. Bu tanım da zilyetliğin yarar alanınca etkisini göstermediği ve zilyetlik kurumunun ruhunu yansıtmadığı için eleştirilmiştir[20]. Zilyetliği kısaca fiili hakimiyet olarak tanımlayanlar da bulunmaktadır[21].

636 Zilyetlik iki anlamıyla anlaşılmalıdır[22]: *madai olgu ya da hukuki sonuç*.

---

14 Bu yaklaşımlar için bkz. **NIGGLI**, s.9 ff. **HEDINGER**, 1985 yılında "System des Besitzrechtes" isimli doktora tezine zilyetlik konusundan yeni bir tanım denemesinde bulunmuştur. Yazar, zilyetliği, süje-obje -ilişki içinde kimin fiili hakimiyetinden haklı olmadığını ortaya koyan hukuki durum olarak açıklamıştır. **HEDINGER**'in zilyetlik teorisi için bkz. **NIGGLI**, s. 15 ff. Ayni yararlanma yaklaşımı için bkz. **NIGGLI**, s. 84 ff.

15 **JOOST**, MünchKom BGB vor § 854 N. 4; **HERMANN**, Staudinger, Eckpfeiler, s.1011 ff.

16 **ERNST**, BSK Vorbem. zu ZGB Art.911, N.1. 23.

17 Zilyetliğin hukuki niteliği için bkz. **STEINAUER**, I. N.166 ff.

18 Kavramsal gelişme için bkz. **COİNG**, Europaische Privatrecht, Band 1, s. 279 ff.

19 **WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN**, SachenR. § 7. Rn.1.

20 von **HECK**, SachenR. § 6. Nr 5. Bu konuda bkz. **GUTZEIT**, Staudinger, BGB § 854, N. 39 ff.

21 **JOOST**, MünchKom BGB vor § 854 N. 6.

22 **STARK**, BK ZGB Einl. N. 22; **HINDERLING**, SPR VI/1, s. 405; **SCHMID/HÜRLİMANN-KAUP**, N.89 ff. **NOMER/ERGÜNE**, s.3. Bu konuda bkz. **JENNY**, s.26; **PFITZER, W.**, s.67.

637 Alman hukukunda *Wolff/Raiser* de zilyetlik kavramının bu iki anlamını vurgulamaktadır[23]. Zilyetlik kavramının ne olduğuna verilecek cevap da bu iki anlama bağlı olarak değişmektedir[24]:

638 Zilyetlik, **maddi olgu** olarak, kişi ile eşya arasındaki maddi ilişkiyi ifade eder. TMK m. 973 I hükmü maddi olguyu şu şekilde ifade etmektedir: "bir şey üzerinde fiili hakimiyet". İsviçre Federal Mahkemesi zilyetliği bir hukuki ilişki olarak değil de maddi hakimiyet olarak ifade etmiştir[25].

639 Zilyetlik, **hukuki sonuç** olarak, bu kavrama bağlanmış çok sayıda hukuki etki, örneğin, hukuki koruma veya sorumluluk kuralı olarak anlaşılır. Bu hukuki sonuçlar zilyet lehine hak ve yükümlülükler yanında bazı ödevler şeklinde de karşımıza çıkar.

640 Zilyetlik kavramı en geniş anlamıyla, eşya zilyetliği yanında, hak zilyetliği ve fiktif (sanal) zilyetliği de kapsar. Dar anlamıyla zilyetlikten ise, eşya zilyetliği anlaşılır. Doktrinde de genellikle zilyetliğin dar anlamıyla tanımlar yapılmıştır[26].

641 Zilyetliği, kişinin bir eşya üzerinde iradesiyle sağladığı sürekli fiili hakimiyetine ilişkin hukuki ilişkideki maddi olgu ve bu olguya bağlanan farklı hukuki sonuçlara yönelik hukuki durum olarak tanımlayabiliriz[27].

III. KONUSU

642 Zilyetliğin konusunu taşınır ve taşınmaz nitelğinde eşya (eşya zilyetliği) ile sadece TMK m.973 II'de belirtilen ayni haklardan, taşınmaz üzerindeki irtifak haklarını ve taşınmaz yüklerini (hak zilyetliğini) konu alır. Bunların dışındak: haklarda, kural olarak zilyetlik söz konusu olmaz[28].

643 Eşya zilyetliği taşınırlarda fiili hakimiyet halinde görünürken, taşınmazlarda tapu sicilindeki hak sahipliğine dayanan bir zilyetlik söz konu-

---

[23] **ENNECCERUS/ WOLFF/RAISER**, SachenR § 3 II.

[24] **HEDINGER**, s.13

[25] BGE 85 II 275; 119 II 127 E. 3.

[26] **SAYMEN/ ELBİR**, s. 26; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 140; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.83; **AYAN**, s. 68; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/OKTAY – ÖZDEMİR**, s. 57; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU**, s. 44; **NOMER/ERGÜNE**, s. 9.

[27] Benzer bir tanım için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.919, N.20.

[28] **STARK**, BK ZGB Art.919, N.63 ff; **DOMEJ**, KurzKomm ZGB Art.919, N.2.

sudur. TMK m.922 hükmüne göre, tapu siciline kayıtlı taşınmazlarda, zilyetlik davalarını açma hakkı sicilde hak sahibi görünen kişiye aittir. İşte tapu siciline dayanan zilyetliğe "*sicil zilyetliği*" ismi verilmektedir.

644 Bütünleyici parçalar, tek başlarına eşya niteliğine sahip olmadığından, sadece bütünleştikleri esas şeyle birlikte zilyetliğin konusunu oluşturabilir[28]. Örneğin arazi üzerindeki binalar araziden bağımsız zilyetlik konusu oluşturmaz.

645 Eklenti ise, esas şeyden ayrıldığında, zilyetliğe konu olur[29]. Asıl şeyin zilyedi, kural olarak bütünleyici parçanın ve teferruatın da karine olarak zilyedi sayılır (TMK m.684 ve 687'e kıyasen).

646 Doğal güçler ve enerji, örneğin nükleer enerji, elektrik vb. TMK m.762 hükmüne göre taşınır olarak kabul edildiğinden, tartışmalı olmakla birlikte, zilyetliğe konu olur[30]. Eşya birlikteliği (malvarlığı) üzerinde, belirlilik ilkesi gereği, zilyetlik oluşmaz; zilyetlik malvarlığını oluşturan her bir eşya üzerinde ayrı ayrı kurulur[31].

647 Ancak, ayni haklardan farklı olarak eşyanın bir kısmında birden çok kişi, birlikte zilyet olmaksızın, "*kısmi zilyetlik*" kurulması mümkündür[32]. Kısmi zilyetlik BGB § 865 hükmünde düzenlenmiştir. TMK m.684 hükmü burada uygulanmaz. Örneğin, bir evin bir odasında, bir binanın reklam için kiralanan bir duvarında.

648 Kamu mallarında, zilyetlik hukuku hükümleri, özellikle zilyetliğin korunmasına ve geri vermenin kapsamına ilişkin hükümler (TMK m.981 vd), özel koruma hükümleri yanında uygulanır[34].

IV. HUKUKİ NİTELİĞİ

649 Zilyetliğin niteliği üzerinde durursak, öncelikle belirtelim ki, *zilyetlik çok boyutlu* (Mehrdimensionalität[35]) soyut bir kavramdır. Kişi ile eşya

---

28 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.919, N.16; **STARK**, BK ZGB Einl. N.71 ff.

29 **ERNST**, BSK ZGB vor Art.919 ff. N.16; **STARK**, BK ZGB Einl. N.77 ff.

30 **STARK**, BK Einl ZGB, N.80 ff.

31 **ERNST**, BSK ZGB vor Art.919 ff. N.17.

32 **STARK**, BK ZGB Einl. N.71; **MEIER-HAYOZ**, Syst. Teil, N. 217-218; **HAAB**, ZGB Art.664, N.19; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.126; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s.67; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.99; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY – ÖZDEMİR**, s.60; **TEKİNAY/ AKMAN/BURCUOĞLU**, s.60; **NOMER/ERGÜNE**, s.9.

34 Aksi yönde fikir için bkz. **STARK**, BK ZGB Einl N.67, Art 919, N 40 f; BGE 133 I 268 E. 6.1.

35 **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.919, N.1.

arasındaki hakimiyet ilişkisi de izafidir. Bu sebeple, zilyetliğin hukuki niteliğinde ve hukuki olgularında uzlaşılamamıştır; bu tartışmalar uygulama yönünden önem arz etmemektedir[36].

A. Hak Görüşü

650 Zilyetlik, fiili hakimiyet olgusuna bağlanan dışarıdaki yansıması olarak hukuki sonuçlar olarak görülmesine; bu hukuki sonuçlar da iç ilişkide ona nispi hak niteliği verilmesine neden olmuştur[37]. Hakkın niteliği konusunda doktrinde farklı görüşler savunulmuştur.

651 Zilyetliğin hak mı yoksa fiili durum mu yoksa ilişki mi olduğu tartışması, eskide kalan bir tartışma olarak günümüzde, zilyetliğin olgusu olan fiili hakimiyette uzlaşılmasıyla aşılmıştır[38].

1. Ayni Hak Görüşü

652 Eski dönemde savunulmuş olsa da zilyetliğin bir ayni hak olmadığı kabul edilmektedir[39]. Y. İBK 09.10.1946 tarih ve 6/12 sayılı kararında zilyetlik, ayni bir hak olarak tanımlanmıştır[40].

653 Zilyetliği, ayni hakkın özel şekli, başka bir deyişle mutavassıt (ortalama) bir görüntüsü olduğunu savunan yazarlar da bulunmaktadır.[41]

2. Nispi Hak Görüşü

654 Zilyetliğin ayni hak olmadığını savunan yazarların bir kısmı tarafından, zilyetliğin normatif yapıya ilişkin subjektif hak niteliğinde olduğu da savunulmaktadır[42].

655 Başka bir görüş ise, zilyetliği, kişi ile eşya arasındaki hukuki ilişkiden doğan bir hak olarak nitelemektedir[43].

---

[36] Bkz. **STARK**, BK ZGB Einl. N.19 ff. **İMRE**, Ayni. s.339 vd.; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s.36 vd.; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.90 vd. Alman hukuku için Bkz. **WESTERMANN**, § 8, 4. **WOLF/RAISER**, § 3, III.

[37] **TUOR/SCHNYDER/SCHMİD/JUNGO**, § 90 Rz 13. Bu konuda bkz. **HEDINGER**, sa. 56 ff.

[38] Bkz. **HOMBERGER**, ZK vor Art.919, N.10.

[39] **İMRE**, Ayni, s. 339 vd., 340; **von TUHR**, I. s. 208.

[40] Ayrıca bkz. Y. İBK. 08.03.1959 T., 22/4 sayılı kararı.

[41] **HINDERLING**, SPR V/1, s.407; **STEINAUER**, I. N.169. Bkz. **İMRE**, Ayni, s.339; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 37; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 92.

[42] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.255; **REY**, Stystt. Teil. N.110; I. N.225; **LIVER**, Einl. zu ZGB Art. 730-792. N.15; **İMRE**, Ayni, s. 339.

[43] **SCHWAB/PRÜTTING**, N.49.

656 Hak olmadığı halde zilyetliğe hak gibi hukuki sonuç bağlandığı da ifade edilmektedir[44].

B. Hukuki Durum Görüşü

657 Doktrinde hâkim görüş, Alman hukukunda savunulan yaklaşıma uygun olarak[45], zilyetliğin bir hak olmadığını, fiili hakimiyetin hukuki durum olduğunu kabul etmektedir[46].

Gerçekten hukuk düzeni fiili hakimiyeti bir olgu olarak dikkate aldığından ve yine olgu olması hukuki bir koruma sağladığından, zilyetlik hukuki durumdur. Buna rağmen, zilyetlik düzenlemesinin nispi bir hak olarak ayni hakka dahil olup olmadığı eskiden günümüze tartışılmaktadır. *von Savigny*, yalın duruma hukuk düzenin hukuki sonuç bağlamakla durum ve hakkın aynı olduğunu ifade etmiştir[47].

658 Bize göre, zilyetlik bir hak değildir; hele ayni hak hiç değildir, iki hakkın benzeri veya arada bir yerde kendine özgü bir hak da değildir. Zilyetlikte, hakkın hukuken korunan yarar olma olgusu bulunmamaktadır. Zilyetlik, başka hukuki ilişkilerden bağımsız olarak, diğer sebeplerle farklı fonksiyonları yerine getirmek üzere, hukuk düzenince olgu olarak dikkate alınmakta veya korunmaktadır. Hukuk düzenin zilyetlikteki koruduğu yararla, haktaki korunan yarar aynı değil; yetki de aynı değildir.

659 İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında zilyetliği, kanunun fiili hakimiyete hukuki sonuç bağladığı hukuki durum olarak ifade etmiştir[48]. Bu tanım bize göre eksiktir, zilyetliğe kanunun hukuki olgu olarak kabul ettiği haller ve yine olgu olarak hakimiyet iradesinin de ilave edilmesi gerekir. Zilyetlik, belirli bir maddi olgu veya kişi ile eşya arasındaki haki-

---

[44] **STARK**, BK ZGB Art.919, N.27; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 114 ff.

[45] BGHZ 32 192 (204). Bu konuda özellikle bkz. **WIELING**, FS von Lübtow, s. 574; **SOSNITZA**, s. 65 ff.

[46] **HAAB**, Einl. Art.911 ZGB, N. 59; **SAYMEN/ ELBİR**, s. 29; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.58; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s.37; **NOMER/ERGÜNE**, s.9; **AYAN**, s.74; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 93; Alman hukuku için bkz. **PALANDT/BASSENGE**, Überbl. Vor § 854 BGB, N.1.

[47] von **SAVIGNY**, Das Recht Besitz, s.22. Bu yaklaşım BGB tasarısına (**MUGDAN** III, s.44) ve protokolüne (**MUGDAN V**, s.422) de hakimdir. Günümüzde de savunulmaktadır. Bkz. **BRODMANN**, **PLANCK** BGB §884, N. 5; **WOLF**, SachR, § 2 A; **HARTUNG**, s.31, ff. 36 ff. Bu konuda açıklamalar için özellikle bkz. **WIELING**, FS von Lübtow, s. 565.

[48] BGE 85 II 280.

miyet ilişkisine bağlanan hukuki sonuçlara ilişkin hukuki durumdur. Katıldığımız yaklaşım, zilyetlik olgusu ile zilyetlik olgusuna kanunun bağladığı hukuki sonuçları ayırt etmektedir.

660 Zilyetlik TMK m.873 vd. hükümlerinin verdiği yetki ile zilyede belirli haklar verir ve hukuki koruma sağlar. Kim ki bir eşyanın zilyedidir, kural olarak, diğer hak ve ilişkilerden bağımsız ve ayrı olarak sadece zilyettir. Örneğin, eşyayı fiili hakimiyetinde iradesi ile tutan malik, kiracı, ödünç alan, saklayan, kullanan, vekil, işgören, hırsız, bulan, mirasçı vb. sadece zilyettir. Zilyetliğin arkasında başka bir –ayni veya nispi- hukuki ilişki yer alabilir. Zilyetlik kural olarak arka plandaki bu ayni hak ve nispi haktan ayrı ve bağımsız bir hukuki durumdur.

V. UNSURLARI

661 Zilyetlik temel görünüm şekilleri ile istisnai görünüm şekillerine göre karşımıza çıkar. Bu görünüm şekillerine göre de diğer benzer kurumlardan ayrılabilir. Belirtelim ki zilyetliğin farklı görünümleri, onun relatif (izafi) bir kavram olmasından kaynaklanmaktadır.

A. Temel Görünüm Şekli: Eşya Zilyetliği

662 TMK m.973 zilyetliğin temel görünüm şeklini, bir şey üzerinde fiili hakimiyet olarak ifade etmiştir. Bu hükümde "**eşya zilyetliği**" (Sachebesitz) düzenlenmiştir. Eşya zilyetliğini yukarıda tanımlamış idik. Bu tanımdan hareketle eşya zilyetliğinin hukuki olgularını şu şekilde belirleyebiliriz[48]: Sürekli fiili hakimiyet, Hakimiyet iradesi.

1. Fiili Hakimiyet

a. Genel Olarak

663 Zilyetliğin temel olgusu, fiili hakimiyettir[49]. Bu olgu zilyetlik kavramının hukuki ve ekonomik anlamını ortaya koyar.

---

[48] **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.1098 vd; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s.23 vd; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.84 vd; **AYAN**, s.68 vd; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY – ÖZDEMİR** s.54 vd; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU**, s. 42 vd; **NOMER/ ERGÜNE**, s.5 vd.

[49] ETMK m. 887 " hakimiyet" sozcüğü yerine yanlış olarak "tasarruf" kelimesi kullanılmıştır. YİBK. T.22.11.1944, E.1944/27, K.1944/32. YİBK. T.09.10.1946, E.1946/6, K.1946/12. YGHK. T. 06.12.2013, E.2013/4-411, K.2013/1652, "*Zilyetlik, bir kimsenin bir eşyayı fiili hakimiyeti altında bulundurması, bir eşya üzerinde fiili kudret olarak tanımlanır.*". Benzer tanım için bkz. YGHK., T.30.10.2013, E.2013/8-1363, K.2013/1507.

Hukuk doktrini fiili hakimiyeti temel kavram olarak ele almakla birlikte, hukuki olarak farklı değerlendirmelere tab: tutmaktadır[51]. Örneğin *Heck*, belirsiz ve karanlık olan bu kavramı, hakimin, zilyedin korunan zilyetlik yararından hareketle belirlemesi gerektiğini savunmaktadır[52].

664 Eşya zilyetliğinde fiili hakimiyet, kişinin eşya ile olan fizikı bağını ve ilişkisini ortaya koyar. Roma hukukunda "*corpus*" olarak ifade edilen bu olguya *objektif veya maddi unsur* da denmektedir. Örneğin, kişinin giydiği elbise, kişinin evindeki mobilyalar, evin otoparkına veya deposuna konulmuş bisiklet vb.

665 Fiili hakimiyetten ne anlaşılması gerektiği üzerinde durulması gereken bir konudur. Fiili hakimiyet bir yönüyle dar, bir yönüyle de geniş bir kavramdır. Zira hizmet zilyedi fiili hakimiyet olgusunu sağladığı halde, zilyet olarak kabul edilmemektedir.

666 Fiili hakimiyetin söz konusu olup olmadığı, fiili hakimiyet kavramının boş kavram olarak[53], *toplumsal ve ticari yaşam ilişkilerinin* bakış acısıyla değerlendirilerek doldurulmasıyla belirlenir[54].

667 Zilyetlik, TMK m. 974'e göre asli veya fer'î zilyetlik; m.975'e göre dolaylı veya dolaysız zilyetlik ve m. 977-978'e göre hazırlar arasında veya hazır olmayanlar arasında (temsilci) gerçekleşir.

b. Fiili (Maddi) Etki

668 Eşya üzerindeki hakimiyet *fiili (maddi) etkili (physische Einwirkung) olmalıdır*[55]. Kişinin eşya üzerindeki fiili hakimiyetinin mutlaka şeyin kendisi üzerinde olmasına gerek yoktur; şey üzerinde hakimiyeti sağlayacak araçlarla da gerçekleşebilir (TMK m.977 I)[56]. Örneğin, evin veya arabanın anahtarlarının verilmesi.

c. Mekansal Fiili (Maddi) İlişki

669 Eşya üzerindeki hakimiyet, eşya ile hakimiyeti sağlayacak kişi arasında belirli bir yoğunlukta *fiili mekansal ilişkiyi* (räumliches Verhältnis)

---

51 Bu konuda bkz. **HARTUNG**, s.142 ff.

52 **HECK**, SachenR § 5. Nr.5-6.

53 Tehlikeli boş kavram olarak fiili hakimiyet için bkz. **KEGEL**, 151. **ERNST**, s.42. **HARTUNG**, s.128. **FÜLLER**, s. 278.

54 **STARK**, BK ZGB Art.919. N.11.

55 **HARTUNG**, s.135 ff.

56 YİBK., T. 09.10.1946, E.1946/6, K.1946/12.

gerekli kılar. Kişinin eşya ile olan mekansal ilişkisi hakimiyeti ortaya koyup koymadığı, genel yaşama ve ticari ilişkilere göre, objektif olarak değerlendirilmelidir[57].

670 Kişinin eşya ile olan mekansal ilişkisi *fiili maddi yakınlıkla* ortaya konulur[58]. Maddi yakınlığın ortaya çıkış şekli eşyanın niteliği veya özelliğine göre farklılık gösterir. Örneğin taşınırlarda farklı, taşınmazda farklı; taşınırlar içinde de cins (çeşit) eşyada farklı, parça eşyada farklı tezahür eder.

671 Maddi ilişkinin mekansal olarak dar olarak gerçeklemesi yeterlidir. Örneğin işletmenin işyerinde bırakılan tepside zilyetlik söz konusuyken taşınmaza konan yabani ördekler üzerinde zilyetlik söz konusu değildir[59]. Fiili ilişkinin bir yetkiye veya rızaya dayanması önemli değildir.

d. Maddi (Fiili) Mekansal İlişkinin Sürekliliği

672 Fiili hakimiyet, eşya üzerinde *belirli süre* devam eden ***sürekli hakimiyet***tir[60]. Fiili (maddi) hakimiyetin belirli bir sürekliliğe sahip olması gerekir. Kanun TMK m.976'nın karşıt kavramı olarak fiili hakimiyetin sürekli olması gerektiğini belirtmiştir.

673 TMK, fiili hakimiyetin sürekliliği konusunda belirli bir süre öngörmemiştir. Doktrinde de her somut olay için fiili hakimiyetteki süreklilliğin her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir[61].

674 Örneğin, kamusal parka parkı gezen birinin yerleşmesi; misafirin çatal bıçağı kullanması geçici olduğundan, bu kişilerin zilyetliği korunmaz[62]. Aynı şekilde, bir aracın kısa süreli olarak park etmesi halinde de zilyetlik korunmaz. Buna karşın, işletmecinin müşterisinin unuttuğu cüzdanı bir rafa koyarak güven altına almasında işletmecinin zilyetliği söz konusudur[63]. Aynı şekilde inşaat ustası inşaatta bulunan inşaat mal-

---

57 **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.97; **STEINAUER**, I, N.173; **ENNECCERUS/ WOLFF/ RAISER**, SachenR § 5 III vor 1. Alman uygulaması için bkz. BGH NJW 2015, 1678 (1679); GBHZ 101 186 (188); BGH MDR 2010, 276.

58 **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.86.

59 LG Augsburg NJW 1985, 499.

60 **MÜLLER-ERZBACH**, AcP 115 (1952), 5 (16 ff); **GIERKE**, ZHR 115 (1952), 223 (229ff).

61 **BAUR/STÜRNER**, SachenR § 7, Rn.7; **ENNECERUS/ WOLLF/ RAISER**, SachenR § 5 III 1.

62 **JOOST**, MünchK BGB § 834, N. 11.

63 BHGZ 101, 186 (188 ff)

zemelerinin zilyedidir[64]. Zorunluluk halinde eşyanın kullanılması da geçicidir.

675 TMK m.976'ya göre, fiili hakimiyetinin geçici sebeplerle ortadan kalkması, örneğin kullanılamaması veya kullanım olanağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmez[65]. Maddi (fiili) mekansal ilişkinin geçiciliğini ve sürekliliğini, zilyetliğin sona ermesinde ayrıca inceleyeceğiz[66].

e. Fiili Hakimiyetin Görünürlüğü

676 Fiili hakimiyet ilişkisinin, görünür olması (Erkenbarkeit) gerektiği doktrinde tartışılmaktadır.

677 Fiili hakimiyet ilişkisinin görünür olması gerektiğini arayan, Alman Hukukundaki hakim görüş ve uygulama[67], tüm kişiler tarafından dikkat edildiğinde hakimiyet ilişkisinin fark edilebilir olmasını aramaktadır. Örneğin, fuar alanını kiralayan kiracı, kiraladığı alanın tümünün kontrolünü elinde tutuyor ve kapı girişleri varsa fiili hakimiyetin görünür olduğu kabul edilir. Fiili hakimiyetin görünür olmasının, ispat yükünün yer değiştirmesinde etkisi söz konusudur[68].

678 Kural olarak, fiili hakimiyet ilişkisinin herkes tarafından anlaşılabilir olması, zilyetlik iradesiyle karıştırılmaması için objektif olarak değerlendirilmelidir.

679 Alman hukukunda hakim görüş ise bu yaklaşımı kabul etmemektedir[69]. Görüşümüze göre, fiili hakimiyetin üçüncü kişiler tarafından görü-

---

[64] OLG Koln MDR 2000, 152.

[65] *"...Türk Medeni Yasasının 976. maddesi hükmü gereği, fiili hakimiyetin geçici sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalkması zilyetliği sona erdirmeyeceği kuşkusuzdur..." (Y. 1. HD. 27.5.2010 T., 5248 E., 5995 K.). "...iradi terkin varlığından bahsedilmesi için taşınmazın belli bir neden yokken uzun yıllar kullanılmaması ve zilyedin taşınmaz üzerinde egemenliğini dile getirecek herhangi bir ilgiyi göstermemiş olması, artık o tarlayı terk ettiği yolunda herkeste bir kanının uyanmış olması gerekir. Zira zilyedin taşınmaz mala ilgi göstermemesi uzun süre taşınmaz üzerindeki başkalarının zilyetliğine itiraz etmemesi, zilyedin zilyetliği terk iradesinin varlığına kannedir. Ancak bu şekilde zilyedin taşınmazı terk ettiği yolunda herkeste bir kanının uyarması durumunda zilyetliğin yitirilmesi söz konusu olur..."* (Y. 8. HD., 10.10.1997 T., 1996/10476 E., 1997/6024 K.).

[66] **ANTALYA**, EH II, N. 682 vd.

[67] BGHZ 44, 27 (32); BGH WM 2003, 1674 (1675). **BASUR/STJRNER**, SachenR § 7 Rn.16; **JOOST**, MünchK BGB § 854, Rd.13.

[68] **BAMBERGER/ ROTH/ FRITZSCHE**, Rn 29. Karşı görüş **WOLF**, SachenR, § 2 A II c 4. Bu konuda bkz. **HARTUNG**, s.130.

[69] BGH JZ 1-976, 65.

nür olması gerekir. İradi zilyetlik hakimiyeti objektif olarak gerçekleşmeli, bunun için mutlaka herkes için anlaşılır ve görünür olması gereklidir.

2. Hâkimiyet İradesi

680 Zilyedin fiili hakimiyetini bulundurduğu şeyde hakimiyeti kurmak isteyip istemediği yani zilyetlik (hakimiyet) iradesinin (Besitzwille-Herrschaftswillen) (*animus rem sibi habendi, animus possidendi, animus domini*) veya sadece fiili hakimiyetin bulunmasının yeterli olması gerektiği hususu günümüzde hala tartışılmaktadır[70].

681 İlk tartışma yukarıda değindiğimiz üzere, bir ius mu, yoksa durum mu söz konusu olduğu idi. Diğer ikinci temel tartışma ise hâkimiyet iradesine ilişkindir.

682 Hâkimiyet iradesi temelindeki tartışmalar sübjektif görüşteki tartışmalardan kaynaklanmaktadır. Subjektif teori yanlıları, *Savigny*'den bu yana zilyetlik iradesini ön plana çıkarmaktadır.

683 Subjektif teoriyi savunan yazarlar da zilyetliği farklı açıklamışlardır[71]: zilyetliğin korunmasına ilişkin zilyedin kişisel hakkı veya onun başka bir görünümü, süreklilik görüşü, huzur teorisi.

684 Bu görüşlerden huzur teorisini savunan *von Rudorff*, özellikle hakimiyet ilişkisinin zilyetliğin korunmasının temelini oluşturduğunu ifade etmektedir[72].

685 Zilyetlik iradesini ayrı bir olgu olarak değerlendirmeyip, zaten fiili hakimiyetin bünyesinde var olduğunu, bu sebeple aranmasının gerekli olmadığını savunanlar söz konusudur[73]. Hatta zilyetlik iradesini hiç kabul etmeyen yazarlar da söz konusudur[74]. Örneğin, zilyetlik iradesini kabul etmeyen bir görüş, zilyetlik iradesinin zilyetliğin korunmasını daraltacağını belirtmekte, objektif olarak zilyedin koruması yararının zilyetlik kurumun etkisinin yeterli olduğunu savunmaktadır[75].

---

[70] **HUBER**, Erl II s.373; **OSTERTAG**, BK. ZGB Art.919, N.13; **EGGER**, ZK. ZGB Art.919, N.7; **STARK**, BK ZGB Einl. N. 24. ff. Ayrıca bkz. **NIGGLI**, s. 1 vd.

[71] Bkz. **HEDINGER**, s. 56 ff.

[72] **RODORF**, Über den Rechtsgrund der prossessorischen Interdicte, Zeitschrift für geschichliche Rechtwissenschaft, Bd.7. (19830), s.111 ff.

[73] Karş. **STARK**, BK ZGB Einl. N. 25; **STEINAEUR**, I. N.187 a. Bkz. **STARK**, BK ZGB Art.919, N.27; **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.919, N.1.

[74] **AYBAY/ HATEMİ**, § 4, N.3.

[75] **HECK**, SachenR. § 10, Nr.4. Bu konuda bkz. **RAAPE**, s. 51 ff.

686 Eşya üzerinde kişinin fiili hakimiyeti yanında, başlangıçta tartışmalı olmasına karşın[76], zilyedin eşya üzerinde hakimiyet iradesinin de bulunması gerekir[77]. Zira eşya üzerindeki hakimiyetin kullanılması ancak eşya üzerindeki hakimiyet iradesi ile mümkündür.

687 TMK zilyetlik kavramıyla ilgili olarak hakimiyet iradesinden açıkça bahsetmemiştir. Buna karşın TMK zilyetlik iradesine, bir hukuki olgu olarak doğrudan veya dolaylı olarak farklı sonuçlar bağlamıştır[78]. TMK m.767'de malik olma iradesiyle zilyetliği kazanandan bahsetmekte, yine TMK m.777'de malik sıfatıyla zilyetliği bulundurandan bahsetmektedir.

688 Hak zilyetliğinde aşağıda görüleceği üzere, zilyetlik iradesi olumsuz irtifaklarda zilyetliğin var olduğunu gösteren olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

689 TMK m.975'nin dolaylı ve dolaysız zilyetlikten ve TMK m.977'nin önceki zilyedin "*rızası*"ndan bahsetmesi, zilyetlik iradesinin zilyetlik olgusu olarak değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Zilyetliğin manevi veya subjektif unsurunu oluşturan bu hakimiyet iradesi Roma hukukunda "*animus*" olarak ifade edilmiştir.

690 Zilyetlik iradesi (*animus possessionis*) olarak da ifade edilen hakimiyet iradesi, mülk edinme iradesinden (*animus domini*) veya diğer hakları kazanmaya ilişkin iradelerden farklıdır.

691 Zilyedin, hakimiyet iradesinin genel, yalın somut bir irade olması yeterlidir[79]. Bu sebeple *zilyetliği kurucu iradeden* bahsedilmektedir (Besitzstbegründungswillen)[80].

692 Zilyetliği kuran irade hukuki işlem iradesi olmayıp, zilyetlik ilişkisinin varlığını ortaya koyan eşya üzerindeki hakimiyeti göstermeye yetecek *doğal irade* olması yeterlidir.

---

[76] Zilyetlik iradesinin zilyetlikteki rolü konusunda pratik sonuçları olmayan, objektif görüş ve subjektif görüş olarak doktrindeki tartışmalar konusunda bkz. **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s.33 vd.; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.87-88.

[77] Alman hukuku için bkz. **ENNECERUS/ WOLFF/ RAISER**, SachenR § 10 II; **HERMANN**, FS Eckert, 2008, s.323 (333); WITT, AcP 201 (2001), 165 (177). Karşı görüş **HARTUNG**, s.171 ff. Yargı uygulaması BGHZ 27, 360 (362); 101, 186 (187); BGH MDR 2012, 276; RGZ 106, 135 (136).

[78] **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N.15 ff.

[79] **STARK**, BK ZGB 919, N. 26.

[80] **HEDINGER**, s.52.

693 Zilyetlik iradesinin objektif olarak fiili hakimiyetle de tezahür ettiğini, bu sebeple zilyedin efektif bir iradesinin değil, zilyetliğin niteliğindeki hakimiyetin *causa* bulunmasını yeterli olarak kabul etmemiz gerekir. Zilyedin *eşya ile olan fiili (maddi) hakimiyet temasının bilinçli* irade sonucu olduğunun anlaşılması gerekir. Zira fiili hakimiyet ve zilyetlik iradesi hem birbirinden ayrı hem de birbirini tamamlayan iki olgudur.

3. Niteliği

a. Doğal İrade

694 Hemen belirtelim ki, burada aranan olgu, *tabii (doğal) hakimiyet iradesidir* (Natürlicher Wille). Aşağıda zilyetliğin kazanılmasında üzerinde duracağımız üzere, zilyetlik iradesi, bir hukuki işlem iradesi değil, *maddi bir fiile ilişkin tabii (doğal) iradedir*[21].

695 Aslen zilyetliğin ve teslimle devren kazanılmasında zilyedin ayırt etme gücünün bulunmasına gerek yoktur[22]. Sınırlı ehliyetliler de yasal temsilcilerinin rızası olmadan bu iradelerini ortaya koyabilirler. Hukuki işlem ehliyeti (Geschäftsfähigkeit) zilyetliğin kazanımı için sadece zilyetlik sözleşmesinde gereklidir: zilyetlik sözleşmelerinde hem zilyetliği alanın hem de zilyetliği devredenin hukuki işlem ehliyeti olmalıdır. Zilyetlik anlaşması için ayırt etme gücünün olması yeterlidir[23].

b. Genel İrade

696 İşlem ehliyeti için aranan hukuki sonuç iradesinin düşük ölçüde, *genel irade* (allgemeiner Wille) olması yeterli görülmelidir[24]. Klasik örnek olarak, mektubun mektup kutusuna atılması verilebilir[25].

697 Zilyetlik iradesi, zilyedin zilyetliğini kazandığını tek başına ortaya koyması için yeterli değildir. Genel hakimiyet iradesinin, hakimiyet ilişkisinden anlaşılmalıdır ki hukuken korunabilsin veya sonuç bağlanabilsin.

---

21 Maddi fiili ve bunun hukuki işlemden farkı için Bkz. **ANTALYA**, BH GH I. s. 84.

22 **STARK**, BK ZGB Art.919. N. 90.

23 **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.116; **GÜRSOY/ EREN/ CANSEL**, s.78; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s.54, dn.11; **NOMER/ ERGÜNE**, s.6; **AYAN**, s.72. Alman hukuku için karş. **JOOST**, MünchK BGB § 859. N.4.

24 **HINDERLING**, SPR. V/1. S.426 f.

25 **ERNST**, BSK ZGB Art.919. N.20.

698 Hakimiyet iradesinin varlığı konusunda, fiili hakimiyet, bu iradenin farazı olarak olduğunu gösterir[86]; hatta bu hakimiyet iradesinin var olduğuna karine teşkil eder[87].

699 Zilyetliğin kazanıldığı an var olduğunun kabulü yanında, fiili hakimiyetin devam ettiği sürece mevcut olduğunu, eşyayı elden çıkardığı veya kaybettiği anda zilyetlik iradesine son vermek istediği, bu sebeple de zilyetliğin sona erdiğini kabul eden yazarlar[88] var ise de hakimiyet iradesinin kurulma anında var olması zilyetlik için yeterlidir. Hakimiyet iradesinin zilyetlik süresince aranmasına gerek yoktur.

c. Özel Durumlar

700 TMK m.978 hükmü, temsilcinin -yasal temsilci dahil- ehliyetsiz bir kişi adına şeyde kurduğu fiili hakimiyet, temsil edenin doğrudan zilyetliği kazanmasını sağlayacağını düzenlemiştir.

701 Eşya üzerinde fiili hakimiyeti ve hakimiyet iradesini gerçekleştirecek kişi, gerçek kişi de olabilir; tüzel kişi de olabilir. Tüzel kişi organları aracılığıyla hakimiyet iradesini ortaya koyar[89].

702 Mirasçıların terekedeki zilyetliği de TMK m.599 hükmü gereğince zilyetlik iradesi olmaksızın kanun gereği kendiliğinden (*ipso iure*) gerçekleşir.

B. İstisnai Görünüm Şekilleri

1. Hak Zilyetliği

a. Kavram

703 TMK m.973 II[90], taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanımını zilyetlik olarak kabul etmiştir. Hakkın fiilen kullanımının zilyetlik sayıldığı durumlarda, eşya üzerinde fiili hakimiyet olmamasına karşın, bazı ayni hakların kullanımı zilyetlik ola-

---

[86] Farazi irade ölçütü için bkz. **TEKİNAY/AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 45.

[87] **NOMER/ ERGÜNE**, s.6; **AYAN**, s. 72.

[88] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 55; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 6; **ERTAŞ**, N.128.

[89] **STARK**, BK ZGB Art.919, N. 47; BGE 81 II 339 ff. 343; 137 IV 134 ff. 144.

[90] Karş. BGB § 1029, 1090; CCfr Art.2228.

rak kabul edilmiştir. Bu zilyetlik çeşidi, **hak zilyetliği** (Rechtbesitz) olarak adlandırılmaktadır[91].

704 Türk-İsviçre hukuku, Alman hukukuna benzer şekilde hak zilyetliği kavramını kullanmamaktaysa da bu konuyu kural olarak düzenlemiştir.

b. Hukuki Olguları

aa. Taşınmaz Üzerine İrtifak Hakkı veya Taşınmaz Yükünden Doğan Bir Hak Olmalı

705 Hak zilyetliği için hakkın tapuya tescil edilmiş olup olması gerekliliği tartışmalıdır: Kural olarak taşınmazdaki bir ayni hakkın tescili gerekli ise de zilyetlik bir ayni hak olmadığından ondan bağımsız olarak kurulmuş ancak tescil edilmemiş irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde de uygulanır[92].

706 İrtifaktan veya taşınmaz yükünden yararlanan aynı zamanda taşınmazı kullanıyorsa, örneğin intifa hakkı, oturma hakkı, kaynak hakkı vb. taşınmazda eşya zilyetliği olarak gerçekleştiğinden, hak zilyetliği hükmüne başvurmaya gerek bulunmamaktadır.

707 Hak zilyetliği *olumsuz irtifak haklarında*, örneğin manzara kapatmama irtifakında uygulama alanı bulur[93]. Olumsuz irtifak haklarında, hak sahibi, yüklü taşınmaz malikinin hakkın konusuna uygun davranmasını ve taşınmaz yükünde ise yükün konusu olan edimlerin yerine getirilmesini zilyetlik hükümlerine dayanarak talep edebilir.

708 Hak zilyetliği sadece düzenlendiği taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde uygulama alanı bulur. TMK m.973 II'de sayılanlara ilave olarak diğer sınırlı ayni haklara kıyasen uygulanması söz konusu değildir[94]. Hak zilyetliği için taşınmaz üzerindeki irtifak hakkının yahut taşınmaz yükünün diğer taşınmaz lehine olması gerekli

---

91 Taşınmaz yükünde hak zilyetliğini gerekli görmeyen görüş için bkz. **ERTAŞ**, N. 158; **PIOTET**, SPR V/1, s 649 ff.

92 **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.121 a. Aksi yönde görüş için bkz. **STARK**, BK ZGB Art 919, N.82; **HOMBERGER**, ZK ZGB ART.919 N.22; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 17. Tescil şartı arayan karar için bkz. BGE 83 II 141 f. Aksi görüş bkz. BGE 94 II 348.

93 BGE 95 II 605 ff. 617; SJZ 1921, 105; **STEINAUER**, I. N.196; **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N.48.

94 **STARK**, BK ZGB Art 919, N.75. Kişisel irtifaklarla ilgili olarak konuyu tartışan BGer kararı için bkz. BGE 94 II 349 E.1.

değildir; kişi lehine tesis edildiğinde de TMK m.973 II kıyasen uygulanır[55].

709 Fırma adı gibi ticari haklar ile fikri ve sınai haklarda zilyetlik–fiili hakimiyet- söz konusu olmayacağından, zilyetlik hükümleri ile korunmalarının söz konusu olmadığı genellikle kabul edilmektedir[56].

710 Görüşümüze göre, fikri ve sınai haklarda, eşya zilyetliği değil, hak zilyetliği söz konusu ise de hak zilyetliği TMK m.973 II'de düzenlenerek; hak zilyetliğinde zilyetliğin korunması söz konusu olabildiğinden, burada açık bir kanun boşluğu olduğunu kabul ederek, kıyasen boşluğun TBK m.973 II hükmüne benzer şekilde doldurulması gerekir.

711 Fırma adı ise, hak olarak, kişilik hakları kapsamında olduğundan, hak zilyetliği kapsamında değerlendirilemez.

bb. Hak Fiilen Kullanılmalı

712 TMK m. 973 II'de sayılan *aynî hakların fiilen kullanılması*, fiili hakimiyetle aynı sayılmıştır.

713 Olumsuz irtifak hak sahibinin hakkını *belirli bir zaman içinde ve/veya belirli sayıda kullanmaması*, BGB § 1029 aksine, TMK'da böyle bir hüküm olmadığından, hak zilyetliğine dayanılması imkanını ortadan kaldırmaz[57]. BGB § 1029 hükmü, haktaki ihlalin bir yıl içinde en az bir kere olması halinde hak zilyetliğini korumuştur.

714 Hak zilyetliği, hakkın fiilen kullanılması ile başlar[58].

715 İrtifak hakkının veya taşınmaz yükünün yükümlüsüne karşı, hakkın fiilen kullanılması yeterlidir[59]. Hakkın kullanılıp kullanılmadığını hakim, aynı hakkın tipiklik kapsamından hareketle, somut olayın özelliklerine göre yaşam ve ticaret ilişkilerini de dikkate alarak belirleyecektir.

---

[55] **STARK;** BK ZGB Art.919. 75, 80, 114; **REY, SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP,** N.119; **ERNST,** BSK ZGB Art.919, N.49; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR,** s.57; **NOMER/ ERGÜNE** s.17. Aksi görüş bkz. **OZSTERTAG,** BK ZGB Art.919, N.25; **HOMBERGER,** ZK ZGB Arrtt.919, N.20; **LEEMANN,** BK ZGB Art.781, N.27.

[56] **STARK,** BK ZGB Art.919, N.49, 71. Aksi görüş için bkz. **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR,** s.60, 783; **AKİPEK/ AKINTÜRK,** s. 127. Bu konuda bkz. **TROLLER,** 76 ff.

[57] **ERNST,** BSK ZGB Art.919, N.52.

[58] **STARK,** BK ZGB Art.919, N.82 Aksi görüş bkz. **HOMBERGER,** ZGB 919, N.23, 34.

[59] **STARK,** BK ZGB Art.919, N.84 f; **LIVER,** ZK ZGB Art.731, N. 134 f; **HOMBERGER,** ZGB Art.921, N.11.

2. Hukuki Sonucu

716 Hak zilyetliği eşya zilyetliği gibi zilyetlik hükümlerine tabi tutularak, hakkın ihlali halinde, zilyetlik hükümleri ile korunmuştur. Ancak hak zilyetliğinin niteliği gereği, bazı hukuki koruma hükümleri uygulanmaz. Örneğin, TMK m.977 vd. düzenlenen zilyetliğin devri hükümleri, iyiniyetli zilyede ilişkin TMK m.993 hükümleri[CC].

3. Fiktif (Sanal) Zilyetlik

717 Fiktif (sanal) zilyetlikt (fiktiv Besitz) halinde, kişinin eşya üzerinde fiili hakimiyeti veya hakimiyet iradesi olmamasına karşın, Kanun bazı olguların gerçekleşmesi halinde o kişileri sanal olarak zilyet olarak kabul etmiştir. Kanun bu durumu iki şekilde düzenlemiştir:

a. Mirasçıların Zilyetliği

718 TMK m.599 II'e göre[C1], mirasbırakanın ölümüyle birlikte, mirasçılar, kendilerine intikal eden tereke değerleri üzerindeki, yani "*taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan kazanır*"[C2]. Kanun koyucu, mirasçıları tereke değerlerinde, dolaysız zilyetlik süjesi olarak belirlemiştir.

719 Bir hak, zilyetlik olgusuna bağlanmışsa, mirasçıların, tereke değerlerinde zilyetliğin hukuki olguları olan fiili hakimiyet ve hakimiyet iradesi olmaksızın, zilyet oldukları kabul edilmiştir[C3]. Bu durumda sanal bir zilyetlik söz konusudur. Bu kazanım yasal mirasçılar için geçerli olduğu kadar, ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması halinde de geçerlidir[C4]. Terekenin zilyetliğinin kanun gereği kazanılması *yasal bir fiksiyondur* (varsayımdır)[C5].

720 Miras ortaklığına dahil olan mirasçılar terekeye doğrudan zilyettir. Miras ortaklığında birden fazla mirasçı söz konusu ise mirasçılar birlikte elbirliğiyle doğrudan zilyettir[C6]. Ölüme bağlı tasarrufla art mirasçılık şeklinde kademeli zilyetlik de kurulabilir.

[CC] **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N.47. **DOMEJ**, KurzKomm ZGB Art.919, N.21.

[C1] Benzer düzenleme için bkz. BGB § 857, CCfr Art.724.

[C2] **ANTALYA/ SAĞLAM**, MH, s. 54. **AKBIYIK**, s. 13.

[C3] **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N. 55 ff.. **AKBIYIK**, s. 13.

[C4] **STARK**, BK ZGB Art.919, N.130. **HOMBERGER**, ZGB art.919ö, N.38.

[C5] **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.919, N.3.

[C6] **STARK**, BK ZGB Art.919, N.74 ff.; **AKBIYIK**, s. 163.

721 Terekeye tereke temsilcisi, tereke resmi tasfiyecisi atanması halinde mirasçıların hukuki durumu değişmez. Bu kişiler terekede dolaylı veya dolaysız zilyet olabilirler[107].

722 Mirasçılar, bu kişilere karşı asli ve duruma göre dolaysız veya dolaylı zilyettir. Vasiyeti tenfiz memurları içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Doğrudan terekeye zilyet olan mirasçılar, özellikle zilyetliğin korunmasından yararlanırlar.

b. Bulunmuş Eşyanın Teslim Edildiği Kişilerin Zilyetliği

723 Oturulan ev veya işyerinde ya da kamu hizmeti görülmekte olan yerde bir şeyi teslim alan kişilerin (o yerin sahibi veya kiracısı ya da kamu hizmetinde denetimle görevli olan kişiler) zilyetliği, hakimiyet iradesi olmasa da söz konusudur[108].

C. Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi

724 Zilyetlik, hukuki bir kavram olarak, benzer kavramlardan ayırt edilmelidir:

1. Mülkiyetten

725 Zilyetlik kavramı, hiçbir zaman ayni hak kavramı ile aynı kavramı ifade etmez[109]. Mülkiyet, bir şey üzerindeki hukuki hakimiyet; zilyetlik ise bir şey üzerindeki fiili hakimiyettir[110].

726 Buna karşın "mülkiyet"le "zilyetlik" kavramları günlük yaşamda, en çok da taşınırlarda genellikle birbiri yerine kullanılmaktadır. Zilyetlikle mülkiyet arasında yoğun bir ilişki bulunmaktadır. Özellikle, taşınırlarda, zilyetlik, mülkiyeti alenileştiren ve onu kamuya açıklayan araçtır. Ancak zilyetlik her zaman gerçek durumu yansıtmayabilir.

727 Mülkiyet hakkı zilyetlik olgusu için zorunlu değildir. Mülkiyet hakkı sahibi olmayan kişi de, başkasının malık olduğu eşyaya zilyet olabilir. Örneğin hırsız; malık olmadan da bir eşyaya zilyet olabilir, bir başka örnek ise kiracıdır.

---

[107] EITEL/ARNET, CHK ZGB Art.919, N.6.

[108] SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N.103.

[109] TUOR/SCHNYDER/SCHMİD/JUNGO, § 90 Rz 4.

[110] ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 81.

2. Hayvan Bulunduran ve İşletenden

728 Zilyet, TBK m.67 anlamında "hayvan bulunduran[111]" ve TKT m. 3'te tanımlanan "işleten[112]" kavramından farklıdır. Her ne kadar bu sorumluluk süjeleri genellikle aynı zamanda zilyet ise de zilyet olmaları zorunlu değildir.

729 Zilyetlikte eşya hukukundaki fiili hakimiyet iradesi söz konusu iken, hayvan bulunduran ve işleten kavramında sorumluluk olgusu olarak, sorumluluk ilişkisi kapsamında belirlenir[113]. Örneğin, motorlu araç yarışları düzenleyenlerin sorumluluğu.

3. Hizmet Zilyedinden

a. Genel Olarak

730 Zilyetlik kural olarak fiili hakimiyet kuran kişi tarafından kazanılır. Ancak yaşam ilişkilerinde, bir *kişinin talimatına bağımlılık ilişkisi* içinde, zilyet olmak isteyenin adına fiili hakimiyeti kurduğu ve ona bağımlı olarak zilyetlik iradesini ortaya koyduğu görülmektedir.

731 Zilyetlikten doğan hukuki ilişkinin, talimat veren yetkili kişi ile talimatı yerine getirme yükümlüsü -onun talimatına bağımlı olan- kişi yönünden farklı hükümlere tabi tutulması gerekliliği düşüncesi, hizmet zilyedi kurumu gereklığını ortaya koyar.

732 Fiili hakimiyeti, başkasının talimatını yerine getirme yükümlüsü gerçekleştirmekteyse bu kişi *hizmet zilyedidir* (Besitzdiener); hizmet zilyedinin hizmette bulunduğu ve onun talimatına bağlı olduğu kişi ise, zilyet *sahibidir* (Besitzherr). Hizmet zilyetliği yerine, "zilyet yardımcısı" terimi de kullanılmaktadır.

733 Hizmet zilyetliği kavramı, BGB § 855 ve 860'ın aksine, TMK'da düzenlenmemiştir. BGB § 855 hizmet zilyetliğini olumsuz olarak tanımlamıştır. Türk ve İsviçre hukuku bakımından hizmet zilyetliğinde bir kanun boşluğunun bulunduğunu kabul etmemiz gerekir[114]. Bu açık boşluğun hakim tarafından hukuk yaratma yöntemiyle doldurulması gerekir (TMK m.1 II).

---

[111] **STARK**, BK ZGB Art.919, N.52; BGE 132 IV 108 ff, 110. Hayvan bulunduran kavramı için bkz. **ANTALYA**, BH GH, II, s. 301.

[112] İşleten kavramı için bkz. **ANTALYA**, BH GH, II, s. 373.

[113] **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.138; **GÜRSOY/ EREN/ CANSEL**, s. 80; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 80-82.

[114] Aynı yaklaşım **STARK**, BK ZGB Art.919, N.34, 84 ff.

b. Zilyet Sahibine Yardım İlişkisinde Talimata Bağlılık

734 Hizmet zilyeci ile zilyetlik sahibi arasında, *yardım ilişkisi* ve bu yardım ilişkisi içinde -*zilyet sahibinin talimatına bağlılık*- bulunması gerekir. Zilyet sahibinin talimatına hizmet zilyedının bağlılığı ilişkisi, uygulamada karşımıza farklı yoğunlukta ve özellikte çıkabilir.

735 Hizmet zilyedinin eşya üzerindeki hakimiyeti, genellikle nispi bir hukuki ilişkiden (sözleşmeden) kaynaklanır. Örneğin, hizmet sözleşmesi, iş akdi, vekaletsiz işgörme, vekalet sözleşmesi gibi. Hukuki ilişki özel veya kamu hukuku ilişkisi olabilir. Özel hukuk ilişkisinin borçlar hukuku ilişkisi olması da gerekli değildir; aile hukuku, velayet veya vesayet hukuku ilişkisi de olabilir.

736 Hizmet ilişkisinden örneklersek, işletmenin aracını kullanan şoför, sekreter, büro elemanları, apartman yöneticisi, yurt veya lojman yöneticisi, hastane personeli, doktor, hemşire, sağlık elemanı vb., eş ve aile konutunda birlikte yaşayan çocuklar.

737 Bu özelliği onun zilyet olarak nitelendirilmemesini ve zilyet olarak korunmamasını gerektirir. Zilyet yardımcısı, örneğin zilyedin temsil yetkisine sahip vekili veya vekaletsiz işgören olarak zilyet sıfatına sahip olabilir.

738 Hizmet zilyetliği, mecazi olarak, zilyedin uzayan kolları[655] olarak, zilyetlik araçları kapsamında zilyetlik yardımı (Besitzhilfe) şeklinde değerlendirilmelidir[656]. Talimata bağlılık ilişkinin, mutlaka *zilyetliğe yardım ilişkisi olması* zorunlu değildir.

739 Alman hukukunda (BGB § 855) hizmet zilyetliğine iki temel örnek verilmektedir: Evde ve işyerinde hakimiyetin kullanılması. Bu iki örnekten hareketle, Alman doktrininde hâkim fikrin kabul ettiği üzere, sosyal *bağımlılık ilişkisinin* bulunması yeterlidir[657].

740 Hizmet zilyeci, zilyetle olan bağımlılık ilişkisi içinde, eşya üzerindeki fiili hakimiyeti başkaları adına, onun emir ve talimatı doğrultusunda ve ona bağlı olarak eşyayı elinde bulunduran ve onu kullanan kişidir.

---

[655] **STARK**, BK ZGB Art.919, N 43.

[656] **OSTERTAH**, ZGB Art.919, N.19; **HOMBERGER**, ZGB Art.919, N: 11; **WIEGAND**, ZGB Art.919, N.2; **STARK**, EK ZGB Art.919, N.34; **ERNST**, BSK ZGB Art.9189, N.22.

[657] **WESTERMANN/ GURSKY/ EICKMANN**, SachenR § 9 Rn 4; JOOST, MünchK BGB § 855, N.4 **HARTUNG**, s.211 ff. Alman yargı uygulaması için bkz. BGH BeckRS 2014, 02220; BGHZ 16, 259; BGH DB 1956 963.

741 Hizmet zilyedine şu örnekleri verebiliriz: ineği alıcıya teslim etmek üzere istasyona götüren kişi[18], yemek servisi yapan garson, yemek yaptığı tencerede aşçı, çocuk eşyaların da çocuk bakıcısı, bavul taşıyan bavul taşıyıcısı vb. Hizmet zilyedi, kendi menfaatine değil, başkalarının menfaatine eşyayı kullanmak üzere bulunduran kişidir.

742 Zilyet sahibine yardım ilişkisindeki *hizmet zilyedinin bağımlılığının maddi olması* yeterlidir[19]. Bu sebeple hizmet zilyetliği bağımlılığın sebebi olan hukuki ilişkinin geçersiz olması halinde, hatta borç ilişkisi halinde de söz konusu olur[20].

743 Talimata bağımlılık ilişkisinin süresi ve süreklilığı önemli değildir. Hizmet zilyetliği iradesi, zilyetlik yardım ilişkisinin hukuki olgusu değildir; hizmet zilyedinin bağımlılık ilişkisinin bulunması yeterlidir[21].

c. Talimata Bağlılık İlişkisinin Görünürlüğü

744 Hizmet zilyedinin, hizmet sahibine olan yardımında, onun talimatına bağlı olduğunun dışarıdan anlaşılabilir olması gerektiği Alman yargı uygulamasında aranmakta[22]; bir kısım doktrindeki yazarlar da bu görüşe katılmaktadır[23].

745 Bu görüşe göre, talimata bağlılık ilişkisinin görünürlüğü kendisine özgü bir olgu olarak ele alınmaktadır. Hizmet zilyedi ile hizmet zilyedi arasındaki yardım ilişkisinin iç ilişki olduğunu, dışarıdan birinin bu iç ilişkiyi bilemeyeceğini; ancak talimata bağlı yardım ilişkisinin anlaşılabilir olduğunda, zilyetliğin korunmaya değer olduğunu ifade etmektedir.

746 Özellikle seyahat eden hizmet zilyedinin, mekan olarak uzak bir şey üzerinde zilyetliğinin zilyet sahibi adına olduğu, ancak talimata bağlılığının objektif olarak diğer kişilerce anlaşılabilir olması halinde mümkündür.

---

[18] BGE 1933 I 405-406.

[19] JOOST, MünchK BGB § 855, N.7.

[20] Karş. **GUTZEIT**, Staudinger, BGB § 855, Rn.11.

[21] BGHZ 8, 130 (133f). **LORENZ**, Erman, BGB § 855, Rn.5; **GUTZEIT**, Staudinger BGB 855, RN.14; **BAUR/STÜRNER**, SachenR § 7 Rn.67; **ENDERS**, s. 76 ff.

[22] BGH BeckRS 2014, 02220, Rn.10; BGHZ 27, 360 (363).

[23] **ENNECERUS/ WOLLF/ RAISER**, SachenR § 6 III; **BAUR/STRÜNER**, SachenR § 7, Rn.67; **WESTERMANN/ GURSKY/ EICKMANN**, SachenR § 9 Rn.7; **JOOST**, MünchK BGB § 855, N.410.

d. Kavram

747 Kısaca, zilyet sahibine sosyal bağımlılık ilişkisi kapsamında zilyet sahibinin talimatına uygun olarak gerçekleşen fiili hakimiyet, hizmet zilyetliğidir. Kim ki bir ev ilişkisinde zilyet sahibi adına, ev eşyalarında fiili hakimiyeti kullanıyorsa o kişi hizmet zilyedidir. Örneğin, temizlikçi, çocuk bakıcısı, şoför, bahçıvan vb.

748 Hizmet zilyetliğini, zilyet sahibine olan sosyal bağımlılık ilişkisi gereği, zilyet sahibinin talimatını yerine getirme yükümlülüğü kapsamında, eşya üzerinde kendisi zilyetlik iddiasında bulunmaksızın zilyet sahibine bağlı olarak kurulduğu anlaşılabilen, eşyayı fiili elde bulundurma durumu olarak tanımlayabiliriz. Hizmet zilyedi, eşyadaki fiili durumu sebebiyle eşya üzerinde zilyetlikten kaynaklanan bir hukuki yetkiye sahip değildir.

e. Zilyetlikten Ayırt Edilmesi

749 Hizmet zilyetliğinin, zilyet sahibiyle olan yardım ilişkisi kapsamında, onun talimatlarına bağlı olarak yerine getirilmesi olgusu, onu zilyetlikten ve birlikte zilyetlikten ayırır.

750 Hizmet zilyedinin, dolaylı zilyetten ve yine fer'i zilyetten ayrılması gerekir. Hizmet zilyedinin, fer'i zilyetten farklı olarak eşyanın kendisine teslimi konusunda bir talep hakkı yoktur. Onun eşya üzerindeki hakimiyeti, zilyede bağlı olduğunu gösteren bağımlılık ilişkisi sebebiyle üçüncü kişiler tarafından anlaşılabilir niteliktedir ve üçüncü kişiler bu bağımlılık ilişkisine bakarak eşyanın kime ait olduğunu ve zilyedin kim olduğunu anlamaktadırlar. Hizmet zilyedi, başkası için zilyet olmaktadır.

751 Hizmet zilyedinde, eşyayı hakimiyet altına alma iradesi yoktur; bu yönüyle[124] zilyetlikten ayrılır. Hizmet zilyedi evde veya bir işletmenin parçası olarak işletmede veya hukuki bir ilişkiye dayanarak, başkasına bağımlı olarak eşyayı fiilen kullanan kişidir. Hizmet zilyedi, doğrudan veya dolaylı zilyede adeta *bir maddi araç, alet gibi* hizmet görmektedir. Örneğin, işverene hizmet eden işçi[125]; ev hizmetlileri, temizlikçi, bahçıvan, şoför vb.; kişisel tasarruf yetkisi olmayanlar[126], özellikle ev eşyaları üzerinde aile üyeleri[127].

---

[124] **HINDERLING**, SPR VI/1, s. 422.

[125] BGE 58 II 371 E.2; II 122 E 6.

[126] BGE 67 II 16 E.1; 75 II 122 E 6. **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N.33.

[127] BGE 58 II 371; 67 II 16. Devlet memurları için bkz. BGE 75 II 129 f. **STARK**, BK ZGB Art.919, N.35; **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N.26.

752 Bir maddi elde bulundurma ilişkisinin, hizmet zilyetliği olup olmadığı, somut olayın özelliklerine ilişkin yaşam ve ticaret ilişkileri dikkate alınarak, objektif olarak belirlenir[28].

753 Eşyayı hakimiyetinde bulunduranla hizmet için bulunduran arasındaki ilişki yanında, hizmet zilyedi ile eşya arasındaki ilişki kapsamında, bu kişinin eşya üzerindeki yetkileri de değerlendirilmelidir[29].

754 Alman hukuk doktrinde bazı yazarlar, eşyayla olan ilişkinin devam süresini, fer'i zilyetle hizmet zilyedi arasındaki ayrımın kriteri olarak kabul etmektedir[30]. Gerçekten tek başına olmamak üzere, bağımlılık yanında ve onu pekiştirmek üzere süreklilik unsuru da ayrım kriteri olarak değerlendirilmelidir.

755 Hizmet zilyedi ile eşya arasındaki ilişkinin yoğunluğunun azlığı ve zilyedin her zaman hizmet zilyedine müdahale imkânı olması veya talimat verebilmesi (zilyedin talimatlarına hizmet zilyedinin bağlılığı), hizmet zilyetliğini zilyetlikten ayırır[31].

756 Buna karşın, eşya üzerinde geniş tasarruf yetkisine sahip, işverenden bağımsız hareket etme ve karar verme yetkisi olan veya bir işletmeyi yöneten kişinin işçi de olsa hizmet zilyedi olarak kabul edilmemesi gerekir. Rehin amaçlı inançlı işlemde zilyetliğin hizmet zilyetliği olduğu tartışılabilir[32].

757 Hizmet zilyedinin, vekilden ayrılması oldukça zordur. Vekalet sözleşmesinde vekil edenin talimatına vekilin bağımlığı söz konusudur. Vekil, örneğin avukat veya vekaletsiz işgören[33], navlun (alt) taşıyıcısı[34], mağaza güvenlikleri[35] vb. kendine özgü bağımsız bir durum söz konusu olduğunda, hizmet yardımı ilişkisindeki yarardan farklı bir yarar söz konusu ise[36], talimata bağımlılık olmadığından veya nispeten zayıf oldu-

---

[28] TUOR/ SCHNYER/ SCHMID/ RUMO-JUNGO, § 89. N.7.

[29] TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 63.

[30] Bkz. WIELAND, ZGB Art.919. N.2; STARK, BK ZGB Art.919. N.132.

[31] HINDERLING, SPR VI/1, s. 423.

[32] DOMEJ, KurzKomm ZGB Art.919. N.11.

[33] JENNY, s.73 f; STARK, BK ZGB 919. N. 39; ERNST, BSK ZGB Art.919. N.33.

[34] BGE 93 II 373 E.1b. SemJud 1917. 4912. Farklı karar: ZBJV 1924. 34.

[35] HOMBERGER, ZK ZGB Art.919. N.11.

[36] MÜLLER-ETZBACH, AcP 142 (1936). 5 (21 f); HARTUNG, s.213 ff.

ğundan, hizmet zilyetliği söz konusu değildir. Saklayan (TBK m.561) hizmet zilyedi değil, fer'i zilyettir.

758 Zilyetliğin temsili konusunda, temsilciye yapılan zilyetlik naklinin, temsil edilene zilyetlik devredilmiş gibi zilyetliği geçirdiği TMK m.978'de düzenlenmiştir. Vekilin temsilci sıfatıyla bağımsız bir statüyle hareket etmesi halinde, bağımsız temsilci zilyet olduğu; diğer durumda ise zilyet yardımcısı olduğu kabul edilmelidir[37]. Benzer şekilde, organı oluşturanlar, temsil yetkileri yoksa hizmet zilyedidir.

f. Organın Zilyetliği ve Hizmet Zilyetliği

759 Tüzel kişiler, eşya üzerinde fiili hakimiyet ve hakimiyet iradesini doğrudan değil, tüzel kişiliği temsile yetkili organları ve bu organların yetkili kıldığı temsilciler aracılığıyla ortaya koyar[38]. Bu durum *organ zilyetliği* (Organbesitz) olarak ifade edilmektedir.

760 Tüzel kişiliğin yetkili yönetim organı, tüzel kişinin amacı doğrultusunda eşya üzerinde fiili hakimiyet ve zilyetlik iradesi sağladığında organ zilyetliği gerçekleşir. Tüzel kişiler zilyetliğin her türünü, örneğin aslî veya fer'i zilyedin süjesini oluşturabilir.

761 Organın zilyet mi yoksa hizmet yardımcısı mı olduğu tartışılmaktadır:

762 Alman hukukunda genellikle kabul edildiği üzere, organı hizmet zilyedi olarak kabul eden görüş yanında, organın kendisini zilyet olarak kabul eden görüş de söz konusudur[39]. Alman hukukunda, hakim görüş, organ zilyetliğinin tüzel kişimin amacı içinde hizmet zilyedi ile zilyet kazanımının mümkün olmadığını savunmaktadır[40].

763 İsviçre Federal Mahkemesi'ne göre, tüzel kişinin organları aracılığıyla kazandığı zilyetliği, tüzel kişilik kazanır[41].

764 İsviçre Federal Mahkemesi bir kararında organın eşya ile ilişkilerinde hizmet zilyedine benzer bir durumu olduğuna işaret etmiştir[42]. Orga-

---

[37] **ERNST**, BSK ZGB Art.919. N.35.

[38] **STARK**, BK ZGB Art.919. N. 47. BGE 81 II 339 ff. 343; 137 IV 134 ff. 144.

[39] **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.116 vd.

[40] **KUCHINKE**, s.46 ff.

[41] BGE 81 II 339 ff. Türk hukukunda bu görüş için Bkz. **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 116

[42] BGE 81 II 339.

nın tüzel kişinin kanuni temsilcisi de olduğu göz ardı edilmemelidir. Yasal temsilci sıfatıyla hareket ettiğinde hizmet zilyedi sıfatı söz konusu olmayacaktır. Benzer şekilde organın vekaletsiz işgören sıfatı da söz konusu olabilir.

765 Bize göre, toplumsal yaşam ve ticaret ilişkilerine hakim ilkelere göre, organın tüzel kişilikle olan eşya dolayısıyla ilişkisinin ve organla eşya arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi gerekir. Eşyanın niteliği ve özelliği ile ilişkinin kapsamı bu konuda yol göstericidir.

766 Eğer organı oluşturan kişilerin temsil yetkisi yoksa, zilyetliği hizmet zilyetliğidir; temsil yetkisi olanların zilyetliği ise TMK m.978'e göre vekil aracılığıyla tüzel kişinin zilyetliği kazanmasına aracılıktır[443]. Hizmet zilyedinde, zilyet yardımcısının hakimiyet kurmaya ilişkin zilyetlik iradesi bulunmamaktadır.

g. Banka Kasa Sözleşmesinde

767 Banka sözleşmelerinde, bankanın zilyetliğinin niteliği ve zilyetlik hükümlerinin uygulanması oldukça tartışılmaktadır[444]. Bu kapsamda kasa sözleşmelerinde, bankanın zilyet olmadığı, zira kasanın içindekiler üzerinde fiili hakimiyetin olmadığı ifade edilmekte, bankanın daha çok hizmet zilyedi olduğu kabul edilmektedir[445].

768 Hizmet zilyedi, zilyedin hukuki durumundan ve hukuki korumasından yararlanmaz[446]. Tartışmalı olmakla birlikte, bize göre, hizmet zilyedi her türlü gasp ve saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir (TMK m.981)[447]; buna karşın emin sıfatıyla zilyet olarak TMK m.988 hükmündeki rıza dışında çıkan eşya bakımından taşınır davasını düzenleyen TMK m.934 hükmündeki korumadan ve diğer korumalardan yararlanmaz[448].

---

[443] **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N.35.

[444] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.919, N.13; **ZOBL**, ZK ZGB Art.884, N.546; **STARK**, BK ZGB Art.919, N.60; **HINDERLING**, SPR V/1, s.420.

[445] **ERNST**, BSK ZGB Art.920, N.28.

[446] **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N.24; **DOMEJ**, KurzKomm ZGB Art.919, N.12.

[447] **HINDERLING**, SPR V/1, s. 422. Hizmet zilyedi emin sıfatıyla zilyet olmadığından, güveni kötüye kullanma suçu (TCK m.155) değil, hırsızlık suçu (TCK m.141) teşkil edeceği konusunda bkz. **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 67.

[448] **STARK**, BK ZGB Art.919, N.39 ff; **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N.24; **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.919, N. 3; **DONEJ**, KurzKomm ZGB Art.919, N.12. Farklı görüş için bkz. **HINDERLING**, SPR V/1, s.422, 503.

769 Hizmet zilyedi, zilyetliği devralana zilyetliği devredebilir. Bunun için ayırt etme gücü olması yeterlidir; fiil ehliyetinin olması gerekmez[45].

VI. FONKSİYONLARI

770 Zilyetlik bir hukuk tekniği enstrümanıdır[50]. Hukuk enstrümanı olarak hukuk düzeninde farklı amaçlarla farklı fonksiyonları yerine getirmek için kullanılmaktadır. Zilyetliğin kendi asli fonksiyonları söz konusudur[51].

771 Bunlardan ilki toplumsal düzeni ve güvenliği (huzuru) sağlamaktır. Bununla ilgili alt bir fonksiyon olarak hukuki korunma sağlama fonksiyonunu sayabiliriz.

772 Zilyetliğin diğer fonksiyonu ise aleniyeti sağlamaktır. Bu fonksiyonla ilgili diğer fonksiyon ise mülkiyetin hukuki olgusunu gerçekleştirmesidir.

A. Toplumsal Düzeni ve Güvenliği (Huzuru) Sağlama Fonksiyonu

1. Huzur Fonksiyonu

773 Zilyetliğin aleniyeti sağlayan maddi olgu olması, ona diğer hukuki sonuçlar bağlanması ve onun yarattığı fiili durumun hukuki olarak korunması; temel işlev olarak toplumsal düzenin ve toplumsal ve ticari yaşam ilişkilerindeki güvenliğin ve huzurun sağlanmasına hizmet eder[52]. Kısaca zilyetliğin korunma sebebi *huzur fonksiyonu*dur (Friedensfunktion)[53].

---

[45] **EITEL/ARNET,** CHK ZGB Art 919. N. 3.

[50] **HERMANN.** Staudinger BGB. Eckpfeiler. s 1039 f.

[51] **GUTZEIT,** Staudinger EGB § 834. Rn.14. **NIGGLI.** s. 21 ff.

[52] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR.** s. 51; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ ALTOP.** s.50. **ÜNAL/BAŞPINAR.** s.97. **AKİPEK/ AKINTÜRK.** s.117. **AYAN.** s.76. *"...zilyetlik eşya ile şahıs arasında eylemli (fiili) bir bağ yani ilişki olup ve buna bağlı olarak da fiili hakimiyet altında bulundurmaktan doğan hukuki yetki ve vecibeleri de gösteren ve düzenleyen hukuki bir müessesedir. Kanunda sözü edilen fiili hakimiyetin meydana geliş şekli önemli değildir. Bunun bir gasp ve tecavüz sonucunda elde edilmiş olması da mümkündür. Zilyetliğin hukuki fonksiyonlarından birisi de, fiili durumun başkaları tarafından keyfi olarak bozulmasını önlemektir. Hukuk düzeni böylece toplumun esenliğini korumak istemiştir. Kendilerini haklı görenler bile başkasının fiili hakimiyetine belli bir çerçeve içinde saygı göstermeye mecburdurlar..."* (Y. HGK. 11.2.2009 T., 8-28 E., 74 K.)

[53] Bkz. **GURZEIT.** Staudirger. BGB § Rn.18. **HEDONGER.** s. 55 ff. 57 f. **SCHÖBI.** s. 127

774 Toplumsal düzen ve yaşam ilişkileri, haktan bağımsız olarak, kişinin eşya üzerindeki maddi ve fiili hakimiyetin -hukuki durumunun tek başına korunması ve bu duruma özellikle taşınırlarda diğer fonksiyonlar olan, özellikle taşınırlarda aleniyeti sağlama ve buna bağlı diğer etkileri doğurmasını için hukuki olgu olarak zilyetliğin kabulünü gerekli kılar. Zilyetlik, sadece maddi bir olgu olarak toplumsal ve ticari ilişkilerin güvenle devamını sağlamaya hizmet eder.

2. Huzur Fonksiyonunu Açıklayan Görüşler

a. Huzur Teorisi

775 Huzur fonksiyonunu açıklayan *huzur teorisi*, zilyetliğin korunmasının genel huzura hizmet ettiğini ve fiili durumun bozulmamasının toplumsal kamu yararı sebebiyle önlenmesini amaçladığını ifade etmektedir[154]. Huzur teorisi yaklaşımı Roma hukukunda söz konu idi[155].

b. Süreklilik Teorisi

776 Huzur teorisine karşı görüş geliştiren *Heck*, geliştirdiği *süreklilik teorisi*ne (Kontinuitätstheorie) göre, zilyetliğin korunmasının arka planında yatan genel yararın geçici olduğunu; doğrudan zilyedin korunmasının sadece zilyedin dolaysız fiili hakimiyetteki özel menfaatinin korunmasına hizmet ettiğini, zira kişinin eşyada kendi yararı için hakimiyet sağladığını ifade eder. Dolayısıyla yaşam ilişkilerinin sürekliliği, zilyetlikteki kurumsal değerin (Organisationswert) korunmasını gerekli kılar[156].

c. Görüşümüz

777 Bize göre ise, kanun koyucu, zilyetliği koruma amacını, toplumsal düzeni ve güvenliği (huzuru) sağlama fonksiyonu yanında, farklı koruma yararlarından hareketle belirleyebilir. Zilyedin özel süreklilik yararından hareketle koruma söz konusu olabileceği gibi, örneğin hırsızın zilyetliğinin korunması; zilyedin kamusal amaçla korunması da söz konusu olabilir; örneğin lokanta müşterisinin zilyetliğinin korunması. Kamusal koru-

---

[154] ENNECERUS/ WOLFF/ RAISER, SachenR § 17 vor I; MEDICUS, AcP 165 (1965), s.115 ff. 119 DULCHEIT, s.13.

[155] WIELING, s.565, 567.

[156] HECK, SachenR § 3, N.5-9. Bu yaklaşımı takip eden BAUR/STÜRNER, SachenR § 9, Rd 9; HARTUNG, s.44.

ma bireysel olarak zilyetliğin korunmasına da genellikle hizmet eder. Bireysel zilyetliğin kurumsal değer olarak korunmasında kamusal yarar da vardır. Bu sebeple huzur görüşünden ayrılmayı gerektiren haklı bir sebep bulunmadığını düşünmekteyiz.

3. Hukuki Koruma Fonksiyonu

778 *Hukuki koruma fonksiyonu*, toplumsal düzenin ve huzurun sağlanması fonksiyonu ile yakından ilgilidir. Hukuk güvenliğini sağlama yararı sebebiyle zilyet; zilyetliğinin ihlali ve elden alınmasına karşı kuvvet kullanarak zilyetliğini savunma hakkına sahiptir (TMK m. 981 I)[157]. Diğer zilyetliği koruyan davalarla da zilyet korunmuştur (TMK m. 982-984). Önceki zilyedin, belirli şartların gerçekleşmesi halinde taşınır davası (TMK m.989) açma hakkı da saklıdır.

779 Zilyetliğin hukuki koruma fonksiyonu, diğer hukuk alanlarında - özellikle haksız fiilden doğan borç ilişkisi (TBK m.49 vd)[158] veya sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkisi kapsamında korunur[159]. Hukuki koruma fonksiyonu genellikle taşınır - taşınmaz ayrımı yapılmaksızın uygulanır.

B. Aleniyeti Sağlama Fonksiyonu

780 Teorik ve uygulama olarak zilyetlik, en fazla taşınır hukukunda mülkiyetin kazanılması ve kaybedilmesinde rol oynar. Zilyetlik, taşınırlarda aleniyet fonksiyonunun yerine getirilmesine hizmet eder. Bu fonksiyonla ilgili diğer fonksiyon ise mülkiyetin kazanılmasını ve hakkın hukuki olgusunu gerçekleştirmesidir[160]. Karine etkisi ve güvenin korunmasını buraya ilave edebiliriz.

781 Aleniyeti sağlama fonksiyonu olarak zilyetlik, kamuya açıklama aracı ve bunun hukuki etki ve sonuçlarını ifade eder. Böylelikle eşya üzerindeki hakkın aleniyetini sağlayarak, toplumsal ve ticari yaşam ilişkilerinde hukuk güvenliğini sağlar[161].

---

[157] **NIGGLI**, s.47 ff.; **ÜNAL/BAŞPINAR** konuyu zilyetliği huzur ve sükunu sağlama fonksiyonu olarak ele almaktadır (s.97).

[158] **HEIERLI/SCHNYDER**, BSK OR Art.41, N.33.

[159] **BUCHER**, OR AT, s.656.

[160] **NIGGLI**, s. 60 ff.

[161] **HROMADKA**, JuS 1980, 89 ff. 90.

782 Aynı hakkın dışa yansıma fonksiyonu olarak, özellikle taşınırlarda özel bir önemi söz konusudur[62]. Bu hukuki sonuç ve etkileri yukarıda eşya hukukuna hakim olan ilkeler başlığında detaylı olarak incelemiş idik. Zilyetlik, aleniyet sağlama fonksiyonu olarak da aşağıdaki hukuki etkileri ve sonuçları doğurur[63]:

1. Hakkı Kurma Etkisi

783 Taşınırın mülkiyetinin kazanımı veya rehnin tesisi, zilyetliğin nakli ile gerçekleşir (TMK m.763, 939). Bu sebeple *Eichler*, zilyetliği eşya üzerindeki "*dış ilişki*"; mülkiyetin ise "*iç ilişki*" olduğunu ifade etmiştir[64].

2. Hakkı Zamanaşımı ile Kazandırma Etkisi

784 Bir taşınmaza veya taşınıra uzun süre zilyetlik, diğer hukuki olgularla birlikte taşınır ve taşınmaz mülkiyetinin kazanımını sağlar (TMK m. 707, 712-713.

3. Karine Etkisi

785 Zilyetlik, zilyedin taşınır mülkiyetini kazandığına karine teşkil eder (TMK m.985)[65].

4. Güvenin Korunması Etkisi

786 Bir taşınırı iyiniyetle kazanan zilyedin kazanımı korunur (TMK m.988-900).[66]

---

[62] WEBER, s. 1 vd.

[63] NIGGLI, s.21 ff. HINDERLING, SPR VI/1, s. 406-407. OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s.51 vd; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.50 vd; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 94 vd.

[64] EICHLER, s. 10.

[65] NIGGLI, s. 30.

[66] NIGGLI, s. 32 ff.

§ 6. ZİLYETLİK ÇEŞİTLERİ

I. GİRİŞ

787 Zilyetlik çeşitli açılardan farklı çeşitlere ayrılmıştır. Kanun, kademeli zilyetlik çeşidi olarak aslı zilyetlik ve fer'i zilyetlik ayrımı ile (TMK m.974) ve dolaylı ve dolaysız zilyetlik ayrımını (TMK m.975) düzenlemiştir.

788 Konusuna göre zilyetlik, eşya ve hak üzerinde zilyetlik olarak ikiye ayrılmaktadır; zilyetliğin bu ayrımını yukarıda incelemiş idik. Aşağıda zilyetlik çeşitleri üzerinde durulacaktır.

II. DOLAYLI ZİLYETLİK - DOLAYSIZ ZİLYETLİK

A. Genel Olarak

789 Dolaylı ve dolaysız zilyet (unmittelbarer Besitz - mittelbarar Besitz) ayrımı, zilyedin eşya üzerindeki *fiili hâkimiyetinin maddi yoğunluğuna* göre yapılan bir ayrımdır. Dolaylı-Dolaysız zilyetlik terimi yerine, vasıtalı ve vasıtasız zilyet terimi de kullanılmaktadır.

790 TMK m.975 hükmünde, "*Bir şeyde fiilî hâkimiyetini doğrudan doğruya sürdüren kimse dolaysız zilyet, başka bir kişi aracılığı ile sürdüren kimse dolaylı zilyettir.*" şeklinde düzenlenmiştir. Kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nda (ZGB) dolaylı ve dolaysız zilyet ayrımı düzenlenmemiştir. Alman Medeni Kanunu'nda (BGB § 868) dolaylı zilyetlik ve dolaysız zilyetlik ayrımı yer almaktadır.

791 Dolaylı ve dolaysız zilyet ayrımı, asli ve fer'i zilyetlik ayrımlarının bazen birbirine karıştırılmasına yol açmıştır[1]. Oysa asli ve fer'i zilyet ayrımı, zilyedin eşya üzerinde iddia ettiği maddi hakka göre yapılan bir ayrımdır. Buna karşılık dolaylı ve dolaysız zilyet ayrımı, malın zilyedin fiili hâkimiyetinde direkt olup olmaması bakımından yapılmıştır[2].

---

[1] İsviçre hukukunda eski doktrin, asli ve fer'i zilyet ayrımı ile doğrudan ve dolaylı zilyet ayrımını aynı olarak kabul etmiş idi. Karş. **HOMBERGER.** ZGB Art.920. N.10. **HINDERLING,** SPR V/1. s.417. Türk hukukunca aynı yaklaşım için bkz. **AKİPEK.** s. 173; **REİSOĞLU,** s. 52; **ESENER/GÜVEN,** s.17; **AYAN.** s.86.

[2] **ERNST.** BSK ZGB Art.920. N. 2.

792 Dolaylı ve dolaysız zilyetlik ayrımında yine zilyetliğe katılım ilişkisi söz konusu olabilir; katılım ilişkisinin zilyetliğe katılımı sağlayan geçerli ve hukuki bir ilişki olması gerekli değildir; aslı zilyedin katılım iradesi aranmaz; zilyetliğe katılım ilişkisi olmasa da dolaylı zilyetlik gerçekleşebilir. Örneğin, malik asli zilyet ve dolaylı zilyet; kira sözleşmesi ile daireyi kiralayan kiracı fer'i zilyet ve dolaylı zilyet; kira sözleşmesinden ve kanundan doğan bir yetkiyle kiracıdan daireyi alt kira sözleşmesi ile kiralayan alt kiracı, fer'i ve dolaysız zilyettir. Kiracının kiraya verme yetkisi olmasa da alt kiracı dolaysız zilyettir. Buna karşın, hâkim görüşe göre, kiracı malike karş: fer'i zilyet; alt kiracıya karşı asli zilyettir[3].

793 Asli zilyet, kademeli zilyette dolaylı zilyet olan kişidir; zira eşya üzerinde direk fiili hâkimiyetini kaybetmiş kişidir. Fer'i zilyet ise, kademeli zilyette eşya üzerinde direkt hâkimiyeti olan kişidir. Asli ve fer'i zilyet ayrımında hukuki bir katılım ilişkisi bulunması gerekirken, dolaylı ve dolaysız zilyet ayrımında, geçerli hukuki bir katılım ilişkisi zorunlu değildir. Bir şeyi bulan kişi, dolaysız zilyettir.

B. Çeşitleri

1. Dolaysız Zilyetlik

794 Dolaysız zilyet, eşya üzerinde hakimiyetini direkt olarak kullanan kişidir. Örneğin kıymetli evrakı kendi bürosunda saklayan kişi dolaysız zilyettir.

795 Birden fazla kişi birlikte zilyet olabilir. Örneğin, eşler ve aile bireyleri aile konutlarında birlikte dolaysız zilyettir; aile bireyleri konutta kademeli zilyette olabilirler. Hatta konutta hizmet zilyedi de söz konusu olabilir. Konutun sahibi eş asli ve doğrudan zilyet olabilir; konut sahibi eş konutta yaşamıyorsa, dolaylı zilyettir; konutta yaşayan diğer eş fer'i zilyet ve doğrudan zilyettir; yine konutta yaşayan çocuklar fer'i ve doğrudan zilyettir; ev hizmetlisi ve çocuk bakıcısı hizmet yardımcısıdır (hizmet zilyedidir)[4].

796 Başkası üzerinden zilyetliği kullanan kişi, eşya üzerinde hakimiyeti maddi olarak kullanabileceği gibi, örneğin taşınır rehninde olduğu üzere; zilyetliği hükmen teslimde olduğu gibi başka şekillerde de dolaysız zilyet olabilir. Taşınır rehninde malık aslı ve dolaylı zilyet; rehin alan fer'i, ve

---

[3] STARK, BK ZGB Art.920. N 4 ve orada belirtilen yazarlar.

[4] ERNST, BSK ZGB Art.920. N. 21.

dolaysız zilyettir[5]. TMK taşınır rehninin teslim rehni şeklinde olacağını düzenleyerek, bu zilyetliğin dolaysız zilyetlik olmasını öngörmüştür[6]. TMK m.941 art rehni düzenlemiştir. Art rehinde, ilk rehin hakkı sahibi, fer'i ve dolaysız zilyet iken, art rehin hakkı sahibi, fer'i ama dolaylı zilyettir. Birinci rehin hakkı sahibi, art rehin kendisine bildirilmişse, rehin konusu taşınırı art rehin hakkı sahibine TMK m. 979'a göre hükmen teslimle devretmekle yükümlüdür[7].

797 Fer'i zilyetlikte olduğu üzere, asli zilyetten geçerli bir katılım ilişkisi ile de zilyetliğe katılması gerekli değildir. Dolaysız zilyetlik gerçekleştiğinde, asli zilyet dolaylı zilyet haline dönüşür.

798 Eşyayı bulan ve vekaletsiz işgören, dolaysız zilyettir. Farklı bir fikir, eşyayı bulanla vekaletsiz işgöreni, malik gibi hareket etmediği sürece fer'i zilyet olarak görmektedir. Bize göre malik gibi görünmek yetmediğinden, malik sayılmaz ve aslı zilyet de olamaz; bulanın zilyetliği geçerli bir zilyetlik iradesine dayanmadığından, fer'i zilyetlik de değildir.

799 Tüzel kişinin organları, onu onun adına zilyet kıldığından, tüzel kişiler dolaysız zilyettir. Tüzel kişi yetkili olmayan organları veya çalışanları aracılığıyla zilyet olursa, hizmet zilyedinden hakimiyeti kazandığından yine dolaysız zilyet olur.

800 Dolaysız zilyetlik, zilyetlikten vazgeçme ve zilyetliği kaybetme yanında; doğrudan zilyedin, yabancı zilyet olmak istemeyip malik sıfatıyla zilyet olarak hakimiyetini devam ettirdiğinde de sona erer.

2. Dolaylı Zilyetlik

801 Dolaylı zilyet; bir eşya üzerindeki fiili hakimiyeti direkt olarak değil de başka bir kişi üzerinden kullanan zilyettir. Aynı örnekten devam edersek, kıymetli evrakın zilyedi, kıymetli evrakı bankaya tahsil için veya yönetimi için bir şirkete verdiğinde dolaylı zilyet durumundadır.

802 Dolaylı zilyet için, zilyetlik ilişkisine katılım iradesi ile geçerli ve hukuki bir katılım ilişkisi gerekli değildir. Zilyetlik için aranan iki unsur, fiili hakimiyet ve hakimiyet iradesidir.

---

5 **OFTINGER/BÄR**, Art 844, N.188; **ZOBK**, BK ZGB Art.884, N.518.

6 İstisnai özel şekilleri için bkz. **ZOBL**, BK Syst. Teil, N.35; **OFTINGER/BÄR**, Syst. Teil, N.35.

7 **ZOBL**, BK ZGB Art.886, N.1; **OFTINGER/BÄR**, BK ZGB Art.886, N.3; **ERNST**, **BSK** ZGB Art.920, N. 26.

C. Hukuki Sonuçları

803 Dolaylı zilyetlik zilyetliğin havalesinde korunması yanında, zamanaşımı ile mülkiyet kazanımında da rol oynar. Aşağıda açıklayacağımız üzere, doğrudan zilyet ile dolaylı zilyet ayrımı zilyedin sorumluluğunu düzenleyen TMK m.988 vd. hükümler bakımından rol oynamaz[4].

1. Zilyetliğin Korunmasında

804 Dolaylı zilyetlik ve dolaysız zilyetlik aynı asli zilyetlik ve fer'i zilyetlik gibi, zilyetlerin zilyetliğin sağladığı avantajlardan yararlanmalarına imkân tanıyan ve bu konuyu düzenleyen hükümlerdir. Dolaylı ve dolaysız zilyetlik ayrımı, özellikle zilyetliğin korunmasında önem taşır.

805 Dolaysız zilyet dolaylı zilyetlere kıyasla, zilyetliğin korunmasından öncelikle yararlanır. Dolaysız zilyedin korunması (TMK m.981-983) daha geniş kapsamda iken, dolaylı zilyedin korunması sınırlı ve daha çok dava yoluyla (TMK m.982-983) sağlanır. Dolaylı zilyet kuvvet kullanarak zilyetliğe olan saldırıyı önleyemeyeceği gibi, vasıtasız zilyede karşı da zilyetliğin korunması yoluna başvuramaz[5]. Dolaysız zilyet, asli zilyet ise o da üçüncü kişilere karşı zilyetlik korunmasından yararlanabilir.

806 Dolaylı zilyet, zilyetliğinde bulunan eşya üzerinde hukuki tasarrufta bulunarak, onun hukuki kaderine etki edebilme imkanına sahiptir. Dolaysız zilyedin ise bu yetkisi yoktur.

2. Taşınır Mülkiyetinin Zamanaşımı ile Kazanımında

807 Zilyetliğin dolaylı ve dolaysız ayrımı değil de dolaylı zilyedin malik sıfatıyla dolaylı zilyet olması, mülkiyetin zamanaşımıyla kazanımına engel değildir. (TMK m.777). TMK m.763.II'e göre, bir taşınırı malik olmak üzere devralan kişi malik sıfatıyla zilyettir. Hükümden anlaşıldığı üzere, her dolaysız zilyet olanın malik sıfatı olduğu söylenemez. Dolaylı zilyedin malik sıfatıyla bu taşınırı dolaysız zilyede vermiş olması, onun taşınır mülkiyetini kazanmasına sebep olabilecek kazandırıcı zamanaşımını kesintiye uğratmaz.

808 İlaveten, sahipsiz bir şeyi malik olma iradesiyle dolaysız zilyetliğine geçiren kişi, onun malikı olur (TMK m.767).

---

[4] STARK, BK ZGB Art.920, N.34

[5] OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s. 67.

3. Kaybedilen Eşyada

809 Bulunan eşyada, bulan bulduğu eşyanın aslî zilyedi değildir; malikin katılma iradesiyle o eşya üzerinde hakimiyeti olan kişi olmadığından fer'î zilyet de değildir; fakat eşyanın dolaysız zilyedidir, bulunan şeyin sahibi ise dolaylı zilyettir.

810 Eşyayı bulan kişi dolaysız zilyet olarak, kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla beş yıl içinde bulunan şeyin maliki de çıkmazsa o şeyin mülkiyetini kazanır (TMK m.771)[10].

III. BASİT ZİLYETLİK - KADEMELİ ZİLYETLİK

811 TMK m. 974 I açıkça kademeli (dereceli) zilyetliğin aslî ve fer'î zilyetlik olarak çeşitlerini düzenlemiştir. Kademeli zilyetlik, birden fazla kişinin birbiriyle aynı olmayan yetkilerle aynı taşınmazda zilyetliğini ifade eder. Kademeli zilyetliğin karşılığını ise basit (yalın) zilyetlik oluşturur. Basit zilyetlik tek kademeli; kademeli zilyetlik ise çok aşamalıdır.

812 Doktrin de terimsel olarak aynı kavramı karşılamasa da özgün zilyetlik - yabancı zilyetlik (Eigenbesitz-Fremdbesitz) (Eigenbesitz-Lehnbesitz), üst zilyetlik - alt zilyetlik (Oberbesitz-Unterbesizt) terimleri de kullanılmaktadır. Basit ve kademeli zilyetlik ayrımının da göreceli - relatif olduğunu ayrıca belirtmek gerekir[11].

813 İki kademe dışında üç ve daha fazla kademeli zilyetlik söz konusu olabilir[12]. Kademe üç ve daha fazla aşamalı olduğunda, bu terimler kurumu açıklamakta yetersiz olduğundan kademeli zilyetlik terimini tercih etmiş bulunmaktayız[13].

A. Basit (Yalın) Zilyetlik

814 Bir eşya üzerindeki fiili hakimiyet -bir bütün olarak fiziksel ve ekonomik yararlar ve kullanımın tümü bir kişide toplanmışsa, basit (yalın) zilyetlik (einfacher Besitz) söz konusu olur[14]. Basit (yalın) zilyet; tek ba-

---

[10] **HAAB/SCHERRER**, ZK ZGB Art.720-722: N.27 ff.

[11] **STARK**, BK ZGB Art.920, N.3; **HOMBERGER**, ZGB Art.920, N10; **HIONDERLING**, SPR VI/1, s. 417.

[12] **HINDERLING**, SPR V/1, S. 417; **ERNST**, BSK ZGB Art.490, N.4.

[13] **STARK**, BK ZGB Art.920, N.3 ff.

[14] **SCHMID/HÜRLIMANNM-KAUP**, N.107.

şına o eşya üzerinde mülkiyet sahibi olarak, o eşyayı sınırlı ayni hak sahibi, eşyaya bağlı hak veya kişisel bir hak sahibinin fiziksel ve ekonomik yararlanmasına ilişkin zilyetliği olmaksızın zilyedi olan kişidir. Örneğin bir kişi malik olduğu dairede tek başına yaşıyorsa, kendisi o dairenin basit zilyedidir[15].

B. Kademeli Zilyetlik

1. Genel Olarak

815 Aşamalı zilyetlik olarak da isimlendirilen kademeli zilyetlik (merfacher oder gestufter Besitz), kendi içinde asli zilyet ve fer'i (selbständiger Besizt unselbständiger Besitz) zilyet olarak ikiye ayrılır.

816 Asli ve fer'i zilyet ayrımı, zilyedin eşya üzerindeki hakkına göre yapılan bir ayrımdır. TMK m.974 hükmüne göre, "*Zilyet, bir sınırlı aynî hak veya bir kişisel hakkın kurulmasını ya da kullanılmasını sağlamak için şeyi başkasına teslim ederse, bunların ikisi de zilyet olur. Bir şeyde malik sıfatıyla zilyet olan asîl zilyet, diğeri fer'î zilyettir.*" TMK m.974 iki kademeli zilyetliği düzenlemiştir.

817 Fer'i zilyet, başkası için bir hakka dayanarak zilyet olan kişidir.

818 Birden fazla kişi, aynı eşya üzerinde eşyayı farklı fiziksel ve ekonomik yarar amacıyla kullanmak isterse, birlikte kademeli zilyetlik söz konusu olur[16]. Kademeli zilyetlik, dereceli zilyetlik (gestufter Besistz), basamaklı zilyetlik olarak da isimlendirilmektedir[17]. Kademeli zilyetlik, Roma hukuku değil, Pandekt hukuku kökenlidir.

819 Birlikte kademeli zilyetlikte, aynı taşınmaza zilyet olan birden fazla kişinin aynı eşya üzerinde yetkileri farklı fiziksel ve ekonomik yararlanmaları söz konusudur[18]. Birlikte zilyetlikte ise, yalın zilyetliğin birden fazla kişi tarafından kullanımı söz konusudur[19]. Asli veya fer'i zilyetlik birden çok zilyet tarafından birlikte kullanılabilir.

---

[15] **STARK**, BK ZGB Art.920, N.1.

[16] Bkz. BGE 132 III 155, 158.

[17] **AYBAY/ HATEMİ**, s. 12; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 131; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 102.

[18] **STARK**, BK ZGB Art.920, N.1; **EITEL/ARNET**, ZGB Art.920, N.1; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.108.

[19] **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 103.

2. Kademeli Geçerli Katılım İlişkisi ve Zilyetliğe Katılım İradesi

820 Kademeli zilyetlik, sadece yalın zilyedin, zilyetlik iradesi ile başkalarına o eşyaya *zilyetliğe katılım ilişkisini* tanıdığı ve kabul ettiği veya kanunun bu imkânı verdiği, zilyetlik hallerinde söz konusu olur. Doktrinde hâkim görüş, söz konusu hukuki katılım ilişkisinin sözde veya görünürde olmasını yeterli görmektedir[20].

821 Doktrinde bir görüşe göre, asli ve fer'i zilyetlik ayrımının zilyetlikteki davranış şekline göre yapılan bir ayrım olduğu[21]; malik sıfatıyla zilyet olmak için mutlaka malik olmanın gerekli olmadığı, malik gibi davranmanın yeterli olduğunu[22], örneğin kiracının veya intifa hakkı sahibinin malik sıfatıyla zilyet olarak hareket ettiğinde asli zilyet olduğunu[23] kabul etmektedir.

822 Doktrinde savunulduğu üzere, fer'i zilyedin, asli zilyedin iktidarını tanıdığı sürece eşyayı verenin asli zilyetliğinin devam ettiğini, tanımadığı anda asli ve fer'i zilyetlik ilişkisinin sona erdiğini ve fer'i zilyet olanın eşyanın artık maliki sıfatına sahip olduğu görüşüne katılamamaktayız.

823 Fer'i zilyedin asli zilyedin iktidarını tek başına tanımaması, hukuki katılım ilişkisini ve bu ilişkiye göre tarafların zilyetlik durumlarını değiştirmez. Fer'i zilyedi, malik sıfatıyla zilyet haline getirmez. Malik sıfatıyla zilyet olabilmek için, fer'i zilyedin malik olarak taşınırı devralması gereklidir (TMK m.763).

824 Doğrudan - dolaylı zilyetlik ayrımında zilyetlik ilişkisine katılım göreceli bir kavram iken, asli - fer'i zilyetlik ayrımında zilyetlik ilişkisine katılım göreceli bir kavram değildir. İddia edildiği üzere, bir kimse durumuna göre, asli ve fer'i zilyet olamaz, tam tersi de olamaz.

Yine iddia edildiği üzere, malik gibi davranma ve buna diğerinin karşı çıkmaması TMK m.974'ün hareket noktası değildir. TMK m.974 II açıkça "*bir şeyde malik sıfatıyla zilyet*" olmadan bahsetmektedir. Zilyedin eşya üzerinde malik sıfatı olup olmadığı asli zilyedin belirleyici olgusudur. Dolaylı doğrudan zilyet ayrımında ise, malik sıfatı ayırıcı olgu değildir.

---

20 **ERNST**, BSK ZGB Art.920, N.10.

21 **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s.64; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 104.

22 **NOMER/ ERGÜNE**, s.12.

23 **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.104. Aksi görüş: **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s.64; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 129.

825 TMK m.974 hükmünün amacı, malike, kendisinin zilyetlik iradesi ile fiili hakimiyeti naklettiği kişilerle birlikte zilyet olma imkânı vererek, malikin hakimiyeti fiilen sona ermiş olsa bile zilyetlik korumasından yararlanmasını sağlamaktır. Malik olmayanın, malik sıfatıyla hareket etmesinden hareketle, onu malik gibi birlikte zilyet olarak kabul etmek ve zilyetlik korumasından yararlandırmak kanunun amacı ile bağdaşmaz.

826 Bize göre, asli zilyetlik sıfatı, sadece malike ilişkindir. Malikten sonrakiler sadece kademeli fer'i zilyetlerdir. Tüm fer'i zilyetliğin ikinci kademesi sonrasında da zilyetliğe katanın zilyetliğe katılım iradesinin bulunduğu geçerli bir katılım ilişkisi gereklidir. İlaveten, doğrudan ve dolaylı geçerli bir katılım ilişkisi gerekli değilse de asli ve fer'i zilyetlik şeklindeki katılım ilişkisinin *geçerli bir hukuki zilyetlik ilişkisi* olması gereklı değildir[24]; sadece asli zilyedin sonraki aşamalarda katılımına imkân veren *zilyetliğe katılım iradesi* olması veya kanunun buna imkân vermesi yeterlidir.

827 Zilyetliğe katılım ilişkisi, hukuki işlem ilişkisi ile aynı kavram değildir; varsayılan (mefruz) bir ilişki yeterlidir[25]. Zilyetliğe katılım iradesi, maddi olarak örtülü veya açık şekilde dışarıya açıklanan hakimiyetin devri iradesidir. Zilyetliği devredenin hukuki işlem ehliyeti gerekli değildir; ayırt etme gücü olması yeterlidir.

828 Zilyetliğe katılım iradesi bir hukuki işleme dayanıyorsa, bu hukuki işlemin geçersiz olması veya sona erdirilmiş olması zilyetlik ilişkisine etkili değildir[26]. Zilyedi belirli bir yükümlülük altına sokmayan, yalın bir hukuki durumu olan soyut zilyetlik tasarımını (abstrakte Besitzkonstitut) ifade eder[27].

829 Üç ve daha sonraki aşamalarda da, ikinci kademedeki -bir önceki kademedeki- zilyedin kanundan doğan yetkisi olması veya yalın zilyedin verdiği yetki ile zilyetliğe katılım ilişkisi kurması gerekir (TMK m.974 I).

830 Yukarıdaki örnekten devam edersek, apartman dairesinin maliki olan yalın zilyet, dairesinde intifa hakkı tesis ederse, intifa hakkı sahibi ikinci

---

[24] **STARK**, BK ZGB Art.920, N.18.

[25] **WIELAND**, ZGB Art.920, N.1; **HOMBERGER**, ZGB Art.920, N.11; **OSTERTAG**, ZGB Art.920, N.4; **STARK**, BK ZGB Art.920, N.15.

[26] **HINDERLING**, SPR V.1, s. 418; **OSTERTAG**, BK ZGB Art.920, N. 14; **STARK**, BK ZGB Art.920, N.16; **ERNST**, BSK ZGB Art.920, N.9.

[27] **STARK**, BK ZGB Art.920, N.16.

kademede zilyet; intifa hakkı sahibi kanundan doğan yetkisine dayanarak daireyi kiraya verirse kiracı üçüncü kademede zilyet; kiracı kira sözleşmesindeki yetkiye dayanarak alt kiraya verirse, alt kiracı dördüncü kademede zilyet olur. Kademeli zilyetlik bir sınırlı ayni hak veya kişisel bir hakkın kurulması veya kullanılması için kurulan belirli bir hukuki ilişkiyi gerekli kılar. Zilyetliğe katılım ilişkisi, doğrudan doğruya kanundan veya katılım ilişkisinden, genellikle sözleşme kuralından kaynaklanabilir.

831 Sözleşmeden doğan zilyetliğe katılım ilişkisi; kullanma veya işgörme sözleşmelerinden veya sınırlı bir ayni hakkın kurulması veya verdiği bir yetkinin kullanılması olarak karşımıza çıkabilir. Kanun doğrudan doğruya bir kişiye zilyetliğe katılma yetkisi vermiş olabilir. Örneğin; aile veya velayet-vesayet hukukundan doğan yönetim ve yararlanma yetkisi eşlere veya yasal temsilciye verilmiştir. Kademeli zilyetlik, TMK m.977-979'da düzenlenen zilyetliğin devrine ilişkin tüm devir çeşitleri ile gerçekleştirilebilir.

3. İkili Kademenin Çeşitleri

a. Asli Zilyetlik

832 Asli zilyet birinci kademede eşyaya zilyet olan kişidir. Bu kişi o eşyaya malik sıfatıyla zilyet olan kişidir. TMK m.924 II Pandekt hukukunun zilyetlik iradesinden hareketle asli ve fer'i zilyetlik ayrımı yapmıştır. Zilyetlik iradesinin *animus domini* unsurunu açıkça vurgulamıştır[24].

833 Malik olduğu düşüncesi ile zilyet olması yeterlidir; bu zilyedin mutlaka objektif bakış açısı ile gerçekten malik sıfatı olup olmaması asli zilyet olmasında rol oynamaz[25]. Ölüme bağlı tasarrufla art mirasçı tayin edildiğinde, ön mirasçı tasarrufta asli ve doğrudan zilyettir[26]. Asli zilyedin sadece bir kişi olması gerekli değildir; birden fazla kişi aynı eşyaya birlikte zilyet olabilir.

b. Fer'i Zilyetlik

834 TMK m.974 I, asli zilyedi bir sınırlı ayni hak veya kişisel bir hakkın kurulması veya kullanılması için şeyi teslim ettiği kişi olarak tanımlamıştır. Fer'i zilyet, asli olmayan zilyet (unselbständiger Besitz) olarak isim-

---

24 **LEEMANN**, ZGB Art.661, N.9; **STARK**, BK ZGB Art.920, N.6.

25 **STEINAUR**, N.221a; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.110.

26 **STARK**, ZGB Art.920, N.45; **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N.82; 920, N. 22

lendirilmektedir. Fer'i zilyetliği niteliğine uygun olarak *zilyet aracısı* (Besitzmittler) olarak da ifade etmekteyiz[31].

835 Fer'i zilyet, bir kişinin bir eşya üzerinde malik olmaksızın, zilyetliğe katılıma ilişkin hukuki bir ilişkiye dayanarak zilyet olmasıdır. Örneğin kişi sahibi bulunduğu kıymetli evrakın yönetimini kıymetli evrak yönetim şirketine bıraktığında, kıymetli evrakın sahibi asli zilyet, yönetim şirketi ise fer'i zilyettir. Fer'i zilyedin mutlaka bir hakka dayanarak -hakkın kurulması ya da yararlanması için- asli zilyedin iradesiyle zilyet kılınması gerekir. Bunun dışındaki bir hukuki ilişkiye veya sebebe dayanan zilyet ise başkası için zilyettir.

c. Başkası İçin Zilyet

836 Eşyaya bağlı zilyet: asli ve fer'i zilyet dışında -yani hak sahibinin zilyetlik iradesine dayanan hukuki bir katılma ilişkisi olmaksızın- sadece başkasının üstün hakkını tanıyarak, eşyada yararlanma hakkı olmadan bir hukuki ilişki sebebiyle eşyaya zilyet olan kişidir. Bunlar kendileri için değil de başkası için zilyettirler[32].

837 Başkası için zilyet olanın karşıt kavramı *kendisi için zilyet olan*dır. Kendisi için zilyet olanlar, bir hakka dayanabilir ya da bir hakka dayanmayabilir. Mülkiyet hakkına dayanıyorsa asli zilyet, bir hakkı kurma ve yararlanmaya ilişkin ise fer'i zilyet söz konusudur. Bunların dışındakilerden kendisi için zilyet olanların haricindekiler genellikle başkası için zilyettir.

838 Başkası için zilyet, eşya üzerinde bir ayni veya kişisel hak talebi olmaksızın, eşya üzerinde fiili hakimiyet sahibi olan kimsedir. Başkası için zilyet, asli zilyet ve fer'i zilyet dışında kalan kişileri kapsar.

839 Fer'i zilyet, kendi lehine bir hakkın kurulması veya kendi yararlanma amacı ile zilyet olanlar olarak belirlediğimizden, bu amaçlar dışında zilyet olanlar başkası için zilyettir. Örneğin vekil, taşıyıcı, tamirci vb.

840 Başkası için eşyayı kullanan hizmet zilyetleri de başkası için zilyettir. Başkası için zilyet, kendi zilyetliğinin korunmasını talep edemez; başkası adına zilyetliğin korunması hükümlerinden yararlanır[33].

---

31 **STARK**, BK ZGB Art.920, N.7.

32 Doktrinde başkası için zilyet nitelemesine gerek görmeyen bir görüş de bulunmaktadır. Bkz. **AYBAY/HATEMİ**, s.42; **ESENER/GÜVEN**, s.14; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞULU/ ALTOP**, s.64, dn. 10a; **NOMER/ERGÜNE**, s.13.

33 **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s.65; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.113.

4. Hukuki Sonuçları

a. Temel Sonuç: Asli Zilyedin Fiili Hakimiyeti Sona Erse Bile Fer'i Zilyetle Birlikte Zilyet Olması (Fiksiyon Zilyet)

841 Asli zilyet olan malik veya ondan zilyetliği alıp, sonra devreden fer'i zilyetler, fiili hakimiyet sahibi olmasalar da bu kişiyle birlikte, birlikte zilyet sayılırlar. TMK m.984, asli zilyedi, zilyetliğin olguları olmasa da fiksiyon (varsayım) olarak fer'i zilyetle birlikte zilyet olarak kabul etmiştir. TMK m.984.I hükmü "*ikisi de zilyet olurlar*" demek suretiyle ifade etmiştir.

842 Asli zilyet ve fer'i zilyet, üçüncü kişilerin ihlallerine karşı ayrı ayrı zilyetliğin korunmasından yararlanırlar[34]; kendileri lehine olan hak karinesinden de kendi hakları için yararlanırlar. Asli zilyet mülkiyet karinesinden; sınırlı ayni hak sahipleri ve eşyaya bağlı hak sahipleri ise kendi haklarına ilişkin olarak hak karinesinden yararlanırlar.

b. Eşler Arasında

843 Bir eşin asli zilyet olup olmadığı o eşyanın evlilik ilişkisinde geçerli olan mal rejimine göre onun birlikte mülkiyet hakkı olup olmamasına göre belirlenir. Mal rejimine göre, örneğin mal ayrılığında, malik olmayan eş, evlilik ilişkisi sebebiyle fer'i zilyettir.

844 Kademeli zilyetlik dışındaki zilyetlik çeşitleri içinde eşlerin durumu, eşler arasında geçerli olan mal rejimi ve bu rejime hâkim olan mülkiyet sisteminden bağımsız olarak, eşlerin zilyet ilişkisine katılımlarına göre eşlerin zilyetlik durumları belirlenir. Örneğin, eşlerin doğrudan zilyetliği veya dolaylı zilyetliği mal rejiminden bağımsız olarak belirlenir.

845 Birlikte zilyetliğin mal rejiminin hukuki durumuna uyumlu olması zorunlu değilse de eşler arasında geçerli olan mal rejiminin hukuki esasları eşlerin zilyetlik ilişkilerini ve durumunu ortaya koyar. Örneğin, mal ortaklığında eşler birlikte malik olduklarından kural olarak da birlikte zilyettirler. Ancak eşler hakimiyeti kullanım şekline göre farklı zilyetlik durumlarında da olabilirler.

---

[34] **STARK**, BK ZGB Art.920, N.31. Aksi görüş için bkz. **HOMBERGER**, ZGB Art.920, N.13.

c. Ön Mirasçı - Art Mirasçı

846 Ön mirasçı, yalın tek başına zilyettir; fer'i zilyet değildir[35]. Ön mirasçının, eşyayı art mirasçıya geçirme yükümlüğü olduğu anda, intikal küllî olmadığından, ön mirasçı yükümlülüğünü yerine getirene kadar yine malik olduğundan aslî zilyet sıfatına sahiptir.

d. Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesinde

847 Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinde, sözleşme konusunun mülkiyet sahibi asli zilyet, devralan ise fer'i zilyettir. Sözleşmenin resmi şekilde düzenlenerek bir sicile kaydedilmesi de aslî zilyet olarak malik haklarının aleniyetini sağlamaktadır (TMK m.764).

IV. KENDİSİ İÇİN ZİLYET - BAŞKASI İÇİN ZİLYET

848 Zilyetliğin kimin adına, kim için, hangi amaçla kullanıldığına ilişkin yapılan ayrımdır:

- Kendisi İçin Zilyet,
- Başkası İçin Zilyet.

849 Kendisi için zilyetlik ve başkası için zilyetlik temel ayrımı, zilyetliğin hakka dayanıp dayanmamasına veya ayni hak (malik) sıfatıyla zilyet olunup olunmamasına göre yapılan bir ayrım değildir. Zilyetliğin, yani fiili hakimiyet ve hakimiyet iradesinin zilyedin kendisi için mi yoksa başkası için mi olduğuna ilişkin yapılan bir ayrımdır.

A. Kendisi İçin Zilyet

1. Genel Olarak

850 Zilyetliğin yani eşya üzerindeki fiili hakimiyet ve hakimiyet iradesinin zilyedin kendisi için olduğu zilyetlik, kendisi için zilyetliktir (Eigenbesitz)[36].

851 Asli zilyet, yani malik, kendisi için zilyettir. Kendisi için zilyedin zilyetliği, malik sıfatıyla zilyetlik veya başka bir ayni hakka ya da kişisel hakka dayanan zilyetlik şeklinde belirebilir. Başkası için zilyetlik, mülki-

---

[35] STARK, BK ZGB Art.920, N.45.

[36] OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s.65; ÜNAL/ BAŞPINAR, s.112; ERTAŞ, s.31, 36-37.

yet dışındaki bir ayni hakka veya kişisel hakka dayandığında fer'i zilyetlik olarak, değişik derecelerde hizmet zilyetliği olarak karşımıza çıkabilir. Yine kendisi için zilyet, eşyaya doğrudan veya dolaylı zilyet olabilir. Yani, doğrudan veya dolaylı zilyet sıfatının edinilmesi, kendisi için zilyet olmaya engel değildir.

2. Ayni Hak (Malik) Sahibi Sıfatıyla Zilyet - Başka Sıfatla Zilyet

852 Zilyedin, fiili hakimiyetine ilişkin davranışı yanında ayrıca ayni hak sahibi, örneğin malik sıfatıyla davranıp davranmamasındaki tutumuna göre, ayni hak sahibi (malik) sıfatıyla zilyet ve başka bir sıfatla zilyet ayrımı yapılmaktadır[27]. Zilyet, bir eşya üzerinde mülkiyet hakkı veya başka bir ayni hakkı olmadığı halde bu sıfatlarla zilyetliği elinde bulundurması durumunda ayni hak (malik) sahibi sıfatıyla zilyettir. Bunun dışındaki zilyetlik başka sıfatla zilyetliktir.

853 Burada önemli olan zilyedin gerçekten ayni hak sahibi, malik olması değil, zilyedin ayni hak sahibi (malik) sıfatıyla ayni hakla olan ilişkisindeki davranışlarıdır. Örneğin hırsız da malik sıfatıyla zilyet olarak davranabilir.

854 Ayni hak sahibi (malik) sıfatıyla zilyetlik, özellikle zamanaşımı bakımından önem taşır. TMK, zilyetliği altındaki eşyanın mülkiyetinin kazanılması için kanunda belirlenen sürenin ayni hak sahibi (malik) sıfatıyla tamamlanmasına bağlamıştır (TMK m.712-713, 777). Yani eşyanın mülkiyetinin zamanaşımı yoluyla kazanılmasının hukuki olgularından biri malik sıfatıyla zilyetliktir.

B. Başkası İçin Zilyet

855 Başkası için zilyet ile başka sıfatla zilyedi birbirinden ayırmaktayız. Başka sıfatla zilyetlikte, zilyet, ayni hak (malik) sıfatı dışında başka bir tutum ve davranışla eşyaya zilyettir. Başkası için zilyette ise, zilyedin eşya üzerindeki zilyetliği kendisi için değildir; onun zilyetliği fer'i zilyetliğin bir derecesinde zilyet veya hizmet zilyedi şeklindedir.

V. BÜTÜN (TAM) ZİLYET – KISMİ ZİLYET

856 BGB § 865 kısmi zilyetliği örnek vererek düzenlemiş; kısmi zilyedin zilyetliğin korunması hükümlerinden (BGB §§ 858 ve 864) yararlanabi-

[27] OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s. 62; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 119; AYAN, s. 88.

leceğini hüküm altına almıştır. Eşyanın belirli bir kısmında, özellikle binanın bir kısmında, evin bir odasında kısmi zilyetlik (Teilbesitz) söz konusu olabilir.

857 Kısmi zilyetlik, tüm zilyetlik çeşitleri (asli-fer'i, dolaysız-dolaylı, birlikte-tek başına zilyetlik) olarak karşımıza çıkabilir. Kısmi zilyedin zilyetliği, eşyanın maddi olarak bir kısmındaki fiili hakimiyettir. Birlikte zilyetlikten bu yönüyle ayrılır.

858 Kısmi zilyetlik, eşyanın mekânsal olarak sınırlandırılmış maddi bir kısmında veya asıl eşyaya bağlı eklenti ya da bütünleyici parçada ortaya çıkar. Örneğin, taşınmazın üzerindeki bir binadaki, bir binanın bir katındaki, bir dairenin bir odasındaki, apartmanın park alanındaki, binanın terasındaki, çatıdaki antenin üzerindeki zilyetlik böyledir.

859 Kısmi zilyedin korunması için, bir eşyanın mekansal olarak belirlenmiş maddi bir kısmında zilyedin fiili hakimiyeti söz konusu olmalıdır. Bununla birlikte üç oda bir salon konutu birlikte kiralayan üç öğrenciden örneklersek, öğrenciler kendi aralarındaki bölüşüme uygun olarak fiilen kullandıkları odalarda, tek başına kısmi zilyet; antre, mutfak, salon, balkon, banyo ve diğer ortak yer ve eşyalarda birlikte zilyettirler.

860 Kısmi zilyet, zilyetliğin ihlaline karşı korunmada, bütün (tam) zilyedin zilyetliğinin ihlalindeki korumanın aynısına sahiptir; tam zilyetliğin korunmasına ilişkin imkanların tümünden kısmi zilyet de yararlanır.

VI. HAKKA DAYANAN ZİLYET – HAKSIZ ZİLYET

861 Bu ayrım; eşya üzerindeki fiili hakimiyetin hakka dayanıp dayanmadığı, yani zilyetliği sağlamaya yetki veren bir hakkın bulunup bulunmamasına göre yapılan bir ayrımdır[23].

A. Hakka Dayanan Zilyet

862 Hakka dayanan zilyetlikte, zilyedin eşyadaki fiili hakimiyeti hakka dayanmakta, yani kişiye eşyada zilyetliği sağlamaya yetki veren bir hak bulunmaktadır. Örneğin, taşınırı rehin sözleşmesi ile teslim almış rehin alan, konutu kira sözleşmesi ile kiralayan kiracı haklı zilyettir.

---

[23] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.62; NOMER/ERGÜNE, s.15; ÜNAL/ BAŞPINAR, s 119; AYAN, s. 89

B. Haksız Zilyet

1. Genel Olarak

863 Hakka dayanmayan zilyetlikte, eşyadaki fiili hakimiyet hakka dayanmamakta, yani kişiye eşyada zilyetliği sağlamaya yetki veren bir hak bulunmamaktadır. Örneğin, eşyayı gasp eden veya hırsız haksız zilyettir.

864 Hakka dayanan zilyetlikte, zilyetliğin dayandığı hakkı doğuran hukuki ilişkinin herhangi bir sebeple geçersiz olduğu durumlarda, eşyayı iade etmeyen, geçersizlik anı itibarı ile yine haksız zilyettir[39].

865 Hakka dayanan zilyetliğin sona erdiği durumlarda ise, katıldığımız görüş uyarınca; ayni hak görüşünü benimsemediğimizden ve eşyanın iadesine yönelik geri verme ilişkisi mevcut olduğundan, istihkak davası ve bununla bağlantılı zilyetliğin iadesi hükümleri uygulanmaz[40].

866 İyiniyetli haksız zilyet – kötü niyetli haksız zilyet ayrımı, haksız zilyedin iyiniyetli olup olmamasına göre yapılan ayrımdır[41]. Başka bir deyişle, haksız zilyedin, zilyetliğinin hakka dayanıp dayanmadığını bilip bilmemesine göre de iyiniyetli haksız zilyet ve kötü niyetli haksız zilyet ayrımı yapılmaktadır.

2. Çeşitleri

867 TMK m.3, Kanunun iyiniyete sonuç bağladığı hallerde uygulama alanı bulur[42]. İşte kanunun iyiniyete sonuç bağladığı hallerden biri de haksız zilyetliktir. Buna göre, haksız zilyedin iyiniyetli veya kötüniyetli olmasına göre hakkında uygulanacak hükümler değişecektir.

868 TMK iyiniyete, haksız zilyedin geri verme borcunun kapsamını belirlemede (TMK m. 993-995) kısmi koruma, zamanaşımı ile ayni hak kazanımında (TMK m.712, 777) ise tam koruma sağlamıştır. Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanımında ise iyiniyet aranmamaktadır (TMK m.713).

---

[39] **ANTALYA**, BH GH. II, s. 594.

[40] **ANTALYA**, BH GH. II, s. 578.

[41] İyiniyet kavramı için bkz. **ANTALYA/TOPUZ**, s. 323 vd.

[42] İyiniyetin uygulama alanları için bkz. **ANTALYA/TOPUZ**, s. 337 vd.

a. İyiniyetli Haksız Zilyet

869 İyiniyetli haksız zilyet, eşya üzerindeki haksız zilyetliğini bilmiyor veya somut olayın özelliklerine göre bilemeyecek durumda olan kişidir.

b. Kötüniyetli Haksız Zilyet

870 Kötüniyetli haksız zilyet, eşya üzerindeki haksız zilyetliğini bilen veya somut olayın özelliklerine göre bilebilecek durumda olan kişidir.

VII. TEK BAŞINA ZİLYETLİK – BİRLİKTE ZİLYETLİK

A. Tek Başına Zilyetlik

871 Tek başına zilyet (Alleinbesitz), kişinin bir eşya üzerinde belirli bir nitelikte, bu nitelik ister doğrudan ister dolaylı zilyet, hatta ister asli ister ferî zilyet olarak bulunsun, tek başına zilyet olmasını ifade eder[43]. Tek başına zilyetlik "münhasır zilyetlik" olarak da isimlendirilmektedir[44]. Zira hangi nitelikte olursa olsun, hangi derecede olursa olsun, o nitelikteki, o derecedeki zilyetlik tek kişiye aittir[45].

B. Birlikte Zilyetlik

1. Genel Olarak

872 Birlikte zilyet (Mitbesitz), tek başına zilyedin tam tersine, aynı eşya üzerinde birden çok kişinin belirli, aynı zilyetlik niteliğinde olmak üzere zilyet bulunmasıdır[46]. Birlikte zilyetlik yerine "toplu zilyetlik" terimi de kullanılmaktadır[47].

873 Birlikte zilyetlik, dereceli (kademeli) zilyetlikten farklıdır. Dereceli zilyetlikte birden fazla kişinin zilyetliği nitelikleri yönünden farklı derecelerde zilyetlik olarak çeşitlendirilmiştir.

---

[43] HINDERLING, SPR VI/1, s. 549; STEINAUER, I, N.217; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N.115; ÜNAL/ BAŞPINAR, s.108.

[44] OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s.67; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 108.

[45] OĞUZMAN/SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s.67; AKİPEK/ AKINTÜRK, s. 129; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 109.

[46] HINDERLING, SPR VI/1, s.549; STEINAUER, I, N.217; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N.115; ÜNAL/BAŞPINAR, s.108. Farklı bir tanım için bkz. STARTK, BK ZGB Art.919, N.55.

[47] AYAN, s. 81; AYBAY/HATEMİ, s.50, topluca zilyet terimi kullanmaktadır.

874 Dereceli zilyetlikte (asli-fer'i zilyetlikte, dolaylı-dolaysız zilyetlikte), zilyetlik değişik açılardan alttan üste doğru kademelendirilmiştir. Her zilyetlik çeşidi içinde, örneğin fer'i zilyetlik derecesinin kendi içinde birlikte zilyetlik kurulması söz konusu olabilir[42].

875 Birlikte zilyetliğin üç temel alt çeşidi söz konusudur[43]: Elbirliği ile zilyetlik, Paylı zilyetlik ve Yan zilyetlik. Yine belirtmek gerekir ki, birlikte zilyetliğin dereceli zilyetlikle birlikte farklı kombinasyonları da söz konusu olabilir[45].

2. Ayrılması ve Mülkiyet Çeşitleriyle Olan İlişkisi

876 Kural olarak, her elbirliği ile malikin elbirliği ile zilyet, her paylı malikin paylı zilyet olduğu anlamına gelmez. Örneğin, birden fazla kişinin - elbirliği veya paylı malik olması fark etmeksizin- malik oldukları daireyi, sadece bir kişi kullanıyorsa, yalın, doğrudan tek başına zilyetliği, diğerlerinin dolaylı zilyetliği söz konusudur[47]. Yine aracın garaj anahtarı ve araç anahtarına sahip kişiler, araca elbirliği ile malik olsalar da paylı zilyettirler.

877 Elbirliğiyle zilyet ile paylı zilyedin birbirinden ayrımı eşya üzerindeki hakimiyetin fiilen maddi olarak kullanılış şekli ve özelliği ile belirlenir[52]. Elbirliği ile maliklerden her birinin diğerinden bağımsız olarak eşya üzerinde ayrı ayrı hakimiyetleri söz konusu ise ve eşyayı bu şekliyle kullanıyorlarsa, elbirliği ile zilyetlik değil, paylı zilyetlik söz konusu dur.

878 Ayrımın ölçüsü fiili kullanımdır; bu sebeple mülkiyet ilişkisinden bağımsız değerlendirme yapılması gerekir. Ancak bu görüşe kanundan doğan bazı istisnalar tanımak gerekir. Kanun gereği malik sıfatına bağlı olarak belirli eşyada doğrudan zilyetlik sağlarmışsa, kanun malikler arasındaki mülkiyet çeşidine uygun olarak zilyetlik çeşidi oluşturabilir. Örneğin, Miras ortaklığına dahil mirasçıların zilyetliği kanun gereği - *ipso iura*- fiksiyon olarak elbirliğiyle zilyetlik şeklinde gerçekleşir. Tereke üzerindeki mülkiyet de TMK m. 640 II gereği elbirliği ile mülki-

---

[42] **ERNST**, BSK ZGB Art.919. N.40 f.

[43] **STARK**, BK ZGB Art.919. N.53 f.

[45] Farklı kombinasyonlar için bkz. **STARTK**, BK ZGB Art.919. N.56.

[47] **HINDERLING**, SPR VI/1. s.42. **MEIER-HAYOZ**, BK ZGB Vorbem zu Art.646-654. N30. Bkz. BGE 69 II 366.

[52] **STARK**, BK ZGB Art.919. N.53 f.

yettir. Bu sebeple, kural olarak terekede elbirliği ile zilyetlik söz konusudur[53].

879 Yine kat mülkiyetinde bağımsız bölüm maliklerinin ortak yerlerdeki zilyetlikleri, malıklık niteliğine -mülkiyet çeşidine- paralel olarak, kendi payları oranında paylı zilyetlik şeklindedir.

3. Çeşitleri

a. Elbirliği (İştirak Halinde) Zilyetlik

880 Birden fazla kişinin eşyadaki zilyetliği fiili hakimiyeti birlikte kullanmalarını gerekli kılıyorsa -yalnızca birlikte kullanabiliyorlarsa- elbirliği ile zilyetlik söz konusudur[54]. Örneğin banka kasa sözleşmesine göre, müşterinin anahtarı ile banka görevlisinin anahtarı aynı anda kullanıldığında kasa açıldığından, elbirliğiyle zilyetlik söz konusudur[55]. Bankanın kasa anahtarı kullanması, kasa zilyedinin güvenliğine hizmet ettiğinden hizmet zilyetliği olarak da nitelenebileceğini burada belirtelim[56].

b. Paylı (Müşterek) Zilyetlik

881 Paylı zilyetlikte ise, elbirliği ile zilyetliğin tam tersine, zilyetlerden her biri, diğerinin veya diğerlerinin katkısı olmaksızın o şey üzerindeki zilyetliği tek başına kullanabilmektedir[57]. Örneğin birlikte zilyet olanlardan her biri diğerinin anahtarına ihtiyaç duymaksızın kasayı kendi anahtarı ile açabiliyorsa, paylı mülkiyet söz konusudur.

882 Paylı zilyetlikte zilyetler, hakimiyeti ne tek başlarına ne de parçalı olarak sadece paylarında zilyet olacak şekilde yürütmektedirler. Onlar, fiili hakimiyeti çoklu olmak üzere, her biri taşınmazın tamamında hakimiyet sahibi olarak zilyettir[58].

883 Paylı zilyetlerin yetki ve hakları, zilyetliğin niteliğinde farklılık yaratmaz. Örneğin paylı malikler, paylı zilyet olmak zorunda değildirler;

---

[53] Aksi görüş için bkz. **STEINAUER**, I. N.232 ff. **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.117.

[54] **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.117a; **STARK**, BK ZGB Art.919, N.54; **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.919/3, N. 4; **JENNY**, s.138 f.; **DÜRING**, s.79 f.

[55] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.919, N.12.

[56] Bu konuda bkz. **STARK**, BK ZGB Art.919, N.60 f.

[57] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.919, N.12; **MEIER-HAYOZ**, BK ZGB Vorbem zu Art.646-654, N.29 f.; **HINDERLING**, SPR VI/1, s. 420; **STARK**, BK ZGB Art.919, N.53 f.; **ERNST**, BSK ZGB Art.919/3, N.39; **JENNY** s.135 f.; **DÜRING**, s.75 f.

[58] **WOLFF/RAISER**, s.38; **JENNY**, s. 134.

paylı maliklerin bir kısmı paylı zilyet olabilirler, hatta tek başına zilyet olabilirler; hatta elbirliğiyle zilyet dahi olabilirler.

884 Paylı maliklerin paylı zilyet, elbirliği ile malik olanların elbirliği zilyet olması hayatın olağan akışına uygundur. Bu nedenle örneğin, eşler kural olarak aile konutundaki eşyalarda paylı zilyettirler.

c. Yan Zilyet

885 İsviçre hukukunda, Alman hukukunda olduğu üzere[59], birden fazla kişinin yan zilyetliğinin (Nebenbesitz) mümkün olup olmadığı tartışılmaktadır. İki dolaysız veya dereceli zilyedin zilyetliği birbiri ile irtibatlandırılarak, birlikle aynı eşya üzerinde fiili hakimiyetlerinin olması yan zilyetliği ifade etmektedir[60].

886 Örneğin asli zilyetle birlikte aynı taşınmazda yaşayan fer'i zilyet kiracılar, ortak banyo ve mutfak eşyalarında yan zilyettirler[61]. Zilyetlikleri paylı yan zilyetliktir. Zilyetlerin zilyetlikleri aynı derecede olmasa da aynı eşya üzerinde birlikte fiili hakimiyet ve kullanımları söz konusudur. Birlikte zilyetlikte zilyetliğin fiilen kullanım şeklinden de aynı sonuca varılmaktadır[62].

887 Yan zilyetliğin uygulaması özellikle mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta görülmektedir.

4. Hukuki Sonuçları

888 Bu ayrımın temel sonucu[63], eşya üzerindeki fiili hakimiyetlerinin paylı veya elbirliği olması, hakimiyetin, özellikle eşyanın kullanımının tümünün birlikte veya birinin veya birkaçının diğerlerinin katılımı olmaksızın gerçekleşmesinde kendini gösterir.

---

59 JOOST, MünchKomm BGB § 868, N.18 ff.

60 DOMEJ, KurzKomm ZGB Art.919, N.17.

61 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s.68.

62 STARK, BK ZGB Art.919, N.58; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.68; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.56; AKİPEK/AKINTURK, s.129; ÜNAL/ BAŞPINAR, s.110.

63 Ceza hukuku bakımından, paylı zilyetlikte paydaşlardan birinin diğerlerinin zilyetliklerini ihlal ederek eşyayı satıp devretmesi halinde, görevi kötüye kullanma suçunu (TCK m.155); elbirliği ile zilyetlikte ise benzer olgu hırsızlık suçunu (TCK m.141) gerçekleştirir. Bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.68; AKİPEK/ AKINTÜRK, s.130; ÜNAL/ BAŞPINAR, s.111. Suçun niteliği özel hukuk bakımından ise fark yaratmaz.

889 İyiniyetli üçüncü kişinin paylı mülkiyet sahibinden iyiniyetli mülkiyet kazanımı mümkün iken, elbirliği ile zilyetten kazanım mümkün değildir. Paylı zilyet, TMK m.988'in aradığı emin sıfatıyla zilyet olabilirken, elbirliğiyle zilyedin bu sıfata sahip olması mümkün değildir[64].

[64] OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s.58; ÜNAL/ BAŞPINAR, s.112

§ 7. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ

I. GENEL OLARAK

890 Bu başlıkta zilyetliğin nasıl kazanılacağı ve nasıl kaybedileceği konusu üzerinde durulacaktır; zira zilyetliğin hangi şartlarda kazanılıp kaybedileceğine kanun -örneğin zilyetliğin korunması, kazandırıcı zamanaşımı bakımından- farklı hukuki sonuçlar bağlamıştır. Bu farklılık özellikle taşınırlarda kendisini daha barız bir şekilde gösterir.

891 Taşınırın mülkiyetinin ve onun üzerinde sınırlı bir ayni hakkın veya rehnin kazanılması, istisnasız olarak, zilyetliğin kazanılmasına, özellikle devren kazanılmasına bağlanmıştır.

892 Taşınırlarda ayni hakkın, özellikle mülkiyetin kazanılmasında zilyetlik temel bir rol oynar. Örneğin TMK m.763 I'e göre, mülkiyet hakkının kazanımı da kural olarak, zilyetliğin devren kazanımı ile birlikte gerçekleşir. Ayni hakkın devren kazanımı, zilyetliğin devren kazanımı ile gerçekleşir. Halihazır zilyet kazanana eşyanın fiili hakimiyetini bilerek ve isteyerek devreder[1].

893 Aynı rol, sınırlı da olsa, zilyetliğin sona ermesiyle mülkiyetin kaybedilmesi arasında da söz konusudur. Ancak, her zilyetliğin kaybının mülkiyetin kaybına sebebiyet vermediği istisnai haller de söz konusudur; taşınırı çalınan yahut kaybeden kişi, taşınırın mevcut zilyedine karşı, önceki zilyedin zilyetliğine dayanarak taşınır davası (TMK m. 989, 991) veya sahip olduğu mülkiyet hakkına dayanarak istihkak davası (TMK m.683) açabilir.

894 Gerçekten, "taşınırın mülkiyeti nasıl kazanılır" sorusu, kural olarak "eşyanın zilyedi kimdir" sorusunun cevabına bağlanmıştır. Zira zilyetliğin devren kazanılması ile mülkiyetin devren kazanılması aynı anda olmaktadır. Zilyetliğin kazanılması teslim veya zilyetlik sözleşmesi ile gerçekleşirken, bu olgular tek başına mülkiyetin devri için yeterli olmamaktadır[2].

---

[1] HAAB/SIMONUS, ZGB Art 714, N.1; STEINAUER, I. N.241; SIMONIUS/ SUTTER, I. § 9. N.20.

[2] ERNST, BSK ZGB Art.922-925, N.3; SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N.131 f.

895 Kanun zilyetliğin yukarıdaki hak sahipliği fonksiyonuna ilaveten zilyetliğe, zilyetliğin korunması ve zilyetlik hakkının korunması şeklinde başka hukuki sonuçlar da bağlamıştır. Kişinin sırf bir eşya üzerindeki zilyetliği kazanması sebebiyle kişiye hukuken koruma yardımı sağlanmaktadır.

896 Zilyetliğin hukuken korunması ilkesi, her zilyedin, örneğin eşyayı çalanın, eşya üzerinde hakimiyeti sebebiyle, onun -örnekte hırsızın- korunmasını gerekli kılmaz. Zilyetliğin hukuken korunması, koruma kurallarının hukuki olgularının belirlediği şekliyle her olay için ayrı ayrı değerlendirilmelidir[3].

II. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI

A. Zilyetliği Kazanma Yolları

1. Genel Olarak

897 Zilyetliğin kazanılması, kural olarak, zilyetliğin olguları olan fiili hakimiyet ve hakimiyet iradesi ile gerçekleşir. Bu olgulardan fiili hakimiyet zilyetliğin kazanılmasında temel rol oynar.

898 Zilyetliğin kazanılması, eşya üzerinde daha önceden zilyetliğin olup olmaması veya daha önceki zilyedin zilyetliğinin sona ermesinden ayrı ve bağımsız olarak zilyetlik olgularının kişide gerçekleşmesi ile kazanılır.

899 Zilyetliği kazanma yolları olarak[4]: **aslen kazanma** (originäre, ursprüngliche, einseitige Besitzeserwerb) ve **devren kazanma** (derivativer, abgeleitete Besitzeserwerb) ayrımı yapılır. Bunlara miras yoluyla kazanmayı da zilyetliğin özel kazanma yolu olarak ilave edebiliriz. TMK m.599 I'in düzenlediği **miras yoluyla zilyetliğin kazanılmasına** yukarıda değinmiş idik[5].

900 Doktrinde, zilyetliğin bu iki kazanma yoluna, *devren* kazanmanın yanında *tesisen* kazanma da ilave edilmektedir[6]. Bu yazarlar, devren kazanmayı önceki zilyetin zilyetliğini bir kimseye bırakması; tesisen ka-

---

[3] **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N. 126.

[4] Roma hukukunda zilyetliğin kazanımı için bkz. **KARAGÖZ**, s. 239 vd.

[5] **ANTALYA**, EH II, N. 116.

[6] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 70-71.

zanmayı ise önceki zilyedin kendisi de zilyet kalmak üzere başka bir kişiye zilyetlik kazandırması şeklinde anlamaktadırlar. Biz de bu ayrımın uygulamada farklılık yaratmadığını dikkate alarak, TMK'nın sistematiğine uygun olarak, tesisen kazanmayı, devren kazanma altında incelemekteyiz[7]. Zira tesisen kazanma zilyedin önceki zilyedin geçerli iradesi ile eşya üzerinde fiili hakimiyeti kazandığı hallerdir.

901 Kazanmanın devren olması halinde, kazandırıcı zamanaşımında, devralan sonraki zilyet, kazandırıcı zamanaşımı için aranan diğer hukuki olgular bulunmak kaydıyla, önceki zilyedin zilyetlik süresini kendi zilyetlik süresine ekleyebilir. Daha önceden eşya üzerinde zilyetlik tesis edilmemiş veya zilyetlik kaybedilmiş, hatta önceki zilyedin zilyetliğinin tanınmaması durumunda, zilyetliğin devren kazanılması değil, asli zilyetliğin kazanılması söz konusudur. Zilyetliğin aslen kazanılması, kazanan ile devredenin her ikisinin hakimiyet iradesi ile gerçekleşir. Hakimiyet iradesi, maddi fiil niteliğinde olduğundan kazananın ayırt etme gücüne sahip olması yeterlidir.

902 **Zilyetliğin devren kazanılması** ise devredenin ve devralanın katılımı, yani zilyetlik iradeleri, zilyetliğin teslimi ve zilyetlik devrinde anlaşma veya teslimsiz zilyetlik sözleşmesi ile gerçekleşir. Zilyetliğin devri için, zilyetlik konusu **eşyanın teslimi** veya eşyada hakimiyeti sağlayan **araçların teslimi** yanında, tarafların zilyetliğin devri konusunda anlaşmaları da gerekir. Zilyetliğin devri anlaşması için maddi -fiil- anlaşma niteliğinde zilyetliğin, hakimiyetin devrinde uzlaşma yeterlidir. Zilyetlik anlaşmasının taraflarının ayırt etme gücüne sahip olması yeterlidir. Teslimli zilyetliği devreden ve devralan TBK m. 978 anlamında temsilci benzeri aracılığıyla teslimi gerçekleştirebilirler.

903 **Zilyetliğin teslimsiz kazanılması**, yani *açıktaki eşyanın zilyetliğinin kazanılması, kısa elden teslim, zilyetliğin havalesi* ve *hükmen teslim* ile zilyetliğin kazanımının sözleşme (hukuki işlem) niteliğinde olduğu **zilyetlik sözleşmesi** ile gerçekleşir. Zilyetlik sözleşmesi taraflarının fiil ehliyetlerinin bulunması gerekir. Zilyetlik sözleşmesi tarafları TBK m.40 vd. anlamında temsilci ile temsil edilebilir.

904 **Eşyayı (emtiayı) temsil eden kıymetli evrakın devri** de özel bir devir şekli olarak TMK m.980 hükmünde düzenlenmiştir. Kazananın zil-

[7] TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 68 dn. 1a; NOMER/ ERGÜNE, s. 21.

yetlikten doğan hukuki durumu için asli kazanım ve devren kazanım ayrımının anlamsız olduğu söylenebilir. Zilyetliğin kazanımı -diğer hukuki olguların gerçekleşmesi ile birlikte- ayni hakkın kazanımı sonucunu doğurmaktadır ki, ayni hakkın kazanımı sadece zilyetliğin devren kazanımı ile gerçekleşmektedir[8].

2. Aslen Kazanma

a. Kavram

905 Aslen kazanma, TMK hükmünde düzenlenmemişse de TMK m.973 I'deki zilyetliğin hukuki olgularından çıkarılabilen bir zilyetliğin kazanma şeklidir.

906 Aslen kazanma, kişinin, bir eşya üzerinde önceki zilyetten zilyetliği devir alma iradesi olmaksızın, kendi zilyetlik iradesi ile o eşya üzerindeki fiili hâkimiyeti sağlamasıdır[9]. Örneğin, evinin bahçesinde gömülü olarak bulduğu Bizans sikkeleri, balıkçının avladığı balıklar vb.

907 Buluntu örneğinde olduğu üzere, zilyetliğin aslen kazanımı haklı iken, hırsız veya gaspçının zilyetlik kazanımı asli kazanım olduğu halde haksız kazanımdır. Zilyetliğin haklı ya da haksız kazanımı ayrımı özellikle kendini zilyetliğin korunması ve zilyetliğin hak karinesi olarak korunmasında önem arz eder. Zilyet, sahipsiz eşyalarda, örnekte sikkeler veya balıklar üzerindeki zilyetliği aslen kazanmıştır. Aslen kazanma sadece sahipsiz şeylerin zilyetliğinin kazanılmasında uygulama alanı bulmaz. Eşyanın daha önce zilyedi olsa bile, yeni zilyedin kazanımı aslen kazanma şeklinde gerçekleşebilir.

b. Hukuki Olguları

908 TMK zilyetliğin aslen kazanılmasını düzenlemediğinden, zilyetliğin aslen kazanılmasının hukuki olgularını TMK m.973 I hükmündeki zilyetliğin hukuki olgularından hareketle belirleyebiliriz[10]. Zilyetlik unsurlarına paralel olarak aslen kazanmanın iki hukuki olgusu söz konusudur:

---

[8] **STARK**, BK ZGB Art.920, N.17.

[9] **STARK**, BK Vorb. N.5.

[10] **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N. 133 ff. **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY- ÖZDEMİR** 69; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s.144. **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 123.

aa. Objektif Unsur

909 Objektif unsur, zilyedin eşya üzerinde fiili hâkimiyeti kurması gerektiğini ifade eder. Zilyedin zilyetliği dış dünya tarafından, ticari ve yaşam ilişkilerine göre üçüncü kişilerce objektif olarak hâkimiyet fiili olarak gerçekleşmelidir. Bu konuda, zilyetliğin hukuki olgularından fiili hâkimiyete atıfta bulunmakla yetineceğiz[1].

bb. Subjektif Unsur: Aslen Kazanma (Hâkimiyet) İradesi

910 Subjektif unsur, zilyedin, eşya üzerindeki fiili hâkimiyeti kendisi için istemesine ilişkin iradesini ifade eder. Eşya üzerindeki fiili hâkimiyeti sağlayan zilyet, zilyetliği devralmak istememekte, kendisi için zilyet olmak istemektedir.

911 Zilyetlik iradesinin yine hukuki işlem iradesi olmadığını, maddi fiil niteliğinde, hâkimiyet iradesi olduğunu söylemeliyiz. Bu iradeyi *aslen (hâkimiyet) kazanma iradesi* olarak isimlendirebiliriz.

912 Zilyetlik (hâkimiyet) iradesinde olduğu üzere, zilyetliğin kazanımı kabul, *maddi fiil*cir (realakt)[2], hukuki işleme ilişkin kurallar uygulama alanı bulmaz. Bu niteleme farkına paralel olarak, hâlihazır zilyedin ayırt etme gücünün mü[3] yoksa fiil ehliyetinin mi[4] bulunması gerektiği doktrinde tartışmalıdır. Bu tartışma zilyetlığın niteliğine ve kabul edilen hukuki olgularına göre farklılık göstermektedir.

913 Biz, zilyedin zilyetlık (hakimiyet) olgusunda kabul ettığımız şekliyle, maddi fiil görüşüne uygun olarak, zilyedın ayırt etme gücünün bulunmasını yeterli görmekteyiz[5].

914 Zilyetliğin aslen kazanılmasında, önceki zilyedin kabulü veya kabul edenin yetkili bulunması gerekli değildir. Diğer konularda, zilyetliğin hukuki olgularından zilyetlık (hakımiyet) iradesine atıfta bulunmakla yetineceğiz[6].

---

[1] **ANTALYA**, EH II, 65 vd.

[2] **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 123; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 144; **AYAN** s.93.

[3] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.83.

[4] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.83; **STEINAUER**, I, N.189, 245; **SCHMID/ HÜRLIMANN- KAUP**, N. 136.

[5] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY- ÖZDENİR**, s.62; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 123.

[6] **ANTALYA**, EH II, N. 82 vd.

c. Zilyetliği Haklı Aslen Kazanma – Zilyetliği Haksız Aslen Kazanma

915 Zilyetliğin aslen kazanılması haklı kazanma veya haksız kazanma şeklinde gerçekleşebilir. Zilyetliği haklı ve haksız kazanma üzerinde yukarıda durmuş idik[17]. Haksız aslen zilyetliği kazanmanın tipik örneği hırsızın çaldığı eşyadaki zilyetliğidir. Hırsız çaldığı eşya üzerindeki zilyetliği aslen kazanır.

916 TMK haklı zilyetliğin kazanılmasını mülkiyeti haklı kazanma şekilleri olarak düzenlemiştir. TMK'nın bu düzenlemelerinden hareketle, zilyetliğin asli haklı kazanma şekillerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

- Sahipsiz taşınır sahiplenme (TMK m. 767- 768),
- Bulunan eşya (TMK m. 769),
- Define (TMK m. 772),
- Düşen ve sürüklenen şeyler (TMK m. 774),
- Taşınmazı işgal (TMK m. 707),
- Olağanüstü zamanaşımı (TMK m. 713).

917 Zilyetliğin aslen haklı olarak kazanılamaması halinde, haksız zilyedin zilyetliğinin korunması ve zilyetlik sebebiyle hakkının korunması söz konusu olmaz.

3. Devren Kazanma

a. Kavram

918 TMK zilyetliğin sadece devren kazanılmasını TMK m.977 ile 980 arasında "Zilyetliğin Devri" başlığında düzenlemiştir. Bu düzenlemelere göre yapılan zilyetlik devirlerinin geçerli ve hukuki sonuç doğuracağını düzenlemiştir.

919 Zilyetliğin devren kazanılması, yani önceki zilyetlikten elde edilen zilyetlik kazanımı, dış dünyada önemli hukuki ve pratik hukuki sonuçlar doğurur. Özellikle taşınır mülkiyetinin geçmesi, zilyetliğin devren kazanımı ile gerçekleşir (TMK m. 763; TBK m. 279). Yine taşınırlarda intifa

[17] ANTALYA, EH II. N. 289. 290.

hakkı veya rehin hakkının kurulması, konusu olan eşyanın zilyetliğinin devren kazanılması ile gerçekleşir (TMK m. 795/1, m.939).

920 Zilyetliğin devren kazanılması ile taşınır mülkiyetinin kazanılması her zaman aynı anlama gelmemektedir. Buna rağmen TMK uyarınca, kural olarak, prototip olarak, taşınır zilyetliğinin devri, taşınır mülkiyetinin devri sonucunu doğurur[18]. Ancak zilyetliğin devrinin gerçekleşmesi mülkiyetin devrinin tek başına gerçekleşmesini sağlayan hukuki olgudur; tek olgu değildir[19].

921 Taşınır zilyetliğinin devri ile mülkiyetin devri arasında paralellik söz konusudur. Bu sebeple, kural olarak, her iki taraf da zilyetliği devralan ile devreden sıfatıyla birlikte, başka bir sıfatla olarak mülkiyeti devreden ve mülkiyeti devralan olarak, zilyetliği kaybeder ve kazanır ve ona paralel olarak mülkiyeti kaybeder ve kazanır. Ancak hemen belirtilmelidir ki, taşınır mülkiyetinin başka kazanma yolları da söz konusudur.

922 Devren kazanma, aslen kazanmadan farklı olarak, halihazır zilyedin tek başına ya da onun yanında veya birlikte, önceki zilyedin iradesiyle eşyanın zilyetliğini elde etmesi, devren kazanmadır. Örneğin, satıcının satılanı alıcıya teslim etmesi, kiraya verenin kiracıya kiralananı kullandırmaya başlaması gibi.

b. Zilyetliğin Devri ile Mülkiyetin Devri Arasındaki İlişki

923 Uygulamaya baktığımızda ise, zilyetliğin devrinin ayni hakkın devri amacıyla birlikte yapıldığını görmekteyiz. Mülkiyetin devredildiğine ilişkin, özellikle taşınırın mülkiyetinin devrine ilişkin tarafların irade uyuşmasının, mülkiyetin devrinin sebebini teşkil eden borçlandırıcı (sebep) işlemden mi ya da yoksa bizzat tek başına eşyanın tesliminden mi yahut bunlardan ayrı bir ayni uzlaşma mı (ayni sözleşme mi veya ifa anlaşması mı) olması gerektiği doktrinde tartışılmaktadır[20].

924 Mülkiyetin devren kazanılmasında, bu kazanmanın zilyetliğin devriyle ve sınırlı ifa sözleşmesiyle ilişkisi[21] ayrıca değerlendirilecektir. Kı-

---

18 **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N. 130.

19 **ERNST**, BSK Vorbem zu ZGB Art.922-925, N. 3 f; **BERGER-STEINER/SCHMID**, OFK ZGB Art.922, N.1; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N. 131 f.

20 Bu tartışmalar için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.922, N.16 ff; **SCHWANDER**, BSK, ZGB Art.714, N.5 ff.

21 Sınırlı ifa sözleşmesi görüşü için bkz. **ANTALYA**, BH GH III, s. 9.

saca belirtelim ki, teslim, *zilyetliğin devri anlaşması* ile zilyetliğin devrinde, *ifa sözleşmesi* (Erfüllungsvertrag) olarak verme borcunun yerine getirilmesinde ve *ayni sözleşme* (dinglicher Vertrag) olarak mülkiyetin devrinde rol oynar.

925 Bu yaklaşımların uygulamaya yansıması da söz konusudur: Teslim anında iradelerin uyuşması, kazanım için gereklidir. Yine asli zilyetlik kazananın hukuki durumundaki sakatlık, önceki zilyedin sonradan vereceği rıza ile giderilebilmektedir.

926 Şu hususa dikkat etmek gerekir ki, zilyetliğin devren kazanılması, kural olarak, görüşümüze göre hükmen teslim hariç, onun ilgili olduğu hukuki işlemin geçerliliğine bağlı değildir[22]. Yine belirtmek gerekir ki, zilyetlik anlaşmasında irade uygunluğunun sebep işlemi (Kausalgechäft) içinde birlikte mi gerçekleştiği yoksa teslim esnasında veya öncesinde açık veya örtülü olarak iradenin açıklanması mı gerektiği her somut olay için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

927 Zilyetliğin teslimle devredilebilmesi için tarafların zilyetliğin devrinde anlaşması yeterlidir. Kural olarak, zilyetliğin devrinde anlaşma ile devredilen zilyetliğe konu eşya üzerindeki ayni hak da kazanılır. Ayni hakkın zilyetliğin devredilmesiyle birlikte zilyede geçmesi kuraldır: bunun içinde ayni hakkı devir konusunda ayrıca tarafların iradelerinin uygunluğu bulunmalıdır. Bu noktada, teslimde, tarafların, hatta bir görüşe göre sadece teslim edenin ayırt etme gücü yeterli olduğu halde, ayni uyuşmada her iki tarafın geçerli bir hukuki işlem iradesi ve fiil ehliyetinin bulunması gerekir.

928 Eşyanın teslimi tek başına aynı anda eşyanın mülkiyetinin devrini gerçekleştirmez; eşyanın teslimi konusunda anlaşma -sözleşme- olmadığından hukuki işlem niteliği taşımaz: hukuki işlem niteliğini taşımadığından da aynı hakkın devri konusundaki uyuşmayı – ayni sözleşmeyi – gerçekleştirmez: eşyanın teslimi maddi -fiil- niteliğinde bir anlaşmadır[23]. Görüşümüze göre, eşyanın mülkiyetinin devri için mutlaka teslimle birlikte taraflar arasında ayrıca ayni sözleşme yapılmalıdır. Buna karşı diğer bir görüş ise, eşyanın teslimi ile birlikte aynı anda ayni hakkın devredildiği

---

[22] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.70 ff; **HINDERLING**, SPR VI/1, s. 429 f; **STEINAUER**, I, N.255c; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N. 147.

[23] **STEINEUER**, I, N.255.

konusundaki uyuşmanın da gerçekleştiğini iddia etmektedir; bu sebeple de bu görüşü savunanlar, zilyetlik anlaşmasını, hukuki işlem niteliğinde sözleşme olarak görmektedirler[24].

929 Teslimsiz zilyetlik sözleşmesi ile zilyetliğin devren kazanımında, hele zilyetliğin hükmen teslîminde, devri sağlayan zilyetlik sözleşmesi sebep işlemden soyutsa da her iki işlem birbiri içine daha fazla geçmiştir. Zilyetlik devir sözleşmesi ile birlikte, örneğin hükmen teslim veya zilyetliğin havalesi sözleşmesi ile de mülkiyet devren geçer; devralan tarafından kazanılır. Teslim olmaksızın zilyetliğin devrini konu alan zilyetlik sözleşmeleri ise, zilyetlik sözleşmesinin yapılmasıyla, kural olarak aynı zamanda ayni sözleşme olarak, mülkiyetin devrini gerçekleştirdiğinden, hukuki işlem niteliğinde sözleşmedir. Bu sebeple de tarafların fiil ehliyeti aranmaktadır.

c. Çeşitleri

aa. Genel Olarak

930 TMK zilyetliği devren kazanım çeşidi olarak, farklı hukuki olguları dikkate alarak düzenleme yapmıştır. TMK'nın sistematiği incelendiğinde, hazır olanlar (m.977) ve hazır olmayanlar arasında (m.978) teslimle zilyetliğin devri ve teslimsiz devir (m.979) düzenlenmiştir. Bunlara ilaveten, TMK m.980 emtiayı temsil eden senetlerdeki zilyetliğin kazanılmasına yer vermiştir.

931 Zilyetliğin devri, devralanın, eşya üzerinde dolaylı veya dolaysız zilyetlik kazanmasına göre ikiye ayrılır[25]: Dolaysız zilyetlik, dolaylı zilyetlik.

932 Dolaysız zilyetlik halleri, TMK m.977 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir: "*Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi veya edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma gelmesi hâlinde devredilmiş olur.*" Bu düzenlemeden hareketle, biz, TMK sistematiğine uygun olarak, zilyetliğin devrinde teslimi esas alarak aşağıdaki ayrımdan hareketle, zilyetliğin devren kazanılması çeşitlerini inceleyeceğiz:

1) Hazırlar Arasında (TMK m.977)

- Eşyanın Teslimi,

---

[24] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.79 ff; **LIVER**, SPR. V/1, s. 318 ff.

[25] Dolaylı zilyetlik ve dolaysız zilyetlik kavramı için bkz. **ANTALYA**, EH II, N. 199 vd.

- Eşyanın Araçlarının Teslimi,
- Hazır Olmayanlar Arasında (Temsilciye Teslim) (TMK m. 978).

2) Eşyanın Teslimi Olmaksızın Zilyetliğin Devren Kazanımı (Zilyetlik Sözleşmesi ile Zilyetliğin Kazanımı),

- Zilyetliğe Açık Durumdaki Eşyanın Devri (TMK m.977),
- Kısa Elden Teslim,
- Hükmen Teslim (TMK m.979 I),
- Zilyetliğin Havalesi (TMK m.979 I),

3) Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi (TMK m.980).

bb. Eşyanın Teslimi ile Zilyetliğin Kazanımı

aaa. Genel Olarak

933 Eşyanın teslimini (Tradion Übergabe der Sache) (*tradio*) esas alarak yapılan ayrımda TMK, hazırlar arasındaki teslimle hazır olmayanlar arasındaki teslimi iki ayrı hükümde düzenlemiştir:

934 Hazırlar arasındaki teslimi düzenleyen TMK m.977, eşyanın teslimi ile eşyanın araçlarının hakimiyetinin teslimini farklı şekilde düzenlemiştir. TMK m.978 de hazır olmayanlar arasındaki teslimin, temsilci aracılığıyla yapılmasını düzenlemektedir.

935 Zilyetliğe sahip olan kişi, sahip olduğu zilyetliği bir üçüncü kişiye devredebilir. Buna karşın, hizmet zilyedi bu sıfatla zilyetliği devren kazandıramaz[25]. Hizmet zilyedi, ancak yardımcı sıfatıyla veya temsilci sıfatıyla başkası adına zilyetliği devredebilir veya devralabilir[27].

bbb. Çeşitleri

(1). Hazırlar Arasında Devir

936 Hazırlar arasındaki teslim eşyanın teslimi veya eşya üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların teslimi şeklinde gerçekleşir (TMK m.977)[28].

---

[25] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.13; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 145.

[27] **BERGER-STEINER**, OFK, ZGB Art.922, N.8; **STARK**, BK ZGB Art.922, N.13;

[28] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.22

(a). Eşyanın Teslimi

937 TMK m.977'e göre, *"Zilyetlik, şeyin ..., edinene teslimi ... hâlinde devredilmiş olur."* Örneğin satıcının satılanın konusu olan bilgisayarı alıcıya teslim etmesi gibi.

938 Zilyetliğin teslimi, fiili hâkimiyet ilişkisinin değiştiğinin dış dünyaya yansıyan bir görünüm şekli olarak zilyetliğin de devredildiğini ortaya koyar. Sadece yalın bir teslim işleminin gerçekleşmesi zilyetliğin devrini gerçekleştirmez; teslim olgusu ile birlikte teslime ilişkin diğer tüm olguların değerlendirilmesinden, özellikle zilyetliğin taraflarının iradelerinden -zilyetlik anlaşmasından-, zilyetliğin devrinin gerçekleştiğinin anlaşılması gerekir[25]. Örneğin, kargo veya mektubun dairenin kilitli posta kutusuna bırakılmasıyla posta idaresinin zilyetliği devretmesinde; kiralanan konutun su ve elektrik aletleri üzerinde kiracının zilyetliğe sahip olmasında durum böyledir.

939 Fiili hâkimiyetin sürekli olarak kurulduğunun görünebilir olması gerekir; sembolik davranışlar yeterli değildir. Örneğin deneme amaçlı test sürüşü.

(b). Eşyada Hâkimiyeti Sağlayacak Araçların Teslimi

940 TMK m.977'e göre, *"Zilyetlik, şeyin veya şey üzerinde hâkimiyeti sağlayacak araçların, edinene teslimi ... hâlinde devredilmiş olur."* Örneğin, kiralanan konutun anahtarlarının teslimi ile, satılan aracın anahtarlarının teslimi ile. Örneklerdeki anahtar, zilyetliğin konusu olan eşyalarda, eve veya motorlu araca hâkimiyeti sağlamaya elverişli araçlardır. Kiraya verenin kiralananın kira süresi sona erdikten sonra anahtarını değiştirmesi veya kiracının kira sözleşmesi sonunda evin anahtarlarını kiraya verene teslim etmesi kiraya verenin kiralananın zilyetliğini kazandığını ifade eder. Aracın mutlaka maddi bir şey olması gerekli değildir. Örneğin, bir bankadaki kasanın açılması için gerekli olan şifrenin verilmesi, araçların teslimi olarak değerlendirilir.

941 Aynı haklarda hâkim olan aleniyet ilkesini gerçekleştirmeye yetecek nitelikteki araçların teslimi ve tarafların bu aracın teslimi ile zilyetliğin devri konusunda anlaşması, TMK m.977 tarafından, zilyetliğin devri için yeterli görülmüştür.

---

[25] ERNST, BSK ZGB Art.920, N.4

942 Eşyada hâkimiyeti sağlayacak araçlar, eşya üzerindeki zilyetliği *sağlamaya elverişli teknik hakimiyet araçlarıdır*[30]. Anahtar örneğinden devam edersek, anahtar[31] kapıyı açarak eve girmek, motorlu aracın kapısını açmak ve çalıştırmak için eşyada hâkimiyeti sağlamaya, ondan yararlanmaya elverişli teknik araçlardır. Ancak hemen belirtilmelidir ki, *eşyayı sembolize eden araçların* teslimi zilyetliğin devri için yeterli değildir[32].

943 Eşyayı temsil eden kıymetli evrakın devrinde, devri sağlayacak teknik araçların teslimi yanında, aranıyorsa, hukuki olguların da gerçekleşmesi gerekir. Örneğin ciro böyledir.

944 Hukuki araçlar, TMK m. 977 anlamında araç değildir. Yukarıdaki örnekte ciro araç değil, devir için gerekli olan tamamlayıcı kurucu olgulardandır.

945 Devir araçları ile zilyetliğin devren kazanımı için tarafların zilyetlik (hakimiyet) iradesi aranır. Aşağıda zilyetliğin teslimle devrinde anlaşma incelecektir. Gerçekten zilyetlik iradesi olmadığında, eşyanın veya eşyada hakimiyeti temsil eden araçların rıza dışı elden çıkmasında, örnekte olduğu üzere anahtarın çalınması veya gaspı halinde, hırsız veya gaspçı anahtarın dolaysız zilyedi, hatta malik sıfatıyla zilyedi olabilirler; evin ve aracın zilyedi olamazlar[33].

(2). Tarafların Zilyetliğin Teslimle Devrinde Uzlaşması

(a). Zilyetliğin Teslimle Devrinde Anlaşma

946 Tarafların, yani zilyetliği devreden ile devralanın, eşyanın teslimi veya hakimiyeti sağlamaya elverişli aracın teslim yoluyla eşyanın zilyetliği konusunda iradelerinin uzlaşmış olması gerekir (*longa manu traditio* teslim)[34]. Önceki zilyedin bu uzlaşmayı bilmesi de gerekmektedir.

947 Taraflar uzlaştıklarına ilişkin iradelerini açık ya da örtülü olarak açıklayabilirler. Örneğin, kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi sonrasında kiraya verenin kiralananda tadilat yapması veya boyaması.

---

30 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.922, N.6; **WIELAND**, ZGB Art.922-923, N. 3; **STARK**, BK ZGB Art.922, N.22; **BERGER-STEINER**, OFK ZGB Art.922, N.7.

31 BGE 132 III 1555 E-.6.1.

32 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.922, N.6; **STARK**, BK ZGB Art.922, N.22.

33 **STARK**, BK ZGB Art.922, N.25.

34 **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.922, N.2; **DOMEJ**, KurzKomm ZGB Art.922, N.2; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 147.

948 Söz konusu iradelerin uzlaşması[35], *maddi -fiili- anlaşma* (Realakt) niteliğindedir; bu sebeple zilyetliğin devrinde anlaşan tarafların ayırt etme gücünün bulunması yeterlidir; fiil ehliyetlerinin bulunması aranmaz[36]; hukuki işleme ilişkin hükümler uygulanmaz[37].

949 Doktrindeki diğer görüş ise, teslim yolu ile zilyetliğin devrinin maddi fiilden ibaret olmadığını, zilyetliğin devrine ilişkin sözleşme (hukuki işlem) olarak görmektedirler[38]. Teslimle birlikte mülkiyetin geçtiğini, zilyetliğe dair uyuşmanın mülkiyetin devredildiğine ilişkin uyuşma niteliğinde olması gerektiğinden, hukuki işlem niteliğinde olduğunu kabul etmektedirler[39].

950 Taraflardan birinin irade bozukluğunun maddi -fiil- anlaşmasına olan etkisi doktrinde tartışmalıdır[40]. Görüşümüze göre, zilyetliğin devrinde anlaşma maddi anlaşma niteliğinde olduğundan, hukuki işleme ilişkin irade sakatlığı kuralları, kural olarak zilyetlik fiili devrindeki uzlaşmaya uygulanmaz[41]. Tarafların zilyetliğin teslimle devrinde uzlaşamama veya zilyetliğin devri uzlaşmasının, örneğin ayırt etme gücünün bulunmaması sebebiyle geçersiz olması durumunda, sadece eşyanın teslimi zilyetliği devretmez. Fakat devralan yine de dolaysız zilyet olur.

951 Zilyetliğin olgusu olan hakimiyet iradesi ve aynı şekilde zilyetliğin teslimle devri konusundaki anlaşmadaki zilyetlik iradesinin – maddi fiille ayni hakkı devreden iradeden – hukuki işlem- farklı olduğunu burada belirtmek gerekir. Zilyetliğin teslimle kazanılmasına ilişkin anlaşma, eşyanın devren kazanım sebebinden, özellikle sebep işlemden soyuttur[42].

---

35 Karş. BGB § 929.

36 **HOMBERGER.** ZK ZGB Art.922, N.7; **STARK.** BK ZGB Art.922, N.6; **ERNST.** BSK ZGB Art.922, N.8; **HINDERLING.** SPR V/1, s. 429 ff; **DOMEJ.** KurzKomm ZGB Art.922, N. 5; **SCHMID/HÜRLIMANN- KAUP.** N.145; **STEINAUER.** I N.255; **TEKİNAY/ AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP.** s.69-70; **AKİPEK/AKINTÜRK.** s.146; **ÜNAL/ BAŞPINAR.** s.129; **SEROZAN.** N.478; **AYAN.** s. 95. İsviçre Federal Mahkemesinin bu görüşü için bkz. BGE 121 III 345, 347.

37 Alman hukuku için bkz. **JOOST.** MünhK BGB § 854, Rn. 29.

38 **LIVER.** SPR V/1, s.319; **WEBER.** Einl. Und Vorbem. Zu OR Art.68-96, N.82; **WIEKAND.** ZK Art.922-923, N.2 f; **HAAB/SIMONIUS.** ZK ZGB Art.714, N.42, 64; **LEEMANN.** Art.884, N.36 ff; **STARK.** BK ZGB Art.922, N.13; **EITEL/ARNET.** CHK ZGB Art.714, N.2 **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR.** s.73; **ERTAŞ.** N.173; **NOMER/ERGÜNE.** s. 23.

39 **LIVER.** SPR V/1, S. 3128 ff; **ERNST.** BSK ZGB ZGB Art.923, N.1. Farklı yaklaşım için bkz. **STARK.** ZK ZGB Art.923, N. 7.

40 Bu tartışmalar için bkz. **STEINAUER.** I, N. 255a.

41 **ERNST.** BSK ZGB Art.922, N.8.

42 **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR.** s.73; **AKİPEK/AKINTÜRK.** s.146; **ÜNAL/ BAŞPINAR.** s. 129.

Temelinde yatan sebep işlem, örneğin satış, kiralama, intifa geçersiz olsa bile zilyetliğin nakli yine geçerli olur.

(b). Zilyetlik Sözleşmesi ile Karşılaştırılması

952 *Longa manu traditio*, farklı zilyetliğin kazanımı süreçlerinin içeriğinde yer alır. İlk olarak, dolaysız zilyetliğin maddi hakimiyetle kazanmasına hizmet eder[43]. Diğerinde ise, zilyetlik sözleşmesi kapsamında, teslimsiz olarak zilyetliğin devrine hizmet eder[44].

953 Birincisinde, zilyetliğin teslimle devri anlaşması söz konusu iken, diğerinde ise zilyetliğin teslimsiz devri söz konusudur. İlki maddi fiil niteliğinde anlaşma iken, diğerinde borçlar hukuku anlamında bir sözleşme söz konusudur. Zilyetliğin teslimle devrinde anlaşmada, borçlar hukukunun hukuki işlem (sözleşme) hükümleri uygulanmaz; irade sakatlığı hükümleri uygulanmaz[45].

954 Zilyetliğin teslimle devri anlaşması için tarafların ayırt etme gücü yeterli iken, zilyetlik sözleşmesinde fiil (işlem) ehliyeti aranır. Zilyetliğin teslimle devri anlaşmasını taraflar, TMK m. 978 hükmündeki temsilci aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Zilyetlik sözleşmesinin taraflarının vekili ise, TBK m.40 vd. anlamında vekil aracılığıyla yapılabilir.

(c). Üçüncü Kişi Yararına Bağışta Bağışlananın Zilyetliği

955 Hâkim görüş, üçüncü kişi yararına bağışta bağışlananın zilyetliğinin söz konusu olmadığını, zira üçüncü kişinin zilyetlik iradesi olmadığını ve onun maddi etkisi altında hakimiyete ilişkin eşya ilişkisi kurulmadığını ifade etmektedir[46].

(3). Hazır Olmayanlar Arasında Devir (Temsilciye Teslim)

(a). Genel Olarak

956 TMK m.978 hükmüne göre, "*Temsilciye yapılan teslim, temsil edilene yapılmış gibi zilyetliği geçirir.*". TMK m. 973 hazır olmayanlar arasındaki devir kenar başlığı altında, maddi bakış açısı ile eşyanın devrala-

---

[43] Alman hukuku için bkz. **ENNECCERUS/WOLFF/RAISER**, SachenR § 11 II; **BAUR/STRÜNER**, SachenR § 7 Rn.19 ff.

[44] Alman hukuku için bkz. **ERNST**, s.56 ff; **ENNECCERUS/ WOLFF/ RAISER**, SachenR § 11 II; **WESTERMANN/ GURSKY/ EICMANN**, SachenR § 12 Rn.10; **BAMBERGER/ ROTH/ FRITZE**, Rn.43.

[45] **HARTTUNG**, s. 205.

[46] **WESTERMANN/ GURSKY/ EICMANN**, SachenR § 12 Rn.10.

na teslimi yanında, temsilciye yapılan teslimin de temsil edilene yani devralana yapılmış gibi zilyetliği geçirdiğini düzenlemiştir[47]. Bu düzenleme, niteliği farklı olsa da TBK m.40'taki yetkili temsilciye bağlanan hukuki sonuca paraleldir.

957 Temsilci, zilyetliğin devrinde, zilyetliği devralan veya devredenin temsilcisi olabilir[48]. Zilyet temsilcisi, zilyetliği devreden veya devralana yardımcı olan kişidir. Zilyet temsilcisinin, zilyetlik devir ilişkisine yardım etmesi, fiili hakimiyetin kurulması şeklinde, zilyetliğe katılma ilişkisinin kurulması ve bu kapsamda hakimiyet (zilyet) iradesinin ortaya konulması şeklinde gerçekleşir. Daha çok da temsilci, eşya üzerindeki fiili hakimiyeti sağlamaya yardımcı olmaz; zilyetliği devir uzlaşmasında veya zilyetlik sözleşmesinde zilyetliğin devrinde taraf temsilcisi olarak yer alır[49].

(b). Niteliği

958 Temsilcinin hukuki niteliği doktrinde, teslimin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Zilyetliğin devrini, hukuki işlem (TBK anlamında sözleşme) olarak kabul eden görüş, her türlü zilyetliğin devrini, teslimle devir halı de dahil olmak üzere, TBK m.40 anlamında teknik temsil olarak gördüğünden, temsil yoluyla zilyetliğinin kazanılmasını mümkün görmektedir[50].

959 TBK m. 40 anlamında teknik temsilcinin teslimsiz zilyetliğin devri olan zilyetlik sözleşmesinin kurulmasında, devredenin temsilcisi ve veya devralanın temsilcisi olabileceğini kabul etmekteyiz.

960 Zilyetliğin asli kazanımında ve özellikle teslimli zilyetliğin devrinin temsilci aracılığıyla kazanımında, zilyetlik (hakimiyet) iradesini veya zilyetlik anlaşmasını maddi fiil (anlaşma) olarak kabul eden görüşe göre, zilyet temsilcisinin teslim fiili, hukuki işlem veya hukuki işlem benzeri nitelikte değil, yalın fiili bir davranıştır[51]. Katıldığımız bu görüşe göre,

---

47 **HINDERLING**, SPR V/1, s. 443.

48 **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N. 148; **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.923, N.1.

49 **STARK**, BK ZGB Art.923, N.7; **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.923, N.1.

50 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.923, N.6; **HINDERLING**, SPR V/1, s. 444; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s.73; **ERTAŞ**, N.173; **NOMER/ERGÜNE**, s. 76-77, dn 85, 86.

51 **ERNST**, BSK ZGB Art.923, N.1; **BERGER-STEINER/ SCHMID**, OFK ZGB Art.923, N.2; **ZACH/KÜNZLER**, ZK Vorbem. Zu OR Art.32-40, N.56; **STEINEUER**, I. s. 256. Türk hukukunda burada Borçlar hukuku anlamında temsil olmadığı ifade edilmektedir: Bkz. **SEROZAN**, s. 262; **GÜRSOY/ EREN/ CANSEL**, s. 91; **AYAN**, s.98.

eşyanın teslimine aracılık eden zilyetlik vekili, hizmet zilyedi, bu surette zilyetliği kazanan da dolaysız zilyet olan **taraf yardımcısı temsilcisidir**[52]. Zira, TBK'nın m.40 ve devamındaki temsil hükümleri hukuki işleme ilişkin olduğundan, maddi fiillerde uygulanmaz[53].

961 Görüşümüze göre, zilyetliğin olgularının zilyetlik iradesinin temsilinde ve teslimle zilyetliğin devri anlaşmasında tarafların zilyetlik iradesinin temsilinde teknik anlamda TBK m.40'ta düzenlenen temsil hükümleri değil, TMK m. 978'deki temsil hükmü uygulanır. Alman hukukunda da bu yaklaşım hâkim görüştür[54].

962 Görüşümüze göre, TMK m.978'de düzenlenen temsilci, TBK m.40 vd. hükümlerinde düzenlenen -teknik anlamıyla- temsilciden farklı bir kavramdır. Zilyet temsilcisi, yardım amaçlı olarak müdahalede bulunan, taraflar adına ya eşyayı teslim alan ya da teslim eden yardımcı veya zilyetlik anlaşmasında irade aracısıdır.

963 Zilyet vekilinin teknik anlamıyla temsilci değilse de TMK m.978 anlamında temsilci, temsil işleminin sonuçları dikkate alındığında hukuki sonuçları "temsilci benzeri" bir niteliğe sahiptir[55]. Bucher, fiili, maddi bir davranış fakat hukuki işlem benzeri hukuki sonuç etkisi olarak nitelemektedir[56].

964 Zilyetlik temsilcisi, *aracı kişi* (Mittelsmann) veya *yardımcıdır* (Gehilfe). Temsilci benzeri nitelemesine bağlı olarak, niteliğine uygun olduğu sürece TBK m.40 ve devamındaki temsil hükümleri zilyetlik temsilinde de doğrudan değil, kıyasen uygulanır[57]. Yetkisiz zilyet temsilcisinin faaliyetini, anlaşma tarafları, temsilcinin zilyetlik kazanımını açık veya örtülü olarak uygun bulabilirler.

965 Zilyet temsilcisinin, devralan ve veya devredene, zilyetliğin devri anlaşmasında veya teslimde yardımı ya hizmet zilyedi ya da fer'i dolaylı

---

[52] **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N. 149. **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 95-96; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s.147; **SEROZAN**, N.523; **AYBAY/ HATEMİ**, § 6, N.14; AYAN, s. 64; **ERMAN**, s. 13.

[53] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.923, N.3; **HINDERLING**, SPR V/1, s. 444; **STARK**, BK ZGB Art.923, N.7; **ERNST**, BSK ZGB Art.923, N.1.

[54] **WESTERMANN/ GURSKY/ EICMANN**, SachenR § 9 Rn.1; JOOST, MünchK BGB § 834, Rn.39; **GUTZEIT**, **STAUDINGER**, Rn.52.

[55] **ERNST**, BSK ZGB Art.923, N.1; **DOMEJ**, KurzKomm ZGB Art.923, N.1. Bu konuda bkz. **ERNST**, s.120 ff.

[56] **BUCHER**, OR AT, s. 600.

[57] **ERNST**, BSK ZGB Art.923, N.1 ve 11 ff.

zilyet şeklinde gerçekleşebilir[88]; fer'i zilyet olması da şart değildir, hakimiyet iradesi temsilcisi de olabilir. Zilyetliği devralana temsilci olarak yardımda, hizmet zilyetliği söz konusu ise, kazanım doğrudan zilyet şeklinde gerçekleşir. Yardım dolaysız fer'i zilyet olarak gerçekleşirse, kazanım dolaylı zilyet olarak gerçekleşir.

966 Zilyetlik temsilciliğinde, TMK m.40'tan farklı olarak, işlemin sonuçlarının doğrudan doğruya olarak temsil olunan üzerinde doğması zorunlu değildir. Hizmet zilyedi, temsilci benzeri olarak hareket ettiğinde, zilyetlik kazanımı dolaylı olabilir. Yardım hangi şekilde olursa olsun, bunun mülkiyetin kazanımına etkisi yoktur.

967 Zilyetliğin teslimsiz devrindeki devir alternatiflerinde hukuki olgu olarak aranan zilyetlik sözleşmesinde tarafları temsil eden temsilcilerin, TMK m.978 anlamında temsilci benzeri değil, TBK m.40 vd. anlamında temsilci olduğunu burada vurgulayalım[89]. Yine aynı hakkın devrine ilişkin irade uyuşması, ayni sözleşme niteliğinde olduğundan, yine TMK m.40 vd. anlamında temsilci aracılığıyla yapılabilir. Teslimle mülkiyetin devredilmesinde ise, teslime ek olarak yapılması gereken ayni sözleşme de yine temsilci aracılığıyla yapılabilir. Temsilcinin teslimle zilyetlik devir anlaşmasının taraflarının zilyet temsilcisi olmasına engel yoktur; aynı kişi hem temsilci hem de zilyet temsilcisi (yardımcısı) olabilir.

ccc. Hukuki Sonucu

968 Devralana eşyanın zilyetliğinin geçme anı, hazırlar arasında eşyanın teslim anı veya eşyadaki hakimiyeti sağlayacak araçların teslim anıdır. Devreden için de zilyetliğin sona erme anıdır. Temsilci aracılığıyla yapılan teslimlerde TMK m.978 hükmü temsilciye yapılan teslimi "*teslim edilene yapılmış gibi*" kabul ettiğinden, zilyet temsilcisine teslim anı zilyetliğin geçiş anıdır.

969 Zilyet temsilcisi, zilyetliğin devrinde, zilyetliği devralan veya devredenin temsilcisi olabilir[90]. Zilyet temsilcisi, zilyetliği devreden veya devralana yardımcı olan kişidir. Zilyet temsilcisinin yardımı ya aracısı kişi (Mittelsmann) olarak ya da hizmet zilyedi (Besitzdiener) olarak gerçekle-

---

88 **ERNST**, BSK ZGB Art.923. N.4.

89 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.923. N.6. **HINDERLING**, SPR V/1. s. 444.

90 **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N. 148. **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.923. N.1.

şir. Yardım, dolaysız fer'i zilyet tarafından yapılıyorsa, kazanılan zilyetlik durumu, kademeli zilyetlik olarak karşımıza çıkabilir.

970 Zilyet temsilcisinin, zilyetlik devir ilişkisine yardım etmesi, fiili hakimiyetin kurulması şeklinde, zilyetliğe katılma ilişkisinin kurulması ve bu kapsamda zilyetlik iradesinin ortaya konulması şeklinde gerçekleşir. Daha çok da, temsilci, eşya üzerindeki fiili hakimiyeti sağlamaya yardımcı olmaz; zilyetliğin devri uzlaşmasında veya zilyetlik sözleşmesinde zilyetliğin devrinde taraf temsilcisi olarak yer alır[61].

971 TMK m.978 hükmü, öncelikle, kazananın temsilcisinin mülkiyeti kazanması yönünden özel önem taşımaktadır. Zira zilyetliği (mülkiyeti) kazanan, doğrudan temsilci zilyetten (veya malikten) kazanmaktadır.

(1). Zilyet Temsilcisi Doğrudan Temsilci İse

972 Kazananın zilyet temsilcisi **doğrudan zilyet temsilcisi** (direkte Vertretung) ise, temsilci fer'i zilyet veya hizmet zilyedi sıfatıyla hareket etmişse temsilcinin aslı zilyetliği söz konusu olmaz; TMK m.978'e göre zilyetlik temsil edilene geçmiş sayılır. Bu durumda, temsilci zilyet olamaz, bununla birlikte de mülkiyeti kazanmaz. Çünkü zilyetliğin kendine devri konusunda bir zilyetlik iradesi bulunamamaktadır[62].

973 Aynı sonuç zilyetlik konusunda kanuni temsilciler için de geçerlidir[63]. Temsilci zilyetliği elde etmesiyle temsilci dolaysız zilyet, adına temsil edilen ise dolaylı zilyet olur. Temsil edilenin, temsil edilen kişinin malik olması için onun adına temsilci sıfatıyla hareket ettiğinde asli zilyet sıfatına sahip olur.

(2). Zilyet Temsilcisi Dolaylı Temsilci İse

974 Kazananın zilyet temsilcisi **dolaylı zilyet temsilci** (indirekte Vertretung) ise, bu halde işlem sonunda ilk olarak temsilci zilyet (veya maliktir); temsilciden temsil edilene zilyetliğin devri için tekrar diğer bir devrin yapılması gerekir[64].

---

61 **STARK**, BK ZGB Art.923, N.7; **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.923, N.1.

62 **STARK**, BK ZGB Art.923, N.10.

63 **HINDERLING**; SPR V/1, s. 444.

64 **STARK**, BK ZGB Art.923, N.18 ff; **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.923, N.2.

975 **Gizli zilyet temsilcisi**nde, temsilci yetkili ise, temsilcinin kimin adına hareket ettiği belli değilse veya temsilci bir bildirimde bulunmazsa, zilyetliğin ve dolayısıyla mülkiyetin kazanımı söz konusu olabilmesi ancak kıyasen uygulanacak olan TBK m.40 II hükmündeki şartların gerçekleşmesine bağlıdır[65]; başka bir deyişle karşı taraf bir temsil ilişkisinin varlığını durumdan çıkarıyor veya çıkarılması gerekiyor veya işlemin temsilci veya temsil olunandan biri ile yapılması farksız ise doğrudan temsilciye bağlanan sonuçlar söz konusu olur[66].

(3). Yetkisiz Zilyet Temsilcisi

976 Temsilcinin **temsil yetkisi olmamasına** rağmen eşya devredilmişse, yanlış temsilci (falsus procurator) söz konusu olmasına karşın, temsil edilen zilyet olur; fakat mülkiyeti kazanamaz[67].

(4). Vekaletsiz İşgörenin Temsili

977 Vekaletsiz işgörenin zilyetlik temsilinde, lehine işgörülen, onayı ile zilyet olur[68].

cc. Eşyanın Teslimi Olmaksızın Zilyetliğin Kazanımı (Zilyetlik Sözleşmesi ile Zilyetliğin Kazanımı)

aaa. Genel Olarak

978 Zilyetlik, teslim olmaksızın da devredilebilir. Eşyanın teslim olmaksızın zilyetliğin devren kazanımı, *zilyetlik sözleşmesi* (Besitzvertrag) ile gerçekleşir. TMK ZGB, zilyetliğin teslimsiz kazanılmasının, Avusturya ve Fransız hukukundan farklı olarak, Alman hukukunda olduğu şekilde (BGB § 854 II), zilyetlik sözleşmesiyle gerçekleşebileceğini düzenlemiştir[69].

979 Zilyetliğin zilyetlik sözleşmesi ile kazanımları, *zilyetliğin teslimle devrinin alternatif*leridir. Zilyetliğin teslimsiz devren kazanımı sadece zilyetlik sözleşmesi gerçekleşir. Zilyetlik sözleşmesi ile ayni bir hak devredilebilir; borçlandırıcı işlemden doğan bir yükümlülük ifa edilebilir.

---

65 **STARK**, BK ZGB Art.923, N.15.

66 **ANTALYA**, BH GH, I, s 515.

67 **STARK**, BK ZGB Art.923, N.17.

68 **STARK**, BK ZGB Art.923, N.23.

69 **STARK**, BK ZGB Art.922, N.31 ff; **ERNST**, BSK ZGB Art.922, N.15.

Zilyetliğin, teslime alternatif zilyetlik sözleşmesi ile devren geçirilmesi dört şekilde gerçekleşir:

- *Zilyetliğe Açık Durumunun Devri* (*longa manu traditio*) (TMK m.977), örneğin kesilerek ve kamuflaj edilerek, tarafların bildiği bir torba içinde toplama alanı kenarında bir miktar marijuanın devri[70],
- *Kısa Elden Teslim* (*brevi manu traditio*), satıcıya daha önceden kiralanmış aracın zilyetliğinin veya mülkiyetinin devredilerek onun zilyetlik niteliğinin fer'i zilyetlikten aslî zilyetliğe değiştirilmesi,
- *Hükmen Teslim* (*constitutum possessorium*) (TMK m.979 I), örneğin, araç üzerindeki zilyetliğin ve mülkiyetin devredilmesine karşın, aynı anda yapılan kira sözleşmesi ile satıcının kiracı olarak kiralananın asli zilyedi olmaksızın dolaysız zilyetliğine devam etmesi,
- *Zilyetliğin Havalesi* (TMK m.979 I), örneğin, kademeli zilyetlikte, üçüncü kişiye kiralanmış araç üzerindeki zilyetliğin ve mülkiyetin devri.

980 Bunların dışında, zilyetliğin devrinin, teslimin alternatifi olabilecek farklı kombinasyonları bulunmamaktadır[71].

981 Belirtmek gerekir ki, kanun gereği, sebep işlemle, zilyetliğin sözleşme ile devredildiği durumlar da söz konusudur. Sebep işlem konusunda tarafların uzlaşması kanun gereği zilyetlik sözleşmesi hükümlerini doğurmaktadır. Halbuki zilyetlik sözleşmesi konusunda uzlaşma eşyanın teslimsiz devrini gerçekleştirmektedir. Örneğin, mal ortaklığı mal rejiminde, ortaklığın kurulması ile birlikte teslim gerçekleşmese de eşler ortaklık malları üzerinde birlikte zilyet olurlar (TMK m.202, 203, ve 256 vd). Zilyetliğin teslim alternatifleri ile devri kıymetli evrak hukukunda da geçerlidir[72].

982 İstihkak hakkından talebin ayrılması, teslimin alternatifi zilyetlik sözleşmesi ile devri çeşidi değildir; bu kurum aracılığıyla zilyetliğin ve bununla birlikte mülkiyetin intikalinin, istihkak hakkına ilişkin talebin devri yoluyla gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir[73].

---

[70] NZZ Nr.197 vom 25.08.2004, 19.

[71] **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N.1.

[72] **JÄGGI**, ZK ZGB 967 N.31; **OFTINGER/BÄR**, OR Art.901, N.34 f; ZOBK, BK ZGB Art.884, N.641 ff; **INDERLING**, ZDR 1970 I, 162.

[73] BGE 132 III 155 E.6.1. Bu konuda bkz **HOFFMANN-NOWOTNY**/von der **CRONE**, SWZ 3/2006, s.233 ff.

bbb. Zilyetlik Sözleşmesi

(1). Genel Olarak

983 Zilyetlik sözleşmesinin tarafları, zilyetliği devreden ile zilyetliği devralan veya kazanandır; sözleşmenin konusu, eşya üzerindeki zilyetliği teslimsiz olarak devredenin kazanması hususunda uzlaşmadır[74].

984 Zilyetlik sözleşmesi zilyetliğin teslimle devri konusundaki anlaşmadan farklıdır. Zilyetliğin teslimle devri konusundaki anlaşma, maddi –fiil- anlaşması niteliğinde iken, zilyetlik sözleşmesi hukuki işlem niteliğinde, yani TBK m.1 anlamında sözleşme niteliğindedir[75]. Bu nitelik farklılıkları sebebiyle, her ikisi de farklı ehliyet, temsil, irade sakatlığı ve diğer hükümlere tabidir.

985 Zilyetliğin teslimsiz devren kazanımı, sadece zilyetlik sözleşmesi ile mümkündür. Teslimle zilyetlik kazanana dolaysız zilyetlik geçerken, teslimsiz zilyetlikte dolaylı zilyet olan kişi, örneğin zilyetliğin havalesinde, kendi zilyetliğini devredebilir.

986 Şeklen maddi olarak zilyet olan fakat zilyetliği haklı olmayan herhangi bir kişi, örneğin bir hilekârın zilyetliği devir iradesi açıklaması durumunda taraflara arasında zilyetlik uyuşması bulunsa da bu durumda zilyetliğin devri söz konusu olmaz. Zira irade açıklamasında bulunan kişi, ilgisiz ve hukuk düzeni tarafından zilyetliği tanınmayan bir kişidir. Bu durum doktrinde *açık zilyetlik* (offene Besiztz) olarak ifade edilmektedir.

(2). Sözleşme Niteliği

987 Zilyetlik sözleşmesi de zilyetliği devredenle devralan arasında yapılan, devredenin devralanla teslimsiz zilyetliğin devri konusunda uzlaştığı sözleşmedir; bu sözleşme TBK m.1 anlamında sözleşme niteliğindedir[76]. Doktrinde eskiden bazı yazarlar, zilyetlik uzlaşmasının hukuki işlem niteliğini kabul etmemekteydi[77]. Doktrinde, hukuki işlem iradesinin, Kanun

---

[74] **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 71; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.150; **ÜNAL/ BAŞPINAR** s.129.

[75] **OFTINGER**, s.35 ff. **HINDERLING**, s.168 ff. **WIELAND**, ZGB Art922-923, N.3b. **HOMBERGER**, ZGB Art.922, N.14; **STARK**, BK ZGB Art.922, N.54 ve burada belirtilen diğer yazarlar.

[76] **OFTINGER**, s.35 ff. **HINDERLING**, s.168 ff. **WIELAND**, ZGB Art.922-923, N.3b. **HOMBERGER**, ZGB Art.922, N.14; **STARK**, BK ZGB Art.922, N.54 ve burada belirtilen diğer yazarlar. **KARAGÖZ**, s.1195 vd.

[77] **OSTERTAG**, ZGB Art.922, N.922. **JENNY, K.**, s.65 f. **GÜLLER, W.**, s. 84 ff.

sadece devredenden bahsettiği için, onda aranması gerektiği, devralan yani kazananın da irade açıklamasında bulunmasının gerekli olup olmadığı eskiden tartışılmaktaydı. Günümüzde, zilyetlik sözleşmesinde her iki tarafın iradelerinin uygunluğu konusu pek tartışılmamaktadır[78].

988 Zilyetlik sözleşmesini kuran irade açıklamaları, varması gerekli hukuki işlem niteliğindedir. Taraflar iradelerini açık veya örtülü olarak açıklayabilirler. Zilyetlik sözleşmesi şarta ve süreye bağlanabilir. İradelerini açıklayan tarafların hukuki işlem ehliyetine sahip olmaları gerekir; ayırt etme gücüne sahip olmaları yeterli değildir[79]. Sınırlı ehliyetsiz olan küçüğün, TMK m.16 I c.2'e göre karşılıksız kazanmalarında, yasal temsilcilerinin rızası gerekli değildir.

989 Taraf iradelerinin irade bozukluğuna da uğramamış olması gerekir[80]. Zilyetlik sözleşmesi zilyetlik kurulabilen eşyayı konu almalıdır. Yine konu ve amaç yönünden geçerli bir sözleşme olmalıdır; örneğin batmış çıkarılması mümkün olmayan geminin satışı gibi başlangıçtaki objektif imkânsızlık sebebiyle kesin hükümsüz veya uyuşturucu madde satımı gibi kanuna aykırılıktan dolayı kesin hükümsüz olmamalıdır.

(3). Tarafların İradi Temsili

990 Taraflar iradelerini TBK m.40 anlamında temsilci aracılığıyla açıklayabilirler. Türk ve İsviçre Hukukunda, zilyetlik sözleşmesinde taraflardan birinin en azından devredenin zilyetlik iradesini temsilci aracılığıyla açıklayıp açıklamayacağı hususunda, zilyetliğin teslimli veya teslimsiz yapılıp yapılmamasına göre bir ayrım yapmamız gerekir. Bu konuda zilyetlik hükümlerinde etkili Germen hukukunun düzenlemesi olan Alman hukukuna bakmamız gerekir[81].

991 Alman hukukunda, BGB § 164 ff düzenlenen temsil hükümlerinin zilyetlik iradelerinin uyuşmasında (BGB § 854 II'de) uygulanacağı; yalın zilyetlik kazanımlarında (BGB § 184 I'e göre) uygulanmayacağı kabul edilmektedir[82]. İradi temsil kuralının dolaylı zilyetliğin devrini konu alan

---

[78] Bu tartışmalar için bkz. **HOMBERGER**, ZGB Art.922, N.14; **WIELAND**, ZGB Art.922-923, N. 3b; **STARK**, BK ZGB Art.922, N.61.

[79] **HOMBERGER**, ZGB Art.922, N.14; **STARK**, BK ZGB Art.922, N.55.

[80] **HOMBERGER**, ZGB Art.922, N.14 ff; **STARK**, BK ZGB Art.922, N.56.

[81] Karş. ABGB ve tarihi kökeni olan aOR 203 için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.922, N.4, 6.

[82] Alman hukuku için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.922, N.1 ff.

zilyetlik sözleşmelerinde de uygulanacağı; zilyetliğin teslimle devri anlaşmasında (BGB § 868) ve hizmet zilyedi ile teslimde (BGB § 855) uygulanmayacağı kabul edilmektedir.

992 Zilyetlikte temsil, zilyetliği ve veya zilyetliğin kazanılması çeşitlerini niteleme, zilyetlikte temsili düzenleyen TMK m.978'e verdiğimiz anlama göre farklılık göstermektedir. Bu konudaki tartışmaları, görüşümüzü açıklamış idik.

993 Görüşümüze göre, zilyetliğin teslimle devrine ilişkin anlaşma, -bu anlaşma maddi –fiili- anlaşma niteliğinde olduğundan- TMK m.978'de düzenlenen temsilci benzeri kişi aracılığıyla yapıldığında temsil edilene yapılmış gibi zilyetliği devreder. Teslimsiz zilyetliğin devrini konu alan zilyetlik sözleşmesi -TBK m.1 anlamında sözleşme niteliğinde olduğundan- TBK m.40 anlamında temsilci aracılığıyla temsil edilen devreden ve veya devralan adına kurulabilir[83].

(4). Zilyetlik Sözleşmesinin Sebep İşlemden Soyutluğu

994 Zilyetlik sözleşmesinde sebep işlemin geçersizliğinin zilyetlik sözleşmesinin geçersizliğine olan etkisi tartışılmalıdır.

995 Taşınırda ayni hak kazanımının, sebep işlemin geçerliliğine bağlı olup olmadığı tartışmasında, taşınırda ayni hak kazanımının sebebe bağlı olarak kabul edilmesi[84], buna bağlı olarak, zilyetlik sözleşmesinin sebebe bağlı mı yoksa soyut mu olduğu tartışmasına yol açmıştır. Başka bir deyişle, zilyetlik sözleşmesine dayanan zilyetliğin teslimsiz devrinde, zilyetliğin devrinin geçerliliği geçerli sebep işlemin varlığına bağlı mıdır, değil midir?

996 İsviçre Federal Mahkemesinin bir kararından[85] bu yana istikrarla uyguladığı ve katıldığımız doktrindeki hâkim görüşe göre, taşınır mülkiyetinin kazanılması, hukuki sebebi oluşturan borçlandırıcı sözleşmenin (sebep sözleşmesinin) geçerliliğine bağlıdır[86].

997 Doktrinde eskiden hâkim olan görüş, zilyetlik sözleşmesi ile zilyetliğin devrini geçerli bir hukuki işlemin varlığına bağlamaktadır[86]. Katıldı-

---

[83] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.65.

[84] İsviçre Federal Mahkemesinin bu yöndeki kararı olan BGE 55 II 302, 306 ff kararından beri istikrarlı olarak devam etmektedir.

[85] BGE 55 II 302.

[86] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.922, N.15; **HAAB/SIMONIUS**, Art.714, N.64; **HINDERLING**, ZSR 1970 I, s.179; SPR VI/1, s. 431; **AYAN**, s.97.

ğımız günümüzün hâkim görüşüne göre ise, zilyetlik sözleşmesindeki zilyetliğin devrini konu alan sebep sözleşmesinin geçerliliğine bağlı değildir; soyuttur[87]. Hükmen teslim sözleşmesinde, aranan özel hukuki ilişki borçlandırıcı (sebep işlemde) yer alıyorsa, sebep işlemin geçersizliği özel hukuki ilişkiyi gerçekleştirmediğinde, sözleşmeyle devir gerçekleşmez.

998 Gerçekten aynî hakkın, bu kapsamda mülkiyetin kazanılması şekli ile zilyetliğin kazanılmasına ilişkin devir şekillerinin aynı olması, iki işlemi bir bütün olarak görmemize sebep oluyorsa da zilyetlik sözleşmesi, sebep işlemin geçersizliğinden soyuttur. Başka bir deyişle, zilyetlik sözleşmesi değil de sebep sözleşmesi, örneğin satış, kira sözleşmesi vb. kesin hükümsüz veya başka bir sebeple geçersizse- başka bir görüşe göre de iptal edilmişse- bundan dolayı zilyetliği devralan, örnekte alıcı, kiracının zilyetliği geçersiz hale gelmez.

999 Diğer yandan, zilyetlik sözleşmesine ilişkin rıza açıklaması, geçersiz sebep anlaşmasının sonradan geçerli olarak düzeltilmesine de hizmet eder. Bu başlıkta tartıştığımız ve benimsediğimiz zilyetlik sözleşmesinin soyutluğu ilkesi, teslimsiz devir yolları olan tüm zilyetlik sözleşmesi ile zilyetlik kazanımlarından, hükmen teslim, zilyetliğin havalesi, kısa elden teslimde de geçerlidir.

(5). Çeşitleri

(a.). Zilyetliğe Açık Durumunun Devri

1000 TMK m.977 hükmünün bu kısmının düzenlemesi, mehaz ZGB Art.922 Abs.2'deki anlamına göre, iki hususu ele almaktadır[88]:

1001 Birincisi, zilyetliğin geçtiği an, eşya üzerinde zilyetlik kurulmaya fiilen açık an olduğundan, hâkimiyet kurulabilecek anın, zilyetliğin devri anı olduğudur. Teslimli zilyetlikte işin niteliği gereği teslim zaten fiili hâkimiyeti sağladığından, teslim anı zilyetliğin devri anıdır.

1002 Diğeri ise, açık zilyetlik durumunun devrini düzenlemesidir.

(aa). Kavram

1003 TMK m.977 zilyetlik sözleşmesinin tipik görünüm şekli olan doktrinde "uzak elden teslim" (*longa manu traditio*) olarak isimlendirilen tes-

---

[87] STARK, BK ZGB Art.922, N.35; ERNST, BSK ZGB ASrt.922, N.26; SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N. 155; BGE 121 III 345, 347 E. 2a.

[88] STARK, BK ZGB Art.922, N.35; STEINAUER, I. N.255c; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N. 151.

limsiz zilyetliği düzenlemiştir. "Uzak elden teslim" terimi, kurumu izahtan uzak olduğundan, "zilyetliğe açık durumunun devri" (Übertragung der offenen Besitzlage) terimini tercih etmekteyiz.

1004 TMK m.977'nin bir bölümünde uzak elden teslim, "*zilyetlik, ... edinenin önceki zilyedin rızasıyla şey üzerinde hâkimiyeti kullanacak duruma geimesi hâlinde devredilmiş olur.*" şeklinde düzenlenmiştir. Açık zilyetlik durumunun devri, teslim dışındaki zilyetliğin devrinden, teslimin alternatiflerinden biridir.

1005 Açık zilyetlik durumunun devri, tarafların yapacağı zilyetlik sözleşmesi ile eşyanın teslimi gerekmeksizin, devralanın eşyanın açık zilyetlik durumunu devralmasını ifade eder. Başka bir deyişle, uzaktan elden teslim, eşyadaki açık zilyetlik durumunun (offene Besitzlage) zilyetlik sözleşmesi ile devralana transferidir.

1006 Devreden önceki zilyet ile yapılan zilyetlik sözleşmesine konu eşya üzerinde devralan zilyet, bu açıkta bulunan eşya üzerindeki fiili hâkimiyetini objektif olarak sağlayabiliyorsa, eşyanın teslimi gerçekleşmese bile zilyetlik devredilmiştir.

1007 Klasik örnek olarak, iki kişi, tarlasındaki ağaçlardan kestiği ve yol kenarına yığdığı odunların zilyetliğinin devralana geçirilmesi konusunda uzlaşmışlarsa, bu zilyetlik sözleşmesiyle devralan, teslim gerekmeksizin, odunların zilyedi olur[48]. Başka örnekler olarak, açık alana bırakılmış inşaat malzemesi, bahçedeki ağaçta bulunan meyveler, gümrük depolama alanındaki konteyner, tatil alanındaki çadır veya karavan hakkında da böyle işlemler yapılabilir.

1008 Buna karşın, devredenin taşınmazındaki eşyalar, kasadaki kıymetli evrak açık zilyetlik olarak kazanıma elverişli değildir[50].

1009 Açık zilyetlik durumu ile zilyetliğin, dolayısıyla ayni hak kazanımı, hak zilyetliğinde[51] ve kıymetli evrakta[52] söz konusu olabilir. Doktrinde hâkim fikir, taşınır rehninin kurulması için açık durumdaki zilyetliğin devrinin yeterli olmadığını kabul etmektedir[53].

---

[48] ZBJV 1924, 484; SJZ 1919, 105.

[50] BGE 132 III 155 E.5. **STARK**, BK ZGB Art.922, N.36, 44.

[51] **JÄGGI**, ZK OR Art.967 N.38; **STARK**, BK ZGB Art.922, N.41; **HINDERLING**, SPR V/1, s. 431; BGE 81 II 339, 341, 93 II 87.

[52] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.41; **BERGER**, s.98.

[53] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.41; **BERGER-STEINER/SCHMID**, CFK ZGB Art.922, N.13.

(bb). Hukuki Olguları

1010 Açık zilyetlik durumun devri için iki hukuki olgunun kümülatif olarak gerçekleşmesi gerekir:

(aaa). Devredenin Eşya Üzerinde Doğrudan Zilyet Olması

1011 Açık zilyetlik durumunun devredilebilmesi için devreden dolaysız zilyet olmalıdır[54]. Dolaylı zilyet ise teslimsiz zilyetlik devri, TMK m.979'a göre hükmen teslimle gerçekleşir.

(bbb). Üzerinde Zilyetlik Kurulabilmeye Elverişli Açık Eşya Olmalı

1012 Eşya, devralan zilyedin üzerinde fiili hâkimiyet kurabilecek şekilde açık durumda olmalı, yani üzerinde zilyetlik kurulabilmeye, -fiili hâkimiyete- imkân verecek şekilde açık olmalıdır[55].

1013 Eşya üzerindeki fiili hâkimiyet kurmaya elverişli açıklık, maddi olmalı, sadece devralan zilyede değil, hâkimiyet kurabilecek üçüncü kişi, yani herkes için söz konusu olmalıdır[56]. Klasik örnekten devam edersek, odunların bir firmanın depolama alanı içinde bulunması halinde eşya için zilyetliğe açık durum söz konusu olmaz[57].

1014 Herhangi bir kişi bir zorluğa uğramaksızın eşyaya ulaşabiliyorsa, eşya açık zilyetlik durumundadır[58]. Eşya üzerinde herkesin hâkimiyet kurmasına elverişli açıklık, açıkça anlaşılabilir olmalıdır[59]. Zilyetliğe açıklık durumu, kısa bir an için değil, yöresel kabullere göre, belirli bir süre için devam etmelidir.

(ccc). Zilyetlik Sözleşmesi

1015 Zilyetliği devreden ile devralan, fiili hâkimiyete açık durumda olan eşyanın zilyetliğinin devri konusunda uzlaşmalıdır. Bu zilyetlik sözleşmesini, niteliği itibarı ile maddi -fiil- anlaşma değil, TBK m.1 anlamında

---

[54] **ERNST**, BSK ZGB Art 922, N.49. **EITEL/ARNET**, CHK ZGB ART.922, N.4. BGE 132 II 155, 160 E.5.1.

[55] **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N. 154.

[56] **HINDERLING**, SPR V/1, s. 432. **ERNST**, BSK ZGB Art 922, N.16; BGE 132 II 155, 159 E.5.1.

[57] **HINDERLING**, SPR V/1, s. 432.

[58] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.37.

[59] **HOMBERGER**, ZK ZGB ASrt.922, N.13, 17. **HINDERLING**, SPR V/1, s. 432.

hukuki işlem (sözleşme) olarak görmekteyiz[CC]. Bu sebeple borçlar hukukunun sözleşmelere ilişkin hükümleri zilyetlik sözleşmesine kıyasen uygulanabilmektedir.

1016 Zilyetlik sözleşmesinin, taraflarının irade bozukluğu sebebiyle (TBK m.30 vd.) geçersizliği söz konusu olabilir[C1]. Zilyetlik sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, zilyetlik sözleşmesinin her iki tarafının da ayırt etme gücüne sahip olması yeterli değildir, fiil ehliyetine sahip olmaları gerekir.

1017 Açık zilyetlik durumun devri için, zilyetlik sözleşmesi taraflarının değil de sadece devredenin rızasının yeterli olup olmadığı doktrinde tartışmalıdır. TMK m.977'nin "*önceki zilyedin rızasından*" bahsetmesinden hareket edilirse, zilyetlik sözleşmesi olmaksızın zilyetlik devrinin söz konusu olabileceği iddia edilmişse de bu görüşe katılmamaktayız. Zira, devralanın da zilyetliği kabul iradesi olmadan zilyetliğin devri söz konusu olmaz.

1018 Zilyetlik sözleşmesi, geçerli bir sebep sözleşmesi bulunmasa da söz konusu olabilir; zilyetlik sözleşmesi zilyetliğin devredildiğini ifade etmekte, yoksa ayni hakkın geçtiğini ifade etmemektedir.

1019 Aynı hakkın geçişini sağlayan sözleşme ayni sözleşmedir ve ayni sözleşme, zilyetlik sözleşmesinden ayrı olarak ayni hakkın geçişi için varlığı aranılan sözleşmedir. *Zilyetlik sözleşmesi soyut bir niteliğe* sahiptir. Zilyetlik sözleşmesi ile ayni sözleşmenin birlikte, hatta sebep sözleşme olan borçlandırıcı sözleşme ile birlikte, aynı sözleşme içinde yapılması sebebiyle, bu ayrım uygulamada genellikle iç içe geçmiştir.

(cc). Hukuki Sonucu

1020 Zilyetliğin açık durumdan kazanılmasına ilişkin zilyetlik sözleşmesinin kurulmasıyla eşyanın teslimi gerekmeksizin ve eşyadaki fiili hâkimiyeti olmaksızın zilyetliği devralan zilyet sıfatına sahip olur ve bu andan itibaren zilyetlik korumasından ve zilyetliğin hak karinesinden yararlanmaya başlar[C2].

[CC] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.922, N.14; **STARK**, BK ZGB Art.922, N.54 ff., 56; **ERNST**, BSK ZGB Art.922, N.20; **DCMEJ**, KurzKomm ZGB Art.922, N.6; **HINDERLING**, ZSR 1970 I 168 ff., N.28 ff; **BERGER-STEINER/SCHMID**, OFK ZGB Art.922, N.13.

[C1] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.62

[C2] **STARK**, BK ZGB Art.922, N.40

1021 Zilyetliğin kazanılmasının mülkiyetin kazanılmasını sağladığı dikkate alındığında, kural olarak, zilyetlik eşyanın açık durumdan kazanılabileceği hallerde mülkiyet de kazanılacaktır. Ancak bazen Kanun bunun yetmeyeceğini, mutlaka eşyanın tesliminin ayni hakkın kazanımı için gerektiğini arayabilir. Örneğin taşınır rehninde durum böyledir.

(b). Kısa Elden Zilyetliğin Devri

(aa). Kavram

1022 TMK düzenlememesine karşın[103], zilyetliğin unsurlarına ve kazanılmasına uygun niteliği dolayısıyla doktrinde ittifakla kabul edildiği üzere, kısa elden zilyetliğin devri (*brevi manu traditio*) (Besitzübertragung kurzer Hand, Besitzwandung) teslimsiz zilyetliğin zilyetlik sözleşmesi ile kazanım şeklidir[104]. TMK'nın bunu düzenlememesi, bu kurumun zilyetliğin niteliği gereği zaten var olduğu, ayrıca düzenlemenin lüzumsuz görülmesinden kaynaklanmaktadır.

1023 Doktrinde, aslında burada eşyanın teslimi söz konusu olmamasına karşın, bu kuruma "kısa elden teslim" denmektedir. Zilyetlik sözleşmesi ile eşyanın teslimi olmaksızın zilyetliğin devri söz konusu olduğundan "kısa elden zilyetliğin devri" terimini tercih edeceğiz.

1024 Kısa elden zilyetliğin devri, zilyetliğin devri öncesi eşyayı elinde tutan fer'i zilyet veya dolaysız zilyedin, zilyetlik anlaşmasıyla zilyetlik sebebinin veya türünün, niteliğinin değişmesi, genellikle asli zilyetliği kazanmasıdır. Örneğin, kiracının kiraladığı konutu satın alması, taşınır rehni alacaklısının rehin konusunu kiralaması veya satın alması[105] halleri böyledir.

1025 Dolaysız zilyedin ya zilyetlik sebebi ya da zilyetlik türü (zilyetliğinin niteliği) değişmektedir. Zilyetliğin türünün değişmesine örnek olarak, ödünç olarak kullandığı eşyayı satın alan alıcı ile satıcı arasında yapılan zilyetlik sözleşmesi ile, ödünç alanın eşya üzerindeki fer'i zilyetliği sona ermekte, malik sıfatıyla asli zilyet sıfatını kazanmaktadır. Zilyetliğin sebebinin değişmesine örnek olarak, ödünç alan dolaysız zilyet olduğu eşya üzerinde, zilyetlik sözleşmesi ile rehin hakkı alacaklısı olarak zilyetliği kısa elden edinebilir.

---

[103] Karş. BGB § 929, ABGB § 428.

[104] ZGB erten Entwurf düzenlemesi için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.924, N.79.

[105] **WIELAND**, ZGB Art.922, N.4; **OFTINGER/BÄR**, ZGB Art.884ff, N. 251 ff; **ZOBL**, ZGB Art.884, N.680 ff; **LEMANN**, ZGB Art.884, N.62.

(bb). Hukuki Olguları

1026 Kısa elden zilyetliğin devrinin iki temel hukuki olgusu söz konusudur:

(aaa). Zilyetliği Kazanacak Olanın Hâlihazırda Zilyet Olması

1027 Zilyetliği kazanacak olan devralan, hâlihazır zilyet fer'i zilyet veya dolaylı zilyet olmalıdır. Zilyetliği devreden ise dolaylı zilyet durumundadır.

(bbb). Kısal Elden Zilyetliğin Devri Sözleşmesi

1028 Zilyetliği devreden ile devralan, zilyetlik çeşidinin, niteliğinin veya sebebinin değiştiği konusunda uzlaşmalıdır[106]. Uzlaşma taraf iradelerinin kısa elden teslim sözleşmesini kurmaları şeklinde gerçekleşmelidir.

1029 Kısa elden zilyetliğin devri sözleşmesi, sebep işlemden ayırt edilmelidir; sebep işlemin, örneğin satış sözleşmesinin geçersizliği kısa elden teslim sözleşmesinin geçersizliğine neden olmaz[107]. Kısa elden zilyetliğin devri sözleşmesi, sebep işlemden bağımsız soyut bir işlemdir[108].

1030 Zilyetliğin devri konusundaki uzlaşmanın anlaşma şeklinde olmasının yeterli olduğu savunulmaktadır. Bu görüşü savunanlar kısa elden devir uzlaşmasını maddi –fiili- anlaşma olarak görmekte ve zilyetlik sözleşmesi taraflarının, bir görüşe göre zilyetliği devredenin ayırt etme gücüne sahip olmasını yeterli kabul etmektedirler[109].

1031 Katıldığımız görüşe göre, burada da TBK m.1 anlamında zilyetlik sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sebeple tarafların fiil ehliyeti bulunmalıdır[110].

(cc). Hukuki Sonuçları

1032 Kısa elden zilyetliğin devri sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte, kurulma anı itibarıyla, kısa elden zilyetliği devralan zilyetliği kazanır[111]. Kısa elden teslim sözleşmesinin kurulduğu an, zilyetliğin kısa elden çeşidi

---

[106] **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s.72; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.72.

[107] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.87.

[108] **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.132. Aksi görüş bkz. **AYAN**, s.99; **ESENER/ GÜVEN**, s. 24.

[109] **HOMBERGER**, ZGB Art.924, N.23; **STARK**, BK ZGB Art.924, N.34 ff, 86.

[110] **HINDERLING**, SPR VI/1, s. 433; **STEINAUER**, I. N.291; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 161.

[111] Karş BGB § 921/I; **STARK**, BK ZGB Art.924, N.89.

değiştirilmiş olur. Zilyetliği devren kazanan iradelerin uyuştuğu anda iyiniyetli ise, devredenin tasarruf yetkisinin bulunmadığını sonradan öğrense bile, mülkiyeti kazanabilir.

1033 Zilyetliğin ve mülkiyetin devri erteleyici (geciktirici) şarta bağlanmış ise, buna bağlı şartlı olgunun gerçekleşmesi ile birlikte zilyetlik ve mülkiyet geçer"[2].

dd. Hükmen Teslim

aaa. Genel Olarak

1034 TMK m.979 I zilyetliğin havalesi ile hükmen teslimi (Besitzeskonstitut Besitzauftragung) (*constitutum possessorium*) birlikte düzenlemiştir. TMK m.979 I hükmen teslimi, *"... zilyetliği devreden, özel bir hukukî ilişkiye dayanarak zilyet olmakta devam ederse zilyetlik, teslim gerçekleşmeksizin kazanılmış olur"* şeklinde düzenlemiştir"[3]. Hükmen teslim, teslim alternatiflerinden biridir. Zilyetliğin hükmen teslimi mülkiyetin devrine de hizmet eder.

1035 Hükmen teslim iki kişinin katıldığı, zilyetliğin havalesi ise üç kişinin katıldığı bir ilişkidir. Hükmen teslimde zilyetlik ilişkisi taraflarından "zilyetliği devreden", zilyetliğin havalesinde ise "üçüncü kişi" ile olan özel bir ilişki sebebiyle devralanın zilyetliği söz konusu olmaktadır.

1036 Hükmen teslimde devreden yönünden hizmet zilyedinin taraf olarak bulunması söz konusu olamaz. Her iki kurum da sadece mülkiyetin kazanılmasına hizmet etmezler; zilyetlik durumunu, yani zilyetlik olgusunu ve buna bağlı zilyetlik korunmasını da belirlerler.

1037 Zilyetliğin havalesinde olduğu gibi, bir zilyetlik sözleşmesi ile burada da başka bir hukuki işlemle bağlantılı olarak teslimsiz bir şekilde zilyetliğin devri gerçekleşir"[4]. Zilyetlik sözleşmesinin irtibatlı olduğu sözleşmenin diğer tarafı ile zilyetlik sözleşmesindeki zilyetliği kazanan taraf aynıdır.

---

[2] BGE 56 II 2009. **HINDERLING.** ZSR NF 89 (1970) I, s.171, Anm.33; **HAAB/ SCHERRER.** ZGB Art.716, N.97; **STARK.** BK ZGB Art.924, N.90.

[3] Karş. BGB § 930.

[4] **STARK.** BK ZGB Art.924, N.18; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.163.

bbb. Kavram

1038 Hükmen teslim, devredenin herhangi bir sıfatla eşya üzerinde sahip olduğu zilyetlik çeşidinin değişmesine karşın, maddi bir teslim gerekmeksizin, özel bir hukuki sebebe dayanarak zilyetliğinin dolaysız olarak devam ettiği, genelde asli zilyetlığın kendisine geçtiği kurumdur.

1039 Zilyetliği devreden, zilyetliği, zilyetlik aracı olarak devralana kazandırmaktadır. Başka bir deyişle, şimdiye kadar asli zilyet olarak, aynı zamanda dolaysız zilyet olan hükmen teslim alan, zilyetliği devretmekle birlikte özel bir hukuki ilişki sebebiyle fer'i zilyet olarak dolaysız zilyetliğini, teslim gerekmeksizin devam ettirmektedir[115].

1040 (A)'nın para sıkışıklığı sebebiyle (B)'ye sattığı aracı (A)'nın belirli bir süre kullanması için kiralaması örneğini incelersek, devreden (A), satıcı olarak aracın zilyetliğini devretmesi gerekirken, başka bir özel hukuk ilişkisi olan kira sözleşmesine dayanarak, aracın zilyetliğini elinde tutmaya devam etmektedir. Bu konuda malikin bir eşyayı satması sonrası onu kiralaması yanında, banka müşterisinin kıymetli evrakını veya hisse senetlerini satması, ancak onları saklamaya devam etmesini[116] örnek verebiliriz.

1041 Yukarıda örneklerden anlaşılacağı üzere, devreden ile devralan iki hususta anlaşmaktadır[117]:

- Birincisi, zilyetliği başkasının kazanması (devri) konusunda anlaşma[118];
- İkincisi, somut zilyetliğe aracılık ilişkisi (hükmen teslim sözleşmesi) konusunda anlaşma.

1042 *Beklenen hükmen teslim* (antizipiert vorweggenommen Besitzeskonsitut) yoluyla da zilyetliğin devren kazanılmasının söz konusu olabileceği kabul edilmektedir[119]. Hükmen teslim sözleşmesi ile devredenin gelecekte kazanması muhtemel beklenen bir zilyetliğin devri, beklenen hükmen teslimdir.

---

[115] **STARK**, BK ZGB Art.924. N.44. **ERNST**, BSK ZGB Art.924. N.22.

[116] ZR 75. N.20.

[117] **HINDERLING**; SPR V/1, s. 434. **DOMEJ**, KurzKomm ZGB Art. 924. N.9.

[118] **ERNST**, BSK ZGB Art.924. N.28.

[119] **STARK**, BK ZGB Art.924. N.46; **ERNST**, BSK ZGB Art.924. N.24; **DOMEJ**, KurzKomm ZGB Art.924. N.10; **BERGER-STEINER/SCHMID**, OFK ZGB Art.924. N. 16; **OFTINGER**, s.42 f.

1043 Hükmen teslim sözleşmesinin yapıldığı anda devralan daha dolaysız zilyet durumunda değildir; ancak devredenin gerçekleşmesi beklenen bir zilyetlik durumu söz konusudur. Doktrinde bu kuruma şu örnek verilmektedir[120]: Antika meraklısı (A), antika restorasyonu yapan (B)'ye, antikacı (C)'den belirli bir antikayı kendisi için satın alıp onarsın diye bir ücret ödemiştir. Antikanın zilyetliği, buna bağlı olarak mülkiyet (A)'ya antikanın restoratör (B)'nin eline geçtiği anda geçmiş olur. Bu kurum özellikle (A)'nın iflası konusunda önem taşır[121].

ccc. Hukuki Olguları

1044 TMK m. 979 I hükmünden hareketle hükmen teslimin hukuki olgularını aşağıdaki şekilde belirleyebiliriz: aa'. Devredenin Özel Bir Hukuki İlişkiye Dayanarak Eşyaya Dolaysız Zilyet Kalması

(1). Devredenin Dolaysız Zilyet Kalması

1045 Devredenin özel bir hukuki ilişkiye dayanarak, özel hukuk ilişkisine dayanarak eşyada dolaysız zilyet kalması gerekir[122]; hizmet zilyetliği yeterli değildir[123].

(2). Özel Hukuki İlişki

1046 Devredenin doğrudan zilyetliği özel bir hukuki ilişkiye dayanmalıdır. Bu hukuki ilişki sebebiyle devralan eşyanın zilyetliğini teslimle kazanamamaktadır.

1047 Devredenin zilyetliği elinde tutması herhangi bir hukuki ilişkiye dayanabilir. Bu hukuki ilişki sözleşmeden doğabileceği gibi, kanundan da doğabilir[124]. Bu özel hukuki ilişki aynî bir ilişki, örneğin intifa hakkı veya nispî bir borç ilişkisi, örneğin kira[125], kullanım ödüncü[126], eser, bağışlama[127] sözleşmesi olabilir; aile -mal rejimi sözleşmesi[128]-, vesayet, velayet

---

[120] **SEROZAN**, N.529.

[121] Alman hukuku için karş. **WIEGAND**, StaudingerKomm. BGB § 930, N.33.

[122] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.48 ff.

[123] **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.180.

[124] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.52; **HOMBERGER**, ZGB Art.924, N. 16; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 87.

[125] BGE 78 II 207 ff. E.2.

[126] BGE 70 II 199 ff. E.3.

[127] Y. 7. HD., 26.10.19776 T., 9792/12151 (YKD, 1978/2, s. 208).

[128] BGE 62 II 194.

veya miras hukuku ilişkisi de olabilir. Örneğin, (A)'nın (B)'ye şartlı bağışladığı hisse senetlerinin gelirlerini ölene kadar elde edebilmek amacıyla elinde tutmaya devam etmesi.

1048 Hükmen teslim genellikle mülkiyetin nakli amacı ile yapıldığından, bu özel hukuk ilişkisi mülkiyeti nakleden sözleşmeler, özellikle de satış sözleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hükmen teslim uygulaması, kademeli zilyetlik ayrımı olan aslî ve fer'î zilyet ayrımında özel bir uygulama alanı bulur.

1049 Görüşümüze göre, her iki zilyetlik hükmen teslim yoluyla kazanılabilir[29]. Doktrinde bir görüş ise, hükmen teslimi, bir kişinin dolaysız zilyetliğinde bulunan eşyadaki aslî zilyetliğin devralana kazandırılması ile sınırlamaktadır[30].

1050 Hükmen teslim sözleşmesi, genellikle aslî zilyetliği konu alır. Fer'î zilyetliğe yol açan sebepler de özel sebep teşkil eder. Birden fazla kademe söz konusu ise yine uygulama alanı bulur. Devredenin zilyet olarak kalmaya devam etmesi farklı şekilde tezahür edebilir: Fer'î zilyet iken aslî zilyet olabilir. Tam tersi de olabilir; fer'î zilyet hükmen teslim sözleşmesi ile çok kademeli zilyetlikte alt fer'î zilyet olabilir. Bir sebebe dayanan fer'î zilyet iken başka bir sebebe dayanan fer'î zilyet olarak zilyet kalmaya devam edebilir.

1051 Örneklersek; (A)'nın para sıkışıklığı sebebiyle (B)'ye sattığı aracı (A)'nın belirli bir süre kullanması için kiralaması; (A)'nın antika dükkânında duran saati (B) satın aldıktan sonra, tamir veya bakımı için saati (A)'da bırakması; (A)'nın galerisindeki sergiden resim alan (B)'nin resmi sergi süresince (A)'da emanet bırakması vb.

1052 Sözleşmenin sona ermesi sebebiyle geri verme ilişkisi yeterli değildir[31]. Hükmen teslime ilişkin özel bir hukuki ilişki olmalıdır. Sözleşmenin kurulmasıyla zilyetlik ve mülkiyet intikal etmediğine göre, sözleşmenin sona ermesiyle de geri gelmez. Özel hukuki ilişkinin geçersizliği zilyetliğin devrinde etkilidir[32]. Hükmen teslim sözleşmesi, özel ilişkiyi düzenleyen sebep işlemle bağımlıdır[33].

---

[29] **STARK**, BK ZGB Art.924. N.52 ff; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s.78.

[30] **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 90; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 137.

[31] **STARK**, BK ZGB Art.924. N.55, 59; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.183.

[32] **STARK**, BK ZGB Art.924. N.62; **BERGER-STEINER/SCHMID**, CFK ZGB Art.924. N. 19.

[33] **AYAN**, s. 100.

(3). Somut Hükmen Teslim

1053 Hukuki ilişki somut olarak hükmen teslimi konu almalıdır. Halihazır malikin, devralanla bir hukuki ilişki olmaksızın, sadece diğer tarafın zilyetliği kazanacağını açıklaması yeterli değildir; *somut hükmen teslim* (konkretes Konsitut individualisiertes Konsitut) söz konusu olmalıdır. Devredenin daha malik sıfatına sahip olmadığı bir durumda, yani *soyut hükmen teslim* durumunda, Alman hukukunda olduğu üzere, hükmen teslim gerçekleşmez[134].

(4). Uygulama Alanı

1054 Hükmen teslimin özel bir uygulama alanının, *sonraki mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi* (nachträglicher Eigentumsvorbehalt) olup olmadığı tartışılmaktadır. Bir eşyanın mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi ile satılmasına karşın, sonradan sicile kayıt edilmiş olmasının mümkün olmadığı kabul edilmektedir[135].

1055 *Parça eşya*, zilyetlik sözleşmesine konu olarak sadece hükmen teslim yoluyla devredilebilir. Parça eşyada özel bir ilişkinin varlığı olgusunun aranması gerektiği savunulmaktadır[136].

1056 Bize göre, devir yapılırken özel ilişkinin varlığının ispatı fazla önem taşımaz, eşyanın parça eşya olması o ilişkinin varlığını zaten göstermektedir; bu sebeple parça eşyanın varlığının ispatı özel ilişkinin ispatı anlamına gelir.

1057 *Teminat amaçlı olarak devrin, hükmen teslimle* rehin olarak yapılması, üçüncü kişiye teslim söz konusu olmadığından geçersizdir[137]; ancak taraflar arasında inançlı işlem olarak geçerli olabilir.

1058 İrade uyuşması olmaksızın mülkiyetin kazanımı ve dolaysız temsilci ile temsil edilen arasında özel hukuki ilişkinin varlığı halinde, dolaylı temsilcinin kendisi aracılığıyla hükmen teslimin gerçekleşebileceği Alman hukukunda kabul edilmemektedir. Bu durumda **görünüşte işlem – görünüşte hükmen teslimden** (Insichtgeschäft - Insichtkonsitut) bahsedilmektedir[138].

---

[134] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.924, N.14. **STARK**, BK ZGB Art.924, N.59.

[135] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.54.

[136] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.55, 60.

[137] BGE 94 II 297 ff, 304.

[138] **STARK**, BK ZGB Art.923, N.21. Parça eşya için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.924, N.60.

1059 İsviçre Federal Mahkemesi, dolaysız temsilcinin temsil edilenin kendisi için hükmen teslimi, hukuki ilişkinin tehlikesinin olumsuz yönlerini temsilcinin dışladığı durumlarda, kabul etmektedir[139].

(5). İspatı

1060 Kim ki iddia veya savunmasını özel hukuki ilişkiye dayandırmaktadır, bu özel ilişkiyi ispatla -temel ispatla- yükümlüdür (TMK m.6)[140]. İspat için genel ispat yeterlidir[141].

ddd. Hükmen Teslim Sözleşmesi

(1). Genel Olarak

1061 Hükmen teslim, zilyetliği devredenle zilyetliği devralan (kazanan) arasında yapılan zilyetliğin teslimsiz devrine imkân veren bir zilyetlik sözleşmesi ile gerçekleşir. Bu sözleşmenin ismi *hükmen teslim sözleşmesi*dir.

1062 Hükmen teslim sözleşmesinde, devralan ile devreden, aralarındaki özel hukuki ilişkiye dayanarak devredenin dolaylı zilyetliğinin devamı konusunda uzlaşırlar. Devralan, zilyetliği kazanan sıfatıyla, dolaylı, genellikle asli zilyet; devreden ise, dolaysız, genellikle fer'i zilyet kalmaya devam eder.

1063 Zilyetliğin kademeli zilyetlik olması halinde zilyetlik sadece hükmen teslimle devredilebilir[142]. Örneğin, (A)'nın, (B)'ye sattığı aracı veya makinayı kiralaması. Hükmen teslim sözleşmesi ile çok kademeli zilyetlik de kurulabilir.

1064 Hizmet zilyetliği yeterli değildir[143].

1065 Hükmen teslim sözleşmesine TBK'nın sözleşmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. Sözleşmenin TBK'nın kesin hükümsüzlük sebepleri ile veya irade bozukluğu sebepleri ile geçersiz olması söz konusu olabilir.

---

[139] BGE 99 Ia 9; 95 II 453, 461; 93 II 481; 89 II 325; 82 II 391; 63 II 174; 57 II 560; 50 II 183; 39 II 568

[140] ANTALYA/ TOPUZ, MHG, s. 429.

[141] STARK, BK ZGB Art.924, N 55.

[142] BGE 132 III 155 E.4.

[143] BGE 112 II 113 E.4.

1066 Hükmen teslimin taraf vekilleri aracılığıyla onun adına yapılması mümkündür. Hükmen teslim sözleşmesinin her iki tarafının da fiil ehliyetinin bulunması gerekir[44].

(2). Zilyetliğin Devredilmesine İlişkin Sözleşme: Zilyetliğin Hükmen Teslimi Sözleşmesi

1067 Devreden ve kazananın, zilyetlığın hükmen teslimle kazanılması için özel hukuki ilişki ve zilyetliğin devrini konu alan zilyetliği hükmen teslimle kazanılmasında uzlaşması gerekir.

1068 Zilyetliği devredenle zilyetliği devralan (kazanan) arasında yapılan hükmen teslim sözleşmesi aşağıdaki sözleşmelerden ayırt edilmelidir[45]; ancak yaşam ve ticari ilişkilerde genellikle bu sözleşmeler birlikte aynı anda kurulur[46]:

- Borçlandırıcı işlem (sözleşme); sebep işlemi,
- Özel hukuki ilişkinin düzenlendiği işlem (sözleşme),
- Zilyetliğin devredenden devralana geçtiğine ilişkin zilyetlik sözleşmesi.

1069 Bu sözleşmelerin hukukçu dışında başka bir kişi tarafından, birinin diğerinden ayırt edilmesi de oldukça güçtür; ama bir hukukçunun da bu ayrımı yapabilmesi onun hukuk bilgisinin gereğidir[47]. Bu işlemler (sözleşmeler) arasındaki ilişkiyi ve bağlantıyı aşağıda inceleyeceğiz.

1070 Zilyetlik ilişkisinin değişmesi konusunda uyuşma (zilyetlik anlaşması veya zilyetlik sözleşmesi), örneğin hükmen teslim veya zilyetliğin havalesi, sebep (borçlandırıcı) işlemin (sözleşmenin) geçerliliğinden bağımsızdır; soyuttur.

1071 Soyutluk ilkesi gereğince, asli zilyetlik, ayni haklardan farklı olarak, sebep işlem geçersiz olsa bile devralana geçecektir. Fakat özel hukuki sebebi düzenleyen işlem, genellikle borçlandırıcı işlem, geçersiz ise, hükmen teslimin özel hukuki ilişkiye dayanan sebebi de gerçekleşmediğin-

---

[44] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.69; **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N.25; **STEINAUER**, I, N.269, 287; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.184.

[45] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.65; **HAAB/SCHERRER**, ZGB Art.717, N.33.

[46] AppH/BE, ZBJV 1946, II.517, 5420 f.

[47] Bkz. **STARK**, BK ZGB Art.924, N.66 ff.

den, hükmen teslim de söz konusu olmayacaktır: devralan asli zilyetliği devirle kazanmış olmayacak, devreden de fer'i zilyet olmayacak, kısaca kademeli zilyetlikten bahsedilemeyecektir.

1072 Borçlandırıcı (sebep) işlem herhangi bir nedenle geçersiz ise, buna bağlı olarak ayni hak kazanılmaz, özel hukuki işlemi konu alan sözleşme, konusu kaybettiğinden imkansızlaşır (TBK m.27). Zilyetliğin hükmen devri ve buna bağlı olarak ayni hakkın devri, geçerli zilyetlik sözleşmesinin bulunmasına bağlıdır[48].

1073 Sebep işlem ve özel hukuki ilişkiyi düzenleyen sözleşmenin geçerliliği, katıldığımız görüşe göre, soyut değil, sebebe bağlıdır. Sebebe bağlılık yaklaşımında, sebep işleminin geçersizliği tasarruf işleminin geçersizliğine sebep olur. Soyutluk görüşüne göre ise, sebep hukuki işleminin geçersizliği ve bu sebeple ayni hakkın kazanımı gerçekleşmez; özel sebebi düzenleyen sözleşme konusuz kalır ve imkânsız bir içeriğe sahip olur.

eee. Hukuki Sonuçları

1074 Taraf iradelerinin hükmen teslimde uyuşması ile (hükmen teslim sözleşmesinin kurulmasıyla) devredenin dolaylı zilyetliği sona erer; devralanın fer'i zilyetliği asli zilyetliğe dönüşür. Zilyetliğin geçtiği an, hükmen teslim sözleşmesinin yapıldığı andır; bu an itibarı ile zilyetlik kazanılır. Zilyetliğin devir anı özellikle TMK m.988 uyarınca emin sıfatıyla zilyedin iyiniyeti yönünden önem taşır[49].

fff. Özel Durumlar

(1). Elden Bağışlama

1075 Elden bağışlamaya ilişkin TMK m.289'un açık hükmü, elden bağışlamanın; bağışlayanın bir taşınırı bağışlayana teslimle olacağını düzenlemiştir. Bu sebeple, elden bağışlama hükmen teslimle gerçekleşmez[50].

1076 İsviçre Federal Mahkemesi ise, elden bağışlamada da hükmen teslim yolunu yasal kabul etmiştir; doktrin de bu yaklaşıma katılmıştır[51]. Karara

---

[48] **STARK**, BK ZGB Art.924. N.71 f.

[49] **STARK**, BK ZGB Art.924. N.71.

[50] **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s.89; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.137; **TÜRKMEN**, s.31.

[51] BGE 70 II 199ff, 204 E.3. Doktrinde de hâkim olan bu görüş için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.924 N.78; **ERNST**, BSK ZGB Art.924. N.36.

konu olayda kocanın kadına yaptığı bağışlamada kadının korunması amaçlanmıştır[52]. Elden bağışlama dışındaki bağışlamanın, bağışlama vaadinin ifasında, zilyetliğin devri hükmen teslimle gerçekleşebilir.

(2). Teslim Şartlı Rehin

(a). Genel Olarak

1077 Teslim şartlı rehin, hükmen teslim yoluyla kurulamaz[53]. Zira, TMK m.939 son fıkrasında, "*taşınır, fiilen yalnız rehnedenin hakimiyetinde kaldığı sürece rehin hakkı doğma*"yacağını düzenlenmiştir. Hükmen teslimin sadece asli zilyetliğin kazanana devri için yapılacağını savunanlar da bu görüşe katılmaktadırlar[54].

(b). Hükmen Teslimle Kanuna Karşı Hile

1078 Taşınır rehninin kurulabilmesi için taşınırın mutlaka fiili (maddi) olarak teslim edilmesi zorunlu olduğundan, taraflar bazı kanuna karşı hile yollarına başvurarak, TMK m.939 hükmünü dolanmak isteyebilirler.

1079 Kanunun bu emredici yasak hükmünü aşmak amacıyla, hükmen teslim kurumunu kullanarak, yani teslimi yapılamayan taşınırın asli zilyetliğini hükmen teslim yoluyla alacaklıya nakledip, fer'i zilyetliği de eşyayı elinde bulunduran borçluda bırakmak isteyebilirler.

1080 Bu durumda, zilyetliğin nakli amacı değil de sırf teminat amacıyla hareket etmiş olurlar. Bu durumda da hükmen teslim ilişkisinin özel sebebi gerçekleşmemiş olur.

1081 İşte bu gibi kanuna karşı hile yollarını TMK m.766 getirdiği özel hükümle engellemek istemiştir: "*Bir taşınırın mülkiyetini nakleden kimse özel bir hukukî ilişkiye dayanarak o şeyin zilyetliğini korursa, mülkiyet teslimsiz geçmiş olur. Ancak, bu işlem üçüncü kişileri zarara sokmak veya taşınır rehni kurallarından kurtulmak için yapılmışsa, mülkiyetin nakli sonuç doğurmaz. Böyle bir amaç güdülüp güdülmediğini hâkim takdir eder.*"

---

[52] TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 88; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 137.

[53] SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N.189; TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 91; OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s. 78; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 137.

[54] STARK, BK ZGB Art.924, N.73 ff; Bkz. TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 90; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 137.

1082 Taşınır mülkiyetinin kazanımında daha detaylı inceleyeceğimiz üzere, TMK m.766 sadece rehin kurallarını dolanmak amacıyla yapılan hükmen teslimi değil, aynı zamanda temlik edenin alacaklılarını zarar uğratmak amacıyla yapılan hükmen teslimleri de geçersiz saymıştır[655]. Örneğin, kişinin, hakkında yapılacak icra takibini engellemek veya iflastan mal kaçırmak amacıyla, kıymetli eşyalarını güvendiği arkadaşına satış olarak gösterip, ondan kullanma ödüncü veya kira sözleşmesi ile kıymetli eşyalardan yararlanmaya devam etmesi böyledir.

1083 TMK m.766 hükmünün karşı anlamından, üçüncü kişilere karşı geçersiz olan işlemin, taraflar arasında teminat amaçlı inançlı işlem olarak geçerli olup olmadığı tartışılmaktadır.

ee. Zilyetliğin Havalesi

aaa. Genel Olarak

1084 TMK m.979 I zilyetliğin havalesi (Besitzanweisung) ile hükmen teslimi birlikte düzenlemiştir[656]. TMK m.979 I zilyetliğin havalesini, *"Bir üçüncü kişi ..., özel bir hukukî ilişkiye dayanarak zilyet olmakta devam ederse zilyetlik, teslim gerçekleşmeksizin kazanılmış olur"* şeklinde düzenlemiştir.

1085 Zilyetliğin havalesi sadece kademeli zilyetlikte uygulama alanı bulur. Hükmen teslimde zilyetlik ilişkisi taraflarından "zilyetliği devreden" ile, zilyetliğin havalesinde ise "üçüncü kişi" ile olan özel bir ilişki sebebiyle devralanın zilyetliğinin söz konusu olması gerekir.

1086 Zilyetliğin havalesi, kademeli zilyetlik ayrımı olan aslî ve fer'î zilyet ayrımında özel bir uygulama alanı bulunmaktadır. Zilyetliğin havalesinin uygulanması, genellikle aslî zilyetliği konu alır. Birden fazla kademe söz konusu ise, fer'î zilyetlikte de uygulama alanı bulur. Zilyetliği devreden aslî veya fer'î zilyet olabilir. Örneğin devreden kiracı, üçüncü kişi ise alt kiracı, devralan kiraya veren veya malik olabilir[657].

---

[655] BGE 78 II 207 ff. 212, E.4; STARK, BK ZGB Art.924 N.73 ff. 56, 77; **SCHMID/ HÜRLIMANN - KAUP**, N.188, 2020 ff. **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N.35; **STARK**, BK ZGB Art.924, N.65 77 ff; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 92 vd.; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 138.

[656] Bkz. **ZWAHLEN**, Mary, Zilyetliğin Havalesi, Kubalıya Armağan, İstanbul 1974, s.383-408; **ZWAHLEN**, M., Zilyetliğin Havalesi, İÜHFAD, sa 13, 1976, s.105-135.

[657] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.7.

bbb. Kavram

1087 Hükmen teslimde olduğu gibi, bir zilyetlik sözleşmesi ile burada da başka bir hukuki işlemle bağlantılı olarak teslimsiz bir şekilde zilyetliğin devri gerçekleşir[68]. Zilyetlik sözleşmesinin irtibatlı olduğu sözleşmenin diğer tarafı üçüncü kişidir.

1088 Zilyetliğin havalesinin uygulanması için kademeli zilyetliğin bulunması gerekir. Zilyetliğin havalesi ilişkisinde, "zilyetliği devreden", "zilyetliği devralan" ve "eşyaya dolaysız zilyet olan üçüncü kişi" olmak üzere üç kişi söz konusudur:

- Birinci (A) kişisi: malik devreden ve dolaylı zilyet, genellikle asli zilyet (zilyetlik sözleşmesinin tarafı),
- İkinci (B) kişisi: kazanan devralan ve gelecekteki dolaylı zilyet (zilyetlik sözleşmesinin tarafı),
- Üçüncü (C) kişisi: özel bir hukuki ilişki sebebiyle eşyaya zilyet olan kişi, genellikle doğrudan zilyet, çoğunlukla fer'i zilyet.

Zilyetliğin havalesi bu üç kişi arasındaki *üç köşeli ilişki*dir.

Zilyetliği devreden kişi (A) ile arasındaki özel bir hukuki ilişki sebebiyle eşya üzerinde doğrudan zilyet olan üçüncü bir kişiden (C'den), eşyanın dolaylı zilyetliğinin devralana (B'ye) devredilmesini konu alan, zilyetliği devreden (A) ile zilyetliği devralan (B) arasında yapılan zilyetlik sözleşmesi zilyetliğin havalesidir.

1089 Örnek bir olayla açıklarsak, (A)'nın yatırım danışmanı (C)'ye verdiği şirket hisselerini (B)'ye satması ve (B)'nin hisse senetlerini (C)'den alması; (A)'nın (C)'ye verileri depolamak için kiraladığı sabit diski, (B)'ye satıp devretme konusunda (A) ile (B) anlaşırlarsa, (B) zilyetliği zilyetliğin havalesi yoluyla kazanmış olur. Başka örnekler olarak, (A) tarafından bakım ve kışlama için liman işletmecisi (C)'ye bırakılan yatın sonradan (B)'ye kiralanması üzerine (B)'nin yatı (C)'den alması; (A)'nın gönderilmek üzere nakliyeci (C)'ye teslim edilmiş ürün veya malı (B)'ye satışında, (B)'nin malı veya ürünü (C)'den alması olayları verilebilir.

1090 Hak zilyetliğinde de hükmen teslim mümkündür.

---

[68] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.18; SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N.163; **EIETEL/ ARNET**, CHK ZGB Art.924, N. 2.

ccc. Hukuki Olguları

1091 Zilyetliğin havalesi, zilyetlığın havalesi sözleşmesi ile eşya üzerindeki dolaylı zilyetliğin teslimsiz kazanılmasıdır. TMK m.979 I hükmünden hareketle zilyetlığın havalesinin hukuki olgularını aşağıdaki şekilde belirleyebiliriz[659]:

(1). Dolaylı Zilyet Olunan Bir Eşyanın Devri Söz Konusu Olmalı

1092 Devreden, kendi yönünden asli ve dolaylı zilyet olmalıdır. Zilyetliğin havalesinde, dolaylı zilyetliğin devri söz konusudur. Zilyetliğin havalesinin söz konusu olabilmesi için *kademeli zilyetliğin bulunması* gerekir. Dolaylı zilyedin dereceli zilyet olarak asli veya fer'i zilyet olması fark yaratmaz[660].

1093 Kademeli zilyet olarak birbiriyle irtibatlı yan yana duran biri fiili biri gelecekte olmak üzere iki dolaylı zilyet ve bir de dolaysız zilyet olan üçüncü kişi bulunmalıdır[661].

1094 Doktrinde, devredenin zilyetliği talimatıyla başkasına kazandırabileceği kabul edilmektedir. Örtülü olarak zilyetliğin havalesi olarak nitelenebilecek bu şekline, doktrinde, "*zilyetliği devredenin talimatıyla devri*" ismi verilmektedir. Buna ilişkin verilen örnek şu şekildedir[662]: Satıcı (A)'nın, alıcıya (C) sattığı, ancak (C)'nin makinayı beğenmemesi üzerine iade edebileceği hususunda anlaştığı satılanı (B)'ye satıp, (C)'den de satılanın (B)'ye teslimini isterse, (B) de bu talimata uyarsa devredenin talimatıyla zilyetliğin devri söz konusudur.

(2). Üçüncü Kişinin Özel Bir Hukuki İlişkiye Dayanarak Eşyaya Dolaysız Zilyet Olması

(a). Genel Olarak

1095 Üçüncü kişinin zilyetliği devredenle arasında özel bir hukuki ilişki bulunmalıdır. Üçüncü kişinin zilyetliği, intifa, rehin gibi ayni hak doğuran bir hukuki ilişkiden veya nispi (alacak) hakkını konu alan kira, ödünç, eser gibi borçlandırıcı hukuki ilişkiden kaynaklanabilir. Bu ilişki sebebiyle taraflar eşya üzerinde kademeli zilyettirler.

---

659 SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N.164 ff.

660 ERNST, BSK ZGB Art.924, N.3; DOMEJ, KurzKomm ZGB Art.924, N.3.

661 HOMBERGER, ZK ZGB Art.924, N.4.

662 SEROZAN, N.538 vd.

1096 Bir eşya hizmet zilyedinin fiili hakimiyetinde olsa da hizmet zilyedi zilyetliğin havalesinin tarafını oluşturmaz. Zira hizmet zilyetliğini kuran hukuki ilişkide zilyet yardımcısı kendi adına değil, bağımlı olduğu hizmet verdiği kişi adına zilyet olduğundan, zilyetlığı havale ile başkasına kazandıramaz. Ancak hizmetinde olduğu kişinin taraf olduğu zilyetlik havalesinde, yardım görevi yapar[663].

1097 Üçüncü kişi zilyetliği devredenle olan ilişkisine dayanarak zilyetlik sözleşmesine konu eşyaya dolaysız zilyet olmalıdır. Üçüncü kişinin eşya üzerindeki dolaylı zilyetliği, fer'i zilyetlik şeklinde de olabilir[664].

1098 Devredenin zilyet aracısının, devredeni için zilyet aracısı olmalı ve onun zilyet aracısı olması gerektiği, onun hakimiyetini tanıması gerektiği, üçüncü kişinin devredenin zilyetliğini tanımadığı takdirde zilyetlığın havalesinin söz konusu olmayacağı görüşü savunulmaktadır[665].

1099 Üçüncü kişi, zilyetliği devredenin eşya üzerindeki hak veya hakimiyetini tanımalı, kendisi aslı zilyet iddiasında olmamalıdır[666]. Bu sebeple hırsız tarafından çalınan havale yoluyla devredilemez[667]. Aynı şekilde, kamu hukuku ilişkilerindeki zilyetlık zilyetliğin havalesine konu olmaz[668].

1100 Üçüncü kişinin devredenin zilyetliğini tanıması ve dolaysız zilyet olan üçüncü kişinin zilyetliğin devrine aracı olması, zilyetlığın havalesine iştirakini veya onayı bulunmasını gerekli kılmaz; itirazı da haklı kılmaz[669].

(b). İstihkak Hakkından Talebin Ayrılmasında Hükmen Teslim

1101 Taşınır mülkiyetinin zilyetliğin devri, teslim ve teslim alternatifleri olmaksızın kuralı dikkate alındığında, zilyetliğin hükmen devrinin mümkün olmadığı durumlarda, -örneğin dolaysız zilyetlikte veya çalınan eş-

---

663 BGE 112 II 113 ff. 115 E.4. **STARK**, BK ZGB Art.924, N.12; **STARK**, BK ZGB Art.924, N.12; **EIETEL/ ARNET**, CHK ZGB Art.924, N. 2; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.167; **OFTINGER**, s. 49; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 140.

664 **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.140'ta asli ve feri zilyet olunmadığında zilyetliğin havalesi yoluyla naklin mümkün olmadığını ifade etmektedir.

665 **STARK**, BK ZGB Art.924, N.7.

666 BGE 132 III 155 E.4.1.

667 **STARK**, BK ZGB Art.924, N.27; **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N.3.

668 **STARK**, BK ZGB Art.924, N.27; **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N.3.

669 **STARK**, BK ZGB Art.924, N.27; **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N. 13; **ZOBL**, BK ZGB Art.884, N.704. Aksi görüş için bkz. **HINDERLING**, SPR V/1, s. 439.

yada- BGB § 931'de söz konusu olan *istihkak hakkından talebin ayrılmasında* (Abtretung des Herausgabeanspruches Vindikationszession) hükmen teslimin söz konusu olup olamayacağı doktrinde tartışılmaktadır[170].

1102 İstihkak hakkından talebin veya taleplerin ayrılarak devri iki şekilde gerçekleşebilir: Aslı olarak istihkak hakkından taleplerin ayrılarak tamamına yakınının devri; fer'i olarak istihkak hakkından talebin ayrılarak devri.

1103 *Fer'i olarak istihkak hakkından talebin ayrılarak devrinde,* malik sahip olduğu mülkiyet hakkını kendisinde tutarak, zilyede karşı ileri sürülebilecek dava hakkını üçüncü kişiye devredebilmesini ifade eder. *Asli olarak istihkak hakkından talebin ayrılarak devrinde,* malik sahip olduğu mülkiyet hakkından doğan haklarının neredeyse tamamını üçüncü kişiye devretmektedir.

1104 Asli olarak istihkak hakkının devrinde, hükmen teslimin olabileceği tartışılmaktadır[171]. İsviçre Federal mahkemesi, fer'i olarak istihkak hakkının devrinde hükmen teslimi kabul etmemişken, asli olarak istihkak hakkının devrinde kabul etmiştir[172].

(3). Zilyetliğin Havalesi Sözleşmesi

1105 Zilyetliğin havalesi, zilyetliği devredenle zilyetliği devralan (kazanan) arasında yapılan zilyetliğin teslimsiz devrine imkân veren bir zilyetlik sözleşmesi ile gerçekleşir[173]. Bu sözleşmenin ismi *zilyetliğin havalesi sözleşmesi*dir (Besitzanweisungsvertrag)[174]. Zilyetliğin havalesi sözleşmesi, üçlü havale ilişkisinin hükümlerini düzenler.

1106 Zilyetliğin havalesi sözleşmesinde, devralan ile devreden, devredenin dolaylı zilyet, üçüncü kişinin dolaysız zilyet olduğu eşyada, bundan sonra devralanın dolaylı zilyet olacağı konusunda uzlaşırlar. Zilyetliğin havalesi sözleşmesine dolaysız zilyet olan üçüncü kişinin katılması veya onay vermesi gerekli değildir.

---

[170] **WIEGAND**, ZK ZGB Art.924, N. 55 ff; **STEINAUER**, I; N.1024b

[171] **WIEGAND**, ZK ZGB Art.924, N. 55 ff; **STEINAUER**, I; N.1024b

[172] BGE 132 III 155.

[173] BGE 112 II 446, 420

[174] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.15 ff; **ERNST**, BSK ZGB ASrt.924, N. 8; **BERGERT-STEINER/SCHMID**, OFK ZGB Art924, N7; **STEINAUER**, I, N. 275; **SCHMID/ HURLIMANN-KAUP**, N.168

1107 Zilyetliğin havalesi sözleşmesi, bir maddi (fiil) anlaşma değil, hukuki işlem niteliğinde sözleşmedir[1]. Zilyetliğin havalesi sözleşmesine, TBK'nın sözleşmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanabilir[2]. Bu sebeple, sözleşme TBK m.40 anlamında tarafların iradi temsilcileri aracılığıyla onların adına kurulabilir.

1108 Yine zilyetliğin havalesi sözleşmesi, kesin hükümsüzlük sebepleri, örneğin hukuka aykırılık, ahlaka aykırılık, kişilik haklarına aykırılık, imkânsızlık vb. sebeplerle kesin hükümsüz olabilir. İrade bozukluğu söz konusu olabilir; sözleşme irade bozukluğuna uğrayan tarafından onanmayarak geçersiz hale getirilebilir.

1109 Zilyetliğin havalesi sözleşmesinin geçerliliği, sebebi oluşturan işleme bağlı değildir; soyut işlem niteliğindedir[3]. Zilyetliğin havalesi ile aynı hak değil, sadece zilyetlik devredilmekte yani kazanılmaktadır. Yine zilyetliğin devri bir hak devri de olmadığından alacağın devri hükümleri de söz konusu değildir.

1110 Zilyetliğin havalesi sözleşmesinin geçerli olarak kurulabilmesi için, taraflarda ayırt etme gücü olması yeterli değildir; fiil ehliyetlerinin de bulunması gerekir[4]. Zilyetliğin havalesi sözleşmesinin geçerliliği şekle tabi değildir[5].

1111 Zilyetliğin havalesi sözleşmesi, zilyetliği devredenle devralan arasında yapılır; dolaysız zilyet olan üçüncü kişinin sözleşmeye katılmasına veya rıza göstermesine gerek bulunmamaktadır. Sözleşmenin kurulması için ona bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak dolaysız zilyede karşı hüküm ifade etmesi için, TMK m.979 II hükmüne göre ona bildirilmesi gerekir.

ddd. Hukuki Sonuçları

1112 Zilyetliğin havalesinin sonuçlarını zilyetlik havalesi sözleşmesinin tarafları -zilyetliği devredenle devralan- arasındaki ilişki ve üçüncü kişi

---

[1] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.86. Aksi görüş: **HINDERLING**, SPR V/1, s.435, 436. **AYAN**, s.102.

[2] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.16, 69, 86.

[3] **HOMBERGER**, ZK ZGB ASrt.924, N.3; **STARK**, BK ZGB Art.924, BN.9; **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N.8, 5, 41. Farklı fikir: **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.924, N.5; **OFTİNGER**, N.3; **von Tuhr/ESCHER**, s. 353; **AYAN**, s.102.

[4] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.16; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.168.

[5] BGE 46 II 45 ff. 48. **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.924, N.5; **STARK**, BK ZGB Art.924, N.16; **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N.7.

ile sözleşmenin tarafları arasındaki ilişki olmak üzere iki başlıkta inceleyeceğiz:

(1). Zilyetliğin Havalesi Sözleşmesinin Tarafları Arasındaki İlişki

1113 Devreden devralan ile zilyetliğin havalesi sözleşmesini yaparak, devredenin dolaylı zilyet üçüncü kişinin dolaysız zilyet olduğu eşyada, bundan sonra devralanın zilyet olacağını kabul eder.

1114 Zilyetlik sözleşmesinin yapılmasıyla sözleşme hükümlerini doğurmaya başlar ve zilyet aracısı olan dolaysız zilyet kişinin ilişkiye katılması gerekmeksizin, zilyetliği devreden kaybeder, zilyetliği devralan tarafından kanun gereği kendiliğinden zilyetlik kazanılmış olur[880].

1115 Zilyetliğin havalesi sözleşmesi, sözleşme taraflarını bağlar; dolaysız zilyet olan üçüncü kişi hariç, herkese karşı ileri sürülebilir[881]. Dolaysız zilyet üçüncü kişiye karşı, devredenin zilyetliğin havalesinin yapıldığını bildirimi ile sözleşme hükümlerini doğurur.

(2). Zilyetliğin Havalesi Sözleşmesi Tarafları ile Üçüncü Kişi (Dolaysız Zilyet) Arasındaki İlişki

1116 Zilyetliğin havalesi sözleşmesi tarafları ile üçüncü kişi (dolaysız zilyet) arasındaki ilişkide tarafların hukuki durumu, zilyetliğin havalesinin dolaysız zilyede bildirim öncesi ve sonrası ayrı ayrı incelenmelidir.

(a). Genel Olarak

1117 Sözleşmenin kurulması dolaysız zilyet üçüncü kişinin rızasına bağlı değilse de, zilyetliğin devrinin onun için hüküm ifade etmesi için, TMK m.979 II hükmüne göre, zilyetliğin havalesinin ona bildirilmesi gerekir. TMK m.979 II'e göre, "*zilyetliğin bu yolla devri, zilyet olmakta devam eden üçüncü kişiye karşı, ancak durumun devreden tarafından kendisine bildirildiği andan başlayarak hüküm doğurur.*" Bu hüküm sadece zilyetliğin havalesinde uygulanır.

1118 Bu hükümde, zilyetliğin havalesinin hüküm ve sonuçlarını doğurması için gerekli olan hukuki olgu olarak, zilyetliğin havalesinin bildirimi düzenlenmiştir[882]. Üçüncü kişiye bildirim yapılana kadar zilyetliğin havalesinin sonuçları onun yönünden askıda belirsizdir.

---

[880] **STARK**, BK ZGB Art.924. N.17. **ERNST**, BSK ZGB Art.924. N.8. 10 ff.

[881] **NOMER/ERGÜNE**, s.29.

[882] **HINDERLING**, SPR V/1. s. 4537. **STARK**, BK ZGB Art.924. N.22.

1119 Bildirimin devreden tarafından üçüncü kişiye yapılacağı TMK m.979 II hükmünde belirtilmiştir. Devralanın zilyetlik havalesi sözleşmesinden veya bunun dışındaki bir ilişkiden doğan temsil yetkisi söz konusu ise, devreden adına bildirimi yapabilir[823]. İhbarın zilyetliği devralan tarafından yapılması durumunda da kanunun amaçladığı zilyetliğin havalesi olgusunu üçüncü kişi öğrenmiş olduğundan, onun öğrenmedim savunması artık TMK m.2 kapsamında dürüstlük kuralına aykırı olduğundan korunmaz[824].

1120 Bildirim, zilyetliğin havalesi sözleşmesi kapsamının dolaysız zilyede bildirimi şeklinde yapılır. Bildirim öncesi veya sonrası, eşyayı kime geri vereceği konusunda tereddüt eden dolaysız zilyet, TBK m.187 hükmünün kıyasen uygulanmasıyla, mahkeme kararı ile belirlenen yere eşyayı tevdi edebilir[825].

(b). Niteliği

1121 Zilyetliğin havalesi bildirimının yapılması zorunlu değildir[826]; zira bildirim kurucu olgu niteliğinde değildir.

1122 Doktrinde bazı yazarlar, dolaylı zilyet tarafından yapılan bildirimi zilyetliğin havalesi anlaşmasının geçerlilik şartı olarak kabul etmektedir; ancak bu geçerlilik şartı dolaylı zilyet yönünden arandığından etkisinin nispi olduğunu kabul ederek, yapılan anlaşmanın taraflar arasında geçerli olduğunu ifade etmektedirler[827].

1123 İstisnai olarak taşınır rehninin zilyetliğin havalesi ile kurulumunda kurucu niteliktedir[828]. Zilyetliğin havalesinin bildirimi, hâkim görüşe göre, *varması gerekli bir hukuki işlemdir*[829].

---

[823] **HOMBERGER**, ZGB Art.924, N.7; **OSTERTAG**, BK ZGB Art.924, N.11; **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N. 18; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.173.

[824] **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s.79.

[825] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.42.

[826] BGE 132 III 155 ff, 158 E.4.1; 119 IV 319 ff, 324 E.2b/aa; 112 II 406 ff, 420, E.5c.

[827] **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.140.

[828] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 81, dn.109; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 29. Bu konuda geniş bilgi ve tartışmalar için bkz. **ERGÜNE**, Taşınır Rehni, s.146 vd; **STARK**, BK ZGB Art.924, N.33 ff.

[829] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.28; **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N. 18. Aksi fikir **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.924, N.6.

(c). Bildirimin Şekli

1124 Devredenin zilyetliğin havalesi bildirimi, kural olarak, şekle tabi değildir[90]. İstisnai olarak, taşınır art rehninin önceki rehin alacaklısına bildirimi yazılı şekle tabidir (TMK m.941)[91].

(d). Bildirimin Hukuki Sonuçları

1125 Bildirimle birlikte zilyetliğin havalesinin hüküm ve sonuçları, bildirim anından başlayarak eşyayı dolaysız zilyet olarak tutan için de doğmaya başlar.

(aa). Bildirimden Önce

1126 Bildirim yapılmadan önce, dolaysız zilyet üçüncü kişi ile zilyetliğin havalesi sözleşmesi uyarınca zilyetliği kazanan arasında bir hukuki ilişki bulunmamaktadır. Ancak zilyetliğin havalesi bildirimden bağımsız gerçekleşir.

1127 Bildirim yapmadan önce dolaysız zilyet olan üçüncü kişi, eşya üzerindeki zilyetliğini eski zilyede iade ederse, bundan dolayı sorumlu olmaz[92]. Bildirimin yapılması veya bildirim yapılmasa bile dolaysız zilyedin zilyetliğin havalesi yapıldığını bir şekilde öğrenmesine rağmen, bilerek zarar vermek amacı ile iade etmişse, TMK m.49 II kapsamında devralana karşı sorumlu olur[93].

1128 Dolaysız zilyet, TMK m.2'deki dürüstlük kuralına aykırı olarak, zilyetliğin havale edildiğini bildiği halde, bilmediğini iddia ederse, bu iddiası dikkate alınmadan, bildirim yapılmış gibi zilyetliğin hüküm ve sonuçlarından sorumlu tutulur[94].

(bb). Bildirimden Sonra

1129 Zilyetliğin havalesinin dolaysız zilyede bildirimi ile zilyetliğin devralan tarafından kazanıldığına ilişkin olarak üçüncü kişi ile zilyetlik ilişkisi kurulmuş olur[95]. Devredenin dolaylı zilyetliği söz konusu ise asli zilyetlik

---

[90] BGE 72 II 351 E.1. **STARK:** BK ZGB Art.924. N. 30. **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP.** N.173.

[91] Bu konuda geniş bilgi için bkz. **ERGÜNE.** Taşınır Rehni, s. 158 vd.

[92] BGE 112 II 406 ff. 420 E.5c.

[93] **HOMBERGER.** ZGB Art.744. N.2; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR.** s.81. **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP,** s.78. **NOMER/ ERGÜNE,** s. 30; **ÜNAL/ BAŞPINAR.** s. 141.

[94] **NOMER/ ERGÜNE,** s. 30.

[95] BGE 112 II 406 E.5c. 119 IV 319 E.2.b.aa.

-dolaylı zilyet üçüncü derecede zilyet ise ikinci derece fer'i zilyetlik- devralan zilyede geçmiştir. Devralan zilyet zilyetlikten doğan haklarını, dolaysız zilyede -üçüncü kişiye- karşı ileri sürebilir. Dolaysız zilyede bildirim yapılmadan önce ya da bildirim yapılsa da dolaysız zilyet, zilyetliğin havalesini tanımayabilir. Dolaysız zilyet zilyetliğin havalesini tanımazsa, zilyetliği havale yolu ile kazanan kişi kanun gereğince dolaylı zilyet olur.

1130 Zilyetliğin havalesi bildirimi ile dolaysız zilyet bilgilendirilmiş olur. Üçüncü kişi havale ilişkisi kapsamında, zilyetliği devredenin artık zilyet olmadığını ve bununla birlikte şartları gerçekleşmişse ayni hak sahibi olmadığını; devralanın da artık zilyet olduğunu, şartları varsa ayni hak sahibi olduğunu öğrenmiş olur[956].

1131 Dolaysız zilyedin bildirimle bilgilendirilmesi, artık devralanın dolaylı zilyetliğini, şartlar varsa eşya üzerindeki mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanımı olduğunu, devralanın zilyetlikten veya ayni haktan doğan yetkilerinin – kişisel hak da olabilir- muhatabı olduğu anlamına da gelir. Bildirim sonrası üçüncü kişi, dolaysız zilyetliğindeki eşyayı sadece devralan (kazanandan) başkasına teslim edemez; ona vermekten kaçınamaz[957].

(e). Dolaysız Zilyedin Eşyayı Geri Vermekten Kaçınması

1132 Devralanın zilyetliğin havalesi dolayısıyla zilyetlik olgusundan veya zilyetliğin havalesi ile mülkiyet gibi ayni ve kişisel hakları kazanması, dolaysız zilyedin eşya üzerindeki zilyetlik durumu ve haklarını kullanmasını engellemez. TMK m.979 III'e göre, "*üçüncü kişi, zilyetliği devredene karşı ileri sürebileceği sebeplerle şeyi edinene vermekten kaçınabil*"eceğini düzenlemiştir. Bu hüküm sadece zilyetliğin havalesinde uygulanır.

1133 Dolaysız zilyet, devredene karşı ileri sürebileceği ayni veya nispi haktan doğan def'i ve itirazlarını savunma olarak, zilyetliğin havalesi ile zilyetliği devralana (kazanana) karşı da ileri sürebilir[958]. Sınırlı ayni hak sahibi üçüncü kişinin hukuki durumu[959] da İsviçre hukukunda eskiden beri tartışılmaktadır[960].

---

[956] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.27; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.172.

[957] **ERNST**, BSK ZGB Art.925, N. 10 ff.

[958] **HOMBERGER**, ZGB Art 895, N.11; **HINDERLING**, SPR V/1, s. 440; **ERNST**, BSK ZGB Art 924, N.17.

[959] Karş. BGB § 931.

[960] **HUBER**, Erlauterungen II, s.387. Farklı görüş **ROSSEL**. Bu tartışmalar için bkz. **EITEL, P.**, s 69 ff.

1134 *Huber'i* takip eden hâkim görüş, dolaysız zilyedin zilyetliği kazanana karşı sadece, sınırlı ayni haklardan doğan haklarını ileri sürebileceği görüşündedir[201]. Bu görüşe göre, dolaysız zilyedin ayni hak sahibi olduğu durumlarda, devralan -yeni- zilyedin de nispi veya ayni hak sahibi olduğu durumlarda, dolaysız zilyet ayni hakkından doğan haklarını veya zilyetlik hukuki durumunu devralan zilyede karşı ileri sürebilir. Buna karşın, zilyetliği devralanın ayni hak kazandığı, dolaysız zilyedin sadece nispi hak sahibi olduğu durumlarda ise, dolaysız zilyet nispi haktan kaynaklanan veya zilyetlik durumundan kaynaklanan hakkı devralan yeni zilyede karşı ileri sürerek eşyayı geri vermekten kaçınamaz. Bu görüş, dolaysız zilyedin devredenle olan ilişkisi sebebiyle sahip olduğu nispi hakları (alacak hakkını) yeni kazanana karşı ileri sürebilmesini, kanunun özel hükümleri uyarınca mümkün görmektedir[202].

1135 *Ernst'in* haklı olarak belirttiği üzere, devralanla dolaysız zilyet arasındaki hukuki ilişki, kanun dolayısıyla havaleyi yapanın hukuki durumunun devralan tarafından kazanımı olarak görülmektedir[203]. Bize göre de, zilyetliğin havalesinin dolaysız zilyede bildirimi ile kanun gereğince devredenin zilyetlik hukuki durumu, buna bağlı olarak hakları *kendiliğinden devralana geçer*. Dolaysız zilyede bildirime kadar devralanla dolaysız zilyet arasındaki ilişki, bekleme durumundadır.

1136 *Rossel* tarafından savunulan yeni bir yaklaşıma göre ise[204], dolaysız zilyet, devredene karşı sahip olduğu ayni hakları dışında, nispi haklarını da devralana karşı ileri sürebilir. Gerçekten, TMK m. 979 III hükmü ayni haklarla nispi hak ayrımı yapmaksızın, dolaysız zilyedin devredene karşı ileri sürebileceği sebepleri şeyi edinene karşı da ileri sürebilmesini düzenlemiştir.

1137 *Görüşümüze göre,* dolaysız zilyet, devredenle olan ilişkisi sebebiyle sahip olduğu sınırlı ayni hakları zilyetliği devralana karşı da ileri sürebilir. Nispi haklara dayanabilmesi yönünden ise, *Ernst*'in haklı olarak ifade

---

201 HUBER'in yaklaşımını benimseyen görüş: HOMBERGER, ZK ZGB Art.924, N.10 f; STARK, BK ZGB Art.924, N.37 ff; SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N.174; STEINAUER, I, N.280; BERGER-STEINER/SCHMID, OFK ZGB Art.924, N.13; OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s. 82-83; NOMER/ ERGÜNE, s. 31; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 141.

202 STARK, BK ZGB Art.924, N.37.

203 ERNST, BSK ZGB Art.924, N.21; KIKINIS, s.135 ff; TEKİNAY/AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 80-81; ERTAŞ, N.192.

204 EITEL, Fahrnis, s. 71 ff.

ettiği üzere[204], özel hukuki ilişkinin kanunla düzenlendiği durumlarda, hak sahibinin hem nispi haklardan hem de ayni haklardan doğan hakkını zilyetliği kazanana karşı ileri sürebileceğini kabul etmekteyiz.

1138 Bu yaklaşıma paralel olarak, TBK m.310 ve m.311 hükmüne göre, kira sözleşmesi kurulduktan sonra, kiralanın mülkiyetinin el değiştirmesinde veya kiralamayla çatışan bir sınırlı ayni hak kurulumunda, dolaysız zilyet olan kiracı, yeni malik ve sınırlı ayni hak sahibine karşı kira sözleşmesinden doğan nispi hakkı ileri sürebilir.

1139 TMK m.950'deki hapis hakkı yönünden de dolaysız zilyet üçüncü kişinin-hapis hakkına dayanıp dayanmayacağı hususunu kanun açık olarak düzenlememiştir. TMK m.979 III düzenlemesinde kanunun koruma amacı, dolaysız zilyet olan üçüncü kişinin nispi hak ve yükümlülükleri değildir[205]. Devralan ile dolaysız zilyet arasındaki ilişkide, dolaysız zilyedin kişisel hakkına bağlı olarak TMK m.950 hükmünde düzenlenen hapis hakkını zilyetliği kazanana ileri sürebilmesi sadece kanunla düzenlenen özel hukuki ilişkilerde saklıdır. TMK m.979 III yasal düzenlemesinin koruma amacı dikkate alındığında, üçüncü kişinin devredenle olan ilişkisinden doğan alacak haklarından ve bu hakka ilişkin hapis hakkından, kural olarak, zilyetliği devralana karşı yararlanamayacağı[206] anlaşılmaktadır.

eee. Özel Durumlar

1140 Taşınır rehni, tartışmalı olmakla birlikte[207], zilyetliğin havalesi yolu ile kurulduğunda, dolaysız zilyet olana rehnin kurulduğu bildirimi, genel zilyetliğin havalesinden farklı olarak, kurucu niteliktedir[208]. Bu bildirim şekle tabi değildir

1141 Yine art taşınır rehninin zilyetliğin havalesi yolu ile kurulumu, dolaysız zilyede (önceki rehin alacaklısına) yapılacak yazılı bildirimle gerçekleşir. Bu yazılı bildirim geçerlilik şeklidir (TMK m.941)[209].

---

[204] **ERNST**, BSK ZGB Art.924, N.21.

[205] Aksi görüş **STARK**, BK ZGB Art.924, N.38 ff. **EITEL/ ARNET**, CHK ZGB Art.924, N.6.

[206] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.38 ff.

[207] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.33 ff.

[208] **ERGÜNE**, Taşınır Rehri, s.146 vd.

[209] **ERGÜNE**, Taşınır Rehri, s.158 vd.

1142 Elden bağışlama, bağışlayanın bir taşınırı bağışlayana teslim etmesiyle kurulacağından (TMK m.289), zilyetliğin havalesi ile kurulamaz[211].

ff. Emtiayı Temsil Eden Evrakların Teslimi

aaa. Genel Olarak

1143 TMK m.980 hükmü emtiayı temsil eden evrakların teslimi ile zilyetliğin devrini, "bir taşıyıcıya veya umumi mağazaya bırakılmış emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslimi, emtianın teslimi gibi sonuç doğurur.

1144 Kıymetli evrakı iyiniyetle teslim alan kimse ile emtiayı iyiniyetle teslim alan kimse arasında uyuşmazlık çıkarsa emtiayı teslim alan tercih olunur." şeklinde düzenlemiştir. Emtianın zilyetliğinin devri ve bununla birlikte bu konudaki uzlaşma eşyayı temsil eden evrakın teslimine bağlanmıştır. Bu kıymetli evrakın teslim fonksiyonu olarak, evrakın temsil ettiği emtianın zilyetliği devredilmektedir.[212]

1145 TMK m.980, mutlak teorinin aksine temsil teorisine (Repräsentationstheorie) göre, emtianın değil, emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ile emtianın zilyetliğinin devredildiğini kabul etmiştir[213]. Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi, kıymetli evrakta gerçekleşen zilyetliğin havalesidir[214]; onun özel bir görünüm şeklidir[215]. İsviçre hukukunda, TMK m.980 hükmünün uygulamada fazla anlamının olmadığı[216], hatta anlamsız olduğu, ikinci fıkranın da gereksiz olduğu savunulmaktadır[217].

bbb. Hukuki Olguları

1146 TMK m.980.I hükmünden hareketle, emtiayı temsil eden evrakların teslimi ile zilyetliğin devrinin hukuki olgularını şu şekilde belirleyebiliriz:

---

[211] Bu konuda yasal düzenlemeye rağmen aksi görüş için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.924, N.35 ve orada belirtilen BGE 63 III 395 ff.

[212] **ERNST**, BSK ZGB Art.925, N.1, 11.

[213] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.18a.

[214] **MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE**, § 27, RZ.36; **STARK**, BK ZGB Art.925, N.19.

[215] **STARK**, BK ZGB Art.925, N.2; **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.925, N.2; **SCHMID/ HÜRLIMANKAUP**, N.196; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.142; **NOMER/ERGÜNE**, s.32.

[216] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.3a; **EIETEL/ARNET**, CHK ZGB Art.925, N.5.

[217] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.35.

(1). Emtia Taşıyıcıya ya da Ardiyeciye veya Umumi Mağazaya Bırakılmış Olmalı

1147 Emtia bir taşıyana, ardiyeciye ya da umumi mağazaya teslim edilmiş olmalıdır. TMK m.980 I hükmünde ifade edilen "*taşıyan*" mehaz OR Art.440 ff hükmünde düzenlenmiş olan "Fachtfuhrer" TBK'nda düzenlenmemiştir. Bu sebeple taşıyıcının kim olduğunu, TTK hükümlerinden hareketle belirlememiz gerekir.

1148 Mehaz ZGB Art.925 hükmünde, "umumi mağaza" yerine, OR Art. 482'yi karşılayan TBK m.571 vd. düzenlenen "ardiyeci"den (Lagerhaus) bahsedilmektedir. TBK m.571 hükmünde de saklanılan malı temsil eden senetten bahsedilmektedir ki bu senet TMK m.980'de ifade edilen emtiayı temsil eden senettir.

1149 Türk hukuku yönünden de burada örtülü boşluk olduğunu kabul ederek, örtülü boşluğu umumi mağaza yerine ardiye olarak hükmün amaçsal düzeltmesi ile değiştirerek doldurmamız gerekir.

1150 Elbette ki, TTK m.839 hükmüne göre de kanunla verilen izinle kurulan umumi mağazalar tarafından emtia üzerindeki mülkiyet hakkını temsil eden *makbuz senedi*, rehin hakkını temsil eden *varant* düzenlenebilir. Bu senetlerin şekil şartları TTK m.834 ve 835'te düzenlenmiştir.

1151 Makbuzun ciosu, ciro lehtarına umumi mağazaya tevdi edilen eşyanın mülkiyetini devreder; varantın cirosu ise, ciro lehtarına umumi mağazaya tevdi edilen eşya üzerinde rehin hakkı sağlar. Kara veya deniz taşımacılığında emtia senetlerinin teslimi yüklenmiş eşyanın teslimi anlamına gelir[2-8].

(2). Emtiayı (Eşyayı) Temsil Eden Kıymetli Evrak Teslim Edilmeli

1152 Emtiayı temsil eden evrak (Warenpapier) söz konusu olmalı, bu evrak kıymetli evrak (Wertpapier) niteliğinde olmalıdır. Emtiayı temsil eden kıymetli evrak, TMK m.980 hükmünde belirtilenlerle sınırlı değildir.

1153 Bir emtiayı temsil eden kıymetli evrak, belgeyi düzenleyenin sadece emtiayı temsil eden belge ibraz edildiği takdirde, belgede belirtilen emti-

---

2-8 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s.84; TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 81; NOMER/ ERGÜNE, s. 32; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 142.

anın ibraz edene teslim edileceği sözünü ihtiva eden, usul ve şekilleri kanunla belirlenmiş belgedir[219]. Emtiayı temsil eden bir kıymetli evrak (Warenpapierre, Traditionspapierre, Dispositionspapierre) söz konusu olmalıdır. TMK m. 980 hükmünün uygulamasındaki kıymetli evraklar, ardiyeci senedi, konşimento, makbuz senedi ve varantır[220].

1154 Hak sahipliğini gösteren dokümanlar ve basit borç belgeleri, yükleme belgeleri, irsaliye, fatura, varış belgesi, gümrük beyan ve belgeleri, vergi beyan ve belgeleri, vb. bu nitelikte değildir[221]. Emtiayı temsil eden kıymetli evrak, ilgilisi tarafından, usulüne uygun olarak ilgili Kanunda belirtilen şekilde düzenlenmelidir. Emtiayı temsil eden kıymetli evrak usulüne ve şekle uygun olarak geçerli bir evraksa, emtiayı temsil edebilir[222].

1155 Her emtiayı temsil eden **temsil evrakı** (Warenpapierre) değil, bunlardan **kıymetli evrak** (Wertpapierre) niteliğince olanlar TMK m.980 hükmünün uygulaması kapsamındadır[223]. Emtiayı temsil eden evraka kıymetli evrak niteliğini Kanun verir.

1156 Emtiayı temsil eden kıymetli evrak, temsil ettiği emtianın üçüncü kişinin dolaysız zilyetliğine bırakıldığını gösterir[224]. Ardiyecinin saklanmak üzere teslim aldığı ticari emtia için çıkardığı senet, *ardiyeci senedi*dir (Lagerschein). TBK m.671 bu senedin yetkili makam tarafından düzenleneceğini ifade etmektedir. Taşıyıcının düzenlediği emtiayı temsil eden evraka kara taşımasında *taşıma senedi*, deniz yolu ile taşımada konşimento adı verilmektedir[225].

1157 TTK m.839 hükmüne göre de kanunla verilen izinle kurulan umumi mağazalar tarafından, emtia üzerindeki mülkiyet hakkını temsil eden *makbuz senedi*, rehin hakkını temsil eden *varan:* düzenlenebilir. Bu senetlerin şekil şartları TTK m.834 ve 835'te düzenlenmiştir[226].

---

[219] **MEIER-HAYOZ**/von der Crone, 27. Rz.3; **OFTINGER, JÄGGI**, OR Art.2253, N.3; **OFTINGER/BÄR**, ZGB Art.902, N.3 ff; **STARK**, BK ZGB Art.925, N.7.

[220] **STARK**, BK ZGB Art.925, N.11; **ERNST**, BSK ZGB Art.925, N. 7; **HINDERLING**, V/1, s.442.

[221] **ERNST**, BSK ZGB Art.925, N. 9; **JÄGGI**, OR Vorbem zu Art.1153 ff; N.30 ff.

[222] **ERNST**, BSK ZGB Art.925, N.7 ff.

[223] **OFTINGER/BÄR**, ZK ZGB Art.902, N.4; **STARK**, BK ZGB Art.925, N.7; **ERNST**, BSK ZGB Art.925, N.2.

[224] **STARK**, BK ZGB Art.925, N.13.

[225] Bkz. **CHRISTEN**, BSK OR Art.1153-1155, N.4 ff.

[226] Bkz. **OFTINGER/ BÄR**, ZK OR Art.902, N.16 f.

1158 Makbuzun cirosu, ciro lehtarına umumi mağazaya tevdi edilen eşyanın mülkiyetini devreder; varantın cirosu ise, ciro lehtarına umumi mağazaya tevdi edilen eşya üzerinde rehin hakkı sağlar. Kara veya deniz taşımacılığında emtia senetlerinin teslimi yüklenmiş eşyanın teslimi anlamına gelir[227]. Emtiayı temsil eden evrak şekil kurallarına uygun olarak düzenlenmemesi halinde, eksik evrak kıymetli evrak olarak nitelenemez; sadece teslim alma belgesi veya diğer ispat belgesi görevini görür[228].

1159 Kıymetli evrakın konusu, belirlenmiş bir gayri misli eşya niteliğinde parça eşya; misli eşya olsa bile parça eşya niteliğinde olmalıdır. Evrakın temsil ettiği eşya, nitelik ve çeşitte ortalama nitelikte olacak şekilde zilyetlik devrine konu edilmez; evraka konu edildiği şekliyle teslim edilir[229]. Misli şeylerin ardiyecinin yetkisine dayanarak karıştırması sonrasında oluşan birlikte depolanmış eşya (TMK m.573), birlikte zilyetlik olarak emtiayı temsil eden kıymetli evraka konu olabilir[230].

ccc. Hukuki Sonucu

(1). Emtianın Teslim Edilmiş Sayılması

1160 Emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslimi -veya cirosu-, temsil teorisi uyarınca, ardiyeciye, taşıyıcıya veya umumi mağazaya bırakılmış emtianın teslimi gibi sonuç doğurur[231].

1161 Emtiayı temsil eden kıymetli evrak, teslim veya yazılı devir beyanı, yani nama, emre ve hamiline şekilde[232] ciro veyahut hem ciro hem de teslimle devredilebilir[233].

1162 Kıymetli evrakta, ada veya nama yazılı devir açıklaması bulunmaması halinde, evrakın zilyedi, evrakın temsil ettiği emtiadaki dolaylı zilyetliği kazanamaz; dolayısıyla emtianın mülkiyetini kazanamaz. Temsil edi-

---

227 OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s.84; TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 81; NOMER/ ERGÜNE, s. 32; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 142.

228 STARK, BK ZGB Art.925, N.30.

229 OFTINGER/BÄR, ZK ZGB, N.9; GAUCHI, OR Art.484, N.1b; STARK, BK ZGB Art.925, N.14.

230 MEIRER-HAYOZ/von Dr. CRONE, 27, Rz.17; WIELAND, ZGB Art.925, N. 4; GAUCHI, OR Art.484, N.3c; STARK, BK ZGB Art.925, N.15; ERNST, BSK ZGB Art.925, N. 10.

231 STARK, BK ZGB Art.925, N.18a; ERNST, BSK ZGB Art.925, N. 13.

232 STARK, BK ZGB Art.925, N.8.

233 STARK, BK ZGB Art.925, N.20; EITEL/ARNET, CHK ZGB Art.925, N.3.

len emtia üzerindeki zilyetlik, evrakın zilyetliğiyle ile değil, evrakta hak sahibi olmayla gerçekleşir[234].

1163 Emtiayı temsil eden senedın teslimi sadece temsil ettiği eşyanın zilyetliğini değil, senede bağlanmış hakkın devrini de gerçekleştirir[235]. Kural olarak zilyetlığın devri, aynı zamanda, geçerli sebep işleme dayanması kaydıyla, aynı hakkın bu kapsamda mülkiyetinin de devri sonucunu doğurur.

1164 Kıymetli evrakla devrinde de aynı hukuki sonuç gerçekleşir. Emtia ve onu temsil eden kıymetli evrak, birlikte aynı hukuki işlemin konusunu oluşturur. Kıymetli evrakla birlikte ayni hakkın devri, emtiayı bulunduranın artık emtiada zilyet bulunmadığı durumlarda mümkün değildir.

1165 Kıymetli evrakın devri ile birlikte emtianın devri gerçekleştiğinden, bunun sonucu olarak, sadece nispi nitelikte borçlandırıcı bir teslim talebi veren bir hak doğmaz. Taşıyıcıya veya ardiyeye veyahut umumi mağazaya teslim edilmiş eşyayı temsilen kıymetli evrak çıkarılmışsa, artık sadece emtiayı temsil eden kıymetli evrakın teslimi ile eşyanın zilyetliğinin kazanımı kendiliğinden ve devredenin dolaysız zilyede bir bildirimine gerek olmaksızın gerçekleşir[236].

1166 Emtiayı temsil eden kıymetli evraklar, usulüne uygun şekilde, devralana ya ciro edilmeli ya da teslim edilmeli veyahut hem ciro hem de teslim edilmelidir[237]. Geçersiz bir şekilde verilen kıymetli evrak, devralana kıymetli evraka konu emtia üzerinde zilyetlik sağlamaz.

1167 Taşıyıcı, ardiyeci, umumi mağaza sahibi kendisine teslim edilen emtianın dolaysız, genelde fer'i zilyedidir[238]. Emtiayı bunlara bırakan ise, genelde, emtianın sahibi sıfatıyla aslî zilyettir; rehin hakkı sahibi olarak fer'i zilyet olabilir; her durumda dolaylı zilyettir.

1168 Emtiayı temsil eden senedın teslimi ile senedi teslim alan emtianın yeni dolaylı zilyetliğini kazanır; senedın teslim alınmasıyla birlikte mül-

---

[234] **WIELAND**, ZGB Art.925. N. 3; **STARK**, BK ZGB Art.925. N.20a.

[235] **STARK**, BK ZGB Art.925. N.20a.

[236] **STARK**, BK ZGB Art.925. N.19.

[237] **STARK**, BK ZGB Art.925. N.20; **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.925. N.3.

[238] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.925. N.6.

kiyeti kazanmışsa aslî zilyet; başka bir ayni veya nispî hak kazanmışsa fer'î zilyet olabilir. Senedi teslim eden, mülkiyet hakkını kendine tutarak, senet üzerinde rehin hakkı veya başka bir ayni hak kurarak çoklu kademeli zilyetlik oluşturabilir.

1169 Senedin teslimının emtianın devri sonucunu doğurması için bunun taşıyıcı, ardiyeci veya umumî mağazaya bildirilmesine gerek yoktur; bu kişiler senedi ibraz edene emtiayı teslim edecek ya da onun hakkını tanıyacaklardır[239]. Taşıyıcı, ardiyeci ve umumî mağaza ise yeni zilyetliği devralan adına dolaysız fer'î zilyetliğini devam ettirir.

1170 Emtiayı temsil eden evrakın devredilmesi ile birlikte evraka dolaysız zilyet olan, evrakı usulüne uygun devralmışsa, kural olarak, temsil edilen emtianın zilyetlikle beraber mülkiyetini de kazanır[240]. Kıymetli evrakı rehin amaçlı olarak, usulüne uygun şekilde teslim alan, evrakın temsil ettiği eşya üzerinde dolaysız zilyet olarak rehin hakkı sahibi olur.

(2). Verme Yükümlülüğünde Hapis Hakkı

1171 Kıymetli evrakta hak sahibi olarak görülen kişinin, emtianın kendisine verilmesini istemesi halinde, emtiayı dolaysız zilyetliğinde bulunduran, örneğin; ardiyeci, taşıyıcı vb. kişinin, hapis hakkını, kıymetli evrakın hak sahibine karşı da ileri sürüp süremeyeceği tartışması gündeme gelir. Emtiayı elinde bulunduran, hak sahibi olana karşı, örneğin ardiye ücretini ve masrafları, hapis hakkını, taşıma ücretini ve masrafından doğan hapis hakkını kullanabilecek midir?

1172 *Oftinger*, emtianın dolaysız zilyedinin hapis hakkını kullanarak emtiayı geri vermekten kaçınamayacağı görüşündedir[241].

1173 Kural olarak, emtiayı temsil eden kıymetli evrakın niteliği gereği, devralanın (hak kazananın) bu hapis hakkı def'isini dikkate alıp değerlendirmesi beklenemez[242]. Zilyetliği devralan (kazanan), devraldığı kişiden bağımsız, kendisi için zilyetliği (hakkı) kazanmaktadır. Bu kural, hamiline ve ada yazılı kıymetli evrakta geçerlidir; fakat nama yazılı ev-

---

[239] **SCHMID/ HÜRLIMAN-KAUP,** N.196; **STEINAUER,** I. N.298.

[240] **HOMBERGER.** ZGB Art.925, N. 6; **WIELAND,** ZGB Art.925, N. 3; **STARK,** BK ZGB Art.925, N.20a.

[241] **OFTINGER**, s. 51.

[242] **JÄGGI,** OR Art.967, N. 184; **STARK,** BK ZGB Art.925, N.30a.

rakta (Namenpapierre) geçerli değildir[243]. Ada veya hamiline yazılı kıymetli evrakla hak kazanana karşı hapis hakkı kullanılamaz.

1174 Bunun dışında nama yazılı kıymetli evrak ve diğer durumlarda, kıymetli evraka konu emtiayı elinde bulunduranın, alacaklarına ilişkin hapis hakkının bulunabileceği gerçeği ve bu riskleri dikkate alarak hak sahibinin kıymetli evrakı devraldığını kabul etmek, ticari ve yaşam ilişkilerinin doğal bir sonucudur. TBK m.574 hükmü, istisna getirmeksizin, ardiyecinin hapis hakkını özel olarak düzenlemiştir.

(3). İyiniyetli Emtiayı Teslim Alanın Korunması

1175 TMK m.980 II'e göre, kıymetli evrakı iyiniyetle teslim alan kimse ile emtiayı iyiniyetle teslim alan kimse arasında uyuşmazlık çıkarsa, bu çatışmada emtiayı teslim alan tercih olunur.

1176 TMK m.980 II hükmü, TMK m.988'in özel bir görünümü şeklindedir[244]. Bu hükümle, emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle ayni hak kazanılmasına senetlerin teslimi yoluyla hak kazanma karşısında öncelik tanınmıştır[245]. Bu öncelığın söz konusu olabilmesi için, emtiayı teslim alanın iyiniyetli yani, emtiayı temsil eden senedin çıkarıldığını bilmemesi veya bilemeyecek durumda olması gerekir.

1177 Doktrinde bazı yazarların savunduğu üzere, emtiayı temsil eden evrakın çıkarılması durumunda, sadece kıymetli evrakın devri yoluyla zilyetlik kazanılabilir; artık TMK m.979 anlamında zilyetlığın havalesi yoluna başvurulamaz[246].

III. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ

A. Genel Olarak

1178 TMK m.976 hükmü, karşıt kavram yorumuyla zilyetlığın kaybedilmesini düzenlemiştir: "Fiilî hâkimiyetin geçici nitelikteki sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalkması zilyetlığı sona erdirmez".

---

[243] JÄGGI, OR Art.988-989, N. 38; STARK, BK ZGB Art.925, N.28.

[244] ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 32.

[245] STARK, BK ZGB Art.925, N. 34 ff; EITEL/ARNET, CHK ZGB Art.925, N.4.

[246] STARK, BK ZGB Art.925, N.3; EITEL/ARNET, CHK ZGB Art.925, N.2; TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 83.

1179 TMK m.976 geçici fiili hakimiyetin kesilmesinin zilyetliğe etkisini düzenlemektedir. Bu hükmün karşıt kavram anlamı (argumentum e contrario) zilyetliğin hukuki olguları ile birlikte yorumladığımızda, zilyetliğin kaybedilmesine sebep olan temel olgunun, eşya üzerindeki fiili hakimiyetin kaybedilmesi olduğunu belirleyebiliriz. Zilyetliğin kazanılması, aynanın öbür yüzünde kaybı demektir. Zilyetlik aslen kaybedileceği gibi devren de kaybedilebilir. Zilyetliğin devren kaybı teslim ve zilyetlik sözleşmesi ile gerçekleşir.

B. Fiili Hâkimiyetinin Sürekli Kaybedilmesi

1. Fiili Hâkimiyetin Geçici Kaybı veya Sürekli Kaybı Kavramı

1180 Fiili hâkimiyetin kullanılmasının veya kullanma olanağının geçici olarak kaybedilmesi halinde, kişinin var olan zilyetliği sona ermez, devam eder[247]; bu kaybolma halının sürekli olması halinde ise kişinin zilyetliği sona erer.

1181 Fiili hâkimiyetin kullanılmasının veya kullanma olanağının kaybının geçici mi yoksa sürekli mi olduğunu, başka bir deyişle yeniden zilyetliğin fiili hâkimiyet olgusunun sağlanıp sağlanmayacağını, hakim, *ticaret ve yaşam ilişkilerine hâkim olan esaslara* göre[248], hâkimiyet altına alınan eşyanın doğal nitelik ve özellikleri dikkate alarak takdir edip (TMK m.4) belirleyecektir. Örneğin; bir kimsenin işe giderken bilgisayarını evde unutması durumunda, bilgisayarın evde bulunması nedeniyle zilyetliği sona ermez, devam eder. Bu sonuç, yaşama ilişkilerine hâkim olan *"evde kaybedilmez" ilkesi*ne uygundur. Zilyetliğin kaybedilmediği durumlara ilişkin diğer bir örnek olarak; bahçeden kaçan köpek ya da evden kaçan kedi örneği verilebilir. Başka bir örnek ise kişinin bilerek sakladığı kıymetli şeyi sonradan bulması halidir[249].

1182 Zilyedin geçici olarak eşyadan uzaklaşması, örneğin seyahate çıkması veya hastanede tedavi görmesi halinde zilyet, o eşya üzerindeki zilyetliğini geçici olarak kaybetmiştir. Aynı şekilde, evin veya işyerinin oto-

---

[247] *"... Türk Medeni Yasasının 976. maddesi hükmü gereği, fiili hakimiyetin geçici sebeplerle kullanılmaması veya kullanma olanağının ortadan kalkmasının zilyetliği sona erdirmeyeceği kuşkusuzdur..."* Y. 1. HD. 27.5.2010 T., 2010/5248 E., 2010/5995 K.

[248] **STARK**, BK ZGB art.921, N.4; **ERNST**, BSK ZGB Art.921, N.4; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.201; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 146.

[249] BGE 71 IV 87 E.2.

parkına aracın bırakılması, hastanede tedavi görüldüğü sırada, evin tadilat altında olduğu dönemde, gözaltına alınma, hatta kısa süreli hapis halinde zilyetlik geçici olarak kaybedilmiştir.

1183 Vahşi hayvanlar üzerindeki fiili hâkimiyet, hayvanın kaçması ile hayvan sahipsiz hale geleceğinden ortadan kalkar. Ev hayvanları ise, üzerlerindeki zilyetlikten vazgeçmeyle veya sürekli olarak hâkimiyetin kullanılamaması halinde sahipsiz hale gelir.[250]

1184 Yolcunun okuduğu kitabı veya çantasını toplu ulaşım aracında unutması, gemide seyahat esnasında üst güvertede saatin unutulması vb. hallerde hakimiyet sürekli olarak kaybedilmişse, zilyetlik sona erer[251]. Zilyet şeyi bildiği bir yerde unuttuğunu kısa bir süre içinde hatırlayarak gidip alırsa ya da bulandan veya onun teslim ettiği bir yetkili kişiden geri alırsa, zilyetliği geçici olarak kaybetmiş olduğundan, zilyetlik kesintiye uğramaz[252].

1185 Zilyetliğin sürekli veya geçici kesilmesi, *eşyanın niteliğinden veya özelliğ*inden kaynaklanabilir[253]. Örneğin, kar pistini düzelten kar araçlarının yazın kullanılmaması zilyetliğin sürekli kesildiği anlamına gelmez[254].

1186 Fiili hâkimiyetin sadece kesilmesi değil, kesilmenin sürekli olarak eşyada fiili hâkimiyeti engellemesi gerekir. Fiili hâkimiyetin kesilmesine ilişkin süreklilliğin süresi konusunda, Kanun belirli bir süre limiti getirmemiştir. Fiili hâkimiyetin kesilme süresinin kısa ya da uzun olması değil, kesilmenin sürekli ya da geçici olup olmadığı önemlidir. Örneğin, zilyedin çalınan eşyası üzerindeki zilyetliği kesilir, kaybettiği zilyetliği geçici bir süre devam eder. Ancak hırsızın eşyayı çalması sebebiyle ke-

---

250 **LEEMANN**, BK ZGB Art.719, N.12; **HAAB/SCHERRER**, ZK ZGE Art.718-719, N.52.

251 Diğer örnekler ve değerlendirilmesi konusunda bkz. **STEINEUER**, I, N.306.

252 BGE 71 IV 183 E.2.

253 **ERNST**, BSK ZGB Art.921, N.5: Ne var ki 2010 tarihli bir HGK. kararında söz konusu husus tartışılmış ve haklı olarak karşı oy gerekçesinde de niteliği gereği taşınmaz ile 3-4 yılda bir de olsa kurulan bağın zilyetliğin devam ettirildiği anlamına geldiği ifade edilmiştir. Söz konusu karşı oy yazısı şu şekildedir. "*... davacının 1980 yıllarında Gökçeada'dan ayrılarak Yunanistan'a yerleştiği ancak Türk Vatandaşlığından ayrılmadığı, 3-4 yılda bir de olsa Türkiye'ye gelerek taşınmazlarla bağını sürdürmesi, taşınmazları serbest hayvancılık yapılması için dahi olsa kiraya vererek asli zilyetliğini devam ettirmesi dikkate alındığında az yukarda açıklanan iradi terk olgusunun somut olayda gerçekleşmediği, davacı yararına tespit gününe kadar kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiğinin kabulü gerekir.*" Y. HGK., 1.12.2010 T., 2010/16-522 E., 2010/614 K.

254 BGE 99 II 36.

silme sürekli ise zilyetliği kaybeder; zilyetliği kaybetmiş olsa bile tekrar kazanabilir.

1187 Zilyetliğin kesilmesi, eşyanın üzerindeki hâkimiyetini kişinin kullanmaması veya kullanma olanağının bulunmaması şeklinde gerçekleşir. Kişinin eşyayı sürekli olarak kullanma olanağının bulunamaması "imkânsızlık" kavramı kapsamında değerlendirilir.

1188 Zilyetliğin geçici kaybedilmesi halinde, zilyedin zilyetliği devam ettiğinden, zilyetlik durumundan kaynaklanan hak ve yükümlülükler de devam eder[255]. Bu kapsamda zilyet, zilyetliğin korumasında, zilyetliğin hak olarak korunmasına ilişkin talepleri de ileri sürebilir. Zilyetliğin sorumluluğunun kapsamına ilişkin hükümler de kendisine uygulanır. Zilyedin zilyetliği kazanması için gerekli olan süre kesintiye uğramaz[256].

2. Fiili Hâkimiyetin Sürekli Kaybıyla Zilyetliğin Kaybedilmesi

1189 TMK m. 976'nın karşıt (*e contrario*) anlamında yer aldığı üzere, zilyetliğin sürekli olarak kesilmesinin, yani zilyedin eşya üzerindeki fiili hakimiyeti kullanamaması veya kullanmasının imkansızlaşmasının sürekli olması halinde, zilyet zilyetliğini kaybeder[257].

1190 Zilyetliğin kaybedilmesi, zilyedin rızasına dayanabilir veya rızası olmaksızın da gerçekleşebilir. Zilyetliğin rıza dışı elden çıkıp çıkmadığı, tasarruf yetkisini ve taşınır davasını düzenleyen TMK m. 988-991 bakımından önem teşkil etmektedir.

a. Zilyedin Rızası ile Zilyetliğin Kaybedilmesi

1191 Zilyetlik zilyetliğin devren geçirilmesi halleri dışında, yalın olarak eşya üzerindeki hakimiyetin fiilen başkasına verilmesi ve zilyedin hakimiyet iradesinden vazgeçmesi yani terk etmesi şeklinde gerçekleşebilir. Örneğin, eskimiş patlamış lastiğin çöplüğe bırakılması, parçalanmış şemsiyenin çöpe atılması gibi.

1192 Zilyetlik, terkle de kaybedilir. Bunun için terk iradesinin ve terk fiilinin olması gerekir. Zilyetliğin terk ile kaybedilmesi için eşyayı fiilen hâ-

---

[255] STARK, BK ZGB ASrt.921, N.11 f.

[256] OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s. 75; TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 98; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 146.

[257] Karş. BGB § 854 Abs.2

kimiyetten çıkarma ile birlikte hakimiyet iradesine son verme iradesi de olmalıdır. Bu irade olmaksızın örneğin; eşyayı kullanmama terk anlamına gelmez[258]. Zilyetlik terk fiili olmaksızın, doğal irade niteliğinde terk iradesi ile de gerçekleşebilir. Genellikle, zilyetliği terk davranışı, terk iradesini ortaya koyar[259].

1193 Zilyetliğin teslimle kaybı, zilyedin zilyetliği devretme iradesini ortaya koyarak, kendi isteğiyle eşya üzerindeki fiili hakimiyetten vazgeçmesidir[260]. Örneğin; rızai teslim açık teslim veya teslim alan şeyin bedelini ödeme örtülü teslim anlamına gelir.

1194 Teslim etme ile zilyetliğin devri için maddi fiil niteliğindeki teslim etme iradesinin olması gerekir. Teslim etme iradesini açıklayanın hukuki işlem ehliyetine sahip olması değil, ayırt etme gücüne sahip olması dahi gerekli değildir. Karşı taraf yönünden bu teslim etme iradesinin görünür olmasına da gerek yoktur.

1195 Zilyetliğin devren geçirildiği teslim, eşyayı hakimiyet sağlayan araçların teslimi veya zilyetlik sözleşmesi ile devri halleri, hükmen teslim, zilyetliğin havalesi vb. durumlarda, zilyetlik zilyedin rızası ile sona ermiştir. Örneğin, arızalanan aracın servise bırakılmasında olduğu gibi. Bu konuda teslimle zilyetliğin kazanılması bölümüne atıfta bulunmakla yetiniyoruz[261]. Zilyet eşya üzerindeki zilyetliği üçüncü kişiye devredebilir veya eşyayı yalın olarak üçüncü kişiye verirse, zilyetliğin devri zilyedin rızasıyla gerçekleşmiştir. Örneğin aracın teslimi, atılan aracın anahtarlarının verilmesi, aracın kullanım dışı kalması sebebiyle parçalanması için hurdacıya bırakılması gibi.

---

[258] ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 146.

[259] *"... Mahkemenin taşınmazların 5 ila 10 yıldır ekilmemesi nedeniyle davacı tarafından iradi olaraktan terk edildiği şeklindeki gerekçesi de yerinde değildir. İradi terkin varlığından bahsedilmesi için taşınmazın belli bir neden yokken uzun yıllar kullanılmaması ve zilyedin taşınmaz üzerinde egemenliğini dile getirecek herhangi bir ilgiyi göstermemiş olması, artık o tarlayı terk ettiği yolunda herkeste bir kanının uyanmış olması gerekir. Zira zilyedin taşınmaz mala ilgi göstermemesi uzun süre taşınmaz üzerindeki başkalarının zilyetliğine itiraz etmemesi, zilyedin zilyetliği terk iradesinin varlığına kanıtlar. Ancak bu şekilde zilyedin taşınmazı terk ettiği yolunda herkeste bir kanının uyanması durumunda zilyetliğin yitirilmesi söz konusu olur. Zilyetliğin iradi olarak terki zilyedin beyanına göre de, anlaşılıp tespit edilebilir. Bu durumda bir kimse tarlasını ekmeyeceği, kullanmayacağı ve artık terk ettiği yolunda niyet ve iradesini belli etmiş ve fiili olaraktan da o yerde egemenliğine son vermiş ise terk olunmuş sayılır..."* Y., 8. HD., 10.10.1997 T., 1996/10476 E., 1997/6024 K.

[260] Karş. BGB § 856.

[261] **ANTALYA**, EH II, N. 378 vd.

1196 Zilyetliğin devren geçirilmesinde, devredenin zilyetliği sona ererken, devralan ise zilyetliği kazanmaktadır[262]. Eşyanın zilyetliği el değiştirmektedir.

b. Zilyedin Rızası Dışında Zilyetliğin Kaybedilmesi

1197 TMK m.989 I hükmü zilyetliğin irade dışı çıkış halı olarak, çalınma ve kaybolmayı örnek olarak vermiştir. Ancak zilyetliğin rıza dışı çıkma halleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Bir kişi fiil: hakimiyetinde bulunan -dolaysız zilyetliğinde olan- eşyadaki, önceki zilyedin dolaylı zilyetliğini tanımazsa, önceki zilyet rıza dışı zilyetliği kaybetmiş olur[263].

1198 Yanılma veya aldatma zilyetlik iradesinin rıza dışı kaybı olarak nitelenemez; korkutmanın etkisi ise tartışılabilir. Alman hukukunda hâkim görüş, korkutma ile zilyetliğin kaybını rıza dışı kayıp olarak kabul etmektedir[264].

---

[262] **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 1612.

[263] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 85.

[264] **JOOST**, MünchK BGB § 856, Rn. 7; **GUTZEIT**, Staudinger BGB § 856, Rn.18; **HECK**, SachenR § 60, Nr.5; **BAUR/STÜRNER**, SachenR § 532, Rn.43; **WESTERMANN/ GURSKY/ EICKMANN**, SachenR § 49 Rn.4.

§ 8. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI

I. ZİLYETLİĞİN KORUNMASININ AMACI VE FONKSİYONU

A. Genel Olarak

1199 Zilyet, TMK m.981'e dayanarak zilyetliğine yapılan her türlü gasp ve saldırının defedilmesini; TMK m.982'ye dayanarak zilyetliğinin gaspı halinde zilyetliğinin geri verilmesini ve TMK m.983'e dayanarak zilyetliğine saldırının sona erdirilmesini ve saldırının önlenmesini isteyebilir.

1200 Zilyet, TMK m.981'deki zilyetliğini savunma hakkını kendisi kuvvet kullanarak ve TMK m. 981 ve 982'deki gasp ve saldırıya karşı savunma hakkını dava yoluyla kullanır. Zilyedin gasp ve saldırıya karşı dava hakkını TMK m. 983'te belirtilen hak düşürücü sürelerde kullanması gerekir; aksi halde dava hakkı düşer.

B. Zilyetliğin Korunmasının Sebebi

1. Genel Olarak

1201 Zilyetliğin fonksiyonlarından birinin toplumsal huzur sağlama ve toplumsal düzenin güvenliğini kurumak olduğunu, kısaca huzur fonksiyonu (Friedensfunktion) yukarıda belirtmiş idik[1]. Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması, hukukun amaçlarından olan toplum düzenin güvenliğinin korunmasının zilyetliğe yansımasıdır[2].

1202 Kanun koyucu da hukuk düzeninin güvenliğini korumak ve toplumsal huzurun bozulmasını engellemek üzere zilyetlik olgusunu, olgu olarak dikkate alan haklardan bağımsız olarak korumuştur.

1203 Zilyetliğin korunmasının temelinde, "*huzurlu olan düzen bozulmamalı*" (*Quieta non movere*) *ilkesi* yatar[3]. Kanun koyucu, bu ilkeden hare-

---

[1] **ANTALYA**, EH II. N. 172.

[2] **DOĞANAY**, s. 465 vd.; **NOMER/ ERGUNE**, s.36.

[3] Söz konusu ilke Yargıtay kararında şu sözlerle ifade edilmiştir: "*... Ne var ki, bu korumanın, hırsızın menfaatini korumak için değil, sosyal huzur ve sükunun korunması ve sağlanması için kabul edilmiş olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Hukuk düzeninin yanında bir de barış düzeni vardır ve zilyetlik, bu barış düzeninin vücut verdiği bir müessesedir. Zilyetlik hukuken korunan*

ketle, fiilen ihtilafsız olan bir durumun hukuka aykırı bir fiille bozulmasını engellemekte, zilyetliğin aksi söz konusu olmadıkça olgu olarak ifade ettiği aynî hakkı, taşınır mülkiyetini, eşya üzerindeki zilyetlik olarak korumakta, dolaylı olarak da mülkiyetin korunmasına hizmet etmektedir[4].

2. Eşya Üzerindeki Haklardan Bağımsızlığı ve Bunlarla İlişkisi

1204 Zilyetlik onu olgu olarak kabul eden haklardan, özellikle mülkiyet hakkından ve aynî hakkın korunmasından (Rechtsschutz/ petitorischen Schutz) bağımsız olarak, özel hükümlerle korunmuştur. Zilyetliğin korunması doğrudan olmasa da eşya üzerindeki hakkın korunmasına da hizmete eder. Eşya üzerinde hak sahibi olan zilyet ise, hakkı koruyan davalar yanında zilyetliği koruyan hükümlere başvurabilir. Zilyet hak sahibi olmasa da zilyetliğin korunmasından yararlanır[5].

1205 Zilyedin korunması için, zilyedin haklı zilyet olması da gerekmez. Haksız zilyet de zilyetliğin korunmasından, örneğin hırsız veya gaspçı da yararlanabilir.

3. Konusu

1206 Zilyetliğin korunması sadece taşınırlara özgü değildir. Taşınırlar yanında taşınmazlara da zilyetliğin korunması hükümleri uygulanır. Örneğin; TMK m.981 II'de zilyedin savunma hakkı taşınmazlarda özel olarak düzenlenmiştir.

1207 Zilyetliğin idarî yoldan korunması ise sadece taşınmazlara münhasırdır; yani 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun taşınırlara uygulanmaz. Zilyetliğin korunması sadece eşya zilyetliğinde değil, hak zilyetliğinde de uygulanır.

1208 Zilyetliğin korunması, zilyedin sıfatından bağımsızdır. Zilyet hangi sıfata sahip olursa olsun, örneğin ister asli zilyet-ister fer'i zilyet, ister do-

---

eylemli bir durum olduğuna göre, bu durumun bir hakka dayanıp dayanmaması önemli değildir. Zilyetliğin hukuki fonksiyonlarından birisi de fiili durumun başkaları tarafından keyfi olarak bozulmasını önlemektir. Burada kişilerin kendi haklarını kanun yolları dışında bizzat almaya kalkışmalarından doğacak sakıncalar bu suretle önlenmek istenilmiştir." Y. HGK. 30.10.2013, T., 2013/8-1363 E., 2013/1507 K.

[4] **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N.213; STEINAUER,** I. N. 317, 382.

[5] *"... Zilyetlik, bir eşya üzerindeki fiili hakimiyettir. Bunun içindir ki zilyetliğin gerisinde bir hak bulunsun veya bulunmasın eşya üzerindeki fiili bir etkide bulunma yetkisini vermektedir. Tanınan bu yetkinin sonucu olarak bir hakka dayanıp-dayanmadığına bakılmaksızın zilyetliğin korunması gerekmektedir ..." Y., 4. HD., 11.10.1993 T., 1992/11553 E., 1993/11714 K.*

laylı zilyet-ister dolaysız zilyet sadece zilyetlik sıfatı olduğu için korunur[5].

C. Hukuki Olguları

1209 Zilyetliğin korunmasının hukuki olgusu, zilyetliğin hukuka aykırı ihlalidir (zilyetliğe haksız el atmadır). Öyleyse zilyet, zilyetliği ihlal edilmişse (zilyetliğine el atılmışsa), zilyetliğin ihlali hukuka aykırı (zilyetliğe el atma haksız ise), zilyetliğin korunması hükümlerinden (TMK m.981-984) yararlanır.

1. Zilyetliği İhlal (El Atma)

1210 Zilyetliğin korunmasının temel hareket noktası zilyetlik olgusudur. Zilyetliğin çeşidi ve kazanılması yolu dikkate alınmaksızın zilyet olan kişi, sadece zilyet olduğu için korunur. Zilyetlik ihlal edilmelidir; yani kişinin eşya üzerindeki fiili hakimiyetine el atılmalıdır.

1211 Zilyetliğin ihlalinin insan fiili neticesinde ortaya çıkmış olması gerekir. Zilyetliğin ihlalinin failin kendi davranışı ya da başka bir kişi aracılığıyla ya da bir araç veya hayvan vasıtasıyla gerçekleştirmesi önem arz etmez[6]. Yeter ki zilyetliğin ihlali failın davranışının sonucu olsun.

1212 Zilyetliğin ihlali, olumlu insan davranışı olarak veya kaçınma şeklinde gerçekleşebilir. Kullanılan aracın bir şey, örneğin balta, keser vb. ya da bir hayvan olması yeterlidir. Hatta hukuka aykırı saldırının bir üçüncü kişi aracılığıyla, örneğin hizmet zilyedi aracılığıyla gerçekleşmesi de mümkündür.

1213 Zilyetliğe saldırı birden fazla kişinin iştiraki ile de gerçekleşebilir. İştirak, birlikte sebep verme yanında, yardım veya yataklık şeklinde de gerçekleşebilir. Zilyetliğin salt doğa olayları ve hayvan fiilleri sonucunda müdahaleye uğraması halinde, zilyetliğin korunması hükümleri uygulanmaz[7]. Zilyetliği ihlal eden failin kusurlu olması, zilyetliğinin korunması için aranmamaktadır[8]. Zilyetliği savuma yollarına başvurmak için gasp

---

[5] NOMER/ ERGÜNE, s. 35.

[6] Y.HGK, 16.06.1983 T., 8-3351/679 (YKD., 1984/7, s.980); OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s.87; TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 100; AKİPEK/ AKINTÜRK, s. 178; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 149; REİSOĞLU, s. 67.

[7] ERNST, BSK ZGB vor Art 926-929, N. 4; NOMER/ ERGÜNE, s. 35.

[8] SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 221.

veya saldırıdan mutlaka zarar doğmuş olması da şart değildir. Zilyetliğin ihlali sebebiyle zilyedin uğradığı zararın tazminin.de (TMK m. 982 III ve 983 II), genel hükümler kapsamında (TBK m.49), haksız fiilden doğan borç ilişkisi için kusurlu davranış olgusu aranmaktadır[12].

2. Zilyetliğin Hukuka Aykırı Olarak İhlali: Zilyetliğe Yasak El Atma

a. Genel Olarak

1214 Zilyetliğin hukuka aykırı ihlali, zilyedin rızası olmaksızın onun doğrudan zilyetliğine hukuka uygun olmayan el atmalar yani gasp veya saldırı fiilleridir. Zilyetliğin ihlalinin yasak el atma olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle, zilyetliğin hukuka aykırı olarak saldırıya uğraması yani zilyetliğin gaspı veya zilyetliğe saldırının söz konusu olması gerekir. Zilyetliğe saldırının bu iki ihlal şekli dışında, fakat buna benzer başka davranışlarla ihlali de söz konusu olabilir[13].

1215 Zilyetliği ihlal fiilinin, hukuka aykırı olması yeterlidir; kusur ehliyeti veya failin kusurlu olması gerekli değildir. Hukuka aykırı zilyetliğin ihlali, olumlu davranış olabileceği gibi olumsuz davranış, özellikle kaçınma şeklinde de gerçekleşebilir[12]. Örneğin; ev hayvanını kontrol etmeme veya gerekli özeni göstermeme vb.

1216 Yine fiilin başkasının zilyetliğini ihlal etmesi gerekli olmadığı gibi; haklı ya da haksız veyahut iyiniyetli ya da kötüniyetli olması fark yaratmamaktadır; hatta saldırganın, zilyedin zilyetliğinin hakka dayandığını veya yetkisinin olmadığını ya da eksik olduğunu bilmesi de şart değildir.

1217 Alman uygulamasında, zilyetliği ihlal eden davranışta üçüncü kişi, sözleşmeyle yetkilendirilmişse, sözleşmenin tarafları, üçüncü kişinin yetkisi kapsamında üçüncü kişinin eşyaya müdahalesine katlanmak zorunda olup olmadığı tartışılmıştır[13]. Özellikle kira ve sigorta sözleşmelerinde, sözleşme tarafları üçüncü kişinin müdahalesine yetki vermişlerse bu önceden rıza (izin) olarak nitelendirilmelidir. Özel hukuk veya kamu hukukunun uygun gördüğü zilyetlik saldırıları hukuka uygun olduğundan, bu zilyetlik ihlallerinde, zilyet hukuku korumadan yararlanamaz.

---

[12] Kusurlu davranış olgusu için bkz. **ANTALYA**, BH GH, II, s. 21.

[13] **STARK**, BK ZGB Art. 926, N22.

[12] **ERNST**, BSK ZGB vor Art.926-929, N. 4; **DOMEJ**, KurzKomm ZGB Art.926, N.3.

[13] **JOOST**, MünchK BGB § 858, Rn. 8 Fn. 75, 76, 77, 78.

b. Görünüm Şekilleri: Zilyetliğin Gaspı (Elinden Alınması) ve Zilyetliğe Saldırı

1218 Zilyetliğe el atma, zilyetliğin gaspı ve zilyetliğe saldırı (tecavüz) şeklinde gerçekleşir. Örneğin, başkasına ait bilgisayarı zorla almak zilyetliğin gaspı, bilgisayarını bozma veya hasar verme zilyetliğe saldırı; arsaya gecekondu yapılması gasp, çöp dökülmesi zilyetliğe saldırıdır.

aa. Zilyetliğin Gaspı (Elinden Alınması)

1219 Gasp (Entziehung), zilyedin rızası olmaksızın, fiili hâkimiyetinin sürekli elinden alınması yani eşyanın fiili hakimiyetinin tamamının bir başkası tarafından sürekli bir şekilde ele geçirilmesidir. Örneğin; saatin çalınması veya zorla ya da tehditle elinden alınması, arsaya gecekondu yapılması, çitle arazinin çevrelenmesi gibi[14].

1220 Gaspçı, başkasının zilyetliğini zorla ya da hile ile ele geçirmekte; onun fiili -maddi- hâkimiyetine son vermekte, zilyetliğini elinden almaktadır. Zilyedin haberi olmadan, gizlice de eşyayı ele geçirebilir. Zilyetliği elinden almada kullanılan araç önemli değildir, zorla elinden alma yanında, bariyer koyma ya da çitle engelleme, kullanılmaz hale getirme, ulaşılmaz hale getirme vb. şekilde de gerçekleşebilir[15].

1221 Gasp tüm araçlarla gerçekleşebilir. Alman yargı uygulamasından hareketle hukuka aykırı gasp olaylarını örneklersek; özel bir yoldan geçirilmesini ateşli silah ve köpekle engellemek, kırbaçla köpeği saldırtarak, tutup sürükleyerek, dövme tehdidiyle vb. şekilde dolaysız zilyetliğin sona erdirilmesi gibi[16].

bb. Zilyetliğe Saldırı

1222 Saldırı (Störung), zilyedin rızası olmaksızın, üçüncü kişinin onun eşya üzerinde hakimiyet sürdürmesini engellenmesi veya güçleştirmesidir. Zilyetliğe saldırı, *kısmi zilyetliğin ihlali* olarak isimlendirilmektedir[17]. Örneğin; taşınmaza araç park etme, çöp dökme, geçidin duvar veya çitle kapatılması, kiracının komşularını rahatsız edecek şekilde camı açık bıraka-

---

[14] STARK, BK ZGB vor Art.926-928, N.16.

[15] Bu ve diğer örnekler için bkz. JOOST, MünchK BGB § 858 Rn 23.

[16] Bu ve diğer örnekler için bkz. JOOST, MünchK BGB § 859 Rn 9.

[17] GÜRSOY/ EREN/ CANSEL, s. 97.

rak yüksek sesle radyo dinleyerek rahatsız etmesi[18], bir kişinin komşusunun zemininden elektrik tesisatı geçirmesi[19] gibi.

1223 Zilyetliğin gaspı ile saldırı arasındaki fark ihlalin niceliğindedir; nicelikle ayrılırlar. İhlalin çeşidini belirlerken, ihlalin fiili hakimiyeti sürekli olarak kesip kesmemesi tam ölçüt değildir; zilyetliğin doğrudan olmasının tamamen mi yoksa kısmen mi engellendiği ölçüttür.

1224 Zilyetliğe saldırı genellikle maddi fiille gerçekleşir. Örneğin, evde bulunulmasını veya tarlaya girilmesini engellemek, işyeri girişi ve çıkışını engelleme veya kuşatma, mektup kutusuna bazı maddeleri atma, ses, kötü koku, komşu taşınmazda kanallar açma, reklam alanlarının üstüne yapıştırma vb.[20].

1225 Saldırının, TMK m. 981'de saldırıyı def etmede, kuvvet kullanarak savunmada, saldırının gizlice veya zorla olması gerekirken, TMK m.983'teki saldırıda saldırının gizlice veya zorla olması gerekli değildir; zilyedin fiili hakimiyetini etkili olan her türlü saldırı dava yoluyla korunma için yeterlidir[21].

1226 Saldırı, eşyanın nitelik veya özelliğine uygun olarak zilyetliğin kullanılmasının engellenmesi şeklide karşımıza çıkar. Zilyetliğe saldırıda, gasptan farklı olarak zilyedin eşya üzerindeki maddi hâkimiyeti sona erdirilmemekte, maddi hâkimiyetin kullanılması engellenmektedir.

1227 Zilyetliği ihlal fiilinin gasp mı yoksa saldırı mı olduğu konusunda karar verirken, ihlal fiili sonucunda, ihlalcinin dolaysız zilyet mi ya da dolaysız birlikte zilyet mi olduğuna bakmamız gerekir. Zilyetliği ihlal eden eşya üzerinde dolaysız zilyet ya da dolaysız birlikte zilyet olmuşsa, gasp söz konusudur; aksi durumda ise zilyetliğe saldırı söz konusudur[22].

1228 Alman Yargı uygulamasında, park alanına rakip firmanın reklam amaçlı panosunun koyulması, bir işletmenin müşteri otoparkında reklam ve tanıtım broşürü dağıtması, alanların ve dolaşanların video kamerası ile izlenmesi, iş akdi sona eren işçinin veya onun eşyalarının işyerinden kaldırılması, işverenin verdiği alet ve malzemenin işçiden alınması, apart-

---

18 **STARK**, BK ZGB Art.928, N.22.

19 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.926, N.6.

20 Bu ve diğer örnekler için bkz. **JOOST**, MünchK BGB § 858 Rn 23.

21 **STARK**, BK ZGB Art.926, N.22; **DOMEJ**, Kuruz Komm ZGB Art.926 N.3.

22 **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s.180.

manın ortak asansörünün kullanılmasının sürekli olarak engellenmesi, kira sözleşmesi sona ermesine rağmen kiracının kiralanan yerden ve müştemilatlarından ya da ortak yerlerden (depo, park yeri, sosyal tesisi, havuz vb.) yararlanmaya devam etmesi vb. haller zilyetliğe hukuka aykırı saldırı olarak kabul edilmiştir[23].

1229 Buna karşın, Alman yargı uygulamasında, bağımsız kat malikinin kiracının rızasını gerektirmeyen inşaat faaliyetleri, kiraya verenin kiracıya hakareti veya kötü davranışları, geçici inşaat gürültüsü, komşunun kişilik haklarını ihlal fiilleri, komşu çocuğunun taş atması, taşınmaza kedi girişinin engellenmesi, balkonun fotoğrafının çekilmesi, kiracıdan gelen katlanılabilir gürültüsü kovandan arıların uçarak konması vb. haller zilyetliğe hukuka aykırı saldırı olarak sayılmamıştır[24].

3. Hukuka Uygunluk Sebebinin Bulunmaması

1230 Yasak el atma, gasıbın veya saldırganın hukuka aykırı davranışıdır. Basit veya toplumsal yaşam ilişkilerinde katlanılması gereken zorunlu davranışlar hukuka aykırı olarak değerlendirilmez. Bir saldırının hukuka aykırı sayılması için zilyedin var olan fiili zilyetlik durumu üzerinde etkili olacak ağırlıkta olmalıdır. Zilyetliğe aykırı fiil, yani gasp veya saldırı, zilyedin rızası veya diğer bir hukuk kuralı uyarınca hukuka uygun sayılmalıdır[25]. Zilyetliğe saldırının hukuka uygunluğu kamu hukuku kuralından veya özel hukuk kuralından kaynaklanabilir.

a. Özel Hukuktan Kaynaklanan Hukuka Uygunluk Sebepleri

aa. Genel Olarak

1231 Özel hukuktan kaynaklanan zilyetliğin ihlalinin hukuka uygunluk sebeplerinin başında zilyedin rızası gelir. TMK m.981 II'de zilyetliğin "zilyedin rızası dışında kendisinden alınmasını", hukuka aykırı olduğunu belirtmiştir.

1232 Zilyetliğin ihlalinin hukuka uygunluk sebebi olan rıza dışında, diğer özel hukuk kuralından kaynaklanan uygunluk sebeplerini şu şekilde sa-

---

[23] Bu ve diğer örnekler için bkz. **JOOST**, MünchK BGB § 858 Rn 11.

[24] Bu ve diğer örnekler için bkz. **JOOST**, MünchK BGB § 858 Rn 12.

[25] BGE 135 III 633. **ERNST**, BK ZGB vor Art 926-929, N.21, 41 ff; **EITEL/ ARNET**, ZGB Art 926, N.2.

yabiliriz[26]: TMK m. 737'de düzenlenen komşuluk hukukundan kaynaklanan katlanma yükümü; başkasının taşınmazına girme (TMK m.751), dalları kesme ve meyveleri toplama (TMK m. 740), hayvanı alıkoyma (hapsetme) ve etkisiz bırakma (gerekirse öldürtme) (TBK m.68), zorunluluk hali (ıztırar) (TBK m.64 II; TMK m.753), haklı savunma (meşru müdafaa) (TBK m.64 I) vb.

bb. Zilyedin Rızası

1233 Zilyetliğinin korunması için zilyetliğin ihlaline yani zilyetliğin gaspına veya saldırıya zilyedin rızası olmaması gerekir[27]. Zilyet rızasını açık olarak verebileceği gibi örtülü olarak da açıklayabilir[28]. Verilen rızanın her zaman geri alınması mümkündür[29].

1234 Zilyedin rızasının hukuki niteliği, doğal iradedir bu sebeple maddi fiildir[30]. Bu niteliğine uygun olarak, zilyedin işlem (fiil) ehliyetine sahip olması gerekli değildir; ayırt etme gücüne sahip olması yeterlidir[31]. Kademeli veya birlikte zilyetlikte, bütün zilyetler tarafından rıza verilmesi gerekir. Verilen rıza sadece veren zilyedi bağlar; diğer zilyedin savunma yollarına başvurma hakkı saklıdır. Zilyedin rızası alınacak kişi olarak yetkili olduğu konusunda yanılma ve yanıltma saldırının hukuka aykırılığını etkilemez; ancak korkutma rızanın geçerliliğini engeller[32].

b. Kamu Hukukundan Kaynaklanan Hukuka Uygunluk Sebepleri

1235 Kamu hukukundan kaynaklanan, örneğin polis ve ceza infaz hukuku kurallarından kaynaklanan hukuka uygunluk sebepleri de söz konusudur[33].

---

[26] Bu haller için bkz. **STARK**, BK ZGB Art. 926, N.21 ff.

[27] BGE 135 III 633.

[28] **STARK**, BK ZGB vor Art.926-929, N. 26.

[29] **STARK**, BK ZGB vor Art.926-929, N. 31.

[30] **JOOST**, MünchK BGB § 858, Rn. 7; **GUTZEIT**, Staudinger BGB § 858, Rn.18; **STADLER, S.**, BGB § 858, Rn.9; Bu konuda bkz. **KOHLE** AcP 185 (195), s.105 ff.

[31] **STARK**, BK ZGB vor Art. 926-929, N.28; **EIETEL/ARNET**, CHK ZGB Art. 926, N.2; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.154.

[32] **STARK**, BK ZGB vor Art.926-929, N.30; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 88; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.154.

[33] BGE 135 III 633 E.3; "*İdarenin kamusal düzenle ilgili sevk ve idare ile yakından bağlantılı bir yere kumarhane ruhsatı vermemek suretiyle vaki eylemi ve muafiyetinden bahis edilemeyeceği...*" Y., 14. HD., 25.2.1997 T., 1996/7391 E., 1997/1126 K.

D. Zilyetliği Korunan Kişi: Zilyet

1. Genel Olarak

1236 Her zilyet, zilyetliğini kuvvet kullanarak veya zilyetlik davaları yolu ile savunma hakkına sahiptir.

1237 Her zilyet haklı veya haksız zilyet ya da iyiniyetli veya kötüniyetli zilyet ayrımı olmaksızın zilyetliğini koruma hakkından yararlanır. Önceki zilyede karşı TMK m.981 II'deki kuvvet kullanmaya yetkili olduğu takdirde kullanabilir[24]. Örneğin, malik hırsıza karşı kuvvet kullanabilir, hırsız malike karşı kuvvet kullanarak savunma hakkını kullanamaz, fakat üçüncü kişiye karşı kullanabilir[25]. Zilyetlik davalarında, gasp halinde üstün hak sahibinin hakkını derhal ispatı halinde geri vermekten kaçınması söz konusudur (TMK m. 982 II). Zilyedin birlikte zilyet olması ya da kısmi zilyet olması fark etmez[26]. Zilyet yardımcısı da yardım ettiği kişi adına zilyetliğin korunmasına başvurabilir[27].

2. Hak Zilyetinin Durumu

1238 Olumsuz taşınmaz irtifakı hakkında ve taşınmaz yükünde yani hak zilyedi (TMK m.973 II), zilyetliğin korunması talebini üçüncü kişiye karşı, hakkın kullanılmasını ihlal eden taşınmaz malikine veya yüklü taşınmaz zilyedine karşı ileri sürebilir[28].

1239 Hak zilyedince, hakkın kullanımını tamamen engelleme gasp, kullanılması mümkün ama hakka uygun kullanılmasını kısmen engelleme söz konusu ise, saldırı söz konusudur. Örneğin, manzara irtifakında manzaranın duvar veya başka engelle görüntünün tamamen ortadan kaldırılması gasp; cam veya pergola ya da başka engellerle görüntünün kısmen engellenmesi saldırı niteliğindedir[29].

1240 Taşınmaz malikı ve yüklü taşınmaz zilyedi arasındakı ilişkide, hak zilyedinin hakkını aşan taşınmazda hakimiyet kullanımlarında, taşınmaz

---

[24] **STARK**, BK ZGB vor Art.926-929, N. 7; **DOMEJ**, Kurzkomm ZGB ART.926, N.6; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 151.

[25] **STARK**, BK ZGB vor Art. 926-929, N. 87; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 151.

[26] **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N 207 ff.

[27] **STARK**, BK ZGB vor Art.926-929, N 26.

[28] **STARK**, BK ZGB vor Art.926-929 N 72 ff; BGE 83 II 141 E. 2 f.; BGE 94 II 348 E. 1; BGer vom 23.07.2001, 5P.195/2002, E. 2.2; BGer vom 22.03.2010, 5A_59/2010, E. 2.

[29] **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 153.

malıkı veya yüklü zilyet, hak zilyedine karşı zilyetliğinin korunmasını talep edebilir[40]. Zilyedin korunmasının sadece irtifak hakkının tapu kütüğüne kayıtlı olanları mı yoksa olmayanları da kapsayıp kapsamadığı; bununla birlikte hukuki durumun *Possessorium* ile *Petitorium* ayrımındaki yeri tartışılmaktadır[41]. Her durumda, taşınmaz yükünün hak sahibinin açık olarak anlaşılabilir olması gerekir[42].

3. Kademeli Zilyetlikte

a. Asli Zilyet ve Fer'i Zilyet İlişkisinde

1241 Kademeli zilyetlikte asli zilyet, dolaylı zilyet olsa da kanun gereği zilyet sayıldığından, üçüncü kişiye karşı zilyetliğin korunması yoluna başvurabilir. Fer'i zilyet, dolaysız zilyede zilyetliğin korunmasından yararlanmasa, hatta vazgeçse bile asli zilyet korumasından yararlanır[43]. Örneğin, kiraya veren kiralanan üçüncü kişinin ihlallerine karşı, kiracı rıza vermiş olsa bile zilyetliğin korunmasına başvurabilir. Tam tersi de söz konusu olabilir.

1242 Kiralamada üç farklı durum birbirinden ayırt edilerek zilyetlik durumu değerlendirilmelidir:

- Kiracının malikin zilyetliğine olan saldırısı,
- Malikin kiracının kira zilyetliğine karşı saldırısı,
- Malikin veya kiracının zilyetliğine üçüncü kişinin saldırısı.

1243 Fer'i zilyet de asli zilyede karşı, zilyetlikten doğan koruma talebini ileri sürebilir[44]. Örneğin, rehin verdiği şeyi zorla almak isteyen malike (aslı zilyede) karşı, rehin hakkı sahibi (fer'i zilyet) savunma haklarını kullanabilir[45]; irtifak hakkı sahibi malike karşı, irtifak hakkının kullanılmasına saldırıya karşı zilyetliğinin korunmasını talep edebilir[46].

---

40 **STARK.** BK ZGB vor Art.926-929. N.72 ff.

41 **BERGER-STEİNER/SCHMID.** OFK ZGB Art.926. N.4.

42 **STEİNAUER.** I. N.318c

43 BGer 5P.122/2004 E.2.1'deki doktrin. **HOMBERGER.** ZK ZGB Art.926. N.20; **STARK.** BK ZGB vor Art.926-929. N. 26, 48 ff; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP.** N.214a.

44 BGE 40 II 329 ff. 330; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP,** N.214a; **STEINAUER.** I. sN 330b

45 *"... Rehin nedeni ile fer'i zilyet olan kişinin taşınmaz üzerindeki hakları ödenmedikçe, taşınmazın asli zilyede iadesine karar verilemez...".* **Y.** 14. HD., 25.4.1991 T., 1990/6534 E., 1991/3974 K.

46 BGE 83 II 141 ff, 145 E. 3a.

b. Dolaylı Zilyet ve Dolaysız Zilyet İlişkisinde

1244 Dolaysız zilyetler, zilyetliğin korunmasından öncelikle yararlanırlar. Zira nitelığı gereği öncelikle dolaysız zilyedin fiili hâkimiyeti ihlal edilir. Dolaysız zilyet, dolaylı zilyet ihlale rıza vermiş olsa bile bu hakkını üçüncü kişiye[47]; hatta ihlal eden dolaylı zilyede[48] karşı kullanabilir.

1245 Dolaylı zilyet de sahip olduğu zilyetlik durumuna ilişkin üçüncü kişilere karşı kuvvet kullanarak zilyetliğini savunabilir. Dolaylı zilyetliğine hukuka aykırı el atmanın gerçekleşmesi bu ihlalin onun eşya üzerindeki dolaylı hakimiyetine etkili olması yeterlidir[49]. Hatta doğrudan zilyedin zilyetliği ihlal eden fiile rızası olsa bile zilyetliğin korumasından yararlanır[50].

1246 Dolaysız zilyet, dolaylı zilyedin dolaysız zilyede karşı zilyetliğini koruması, sadece, doğrudan zilyedin zilyetlik yetkisini hukuken ihlal etmemek kaydıyla, söz konusudur; başka bir deyişle, dolaylı zilyedin dolaysız zilyede karşı zilyetliğin korunmasını talep edebilmesi, sadece doğrudan zilyedin onun yetkisinin kapsamını tartışmasız olarak kabul ettiği halle sınırlıdır[51].

4. Hizmet Zilyetinin Durumu

1247 Hizmet zilyedinin, kendi adına zilyetliği koruması söz konusu olmaz; hizmet zilyedinin zilyetliği koruması sadece adına zilyet olduğu (hizmet verdiği) kişi için söz konusudur[52].

1248 Zilyet yardımcısı, TMK m.926 I hükmündeki kuvvet kullanma hakkını, zilyet sahibi adına kullanır[53]; zilyedin temsilcisi sıfatı var ise, üçün-

---

47 BGE 40 II 329, 330. **HOMBERGERR,** ZK ZGB Art.926, N.20. **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP,** N.214a.

48 **STARK,** BK ZGB vor Art. 926-929, N.62.

49 **STARK,** BK ZGB vor Art. 926-929, N.51. Farklı olarak bkz. **HINDERLING,** SPR V/1, s. 451. Karşı görüş bkz. **HOMBERGER,** ZK ZGB Art.926, N.20.

50 **STARK,** BK ZGB vor Art.926, N.51 ff; 62 **DOMEJ,** KurzKomm ZGB Art.926, N.7. Farklı şekilde bir görüş için bkz. **HINDERLING,** SPR V/1, s. 451. Aksi görüş için bkz. **HOMBERGER,** ZK ZGB Art.926, N.20.

51 **STARK,** BK ZGB vor Art.926-928, N.57. BGE 118 II 291 E.2, BGer vom 29.06.2004, 5P.122/2004, E2.1.

52 **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP,** N. 214, 214a. **ERNST,** BK ZGB vor Art.926-929, N. 30; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ALTOP,** s. 66; **NOMER/ERGÜNE,** s. 37; **SEROZAN,** N.572. Zilyet yardımcısının ne kendi adına ne de zilyet adına kullanmayacağı görüşü için bkz. **ÜNAL/ BAŞPINAR,** s. 152.

53 **HINDERLING,** SPR V/1, s. 452. Sınırlı olarak **STARK,** BK ZGB Art.926, N.87 f.

cü kişiye karşı zilyetliği koruma davalarına (TMK m.927-928) başvurabilir[54].

1249 Görüşümüze göre, zilyet yardımcısı, savunma hakkını yardım ettiği zilyet sahibine karşı kullanamaz[55].

1250 Doktrinde bazı yazarlar, hizmet zilyedinin, zilyet adına zilyedin korunması hükümlerinden yararlanamayacağını; sadece eşyaya saldırı halinde TMK m.64 hükmündeki haklı savunmadan yararlanabileceğini savunmaktadır[56].

5. Birlikte Zilyetlik ve Elbirliği ile Zilyetlik

1251 Birlikte zilyetlik halinde, her zilyedin zilyetliğinin korunmasını üçüncü kişinin zilyetlik ihlallerine karşı olabileceği gibi, diğer birlikte zilyetlerin zilyetlik ihlallerine karşı da olabilir[57].

1252 Birlikte zilyetlik halinde, zilyetlik çeşidi paylı zilyetlik ise her bir zilyet (TMK m. 693 III kıyasen); elbirliği ile zilyetlik ise yine her bir ortak zilyet dava açabilir (TMK m.702 IV kıyasen).

1253 Birlikte zilyetlerden birinin diğerine karşı zilyetliğinin korunması imkânı da söz konusu olabilir; bu durumda, diğer birlikte zilyet olanların diğerinin zilyetliğini tartışmasız olarak hukuken tanımış olması yeterlidir. Bu durumda dolaysız zilyedin dolaylı zilyede karşı korunmasına benzer bir durum söz konusudur[58]. Örneğin birlikte kiracı olanların, ortak olarak kiraladıkları alana ilişkin ortak anahtarın bir kiracı tarafından değiştirilmesi ve değiştirilen kilidin anahtarının verilmemesi halinde, zilyetliğin korunması hükümlerinden yararlanarak, gerekli anahtarı elde edebilmeleri mümkündür. Yine, kat maliklerinden birinin, TMK m.982 vd. hükümlerine dayanarak, zilyet sıfatıyla aynı binada açılan masaj salonuna karşı zilyetlik hükümlerine dayanabilmesi gerekir[59].

---

[54] RK. BK ZGB vor Art.926-928. N.67 ff.

[55] Aksi yönde görüş için bkz. **ERNST**, BSK ZGB vor Art.926-929 N.30.

[56] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 66, 89; **GÜRSOY/ EREN/ CANSEL**, s.100. **AYAN**, s. 111.

[57] Bu konuda bkz. **STARK**, BK ZGB vor Art.926-928, N.67 ff. Ayrıca bu konuda bkz. BGer 5P.220/2000 E.2a, 5A_3/2010 E.4.4.1.

[58] **STARK**, BK ZGB vor Art. 926-929, N.67 ff.

[59] **MEIER-HAYOZ/REY**, EK ZGB 712a, N.125 ff.

E. Zilyetliğin Korunması Talepleri ile Haklardan Doğan Davalar Arasındaki İlişki

1254 Zilyetliğin korunmasına ilişkin hukuki korumanın (*possessorium*), maddi hakkı konu alan davalardan (*petitorium*) ayrılması gerekir.

1255 Doktrinde "*petitorium*" kavramına farklı anlamlar yüklenmektedir. İsviçre Federal Mahkemesi, söz konusu davaların, eşya üzerindeki ayni hak ve nispi hak taleplerinin birlikte geçerli olduğunu, yarışacağını kabul etmektedir. Bu sebeple eşya ile ilgili sözleşmeden doğan davaların yanında, mülkiyete dayalı davalar da söz konusu olabilmektedir. Zilyetlik davalarının, taşınır davasından farkına da ileride değineceğiz.

1256 Zilyetliğin korunması talepleri, taşınır davasından ve istihkak davasından bağımsız olup, eşya üzerindeki haktan bağımsız zilyetliğin korunmasına yönelik davalardır.

F. Hukuki Sonucu

1. Genel Olarak

1257 TMK genel olarak, zilyetliğin ihlalini onaylamamakta, getirdiği zilyetliğin korunması hükümleri ile zilyedi korumaktadır. TMK m.982/I bir şeyi gasp eden kişiyi, o şey üzerinde üstün hakkı olsa bile, geri vermekle yükümlü tutmuştur. Yine TMK m.983'te zilyetlik saldırıya uğramışsa, zilyetlik durumu, haktan doğan hukuki durumdan bağımsız olarak, korunmuştur. Hatta TMK m.981/I hükmü, zilyede, şeye olan her türlü gasp ve saldırıyı kuvvet kullanarak defetme imkanı tanınmıştır.

1258 Bu düzenlemelerden hareketle, genel olarak, kişilerin, '*başkasının zilyetliğini ihlalden kaçınma yükümlülüğü*' altında olduğunu söyleyebiliriz[1]. TMK m. 981 ile 983 arasında, zilyedi, zilyetliğine aykırı davranışlara karşı, TMK m.984'te belirtilen süreler içinde, zilyetliğinin korunmasına yönelik olmak üzere iki koruma aracı düzenlenmiştir.

1259 Bunlardan ilki, *meşru müdafaa* için *kuvvet kullanma yetkisi* veya kendi hukuki durumunu sağlamak için *kendisinin kuvvet kullanma yetkisidir*. Bu hakkı kullanması için dava açmasına gerek yoktur, zilyet bizzat bu hakkı kullanır.

---

[1] SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N 222

1260 İkincisi ise, *dava hakkıdır (zilyetlik davaları)*. Zilyedin zilyetliği yargı kararı ile korunur. TMK, zilyetliğin gaspı halinde dava hakkı (TMK m.982) ve zilyetliğe saldırı halinde dava hakkı (TMK m.983) ile, iki ayrı maddede özel olarak düzenlemiştir. Ayrıca gasp veya saldırı halinde uğranılan zararın genel hükümlere göre tazmini hakkı da ayrıca saklıdır.

2. Zilyedin Kuvvet Kullanarak Zilyetliğini Koruması

a. Genel Olarak

1261 Hukukumuzda kural olarak ihkak-ı hak yasağı olmasına karşın, kanunun istisnai olarak koruduğu hukuki durumlardan biri de zilyetliktir. Bir diğeri de TMK m.64 III'te düzenlenen kendi gücü ile hakkın korunması halidir TMK m. 981'den farklı olarak, TMK m.64 III'teki zorda kalma halinde, kusurlu olma ve zarara uğrama tehlikesi aranmaktadır.[61]

1262 Doktrinde ifade edildiği şekliyle[62] TMK 981 I'deki zilyetliğin kuvvet kullanma ile savunulması, bir zorda kalma durumunda söz konusu değildir[63]. TMK m. 981 zilyedin bizzat kendisinin, hâkimin yardımına –yargı kararı olmaksızın- başvurmaksızın zilyetliğe aykırı davranışa karşı kuvvet kullanmasını düzenlemiştir. TMK m.981 zilyetliği ihlal eden davranışların iki ayrı şekline göre, farklı hukuki koruma getirmiştir.

Zilyedin savunma haklarını incelersek:

1263 TMK m.981 I'de zilyetliği ihlal eden **saldırıya** karşı meşru savunma: *kuvvet kullanarak defetme yetkisi*; TMK m.981 II'de zilyetliğin **elinden alınmasına** karşı kendisini savunması: kuvvet *kullanarak zilyetliğini geri alma yetkisi* düzenlenmiştir.

1264 Zilyedin kuvvet kullanarak zilyetliği geri alması hakkı, zilyetliği ihlal edilen eşyanın taşınır ve taşınmaz olmasına göre farklı düzenlenmiştir: **Taşınmaz**da, *el koyanı kovma yetkisi*, **taşınır**da, *elinden alma yetkisi*.

1265 Zilyet, bu savunma haklarını, *durumun haklı gösterdiği derecede kendisi kuvvet kullanarak* gerçekleştirir.

---

[61] Bkz. **ANTALYA**, II, s. 77.

[62] Bkz. bu yaklaşım **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.926, N.22 ff.

[63] Her iki kurum arasındaki ilişki için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.926, N. 8 ff, 17.

b. Zilyedin Savunma Yetkisinin (Kuvvet Kullanma Hakkının) Hukuki Olguları

aa. Zilyetliğe Olan Hukuka Aykırı İhlalin Başlamış ve Halen Devam Ediyor Olması

1266 TMK m.981 I'de, meşru müdafaanın haklı gördüğü sınırlar içinde, zilyetliğe gasp ve saldırıyı zilyedin kuvvet kullanarak defetme yetkisini düzenlenmiştir. Burada zilyetliğin *meşru müdafaa ile savunması* söz konusudur. TMK m. 981 II'de[64], zilyetliğe gizlice veya zorla yapılan saldırıda, saldırı esnasında, zilyedin yine kuvvet kullanarak, yargıya gitmeksizin, ihlal öncesi zilyetlik durumunu kendisinin tekrar –taşınırlarda geri alarak veya taşınmazlarda kovarak- sağlaması söz konusudur. Burada zilyedin yargıya gitmeksizin *zilyetliğini kendisinin koruması* (Selbsthilfe) söz konusudur. Her iki durumda da kuvvet kullanma söz konusudur.

1267 Zilyetliğin ihlali, hukuka aykırı olarak, özellikle zilyedin rızası olmaksızın gerçekleşmelidir. Zilyetliğin ihlali, gasp veya saldırı şeklinde gerçekleşebilir. Saldırı fiilinde zilyedin kusurlu olması savunma hakkının kullanılmasının hukuki olgusu değildir[65]. Zilyetliğin kuvvet kullanılarak savunulması için zilyedin eşya üzerindeki zilyetlığı sonlandırılmamış olmalıdır[66].

1268 Zilyedin zilyetliğini kuvvet kullanarak savunabilmesi için, ihlal fiilinin başlamış veya halen devam ediyor olması, yani gaspın önceden tamamlanmamış olması veyahut saldırının bitmemiş olması gerekir. Zilyetliğin gaspı veya zilyetliğe saldırı gerçeklemekte olmalı veya gerçeklemesinden hemen sonra olmalıdır. Gerçekleşmemiş olmakla birlikte gerçekleşme ihtimali olan zilyetlik ihlallerine karşı kuvvet kullanılamaz. Zilyet, kuvvet kullanarak savunma hakkını, *ihlal davranışı esnasında derhal tepki göstererek veya en geç bu ihlalden hemen sonra kullanmalıdır.*

1269 Kuvvet kullanmanın ihlalden hemen sonra kullanılıp kullanılmadığı durumun şartları dikkate alınarak, hâkim tarafından takdir edilecektir (TMK m.4). Hâkim ihlalle savunma arasındaki zaman dilimini mümkün olduğunca dar bir zaman ilişkisi olarak değerlendirmelidir. Hâkim değer-

---

[64] Karş. BGB § 859.

[65] **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N 221.

[66] **EIETEL/ ARNET**; CHK ZGB Art.926, N.1.

lendirmesini o ilişkiye ilişkin yaşam deneyi ve toplumsal ilişkileri dikkate alarak objektif olarak belirleyecektir.

1270 TMK, sadece mevcut zilyetlik durumunun ihlali devam ederken veya en azından ihlal sonrası derhal yeniden tesisi mümkün ise, zilyede kuvvet kullanarak savunma hakkı tanımıştır; aksi halde zilyet bu yetkisini kaybeder. Zilyetlik davası açma hakkı saklıdır.

1271 TMK m.938 II hükmünde ifade edildiği üzere, failin "*eylemi sırasında veya kaçarken*" zilyetliğin ihlali halinde zilyet savunma hakkını kuvvet kullanarak gerçekleştirebilir yani fail, eşyayı önceden ele geçirmiş veyahut saldırı bitmişse, zilyet faile karşı kuvvet kullanamaz. Örneğin, zilyet hırsızı kaçarken yakalamayıp da hırsızla ertesi hafta veya daha sonra karşılaşırsa, kuvvet kullanarak hırsızın elindeki kendi eşyasını alamaz.

1272 Zilyedin kuvvet kullanması zorunlu değildir; kuvvet kullanmamış olan kişi, zilyetliği koruma davalarına başvurabilir. Kuvvet kullanabilecekken kuvvet kullanmama, zilyetliği koruyan davaların hukuki olgusu değildir. Ancak zilyetliğin ihlaline kuvvet kullanmayıp suskun kalması, ihlale rıza göstermesinden kaynaklanıyorsa, rıza zilyetliğin dava yoluyla korunmasında da hukuka aykırılığı kaldırır. Diğer yandan zilyetliği ihlale karşı koymama veya susma ihlale rıza olarak yorumlanamaz.

1273 Zilyedin, hal ve şartlara göre, hemen kolluk gücüne başvurabilme imkânı varken bile, kolluk kuvvetine başvurmaksızın kendisinin kuvvet kullanarak zilyetliğini savunma hakkı mevcuttur[67].

bb. Sınırı: Durumun Haklı Gösterdiği Derece Kuvvet Kullanılması

aaa. Kuvvet Kullanmanın Saldırıyla Orantılı Olması İlkesi

1274 TMK m. 981 c.2'ye göre, zilyet, bu savunma yetkisini "*durum haklı gösterdiği derecede kendisi kuvvet kullanarak*" gerçekleştirir. Zilyet kuvvet kullanma hakkını, orantılı olarak kullanmalıdır. Zilyedin kuvvet kullanmasının orantılılığından anlaşılması gereken, şeydeki fiili hâkimiyetin tamamını tekrar sağlamasına yetecek derecede kuvvet kullanmasıdır. Bu ilke, *kuvvet kullanmanın saldırıyla orantılı olması ilkesi*dir.

---

[67] STARK, BK ZGB Art. 926, N 23; STEINEUR, I, N 333a; SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N 229.

1275 Kullanılan kuvvetle saldırının orantılılığı, *saldırıyı engelleme ve sona erdirmenin amaca uygun araçlarla* gerçekleştirilmesidir. Zilyet engellemeye uygun aracı belirlerken, bu araçlardan *saldırgana da en az zarar verici aracı seçme*lidir[68].

1276 Zilyetliğe saldırıda, saldırıyı defedecek oranda; gaspta, eğer ihlal taşınıra yönelik ise şeyi tekrar geri alabilmeye yetecek, eğer ihlal taşınmaza yönelik ise, kovmaya yetecek oranda kuvvet kullanılmalıdır. Saldırı ile kuvvet kullanmanın saldırının def edilebilmesi için orantılı olup olmadığı, *objektif* olarak değerlendirilir[69]. Farklı olarak zilyet yönünden *ex ante* değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır[70].

1277 Zilyedin kolluk kuvvetlerine hemen başvurma olanağının olması dahi, kuvvet kullanarak şeyi savunmasına engel değildir. Saldırıda, kuvvet kullanma, ihlali önlemeye ve devamını engellemeye yetecek derecede ise, orantılılık ilkesi gereği haklıdır; bu derecenin üstünde ise haksızdır. Gaspta ise, taşınırda zilyetliği tekrar sağlamaya yetecek; taşınmazda kovmaya yetecek derecede ise, orantılılık ilkesi gereği haklıdır. Bu derecenin üstünde ise haksızdır.

1278 Saldırıya veya gaspa karşı orantılı olarak savunma hakkı, *ihlale uygun oranda* saldırıyı önlenmeye veya şeyi geri almaya uygun oranda olmalıdır. Küçük ya da ayırt etme gücü olmayan saldırgana karşı sert veya ağır kuvvet kullanmaktan kaçınmalı, kullanılan kuvvette de ihlal edene uygun şekilde daha özenli ve dikkatli olmalıdır[71].

1279 Eğer zilyet hangi derecede kuvvet kullanırsa kullansın, şeyi gasıptan geri alamayacak ya da saldırıyı def edemeyecek veya kullandığı kuvvet orantısız olacaksa saldırıyı veya gaspı zilyetlik davaları yoluyla savunmalıdır.

bbb. Savunma Hakkının Sınırının Aşılması (Orantısız Kuvvet Kullanma)

1280 Savunma hakkının sınırının aşılması yani orantısız kuvvet kullanılması durumunda, zilyetliğin ihlalini engelleyen kuvvet kullanma

---

68 **STARK**, BK ZGB Art. 926, N.18 ff; **DOMEJ**, KurzKomm ZGB Art.926, N.21.

69 Aksi yönde subjektif görüş için bkz. **AYAN**, s. 114.

70 **STARK**, BK ZGB Art. 926, N.18.

71 **ERNST**, BK ZGB vor Art.926-929, N.21.

haklı olmaktan çıkar; haksız bir davranışa yani hukuka aykırı bir davranışa dönüşür. Örneğin, bahçedeki meyveleri yemek için giren çocuklar bahçeden kovalanabilir; ancak hırpalanıp dövülemez, bostana giren hayvanlar ürkütülüp dışarıya atılabilir, ancak yaralanıp öldürülemez.

1281 Savunma hakkının sınırları içinde kullanılması halinde, zilyet haksız fiilden doğan borç ilişkisinden dolayı sorumlu olmaz. Savunma hakkının orantılı kullanılması halinde saldırıyı def davranışı hukuka uygun bir davranıştır. Geri almada ise geri alma davranışı fiili hâkimiyeti sağlamaya yeter olmalıdır.

1282 Saldırıyı önleme veya sona erdirmeye yetecekten fazlasını etme veya gaspta geri almayı aşacak olan kuvvet kullanarak savunma davranışı artık hukuka aykırı bir davranıştır; hukuka aykırı davranış olarak, haksız fiilden doğan borç ilişkisinin diğer hukuki olguları da söz konusu ise, zilyet zararı tazmin ile yükümlü olur (TMK m.49)[72].

cc. Zilyetliğe Aykırılığın Hukuka Aykırı Olması

1283 Zilyetliğe aykırı fiil, yani gasp veya saldırı, zilyedin rızası veya diğer bir hukuk kuralı uyarınca hukuka uygun sayılmamalıdır[73]. Zilyetliğe saldırının hukuka uygunluk sebeplerini yukarıda inceledik[74].

c. Savunma Yetkisinin Tarafları

aa. Savunma Yetkisinin Aktif Tarafı: Zilyet

1284 Yukarıda zilyetliğin ihlalinde korunan zilyetlik durumuna ilişkin zilyet konusunda yaptığımız açıklamalara ilaveten aşağıdaki konuyu tekrar değerlendirirsek:

1285 Savunma hakkı süjesi hakkını, ihlal fiili tamamlanmadan veya hemen akabinde kullanılabildiğinden, saldırı fiilinin gerçekleştiği, genelde dolaysız zilyet veya bu kapsamda dolaysız asli veya dolaysız fer'i zilyetin fiili hâkimiyetine yönelik olarak gerçekleşir. Bu sebeple kuvvet kullanma hakkına sahip olan kişi dolaysız zilyettir.

---

[72] **STARK**, BK ZGB Art. 926, N.18 ff.

[73] BGE 135 III 633; **ERNST**, BK ZGB vor Art 926-929, N.21, 41 ff; **EITEL/ ARNET**, ZGB Art 926, N.2

[74] **ANTALYA**, EH II, N. 749.

1286 Zilyedin savunma hakkını kullanması, zilyedin dayandığı haktan bağımsız olarak değerlendirilir; bu sebeple haksız zilyet ya da kötüniyetli zilyet de kuvvet kullanarak savunma hakkına sahiptir[75].

1287 Asli zilyet, genelde malik TMK m. 974 hükmüne göre zilyet sayıldığından, savunma hakkını kullanabilir. Birlikte zilyet olanların her biri zilyetlik hükümlerine dayanarak kuvvet kullanabilir.

1288 Hizmet zilyedi, eşyanın zilyedi adına koruma hükümlerine başvurabilir; korumaya kuvvet kullanarak katılabilir[76].

1289 Hizmet zilyedi zilyet sahibinin haklarının aracısı olan koruyucusu olduğundan ona karşı zilyetliğin korunmasını isteyemez. Hizmet zilyedinin bu hakkı kullanabilmesi zilyet sahibine bağlıdır; zilyet sahibi her zaman hizmet zilyedinin korunmasını yasaklayabilir, durdurabilir[77]; buna rağmen hizmet zilyedi kuvvet kullanmaya devam ederse, fiili hukuka aykırı bir fiil olarak sorumluluğuna yol açar.

1290 Doktrinde, bazı yazarlar, hizmet zilyedinin zilyet adına zilyedin korunması hükümlerinden yararlanamayacağını; eşyaya saldırı halinde TMK m. 64 hükmündeki haklı savunmadan yararlanabileceğini savunmaktadır[78]. Unutmamak gerekir ki TMK m.981 hükmü; TBK m.64'e göre daha özel bir hükümdür[79].

1291 Zilyedin, iradi temsilcileri hizmet zilyedi sıfatıyla kuvvet kullanarak savunma yetkisine sahiptir. Yasal temsilcileri de temsil ettikleri kişi adına bu yetkiyi kullanabilirler. Zilyedin haksız zilyet olması da önem taşımaz. Örneğin hırsız da zilyetliğini kuvvet kullanarak defedebilir (TMK m.981 I). Hırsız bu hakkını zilyetliğini rızası dışında kaybetmiş kişiye karşı kullanamaz (TMK m.981 II).

---

[75] **STARK**, BK ZGB vor Art. 926-929, N.7.

[76] Hizmet zilyedinin kuvvet kullanarak savunması özel düzenlemesi için bkz. BGB § 860. **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 214; **ERNST**, BK ZGB vor Art.926-929, N. 30; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s.66; **NOMER/ERGÜNE**, s.37; **SEROZAN**, N.572. Alman Hukukunda hâkim fikir için bkz. **ENNECERUS/ WOLFF/ RAISER**, SachenR § 6 IV; **JOOST**, MünchK BGB § 860, Rn.2.

[77] **BAMBERGER/ ROTH/ FRITZCHE**, BGB § 860, Rn.3.

[78] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 66, 89; **GÜRSOY/ EREN/ CANSEL**, s.100; **AYAN**, s. 111.

[79] **BREHM**, BK Art. OR 52, N 61.

bb. Savunma Yetkisinin Pasif Tarafı: Gasp veya Saldırgan

1292 Zilyetliği koruyan davalardan farklı olarak, zilyetliğin kuvvet kullanılarak korunması sadece gasıba veya saldırgana karşı mümkündür[40]. Zilyetliği ihlal eylemi sırasında veya eylemden hemen sonra kaçma durumunda iken kuvvet kullanılabileceği için bu hak sadece saldırgan(lar)a veya gaspçı(lara)a karşı kullanabilir[41]; onların küllî ve cüzî haleflerine karşı kullanılamaz.

1293 Gasp eden veya saldırgan, hizmet zilyedi veya bir tüzel kişinin organı olabilir; bu takdirde kuvvet bu kişilere karşı kullanılarak zilyetlik korunur.

d. Savunma Yetkisi

1294 TMK m.981 zilyetliği ihlal eden davranışların iki farklı şekline göre zilyede zilyetliği savunma (Besitzabwehr) yetkisi vermiştir:

aa. Zilyetliği İhlal Eden Saldırıya Karşı Kuvvet Kullanarak Defetme Yetkisi

aaa. Zilyetliği İhlal Eden Saldırıya Karşı Savunma Yetkisi

1295 TMK m.981 I hükmü, zilyede, zilyetliği ihlal eden saldırıya karşı kuvvet kullanarak bu saldırıyı defetme yetkisi vermiştir. Defetme yetkisi zilyedin zilyetlik durumunu meşru müdafaa ederek savunmasıdır[42]. TMK m.981 I, zilyede yapılan müdahaleye karşı savunma imkânı vermektedir.

1296 Defetme yetkisi zilyetliğe saldırı esnasında kullanılır; zilyedin defetme yetkisi, saldırı sonrasında kullanılmaz[43]. Defetme yetkisi, karşı saldırıyla ve saldırıyı defetmeyle orantılı olarak kullanılmalıdır[44]. Zilyet, zilyetliğe olan ihlali defetmeye ilişkin kuvvet kullanırken gereklı özeni göstermelidir[45].

1297 Meşru müdafaa yetkisinde saldırıyı veya gaspı def etme yetkisi, dava yoluyla değil, bizzat zilyet tarafından kullanılır. Zilyetlik davaları veya hakka dayanan davalarla koruma hakkı saklıdır.

---

40 SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N 214c.

41 STARK, BK ZGB Art. 926, N 4.

42 HOMBERGER, ZK ZGB Art.926, N.22 ff.

43 EIETEL/ARNET, CHK ZGB ASrt.926, N.1.

44 STARK, BK ZGB Art. 926, N.10.

45 DOMEJ, KurzKomm ZGB Art.926, N.18.

bbb. Meşru Müdafaa İçin Kuvvet Kullanarak İhlali Defetme Yetkisi

1298 Zilyetliğe saldırıya karşı meşru müdafaa için kuvvet kullanmanın şekli önemli değildir. Önemli olan saldırıyı def edecek oranda -derecede- olmasıdır. Savunma saldırının şekline uygun olarak, kişinin davranışına karşı olabilecek veya tecavüzü def edebilecek başka bir davranış şeklinde tezahür edebilir. Örneğin: bahçeye atılmış çöpün atılmasını engelleme veya dökülenlerin bahçe dışına çıkarılması, geçidi kapatan duvarın yapılmasına engel olma veya yapılanın yıkılması şeklinde[65].

bb. Zilyetliğin Elinden Alınmasına Karşı Kuvvet Kullanarak Zilyetliği Geri Alma Yetkisi

aaa. Zilyetliğin Elinden Alınmasına Karşı Savunma

1299 TMK m.981/II hükmü, zilyede, zilyetliğin elinden alınmasına karşı kuvvet kullanarak zilyetliği geri alma (Besitzkehrung) hakkı tanımıştır[66].

1300 Zilyetliğe saldırıda zilyedin kuvvet kullanabilmesi için, bu *saldırının gizlice ve zorla* (heimlich oder gealtsam) gerçekleşmesi gerekir. Zilyetliği elinden alınanın, zilyetliği savunma davaları veya malik sıfatıyla istihkak davası açma imkânının bulunması, bu hakkı kullanmasına engel değildir; bu davalardan istihkak davasını veya zilyetliği koruma davalarını kullanma hakkı hak düşürücü süre içinde saklıdır.

bbb. Kuvvet Kullanarak Zilyetliği Geri Alma Hakkı

1301 TMK m.981/II hükmünde, zilyedin kuvvet kullanarak zilyetliği geri alması hakkı, zilyetliği ihlal eden eşyanın taşınırlar ve taşınmaz olmasına göre farklı şekilde düzenlenmiştir. **Taşınmaz**da, *el koyanı kovma hakkı*, **taşınır**da, *elinden alma hakkı*.

(1). Taşınmazlarda El Koyanı Kovma Hakkı

1302 Taşınmazlarda, zilyet, saldırganın fiilini sona erdirip, tekrar taşınmazda fiili hâkimiyeti tamamen elde edebilmek için gerekli ve yeterli kuvveti kullanarak, zilyetliğini geri alır. Taşınmazlarda zilyetliğin geri alınma şekli, ihlalin ve sonuçlarının giderilmesi için yeterli olacak oranda ve şekilde olmalıdır.

---

[65] TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 105

[66] STARK, BK ZGB Art. 926, N.11.

1303 Kanun, bu gibi hallerden uygulamada en çok karşılaşılan el koyanı kovmayı örnek olarak göstermiştir. Taşınmaz zilyetliğinin korunması sadece bu örnekle sınırlı değildir, durumun özelliğinin gerektirdiği taşınmazı savunma araçları da söz konusu olabilir[44]. Bunlara örnek verirsek[45]; kilidi sökmek veya anahtarın göbeğini değiştirmek, çiti kaldırmak, yığılan moloz veya otları atmak gibi.

(2). Taşınırlarda Elinden Alma Hakkı

1304 TMK m.981 II hükmü, zilyede, zilyetliği ihlal edenin elinden şeyi alma hakkı tanımıştır. Zilyet bu hakkını saldırı sırasında veya saldırgan kaçarken kullanabilecektir[46].

3. Dava Yoluyla Zilyetliğin Savunulması

a. Genel Olarak

1305 Zilyetlik davaları, bir hakka dayanmaksızın[47], zilyetliğin huzuru sağlama fonksiyonu olarak, var olan -önceki- huzurlu durumun devam etmesi ve tekrar yeniden sağlanmasını (*quiete non movere*) gerçekleştirir[48]. Zilyet zilyetliğini TMK m.981'deki olguların gerçeklemesi halinde kuvvet kullanarak savunabileceği gibi, TMK m.981 ve 982'de dava yoluyla zilyetliğinin korunmasını, TMK m.984 hükmünde düzenlenen süre içinde talep edebilir.

1306 TMK m.981 ve 982'de düzenlenen dava yoluyla zilyetliğinin korunması davalarına zilyetlik davaları ismi verilmektedir. Zilyetlik davaları iki tanedir: Zilyetliğin gaspında zilyetlik davası ve zilyetliğe saldırıda zilyetlik davası.

b. Zilyetlik Davalarının Özelliği

1307 Zilyetlik davaları hem taşınırlarda hem de taşınmazlarda uygulanır. Zilyetlik davaları tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar da uygulanır[51]. Zil-

---

44 **STARK**, BK ZGB Art. 926, N.16.

45 Diğer örnekler Bkz. **STARK**, BK ZGB Art. 926, N.16.

46 **STARK**, BK ZGB Art. 926, N.17.

47 *'Bu tür davaları zilyetliğin arkasında bir hak bulunup bulunmadığı araştırmaksızın, sadece zilyet olduğu için açılan dava'dır. Amaç sosyal düzenin sürdürülmesidir.'* Y. 8. HD., 26.10.2005 T., 6377/7214 (KHO).

48 Bu konuda bkz. **SCHÖBI**, Art.926-929 ZGB.

51 **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s.184; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 171.

yetliğin korunması davaları[54], zilyetliğin hak olarak korumasından ve eşya üzerindeki haktan bağımsız olarak[55], sadece zilyedin fiili hâkimiyeti sebebiyle- *possesorium* dava olması sebebiyle- korunmasını sağlayan davalardır. Bu davalarda zilyetlik durumunun maddi hakka ilişkin hukuki durumuyla -*petitoirium*- ilgilenilmez[56]. Ancak yargılama hukukunda, zilyetlik davası ile hak davasının birbirine olan bağlılığı ve bağımsızlığı konuyla ilgili olarak, zilyetliğin artık nispi veya ayni hak olarak kabul edilmemesi şeklinde geliştiğini yukarıda açıklamış idik[57].

1308 Zilyetliğin dava yoluyla korunmasına (*petitorische* Rechtsschutz) ilişkin TMK m.982 gasp edilenin geri verilmesi kararı ve TMK m.983 hükümlerindeki saldırının önlenmesi ya da saldırının sona erdirilmesi kararı, sadece eşya üzerindeki halihazır fiili durumun belirlenmesi niteliğindedir; eşya ile ilgili hakka ilişkin sonraki davada esas alınmaz[58]. İsviçre Federal Mahkemesinin uygulaması da bu yöndedir[59].

1309 Zilyetliğin dava yoluyla korunmasının haktan bağımsız olarak korunduğu, TMK m.982 I'de gasp edenin kural olarak üstün hak iddia etse bile geri vermekle yükümlü olduğu şeklinde ve TMK m.983 I'de saldır-

---

[54] Bu konuda bkz. FS Guido von Castelberg, s. 303 ff; WEBER, Franz, Die Besitesschutzklagen, insbsbesondere ihre Abgrenzung von den petitorischen Klagen, Freiburg, 1975.

[55] "...*Zilyetlik hukuken korunan korunmuş eylemli bir durum olduğuna göre, zilyetliğin korunması davasında bu durumun bir hakka dayanıp dayanmadığı önemli değildir...*" Y. 8. HD., 26.10.2015 T., 5377/7214 (KHO): "...*Davacı vekili, dilekçesinde açıkça TMK'nın 982. ve devamı maddelerinde düzenlenen zilyetliğin dava yoluyla korunması hükümlerine dayanarak istekte bulunmuştur. Malik mülkiyet hakkına dayanarak dava açabileceği gibi bu haktan bağımsız olarak zilyetliğin korunması yoluyla da elatmanın önlenilmesini isteyebilir. Davacı vekili, gerek dava dilekçesinde gerekse yargılamanın tüm aşamalarında zilyetliğin korunmasını açıkça istediğine göre, ileri sürülen olaylar ve açıklamalar yanlış değerlendirilerek isteğin mülkiyet hakkına dayalı olduğu gerekçesiyle yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması doğru değildir.*" Y. 8. HD., 18.10.2004 T., 2004/5815 E., 2004/6906 K.; "...*Mahkemece, davacının dava dilekçesinde tanımladığı yer için tescil davası açtıktan sonra eldeki zilyetliğin tespiti ve korunması davasını açtığı, tescile dair karar kesinleştiğinde zilyetlik davası ile elde edilmek istenen menfaatin karşılanacağı gerekçeleriyle davacının davasının hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmesi üzerine, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir... davaya konu yerde davacının zilyetliğin korunması talep edildiği ve mülkiyet hakkına dair talepte bulunmadığına göre taraflar arasındaki uyuşmazlığın zilyetlik hükümleri çerçevesinde çözümlenip sonuçlandırılması gerekir. Eş anlatımla bu tür davalarda taşınmaz üzerinde hangi tarafın üstün ve korunmaya değer zilyetliğinin bulunduğunun saptanması uyuşmazlığın buna göre çözümlenmesi gerekir.*" Y. 8. HD., 11.05.2016 T., 2014/23467 E., 2016/8646 K.

[56] Alman hukukunda da BGB §§ 861-867 hükümlerinde düzenlenen zilyetliğin korunmasının (prossesorium), BGB § 975'te düzenlenen mülkiyet hakkının korunmasından (petitorium) farklı olduğu kabul edilmektedir. Bkz. **JOOST,** MünchK BGB § 861 Rn. 1.

[57] **ANTALYA**, EH II, N. 46 vd. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. **STARK,** BK ZGB Vorbem. Art926-929 Art.927, N.97; **LEIFOLD**, s. 74 ff.

[58] **REY,** N. 2099.

[59] BGE 113 II 243; BGE 135 III 633 E. 4.1.

gan şey üstünde hak iddia etse bile aleyhine dava açılabilmesi şeklinde ifade edilmiştir.

1310 Yargıtay 8. HD'nin 07.02.2011 T., 2010-3637/491 sayılı kararında *"... Zilyetlik davalarının en belirgin özelliği yukarıya alınan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da açıklandığı gibi*[100] *davada hakkın tartışma konusu olmaması ve davayı kazanma veya kaybetmenin mevcut olabilecek hak üzerinde herhangi bir etkisinin olmayışıdır. Bunun içinde bu tür davalarda mahkemenin zilyetliğin korunmasına ilişkin vereceği karar, sadece eski zilyetlik durumunun yeniden kurulmasını sağlamaktır. Bu karar zilyede mülkiyet hakkı vermez ve* ***diğer tarafa mülkiyet iddiasıyla dava açma hakkına dokunmaz****. Bu karar davaya dahil olmayan üçüncü kişilerin o şey üzerinde hakları olmadığının kabulü şeklinde anlaşılamaz. Zilyet davaları sonunda verilen mahkeme kararları tamamen* ***geçici bir etkiye sahip olup****, mülkiyet sorunu çözümlenmediğinden* ***mülkiyet yönünden kesin hüküm teşkil etmezler****. ..."*[101].

1311 Zilyetlik hakka dayanıyorsa, hak sahibinin hukuki olguları söz konusu ise, hakka dayanan taşınır davası (TMK m.989) veya istihkak davası (TMK m.683) açarak eşyayı geri alma hakkı saklıdır. Zilyetlik korunmasına ilişkin korunma istemleri, kural olarak talep niteliğindedir. Zilyetliği ihlal edenden varması gereken taleple de istenebilir; ancak yargı kararıyla cebren yerine getirilmesi için TMK m. 984'te düzenlenen yasal sürede ileri sürülmelidir, aksi takdirde dava hakkı düşer.

1312 Zilyetliğin korunması talepleri, haktan ayrılmaz[102]; ancak mirasçılarına intikal eder[103].

---

[100] 09.10.1946 gün ve 12 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gerekçesinden: *"... gasp ve tecavüzüne son verilen davalı, varlığını iddia ettiği hakka dayanarak zilyedi her zaman dava edebilir ve hakkının bu yoldan sağlanmasını mümkün kılabilir. Çünkü, zilyetlik davaları sonunda verilen mahkeme kararları, tamamen geçici bir etkiye sahip kararlardandır; özellikle de bu davalarda mülkiyet sorununun (zilyetliğin arkasında bulunan hak yönünden mülkiyet uyuşmazlığı) çözümlenmediğinden verilen kararlar (mülkiyet yönünden) kesin hüküm teşkil etmezler; yani kesin bir hukuki gerçeği ifade etmezler ..."*. (KHO). Yine aynı yönde bkz. *"Zilyetlik davalarının en belirgin özelliği, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'nun 09.10.1946 tarih 1946/6 Esas, 1946/12 Karar sayılı kararında açıklandığı gibi, davada hakkın tartışma konusu olmaması ve davayı kazanma veya kaybetmenin mevcut olabilecek hak üzerinde herhangi bir etkisi olmayışıdır. Bunun için de bu tür davalarda mahkemenin zilyetliğin korunmasına ilişkin vereceği karar, sadece eski zilyetlik durumunun yeniden kurulmasını sağlamaktır. Bu karar zilyede mülkiyet hakkı vermez ve diğer tarafın mülkiyet iddiasıyla dava açma hakkına dokunmaz."* Y. 8. HD. 07.02.2011 T., 2010/3637 E., 2011/491 K.

[101] Y. 8. HD., 07.02.2011 T., 2010-3637/491 (KHO). Aynı şekilde, Y. HGK., 12.5.1982 T., 1979/8-589 E., 1982/482 K.

[102] **JOOST,** MünchK BGB § 861 Rn 5. Bu konuda bkz. **WOITKEWITSCH,** MDR 2005, 1023-1024.

[103] Bu konuda bkz. **ECKARDT,** ZIP 1999, 1734-1743.

c. Zilyetlik Davalarında Yargılama

1313 Zilyetlik davaları[104], sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girer (HMK m. 4/I c)[105]. Sulh mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır (HMK m.316/I, a). Bu yargılama usulü basit ve hızlı olduğundan zilyetliği koruyan davalara uygundur.

d. Zilyetliğin Gaspında Zilyedin Dava Hakkı: Geri Verme (Alma) Davası

aa. Terim

1314 TMK m.982 hükmü[106], zilyetliğin gaspında zilyetliğin tekrar geri alınmasına ilişkin dava hakkını düzenlemiştir[107] (die Klage aus Besitzesentziehung).

1315 Zilyetliğin gaspında, zilyetliğin geri alınması davasının düzenlenmesinin amacı, yukarıda açıkladığımız üzere, haktan bağımsız olarak zilyetliğin korunması, zilyetliği gasptan önceki duruma döndürerek toplumsal huzurun sağlanmasıdır.

1316 Zilyetliğin gaspından doğan dava, TMK'da geri verme davası, eTMK 896'da iade davası, doktrinde ise bazı yazarlar tarafından yedin iadesi olarak isimlendirilmiştir.

1317 Biz, buradaki davanın *geri alma davası* olarak isimlendirilmesinin daha doğru olduğunu; ancak gasp eden yönünden kanunda ifade edilen terim olan geri verme terimini kullanacağız.

bb. Hukuki Olguları

1318 Zilyedin eşya üzerindeki fiili hâkimiyetinin gaspla ihlali söz konusu olmalıdır. Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasbeden kimse, o şeyi geri vermekle yükümlüdür (TMK m.982/I).

---

[104] Bkz. **ERNST**, s.101 ff. **PORTMANN**, s. 1 vd.

[105] *"... Yalnız zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesinde görülür..."* Y. HGK., 25.11.2009 T., 2009/8-518 E., 2009/573 K.; *"Davacılar vekili davada yukarıda belirtildiği üzere zilyetliğin arkasında bulunan ayni veya şahsi bir hakka dayanmadığına ve taşınmaz tapuda Hazine adına kayıtlı bulunduğuna göre, uyuşmazlık zilyetliğin korunması hükümleri gereğince çözümlenmelidir. Mahkemece zilyetliğin korunması talebi ile TMK'nın 981 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan davalarda, dava konusu taşınmazın değerine bakılmaksızın 6100 sayılı HMK'nın 4/c (1086 sayılı HUMK'un 8/II-3) bendine göre Sulh Mahkemelerinin görevli bulunduğu dikkate alınmadan, yazılı şekilde hüküm kurulmuş bulunması usul ve yasaya aykırıdır."* Y. 8. HD. 20.10.2011 T., 2011/609 E., 2011/5283 K. Aynı yönde bkz. Y. 3. HD. 25.03.2010 T., 2010/1989 E., 2010/5166 K.

[106] Karş. BGB § 858.

[107] YHGK., T.25.11.2009, E.2009/8-518, K.2009/573. YHGK., T.11.02.2009, E.2009/8-28, K.2009/74

1319 Zilyetliğin gaspına karşı açılan geri verme davası, zilyetliğin dava yoluyla savunulmasının bir yoludur. Bu dava, TMK m.981'e göre, genellikle kuvvet kullanarak zilyetliğin korunmasının mümkün olmadığı veya zilyedin bu yola başvurmadığı durumlarda söz konusu olur. Hukuka aykırı gasp fiilini yukarıda incelemiş idik[1058]. Bir fiilin saldırı olup olmadığı, o fiile ilişkin yaşam deneyimi ve toplumsal ilişkilerin objektif değerlendirmesiyle belirlenir.

1320 Kişi bir şeye gasp anında dolaysız zilyet olmalıdır. Zilyedin zilyetliği gasp suretiyle hukuka aykırı olarak ihlal edilmelidir. Bu ihlalle zilyet, eşya üzerindeki zilyetliğini yani fiili hakimiyetini kaybetmektedir. Gaspla, önceki zilyedin fiili hakimiyeti geçici değil, sürekli olarak ortadan kaldırılmıştır[1059].

1321 Zilyetliği hukuka aykırı gasp edilen kişi, kaybettiği dolaysız zilyetliğini tekrar sağlamayı amaçlamaktadır. Kuvvet kullanarak savunmadan farklı olarak, gasıbın el koyma esnasında kaçar durumda olması gerekli değildir. Yine farklı olarak, gasp fiilinin gizlice ve zorla olması da gerekli değildir[1060]. Geri verme davasında gasp edenin fiilinin kusurlu olması da gerekli değildir.

cc. Korunan Kişi (Davacı Sıfatı/Aktif Dava Tarafı: Davacı): Zilyet

1322 Zilyetliği gasp edilen her zilyet bu zilyetliğin korunması davasından yararlanabilir. Bu konuda aşağıda özellik arz eden durumlar dışında, yukarıdaki açıklamalara atıf yapmakla yetineceğiz[1061].

aaa. Haksız Zilyedin Davacı Sıfatı

1323 Zilyetliği geri verme davasını açma hakkı, dolaysız zilyetliği gaspla ortadan kalkan eski dolaysız zilyede aittir. Zira TMK m. 982 I gasp eden kişi üstün hak sahibi olduğunu iddia etse bile şeyi geri vermekle yükümlü kılınmıştır. Bu kurala TMK m.982 II istisna getirerek kuralı yumuşatmıştır. TMK m.982 II'ye göre, açılan geri verme davasında, malik üstün hak sahibi olduğunu derhal ispat ederek taşınırı geri vermekten kaçınabilir.

[1058] ANTALYA/TOPUZ, EH N. 735.

[1059] ERNST, BSK ZGB Art 927, N.2.

[1060] EITEL/ARNET, CHK ZGB Art 927, N.2.

[1061] ANTALYA/TOPUZ, EH N. 757 vd.

Hizmet zilyedinin kendi başına zilyetliği geri verme davası açma hakkı kural olarak bulunmamakla beraber zilyet sahibinin vekili sıfatıyla dava açma hakkı saklıdır.

bbb. Dolaylı Zilyedin Davacı Sıfatı

1324 Dolaylı zilyedin geri verme davasındaki özellik arz eden hususlarına da değinmek gerekir. Bilindiği üzere, zilyetliğin gaspı halinde geri verme davası, genelde dolaysız zilyet tarafından açılabildiği gibi, dolaylı zilyet de bu konuda geri verme davası açma hakkına sahiptir.

1325 Dolaylı asli zilyedin bu hakkını kanun tanımıştır. Örneğin; rehinli verilen taşınırın çalınması halinde, dolaysız zilyet olan rehin hakkı sahibi geri verme davasını açabileceği gibi, malik asli dolaylı zilyet olarak da geri verme davası açabilir.

1326 Dolaylı zilyedin açtığı geri verme davasında, gaspçının geri vermeyi kime yapacağı konusu tartışmalıdır. Örnek olayda olduğu üzere, malik dolaylı zilyet olarak hırsıza karşı açtığı geri verme davasında, hakim, davalı hırsızın taşınırı malike geri vermesine mi yoksa rehin hakkı sahibine geri vermesine mi hükmedecektir; bu soruna paralel olarak dolaylı zilyet olan davacı malikin geri verme davasındaki netice-i talebi ne şekilde olacaktır sorularına verilen cevap doktrinde tartışmalıdır.

1327 TMK dolaylı zilyedin geri verme davasında geri vermenin kime yapılacağı hususunu düzenlemediğinden, bu konuda *açık kanun boşluğu* olduğunun kabulü gerekir. Açık kanun boşluğunun hakim tarafından yaratma yöntemiyle bu konuyu düzenleyen BGB § 869 hükmünden yararlanılarak doldurulması gerekir.

1328 BGB § 869 hükmü, dolaylı zilyede, dolaysız zilyet zilyetliğini korumasa da dolaylı zilyedin kendisine özgü olarak zilyetliği ihlal edene karşı, zilyetliği elinden alınan dolaysız zilyedin rızası olmaksızın, zilyetliğini koruma hakkı olduğunu; zilyetliğin gaspı halinde, önceki zilyet artık zilyet olamıyor veya artık olmak istemiyorsa, kendisine teslimini isteyebileceğini düzenlemektedir[1-2]. Benzer düzenleme BGB § 861 Abs.1'de de söz konusudur.

[1-2] GOST, MünchK BGB § 869, RN.3

1329 BGB § 869'un çözüm tarzının İsviçre Türk hukuku için de uygun çözüm olduğu Doktrinde hâkim görüş tarafından kabul edilmektedir[113]. Davacı dolaylı zilyet, davalı gaspçıya karşı açacağı geri verme davasında, terditli olarak, davayı aslî müdahale etmesi için davalı dolaysız zilyedin taşınırın dolaysız zilyede geri vermesini; şayet dolaysız zilyet eşyayı geri alabilecek durumda değilse veya geri almak istemiyorsa, taşınırın kendisine verilmesini talep etmelidir[114].

1330 Kademeli zilyetlikte asli zilyet, dolaylı zilyet durumunda olarak, aynı korumadan yararlanır; bu konudaki boşluk için önerdiğimiz şekliyle, BGB § 861 s.2'de olduğu üzere, fer'i zilyet artık zilyet olamıyor veya olmak istemiyorsa asli zilyet şeyin kendisine teslimini isteyebilir[115].

1331 Dolaysız -fer'i- zilyet, dolaylı -asli- zilyetliği tanımıyorsa, dolaylı asli zilyedin TMK m.982 hükmüne dayanarak zilyetliğinin tanınmasını sağlaması da mümkündür. Dolaylı zilyet, eşyayı gasp eden dolaysız zilyede karşı da geri verme davası açabilir. Örneğin, örnek olayda olduğu üzere dolaylı -asli- zilyet (malik), rehinli taşınırı dolaylı -fer'i- zilyedin rızası dışında gasp etmiş olabilir.

ccc. Birlikte Zilyedin–El Birliği ile Zilyetlerin Davacı Sıfatı(ları)

1332 Birden fazla zilyetliğin bulunması durumunda, zilyetliğin birlikte mi yoksa elbirliği ile olduğuna bakmamız gerekir[116].

1333 Birlikte zilyet halinde, birlikte zilyetlerin her biri gaspçıya karşı tek başına geri verme davasını açabilir[117] (TMK m.693 III). Birlikte zilyetlerin eşyanın kullanımına ilişkin aralarındaki hukuki ilişkiden ve birliktelıklerine esas haktan kaynaklanan uyuşmazlıklar, zilyetliğin geri verme davasının konusunu oluşturmaz[118].

---

[113] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 91.

[114] **NOMER/ ERGÜNE**, s.40.

[115] **ENNECCERUS/WOLFF/RAISER**, SachenR § 20 Anm. 3.

[116] **STARK**, BK ZGB Art. vor 926-929, N. 64 ff.

[117] **ENNECCERUS/WOLFF/RAISER**, SachenR § 20 Anm. 3; GOST MünchK BGB § 869, RN.3.

[118] Aynı konutu paylaşan eşlerin, birlikte zilyet sıfatını taşıdıkları bir olayda davalı eşin aynı konutu paylaşmasından hareketle zilyetlik davalarında hasım gösterilemeyeceğine dair karar için bkz. Y. 8. HD. 27.10.2011 T., 2011/848 E., 2011/5509 K.: "*Dava, eşitmanın önlenmesine ilişkindir. Davanın alıcının davalı olan eşine yöneltilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Çünkü davalı da aynı evde oturmaktadır. Dava zilyetliğin korunması davası olarak nitelendirilemez. Davanın aynı hakka ilişkin müdahalenin önlenmesi davası olduğunun kabulü ile uyuşmazlığın bu doğrultuda çözüme kavuşturulması gerekmektedir...Saptanan bu hukuki ve somut olgu*

1334 Elbirliği ile zilyetlikte de zilyetlerin her biri gaspçıya karşı dava açabilirler. TMK m.702 IV hükmü, eTMK'da olmayan yeni bir düzenleme olarak, ortaklardan her birine el birliği topluluğuna giren hakların korunmasını sağlama imkânı vermiştir. Bu hükmün kapsamına, hakların yanında da zilyetliğin korunması da dahildir. Açılan zilyetlik davasının korumasından, diğer elbirliği ortakları da yararlanacaktır.

dd. Karşı Taraf (Davalı Sıfatı Pasif Dava Tarafı: Davalı): Gaspçı

1335 Geri verme davası, halihazır zilyetliği gaspla elde eden halihazır haksız zilyede karşı açılır. Zilyetliği gasp eden kişi, haksız veya kötü niyetli olmasa da zilyetliğin gaspı halinde geri verme davası açabilir. Örneğin; hırsız eşyayı sonradan geri almak isteyen, ancak kuvvet kullanarak elinden alma hakkı olmayan malike karşı geri verme davası açabilir.

1336 Zilyetlik davası gasp eden(lere) ve onun küll: haleflerine karşı açılır. Zilyetlik davasından sonuç alınabilmesi gasp edilen eşyanın halen davalının zilyetliğinde bulunmasına bağlıdır[119].

1337 Zilyetliği gasp edenin filine iştirak edenlere de örneğin yardım ve yataklık edenlere de dava açılabilir.

1338 Zilyetliği gasp eden dolaysız zilyetliğini kaybederse, kural olarak ona karşı artık geri verme davası açılamaz. Ancak, geri verme davasını gaspçının cüz'i haleflerine, taşınırın devredildiği üçüncü kişiye karşı açılamayacağı savunulmuştur. Bu görüş, geri verme davasının zilyetliğin gaspa karşı korunmasına yönelik özel bir koruma davası olduğunu, davanın hukuki olgusu olarak, gasıbın iyiniyetli olup olmamasının aranmadığını belirtmekte; gasp nedeniyle zilyetliğini kaybeden kişiye karşı, hakka dayanan taşınır davası veya istihkak davası yoluna başvurabileceğini savunmaktadırlar[120].

1339 Doktrinde, haklı olarak, kötüniyetli cüzi haleflere karşı da açılabileceği kabul edilmektedir[121]. Hatta bazı yazarlar, daha da ileri giderek,

---

karşısında davanın TMK'nın 982 ile 987. maddelerinde yer alan zilyetliğin korunması davası olarak nitelendirilemez. O halde mahkemece yapılacak iş; davanın aynı hakka ilişkin müdahalenin önlenmesi davası olduğunun kabulü ile uyuşmazlığın TMK'nın 683. maddesi uyarınca, iddia ve savunma çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerekmektedir".

[119] **SCHMID/ HÜRLIMAAN-KAUP**, N. 237.

[120] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 92-93; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s.123-124; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s.176; **AYAN**, s.115. Bkz. **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 186.

[121] **STARK**, BK ZGB Art. vor 927, N. 5.

iyiniyetli cüz'i haleflere de bu davanın yöneltilebileceğini iddia etmektedir[22].

1340 Görüşümüze göre, bu konuda bir kanun boşluğu söz konudur. Kanun boşluğu, BGB § 858 II'de düzenlendiği şekliyle doldurulmalıdır. BGB § 858 zilyetliği gasp edilenin kötü niyetli cüz'i haleflere karşı dava açabileceğini öngörmektedir[23].

ee. Hukuki Sonucu

1341 Dava, şeyin geri verilmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur (TMK m.982 III).

aaa. Zilyetliğin Geri Verilmesi Talebi

(1). Genel Olarak

1342 Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasp eden kimse, o şey üzerinde üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yükümlüdür (TMK m.982 I). Zilyetliği gasp eden, zilyetliğin gasbının sebep olduğu zararlar kapsamında, geri verilmesi masraflarını da zararın giderimi kapsamında yüklenmek zorundadır.

1343 Zilyedin, geri ver talebi niteliği itibarı ile bir taleptir. Bu talebin dava dışı ihtarla istenmesi mümkündür; ancak dava ile cebri icraya konu edilebilecek kararla yerine getirilebilir. Davanın da TMK m.984'te düzenlenen süre içinde açılması gerekir, aksi takdirde dava hakkı düşer. Gaspeden, kural olarak, eşyayı gasp ettiği yerde eski zilyede geri vermesi gerekir.

1344 Gasp eden, gasp ettiği eşyayı kaim eşya olarak değil, aynen iade ile yükümlüdür; aksi takdirde, eşyayı aynen iade edemiyorsa, TMK m.982 III hükmüne göre, öncelikle gasıp kusurlu ise haksız fiil hükümlerine göre, kusursuz ise zilyetliğin iadesi kapsamından eşyayı iade edememesinden doğan zararı tazminle yükümlü olur.

(2). Davalının Üstün Hakkı Savunması (Geri Vermekten Kaçınma Hakkı)

1345 Başkasının zilyet bulunduğu bir şeyi gasp eden kimse, o şey üzerinde üstün bir hakka sahip olduğunu iddia etse bile onu geri vermekle yüküm-

---

[22] **AYBAY/ HATEMİ**, § 8. N.21-22

[23] **JOOST**, MünchK BGB § 858 Rn.16; § 861 Rn.14. **GUTZEIT**, Staudinger BGB BGB § 861. Rn 8. Fakat **ENNECCERUS/ WOLFF/ RAISER**, SachenR § 19 Anm 1 zilyetliğin kaybının kasti olmasını aramaktadır.

lüdür (TMK m.982 I). Zilyetlik davalarında, gasp edene karşı, hak sahibine karşı -üstün- hak iddia etse bile, zilyetliğin tekrar sağlanması veya saldırının önlenmesi ya da sona erdirilmesi gerçekleşir[24]. Örneğin: eşyayı gasp eden hırsıza karşı malik üstün hak savunmasında kural olarak bulunamaz.

1346 Ancak davalı, o şeyi davacıdan geri almasını gerektirecek üstün bir hakka sahip olduğunu derhal ispat ederse onu geri vermekten kaçınabilir (TMK m.982 II)[25]. TMK'nın zilyetlik davaları halihazır zilyedi haksız ve kötüniyetli olsa da koruması, var olan yaşam ve toplum huzurunun korunmasıyla açıklanmaktadır. Ancak bu sonucun adil olmadığını düşünen kanun koyucu bu kurala TMK m.982 II'de bir istisna getirmiştir. Bu hükme göre, zilyedin üstün hak savunmasından sonuç alabilmesi, sadece zilyedin -üstün- hakkını derhal ispat edebilmesine bağlanmıştır.

1347 TMK m.982 II burada, davacıya karşı davalının zilyetlik durumundan doğan bir itiraz (*possesorium absorbet petitorium*) savunması düzenlemiştir. Davalı, davadaki bu savunmasıyla, zilyetliğe yapılan saldırının hukuka aykırı bir saldırı yani haksız bir el atmanın olmadığını ortaya koyarak davanın reddedilmesini sağlar. Davalı bu savunması yanında zilyetliğin korunmasını gerektiren hukuki olguların olayda gerçekleşmediğini de savunabilir.

1348 Üstün hak ayni hakka dayanabileceği gibi nispi bir hakka da, örneğin; kira veya kullanma ödüncüne, geri verme yükümlülüğüne de dayanabilir; zilyetliği ihlal edilenin üçüncü kişi olarak, zilyet olanın taraf olduğu bir başka sözleşme ile yetkili olduğunda da bu üstün hakkını, doktrinde tartışmalı olmakla birlikte ileri sürebilir.

1349 Üstün hakkı, davacının fiiline davalının katlanması yükümlülüğü çıkabilir. Getirilen TMK m.982 II hükmü, hakka dayanan ayrı bir dava açılmasına hizmet ettiğinden yargılama hukukuna hâkim usul ekonomisine uygundur[26]. Diğer yandan, üstün hak sahibini özellikle haksız ve kötüniyetli zilyede karşı koruması adildir[27].

---

[24] BGE 119 Ia 28 ff. 33 E.3.

[25] Karş. BGB § 861, § 862.

[26] **STARK**, BK ZGB Art.927, N.198; **SCHMID/HÜRLIMAAN-KAUP**, N.236; **STEINAUER**, I, N.346.

[27] **NOMER/ ERGÜNE**, s. 41.

1350 Hakka karşı zilyet durumu çatıştığında, kanun koyucu üstün hakkı zilyetliğe karşı bazı şartlarla korumuştur. TMK m.982 II hükmünde, davalının savunduğu üstün hakkını derhal ileri sürmesi gerekir[128]. Üstün hak, nispi haktan veya ayni haktan kaynaklanabilir[129]. Üstün hak, kamu hukukundan veya özel hukuktan da kaynaklanabilir. TMK m.982 II'de bir ispat kuralı da düzenlenmiştir[130]. Davalı üstün hakkını ispat yükü altındadır. Davalı, üstün hak savunmasını yargılamada, derhal ileri sürmeli ve tartışmasız ispat etmelidir.

1351 Davalı üstün hak sahibi olduğunu, üstün hakkın varlığını ortaya koyan *tartışmasız* ve *açık belgelerle*, örneğin HMK'nın öngördüğü kesin delillerle ispat edebilir. Takdiri delillerle ispat, üstün hakkı tartışmasız ve açık olarak gösteriyorsa dayanılabilir. Örneğin; tanıkla ispat davalının derhal ispatını gerçekleştirmez.

1352 Buna karşın fatura, araç ruhsatı, hayvan sahiplik belgesi vb. delillerle üstün hak ispat edebilir. Örneğin; bir köpeğin sahibi çalana karşı onun geri verilmesini talep ettiğinde, hayvanın kimliğindeki sahip bölümüyle veya hayvana takılı çipteki bilgilerle üstün hakkını ispat edebilir[131]. Davalı tapu kaydı, araç ruhsatı, kira sözleşmesi vb. belgeleri ibra ederek üstün hakkını derhal ispat edebilir.

bbb. Zilyetliğin Gaspından Dolayı Uğradığı Zararın Tazminini Talep

1353 Zilyet, zilyetliğin geri verilmesi davası ile birlikte veya ondan ayrı olarak zararının giderilmesini talep edebilir (TMK m. 982 III). Gaspçının hukuki sorumluluğunun niteliği doktrinde tartışmalıdır.

1354 Katıldığımız hâkim görüş, gasptan doğan zararın tazminini, haksız fiilden doğan borç olarak nitelerken[132], *Ernst*, gaspçının sorumluluğunu haksız zilyedin iadesi hükümlerine (TMK m.993-995) tabi tutmaktadır[133].

---

[128] BGE 113 II 243 ff. 245 E.1b.

[129] **STARK**, BK ZGB Art.927. N.20.

[130] **ANTALYA/ TOPUZ**, MHG. s. 429.

[131] **SCHMID/ HÜRLIMAAN-KAUP**, N. 236.

[132] BGE 66 II 228 ff. 236. **STARK**, BK ZGB Art. 927. N.26 ff. **STEINAUR**, I, N. 354; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 177; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 41. Alman hukukunda zararın tazmini BGB § 242 haksız fiil kapsamında değerlendirilmektedir. bkz. **JOOST**, MünchK BGB § 859 Rn.10.

[133] **ERNST**, BSK ZGB Art.927. N.8 ff.

Hinderling ise, haksız fiil hükümleri yanında zilyetliğin iadesi hükümlerinin uygulanabileceğini kabul etmektedir[34].

1355 Görüşümüze göre, zilyetliğin haktan ayrı ve bağımsız olarak korunması söz konusu olduğundan zilyetliğin iadesi kapsamında yapılan hakkın haklı (iyiniyetli) ya da haksız (kötüniyetli) olması önem taşımadığından, bu ayrımı esas alan bir iade rejimi olan TMK m.993 vd. hükümleri zilyetlik ihlalinden doğan zararın tazmine uygun değildir. Diğer yandan zilyetliğin geri verilmesi değil, zararın giderilmesi söz konusudur.

1356 TMK m.982 II'deki zararın tazmini, kendine özgü özel bir sorumluluk sebebi değildir. Gasıbın gaspıyla sorumlu tutulabilmesi için, gasıbın fiilinin hukuka aykırı fiil olmasına ilaveten, TBK m.49'da aranan hukuki olguların gerçekleşmesi, yani gasıbın davranışının kusurlu olması ve zarar verici fiil olması gerekir[35].

1357 Gaspçının kusursuz sorumluluğu söz konusu ise, kusurlu davranış olgusu aranmaz.

1358 Zilyetliğin ihlali sebebiyle uğranılan zararın tazminında TMK m.49 vd. hükümleri uygulanır. Zilyedin fiili hâkimiyetini kaybetmesi sebebiyle doğan kişi, eşya ve malvarlığı zararları tazmin edilir; yeter ki zilyetliğin ihlali sebebiyle doğmuş olsun[36].

1359 *Stark*'a göre saldırı sebebiyle eşyada gelecekte beklenen değer kaybı da giderilmelidir[37].

1360 Zararın giderimi için, gaspçının fiilinin eşyaya zarar vermesi gerekir. Davacının uğradığı zararın, zilyedin eşya üzerinde iddia ettiği hakla sınırlı olduğu kabul edilmektedir[38]. Örneğin kiracı gasp dolayısıyla kiralananı kullanamamaktan doğan zararının giderimini talep edebilir; eşyanın maddi varlığına ilişkin zararın tazminini ise talep edemez.; eşyanın maddi varlığına ilişkin zararın tazminini malik talep edebilir.

1361 Görüşümüze göre, bu yaklaşım, zilyetliğin bağlı bulunduğu haktan hareketle zararın giderimini esas almaktadır. Hâlbuki burada zilyetlik du-

---

[34] **HINDERLING**, SPR V/1, s.455.

[35] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 93.

[36] **STARK**, BK ZGB Art.928, N 47.

[37] **STARK**, BK ZGB Art.928, N 50 f.

[38] **NOMER/ ERGÜNE**, s. 41.

umunun ihlalinden doğan zararın giderimi söz konusudur. Bu yaklaşımımız normun koruma amacına uygundur. Zilyet gasp sebebiyle fiili hâkimiyeti tamamen kaybetmesi sebebiyle uğradığı zararın tazminini talep edebilmelidir. Kanun zilyede hak sahibi olduğu için değil, zilyet olduğu için uğradığı zararının tazmini imkanını vermeyi amaçlamıştır. Zilyedin zilyetliğinin varsa dayandığı hakkın ihlali veya hak sahibinin hakkı ihlal sebebiyle de tazminat hakkı saklıdır. Ancak saldırganın kusurunun bulunmaması halinde, zilyet haksız zilyedin iadesi hükümlerine (TMK m.993-995) başvurabilir[1].

e. Zilyetliğe Saldırıda Dava Hakkı

1362 Zilyetliğe olan saldırıda saldırının sona ermesi veya önlenmesi davası, zilyetliğin haktan bağımsız olarak toplumsal huzurun korunmasını amaçlar. Bu amaçla zilyetliğin korunması, özellikle aynı (mülkiyet) hakkı olmayan özel hukuk (borçlar hukuku) ilişkilerinden kaynaklanan haklı doğrudan zilyedin, örneğin kiracının, ödünç alanın, kullananın vb. korunmasına hizmet eder.

1363 Zararın tazminini öngören tazminat davası bir kenara bırakılırsa, saldırıya karşı zilyetliği koruyan iki dava söz konusudur; devam eden saldırıya yönelik *saldırıyı sona erdirme davası* ve kuvvetle gerçekleşmesi beklenen saldırıya karşı *saldırıyı önleme davası*. Saldırının önlenmesi davası da tekrarlanabilecek saldırının önlenmesi veya kuvvetle gerçekleşmesi beklenen saldırının önlenmesi olmak üzere iki çeşittir.

aa. Terim

1364 TMK m.983 hükmü, zilyetliğe saldırıya karşı dava hakkını düzenlemiştir (die Klage aus Besitzesstörung). Zilyetliğe saldıran, zilyetliğe saldırının sebep olduğu zararlar kapsamında, geri verme masraflarını da zararın giderimi kapsamında yüklenmek zorundadır.

1365 Zilyedin, saldırının önlenmesi talebi niteliği itibarı ile bir taleptir. Bu talebin dava dışı ihtarla istenmesi mümkündür; ancak dava ile cebri icraya konu edilebilecek kararla yerine getirilebilir. Davanın da TMK m.984'te düzenlenen süre içinde açılması gerekir, aksi takdirde dava hakkı düşer. Saldırganın, kural olarak, taleple zilyetliğe saldırıya son vermesi gerekir.

[1] HINDERLING, SPR V/1, s.455; STEINEUR, I, N.354.

1366 Zilyetliğin gaspından doğan dava, TMK'da sona erdirme davası ve önleme davası, eTMK 897'de tecavüzün ref'i davası ve sebebin men'i davası, doktrinde ise bazı yazarlar ve uygulama tarafından tecavüzün men'i, men'i müdahale, el atmanın önlenmesi, saldırının önlenmesi olarak isimlendirilmiştir. Biz kanundaki terimlere sadık kalacağız.

bb. Hukuki Olguları

1367 Zilyedin eşya üzerindeki fiili hakimiyetini, sona erdirecek şekilde olmamak üzere, katlanılamayacak şekilde hukuka aykırı olarak devam eden müdahale veya yakın müdahale tehlikesi halinde, zilyetliğe saldırıdan bahsedebiliriz[40].

1368 Saldırı fiilinin mutlaka maddi olarak doğrudan gerçekleşmesi beklenmez; eşya üzerindeki zilyetliği ihlal dolaylı fiillerle de gerçekleşebilir. Örneğin; fabrika bacasından gelen kirli duman, imalattan gelen zehirli atık, alçaktan uçarak gürültü yapan uçak vb. gibi.

1369 Zilyetliğe saldırı hukuka aykırı olmalıdır. Saldırganın saldırı fiiline dava açmak için, kusurlu bir fiili olması gereklı değildir[41]; kusur zilyetliğe saldırıdan doğan zararın haksız fiil kapsamında tazminında aranır. Saldırgan şey üzerinde bir hak iddıa etse bile saldırıdan kaçınmakla yükümlüdür. TMK m.983 zilyetliğe saldırıda, TMK m.982 II'de olduğu üzere, üstün hakkı olduğunu derhal ileri sürer ve ispatlarsa, saldırıya katlanmakla yükümlü olduğunu düzenlememiştir. Bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür.

1370 Doktrinde bir görüş, saldırgana üstün hak savunmasının verilmesi gerektiği yönündedir[42]. Aksi görüş ise, yasal düzenlemeden hareketle, burada bilinçli bir tercihin olduğunu, geri verme davasından farklı olarak zilyetliğe saldırıya ilişkin davalarda, üstün hak iddiasının dinlenemeyeceğini savunmaktadır[43].

---

[40] **STARK**, BK ZGB Art.928 N.19. *Mirasbırakanın önceki zilyet olduğu iddiasına dayanan mirasçıların açtığı davada Hazine'nin tapuda malik olarak görülmesinden hareketle TMK m. 992 sicil zilyetliğine öncelik tanıdığı ve saldırıdan ziyade mirasçılık hakkına dayanan taleplerin TMK m. 982 vd. kapsamında değerlendiremeyeceğini ifade eden kararı için* bkz. Y. HGK. 25.11.2009 T., 2009/8-518 E., 2009/573 K. Yargıtay bir diğer kararında zilyetliğe saldırı olgusunun bulunmadığını ortaya koymuştur: "... *Olayımızda davacı ve davalı taraf aynı satış senedi ne dayanarak talepte bulunduklarına göre her iki tarafın ayrı ayrı şahsi hakka dayandığının kabulü gerekir. Bu itibarla dava zilyetliğin korunmasına yönelik bir dava olmayıp, şahsi hakka dayalı elatmanın önlenmesi niteliğindedir.*" Y. 8. HD. 13.02.2006 T., 2005/8856 E., 2006/1111 K.

[41] **STARK**, BK ZGB Art.928 N.38.

[42] **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 190.

[43] **STARK**, BK ZGB Art.928 N.2; **EİETEL/ ARNET**, ÇHK ZGB Art.928 N.2; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 41.

1371 Görüşümüze göre, kanunda bir boşluğun olduğunu kabul etmekteyiz Bu boşluğun, TMK m.982 II'ye kıyasen, çokta olan azda olmalı ilkesinden hareketle, daha ağır gasp halinde tanınan bu hak ondan daha az şiddetteki saldırıda da tanınmalıdır düşüncesiyle, TMK m.982 II hükmüne benzer şekilde doldurulmalıdır. Öyleyse, davalı o şeyin zilyetliğine müdahalede bulunmasını gereklı kılacak üstün bir hakkı olduğunu derhal ispat ederse, zilyet buna katlanmakla yükümlüdür. Gerçekten, komşuluk hukukunda hukuka aykırı saldırının sınırları TMK m. 737'de düzenlenmiştir; komşuya saldırganın katlanması gerektiği savunmasını vermek gerekir[144].

1372 Davalının hakka dayanan taşınır davası veya el atmanın önlenmesi davası açma hakkı saklıdır.

cc. Konusu

1373 Zilyetliğe saldırıya karşı koruma davaları hem taşınırlarda hem de taşınmazlarda uygulanır. Hak zilyetliğinde de uygulaması söz konusudur. Örneğin; geçit hakkı ile yüklü taşınmaz malikı, yoldan geçişi engellerse bu dava uygulanır[145].

dd. Davacı Sıfatı ve Davalı Sıfatı

1374 Saldırganın, zilyetlik durumunu ihlal etmekten kaçınma yükümlülüğü söz konusudur. Saldırıda bulunan, şey üzerinde bir hak iddia etse bile, zilyetliği saldırıya uğrayan, ona karşı dava açabilir (TMK m.983 I).

1375 Zilyetliğe saldırıda davacı sıfatı, niteliği ve çeşidi ne olursa olsun, her türlü zilyede, davalı sıfatı ise saldırgana aittir[146].

1376 Hizmet zilyedinin kendi başına zilyetliği önleme veya geri verme davası açma hakkı kural olarak bulunmamakla beraber, zilyet sahibinin ve-

---

[144] **HOMBERGER.** ZK ZGB Art.928 N.4. Koruma talep eden zilyedin, kendine ait taşınmazda zilyet olmasının gereklilik olmadığı ve bu davaların salt zilyetliği koruyucu etki taşıdığı yönünde bkz. Y. 8. HD. 26.10.2005 T., 2005/6377 E., 2005/7214 K.: "*...Davacılar, Hazine'ye ait 274 ada 6 numaralı parsel üzerinde zilyet bulunduklarını, davalıların da zilyetlikten kaynaklanan haklarını kullanmasına engel olduklarını iddia ederek bu davayı açmışlardır. Davacıların başkasına ait taşınmaz üzerinde zilyet olması mümkün olduğu gibi TMK 973 ve müteakip maddeleri gereğince zilyetliğin korunmasını da istemeye hakları bulunmaktadır. Bu tür davalar zilyetliğin arkasında bir hak bulunup bulunmadığı araştırılmaksızın sadece zilyet olunduğu için açılan davalardır. Amaç sosyal düzenin sürdürülmesidir.*"

[145] **STARK.** BK ZGB Art.928 N.24.

[146] **STARK.** BK ZGB Art.928, N.7. Bu yönde bkz. "*.. kiracının mecura zarar veren kişilere karşı davacı olma sıfatının bulunduğu kabul edilmelidir. Davacının aktif husumet ehliyeti bulunduğu gözetilerek işin esasının incelenmesi gerekirken, mahkemece yazılı şekilde davanın reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir.*" Y. 4. HD. 06.10.2003 T., 2003/5676 E., 2003/11196 K.

kili sıfatıyla dava açma hakkı saklıdır. Birlikte zilyet halinde, zilyetlik çeşidi paylı zilyet ise her bir zilyet (TMK m. 693 III kıyasen); elbirliği ile zilyet ise yine her bir zilyet dava açabilirler (TMK m.702 IV).

1377 Saldırıyı önlemekle yükümlü olduğu halde, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere karşı da bu dava yöneltilebilir. Örneğin; başkasının hayvanlarını kendi taşınmazı üzerinden komşusunun tarlasına girerek ekinleri ezmesine sürekli göz yuman komşu tarla sahibine karşı saldırının sona ermesi davası açılabilir[147].

1378 Gasp bölümünde, tartıştığımız ve kabul ettiğimiz üzere, dolaylı zilyet veya kademeli zilyetlikte asli zilyet, saldırıya uğrayan dolaysız zilyedin rızası olmaksızın da saldırgana karşı saldırının sona erdirilmesini veya önlemesini dava edebilir. Dava saldırgana veya onun küllî haleflerine[148] ve de tartışmalı olmakla birlikte görüşümüze göre kötüniyetli cüzi haleflere, işçiye, işgörene, vekile karşı açılabilir[149].

1379 *Stark*, kötüniyetli cüzi haleflere, TMK m.982'deki zilyetliğin gaspı davasının yöneltilebileceğini savunurken[150], TMK m.983'teki zilyetliğe saldırıda davanın kötüniyetli cüzi haleflere yöneltilemeyeceğini savunmaktadır[151]. Bu konuda zilyetliğin dava yoluyla korunmasında, ihlalin çeşidine göre ayrım yapmayı uygun bulmamaktayız.

1380 Dava taraflarını sıfatı konusunda gaspta yaptığımız açıklamalara atıfta bulunmakla yetineceğiz.

ee. Hukuki Sonucu

1381 Dava, saldırının sona erdirilmesine ya da sebebinin önlenmesine ve her iki durum için zilyetliğin ihlalinden doğan zararın giderilmesine yönelik olur (TMK m.983 II).

1382 Her iki dava da zilyetliğin ihlalinin, gelecekteki de dahil olmak üzere önlenmesini amaçlamaktadır. Davalar müdahalenin men'i davası (*actio negatoria*) karakterindedir. Söz konusu koruma davasından doğan talepler dava hakkından ayrılamaz[152].

---

147 **NOMER/ ERGÜNE**, s. 42.

148 **STARK**, BK ZGB Art.928, N.10 ff.

149 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.927 N 8; **STEINAUER**, I. N. 341a.

150 **STARK**, BK ZGB Art.927, N.5.

151 **STARK**, BK ZGB Art.928 N.11.

152 **STARK**, BK ZGB Art.928, N.8; **EITEL/ ARNET**, CHK Art.928, N.4.

aaa. Zilyetliğe Saldırı Fiilinin veya Saldırı Sebebinin Önlenmesi Davası

1383 Zilyetliğe saldırının yakın bir gelecekte gerçekleşmesi *beklenmekte olan saldırı tehlikesi* (Begehungsgefahr) veya *tekrarlanması beklenen saldırı tehlikesi* (Widerholungsgefahr) söz konusu olmakla birlikte, saldırı henüz gerçekleşmediğinde önlenme (Unterassung) davası açılabilir. Bu sebeple, saldırının önlenmesi davasını, *gerçekleşmesi beklenen saldırının önlenmesi* davası ve *tekrarlanması beklenen saldırının önlenmesi* olarak ikiye ayırarak incelememiz gerekir.

1384 *Saldırı sebebini önleme davası* (Unterlassungsklage), zilyetliğe henüz bir saldırı olmamasına karşın, zilyetliğe yönelik yakın bir gelecekte meydana gelmesi yüksek olasılıkla muhtemel olan saldırı fiilinin veya saldırı sebebinin önlenmesi için açılır[353]. Örneğin; taşınmaz zilyedi ileride yaşanması muhtemel saldırının engellenmesine yönelik olarak komşusu spor tesisine karşı açabilir.

1385 Zilyetliğe saldırı başlamışsa, saldırı sebebini önleme davası değil, *saldırının sona erdirilmesi davası* açılmasının gerekir. Zilyetliğe saldırı gerçekleşmiş, ancak saldırının tekrarlaması tehlikesi söz konusu ise, sona erdirme davası ile birlikte tekrarlanacak saldırının önlemesi davası açılabilir; birbirinden ayrı da dava edilebilir.

1386 Zilyetliğe yönelik saldırının yakın zamanda meydana gelmesi beklenmiyorsa veya gerçekleşmesi ihtimali yüksek değilse veyahut muhtemel olmayan bir saldırı ise önleme davası kabul edilmez. Zilyetliğe saldırının önlenmesi davası, saldırı henüz başlamamış ancak saldırı ciddi olarak korkutuyorsa söz konusu olur[354].

1387 Saldırının önlenmesi davasında verilecek karar, TBK m.113 hükmü kapsamında düzenlenen yapma veya yapmama borçlarının yerine getirilmesi verilecek karar niteliğinde olduğundan, TBK m.113'teki talebe ve de karara konu edilerek, cebren yerine getirilir[355].

---

[353] **EITEL/ARNET,** CHK Art.928. N.6; **ÜNAL/ BAŞPINAR**. s. 181.

[354] **STARK,** BK ZGB Art.928. N.43.

[355] **STARK,** BK ZGB Art.928. N.40. **EITEL/ARNET,** CHK Art.928. N.5.

bbb. Saldırının Sona Erdirilmesi Davası

1388 Halen sürmekte olan[656] veya en azından zilyetlik durumunun var olduğu hallerde, zilyetliğe devam etmekte olan saldırının sona erdırılmesi (Beseitigung) dava yoluyla talep edilebilir[657]. Zilyetliğe başlamış olan halihazırda var devam eden bir saldırının sona erdirilmesi için dava saldırının sona erdırme davasıdır (Beseitigungsklage). Örneğin zilyedin halihazır kamu yolu inşaatı dolayısıyla yapılan duvar sebebiyle taşınmazdaki yolu kullanamama veya ulaşamama şeklinde zilyetliğinin saldırıya uğraması.

1389 Sona erdirmenin konusu sadece zilyetliğe saldırı fiilinin değil, saldırının sebebinin veya kaynağının (Storungsquelle) sona erdirilmesini de ifade eder[658]. Davanın amacı, sadece saldırıdan önceki zilyetlik durumunun sağlanması değil, saldırı kaynağını ortadan kaldırmaktır[659]. Özellikle işletmeden kaynaklanan zilyetlik saldırıları bakımından bu yaklaşım önem taşımaktadır[660].

1390 Saldırının önlenmesi davasında verilecek karar, TBK m.113 hükmü kapsamında düzenlenen yapma veya yapmama borçlarının yerine getirilmesi verilecek karar niteliğinde olduğundan, TBK m.113'teki şeklinde talebe ve de karara konu edilerek, yerine getirilir[661].

1391 Saldırının sona erdirilmesi davasında verilecek karar, TBK m.113 hükmü kapsamında düzenlenen yapma veya yapmama borçlarının yerine getirilmesinde verilecek karar niteliğinde olduğundan, TBK m.113'teki talebe ve de karara konu edilir. Kararda yapma veya yapmama kararı ola-

---

[656] **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.928, N.5. Zilyet olan kimsenin hakka dayanmak yerine, ivedi bir biçimde devam eden saldırının sonlandırılmasını talep edebileceğine dair karar hakkında bkz. Y. 8. HD. 10.11.2005 T., 2005/6080 E., 2005/7483 K.; "*...Davacı TMK'nın 996 maddesine (MK 909 m.) dayanaraf önceki malikin zilyetlik süresi ile kendisinin zilyetlik süresinin 50-60 yılı bulduğunu açıklayarak tecavüzün men'i isteğinde bulunmuştur. Bu istekten de anlaşılacağı gibi davacı kazanmayı sağlayacak süre zilyet olduğunu ileri sürmektedir. Davacının zilyetliğe vaki müdahalesinin önlenmesini hakka dayanarak istemesi mümkün olduğu gibi, TMK'nın 973 maddesine göre "...şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir..." hükmünden hareketle TMK'nın 982. maddesine göre zilyetliğe vaki müdahalenin önlenmesini isteyebilecektir. Mahkemenin davacıya eda davası açmaya zorlanmasının kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır. Davacının öncelikli isteği tecavüzün önlenmesidir.*"

[657] **BAUR/STÜRNER**, SachenR § 12. Rn.20.

[658] BGE 88 II 252 E.4.

[659] Alman hukukunda hakim olan bu yaklaşım için bkz. **GURSKY**, Staudinger BGB § 1004, N.137 ff.

[660] **STARK**, BK ZGB Art.928, N.40 ff.

[661] **STARK**, BK ZGB Art.928, N.40. **EITEL/ARNET**, CHK Art.928, N.5.

rak cebren yerine getirilir[62]. Zilyetliğe olan saldırıdan doğan zararı, saldırgan gidermekle yükümlüdür (TMK m. 983 II).

ccc. Zilyetliğe Saldırıdan Dolayı Uğradığı Zararın Tazminini Talep

1392 Zilyet, zilyetliğe saldırının sona ermesi veya önlenmesi davası ile birlikte veya ondan ayrı olarak zararının giderilmesini talep edebilir (TMK m. 983 II). Örneğin; engelli birinin sokakta park etmesine ve doktoruna erişimine uygun yol inşaatı yapılmamasından doğan zararın tazmini talep etmesinde olduğu gibi[63]. Tazminat davasının, telafi edici amacı söz konusudur: saldırının zilyedin malvarlığında yarattığı eksilmeyi, gidermeyi amaçlar.

1393 Tazminat davasının diğer davalarla birlikte ileri sürülmesi gerekli değildir; zilyetliği koruyan sona erdirme veya önleme davasından ayrı veya onlardan sonra ileri sürülebilir. Zira tazminat davası, zilyetliği koruyan davalardan bağımsızdır[64].

1394 Katıldığımız hâkim görüş, saldırıdan doğan zararın tazminini, haksız fiilden doğan borç olarak nitelemektedir; bu sebeple saldırganın tazminle sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olması gerekir ve TMK m.49 vd. hükümleri kıyasen uygulanır[65].

1395 Zilyedin fiili hâkimiyetini kaybetmesi sebebiyle doğan kişi, eşya ve malvarlığı zararları tazmin edilir; yeter ki zilyetliğin ihlali sebebiyle doğmuş olsun[66]. *Stark*'a göre saldırı sebebiyle *eşyadan gelecekte beklenen değer kaybı* da giderilmelidir[67].

1396 TMK m.983 II zararın tazmini kendine özgü özel bir sorumluluk sebebi değildir. Saldırıdan sorumlu tutulabilmesi için, saldırganın hukuka aykırı saldırı fiili olmasına ilaveten, TBK m.49'da aranan hukuki olguların, yani saldırı davranışının kusurlu olması ve zarar verici fiil olması ol-

---

[62] **STARK**, BK ZGB Art.928, N.40; **EITEL/ARNET**, CHK Art.928, N.5.

[63] BGE 100 II 326 ff.

[64] **STARK**, BK ZGB Art.928, N.8.

[65] BGE 99 II 28 ff. 33 E.3b; **STARK**, BK ZGB Art. 928, N.46; **EITEL/ARNET**, CHK ZGB Art.928, N.6; **ERNST**, BSK ZGB Art.928, N.12; **STEINAUR**, I. N. 245; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 42; **AYAN**, s. 117.

[66] **STARK**, BK ZGB Art.928, N.47.

[67] **STARK**, BK ZGB Art.928, N.50 f.

gularının da gerçekleşmesi gerekir. Saldırganın kusursuz sorumluluğu söz konusu ise, kusurlu davranış olgusu aranmaz.

1397 TMK m.983 II'deki zararın giderimi, zilyetliğin bağlı bulunduğu haktan hareketle zararın giderimini esas almamaktadır. Burada zilyetlik durumunun ihlalinden doğan zararın giderimi söz konusudur. Zilyet, gasp sebebiyle fiili hâkimiyeti tamamen kaybetmesi sebebiyle uğradığı zararın tazminini talep edebilmelidir. Bu yaklaşımımız normun koruma amacına uygundur. Kanun zilyede hak sahibi olduğu için değil, zilyet olduğu için uğradığı zararının tazminine imkân vermeyi amaçlamıştır. Zilyedin zilyetliğinin varsa dayandığı hakkın ihlali veya hak sahibinin hakkı ihlal sebebiyle de tazminat hakkı saklıdır. Ancak saldırganın kusurunun bulunmaması halinde, zilyet haksız zilyedin iade yükümlülüğü hükümlerine (TMK m.993-995) başvurabilir[64].

f. Dava Hakkının Düşmesi

aa. Genel Olarak

1398 TMK m.984 hükmü, gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkının, zilyedin fiili ve failini öğrenmesinden başlayarak iki ay ve her halde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle düşeceğini düzenlemiştir. Zilyetliğin korunmasının belirli bir süre içinde dava konusu edilebilmesi, korumanın niteliğine uygun olarak geçici özelliğini ortaya koyar.

1399 Zilyedin, zilyetliğinin korunmasını mahkemede dava açarak kullanması zorunlu değildir; zilyedin, gasıba veya saldırgana varması gereken, şekle bağlı olmayan irade açıklaması ile saldırıyı protesto ederek, zilyetliğinin ihlalinin engellenmesini talep edebilmesinin engeli yoktur[65]; ancak her durumda karşı tarafı, gasıbı, geri vermeye veya saldırganın saldırısını sona erdirmeye veya saldırıyı önlemeye zorlayabilecek karar alabilmesi için, TMK m.984 düzenlenen hak düşürücü sürelerde dava açması gerekir.

1400 Zilyetlik hakka dayanıyorsa, hak sahibinin, hukuki olguları söz konusu ise, hakka dayanan taşınır davası (TMK m.939) veya istihkak davası (TMK m.683) açma hakkı saklıdır. TMK m.984 III'deki zilyedin zararının giderilmesi, haksız fiil niteliğinde olduğundan, bu tazminat davaları

[64] HINDERLING, SPR V/1, s.455; STEINEUR, I, N 354.

[65] STARK, BK ZGB Art.929, N 4.

TMK m.72'de düzenlenen zamanaşımı sürelerine tabidir[770]: ceza zamanaşımı süresi saklı olmak üzere, zararın ve failin öğrenilmesinden başlayarak iki yıl; her durumda fiilin işlenmeye başlamasından itibaren en geç on yıl içinde açılması gerekir.

bb. Hak Düşürücü Sürenin Niteliği

1401 Dava süresinin eTMK m.897 uygulandığı dönemde, hükümdeki sürenin zamanaşımı[771] mı yoksa hak düşürücü süre[772] mi olduğu doktrinde tartışma konusu olduğundan ve Yargıtay uygulamasında iki görüşe uygun çelişkili kararlar verdiğinden[773], gerek bu iki aylık sürenin gerek fiil tarihinden itibaren işleyecek bir yıllık sürenin *hak düşürücü süre* olduğu kabul edilerek, yeni TMK m.984 kenar başlığı ve metni buna göre yeniden düzenlenmiştir[774].

1402 Söz konusu sürelere, hak düşürücü nitelikleri gereği, TBK'da düzenlenen zamanaşımına ilişkin sürelerin kesilmesi ve durması hükümleri uygulanmaz[775]. TMK m. 984'te düzenlenen davayı düşüren süreler, hak düşürücü süre niteliğinde olduğundan, yargılamada itiraz olarak her zaman ileri sürülebilir ve hâkim tarafından resen nazara alınırlar[776].

cc. Dava Hakkının Düşme Süresi

1403 TMK m.984 hükmüne göre, gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyedin fiili ve failini öğrenmesinden başlayarak iki aylık kısa süre ve her halde fiilin üzerinden bir yıl süre geçmekle düşer.

---

[770] **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.173; **AYAN**, s.123.

[771] eTMK m.897, başlık ve madde metninde müruruzaman kelimesini kullanmış idi.

[772] **STARK**, BK ZGB Art.929, N.10; **EITEL/ ARNET**, CHK ZGB Art.929, N.2; **TEKİNAY/ AKMAN/ BUCUOĞLU/ ALTOP**, s. 128; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY- ÖZDEMİR**, s. 83; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s.188; **REİSOĞLU**, s.74; **ERTAŞ**, s. 51; **GÜRSOY**, s. 79.

[773] Bkz. Y., HGK., 20.01.1968 T. 6-10/13. Y., 8. HD., 11.10.1983 T., 8308/9377 (YKD, 1983/11, s.1632).

[774] Bkz. TMK m.984'ün madde gerekçesi **ANTALYA**, TMK, s. 737. TMK'nın yürürlüğe girmesi ile Yargıtay'ın hak düşürücü süre ile ilgili verdiği karar için bkz. "*TMK'nın 984. maddesi hükmüne göre, gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkı, zilyedin fiili ve failini öğrenmesinden başlayıp iki ay ve herhalde bir yıl geçmekle düşer. Temyiz incelemesine konu davada dinlenen taraf tanıkları davalıların zilyetliğinin 10-15 yılı aştığını açıkladıkları gibi, dava dilekçesinde dahi davalıların 7-8 yıldır rızalı yerden gelip geçtikleri belirtilmiştir. Bu durumda davacının davalı tarafın zilyetlik olgusunu çok daha önce öğrendiğinin kabulü gerekir. O halde zilyetliğin korunması davası süresinde de açılmamıştır. Davanın reddine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ve gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru değildir.*". Y. 8. HD. 19.01.2012 T., 2011/1968 E., 2012/165 K.

[775] **STARK**, BK ZGB Art.929, N.10.

[776] **ERNST**, BSK ZGB Art.929, N.4; **DOMEJ**, KurzKomm ZGB Art.928, N.3.

aaa. Dava Hakkının Düşeceği Kısa Süre

1404 eTMK m.897, gasp ve saldırı öğrenildiği halde derhal dava açılmasını düzenlediği halde, TMK m.984 gasp ve tecavüz halinde *dava hakkının, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren iki ay içinde* düşeceğini düzenlemiştir. Zilyetliğin tespiti talebi kısa ve uzun süreyi kesmez. Zira zilyetliğin korumasından yararlanmak için talep yeterli değildir; dava açılması zorunludur. Eğer zilyetliğin ihlalinin tespiti talep edilmişse, tespit talebi tarihinin mi yoksa tespit kararının tarihinin mi esas alınacağı tartışılabilir. Davalı aksini ispat edemediği sürece, tespit kararını talep eden zilyede tebliğ tarihi esas alınmalıdır.

bbb. Dava Hakkının Düşeceği Uzun Süre

1405 TMK m.984 hükmü, gasp ve saldırıdan dolayı dava hakkının, *her halde fiilin üzerinden bir yıl geçmekle* düşeceğini düzenlemiştir[1777]. Dava açma süresi, zilyetliğin ihlalinin, saldırının veya gasp fiilinin sona erdiği andan itibaren işlemeye başlar. Eğer saldırı tekrarlanan nitelikte ise her saldırıda süre baştan işlemeye başlar.

1406 Davanın düşeceği sürenin hesaplanmasında zilyetliği ihlal edilen bunu öğrenmese de süre ihlal fiilinden itibaren işlemeye başlar.

II. ZİLYETLİĞİN İDARİ YÖNDEN KORUNMASI

1407 Zilyetliğin idari yönden korunması, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun[1778] ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik[1779] hükümlerinde düzenlenmiştir.

A. 3091 Sayılı Kanunun Uygulama Alanı: Taşınmazlar

1408 Zilyetliğin idari yönden korunması, sadece taşınmazlara ilişkindir. Bu yönüyle TMK daha dar bir zilyetlik koruması gerçekleştirir. 3091 sayılı Kanun, TMK m.704'te taşınmaz tanımından farklı daha geniş bir taşınmaz kavramını benimsemiştir[1780].

[1777] Karş. BGB § 864.

[1778] R.G. Tarihi: 15/12/1984 Sayı: 18606. Yayımlandığı Düstur: Tertip 5, Cilt: 24, s. 110.

[1779] R.G. Tarihi: 31.07.1985 Sayısı: 18828.

[1780] ÜNAL/BAŞPINAR, s. 158; ERTAŞ, s.52.

1409 TMK'nın benimsediği zilyetliği ihlalde gasp ve saldırı kavramından farklı kapsamda ve onunla uyumlu olmayan, zilyetliği ihlalde tecavüz ve müdahale kavramını benimsemiştir[81]. Aşağıda 3091 sayılı Kanunun benimsediği, zilyetliğe tecavüz ve müdahale kavramları üzerinde durulacaktır.

1410 Zilyetliğin korunması temel olarak kamu taşınmazlarının korunmasını konu almaktaysa, koruma özel hukuk konusu taşınmazları da kapsamaktadır. Halen üzerinde zilyetlik kurulmamış kamu mallı nitelikteki taşınmazlarla devletin hüküm ve tasarrufunda olan sahipsiz yerlerde uygulanır. 3091 sayılı Kanun gerçek ve tüzel kişilerin zilyet[82] bulunduğu taşınmaz mallarla[83], kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait[84] veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara[85] yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa dair güvenliği ve kamu düzenini sağlar. (Kanun m.1 - Yönetmelik m.3)[86].

---

[81] **ERTAŞ**, s.53; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 158.

[82] Zilyetlik, taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere olanları fiilen hakimiyet altında bulundurmadır. Zilyet, taşınmaz maldan bir yarar sağlamak üzere o taşınmaz malı fiilen hakimiyeti altında bulunduran gerçek ve tüzel kişilerdir. (Yönetmelik m.10)

[83] Yönetmelik m. 7 hükmüne göre, *' Taşınmaz mal; arz üzerinde sabit olan tarla, bağ, bahçe, arsa, orman, ağıl, apartman, dükkan, fabrika, otel gibi bütün arazi, bina ve madenlerdir. Taşınmaz mala sahip olan o malın altına ve üstüne de sahiptir. Taşınmaz mallar 3 gruba ayrılır. a) Arazi, arazinin tamamlayıcı parçası sayılan bina ve ağaçlar, arz üzerinde kaynaklar, akarsular. b) Tapu siciline müstakil ve daimî olmak üzere kayıtlı ayni haklar (üst hakkı, kaynak hakkı, irtifak hakkı gibi). c) Yer altındaki madenler*'.

[84] Devlete ait taşınmaz mallar, tapuda Hazine adına kayıtlı olanlar ile tescil edilebilir nitelikte Hazineye ait taşınmaz mallardır (Yönetmelik m.8).

[85] Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar, herkesin istifadesine açık olan denizler, goller, nehirler, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler ve dağlar gibi sahipsiz şeyler ile Devlet veya bir kamu hukuku tüzel kişisi tarafından umumun yahut bir kısım halkın yararlanmasına terk ve tahsis edilen umumi yollar, köprüler, parklar, meydanlar, mer'alar, yaylak ve kışlaklar gibi menfaati umuma ait olan taşınmaz mallardır. (Yönetmelik m.9)

[86] 3091 sayılı Kanuna gore özel kanun durumunda olan 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile diğer özel kanunlar kapsamına giren taşınmazlara tecavüz veya müdahalelerin olması halinde, ilgililerin başvurması ya da vali veya kaymakamın tecavüz veya müdahaleyi öğrenmeleri halinde 3091 sayılı Kanuna göre soruşturma yaptırarak tecavüz veya müdahale önlenmekle birlikte, ayrıca ilgili kanunlarına göre de gereği yapılmak üzere ait olduğu kamu kuruluşlarına bildirir (Yönetmelik m.5). Bir taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişilerin bir arada zilyet oldukları müşterek veya iştirak halinde mülkiyet hallerinde, yani anlaşmazlığa düşenlerin taşınmazda hissedar olmaları halinde, o taşınmazı fiilen tasarruf edenin zilyetliğinin hem diğer hissedarlara hem de üçüncü şahıslara karşı korunması esastır. Bu gibi durumlarda "müşterek hissedarlıktan" soz edilerek 3091 sayılı Kanunun olaya uygulanmaması yoluna gidilemez. (Yönetmelik m.13/I)

1411 Bu Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden açıkça ve kesinlikle anlaşılan başvurular, yerinde soruşturma yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir (Kanun m.5 III)[867].

B. Korumanın Amacı

1412 Zilyetliğin idari korunmasındaki amaç, sadece şahısların kendiliğinden hak almalarını önleyici ve asayişin bozulmasını sağlayıcı tedbir almaktır[868]. 3091 sayılı Kanun, emniyet ve asayişi, tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya yönelik bir kanun olup, bu Kanuna göre verilen kararlar mülkiyet yönünden bir hak sağlamayan, sadece bir idari kolluk tedbiri niteliğindeki kesin kararlardır. Taşınmaz mal üzerinde fiili hakimiyet ve tasarrufu esas alarak zilyetliği korur (Kanun m.1, Yönetmelik m.4).

1413 Taşınmaz mal üzerindeki anlaşmazlığın ortaklıktan veya kira sözleşmesinden kaynaklanmış olması idarenin taşınmaza eylemli olarak kimin veya kimlerin zilyet olduklarını araştırarak karar vermesine engel değildir. Ortaklığın veya kira sözleşmesinin sona erip ermediği, bulunduğu aşamada geçerliliği olup olmadığı adli yargının çözümleyeceği üstün hak iddiası niteliğindedir (Yönetmelik m. 14).

C. Taşınmaz Zilyetliğine Tecavüz ve Müdahaleye Karşı İdari Korunma

1. Tecavüz ve Müdahale Kavramları

1414 Taşınmaz zilyetliğine yapılan saldırı çeşidi olarak tecavüz ve müdahale Yönetmelikte aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

1415 Tecavüz: taşınmaz malı zorla veya zilyedinden habersiz olarak işgal etmek veya ele geçirmek veya taşınmazın aynında değişiklikler meydana getirmektir (Yönetmelik m. 11 I).

1416 Müdahale; zilyedin taşınmaz mal üzerindeki mutlak hâkimiyetini kısmen veya tamamen ihlal etmektir (Yönetmelik m.11 II).

---

[867] Anlaşmazlık konusunun 3091 sayılı Kanunla çözümlenmesi mümkün olmayan hukuki mahiyette bulunması, başvurunun süresi içinde yapılmaması, başvuruda bulunanın yetkili olmaması veya başvurunun yetkili makama yapılmamış olması gibi bu Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden açıkça ve kesinlikle anlaşılan hallerde, başvurular mahallinde soruşturma yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir (Yönetmelik m.21).

[868] AYM., 27.03.1984 T., 3/4 (RG. 25.09.1984 T., sa.18526)

2. Tecavüz ve Müdahale Sayılan Haller

1417 Yönetmelik m.12 hükmü, aşağıdaki olay ve durumları 3091 sayılı Kanunun uygulanmasında taşınmaz mala yapılmış tecavüz veya müdahale saymıştır:

a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak.

b) Ekim ve dikimde bulunmak.

c) Bir hak iddia ederek tarla veya bahçelerdeki mahsulü biçmek, toplamak.

d) Başkasının taşınmaz malına taş, toprak, ağaç, gübre ve benzeri şeyleri bırakmak suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak.

e) Sulama veya içme sularından, su kuyularından, sarnıçlarından, suyollarından, su borularından ve arklarından yararlanmayı engellemek.

f) Başkasının arazisi üzerine su geçirmek üzere ark açmak.

g) Temel açmak, hendek kazmak, bina yapmak.

h) Yukarıda sayılanlara benzer diğer davranışlarda bulunmak.

3. Damlı Yapının Fuzuli İşgaline Koruma

1418 Konut, dükkân, depo ve ahır gibi damlı yapılarda bu Kanunun uygulanabilmesi taşınmazın fuzulen işgal[25] edilmiş olmasına bağlıdır (Yönetmelik m.14).

D. Korumaya Yetkili İdari Makamın Yetki ve Görevi

1419 Taşınmaz malın merkez ilçesi sınırları içinde bulunması halinde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde bulunması halinde ise kaymakamlar tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar vermeye yetkilidirler. Vali, bu yetkisini vali yardımcılarından ancak birine devredebilir (Kanun m. 2- Yönetmelik m.16).

---

[25] Fuzuli işgal, bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselerle hukuki bir bağlantı kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden girme durumudur. (Yönetmelik m.15/II)

E. İdari Makama Başvuru

1. Genel Olarak

1420 Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için, yetkili makamlara başvurmaya, o taşınmaz malın zilyedi, zilyet birden fazla ise içlerinden biri yetkilidir (Kanun m.3 I – Yönetmelik m. 17 I).

1421 Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzelkişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş ve tüzelkişinin yetkilisi tarafından yapılır (Kanun m.3 II – Yönetmelik m.17 II

1422 Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de yetkili makama başvuruda bulunabilir (Kanun m.3 III – Yönetmelik m. 17 III). Köy tüzel kişiliğine ait tapulu veya tapusuz her nevi taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalelerde köyün kanuni temsilcisi olan köy muhtarının başvurması esastır. Ancak o köyde oturan köy halkından herhangi biri tarafından yapılan başvurular üzerine de yetkili makam tarafından soruşturma yaptırılır (Yönetmelik m.18).

1423 Vali veya kaymakam görev alanları içinde bulunan kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede bulunulduğunu öğrendiklerinde, soruşturmayı doğrudan doğruya yaptırırlar ve sonucu karara bağlarlar (Kanun m.3 IV – Yönetmelik m.19).

2. Başvuruda Bulunma Süresi

1424 Yetkililerin; tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten altmış gün içinde, yetkili idari makama başvuruda bulunmaları gerekir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz (Kanun m.4 I - Yönetmelik m.20 I).

1425 Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde süre aranmaz (Kanun m.4)[90].

[90] Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara bu Kanunun yürürlüğe girdiği 15.12.1984 tarihinden sonra yapılan tecavüz veya müdahalelerde başvuru için süre aranmaz (Yönetmelik m.20/II).

3. Soruşturma ve İnfaz Giderleri

1426 Soruşturma ve infaz memurları ile infaz memuruna teknik yönden yardımcı olarak görevlendirilecek memurların yevmiye ve taşıt giderleri, başvuruda bulunanlar tarafından maliye veznesine yatırılır (Kanun m.17)[91].

4. Başvuru Sahibinin Başvurusundan Vazgeçmesi

1427 Başvuru sahibinin, başvuru tarihinden karar verilinceye kadar geçen süre içinde başvurusundan herhangi bir sebeple vazgeçtiğini yazılı veya elektronik dilekçe ya da sözlü olarak bildirmesi halinde, sözlü ifadesi yazılı hale getirilerek, yetkili makamın onayı ile dosyası işlemden kaldırılır.

1428 Bu durumda soruşturma için yatırdığı paralar, yapılan masraflar üzerinde kalmak üzere başvuru sahibine geri verilir (Yönetmelik m.27).

F. Soruşturma

1. Soruşturmacı Tayini

1429 Başvuru üzerine, karar vermeye yetkili kişiler veya bunların görevlendireceği bir veya birkaç memur tarafından yerinde soruşturma yapılır[92] (Kanun m.5).

---

[91] **Soruşturma ve infaz giderleri – Yönetmelik m. 53** Soruşturma ve infaz memurları ile gerektiğinde görevlendirilecek teknik eleman ve yardımcı personelin yevmiyeleri, taşıt ücreti şikayetçi tarafından sağlanmayacaksa yolun niteliği, iklim şartları, mesafesi ve bekleme süresi dikkate alınarak tahmin olunacak taşıt giderleri başvuruda bulunanlar tarafından maliye veznesine yatırılır.

Kararın ne yolda verileceği başlangıçta belli olmayacağından, infazla ilgili giderler karar verildikten sonra da yatırılabilir. Başvuru sahibinin peşin yatırmakta ısrar etmesi halinde, teknik eleman görevlendirilmesi ihtimali de dikkate alınarak yevmiyeler ile taşıtı kendisi sağlamayacaksa tahmini taşıt gideri maliye veznesine yatırılır. Red kararı verilmesi halinde infaz gideri olarak yatırılan para başvuru sahibine geri verilir ve bu husus kararda belirtilir.

İnfaz için yapılan harcamalar karar veren makam tarafından onaylanarak karara eklenir ve soruşturma giderleri ile birlikte mütecavizden tahsil edilerek başvuru sahibine ödenmek üzere icra dairesine gönderilir.

Soruşturma ve infaz için taşıtı başvuruda bulunanın sağlaması halinde, taşıt için ödenen ücretle ilgili olarak taşıt sahibinden senet alınıp dosyasına konmakla birlikte, ödenen ücretin mahalli rayice uygunluğu konusunda kuşkuya düşüldüğü takdirde durum belediyeden, ticaret odasından veya şoför ve otomobilciler derneklerinden soruşturulur. Fazla ödemede bulunulduğunun anlaşılması halinde, fazla ödenen miktar masraf olarak gösterilmez ve bu husus kararda belirtilir.

Taşıtın kamu kuruluşlarına, başvuru sahibine veya başvuru sahibinin bir yakınına ait olması ve bu nedenle bir ücret ödenmemesi halinde de soruşturma ve infaz memurları tarafından taşıt ücreti mahalli rayice göre belirlenir ve kararda gösterilir.

Taşıt ücretinin önceden yatırılmış olması nedeniyle taşıtın soruşturma veya infaz memuru tarafından sağlanması halinde, karar vermeye yetkili makamın gerek görmesi üzerine, taşıt için ödenen ücretin mahalli rayice uygunluğu araştırılır.

[92] **Yönetmelik m.22** Başvuru dilekçesini alan vali, yetkili vali yardımcısı veya kaymakam tecavüz veya müdahalenin olup olmadığını yerinde doğrudan soruşturabileceği gibi, bu amaçla devlet

1430 Soruşturmayı yapan kişilere gerektiğinde teknik eleman ve yardımcı verilir.

2. İlgililere Tebligat

1431 Soruşturmanın yapılacağı, kararın yerine getirileceği yer, tarih ve saat taraflara tebliğ edilir[91]. Şikayetçinin, varsa kanuni vekilinin veya dilekçesinde ismini belirttiği temsilcisinin; başvuru, 3'üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılmış ise köy muhtarı veya ihtiyar meclisi üyelerinden birinin; soruşturma yapılması ve kararın yerine getirilmesi sırasında taşınmaz malın başında bulunması zorunludur. Mütecavize tebligat yapılamaması halinde soruşturmanın yapılacağı veya kararın yerine getirileceği yer, tarih ve saat 3 gün önceden alışılmış usullerle taşınmaz malın bulunduğu köy veya beldede ilan edilir. Mütecaviz gelmezse soruşturma ve kararın yerine getirilmesi yokluğunda yapılır[92] (Kanun m.8).

1432 Yetkili makamların, talebin esastan veya süreden reddine ilişkin karar ve işlemleri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere duyurulur.

---

memurlarından bir veya işin mahiyetine göre birkaçını soruşturma yapmak üzere görevlendirebilir.

Taşınmazın ölçülmesi, sınırlarının belirlenmesi, krokisinin çizilmesi ve tapu uygulaması gibi hususlarda yardımcı olmak üzere soruşturma memurlarına eleman verilebilir.

Adli ve askeri personel ile güvenlik kuvvetlerinin amir ve memurları soruşturma ile görevlendirilemez.

[92] **Yönetmelik m.24** Kanun, soruşturmanın 15 gün içerisinde yaptırılarak karara bağlanmasını öngördüğünden, soruşturma emrini alan memur, soruşturmanın yapılacağı yer, gün ve saati, tarafların tanık ve diğer delilleri ile hazır bulunmaları, aksi halde sonradan tanık dinletemeyecekleri hususunu her türlü imkândan yararlanarak tebliğ eder ya da köy veya mahalle muhtarları vasıtasıyla tebliğ ettirir ve tutanağını dosyasına koyar.

Taraflara tebligat yapılmadan veya 25'inci maddede belirtilen ilan yaptırılmadan mahallinde soruşturmaya başlanamaz.

Zorunlu ve acele hallerde bu konu ile ilgili bildirimler, Tebligat Kanunu ve Tüzüğü esaslarına göre valilik veya kaymakamlık emri ile yollukları ödenmek suretiyle güvenlik kuvvetlerine yaptırılır.

Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde köy halkından biri tarafından başvuruda bulunulmuş ise, soruşturma sırasında muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin mahallinde hazır bulunması zorunlu olduğundan, yukarıdaki usullere göre bunlara da gerekli tebligat yapılır.

[93] **Yönetmelik m.25** Adresinin tespit edilememesi, gösterilen adreste bulunamaması gibi nedenlerle mütecavize tebligat yapılamaması halinde soruşturmanın yapılacağı yer, tarih ve saat soruşturma memuru tarafından 3 gün önceden alışılmış usullerle taşınmaz malın bulunduğu köy veya beldede ilan ettirilir ve durum tutanakla belgelenir. Bu duyuruya rağmen mütecavizin soruşturma mahalline gelmemesi halinde ilân tutanağı dosyasına konularak soruşturma mütecavizin yokluğunda yapılır.

3. Soruşturma

1433 Soruşturma memuru, taşınmaz malın bulunduğu yerde sırasıyla önce şikayetçinin, sonra mütecaviz olduğu iddia edilen kişi veya kişilerin, daha sonra tarafların tanıklarının ve gerek gördüğünde doğrudan seçeceği bilirkişiler ile ilgilisine göre Hazine, özel idare ve belediye temsilcilerinin, köy veya mahalle muhtarı ve ihtiyar kurulu üyelerinin ifadesini alarak:

a) Taşınmaz malın niteliğini ve bütün sınırlarını,

b) Taşınmaz malı fiilen tasarruf eden zilyedin kim veya kimler olduğunu, ne zamandan beri ve ne suretle zilyet olduğunu,

c) Mütecavizin kim veya kimler olduğunu,

d) Taşınmaz mala mütecaviz veya mütecavizler tarafından ne şekilde ve ne zaman tecavüz veya müdahale edildiğini,

e) Tecavüz veya müdahalenin bu taşınmazın hangi kısmına veya miktarına yapıldığını,

f) Başvuru sahibinin bu tecavüzü veya müdahaleyi hangi tarihte öğrendiğini, tespit eder (Yönetmelik m.28).

1434 Bu amaçla taraflarca gösterilen tapu ve her türlü belgeleri inceler, araziye uygunluğunu araştırır.

4. Şahitlerin Dinlenmesi ve Karar

1435 Soruşturma memuru, tarafların şahitlerini dinledikten sonra gerekli gördüğü takdirde tarafsız kişileri ve ilgisine göre hazine, özel idare ve belediye temsilcilerini, köy muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerini de dinleyebilir. İfadeler, Ceza Muhakemesi Kanunundaki hükümler dairesinde yeminli olarak alınır (Kanun m.6).[55]

---

[55] **Yönetmelik m.30:** Tanıkların ve bilirkişilerin ifadeleri tek tek alınır. İfadeler alınırken hazır bulunan diğer tanıklar ve bilirkişiler tanığın söylediklerini duyamayacak şekilde uzaklaştırılır.

İfade alınmasına başlanmadan önce tanıkları tanıyıp tanımadıkları ve anlaşmazlık konusu hakkında bilgileri olup olmadığı sorularak gerekli açıklamalarda bulunur. Soruşturmanın amacının zilyedi belirlemek olduğu, mülkiyet anlaşmazlıklarının bu soruşturmanın kapsamı dışında kaldığı anlatılır.

Tanık ifadeleri ile bilirkişilerin görüşleri 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yeminli olarak, başvuru sahibinin ve mütecavizin ifadeleri yeminsiz olarak alınır.

5. Kroki Çizilmesi

1436 Soruşturma sırasında soruşturma memuru veya görevlendirilmiş ise teknik eleman tarafından taşınmaz malın mevkii, yönleri sınırları ve tecavüz veya müdahale edilen kısmı çizilerek basit bir kroki üzerinde gösterilir. Krokının altında düzenlendiği tarih ile düzenleyenin kimlığı ve imzası bulunur (Yönetmelik m.29).

6. Soruşturma Süresi

1437 Soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanarak karara bağlanır.

7. Tarafların Anlaşması

1438 Mahallinde soruşturmanın başlamasından karar verilinceye kadar geçen süre içinde tarafların aralarında anlaşmaları halinde, buna ilişkin ifadelerin bulunduğu bir anlaşma tutanağı düzenlenir. Tutanakta anlaşmanın hangi şekil ve şartlarda yapıldığına değinilmez.

1439 Anlaşma tutanağı dosyasına bağlanarak herhangi bir karar verilmeksizin yetkili makamın onayı ile dosya işlemden kaldırılır ve maliye veznesine yatırılıp da sarf edilmeyen paralar başvuru sahibine geri verilir.

1440 Kamu idareleri, kamu kurumları, kamu kuruluşları ile köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde tarafların anlaşması söz konusu olamaz (Yönetmelik m.32).

8. Soruşturma Evrakı ile Fezlekenin Yetkili Makama Verilmesi

1441 Soruşturma memuru, soruşturma bittikten sonra soruşturma evrakındaki bilgiler ile şikayetçi, mütecaviz ve tanık ifadelerinin, bilirkişilerin görüşlerinin özetlerinin bulunacağı bir fezleke düzenler. Fezlekede bu ifade ve görüşleri ve diğer delilleri değerlendirerek durumun tartışmasını yapar ve verilecek karara esas olacak görüşünü belirterek fezlekeyi soruşturma evrakı ile birlikte en kısa zamanda valilik veya kaymakamlığa verir (Yönetmelik m.33).

Tanıklar ayrı ayrı ve tanıklıktan önce yemin ederler. Yemin: "Bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim" şeklinde olur.

Bilirkişiler görüşlerini söylemeden veya raporunu vermeden önce: "Tarafsız ve tamamen ilim ve fenne uygun olarak görüşünü açıklayacağına vicdanı üzerine" yemin ederim.

Yönetmelik m.31: Daha önce taraflara tanık ve diğer delilleri ile birlikte soruşturma yapılacak yerde hazır bulunmaları hususu tebliğ edilmiş olduğundan, ilgililerin tanıklıklarını getiremedikleri ve sonradan dinletmek istedikleri yolundaki istek ve iddiaları kabul edilmez.

1442 Karar vermeye yetkili makam, soruşturma evrakı üzerinde en kısa zamanda gerekli incelemeyi yapar. Eksiklikler var ise evrakı soruşturma memuruna vererek tamamlattırır. Dosyadaki bilgilere göre tecavüz veya müdahalenin önlenmesine veya talebin reddine karar verir (Yönetmelik m.35).

1443 Kararlarda, taşınmaz mal üzerinde üstün sayılabilecek bir hakkı olduğunu iddia edenlerin yargı yoluna başvurması gerektiği belirtilir.

1444 Talebin reddine ilişkin kararlarda soruşturma giderlerinin şikayetçinin üzerinde kalacağı, tecavüzün önlenmesine ilişkin kararlarda ise soruşturma ve infaz giderlerinin mütecavizden icra yolu ile tahsil edilerek şikayetçiye ödeneceği belirtilir.

G. Karar

1445 Başvuru tarihinden itibaren soruşturmanın en kısa zamanda yapılarak kararın 15 gün içerisinde verilmesi zorunludur (Yönetmelik m.36). Başvuru sırasında, taraflar arasındaki taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilmiş veya anlaşmazlık dava konusu yapılmış ise bu Kanun hükümleri uygulanmaz (Kanun m. 14/I). Bu Kanuna göre idari makam tarafından verilmiş bir önleme kararı varken, taraflarca taşınmaz mal anlaşmazlığına ilişkin dava açılmadan adli mercilerce ihtiyati tedbir kararı verilemez (Kanun m. 14/II). Yürütmenin durdurulmasını düzenleyen 3091 sayılı Kanunun m. 13 hükmü, Anayasa Mahkemesi'nin 03.06.2010 tarihli 2008/77 esas no.lu ve 77 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

1446 3091 sayılı Kanuna göre verilen kararlar idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir. Ancak, açık olan yazı ve hesap hataları karar veren yetkili makamca kendiliğinden düzeltilir. Taşınmaz mal üzerinde üstün sayılabilecek bir hakkı olduğunu iddia edenlerin yargı yoluna başvurması gerektiği kararda belirtilir (Kanun m. 7)[96].

H. Anlaşmazlığın Dava Konusu Olması

1447 Başvuru sırasında, taraflar arasındaki taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında mahkemece bir ihtiyati tedbir kararı verilmiş veya anlaşmazlık

[96] **Yönetmelik m.37:** 3091 sayılı Kanuna gore verilen kararlar idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir. Yetkili makam verdiği bu karardan dönemez, kararı kaldıramaz ve değiştiremez. Bu kararlar hiyerarşik denetime tabi tutularak üst makamlarca da kaldırılamaz, değiştirilemez. Tarafların kararın düzeltilmesine ilişkin talepleri dikkate alınmaz. Ancak verilen kararın esasına etkisi olmayan açık ve belirgin yazı ve hesap hataları gibi maddi hatalar kararı veren makamca düzeltilir.

dava konusu yapılmış ise 3091 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz (Yönetmelik m.34).

1448 Soruşturma memuru soruşturma öncesinde, soruşturma sırasında ve gerek görürse yetkili makamın emri ile soruşturma sonrasında taşınmaz malla ilgili anlaşmazlığın taraflar arasında Medeni Kanun'a göre mülkiyet hakkına dayalı bir müdahalenin men'i veya zilyetliğin ihlali nedeniyle açılmış bir tecavüzün refi davasına konu olup olmadığını, taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında mahkemelerce verilmiş bir ihtiyati tedbir kararı bulunup bulunmadığını araştırır.

1449 Bu tür bir davanın açılmış olduğunun veya bir ihtiyati tedbir kararının verilmiş bulunduğunun anlaşılması halinde soruşturma hangi aşamada ise işlemler durdurulur ve bu Kanuna göre karar verilemeyeceği gerekçesi ile birlikte şikayetçiye yazılı olarak duyurulur. Mahkemeye yapılan taşınmaz malla ilgili başvuru Medeni Kanun'a göre müdahalenin men'i veya tecavüzün refi talebi dışında ise bu durum idarenin soruşturma yapmasına ve karar vermesine engel değildir. 3091 sayılı Kanuna göre idari makam tarafından verilmiş bir önleme kararı varken, taraflarca taşınmaz mal anlaşmazlığına ilişkin dava açılmadan adli mercilerce ihtiyati tedbir kararı verilemez.

I. Kararın Uygulanması: İnfaz

1. Genel Olarak

1450 Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar, karar vermeye yetkili amirce görevlendirilecek infaz memuru tarafından, taşınmaz malın yerinde ve o andaki durumu ile zilyedine, tüzelkişiliğe veya kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşlarına teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir (Kanun m.9).

1451 Karar gereğinin, kararın infaz memuruna geldiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur.

1452 Karar vermeye yetkili makamın gerekli göreceği durumlarda, infaz memuruna teknik yönden yardımcı olmak üzere yeteri kadar memur görevlendirilir.

1453 Mahallin en büyük mülki idare amirinin yazılı emri ile güvenlik kuvvetlerince gerek soruşturma gerekse kararın yerine getirilmesi sırasında mahallinde, gerekli önlemler alınır.

2. İnfaz

1454 İnfaz, üzerinde anlaşmazlık bulunun taşınmaz malın bulunduğu yerde, mütecavizin taşınmaz mal üzerindeki tecavüz veya müdahalesi men edilerek taşınmaz malı o andaki durumu ile zilyedine teslim etmek suretiyle yapılır (Yönetmelik 42).

1455 Bu amaçla, infaz memuru önceden tespit ve taraflara tebliğ edilen gün ve saatte, görevlendirilmiş ise teknik elemanlar ve güvenlik görevlileri ile birlikte taşınmaz malın bulunduğu yerde hazır bulunur. Tarafların gelip gelmediğini kontrol eder. mütecavizin gelmemesi halinde durumu tutanağa geçirerek infaz sırasında hazır bulunmak üzere yöre halkından iki kişi seçer. İnfazı güçleştirecek veya engelleyecek bir durum olması halinde güvenlik kuvvetlerinin gerekli önlemleri alarak güvenliğin sağlanmasından sonra infaz işlemine başlar.

1456 Yetkili makamca verilen kararı okur ve kararın birer örneğini taraflara vererek gerekirse kararın mahiyeti hakkında açıklamalarda bulunur. Mütecavizin tecavüzü veya müdahalesi defedilerek taşınmaz mal mahallinde zilyet veya zilyetlere teslim edilir.

1457 İnfaz mahallinde hazır bulunan mütecaviz veya vekilinden, bunlar yoksa aile efradından veya işçilerinden reşit olan kişilerden taşınmaz malı açması istenir, gerekirse zorla açtırılır. Bunların mümkün olmaması halinde, infaz memuru tarafından tutanağa geçirilmek suretiyle kilit ve her türlü tertibin kırılarak açtırılması temin edilir.

1458 Tecavüz ve müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararın uygulanmasında, kilitli ve kapalı taşınmaz malların açılması zorunludur. Gerekirse bu yerler zorla açtırılır; kilit ve her türlü tertipler kırılabilir. Üzerindeki tecavüz ve müdahale men edilen taşınmaz mal içindeki mütecavize ait eşyanın boşaltılmasında durumun gerektirdiği tedbirler alınır (Kanun Ek Madde 1).

1459 İnfaz sırasında mütecaviz, anlaşmazlık konusu taşınmaz mal üzerinde üstün bir hakkı bulunduğunu ileri sürse bile, kararda da belirtilmiş olduğu üzere yargı yoluna başvurması gerektiği bir kez de sözlü olarak kendisine duyurulur.

1460 Üzerindeki tecavüz veya müdahale men edilen taşınmaz mal içinde bulunan mütecavize ait eşya çıkarılarak mütecavize, vekiline veya bunlar hazır değilse mütecavizin aile efradından veya işçilerinden reşit bir kişiye teslim edilir. Bunlardan hiçbirinin bulunmaması halinde, anılan eşya

yed'i emin olarak zilyedin uhdesinde muhafaza altına alınır ve infaz memurunca mütecavize hemen tebligat yapılarak; eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değilse otuz gün içinde eşyayı teslim alması, aksi halde eşyanın açık artırma yolu ile satılacağı bildirilir. Verilen süre içinde teslim alınmayan eşya; kaymakamın, vali veya yetkili vali yardımcısının emriyle görevlendirilen en az bir memur veya gerekirse bilirkişiler tarafından yapılacak bedel takdiri ve ilanı takiben açık artırma yolu ile satılarak muhafaza ve satışla ilgili bütün giderler karşılanır. Artan para, mütecaviz hesabına Ziraat Bankasına yatırılır ve durum kendisine tebliğ edilir. Bozulması ihtimali bulunan eşya, tebligat aranmaksızın, miktar tespiti ve bedel takdiri yapıldıktan sonra satılır (Kanun Ek Madde 2).

1461 Taşınmaz mala mütecavizin ikinci defa veya onun yararına başkaları tarafından bilerek yapılacak tecavüz veya müdahalenin suç teşkil edeceği ve Kanunun 15'inci maddesi uyarınca cezalandırılacağı belirtilir ve infaz tutanağı düzenlenerek imza altına alınır.

3. İnfazın Ertelenemeyeceği

1462 Karar verildikten sonra tarafların herhangi bir nedenle infazın durdurulması ya da ertelenmesi yolundaki talepleri dikkate alınmaz (Yönetmelik m.44). Karar verildikten sonra tarafların aralarında anlaşmış olmaları infazın yapılmasına engel değildir. Ancak, başvuru sahibinin, aralarında anlaşmış olduklarından bahisle infaz giderlerini yatırmaması halinde durum tutanakla tespit edilir ve kararın ilgililere tebliği ile yetinilir.

4. Taşınmaz Mal Üzerindeki Ekim, Tesis ve Değişiklikler

1463 Tecavüzü veya müdahalesi önlenen kişi, taşınmaz mal üzerinde vücuda getirdiği her türlü ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak genel hükümler dairesinde yargı yoluna başvurabilir (Kanun m.10).

5. İkinci ve Daha Sonraki Tecavüzler

1464 Taşınmaz mala aynı mütecaviz tarafından ikinci defa veya onun yararına başkaları tarafından bilerek ilk defa tecavüz veya müdahalelerle ilgili başvurularda da birinci başvuruda olduğu gibi soruşturma yapılır ve sonucu karara bağlanır (Kanun m.12). Tecavüz veya müdahale varsa 9'uncu madde hükümlerine göre karar uygulanır, her iki kararla ilgili dosya, karar vermeye yetkili makamlarca, 15. maddeye göre işlem yapılmak üzere adli mercilere gönderilir.

§ 9. ZİLYETLİĞİN HAKKIN OLGUSU OLARAK KORUNMASI

I. GENEL OLARAK

A. Yasal Düzenleme

1465 Zilyetliğin hukuku durum olarak düzenlenmesi, özellikle korunması yanında, zilyetliğin hakkın olgusu olarak hukuki sonuç bağlanması ve korunması söz konusudur.

1466 Toplumsal yaşam ve ticari ilişkilerde, zilyetliğin temelinde bir hak yatmaktadır; genelde zilyetlik durumu bir ayni veya nispi bir hakka dayanmaktadır. Hakka dayanmayan zilyetlik durumu ise istisnadır. Bu sebeple de kanun koyucu hayatın olağan akışına uygun olarak, zilyetliğin bir hakka dayandığını ve zilyetlik durumunun üstün bir hukuki durum olarak korunması gerektiğini düşünerek, zilyetliği hakkın olgusu olarak korumuştur.

1467 Eşya üzerindeki ayni hakkın varlığının üçüncü kişiler tarafından doğrudan anlaşılabilmesi mümkün değildir. Toplumsal yaşam ve ticari ilişkilerde, üçüncü kişiler yönünden, taşınırlarda, ancak zilyetliğin aleniyet aracı olmasıyla hakkın varlığının görünür olmaktadır. TMK m. 985 ile 992'nci maddeleri arasında zilyetliğin hakkın olgusu olarak korunması düzenlemiştir. Zilyetliğin temelinde yatan hakka dayanarak korunan kişi halihazır zilyettir.

B. Zilyetliğin Hakkın Olgusu Olarak Korunmasının Amacı

1468 TMK m.985-992 arasındaki düzenlemenin amacı, zilyedin fiili hâkimiyetindeki eşya üzerinde bu olguya dayanarak, iddia ettiği hakkı korumak amacıyla zilyetlik olgusuna hangi hallerde, nasıl ve hangi ölçüde dayanabileceğini düzenlemektir[1].

1469 Ayni hakkın, bu kapsamda mülkiyetin aslen kazanılması bir kenara konursa, mülkiyetin devren kazanıldığını, zilyetlik olgusuna dayanmaksızın ispatlayabilmesi, hak sahipliğini bir önceki devredenin hak sahipliğine dayandırması gerekir ki, bu ispat da bir öncesine giderek asli kazanıma kadar hak sahipliğini ispatını gerektirir; bu bir öncekinin kendisine

---

[1] SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N 255

devrinin haklı olduğunun ispatı, ortak hukukta "*probatio daibolica*" olarak ifade edilmektedir[2]. Bu noktada, zilyetlik hak sahipliğine hukuki araç olarak bir dayanak noktası olarak hizmet etmektedir. Bu hizmet, eşyanın geri alınmasının sağlanmasında, hakka dayanmada ispat kolaylığı sağlamakta ve ayni hakkı görünür kılarak eşya hukukunun maddi yönüne hizmet şeklinde gerçekleşir.

1470 TMK, ilk olarak, zilyedin maddi hakkına ilişkin karineler getirmekte (TMK m.985-986), ispat yükünü ters çevirerek, hakkın varlığının ispatının zorluğu hafifletilmiştir.

1471 Eşya üzerindeki hakka ilişkin uyuşmazlık çıktığında, hak sahibinin, zilyetlik olgusuna dayanarak zilyetliğe hakkın bir olgusu olarak dayanarak, onun yardımı ile korunmasını düzenlemiştir[3]. Uyuşmazlıkta, zilyet hakka dayandığı vakitte de hakkın varlığı karineler yardımıyla ispatlanır. TMK m.985 ile 993 arasında korunan zilyetlik durumudur; ancak bu koruma doğrudan değil, karine teşkil ettiği hak dolayısıyla gerçekleşmektedir[4]. Zilyedin, hak sahibi olarak korunması saklıdır. Emin sıfatıyla zilyet olandan zilyetliği iyiniyetli olarak kazanan kişinin, devredenin tasarruf yetkisi olmasa da kazanımı korunur (TMK m. 988). Hakka ilişkin uyuşmazlık, mülkiyete, sınırlı ayni hakka veya eşya üzerindeki nispi hakka, alacak hakkına ilişkin olabilir.

C. Zilyetlik Olgusuna Dayanarak Zilyetliğin Korunmasından Farkı

1472 Zilyetliğin sadece zilyetlik olgusu dolayısıyla korunması ile zilyetliğin hakkın olgusu olması sebebiyle korunmasından farklıdır. Zilyetliğin zilyetlik olarak korunması hem taşınır hem de taşınmazlardan, haktan bağımsız, ayrı olarak, toplumsal huzuru korumak amacıyla önceki fiili durumun yeniden tesisinin sağlamaktadır. Hâlbuki burada, hakkın zilyetlik olgusuna dayanılarak savunması söz konusudur[5].

1473 Zilyetliğin hakkın olgusu olarak korunmasında kural olarak taşınırlarda zilyetlik, taşınırlarda iddia ettiği hakkın varlığına karine kabul etmiş ve bu karineye uygun hukuki sonuçlar bağlamıştır. Taşınmazlarda ise zil-

---

2 **STARK**, BK ZGB Vorbem. Art 930-937, N.2.

3 **ZOBL**, s.313 ff.

4 **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 161; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 183.

5 **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N 255.

yetliğe bağlanan karinelerin uygulanması daha sınırlı olup, TMK m.922 hükmü ile sınırlıdır.

1474 Hakkın olgusu olarak zilyetliğin korunmasında, istihkak davasından farklı olarak korunan, hakkın kendisi değildir; zilyetliği koruyan davalardan farklı olarak da hakka karine teşkil eden zilyetlik sebebiyle korunmaktadır. Aşağıda zilyetlik olgusuna dayanan hukuki koruma düzenlemesi olan menkul davası ile diğer davalar arasındaki farklara aşağıda değinilecektir.

D. Zilyetlik Olgusuna Dayanılarak Hakkın Korunması Araçları

1475 TMK zilyetlik olgusuna dayanarak hakkı korunmasına yönelik araçları farklı hükümlerde düzenlenmiştir. Zilyetlik olgusunun hakkı korumada kullanılabilecek araçları, zilyetliğin etkisinden hareketle, aşağıda temel olarak iki başlıkta toplayabiliriz:

- İlki, zilyetliği olgu olarak temel alan karinelere dayanan korunma;
- TMK m.985 ile 986 hükümleri zilyetlik karine olgusu olarak taşınırlardaki karine olması,
- TMK m. 992'de, zilyetlik olgusunun taşınmazlarda hangi olguyla karine olması gerektiği düzenlenmiştir;
- Diğeri ise, TMK m. 987 ve m. 998 ile 991 arasında düzenlenen özel savunma ve müdahale imkânı düzenlemiştir. Diğer bir deyişle zilyetliğin hakkın korunmasına olan etkisi ise üç şekilde karşımıza çıkar:
- Zilyetliğin *savunmada* etkisi, yani davada hakka dayanarak yapılan savunmada zilyetliğe dayanma;
- Zilyetliğin dolaylı *kazanım* etkisi, yani iyiniyetli zilyedin hakkı kazanması;
- Zilyetliğin *ileri sürülebilme* etkisi, yani davada zilyetliğe dayanarak hakkı ileri sürerek hakkı koruma, yani hakkın zilyetlik olgusuna dayandığı davalar, bu kapsamda menkul davası ile korunma.

II. ZİLYETLİK OLGUSUNA BAĞLANAN KARİNELER

1476 Tüm uyuşmazlıklarda, özellikle taşınırlarla ilgili davalarda, ispat yükünün[6] dava tarafları arasında dağılımı, başka bir deyişle kime ait olacağı önemlidir.

[6] İspat yükü için bkz. ANTALYA/ TOPUZ, MHG, 426 vd.

1477 Bu konuda TMK m.6'da genel bir ilke düzenlenmiştir; kanunda aksine hüküm bulunmadığı durumlarda, taraflardan her biri, hakkının dayandığı maddi olguların varlığını ispatla yükümlüdür[7]. Bu ilke, *temel ispat kuralı*dır[8].

1478 TMK m.6'da düzenlenen ispat yükü kuralının –bazı durumlarda kısmen- tersine çevrildiği kanunla düzenlenen hallerden biri de karinelerdir. Taşınırlarda TMK m. 985 ve 986 ile taşınmazlarda TMK m. 992 karine olguları ve bu olgulara bağlanan karine sonuçlarını düzenlemiştir[9].

1479 Kanunla düzenlenen bu karinelerle TMK m.6'daki ispat yükü yer değiştirilmiştir; ispat yükü tersine çevrilmiştir. Eğer söz konusu karineler düzenlenmemiş olsaydı, aslen kazanım halleri dışında, zilyet de olsalar, hakkı devren kazanan cüzi ve külli halefler, zilyetlikten bağımsız olarak dayandıkları hakkı ispat yükü altında kalacaklardı. Hak sahibinin, hakkını ispat etmesi zorlaşmakta, hakkını ispatlayamama durumunda düşmekte, buna bağlı olarak yaşam ve ticari ilişkilerde hukuk güvenliği sarsılması söz konusu olabilecekti.

1480 Zilyetliğin taşınırlarda hakkı alenileştirme aracı olarak, zilyetliği gerektiren bir hakkın varlığını teyit eden zilyedin, eşya üzerindeki hak iddiasına üstünlük tanınmıştır. Kanun, zilyetliğin varlığını karine olgusu olarak kabul ederek, karine sonucu olarakta hakkın varlığını kabul ederek, hakkın alenileşmesinde zilyetliği üstün tutmuştur[10].

1481 Böylelikle kanun, taşınıra zilyet olan kişinin, zilyet olduğu eşyada iddia ettiği hakkın varlığını karine olarak kabul ederek, onu ileri sürdüğü hakkın varlığını ispat külfetinden kurtarmıştır[11].

1482 Karineler ispat yükünü karşı tarafa yükleyerek, hak sahibinin ispat yükünü hafifletmekle birlikte; ispat konusunu değiştirmez, kişinin haklılığına ilişkin ispat yükü yer değiştirmez ancak zilyetlik durumuna ilişkin ispat yükü yer değiştirir[12].

---

7 **ANTALYA/ TOPUZ,** MHG. s. 428.

8 Temel ispat kuralı, karşı ispat ve karşı tarafın ispatı için bkz. **ANTALYA/ TOPUZ**, MHG. s. 428 vd.

9 Karine olgusu ve karine sonucu için bkz. **ANTALYA/ TOPUZ,** MHG. s. 435 vd.

10 **ENST,** BSK ZGB Art.930. N.2.

11 **EGGER,** Art 8. N.22 ff. **KUMMER,** BK ZGB Art 8. N.320 ff.

12 **KUMMER,** BK ZGB Art.8. N.324. **OSRETAG.** BK ZGB Art.930-931. N.2; **ERNST,** BSK ZGB Art.930. N.4. Karşı karar BGE 52 II 46. 52.

1483 TMK m.985 ve 996 ile 992'de düzenlenen karineler, TMK m.900 hariç, nitelikleri itibarı ile adi yani aksi ispat edilebilen kanuni karinelerdir[3].

A. Taşınırlarda Zilyetliğe Bağlanan Karineler

1. Genel Olarak

1484 Kanun koyucu, zilyetliğin hayatın normal akışı içinde dayandığı hakkın dış dünyaca görünüm şekli olduğunu; bununla irtibatlı olarak aleniyet ilkesini[4] dikkate alarak, taşınırlarda zilyetlik karinelerini düzenlemiştir[5]. Diğer yandan, şüpheden zilyet yararlanır (*in dubio pro possessore*) ilkesi söz konusudur.

1485 Zilyetlik olgusunun temelinde yatan hakka dayanarak, lehine zilyetlik karinesi getirilen kişi, hazır zilyettir. Taşınırlarda TMK m. 985 ve 986'da karine olguları ve bu olgulara bağlanan karine sonuçları düzenlenmiştir. Kanunla düzenlenen bu karinelerle TMK m.6 ve HMK m.190'daki ispat yükü tamamen veya bazı durumlarda kısmen yer değiştirilmiştir. Böylelikle TMK, taşınıra zilyet olan kişinin zilyet olduğu eşyada iddia ettiği hakkın varlığını karine olarak kabul ederek, onu ileri sürdüğü hakkın varlığını ispat külfetinden kurtarmıştır.

1486 Taşınırlarda TMK m.985 hükmü aslî zilyetlikten kaynaklanan karineyi -madde kenar başlığında ifade edildiği üzere mülkiyet karinesi- ve TMK m.986 hükmü fer'i zilyetlikten kaynaklanan karineyi düzenlemiştir.

1487 Zilyetlik karineleri, kural olarak aksi ispatlanabilen -adi- yasal karine niteliğindedir. Ancak iki olgu için, ticari ve yaşam ilişkilerinde hukuk güvenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla, karineleri adi karine olarak değil, kesin karine[6] olarak düzenlemiştir. TMK m.900 hükmüne göre, iradi veya irade dışı çıkan para veya hamiline yazılı senetleri iyiniyetle kazanmış kişiye taşınır davası açılamayacaktır.

---

[3] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.101vd.; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s.126; ÜNAL/BAŞPINAR, s.185.

[4] Aleniyet ilkesi ve zilyetlik karineleri arasındaki ilişki için bkz. ANTALYA, EH I, N 466; ANTALYA, Aleniyet, s. 419 vd.

[5] STARK, BK Vorbem. ZGB Art.930-937, N.23; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 263.

[6] Fiksiyon olarak nitelemesi için bkz. ÜNAL/BAŞPINAR, s. 184; STEINAUER, I, N 384.

1488 Hak karinesi olarak zilyetliğin biri taşınır davasında, diğeri hakkın iyiniyetli korunmasında etkisini göstermektedir:

1489 Zilyetliğe bağlanan hak karinesinin taşınır davasındaki davalının savunmasındaki rolü, TMK m.986 hükmünde düzenlenmiştir; bir taşınır zilyedi, kendisi aleyhine açılan davada üstün hakka sahip olduğuna ilişkin karineye dayanabilir.

1490 Yine, zilyetliğe bağlı hak karinesine dayanarak evvelki zilyedin açtığı taşınır davasında, önceki zilyet iki durumda, halihazır zilyedin karinesinden üstün tutularak korunmuştur. TMK m. 985 I ve 986 hükümleri, kural olarak, halihazır zilyedin hak karinesini, önceki zilyedin hak karinesinden üstün tutmuştur. Bu kuralın iki istisnası olarak; TMK m.989 zilyetliğin rıza dışı kaybedilmesinde, TMK m.904 zilyetliğin iyiniyetli edinilmemiş olması durumunda, evvelki zilyede eski zilyede, eski zilyetliğine dayanan özel bir dava hakkı vermiştir (TMK m.989). Bu dava hakkını aşağıda taşınır davası olarak ayrıca inceleyeceğiz[17].

1491 Yargı uygulaması ve doktrin söz konusu karinelerin uygulama bulması için kanunda gösterilen karine olgularına ek olarak iki temel olgunun da gerçekleşmesi gerektiğini aramaktadırlar[18]:

a. Zilyetliğin Haksız Olduğunun Görünüşten Anlaşılamaması

1492 Taşınırı fiili hakimiyetinde bulunduran zilyedin, zilyetliğinin haksız olduğunun, yani zilyetliğin gizlice ve zorla ele geçirildiğinin ilk bakışta anlaşılabilir olmaması gerekir; başka bir deyişle zilyetliği elinde bulunduranın zilyetliğinin, muhtemelen hakka dayandığının, somut olayın şartlarından anlaşılır olması gerekir (Wahrscheinlichkeitsforderung)[19]. Örneğin, hırsız çaldığı eşyada TMK m.985 I'deki mülkiyet karinesinden yararlanamaz[20].

1493 Somut olayın şatlarından, zilyedin kural olarak aynı zamanda hak sahibi olduğunun, zilyetliğin görünüşün muhtemel sonucu olduğu su götürmez şekilde anlaşılmalıdır. Bu sebeple, açık zilyetlikten (unzweideutiger Besitz) bahsedilmektedir[21].

---

17 **ANTALYA**, EH II. N. 1159 vd.

18 **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.260 f; **STEINAUER**, I. N.391 ff.

19 **STARK**, BK ZGB Art.930, N. 1; **ERNST**, BSK ZGB Art.930, N.7; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.261.

20 BGE 120 Ia 120 ff, 122 E.1b.

21 **STARK**, BK ZGB Vorbem. Art.930-937, N. 49; **LIVER**, SPR V/1, s.395; **ARNET/EITEL**, CHK ZGB Art.931, N.1.

1494 Zilyetliğin sonucunun muhtemel hak sahipliği olduğunun açık olarak anlaşılabilir olup olmadığını hâkim takdir edecektir (TMK m.4)[22]. Örnek olarak, birlikte yaşayan veya yaşamış olan eşler, ortak ev eşyaları üzerinde birlikte hak sahibidirler[23].

1495 İsviçre Federal Mahkemesinin bir kararında yer aldığı üzere, eşlerden biri, cebri icra takibi dolayısıyla birlikte oturdukları aile konutundaki eşyalarının haczinde, tek başına mülkiyet karinesinden değil, paylı mülkiyet karinesinden yararlanır[24].

1496 TMK mal rejimlerinde düzenlediği özel kurallarda *paylı mülkiyet karineleri* getirmiştir[25]. Örneğin, TMK m.222 II edinilmiş mallara katılma rejiminde paylı mülkiyet karinesini; TMK m.245 paylaşmalı mal ayrılığında paylı mülkiyet karinesini düzenlemiştir. Miras bırakanla birlikte yaşayan kişi, o konutta bulunan miras bırakana ait eşyaya zilyet olsa da tek başına mülkiyet karinesinden yararlanamaz[26].

1497 Kayıt edilmiş mülkiyeti saklı tutmada, satıcı da TMK m.985 hükmündeki mülkiyet karinesinden yararlanır[27].

b. Karine Sonucu Hakkın Taşınır Üzerinde Zilyetlik Yetkisi Vermesi

1498 Zilyedin, taşınır üzerinde iddia ettiği hakkın, o taşınır üzerinde fiilen hakimiyetine sahip olma yetkisi vermesi gerekir. Örneğin, mülkiyet, irtifak, rehin, satış, kira, vekalet gibi.

1499 Eğer zilyetlik olgusunun varlığına imkân verdiği hak, zilyede o eşya üzerinde fiili hakimiyet yetkisi vermiyorsa, örneğin; onalım hakkı, geri alım hakkı vb. zilyet, mülkiyet karinesinden yararlanamaz.

2. Asli Zilyetlikten Kaynaklanan Karine: Mülkiyet Karinesi

1500 TMK m. 985 hükmü "Mülkiyet Karinesi" kenar başlığı altında, birinci fıkrasında, "*Taşınırın zilyedi onun maliki sayıl*"acağı karinesini ge-

---

[22] BGE 81 II 197 E.4. **STARK**, BK ZGB Vorbem. Art.930-937. N. 50

[23] **STARK**, BK ZGB Art.930. N. 11 ff. Bu konuda bkz. **ERNST**, BSK ZGB Art.930. N.8 ff.

[24] BGE 116 III 32 ff. 34 E.2; 71 II 255 f.

[25] **STARK**, BK ZGB Art.930. N. 16 ff; **ARNET/EITEL**, CHK ZGB Art.931. N.1. Ayrıca bkz. BGE 117 II 124 E.2.

[26] **STARK**, BK ZGB Art.930. N.14

[27] **STARK**, BK ZGB Art.930. N. 38. **ERNST**, BSK ZGB Art.930. N.21-22.

tirmiştir. İkinci fıkrasında da "*Önceki zilyetler de zilyetlikleri süresince o taşınırın maliki sayıl*"acağı karinesi düzenlenmiştir.

a. Taşınırın Halihazır Zilyedinin Mülkiyet Karinesi

1501 Taşınırın halihazır -şimdiki- zilyedi olan -karine olgularının gerçekleştiği- zilyet, karine sonucu olarak taşınırın malıkı sayılır (TMK m.985 I). TMK m.985 I hükmü, karine olgusu olarak halihazır zilyet olmayı; karine sonucu olarak halihazır zilyedin taşınırın maliki olması, yani zilyetlik konusu olan taşınırda zilyedin mülkiyet hakkı sahibi olduğunu düzenlemiştir.

1502 TMK m.985'teki mülkiyet karinesi, sadece zilyet olunan eşyada kimin mülkiyet hakkına sahip olduğunu ortaya koymaya hizmet etmez; zilyetliği olgu olarak alan davalarda, örneğin; taşınır davasında hak iddiasının ispatına[22] veya bu ve diğer davalarda savunmada hakkın ispatına hizmet ederek[23], hakkın korunmasına hizmet eder.

1503 TMK m.985 I hükmündeki mülkiyet karinesi, para ve hamiline yazılı kıymetli evrakta da geçerlidir[24]. Halihazır zilyet, TMK m.985 I'deki mülkiyet karinesini, önceki zilyetler de dahil olmak üzere herkese karşı ileri sürebilir; ancak bu durumda hakkın değil de, sadece zilyetliğin devredildiği durumların söz konusu olduğu dikkatten kaçırılmamalıdır[25].

1504 TMK m.985 I'deki mülkiyet karinesi analiz edildiğinde, kısaca, *zilyetlik* karine olgusudur; bu olgunun karine sonucu ise *mülkiyet hakkı*dır.

aa. Karine Olgusu

1505 TMK m.985 I hükmü, karine olgusu olarak, halihazır zilyet olmayı düzenlemiştir. Mülkiyet karinesi, halihazır zilyetlerden dolaylı veya dolaysız olması fark yaratmaksızın aslî zilyede ilişkindir[26]. TMK m.985 I hükmündeki zilyedin malik sayılması karinesine ilişkin özel hüküm, "*zil-*

---

22 **STARK**, BK ZGB Art.930, N. 36, 46 ff. **ARNET/EITEL**, CHK ZGB Art.931, N.1.

23 **STARK**, BK ZGB Art.930, N. 49; **ARNET/EITEL**, CHK ZGB Art.931, N.1.

24 BGE 109 II 239 E.2. **STARK**, BK ZGB Art.930, N. 32; **ERNST**, BSK ZGB Art.930, N.27. Ada yazılı kıymetli evrakta uygulama alanı bulmaz (BGE 812 II 197, 204 f; **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.930, N.28. **HAAB/SIMONIUS**, ZK ZGB Art.714, N. 7 ff.; Nama yazılı kıymetli evrakta ise uygulanmaz (BGE 84 II 505, 512). Bkz. **ERNST**, BSK ZGB Art.930, N.28-29.

25 **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N 267; **STEINAUER**, I, N. 401a.

26 **STARK**, BK ZGB Art.930, N. 42.

yet daha iyi durumda bulunur" (*Melior est condictio possidentis*) ilkesinin sonucudur[33].

1506 Tek başına zilyet olan, karine sonucu olarak tek başına malik sayılır. Birlikte zilyet olan, karine sonucu olarak birlikte malik: kural olarak, paylı malik sayılırlar[34]; eğer elbirliği mülkiyeti için söz konusu olan özel hukuk ilişkisi söz konusu ise elbirliğiyle malik olurlar[35].

1507 TMK m.985/1 hükmünde getirilen mülkiyet karinesi, genellikle dolaysız zilyetlik durumunda uygulandığı gibi, dolaylı zilyetlikte de uygulanır. Dolaylı zilyet, dolaysız zilyedin zilyetliğini tanıdığı sürece, mülkiyet karinesinden yararlanır[36].

bb. Karine Sonucu

1508 TMK m.985/1 hükmü, karine olgusu gerçekleştiğinde, karine sonucu olarak, halı hazır zilyedin taşınırın malikı olması, yani zilyetlik konusu olan taşınırda zilyedin mülkiyet hakkı sahibi olduğunu düzenlemiştir.

1509 Zilyetliğini ispat eden zilyet, bunun karine olduğu mülkiyet hakkına dayandığında, mülkiyet hakkını ispat etmek yükünden kurtulur; ispat yükü yer değiştirir (Beweislastumkehr)[37].

1510 Kanuni karine sonucunun, adi karine söz konusu olduğundan, aksini iddia eden her kişi -taraf- zilyedin malik sıfatını yani mülkiyet hakkı olmadığını -karine sonucunun aksini- ispat edebilir (karşı tarafın ispatı).

Yine zilyetlik olgusunun söz konusu olmadığını yani eksik olduğunu, gerçekleşmediğini veya sona erdiğini, halen söz konusu olmadığını ispat ederek -karşı ispat- yaptığı savunma ile karinenin maddi olgularını çürütebilir[38].

1511 Örneklersek, tek başına köpeğe zilyet olan kişi, hayvanın malikı olduğuna ilişkin olarak mülkiyet karinesine dayanabilir. Üçüncü kişi, önce-

---

33 **SCHMID/HÜRLIUMANN-KAUP**, N.266.

34 BGE 116 III 32, 34 E.2.

35 Birlikte zilyedin hangi türünün söz konusu olacağı konusunda bkz. **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 139-140.

36 Karş. BGB § 1006/III.

37 **STARK**, BK ZGB Art.930, N. 1 ff, 4, 25.

38 **STARK**, BK ZGB Art.930, N. 43 f. İsviçre Federal Mahkemesi, belirsiz ilişkilerde mülkiyet karinesi için belirli bir zilyet yoğunluğu aramaktadır Bkz. BGer 5P.39/2006 E.6.

likle zilyetlik olgusunun gerçekleşmediğini yani hak iddia edenin köpeğin zilyedi olmadığını ya da kendisinin köpeğin maliki olduğunu ispat edebilir.

b. Taşınırın Önceki Zilyedinin Mülkiyet Karinesi

1512 Taşınırın önceki zilyedi olan -karine olgularının gerçekleştiği- zilyet, (karine sonucu olarak) zilyetlik süresi için taşınırın malik sayılır (TMK m.985 II). TMK m.985 II hükmü, karine olgusu olarak, önceki -evvelki- zilyet olduğunu; karine sonucu olarak, önceki zilyedin zilyet olduğu süre -dönem- için taşınırın malik olması, yani zilyetlik konusu olan taşınırda zilyedin mülkiyet hakkı sahibi olduğunu düzenlemiştir.

aa. Karine Olgusu

1513 TMK m.985 II hükmü, karine olgusu olarak, önceki -evvelki- zilyet olmayı düzenlemiştir. Böylelikle, sadece halihazır zilyet değil, ondan önceki zilyetler de mülkiyet karinesinden yararlanır.

bb. Karine Sonucu

1514 TMK m.985 II hükmü, karine olgusu gerçekleştiğinde, karine sonucu olarak, önceki zilyedin zilyet olduğu süre -dönem- için taşınırın malik olması, yani zilyetlik konusu olan taşınırda zilyedin mülkiyet hakkı sahibi olduğunu düzenlemiştir.

1515 Önceki zilyetlerin mülkiyet karinesi, sadece zilyet oldukları süre ile sınırlıdır. Mülkiyet karinesi, sadece önceki zilyedin, aynı zamanda malik olduğuna ilişkindir; zilyetlik süresine ilişkin değildir.

1516 Önceki zilyet, zilyet olgusunun yanında zilyetlik süresini de ispat yükü altındadır. Malik olan doğrudan zilyet olmayan önceki zilyet, TMK m.985 II'deki mülkiyet karinesini, halihazır zilyede karşı da ileri sürebilir[39]. Örneğin; geçersiz işleme dayanarak zilyetliği devralana karşı ileri sürebilir[40].

3. Fer'i Zilyetlikten Kaynaklanan Karine

1517 TMK m.986 hükmünde, "fer'i zilyetlikte karine" başlığı altında şu düzenlemeyi getirmiştir: "Bir taşınıra malik olma iradesi bulunmaksızın

[39] STARK, BK ZGB Art.930. N. 45.

[40] STARK, BK ZGB Vorbem. Art.930-937. N. 36.

zilyet olan kimse, taşınırı kendisinden iyiniyetle aldığı kişinin mülkiyet karinesine dayanabilir.

1518 Taşınıra bir sınırlı aynî hak veya kişisel hak iddiasıyla zilyet bulunan kimsenin iddia ettiği hakkın varlığı karine olarak kabul edilir. Ancak, zilyet bu karineyi şeyi kendisine vermiş olan kişiye karşı ileri süremez. TMK m. 986 I hükmü yeni bir karine getirmeksizin, TMK m.985'teki mülkiyet karinesinin uygulama alanını genişletmektedir. TMK m.986 II ise, zilyetliğe dayanan sınırlı ayni hak karinesi ile nispi hak karinesini düzenlemiştir.

a. İyiniyetli Malik Sıfatıyla Asli Zilyedin Mülkiyet Karinesine Dayanılabilmesi

1519 TMK m. 986 I hükmünde, asli zilyedin mülkiyet karinesine dayanılabilmesini, "*Bir taşınıra malik olma iradesi bulunmaksızın zilyet olan kimse, taşınırı kendisinden iyiniyetle aldığı kişinin mülkiyet karinesine dayanabilir*" şekilde düzenlemiştir. Bu hükümden ne anlaşılması gerektiği yeteri kadar açık değildir.

1520 Kanunun dar düzenlemesinden, buradaki başkasının mülkiyet karinesine dayanabilme, kademeli zilyetlikte -çok kademeli dahil olarak- uygulama alanı bulur. Malik sıfatıyla zilyet olmayan zilyet, genellikle fer'i zilyet, TMK m.985 I hükmüne dayanarak üçüncü kişiden eşyanın geri verilmesini, iyiniyetli ise taşınırı aldıkları kişinin mülkiyet karinesine dayanarak isteyebilir[41].

1521 TMK m.986 I hükmünde, TMK m.985'te düzenlenen mülkiyet hakkına dayanabilecek kişilerin kapsamını genişletmiştir[42]. Taşınır üzerinde sınırlı ayni hak veya alacak hakkı sahibi olan iyiniyetli zilyet, kendisi lehine mülkiyet karinesi olmasa da taşınırı veren kişinin mülkiyet hakkına dayanabilir[43]. Örneğin; rehin veya kira sebebiyle bir şeye zilyet olan rehin alan veya kiracı iyiniyetli ise, kendilerine zilyetliği veren rehin edenin veya kiraya verenin mülkiyet hakkından yararlanır.

1522 Bir taşınıra malik iradesi olmaksızın zilyet olanlar, başkasının malik sıfatını kabul eden fer'i zilyetler asli zilyedin mülkiyet hakkından yarar-

---

41 TUOR/ SCHNYDER/ SCHMID/ RUMO-JUNGO, s.839. TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 158 vd.

42 SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 270.

43 STARK, BK ZGB Art.931, N. 11.

lanır. Fer'i zilyetliğin doğrudan asli zilyetten ya da aracı kişilerden zilyetliği elde etmesi önemli değildir[44].

1523 Fer'i zilyedin başkasının mülkiyet hakkına dayanabilmesi için, malik iradesi olmaması yanında, iyi niyetli de olması gerekir[45]; taşınırı kendisine veren önceki zilyedin malik -hak sahibi- olmadığını bilmemesi veya bilememesi gerekir[45]; aksi takdirde fer'i zilyet başkasının mülkiyet karinesinden yararlanamaz. Fer'i zilyedin iyiniyetli olduğuna ilişkin olarak, TMK m.3'teki iyiniyet karinesi geçerlidir; aksini iddia eden ispatla yükümlüdür.

1524 TMK m.986 metni, sadece fer'i zilyedin, taşınırı veren kişi olan asli zilyedin mülkiyet karinesine yararlanabileceği şeklinde düzenlenmiştir.

1525 Buna rağmen, doktrinde, taşınırı fer'i zilyede veren kişinin yine fer'i zilyet olması halinde de yani birden çok kademeli zilyetlikte, hükmün yine uygulama alanı bulacağı savunulmuştur[47]. Bu yaklaşıma göre, ikinci fer'i zilyet, birinci fer'i zilyedin aldığı kişinin asli zilyetliğindeki mülkiyet karinesine değil, zilyetliği aldığı kişinin fer'i zilyetliğine dayanabileceği savunulmuştur[42]. Örneğin, intifa hakkı sahibinden taşınmazı kiralayan kiracı, intifa hakkı karinesine dayanabilir.

1526 Hatta doktrinde bazı yazarlar, fer'i zilyet, aracı konumundaki fer'i zilyede veren asli zilyedin mülkiyet karinesine de dayanabileceğini kabul etmişlerdir[49]. Bu görüşe göre ise, örnekten hareket edersek, kiracı, asli zilyedin mülkiyet karinesine dayanabilir. Bize göre de İsviçre doktrininde hâkim görüşün savunduğu üzere[50], çok kademeli zilyetlikte, altın altı olan zilyet, örneğin alt kiracı, aslı zilyedin, malikin yararlandığı mülkiyet karinesinin yanında; TMK m.986 II'deki birinci fer'i zilyedin nispi hak karinesine dayanabilir.

---

[44] **STARK**, BK ZGB Art.931, N.13 f; **ERNST**, BSK ZGB Art.931, N.4; **BERGER-STEINER/ SCHMID**, OFK ZGB Art.931, N.2.

[45] İyiniyet olgusunun aranmasının anlamsızlığı konusunda bkz. **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 160.

[46] **STARK**, BK ZGB Art.931, N. 15.

[47] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.931, N.3 f.

[42] **NOMER/ERGÜNE**, s. 49.

[49] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s.102, dn.187; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 175. Bu konuda bkz. **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 156-158.

[50] **STARK**, BK ZGB ASrt.931, N.12 ff. 13; **ARNET/EITEL**, CHK ZGB Art.931; N.2.

1527 Başkası için zilyedin, bu kapsamda fer'i zilyedin aslî zilyedin mülkiyet hakkına dayanması, özellikle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen istihkak iddialarında önem arz eder[51].

b. Sınırlı Ayni Hak Karinesi veya Nispi Hak Karinesi

1528 Zilyetliğin aslı zilyetlik olgusu olarak mülkiyet hakkının yanında zilyedin taşınıra bir sınırlı ayni hak veya kişisel hak iddiasıyla zilyet bulunacağını dikkate alarak, TMK m.986 II'de bir sınırlı ayni hak veya kişisel hak iddia eden zilyedin hakkının varlığı karine olarak kabul edilmiştir. Örneğin, taşınıra zilyet olanın, zilyetlik olgusunun dayandığı ayni hakkın, örneğin; rehin, irtifak vb. veya nispi hak olarak, örneğin; ödünç, kira, taşıma vb. alacak hakkının sahibi bulunduğuna ilişkin karine teşkil eder. Sınırlı ayni hak karinesi, rehin hakkında, ona temel teşkil eden alacak hakkını da kapsar[52]. Bu düzenlemenin uygulamada fazla anlamı bulunmadığı kabul edilmektedir[53].

1529 Zilyetliğin muhtemel olarak hakkın varlığını açık olarak somut olayın şartlarından ortaya koyması gerekir[54]. TMK m.986 II, aksi ispatlanabilen *-adi- yasal karine* niteliğindedir.

1530 Sınırlı ayni hak karinesi veya nispi hak karinesine dayanan fer'i zilyet, zilyetliğini dayandırdığı sınırlı ayni hak veya alacak hakkını ispat yükünden kurtulur; karine olgusu olan zilyetlik olgusunu ispat ettiğinde, karine sonucu olarak, zilyedin hak sahibi olduğu kabul edilir ve bunun aksini ispat yükü karşı tarafa geçer[55].

1531 Ancak zilyet bu karineyi, şeyi kendisine vermiş olan aslî zilyede karşı ileri süremez; sadece üçüncü kişiye karşı ileri sürebilir[56]. TMK m.986 II c.2 bu hususu; "*Ancak, zilyet bu karineyi şeyi kendisine vermiş olan kişiye karşı ileri süremez*" şeklinde düzenlemiştir. Örneklersek, bir taşınmazı malikten kiralayan kiracı, taşınmazda kiracı olarak nispi hakkı olduğuna ilişkin uyuşmazlıkta, kiraya verene karşı TMK m.986 II'de düzenlenen zilyetliğe dayalı nispi hak karinesine dayanamaz; davasını genel hükümlere göre (TMK m.6) ispat yükü altındadır.

---

51 TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 153, 160.

52 Bu konudaki tartışmalar için bkz. TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s.153-152.

53 STARK, BK ZGB Art.931, N.9.

54 STARK, BK ZGB Art.931, N. 8.

55 SCHMID/ HÜRLIUMANN-KAUP, N.266.

56 BGE 543 II 244 ff, 245 E.2. SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N.271. STEINAUER, I, N.408.

1532 Sınırlı ayni hak karinesi veya nispi hak karinesi sadece üçüncü kişilere karşı ileri sürebilir; karinenin üçüncü kişiye olan hukuki sonucu ise farklıdır[57].

1533 Fer'i zilyedin zilyetliğini dayandırdığı hak sınırlı ayni hak ise, ayni hak karinesine dayanan kişi, aksi ispat edilemediği takdirde, eşyayı iade yükümlülüğünden kurtulacaktır[58]. Eğer fer'i zilyet nispi hak karinesine dayanıyorsa, bu alacak hakkı niteliği gereği, üçüncü kişiye karşı ileri sürülemeyeceğinden, eşyayı geri verme yükümlülüğünden kurtulamaz; ancak tazminat davasında ispat yükünden kurtulur[59].

1534 Nispi hak sahibi olan fer'i zilyet, eşyayı verenin mülkiyet hakkına dayanabiliyorsa, bu takdirde eşyayı iadeden kaçınabilme imkânı bulunmaktadır.

1535 Unutmamak gerekir ki, konuları yapma veya yapmama borcunu konu alan haklar, zilyetlik yetkisi vermediğinden, karineden yararlanmaz[60].

B. Taşınmazlarda Zilyetliğe Bağlanan Karineler

1536 TMK m.985 ve 986'da düzenlenen karineler, taşınırlara ilişkindir. Taşınmazlarda TMK m. 992'de karine olguları ve bu olgulara bağlanan karine sonuçları düzenlenmiştir. TMK m.992, taşınırlardan farklı olarak hak karinesinde zilyetliği hareket noktası olarak ele almamıştır; zira taşınmazlarda aleniyet fonksiyonu aleniyet aracı olan tapu sicili ile gerçekleşmektedir[61]. Ancak zilyedin gasp ve saldırı halinde zilyetliği savunma hakkını (TMK m.982-984) kullanabileceğini ifade etmiştir. Zilyetlik durumunun korunmasına hizmet eden bu davalar, zilyetliğin temelinde yatan haktan, yani tapu kütüğünde tescil edilmiş haktan bağımsız ve ayrı olarak koruma sağlar[62]. *Stark*'ın anlatımıyla, taşınırlarda "*zilyetlikten doğan dava*" söz konusu iken, taşınmazlarda, "*tapuya tesciden doğan dava*" söz konusudur[63].

---

57 **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 176-177.

58 **STARK**, BK ZGB Art.931. N. 6. **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 156 vd.; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 188.

59 **STARK**, BK ZGB Art.931. N. 7. **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 156 vd.; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 189.

60 **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 155.

61 **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.81 ff.. Bu konuda bkz. Y.HGK. T.03.02.2010, E.2010/4-4, K.2010/56.

62 **STARK**, BK ZGB Art.937. N.31 f.

63 **STARK**, BK ZGB Art.937. N.21.

1537 TMK m.992 sadece tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerindeki kayıtlı haklara ilişkin karine getirmiştir. Kanunla düzenlenen bu karinelerle TMK m.6'daki ispat yükü yer değiştirilmiştir. TMK m.992 sadece tapuya kayıtlı taşınmazlarda ve yalnız adına tescil bulunan kişi yararına hak karinesi getirmiştir. Bununla birlikte taşınmaz üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kişinin, gasp veya saldırı sebebiyle dava açma hakkı saklıdır. Bu sebeple, hak karinesini tapuya kayıtlı taşınmazlar ve tapuya kayıtlı olmayanlar olarak ikiye ayırarak incelemek gerekir:

1. Tapuya Kayıtlı Taşınmazlar

1538 TMK m.992 hükmünün dar anlamından, hak karinesinden yararlanma ve zilyetlikten doğan davaları açma hakkının, tapuya kayıtlı taşınmazlarda, tapu siciline kayıtlı haklarla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte hangi tescilin hak karinesinden yararlanacağı konusunu açık bırakmıştır.

1539 TMK m.992 hükmündeki hak karinesi, her halükârda: Tapuya kayıtlı ayni haklarda yan: mülkiyet hakkı, taşınmaz rehni hakkı, irtifak hakkı, taşınmaz yükü, tapu kütüğüne şerh edilmiş nispi –alacak- haklarında uygulama alanı bulur.

1540 TMK m.992 hükmü, TMK m.7'ye paralel olarak, tapu siciline tescil edilmiş haklara, aksi ispat edilebilir hak karinesi getirerek, ispat yükünü tersine çevirmiştir[64].

1541 Tapuya şerh edilmiş alacak haklarının bu karineden yararlanabilmesi TMK m.7 hükmünün de doğal sonucudur[65].

1542 TMK m.1010'da düzenlenen tasarruf yetkisi kısıtlamaları ve beyanlar, karine oluşturmaz. Buna karşın, TMK m.862 II rehin kapsamında beyanlar hanesine yazılan eklenti niteliğinde olan şeylerde hak karinesi söz konusudur[66].

1543 Tapu sicilindeki tescilin yolsuz olması, tapuya hakkı şeklen de yazılı olan kişının, hak karinesi ve zilyetlikten doğan davaları açabilmesine engel değildir.

---

[64] **STARK**, BK ZGB Art.937, N.11.

[65] **STARK**, BK ZGB Art.937, N.12 ff. 13; **ERNST**, BSK ZGB Art.937, N.3; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 118, dn.270.

[66] Bu ve diğerleri konusunda bkz. **STARK**, BK ZGB Art.937, N.14 ff.

1544 Gerçek hak sahibi ise, tapu sicilindeki kaydı düzeltince hak karinesinden yararlanmaya başlar: Gerçek hak sahibinin, tescilin yolsuzluğunu davada ispat hakkı saklıdır.

1545 Tapuya kayıtlı taşınmaz üzerinde, tescilsiz kazanılan haklara ilişkin olarak, karineden yararlanabilmek için açıklayıcı tescilin yapılması gerekir mi yoksa tescilsiz kazanım kazanana hak karinesinden yararlanma hakkı verir mi hususu tartışılmaktadır. Görüşümüz göre, tapulu bir taşınmazda tescilsiz hak kazanımlarında, açıklayıcı tescile gerek olmaksızın, tescilsiz kazanım olgusunun varlığını ispat eden kişi, TMK m.992 hükmünden yararlanmalıdır.

1546 TMK m.992'nin hükmü, hakka dayanan dava ile taşınmazlarda, tescil edilmiş hakkın kapsamına uygun olarak durumun düzeltilmesini (Legitimation) gerçekleştirir[67].

2. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar

1547 Tapusuz taşınmazlarda hak karinesi olup olmadığı; varsa niteliği konusu tartışmalıdır. Doktrinde bir görüşe göre, tapusuz taşınmalarda hak karinesi söz konusu değildir. Bu görüşe göre, tapusuz taşınmaz zilyedi, malikse mülkiyet hakkına, değilse sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak açacağı davayla fiili durumunu gaspa veya tecavüze karşı savunur[68].

1548 Doktrinde tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda da hak karinesinin geçerli olduğu savunulmuştur[69]. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar bakımından, TMK m.922'de düzenlenen hak karinesi söz konusu değildir[70]. Aksi görüşe, TMK m.992 hükmünün açık anlamına ters düştüğü ve taşınırlarda aleniyet ilkesiyle uyumlu olmadığından katılmamaktayız.

1549 Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamasında ise, tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar taşınır hükümlerine tabi tutulmuştur[71]. Yargıtay'ın yaklaşımına uygun olarak doktrinde katıldığımız diğer yazarlar ise, taşınırlarda geçerli

---

[67] **STARK**, BK ZGB Art.937, N.22.

[68] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 119.

[69] **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 118, 165, 193.

[70] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 119; **SEROZAN**, N.589; **ERTAŞ**, s.297; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 71.

[71] Y. 8. HD., 01.12.2005 T., 7634/8084 (KİB).

olan zilyetliğin hak karinesi olduğu ilkesi ve buna bağlı olarak kabul edilen karinelerin, tapusuz taşınmazlara, niteliklerine uygun olduğu ölçüde uygulanması gerektiğini kabul etmektedir[72].

III. DAVADA ZİLYETLİK OLGUSUNA DAYANAN HAK KARİNESİNE DAYANARAK TALEP VEYA SAVUNMA, HAKKA DAYANABİLME

A. Davalının, Davada Zilyetlik Olgusunun Dayandırdığı Hakka Dayalı Savunması

1550 Zilyedin aleyhine açılan bir davada, üstün hakkına dayanarak savunma yapma imkânı TMK 987'de düzenlenmiştir. TMK m.987'de düzenlenen kuralın, kendi başına özgün, farklı bir anlamı ve özelliği bulunmamaktadır[73]. Bu düzenleme, zilyetliği koruyan davalarla, zilyetliği hakka dayanarak koruyan davalar arasındaki farkı ve ilişkiyi vurgulamaktan öteye gitmez[74]. TMK m.987 halihazır zilyedin davada davalı sıfatıyla savunmasını düzenlemiştir.

1551 Aleyhine dava açılan zilyet, bu davada zilyetlik olgusunun dayandığı üstün hakka dayanarak savunma yaparak, zilyetliğindeki şeyi geri vermekten kaçınabilir. TMK m.982'deki gasp veya saldırı halinde zilyetliğin korunmasına ilişkin hükümler ve tartışmalı olmakla birlikte bize göre m.983'teki hükümler saklıdır. Zilyetliğin gasp ve saldırıya karşı korunması davasında, üstün hakkın ileri sürülmesi üstün hakkın derhal ispatına bağlanmıştır.

1552 Zilyet, kanundan doğan karinelerle üstün hakkını ispat edebilir. Zira bu karineler aksi ispat edilebilir hak karineleridir. Karşı taraf a) karine olgularının aksini -karşı ispatı- veya b) daha üstün hakkını -karşı tarafın ispatını-, sadece zilyetlikten doğan hak karinelerinden yararlanarak değil, maddi hak sahıplığını ve bunun üstünlüğünü maddi hukuka göre ispatlayabilecektir[75].

---

[72] **AKİPEK**, Menkul Davası, s. 24; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 204; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 211. Bu yönde karş. 1984 tarihli TMK Ön Tasarısı m.910.

[73] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.932, N.1.

[74] **STARK**, BK ZGB Art.932, N.1 ff. 4; **ARNET/ EITEL**, CHK Art.932, N.1.

[75] **STARK**, BK ZGB Art.932, N.4 f; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.266.

B. Davacının, Zilyetlik Olgusunun Dayandığı Hak Karinesi veya Hakla Korunması, Özelikle Taşınır Davası

1. Davacının Zilyetlik Olgusunun Dayandığı Hak Karinesi veya Hakka Dayanarak Korunması

1553 TMK m.987 halihazır zilyedin davalı olduğuna göre düzenleme getirmişse de halihazır zilyedin, zilyetliğini dayandırdığı üstün hakkına dayanarak dava açarak hakkını koruması söz konusu olabilir. Davacı sıfatıyla açtığı davada, halihazır zilyet, TMK m. 985 ve 986'da düzenlenen hak karinelerinden yararlanabilir; zilyetliğin olgu olarak bağlandığı hakkı, karineler vasıtasıyla ispat edebilir.

1554 Taşınır davasında, davacı ve davalı, zilyetliğin kendi lehlerine olan hak karinelerine dayanabilir. Davacının yararına olan hak karinesi maddi bir hakla desteklenebileceği gibi; davalı davacının üstün hak karinesini, davacının hiçbir hakkı bulunmadığını veya kendisinin daha üstün maddi bir hakkı olduğunu ileri sürerek yıkabilir.

1555 TMK m.985 II hükmünün, halihazır zilyedin hak karinesini, önceki zilyedin hak karinesinden üstün tuttuğunu daha önceden ifade etmiş idik. Bu hükümden hareketle halihazır zilyet, önceki zilyedin açtığı iade davasında üstün hak karinesine dayanarak kendisini savunabilir. Buna karşın, TMK iki durumda, önceki zilyet lehine tanınan hak karinesini, halihazır zilyedin hak karinesine üstün tutmuştur:

1556 Önceki zilyedin zilyetliğini rıza dışı kaybetmesi (TMK m.989); halihazır zilyedin zilyetliğini iyiniyetle edinmemiş olması (TMK m.904).

2. Tarihi Kökleri

1557 Cermen hukuku kökenli "Gewere" kavramı; eşyanın hukuktaki giysisi, hakkın gizlendiği dış görünüştür. Hukuk sırf bu dış görünüş sebebiyle "Gewere"yi korur; bu koruma "Gewere"nin gerçeğe uymadığının kanıtlanmasına kadar sürer. Cermen hukukunun bu "Gewere" koruması taşınır davası olarak BGB ve ZGB'ye intikal etmiştir[76]. "Gewere", zilyetliğin zilyetlik kavramını belirlemiş, zilyedi zilyet olarak korunmasına ve zilyedi zilyetliği olgu olarak kabul eden hak karineleri ile korunmasına temel teşkil etmiştir. Aşağıda taşınır davasında tekrar üzerinde durulacaktır.

[76] Tarihi kökleri için bkz. **GIERKE**, Besitz, s.2 vd, 9, 19; **HUBER**, Gewere, s. 8 vd, 22, 46.

3. Haksız Zilyetlik Kazanımı Kavramı

1558 Bir kişi, aslen kazanma halleri hariç, kural olarak, zilyetliğini diğer zilyetten kazanır. Zilyetlığın kazanımı, normal olarak, devre yetkili olan bir kişiden kazanılır. Kişinin, zilyetliği kazanımı, zilyetliğin haklı kazanımı ve onunla birlikte onun temelinde yatan hak sahibinden kazanım söz konusu ise, haklı hak kazanımdır. Örneğin: (A), sahibi olduğu aracı satış sözleşmesi ile alıcı (B)'ye aracın zilyetliğini devreder ve bununla birlikte (B) aracın mülkiyetini kazanır.

1559 İstisnai ve uygun olmayan zilyetliğin kazanım şekli ise, **haksız olarak zilyetlik kazanımıdır**. Haksız zilyetlik kazanımında, zilyetlik kazanımındaki tasarruf yetkisi eksiktir. TMK m.988 haksız kazanımı "... *tasarruf yetkisi bulunmama ...*" şeklinde ifade etmiştir. Örneğin: (A)'nın sahibi olduğu 3D yazıcıyı kullanmak üzere alan arkadaşı (B), yazıcıyı üçüncü kişiye satıp, teslim etmişse; (A)'nın bilgisayarını çalan (B) bilgisayarı (C)'ye satarak, teslim etmişse haksız zilyetlik söz konusu olur. Haksız zilyetlik kazanımına katılan üç kişi arasındaki ilişkiden bahsedebiliriz: Önceki haklı zilyet, devreden zilyet ve kazanan halihazır zilyet.

1560 Eşya hukuku yönünden buradaki sorun, önceki haklı zilyedin, eşyayı haksız olarak kazanandan -halihazır zilyetten- hangi şartlarla geri isteyebileceğidir[77].

4. Haksız Zilyetlik Kazanımında Eşyanın İadesi

a. Genel Olarak

1561 Haklı olan zilyedin iade talebine ilişkin Roma Hukuku'nda var olan: "*Hiç kimse kendisinin sahip olmadığı hakkı başkasına devredemez*" (*Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*) ilkesi; Türk-İsviçre hukukunda kural olarak, kısmen yumuşatılarak, benimsenmiştir[78]. Cermen hukukundaki "*bir kere rıza dışı çıkan eşya, her zaman rıza dışı çıkmış durumdadır*" ilkesi uygulanmıştır[79]. Burada zilyetliğin iddia etkisi (Offensivwirkung) söz konusudur.

---

[77] SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 280.

[78] BGE 57 II 258 ff (262) E 2. SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N.281.

[79] HINDERLING, SPR VII s.474 f.

1562 Önceki haklı zilyedin eşyayı geri isteme hakkı TMK m.988 ile 991 arasında düzenlemiştir[22]. Bu kapsamda da TMK m.989 ve 991 hükmünde taşınır davası düzenlenmiştir. Haksız zilyedin iadesine ilişkin yasal düzenlemenin getirdiği çözümü kısaca özetlersek:

1563 İlk önce *emin sıfatla kazanılan eşya* (TMK m.988) *ve rıza dışı elden çıkan eşya*, özellikle kaybedilen ve çalınan eşya (TMK m.989) ayrımı yapmamız gerekir.

1564 **Emin sıfatıyla kazanılan eşyada**, kazanan -halihazır (sonraki) zilyet- ***iyiniyetli*** ise, halihazır zilyedin kazanımı korunur (TMK m.988).

1565 Kazanan -halihazır (sonraki) zilyet- ***kötüniyetli*** ise, önceki zilyet her zaman ondan eşyayı geri isteyebilir (TMK m.991 I). TMK m.991 I'deki kuralın istisnası, önceki zilyedin kazanımı da kötüniyetli kazanım ise halihazır (sonraki) zilyedin iade yükümlülüğünden kurtulmasıdır (TMK m.991 II).

1566 **Rıza dışı elden çıkan eşyada**, özellikle kaybedilen ve çalınan eşya, kazanan -halihazır (sonraki) zilyet- ***iyiniyetli*** ise, önceki zilyet elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açarak eşyayı geri isteyebilir (TMK m.989 I). Rıza dışı elden çıkan eşyanın iyiniyetli kazanımı ilgili olarak iki özel hüküm söz konusudur:

1567 Bunlardan birincisi; eşyanın açık arttırma veya pazardan ya da benzeri eşya satandan kazanımında, önceki zilyedin eşyanın geri verilmesi istemi, iyiniyetli kazanana –halihazır (sonraki) zilyede- ödediği bedelin verilmesine bağlıdır (TMK m.984 II).

1568 Diğeri ise; geri istenecek eşya, para ve hamiline yazılı senet ise, bunların iyiniyetli kazanandan -halihazır (sonraki) zilyetten- geri istenmesi söz konusu değildir.

1569 Kazanan -halihazır (sonraki) zilyet- ***kötüniyetli*** ise, önceki zilyet her zaman ondan eşyayı geri isteyebilir (TMK m.991 I). TMK m.991 I'deki kuralın istisnası, önceki zilyedin kazanımı da kötüniyetli kazanım ise halihazır (sonraki) zilyedin iade yükümlülüğünden kurtulmasıdır (TMK m.991 II).

---

[22] Bu hükmün İsviçre hukukundaki tarihi gelişimi aOR Art.205 – 209 hükümlerine dayanmaktadır Bkz. **STARK.** BK Vorbem. ZGB Art.930-937. N.22.

1570 TMK m.988 ile 991 arasında düzenlenen hükümler zilyetlik durumunun korunmasına ilişkindir. Zilyetliğin haksız kazanımına ilişkin olarak zilyetlik olgusuna temel alan karinelere dayanarak, aynı şekilde mülkiyet veya rehin hakkı gibi ayni hakkın korunmasında da (TMK m. 763 II, m. 989 II) aynı etkiyi yaratır. Gerçekten, TMK m.763 mülkiyetin zilyetlikle devrinde, bir taşınırın zilyetliğini iyiniyetle ve malik olmak üzere devralan kişi, devredenin mülkiyeti devrinde yetkisi olmasa bile zilyetlik hükümlerine göre kazanımın korunduğu hallerde o şeyin malikı olacağını düzenlemiştir.

1571 Halihazır zilyedin taşınır davası ile geri verme yükümlülüğü kapsamı, TMK m.993 ile 995 arasında, haksız zilyedin sorumluluğu kapsamında düzenlenmiştir.

b. Taşınır Davası

aa. Terim

1572 743 sayılı ETMK m.902'de, mülkiyete dayanan ayni nitelikteki "istihkak davası" (TMK m.683 ETMK m.618) karıştırılmaya müsait olarak, "istihkak davası"; TMK m. 988 ve devamı hükümlerinin üst kenar başlığında "taşınır davası" adıyla düzenlenmiştir.

1573 Taşınır davası terimi yerine, doktrinde, zilyede haklılık davası, önceki zilyet davası, zilyetlik için üstün hak davası vb. önerilerde bulunulmuşsa da[81], yazarlar ağırlıklı olarak *menkul/taşınır davası* (Fahrnisklage, Besitzesrechtklage) terimini tercih etmişlerdir[82].

bb. Kavram

1574 Davalının halihazır zilyet olması, eşya üzerindeki üstün hakkını ve bunu teyit eden önceki zilyetliğine bağlı hak karinesini taşınır davasında ileri sürebilme imkânı verir[83]. Bu üstün hak ve bunu ispata yarayan hak karinesi taşınır davasının da hukuki dayanağıdır[84]; zira bu hak karineleri

---

[81] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 104; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s.161; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 191; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 191; **AYAN**, s.151; **GÜRSOY**, s. 93; **REİSOĞLU**, s. 84; **ÖZAKMAN**, Menkul, s.482; **BURCUOĞLU**, Menkul, s. 493.

[82] **AKİPEK**, Menkul, s. 16; **AKİPEK**, Menkul, s. 482.

[83] **AKİPEK**, Menkul, s. 19, 105, 106; **ÖZAKMAN**, s. 488 vd.; **BURCUOĞLU**, Hak Karineleri, s. 495. Bu konuda bkz. **SCHMIDLIN**, Bruno, s. 141 ff.; **SCHWENZER/ MÜLLER-CHEN**, 303 ff.

[84] **TEKİNAY/AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 135; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 184.

önceki ve halihazır zilyedin mülkiyet veya ayni hak karinesini oluşturur; nispi hakların da karinesidir.

1575 Menkul davası, tek başına zilyetlik olgusuna ve zilyetliği karine olgusu olarak kabul eden hak karinelerine dayanır.

1576 Davacı taşınır davasında üstün hakkını değişik şekillerde ortaya koyabilir[85]:

- Davalının kötüniyetli kazanım yaptığını,
- Eşyanın rıza dışı elden çıktığını,
- Kendisinin aslen kazanılmış ayni hakkı olduğunu,
- Kendisinin nispi bir –alacak- hakkı kazandığını,
- Üçüncü kişiden ayni bir hakkı kazandığını.

1577 Taşınır davası, davalı yönünden, kendisine karşı açılan davada ancak davacıdan üstün bir hakkı bulunduğu savunması ileri sürebileceği bir davadır[86].

1578 Dava doğrudan zilyetliği, dolaylı olarak hakkı korur. Zilyetliği olgu olarak kabul eden karine, aynı zamanda hakkı da ortaya koyar. Davacı önceki zilyet olduğu şeyin rızası dışında elinde çıktığını veya davalının kötüniyetle zilyetliğini kazandığı anda onun yararına olan zilyetliğe bağlı hak karinesini de çürütmüş olur.

1579 İyiniyetli önceki zilyedin, halihazır zilyedin lehine olan üstün hak karinesini kanunda çürüterek, kendi zilyetliğine ait hak karinesine dayanarak, halihazır zilyetten geri alabilmek için açtığı dava, taşınır davasıdır[87].

1580 Halihazır zilyet, önceki zilyedin üstün hak karinesini;

- Ya zilyetliği rızası dışında kaybettiğini,
- Ya da halihazır zilyedin zilyetliği kötüniyetli olarak kazandığını ispatlayarak çürütülebilir.

1581 İyiniyetli önceki zilyedin, kendi zilyetliğine ait üstün hak karinesine dayanarak, halihazır zilyedin lehine olan hak karinesini, zilyetliği rıza dı-

---

85 Bkz. **STARK**, BK ZGB Art.934, N.17.

86 **ACEMOĞLU**, s.26; **ÖZAKMAN**, Menkul, s.488 vd., 510 vd., 511; **AKİPEK**, Menkul, s. 81, 107.

87 Benzer bir tanım için bkz. **ÖZAKMAN**, s. 482.

şında kaybettiğini veya halihazır zilyedin zilyetliğini kötüniyetli olarak kazandığını ortaya koymak suretiyle çürüterek, halihazır zilyetten geri alabilmek için açtığı dava, taşınır davasıdır.

cc. Hukuki Niteliği

aaa. Taşınır Davasının Hukuki Dayanağının Niteliği

1582 Taşınır davasının hukuki niteliği tartışmalıdır: Azınlık görüşü, bu davayı hakka veya hak karinesine dayanmayan bir tür zilyetlik davası olarak görmektedir[84]. Bu görüştekiler taşınır davasında zilyetliğin soyut bir üstünlük anlamına geldiğini ve böylelikle bir hakka karine olduğunu veyahut hakkın dış dünyadaki yansıması olan zilyetlik aracılığıyla dava yetkisi veren özel nitelikte bir hak olduğunu savunmaktadırlar[85]. Buna karşın baskın görüş, taşınır davasının zilyetlik olgusuna dayanan ve hak karineleriyle ispat edilebilen bir dava olarak kabul etmektedir[86].

1583 Netice itibarı ile korunan hak değil, zilyetliktir. Zilyetlik aleniyeti sağlayan araç olduğundan kanun koyucu, zilyet olanın taşınır üzerinde hakkı olduğunu karine olarak kabul etmiş ve zilyetliği sağlayan kişinin hak iddiasına sırf bu sebeple üstünlük tanıyarak, taşınır davası ile onu haksız zilyede karşı korumuştur.

1584 Hak karinelerin düzenlenmiş olması, hakkın varlığının dava konusu olmasını engellemez. Davacı, davalının hak karinesini çürütmek için kendi hakkını ispatla yükümlü değildir. Taşınır davası ile davalının hak karinesinin çürütülmesi ve taşınırı üzerindeki önceki zilyetliğini ispatlayan davacının uyuşmazlık konusu eşya üzerinde üstün hakkının bulunduğunu kabul için yeterlidir. Hak karinesi bu durumda davacı lehine sonuçlarını doğurmaya başlar. Ancak bazı yazarlar zilyetliği hak olarak kabul ettiklerinden, taşınır davasını da bir hak davası olarak kabul etmektedirler[87].

1585 Bu sebeple TMK m.988 ile 991 arasında düzenlenen hükümler zilyetlik durumunun korunmasına ilişkindir. Zilyetliğin haksız kaza-

---

[84] **AYBAY/ HATEMİ**, s.72. Bu görüşte bkz. **BURCUOĞLU**, s. 496 vd., 502 vd., 513, 521.

[85] Bkz. bu görüş ve görüşler için s.502 vd.

[86] **AKİPEK**, Menkul, 105 vd.; **ÖZAKMAN**, Menkul, s. 488 vd.; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s.104; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 161; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 191; **AYAN**, s.151; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 183, 191.

[87] **AKİPEK**, Menkul, 108 vd.

nımına ilişkin olarak zilyetlik olgusunu temel alan karinelere dayanarak sağlanan zilyetlik koruması, aynı şekilde, mülkiyet veya rehin hakkına ilişkin ayni hakkın korunmasında (TMK m. 763/II, m. 989/II) aynı etkiyi yaratır.

1586 Doktrinde bir kısım yazarlar aksini savunsa da, davada hak ya da daha üstün hak, zilyetliğe ilişkin hak karineleri ile ortaya konulabilir. Aksini savunan yazarlar, zilyetlikten doğan hak karinelerinin taşınır davasında rol oynamayacağı görüşündedirler[52].

bbb. Taşınır Davasının Niteliği

1587 Taşınır davası, zilyetlik olgusunu esas alan üstün hakka dayanan bir *eda davası*dır. Davacı zilyetliğin kendisine tanıdığı kendi üstün hakkına dayanarak taşınırı geri istemektedir. Davalının dava konusu taşınır üzerinde nispi bir alacak hakkı bulunduğu durumlarda, davacı geri almaya yetkili olmadığı durumlarda, hakkının tanınmasını isteyebilir ki bu durumda bir tespit davası söz konusudur[53].

1588 Taşınır davasındaki iade talebi, maddi haktan değil, zilyetliği olgu olarak kabul eden hakka dayandığından, istihkak davasından farklı olarak haktan ayrılıp ayrı bir talep olarak devredilemez[54].

ccc. Kararın Kesinliği

1589 İstihkak davası için kesin hüküm Taşınır davaları hak karinelerinden hareketle, maddi hukuk uyuşmazlığını çözdüğü ve yukarıda açıkladığımız üzere, davada maddi hakların tartışıldığı, özellikle davalının üstün hakkına dayanma imkanına sahip olduğu düşünüldüğünde ve hatta davalının davacının o şey üzerinde bir hakkı olmadığını, onun da eşyayı rıza dışı elde ettiğini ortaya koyma imkânı olduğu dikkate alındığında, dava sonunda verilen karar tarafları yönünden kesin hüküm teşkil eder[55]. Bu görüşün sonucu olarak da artık mülkiyete dayalı hak (istihkak) davası, açılamayacağı savunulmuştur[56].

---

52 **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s.190 vd. Bu konuda ayrıca bkz. **BURCUOĞLU**, Hak Karineleri, s. 493 vd.

53 **AKİPEK**, Menkul, s.108; **ÖZAKMAN**, Menkul, s. 489.

54 **AKİPEK**, Menkul, s. 63-64; **ÖZAKMAN**, Menkul, s.508.

55 **HOMBERGER**, ZGB Art.934, N.19; **ÖZAKMAN**, Menkul, s. 491.

56 **HOMBERGER**, ZGB Art.934, N.19; **ÖZAKMAN**, Menkul, s. 491.

1590 *Akipek* ise, kararın niteliğine davacının taşınır davasında zilyet olmak hususundaki belirli ve somut bir hakka dayanıp dayanmamasına göre farklı sonuçlar bağlamaktadır; davacı talebini somut ve belirli bir hakka dayandırmamışsa kararın kesin hüküm teşkil etmeyeceğini savunmaktadır[87].

1591 Bize göre de davayı açmak için aranan hukuki olguların gerçekleşmediği, davanın hak düşürücü süre içinde açılmadığı, pasif (davalı) sıfatı yokluğundan dava reddedildiği ve de davalı maddi hakkına dayanan bir savunma yapmadığı durumlarda taşınır davası teşkil etmez[88].

dd. Konusu

1592 Zilyetlik davası sadece taşınırlara ilişkindir[89]; taşınmazları konu almaz. Bu sebeple taşınır davası ismini taşımaktadır. Taşınmazın bütünleyici parçası haline gelen taşınırlar da taşınırlar artık taşınmazın hukuki geleceğine tabi olduğundan onlara uygulanmaz. Eklentilerin ise taşınmazdan bağımsız varlığı söz konusu olduğundan taşınır davasına konu olabilir.

1593 Taşınır eşyanın konusunu hayvanlar da oluşturabilir. Ancak bir başkasının arı kovanına uçan arı oğulu örneğinde göçülen kovan maliki mülkiyeti kazandığından taşınır davası söz konusu olmaz (TMK m.774 II). Doğal güçler, özellikle enerji fiilen maddi olarak hakimiyete elverişli olmadıklarından taşınır davasına konu olmazlar.

1594 Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazları taşınır hükümlerine tabi tutuğumuzdan, örneğin; zilyetlik tapusuz taşınmazlarda mülkiyete karine teşkil eder.

1595 Doktrinde tartışmalı olmakla birlikte, Yargıtay uygulamasında olduğu üzere[90], söz konusu bu taşınmazların taşınır davası ile korunabileceğini savunmaktayız[91]. Özel hukuka tabi eşyalarda, taşınırlarda da uygulanır[92].

---

87 **AKİPEK**, Menkul. s. 108.

88 **STARK**, ZK ZGB Art 934, N.26; **AKİPEK**, Menkul. s. 118-119; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 196.

89 Gemiler ve uçan hava araçları için bkz. **AKİPEK**, Menkul. s. 22-23; **ÖZAKMAN**, Menkul. s 484.

90 Y., İBK 09.10.1946 T., 12/6; Y., HGK, 12.06.1963 T., 8-30/26, 13.07.1966 T., 8/223 (başka kararlar için bkz. **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 33.

91 Aksi görüş için bkz. **ACEMOĞLU**, s.1051; **ÖZAKMAN**, Menkul. s. 484. Bu görüş tapusuz taşınmazlarda kimsenin hak karinesinden yararlanamayacağını, taşınmazlarda ancak hakkın varlığını ispat edenin hakkının korunacağını kabul etmektedir **ÖZAKMAN**, Menkul. s.513. Bkz. **GÜRAL**, s. 86 vd.

92 **AKİPEK**, Menkul. s.24-25; Aksi görüşte olan Özakman, tapusuz taşınmazlarda hak karinelerinden faydalanamayacağından uygulamanın soz konusu olmadığını belirtmektedir **ÖZAKMAN**, Menkul. s.484, 487.

ee. Tarafları

1596 Taşınır davasında, davacı önceki zilyet; davalı halihazır (şimdiki) zilyettir.

aaa. Davacı Sıfatı

(1). Genel Olarak

1597 Davacı sıfatı, taşınırı iyiniyetli olarak kazanan önceki zilyede aittir. Davacı sıfatı, zilyetlikleri kötüniyetle veya rıza dışı sona erdirilen iyiniyetli önceki zilyetlerdir. Davacının taşınır davasında, zilyetliğini olgu olarak dayandırdığı hakkın aynî hak ya da nispî bir hak olması fark yaratmaz; ama zilyetliği bir hakkın olgusu olduğunu iddia edebilecek bir önceki zilyet olması gerekir. Klasik örneği verirsek, tavuğu başkasının bahçesine yumurtlayan kişi taşınır davası açamaz.

1598 TMK m.991 II önceki zilyedin, zilyetliğini iyiniyetli elde edememiş olması halinde, sonraki zilyede dava açamayacağını düzenlemiştir.

(2). Asli Zilyet ve Fer'i Zilyet

1599 Zilyedin asli zilyet veya fer'i zilyet olması fark yaratmaz. Örneğin, intifa hakkı sahibi de kuru mülkiyet sahibi de rıza dışı sona eren dolaylı -asli- zilyetliğine dayanarak, taşınır davasını açabilir.

1600 Asli zilyet, fer'i zilyedin zilyetliği gasp edildiğinde, fer'i zilyet eşyanın geri alınması için asli zilyede karşı taşınır davası açamaz[C3]. Zira, TMK m.986 II c.2, fer'i zilyet, kendi fer'i zilyetliğine ilişkin karineyi asli zilyede karşı ileri süremez. Fer'i zilyet, zilyetliğin gaspa karşı korunmasına ilişkin TMK m.982 hükmünden yararlanabilir. Fer'i zilyedin, zilyetliğine esas hakka esas hukukî ilişkiden dolayı taşınmazın teslimini talep hakkı saklıdır.

(3). Dolaysız Zilyet ve Dolaylı Zilyet

1601 Zilyedin dolaylı zilyet veya dolaysız zilyet olması fark yaratmaz. Dava konusu eşyanın dolaysız zilyedin elinden çıkması halinde, dolaysız zilyet gibi, dolaylı zilyet de zilyetliğini kaybeder. Her iki kademeli zilyedin zilyetliklerini olgu olarak dayandırdıkları menkul davasındaki talepleri birbirinden bağımsızdır. Dolaylı ve dolaysız zilyetlerin talepleri teknik

[C3] ÖZAKMAN, Menkul, s. 495.

olarak değilse de, müteselsil bir talep hakkına benzer nitelikli taleplerdir[104].

1602 Dolaylı zilyedin açtığı taşınır davasında, eşyanın kime teslim edileceği hususu tartışılabilir. Dolaylı zilyet, taşınır davasında, kural olarak, eşyanın önceki dolaysız zilyede teslimini talep edecektir. Eğer önceki dolaysız zilyede eşyanın geri verilmesi mümkün olmazsa veya eski dolaylı zilyet artık zilyetliği yeniden elde etmek istemezse, eşya dolaylı zilyede teslim edilecektir. Bu konudaki kanun boşluğunun yukarıda önerdiğimiz şekilde, BGB § 869'daki çözüme benzer şekilde, hâkim tarafından doldurulması gerektiğini savunmuş idik[105]. Davacı –dolaylı zilyet- bu talebini terditli talep olarak taşınır davasında ileri sürecektir.

1603 Eğer dolaylı fer'i zilyet, dolaylı zilyedin aslî zilyetliğini kabul etmezse, dolaylı zilyedin zilyetliği rıza dışı sona ermiş olacağından, dolaylı zilyet dolaysız zilyetten eşyanın geri verilmesini talep edebilir.

(4). Birlikte Zilyet

1604 Paylı (müşterek) zilyetlerden, zilyetliği kısmen veya tamamen rıza dışı sona eren her bir zilyet, zilyetliğin geri alınmasını talep edebilir; ancak iadenin birlikte zilyetlerin hepsine yapılması gerekir[106]. Birlikte zilyetlerden biri zilyetliği bir üçüncü kişiye devretmiş ise, emin sıfatıyla edinme söz konusu olduğundan (TMK m.988), taşınır davasının uygulanması söz konusu olmaz.

1605 Elbirliği ile zilyetlikte ise, tüm zilyetler birlikte hareket etmek zorundadırlar; tek başlarına dava açma yetkileri yoktur[107]. Tüm malikler malın yönetim ve tasarrufu için aldıkları karar uyarınca bir elbirliği ile zilyet tarafından devir yapılmışsa, yine TMK m.988 anlamında emin sıfatıyla zilyetten kazanım söz konusudur.

(5). Hizmet Zilyedi

1606 Hizmet zilyedi, davacı vekili olarak yetkilendirilmemişse, önceki iyiniyetli zilyet adına taşınır davası açamaz.

---

[104] **ÖZAKMAN**, Menkul, s. 506.

[105] **AKİPEK**, Menkul, s. 56 **ÖZAKMAN**, Menkul, s.505. Bkz **ANTALYA**, EH II, N. 831.

[106] **AKİPEK**, Menkul, s. 56 **ÖZAKMAN**, Menkul, s.506.

[107] **AKİPEK**, Menkul, s. 56 **ÖZAKMAN**, Menkul, s.506.

bbb. Davalı Sıfatı

1607 Taşınır davasında, davalı sıfatı taşınırın hâlihazır zilyedidir[108]. Hâlihazır zilyetten önceki zilyetlerin, zilyetlikleri sona ermiş ise, taşınır davası onlara yöneltilmez; önceki zilyet rıza dışında çıkan taşınmaza bu aradaki zilyetlere, uğradığı zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

1608 Taşınır davası kademeli zilyetlikte hem hâlihazır -doğrudan- zilyede hem de dolaylı zilyede karşı açılabilir[109]. Doğrusu dolaysız zilyede karşı açılan dava eşyanın geri verilmesini sağlar. Sadece dolaylı zilyede açılan davada zilyetliğin olgu olarak tanınması talep edebilir; iade talepli bir davanın dava aşamasında dolaysız zilyede asli müdahalesi için yöneltilmesi gerekir.

1609 Taşınır davası tüm paylı zilyetlere yöneltilir. El birliği zilyetliğinde de tüm ortaklar birlikte zorunlu dava arkadaşı durumundadır.

1610 Taşınır davasında, hâlihazır zilyedin (davalının) zilyetliği kötüniyetli kazanmış olması söz konusu ise dava kötüniyetli hâlihazır zilyede yönelir. Taşınır davasında, taşınırın zilyetliği kendi elinden rıza dışı çıkmış ise, iyiniyet veya kötüniyet ayrımı yapılmaksızın, dava hâlihazır zilyede karşı açılır.

1611 Zilyetlik davası sadece hâlihazır zilyede değil, ondan haksız olarak zilyetliği ele geçirmiş dolaysız zilyede, örneğin hırsıza karşı da açılabilir[110]. Davalı iyiniyetinin kısmen korunduğu durumları (TMK m. 990, 989 II hükümlerine dayanarak), davada savunmasında, yasal cevap süresi içinde def'i olarak ileri sürebilir.

1612 Zilyetliğin tamamen korunduğu duruma da (TMK m.988 hükmüne de) zilyet savunmasında dayanabilir. Bunlara ilaveten davalı, mevcut zilyet durumunun dayandığı üstün hakkının bulunduğunu ve/veya davacının da kötüniyetli olduğunu (TMK m.991 II) ve/veyahut taşınırın kendi elinden rıza dışı çıktığı savunmasında bulunabilir. Davalının ispatla yükümlü olduğu üstün hakkın çürütülmesine ilişkin olarak da karşı savunma yapabilir.

---

[108] BGE 71 II 90 E.2. **AKİPEK**, Menkul. s. 59. **ÖZAKMAN**, Menkul. s.507.

[109] **ERNST**, BSK ZGB Art.934. N.11 ff.

[110] **STARK**, BK ZGB Art.934. N.7.

ff. Haksız Kazanımın İadesinde Temel Kriter Olarak: İyiniyetli Kazanım ve Kötüniyetli Kazanım

aaa. Genel Olarak

1613 Önceki zilyedin taşınır davasındaki iade istemi, taşınır davasındaki olgular bakımından önceki zilyedin (davacının) kazanımının iyiniyetli olmasına (TMK m.991 II), hâlihazır zilyet olanın üstün hakkının çürütülmesi hallerinden biri olan kazananın kötüniyetli olmasına bağlanmıştır (TMK m. 991 I). Zilyetliği rıza dışı kazanma hali de en geniş anlamıyla bir kötüniyetli kazanımdan daha ağır bir kazanımdır.

1614 Yine, TMK m.988 hükmünde, emin sıfatıyla kazanılan eşyada, kazanımın iyiniyetli olması kaydıyla tasarrufta bulurma yetkisi olmasa bile kazanım korunmaktadır[1]. TMK m.989 II'de rıza dışı çıkmış olsa bile açık arttırmadan veya pazardan iyiniyetli kazanımda geri verme yükümlülüğü devam etse de, geri isteyen eşyanın bedelini ödemek durumunda kalmaktadır[2]. Yine rıza dışı çıkmış olsa da, iyiniyetli para veya hamiline yazılı senet kazanımı korunmaktadır. Bu hükümlerde görüldüğü üzere, haksız kazanımda, iyiniyet veya onun karşı kazanımı kötüniyet önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple iyiniyet kavramı üzerinde kısaca duralım; kötüniyet de zaten iyiniyetli olmama durumudur.

bbb. İyiniyetle Kazanım

1615 İyiniyeti, mazur görülebilir şekilde, var olarda bir hukuki eksikliği bilmeme veya bilemeyecek durumda olmada haklı olma şeklinde tanımlayabiliriz[3].

---

[1] *"... bir kimsenin zilyetliği, malik sıfatıyla ve bu sıfatı muhafaza iradesiyle hareket eden kişinin rızasına dayanıyorsa, o takdirde "emin sıfatı ile zilyetlik" söz konusu olur. Trafik kaydının mülkiyeti saptayan sicillerden olmadığı ve otomobilin menkul mal hükmünde bulunduğu Yargıtay'ın kökleşmiş içtihatları gereğidir. Bu menkul malın Nuri tarafından Mehmet Yılmaz'a, onun tarafından da B... Galeri aracılığıyla davalı H.Avni'ye satılarak zilyetliğinin devredildiği, bu bakımdan da önce Mehmet, daha sonra da H.Avni adına, şahsi bir hak olarak değil, ayni bir hakkın, diğer deyişle mülkiyet hakkının oluştuğu açıktır..."* Y., 4. HD., 30.11.1982 T., 9252 E., 10981 K., (KİB).

[2] **NOMER/ ERGÜNE**, s.51. *"... Görülüyor ki kanun iyi niyetin korunması hususunda, emaneten bırakılan mallarda, sahibinin elinden rızası olmadan çıkan mallar hususunda bir ayrım yapmıştır. Bu ayrım şu düşünceye dayanmaktadır: malı başkasına emaneten bırakan kimse az çok risk altına girmiş ve emaneten verdiği şeyin alan tarafından başkasına geçirilmesi tehlikesini göze almış sayılabilir. Oysa bir malı rızası olmadan elinden çıkaran kimsenin böyle bir riske önceden katlandığı söylenemez. Böyle olunca, bir malı iyiniyetle iktisap eden 3. şahsın menfaati, malı emaneten veren kimsenin menfaatine tercih edilmekte, rızası olmadan malını elinden çıkaran kimsenin menfaatine ise feda edilmemektedir..."* Y., 4. HD., 22.4.2013 T., 2012/7908 E., 2013/7507 K.; Y. HGK., 25.9.2002 T., 2002/4-608 E., 2002/643 K. (KİB).

[3] Diğer tanımlar için bkz. **ANTALYA/ TOPUZ**, MHG. s. 323 vd.

1616 Eşya hukukunda zilyetliğin haksızlığını iyiniyet yönünden değerlendirirsek, zilyedin iyiniyetli olabilmesi için, *hukuki eksiklik* bulunmalıdır: zilyetlikteki kazanımın haksızlığı, yani kazanımdaki devredenin zilyetliği tasarruf yetkisinin bulunmasındaki eksikliktir[114].

1617 Zilyedin kazanımdaki haksızlığı yani tasarrufta yetkisi olmadığını eksikliği bilememesi, *mazur görülmelidir*. TMK m.3 II hükmü, durumun gereklerine göre gerekli özeni göstermeyen -mazur görülmeyen- kişi, iyiniyet iddiasında bulunamaz. Zilyetliği kazanan hukuki eksikliği *bilmemeli veya bilecek durumda olma*malıdır. Bir kazanımın iyiniyetli ya da kötü niyetli bir kazanım mı olduğu, kazanıma ilişkin tüm hal ve şartların değerlendirilmesi ile belirlenir.

1618 Öyleyse, zilyetliğin haksızlığında iyiniyet[115], zilyedin, kazandığı zilyetlikte mazur görülebilir bir şekilde, önceki zilyedin zilyetlikteki tasarruf yetkisindeki eksiliği bilmeme veya bilemeyecek durumda olmada haklı olmamadır[116]. Zilyedin bilmeye ilişkin göstermesi gereken özen ölçütü, dürüstlük kuralındaki dürüst bir ortalama normal bir kişinin aynı durum ve şartlarda göstermesi gereken özenli davranıştır.

1619 Zilyetliği kazananın temsilcisinin bilmesi veya bilmemesi zilyetten ayrı değerlendirilir[117]. Alman hukukunda, BGB § 166'da düzenlendiği üzere, hem temsilcinin, hem de temsil edilenin iyiniyetli olması gerekir[118].

1620 Bazı özel kanunlarda, taşınırlar üzerindeki bazı haklar bakımından bir takım sicillerin tutulması zorunluluğu getirilmiştir; bu sicillerin bir kısmı taşınır üzerindeki hakkı zilyetlik dışında alenileştiren kamuya açık sicillerdir.

1621 Örneğin; 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Hakkındaki Kanunun 22. maddesi, finansal kiralama sözleşmelerinin Birlik tarafından tutulan özel sicile zorunlu kaydını düzenle-

---

[114] BGE 103 II 186, 188 E.2a. **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.290.

[115] Karş. BGB § 166.

[116] **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.290.

[117] **JÄGGI**, BK ZGB Art.3, N.137 ff; **RIEMER**, BK ZGB Art.54-55, N.47 ff; **GAUCH/ SCHLUEP/ SCHMID**, N.1448.

[118] **NOMER/ ERGÜNE**, s. 60, dn.128.

mektedir. Bu siciller kamuya açık olarak aleniyeti sağladıklarından, hiç kimse sicildeki kaydı bilmediğini ileri süremez; bu sicillere kayıtlı haklara ilişkin tasarruf yetkisinin eksikliğini kazanan bilmediğini ileri süremez[119].

1622 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu m.4 I, taşınır rehni siciline zorunlu kayıt öngörmektedir. Bu sicilin aleni olduğu TRK m.2 I k, m.8 I'de vurgulanmıştır. Sicilin aleniliği gereği sicildeki kayıtlar bakımından, herkes TMK m.3 anlamında kötüniyetli sayılır[120].

1623 Karayolları Trafik Kanunu'na göre, tutulan motorlu araçların trafik sicilleri görüşümüze göre, taşınır mülkiyetini koru alan satışta mülkiyeti saklı tutma kaydının tutulduğu noter sicili özel sicil olup, kamuya açıklığı sınırlıdır. Yine de, bu sicilleri inceleme ve tasarruf yetkisinin belirlenmesi konusunda kazananın gerekli ve yeterli özeni göstermesi gerekir; aksi takdirde iyiniyeti kartışılabilir. Motorlu aracı satın alacak kişi, aracın ruhsatını, satış anında sicildeki yetkisini ve tasarruf sınırlamalarını öğrenmek konusunda özen göstermelidir. Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satışın kaydedildiği Noter Sicilini incelemede özen daha zayıf olarak değerlendirilmelidir.

1624 Kötüniyet, tam tersine, zilyedin, kazandığı zilyetlikte mazur görülemeyecek bir şekilde, önceki zilyedin zilyetlikteki tasarruf yetkisindeki eksikliği bilme veya bilecek durumda olmada haklı olmamasıdır. İyiniyetin arandığı an, eşyanın zilyetliğinin kazanıldığı andır; kazanımdaki eksiliğin sonradan öğrenilmesi iyiniyeti ortadan kaldırmaz[121].

ccc. İyiniyetin Karine Olması

1625 İyiniyetin aksi ispatlanabilir -adi- karine olduğu TMK m.3 I'de düzenlemiştir[122]: Kanunun iyiniyete sonuç bağladığı TMK m.988, 989 II, 990 991 I ve II'de, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.

---

[119] *"... Finansal Kiralama Kanunu'ndaki finansal kiralama sözleşmesinin noterliğe tecil edileceği ve tescilden sonra üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki ayni hak iktisaplarının kiralayana karşı ileri sürülemeyeceğine dair düzenleme kapsamında Medeni Kanun'un 988. maddesinde düzenlenen emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle mal iktisabına bir istisna getirildiği ve davalı şirketin iktisabının iyiniyetli olması durumunda dahi korunmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davasının kabuluyle..."* Y., 19 HD., 21.2.2017 T., 2016/2816 E., 2017/1331 K. (KİB).

[120] **ANTALYA/ ACAR**, Taşınır Rehni, s. 46 vd.

[121] **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N 291; **STEINAUER**, I. N.432.

[122] **ANTALYA/ TOPUZ**, MHG, s. 343 vd.

gg. Hukuki Olguları

aaa. Genel Olarak

1626 *Özakman*, taşınır davasının hukuki olgularını, zorunlu olgu ve seçimlik olgu olmak üzere ikiye ayırarak incelemektedir[123]: Zorunlu hukuki olgu, önceki zilyedin zilyetliğini iyiniyetli olarak kazanmış olması; seçimlik hukuki olgular ise, halihazır zilyedin üstün hak iddiasının çürütüldüğü hallerden birisidir; taşınırın önceki zilyedin elinden rıza dışında çıkmış olması veya halihazır zilyedin kötü niyetli olmasıdır.

1627 Verdiğimiz tanımdan anlaşılacağı üzere biz de aynı yaklaşımla taşınır davasının hukuki olgularını belirleyebiliriz:

- Önceki Zilyedin (Davacının) Kazanımının İyiniyetli Olması,
- Halihazır Zilyedin (Davalının) Üstün Hak İddiasının Çürütülmesi Hukuki Olgusu Olarak (Alternatifli (kümülatif olarak):
  - ✓ Ya Halihazır Zilyedin (Davalının) Zilyetliği Kötüniyetli Kazanmış Olması
  - ✓ Ya da Taşınırın Önceki Zilyedin (Davacının) Elinden Rıza Dışı Çıkmış Olması[124].

bbb. Önceki Zilyedin (Davacının) Kazanımının İyiniyetli Olması

1628 Önceki zilyedin kazanımı da iyiniyetli olmalıdır. TMK m.991 II, önceki zilyedin taşınır davası açabilmesi için iyiniyetli olmasını aramıştır. Burada aranan iyiniyet, zilyedin, kazandığı zilyetlikte mazur görülebilir bir şekilde, önceki zilyedin zilyetlikteki tasarruf yetkisindeki eksiliği bilmeme veya bilemeyecek durumda olmada haklı olmamasıdır.

1629 Önceki zilyedin zilyetliği kazanımı anında kötüniyetli olduğu davalı tarafından ispatlandığında taşınır davası reddedilecektir. Her iki dava tarafının zilyetliğinin kötüniyetli olduğu durumlarda, Kanun hâlihazır zilyedin durumunu üstün tutmuştur[125].

---

[123] **ÖZAKMAN.** Menkul. s.451.

[124] BGE 103 II 186 E 2a

[125] **ÖZAKMAN.** Menkul. s.504.

ccc. Hâlihazır Zilyedin (Davalının) Üstün Hak İddiasının Çürütülmesi

1630 İyiniyetli önceki zilyedin (davacının), zilyetliğini geri alabilmesi için hâlihazır zilyedin (davalının) üstün hak iddiasını çürütmek durumundadır. Davacı, hâlihazır zilyedin üstün hak iddiasını iki şekilde çürütebilir:

1631 Hâlihazır zilyedin (davalının) zilyetliği kötüniyetli kazanmış olduğunu veya taşınırın zilyetliğinin kendi elinden rıza dışı elden çıkmış olduğunu ispatlayarak çürütebilir. Davacının bu iki alternatiften birini ispatlaması, davalının üstün hakkını çürütmek için yeterlidir. Bu iki alternatif dışında davacının diğer üstün hak iddiaları, örneğin; kendisinin asli olarak hakkı kazandığı söz konusudur. Davalı da kendi üstün hakkını ortaya koyabilir[26].

1632 Üstün hakkına ilişkin hukuki olguları ispat yükü, davacıdadır; davacı hak karinelerinden yararlanabilir.

(1). Hâlihazır Zilyedin (Davalının) Zilyetliği Kötüniyetli Kazanmış Olması

1633 Davacının, davalının üstün hakkını çürütmek için, sadece hâlihazır zilyedin (davalının) zilyetliğini kötüniyetli kazanmış olduğunu ispatlayarak çürütmesi yeterlidir.

1634 TMK m. 991 hükmüne göre, "*Bir taşınırın zilyetliğini* ***iyiniyetle edinmemiş*** *olan kimseye karşı önceki zilyet, her zaman taşınır davası açabilir*". Örneğin; (A)'nın taşınırını hırsız (B) çalsa, ondan da üçüncü bir kişi (C) elinden zorla alsa, ilk hırsız (B) gasp edene -(C)'ye- taşınır davası açamaz. Aynı hırsız (B) malı emanetçi (D)'ye verse, emanetçi (D) de bunu kötüye kullanarak başka birine (E)'ye satsa, hırsız (B), taşınırı emanetçi (D)'den veya malı satın alan (E)'den taşınır davası ile isteyemez.

1635 Davayı açacak olan önceki zilyedin de kötüniyetli olmaması gerekir. TMK m.991 II hükmü, hem önceki hem de sonraki zilyetliği kötüniyetle kazanmış ise, "*iki kötü zilyetten hâlihazır zilyet tercih edilmelidir*" (*in pari turpitudine melior est condictio possidentis*) ilkesine uygun olarak, hâlihazır zilyedi diğerlerine üstün tutmuştur[27]. Hak sahibinin talebini istihkak davası ile ileri sürebilme hakkı saklıdır.

---

[26] **STARK**, BK ZGB Art.936, N.12 ff; **ERNST**, BSK ZGB Art.936, N.8.

[27] **STARK**, ZGB Vorbem. Art. 930-937, N.47; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 105; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s.196; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.193.

1636 Kötüniyeti, zilyedin, kazandığı zilyetlikte mazur görülemeyecek bir şekilde, önceki zilyedin zilyetlikteki tasarruf yetkisindeki eksikliği bilme veya bilecek durumda olmada haklı olmaması şeklinde tanımlamış idik[28]. Örneğin, hâlihazır zilyedin, eşyanın önceki zilyedin elinden rızası dışında çıktığını veya eşyanın devreden kişinin emin sıfatıyla edinmediğini veyahut tasarruf yetkisi olmadığını bilen veya bilmesi gereken zilyetliği devralandır.

1637 Zilyetliği kazanmasında zilyetliği devredenin mazur görülemeyen haksız kazanımını anlayan veya bu konuda hayatın olağan akışıyla bağdaşmayan, şüpheli ve karanlık noktaları olduğu anlaşılabilir olduğu halde, zilyetliği buna rağmen kazanan kişi kötüniyetlidir. Emin sıfatıyla kazanılan eşyalarla ve zilyedin rızası dışında çıkan taşınırlar için kötüniyetli hâlihazır zilyede karşı taşınır davası açılabileceği düzenlenmiştir.

1638 *Paylı zilyetlikte* paydaşların birinin kötüniyeti diğer paydaşların iyiniyetini ortadan kaldırmaz. Tam tersine *elbirliği ile zilyetlikte* ise, birinin kötüniyeti tümünün iyiniyetini ortadan kaldırır.

1639 Zilyetliği kazanan hâlihazır zilyedin temsilcisinin kötüniyeti, temsil ettiği kişinin iyiniyetini kaldırır. Temsilin iradi veya kanuni temsil olması fark yaratmaz[29].

1640 Günümüzde, Alman hukukunun etkisiyle iyiniyetin hem kazananda hem de temsilci de birlikte olması gerektiği, birindeki kötüniyetin kazanımın kötüniyetli olması için yeterli olduğu kabul edilmektedir. Davacı, TMK m.991 I hükmünde düzenlenen, hâlihazır zilyedin (davalının) zilyetliği kötüniyetli kazanmış olduğuna dayandırdığı taşınır davasını, bir süreye tabi olmaksızın *her zaman açabilir.*

(2). Taşınırın Önceki Zilyedinin (Davacının) Elinden Zilyetliğin Rıza Dışı Çıkmış Olması

(a). Hukuki Olguları

1641 TMK m. 989 I hükmüne göre, "*Taşınırı çalınan, kaybolan ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan zilyet, o şeyi elinde bulunduran herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir.*"

---

[28] *".. Diğer deyişle "eğer zilyet" a) gerek intikali yapan kimsenin ehliyet veya selahiyetinde gerek muamelenin şartlarında, şeyin zilyetliğini kendisine muteber bir şekilde geçirmeye mani bir sebebin bulunduğunu bilmiyorsa ve b) bilmeyişi mazur görülebilir mahiyette ise, başka bir ifadeyle ahvalü vaziyete göre beklenen ihtimam ve dikkati sarfettiği halde bilemeyecek durumda ise o hüsniniyetli bir zilyettir.." Y.. 3. HD.. 30.1.2013 T.. 2013/218 E.. 2013/1351 K. (KİB).*

[29] **AKİPEK**, Menkul. s. 54. **ÖZAKMAN**, Menkul. s 503.

1642 Davacının, davalının üstün hakkını çürütmek için, sadece taşınırın kendi elinden zilyetliğin rıza dışı çıkmış olduğunu ispatlayarak çürütmesi yeterlidir. Örneğin; (A)'nın bilgisayarını çalan (B), bunu iyiniyetli (C)'ye satıp teslim etmişse; (A), iyiniyetli (C)'ye karşı, TMK m.991 dayanarak değil de, TMK m.989'a dayanarak beş yıl içinde taşınır davası açabilir; (C) kötüniyetli olsa idi, TMK m.991 I'e dayanarak her zaman taşınır davası açabilirdi.

1643 TMK m.989 I hükmü, rıza dışı elden çıkmış eşyaları (Abhanden gekommene Sachen) konu alır. Rıza dışı çıkmaya TMK m.989 I hükmü çalmayı, kaybolmayı örnek olarak vermiştir. Zilyetliğin rıza dışı kaybedilmesi yeterlidir; Zilyetliğini kaybeden önceki zilyedin kusurlu olup olmaması; kusurunun çeşidi önem arz etmez[130].

1644 Bir kere zilyetlik rıza dışı elden çıktıktan sonra, sonradan iyiniyetli olarak kazanılsa da, TMK m.933'teki emin sıfatıyla zilyetten kazanım olsa dahi, sonraki zilyetlerin hukuki durumu korunmaz[131]. Burada bir kere rıza dışı elden çıkan, her zaman rıza dışı elden çıkmış sayılır genel ilkesi uygulanır. Örneğin, (A)'nın sahibi ve zilyet olduğu aracı çalan (B), bunu iyiniyetli (C)'ye satsa ve o da iyiniyetli (D)'ye kiralasa bile (D)'nin iyiniyeti korunmaz.

1645 Zilyetliğin rıza dışı çıkma halleri ile zilyetliğin rıza dışı sona erme hallerini birbirine karıştırmamak gerekir. Eşyanın rıza dışında elden çıkmasında, zilyetlik her zaman rıza dışı sona ermiş olur; ama tersine, zilyetliğin rıza dışı sona erdiği her halde, eşya rıza dışı elden çıkmış olmaz[132]. Örneklersek, bir taşınmazı kiralayan kiracı (B), malik (A)'nın rızası olmaksızın kiralananı (C)'ye alt kiraya vermesi durumunda, (A) dolaylı zilyetliğini rıza dışı kaybetmiş olur; fakat eşya onun elinden rıza dışı çıkmamıştır. Örnekten devam edersek, (A) zilyetliği kendi elinden rızaen kaybettiğinden, TMK m.989 I dayanarak, taşınır davası açamayacak; hâlihazır zilyedin kötü niyetli olması durumunda ise, davalının kötüniyetli olduğu olgusunu düzenleyen TMK m.991 I hükmüne dayanarak taşınır davası açacaktır.

1646 Rıza dışı elden çıkma halinde açılacak taşınır davası, konu bakımından sınırlandırılarak, para ve hamiline senetler bakımından iyiniyetli kazanımlar tam korunmuştur (TMK m.990).

---

[130] NOMER/ ERGÜNE. s.54.

[131] HINDERLING. SPR V/1. s. 474 f. SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, N 304.

[132] NOMER/ ERGÜNE. s.54.

1647 Kazanım yeri bakımından sınırlandırılarak, açık arttırma, pazar veya benzeri yerlerden iyiniyetli kazanımlar kısmen korunarak, davacı kazanım bedelini ödeme yükümlülüğü altına sokulmuştur (TMK M.989 II).

1648 Son olarak, iyiniyetli zilyet aleyhine açılacak davalar beş yıllık hak düşürücü süreye tabi tutulmuştur (TMK m.989 I); kötüniyetli zilyetler bakımından ise süre sınırı bulunamamaktadır (TMK m.991).

1649 Rıza dışında zilyetliği sone eren her zilyet, taşınır davası açabilir. Rıza dışı sona erdirilen zilyetliğin asli veya fer'i zilyet ya da dolaylı zilyet veya dolaysız zilyet olması fark yaratmaz.

(b). Rıza Dışı Elden Çıkma Halleri

1650 Rıza dışı elden çıkmaya kanunda "*çalınma*", "*kaybolma*" örnekleri verilmiştir.

1651 TMK m.989 I hükmü, "rıza dışı" terimi yerine "*iradesi dışında*" terimini kullanmıştır. "*İrade*" teriminin sadece zilyedin iradesini esas alması sebebiyle dar olduğundan rıza kelimesini tercih etmekteyiz. Rıza dışı kaybetme, sadece zilyedin davranışından değil, doğa olaylarından, hatta zilyedin zilyetlik iradesinde aranan ayırt etme gücü olmaması dolayısı ile de gerçekleşebilir. Zilyedin iradesine dayanmayan, kanunun ifadesi ile "*herhangi bir şekilde elinden*" zilyetlik çıkışları da, zilyetliğin rıza dışı kaybı olarak değerlendirilecektir.

1652 Kaybolan eşyalar, hâkimiyetin zilyetliği devir ve terk iradesi olmaksızın, iradi olmayan bir fiille sona ermesidir. Hizmet zilyedinin ya da ayırt etme gücü olmayan zilyedin elinden çıkma[33] da rıza dışı elden çıkmış eşya hükmündedir.

1653 Çalma dışında, dolandırıcılık veya görevi kötüye kullanma suretiyle elden çıkan eşyalar rıza dışı elden çıkmış eşya niteliğindedir[34]. Rıza dışı çıkma, unutulma, kaybetme gibi kendi fiiliyle elinden rızası dışında çıkmış olabileceği gibi, doğal sebeplerle, örneğin sel, fırtına, deprem vb. veya başka bir araçla da rıza dışı elden çıkma söz konusu olabilir[35].

---

[33] TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 162; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 192.

[34] TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP, s. 163; OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, s. 105; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 191.

[35] AKİPEK, Menkul, s. 27; ÖZAKMAN, Menkul, s. 492.

1654 Zilyetliğin devri geçerli olduğu halde, devre esas sebep işlem - borçlandırıcı- işlem, örneğin: satış sözleşmesi, kira sözleşmesi vb. geçersiz ise, zilyetlik anlaşması sebep işlemden soyut olduğu ve zilyetlik rızaen devredilmiş olduğundan, taşınır davası söz konusu olmaz[36]. Bu durumda, zilyetliğin sebepsiz kazanım (*condictio possessionis*) olması sebebiyle sebepsiz zenginleşme ilişkisi kapsamında veya istihkak davasıyla ya da dönüşüm ilişkisi kapsamında eşyanın iadesi gündeme gelir[37]. Zilyetlik rızaen devredilmesine rağmen mülkiyetin devri gerçekleşmemişse, örneğin; devredenin tasarruf yetkisi eksıklığı söz konusuysa veya sebebe bağlı olarak tasarruf işlemi geçersiz ise, taşınırın iadesi mülkiyet hakkına dayalı istihkak davası ile gerçekleşir[38].

(c). Dava Süresi

(aa). Rıza Dışı Elden Çıkmış Eşyada

1655 Davacı, TMK m.989 I'de düzenlenen taşınırın kendi elinden zilyetliğin rıza dışı çıkmış olduğu herkese karşı beş yıl içinde taşınır davası açabilir. Kötüniyetli zilyede karşı açılacak taşınır davası ise süreye tabi değildir.

1656 Beş yıllık süre, hak düşürücü süre niteliğindedir[39]; zira TMK m.989 I dava hakkının ortadan kalkmasından bahsetmektedir. Bu niteliği dolayısıyla hâkim tarafından re'sen nazara alınır. Beş yıllık süre, zilyetliğin rıza dışı olarak elinden çıktığı andan itibaren işlemeye başlar; hak sahibinin rıza dışı olgusunu bilmesi veya bilmemesi önemli değildir[40]. Sürenin zamanaşımı niteliğinde olmadığından, durması veya kesilmesi söz konusu olmaz. Bunların dışında TBK'nın sürelere ilişkin diğer hükümleri kıyasen uygulanır.

1657 Doktrinde beş yıllık sürenin geçmesi halinde taşınırın zilyetlikle kazanımı için aranan olgular söz konusu ise, ayni hak iktisabının söz konusu olabileceği belirtilmektedir. Eğer davalı taşınırın mülkiyetini zamana-

---

[36] **ÖZAKMAN**, Menkul, s. 492.

[37] **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 162; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 92; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 192. **AKİPEK**, Menkul, s. 44. **ÖZAKMAN**, Menkul, s. 494.

[38] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.106. **NOMER/ERGUNE**, s.51, dn.109; **ERTAŞ**, N.322; **AYAN**, s. 114.

[39] **AKİPEK**, Menkul, s. 111; **ÖZAKMAN**, Menkul, s.511.

[40] **STARK**, BK ZGB Art.934, N.28.

şımı ile kazanamamış ise, davacının bu süre bittikten sonra istihkak davası açma hakkı saklıdır.

1658 Bu konuda doktrinde farklı görüşler ileri sürülmüştür: Doktrindeki hâkim görüş ve İsviçre Yargı uygulaması[41], TMK m.989 I'deki taşınır davasındaki beş yıllık sürenin geçmesiyle, iyiniyetli zilyedin rıza dışı çıkan eşyanın mülkiyetini kazanacağını savunmaktadır.

1659 Katıldığımız diğer azınlık görüşü ise[42], TMK m.763 II hükmünün TMK m.989 II'den farklı hukuki olguları olduğundan, örneğin malik olmak üzere devralma gibi ve tasarruf yetkisindeki eksikliği daha dar olarak mülkiyeti devir yetkisi olmama ile sınırladığından, her durumda TMK m.989 II olgularının gerçekleşmesi otomatik olarak TMK m.763 II'nin olgularının da gerçeklemiş olduğunu göstermez. Ancak söz konusu olguların bazı durumlarda eş zamanlı olarak gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu da belirtmek gerekmektedir.

(bb). Kötüniyetle Kazanımlara Karşı

1660 Kötüniyetli zilyet olan davalıya karşı açılacak davalarda, her hangi bir süre söz konusu değildir. Kötüniyetli zilyet her zaman önceki zilyet tarafından iade talebine muhatap olabilir.

(aaa). Hukuki Sonucu

1661 Taşınırın çalınma, kaybolma ya da iradesi dışında başka herhangi bir şekilde elinden çıkan davacının, rıza dışı elden çıkan eşyayı geri isteme hakkı (Rückforderungsrecht) söz konusudur.

1662 Önceki zilyedin geri isteme hakkını mutlaka dava yoluyla ileri sürmesi zorunlu değildir. Hak sahibi önceki zilyedin talebi üzerine, halihazır zilyet eşyayı geri verebilir; geri vermez ise, zilyedin dava açma hakkı saklıdır.

(bbb). İyiniyetin Korunması

1663 TMK m. 988 emin sıfatıyla zilyetten rızaen zilyetliği iyiniyetli edinen kişinin korunmasını düzenlemiştir. TMK m.988'i ayrıca inceleyeceğiz.

---

[41] BGE 109 II 319, 322; 112 III 1, 2.

[42] **STARK**, BK ZGB Art.936, N.5; **HAAB/SCHERRER**, ZK ZGB Art.714, N.68; **LIVER**, SPR V/1, s 390.

1664 İyiniyetin rızaen elden çıkma halinde korunması ise, sadece iki halde söz konusudur: TMK m.989 II hükmüyle açık arttırmadan, pazardan ya da benzeri eşya satandan iyiniyetle edinmede ve TMK m.990 hükmüyle para ve hamile yazılı senetlerin iyiniyetle kazanımında. Şimdi bu halleri inceleyelim:

1665 Açık arttırmadan, pazardan ya da benzeri eşya satandan iyiniyetle edinmede iyiniyetin eksik korunma etkisi söz konusudur[43]. İyiniyetin bu etkisi, taşınır davası için zilyetliğin rıza dışından çıkması, bazı kazanım yerlerinden kazanım bakımından sınırlandırılması, ticari yaşamda istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yöneliktir[44]. Kazananın külli ve cüzi haleflerı bu korumadan yararlanır. Kötüniyetli zilyetlik kazanımlarında bu hüküm uygulanmaz; kötüniyetli kazananın küllı veya cüzi haleflerinin iyiniyetli olması sonuca etkili değildir.

1666 Bu taşınır, açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan **iyiniyetle** edinilmiş ise; iyiniyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası, ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir (TMK m.989 II). Örneğin; Yargıtay'a konu olan bir olayda, TMK m.989 II belirtilen yerlerden kazanımda bulunmayan kuyumcu, çalınma malı bilerek alma suçundan beraat etmiş olsa bile, malı çalınan kişiden, verdiği altını veya onun bedelini isteyemez[45].

1667 Diğer konularda **iyiniyetli** zilyedin haklarına ilişkin hükümler uygulanır (TMK m.989 III).

1668 Açık arttırma ile satıştan, eşyanın ihtiyari açık arttırma (TBK m.274) veya cebri açık arttırma ile yapılan satışlar anlaşılır. Açık arttırmanın mahkeme veya bir kamu otoritesi izni veya aracılığıyla yapılması önemli değildir. Önemli olan açık arttırmanın aleni olarak yapılmış olmasıdır. Bu sebeple icra memurunun pazarlık yoluyla satışı da TMK m.989 II kapsamında kabul edilir[46].

1669 Diğer yandan internette yapılan açık arttırmaların da, TMK m.989 II kapsamında değerlendirilmesi gerektiği tartışılmaktadır[47]; biz ortamın

---

[43] Geniş bilgi için bkz. **İNCEOĞLU**, s. 311 vd.

[44] **STARK**, BK ZGB Art.924, N.7.

[45] Y., HGK, 18.03.1988 T., 4-187/226 (KİB).

[46] **AKİPEK**, Menkul, s. 89; **ÖZAKMAN**, Menkul, s.496.

[47] **ERNST**, BSK ZGB Art.934, N.21b.

sanal olmasının TMK m.989 hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmediğini düşünmekteyiz.

1670 Pazardan edinmeden anlaşılması gereken, aynı cinsten eşyaların tüketicilere alenen sunulduğu yerden edinmedir. Ancak pazarda pazarlanan eşyanın da o pazarda satışa sunulmasının olağan olması gerekir. Sebze pazarında, bir saat alınması durumu TMK m.989 I kapsamı dışında kalır. Borsa da pazar olarak değerlendirilmelidir; hatta TMK m.990 kapsamında tam koruma da tartışmaya değerdir[48]. İnternet ortamı pazar kavramı dışındadır[49].

1671 Benzeri eşya satımıyla uğraşan tacirden, eşyanın iyiniyetli edinimi de korunmuştur. Örneğin; Yargıtay, galeriden alınan otomobilin trafik kaydında da malik olandan kazanımını korumuştur[50]. Benzeri eşya satımıyla uğraşan tacir, aynı nitelik ve özellikteki malları belirsiz sayıda ticari işleme konu yapan kişidir[51].

1672 Tacir kavramı, TTK anlamında bir kavram değildir; bu sebeple tacir olarak ticaret sicilinde tescil edilmiş olması veya vergi kaydının bulunması gerekli değildir. Devredenin olağan olarak kendi adına ticari faaliyette bulunmak üzere hukuki işlemler yapan kişi olması yeterlidir.

1673 İyiniyetli eşyayı edinen hâlihazır zilyet, eşyanın iadesini o eşya için ödediği meblağın kendisine iadesi halinde geri vermekle yükümlü olur. Rıza dışı çıkmış olsa bile iyiniyetli kazanım halinde davacının ödeyeceği devir bedeli bir *çözüm bedeli*dir (Lösungsrecht). İyiniyetli kazananın halefleri de bu korumadan yararlanır. Satıcının zapta karşı garantiden doğan sorumluluğu saklıdır. Alıcının zapttan doğan seçimlik taleplerle olan ilişkisi ayrıca değerlendirilmelidir[52].

1674 Davalının talep edebileceği miktar sadece eşyaya açık arttırmada, pazarda veya benzeri eşyayı satana ödediği miktara eşit meblağdır. Sözleşme masrafları da bedele dahil edilir[53]. Ödenen, devri bedelinin karşı ta-

---

[48] **STARK**, BK ZGB Art.934. N.37 f.

[49] **ERNST**, BSK ZGB Art.934. N.21a.

[50] Y. 11 HD., 18.03.2004 T., 2003-8253/2668 (KİB).

[51] **ERNST**, BSK ZGB Art.934. N.21.

[52] Bu konuda bkz. **ERNST**, BSK ZGB Art.934. N.45 ff.

[53] **ERNST**, BSK ZGB Art.934. N.24.

rafta kaldığı süre için ödediği bedele ilişkin faiz talep edemez[654]. Ödediği meblağı talep ettiği andan itibaren bedele temerrüt faizi işlemeye başlar.

1675 Davalı ödediği bedelin iadesini davada itiraz niteliğinde bir savunma olarak, taşınır davasından sonra da ayrı bir davada isteyebilir. Davalının devri bedeli için hapis hakkı varsa onu kullanabilir[655]. Davada devri bedelini talep etmemesi, bu hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez[656].

1676 Davacının halihazır zilyetten taşınır davası ile eşyayı geri alabilmesi için TMK m.989 II hükmünde ödediği bedeli, iyiniyetli zilyede edinenlerden –satanlardan- farklı hukuki sebeplerle talep edebileceği kabul edilmektedir[657]:

1677 Davacı ilk olarak TBK m.49'da düzenlenen haksız fiil hükümlerine dayanarak uğradığı zarar kapsamında ödediği semenin tazminini talep edebilir. Ödenen bedeli geri veren satıcının, bunu sebepsiz zenginleşme talebi konusu yapabileceği tartışılmaktadır.

1678 Sözleşme ilişkisi kapsamında alıcı, zapta karşı garanti sorumluluğu kapsamında satış bedelinin iadesi seçimlik hakkını kullanarak satıcıya başvurmuşsa, artık çözüm bedelini talep edemez. Davacı taşınır davasında çözüm bedelini dava ederek almışsa, bu zapta karşı sorumluluk davasında ödenen çözüm bedelinden mahsup edilir. En son durumda ise davacı vekaletsiz işgörme hükümlerine de dayanabilir.

1679 Para ve Hamiline yazılı senetleri kazanmada iyiniyetin tam koruma etkisi söz konusudur: para veya hamiline yazılı senetlerin iyiniyetli kazanımı, kazanımdaki tasarruf yetkisinin bulunmaması eksikliğini tamamen giderir.

1680 İyiniyetin korumasındaki amaç, ticari yaşamda tedavül eden para ve senetlerin dolaşım güvenliğinin ve istikrarın sağlanmasıdır[658]. Bu konu bakımından sınırlama sadece rıza dışı zilyetliğin kaybında söz konusudur. Kazananın külli ve cüzi halefleri bu korumadan yararlanır. Zilyetliğin

---

[654] **AKİPEK**, Menkul. s. 97. **ÖZAKMAN**, Menkul. s. 497.

[655] BGE 71 II 90 E.2. **STARK:** BK ZGB Art.934. N.46. **ERNST**, BSK ZGB Art.934. N.46. **SCHMID/ HÜRKLIMANN KAUP**, N. 311.

[656] Aksi görüş bkz. **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 208.

[657] Bu konuda bkz. **AKİPEK**, Menkul. s. 97 vd.

[658] **STARK**, BK Vorbem Ar. 930-937. N33. Art 935. N.3. **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**. N.310

kötüniyetle kaybında uygulanmaz; kötüniyetli kazananın külli veya cüzi haleflerinin iyiniyetli olması sonuca etkili değildir.

1681 Zilyet, iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile, para ve hamile yazılı senetleri **iyiniyetle** edinmiş olan kimseye karşı taşınır davası açamaz (TMK m. 990). Örneğin; Yargıtay hamiline yazılı çekleri, kötüniyetle alındığı ispat edilmediği sürece kazanımı korumuştur[655].

1682 Para, tedavülde bulunan yerli veya yabancı kâğıt veya madeni parayı ifade eder; antika ve koleksiyon paraları TMK m.990 kapsamı dışındadır[656].

1683 Davalı davada para veya hamiline yazılı senedi iyiniyetle kazandığını iddia ederse, taşınırı geri verme yükümlülüğünden kurtulur. Davalının iyiniyet savunması, TMK m.3'e göre karinedir. Davacı bunun aksini ispatla yükümlüdür. İsviçre Federal Mahkemesi, özellikle bankaların iyiniyetli olabilmeleri için göstermeleri gereken özen seviyesini daha ağırlaştırmıştır[661]. Hamiline senetler de TMK m.990 kapsamında düzenlenmiştir. Senedin zilyedinin korunması, senede bağlı hakkın sahibi sayılmasının sonucudur. Tren, vapur veya ulaşım biletleri ile sinema, tiyatro vb. biletler bu kapsamda değerlendirilmez[662].

1684 Zilyetliği kaybeden kişi -önceki zilyet-, hâlihazır zilyedin hak karinesini çürüterek yani onun kötüniyetli zilyet olduğunu ya da zilyetliğin rıza dışı çıktığını ispat ederek, eşyanın iadesini hâlihazır zilyetten talep edecektir[663].

1685 Davacı önceki zilyedin herhangi bir ayni ya da nispi bir hakka dayanması zorunlu değildir. Bu sebeple zilyetliğe bağlı hak karineleri davalı veya davacı yararına uygulanabilir. Her taraf karşı tarafın karinesinin karine olgularının maddi bir hakka dayanmadığını ileri sürerek de çürütebilir. Hukuk doktrinin çoğunluğu[664] ve İsviçre Federal Mahkemesi'nin uygulaması[665] bu yöndedir. Davalının iyiniyeti, TMK m.3'e göre karine olduğundan, davalının kötü niyetli olduğunu davacı ispat edecektir.

---

[655] Y. HGK. 01.07.1992 T. 11-292/423 (KİB).

[656] **STARK**, BK ZGB Art.935. N.6. **ERNST**, BSK ZGB Art.935. N.3.

[661] BGE 100 II 8 E.4a; 131 III 418 E.2.3.3.

[662] Aksi görüş: **ÖZAKMAN**, Menkul. s.502.

[663] **AKİPEK**, Menkul. s.65-67 vd.; **ÖZAKMAN**, Menkul. s.509-511.

[664] **ACEMOĞLU**, s.26; **ÖZAKMAN**, Menkul. s.488 vd., 510 vd., 511; **AKİPEK**, Menkul. s. 81, 107; Aksi görüş **BURCUOĞLU**, Hak Karineleri, s. 513 vd.

[665] BGE 1959 I 119.

1686 Davacı ikinci imkân olarak, davalının kötüniyetini değil de, zilyetliğinin rıza dışı sona erdiğini ispat edebilir. Davalı bu durumda zilyetliğinin iyiniyetli olduğunu iddia ederek kısmen, örneğin: açık arttırmadan aldığından veya tamamen, örneğin: eşyanın para niteliğinde olduğundan korunması gerektiği savunmasında bulunabilir.

1687 Yine davalı, zilyetliği rıza dışı kaybettiğini, ancak eşya üzerinde -maddi- bir hak elde ettiğini kanıtlayarak, davacının iddiasını etkisiz bırakabilir. Böylelikle davalı davacının iddialarını ispat etmesine karşın, davalı kendi üstün hakkını ortaya koyarak iddiaya karşılık verebilecektir. Davalının hakka dayanan savunmasına davacı, ondan daha üstün hakka dayanarak karşılık verebilir.

1688 Davacı kendisinin de önceki zilyet olduğunu ispat edecektir. İyiniyet, TMK m.3'e göre karine olduğundan, davacının kötüniyetli olduğunu, davalı ispat edecektir. Zaten davacının kötüniyetli kazanımı taşınır davasında kazanımın haklı olmadığını ortaya koyar.

1689 Doktrinde bir kısım yazarlar, haksız olarak, davalının bu savunmasının davacının menkul davasına dayanması imkânını ortadan kaldırdığını kabul etmektedir[68].

1690 Görüşümüze göre davalı, davacının kötüniyetli olduğunu ileri sürebileceği gibi, bununla birlikte veya bundan bağımsız olarak iade etmemeyi haklı kılan -maddi- bir hakkı olduğunu da ispatlayabilerek davacının iddialarına karşı kendisini savunabilir. Davacı da bu durumda davalının hakkından daha üstün bir hakkı olduğuna dayanarak karşılık verebilir.

1691 Davalının, davacının iddialarına karşı savunmalarına tekrar değinirsek, davalı, davacının önceki zilyetliğini kötüniyetle elde ettiğini ve kendisinin kötüniyetli olarak zilyetliği kazanmasına karşın, taşınır üzerinde üstün hak elde ettiği savunmasında bulunabilir.

1692 Davacı davalının bu savunmasına daha üstün hak iddiası ile karşılık verebilir. Davacının ispatla yükümlü olduğu taşınır davasının hukuki olgularına karşı davalı tarafın ispatı hakkı saklıdır. Diğer yandan davalı, davacının ispatla yükümlü olduğu alternatifli taşınır olgusuna ilişkin her iki durumda da, eşyayı emin sıfatıyla zilyetten kazandığı savunmasında bulunabilir.

---

[68] **STARK**, BK ZGB Art.936, N.19; **HINDERLING**, Besitzklage, s.15; **ÖZAKMAN**, Menkul, s.504; **AKİPEK**, Menkul, s.68

1693 Alman Hukukunda, BGB § 100 III; davalıya ek bir savunma imkânı olarak, davacının zilyetliği rızaen kaybettiği savunmasını yapma imkânı da vermektedir. Doktrinde tartışmalı olmakla birlikte, biz bu konuda zilyetliğini rızaen kaybeden kimsenin menkul davası açamayacağını; gasp sebebiyle zilyetliğin korunması hakkının ise saklı olduğunu kabul etmekteyiz[667].

1694 Davalı her iki durum için de, o şey üzerinde bir hakkı veya davacının hakkından üstün hakkı olduğunu ispat ederek zilyetliği geri vermekten kurtulabilir. Örneğin; (A)'nın zilyet olduğu eşyayı (B) çalıp, (C)'ye satıp teslim ettiği; sonrasında eşya tekrar çalınıp ve el değiştirip tekrar (A)'ya geri döndüğü ihtimalinde, (C)'nin taşınır davasında (A), tercihe şayan hakkı olduğunu ispat ederek davayı reddettirebilir.

1695 Yukarıda açıkladığımız üzere, davalı, davacının üstün hak iddiasına karşın kendi daha üstün hakkına ilişkin itiraz niteliğindeki aşağıdaki savunmalarını şu şekilde özetleyebiliriz[668]: Davacının kazanımının kötüniyetli olduğunu (TMK m.991), iyiniyetli davalı, davacının kendi zilyetlik döneminde eşyayı rıza dışı elde ettiğini, kendi feri zilyetliğine temel teşkil eden üstün hakkı olduğunu, asli olarak aynı hakkı kazandığını, iyiniyetli haksız zilyet olarak zorunlu ve yararlı giderlere ilişkin tazminat ödeninceye kadar geri vermekten kaçınma hakkı olduğu (TMK m.994 I) savunmasında bulunabilir.

1696 Davalının önceki zilyedin o şey üzerindeki hakkı bulunmadığı, kendisinin hakkı bulunduğu savunmasını yapıp yapamayacağı tartışılmaktadır[669].

1697 Soruna olumsuz bakan bazı yazarlar, taşınır davasının hukuki niteliğinin zilyetliğe bağlı hak karinesi olduğunu kabul etmekle birlikte, davalıya taşınır davasının niteliği ile bağdaşmayan maddi bir hakka dayanan savunma hakkının verilmemesi gerektiğini savunmaktadır[670]. Buna karşın klasik anlamda zilyetliğe bağlı hak karinelerini ve bilinegelen hakları menkul davasının hukuki dayanağını oluşturmadığını savunan görüşler de söz konusudur[671].

---

[667] **BURCUOĞLU**, Hak Karineleri, s. 523.

[668] **ERNST**, BSK ZGB Art.934, N.12.

[669] Bu konuda bkz. **BURCUOĞLU**, Menkul, s. 493 vd.

[670] **AKİPEK**, Menkul, s.81.

[671] Bu görüş ve bu görüşlerin farklı sonuçları için bkz. **BURCUOĞLU**, Hak Karineleri, s.502 vd., s.513 vd.

1698 Katıldığımız hâkim görüş, davalının maddi hakkına dayanan bir savunma yaparak eşyayı iadeden kaçınabileceğini kabul etmektedir[172]. Aynı hak davacı içinde söz konusudur. Zilyetliğe bağlı hak karinelerinin bir hakka sahip olup olmadığını ispat ederek çürütme imkânına her iki taraf da sahiptir.

1699 Davacının maddi hakka dayanan iddiası veya davalının maddi hakka dayanan üstün bir hakkı olduğu savunması yapılıp, bunun ispatlanması durumunda verilen karar da kesin niteliktedir. Davacı maddi hak iddiasında bulunmamışsa veya davalı bu yönde savunmada bulunmamışsa, iadenin kabulü veya reddi kararı kesin değildir; davalının mülkiyete dayalı iade talebi saklıdır.

1700 Doktrinde bazı yazarlar, zilyetliğe bağlı hak karinelerinin istihkak davasında uygulanmayacağı görüşünü savunmaktadırlar[173]. Katıldığımız hâkim görüş, zilyetliğe ilişkin hak karinelerinin istihkak davalarında uygulanacağını kabul etmektedir[174]. Böylelikle taşınırlarda hak sahipliğinin karineler yoluyla belirlenmesi imkânı kolaylaşmaktadır. Hak karineleri istihkak davasının en önemli uygulama alanıdır.

IV. TAŞINIR DAVASININ DİĞER DAVALARLA OLAN İLİŞKİSİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

A. Zilyetliği Koruyan Davalarla

1701 Zilyetliğin temelinde yatan maddi hakka dayanmama bakımından, zilyetliği koruyan davalarla taşınır davası birbirine yakınsa da aralarında aşağıdaki farklar söz konusudur[175]:

1. Nitelikleri Bakımından

1702 Her ikisi de aslında zilyetliği koruyan davalardır, şu farkla ki; gaspa karşı zilyetliği koruyan dava ve diğerleri sadece doğrudan doğruya zilyet-

---

[172] **STEINAUER**, I. N.465; **BERGER-STEINER/SCHMID**, OFK ZGB Art.934 N. 6; **ACEMOĞLU**, s 26; **ÖZAKMAN**, Menkul s 488 vd., 510 vd., 511.

[173] **ÖZAKMAN**, s 451.

[174] **HOMBERGER**, ZGB Art.930, N.14-21; **HAAB**, ZK ZGB Art.641, N.35; **STARK**, Vorbem 930-937, N.5-6; **BURCUOĞLU**, Hak Karineleri, s 516.

[175] **AKİPEK**, Menkul, s.121 vd.; **ÖZAKMAN**, Menkul, s.513 vd.; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s.197 vd.; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s.112 vd.; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 203 vd.; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 197.

lik olgusuna dayanmakta, zilyet sadece zilyet olduğu (yani fiili hâkimiyeti bulunduğu) için korunmaktadır.

1703 Bu davalar, istihkak davalarından farklı olarak maddî bir hakka veya taşınır davalarından farklı olarak zilyetliği olgu olarak kabul eden hak karinelerine dayanmamaktadır. Zilyetliğin gasp edilmesi veya zilyetliğe saldırıda bulunulması yeterlidir. Maddî hak ya da üstün hak kural olarak tartışılmaz; istisnaî olarak derhal ileri sürüp ispat edilebilmesi halinde söz konusu olabilir.

1704 Taşınır davası ise, zilyetliği karine olgusu olarak kabul eden hak karinelerine dayanan davadır. Bu davada, davacı davalının hak karinesini çürütmek ve kendi hak karinesinin bulunduğunu veya hak karinesinin üstünlüğünü ispat etme durumundadır.

2. Konusu Bakımından

1705 Taşınır davası sadece taşınırları konu alırken, zilyetliğin korunması davaları hem taşınırları hem de taşınmazları konu alır.

3. Hukuki Olguları Bakımından

1706 Taşınır davasının uygulama alanı hukuki olguları bakımından, gasp sebebiyle zilyetliğin geri verilmesinden daha geniştir. Zilyetliğin korunması davaları sadece gasp ile elden çıkan eşyalar hakkında uygulanır; buna karşın taşınır davaları, taşınırın önceki zilyedin elinden rıza dışı çıktığı gasp dâhil diğer hallerde veya hâlihazır zilyedin kötüniyetli olduğu tüm hallerde uygulanır.

1707 Bu sebeple, taşınır davasının davalısı, hâlihazır rıza dışı taşınırı kazanan zilyettir veya kötüniyetli olarak taşınırı kazanan zilyettir. Gasp sebebiyle geri verilme davasının pasif tarafı –davalısı- gasp eden veya onun küllî halefidir. Taşınır davası zilyetliğin rıza dışı veya kötüniyetle elden çıkma fiillerinde koruma getirirken, zilyetliği koruyan davalar gaspın yanında saldırıya karşı saldırının önlenmesi şeklinde koruma öngörmüştür.

4. Dava Süreleri Bakımından

1708 Gasp sebebiyle açılan zilyetliğin korunması davalarında dava süresi, taşınır davasına nazaran nispeten dar bir zaman süresi içinde açılması gerektiği niteliklerine uygun olarak öngörülmüştür. Taşınır davasında ise dava süresi sadece iyiniyetli davalı bakımından ve belirli yer veya kişi-

lerden kazanımlar için söz konusudur. Kural olarak, taşınır davası süreye tabi değildir.

1709 Gasp sebebiyle eşyanın geri verilmesi davası, gasp fiilinin ve failinin öğrenildiği tarihten itibaren iki ay ve her durumda gasp fiilinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. Taşınır davası ise, eşyayı açık arttırma, pazar ve bazı yerlerden edinen iyiniyetli kişiler yönünden, rıza dışı elden çıkmadan itibaren beş yıl ile sınırlandırılmış; kötüniyetli zilyetler yönünden ise bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

5. Kararın Niteliği Bakımından

1710 Zilyetliğin korunması davalarında, gasp halinde geri verme davası dâhil verilen karar kesin hüküm niteliğinde değildir. Buna karşın taşınır davalarında verilen karar, tartışmalı olmakla birlikte, yukarıda incelediğimiz üzere, bu davada üstün hak için maddi hakka dayanılmış veya davalı maddi hakka dayanarak savunma yapmışsa, karar da maddi hakka dayanılarak verilmişse, kesin hüküm niteliğindedir; bunun dışında kesin hüküm niteliğini haiz değildir.

1711 Taşınır davaları yukarıdaki istisna hariç kural olarak kesin nitelikte değildir. Bu davanın açılması gasp sebebiyle eşyanın geri verilmesi davasının açılmasına engel değildir. Ancak taşınır davasında eşyanın geri verilmesine karar verilmişse, bu davadaki kabul edilen maddi olgular gasp sebebiyle iade davası için delil teşkil eder.

1712 Aynı şekilde, taşınır davasında maddi hakka dayanılarak bir hüküm verilmişse, verilen hüküm istihkak davası için kesin delil niteliğinde olacaktır. Ancak taşınır davasında verilen karar maddi hakka ilişkin bir karar niteliğinde değilse, maddi hak sahibi hakkına dayanarak istihkak davası açabilir. Bazı durumlarda taşınır davasının açılamayacağı, sadece istihkak davasının açılabileceği haller söz konusudur. Bu halleri şu şekilde belirleyebiliriz:

1713 Davacının mülkiyeti, zilyetliği elde etmeden kazanımında, örneğin: açık arttırma veya pazardan kazanım, başkasının kümesine yumurtlayan tavukların yumurtalarının tavuk malıki tarafından kazanımı, taşınır davası ile değil, istihkak davası ile korunur. Davacının önceki dolaylı zilyet olduğu ve taşınırın kendisine iadesini sağlayabilmesi için istihkak davası açması gerekir. Taşınır davası açmak için, devir öncesi önceki zilyedin dolaysız zilyet olması aranmaktadır.

1714 Zilyetliği kötüniyetle iktisap etmesine karşın taşınır üzerinde sonradan hak kazanmış olan kişi, örneğin; miras sebebiyle eşyayı kazanan mirasçı, zilyetlik rızaen devredildiğinden yalnız istihkak davası açabilir. İktisap sebebinin geçersiz olmasına karşın, taşınırı iyiniyetli olarak zamanaşımı ile kazanımı için süre geçmemişse, zilyetlik rızaen devredildiğinden, kötüniyetli kazanım hariç sadece istihkak davasına konu edinebilir.

B. Mülkiyet Hakkına Dayanan İstihkak Davası ile

1715 Taşınır davası, zilyetliği karine olgusu olarak kabul eden hak karinelerine dayanarak zilyetliği korumak ve eşyanın geri verilmesini talep hakkı vermekteyken, istihkak davası ayni (mülkiyet) hakkına dayanarak eşyanın geri verilmesini sağlamaktadır. Zilyetlik mülkiyetin (ayni hakkı) devrini sağlayan bir olgu olması, mülkiyet hakkı da zilyetlik karinelerinin karine sonucu olması itibarı ile birbirine bağlıdır[776].

1716 Farklı hukuki olgularla da olsa her iki dava da, maddi olarak haklı olanın eşya üzerindeki hâkimiyetini eşyanın geri verilmesini gerçekleştirerek sağlamayı amaçlamaktadır. Yargılama hukukunda bu iki dava arasındaki farklılık daha da kaybolmaktadır[777]. Uygulanacak hukuku belirleyecek hâkim, tarafların iddia ve savunmaları kapsamında, fakat onların nitelemelerinden bağımsız olarak, davacıya en fazla korumayı sağlayacak kuralı olaya uygulayacaktır.

1717 Aşağıdaki durumlarda, taşınır davasının söz konusu olmadığı kabul edilmektedir[778]:

- Davacı uyuşmazlık konusu eşyada hiç zilyet olmamışsa, eşyanın zilyetliği rıza dışı çıkmamış veya davalı kötüniyetli değilse,
- Zilyetliğin rıza dışı çıkmasından itibaren beş yıllık hak düşürücü süre geçmiş ise, önceki zilyet eşyayı iyiniyetli olarak elde etmemişse.

Her iki kurum arasındaki farkları şu şekilde belirleyebiliriz[779]:

---

[776] Bu konuda bkz. **ZOBL.** s. 303 ff.

[777] **GULDENER,** ZPR. s.15 ff. **VOGEL/ SPÜHLER,** ZPR 6.Kap., N.31 f.

[778] **MEIER-HAYOZ,** BK ZGB Art 641, N.84.

[779] **AKİPEK,** Menkul. s.121 vd.; **OZAKMAN.** Menkul. s.515 vd.; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP,** s.197 vd.; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR** s. 112 vd.; **AKİPEK/ AKINTÜRK** s. 203 vd.; **ÜNAL/ BAŞPINAR** s. 198.

1. Konu Bakımından

1718 Taşınır davası, isminde yer aldığı üzere sadece taşınırları; görüşümüze göre tapuya kayıtlı olmayan taşınmazları konu alır. İstihkak davası hem taşınırları hem de taşınmazları konu alır.

2. Nitelikleri Bakımından

1719 İstihkak davasını, ayni hak, özellikle mülkiyet hakkı sahibi açabildiği halde; taşınır davasını eşya üzerinde ayni hak iddia etmeyen kişiler de açabilir. İstihkak davası bir ayni hakka, özellikle mülkiyet hakkına dayandığı halde, taşınır davasında zilyetliğin dayandığı olgu olarak zilyetliğin temelinde ayni hak veya nispi hak olması fark yaratmaz.

3. Hukuki Olguları Bakımından

1720 Taşınır davasının istihkak davasına nazaran hukuki olguları itibarı ile uygulama alanı daha dardır. Taşınır davası açabilmek için davacının önceki zilyetliğinin iyiniyetli olması ve davalının da sonraki zilyetliğinin kötüniyetli olması veya zilyetliğin rıza dışı elden çıkmış olması gerekir. Bu sebeple istihkak davasının uygulama alanı daha geniştir.

1721 Emin sıfatıyla zilyet olunan eşyanın iadesi, taşınır davasının konusunu oluşturamazken, mülkiyet davasının konusunu oluşturabilir. Kişi zilyet olmadığı bir eşyanın iadesini isteyemezken, malik zilyet olmadığı bir eşyanın iadesini ayni hakkına dayanarak geri isteyebilir. Klasik örnekle açıklarsak, komşunun kümesine yumurtlayan tavuğun malikı yumurtanın iadesini sadece istihkak davası ile isteyebilir.

1722 Yine zilyetliğini rızaen devrettiği, fakat mülkiyetin bir sebeple geçersiz olduğu durumlarda, iade, tartışmalı olmakla birlikte, bir görüşe göre, sadece mülkiyete dayalı istihkak davası ile sağlanır.

4. İspat Bakımından

1723 Taşınır davasında kural olarak, davacı kendi hak karinesine dayanarak davalının hak karinesini çürütmek durumundadır. Davacı taşınır davasında, maddi hakka dayanmaksızın, zilyetliği olgu olarak alan hak karinesine ve bazı olgulara dayanacaktır. Örneğin; hâlihazır zilyedin kötüniyetli olduğunu veya rıza dışı elinden çıktığını ispat, davacının üstün hakkını ispat için yeterli olacaktır. Hâlbuki istihkak davasında, davacı ayni hakkını ispat etmek zorundadır.

5. Süreleri Bakımından

1724 Taşınır davası, rıza dışı elden çıkan eşyayı bazı yerlerden, örneğin: pazardan zilyetliği kazanan iyiniyetli zilyede (davalıya) karşı beş yıllık hak düşürücü süre içinde açılabilir; kötüniyetli zilyet için bir süre söz konusu değildir. İstihkak davasının dava açma süresi söz konusu değildir.

1725 Her iki durumda da, TMK m. 777'nin hukuki olgularını gerçekleştiren hâlihazır iyiniyetli zilyedin kazandırıcı zamanaşımı ile mülkiyeti kazanması veya TMK m. 988'e göre emin sıfatıyla zilyetten iyi niyetli kazanımla mülkiyetin kazanımı söz konusudur.

V. İYİNİYETLİ ZİLYETLİK OLGUSUNUN HAKKI KAZANDIRMASI

A. Genel Olarak

1726 Zilyetliği aleniyeti sağlama aracı olarak düzenleyen kanun, ona karineler bağlayarak ona ve onun dayandığı hakkı ispat kolaylıkları sağlamış ve onun aleniyetini sağlayarak üçüncü kişilerin var olan hukuki duruma güvenmelerini sağlamıştır[80]. Zilyedin var olan zilyetlik hukuki durumuna güvenerek zilyetliği ve buna bağlı olarak hakkı kazanan üçüncü kişilerin iyiniyetli kazanımlarının da korunması gerekir.

1727 İyiniyetli üçüncü kişilerin hukuki durumunun korunmasını kabul etmeyen Roma hukukunun "*hiç kimse sahip olduğundan fazlasını devredemez*" (*nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*) ilkesi, Cermen hukukunun etkisiyle günümüzde yumuşatılmıştır. Roma hukukunda kabul edilen ilke malikin mülkiyet menfaatini korur. TMK ise, malikin menfaati ile iyiniyetli kazanının menfaati ve kamu menfaati arasında bir denge kurmaya çalışmıştır[81]. Unutmamak gerekir ki, iyiniyetli kazanımı korumayan Roma hukuku, kazandırıcı zamanaşımı kabul etmiştir.

---

[80] Bu konuda bkz. **HUWILER**, s. 75 ff.

[81] **BERGER-STEINER/ SCHMID**, OFK ZGB Art.933, N.2: "*... Bilindiği üzere, hukukumuzda, diğer çağdaş hukuk sistemlerinde olduğu gibi kişilerin huzur ve güven içerisinde alış veriş bulunmaları satın aldıkları şeylerin ileride kendilerinden alınabileceği endişelerini taşımamaları, dolayısıyla toplum düzenini sağlamak düşüncesiyle, alan kişinin iyi niyetinin korunması ilkesi kabul edilmiştir. Bu amaçla Medeni Kanunun 2. maddesinin genel hükmü yanında menkul mallarda 988 ve 989, tapulu taşınmazların el değiştirmesinde ise 1023. maddesinin özel hükümleri getirilmiştir...*" (Y. HGK, 28.11.2012 T., 2012/1-542 E., 2012/905 K.).

1728 Türk-İsviçre yasal düzenlemesi, emin sıfatıyla zilyetliğin iyiniyetli kazanımında tam koruma; zilyetliğin rıza dışında elden çıkması durumunda iki halde ise, kısmi koruma getirmiştir. Üçüncü kişinin, iyiniyetli olsa bile, gerçek hak sahibi karşısında hiç korunmaya değer görülmediği haller de söz konusudur.

1729 TMK m.3 I iyiniyeti kanunda düzenlenen hallerle sınırladığından, iyiniyetli zilyetlik kazanımlarının korunduğu haller sadece kanunla düzenlenen üç halle sınırlıdır: TMK m. 988, 989 II ve 990.

1730 Zilyetliğin hakka ilişkin sağladığı koruyucu fonksiyonlardan biri de zilyetliği kazananın iyiniyetli olması kaydıyla eksikliği gidermesidir. Aynı zamanda kanunun iyiniyeti koruduğu durumlarda hukuki olgulardaki eksikliğin giderilerek, hukuki olgunun arandığı şartların gerçekleştiğini kabul ederek, onun hukuki sonucu doğurmasını sağlamasıdır. TMK m.989 emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetli kazanımda, tasarrufta bulunma yetkisi eksikliği söz konusu olsa bile kazanımı korumuştur.

1731 İyiniyetin taşınır davasında, eksiliğin tamamen veya kısmen giderdiği hallerde, TMK m. 989 II uyarınca ödenenin geri verilmesi koşuluyla geri verilmesini talep (kısmen korunma) ve m.990 para ve hamiline senetlerin iyiniyetli kazanımı (tam koruma) söz konusudur. Bu halleri yukarıda incelemiş idik[82].

B. Emin Sıfatıyla Zilyetten İyiniyetli Edinim

1. Genel Olarak

1732 TMK m.988 hükmü, zilyedi ve onun eşya üzerindeki fiili hâkimiyetini zilyet olması sebebiyle değil; iyiniyetli devralanının, tasarrufta bulunan zilyedin, zilyetliğinin yarattığı devre konu ayni hakta tasarrufa yetkili olduğuna -tasarruf eksiklığı bulunmadığına- olan inanca güven sebebiyle korumaktadır[83].

1733 Roma hukukunun "hiç kimse sahip olduğundan fazlasını devredemez[84]" kuralının karşıt anlamıyla, sağlıklı yaşam ilişkilerinde, normal olarak, bir kişi dolaysız zilyet olarak bir hakka dayanarak –emin sıfatıyla

---

[82] **ANTALYA**, EH II. N. 1286 vd.

[83] Konuya ilişkin Yargıtay kararları için bkz: YGHK. T.25.09.2002. E.2002/4-608. K.2002/643. YGHK. T.12.02.1986. E.1984/11359. K.1986/107.

[84] *Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.*

zilyet olandan- taşınırı devralmışsa, onun o eşya üzerinde tasarruf yetkisi olduğunun kabulü gerekir. Eğer tasarruf yetkisi eksik ise, devralan iyiniyetli ise onun kazanımı korunur.

1734 TMK m.988'e göre, bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde **iyiniyetle** mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korunur[685].

1735 TMK m.988 hükmü, TMK m.763 II hükmüyle birlikte zilyetlikle mülkiyetin kazanımını uyumlaştırmıştır. Emin sıfatıyla zilyetten zilyetliği kazanan –üçüncü- kişi, sadece zilyetliği değil, mülkiyeti de kazanır. Bu kazanımın niteliğinin asli mi yoksa devren mi kazanım olduğu ya da arada bir yerde mi olduğu tartışmalıdır[686]; bize göre ise, hukuki işleme dayanarak kazanıma ilişkin tasarruf yetkisindeki eksiklik giderildiğinden, devren kazanım söz konusudur. Korunum sadece mülkiyete ilişkin değil, sınırlı ayni haklara da ilişkindir.

1736 TMK m.988, tasarruf yetkisi olmayan iyiniyetli bir kişinin, bir eşyayı hukuki işlemle kazanımını korumayı amaçlamaktadır. Bu hüküm, bir eşya üzerindeki tasarrufta üç kişi arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir: tasarrufun hak sahibi, tasarruf yetkisi olmadığı halde hakkı devreden, -bu kişi emin sıfatıyla zilyet olarak da anılmaktadır- ve –iyiniyetli- tasarrufa hak kazanan, -bu son kişi kısaca –iyiniyetli, üçüncü kişi veya üçüncü kişi olarak da anılmaktadır-.

1737 TMK m.988 hükmü, sadece, önceki malik ile onun sözleşme ilişkisinde bulunduğu kişiden iyiniyetli kazanım yapan kişi arasındaki ilişkiyi düzenlemekte ve iyiniyetli kazanımı korumaktadır. *Zilyetliğin savunma etkisini* (Translativwirkung), TMK m.988 düzenlemiştir[687]. İyiniyetli kazanımın, *tasarruftaki geçersizliği giderici etkisi* (endgültig heilende Wirkung) söz konusudur[688]. Giderilen eksilik devirdeki tasarruf eksikliğidir.

1738 Taşınırı devreden emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetli taşınır kazanımında, kazananın iyiniyeti tam olarak korunur. TMK m.985 I'in koyduğu *karinenin fiksiyona -varsayıma- dönüştüğü* ifade edilmektedir[689].

---

[685] Bu konuda bkz. **PIOTET**, SJZ 1959, s.285 ff; **BUHLER**, ZSR 1973 I, s. 55 ff.

[686] Bu tartışmalar için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.933, N.4, 88.

[687] **TUOR/ SCHNYDER/ SCHMID**, § 91, N.38.

[688] **HAUSHEER/ JAUN**, ZGB Art.3, N.51 f. Bkz. **ANTALYA/ TOPUZ** MH. §10, IV, B.

[689] **STEINAUER**, I, N.416-417; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 201.

1739 Emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetli kazanımın tam olarak korunmasının sebebi, tasarrufta hak sahibi olan kişinin, özellikle malikin bir hukuki işlemle kendi rızası ile başkasına taşınır üzerinde bir zilyetlik durumu yaratarak, o kişiyi dış dünyada üçüncü kişiler nezdinde, TMK m.985'teki mülkiyet karinesi sonucu, taşınırın malikı imiş gibi etkili bir dış görünüş yaratmaktadır. Tasarrufta hak sahibi olan (malik), kendi rızasıyla yarattığı bu etkili dış görünüşün sonuçlarına da kendisi katlanması gerektiğinden, iyiniyetli olmak kaydıyla başkasının kazanımı tam olarak korunmuştur.

2. Hukuki Olguları

a. Eşyayı Emin Sıfatıyla Zilyetten Kazanım

aa. Konusu

1740 Emin sıfatıyla zilyet olunan eşya, sadece taşınır eşyadır. Taşınır kavramına dâhil olduğu halde, niteliği uygun olmadığından doğal güçlere, örneğin; enerjiye TMK m.988 hükümleri uygulanmaz[90]. Bir alacak hakkı, kıymetli evrakın muhtevasına dahil edilmiş ve kıymetli evrakın devri alacağın devri anlamına geliyorsa TMK m.933 hükmü uygulanır.

1741 TMK m.988 hükmü taşınmazlarda uygulanmaz. TMK m.1023 iyiniyetli taşınmaz kazanımının tasarruf eksikliğini giderici etkisini özel olarak düzenlemiştir. Taşınmazdan ayrılmış olan eklentinin devrinde TMK m.933 uygulanır[91].

bb. Emin Sıfatıyla Zilyet Kavramı

1742 Emin sıfatıyla zilyet olunan eşya (anvertraute Sachen) söz konusu olmalıdır. İyiniyetli kazanımı korunan kişi, emin sıfatıyla zilyetten taşınırı kazanan kişidir. Öyleyse emin sıfatıyla taşınırın zilyetliğini devreden kişi kimdir sorusuna cevap aranması gerekir.

1743 Emin sıfatıyla zilyet, ilk bakışta saklama sözleşmesi uyarınca taşınıra zilyet olan emanetçi olduğu şeklinde anlaşılabilir; ancak aşağıda açıklanacağı üzere diğer özel hukuk ilişkilerine dayanarak veya dayanmaksızın, önceki veya halihazır zilyedin rızasına dayanan bir zilyetlik hali olarak ondan daha geniş bir kavramdır.

---

[90] **STARK**, BK ZGB Art.933 N.8.

[91] **STARK**, BK ZGB Art.933, N. 11 ff. **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.7; **HINDERLING**, SPR V/1, s 489. Aksi görüş: **HAAB**, ZK ZGB Art.644-645, N.20; Art.930, N.25 f.

1744 Emin sıfatıyla zilyet, TMK m.989 hükmündeki düzenlemenin zıt anlamıyla hareketle belirlenmelidir. Bu sebeple, rıza dışı çıkan bir eşya üzerinde bir daha emin sıfatıyla zilyetlikte oluşmaz. Emin sıfatıyla zilyet, zilyetliğini zorla veya kaybedilme yoluyla değil, devredenin rızasına dayanarak elde eden kişi olmalıdır. Öyleyse, emin sıfatıyla zilyedi, tasarrufa yetkili hak sahibinin rızası ile –doğal iradesiyle- devraldığı eşyayı, daha sonra tekrar devraldığı kişiye büyük olasılıkla iade etmeyi düşünen zilyet şeklinde tanımlayabiliriz[92].

1745 Emin sıfatıyla zilyet öncelikle, tasarrufta hak sahibi olan, yani malikin rızası ile zilyetliği elde etmiş kişidir (TMK m. 991 II). Örneğin: (A)'nın temizleyici (B)'ye verdiği pantolonunun cebinde unutulan cüzdanda, temizleyici (B) emin sıfatıyla zilyet olmaz[93].

1746 Hatta zilyetliğin emin sıfatıyla zilyet olandan kazanana intikalinin gerçekleşmesi de önem taşımaz. TMK m.991 başvurulması zilyetliğin teslimle veya teslimsiz zilyetlik sözleşmesi ile devrinden bağımsız olarak soyut şekilde geçerlidir. Zilyetliğin havalesi ya da hükmen teslimde bu soyutluk daha belirgin ise de, bire bir eşyanın teslimi halinde, somut olayın şartlarının iyiniyete olan etkisi değerlendirilmelidir. Örneğin, teslim edilen kitaptaki bir kütüphane mührü veya kayıt bilgisi emin sıfatıyla kazanımın olduğunu fakat iyiniyetin bulunmadığını ortaya koyar[94].

1747 Emin sıfatıyla taşınırı zilyetliği devreden kişi, ivazlı veya ivazsız olarak genelde bir hukuki işleme dayanarak taşınırı kazanana rızaen devreden kişidir. Örneğin: satıcı, kiracı, ödünç alan, vekil, yüklenici, taşıyıcı, saklayan vb. malikin rızasına dayanarak, bir hukuki işlem sonucu eşyaya emin sıfatıyla zilyet olan kişilerdir.

1748 Sebep -borçlandırıcı- işlemle verilen rızada, borçlandırıcı işlemin sonradan geçersiz olması, zilyetliği devredenin geçersiz sözleşmeye göre eşyayı hak sahibine geri vermekle yükümlü olması, eşyanın üzerindeki

---

[92] **STARK**, BK ZGB Art.933. N.23a; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.298. Bu yönde bkz. Y. 4. HD. 16.11.2017 T., 2017/3623 E., 2017/7357 K.: "*...Somut olayda; davacı aracını dava dışı bir kişiye kira sözleşmesi ile kiralamış ve teslim etmiştir. Dolayısıyla araç, araç malikinin elinden rıza ile çıkmıştır. O halde emin sıfatıyla zilyetten araç iktisap eden davalının iyi niyetli olup olmadığı hususunun irdelenmesi gerekir.*" Yargıtay'ın aynı yöndeki diğer kararları için bkz. Y. 4. HD. 14.06.2017 T., 2015/11463 E., 2017/4048 K.; Y. 4. HD. 07.04.2016 T., 2016/1025 E., 2016/4703 K.

[93] Bu konudaki tartışmalar için bkz. **ERNST**, BSK ZGB Art.933. N.18; **SEROZAN**, N.623.

[94] **ERNST**, BSK ZGB Art.933. N.26.

zilyetliğin emin sıfatıyla zilyetlik olmasını engellemez[955]. Aynı şekilde sözleşmenin sona ermesi, verilen rıza üzerinde etkili değildir[956].

1749 Emin sıfatına ilişkin rıza olgusu, *doğal iradeye* nitelikte maddi fiil olduğundan[957], hukuki işlem niteliğinde beyan değildir; bu sebeple rızada hukuki işlem ehliyeti değil, ayırt etme gücü aranır[958]. Emin sıfatıyla zilyetliğin devri geçici kısa bir süre için gerçekleşirse, TMK m.988 uygulanmaz[959].

1750 Emin sıfatıyla zilyet olmak için, zilyetliği bir hukuki işleme dayanarak veya ondan bağımsız devredenin rızasının alınması yeterlidir; doğrudan tasarrufa yetkili kişiden -malikten- almaları da gerekli değildir; bu sıfatı muhafaza iradesiyle hareket eden kişinin rızasına dayanma yeterlidir[960]. Örneklersek, yazıcıları (A)'dan kiralayan (B), bozulanları tamir için (C)'ye vermişse, (C) de emin sıfatıyla zilyettir; yeter ki zilyetlik devrindeki zincir rızaen gerçekleşmiş olsun; rıza dışı olarak kesilmesin.

1751 Taşınır rıza dışı elden çıkmış olsa bile, halihazır zilyedin zilyetliğine sonradan verilen rıza, o kişiyi rıza anından itibaren emin sıfatıyla zilyet yapar[961]. Yukarıdaki örnekten devam edersek, (A) temizleyiciden cüzdanı alıncaya kadar (B)'den saklamasını isterse, (B) emin sıfatıyla zilyet olur.

1752 Doktrinde, emin sıfatıyla zilyetlikten hak kazanımının sadece ivazlı işleri kapsadığı; ivazsız işlemleri kapsamadığı iddia edilse[962] de, bu görüşe katılmamaktayız. Külli halefler, örneğin; mirasçılar, zilyetliği kanun gereği kendiliğinden *ipso iura* kazandıklarından emin sıfatıyla zilyet sayılmazlar[963].

1753 Emin sıfatıyla zilyedin iyiniyetli kişi ile tasarruf işlemi yaparken, malikin yetkili temsilcisi olarak hareket etmesi gerekip gerekmediği hususu doktrinde tartışmalıdır:

---

955 **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.7, 24, 32; **ARNET/ EITEL**, CHK ZGB Art.933, N.4.

956 **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.25.

957 **ERNST**, Eigenbesitz, s. 70 ff.

958 **STARK**, BK ZGB Art.933, N.28; **BUCHER**, BK ZGB Art.12, N.79.

959 BGE 80 II 235 E.2; **STARK**, BK ZGB Art.933, N.25b.

960 Y., 4. HD., 30.11.1092 – 9252/10981 (KİB).

961 **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 166-167.

962 **SEROZAN**, N.607, 651.

963 **STARK**, BK ZGB Art.933, N.41; **ARNET/ EITEL**, CHK ZGB Art.933, N.4.

1754 Doktrinde hâkim görüş, eğer zilyetlikle hakkı kazanan kişi, emin sıfatıyla zilyedin malikin vekili olmadığını biliyor, fakat onun tasarruf yetkisi olduğuna güveniyor ve bu güveni gösterirken tasarruf yetkisi olduğu konusunda, gerekli özeni göstermişse, ondan hak kazanımı korunacaktır[204].

1755 Azınlık görüşü ise, TMK m.988 tasarruf yetkisindeki eksikliği giderir, temsil yetkisindeki eksikliği gidermez. Bu sebeple emin sıfatıyla zilyedin, malikin yetkili temsilcisiymiş gibi hareket ettiği hallerde, üçüncü kişi iyiniyetli olsa dahi temsil yetkisi olmadığından, ondan yapılan hak kazanımı korunmayacaktır[205].

cc. Zilyetlik Çeşitlerinde

1756 *Kademeli zilyetlikte*, emin sıfatıyla zilyet genelde, dolaysız zilyettir; istisnai de olsa dolaylı zilyet olarak da emin sıfatıyla zilyetlik söz konusu olabilir[206]. Örneğin; çok kademeli zilyetlikte alt kiracı emin sıfatıyla zilyettir. Yine hükmen teslim yoluyla iyiniyetli üçüncü kişi lehine dolaylı zilyetlik tanınmışsa, yine TMK m.988 uygulanır.

1757 *Birlikte zilyetlikte*, paylı zilyetlerden her biri, diğeri karşısında emin sıfatıyla zilyet iken, elbirliğiyle zilyetlikte hiçbiri tek başına emin sıfatıyla zilyet değildir; tümünün birlikte emin sıfatıyla zilyet olarak hareket etmeleri gerekir[207].

1758 *Hizmet zilyedi*, zilyet sahibinin yardımcısı olduğundan emin sıfatıyla zilyet sıfatına sahip gibi görünse de, emin sıfatında aranan bağımsızlık söz konusu olmadığından, ondan kazanımda hizmet sahibi devre yetki vermemişse veya onayı yoksa kazanım korunmaz[208]; kazanana yardımcı olan hizmet zilyedi için de aynı kural geçerlidir.

1759 Eşlerden birinin eşya üzerindeki tasarrufu, TMK m.215 uyarınca malların yönetiminin diğerinin rızası ile diğerine bırakıldığı durumlarda, emin sıfatıyla kazanımı sağlar[209].

---

[204] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s.116; **SEROZAN**, N.605; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 64; **GÜRSOY/ EREN/ CANSEL**, s. 141; **AYAN**, s.106.

[205] **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 172 dn.5.

[206] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.26.

[207] **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 203.

[208] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.36 f; **ERNST**, BSK ZGB Art.919, N.24, Art.933, N.22; **STEINAUER**, I, N.431; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 167; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 115; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 203. Aksi görüş: **HINDERLING**, SPR V/1, s. 485.

[209] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.40, 40a.

dd. İrade Sakatlıklarının Zilyetliğin Devrine Etkisi

1760 Zilyetliğin emin sıfatıyla zilyetten kazanım mı yoksa rıza dışı kazanım mı olduğunun tespiti, zilyetliğin devrine temel teşkil eden sebepten bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Önceki zilyet (malik) ile emin sıfatıyla zilyet arasındaki sözleşmenin sonradan geçersiz olması veya sona erdirilmesi, TMK m.988 uygulanmasına engel teşkil etmez.

1761 İrade sakatlıklarının zilyetliğin devrine olan etkileri tartışılmaktadır. Bu tartışmalara kısaca göz atarsak[210]:

1762 Öncelikle zilyetliğin devrindeki rızadaki irade bozukluğu ile zilyetliğin devri borcunu yükleyen sözleşmelerdeki irade bozukluğunu ayırmamız gerekir. Zilyetliğin devri, sebep işlemden soyut işlem olduğundan, aldatma ve korkutma dâhil, irade bozukluğunun sebep -borçlandırıcı- işlemi geçersiz kılması, zilyetlik anlaşmasını etkilemez; meğerki bu irade bozukluğu zilyetliğin devrinde etkili olsun.

1763 Zilyetliğin zilyetlik sözleşmeleri, hükmen teslim, kısa elden teslim, zilyetliğin havalesi haricinde, devrine ilişkin verilen rızaya ilişkin iradenin doğal irade olup, maddi anlaşma niteliğinde olduğunu belirtmiş idik. İşte zilyetliğin devrindeki rızayı da bu kapsamda değerlendirmemiz gerekir.

1764 Ağırlıklı hâkim görüş, zilyetliğin devrindeki *yanılma* (hata) (TMK m.31 vd.) ve *yanıltma* (hile[211]) halinin, zilyetliğin devrinde etkili olmadığını[212] ve tartışmalı olmakla birlikte *korkutma*[213] halinin ise (TBK m.37-38), zilyetliğin devrindeki rızanın geçersizliğine sebep olacağını kabul etmektedir[214]. Eğer doğrudan doğruya eşyanın devrine ilişkin yanılma söz konusu ise, o zaman yanılma sonucu elde edilen zilyetliğin emin sıfatıyla zilyetliğe yol açmayacağı savunulmaktadır[215]. Gerçekten, örneğin; temiz-

---

210 Bkz. **HARTMANN**, recht. s. 136 ff.

211 BGE 121 IV 26 E.2.d. Yanılmanın zilyetliğin devrindeki rızaya etkili olmadığını kabul eden görüş için bkz. **ERTAŞ**, N.335.

212 BGE 100 II 8 E.3. **STARK**, BK ZGB Art.933, N.31; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.298.

213 **HARTMANN**, s.136, 142 ff. **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.19; **STEINAUER**, I, 430b.

214 **STARK**, BK ZGB Art.933, N.29 ff; **HARTMANN**, s.144; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.299; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 167; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 116; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 63; **GÜRSOY/ EREN/ CANSEL**, s. 135; **AYAN**, s. 104. İsviçre Federal Mahkemesi kararı için bkz. BGE 121 III 345, 347. Bu kararın incelemesi için bkz. **BOMMER/ WICHTERMANN**, recht. s. 156 f. Aksi yönde karar için bkz. BGer SJZ 1995, s. 178.

215 **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 203.

leyiciye temizlenmek üzere bırakılmış pantolonda unutulan cüzdan örneğinde, temizleyici cüzdanın zilyetliğini emin sıfatıyla kazanmamıştır. Buna karşın temizleyiciye temizlenecek pantolon yerine başka bir pantolon verildiği durumda ise, temizleyici yanılmadan etkilenmeden, emin sıfatıyla zilyet olur.

1765 Karşı görüş ise, zilyetliği devredenin iradesinin sakatlanmış olmasının hangi sebebe dayanırsa dayansın, TMK m.988'in uygulanmasına engel görmemektedir[214]. Ayni hak kazanımındaki sakatlık, zilyetliği devredenin ehliyetsizliğinden kaynaklanıyorsa, emin sıfatıyla zilyetlik kazanılmamıştır[215].

b. Yeni Zilyedin İyiniyetli Olarak Ayni Bir Hak Kazanımı

aa. Ayni Hak Kazanımı

1766 TMK m.988, zilyetliğin aleniyet aracı olarak hakkın dış dünyada yarattığı görünüm sebebiyle ondan iyiniyetli ayni hak kazanımını, mülkiyet ve sınırlı ayni hak kazanımını, korumuştur. TMK m.993'ün uygulanması için ayni hak kazanımın mutlaka teslim şeklinde maddi olarak gerçeklemesi gerekli değildir[216]; zilyetlik sözleşmeleri, havale veya hükmen teslim şeklindeki ayni hak devirlerinde de uygulama alanı bulur[217]. TMK m.998 sadece taşınırlarda iyiniyetli ayni hak kazanımını korur; taşınmazlarda iyiniyetli kazanımın eksiliği giderici etkisi TMK m.1023'te özel olarak düzenlenmiştir.

1767 Yeni zilyedin emin sıfatıyla zilyetten yeni zilyedin her türlü ayni hak kazanımını hedef tutan her türlü tasarruf işlemini konu alır; işlemin karşılıklı veya karşılıksız olması önemli değildir[218].

---

[214] **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.19.

[215] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 115.

[216] *Homberger*, teslimsiz zilyetliğin devri alternatiflerinde kazananın iyiniyeti sorununu gündeme getirmektedir. Yazar söz konusu hallerde, kazanana teslim söz konusu olsaydı aynı şartlarda bu kişiyi iyiniyetli sayacak idiysek korumanın söz konusu olacağını kabul etmektedir. Bkz. **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.933, N.19 ff. Ayrıca bkz. **HINDERLING**, SPR V/1, s. 487 Fn.75.

[217] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.81 ff.; **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.25 f.

[218] **EMMENEGGER**, FS Huwiler, s. 219 ff. Yargıtay önüne gelen bir uyuşmazlıkta kiraya verilen taşıtın üçüncü kişi tarafından iktisap edilmesi üzerine, taşıtı emin sıfatıyla zilyede bırakan önceki malikin, aktüel malike aracın ödemesi halinde taşıtın önceki malike iade edilebileceğine ilişkin karar vermiştir. Ne var ki, emin sıfatı ile zilyetten mülkiyet teslim anında kazanılır ve önceki malikin taşınırın bedelini ödeme teklifi ile kendiliğinden iade ilişkisi kurulamaz. Yargıtayın söz konusu kararı ve künyesi için bkz. *"...Davacı kendisine ait aracı dava dışı kişiye kiralamış olduğundan araç malikinin rızası ile elinden çıkmıştır. Bu noktada davalının iyi niyetli olup olmadığının*

1768 Zilyedin kazandırma yetkisinin eksik olmasına karşın, zilyetliği devrederek ayni hakkı kazandırmış olması gerekir; ayni hakkı kazanan emin sıfatıyla zilyetten bir ayni hak değil de bir nispi -alacak- hakkı kazanırsa bu kazanım eşyanın gerçek hak sahibine karşı korunmaz[220]. Örneğin: (A), (B)'nin kendine emanet ettiği bilgisayarı (C)'ye satar, fakat bilgisayarı teslim etmez ise (C) sadece alacak hakkına sahip olduğundan bu hakkı TMK m.988 kapsamında korunmaz; teslim etmiş ise korunur.

1769 Alacak hakkını malik gibi hareket edene karşı ileri süremezse de, bu hak dolayısıyla sahip olduğu hapis hakkını, ayni hak niteliği dolayısıyla ona karşı ileri sürebilir[221]. Örneğin; apartman görevlisi (A)'nın evinde emanet olarak bulunan kiracı (B)'nin ev eşyaları üzerinde kira alacağından doğan hapis hakkını (TMK m.336) kullanabilir.

1770 Sadece, iyiniyetli üçüncü kişinin kişisel hakkı sebebiyle hapis hakkının, örneğin TMK m.950 III'deki hapis hakkının kazanılmasında tasarruf eksikliğinin giderilmesi TMK m.988 kapsamında değerlendirilebilir[222]. Bütünleyici parça, asıl eşyanın hukuki geleceğine tabi olduğundan asıl eşyadan bağımsız olarak TMK m.988 hükmünün konusu olmasa da, eklenti TMK m.988 konusu olabilir[223].

bb. İyiniyetle Ayni Hak Kazanımı

1771 Kazanan üçüncü kişinin, devir anında, devredenin (emin sıfatıyla zilyet olanın) ayni hakkı devre ilişkin tasarruf yetkisi olduğunu bilmemesi veya bilemeyecek durumda olması kazanımının iyiniyetli olduğunu ifade eder[224]. İyiniyetli kazanımın aksi kötüniyetli kazanımdır (TMK m.3 I).

---

irdelenmesi gerekir. Olayla ilgili ceza soruşturması ve dosyaya sunulan deliller birlikte değerlendirildiğinde davalının kendisini başka biri olarak tanıtan kişi ile birlikte hareket ederek davacıyı zarara uğratmak istediği yönünde bir delil bulunmadığından davalı iyi niyetli kabul edilmelidir. Kaldı ki mahkemece de davalının iyiniyetli olduğu kabul edilmiştir. O halde, davacının araç mülkiyetinin tespiti davasını kazanabilmesi için davalının satış bedeli olarak ödemiş olduğu bedeli kendisine iade etmesi gerekir. Mahkemece bedelin ödenmemesi halinde davanın reddine karar verilmesi gerekirken cebrî gerçekleşmeden yazılı gerekçe ile davanın kabulü doğru değildir. Y. 4. HD. 16.09.2015 T. 2015/9610 E., 2015/9907 K.

220 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.933, N.5, 11; **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.3.

221 **OFTINGER/BÄR**, ZK ZGB Art.895, N.126 ff; **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.23; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.300.

222 **ÇETİNER**, s.265 vd.

223 Gemi ve uçaklar için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.933, N.9 ff.

224 Benzer bir tanım için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.933, N.44.

1772 İyiniyetin konusu, emin sıfatıyla devredenin tasarruf yetkisidir; kanun bu yetkideki eksikliği, yani malik olmaması veya diğer bir sebepten dolayı tasarruf yetkisinin olmamasına ilişkin eksikliği, kazananın iyiniyetli olması halinde düzeltmektedir[226].

1773 Zilyet borçlandırıcı işlem yaparak sözleşme konusu taşınırın zilyetliğini devir borcuna girmesi ama devretmemesi, tasarruf yetkisindeki eksiklik olarak değerlendirilemez; borçlandırıcı işlemdeki bu eksiklik TMK m.988 hükmü kapsamında giderilmez[227].

1774 Miras hukukunda, mirasçıların tasarruf yetkisinde eksiklik söz konusu olduğu, örneğin ön mirasçılık, tereke temsilcisi, vasiyeti yerine getirme görevlisi söz konusu olduğu durumlarda, mirasçının emin sıfatıyla sahip olduğu eşyadaki tasarrufundaki eksiklik Kanun kapsamında giderilir[228].

1775 Kazanan kazanım anında, teslimsiz kazanımda ise sözleşme anında iyiniyetli olmalıdır[229]. Devir sonrasında kazananın sonraki bilmesi, başlangıçtaki iyiniyeti kötüniyete dönüştürmez[230]. Kazananın iyiniyetinin mazur görülebilmesi değerlendirilirken, somut olayın özelliklerini hakim takdir etmek durumundadır (TMK m.4)[231].

1776 Sebep -borçlandırıcı- işlemden doğan bilgi verme ve aydınlatma yükümlüğü[232] olup olmadığı; varsa emin sıfatıyla kazananın iyiniyeti, devredenin devir yetkisi konusunda bilgilendirme yükümlüğü kapsamında değerlendirilir[233].

1777 İyiniyetin varlığı konusunda şüphe halinde, bu bilgi verme ve aydınlatma yükümlülüğü iyiniyeti ortadan kaldırır[234]. Örneğin; İsviçre Yargı uygulamasından örneklersek, ikinci el oto satışında ağırlaştırılmış özen ve bu kapsamda tasarruf yetkisi konusunda bilgi verme yükümlülüğü söz

---

226 Bu konuda bkz. **SCHMID**, SJZ 1967, s. 305 ff.

227 **HAAB/SIMONIUS**, ZK ZGB Art.714, N.46.

228 **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.31.

229 **STARK**, BK ZGB Art.933, N.79. **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.40. **ARNET/EITEL**, CHK ZGB Art.933, N.5.

230 BGE 105 IV 300, 305 E.3.

231 BGE 113 II 397 E.2. **STARK**, BK ZGB Art.933, N.49. **ARNET/EITEL**, CHK ZGB Art.933, N.5.

232 **ANTALYA**, BH GH, I, s. 15.

233 **STARK**, BK ZGB Art.933, N.50 ff.

234 BGE 131 III 418 E.2.3.2, 139 III 305, E.3.2.2.

konusudur[235]; yine kültür varlıklarının kazanımında tasarruf yetkisi konusunda ağırlaştırılmış bilgi verme yükümlülüğü aranmaktadır[236]. Bunlara antika, özellikle resim ve heykel gibi güzel sanat eserlerini dahil edebiliriz.

1778 Kamuya açık veya açık olmayan sicillerin iyiniyete olan, özellikle bilme ve mazur görülmeye ilişkin özeni kaldırıcı ve veya ağırlaştırıcı etkisi söz konusudur. Örneğin; tapu siciline kayıtlı eklentiler için iyiniyetli sayılmama etkisi söz konusudur[237]. Kamuya açık sicillerde, kayıt konusundaki yetki durumlarının bilindiği varsayılır ve diğer sicillerde ise, mazur görülme daha ağır değerlendirilir.

1779 Emin sıfatıyla kazanımda, yeni zilyedin kazanımda bulunduğu kişinin tasarruf yetkisi eksikliğini bilmemesi veya tasarruf yetkisine güvenirken de gerekli makul özeni göstermesi gereklidir. Emin sıfatıyla zilyedin temsilcisinden kazanımda da kazanan iyiniyetli olmalıdır.

1780 Kazanımda hizmet zilyedinin aracılığına başvuran veya bulunanın temsilcisinin temsil edilen adına yaptığı kazanımında da iyiniyet aranır. Hizmet zilyedinin veya temsilcinin kötüniyeti, temsil ettiği kazananın da kötüniyeti sayılır[238]. Temsilcinin iradi temsilci veya kanuni temsilci olması fark yaratmaz.

1781 Kazananın iradi *temsilinde*, hem temsil olunan hem de temsilci iyiniyetli olmalıdır[239]. Temsilci iyiniyetli, temsil olunan kötüniyetli ise, kazanım kötüniyetli kazanım niteliğindedir. Aynı kural kanuni temsilde de geçerlidir. *Stark*, doğrudan temsilde bu yaklaşımı benimsemekle birlikte; dolaylı temsilde, temsil edilen kötüniyetli olsa da temsilcinin iyiniyetli olabileceğini ve tam tersinde kazanımın korunacağını kabul etmektedir[240]. Aynı şekilde organın kazanımında da hem tüzel kişinin hem de organın iyiniyetli olması gerekir; sadece birinin iyiniyetli olması yeterli değildir[241].

---

[235] BGE 121 III 345; 113 II 397; 107 II 41; 105 IV 303.

[236] BGE 131 III 418 E.2.3.2. **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.430 f.

[237] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.53 f.

[238] **HAUSHEER/JAUN**, ZGB Art.3, N.28 ff.

[239] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.75; **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.933, N.35; **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.41; **HINDERLING**, SPR V/1, s. 486, Fn.72; **ARNET/EITEL**, CHK ZGB Art.933, N.8.

[240] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.72, 90 ve Art. 934, N.32, Art.936, N.3.

[241] **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 205.

1782 Emin sıfatıyla zilyetten yapılan iyiniyetli kazanımda, kazanımın sonraki takip eden kazanımlara olan etkisinin değerlendirilmesi gerekir. Örneklersek, (A) sahibi olduğu bilgisayarı (B)'ye emanet bırakıp teslim ettikten sonra, (B) bu bilgisayarı iyiniyetli tamirci (C)'ye satar ve teslim ederse, (C) bu bilgisayarı tamir ettikten sonra tekrar (D)'ye sattığı olayda, (C)'nin (B)'den emin sıfatıyla iyiniyetle kazanımı korunur; (D)'nin kötüniyetli olması, yani emanetçi (B)'nin tasarruf yetkisine sahip olmadığını bilmesi veya bilebilmesi onun kazanımına engel olmaz[242].

c. Zilyedin Ayni Hak Kazandırma Yetkisinin Olmaması

1783 Zilyetlikte tasarrufta bulunanın zilyet olması gerekir. Ayni hakkı kazananın korunmasının sebebi taşınırın zilyetliğinin dış dünyada yarattığı güvenin korunmasıdır. Kazanımın vasıtalı veya vasıtasız zilyetten olması fark yaratmaz.

1784 TMK m.988 sadece iyiniyetli zilyedi ayni hak kazanımında, devredenin tasarruf yetkisindeki eksikliğe karşı korumuştur. Bu koruma, emin sıfatıyla zilyedin tasarruf yetkisindeki eksikliği giderir. Sebep - borçlandırıcı- işlemdeki eksikliğe TMK m.988 etkili değildir. Başka bir deyişle iyiniyetli kazanım, sebep işlemdeki geçerliliğindeki eksikliği gidermez[243]. Örneğin; işlem, kazananın fiil ehliyetinde eksiklik olması veya başka bir kesin hükümsüzlük sebebiyle geçersiz olursa, bu geçersizliği TMK m.988 düzeltmez.

1785 Emin sıfatıyla zilyetle hakkı kazanan arasında kazanıma esas sebep - borçlandırıcı- işlem, dönme, fesih, iptal veya başka bir sebeple sona erdiğinde, borçlu sebep işlemin geçersizliğinden ayni hak kazanımı etkilenir. Bu eksiklik de TMK m.988 hükmüyle giderilemez.

1786 Malikin hukuki tasarruf yetkisinin kanun veya hukuki işlemle sınırlandığı durumlarda, malikten kazanım yapan iyiniyetli kişinin kazanımının korunacağı kabul edilmektedir[244]. Örneğin; İİK m.886 II haczedilmiş olan taşınır üzerinde üçüncü kişilerin zilyetlik hükümlerine dayanarak iyiniyetli kazanımlarının korunacağı ifade edilmiştir.

---

[242] **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 174.

[243] BGE 93 II 373, 375; **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.4.

[244] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.3, 57; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 179; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY- ÖZDEMİR**, s. 113 dn. 242; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 65; **GÜRSOY/ EREN/ CANSEL**, s. 139.

3. Taşınır Rehninin İyiniyetli Kazanımı

1787 TMK m.989 II hükmü, m.988'e paralel olarak taşınır rehninin iyiniyetle kazanımını düzenlemiştir. Bu hükme göre, "Rehnedende tasarrufta bulunma yetkisi olmasa bile, rehin konusu taşınıra iyiniyetle zilyet olan kimse, zilyetlik hükümlerine göre edinimi korunduğu ölçüde rehin hakkı kazanır. Üçüncü kişilerin önceki zilyetlikten doğan hakları saklıdır".

1788 Bu hükmü değerlendirirken, rehin hakkının alacağın feri nitelığine haiz olduğu dikkate alındığında, taşınır rehninin iyiniyetli kazanımından bahsedilebilmesi için, rehin verenin emin sıfatıyla zilyet olmasının ve rehin alanın iyiniyetli olmasının yanında, rehinle teminat altına alınan alacağın da mevcut olması gerekir[245].

4. Hukuki Sonucu

1789 TMK m.988'de belirtilen hukuki olguların gerçekleşmesinin hukuki sonucu, iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimının, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisinin olmaması halinde bile korunmasıdır. Başka bir deyişle, iyiniyetle eşyayı kazanan devredenin tasarruf yetkisi bulunmasa bile kural olarak mülkiyeti kazanır[246]. Hemen belirtelim ki, emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetli kazanım, sebep işlemin geçerliliğindeki eksikliği gidermez[247].

1790 İyiniyetle hak kazanımının aslen mi yoksa devren mi olduğu tartışılmaktadır[248]; iyiniyetli hak kazanımı görüşümüze göre, kazanımın çeşidi: hiç malik olmayan kazanım söz konusu ise asli kazanıma yakın; malik, fakat tasarruf yetkisi eksikliği söz konusu ise devren bir kazanıma yakındır; bu yönüyle TMK m.988'in düzenlediği kazanım, her iki kazanım arasında, özel kazanım olguları olan ayrı bir kazanım çeşididir[249].

1791 İyiniyet tam koruma eksikliğini giderici etkisiyle[250], mülkiyet ve ayni haktaki eksikliği gidererek, onun geçerli olmasını ve geçerli olarak hukuki

---

[245] **ERGÜNE**, s. 163.

[246] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.55 ff.

[247] **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.24.

[248] **STARK**, BK ZGB Art.933, N. 88; **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.44; **STEINAUER**, I, N.449; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 174.

[249] **HAAB/ SIMONIUS**, ZK ZGB Art.714, N.1; **ERNST**, BSK ZGB Art.933, N.44.

[250] **TUOR/ SCHNYDER/ SCHMID**, § 91, N: 38; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.302.

sonuç doğurmasını sağlar; kısaca iyiniyet tasarruf yetkisindeki eksikliği tamamen giderir; devralan, işlem konusu taşınır üzerinde ayni hak kazanır.

1792 Eğer iyiniyetli kişi eşyanın mülkiyet hakkını kazanmışsa, eski malikin mülkiyet hakkı sona erer. İyiniyetli kişi eşya üzerinde yani sınırlı bir hak kazanmışsa, malik yeni hak sahibinin sınırlı ayni hakkına katlanmak durumunda kalacaktır; diğer sınırlı ayni hak sahipleri ile olan ilişkilerinden hak kazandığı an dikkate alınarak sıraya girer; kendisinden önceki sınırlı ayni haklardan sonra yerini alır.

1793 TMK m.988 hükmü sadece ayni hakkı konu aldığından, nispi hakta, alacak hakkındaki noksanlıklar, eksiklikler ve sınırlamalar sebebiyle hak sahibini korumaz. Örneğin; sınırlı ehliyetliden kazanım halinde, TMK m.988 söz konusu olsa bile sebep -borçlandırıcı- işlemi geçersizdir[281].

1794 Buna karşın, eşlerin mal rejimlerine dahil birlikte sahip oldukları eşyalardaki tasarruf yetkisindeki eksiklik TMK m.988 kapsamında hukuki olgular varsa giderilir; ayni hak kazanılabilir[282]. Miras hukukundan doğan tasarruf yetkisi ve şartlı mülkiyetin devrinde, TMK m.988'in uygulanıp uygulanmayacağı hususu tartışmalı olmakla birlikte[283], TMK m.988 bu her iki durumda da uygulanmalıdır.

1795 İyiniyetli olarak hakkı kazanmış olan kişinin, tasarruf yetkisindeki eksikliği öğrendikten sonra, saik hatasına düştüğünü yanılma veya aldatma hükümlerine, şartları varsa dayanarak sebep işlemi onamayarak geçersizliğini; buna bağlı olarak ve buna bağlı olan tasarrufu geçersiz kılabilme hakkı saklıdır. Yine iyiniyetli hak kazananın sebep –borçlandırıcı- işlemin çeşidine bağlı olarak hukuki ayıp ya da zapta karşı garanti hükümlerine başvurma hakkı saklıdır.[284]

1796 Malik, kendi rızasını almadan tasarruf işlemi yapan emin sıfatıyla zilyetten, aralarındaki ilişkiye göre, uğradığı zararın tazmini isteyebilir.

---

[281] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.58.

[282] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.71a.

[283] **STARK**, BK ZGB Art.933, N.59 f.

[284] **STARK**, BK ZGB Art.933, N. 91 ff. **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 177; **SEROZAN**, N.641.

§ 10. HAKSIZ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU

I. GİRİŞ

A. Yasal Düzenleme

1797 TMK, m.993 ile 995 arasında haksız zilyedin özel olarak eşyayı iade sorumluluğunu düzenlemiştir. Bu kapsamda; şeyin iadesini talebe haklı zilyedin, yararlanma talebi ile zararın tazmini talebi; haksız zilyedin ise giderlerinin ödenmesi talebi düzenlenmiştir.

1798 Haksız zilyedin, zilyetliğini elde ettiği eşyayı iade etmek durumunda kalması haline, haksız zilyedin iade sorumluluğunun kapsamı ile onun ileri sürebileceği talepler, haksız zilyedin iyiniyetli haksız zilyet veya iyiniyetli olmayan haksız zilyet olmasına göre farklı olarak düzenlenmiştir. Zilyetliğin karşılıklı veya karşılıksız olması ya da bunların iade davasına konu yapılıp yapılmaması önem arz etmez. Tarafların taleplerini; iade davasında iade ile birlikte veya karşı dava içinde talep etmesi mümkün olduğu gibi; taleplerini iade davasından sonra ayrı bir davada ileri sürebilmesi de mümkündür[1].

1799 İade yükümlüsünün birden fazla olması durumunda, her bir iade yükümlüsünün durumu onun iyiniyetli veya kötüniyetli olmasına göre ayrı ayrı değerlendirilecek, farklı hükümlere tabi tutulacaktır. İyiniyetli haksız zilyedin iade yükümlülüğü ve sorumluluğu, kötüniyetli haksız zilyede göre daha dar tutulmuştur. Sorumluluk sadece haksız zilyetliğe ilişkindir. Haksız zilyetlikte zilyet, zilyetliğindeki şeyi geri vermekle yükümlüdür.

B. Niteliği

1. Sebep Sorumluluğu Olması

1800 TMK m.993-995 hükümleri uyarınca, iade talebinde bulunan ile haksız zilyet arasında *kanundan kaynaklanan bir özel hukuk ilişkisi* kurulmuş olur[2]. TMK m.993 vd. haksız zilyedin iade sorumluluğu, zilyedin kusurundan bağımsız olarak gerçekleşir. Zararın, haksız zilyedin kusurlu davranışı sonucunda doğmuş olmasına gerek yoktur.

---

[1] Alman hukukunda farklı olarak bkz. BGB § 987-989, 996

[2] KELLER, s.18.

1801 Kötüniyetli haksız zilyet, zararın doğmaması için gerekli tüm özen ve dikkati gösterse bile, hatta zarar kaza sonucu meydana çıksa bile, sorumluluktan kurtulamaz[3]. Haksız zilyedın sorumluluğunun doğabilmesi için zararın, haksız zilyetlik sonucu olarak haksız zilyetlik durumu ile uygun illiyet bağı içinde meydana gelmesi yeterlidir.

1802 Sorumluluğun niteliği, sözleşme dışı sorumluluktur[4]. İsviçre Federal mahkemesinin bir kararında yer aldığı şekliyle[5], haksız zilyedin sorumluluğunun *sebep sorumluluğu* olduğu kabul edilmektedir[6].

2. Zilyetliğin İadesine İlişkin Yan Hukuki Sonuçları (Talepleri) Düzenlemesi

1803 Zilyedin hak sahibine eşyayı geri vermesi temel hukuki sonuç olup, bu temel sonuca bağlı diğer **yan sonuçlar** (Nebenfolgen) TMK m.993 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda Değer zararı, değerde azalma zararı, yarardan yoksunluk zararı, haktan yoksunluk zararı, çözüm bedeli zararı, haksız zilyetlikten doğan diğer zararlar. Görüldüğü üzere, TMK m.933 vd. zilyetliğin iadesinin yan sonuçlarını düzenlenmiştir.

3. Hükümlerin Özel Hüküm (Leges Speciales) Niteliği

a. Genel Olarak

1804 TMK m.993- 995 arasında kanun tarafından düzenlenen, *yasal özel hukuk ilişkisi* söz konusudur. Haksız zilyedın geri vermesine ilişkin yükümlülük, bir yapma veya yapmama şeklindeki davranışı değil; "durum sorumluluğu[7]" (Zustanhaftung) olarak, verme ve buna bağlı *yan sonuçları - yan talep benzerini*[8] - düzenler.

1805 TMK m.993 vd. hükümlerinden doğan hukuki ilişkinin, borçlar hukuku ile olan ilişkisi söz konusu ise de bu ilişki; borç ilişkilerinden, örneğin haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden bağımsızdır[9]. Bu ilişki, borçlar

---

3 **ÖZEN**, Haksız Zilyetlik, s.194.

4 BGE 120 II 191, 196 E.4c.

5 BGE 45 II 263, 265.

6 BGE 45 II 263; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.348; **STEINAUER**, I, N.499; Ünal/Başpınar; objektif sorumluluk olarak ifade etmektedir **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.214.

7 **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 89, dn.168.

8 **STARK**, BK ZGB Vorbem zu Art.938-939, N. 3, 3a; **HÜRLIMANN-KAUP**, N.264; **LINDEMANN**, s. 71; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.90-91.

9 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.938, N.3; **STARK**, BK ZGB Vorbem. Art.938-940, N.7.

hukukundan kaynaklanan talepleri değil, zilyetlikten kaynaklanan kendine özgü talepleri düzenler[10].

1806 Zilyetliğin iadesini düzenleyen hükümler *özel hüküm (leges speciales)* niteliğindedir. Başka bir deyişle, bu hükümlerden doğan talepler, *bağımsız ve kendine özgü taleplerdir*[11]. Bu talepler, aynî talep niteliği taşımazlar; alacak niteliğindedir[12].

1807 Özel hüküm niteliği, diğer özel hukuk ilişkilerine dair hükümlerin burada uygulanmasını, kural olarak, dışlar. Haksız zilyetlikte iade borcunun, diğer geri verme borcu doğuran ilişkilerle olan ilişkisi aşağıda incelenecektir:

b. Diğer Geri Verme Sebepleri ile Olan İlişkisi

1808 TMK m.993-995 hükümleri, bir yandan sebepsiz zenginleşme, diğer yandan haksız fiil hükümleri ile yakın ilişki içindedir; bunlara vekaletsiz işgörmeyi de dâhil edebiliriz. Bu ilişkiler sebebiyle birçok hukuki sorun ve bu sorunlara ilişkin olarak doktrinde farklı tartışmalar ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Aynı tartışma zemini Alman hukuk doktrininde de söz konusudur.

aa. Sebepsiz Zenginleşme ile Olan İlişkisi

1809 TMK m.993 vd. hükümlerinin amacı, iyiniyetli haksız zilyedi korumayı amaçlamaktadır. Sebepsiz zenginleşme, sorumluluğu kapsamında iyiniyet veya kötüniyet ayrımı yapsa da; haksız fiil hükümleri böyle bir ayrıma bile yer vermeksizin, iadeden doğan yararlanma ve zararın tazminini, daha dar olarak ve farklı esaslarla düzenlemiştir[13]: Sebepsiz zenginleşme, sebepten –causa- hareket ederek zenginleşmeyi esas alarak[14]; haksız fiil, kusurlu davranıştan hareketle, iyiniyet veya kötüniyet ayrımı yapmaksızın iade borcunun kapsamını belirlemektedir.

---

[10] **HINDERLING.** SPR. VII. S.509. **STARK** ise, bazı hükümlerin borçlar hukukuna, bazılarının ise eşya hukukuna ilişkin talepler olduğunu, her talebin yarı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. **STARK.** BK ZGB Vorbem. Art.938-940. N.7.

[11] **KELLER,** s. 87. **ÖZEN,** Haksız Zilyet. s. 374.

[12] **KELLER,** s. 90. **ÖZEN,** Haksız Zilyet. s. 375-376.

[13] **ERNST.** BSK ZGB vor Art.938 ff. N.2.

[14] Zenginleşme yoktur ki sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulansın. yaklaşımı için bkz. **STARK,** BK ZGB Art Vorbem. Art.938-940. N.21; **FEYZİOĞLU,** Zilyetlikte İade. s.109.

bb. Taleplerin Yarışması (Zilyetlik Hükümlerinin Mutlak Önceliği)

1810 Tartışılan temel hususlardan biri de, özellikle iyiniyetli haksız zilyedin TMK m.993 hükmü dolayısıyla sorumlu tutamayan gerçek hak sahibinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvurup vuramayacağı meselesidir. İyiniyetli haksız zilyedin gerçek hak sahibine karşı sorumlu olamayacağına ilişkin hukuki sorumsuzluk durumu, bu ayrıcalığın sebepsiz zenginleşme yardımı ile aşılabilip aşılamayacağı tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Bu tartışmalar kapsamında; gerçek hak sahibinin haksız zilyet karşısında zilyetlik veya sebepsiz zenginleşme hükümlerinden dilediğine başvurma imkânı olduğunu savunan yenilik doğurucu hak görüşü, hukuk kurallarının yarıştığı kural derlemesi görüşü, edim zenginleşmesinin mutlak önceliği görüşü ve zilyetlikte iade hükümlerinin mutlak önceliği görüşü savunulmuştur[5].

1811 Taleplerin yarışması bakımından konu değerlendirildiğinde, bir görüş, zilyetliğin iadesi kapsamındaki sorumluluğu düzenleyen hükümlerin daha özel hüküm olmasından hareketle, haksız zilyetlikte iade yükümlülüğünün sebepsiz zenginleşme ve haksız fiil hükümleri ile yarışmayacağını savunmaktadır[6].

1812 Doktrinde hâkim görüş, zilyetlik hükümlerinin mutlak önceliği görüşüdür[7]. Bu görüşe göre, TMK m.993-995'te düzenlenen yan sonuçlar bakımından, sebepsiz zenginleşme hükümlerinden ve vekâletsiz işgörme hükümlerinden de yararlanılamayacağı, zira haksız zilyetlikte iade hükümlerinin daha özel hüküm (*leges speciales*) olduğu kabul edilmektedir[8]; aynı yaklaşım, benzer bir sonucun haksız fiil sorumluluğu bakımından da söz konusu olduğunu kabul etmektedir[9].

1813 İsviçre Federal Mahkemesi, birlikte mirasçı olan bir mirasçının tereke malını devretmesini, TMK m. 993 vd. karşılayan ZGB Art.938

---

[5] Bu görüşler için bkz. **ÖZEN,** Haksız Zilyet, s. 133 vd.

[6] **STARK;** BK ZGB Art.938, N.4. Haksız zilyetlikte iade hükümlerini düzenleyen TMK m. 993-995 hükümlerinin özel hüküm olmasından dolayı, sebepsiz zenginleşme talebini engelleyeceği yönünde bkz. Y. HGK, 01.10.2014 T., 2013/1-1117 E., 2014/745 K. (KİB).

[7] **ÖZEN,** Haksız Zilyet, s. 140-141.

[8] **STEINAUER,** I, N.496; **ÖZEN,** Haksız Zilyet, s. 156. Farklı olarak **ERNST,** BSK ZGB Vorbem zu Art 938-940, N.2 ff.

[9] **STEINAUER,** I, N.496; Farklı yönde bir yaklaşım için bkz. **ERNST** BSK Vorbem. zu ZGB 938–940 N 2 ff. **PULAŞLI,** s. 279; **ÜNAL/ BAŞPINAR,** s. 214; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY- ÖZDEMİR,** s. 121. Bu konudaki tartışmalar için bkz. **ÖZEN,** Haksız Zilyetlik, s. 4 vd.

kapsamında değil; miras hukuku kuralları kapsamında çözümlemiştir[20].

1814 Görüşümüze göre ise, kötüniyetli haksız zilyede karşı yönelen haksız fiil, sebepsiz zenginleşme veya zilyetliğin iadesinden doğan taleplerin (TMK m.995) birbiri ile yarışacağını; kötüniyetli haksız zilyedin taleplerinin ise sadece TMK m.995 kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kabul etmekteyiz. İyiniyetli haksız zilyede karşı yöneltilecek talepler bakımından ise (TMK m.993-994), haksız zilyetlikte iade talebinin haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hükümleri ile yarışmadığını kabul etmekteyiz. Gerçekten, TMK m.993 hükmü ile iyiniyetli haksız zilyede, eşya üzerinde bir kullanma ve yararlanma hakkı verilmiştir. Bu kullanma ve yararlanma hakkı, haksız zilyedin eşya üzerinde elde edeceği kazanımların yasal hukuki sebebini oluşturur; bu sebeple de gerçek hak sahibi tarafından iadesi isteneme z. Kısaca, kötüniyetli haksız zilyede karşı yöneltilecek talep, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme hükümleri ile yarışabilir.

1815 Haksız zilyetlik hükümlerindeki **boşlukların tamamlanması** bakımından ise, doktrinde bazı yazarlar, haksız zilyetlikten doğan taleplerde, TMK m.993-995'in yanı sıra, sebepsiz zenginleşme hükümlerinin (TBK m.77-82) tamamlayıcı olarak uygulanması gerektiğini savunulmaktadır[21]. Boşlukların tamamlanması bakımından sebepsiz zenginleşme hükümlerine, vekâletsiz işgörme hükümleri de ilave edilebilir. Hak sahibi ile zilyet arasında hukuki ilişki, özellikle sözleşme ilişkisi söz konusu olduğunda, hukuki ilişki -sözleşme- hükümlerinin zilyetliğin iadesine olan etkisini, aşağıda sözleşmenin geçersiz olması ile sözleşmenin sona ermesi durumları bakımından ayrı ayrı aşağıda değerlendireceğiz.

4. Eşyanın İadesi Erteleyici Şartına Bağlı Talep Niteliği

1816 TMK m.993 ve devamında düzenlenen yan talepler veya yan sonuçlar -benzeri niteliğinde-, kural olarak onun temelini teşkil eden zilyetliğin iadesi talebine, onun fer'isi olma niteliğine benzer şekilde (quasi-akzessorischer Natur), gerçek hak sahibinin eşyayı iadesinin talebine bağlıdır[22].

---

20 BGer von 23.09.2011, 5A-88/2011 E.7. Ayrıca bkz. BGE 84 II 369 E.4.

21 **GÜRSOY/ EREN/ CANSEL**, s.146; **NOMER/ ERGÜNE**, s.73; Serozan, örnekseme koprülerinin haksız zenginleşmeye her zaman açık olduğundan bahsetmektedir. **SEROZAN**, N. 694.

22 **STARK**, BK ZGB Vorbem. zu Art.938-940, N.13 f. Bu niteliğinden hareketle BGE 120 II 191 gider talebinin iade talebi yapıldığı anda talep edilmesi gerektiğini belirtmiştir (E.3.c aa).

1817 Yan taleplerin ileri sürülebilmesi, temel iade talebinin varlığına bağlıdır. Yan talebin söz konusu olabilmesi -doğabilmesi-, kural olarak, iade talebinin varlığına bağlıdır; ancak yan talepler doğduktan sonra, sona erene kadar olan gerçekleşmiş; iade gerçekleşmiş olsa bile zamanaşımı süresi içinde ileri sürülebilir. *Stark*, bu bağımlılığın dar anlaşılması gerektiğini, yan talebin varlığının, yani doğumu için bir anlam taşıdığını ifade etmektedir[22]. Örneğin; karışma, birleşme veya işleme sonucu bir kişiye mülkiyet geçmişse, mülkiyetten kaynaklanan bir iade talebinde, TMK m.993 vd. hükümleri uygulanmayacaktır.

1818 Yine, temel iade talebinden bağımsız olarak yan taleplerin başkasına devredilmesi veya kendisi için saklı tutulması söz konusu olabilir. Temel iade talebinin devri, buna bağlı yan taleplerin de devri anlamına gelmez; temel devrin yan talepleri de kapsayabilmesi için bu hususun da devre konu yapılmış olması gerekir[24].

1819 Yan sonuçlardan tazminat veya gider talebinin, temel iade yükümlülüğüne olan bağımlılığı onların iade gerçekleştikten sonra, bağımsız olarak ileri sürülmesi olanağının bulunmadığı, bu taleplerin eksik borç olduğu görüşüne[25] veya iade etmeyi haktan feragat olarak nitelendirilmesine[26] sebep olmuştur.

1820 Gerçekten, haksız zilyet kendisinden iade talep edilmediği sürece yaptığı giderleri, yan sonuçları (tazminat veya giderleri) talep edemez. Haksız zilyedin –giderleri karşılatarak eşyayı kabule zorlaması söz konusu değildir. Ancak gerçek hak sahibinin iadeyi talep etmesiyle birlikte haksız zilyet, giderlerinin karşılanmasını isteyebilir.

1821 Haksız zilyet, giderleri karşılanıncaya kadar da eşyayı iadeden kaçınma hakkına sahiptir. Haksız zilyedin iadeden kaçınma hakkını kullanmadan eşyayı iade etmesi de yan sonuçlardan feragat etmiş olduğu anlamında yorumlanamaz.

---

[22] **STARK**, BK ZGB Vorbem. Art.938-940, N.9, 23 f. Bazı yan taleplerin temel iade gerçekleşse bile varlığını sürdüreceği görüşünde **ÖZEN**, Haksız Zilyetlik, s. 90.

[24] **SEROZAN**, N.690. Alman hukukunda bu görüş için bkz. **MUHL**, Soergel, Vorbem 987-993, N.13. **STARK**, BK ZGB Vorbem. Art.938-940, N.11; **ÖZEN**, Haksız Zilyetlik, s. 92.

[25] **KELLER**, s.80-81.

[26] **OSTERTAG**, Art.939, N.4.

1822 Türk-İsviçre hukuk doktrininde hakim görüş yan sonuç taleplerinin (tazminat ve giderin talebinin) iade talebinden bağımsız olarak kullanabileceği yönündedir[27].

1823 Eşya gerçek hak sahibine iade edilene kadar yan sonuçlara ilişkin tüm talepler, yasal geciktirici şartla alacak niteliğindedir. Eşyanın iadesi talebi şartlı olgusu gerçekleştiği anda, yan talepler- tazminat ve gider talebi bağımsız olarak talep edilebilir nitelik kazanır[28].

II. HUKUKİ OLGULARI

A. Haksız Zilyetliğin Söz Konusu Olması

1. Genel Olarak

1824 Haksız zilyetliğe bağlanan yan sonuçları düzenleyen TMK m.993-995 hükümlerinin uygulanabilmesi için temel olgu, zilyetlik konusu eşyanın iadesini gerektiren bir talebin bulunması gerekliliğidir. Bu talep, bir ayni hakka veya hak karinesine dayalı bir zilyetliği koruyan bir dava olarak karşımıza çıkabilir. Bu sebeple bu talebin pasif süjesi de eşyayı iade etmesi engelleme durumunda olamayan halihazır zilyettir.

1825 Halihazır zilyedin iade talebini engelleyecek bir hakkı söz konusu olduğunda, bu ana talep olan iade talebine bağlı olan yan son sonuçlara ilişkin talepler de ileri sürülemeyecektir[29]. İade talebini haklı kılan talebin ayni hakka veya nispi hakka dayanması fark yaratmaz.

2. Sınırlı Ayni Hakta Haksız Talep

1826 Mülkiyetin korunması yetkisi kapsamında, eşyanın malike iadesi talebi en önemli haklı taleptir. Malik, eşya üzerinde başkası lehine bir ayni hak kurduğunda, tasarruf işlemi ile mülkiyet hakkına dâhil sınırlı ayni hakka ilişkin yetkinin malikten bağımsızlaştığı ve sınırlı ayni hak sahibine geçtiği kabul edilir.

---

27 **HOMBERGER**, Art.939, N.15-16; **HINDERLING**; SPR V/1, s. 514; **FEYZİOĞLU**, s. 223; ÖZEN, Haksız Zilyetlik, s. 382.

28 **ÖZEN**, Haksız Zilyetlik, s. 386 vd. 442.

29 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.1938, N.1-2; **STARK**, BK ZGB Vorbem Art.938-940, N.16; **KELLER**, s. 18; **ÖZEN**, Haksız Zilyetlik, s. 6.

1827 Tasarruf işlemi ile sınırlı yani hak sahibi hakkının gerekli kıldığı kapsamda, eşya üzerinde ayni hak kazanır; bu ayni hak yine hakkın belirlediği sınırlar içinde eşya üzerinde doğrudan hâkimiyet hakkı sağlar, bu hakimiyet hak üzerinde doğrudan zilyetlik kurmayı veya zilyetliğe ilişkin eşyanın kendisine iadesini haklı kılar.

3. Alacak Hakkında Haksız Talep

1828 Malikin doğrudan hâkimiyeti altında olan eşya üzerinde, o eşyanın kendi fiili hâkimiyetinde bulunmasını gerektiren bir alacak hakkı tanıması durumunda, alacak hakkı bir ayni hak veya alacak hakkı teknik dar anlamıyla tasarruf işlemi olmadığından, malikin mülkiyet hakkına rağmen, eşyanın iadesini malikin isteyememesinin açıklaması konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür[30]: karşı hakkın sağladığı def'i görüşü; malikin eşyayı iadeye ilişkin hakkının muaccel olmadığı görüşü; sözleşme ilişkisinin inhisarilik etkisi görüşü.

1829 Katıldığımız inhisari etki görüşü, sözleme ilişkisinden doğan alacak hakkıyla sözleşme tarafının ayni hakkından doğan talebin kalıcı olarak etkisizleştiğini kabul etmektedir. Bu görüşü savunan *Scherk*, *Raiser* ve *Diederich*, bu durumda zilyetlikle güçlenen bir alacak hakkı tanıyan malikin yaptığı işlemin geniş anlamıyla da olsa bir tasarruf işlemi olmadığını kabul etmektedirler[31]. Alacak hakkı sahibinin hukuki durumunun sınırlı ayni hak sahibinin malikle olan iç ilişkisinde farklı bir durumu söz konusu değildir; fark dış ilişkide üçüncü kişilerle olan ilişkide çıkmaktadır.

1830 *Özen* ise, hakkı olarak geniş anlamıyla da olsa tasarruf sözleşmesinin söz konusu olmadığını, zilyetlikle güçlenen alacak hakkı şeklinde nispi etkili bir hâkimiyet hakkı tanınmasının söz konusu olmayacağını isabetle ifade etmektedir. Yazar, borç ilişkisi kurarak bu sözleşme kapsamında eşyadan alacaklının yararlanmasını sağlamak amacıyla, aynı sözleşme ile alacaklısına karşı ayni talepte bulunmayacağı konusunda da yapmama borcu altına girdiğini kabul etmektedir[32].

---

30 Bu görüşler için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyetlik, s. 11 vd.

31 Bu yazarlar arasında yaklaşım farklılıklar söz konusudur. **SCHERK**, eşya üzerinde doğrudan zilyetliği sürdürme yetkisinin dolaylı zilyetliğe dönüştüğünü, **RAISER**, ayni taleplerde bulunma hakkının temelli kalktığını, kendisini sözleşeme hukuku kapsamında sınırladığını ve **DIEDERICH**, eşya üzerinde hâkimiyet kurma hakkını alacaklıya tahsisi ettiğini savunmaktadır. Bu görüşler için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyetlik, s. 18 vd.

32 **ÖZEN**, Haksız Zilyetlik, s. 26

1831 Malikin yapmama borcu, alacaklının hak taşkınlığında bulunmaması veya alacak hakkının hakkın sınırları içinde kullanma veya yararlanma şartına bağlıdır. Alacaklının, nispi hakkını sözleşmedeki sınırlar dışında kullanması durumunda, hak taşkınlığı sebebiyle haklı zilyet sıfatını kaybeder. Yapmama borcu alacağa temel olan borç ilişkisinin devamı süresince, bize göre ilaveten sona erse bile, -borç ilişkisi geri verme ilişkisine dönüştüğünden - söz konusudur. Ayni iade talebi bize göre, sözleşmenin sona ermesi durumunda uygulanamaz.

1832 Görüşümüze göre malik, mülkiyetten doğan hakkına dayalı olarak eşya üzerinde dolaylı şekilde fiili hâkimiyet kurma yetkisini elinde tutmakla birlikte, dolaysız zilyetliği alacak hakkı sahibine devren tesis etmiştir. Dolaysız zilyetliği devreden mülkiyet hakkı sahibi, malik sıfatıyla istihkak hakkını kendisinde tutmakla birlikte, eşyanın zilyetlikle ve zilyetlik karinesi yardımıyla koruma yetkisini alacak hakkı sahibiyle de paylaşmaktadır; en önemlisi mülkiyetim koruma yetkisini, yani iade talebini, alacak hakkı sahibi dolaysız zilyede karşı ileri sürme hakkını borç ilişkisi devam ettiği sürece askıya, yani bekleme durumuna almıştır. Alacaklı nispi hakkını sözleşmeye uygun kullanma şartlı olgusuna bağlı istihkak davasındaki iade talebi bozucu şartına bağlıdır.

1833 Haksız zilyetlik olgusu, taşınır eşya veya taşınmazlarda söz konusu olabilir. Haksız zilyedin asli zilyet ya da fer'i zilyetlik iddia etmesi farklılık yaratmaz. Hizmet zilyedinin iade yükümlülüğü, haksız zilyetlikteki iade kurallarına göre, taraflar arasındaki ilişkiye göre belirlenir.

1834 TMK m.993-995 hükümleri, haksız zilyetlik söz konusu olduğunda uygulanır. Bir kişi o şey üzerinde bir hakkı olmadığı halde, o şeyin zilyetliğini belirli bir zaman sürdürmüş veya sürdürmeye devam ediyorsa haksız zilyettir. Zilyetlik de bu sebeple haksız zilyettir; haksız zilyette şeyi hak sahibine geri vermekle yükümlüdür. Zilyetlikte haksızlık, zilyet olan kişinin o şey üzerinde zilyetliğini konu alan ve zilyetliğin hak sahibinde bulunmasını düzenleyen ayni bir hakkın ya da nispi hakkın, alacak hakkının bulunmamasıdır.

1835 Aşağıda durumlarda haksız zilyedin geri verme yükümlülüğü söz konusu olduğundan haksız zilyetlikte iade hükümleri uygulanır:

4. Haksız İade Talebini Konu Alan Davalar

a. Taşınır Davası ve İstihkak Davası

1836 TMK m.993 ile 995 arasındaki hükümler, ayni hakka dayalı davalarda yani istihkak davasındaki (TMK m.683 II) ve zilyetlik olgusunu esas alan zilyetlik karinelerine dayanan koruma davalarında yani taşınır davasındaki iade taleplerinde (TMK m.989, m. 991) uygulanır. Taşınır davasında ve istihkak davasında, davalı haksız zilyet olarak zilyetliğindeki şeyi geri vermekle yükümlüdür[33].

b. Zilyetliğin Gaspı Davasında Uygulanmaması

1837 TMK m.989 düzenlenen zilyetliğin gaspı davasında, davalının geri verme yükümlüğüne haksız zilyetlikte iade hükümlerinin uygulanacağını savunmaktayız[34]. Aksi görüş ise, bu davada, geri verilecek eşya üzerinde gasp edenin hakkının bulunup bulunmadığını değerlendirme konusunu dışı dışladığından, yani iadeyi talep edenin üstün hakkı tartışılmamış olduğundan, TMK m.993-995 hükümleri uygulanmaz olduğu yönündedir[35].

1838 Yukarıda belirtilen aksi görüşün haklı eleştirilerine katılmakla beraber; bu konuda boşluk bulunduğunu, bu boşluğun, iade talebine bağlanan yan sonuçlarda TBK m.49 vd. haksız fiil hükümleri yerine; kurumun niteliğine en uygun çözüm olan ve zilyetliğin iadesini konu alan TMK m.993 -995 hükümleri ile doldurulması gerektiğini savunmaktayım.

c. Taşınmazlarda Hak Karinesinden Yararlanılarak Açılan Davalarda

1839 Tapuya kayıtlı taşınmazlarda, TMK m. 992'de düzenlenen hak karinesine dayanarak adına tescil yapılmış kişinin açtığı zilyetliğin korunması davasında da TMK m.993 vd. hükümler uygulanır.

d. Haksız Zilyetliğe Yapılan Atıflar

1840 Kanunun bazı kurallarında, TMK m.993 ile 995 arasındaki hükümlere veya haksız zilyetlikte iade kurumuna atıf yapılmıştır. Özellikle miras

---

[33] İstihkak talebi için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.76 vd., taşınır davası için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 85 vd.

[34] **STASRK**, BK ZGB Vorbem. Art. 938-940, N.17; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.338; **BERGER-SATEINER**, OFK ZGB Art.938, N. 3; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 87; **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 207; **GÜRSOY/ EREN/ CANSEL**, s.151; **AYAN**, s. 123.

[35] **KELLER**, s. 34; **FEYZİOĞLU**, s. 224; **ÖZEN**, s. 87-88; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 122; **ERTAŞ**, N.345; **NOMER/ ERGÜNE**, s. 73.

hukukunda yapılan bu atıflarla, haksız zilyetlikte iade hükümleri diğer hukuk kurumlarında uygulama alanı bulmaktadır[36]:

- Gaibin mirasını ve gaibe düşen mirası elde edenlerin iade yükümlülüğünde (TMK m.585, 586)
- Kanuni mirasçıların, atanmış mirasçılara düşen mirası kendilerine iade yükümlülüğünde (TMK m.599 III)
- Miras sebebiyle istihkak davasında, terekenin veya terekeye dahil bir malın davacıya geri verilmesinde (TMK m.638).

e. Sözleşmeden Doğan İade Yükümlülüklerinde

1841 Sözleşme ilişkisi alacaklısına devredilen eşyanın iadesi talep edildiğinde, sözleşmeye aykırılık aynı zamanda, hak taşkınlığı nitelığında ise, şartlı olgu gerçekleştiğinde, mülkiyetin bekleme durumu sona ereceğinden, malik doğrudan zilyet olan alacaklıya iade talebini hangi hukuki sebebe dayandırabilir, sorusu tartışılmalıdır.

1842 Bu konuda, sözleşmeden doğan hakla ayni hak arasındaki ilişki üç farklı şekilde değerlendirilebilir[37]: İlk olarak, malikin sadece sözleşmeden doğan iade hükümlerine dayanabileceği, bu konuda bir boşluk bulunması halinde haksız zilyedin sorumluluğu hükümlerinin uygulanacağı[38] veya tam tersi: İkinci olarak, haksız zilyetlik hükümlerinin sözleşmeye aykırılık rejimiyle kümülatif olarak birbirini tamamlayıcı olarak aynı anda uygulanması[39] ve son olarak hak taşkınlığı halinde malikin sözleşmeye aykırılık rejimiyle haksız zilyetlik rejiminin yarışan biçimde uygulanmasıdır.

1843 Borç ilişkisinin devamında malikin mülkiyete dayanarak eşyayı iade hakkını koruduğunu savunan görüşlerden birine göre malik, muaccel olmasa da mülkiyete dayanarak verdiği eşyanın iadesini istemeye yetkili olarak kabul etmektedir.

---

[36] ETMK m.607 hükmünde mirasta iade hükümlerine atıfta bulunurken, yeni TMK m.673 hükmü gerekçesinde ifade edildiği üzere, maddenin amacına uygun yarar ve zarar dengesi ile gelir ve giderlerin dağılımı dikkate alarak sebepsiz zenginleşme hükümlerine atıfta bulunmuştur.

[37] **ÖZEN**, Haksız Zilyetlik, s. 29 vd.

[38] Alman hukukunda ağırlıklı olarak savunulan görüş için bkz. **GURSKY**, Staudinger, Vorbem zu § 987-993, N.9. **MÜHL**, Soergel, Vorbem zu § 987-993, N.12. Aksi görüş için bkz. **MEDICUS**, Vorbem zu § 987-1003, N.13.

[39] **DIMOPOULOS-VOSIKIS**, s. 269 vd. Aksi görüş için bkz. **KÖBL**, 97 ff.

1844 Daha ağırlıkta olan görüş ise, malikin mülkiyete dayanan iade talebinin alacak hakkı karşısında çekilmediğini, yarıştığını; yani malikin hakkının ihlali halinde sözleşmeye aykırılık rejimiyle yarışan şekilde, kötüniyetli haksız zilyedin sorumluluğu hükümlerinden yararlanacağını savunmaktadır[40].

1845 Malikin alacaklıya nispi hak kazandırdığını veya malikin iadede bulunma yetkisini kaybettiğini savunanlara[41] ve görüşümüze göre de malikin mülkiyetten kaynaklanan koruma yetkileri; sözleşmenin devam ettiği, hatta sözleme sona erse bile geri verme anından sonra borç ilişkisinin devam ettiğini kabul ettiğimiz için sözleşme alacaklı taraf için bekleme durumunda yani askıdadır; bu sebeple sözleşme ilişkisinin devam ettiği durumda haksız zilyedin sorumluluğu hükümlerin uygulanması söz konusu olmaz.

1846 Doktrindeki ağırlıklı görüş de bir kişinin sözleşme hükümleri kapsamından doğrudan zilyet kılınan kişinin hak taşkınlığı durumunda, bu davranışının sadece sözleşmeye aykırılık rejimine tabi olduğunu kabul etmektedir[42].

1847 Hak sahibi ile zilyet arasında hukuki ilişki, özellikle sözleşme söz konusu olduğunda, hukuki ilişki -sözleşme- hükümlerinin zilyetliğin iadesine olan etkisini[43], aşağıda sözleşmenin geçersiz olması ile sözleşmenin sona ermesinde ayrı ayrı aşağıda değerlendirmekteyiz. Sözleşmeden doğan iade yükümlüğünde ikili ayrım yapmaktayız: İade yükümlüğünün sözleşmenin geçersiz olmasını, örneğin şekle aykırılıktan kesin hükümsüz olmasıyla sözleşmenin sona ermesini, sürenin geçmesi, sözleşmeye aykırılık sebebiyle dönme veya feshi birbirinden ayırmaktayız.

aa. Sözleşmenin Geçersiz Olması

1848 Taraflar arasındaki sözleşme herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmişse, bu geçersiz sözleşmeye göre verilmiş olan şeyler, haksız zilyetlik-

---

40 **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 35 vd.

41 Bu görüşler için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 11 vd.

42 **HOMBERGER**, ZK Art.938, N.1; **STARK**, BK ZGB Vorbem Art.938-940, N.19; İ **KELLER**, s. 8.

43 **ANTALYA**, BH GH I, s. 31 vd.; Alman hukuku için bkz. **BALDUS**, MünchK BGB vor § 987, N.21.

te iadeye ilişkin hükümler kapsamında iade edilmelidir[44]. Geçersiz sözleşmenin bilerek ifasında, eğer geçersizlik taraflarca biliniyorsa, sözleşmenin ifası kapsamında zilyetliğin devri ile zilyetliğe geçici olarak haklılık sağlayan bağımsız bir sözleşme taraflar arasında kurulduğundan, zilyetlik haklıdır; çıkacak sorunlarda sözleşme kuralları kapsamında çözülür[45].

1849 İsviçre Federal Mahkemesi, kullanma sözleşmelerinin geçersiz hale geldiğinde, ilişkiyi *fiili sözleşme ilişkisi* (faktische Vertragsverhalniss) kapsamında değerlendirilmektedir[46]. Örneğin, araç finansal kiralama sözleşmesinin şekle aykırılık sebebiyle geçersiz olması durumunda, kusurlu yararlananın tazminat sorumluluğunda bu yaklaşımı sergilemiştir[47]. Doktrinde BGer'in bu çözüm tarzı doktrinde tartışılmaktadır[48]. *Stark*, bu yaklaşımı eleştirmektedir[49].

1850 Buna karşın, İsviçre Federal Mahkemesi, mülkiyeti nakleden sözleşmelerin geçersizliğinde, sözleşme konusu eşyanın geri verilmesinde mülkiyet hakkına dayanan geri vermeyi ve bunun yan sonuçlarında da zilyetlikte iadenin sorumluluğu (ZGB Art.938 f) hükümlerini uygulamaktadır[50]. Hatta İsviçre Federal Mahkemesi, sürekli borç ilişkisinin irade sakatlığı sebebiyle geçersizliği, yeni eğilimlere paralel olarak, kural dışı fesih olarak geriye etkili olarak (*ex nunc*) geçersizliği kabul etmiştir[51].

bb. Sözleşmenin Sona Ermesi

1851 Haksız zilyetliğin söz konusu olmadığı, zilyetliğin ayni hakka ve alacak hakkına dayandığı durumlarda, TMK m.993 vd. hükümleri uygulanmaz. TMK m.993-995 hükümlerinin amacı iyiniyetli haksız zilyetliğin korunmasına hizmet etmektir. Sözleşme ilişkilerinde, iyiniyetli haksız

---

[44] **ERNST**, BSK ZGB vor Art.938-940, N.5-6; **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.339, **AKİPEK/ AKINTÜRK**, s. 208; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 213. Bu konuda bkz. **LINDENMANN**, s.82 ff; **DEDE**, s. 866-869; Y., HGK, 01.10.2014 T., 2013/1-1117 E., 2014/745 K.

[45] **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.49 vd., 55.

[46] BGE 110 IIU 244 E.2b.

[47] BGE 84 II 369 E.4a.

[48] **ANTALYA**, BH GH I, s. 199 vd.

[49] **STARK**, BK ZGB Vorbem zu Art.938-940, N.10 f, 16 ff; **BUCHER**, BSK OR Art.1, N.74.

[50] BGE 141 II 131 E.3b, 126 III 179 E.3b; 137 III 243 E.4.3.3. Bu konuda bkz. **SCHMIDLIN** OR Art.31, N.89, 97 ff.

[51] BGE 132 III 242 E.4. Bu konu kararın eleştirisi ve tartışmalar için bkz. **HATMANN**, AJP 2003, s.1475 f.

zilyedin sözleşme tarafının iradesi ile koyduğu kuraldan ya da tamamlayıcı kuraldan daha fazla korunmasına gerek yoktur[52].

1852 TMK m.993 vd. hükümlerinde düzenlenen, hak sahibinin haksız zilyede karşı talepleri de tek başına ilişkiden bağımsız olarak ilişkideki menfaat dengesine uygun değildir; onun nitelik ve özelliği ile de genelde çelişir. Kaldı ki sözleşmenin inhisari etkisi, görüşümüze göre sözleşme ilişkisi tasfiye devam ederken de malikin mülkiyetten doğan korunma yetkisi bekleme durumunda yani, askıda olduğundan, aynı iade talebi gündeme gelmeyeceğinden, zilyetliğin iadesi rejiminin uygulanması söz konusu olmaz.

1853 Doktrinde sözleşme ilişkisinin sona ermesi durumunda, sona eren sözleşme ilişkisinin yine o sözleşme tipi hükümlerine göre sözleşme hükümlerine göre tasfiye edileceği, haksız zilyetlikte iade hükümlerinin uygulanmayacağı kabul edilmektedir[53].

1854 Doktrinde farklı görüşün bir kısmı, sözleşme ilişkisi sona erdikten sonra malik tarafından aynı iade talebiyle istenmesinin mümkün olduğunu; diğer kısmı ise yararlanabileceğini kabul etmektedir[54]. Her iki talebin aynı amacı taşıdığı, birbiriyle çelişmediği aynı anada var olabileceği bu görüş taraftarlarınca savunulmaktadır.

1855 Diğer yandan borç ilişkisinden doğan bir hakka dayanılarak gerçekleşen zilyetlik haklı zilyetliktir. Hakka vücut veren borç ilişkisinin -sözleşmenin- sürenin sona ermesi veya dönme ya da fesihle sona ermesi, yararlanmayı veya kullanmayı sonlandırır, zilyetliği haksız hale getirmez. Sözleşme ilişkisi gereğince verilenler, aynı nitelikteki dönüşüm (geri verme) ilişkisi kapsamında, hukuki -sözleşme- ilişkinin düzenlediği şekliyle geri iade edilir[55].

1856 İsviçre Federal Mahkemesi, borçlunun temerrüdüne bağlanan hukuki sonuç olarak (OR Art.109) sözleşmeden dönme halıne, sözleşmenin tasfiyesini dönüşüm veya ters sözleşme ilişkisi kapsamından değerlendirmekte; sözleşme ile alınan eşyanın sözleşme ilişkisi kapsamında geri ve-

---

52 **STARK**, ZGB Vorbem. zu Art.938-940, N.8a.

53 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.938, N.1; **STARK**, BK ZGB Vorbem Art.938-940, N.18; **KELLER**, s. 19; **KÖBL**, s.153.

54 **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 37 vd.

55 **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N.339; **STEINAUER**, I, N.498; **ANTALYA**, BH GH III, s. 512

rileceğini, bu konuda zilyetliğin iadesi hükümlerinin uygulanmayacağını kabul etmektedir[56]. Satış sözleşmesinde satıcının ayıba karşı sorumluluğu kapsamında alıcının dönme hakkında uygulamanın ne şekilde olacağı ise doktrinde tartışmalıdır.

1857 Doktrindeki katıldığımız yeni eğilim, satış sözleşmesinde alıcının ayıba karşı garanti sorumluluğu kapsamında sözleşmesinden dönen alıcının geri verme yükümlülüğü dâhil, tüm sözleşmeden dönme hallerinde borçlandırıcı satış sözleşmesine ilişkin hükümlere göre geri verme yükümlülüğünün kapsamının belirleneceği kabul edilmektedir[57].

B. Haksız Zilyetliğin Hak Sahibinin Zararına Sebep Olması

1858 Zilyetliğin haksız olması sebebiyle gerçek hak sahibinin zarara uğramış olması gerekir. Davalı hak sahibinin malvarlığındaki rızası dışı azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.

1859 Hak sahibinin malvarlığında meydana gelen zarar kalemlerinden bazılarını şu şekilde belirleyebiliriz[58]:

- Söz konusu eşyada meydana gelen *değer azalması*; örneğin, eşyanın eskimesi, yabancı bir hakla yükümlenmesi veya yok olması (*değer zararı veya değerde azalma zararı*),
- Hak sahibinin eşyayı haksız zilyetlik süresince kullanamaması veya yararlanamaması sebebiyle uğradığı zarar (*yararlanamama zararı*),
- Söz konusu eşyayı üzerinde hak sahibi olarak tasarruf edememeden doğan zarar (*haktan yoksunluk zararı*),
- Söz konusu eşyanın tekrar tasarrufta bulunulması sebebiyle hak sahibinin eşyayı geri alamamasından (*değer zararı*), -
- TMK m.989 II'e göre sadece ödediği -çözüm- bedelinin ödenmesinden doğan zarar (*çözüm bedeli zararı*),
- Haksız zilyetlikten doğan *diğer zararlar*.

---

[56] BGE 114 II 152, 126 III 119 E 3c, 137 III 243 E.4 4.2. Bu konudaki farklı görüşler için bkz. **ANTALYA**, BH GH III, 512

[57] Tük hukuku için bkz. **ANTALYA**, BH GH, III, 510 vd. İsviçre hukuku için **HONSEL**, BSK OR Art.208; n3.

[58] **SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP**, N 342 f

III. HUKUKİ SONUÇLARI

A. Genel Olarak

1860 TMK m.993 – 995 haksız zilyedin iade sorumluluğunu zilyedin iyiniyetli olup olmasından hareketle düzenlemiş, iyiniyetli haksız zilyedin iade sorumluluğunu azaltmış; kötüniyetli haksız zilyedin durumunu ağırlaştırmıştır[59].

B. İyiniyet Kavramı

1861 Haksız zilyedin iadesinin kapsamının hareket noktası olan iyiniyeti belirlerken, önce haksız zilyedin hangi konuda iyiniyetinin bulunması gerektiği tespit edilmelidir. Sonra bu konuya yönelik bir iyiniyetin bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekir.

1862 Zilyedin iyiniyetinin konusu, zilyetliğin haksız olup olmadığıdır; yani zilyedin içinde bulunduğu konumun bir hakka dayandığı konusundaki inancının mazur görülebilir olup olmadığıdır[60]. Zilyetliğin haksız olmasına yukarıda değinmiş idik. Kısaca belirtirsek, hak sahibi olmayandan eşyayı devralan kişinin, eşyayı devredenin malik ya da tasarruf yetkisine sahip olup, olmadığı zilyetliğin konusunu oluşturur.

1863 Zilyedin bu hukuksal durumla veya hakla bağdaşmayan kanaati – yanılması- mazur görülebiliyorsa, haksız zilyet iyiniyetlidir[61]. Haksız zilyedin yanılması, fiili veya hukuki yanılma şeklinde gerçekleşebilir. Hukuki yanılma, fiili bir olgunun yanlış hukuki nitelemesinden, hukuken doğru nitelemeye yanlış hukuki sonuç bağlamadan veya haksız zilyedin kendi hukuki durumu hakkında yanlış kanaat sahibi olmasından kaynaklanabilir[62].

1864 İyiniyet somut olayda, kişinin zilyetliğinin haksız olduğunu, başka bir deyişle şeyi iade yükümlüsü olduğunu gerçekten bilmemesi veya bi-

---

[59] KELLER, s.22; ÖZEN, Haksız Zilyet, s. 99.

[60] ÖZEN, s.103; ANTALYA/ TOPUZ, MHG, s. 323; Muvazaalı satış sözleşmesinin tarafının, sözleşmenin geçersizliğini biliyor olmasından ötürü, iyiniyetli haksız zilyet sayılamayacağı yönünde bkz. Y. 3. HD., 30.01.2013 T., 2013/218 E., 2013/1351 K.; aynı yönde bkz. Y. 4. HD., 25.09.1989 T., 1989/7047 E., 1989/6940 K.; ehliyetsizle işlem yaptığının bilincinde olan kimsenin iyiniyetli haksız zilyet olamayacağı yönünde bkz. 20.03.2006 T., 2006/586 E., 2006/2750 K.

[61] KELLER, s. 24, 27.

[62] ÖZEN, Haksız Zilyet, s. 101.

lebilecek durumda olmamasında mazur görülmesini ifade eder; aksi durumda ise haksız zilyet kötüniyetlidir[63].

1865 Kişi bir eşya üzerinde hakkı kazanırken durumun gerektirdiği özeni göstermelidir; aynı özen, zilyetliği kazanırken de gösterilmelidir. Gösterilecek özenin ölçüsü somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Özensizlik, aynı durum ve şartlarda olabilecek kişiler dikkate alınarak, objektif olarak değerlendirilir. Bu konuda iktisap edilen zilyetliğin konusuna ve kazanım biçimine dikkat etmemiz gerekir.

1866 Özensizliğin, zilyedin mazur görülmesini kaldıran ölçüde olması yeterlidir. Hakkın –zilyetliğin- kazanılmasında özen derecesi daha yüksek tutulurken, zilyetliğin kazanılması sürecinde bu özen derecesinin normal ölçüden daha az olması gerektiğini öne süren hafifletici yaklaşıma katılmamaktayız; iyiniyetin, zilyetlik kazanımının başlangıcında ve devamında ölçü farklılığı olmaması gerekir[64].

1867 Zilyedin kişiliğinden kaynaklanan, örneğin geçmişinin karanlık olması vb veya sözleşmede yer alan bazı verilerden, örneğin eşyanın değerinin düşük değer biçilmesi vb şüpheli olaylar söz konusu olduğunda, zilyet söz konusu şüpheye rağmen araştırma yükümlülüğü yerine getirmemişse, haksız zilyedin iyiniyetli olarak kabul edilmesi söz konusu olmaz; hele şüpheye ve yoruma imkan tanımayan inandırıcı delillerin – likit kanıt- bulunması halinde, iyiniyetten hiç bahsedilemez[65].

1868 İyiniyet, zilyetlik süresince devam etmelidir. Zilyet zilyetliğinin haksız olduğunu öğrendiği andan itibaren, zilyetliği kötüniyetli haksız zilyetliğe dönüşür. Zilyedin iyiniyetli olarak geçirdiği dönem iyiniyetli haksız zilyet hükümlerine, kötüniyetli olarak geçirdiği süre kötüniyetli haksız zilyet hükümlerine tabi olur. Örneğin satın aldığı bilgisayarın, daha sonra çalıntı olduğunu öğrenmesi durumunda, satın alınan bilgisayarın teslimi ile çalıntı olduğunu öğrendiği an iyiniyetli zilyet hükümlerine, çalıntı ol-

---

[63] Benzer tanım için bkz. **ÖZEN.** Haksız Zilyet. s.103: "*... kooperatif üyesi olan davalı(nın) kendisine tahsis edildiğini düşündüğü dairede oturmasında kötüniyetli olduğu kabul edilemeyeceğinden ecrimisil isteminin reddine karar verilmesi gerekirken...*" Y. 23 HD., 10.03.2017 T., 2016/170 E., 2017/757 K.

[64] **OSTERTAG.** Art.940. N.1. **FEYZİOĞLU.** s.135. Aksi Görüş bkz. **HOMBERGER.** ZK ZGB Art.938. N.8; **KELLER.** s.25; **ÖZEN.** Haksız Zilyet. S.105.

[65] **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP.** s. 208.

duğunu öğrendiği andan sonraki dönem ise kötüniyetli zilyet hükümlerine tabi olur[66].

1869 Kötüniyetli zilyedin iyiniyetli zilyede dönüşmesi ise pek sık rastlanan bir durum olmasa da, Doktrinde şu örnek verilmektedir: kötüniyetli zilyedin daha sonra miras sebebiyle zilyetliği kazanması[67].

1870 Zilyet aleyhine bir davanın açılması zilyedi kendiliğinden, kötüniyetli hale getirmez; bu davada iddia edilen olaylarla zilyetliğinin haksız olduğunun kendisine bildirilmesiyle bu olgular ispatlanması kaydıyla dava anından itibaren davalının zilyetliği kötüniyetli hale dönüşür[68].

1871 Yatay-birlikte zilyedin haksızlığı söz konusu ise, paylı zilyetlikte veya elbirliği ile zilyetlikte, her bir zilyedin iyiniyetli olup olmadığı diğerlerinden bağımsız ayrı ayrı değerlendirilmelidir[69]. Birlikte haksız zilyetlerin, zilyetliğin iadesinden sorumlulukları müteselsil sorumluluk kapsamında değerlendirilir.

1872 Kademeli zilyetlikte ise, doğrudan- dolaylı veya asli-fer'i zilyet olanların sorumluluğu sorumluluk olgusu tek olduğundan birlikte sorumluluğa sebep olur ancak zilyetlikteki haklılık yine her kademe için ayrı ayrı değerlendirilir[70].

C. Zamanaşımı

1873 TMK, haksız zilyedin iade yükümlülüğüne ilişkin sorumlukta özel bir zamanaşımı süresi düzenlememiştir. Doktrinde hâkim görüş, haksız zilyedin iade yükümlülüğünde *haksız fiile ilişkin zamanaşımı hükümleri*nin (TBK m.72 vd.) kıyasen uygulanması gerektiği kabul etmektedir[71]. TMK m.993-995'te haksız zilyedin iade sorumluluğuna benzer düzenleme getiren gerçek

---

66 **FEYZİOĞLU**, s.123; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.113; **DEDE**, s. 872; Tapu iptal ve tescil davası ret hükmü ile sonuçlanmasına rağmen; başkası adına kayıtlı taşınmazı kullanmaya devam eden kimsenin haksız zilyetliğinin iyiniyetli haksız zilyetlikten, kötüniyetli haksız zilyetliğe dönüşmesi yönünde bkz. Y., HGK, 07.03.2012 T., 2011/3-834 E., 2012/127 K.

67 **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 123.

68 "*...itiraz davasının kesinleştiği tarihe kadar taşınmazın iyiniyetli zilyedi olduğu kabul edilerek ancak o tarihten sonraki süre için ecrimisile hükmedilebilir.*" Y., 3 HD., 18.10.1990 T., 1990/404 E., 1990/8080 K.

69 **STARK**, BK ZGB Vorbem. zu Art.938-940, N.28; **STEINAUER**, I, N. 501a; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.61 vd; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 215.

70 **ÖZEN**, Haksız zilyet, s. 111.

71 **STARK**, BK ZGB Vorbem. zu Art.938-940, N.14, 24 ff; **HINDERLING**, SPR V/1, s. 509; **STEINAUER**, I, N. 501b; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 236; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 215.

olmayan vekâletsiz işgörme hükümlerinin de haksız fiil zamanaşımı hükümlerine tabi olduğunun düzenlendiği, bu sebeple haksız fiil zamanaşımı süresinin, kurumun niteliğine uygun olduğu ifade edilmektedir.

1874 *Özen*, TBK m. 147 b.5'te düzenlenen, vekâlet sözleşmelerinden doğan beş yıllık zamanaşımı süresini önermektedir[72]. Öncelikle temel iade talebinin zamanaşımı süresini, temel iade talebine bağlı yan sonuçlar bakımından bağımsız olarak, onların zamanaşımı hükümlerinden ayrı olarak değerlendirmemiz gerekir[73]. Örneğin, ayni talebe dayanan iade talebi, iade konusu halen mevcutsa, her zaman ileri sürülebilir.

1875 Görüşümüze göre, TMK m.993 vd. düzenlenen haksız zilyedin yan taleplerine, gerçek olmayan vekâletsiz işgörme hükümlerine benzer niteliği sebebiyle, kurumun niteliğine uyan, haksız fiil hükümlerinin uygulanması gerekir. Doktrinde, katılmamakla birlikte, haksız zilyedin sorumluluğunun haksız fiilin özel görünümü olduğu da iddia edilmektedir[74].

1876 Yargıtay uygulaması ise, aynı kurumda iki farklı yaklaşım sergilemektedir. Kötüniyetli haksız zilyedin sorumluluğuna ilişkin taleplerden ecrimisil haricinde kalanlara, doğru olarak haksız fiil zamanaşımı hükümlerini uygulamakta; ecrimisil taleplerine beş yıllık zamanaşımı süresini uygulamaktadır[75]. Bu ikili uygulama iki farklı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayanmakta olup, uygulama yeni TMK döneminde de devam etmektedir[76]. Halbuki sonraki Yargıtay kararının, öncekinin uygulanmasını ortadan kaldırdığının kabulü gerekir. Bu hususun başka bir Yargıtay kararına konu edilerek, niteleme ve uygulama farklılığın giderilmesi gerekir.

1877 Yargıtay'ın 25.05.1938 tarih ve 29/10 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, "... *sarih veya zımnen akitten ... mezkur 126. madde hükmüne tevfikan beş senelik müruru zaman cereyan edeceğine* ..." karar vermiştir. Kararda ifade edildiği üzere, beş yıllık sürenin dayanağı kira sözleşme-

---

[72] **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 94-95.

[73] *Özen*, danışmalığımda hazırladığı doktora tezinde, bu beş yıllık zamanaşımı süresinin hem gerçek hak sahibinin haksız zilyede karşı ileri süreceği talepler bakımından, hem de idareci vekilin vekâleti ifa ederken yaptığı giderler bakımından geçerli olduğunu ifade etmektedir (**ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.95).

[74] **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 235.

[75] Y. HGK, 19.06.2015 T., 2014/5-39 E., 2015/1718 K.; Y. HGK, 06.02.2008 T., 2008/3-45 E., 2008/103 K.; Y. HGK 06.10.2004 T., 2004/1-433 E., 2004/483 K.

[76] Yargıtay'ın aynı yönde kanaat içeren kararları için bkz. Y. 1. HD., 24.01.2017 T., 2014/16640 E., 2017/428 K; Y. 1. HD., 24.11.2014 T., 2014/13940 E., 2014/18257 K.

sinden doğan taleplere uygulanan zamanaşımı süresidir. TMK m.993 vd. düzenlenen haksız zilyedin iadesi sorumluluğunun hukuki niteliğinin kira ilişkisi ile bir benzerliği bulunmadığını belirtelim. Bu görüş sadece belki, temel iade talebinin kira ilişkisi olduğu ihtimalde, temel iade talebinin zamanaşımı süresinin, aynı zamanda yan taleplerin zamanaşımı olduğunun kabulü halinde belki savunulabilir. Ancak TMK m.993 vd düzenlenen taleplerin, temel iade talebinden bağımsız olduğunu ifade etmiş idik.

1878 Yargıtay, daha sonra verdiği, 25.05.1938 tarihli ve 29/10 sayılı kararla çelişen ve onu zımnen ortadan kaldıran 04.06.1958 tarih ve 16/6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, "*... işgal tazminatı ... Medeni Kanunun 908. maddesine dayanan bir dava olarak tavsif edildiği hallerde ise, Borçlar Kanununun 60. maddesindeki 1 ve 10 yıllık müruru zamanaşımına ... tabi olacaktır...*" demek suretiyle zilyetliğin iadesi kapsamında, haksız fiil hükümlerinin uygulanacağını benimsemiştir.

IV. İYİNİYETLİ HAKSIZ ZİLYEDİN (İADE SORUMLULUĞU)

A. Genel Olarak

1879 TMK getirdiği düzenleme ile, iyiniyetli haksız zilyedi, hakkının varlığına inandığı hakkın sınırları içinde kalmak kaydıyla, haksız zilyetliğin iyiniyetli olarak devamı süresince, gerçek hak sahibi imiş gibi kabul etmekte ve buna uygun hukuki sonuçlara bağlamaktadır[1]. İyiniyetli haksız zilyedin sorumluluğunu eşyanın varlığından ve alıkoymadan sorumluluk ile ürün ve kullanma çıkarından sorumluluk olmak üzere iki temel başlıkta inceleyebiliriz. Daha sonra da iyiniyetli haksız zilyedin zorunlu ve yararlı giderleri talep hakkı incelenecektir. Söz konusu iyiniyetli haksız zilyedin hukuki durumuna ilişkin hükümler, hem taşınır hem de taşınmaz için geçerlidir.

B. İyiniyetli Haksız Zilyedin Eşyanın Varlığından veya Eşyayı Alıkoymadan Sorumlu Olmaması

1. Var Olan Haliyle Eşyanın İadesi

1880 İyiniyetli haksız zilyet; iadesi talep edilen eşyayı, talep anında ne durumdaysa, o şekliyle iade etmelidir. Başka bir deyişle iyiniyetli haksız zilyet, varlığına inandığı hakkın sınırları içinde kullanma veya yararlan-

[1] STARK, BK ZGB Art.938, N.1; ERNST, BSK ZGB Art.938, N.1; LINDEMANN, s. 2, 99, 122.

ma sonucu eşya hangi halde ise, eşyayı o haliyle iade edecektir. Örneğin; kendisinin var olduğuna inandığı şekliyle malik sanıyorsa, mülkiyet hakkının kapsamına câhil olan tüm yetkileri kullanabilir; dilediği şekilde eşyayı kullanır ve ondan serbestçe yararlanır; karşılıklı veya karşılıksız tasarruf edebilir -satıp devredebilir- hatta eşyayı yok edebilir veya tahrip edebilir. Eşyanın doğal ve hukuki ürünlerinden faydalanabilir.

2. Varlığına İnanılan Hakkın Sınırları İçinde Kayıptan, Yok Olmadan ve Hasardan Sorumlu Olmama

1881 İyiniyetli haksız zilyet, asli zilyet ise, şeyin kaybedilmesinden, yok olmasından veya hasara uğramasından sorumlu olmaz (TMK m. 993 II). Eşya kısmen kayba uğramışsa, kalan kısmını iade sorumluluğu saklıdır.

1882 İyiniyetli haksız zilyet, asli zilyet ise, başka bir deyişle, kendisinin malik sıfatına sahip olduğuna inanıyorsa, eşyada meydana gelen eksilmeden veya değer kaybından sorumlu değildir[78]. Buna karşın yukarıda açıkladığımız üzere, fer'i zilyet ise, kendisinin sahip olduğuna inandığı hakkın sınırları içinde eşya üzerindeki kullanımı ve eşyadan yararlanmasından sorumlu değildir; fer'i zilyet sahip olduğuna inandığı hakkın sınırlarını aşarsa sorumlu olacaktır[79].

1883 İyiniyetli haksız zilyedin iade sorumluluğu kusurdan bağımsız olduğundan, haksız zilyet eşyayı kasten yok etse bile gerçek hak sahibine karşı ne iade ne de tazminatla sorumluluk altındadır[80].

3. Elden Çıkarmadan Sorumlu Olmama

a. Genel Olarak

1884 İyiniyetli haksız zilyet, eşyayı kısmen veya tamamen elden çıkarmışsa, kural olarak, bundan dolayı sorumlu değildir.

b. Malvarlığına Giren Karşılıktan Sorumlu Olma

1885 İyiniyetli haksız zilyet, eşyayı kısmen veya tamamen elden çıkarmış olmaktan sorumlu değilse de çıkan eşyanın değeri karşılığında malvarlığına başka bir değer girmişse, iyiniyetli haksız zilyedin malvarlığına gi-

---

[78] STARK, BK ZGB Art.938, N.4.

[79] STARK, BK ZGB Art.938, N.5, 11.

[80] ERNST, BSK ZGB Art.938, N.1.

ren bu değeri iade etmekle yükümlü olup olmadığı, böyle bir yükümlülüğün varlığından söz edilmekteyse, bu yükümlülüğün hukuki dayanağının sebepsiz zenginleşme oluşturup oluşturmadığı doktrinde tartışılmaktadır[81].

1886 Bir görüşe göre, eşyayı elinden çıkarmış olan iyiniyetli haksız zilyedin bir sorumluluğu olmadığı savunmaktadır[82].

1887 Diğer görüşe göre; iadesi gereken eşya yerine, talep sahibinin eşyanın yerine geçen karşılığını (*surrogat*'ını), örneğin; satış bedelini talep edebileceğini, kabul etmektedir.

1888 Başka bir görüş, iyiniyetli haksız zilyedin elde edilen karşılığının kazanç meydana getirmesi halinde; yani eşyanın zilyetliğini elde ederken ödediği bedel ile eşyayı elden çıkarırken elde ettiği bedel arasındaki farkı, gerçek hak sahibine sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca vermesi gerektiğini iddia etmektedir[83].

1889 Hâkim görüş ise, eşya karşılığı elde edilen değerin iyiniyetli haksız zilyetten sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre edilebileceğini savunmaktadır[84]. Üçüncü görüşten bir yönüyle farklı olarak onu sınırlayan katıldığımız görüş ise, iyiniyetli haksız zilyedin sebepsiz zenginleşme hükmüne dayanılarak iade etmeye zorlanabilmesini, onun zilyetliği ivazsız elde etmesi şartına bağlamaktadır[85].

1890 Alman hukukunda olduğu üzere, haksız zilyedin eşyanın varlığına müdahale ile eşyanın kullanılması veya yararlanması müdahalesi birbirinden ayrılmalı, kullanma ve yararlanmadan doğan malvarlığı artış değeri iyiniyetli zilyede; eşyanın varlığına ilişkin değer ise gerçek hak sahibine ait olmalıdır. Eğer haksız zilyet, eşyanın varlığına müdahale etmiş ve bu müdahale sonucunda eşyanın karşılığı bir değer elde etmişse, gerçek

---

81 Bkz. **STARK**, BK ZGB Art.938, N.8, 15 ff;. 18; **HINDERLING**, SPR V/1, s.512; **LINDENMANN**, s.131 ff; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 158 vd.

82 **OSTERTAG**, ZGB Art.938, N.15-16; **STARK**, BK ZGB Art.938, N.18; **STEINAUER**, I, N.507; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 208; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s. 217; BGE 110 II 224, 227.

83 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.938, N.12.

84 **HINDERLING**, SPR V/1, s. 512; **FEYZİOĞLU**, s.153; **OKTAY**, İade Borcu, s.10-12; **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 124.. Sınırlı olarak bu görüşü kabul edenler için bkz. **KELLER**, s. 40.

85 **FEYZİOĞLU**, s.153; **TEKİNAY /AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 207 vd.

hak sahibi bu değeri sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre talep etmelidir[86].

1891 Hak sahibi, iyiniyetli haksız zilyetle işlem yapan üçüncü kişiden eşyanın iadesini sağlamışsa, artık iyiniyetli haksız zilyedin eşyanın karşılığını talep hakkı, söz konusu olmaz. Hak sahibi, iyiniyetli haksız zilyetten elinden çıkardığı eşyanın karşılığını talep etmişse, üçüncü kişiye karşı sahip olduğu talep hakkını da tazminat talep ettiği iyiniyetli haksız zilyede devretmesi gerekir[87].

C. İyiniyetli Haksız Zilyedin Ürünlerden ve Kullanma Çıkarından Sorumlu Olmaması

1. Genel Olarak

1892 TMK m.993 eşyadan elde edilen ürün ve diğer yararların kime ait olacağını mülkiyet yönünden değerlendirdikten sonra, bunların eşya ile birlikte iade edilip edilmeyeceği sorununu çözümlemektedir. TMK m. 993 I'e göre "*İyimyetle zilyedi bulunduğu şeyi, karineyle mevcut hakkına uygun şekilde kullanan veya ondan yararlanan zilyet, o şeyi geri vermekle yükümlü olduğu kimseye karşı bu yüzden herhangi bir tazminat ödemek zorunda değildir.*"

1893 İyiniyetli haksız zilyet varlığına inandığı hakkına uygun olarak, eşyayı kullanmış veya ondan yararlanmışsa, bunun karşılığında, geri vermekle yükümlü olduğu kişiye karşı bunlarla ilgili olarak tazminat ödeme yükümlülüğü altında değildir[88].

2. Yasal Kazanım Sebebi Oluşturması

1894 Eşyanın kullanılması veya ondan yararlanılması sebebiyle iyiniyetli zilyedin malvarlığına giren değerler bakımından, TMK m.993 *bir yasal kazanım sebebi* yaratmıştır[89]. Bu yasal kazanım sebebiyle iyiniyetli haksız zilyet, eşyadan elde ettiği ürün ve diğer yararların mülkiyetini kazanır ve eşyanın kullanılmasından kaynaklanan diğer malvarlığı yararlarından da sorumlu olmaz[90].

---

86 **UTKU**, s. 31; **FEYZİOĞLU**, s. 156; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.170.

87 **SEROZAN**, N.721 vd.

88 **LINDEMANN**, s.130 f.

89 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.938, N.12; **OSTERTAG**, Art.938, N.15; **HINDERLING**; SPR V/1, s. 512; **STARK**, BK ZGB Art.938, N.10; **KELLER**, s. 54 ff; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 237 vd.

90 **KELLER**, s.47; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 227.

1895 İyiniyetli haksız zilyedin ürün ve kullanma çıkarından sorunlu olmamasının hukuki temeli, hak sahibi olmayan kişiden iyiniyetle hak kazanımı kuralına dayandırılmaktadır[51]. İyiniyetli haksız zilyedin elde ettiği ürünler bakımından, kendisine karşı sebepsiz zenginleşmenin ileri sürülememesi konusunda, zilyetliğin ivazlı veya ivazsız olarak kazanılması fark yaratmaz[52]. Kazanımın olağan ölçüde veya taşkın bir şekilde olağan dışı elde edilmesi de önemli değildir[53].

3. Ürünlerin Mülkiyetinin Kazanımı

1896 Haksız zilyet, iyiniyetli olduğu dönemde, esas eşyadan ayrılan ürünlerin, ayrıldığı -bağımsızlaştığı- anda, varlığına irandığı hak ona eşyadan ürün elde etme ve bu ürünü sahip olma yetkisi vermişse, o ürünlerin mülkiyetini kazanır[54]. Kalıcı olarak iyiniyetli haksız zilyedin mülkiyetine dahil olan ürünlerin, tüketilmesinden veya değerlendirilmesinden de sorumluluk söz konusu olmaz.

1897 Haksız zilyedin iyiniyeti sona erdiği anda, onun kullanma ve yararlanma hakkı sona erer. Bu durumda, iyiniyetin sona erdiği anda, daha eşyadan ayrılıp bağımsızlaşmamış ürünlerin hukuk: durumunun ne olacağı tartışmalıdır[55]:

1898 Bir görüş[56]: henüz bağımsızlaşmamış doğal ürünler üzerinde, haksız zilyedin mülkiyet hakkı olmadığını; ancak durumu iyiniyetli intifa hakkı sahibine benzeyen haksız zilyedin iyiniyetinin ortadan kalktığı anda olgunlaşmamış doğal ürünler üzerinde ayni etkili talep hakkı olduğunu kabul etmektedir. Bu görüş: haksız zilyedin bu ayni etkili talep hakkına dayanarak, ürünlerin olgunlaştıktan sonra eşyadan ayrılması ve kendisine verilmesi yönünde talep hakkı olduğu kabul etmektedir.

---

51 **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 229. Aksi görüş için bkz. **STARK**, BK ZGB Art.938, N.10.

52 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.11; **KELLER**, s. 54. Zilyetliğin ivazsız iktisap ettiği durumlarda sebepsiz zenginleşme kurallarını devreye sokan görüş için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 241 vd.

53 **KELLER**, s. 54. Eşyadan aşırı yararlanma halinde gerçek hak sahibine sebepsiz zenginleşme talebi veren görüş için bkz. **UTKU**, s. 31. Bu konuda bkz. **FEYZİOĞLU**, s. 155; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 243 vd.

54 **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.938, N. 11; **STARK**, BK ZGB Art.938, N.10; **KELLER**, s. 53; **PULAŞLI**, s. 109; **UTKU**, s. 39; **FEYZİOĞLU**, s. 168; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 229.

55 Bu konuda bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 230 vd.

56 **OSRETAG**; ZGB Art.938, N.13; **KELLER**, s. 53; **UTKU**, s. 35 vd.; **FEYZİOĞLU**, s. 169-170; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 230-231.

1899 Görüşümüze göre, kanunda bir atıf veya düzenleme olmadan, kurumun niteliği itibarı bir alacak hakkına ayni etki tanımak uygun değildir. Katıldığımız görüşe göre ise, bu durumda olan ürünlerin esas eşya ile birlikte gerçek hak sahibine iade edilmesi gerektiği; mülkiyet hakkını kazanamayan haksız zilyedin de iyiniyetli olarak ürünü elde etmek üzere yaptığı giderleri talep hakkı olduğu kabul edilmektedir[97].

1900 Haksız zilyet iyiniyetli olduğu dönemde doğal ürünler yanında, medeni ürünleri (kira bedeli, faiz vb.) de kazanır. Medeni ürünün iyiniyetin devamı sırasında doğması yeterli değildir; muaccel olması gereklidir. Medeni semerenin kime ait olacağı konusunda temel hareket noktası muacceliyet anı olmalıdır[98]. Medeni ürün, doğduktan sonra ve haksız zilyedin iyiniyetinin devam ettiği dönemde muaccel olmuşsa, ürünler haksız zilyede; kötüniyetli olduğu dönemde muaccel olmuşsa gerçek hak sahibine ait olacaktır.

1901 Farklı bir görüş ise, iyiniyetin devam ettiği anda doğmuş olan medeni ürünlerin, iyiniyet ortadan kalktıktan sonra muaccel olsa bile, haksız zilyet tarafından talep edilebileceğini savunmaktadır. Bu görüşü savunanlar, TMK m.805 hükmünü karşılayan ZGB Art.757 hükmündeki intifa hakkına konu olan sermaye faizleri ve diğer dönemsel gelirleri, daha geç muaccel olsa bile, intifa süresince intifa hakkı sahibine ait olacağı noktasından hareket etmektedir[99].

1902 Eğer haksız zilyedin kötüniyetli olduğu döneme ilişkin olan bir medeni semere, iyiniyetli olunan dönemde ifa edilmişse; haksız zilyet, iyiniyetinin devam ettiği süreyle orantılı miktarı alı koyup, kötüniyetli döneme karşılık gelen kısmı gerçek hak sahibine iade etmekle yükümlüdür[100].

4. Üründen Sorumsuzluğun Sınırı: Haksız Zilyedin Varlığına İnandığı Hak

1903 TMK m.993 hükmünün, haksız zilyede tanıdığı kullanma ve yararlanma hakkının sınırını, haksız zilyedinin kendisinde bulunduğuna inandığı

---

[97] **STARK**, BK ZGB Art.938, N.16.

[98] **STARK**, BK ZGB Art.938, N.17; **HINDERLING**; SPR V/1, s. 511; **FEYZİOĞLU**, s. 170. Bu konuda bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 233 vd.

[99] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.938, N.13.

[100] **PULAŞLI**, s. 110.

(veya varsaydığı) hak olduğunu düzenlemiştir. Yargıtay 1. HD. 13.11.1989 T., 12036/13431 sayılı kararında, iyiniyetli haksız zilyedin sorumluluğunun kapsamının tayininde kullanılacak kıstasın dayanılan hakka göre belirleneceğine işaret etmekte, kendisine bırakıldığına inandığı hakka -kanı olunan "Mefruz" hakka- uygun surette hareket ederek taşınmazı kullanan ve ondan faydalanan zilyedin, kural olarak borcunun, iyiniyetin sona erdiği andaki haliyle şeyi iade etmek olduğunu ifade etmiştir[101].

1904 İyiniyetli haksız zilyet, eşyayı kullanırken veya yararlanırken varlığına inandığı hakkın sağladığı yetkileri aşmışsa; örneğin, varlığına inandığı kiracılık hakkının kendisine sağladığı kişisel hakkın verdiği yetkilerin sınır aşmışsa, bundan dolayı tazminatla sorumlu olur.

1905 TMK m.993 I hükmünün karşıt anlamından – *e contrario*-, haksız zilyedin davranışlarını dayandırdığı ve varlığına inandığı hak gerçekte var olsaydı, hakkın sağladığı sınırlar içinde kullanmamasından sorumlu nasıl olacak idiyse, haksız zilyet de iyiniyetli olsa da, varlığına inanılan hakkı bu sınırlar içinde kullanmamasından, yani hakkın sınırlarını aşan davranıştan sorumlu olur[102]. Örneğin rehin hakkı sahibi, eşyayı kullanmışsa şeyi kullanmadan dolayı tazminatla sorumlu olur; zira rehin hakkı şeyi kullanmama hakkı vermez (TMK m.945). Kullanma ödüncü veya kirada olağan kullanma dışında kalan kötü kullanmadan dolayı yine sorumlu olur (TBK m.316, 380). Yararlanma, doğal ürünler yanında hukuki ürünleri ve de eşyadan elde edilen her türlü faydayı ifade eder.

D. Zorunlu ve Yararlı Giderlerin Tazminini Talep Hakkı

1. Genel Olarak

a. Gider Kavramı

1906 Gider (Verwendung) kavramı, daha geniş kapsamlı harcama (Aufwendung) kavramının bir alt ayrımıdır. Harcama, bir kişinin belirli bir amaca yönelik olarak, iradi biçimde, kendi malvarlığından bulunduğu tüm sarf durumlarını ifade eder. Buna karşın gider, daha dar bir kavram olarak taşıdığı özel amaç itibarı ile harcama kavramından ayrılır.[103]

---

[101] Y. 1. HD. 13. 11.1989 T., 12036/13431 (KİB).

[102] **STARK**, BK ZGB Art Vorb. zu Art.938-939, N.13; **EITEL/ARNET**, CHK, ZGB Art.938, N.1; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.125 vd.; **TEKİNAY /AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 207 vd.

[103] **FIELER**, s. 1 vd.; **KELLER**, s. 62; **STARK**, BK ZGB Art.939, N.2 f; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 287-288. Harcama ve gider (masraf) arasında fark görmeyen yaklaşım için bkz. **FEYZİOĞLU**, s. 197.

1907 Gider, bir kişinin (haksız zilyedin), başkasına ait belirli bir eşya veya eşya topluluğu yararına olmak amacıyla, iradi bir biçimde, harcama yapmasıdır; yani doğrudan veya dolaylı olarak yaptığı kendi malvarlığında eksilmeye sebep olması veya ona yük getirmesidir[1054]. Bu tanımdan hareketle, giderin unsurlarını şu şekilde belirleyebiliriz[1055]:

aa. Gider Yabancı Bir Eşyaya Yönelik Yapılmalı

1908 Eşya hukuku anlamında gider kavramı sadece belirli bir eşyaya yapılan harcamaları kapsar; belirli kişiye yapılan harcamalar, gider kavramına dâhildir[1056].

bb. Gideri Oluşturan Ekonomik Kayıp Kesin Olmalı

1909 Malvarlığındaki geçici yük veya azalma, gideri oluşturmaz; giderin, malvarlığına yük getirmesi veya azalması kesin olarak gerçekleşmelidir.

cc. Gider Objektif Açıdan Sonuç Doğurmaya Elverişli Olmalı

1910 Harcama için güdülen özel amacın gerçekleşmesi, yani harcamanın belirli bir eşya için ekonomik anlamada yarar sağlamasının gerekip gerekmediği tartışılmaktadır[1057]:

1911 Harcamanın özel amaçla istenen yararı sağlamaya gerekli ve elverişli olması yani objektif bakımdan gerçekleştirmeye elverişli olmasını, gider için yeterli görmek gerekir.

1912 Konunun daha iyi anlaşılması için doktrinde verilen klasik örneği sizlerle paylaşalım: Köpeğin hastalanması üzerine, köpeğin haksız zilyedi veteriner çağırmış ve köpeğin tedavisi için gerekli ilaçları satın almamıştır. Köpek ilaçlar verilmeden ve veteriner gelmeden ölmüştür. Acaba veterinere ödenecek ücret ve ilaç bedelleri, hayvana bir yarar getirmediği için yani istenilen özel amacı gerçekleşmediğinden gider kapsamı dışında mı kabul edilecektir? Görüşümüze göre, yapılan harcamalar objektif ola-

---

[1054] **ÖZEN.** Haksız Zilyet. s. 288. **HOMBERGER.** ZK ZGB Art.938. N.3; **STARK.** BK ZGB Art.938. N.2

[1055] **ÖZEN.** Haksız Zilyet. s. 289 vd.

[1056] Belirli bir kişiye yapılan harcamaları gider olarak kabul eden görüş için bkz. **SARI.** Alıkoyma. s. 21.

[1057] Bu görüşler için bkz. ÖZEN. Haksız Zilyet. s. 292 vd. Feyzioğlu, giderin eşyaya fayda sağlanmasından **FEYZİOĞLU.** s. 199. Ostertag, eşyada bir değişim meydan getirmesinden bahsetmektedir **OSTERTAG.** Art.939. N.2.

rak arzulanan özel amacı gerçekleştirmeye gerekli ve yeterli olduğundan, gider kavramı içinde değerlendirilecektir[108].

dd. Gider Yapılan Malvarlığına İradi Olarak Bir Yük Getirmeli veya Eksilmeye Sebep Olmalı

1913 Gider, haksız zilyedin malvarlığının aktifinde hukuki veya fiili bir azalma ya da pasifinde çoğalma şeklinde karşımıza çıkabilir.

1914 Gider, haksız zilyedin malvarlığında azalma meydana getirmese de giderin yük getirmesi yeterlidir. *Keller*, gideri; gider yapanın kendi malvarlığından fedakârlıkta bulunması şeklinde kısaca ifade etmiştir[109]. Örneğin; masraf, tamir, malvarlığı değer verme, vergi ödeme, para harcama vb.[110].

1915 Malvarlığında azalma veya malvarlığına yük getirme değişik şekilde karşımıza çıkabilir[111]; para ödeme, bütünleyici parçası haline getirme, işgörme faaliyeti, kendi malzemesini kullanma veya malzeme tedariki, borç altına girme vb.

1916 Bir giderden bahsedilebilmesi için malvarlığındaki azalmanın ya da malvarlığına getirilen yükün, haksız zilyedin iradesi ile meydana getirilmiş olması gerekir.

ee. Giderin Özel Bir Amaca Dayalı Olması

1917 Yukarıda kısaca değindiğimiz üzere, harcama ile gideri birbirinden ayıran temel unsurun iradi yapılmış olmasının yanı sıra; gider, aynı zamanda özel bir amaç taşıyan bir davranış olmalıdır. Bu özel amaç, gider yaptığını iddia eden haksız zilyedin bu davranışının başkasına ait eşyaya yararlı olmasıyla gerçekleşir.[112]

1918 Giderin dayandığı amaçtaki yararlı olma, farklı görünümlerde karşımıza çıkabilir: saklama, eski hale getirme, iyileştirme vb. Örneklersek, aracın bakım harcamaları, muhafazası için otopark ücreti, olağan idari faaliyet ücretleri, bataklık arazisinin kurutulması, toprağın taş ve ottan te-

---

[108] Dernburg'un verdiği bu örnek için bkz. **KELLER**, s. 66; bu ve diğer örnekler için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 294-295.

[109] **KELLER**; s.67.

[110] **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 297 vd.; **STARK**, BK ZGB Art.938, N.3 f.

[111] Giderin özel görünüm şekilleri için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 298 vd.

[112] **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 305 vd.

mizlenmesi, fidan dikimi, ağacı budama, ilaçlama ve gübreleme, ipotekli taşınmazın paraya çevrilmesi önlemek için ipotek bedelini ödemek vb.[113].

1919 Buna karşılık bir eşyanın, TMK m.989 hükmü uyarınca iyiniyetli edinenlerden taşınır davası aracılığıyla geri alınabilmesi için ödenen devir bedeli, gider niteliğini taşımaktadır. Bu durum hariç olmak üzere, satış bedeli gider niteliği taşımaz. Özel amaçla birlikte farklı diğer amaçların bulunması, özel amacın varlığını ortadan kaldırmaz.

b. Gider Çeşitleri

aa. Genel Olarak

1920 Roma hukukunda "*impensae in rem factae*" (eşyanın cevherine -yani sermaye- değerine yönelik gider) ve "*impensae in fructus factae*" (eşyadan getiri -gelir- elde etmeye yönelik gider) şeklindeki yapılan ayrım, Alman hukukunda BGB §§ 994-995 hükmünde benimsemiştir.

1921 İsviçre - Türk hukuku bu temel düşünceyi kabul etmekle birlikte konuyu kendine özgü bir yöntemle ele alarak farklı bir biçimde düzenlemiştir. Bu ayrıma ilişkin başka bir temel ilke olan "bir eşyadan ürün elde ederek yararlanan kişi, o eşyaya ilişkin olağan giderlere de katlanmakla yükümlüdür" ilkesini ise TMK m.994 hükmünde Roma hukukundaki ayrımı yapmaksızın benimsemiştir[114].

1922 TMK, iyiniyetli haksız zilyedin eşya için yaptığı giderleri üçe ayırarak, giderin türüne göre farklı hukuki sonuçlar bağlamıştır (TMK m.934). Giderler,

- "Zorunlu giderler" (*necessariase*),
- "Yararlı giderler" (*impensae utiles*) ve –
- "Diğer giderler" yani "lüks giderler "(*voluptuariae*) olmak üzere üçe ayrılır"[115].

bb. Ayrım Ölçütü

1923 Haksız zilyedin yapmış olduğu giderin türü, somut olayın tüm özellikleri dikkate alınarak *ticari yaşam ilişkilerine* göre *objektif* olarak giderin hizmet ettiği amaca göre belirlenecektir[116].

---

[113] Bu ve diğer örnekler için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 306 vd.

[114] **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 311 vd.

[115] **FEYZİOĞLU**, s. 97 vd.

[116] **STARK**, BK ZGB Art.939, N.12; **ERNST**, BSK ZGB Art.939, N.3; **FEYZİOĞLU**, s. 202; **KELLER**, s. 75; **UTKU**, s. 47; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 328.

1924 Ne eşya sahibinin ne de masrafı yapan iyiniyetli haksız zilyedin iradesi, bu ayrımda ölçüt değildir. Giderin objektif olarak değerlendirilmesi, o gidere ilişkin tüm olguların maddi olguya ilişkin hal ve şartların ekonomik bakımdan, -ticari- yaşam ilişkileri dikkate alınarak, değerlendirilmesi anlamına gelir.

1925 İadeyi talep edenin; gideri, zaruri addedip etmemesi önemli değildir.

cc. Zorunlu Gider

aaa. Kavram

1926 Eşyanın ekonomik tahsis gayesine uygun olarak varlığının korunmasını ve bu gayeye uygun olarak yararlanma imkânını korunmasını ve devam etmesini sağlayan harcamalar, *zorunlu gider*leridir[1167]. Otomobilin yıllık periyodik bakımının yaptırılması, cam suyunun değiştirilmesi, aşınan veya patlayan lastiğinin değiştirilmesi, çürüyen kaportanın tamiri vb. zorunlu giderlere örnektir.

bbb. Kıstas: Objektif Değerlendirme

1927 Giderin zorunlu olup olmadığının objektif olarak değerlendirilmesi, sadece eşyanın değer varlığını ekonomik olarak koruması yönünden değil; tahsisi amacına uygun şekilde ekonomik olarak yönetilmesi gerekli olan giderleri de kapsar. Bu kapsamda bir işletmenin yenilenmesi, zamanın şartlarına uydurulması, genişletilmesi, hatta faaliyet alanının değiştirilmesi, o işletmenin hayati nitelikteki çıkarının korunmasına veya yönetilmesine için gerekli ve yerinde ise, zorunlu gider sayılmalıdır[1168].

1928 Bu yaklaşımla, sadece mevcut durumu değil, durumun zaman uygun hale getirilmesine yönelik gelir artırıcı harcamalar da zorunlu gider kavramına dâhil edilmekte[1169] ve zorunlu gider kavramı amaçsal yorumla genişletilmektedir.

1929 Giderin sonuçları itibarı ile gerçek hak sahibine yarar sağlaması gerekli değildir; giderin zorunlu olup olmadığına *ex ante* karar verilir. Gider yapılacak olan eşya sonradan yok olmuş olsa bile, hatta gider yapılan eş-

---

[1167] Benzer bir tanım için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s. 327. Diğer tanım denemeleri için bkz. **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.938. N.6. **OSTERTAG**, ZGB Art.939. N. 3; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 227; **SARI**, Alıkoyma, s. 24.

[1168] **OSTERTAG**, ZGB Art.939. N.3. **FEYZİOĞLU**, s. 203. **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s. 330.

[1169] **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s.330 vd., 332.

yaya ilişkin koruyucu tedbirler, beklenen sonucu vermemiş olsa bile, zorunlu giderin varlığı halinde talep edilebilirliği kabul edilebilir.

1930 Hukuk düzeninin emredici kuralı, özellikle kamu hukuku kurallarının, örneğin verg: kurallarının emrettiği harcamalar, zorunlu gider kapsamında değerlendirilmelidir[121]. Gerçek hak sahibinin onayladığı giderler de hak sahibi tarafından gider olarak kabul edildiğinden, bunların ayrıca nitelendirilmesine gerek olmaksızın, talebi mümkündür.

dd. Yararlı Gider

aaa. Kavram

1931 Zorunlu olmamakla birlikte, eşyanın objektif piyasa değerini çoğaltan veya kendisinden beklenen ekonomik verimini arttıran, kısaca eşyadan elde edilen yararı arttıran harcamalar, *yararlı gider*lerdir[122]. Arabanın solmuş kaportasının yeniden boyanması, eskiyen koltuklarının değişimi vb., yararlı giderlere örnek olarak gösterilebilir.

bbb. Gerçek Hak Sahibine Yarar Sağlamasının Gerekli Olmaması ve Eşyanın Değerini Arttırması

1932 Bir giderin aynı zorunlu giderde olduğu üzere, yararlı gider olarak sayılarak talep edilebilmesi için, gerçek sahibine bir yarar sağlaması gerekli değildir; yani ekonomik yararı arttırması için gerekli olması yeterlidir. Eşyanın gerçek hak sahibine iadesi anında da mevcut olması gerekli değildir.

1933 Öncelikle belirtelim ki, yararlı gider tanımınca, olumsuz olgu olarak, zorunlu gider olmama hukuki olgusuna yer vermiş bulunmaktayız. Bu sebeple giderin yararlı gider olarak nitelendirilebilmesi için, eşyanın varlığı ve ekonomik fonksiyonu için gereklidir; ancak zorunlu olması gerekli değildir. Eşyanın değerinin arttırılması satım değerini arttırma şeklinde veya yararı arttırma şeklinde ya da her iki görünümde karşımıza çıkabilir.

1934 Alman hukukunda bu meseleye ilişkin çözüm getiren BGB § 996'da; zorunlu gidere ilişkin olarak gerçek hak sahibinin eşyadaki değer artışına ilişkin somut yararı aranmamaktayken; zorunlu gider dışındaki diğer giderlerde gerçek değer artışı gibi somut yararı arayan yaklaşım benim-

---

[121] UTKU, s. 47; FEYZİOĞLU, s. 202; SARI, s. 25; ÖZEN, Haksız Zilyet, s. 332.

[122] HOMBERGER, ZK ZGB Art.938, N.7.

senmiştir[22]. Dolayısıyla yukarıda benimsenen çözüm ile Alman hukukundaki çözümün, farklılık arz ettiğini belirtmek gerekecektir.

1935 İsviçre hukukunda da iyiniyetli haksız zilyedin yararlı giderlerini talep edebilmesi için, bu gider sebebiyle gerçek hak sahibinin somut yarar elde etmesi gerektiğini ve iade anında da eşyanın değer artışının devam ediyor olmasını, yani gerçek hak sahibi tarafından yararlanılabilir olmasını arayan görüş söz konusudur[23].

1936 Katıldığımız görüşümüze göre[24], *Keller* bu görüşü OR Art.60 / TBK m.80 II dayandırarak yararlı gider kavramını açıklamaktadır[25]. Yazara göre, TMK m. 994 tüm yararlı giderlerin bir sınırlama getirilmeksizin talep edilebileceğini düzenlediğinden, OR Art.65 / TBK m.80 II'de yer alan zenginleşenin yararlı giderler bakımından talepte bulunmasını sınırlayan hükmün, burada uygulanması söz konusu değildir.

1937 Giderin yapıldığı anda ortaya çıkan değer artışı, harcamanın yararlı gider olarak kabul edilmesi için yeterli görülmelidir. Eşyadaki değer artışının iade anında devam ediyor olması ve gerçek hak sahibinin bu gider sebebiyle somut zarar elde etmesi de gerekli değildir[26].

1938 Fakat yararın niteliği değişik zaman içinde farklı niteliğe dönüşebilir. Yapıldığı an için lüks olarak kabul edilen yarar sonradan zorunlu gider veya yararlı gider niteliğine bürünebilir. Bunun tam tersinin vücut bulması da mümkün olabilir. Böylesi durumda, artışla eşyanın değerinin değişmesi ve bununla birlikte giderin niteliğinin farklılaşması riskini zilyet taşımalıdır[27]. Gerçek hak sahibinin giderin niteliğinin geriye yönelik değişmesinden sorumluluğu, ancak rızası veya eşyayı kabul halindeki alacaklı direnimi ihtimallerinde söz konusu olur[28].

1939 Buna karşın, eşyada meydana gelen değer artışı, eşyanın haksız zilyette bulunduğu sürece, yine kendisine bağlanan hal ve şartlar sebebiyle

---

[22] **KELLER**, s. 76; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 346 dn.705.

[23] **OSTERTAG**, ZGB Art.939, N.4.

[24] **FEYZİOĞLU**, s. 205; **SARI**, s. 26; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 352.

[25] **KELLER**, s. 77; Aynı yaklaşım için bkz. **HOMBERGER**, ZGB Art.939, N.8.

[26] Aksi görüş yapılan gider bağlanan artı değerin eşyanın iadesi anında ortadan kalkmış ise, yararlı giderin karşılanmasını talep edemeyeceği yönündedir. Bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 358.

[27] **RAFF**, MüKoBGB § 996, Rn 4.

[28] **WOLFF/ RAISER**, SachenR § 86 I 2; **WESTERMANN/GURSKY/EICKMANN**, SachenR § 32 II 2; **RAFF**, MüKoBGB § 996, Rn 5; **GURKY**, Staudinger BGB § 995, Rn.2.

ortadan kalkarsa, bu giderler sebebiyle gerçek hak sahibinden bir talepte bulunamaz[129]. Bir giderin yararlı gider sayılabilmesi için eşyaya doğrudan veya dolaylı bir yarar sağlaması gerekir; bu yarar eşyanın iyileşmesi, ürünün artması, piyasa değerinin artması şeklinde karşımıza çıkabilir.

ccc. Yararlı Gider Miktarının Belirlenmesi

1940 Katıldığımız görüş uyarınca eşyanın değer artışının varlığını, eşyanın iadesi anında koruması gerekli değildir. Giderin talep edilebilmesi için, giderin yapıldığı anda eşyada objektif olarak değer artışı oluşturması yeterlidir. İstenilecek yararlı gider miktarı da eşyada objektif değer artışına sebep olan harcama miktardır. İyiniyetli haksız zilyet yararlı gider için hangi tutarda harcamada bulunmuşsa, tazmini gereken miktar da o tutardır[130]. Ancak yararın artışına sebep olan gider, akla ve bilime uygunluk, eşyanın niteliğine ve özelliğine uygunluk, mevcut durumun şartlarına uygunluk ve piyasa şartlarına uygunluk yönünden, rasyonel yönetim sonucuna göre değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme sonucunda, fiili harcamadan daha az bir gider harcanması söz konusu ise, bu tutar yararlı gider miktarı olarak esas alınacaktır.

ee. Diğer Giderler

1941 Zorunlu ve yararlı giderler dışındaki *diğer gider*lerdir; bunlar *lüks gider*ler olarak isimlendirilebilir[131]. Örneğin, otomobilinin jantlarının değişimi, camlarına film kaplanması, arka koltuklara TV bağlanması, ek ses sistemleri takılması, cam tavan takılması vb. gibi.

1942 Öncelikle giderin zorunlu veya yararlı gider olup olmadığı, yapıldığı ana göre objektif değerlendirmeyle belirlenecek, yapılan harcama eşyada objektif değer artışına sebep olmuşsa, yararlı gider olarak kabul edilecek; bir değer artışı yaratmamışsa "diğer gider" sayılacaktır. Yapıldığı anda yararlı olan bir gider sonradan iade anına değin diğer gidere veya yapıldığı anda diğer gider kategorisinde olan bir gider iade anına değin yararlı gidere dönüşebilir[132].

---

[129] **KELLER**, s. 70 ff. 80; Y. 13. HD., 17.11.1981 T., 1981/6775 E., 1981/7318 K.

[130] **HOMBERGER**, ZGB Art.939, N.9; **UTKU**, s. 49; **FEYZİOĞLU**, s. 206; **SARI**, s. 28. Eşyanın iadesi anında varlığını korumasını arayan görüş yönünden miktar belirleme için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 360-361.

[131] **UTKU**, s. 49-50; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 366.

[132] **UTKU**, s. 49; **FEYZİOĞLU**, s. 208; SARI, s. 27. İade anındaki değer artışı anından niteliğini esas alan görüş için bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 367.

c. İspat Yükü

1943 Haksız zilyedin zilyetliğinin iyiniyetli olduğu TMK m.3'te karine olarak kabul edildiğinden; bunun aksini, yani giderin yapıldığı anda haksız zilyedin kötüniyetli olduğunu ispat etme yükü gerçek hak sahibine düşmektedir.

1944 Haksız zilyedin, zorunlu veya yararlı giderler sebebiyle gerçek hak sahibine karşı tazmin talebinde bulunabilmesi için iyiniyetli haksız zilyet; zararın niteliğini, yani giderin zorunlu veya yararlı niteliğe sahip olduğunu ve giderin miktarını ispat yükü altındadır (TMK m.6).

1945 Gerçek hak sahibi, iyiniyetli haksız zilyedin yarar elde ettiğini, yani doğal veya hukuki ürün elde ettiğini iddia ediyorsa, haksız zilyedin ürün elde ettiğini ve bunun değerini ispatla yükümlüdür. Gerçek hak sahibi, haksız zilyedin kötüniyetli olduğunu ispat ederse, kötü niyetli haksız zilyet zorunlu gider olduğunu iddia etiği yaptığı harcamaların, gerçek hak sahibinin farazi iradesine uygun olduğuna ya da en azından onun çıkarına uygun olduğunu ispat etmelidir.

1946 Haksız zilyet, yaptığı giderin gerçek hak sahibinin açık veya örtülü rızası ile yaptığını da ispat edebilir. Haksız zilyet, giderleri gerçek hak sahibinin rızası ile yaptığını ispatlamakla beraber, bu giderlerin tazminini talep edebilir.

d. Zorunlu ve Yararlı Giderlerin Tazmini

1947 TMK m.994 I'e göre, "*İyiniyetli zilyet, geri vermeyi isteyen kimseden şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri tazmin etmesini isteyebilir*"[33]. İyiniyetli haksız zilyet, zorunlu ve yararlı giderlerinin tamamının karşılanması talep edebilir; bu talep sadece eşyanın iadesini isteyen kişiye karşı ileri sürebilir.

1948 Hâkim görüşe göre, zilyet giderle birlikte, giderin yapıldığı andan itibaren ödeme anına kadar da işleyecek faizi talep edilebilir[34]. Zira gider miktarı yapıldığı ana göre belirlenir[35].

---

[32] YİBK. T.01.03.1950. E.1947/11. K.1950/2.

[34] **STARK;** ZGB Art.939. N.22-23. **ERNST**, BSK ZGB Art.939. N.5. Aksi görüş eşyadan yararlanma hakkının son bulduğu anı esas almaktadır. Bkz. **HOMBERGER**, ZGB Art.9389. N. 12; **FEYZİOĞLU**, s. 215-216; onu takip eden Sarı, giderlere yapıldığı andan itibaren faiz işlemesini savunurken, iyiniyetli ziyedin elde ettiği ürünlerin mahsuba konu değerlere faiz yürütülemeyeceğini savunmaktadırlar. **SARI**, s. 30.

[35] Özen; zorunlu ve yararlı gider aynını yapmaktadır. Zorunlu gideri yapıldığı ana göre, yararlı giderin iade anındaki değerine göre belirlenmesini önerdiğinden faizi de bu andan itibaren işletmektedir. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 370.

1949 Eşyanın giderlerinin ödeme yükümlülüğünün *eşyaya bağlı borç* niteliğinde olduğu da kabul edilmektedir. Bu nitelemeden hareketle, iadeden sonra malın mülkiyeti el değiştirmiş olsa bile iyiniyetli haksız zilyet, tazminat talebini yeni malike karşı ileri sürülebilir[136]. Görüşümüze göre, giderleri ödeme yükümlülüğünün niteliğinden hareketle değil de, burada bir kanun boşluğunun bulunduğunu kabul etmek ve kanundaki boşluğunun BGB § 999 II'de öngörülen çözüm tarzına uygun şekilde doldurulması gerektedir. EGB § BGB § 999 I hükmü, zilyetliğin değişiminde, taraflar devir sözleşmesinde aksini kararlaştırmamışlarsa[137], halef durumunda olan iade yükümlüsü sonraki zilyedin, seleflerinin[138] (önceki zilyettin) yaptığı giderlerden kaynaklanan tüm talepleri talebi[139], önceki zilyet hangi kapsamda ileri sürebiliyorsa, aynı kapsamda ileri sürebileceğini düzenlemiştir.

1950 İyiniyetli haksız zilyedin, zorunlu ve yararlı giderlerin tazmini, ancak eşyanın kendisinden iadesi talep edildiği takdirde isteyebileceği, sonradan bunları tazminat davası konusu yapıp yapamayacağı tartışmalıdır. Bunun tartışma konusuyla bağlı olarak da iyiniyetli haksız zilyet, eşyanın iadesi talep edilmemişse veya iade talebine rağmen iadeye konu eşyayı iyiniyetli haksız zilyet tarafından iade edilemeyecek durumdaysa; örneğin eşya kaybolmuşsa, elden çıkarılmışsa vb., iyiniyetli haksız zilyedin eşya için yaptığı giderleri ileri sürüp süremeyeceği tartışılmaktadır.

1951 Doktrinde bir görüş, iyiniyetli haksız zilyedin giderleri talep hakkının sadece eşyanın kendisinden talep edildiğinde isteyebileceği, bunun dışında giderlerin tazminin talebinin sonradan istenemeyeceğini kabul etmek-

---

[136] **SEROZAN**, N.734; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 371.

[137] **WOLFF/RAISER**, SachenR § 86 III; **RAFF**, MüKoBGB § 999, Rn.9; **EBBING**, Erman GBG § 999 Rn.7; **PIKART**, RGRK BGB §999, Rn.2; **STADLER**, Soergel, BGB § 999, Rn.3. Satıcının ayıba karşı garantiden doğan talepleri ve bunların indirimi için bkz. **RAFF**, MüKoBGB § 999, Rn.10.

[138] Sonraki zilyedin, yalın borçlandırıcı işlem değil, hak selefi olması gerekir. RGZ 129, 199 (204); **WOLFF/ RAISER**, SachenR § 86 III; **HERRIER, PALAND** BGB 999 N.2; RAFF, MüKoBGB § 999, Rn.4; **GURSKY**, Staudinger BGB § 999, Rn.1; **PIKART**, RGRK BGB §999, Rn.2; **STADLER**, Soergel, BGB § 999, Rn.3; **EBBING**, Erbil, BGB § 999, Rn.5. Karşı görüş için bkz. **GURSKY**, AcP 171 (1971), s.82 Fn.2. Yine doğrudan zilyetliğin dolaylı zilyetliğe dönüşümü zilyetliğin devri, örneğin kiralama yeterli değildir; **WOLFF/RAISER**, SachenR § 86 III; **FRITZSCHE, BECKOK** BGB § 999, N.5; **RAFF**, MüKoBGB § 999, Rn.3; **GURSKY**, Staudinger BGB § 999, Rn.1; **PIKART**, RGRK BGB §999, Rn.3; **STADLER**, Soergel, BGB § 999, Rn.3; **EBBING**, Erbil, BGB § 999, Rn.5. Uygulama için bkz. RGZ 158 394 ff (397).

[139] Bu gidere ilişkin şartlı talebin, kanuni ve hukuki işlemle kazanıma bağlı olduğu yaklaşımı için bkz. **WIELING**, SachenR I § 12 V 7a; **RAFF**, MüKoBGB § 999, Rn.1; **GURSKY**, Staudinger BGB § 999, Rn.1. Bu tartışmalar için bkz. **GURSKY**, AcP 171 (1971), s.82, ff. 84.

tedir. Bu görüşe göre, gerçek hak sahibinin, giderleri tazmin suretiyle eşyayı kabule zorlanamayacağı ifade edilmektedir[40]. Bu giderler, TMK m.994 kapsamında eşyanın iadesi sebebiyle ileri sürülmemiş olsa da tazmin edilemese bile sebepsiz zenginleşme talebine veya vekâletsiz işgörme talebine konu edilebilir.

1952 Yargıtay uygulaması[41] ve doktrinde diğer yazarlar[42], haklı olarak, haksız fiil zamanaşımı süresine tabi olarak iyiniyetli haksız zilyedin, eşyanın iadesi talebinin sonrasında da giderlerinin tazminini talep edebileceğini kabul etmektedir. Gerçekten, iyiniyetli haksız zilyet, zorunlu ve faydalı giderlerinin tazminini iade talebinden bağımsız olarak ileri sürebilir; yeter ki bu talep hakkından vazgeçememiş olsun[43]. İade talebi esnasında bu hakkını kullanmamış olması veya saklı tutmamış olması, gider talep hakkından vazgeçme olarak kabul edilemez.

1953 Arka arkaya birden fazla haksız zilyedin bulunması durumunda, iade istemiyle karşılaşan ikinci, zamansal olarak son haksız zilyedin, önceki haksız zilyedin eşya ile ilgili gerçekleştirdiği zorunlu veya yararlı giderleri isteyip isteyemeyeceği noktası tartışılmaktadır.

1954 Bu sorun hakkında zilyetliğin değişiminde, taraflar devir sözleşmesinde aksini kararlaştırmamışlarsa[44]; BGB § 999 I hükmü, halef durumunda olan iade yükümlüsü zilyedin, seleflerinin yaptığı giderlerden kaynaklanan bir talebi, selefi hangi kapsamda ileri sürebiliyorsa, aynı kapsamda ileri sürebileceğini düzenlemiştir.

1955 Bu çözümün Türk-İsviçre hukuku içinde kabul edilmesi gerektiği savunulmaktadır[45]. Görüşümüze göre, kanundan bir benzer halefiyet hükmü doğmadığından, sonraki haksız zilyedin selefi olduğu önceki haksız zilyedin yaptığı giderleri davacıdan talep edememesi gerekir.

---

[40] **NOMER/ERGÜNE**, s. 77.

[41] Y. 4. HD., 03.06.1958 T., 3265/3847 (AD, 1959, s.228 vd.).

[42] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 126; **ÜNAL/ BAŞPPINAR**, s. 220.

[43] **STARK**, BK ZGB Art.939, N.33; **HINDERLING**, SPR V/1, s. 514; **DIOMEJ**, KurzKomm ZGB Art.9398, N.5.

[44] **WOLFF/ RAISER**, SachenR § 86 III; **RAFF**, MüKoBGB § 999, Rn.9; **EBBING**, GBG § 999 Rn.7; **PIKART, RGRK** BGB §999, Rn.2; **STADLER**, BGB § 999, Rn.3. Satıcının ayıba karşı garantiden doğan talepleri ve bunların indirimi için bkz. **RAFF**, MüKoBGB § 999, Rn.10.

[45] **STARK**, BK ZGB Art.939, N.6; **KELLER**, s. 21; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.74-75; **ÜNAL/ BAŞPINAR**, s.219.

e. Zorunlu ve Yararlı Giderleri Dışındaki (Lüks) Giderlerin Tazmin Edilememesi

1956 İyiniyetli haksız zilyet, diğer giderler için tazminat isteyemez (TMK m.994 II c.1). İyiniyetli zilyet, diğer giderler için tazminat isteyemez; ancak, şeyin geri verilmesinden önce kendisine bu giderleri için bir tazminat önerilmezse, kendisi tarafından o şeyle birleştirilen ve zararsızca ayrılması mümkün bulunan eklemeleri o şeyi geri vermeden önce ayırıp alabilir (TMK m.994 II).

1957 TMK m.994 II hükmü ile diğer (lüks) giderler bakımından bu giderlerin haksız zilyede ödenmesi için haksız zilyede talep hakkı verilmezken, bu giderlerle ilgili şeyleri eşyadan ayırıp alma hakkı *(ius tollendi)* haksız zilyede tanınmıştır. Lüks gidere sebep olan şeyin, iade konusu eşyadan ayırıp alma hakkı, şeyin geri verilmesiyle sona erer[146].

1958 TMK m.994 II hükmü sadece diğer (lüks) giderlerle ilgili olarak ayırıp alma hakkını düzenlemiştir. Bu maddeden hareketle, evleviyet ilkesi gereği, zorunlu ve yararlı giderler için de iyiniyetli haksız zilyedin ayırıp alma hakkının bulunduğunun kabulü gerekir[147].

1959 İyiniyetli haksız zilyet, onun bütünleyici parçası haline getirmek üzere gider yaparak birleştirdiklerini veya eklediklerini ayırıp alma hakkına sahiptir[148]. Eklenti niteliğinde olan birleşen veya eklenenleri ise, haksız zilyet iade dışında tutabilir. Haksız zilyedin eklentiler için ayırıp alma hakkını kullanmasına gerek yoktur.

1960 Haksız zilyedin ekleme ve birleşenlerin ayırıp alabilmesi için, ayırmanın iadesi gereken eşyaya zarar vermemesi gerekir. Doktrinde, ayırıp alma hakkının kullanılması, iadesi talep edilen eşyaya zarar verecek nitelikte olsa bile, haksız zilyedin eşyayı eski duruma getirmesi veya bunu taahhüt ederek teminat vermesi durumunda ayırıp alma hakkını kullanabileceğini kabul savunmaktadır[149].

aa. İade Yapılacak Kişinin Ayrılacak Şeyin Giderlerini Ödeme Teklifinde Bulunmaması

1961 Eşyanın iadesini talep eden hak sahibi, ayrılacak şeylerle ilgili diğer (lüks) giderleri ödeme teklifinde bulunursa, iyiniyetli haksız zilyet ayırıp

---

[146] **STARK**, BK ZGB Art.939, N.38.

[147] **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 417. Aksi görüş için bkz. **FEYZİOĞLU**, s. 226.

[148] **ERNST**, BSK ZGB Art.939, N.11; **FEYZİOĞLU**, s. 229; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 406 dn.839.

[149] **FEYZİOĞLU**, s. 229-230; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 413; **DEDE**, s. 872.

alma hakkını kullanamaz[150]. Haksız zilyet, ayırıp alma hakkını dürüstlük kuralına uygun kullanmalıdır[151]. Örneğin haksız zilyet kendisine hiç yarar sağlamayacak ya da sırf karşı tarafa zarar vermek amacıyla ayırıp alma hakkını kullanmamalıdır.

f. Giderlerin Tazmini

aa. Genel Olarak

1962 İyiniyetli haksız zilyedin yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderlerin tamamı, gider için ödediği tutar dikkate alınarak tazmin edilir; eğer zilyedin ödediği tutar piyasa değerinin üstünde ise piyasa değeri esas alınır[152].

bb. Zilyedin Elde Ettiği Ürünlerin Mahsubu

1963 İyiniyetli haksız zilyet iadesi talep edilen eşyanın doğal ve hukuki ürünlerinden yararlanmışsa, yararlanma miktarı, giderler nedeniyle talep edebileceği alacak miktarından mahsup edilir. Bu husus TMK m.994 III hükmünde, "*Zilyedin elde ettiği ürünler, yaptığı giderler sebebiyle doğan alacaklarına mahsup edilir*" şeklinde düzenlenmiştir. Bu hüküm, eşyayı iade ile yükümlü olan, eşyanın yararlarını elde ediyorsa, giderlerine de katlanmalıdır şeklindeki Roma hukukuna hakim temel ilkeye uygun bir yaklaşımıdır.

1964 TMK m.994 III hükmü, Roma hukukundan yapılan sermaye ve getiri gideri ayrımına yer vermeksizin ve bu ayrımın yapıldığı BGB §§ 994-995 hükmündeki olağan saklama giderleri ve olağan dışı gider ayrımından farklı olarak, iyiniyetli haksız zilyedin talep edebileceği bütün zorunlu ve yararlı giderlerin tutarından, elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği yararları, bu kapsamda doğal ve medeni ürünlerden düşmesi gerekir[153].

1965 *Stark* farklı olarak, eşyaya zarar verilmesinden iyiniyetli haksız zilyet kusurlu fiiliyle sorumlu ise ya da aynı şekilde iyiniyetli haksız zilyet kusurlu fiiliyle ihmal etti ettiği yararların değerini, gider talebinden mahsup edilmesine imkân tanımamaktadır[154]. Elde edilen yararın mutlaka doğal

---

[150] **HOMBERGER**, ZK ZGB Art.939, N.19-20.

[151] **FEYZİOĞLU**, s. 230; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 414.

[152] **OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 126, dn.303.

[153] **HOMBERGER**, ZGB Art.939, N.10; **OSER/SCHÖNENBERGER**, OR Art.65, N.2; **KELLER**, s. 111; **UTKU**, s.70; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 316. Aksi görüş **WIELAND**, ZGB Art.939, N.7-8.

[154] **STARK**, BK ZGB Art.939, N.16. Aynı yaklaşım için bkz. **FEYZİOĞLU**, s. 179.

veya medeni ürün olması gerekli değildir; eşyadan ürün dışında başka bir yarar elde edilmişse, onun değeri de giderden mahsup edilecektir[655].

1966 İyiniyetli haksız zilyet, iade davasında giderlerinin ödenmesini talep ettiğinde, iadeyi talep eden davacı, gerçek hak sahibi; giderlerden elde edilen veya elde edilmesi ihmal edilen doğal ve hukuki ürünlerin mahsubu savunmasında bulunabilir. İtiraz niteliğinde olan bu mahsup talebini, talepte bulunan davacı ispat yükü altındadır (TMK m.6)[656].

1967 Hakim iyiniyetli haksız zilyedin yaptığı giderler için tazminata hükmederken, davacının mahsup talebini dikkate alarak, tazminatın kapsamını belirleyecektir[657]. Davacının mahsup talebi bulunmuyorsa hakim, bunu resen dikkate alamaz[658]. Katılmamakla birlikte bir görüş, iade talebinin yöneldiği iyiniyetli haksız zilyedin giderlere ilişkin talebi karşısında, mahsup edilecek yararların hesaplanmasında kendisinden önceki zilyetlerin elde ettiği ürünlerin de dikkate alınması gerektiğini savunmuştur[659].

2. Eşyayı Geri Vermekten Kaçınma (Alıkoyma Hakkı)

1968 TMK m.994 I'e göre, iyiniyetli haksız zilyet, geri vermeyi isteyen kimseden şey için yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderlerine ilişkin talep edilen tazminat ödeninceye kadar şeyi geri vermekten kaçınabilir.

1969 Eşyayı geri vermekten kaçınma hakkı, zilyede paraya çevirme yetkisi vermeyen ve def'i niteliği taşıyan bir alıkoyma hakkıdır[660]. Eşyayı geri vermekten kaçınma hakkı, bir alıkoyma hakkıdır, hapis hakkından farklı olarak, eşyayı paraya çevirme yetkisi vermez. Bu nedenle de iadeden kaçınma hakkını "*eksik hapis hakkı*" olarak görülmektedir. Alıkoyma hakkını teknik bir hapis hakkı olarak niteleyenler de söz konusudur[661]. Bunun yanında bir diğer görüş ise, daha doğru olarak *eşyaya bağlı borç* olarak nitelemektedir[662].

---

[655] **STARK**, BK ZGB Art.939. N.15; **FEYZİOĞLU**, s. 179; **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s. 317.

[656] **STARK**, BK ZGB Art.939. N.9; **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s.317 dn. 648.

[657] **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s. 318. Aksi görüş **FEYZİOĞLU**, s.176.

[658] Aksi fikir: **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s. 318.

[659] **ERNST**, BSK ZGB Art.939. N.7.

[660] **SARI**, s. 13 vd.

[661] **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 231.

[662] **EREL**, s.70; **SEROZAN**, N.462.

1970 TMK m.994 I'e benzer alıkoyma hakkı; TMK m.989 hükmünde düzenlenmiştir. Orada da ifade ettiğimiz üzere, alıkoyma hakkı, zilyetlikle güçlendirilmiş bir yenilik doğuran haktır. Haksız zilyede bağlı olarak verilmiş alıkoyma hakkı ileri sürülmeksizın, zilyetlik iade edilmişse, hak kullanılmamakla birlikte düşer. Alıkoyma hakkından yararlanacak olan iyiniyetli haksız zilyettir.

1971 Haksız zilyet, iade talebi kendisine yöneltildiğinde, alıkoyma hakkına dayanarak yenilik doğuran hakkını kullanabilir. Bu hakkı kullanmasıyla haksız zilyetlik durumu sona erer, hakka dayanan zilyetliğe dönüşür ve artık bu an itibarıyla haksız zilyetliğe ilişkin hükümler uygulanmaz.

1972 *Stark*, haksız zilyedin alıkoyma hakkına sahip olduğu andan itibaren giderler ödeninceye kadar zilyetlik bakımından üstün hakkı olduğunu kabul etmektedir[63]. Görüşümüze göre, gerçek hak sahibinin haksız zilyetten şeyi istediği an olan, yenilik doğurucu hakkın kullanılması anından itibaren, zilyetlik hakka dayanan haklı zilyetliğe dönüşür.

1973 Taraflar arasında kanundan kaynaklanan özel bir hukuki ilişki oluşmuş olur. Bu özel hukuki ilişkiye saklama sözleşmesi hükümleri kıyasen uygulanır[64].

1974 *Özen*, hapis hakkında olduğu üzere, teslime bağlı rehin kurallarının uygulanması gerektiğini haklı olarak savunmuştur[65].

1975 *Sarı*, alıkoyma hakkını kullanan kişiye, saklayan kişi veya intifa hakkı sahibine ilişkin kuralların uygulanacağını savunmaktadır[66].

1976 Hapis hakkı için kabul edildiği üzere, alıkoyma hakkına dayanan zilyet, eşyanın yok olmasından veya değer kaybından sorumludur[67]. Alıkoyma hakkını kullanmış olan zilyedin, alıkoyma hakkını kullandıktan sonraki dönemde, eşyayı üçüncü kişiye devretmesi halindeki sorumluluğu saklıdır.

1977 Alıkoyma döneminde, zilyedin eşyayı kullanma veya yararlanma hakkı söz konusu değildir; eğer eşyadan bir ürün veya bir değer elde et-

---

[63] **STARK**, BK ZGB Art.939, N.28.

[64] **KOBL**, s. 112.

[65] **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 48.

[66] **SARI**, Alıkoyma, s. 78.

[67] **STARK**, BK ZGB Art.939, N.29; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 49.

mişse, onları da alıkoyma hakkının sona erdiği anda eşya ile birlikte iade etme yükümlülüğü altındadır[662].

V. KÖTÜNİYETLİ HAKSIZ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU

A. Genel Olarak

1978 Kötüniyetli haksız zilyedin sorumluluğunu, eşyanın varlığından ve alıkoymadan sorumluluk ile ürün ve kullanma çıkarından sorumluluk olmak üzere iki temel başlıkta inceleyebiliriz. Daha sonra da kötüniyetli haksız zilyedin zorunlu giderleri talep hakkı incelenecektir. TMK m.995 I'e göre, "*iyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır*".

B. Kötüniyetli Haksız Zilyedin Eşyanın Varlığından ve Alıkoymadan Sorumluluğu

1. Genel Olarak

1979 Kötüniyetli zilyedin sorumluluğunun temeli, genelde aynı zamanda kusurlu davranış olarak ortaya çıksa da kusur oluşturmadığını; sorumluluğun sebebinin haksız zilyetliğinin kötüniyetli olmasından ileri geldiğini yukarıda açıklamış idik. Bu sebeple, kötüniyetli haksız zilyedin zararın meydan gelmemesi için gerekli önlemleri almış olması veya gerekli özeni göstermiş olması, onu sorumluluktan kurtarmaz. Haksız zilyedin zilyetliğinde bulundurduğu eşya üzerinde bir hakkı olmadığını bilmesi veya bilebilecek durumda olması yeterlidir.

1980 Kötüniyetli haksız zilyedin sorumlu olabilmesi için, gerçek hak sahibinin uğradığı zarar ile eşyanın kötüniyetli zilyet tarafından alıkonulması veya eşyanın varlığına müdahale edilmesi arasından uygun nedensellik bağının bulunması yeterlidir[663].

1981 Bu kapsamda kötüniyetli haksız zilyet, kötüniyetli haksız zilyetlik sebebiyle meydana gelen zararın, eşyanın gerçek hak sahibinin elinde bulunsaydı yine de meydana gelebileceğini ispatlayabilirse, nedensel-

[662] **STARK**, BK ZGB Art.939, N.29; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 49.

[663] **KELLER**, s. 42; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 247.

lik bağı kesilmiş olduğundan kötü niyetli haksız zilyet sorumlu olmayacaktır[170].

2. Sorumluluğun Kapsamı ve Kapsamının Belirlenmesi

1982 Kötüniyetli haksız zilyedin tazmin sorumluluğunun kapsamında, niteliğine uygun olarak, TBK m.51-52 hükümleri uygulanır. Kötüniyetli haksız zilyedin, adam çalıştıranın sorumluluğuna ilişkin olarak TBK m. 66 hükmü ve yardımcı kişinin fiilinden dolayı da TBK m.116 hükmü kapsamından sorumluluğu söz konusu olabilir.

a. Eşyanın Varlığının Uğradığı Zarardan

1983 Kötüniyetli haksız zilyet eşyanın varlığının uğradığı zarardan sorumludur. Başka bir deyişle, kötüniyetli haksız zilyet eşyanın maddi yönden zarara uğramasından ve ekonomik fonksiyonların: yerine getirmeye engel teşkil eden tüm eksilme ve kötüleşmelerden sorumludur[171]. Örneğin eşyanın yok olmasından, hasara uğramasından, çalınması, tüketilmesi veya değerinin düşmesinden sorumludur. Kötüniyetli haksız zilyedin olağan kullanımı sebebiyle meydana gelen eksilme ve kötüleşmelerden de sorumluluğu söz konusudur. Örneğin eşyanın olağan kullanım aşınımlarından da sorumludur.

b. Eşyanın Devrinden veya Hakla Sınırlandırılmasından Doğan Zarardan

1984 Kötüniyetli haksız zilyet eşyayı elden çıkarmışsa veya başkasına devretmişse bundan dolayı gerçek hak sahibinin uğradığı zararlardan sorumludur. Aynı şekilde, eşyanın sınırlı bir ayni hakla kayıtlanması veya başka bir hakla yük getirilmesi halinde de kötüniyetli haksız zilyet sorumludur[172].

1985 Kötüniyetli haksız zilyet, zilyetliğindeki eşyayı devretmiş ve bu devir karşılığı bir değer elde etmişse gerçek hak sahibi, sebepsiz zenginleşme kurallarına veya vekâletsiz işgörme hükümlerine göre, yarışan haklardan birine başvurarak, bu zenginleşmeyi isteyebilir[173].

---

[170] **HOMBERGER;** ZK ZGB Art 940, N.7; **HINDERLING,** SPR V/1, s. 515; **KELLER,** s. 42; **ÖZEN,** Haksız Zilyet, s 195 vd.

[171] **STARK,** BK ZGB Art 940, N.5-6; **KELLER,** s. 41; **UTKU,** s. 83; **FEYZİOĞLU,** s. 250; **ÖZEN,** Haksız Zilyet, s. 203.

[172] **STARK,** BK ZGB Art 940, N.7; **HINDERLING,** SPR V/1, s. 515; **KELLER,** s. 41; **ÖZEN,** Haksız Zilyet, s 205.

[173] Vekaletsiz işgörme hükümlerinin sebepsiz zenginleşmeye nazaran daha tercih edilebilir olduğu görüşü için bkz. **HINDERLING,** SPR V/1, s. 516; **ÖZEN,** Haksız Zilyet, s. 214.

1986 Kötüniyetli haksız zilyedin iadeyi zorlaştırıcı davranışlarından doğan örneğin, birlikte zilyetlik veya eşyanın yerinin değiştirmeden doğan zararlar da tazmin edilmelidir[774].

c. Alıkoymaktan Doğan Zarardan

1987 Eşyanın haksız elde tutulması sebebiyle, gerçek hak sahibinin bazı yararlar elde edememesi veya fırsatlar kaçırmasından doğan zararların da tazmini gerekir[775]. Örneğin, eşyanın haksız zilyet elinde olması sebebiyle elverişli fiyatla satılamamış olması sebebiyle kazanç kaybına uğrama, bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

C. Kötüniyetli Haksız Zilyedin Ürünlerden ve Kullanma Çıkarından Sorumluluğu

1. Genel Olarak

1988 TMK m.995 I'e göre, "*iyiniyetli olmayan zilyet, ... elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır*". Bu düzenlemeyle, kötüniyetli haksız zilyedin elinde bulunan eşya, eğer gerçek hak sahibinin elinde olsaydı, gerçek hak sahibine ne şekilde ve ne miktarda ürün ve kullanım çıkarı sağlayacağı, özellikle gerçek hak sahibinin sahip olduğu olanaklar ve araçlar dikkate alınarak, kötüniyetli haksız zilyedin sorumluluğu belirlenecektir. Böylelikle, kötüniyetli haksız zilyedin gerçek hak sahibinin hukuk alanına ve eşyaya haksız müdahalesi sebebiyle bir yarar elde etmesini önlenmek istenmiştir.

1989 TMK m.995'te yer alan bu düzenleme sonuçları itibarı ile, gerçek olmayan vekaletsiz görmeye benzemektedir[776].

2. Elde Edilen Ürünlerden Sorumluluk

1990 Kötüniyetli haksız zilyedin sorumluluğunun olguları, eşyanın varlığından doğan sorumluluğun hukuki olguları ile aynıdır; kötüniyetli haksız zilyedın sorumluluğu için kötüniyetli olması yeterlidir, kusurlu olması gerekmez.

---

[774] **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 215-216.

[775] **KELLER**, s. 41; **PULAŞLI**, s. 119; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 217.

[776] **KELLER**, s. 55; **PULAŞLI**, s.90; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.246.

1991 TMK m.995 I hükmü, sadece elde edilen ürünlerin tazmininden bahsetse de kötüniyetli zilyedin elde ettiği ürünler halen mevcutsa, kötüniyetli haksız zilyet bunları *aynen iade* etmekle yükümlüdür.

1992 Kötüniyetli haksız zilyedin elde ettiği ürünlere ilişkin olarak, dürüstlük kuralından kaynaklanan *bilgi verme yükümlülüğü* söz konusudur.

1993 Kötüniyetli haksız zilyedin bu ürünler üzerinde mülkiyet hakkı söz konusu olmayıp, bu ürünler eşyadan ayrılmakla birlikte eşyanın gerçek hak sahibinin mülkiyetine geçmektedir. Bu nedenle gerçek hak sahibinin mevcut ürünleri iade talebi, *ayni bir talep* niteliğindedir[777].

1994 Bu niteleme, iflas hukuku bakımından önemlidir: Kötüniyetli haksız zilyedin iflası halinde eşya ve bundan üreyen mevcut ürünlerin, iflas yoluyla takipte, mülkiyet hakkına dayanan gerçek hak sahibi tarafından iflas masasından ayrılıp, alınma imkânı söz konusu olacaktır[778].

1995 Kötüniyetli haksız zilyet, elde ettiği ürünü başkasına kazandırmış ve kazandırma dolayısıyla bir karşılık elde etmişse, bu karşılığı mevcutsa iade etmek durumundadır. Gerçek hak sahibinin ürünün devri sebebiyle hiç zarara uğramasa veya uğradığı zarar daha düşük olsa bile, gerçek hak sahibi kötüniyetli haksız zilyetten devre konu eşyanın karşılığını talep edebilir[779]. Örneğin kötüniyetli haksız zilyet eşyayı kiraya vermişse geçek hak sahibi, kira sözleşmesi gereği ödenmiş ve ödenecek olan kira bedelinin kendisine verilmesini kötüniyetli haksız zilyetten isteyebilir. Doktrinde ileri sürüldüğü şekliyle[780]; gerçek hak sahibi, kiracı durumundaki üçüncü kişiden, kötüniyetli haksız zilyede ödeyeceği kira bedelini kendisine ödenmesini isteyemez[781].

1996 Haksız zilyetliğin konusunun taşınmazla bağlantılın olması durumunda, işletmenin elde ettiği kazancın ürün olarak nitelendirilip nitelendirilmemesi doktrinde tartışılmaktadır[782].

1997 Söz konusu işletme kazancı, teknik olarak, eşyadan elde edilen yarar niteliğinde olmadığından ürün olarak nitelenemese de, TMK m. 995

---

[777] **HIOMBERGER.** ZK ZGB Art.938, N.12; **STARK**, BK ZGB Art.940, N.24; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP.** s. 214; **PULAŞLI**, s. 118; **KOÇ.** s. 614; **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s.247.

[778] **STARK**, BK ZGB Art.940, N.24; **PULAŞLI**, s. 118; **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s.247.

[779] **KELLER**, s.55; **STARK**, BK ZGB Art.940, N.2.

[780] **STARK**, BK ZGB Art.940, N.25.

[781] **UTKU**, s. 37; **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s. 248.

[782] **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s.250 vd.

hükmünün doğrudan değil de kıyasen uygulanmasının söz konusu olabileceği iddia edilmiştir.

1998 Ancak görüşümüze göre, ürün kavramı amaçsal geniş yorumlanarak, doğal ve medeni ürün dışındaki diğer yararlar bakımından da TMK m.995 hükmünün uygulanabileceği aşağıdaki şekliyle kabul edilmelidir.

1999 *Medicus*'[83] tarafından savunulan *Özen*'[84] tarafından benimsenen görüşte de ifade edildiği üzere, işletmenin tekel konumunda sahip imtiyazlı işletme olup olmamasının önemli olmadığı ve bu tür işletmelerden elde edilen kazancın gerçek hak sahibine iade edilmesine karşı çıkmaktadırlar. İşletme çerçevesinde elde edilen kazancın, haksız zilyedin kişisel faaliyet mi yoksa işletmenin kendine özgü niteliğinden mi kaynaklandığı şeklindeki ayrımının yetersiz olduğunu kabul etmektedir.

2000 Bu konudaki tek ölçüt, söz konusu işletmenin ürün kirası sözleşmesine konu edilmesi durumunda ödenmesi gereken kira bedelidir. Kötüniyetli haksız zilyet, eşyayı bizzat kullanma yararı olarak, bu hasılat kirası bedelinden sorumlu olmalıdır.

2001 Ürün mevcut değilse veya elde edilmesi ihmal edilmiş ürün söz konusu ise, kötüniyetli haksız zilyet bu ürünlerin parasal karşılığını iade etmek durumundadır. Kötüniyetli haksız zilyedin, elde etmiş olduğu ürünleri gerçek hak sahibinin elde edemeyeceğini iddia ederek, sorumluluktan kurtulması söz konusu değildir. Gerçek hak sahibinin ürünleri elde etmeyi düşünüp düşünmemesi veya onları elde etme yeteneği ya da kudretinin bulunup bulunmaması önem arz etmez. Aynen iade edilemeyen veya derhal iade edilemeyen ürünün gerçek hak sahibi tarafından daha iyi bir fiyattan elden çıkarılmamasından doğan kazanç kaybı zararı da kötüniyetli haksız zilyet tarafından tazmin etmelidir.

2002 Elde edilmiş olan ürünler, sonradan yok olsa bile kötüniyetli haksız zilyet sorumludur. Bunun istisnası olarak ürünün gerçek hak sahibine iadesi hususunda imkânsızlık söz konusu ise, kötüniyetli haksız zilyedin kusuru yoksa, sorumluğunun olmadığı TMK m.995/III'de düzenlenmiştir. Kötüniyetli haksız zilyet, ürün elde etmek için yapığı zorunlu giderlerden TMK m.995/II koşullarını taşımayanları ve bu zorunlu gider dışındaki diğer giderleri gerçek hak sahibinden isteyemez. Kötüniyetli hak-

[83] MEDICUS, N.12.

[84] ÖZEN, Haksız Zilyet, s.255.

sız zilyet yaptığı giderleri elde ettiği ürünün veya bunun karşılığını karşılasın karşılamasın hak sahibine vermekle yükümlüdür.

3. Elde Edilmesi İhmal Edilen Ürünlerden Sorumluluk

a. Kavram

2003 Kötüniyetli haksız zilyet sadece elde ettiği ürünleri değil; elde etmeği ihmal ettiği ürünlerin değerini de gerçek hak sahibine ödemek durumundadır. Kötüniyetli haksız zilyedin elde etmeyi ihmal ettiği ürünlerin nasıl belirleneceği hususu doktrinde tartışılmıştır.

aa. Subjektif Görüş

2004 Bu konuda *subjektif ölçütü* savunan yazarlar, subjektif ölçütün kimin yönünden ele alınacağı konusunda da ikiye ayrılmaktadırlar:

2005 Bir kısım yazarlar, gerçek hak sahibini esas alarak, bu kişinin sahip olduğu olanak ve araçlarla, olağan bir işletme sonucu elde edilen ürünleri, elde edilmesi ihmal edilen ürün olarak belirlemektedir[365].

2006 Diğer kısmı ise, ilişkinin diğer tarafı olan, kötüniyetli haksız zilyetten hareketle kavramı açıklamaktadır. Bu yazarlar kötüniyetli haksız zilyedi, kendi olanak ve araçlarıyla elde edebileceği, gerçek hak sahibinin olanak ve araçlarıyla elde edemeyeceği ürünlerden de sorumlu tutmaktadır[366]. Subjektif görüş benimsenmesi halinde, elde edilmesi ihmal edilen ürünleri, gerçek hak sahibinin sahip olduğu olanak ve araçlarla elde edilemeyeceği savunması ileri sürülebilir.

bb. Objektif Görüş

2007 Objektif görüşü benimseye yazarlar, kötüniyetli haksız zilyedin, özenli bir idari faaliyet sonucu elde edilebileceği ürünleri elde etmeyi ihmal etmesi durumunda, sorumlu olacağını ifade etmektedirler[367].

2008 Gerçekten TMK m.995 hükmü, kötüniyetli haksız zilyede özenli bir yönetici gibi eşyayı kullanma ve eşyadan yararlanma yükümlülüğü yüklemiştir. Kötüniyetli haksız zilyet özenli bir yöneticinin yapması gerektiği gibi eşyadan ürün elde etmezse, onun sorumluğu söz konusu olacaktır.

---

[365] **OSTERTAG;** ZGB Art.940. N.10; **KELLER**, s. 55; **FEYZİOĞLU**, s. 275.

[366] **HOMBERGER;** ZK ZGB Art.940. N.11. i; **UTKU**, s. 94; **KURTOĞLU**, İÜHFM. C 29. s. 1199.

[367] **STARK**, BK ZGB Art.940. N.23; **HINDERLING**, SPR V/1. s. 51; **ÖZEN**, Haksız Zilyet. s.261.

2009 Alman BGB § 987 hükmü, kötüniyetli haksız zilyedin özenli bir yönetimin gereklerine uygun davranmaması sebebiyle elde etmeyi ihmal ettiği üründen sorumlu olduğunda bahsetmektedir[84]. Kötüniyetli haksız zilyedin sorumluluğu için hafif özen eksikliği bile yeterlidir.

2010 Objektif görüşte, kötüniyetli haksız zilyet sadece, ihmal ettiği ürünleri, olağan idari faaliyet sonucu gösterdiği özenle elde edemeyeceği savunmasında bulunabilir. Gerçek hak sahibi bu ürünleri kendi olanak ve araçları ile elde edemeyecek olsa bile, yani zararı olmasa dahi kötüniyetli haksız zilyet elde edilmeyen üründen sorumludur.

b. İhmal Edilen Ürünün Değeri ve Tazmini

2011 Kötüniyetli haksız zilyet, elde etmeyi ihmal ettiği ürünün objektif piyasa değerini tazmin etmelidir. Bu ihmal sebebiyle eşyanın varlığı zarar uğramışsa, kötüniyetli haksız zilyet aynı zamanda, bu zarar; kaza sonucu meydana gelse bile, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Eğer ihmal edilen ürün sebebiyle piyasa değeri üzerinde bir zarar söz konusu ise, eşyanın alıkonulmasından doğan zarar kapsamında, kötüniyetli haksız zilyedin sorumluluğuna gidilebilir.[85]

2012 Tazminatın kapsamının belirlenmesinde, benzerliği dolayısıyla gerçek olmayan vekaletsiz işgörme ilişkisine, bu kurumun niteliği olan haksız fiil hükümlerine ilişkin TBK m.51 ve 52 hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilir. Tazminat durumun şartlarına, özellikle, haksız zilyetlikte iade rejiminin kusura dayanmıyor olmasına karşın; kusurun ağırlığına göre belirlenir (TBK m.51)[86]. Tazminat TBK m.52 hükmünde belirtilen sebeplerle, örneğin rıza sebebiyle indirilebilir, hatta kaldırılabilir.

4. Kullanım Yararından Sorumluluk (Ecrimisil)

2013 Kötüniyetli haksız zilyet elde ettiği kullanım yararından (ecrimisilden) değil; elde etmeyi ihmal ettiği kullanım yararından da (ecrimisilden de) sorumludur.

a. Hukuki Dayanağı

2014 Haksız zilyet, zilyet olduğu eşyayı bizzat kullanması sebebiyle doğan kullanma yararının objektif piyasa değerini tazmin etmekle yükümlü-

---

[84] **RAFF**, MünchKomm BGB § 987, N.34; **FRITZSCHE**, BeckOK BGB § 987, N.75; **BERGER**, Jauernig BGB § 987 N.75.

[85] **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.263-264.

[86] **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.265.

dür[91]. Kullanım çıkarı, Türk doktrin ve uygulamasında, "*ecrimisil sorumluluğu*" olarak isimlendirilmektedir.

2015 Aslında kullanım yararı, teknik anlamada eşyadan elde edilen bir ürün değildir. Buna karşın, TMK m.995 hükmü sadece üründen bahsetse de, kullanım çıkarından kötüniyetli haksız zilyedin sorumlu olduğu kabul edilmektedir.

2016 Doktrinde bazı yazarlar, TMK m.993 karşıt kavramından, kötüniyetli haksız zilyedin kullanım yararından (ecrimisilden) sorumlu olduğunu sonucu çıkarmaktadır[92].

2017 Bazıları ise, ürün terimini geniş yorumlayarak aynı sonuca ulaşmaktadır[93].

2018 Biz ise, gerçek hak sahibinin yararını dikkate alarak, kullanım çıkarının ürün olmadığını, TMK m.995 hükmünde örtülü boşluk söz konusu olduğunu, dürüstlük kuralından (TMK m.2 hükmünden) hareketle amaçsal düzeltme ile kullanım yararının TMK m.995 kapsamına dahil olduğunu kabul etmekteyiz.

2019 Kötüniyetli haksız zilyedin kullanım çıkarı, elde ettiği ürün kapsamında değil de elde edilmesi ihmal edilen ürünler kapsamında değerlendirilmesinin daha doğru olduğu ifade edilmektedir. Bize göre ise elde edilen yararların kapsamında değil; ihmal edilen yararlar kapsamında değerlendirilmelidir.

---

[91] "*... davacı, rızası bulunmadan taşınmaz mal üzerindeki zilyetliği elinden alınmış (gasp edilmiş) olan kişidir. Bir taşınmaz malın yararlanma hakkının malik tarafından başka kimseye bırakılması halinde, işgal tazminatını istemek hakkı, yararlanma hakkına sahip olan kişiye (davacıya) ait olur. Başka bir deyişle hak sahibi zilyet, kötü niyetli zilyetten her zaman ecrimisil isteyebilir.*" Y. 3. HD. 04.10.2005 T., 2005/10426 E., 2005/9473 K.; "*... ortak kullanım alanı (sığınak) ... davalı tarafından bodrum katla ilişkilendirilerek, ekonomik fayda sağlamak amacıyla birlikte kullanıldığı; bir kimsenin başkasına ait olduğunu bildiği taşınmazı, hukuki bir dayanağı olmadan kendi malı gibi kullanması ve dolayısıyla ekonomik yarar sağlamasının bir karşılığının olması gerektiği ... Davalı, taşınmazı bizzat kullanmasının objektif değerini ödemeye mahkum edilmelidir...*" Y. HGK. 04.03.2015 T., 2013/3-1640 E., 2015/898 K.; "*... arsaların dava tarihinden geriye doğru ecrimisil istenen süre içinde kiraya verilip verilmediklerinin, veriliyor iseler nasıl ve ne şekilde kiralandıklarının taraflardan delilleri sorulmak suretiyle tespit edilmesi, varsa emsal kira sözleşmeleri ibraz ettirilerek yalnız bu yönden mahallinde keşif yapılıp alınacak rapor doğrultusunda hüküm kurulması gerektiği ...*" Y. 5. HD., 24.11.2009 T., 2009/10257 E., 2009/16575 K.; emsal kira bedelinin göz önüne alınması yönünde ayrıca bkz. Y. 18. HD., 27.01.2016 T., 2015/21939 E., 2016/1289 K.; Y. 5. HD. 04.07.2011 T., 2011/5053 E., 2011/12223 K.

[92] **KELLER**, s. 55-56; **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s. 271.

[93] **STARK**, BK ZGB Art. 940, N.21. Aynı yaklaşım **FEYZİOĞLU**, s. 322-324; **SUNGURBEY**, Kazandırıcı Yıllanma, s. 87-98; **TEKİNEY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 220.

b. Kullanma Yararının (Ecrimisilin) Belirlenmesi

2020 Kullanım yararının (ecrimisilin) yani kötüniyetli haksız zilyedin eşyayı bizzat kullanmasının parasal karşılığının ne şekilde belirleneceği hususu tartışmalıdır[954].

2021 Bu konuda *sübjektif görüş*, kötüniyetli haksız zilyedin eşyayı bizzat kullanması durumunda kendisinin malvarlığına sağladığı yararın esas alınmasını yani kötüniyetli haksız zilyedin eşyayı bizzat kullanarak malvarlığına sağladığı artışın parasal karşılığını tazmin edeceğini savunmaktadır[955].

2022 Doktrinde ve uygulamada benimsenen diğer görüş ise, kötüniyetli haksız zilyedin eşyayı bizzat kullanmasının objektif parasal karşılığını tazmin etmesini savunan *objektif görüş*tür. Objektif kullanım değeri, zilyet olunan eşyanın kullanımını esas alan bir kullanım sözleşmelerinde, bu kullanımın karşılığı olarak geçerli -ticari- yaşam ilişkilerinde hangi piyasa değeri kullandırana ödenecekse, bu kullanım (ecrimisil) bedeli olarak esas alınır[956].

2023 Görüşümüze göre, elde edilmesi gereken kullanım çıkarı yönünden objektif görüş esas alınmalıdır.

2024 Kullanıma esas alınacak kullanım sözleşmesi, eşyanın varlığına ve ekonomik olarak tahsis gayesine uygun sözleşmedir; genellikle kira sözleşmesidir. Yine aynı ölçütten hareket ederek, kira sözleşmesinin çeşidinin ne olduğu yani adi kira mı yoksa ürün kirası mı olduğu belirlenecektir[957]. Örneğin, bir arsanın kullanımında adi kira sözleşmesi, tarlanın kullanımında ürün kira sözleşmesi, dairenin kullanımında konut veya çatılı yeri kira sözleşmesinde ödenecek olan kullanım bedeli esas alınacaktır.

---

954 Bu konuda bkz. **ÖZEN,** Haksız Zilyet, s.271 vd.

955 *"... Dava konusu taşınmazın üzerinde gelir getirici herhangi bir yapı olmamakla birlikte ... davalının bu yeri yol olarak kullanmak suretiyle ekonomik bakımdan fayda sağladığı açıktır. Taşınmaz davalı tarafından kira ödenmeden kullanıldığına ve ekonomik yarar sağlandığına göre ecrimisilin belirlenmesinde davacının sağlayabileceği değil, davalının sağladığı yararın esas alınması gerekir."* Y. HGK., 31.03.2010 T., 2010/3-146 E., 2010/184 K.

956 *"... Bu engel olmanın sağladığı mal varlığına girmeyen çoğalma en az kira, en çok da tam gelir yoksunluğu olarak değişebilir."* Y. HGK. 19.06.2015 T., 2014/5-39 E., 2015/1718 K.; aynı yönde bkz. Y. HGK. 04.03.2015 T., 2013/3-1640 E., 2015/898 K.; Ecrimisil hesaplamasında ÜFE'nin de nazara alınması yönünde bkz. Y., 1. HD., 24.01.2017 T., 2016/12231 E., 2017/483 K.; Y. 1. HD., 24.01.2017 T., 2014/16640 E., 2017/428 K.

957 **ÖZEN,** Haksız Zilyet, s.272.

D. Zorunlu Giderler Tazminatının Hak Sahibi İçin Zorunlu Olanlarla Sınırlandırılması

2025 İyiniyetli olmayan haksız zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir (TMK m.995 II). Kötüniyetli haksız zilyet, yararlı giderleri talep edemez; sadece "*söküp alma hakkını*" kullanabilir.

2026 Zorunlu gider harcamasının yine haksız kötüniyetli zilyet tarafından yapılması gerekir. Bir giderin zorunlu olup olmadığı yukarıda açıkladığımız üzere, objektif değerlendirmeye tabidir. Ancak, TMK M.995 II, kötüniyetli haksız zilyedin yaptığı zorunlu giderlerin tazminin talep edebilmesini, bu giderlerin yapılmasının gerçek hak sahibi için de zorunlu olması şeklindeki subjektif bir olguya bağlayarak onu sınırlandırmıştır.

2027 Bu hüküm şu şekilde anlaşılmalıdır: Kötüniyetli haksız zilyet, sadece kendisini, TMK m.995 II hükmüne göre sorumlu olmaktan korumak için yaptığı giderleri talep edebilir; yaptığı giderler içinde ise kendisini bu sorumluluktan kurtarmaya yaramayanları talep edemez[198].

2028 Kötüniyetli haksız zilyedin yaptığı değerlendirmelerin, zorunlu olup olmadığı hususunda, bu giderin gerçek hak sahibinin kişisel çıkarına ve kişisel ilişkilerine uygunluğu konusunda subjektif değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirme yapılırken, kötü niyetli zilyedin zorunlu gider yapmasını haklı göstermesi gerekir.

2029 *Keller*, kötüniyetli haksız zilyedin yaptığı zorunlu giderler konusunda, BGB § 994 hükmünde düzenlen vekaletsiz işgörme hükümlerine yapılan atfa ilişkin çözümü[199], İsviçre hukuku için savunmaktadır[200].

2030 Bu görüşe göre, kötüniyetli haksız zilyedin giderinin zorunlu olarak nitelendirilmesi için, Alman hukukunda kabul edildiği üzere, kötüniyetli zilyedin sadece "başkasının işini görme iradesi" aranmaksızın, bu giderlerin yapılması ve bunun karşılanması, gerçek hak sahibinin yararına ve onun çıkarına veya farazi iradesine uygunsa, bu giderleri zorunlu olarak kabul etmek gerekir[201].

---

[198] **KELLER**, s. 81. Bu yakaşım bkz. **ÖZEN**, Haksız Zilyet, s.339 vd.

[199] Bkz. **MÜLLER**, SachenR Rn. 596; **STADLER**, Soergel BGB § 004. N. 9; **GURSKY**, Staudinger BGB § 994. N. 23.

[200] **KELLER**, s. 85 ff.

[201] **WIELAND**, ZGB Art.939, N.12; **STARK**, BK ZGB Art.939, N.30. Hinderling, kötüniyetli haksız zilyedin, gideri özenli bir idarenin gereği olarak gerçekleşmesi halinde, bu giderin gerçek hak sahibi bakımından zorunlu kabul etmektedir. **HINDERLING**, SPR V/1, s. 516.

2031 Bu husus, gerçek hak sahibinin kendi malvarlığına yönelik davranış biçimi, kurduğu ilişkiler, kendi işini yürütürken aldığı tedbirler yönünden değerlendirilecektir. Gerçek hak sahibinin rızası varsa, tür nitelemesi dahi yapılmaksızın kötü niyetli haksız zilyet tarafından yapılan gideri, tazmini gereken zarar olarak kabul etmek gerekir.

E. Özel Durum: Eşyanın Kime İade Edileceğinin Bilinmemesi

2032 İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur (TMK m.995 I). TMK m.995 I hükmünün en önemli uygulama alanı TMK m.769 ile 771 arasında düzenlenen bulunmuş eşya hükümleri olduğu kabul edilmektedir[221]. Taşınırı bulan kişinin bu eşya üzerinde hak sahibi olmadığını, başkasının hak sahibi olduğunu bilecek durumdadır; en azından bilinmesi gerekir. Bu sebeple eşyayı bulan kişi, kural olarak, kötüniyetli haksız zilyet durumundadır. Terk edildiği durum şartlardan anlaşılıyorsa, şartlara göre iyiniyetli sayılabilir.

2033 Bulan kimsenin haksız zilyet sayılmaması için ortaya atılan görüşler; bulan kişi, kaybeden yararına, kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmişse, zilyetliği gerçek sahibi çıkana kadar kanundan doğan bir bulundurma yetkisinin olduğu kabul edilir; bu sebeple de haksız ve kötüniyetli zilyet sayılmaz. Eğer bulan kişi TMK m.769-7790'daki yükümlüklerini gerçek sahibi bulmak için yerine getirmez veya gerekli özeni göstermezse kusurlu sayılır.

---

[221] KELLER, s.42. Aksi yaklaşım bkz. ÖZEN, Haksız Zilyet, s. 40.

Üçüncü Bölüm

TAPU SİCİLİ

Yazarlar:
Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA
Doç. Dr. Murat TOPUZ

§ 11. TAPU SİCİLİNİN ANLAMI, TÜRK MEDENİ KANUNUNDAKİ YERİ, TAŞINMAZLAR BAKIMINDAN ALENİYETİ SAĞLAYAN SİSTEMLER İLE MODERN HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER

I. GENEL AÇIKLAMALAR

2034 TMK'nın dördüncü kitabı Eşya Hukuku kitabıdır. Eşya Hukuku kitabı, TMK m. 683 ile 1027 arasında düzenlenmiştir. Eşya Hukuku, Medeni Hukukun "ayni hak"kı düzenleyen alt dalıdır. Eşya hukuku kitabı kendi içinde üç kısma ayrılır: 1- Mülkiyet, 2- Sınırlı Ayni Haklar, 3- Zilyetlik ve Tapu Sicili. TMK'da "Tapu Sicili" bölümünün sistematiği aşağıdaki gibidir.

İKİNCİ BÖLÜM: TAPU SİCİLİ

A. Kurulması: TMK m.997-1003
   I. Sicili Bakımından: TMK m.997-1003
   II. Tapu Sicilinin Tutulması: TMK m.1004-1005
   III. Tapu İdareleri: TMK m.1006-1007

B. İşlemler: TMK m.1008- 1019
   I. İşlemin Konusu: TMK m.1008-1012
   II. Tescilin ve Terkinin Koşulları: TMK m.1013-1016
   III. Tescilin Biçimi: TMK m.1017-1018
   IV. Tebliğ Sorumluluğu: TMK m. 1019

C. Tapu Sicilinin Açıklığı: TMK m.1020

D. Tescilin Etkileri: TMK m.1021-1024
   I. Tescil Yapılmamasının Sonuçları: TMK m.1021
   II. Tescil Sonuçları: TMK m.1022- 1024

E. Terkin ve Değiştirme: TMK m.1025-1026
   I. Yolsuz Tescilde: TMK m.1025
   II. Ayni Hakkın Sona Ermesinde: TMK m.1026.

2035 Türk Medeni Kanunu'nun Üçüncü kısım, ayni hakkın kazanılması, el değiştirmesi ve sona ermesi bakımından büyük önem taşıyan zilyetlik ve tapu siciline tahsis edilmiştir (TMK m. 923-1027). Her iki kurumda da temel amaç ayni hakka aleniyeti sağlamaktır. Taşınırlarda zilyetlik, taşınmazlarda tapu sicili tarafından gerçekleştirilir[1].

2036 TMK m. 997 "*Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur*" hükmünü düzenlemiştir. Tapu sicili, tapu kütüğü, yevmiye defteri ve plan gibi resmi belgeler ile pek çok yardımcı sicilden meydana gelen bir bütünü ifade eder (TMK m.997 II).

2037 Tapu sicili (*Grundbuch*), sadece taşınmaz üzerindeki ayni haklar konusunda bilgi veren bir sicil, bu sicilin dahil olduğu geniş anlamıyla diğer defterler ve belgeler sistemi değildir. Taşınmaz üzerindeki ayni hakların kurulması ve devrinin özel olarak düzenlenmiş resmi kütüğe yazılımı ile aynı hakkın etki ve hukuki sonuçlarını göstermesi sistemi taşınmaz hukuku için benimsenmiştir.

2038 Tapu sicilinin temel amacı taşınmazlarda aleniyet ilkesini gerçekleştirmeye aracı olmak ve böylelikle taşınmaz üzerindeki ayni hakkı görünür kılmaktır[2].

2039 Ayni haklar tapu sicili sayesinde, -mutlak hak niteliğine uygun olarak- herkese etkili olur ve hukuki sonuç doğurur. Tapu sicili ayni hakları herkese bilinebilir kıldığından, herkesin de tapu sicilindeki hakka uyması beklenir[3].

2040 Tapu sicilinin tutulmasında, aynilik ilkesi, tescil ilkesi, sebebe bağlılık ilkesi, talep ilkesi, güven ilkesi, devletin sorumluluğu ilkesi gibi ilkeler göz önünde tutulur. Kişiler, güven ilkesi çerçevesinde, tapu sicilindeki kayıtlara dayanarak, iyiniyetle ayni hak kazanabilirler (TMK m. 1023). Tapu siciline tescil edilebilen taşınmaza ilişkin ayni hakları TMK m.1008 saymıştır: Mülkiyet, irtifak hakları ve taşınmaz yükleri, rehin hakları.

2041 Bunlara ilaveten tapu kütüğüne devletin (kamu kurum ve kuruluşlarının) kamu irtifak haklarının da yazıldığını belirtelim.

---

1 **ANTALYA**, EH I, N. 459, 473; **ANTALYA**, EH II, N. 176.

2 **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N.364; **STEINAUER**, I, N.526 ff.

3 **DESCHENAUX**, s. 6.

2042 Tapu sicilinde, kayıt, tescil, terkin, şerh, beyan ve düzeltme adını taşıyan çeşitli işlemler yapılır:

2043 "Kayıt", taşınmaz malların tapu kütüğüne ilk olarak yazılmasıdır. Söz konusu işlemde her taşınmaza bağımsız bir çift tapu kütüğü sayfası ayrılır. Buna "ayni yöntem" denir. İstisnalar dışında taşınmaz malların kaydı kadastro (tapulama) faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilir.

2044 "Tescil", ayni hakların ve edinme sebeplerinin tapu kütüğünün ilgili sütununa yazılmasıdır. Tescilin kendisinden beklenen sonuçları yaratmasının, geçerli bir hukuki sebep ile yetkili kişinin talebinin mevcut olması şeklinde iki şartı vardır. Aynı esaslar, sona erdirmek amacıyla ayni hakkın çizilmesi şeklinde tanımlanabilecek "terkin" işlemi açısından da geçerlidir.

2045 Şerh, özellikle bir kısım alacak haklarının güçlendirilmesi bakımından önem taşıyan bir işlemdir. "Şerh", hukuk düzeninin izin verdiği hususların tapu kütüğünün şerhler sütununa; "beyan" da, yine hukuk düzeninin izin verdiği hususların tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazılması demektir.

2046 "Düzeltme (tashih)" işlemiyle de gerçek hak durumuna uygun düşmeyen tapu sicili kayıtlarının gerçeğe uygun hale getirilmesi sağlanır. Düzeltme, ilgililer muvafakat etmezlerse, hukuk düzeninin öngördüğü istisnalar dışında sadece mahkeme kararına dayanılarak yapılabilir. Bu amaçla açılacak dava Medeni Kanun'un 1025'inci maddesinde düzenlenmiştir ve ayni nitelik taşır.

II. İNCELEMEDEKİ YERİ

2047 TMK m.973 ve devamında düzenlenen zilyetlik ve TMK m.997 ve devamında düzenlenen tapu sicili doktrinde genellikle sistematik olarak, kanun sistematiğinden farklı olarak, TMK m.683 ve devamında düzenlenen mülkiyet ve sınırlı ayni haklardan önce incelenir. Bunun sebebi bu iki kurumun da ayni hakkın aleniyetini sağlayan kamuya açıklık aracı olmasındandır. Eşya üzerindeki hak kendini dışarıya zilyetlik ve tapu sicili ile görünür kılmaktadır. Bir kişinin ayni hak sahibi olduğu eşya ile olan ilişkisi taşınmazlarda tapu sicili, taşınırlarda zilyetlik şeklinde dışa yansıyan bir görünümle anlaşılır.

2048 Aleniyeti sağlayan; bir şey üzerindeki hukuki hakimiyet mülkiyet, bir şey üzerindeki fiili hakimiyet ise zilyetliktir[4].

2049 Biz de TMK Eşya Hukuku sistematiğini takip etmeyerek, öncelikle tapu siciline ilişkin açıklamalarda bulunacağız. Bu ayrıma uygun olarak, zilyetlik incelenmiş idi. İlerleyen bölümlerde ise, TMK sistematiğine uygun olarak önce mülkiyeti, daha sonra sınırlı ayni hakları inceleyeceğiz[5].

2050 Bu incelememizde, zilyetliğin ve tapu sicilinin aleniyeti sağlama aracı olarak sadece şekli değil, maddi hükümlerde de düzenlenmesinden; özellikle şekli eşya hukuku ve maddi eşya hukuku ayrımı yapmayacağız[6]. Yine zilyetliğe ve tapu siciline sadece mülkiyetin içinde yer veren bir sistematikten[7] de kaçınacağız.

III. ZİLYETLİĞİN TAŞINMAZLARDA KAMUYA AÇIKLIK SAĞLAMADA YETERSİZLİĞİ

2051 Zilyetlik, taşınırlarda, kamuya açıklık aracı olarak aleniyeti sağlayarak ayni hakkı kurucu ve düzenleyici fonksiyonu icra eder.

2052 Tarihi gelişimi içinde, özellikle Roma Hukukunda zilyetlik taşınmazlarda da kamuya açıklık aracı olarak kullanılmak suretiyle aleniyeti sağlanmaya çalışılmıştır.

2053 Taşınmazlar, nitelikleri ve özellikleri gereği bir yerden başka bir yere taşınamadıklarından, cep telefonu örneğinde olduğu üzere taşınırlarda olduğu gibi üzerinde hakimiyeti sağlanamadığından, örneğin bina, arazi gibi taşınmaz üzerindeki hakkın ve hak sahibinin herkes tarafından anlaşılabilir kılmakta yeterli değildir. Başka bir deyişle, zilyetlik taşınmazlar üzerindeki bir ayni hakkın varlığı konusunda aleniyeti fonksiyonunu gerçekleştirmeye yetersizdir[8]; belirsizliğe yol açar. İlaveten zilyetlik taşınmazlarda, hak karinesi ve tapuya güven ilkesinin uygulanmasında taşınırlar gibi haklı hukuki sonuçları doğurmaya elverişli değildir[9].

---

4 ÜNAL/BAŞPINAR, s. 81.

5 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 33 vd.; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 49 vd.; AKİPEK/AKINTÜRK, s. 5; NOMER/ERGÜNE, s.1 vd.

6 ÜNAL/BAŞPINAR, s. 78.

7 REY, I, 1319 ff, 1693 ff.

8 ŞENGÜL, s. 15.

9 ZOBL, N.14; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 241 vd.

2054 Gerçekten taşınmaz üzerindeki hak sahibini belirlemek yani kimin hak sahibi kimin diğer bir ayni hak sahibi olduğu konusundaki sonsuz tahminleri ve ihtimalleri gündeme getirebilir; bu tahmin ve ihtimaller taşınmaz üzerindeki gerçek ayni hak sahibini belirlemeyi maddi hukuk yönünden bazen imkânsız; bazen de en azından hak sahibini belirsiz kılar. Bu belirsizlik Yargılama hukukunda da ispat zorluklarını, ardı kesilmez hak taleplerini gündeme getirir ki bu hukuk güvenliğini ilkesi ile bağdaşmaz[10].

2055 Yine taşınmazlar üzerindeki hakların taşınırlara göre daha uzun süreli olması, üzerindeki hakkın uzun süre sonra ispatına gerekli kılabilir; bu noktada zilyetlik geçmişte kurulmuş olan ayni hakkın varlığının veya taşınmaz üzerinde kurulmuş olan birden fazla ayni hakları hizmet edemez.

2056 Son ihtimalde, zilyetliğin taşınmazlarda kamuya açıklık aracı olarak kabul edilmesi, başta taşınır rehni olmak üzere sınırlı ayni hak sistemi üzerinde olumsuz ve haksız sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olur[11].

2057 Günümüzde gelişen ve globalleşen hukuk düzeninde, bazı özellikli taşınırlarda zilyetliğin tek başına bile aleniyeti sağlamada yeterli olamaması sebebiyle tapu siciline benzer fonksiyon ve işlev gören sicil sistemleri getirilmiştir[12]. Bunlardan bazısı sicilin hem olumlu hem olumsuz hukuki etkisini yerine getirirken, bazıları ise sadece olumsuz hukuki etkisini gerçekleştirmektedir.

2058 Taşınmazların yeryüzünde sınırlı olması sebebiyle gerek hak sahipleri gerekse kamu tüzel kişileri için özel bir iktisadi öneme sahip olmaları yanında bir finans aracı olarak da kullanılmaktadırlar[13]. Bu özelliklerine uygun fonksiyon icra edebilmeleri aleniyet fonksiyonunu zilyetlikle değil, tapu sicil sistemi içinde gerçekleştirebilirler.

2059 Bu sebeplerle, taşınmazlardaki aleniyet fonksiyonu taşınırlara ilişkin kamuya açıklık aracı olan zilyetlikle sağlanamaz. Bu sebeple taşınmazlarda üzerindeki ayni haklarda kamuya açıklık aracı olarak farklı sistemler geliştirilmiştir.

---

[10] ZOBL, N.12 ff.

[11] ŞENGÜL, s. 16.

[12] Bu siciller için bkz. ANTALYA, EH I, N. 460 vd.

[13] ÜNAL/BAŞPINAR, s. 272.

IV. TAŞINMAZLARDA KAMUYA AÇIKLIĞI SAĞLAYAN SİSTEMLER

A. Tarihi Gelişim

2060 Babil ve eski antik Yunan şehirlerinde taşınmaza ilişkin hakların kayıtlarının tutulduğu bilinmektedir. Özellikle Roma yönetimindeki Mısır'da, emlak değişiminin kayıt altında olduğu ifade edilmektedir[4]. Bu kayıtların günümüz anlamında tapu sicili sistemi anlamında değil de daha çok kamu otoritesinin vergi amaçlı kontrol sistemi olduğu kabul edilmektedir[5].

2061 Klasik Roma hukukunun aleniyet düşüncesine yabancı olduğu; Roma ekonomik yaşamının taşınmazlar dahil bazı özellikli malvarlığı değerlerinin *mancipatio* aracılığıyla ve *in iure cessio* özel devir şekillerinde yapılmakta ve malvarlığının devri için teslim (*tradio*) yeterli görülmekte idi[6]. Bu sebeple, Roma-Pandekt hukukunda tapu sicil sistemlerinin gelişmesine katkısı olamamıştır[7].

2062 19. yüzyıla kadar olan dönemde eski ortak Alman hukuk çevresinde, sonradan mahkeme şahitliğine başvurma şeklindeki uygulama, modern tapu siciline temel teşkil edebilecek izleri ortaya koymaktadır[8].

2063 Eski ortak alman hukuku uygulamasında, devir anlaşması ayni hakkın temlikı anlamına gelmekte, taraflar isterse bunu mahkemeye sunmakta idiler. Bu takdirde anlaşma ispat belgesi haline gelmektedir. 12. Yüzyıldan itibaren ise bu temlik belgesi yalın bir tarihi kronoloji içinde kişi ve taşınmaz bazında düzenlenmekte, defterler tapu defteri (*Grundbücher*) ve belge defteri (*Schreinsbücher*) isimleri ile kullanılmaya başlamıştır. Bu defterler günümüzdeki tapu siciline hakim kişi ve her taşınmaza tek sayfa siteminin de temelini oluşturmuştur[9].

2064 Bir sonraki aşamada da bu defterler güvenin korunması ve tescilin kurucu etkisi fonksiyonu görmeye başlamıştır[10]. Bu fonksiyonlar günü-

---

4 SIMONIUS/SUTTER, I, s.172; LIVER, ZBGR 1970, s. 3; WACHE, MünchKomm vor §§ 873 ff., BGB, N.11.

5 Ayrıntılı bilgi için bkz. WOLF, H. J., s. 185 ff (190).

6 HONSELL/ MAYER-MALY/ SELB, s. 83.

7 WACHE, MünchKomm vor §§ 873 ff BGB, N.11.

8 WOLFF/RAISER, s.81; LIVER, ZBGR 1970, s.3.

9 GSCHNITZER, s. 27.

10 LIVER, ZBGR 1974, s.4.

müz tapu sicil sisteminin tescil ilkesi ve güvenin korunması ilkesinin temelini oluşturmaktadır[21].

2065 Roma hukukunun iktibası döneminde ise, Alman hukuk çevresinde tapu sicili sisteminin kısmen terk edildiği, Roma hukukunun tapu sicili ve benimsenmediği, Roma hukukunun alenileştirme şekilleriyle yetinildiği görülmektedir. Ortak hukukta Roma hukuku etkisiyle tapu sicil sisteminden tamamen de terk edilmediği karma sisteminde, ipotek sicilinin genellikle uygulandığı da ifade edilmektedir[22].

2066 Kanunlaştırmalara (ZGB (İsviçre Medeni Kanunu)[23] ve BGB (Alman Medeni Kanunu)[24]'nin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yeknesak bir taşınmaz devri sisteminin ve buna bağlı sicil sisteminin varlığından bahsedilemez.

2067 İlk defa Prusya'da 1872 yılında tapu sicili sitemi uygulamaya konulmuş; bu kanunu takip eden 1897 tarihli Tapu Sicil Kanunu günümüz Alman hukuk düzenlemelerine en azından madci hukuk yönüyle temel teşkil etmiştir[25]. Bu düzenleme en kuvvetli yansımasını Avusturya hukukunda 1871 tarihli Tapu Sicili Kanun'unda kendisini göstermiş; tüm ülkede yeknesak bir hukuk sistemi getirilmiştir[26].

B. Taşınmazlarda Kamuya Açıklık Araçlarına İlişkin Sistemler

2068 Taşınmazlarda aleniyeti sağlayan kamuya açıklık araçlarına ilişkin sistemleri üç temel başlıkta toplayabiliriz: Kayıt tespit sistemi; Tasdik sistemi; Sicil sistemi.

1. Kayıt/Tespit Sistemi

a. Genel Açıklamalar

2069 Kayıt sistemi (*Transcription; Registersystem*), ZGB ile tapu sicil sistemine geçilmeden önce İsviçre'nin genellikle Fransızca konuşan kantonlarında Geng, Wallis, Freiburg Neuenburg, Tessin ve Bern (yeni

---

21 GSCHINITZER, s. 27.

22 WOLFF/RAISER, s.82; Ayrıca bkz. WIEACHER, F., s. 2.

23 ZOBL, N.28 ff. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. HUBER, System und Geschichte IV, 700 ff.

24 ZOBL, N. 26 ff.

25 COING, s.228, 232 ff.; LIVER, ZBGR 1979 s.4 ff.; ZOBL, N.26.

26 COING, s.228; ZOBL, N.27.

Kantonsteil) gibi uygulanmakta idi[27]. Bu sistem günümüzde etkisini Fransız hukukunda göstermiştir[28].

2070 Taşınmazlar ayni hakkı konu alan yazılı veya resmi şekilde yapılan ayni hakkı devrini konu alan hukuki işlemlerle, örneğin satış, bağışlama, rehin vb sözleşmesi ile - devredilir veya mülkiyet hakkını sınırlayan, örneğin irtifak, rehin vb. sözleşmelerin kurulmasıyla birlikte sınırlı ayni haklar tesis edilir. Kısaca, tarafların iradelerinin ayni hakkın tesisi veya devri konusunda uyuşmasıyla (uyuşma prensibi) birlikte aynı hakta tesis edilir[29].

2071 Tarafların yaptıkları hukuki işlem sadece taraflar arasında kişisel değil, aynı zamanda taraflar arasında ayni sonuçlar da doğurur. Hukuki işlemin kurulmasıyla sadece borçlandırıcı işlem değil, tasarruf işlemi de gerçekleşir; sözleşme konusu taşınmazın mülkiyeti sözleme tarafı olan devralana intikal etmiş olur. Sözleşme yapma özgürlüğü kapsamında yapılan sözleşme ile mülkiyetin aynı anda intikali gerçekleşir[30].

2072 Taraflar yaptıkları taşınmazdaki ayni hakkının devrine veya kazanımına ilişkin sözleşmeyi kamu veya resmi bir makam tarafından tutulan bir sicile kaydettirebilirler.

2073 Sözleşmenin sicile kaydı, mülkiyetin intikalinin veya ayni hakkın kazanımının bir kurucu olgusu niteliğinde değildir. Zira sicili kayıttan önce mülkiyet intikal etmiş veya sınırlı ayni hak sözleşmenin kurulmasıyla kazanılmıştır.

2074 Sözleşmenin sicile kaydı ise kurucu değil açıklayıcı hukuki etkiye sahiptir. Sözleşmenin kaydı ile birlikte ayni hak aleniyet kazanır ve kazanılan aynı hak sadece sözleşmenin karşı tarafına değil, üçüncü kişilere de ileri sürülebilir bir hukuki etkiye kavuşur[31].

2075 Bir ayni hakkı sona erdiren sözleşmeler ve bu sözleşmelerin sicile kaydı aynı hukuki etkiye sahiptir.

---

27 Bu sistem için bkz. **DESCHENAUX**, SPR V/3, s. 25; **SIMUNIUS/SUTTER**, I 171; **STEINAUER**, N.530; **ZOBL**, N. 27 ff.

28 **NIKLAUS**, L., s. 26 ff.

29 **ZOBL**, N. 32.

30 **DESCHENAUX**, SPR V/3, s.13 ff.; **STEINAUER**, I, N.529; **ŞENGÜL**, s. 14-15; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 274.

31 **HOMBERGER**, vor Art.942 ff., N.6; **SIMUNIUS/SUTTER**, I, 171 f; **ZOBL**, N. 33.

2076 Kayıt sisteminde, tüm ayni hakkı konu alan sözleşmelerin aynı –tek bir - sicile yazıldığı veya ayni haklar için ayrı ayrı sicile kaydedildiği, örneğin mülkiyetler mülkiyet siciline, rehnin rehin siciline, hatta karşılıksız kazandırma sözleşmelerinin, örneğin bağışlamanın bağışlama siciline kaydedildiği uygulamalar da söz konusudur. Bu temel sicil yanında hak sahipleri veya taşınmaz sicili şeklince yardımcı siciller söz konusudur.

2077 Kayıt sisteminde aynı taşınmaz üzerindeki hakları bir bütün olarak aynı sayfada görme imkânı bulunmadığından, aleniyetin tam anlamıyla gerçekleştiğinden bahsedilemez[32].

2078 Kayıt sisteminde sicile kayıt genellikle taşınmaz esas alınarak değil, hukuki işleme dayanılarak başvuru tarihi esas alınarak gün ve saat belirtilerek kronojik olarak yapılmaktadır[33]. Taşınmaza ilişkin her ayni hak başvurusu yetkili resmi makamca tarih esasına göre kaydedilmektedir. Haklarda öncelikte bu kayıt tarih ve saatine göre belirlenmektedir. Örneğin taşınmaz rehnindeki öncelik kayıt sırasına göre belirlenecektir. Bu sebeple de kayıt sisteminde rehinli dereceler sisteminin uygulanması mümkün değildir.

2079 Taşınmazın devrini veya sınırlı ayni hakkı konu alan Mahkeme kararları da bu sicile kaydedilerek açıklayıcı etkiye sahip olur. Kayıt bu sistemde sadece ispat fonksiyonu görür.

2080 Herkes sözleşmenin kaydedildiği sicili inceleme ve bu sicildeki bilgileri öğrenme hak ve yetkisine sahip olur. Sözleşmenin kaydedildiği sicil kurucu olmadığı için, sicile kayıt hukuki işlemdeki eksikliği gidermez ve kayıt konusu hak konusunda karine teşkil etmez[34].

2081 İlaveten aynı sebeple, aksine yasal düzenleme yoksa, sicile güvenene iyiniyetli üçüncü kişilere ayni hak kazandırmaz. Buna karşın, yasal düzenleme imkan veriyorsa, iyiniyetli olarak ayni hak kazanan lehine yapılan kayıt, onun tarafından ayni hakkın onun tarafından kazanılmasına imkan verir.[35]

---

[32] ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 275; DESCHENAUX, SPR V/3, s.14.

[33] ZOBL, N.33.

[34] ZOBL, N.33.

[35] ÜNAL/ BAŞPINAR, s.275; DESCHENAUX, SPR V/3, s.13 ff.

b. Kayıt Sistemini Uygulayan Ülkeler

aa. Kıta Avrupası Ülkelerinde

Kayıt sistemi halen Fransa ve İtalya'da uygulanmaktadır.

aaa. Fransa

2082 Fransız hukukunda, kural olarak, ayni hakkın intikali (veya değişimi veya sınırlanması) borçlandırıcı işlemin kurulması ile geçekleşmektedir. Bu sisteme uyuşma sistemi (*Konsensprinzip*) ismi verilmektedir[36].

2083 Bu ilke taşınır ve taşınmaz ayrımı yapılmaksızın uygulanmaktadır. Bunun sonucu olarak da taşınmaz konu alan ayni haklar kural olarak kaydına gerek bulunmamakta, taşınmazın ticari işlemlerde devri sadece tarafları arasında –*inter partes*-, kamu katkısı olmaksızın etkili olmaktaydı[37]. Bu sebeple de maddi sonuçlarını düzenlemediğinden, arazinin veya ona ilişkin bir değerin örneğin binanın arazi defterine yazılımı sadece vergi dairesi için bilgilendirmeden öteye bir maddi hukuk açısından bir anlam taşımamaktaydı.

2084 Sonraki dönemde ise taşınmaz üzerindeki bir ayni hakkın değişiminin bir sicile yazılımı, sadece borçlandırıcı ve bilgilendirici değil, ayni hakkın üçüncü kişilere karşı etkili kılma amacını sağlama işlevi kazanmaya başladı. Bu *dolaylı etki* (*Translativwirkung*) olarak ifade edilmektedir[38].

2085 Taşınmazların ticari hayatta değişiminin artması ve artan bina inşası imkanı Fransız tapu sicil sisteminin yetersizliğini ortaya koymaya başlamıştır. Örneğin taşınmaz rehni sisteminde özellikle çok sayıda yasal ipoteğin takip edilmesini ve belirlemesini imkânsız kılması ticari hayatı ve bu yattaki işlem güvenliğini etkilemeye başlamıştır.

2086 Yine taşınmazda yapılan bina inşasıyla binanın tamamının veya bir kısmının (dairenin) sahibi ile arazi sahibini belirlemekte zorluklar ve bunların ipotek sahibi ile olan ilişkileri yönünden hukuki sorunları de beraberinde getirmiştir. 1995 yılında şekli tapu siciline kaydında temel bir reformu gerekli kılmıştır[39].

---

[36] DESCHENAUX, SPR V/3, s.116 ff.; ZOBL, N.46 ff., FERID/SONNENBERGER, N.519, 643.

[37] FERID/SONNENBERGER, N.584.

[38] FERID/SONNENBERGER, N.585 ff.

[39] FERID, s. 953 ff.

2087 Bu reform düzenlemesi ile birlikte ayni hakkı konu alan bazı hukuki işlemlerin (ipotek ve bağışlama sözleşmelerinin) bir sicile kaydedilerek kamuya açık hale getirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sistem gizli rehin taşınmaz rehni kurulmasına imkân vermektedir[40].

2088 Tüm yükümlülük ayni hakkı konu alan tüm hukuki işlemler içinde söz konusu olabilmektedir. Kayıt ederek alenileştirme yükümlülüğüne aykırı davranışın hukuk sonucu ise zararın tazmınıdır. Tapu siciline kayıt taşınmaz kataloğuna kaydedilmektedir; söz konusu katalog kişi ve taşınmaz katalogları ile desteklenmiştir.

2089 Fransız kayıt sisteminde kaydedilen hukuki işleme konu ayni hak üçüncü kişilere de etki olmakta; kaydedilmemiş hukuki işlem konu ayni hak ise Sadece taraflar arasında hukuki sonuçlarını göstermektedir[41]. İşlemin sicile kaydı, üçüncü kişinin kamuya güvenin korunmasını hukuki sonucunu doğurmamaktadır[42].

bbb. İtalya

2090 İtalyan tapı sicil hukuku Ccit art.2643 vd. hükümlerinde düzenlemektedir[43]. İtalyan kamu sicili resmi bir sicildir (Ccit art.2673). Tescil, Fransız hukukunda olduğu üzere, taşınmazlarda ayni hak kazanımı için kural olarak kurucu olgu değildir; ayni hak kazanımı için uyuşma ilkesi geçerlidir (Ccit art.253, 2644 I)[44]. Ancak işlemin tescili halinde tescil üçüncü kişilere etkilidir (Ccit art.2644). İtalyan hukukunda sebebe bağlılık ilkesi geçerlidir[45].

bb. Anglo-Amerikan Ülkelerinde

2091 1926 yılına kadar Anglo-amerikan taşınmaz hukuku sistemine dahil ülkelerden İngiltere ve Galler'de taşınmaz ilişkin hukuki işlemler bir deftere veya sicile kaydedilmemekteydi. Kayıt İngiltere içinde sınırlı olarak sadece bazı şehirlerde (Gradfschaften Middlesex, Yorkshire ve London) uygulanmaktaydı. 1926 tarihinde 1925 tarihli England und Wales der

---

40 FERID/SONNENBERGER, N. 586.

41 STADLER, s. 504 ff.

42 FERID, s.954; STADLER, s.514 ff.

43 ZOBL, N.44; DESCHENAUX, SPR V/3, s.17-18. Bkz. BAUER/KÖNIG/KREUZER/ZANON, s. 1351 ff.

44 STEFANI, s. 17 ff.

45 DESCHENAUX, SPR V/3, s. 18; ZOBL, N. 53.

Land Charges Act ve Land Registrarion Act yürürlüğe girmesiyle birlikte kayıt sistemi Anglo-amerikan siteminde uygulanmaya başlamıştır.

2092 Bu kayıt sistemi iki şekilde uygulanmıştır[46]:

- Deed kayıt sistemi (*Die Deeds Registration*),
- Title kayıt sistemi (*Die Title Registration*).

aaa. Deed Kayıt Sistemi

2093 Kayıt sistemine benzer "Deeds Registration" adıyla ifade edilen sistem halen bazı Angloamerikan ülkelerinde, örneğin İngiltere, Galler, İrlanda, Kanada'nın Kepek (Quebec) eyaletinde; Avusturalya'da uygulanmaktadır. Bazı Asya, Afrika ve Amerika'da bazı eski İngiliz kolonilerinde uygulanmaktadır.

2094 "Deed" taşınmaz üzerindeki tasarrufları gösteren özellikli şekli sahip bir belgedir. Kayıt sistemi bu "Deed"lerdeki bilgilerin yazıldığı kopya veya çıktılar toplandığı kayıtlara ilişkin sicillerin hepsini ifade etmektedir. Deed kayıtlar taşınmazlardaki tasarrufun kamuya açıklığını sağlayan araçtır. Deed kayıt sistemi iki farklı şekilde uygulanmıştır[47]:

2095 İngiltere ve Galler'de 1925 tarihli Land Charges Act kayıt sicillerinde, mülkiyetin devirleri değil, sadece önemli ayni sınırlama ve yükler kaydedilmekteydi. Diğer deed kayıt sistemi uygulama şekli ise, mülkiyetin nakli ve sınırlı ayni hakların kaydedildiği kayıt sicillerinden oluşmaktaydı. Bu uygulama, İrlanda, Avusturalya, Kanada'da Quebec, Ontario, Manitoba ve bazı İngiliz kolonilerinde uygulandı.

2096 Deed sistemi, bir kayıt sistemidir. Tarafların taşınmazın mülkiyetinin devri veya mülkiyetin sınırlanması hususunda tarafların uzlaşması ile (uzlaşma ilkesi) ayni hak, uzlaşmaya ilişkin belge sicile kayıt olmaksızın taraflara arasından etkili olacak şekilde geçer (conveyance). Deed'in kaydı kural olarak zorunlu değildir. Deed sistemine kayıtlı olmayarak hak kazanan ispat edemem sebebiyle hakkını kaybetme sebebiyle doğacak tehlikeyi üstlenir[48].

---

[46] **DESCHENAUX**, SPR V/3, s. 18 ff.

[47] **DESCHENAUX**, SPR V/3, s. 18-19.

[48] von **METZLER**, s. 49 ff

2097 Deed'in imzalanması ile gerçekleşen tasarruf soyut niteliğe sahiptir. Ancak taşınmazdaki "private conveyancing", yani kazanımın Deed ispat edilmektedir. Deed'in sicile kaydedilmesi bu nedenle sadece ispat anlamında fonksiyona sahiptir. Kayıtlı bir Deed'e dayanan tasarruf diğer tasarruflardan doğan yanı hakka nazaran avantajlı idi. Ancak, Deed'e kayıt halinde, üçüncü kişinin kayda güveni korumadığını da belirtelim.

bbb. Title Kayıt Sistemi

2098 Title sistemi ilk defa taşınmaza ilişkin ayni hakka ilişkin bu sistem ilk defa o tarihlerde İngiliz kolonisi olan güney Avusturya'da Sir Robert Torrens bir sistemi olarak 17 Ocak 1858 sayılı Kanunla uygulanmıştır[45].

2099 Bu sebeple "Title sistemi" adını kurucusundan alarak "Torrens sistemi" olarak da adlandırılmaktadır[46]. Torrens sisteminde, bir araziyi kazanan onun kazandığı hakkı tartışmasız olarak kazanılmalı ve hukuki sebebi belirli olmalıdır.

2100 Bu sistemi temel alan kamulaştırma çalışmaları iki ayrı grupta etkili olmuştur[47]: Avusturya, Yenizelanda ve Kanada grubu (Kanada'nın etkili olduğu Mattoba, Saskatschewan, Alberta, İngiliz Kolonileri) ve ABD eyaletlerinde (12 eyalette: Hawaii, Colorado, Georgia, Illinois, Massachussetts, Minnesota, New York, Nort-Carolina, Ohio, Oregan, Virgina ve Washington). Bu onıki Amerikan eyaletinde Amerikan idaresinin katılımında yani tapu memurunun tapu siline ilişkin hukuki ödevinde kuvvetleri ayrılığı ilkesi söz konusudur.

2101 "Title", zilyetin taşınmaz üzerinde fiili hakimiyetini ifade etmekte, böylelikle "title" kimin malik, rehin alacaklısı, intifa hakkı veya kiracı olduğunu belirlemektedir. Söz konusu sistemde kayıt sadece *dolaylı etkiye (konstituve Wirkung)* sahiptir. Anglo-amerikan title sistemi Kıta Avrupası tapu siciline yakın bir sistemdir. Sistem taşınmaz sistemi üzerine inşa edilmiştir.

2102 Title kayıt sisteminde, taşınmazlar kamu otoritesinin sorumluluğunda tutulan taşınmaz esaslı olarak tutulan bir deftere kaydedilir. Tapu kütüğünde olduğu üzere her taşınmaz ayrı bir sayfada kayıtlıdır. Bazı uygu-

---

45 von METZLER, s. 29 ff.; DESCHENAUX, SPR V/3, s. 20; ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 277 vd.

46 ÜNAL/ BAŞPINAR, s. 277.

47 DESCHENAUX, SPR V/3, s. 20-21; ŞENGÜL, s. 18.

lamalarda kaydedilen taşınmazı temsilen bir senet kamu otoritesi tarafından düzenlenerek ayni hak sahibine verilmektedir. Ayni hakkın kazanımı için sicile kayıt şarttır.

2103 Title kayıt sisteminde, *şekli kanuna uygunluk denetimi ilkesi* ve *kamuya güven ilkesi* söz konusudur.

2104 Tapuya kaydedilecek önemli hukuki işlemler (satış, rehin, kira vb. sözleşmeler) basılmış standart belgelerle veya sözleşmelerle tasarruf edilmekteydi. Malik kendi taşınmazını satmak isterse söz konusu standart belgeyi kendisi veya sözleşmeyi alıcı ile birlikte düzenlemekte ve belge (veya sözleşmeyi) kayıt makamına teslim etmektedir.

2105 Söz konusu belgeyi (sözleşmeyi) kayıt alan makam, bu belgeyi (veya sözleşmeyi) incelemekte, incelemesi sonrasında geçersiz olduğu sonucuna varırsa, kaydı ret etmektedir.

2106 Satıcının veya tarafların geçersizlik sebebine göre yeni sözleşme veya belge düzenleme imkanı bulunmaktadır. Tasdik makamı, belge veya sözleşmenin geçerli olduğu kanaatine varırsa, taşınmaz yeni malik olan alıcı adına kaydedilir. Tasdik makamı, eğer taşınmaz için senet düzenliyorsa, eski senet iptal edilip yeni malik adına senet düzenlenir ve kendisine teslim edilir.

2107 Kayıt için kendisine başvurulan kamu kayıt otoritesi hukuki sebebi geçerliliğini ve incelemekle yetkilidir. Kayıt otoritesi, hatasından doğan zararın tazmini söz konusudur. Hukuki sebebe esas sebep iptal edilebilir. Ayni hakkın devrine ilişkin belge veya sözleme geçersiz olsa bile deftere yapılan kayıt hakkın devrini sağlar; soyutluk ilkesi geçerlidir.

2108 Kamuya açıklık üçüncü kişilere etkilidir; kaydın doğruluğu kabul edilir, aksini ispat eden iddiasını ispatla yükümlüdür.

2. Tasdik Sistemi

2109 ZGB öncesi İsviçre'nin genellikle Alman Kantonlarında[42] - örneğin, Zürich, Schaffhausen; Zug, St.Gallen, Appenzell, Thurgau, Basseland, Uri, Bern -eski kısmı, Luzern, Aargau tasdik sistemi (*Homologation, Fertigung*) uygulanmaktaydı[43].

---

[42] Tasdik sistemini uygulayan Kantonların tasdik sistemlerinin incelemesi için bkz. ZOBL. N.31 Fn. 68-73 de zikredilen yazarlar.

[43] Benzer bir sistem Glaurus, Ob- ve Nidwalden kantonlarında da uygulanmaktadır. Bkz. ZOBL. N.31.

2110 Tasdik sisteminde, taraflar kendi aralarında yaptıkları taşınmaz mülkiyetinin devrini veya bir ayni hakkı konu alan borçlandırıcı işlemi resmi bir makamın tasdik edilmesi için incelemesine sunarlar.

2111 Yetkili resmi makam borçlandırıcı sözleşmenin hukuki geçerliliğini yani kazanımın hukuki sebebini inceler. Başvurulan tasdik makamı, tarafların düzenledikleri belgenin ayni kazanımına veya tesisine sağlayıp sağlamadığına değerlendirir. Yetkili tasdik makamı, sözleşmenin geçerli ve tarafları bağladığına kanaat getirirse sözleşmeyi tasdikine karar verir (tasdik kararı (*Fertigungakt*)) veya aksi kanaate varırsa sözleşmeyi tasdik talebini red eder[54].

2112 Yetkili makam, tasdike ilişkin bir resmi bir tutanak düzenler; bu tasdikleri kendisi tarafından tutulan bir sicile ya da kataloğa kaydeder. Sicil ve kataloglara ayni haklar tasdik sırasına göre gün ve saat belirtilerek kronolojik[55] olarak kaydedilir.

2113 Genellikle tasdik sisteminde her ayni hak çeşidi için ayrı bir sicil ya da katalog tutulmaktadır: örneğin mülkiyet için mülkiyet sicili, irtifak hakkı için irtifaklar sicili, rehin için rehin sicili gibi.

2114 Resmi makam, hak ayni hak kazanımını gösteren bir tasdik belgesini veya tasdik senedini düzenler ve hak sahibine verir. Tasdik sisteminde gerçekleşen hukuki sebep (sözleşme), tasdik kararı, tasdik belgesi veya senedi ve sicile kayıt arasındaki ilişkiler, bu ilişkilerin şekli ve bu ilişkiler bağlanan hukuki sonuçlar farklı ülkelerde, örneğin ZGB öncesi İsviçre'nin Alman Kantonlarında farklı şekillerde düzenlenmiştir[56].

2115 Yetkili resmi makamın tasdiki, kural olarak kurucu bir olgu olarak, ayni hakkın devrini yani kazanılmasını sağlar[57]. Tasdik, kısaca sözleşmeyi ayni etkili yapar. Başka bir deyişle, ayni hakkın kazanılması için resmi makamın tasdiki şarttır. Kural olarak, sözleşmenin kurulması veya mülkiyetin nakli ve bir ayni hakkın tasdiki sonrasında sicile veya kataloğa kaydı, ayni hakkın tesisine etkili değildir. Bir sicil defterine veya kataloğa yapılan kayıt, sadece ayni hakkın varlığının ispatına hizmet eder.

---

[54] **DESCHENAUX**, SPR V/3, s. 24.

[55] **ZOBL**, N.30; **OSTERTAG**, ZGB vor Art.942 ff. N. 5.

[56] Bu sistem için bkz. **HOMBERGER**, vor 942 ff. N. 4; **DESCHENAUX**, SPR V/3, s. 24 f.; **ZOBL**, N. 30 ff.

[57] **SIMUNIUS/SUTTER**, I 170; **STEINAUER**, I, N.531

3. Tapu Sicili Sistemi

2116 Tapu sicili sistemi bu günkü anlamına uygun uygulaması 19. Yüzyılda İsviçre'nin Solthurn, Basel ve Waadt kantonlarında rastlanmakta idi; ZGB kabulü öncesinde Schwyz[58], Graubünden, Glarus, Ob- ve Nidwalden[59] kantonlarında farklı şekillerde uygulanmakta idi[60]. Türkiye, mehaz İsviçre ile birlikte Almanya ve Avusturya ile birlikte resmi makam tarafından tutulan geliştirilmiş tapu sicilini uygulamaktadır.

2117 Tapu sicilindeki sistemde taşınmazlar tapulama (veya kadastro) ile belirli bir harita sistematiği ile göre plana kayıtlandığı sicil sisteminde, her bir taşınmaz kendisine ilişkin bir sayfada (veya sayfalarda) o taşınmaz üzerindeki tüm ayni haklar yer vermektedir. Tapu sicili taşınmaz üzerindeki tüm ayni hakların tümünü ve ilgili hukuki ilişkiden doğan hakların tüm içeriğini görünür kılmaktadır[61].

2118 Tapu sicilindeki tescil ayni kurucu, değiştirici veya sona erdirici hukuki sonuç doğurmakta ve tapu siciline tescil ayni hakka olumlu ve olumsuz hukuki etki göstermektedir. İlaveten tescil güvenin korunmasına da hizmet eder.

Şimdi kısaca Almanya, Avusturya ve İsviçre Tapu sicili sistemi hakkında bilgi verelim:

a. Almanya[62]

2119 Maddi taşınmaz hukukuna ilişkin olarak taşınmazları konu alan ayni hak değişimi hükümleri BGB §§ 873 ff BGB düzenlenmektedir[63].

2120 Alman hukukunda, kural olarak, taşınmazı konu alan bir ayni tesisi, bir taraftan tarafların uzlaşması ve diğer taraftan tapu siciline tescil (*Eintragung*) ile gerçekleşmektedir[64]. Kaydın olumsuz veya dolaylı etkisi

---

58 Bu konuda ayrıntılı inceleme ve açıklamalar için bkz. **SCHORNC, A.**, Fertigung und Grundbuch in Kanton Schwyz, Bern 1903.

59 Bu konuda Bu konuda ayrıntılı inceleme ve açıklamalar için bkz. **RISI. A.**, Das kantonale und eidgenossische Grundbuch in Nidwalden. Bern 1932

60 **HOMBERGER**. vor Art.942 ff. N.7

61 **ZOBL**. N.34.

62 Ayrıntılı bilgi için bkz. **ANTALYA. O.G.**, Elektronik Tapu Sicili. Ankara 2019. s. 75 vd.

63 **ZOBL**. N. 37-41; Tarihi gelişim için bkz. **STADLER**. s. 57 ff.

64 **WACHE**. MünchKomm Bem. zu § 873 BGB. N. 20

söz konusudur. Tescil, tek başına taşınmaz mülkiyetinin kazanımı için yeterli değildir. Tarafların uzlaşması gereklidir.

2121 Uzlaşma, ayni tasarruf işleminin bir parçası olarak sebep işlemeden, örneğin satış sözleşmesinden ayrılır. Alman hukukunda, temel (sebep) işlemle tasarruf işlemi hukuki olarak ayrılmıştır; bu sebeple Türk-İsviçre hukukundan farklı olarak, *soyutluk prensibi* (*Abstraktionsprinzip*) geçerlidir[65]. Tasarruf işlemi borçlandırıcı işlemden etkisi ve hukuki olgulardan bağımsızdır.

2122 Alman tapu sicil sistemi taşınmazın kamuya açıklık olarak taşınmaz değişiminde hukuk güvenliğini sağlamayı amaçlar. Tapu siciline kapsamına güvenenin ayni hak kazanımının korunur. Bu sebeple tapu sicilinin *kamuya açıklığına güvenin korunmasını ilkesi* (*Prinzip des öffentlichen Glaubens*) geçerlidir (BGB § 891)[66]. Bu ilke *maddi aleniyet prensibi* (*materielle Publizitätsprinzip*) olarak da ifade edilmektedir[67]. Tapu siciline kayıtlı haklar ve sınırlamalarda aksi ispat edilebilen karine geçerlidir (BGB § 892).

2123 Şekli maddi ayni hakkın tapu siciline kaydı işlemi ve kayıtları 24.03.1987 tarih ve son şekli Tapu Sicil Yönetmeliğinde (GBO) düzenlenmiştir. Türk-İsviçre hukukunda olduğu üzere, tapu sicilinin ayni hak sahibine göre düzenlenme sistemini (*Personalfoliensystem*) değil, her taşınmazın tapu sicilinde ayrı bir sayfaya kayıt sistemi olan taşınmaz sistemi (*Realfoliensystem*) GBO §§ 3 ff) temel alınmıştır[68]. Tapu sicilini sadece haklı yararı olduğu ispatlayanlar inceleyebildiğinden, sınırlı kamuya açıklık ilkesi söz konusudur (GBO § 12).

2124 Almanya'da elektronik tapu siciline geçiş ile ilgili ilk çalışmalar 1970'li yıllarda başlatılmıştır[69]. 1979 yılından itibaren, elektronik tapu sicili veri tabanı oluşturulması amacıyla tapu sicili veri bankası oluşturulması çalışmaları hızlandırılmıştır. Bu kapsamda, 27.06.2013 tarihli Tapu Sicili Veri Bankası Kurulması Hakkında Kanun (Gesetz zur Einführung

---

[65] **STEFANI**, s. 20; **von TUHR**, ZHR 1921, 43; **SEILER**, Staudinger, Einl. Zu §§ 854 ff BGB, N. 48.

[66] Bu konuda bkz. **WACKE**, MünchKomm Bem. zu § 892 BGB.

[67] Bu konuda bkz. **WACKE**, MünchKomm Bem. zu § 891 BGB.

[68] Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. **MEIKEL, G.**, Grundbuchrecht: Kommentar, Neuwied/Kriftel/Berlin 2003; **DEMHARTER**, Beck'scher Kurzkommentar zur Gerundbuchordung, München 2002; **SCHÖNER, J.H./KRAMER, A.**, Grundbuchrecht: München 1994.

[69] **GÖTTLINGER, Franz**, Projekt Grundbuchautomation in der Bundesrepublik Deutschland, ZBGR 2/1981, s. 65 ff.

eines Datenbankgrundbuchs: DaBaGG) 08.10.2013 tarihinde yayınlanarak 09.10.2013 tarihinde yürürlüge girmiştir[70].

2125 DaBaGG'ın amacı, tapu verilerinden oluşan bir banka vasıtasıyla modern bir tapu sicili kurarak tapu memurlarının daha verimli çalışmasını sağlamaktır[71]. Bu amaç doğrultusunda, ülke genelinde tek bir veri bankası oluşturulacak, oluşturulan bu veri bankası üzerinden tapu kayıtları sistematik ve düzenli olarak tutulması ve tutulan bu bilgilere uzaktan ve kolay ulaşımı sağlanacaktır[72].

2126 DaBaGG'ı yasallaştırmanın temelinde ise ulusal e-devlet stratejisinde yer alan dijital tapu sicili veri bankasının kurulmasını sağlamak yatmaktadır. Almanya'da yaklaşık 400 milyon sayfadan oluşan 36 milyon tapu sicili defteri sayfası üzerinde çalışılarak kaydedilmiştir. Böylelikle tüm Almanya'da tapu sicilinin yeknesak bir software üzerinde sağlanması gerçekleştirilmiş ve bu veri bankası üzerinden de tüm eyaletlerin online bilgiye ulaşımı sağlanmıştır[73].

2127 Almanya'da yaklaşık 26 milyon tapu kütüğü sayfası dijital olarak resim veya PDF[74] formatında sisteme kaydedilmiştir[75].

2128 11.08.2009 yılında kabul edilen kanunla (Gesetz zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs und elektronischen Akte im Grundbuchverfahren: ERVGBG) tapu siciline ilişkin işlemlerin ve sözleşmelerin elektronik ortamda Noterler tarafından yapılması imkanı getirilmiştir[76].

2129 Noter ile tapu sicili memurluğu arasındaki işlemler, tapu sicili veri bankası programı aracılığıyla otomatik olarak veri transferi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu otomatik veri transferi: "Migrationsautomat" olarak isimlendirilmektedir[77].

---

[70] BGBl. I 3719.

[71] **WIGGERS**, s. 235 ff.

[72] **SCHNEIDER, Wolfgang**, Verwalter und Grundbuch, ZWE 2014, s. 350 ff.

[73] http://www.it-planungsrat.de

[74] PDF: Portable Document Format.

[75] **BÜTTNER, Walter/FROHN, Matthias**, Elektronischer Rechtsverkehr in Grundbuchsachen, DNotZ-Sonderheft 2016, s. 157.

[76] BGBl. I 2713.

[77] **BÜTTNER/FROHN**, s. 161-162.

2130 Elektronik tapu siciline geçiş, tapu siciline ilişkin resmi şekilde yapılması gereken işlemlerin sözleşmelerin güvenilir elektronik imza ile resmi şekilde yapılmasına ilişkin altyapıyı da sağlamaktadır. Alman eyaletlerinin, elektronik tapu işlemlerinde elektronik hukuki işlemlere ve veri bankası aracılığıyla elektronik tapu siciline geçişinin birlikte olması gereği ifade edilmiştir[74]. GBO § 127 I Nr. 3-4 hükmü, tapu sicili işlemlerinin elektronik hukuki işlemlerle yapılabilmesi kararını eyaletlere bırakmıştır.

2131 Elektronik hukuki işlemlerin tapu müdürlüğünde nasıl yapılacağı hususunu ise, 11.08.2009 tarihli elektronik hukuki işlemlere ilişkin temel esasları ve tapu sicili işlemlerinde ilişkin sözleşmelere ilişkın Kanun (ERVGBG[75]: Gesetz zur Einfuhrung des elektronischen Rechtsverkehrs und der elektronischen Akte im Grundbuchverfahren sowie zur Änderung weiteterer grundbuch-, register- und kostenrechtlicher Vorschriften) hükümleri ile GBO §§ 135-141 hükümlerinde düzenlemiştir.

2132 Alman Tapu Sicili Tüzüğü'nde (GBO) elektronik tapu sicilinin gerçekleşmesi amacıyla sicil kurallarında uygulanması ve sistemle uyumlaşmasına yönelik kapsamlı değişiklikler yapılmış, örneğin § 12 Abs. 4, 12a Abs. 3, 71a, 76 düzenlemeleri, elektronik tapu sicili §§ 126-134 arasındaki hükümler arasında düzenlenmiştir. Bu değişiklikler ve düzenlemeler elektronik tapu sicilinin hukuki dayanağını oluşturmuştur. Bu değişiklikler 01.10.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlaveten elektronik tapu sicili kuralları, GBO genel düzenlemesi GBV § 61 vd. özellikle GBV §§ 71a, 76 hükümlerine getirilen değişiklik ve eklerle detaylandırılarak tamamlanmıştır.

2133 Elektronik ortamda tutulan asıl sicilin yardımcı sicilleri de elektronik ortamda tutulur (GBO § 126 Abs. 2). GBO § 127 hükmü, kadastro ve tapu verilerinin bir bütünlük içinde karşılıklı iletişim halinde çalışması için iki sistemin verilerinin birbiriyle paylaşımı gereğini ifade etmiştir. Karşılıklı olarak tutulan veriler, her iki tarafça çağrılabilmekte, erişilebilmekte ve incelenebilmektedir (GBV § 86 Abs. 1-2).

2134 Tapu sicil memurluklarının, taşınmazın bilgileri ve numarası, taşınmazın sınırı ve buna benzer diğer maddi açıklamalara erişim haricinde,

[74] BT-Dr. 17/12365, 06.03.2013, s. 21-22.

[75] BGBl. I 2713.

hukuki içeriğe ilişkin veri değişim ve kayıt yetkisi bulunmaktadır[82]. Bu yetki aleniyet kazanmış verilerde kullanılamaz. Aleniyet kazanmamış verilerin müdürlükçe resen düzeltilmesi GBO §§ 13, 22 I hükmüne göre, aleniyet kazanmış verilerin düzeltilmesi ise müdürlüğe itiraz usulü ile GBO § 53 I hükmüne göre yapılmaktadır[83].

2135 Alman elektronik tapu sicili, kural olarak, sınırlı kamuya açıklık tapu sicili niteliğine sahiptir (GBO § 12). Bu ilkeye uygun olarak, elektronik tapu sicilinin incelenmesi GBO § 132 ve devamında düzenlenmiştir. Diğer taraftan, elektronik tapu siciline geçilmesiyle birlikte Alman Tapu Sicili Tüzüğü'nde 1995 yılında yapılan değişiklikler (GBO §§ 132 ff.) ve 1995 yılında kabul edilen Alman Tapu Sicili Tüzüğü Uygulama Talimatı'nda yer alan düzenlemeler neticesinde, aleniyet ilkesinde önceden var olan sınırlamalar daha da daraltılarak uygulanmaktadır. Elektronik tapu sicilinde de GBO § 12 kuralı geçerlidir. Bu kuralda belirtildiği üzere haklı bir ilgisi yararı (berechtiges Interesse) olan kişiler tapu sicilini inceleme hakkına sahiptir (GBO § 12 Abs.1 S.1; Karş. GBV § 63, § 77)[84]. Elektronik tapu sicilinin incelenmesi GBO §§ 131 - 132 hükümlerinde düzenlenmiştir.

2136 İlgililer elektronik tapu sicilinin ilgili verisinin resmi çıktısını (amtlicher Ausdruck) yetkililerden alabilirler. Resmi çıktıda, herhangi bir imza aranmamakta, sadece mühür basılmakta veya çıktı alınırken form halinde mühür basılabilmektedir[85]. Mühürlü çıktının tapu hukuki işlemleri bakımından hukuki etkisi söz konusu olmamaktadır. Taşınmaz üzerinde aynî hakkı olanlar, online olarak tapu sicil verilerine ulaşanların protokolleri hakkında bilgi alma haklarına sahiptirler[86].

2137 GBO § 133 hükmü, verilere erişim hakkı olanları iki kategoride değerlendirmektedir.

2138 İlk grubu, sınırsız erişim hakkı olanlar oluşturmaktadır. GBO § 133 Abs. 2 hükmü, tapu verilerine ulaşma hakkı olanları şu şekilde belirle-

---

[82] **WILSCH, Herald**. Beck'scher Online-Kommentar Grundbuchordnung (Hrsg. **HÜGEL, Stefan**), 35. Ed., München 2019, § 127, N. 1.

[83] **HOLZER**, s. 484.

[84] **DEMHARTER**, GBO § 132, § 130 Rn. 5; **WILSCH**, BeckOK GBO § 129, Rn. 4; **SCHMIDT-RÄNTSCH**, Grundbuchrecht, s. 12 ff.

[85] **SCHMIDT-RANTSCH**, VIZ 1997, s. 87.

[86] **BÖHRINGER**, DNotZ 2014, s. 21.

miştir: Bu hüküm ile, mahkemeler, resmi makamlar, noterler, resmi olarak görevlendirilmiş olan kadastro mühendisleri, ayni hak sahipleri, ayni hak sahipleri tarafından görevlendirilmiş temsilciler ve Devlet Bankası, yapılacak protokol kapsamında, (özellikle bu protokolde belirtilen giriş kontrolü yapılarak, elektronik tapu sicili veri bankasına online olarak ulaşma imkanına sahiptir. Sınırlı sayıda erişim yetkisi verilenler dışında, elektronik tapu sicili kayıtlarına erişim mümkün değildir. GBO § 133 hükmünde sayılanların, erişime yetkili oldukları siciller sınırlandırılmamıştır; temel sicillerin yanında yardımcı sicillere de ulaşma yetkileri bulunmaktadır.

2139 GBO § 133 Abs. 2, S. 2'de sayılan bu kişiler, inceleme için haklı yararlarını ortaya koymaktan muaf tutulmuştur (GBV § 43)[84]. Haklı yarar gösterme şartı açısından istisna teşkil etseler de inceleme yetkilerinin, yerine getirdikleri görevle (fonksiyonla) sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Tapu kütüğü yanında diğer yardımcı siciller de buna dahildi

2140 GBV § 82 Abs. 2 hükmü, sınırlı tapu sicili inceleme yetkisi olanların kimler olduğunu belirlemiştir: Taşınmaz üzerinde hak sahibi olanların (malikin) yetki verdiği kişiler ve taşınmaza cebri icra işlemi yapmaya yetkili olanlar (rehin alacaklısı, kredi kurumu, banka vb.). Sınırlı inceleme yetkisi olanlar: incelersek;

- Taşınmaz tarafından yetkilendirilen kişi veya kurumlar (sigorta şirketi, sandık, banka vb.);
- Cebri icra işlemleri ile yetkili olan kişi ve kurumlar (avukatlar),
- Kamu hizmeti tedarikçileri (su, elektrik, doğalgaz işletmeleri, Telekom vb.[85]),

2141 Kat mülkiyeti yöneticilerinin ise tapu sicilini online inceleme yetkisi olmadığı kabul edilmektedir[86].

2142 Söz konusu inceleme yetkisi olan kişilerin, inceleme yetkisi ilgilinin haklı yararı kapsamıyla sınırlıdır. Bu kişilerin inceleme yetkisi, sadece ana sicildeki verilerde yer alan bilgilerle sınırlıdır. Bu sebeple her başvu-

---

[84] **WILSCH**, BeckOK GBO § 133, Rn. 3; **DEMHARTER**, GBO § 133, Rn. 4; **BAUER/OEFELE/WALDNER**, GBO § 133, Rn. 9.

[85] **DEMHARTER**, GBO § 133, Rn. 4.

[86] **DEMHARTER**, GBO § 133, Rn. 4 ff.; Uygulama için bkz. OLG Hamm, FGPrax 2008, s. 51.

ruda ilgi haklı yarar, buna ilişkin kod formunda açıklanarak bilgi talep edilmeli ve ekran görüntüsü de bu ilgiye uygun şekilde verilmelidir.

2143 Noter, tapu sicili verilerine ulaşma anını da ihtiva eden tapu verisi çıktısını, ilgilisine verebilir (GBV § 85). Noterlerden edinilen tapu verilerine ait çıktılarda yer alan yanlışlardan dolayı noterler sorumlu değildir; sorumluluk tapu memurluğuna aittir[88]. Noterler, verilen bu hizmetler karşılığında bir ücret almaktadır[89]. Noterin verdiği tapu veri çıktı belgesi, tapu memuru tarafından verilen resmi belge ile aynı hukuki sonuç ve etkiye haizdir. Noterlerin tapu sicilini inceletme yetkisi, kişisel olarak ilgisi olan kişiler için söz konusudur; kamu yararı, ekonomik veya araştırma amaçlı olarak tapu sicili verilerini inceletme yetkisi söz konusu değildir (GBO § 133a Abs.2)[90].

b. Avusturya[91]

2144 Avusturya'da tapu sicili işlemleri 1811 tarihli Avusturya Medeni Kanunu (ABGB) hükümlerine göre yürütülmekteyken, 1929 yılında tapu siciline ilişkin ilk özel kanun olan "Tapu Sicili Uygulama Kanunu" yürürlüğe konulmuştur. 1955 yılında kabul edilen "Avusturya Tapu Sicili Kanunu (Allgemeines Grundbuchsgesetz 1955: GBG[92])" ise, tapu siciline ilişkin en kapsamlı ve ayrıntılı mevzuattır[93]. Bu Kanuna göre, tapu sicili Türk ve İsviçre hukuklarında olduğu gibi "ayni kayıt ilkesine göre" tutulmaktadır. Taşınmaza ilişkin kayıtlar, tapu kütüğüne yapılmaktadır.

2145 Avusturya'da elektronik tapu sicilinin başlangıcı 1950 yıllarında arazi veri bankası kurulması fikri ile birlikte ortaya çıkmıştır. 27.11.1980 tarihli "Tapu Kayıtlarının Dönüştürülmesi Kanunu (Grundbuchsumstellungsgesetz: GUG[94])" kabul edilerek, tapu kayıtlarının elektronik ortama aktarılması işlemleri başlatılmıştır[95]. Ocak 1980

---

88 **ÇEVİK**, s. 1103.

89 İnceleme ücreti 15 EUR, çıktı ücreti 10 ile 15 EUR arasında değişmektedir (KV 25209, 25310 ff GNotKG).

90 **WILSCH**, BeckOK GBO § 129, Rn. 10.

91 Avusturya tapu sicil sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. **ANTALYA**, Elektronik Tapu, s. 102 vdç.

92 BGBl. Nr. 39/1955.

93 Bu konuda bkz. **KILIÇ**, Tez, s. 32 vd.; **BAŞPINAR**, s. 108.

94 BGBl. Nr. 550/1980.

95 Bkz. **FEIL, Erich/MARENT, Karl-Heinz/PREISL, Gerhard**, Grundbuchsrecht Kommentar, 2. Aufl., Wien 2010, s. 257 ff.

Viyana'da ilk test çalışması yapılmıştır. 2008 yılında yapılan düzenleme (Grundbuch-Novelle 2008) ile 20 yılda 60 hukukçu ve 25 veri giriş uzmanının çalışması sonucu 1,6'dan 2,3'e kadar milyar karakterden oluşturulan ve girişçisiz den taşınmaz veri bankasının (Grundstücksdatenbank: GDB), tapu sicili işlemlerinde teknolojik gelişmelere göre bilişim teknolojisine uygun elektronik hukuki işlem (ERV) yapılabilecek hale getirecek şekilde sistemin yenilenmesi (GDB-neu) amaçlanmıştır. Bu süreç 2008 sonrası test ve deneme aşamasından sonra, 1992 yılında elektronik tapu sicili uygulamasına Avusturya'da tamamen geçilmiştir.

2146 Elektronik tapu siciline geçişle birlikte, el ile kayıtların yapıldığı defterlerin yerini, elektronik veri depolamaya yarayan disklerden oluşan veri bankaları almıştır. Tapu kütüğü sadece kaydın (tescilin) veri bankasına depolanması ile gerçekleşir ve bu taşınmaz veri bankaları ile sınır ve arazi kadastral verileri birbiriyle bağlantılı ve bütünleşik bir şekilde çalıştırılmaktadır (GUG § 2 Abs.1).

2147 Avusturya Adalet Bakanlığı, tapu kütüğünde kayıt yapmaya ve bu kayıtların tekrar geri alınmasına, kayıtların arazi ve sınır kadastrosu ile uyumunu sağlamaya ve buna ilişkin düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Adalet Bakanlığı, bu yetkisini haklı yararı bulunanların tapu sicilini inceleyerek bilgi edinmesini engellememek ve taşınmaz veri bankasının işletimini uygunsuz şekilde zorlaştırmadan kullanmak durumundadır (GUG § 2 Abs. 3 (1)).

2148 Adalet Bakanlığı, tapu sicili verilerinin elektronik ortamda tekrar yazılımını (veri transferi nakli (Datenmigration)), teknik gelişmeleri de dikkate alarak belirlemeye yetkilidir (GUG § 2a Abs 1). Tapu sicili kayıt verileri mutlaka tarih belirtilerek elektronik sicile kaydedilmelidir. Taşınması mülkiyet, malvarlığı değeri ve yükler sayfasına da aynı anda, yine aynı tarihle işlenmelidir (GUG § 2a Abs. 2). Tapu sicilinden terkin edilen bir kaydın veri işlemleri, hukuken aynı anda sicile yansımalıdır ((GUG § 3 Abs. 1). Kamu malvarlığı değerlerinin elektronik bir defterde tutulması GUG § 2b ve kamu malvarlığı değerleri mülkiyetinin kaydı da GUG § 2c hükmünde düzenlenmiştir.

2149 Adalet Bakanlığı, söz konusu önlemleri ve sorgulama ile ilgili düzenli bir işletmenin alması gereken önlemleri ve buna ilişkin kuralları belirlemekle yükümlendirilmiştir (GUG § 8). Tapu sicilinin haklara karine teşkil etmesi ve hakları üçüncü kişilere açıklaması işlevleri sebebiyle GBG § 7

(1)'de "tapu sicilinin kamuya açık olduğu" ilkesi düzenlenmiştir. Avusturya Hukukundaki "aleniyet" fonksiyonu açısından, sınırsız bir aleniyet ilkesi söz konusudur. İsteyen herkes ilgisini inanılır kılmaksızın (veya ilgisinin haklılığını ortaya koymaksızın) tapu kayıtlarını inceleyebilmekte ve bir örneğini alabilmektedir (GBG § 7 (2)). Herkes, teknik ve kişisel imkanlar elverdiği takdirde, tapu sicili, varaklar toplamı sicili ve diğer yardımcı sicilleri, kişi veri bankası hariç olmak üzere, taşınmaz veri bankası evrak data bankası üzerinden sorgulayabilir (Grundbuchabfrage - GUG § 6 Abs.1).

2150 Kişi veri bankasına noterler ve avukatlar, vasiyeti yerine getirme görevlileri veya mahkemece atanan taşınmaz yöneticileri ulaşabilirler. Yine avukatlar ve noterler, cebri icra işlemlerinde alacaklının vekili olarak kişisel verilere ulaşabilir (GUG § 6 Abs. 2). Kamu hizmeti gören devlet, eyalet ve topluluk şeklindeki kamu kuruluşları, sosyal sigorta kurum ve kuruluşları veya bunların birlikleri sorgulamaya yetkilidir (GUG § 6 Abs. 2 (2)). Tapu sicili bilgisinin sorgulanmasının noterler aracılığıyla yapılması imkanı GUG § 7 hükmünde düzenlenmiştir. Noterler, ilgili kamu kuruluşunun aradığı teknik yetkinliği sağlamaları durumunda, tapu sicilinin kendileri aracılığıyla sorgulanmasını ve herkesin tapu sicilini incelenmesini gerçekleştirebilirler. Tapu sicilinin belgelenmesi ve mahkemelerin tapu sicilini sorgulama yetkisi GUG § 5'te özel olarak düzenlermiştir.

V. TAPU SİCİLİ İLE AYNİ HAK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ

2151 Taşınmazlarda tapu sicili aynı hakkın aleniyetin sağlanmasına yönelik kamuya açıklık aracı olmasına hukuki etki ve sonuçlar bağlanmıştır. Bu hukuki etki sonuçlardan bazı temel hukuki etkileri belirtirsek;

- *Taşınmazlarda karine etkisi:* TMK m.922 hükmüne göre, tapuya kayıtlı taşınmazlarda, hak karinesinden ve zilyetlikten doğan dav açma hakkına yalnız adına tescil bulunan kişi açabilir.
- *Taşınmazlarda kurucu etki:* Kurulması kanunen tescile tabi ayni haklar, tescil edilmedikçe varlık kazanamazlar (TMK m. 1021).

2152 Taşınmaz mülkiyetinin kazılması kural olarak tapu siciline tescille olur (TMK m.705.I).

2153 Sınırlı ayni hakların kurulması ve devri tapu siciline tecille gerçekleşir (TMK m. 780.I; 795; 823 III; 840 I ve 856)

§ 12. TAPU SİCİLİNİN YASAL DÜZENLEMESİ

I. TARİHİ GELİŞİMİ

2154 Osmanlı devletine Fatih Sultan Mehmet ve sonrasında özellikle Kanuni ve I. Ahmet döneminde arazi tahriri (yazılımı) yapılmıştır[1]. 1847 tarihinden sonra, özellikle Tanzimat döneminde çıkarılan Nizamnamelerle taşınmaz hukuku düzenlemelere rastlanmaktaysa da bunlar günümüzü anlamında tapu sicil düzenlemeleri değildi. Tapu sicil sistemi Türk hukukuna ilk defa 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin kabulü ile Türk hukukunda yerini bulmuştur. Bu Kanun Hükümleri 1930 Tarihli Tapu Sicili Nizamnamesi ile tamamlanmıştır.

2155 Tapu sicilinin fonksiyonunu yerine doğru olarak getirebilmesi için, arazinin kadastro biliminin usul ve esaslarına uygun olarak planlarının çıkarılması ve arazinin sınırlarının belirlenmesi gerekli olduğundan, 15.12.1934 tarihli 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ve bunu takiben de 16.03.1960 tarihli 5602 sayılı Tapulama Kanunu çıkarılmıştır. Bu son kanun yerini 17.07.1964 tarih 509 sayıl: Tapulama Kanuna bırakmıştır. 509 sayılı Tapu Kanunun Anayasa Mahkemesi'nin 12.05.1966 tarihli Kararı ile iptali üzerine 28.06.1966 tarihli 766 sayılı Tapulama kanunu yürürlüğe kcyulmuştur.

2156 İl ve ilçe belediye sınırları içinde arsaların kadastral plan ölçümünde ve sınırlarının belirlenmesinde 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu; il ve ilçe belediye sınırları dışında tarlaların plan ölçümünde ve sınırlarının belirlenmesinde 766 sayılı Tapulama Kanunu uygulanmakta idi. Bu yapay ve anlamsız ikilik[2] her iki kanunu mülga eden 21.06.1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır. Kadastro çalışmasının henüz tamamlandığı yerlerde, tapu sicil sisteminin sistemi yerine varsa Osmanlı döneminden intikal eden zabıt ve kayıt defterlerine dayanılarak uyuşmazlıklar çözümlenmektedir.

2157 Tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini

---

[1] Geniş bilgi için bkz. **AKMAN**, s. 12 vd.

[2] **AKMAN**, s. 13.

sürdürmüştür. Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi konusunda da bir çalışma yapılmamıştır.

2158 Cumhuriyetin kurulmasından sonra bağımsız bir tapu teşkilatının oluşturulması konusu; özel bir dal olması, bu hususta özel bir deneyim gerektirmesi ve kapsamının genişliği sebepleriyle önem kazanmıştır. Bunun üzerine 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine 1925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir.

2159 Tapu sicilini tutmak ve ilgili işlemleri yürütmek ü zere bir kamu teşkilatının kurması gerekli olduğundan, 25.06.1932 tarihinde 2015 sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicili Muhafızlığı Teşkilatına Dair Kanunla taşra teşkilatı; 29.05.1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunla merkez teşkilatı kurulmuştur[3]. Bu gereklilik TMK m.1006 (743 sayılı eMK m.916) hükmünde ifade edilmiştir. Tapu ve kadastro kamusal teşkilatlanmasını düzenleyen bu iki kanun 3045 sayılı Kanunla kaldırılarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Son olarak da 3045 sayılı Kanun 10.12.2010 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan 25.11.1010 tarih ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla merkez ve taşra teşkilatı düzenlenmiştir.

2160 6083 sayılı Kanunla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bugünkü statüsüne kavuşmuş, 08 Temmuz 2011 tarihinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.

II. TAPU SİCİLİNİN YASAL KAYNAKLARI

2161 Tapu sicili, öncelikle TMK'da şekli ve maddi yönüyle ağırlıklı olarak düzenlenmiştir. TMK'nın hükümleri daha çok şekli yönü itibarı ile Tapu Kanunu (TK) hükümleri ile tamamlanmıştır. TMK'nın bazı hükümlerinin uygulanmasını yönelik olarak çıkarılmış bulunan Tapu Sicil Tüzüğü (TST)'nün ayrı bir önemi bulunmaktadır. TMK ve TK dışında konuyla ilgili diğer özel kanun hükümleri de söz konusudur.

2162 Tapu sicil mevzuatını ana hatları ile incelersek;

---

[3] Geniş bilgi için bkz. **AKMAN**, s. 12 vd.

A. Temel Hukuki Kaynak

1. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu

2163 Mehaz İsviçre hukukunda, tapu sicil hukuku İsviçre Medeni Kanunu'nda (ZGB) Art.937 Abs.1 ve 942-977 arasında düzenlenmiştir[4]. İsviçre Medeni Kanun'un bu hükümleri, 01.01.19994 tarihinde yürürlüğe giren bir Kanunla, İsviçre Borçlar Kanunu'nu (OR) hükümlerini kapsayacak şekilde, taşınmaz hukukuna ilişkin olarak esaslı bir biçimde kısmi değişliğe uğramıştır[5].

2164 Tapu sicil sistemi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Dördüncü Kitabı'nın Üçüncü Kısmı'nın İkinci Bölümü'nde "Tapu Sicili" Başlığı altında 997 ile 1027'nci maddeleri arasında düzenlenmiştir.

2. Tapu Sicil Tüzüğü

2165 Tapu Sicil Tüzüğü (TST), Türk Medeni Karun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin önemli hükümler getirmektedir. TST, maddi eşya hukuku ve şekli tapu sicil hukuku tamamlayan, uygulanmasını belirgin hale getiren ve açıklayan hükümler getirmiştir.

2166 İlk düzenleme 1930 sayılı Tapu Sicili Nizamnamesidir; bu Nizamname daha sonra 18.051994 tarih ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe sokulan Tapu Sicil Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Tüzüğün yerini de 17.08.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 22.07.2013 tarih ve 2013/5150 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Tapu Sicil Tüzüğü almıştır.

2167 Mehaz İsviçre hukukunda Türk Tapu Sicil Tüzüğüne paralel 22.01.1910 tarihli Tapu Sicili Tüzüğü (*Grundbuchverodnung* = GBV) söz konusudur[6]. GBV yakın zamanlarda çok sayıda kısmi revizyona tabi tutulmuştur. Bunlara işaret edersek, 01.01.19897 tarihinde yürürlüğe giren 1987 revizyonu[7]; 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe giren 1994 revizyonu[8];

---

[4] Ayrıca bkz. SchIT ZGB Art. 17 ff.; 38-48.

[5] Bu konuda bkz. **PFÄFFLI, R.**, s. 449 ff.

[6] Bu konuda bkz. **SCHNYDER**, ZK. Allg.Einl., N.256 ff. **DESCHENAUX**, SPR V/3, s. 5; **ZOBL**, s. 7 ff.

[7] EGBA'nın açıklaması için bkz. **LIVER**, ZBGR 1988 48 ff.; Bu konuda bkz. **HUBER**, ZBGR, 129 ff.; **PFÄFFLI**, BN s. 221 ff.

[8] EGBA'nın açıklaması için bkz. ZBGR 1995 252 ff.; Bu konuda bkz. **SCHMID**, ZBGR 1995 261 ff.; **PFÄFFLI**, BN 1995 45 ff.

01.01.1997 tarihinde yürürlüğe giren 1996 değişikliği[9]. Ayrıca, GBV haricinde, İsviçre Kantonlarında ilgili mevzuatın verdiği yetki dolayısıyla, örneğin ZGB Art.953, 962, 949 II, 949a, 970a III vb. tapu hukukuna ilişkin olarak çıkarılmış kanton düzenlemeleri olduğunu da belirtelim[10]. Bunların dışında Kanton bazında tapu sicilinde doğrudan etkili olan, örneğin imar, planlama ve vergi vb kamu hukuku kurallarının bulunduğunu da vurgulamakta yarar bulunmaktadır[11].

2168 Bu değişiklikler sadece şekli tapu sicili hukukuna ilişkin değildir; maddi taşınmaz hukukunu da ilgilendirmektedir. Örneğin, bu değişikliklerle ZGB Art.949 I hükmünde ilişkin temel uygulama değişikliğine gidilmiştir.

B. Diğer Hukuki Kaynaklar

1. Tapu Kanunu

2169 Medeni Kanunun yürürlüğünü takiben Tapu Sicil Tüzüğü (TST) ile birlikte tamamlayıcı bir başka kanunun varlığına duyulan ihtiyaç sebebiyle, 22.12.1934 tarihinde 2644 sayılı Tapu Kanunu (TK) yürürlüğe konulmuştur. Yürürlük tarihi olan 29.12.1934 tarihinden, 15.07.2008 tarihine kadar birçok defa değişikliğe uğramış, bazı hükümleri tümüyle yürürlükten kaldırılırken bazı hükümleri değiştirilmiş ya da ek hükümler getirilmiştir[12].

2170 2644 sayılı TK'nın 1. maddesine göre, taşınmazların tescili talebe kimlerin yetkili olduğunu belirlemiştir. Bu hüküm doğrultusunda tescili istenen taşınmaz Devlete ait ise, bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru (Defterdar ya da mal müdürü), hususi idareye (Özel idare) ait ise Vali,

---

[9] EGBA'nın açıklaması için bkz. ZBGR 1997 126 ff.; Bu konuda ayrıca bkz. SCHMID, ZBGR 1997 66 ff.

[10] ZOBL, N.8.

[11] Karş. SCHMID/HÜRLIMANN, N. 378

[12] Örneklersek, 2644 sayılı kanunun 5. maddesi şehir ve kasabalarda muhtarlığın ifasına dair 2295 sayılı kanun sebebiyle, 10.04.1944 tarihli 4541 sayılı kanun ve muhtarlığa ait olduğu belirtilen vazifeler hakkındaki hükümleri 04.11.1990 tarihli 3678 sayılı kanunun 31. maddesi ile, arazi dağıtılması hakkındaki diğer makamların yetkilerine ilişkin 6. maddesi 11.06.1945 tarihli 4753 sayılı kanunun 64. maddesi ile, hazine arazilerine ait düzenlemelere ilişkin 7. maddesi 16.02.1995 tarihli 4070 sayılı kanunun 15. maddesi ile, 15. maddenin 1. fıkrası 18.01.1950 tarihli 5516 sayılı kanunun 12. maddesi ile, 29. maddesi de 25.02.1952 tarihli 5887 sayılı kanunun 126/c maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, 35. ve 36. maddeleri de 29.12.2005 tarihli 5444 sayılı kanunun 1. ve 03.07.2008 tarihli 5782 sayılı kanunun 1. ve 2. maddeleri ile yeniden düzenlenmiştir.

evkafa (vakıf) ait ise evkaf müdürü veya memuru, Belediyelere ait ise Belediye reisi (başkanı), köye ait ise muhtar, mahsus (özel) kanunla teşekkül etmiş diğer tüzel şahıslara ait ise bunların kanuni mümessilleri, tescil isteme hak ve yetkisine sahiptirler[3].

2171 TK m. 2 ise, tüzel şahısların nasıl temsil edecek yetkililerinin yetki belgelerini nereden temin edecekleri hususlarını düzenlemiştir. Bu hükme göre, tüzel şahısların (dernekler gibi) tapu işlerinde merkez ya da şubelerinin bulundukları yerin en büyük mülkiye amirinden, nizamnamelerine (kuruluş tüzüklerine) göre taşınmaz tasarrufuna izinli olduklarına ve tescil işini yapacak mümessilin salâhiyetine (yetkisine) dair alınacak belgenin ibrazı zorunlu kılınmıştır. Ticaret şirketlerinin bahsedilen yetki belgesini temin edecekleri mercide, ticaret sicil memurlukları olarak belirtilmiştir.

2172 Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış olan yabancılara ait dini, ilmi, hayri müesseselerin fermanlara ve hükümet kararlarına istinaden sahiplendikleri taşınmazlar, bu belgenin sınırları dışına çıkmamak ve hükümetin izni alınmak şartıyla müesseselerin tüzel şahsiyetleri namına tescil edilebileceği, Kanunun 3. maddesinde ifade edilmiştir[4]. Yine 2644 sayılı Kanunun 8 ilâ 15. maddeleri deniz, bataklık olmayan göl ve nehirlerdeki doldurma işlemlerini düzenlemiştir. Kanunun 16. maddesi, hususi kanunlarında müsaade edilenleri hariç olmak üzere Devlete, belediyelere ve köylere ait orman, koru ve baltalıklardan tarla açılamaz ve hususi bina yapılamayacağı; kişilere ait ormanlarda dahi ait olduğu vekâletten (Bakanlıktan) izin alınmadıkça tarla açılamayacağını düzenlemiştir. Tapu Kanunu'nun bu yasaklamaya ilişkin hükmü, Anayasa ile 6831 sayılı Orman Kanunu'nda da düzenlenmiştir.

2173 Yine yukarıdaki TK'nın ilgili maddelerinde, işleme esas olacak değer pahaları ile tahsile ait belirli yüzdelerden bahsedilmişti. 2644 sayılı Kanunun 17 ile 20. maddeleri bahsedilen pahaların belirlenme biçimlerini

---

[3] Tapu sicil tüzüğünün 13. maddesinde yer alan hak sahibinin belirlenmesinde, bu yetkilendirmeler önem kazanacaktır.

[4] TK'nın 4. maddesindeki, madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve nizamlarına göre verilecek belgelerin, iktisat vekâletince (maliye bakanlığı) tasdik edilmiş olması şarttır hükmü, daha sonraki yıllarda uygulama alanı itibariyle değişikliğe uğramıştır. Örneğin 04.06.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3213 sayılı maden kanunu ve buna istinaden düzenlenen 03.02.2005 tarihinde 25716 sayılı Resmi gazetede yayınlanan maden kanunu uygulama yonetmeliği, getirdiği düzenlemelerle artık madenlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı maden işleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulacak maden sicilinde takibini on görmüştür.

düzenlemiştir. Tapu Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca, köy ya da belediye sınırları içindeki kapanmış yollarla yol fazlaları, hazine adına tescil edilemeyeceği, plân uygulaması sonucu oluşan bu fazlalıklar ya da kapanmış yollar, köy tüzel kişiliği veya belediye namına tescil olunacağını düzenlemiştir. Tapu kanununun 22. ve 23. maddeleri ilmühaber konusunu hükme bağlamıştır.

2174 Kanunun 24. maddesi; köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarlıklarla, vakfa ait umumi mezarlıklar köyün manevi şahsiyeti namına tescil olunur, hükmündedir[5]. Tapu Kanunu'nun 25. maddesinde bahsedilen 2510 sayılı iskân kanununun 21. maddesi 11.06.1945 tarihli 4753 sayılı kanunun 64. maddesi ile iptal edilmiş, daha sonra bahsedilen kanunun tamamı 5543 sayılı kanun ile tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

2175 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun çok fazla değişiklik gören maddelerinde biriside 26. maddedir. Bahsedilen maddenin 06.01.1954 tarihli 6217 sayılı kanunun 1. maddesi ile değişik ilk fıkrası; mülkiyete, mülkiyetin gayri aynı haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl taşınmaz sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o taşınmaz üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakilen istimale (kullanılmaya) elverişli bir bölümünden münhasıran istifadesini temin gayesiyle TMK'nın 753. maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vaadine mütedair resmi senetler tapu sicil muhafızları veya memurları tarafından tanzim edileceğini; son fıkrası ise bahsedilen irtifak tesisi vaatleri tapu siciline resen şerh verilebileceğini, irtifak hakkı tesisi vadine mütedair

---

[5] 13.06.1994 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 09.06.1994 tarihli 3998 sayılı mezarlıkların korunması hakkında kanunun 1. maddesi Devlet mezarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki tarihi mezarlıklar ile şehitlikler ve cemaatlere ait özel statüsü bulunan mezarlıklar hariç umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde köy tüzel kişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zaman aşımı ziyetliği yoluyla iktisap edilemez hükmü ile, mezarlıkların edinimine ve tesciline netlik kazandırılmıştır. Yürürlük ve yürütme maddeleri dahil toplam 5 maddeden oluşan kanunun 2. maddesi koruma hükümlerini, 3. madde inşa, bakım ve onarım maddelerini içermekte, bu konuda köy muhtarlıkları ile belediyelere yetki ve yükümlülük getirmektedir. 24.12.2004 tarihinde 25680 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5272 sayılı Belediye kanununun 79. maddesi, eski 159. maddeyi yeniden düzenlemiştir. Buna göre, diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harmanyeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır. Belediyeler tarafından deniz, akarsu ve golden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, kıyı kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, Büyükşehirler de Büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır.

resmi senetler tapuya şerh verilmekle, taallûk ettiği taşınmazın sonraki maliklerini de ilzam edeceğini düzenlemiştir.

2176 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 27. maddesi; tapu sicil muhafız veya memurları tarafından yapılan resmi senetlere iki tarafın ve tapu senetleriyle akde müstenit olmayan iktıbaslarda (alıntılarda) kayıtlara, sahibinin 6x4 büyüklüğünde ve mümkün olan yerlerde fotoğrafları yapıştırılır. Bu imkânı idare heyeti tayin eder.

2177 Tapu Kanunu'nun 28. maddesi, akde ve tescile müteallik tapu işlerinin idari emirlerle durdurulamayacağını hüküm altına almıştır. Söz konusu maddede, TMK, HMK ve İİK veya benzeri kanunlarla getirilen yasaklamalar dışında, idari emirlerle yasak getiremeyeceği hususu vurgulanmıştır. Kanunun 30. maddesi; plân ve resmi evraka dayanmayan taşınmazlarda, eskiden beri malûm ve muayyen olan hududa itibar olunur. Tapu Kanunu'nun 25.01.1950 tarihli 5520 sayılı kanunun 1. maddesi ile değişik 31. maddesinde; taşınmazların yüzölçüsü tapu sicilinde yazılı miktardan fazla çıkıp ta, bu fazlalığın bitişik araziye el uzatmaktan ileri gelmediğine ve sınırca da bir değişiklik olmadığına mahkemece karar verilirse, sicile karar veçhile kaydolunur. Mahkeme taşınmaz başında incelemeler yapar ve bitişik taşınmaz maliklerini dinler. Mahkeme kararına, tapu fen memurlarına ve bunlar yoksa yetkili fen memurlarına veya mühendislere yaptırılacak o yere ait harita da eklenir. İtiraz halinde genel hükümler çerçevesinde dava açılır, denilmektedir. Madde metninde, zemindeki yüzölçümü ile sicilde kayıtlı miktarın uyumsuzluğundan bahsedilmektedir. TMK'nın 719. maddesi uyarınca böyle bir durumda plândaki sınır esas alınacaktır. Sicilde yapılacak işlem, bir düzeltme işlemidir. TMK m. 1027. maddesi; ilgililerin yazılı rızası olmadıkça tapu memurunun, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebileceğini hükme bağlamıştır[6].

2178 Tapu Kanunu'nun 32. maddesi; plânı veya resmi şekilde yapılmış haritası bulunan taşınmazların gerek yargı kararıyla ve gerekse rızaen parçalara ayrılmasında harita yapılması mecburidir. Şehir ve kasabaların belediye sınırı içinde olup ta tapu fen memuru bulunan yerlerde plân ve haritaya bağlı olmayan taşınmazların parçalara ayrılmasında da harita yapı-

[6] Tapu Sicil Tüzüğünün §5. maddesinde, 5304 sayılı Kanunla değişik 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 41. maddesinde, 6831 sayılı Orman Kanununun 05.11.2003 tarihli 4999 sayılı Kanunun 4. maddesi ile değişik 9. maddesinde de düzeltmelere ilişkin hükümler mevcuttur.

lır. Belediye sınırları dışında bulunan taşınmazlardan yargı kararı ile parçalara ayrılanların haritasını yaptırmak hakimin takdirine bağlıdır, hükmündedir[7].

2179 Tapu Kanununun 33. maddesinde: TMK 934 ve 935 maddelerine göre sicilin tashihine ve bir ayni hakkın sükut edip etmediğinin tayinine dair tapu sicil muhafız veya memuru tarafından mahkemeye yapılacak müracaatlar ve bunun üzerine verilecek kararlardan herhangi bir harç ve resim alınmaz ve bunlara damga pulu yapıştırılmaz, (5281 sayılı vergi kanunlarının yeni Türk lirasına uyumu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile, 01.01.2005 tarihinden itibaren pul yapıştırılması suretiyle damga vergisi tahsili uygulamasına son verilmiştir) denilmektedir.

2180 33. maddede sözü edilen 934. ve 935. maddeler, 4721 sayılı TMK 1026, ve 1027. Maddeleri ile kısmen değişikliğe uğramıştır. Tapu Kanunu'nun bahsedilen bu maddesi, tapu müdürünün sağlayacağı düzeltme kararı sebebiyle harç, resim ve damga vergisi ödemeyeceğini belirlemektedir. Medeni kanunun halen uygulanan 1026. ve 1027. maddeleri doğrultusunda, tapu kanununun bu maddesi güncelliğini korumaktadır.

2181 Tapu Kanunu'nun 34. maddesi ise, bedelli akitlerde ve bir akdin yapılması diğerinin yapılmış olmasına bağlı olan hallerde, ilgililer tapu sicil muhafızı veya memurunu yediadil (güvenilir kişi) yapabilirler. Bu takdirde memur tarafından paranın hak sahiplerine verilmesi akitlerin tamam olmasına bağlıdır. Akitler tamam olmazsa memur parayı kimden almış ise alâkalılar dağılmadan huzurlarında derhal ona geri verir ve taâlluk ettiği muameleleri bozar.

2182 2644 sayılı Kanunun 29.12.2005 tarihli 5444 sayılı kanunun 1. maddesi ile değişik 35. maddesi uyarınca: Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, Türkiye'de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, tescil edilen taşınmaz edinimini veya sınırlı ayni hak tahsisini düzenlemiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 11.4.2007 tarihli ve E.: 2006/35, K.: 2007/48 sayılı kararı ile, dördüncü cümledeki "bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir hükmü" iptal edilmiştir. Tapu Kanunu'nun 03.07.2003 tarihli 4915 sayılı Kanunun 38. maddesi ile iptal edilen ve 03.07.2008 tarihli 5782 sayılı

[7] 06.08.1973 tarihli 14617 sayılı Resmi gazetede yayınlanan "Tescile Konu Harita ve Plânlar Yönetmeliği.

Kanunun 2. maddesi ile Kanunun 36. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 11.04.2007 tarihli ve 2006/35 E, 2007/48 K. sayılı kararı ile; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin, Türkiye'de taşınmaz mal edinimlerini düzenleyen 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi olan "Bu fıkrada belirtilen koşullarla, yüzölçümü miktarını otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü ile yedinci fıkrasında yer alan "ve yabancı uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını tespite" ibaresi iptal edilmiştir. Bilâhare, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35. ve 36. maddeleri, 03.07.2008 tarihli ve 5782 sayılı kanunla yeniden düzenlenmiş ve 15.07.2008 tarihli ve 26937 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2183 Bu defa 2762 sayılı Vakıflar Kanunu, 20.02.2008 tarihli 5737 sayılı kanunla yeniden düzenlenerek, 27.02.2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir[8]. Tapu Kanunu'nun 37. maddesindeki, yabancı hakiki şahısların intikal işleri Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden verilen ya da kendi yetkili makamlarından verilerek Türk kanunlarının veraset usulü hakkındaki hükümlerine uygun olduğu, Türk mahkemelerince tasdik edilen veraset senetlerine istinaden yapılır hükmü, uygulanmakta olan güncel bir hükümdür. Kanunun 38. maddesi yürürlükten kaldırılan kanun ve nizamnameleri belirlemiştir. 39. madde yürürlük ve son maddeyi oluşturan 40. madde ise yürütme hükümlerini içermektedir.

2. Kadastro Kanunu

2184 Ülkemizde Kadastro faaliyetlerine ilk kez 05.02.1912 (1328) tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkındaki Muvakkat Kanun ile, Konya ilinin Çumra ilçe merkezinde başlamıştır; ancak, araya 1. Dünya Savaşının girmesi üzerine uygulamaya devam edilememiştir. 1925 tarihli ve 658 sayılı Kadastro Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından 1925 yılından itibaren Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya'da kadastro çalışmalarına başlanmıştır. 1926 yılında Türk Kanunu Medenisi

[8] Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı tarafından 5737 sayılı kanunda belirtilen esaslara göre, Cemaat Vakıflarının ülkemizde taşınmaz mal edinimlerini kapsayacak şekilde 29.05.2008 tarihli 2008/9 (1659) sayılı genelge düzenlemiştir.

yürürlüğe girdiği tarihte taşınmazların çoğu tapusuz veya sicil dışı kalmış; tapulu olanlar da harici satışlarla el değiştirmiştir. Taşınmazlar üzerinde eylemli durum ile hukuki durum arasında geniş kapsamlı bir aykırılığı gidermek için eylemli durumları hukuksallaştırmak, tapusuz taşınmazları tapulamak ve kadastroya dayanan haritaları yapmak amacıyla 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 15.12.1934 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

2185 Gerek kentlerde ve gerekse köylerde 1950 yılına kadar uygulama alanı gören 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir: Kanunu ile, ülkemizin kadastrolama sorununun istenilen hızda çözümlenilemeyeceği düşünülerek, kentlerin belediye sınırları dışında kalan taşınmazların kadastrolanması için 1950 yılında 5602 sayılı Tapulama Kanunu yürürlüğe girmiştir. 5602 sayılı Kanunun uygulama süresi içinde görülen aksamaların giderilmesi için 1964 yılında 509 sayılı, daha sonra 1966 yılında da 766 sayılı Tapulama Kanunları yürürlüğe konulmuştur. 2613 Sayılı Kanun ise, sadece il ve ilçelerin merkez belediye sınırları içinde kalan taşınmazların kadastrolanmasında uygulanmıştır.

2186 Aynı amaca yönelik, fakat farklı hükümler içeren 2613 sayılı Kanun ile 766 sayılı Kanun birleştirilerek 10.10.1987 tarihinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu yürürlüğe konulmuştur. 3402 sayılı Kanunda, 5304, 5831 ve 5841 6302 sayılı Kanunlarla, 2013 yılında da 6495 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır.

3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

2187 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un[5] amacı; mülkiyet hakkını tespit etmek üzere taşınmazların kadastro çalışmalarını planlamak, yürütmek, yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, tapu sicillerini oluşturmak, arşivlenerek korunmasını sağlamak, harita yapmak, üretim standartlarını tespit etmek ve arşivlenmesini sağlamak üzere, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilatlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

---

[5] Kanun Numarası: 6083, Kabul Tarihi: 25/11/2010, Yayımlandığı R.G.: Tarih: 10/12/2010 Sayı: 27781 - Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 50.

2188 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde tapu müdürlüklerine gitmeden taşınmazlarını yönetebilecekleri, başvurularının elektronik ortamda alınmasını sağlamaya yönelik web-tapu sistemi oluşturulmuştur. Web-Tapu sistemine giriş E-devlet kimlik doğrulama sistemi kullanılarak yapılmakta ve sistem TKGM-TAKBİS alt yapı güvencesi altında yapılmaktadır.

§ 13. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI SİSTEMLERİ[1]

I. GENEL OLARAK

2189 Bilindiği üzere, tapu sicilleri, taşınmaz veya taşınmazı ilgilendiren diğer haklar, özellikle sınırlı ayni haklar, yaşam ve ticari ilişkilerde hukuki ilişkilerin aleniyetini sağlamaktadır[2]. Tapu sicilinin düzenlenmesi, yani tutulması temelde iki şekilde gerçekleşir:

- Defter (kağıt) sicil sistemi ve
- Elektronik tapu sicil sistemi[3].

2190 Tapu Sicili Tüzüğünde düzenlenen tapu kütüğü ve yevmiye defteri ve diğer yardımcı siciller aynı fonksiyonu yerine getirmektedirler. Bu fonksiyon tapu sicilinde önce boş defter (kağıt) siciline yazılma şeklinde, tapu sicilinin tutulması şeklinde gerçekleşmiş; daha sonra teknolojinin gelişmesiyle defter tapu sicili bilgisayarla desteklenmiştir.

2191 Günümüzde ise, seksenli yıllardan sonra elektronik tapu siciline ilişkin gelişmelere paralel olarak, tapu sicilleri artık defter şeklinin yanında, onunla birlikte veya onun yerine artık elektronik tapu sicili (E-Tapu Sicili) olarak tutulmaktadır. Elektronik ortamda tapu sicilinde yazı değil, elektronik veri; yazılma değil, işleme ve kaydetme; defterin saklanması değil kaydedilen verinin saklanması; defterin incelenmesi değil, ekrana getirilen veri görüntüsünün incelenmesi söz konusu olmaktadır.

II. ELEKTRONİK TAPU SİCİL KAVRAMI VE UNSURLARI

2192 Elektronik tapu sicilini, elektronik ortamda tutulan kadastro sicilleri ve diğer elektronik sicillerle aynı elektronik ortamda, ortak ağ içinde irtibatlı olarak, tüm tapu sicillerinin ve bu sicillere kaydedilebilen taşınmaz-

---

1 Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. **ANTALYA**, Elektronik Tapu, s. 22 vd.

2 Kamuda açıklığı sağlayan sistemler için bkz. **KILIÇ**, Tez, s. 15 vd.; **ÜNAL, Mehmet/BAŞPINAR, Veysel**, Şekli Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara 2017, s. 278 vd.

3 **MÜLLER, Manuel**, Als dem Tagebuch des Eidgenössischen Amtes für Grundbuch- und Bodenrech, ZBGR 6/2001, s. 337 ff.; Erlauterungen des Eidgenossischen Amtes für Grundbuch- und Bodenrecht zur Revision der Grundbuchverordnung vom 23. November 1994, ZBGR 4/1995, s. 253; **MÜLLER/SCHMID**, s. 144; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 278 vd., 323 vd.

ların fiili ve hukuki durumuna ilişkin tüm bilgilerin ve verilerin elektronik ortamda tutulduğu, bu sicillere ilişkin tüm tapu işlemlerinin ve sözleşmelerin elektronik ortamda yapıldığı ve sicile veri olarak elektronik olarak işlendiği, işlenen verilerin elektronik bir veri bankasında yedeklenerek saklandığı ve veri bankasında saklanan tapu verilerine, yetkili kişilerin erişiminin elektronik ortamda sağlandığı ve erişilen verilerin güvenliğinin minimum standartlar çerçevesinde sağlandığı, elektronik bir resmi tapu sicil sistemi olarak tanımlayabiliriz[4].

2193 Yukarıdaki tanımdan hareketle de, elektronik tapu sicilinin unsurlarını[5]:

1) Elektronik ortamda tutulan kadastral sicillerle ve nüfus sicilleri ve diğer elektronik sicillerle, aynı elektronik ortamda, ortak bir ağ içinde irtibatlı şekilde olması,

2) Tüm tapu sicillerinin ve bu sicillere kaydedilebilen taşınmazların fiili ve hukuki durumuna ilişkin tüm bilgilerin ve tüm verilerin elektronik ortamda tutulması,

3) Tapu sicillerine ilişkin tüm tapu işlemlerinin, özellikle sözleşmelerin resmi memurun, ilgililerin ve tarafların güvenli elektronik imzası ile elektronik ortamda yapılması ve sicile elektronik veri olarak işlenmesi;

4) İşlenen tapu verileri ve kayıtlarının elektronik bir veri bankasında yedeklenmesi ve güvenli olarak saklanması;

5) Veri bankasında saklanan tapu verilerine, yetkili kamu ve özel kişilerin erişiminin elektronik ortamda sağlanması ve bu erişim sebebiyle veri güvenliğinin sağlanması;

6) Elektronik bir resmi tapu sicil sistemi olması;

olarak belirleyebiliriz.

---

[4] **ANTALYA**, Elektronik Tapu, s. 24. KILIÇ, elektronik tapu sicilini şu şekilde tanımlamıştır: "*Elektronik veri tabanını kullanarak tapu sicilinin unsurlarını oluşturan asli siciller ile feri sicillerin elektronik ortamda tutulduğu ve taşınmazların fiili ve hukuki durumlarıyla ilgili diğer her türlü verilerin otomatik bir sistem aracılığıyla saklandığı, oluşturulan veri bankaları arasında elektronik bağlantıların kurulduğu, önceden belirlenen kullanıcı grubu tarafından bu veri bankalarını her şekilde kullanma hakkının tanındığı, kendine özgü yapısı ve tekniği olan başlıca bir sistem*" olarak tanımlamıştır (Tez, 67). Yazarın bu tanıma uygun olarak belirlediği unsurlar için bkz. **KILIÇ**, Tez, s. 68 vd.

[5] **ANTALYA**, Elektronik Tapu, s. 24.

III. DEFTER (KLASİK) TAPU SİCİLİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAPU SİCİLİ

A. Defter (Klasik) Tapu Sicil Tutma Sistemi

2194 Defter kağıt (klasik) tapu sicili (Papiergrundbuch) tutma sistemi, klasik tapu sicilidir. Bu anlamda ana kütük ve yevmiye defteri fiziksel şekilde mevcuttur. Bu sistemde tapu kayıtları (tescil) görevli tapu memuru tarafından kaydın ilgili olduğu deftere, taşınmaza ayrılmış olan sayfaya memurun el yazısı ile kelime ve rakam olarak yazılmak suretiyle gerçekleşir[6]. Tapu memuru ilgili kaydı yapılan işleme uygun olarak deftere el yazısı ile işlemekle yükümlüdür. Yapılan kayıtların teknik yardımcı araçlar olmadan defter içindeki kağıttan okunabilir olması gerekir[7].

2195 Mehaz ZGB'nin tarihi geçmişinde defter tapu sicili ilk defa 1907 tarihinde model olarak kabul edilmiştir. Tapu sicilinin temel yapısı, TMK'de düzenlenen ayni haklar sistemine ve bunların tapu siciline kaydına dayanmaktadır (TMK m. 997, 998, 1000). TMK m. 997 II (ZGB Art. 942 II) geleneksel ve klasik olarak ifade edebileceğimiz tapu sicil sistemi olan defter (kağıt) tapu sicilini esas almaktadır. Taşınmazlar, görünüm şekli olarak tapu sicili kütük ve defterlerinin sayfalarından tezahür etmektedir. Kütüklerde aslında kağıt sayfalardan oluşan defterlerdir.

2196 Belirtmek gerekir ki, tapu sicilinin maddi etkisini göstermesi, aslında onun defter, bilgisayar destekli defter veya elektronik tapu sicili olarak tutulmasından bağımsızdır. TMK tapu siciline hangi hakkın kaydedilebileceğini; hangi hukuki etkiyi gösterdiğini düzenlemektedir. Eşya hukukuna hakim olan bu ilkeye **tipe bağlılık ilkesi** (*numerus clausus*) denmektedir[8].

2197 Aynı hukuki sonuç, elektronik tapu sicilinde, defter şeklinde düzenlenen tapu sicilinden farklı değildir. TBK m. 1000 I her taşınmazın bir sayfada yer alacağını ve sayfa numaralarının birbirini izleyeceğini düzenlemiştir. Bu sebeple tapu sicili sisteminde, aynilik ilkesi **ayni görünüm ilkesi** (Realfoliensystem) yani her taşınmaza ayrı bir sayfa açılması ilkesi geçerlidir[9].

---

6 Karş. GBO § 445 Abs 1 S.1 Hs.1.

7 **ZOBL, Dieter**, Grundbuchrecht, 2. Aufl., Zürich 2004, N. 273; **STEINAUER, Paul-Henri**, Les droits réels, Bd. I, 5. Aufl., Bern 2012, N. 578b.

8 **ANTALYA**, EH I, N. 569 vd.

9 **ANTALYA**, EH, N. 180.

2198 Aynı görünüm ilkesinin bir istisnası TMK m. 1000 hükmünün son fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hükme göre, aynı malike ait olan birden çok taşınmaz, sınırları birbirine bitişik olmasa bile, malikin isteğiyle kütükte ortak bir sayfaya kaydedilebilir. Bu sisteme tapu sicilinde **kişi görünüm ilkesi** (Personalfoliensystem) ismi verilmektedir.

2199 TMK m. 942 II tapu sicilinin tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ve bunları tamamlayan yevmiye defterinden oluştuğunu ifade etmektedir. Tapu kütüğünü ve kat mülkiyeti kütüğünü ana kütük olarak da ifade edebiliriz. Ana kütük, belirli bir şekilde düzenlenmiş boş kağıtlardan oluşan defter şeklinde olabileceği gibi, yine belirli şekilde düzenlenmiş boş kağıt yaprak şeklinde de olabilir[10].

B. Bilgisayar Destekli Defter (Kağıt) Tapu Sicil Sistemi

1. Genel Olarak

2200 Bilgisayar destekli tapu sicilinin[11] (computerunterstütztes Grundbuch) esası yine tapu sicili bir kağıttır (defterdir); fakat bu sistemde defter şeklindeki kütükler ve diğer yardımcı siciller hem kağıt üzerinde hem de veya yalnızca bilgisayarlarla tutulmaktadır[12].

2201 Ana kütük bilgilerinin bir program dahilinde bilgisayara veri olarak işlenmesinde ve yardımcı defterlerin tutulmasında, bilgisayar yardımcı bir araçtır[13]. Örneğin, bina kayıt düzeninin, adres ve veya köy/mahalle, cadde ve sokak düzenin ve diğer bilgilendirme sistemlerının kurulmasında, taşınmaz ve bu taşınmaz üzerindeki hak sahipliğine ilişkin verilerin, bu verilerle uyumluluğu ve bütünlüğü ana kütük verilerinin de bilgisayarda tutulmasını zaten zorunlu kılmaktadır.

2202 Bilgisayar destekli defter tapu sicilinde tapu kütüğü (ve kat mülkiyeti kütüğünün) ve yevmiye defterinin içeriğinin kağıt olarak yer alması ve

---

[10] Karş. GBV Art. 8 Abs. 4.

[11] Elektronik tapu sicili kavramının yanı sıra, aynı anlam yüklenerek bilgisayar destekli tapu sicili, mekanik tapu sicili, elektronik bilgi işlem ile tutulan tapu sicili, otomatik bilgi işlem ile tutulan tapu sicili, e-tapu, dijital tapu, otomatik tapu, mekanik tapu gibi çok çeşitli terimler kullanılagelmiştir (Bkz. **KILIÇ**, Tez, s. 32).

[12] **ZOBL**, N. 274; **SCHMID, Jörg/HÜRLIMANN-KAUP, Bettina**, Sachenrecht, 4. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2012, N. 381; **STEINAUER**, N. 578b; **MÜLLER/SCHMID**, s. 145.

[13] **SCHMID, Jürg**, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II (Hrsg. **HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter/GEISER, Thomas**), Art. 457-977 ZGB und Art. 1-61 SchlT ZGB, 5. Aufl., Basel 2015, Art. 949, N. 12; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 381.

hakkın kaydedildiği tapu kütüğünün mutlaka kağıt olarak okunabilir olması şarttır. Buna karşın, yardımcı kütüklerin deftere kağıt olarak bilgisayardan basılması gerekli olmayabilir.

2203 TMK m. 997 II hükmü gereği, tapu sicil kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ve yevmiye defterinin, defter (kağıt) tapu sicili olarak tutulması zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmak koşulu ile, Türk Hukuku yönünden Tüzükle düzenlenmek kaydıyla, bilgisayar destekli tapu sicili veya elektronik tapu sicili sisteminin kurulmasına bir engel bulunmamaktadır. Tapu sicil kütüğü (kat mülkiyeti kütüğü) ve yevmiye defterinin sadece elektronik tapu sicil sistemiyle tutulmasına geçilmesi için ise, TMK m. 997 hükmünde buna imkan veren bir düzenlemenin yapılması gereklidir.

2204 TMK m. 997 hükmü yardımcı siciller konusunda kütük veya defter zorunluluğu getirmemiş; bu hususu TST'ye bırakmıştır. TST m. 7/3 tapu sicilinin, aşağıda belirtilen yardımcı sicillerden oluştuğunu düzenlemiştir: Azil-ler sicili, Düzeltmeler sicili, Kamu orta malları sicili, Tapu envanter defteri.

2205 TST'ye yapılacak ek ve değişiklikle sadece yardımcı siciller için bilgisayar destekli tapu sicil sistemi veya elektronik tapu sicil sistemi uygulaması yapılabilir. Bu konuda Türk tapu sicil sisteminin bilgisayar destekli kağıt (defter) sicil sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Ana kütüklerin, yani tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğünün kağıt (defter) tapu sicil sistemi içinde tutulması zorunluluğu, bu sicillerin bilgisayarla desteklenmesini engellemez. Hatta yevmiye defteri TMK m. 997 II hükmünde yapılacak bir değişiklikle sadece elektronik ortamda tutulabilir. Ana kütükler: destekleyen ve aynı kayıtları ihtiva eden bilgisayar verilerinin çıktıları, yetkili makam tarafından onaylanmak şartıyla, ana kütükteki bilgileri derleyen sadece resmi biri yazı (belge) niteliğindedir. Belgedeki bilgilerin aksi ana kütükteki bilgilerle her zaman ispatlanabilir. Bilgisayara işlenen taşınmaza ilişkin veriler kurucu nitelikte değildir; asıl olan yine ana kütükte yer alan kayıtlardır.

2206 Bu durum ana kütüğün sadece fiziksel şekilde var olması ve diğer defterlerin bilgisayar destekli ve elektronik ortamda olması diğerinin yararsız olması veya kağıda dönüşmeyeceği anlamına gelmez. Örneğin elektronik ortamdaki yevmiye defteri gün sonu günlük olarak basılması gerekli olabilir[4]. Buna karşın yardımcı sicilin basılmasına dair bir zorunluluk olmayabilir[5].

[4] ZOBL, N. 274; STEINAUER, N. 578b

[5] MÜLLER/SCHMID, s. 146 ff.

2. Yararları

2207 Sayıları milyonları bulan defter ve bu defterlerin sayfalarındaki tapu ve kadastro kayıtlarının, defter ve sayfa ortamında manuel olarak yönetilmesi ve arşivlenmesi nerdeyse imkansızdır. Halbuki veri depolama alanı, veri yazılım teknikleri, depolama, arama ve transfer hızı, veri programları ve benzeri teknik ve teknolojik gelişimler, bu defterlerde yazılı verilerin elektronik ortamda tutulması, depolanması ve yönetilmesini daha basitleştirmekte ve işlevsel kılmaktadır.

2208 Tapu ve kadastro verileri elektronik ortamda birbirine entegre edilerek, kadastronun mekânsal bilgi sistemi ile bütünlük oluşturması bilgisayar destekli tapu sicili sisteminde mümkündür. Böylelikle tapu bilgileri, coğrafi konumları ile ilişkilendirilerek taşınmazlar arasında bağ kurulabilme imkanına kavuşacaktır.

2209 Taşınmaz kaydına ulaşmak kolaylaşacak ve dolayısıyla sicil, aleniyet fonksiyonunu daha etkin şekilde yerine getirecektir. Diğer yandan, bilgisayar destekli tapu sicil sisteminde, Kamu kurum ve kuruluşları arasında veri paylaşımı da daha basit, hızlı ve güvenilir biçimde gerçekleşecektir.

3. Türk Tapu Sicilin Düzenlenmesi Sistemi

a. Genel Olarak

2210 E-Devlet Sistemi yürürlüğe konularak, kamu hizmetlerinin www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda sunulmasıyla, her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurum ve kuruluşlarına, bu kapsamda Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince sunulan hizmetlere kolayca erişebilmesi ve faydalanabilmesi amacıyla **T**apu ve **K**adastro **B**ilgi **S**istemi: **TAKBİS** oluşturulmuştur[1]. Kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile de sağlanabilmektedir.

2211 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun m. 9 IV'üncü fıkrasıyla, Genel Müdürlüğün, sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasına karar vermeye yetkili olduğu yönünde düzenleme yapılmıştır. Türk hukukunda TST m. 12 vd. uyarınca yapılan düzenleme ile TAKBİS uygulamaya konulmuş, ancak

[1] Bu konuda bkz. KILIÇ, Tez, s. 40 vd.

klasik kağıt (defter) tapu sicili sistemi de terk edilmemiştir. Bu hükümler dikkate alındığında, Türk hukukunda uygulanan sistemin bilgisayar destekli tapu sicili sistemi olduğu görülmektedir.

2212 Aksi görüşte olan *Kılıç*'a göre ise, elektronik tapu siciline geçilmesiyle birlikte aslî ve fer'î siciller ortadan kalkmakta ve bunların yerini, tüm unsurları ile elektronik ortamda yürütülen yeni bir sistem almaktadır. TAKBİS ile tapu ve kadastro verilerinin bütünleşik yapıda bilgi sistemi içerisinde yönetilmesi, taşınmazın değerinin taşınmazın tanımlayıcı bilgisi olarak elektronik ortamda kayıt altına alınması, adres kayıt sistemi ile bağlantı kurulması, bağımsız bölümlerin net ve brüt yüzölçümlerinin elektronik veritabanına aktarılması sağlanmıştır.

2213 Kadastro ve tapu sicili hizmetlerini yürütmekle görevli TKGM'nin teşkilatlanmasını ve görevlerini düzenleyen ve 6083 Sayılı Kanun[17] ile elektronik tapu siciline geçiş ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. 6083 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan, "*Genel Müdürlük sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasına karar vermeye yetkilidir*" şeklindeki düzenleme ile elektronik tapu siciline geçişin yasal dayanağı oluşturulmuştur.

2214 6083 Sayılı Kanun ile elektronik tapu siciline geçiş ile ilgili yasal dayanak oluşturulduktan sonra, TKGM'nin teşkilat yapısında ve görevlerinde de elektronik sicile geçişin gerektirdiği değişiklikler ve yenilikler söz konusu olmuştur. 6083 Sayılı Kanun'un 5'inci maddesiyle, "*sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasıyla ilgili düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek*" görevi ana hizmet birimi olan Arşiv Dairesi Başkanlığı'na verilmiştir. 6083 Sayılı Kanun ile TKGM'de daha evvel "Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü" şeklinde teşkilatlanan ve TAKBİS projesini yürüten birim, daire başkanlığı şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. Daha sonra, elektronik tapu siciline geçiş süreci ve TAKBİS projesinin bütün unsurlarıyla hayata geçirilmesi müdürlük şeklindeki yapılanmayla yürütülemeyeceğinden, 6083 Sayılı Kanun'un 5'inci maddesiyle "Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı" kurulmuştur.

2215 Teknolojik alandaki gelişmeler, TAKBİS projesinin hayata geçirilmiş olması ve mevzuatta yapılan değişiklikler sonucunda TKGM tarafından "Tapu Sicili Tüzüğü Tasarısı" hazırlanmış; Tasarı hakkında bütün

[17] 10.12.2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmî Gazete.

Bakanlıkların, bazı üniversitelerin ve baroların görüşleri alınmış ve değerlendirilmiş; Danıştay Başkanlığı'nın da görüşü alınmak ve yürürlüğe konulmak üzere Başbakanlığa sevk edilmiştir. Taşınmazlarla ilgili mülkiyet hakkı, sınırlı aynî haklar ve kişisel hakların tapu siciline tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sicil ve belgelerin arşivlenmesinin usul ve esaslarını defter tutma yöntemiyle düzenleyen "Tapu Sicili Tüzüğü" yürürlüğe girmiştir[8]. Söz konusu bu Tapu Sicili Tüzüğü'nün üçüncü bölümünün başlığı "Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması" olarak belirlenmiş ve eski İsviçre Tapu Sicili Tüzüğü'ndeki elektronik tapu siciline yönelik düzenlemeler uygun düştüğü ölçüde, Tüzüğün 12 ile 15'inci maddelerine alınmıştır. Tapu Sicili Tüzüğü'nün yeni düzenlemesine geçmeden önce TAKBİS hakkında kısaca bilgi verelim.

b. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi: TAKBİS

2216 TAKBİS, kısaca **T**apu ve **K**adastro **Bi**lgi **S**istemidir; onun baş harflerinden oluşmuştur. TAKBİS, "e-Devlet" projesinin bir alt bileşenidir. TAKBİS, TKGM tarafından üretilen her türlü bilginin veri olarak elektronik ortamda, elektronik araçlarla işlenmesi ve saklanması ve bilişim teknolojilerinden yararlanılarak, tapu ve kadastro işlem ve hizmetlerinin daha sağlıklı, süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde elektronik ortamda sunulması, planlanması ve yönetilmesi, bu verilerin elektronik ortamdan paylaşılması, bu çerçevede tapu ve kadastro çalışmalarından elde edilen bilgilerin Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine dönüştürülmesinin amaçlandığı, diğer kurum ve kuruluşların da sisteme entegre olarak çoklu kullanıma sunulacağı bir "e-Devlet" projesidir.

2217 TAKBİS'in amacı, konumsal harita bilgilerine dayalı olarak tapu sicilindeki aynı hak ve kadastro bilgilerini elektronik ortamda oluşturmak; elektronik ortamda doğru, güvenilir, kolay ve hızlı erişilir tapu ve kadastro sistemi sağlamak ve her türlü kadastro ve tapu bilgisinin veri olarak elektronik araçlarla işleyerek saklamak ve bilişim teknolojilerinden yararlanılarak, tapu ve kadastro işlem ve hizmetlerini elektronik ortamda vererek, tapu ve kadastro bilgilerine kamunun ulaşımını sağlamaktır.

2218 TAKBİS projesi ile ülke genelinde, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin oluşturulması planlanmıştır. Bu kapsamda; ülke genelinde merkez ve taşra teşkilatların ortak ağa bağlanması; tapu kadastro hizmetlerinin

[8] 17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmî Gazete

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS GIS) ve Arazi Bilgi Sistemi (LIS) ile analiz ederek sorunların belirlenmesi, bu sorunların çözüm yollarının bulunması; tapu ve kadastro hizmetlerinin elektronik araçlarla ülke genelinde hızlı, doğru, standartlara uygun ve elektronik ortamda yerine getirilmesi; ilgilisine ve kamu kurum ve kuruluşlarına arazi ve tapu bilgilerinin hızlı, doğru, güvenilir ve güncel olarak sunulması hedeflenmiştir.

c. Taşınmaz Verilerinin TAKBİS'e Kayıt Edilmesi

2219 Elektronik tapu siciline geçişin önkoşulu tapu ve kadastro kayıtlarının sayısallaştırılması ve bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. TMK'nın 1007'nci maddesi uyarınca, tapu sicilleri devletin sorumluluğu altında tutulduğu için, tapu verilerinin gerçek hak durumuna uygun ve doğru olarak elektronik ortama aktarılması gerekir. Bilgi ve verilerin kontrolünün belirli usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak TKGM tarafından, "TAKBİS Tapu Sicil Belgelerinin Sayısallaştırılması Eğitim Dokümanı" hazırlanmıştır. Kadastro ve tapu bilgilerine ilişkin verilerin elektronik ortama aktarılması eğitim dokümanında *sayısallaştırma* olarak ifade edilmiştir.

2220 Bu Eğitim Dokümanına göre[5], kadastro ve tapu bilgilerine ilişkin verileri sayısallaştırmanın temel prensibi, klasik anlamda defter usulüne göre tutulan ve saklanan verilerin TAKBİS kurallarına uygun bir şekilde parametrize edilerek ve bilgi sistemi mantığına uygun olarak veri tabanına aktarılmasıdır. Veri girişi, bilgisayarların veri giriş ekranı üzerinden, sicil sistemine uygun olarak tasarlanmış bir programa uygun forma veri işlenmesiyle gerçekleşmektedir. Tapu sicil kayıtlarında yer alan her taşınmaz için o taşınmazın kadastro bilgileri ve tapu sicil defterlerinin üzerindeki bilgilerin veri olarak girişini uygun mümkün kılacak şekilde sicil sistemine uygun olarak, ayni hakların çeşitleri de dikkate alınarak, bilgisayar üzerinde hazırlanmış farklı veri giriş formları oluşturulmuştur. Bu formlar üzerinde, yapılacak işlemin türüne göre sırasıyla; elektronik ortamda formların doldurulması, doldurulan formların kontrolden geçirilmesi, daha sonra da verilerin, elektronik tapu sicilinin veri hafızasına alınması işlemi gerçekleştirilmektedir.

[5] Burada "Eğitim Dokümanı"na göre, bir taşınmazın sayısallaştırması için hazırlanan elektronik ortamda forma işlenmesi, kontrol edilmesi ve kaydedilmesinin aşamaları örneklerle açıklanmaktadır.

2221 TKGM tarafından kadastro verileri de elektronik ortamda işlenmekte, saklanmakta ve yönetilmektedir. KK'nın 22'nci maddesi ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun, kadastro verilerinin de güncellenmesine imkan vermektedir. Mevcut tapu-kadastro bilgilerinin, Kadastro Kanunu'nda öngörüldüğü gibi mekansal bilgi sistemlerinin altyapısını oluşturacak şekilde ve yapıda güncellemek, sayısal ve hukuksal formda bilgisayar ortamına aktararak kullanıma sunmak amacıyla 9.6.2008 tarihinde Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında imzalanan "Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi" (TKMP) başlatılmıştır[22].

2222 Yine "Kadastro Veri Konsolidasyonu" (KVK) adı verilen bir coğrafi bilgi sistemi projesi başlatılmıştır. KVK, kadastro verilerinin sayısal olarak toplanması, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve sunulması amacıyla geliştirilmiş web tabanlı bir uygulama yazılımıdır. KVK projesi ile tapu ve kadastro verilerinin karşılıklı olarak kontrol edilmesi, ITRF96 (Uluslararası Yersel Referans Koordinat Sistemi) koordinat sistemiyle bütünleşmesi ve sunulması, hava görüntüleri kullanılarak doğrulanması, kontrol sorgulamaları ile veri kalitesinin artırılması, verilerin güncel olarak tutulmasının sağlanması amaçlanmıştır.

2223 KVK uygulamasının Ağustos 2012 tarihinde TKGM tarafından işletime alınmasını takiben, TKGM'nin kadastro otomasyon altyapısını oluşturmak üzere "Mekansal Gayrimenkul Sistemi" (MEGSİS) projesi hazırlanarak, 25.02.2013 tarihi itibarı ile kadastro müdürlüklerinin tamamının işletimine dahil edilmiştir. MEGSİS, kadastro verilerinin sayısal olarak toplanması ve tapu verileri ile uyumlaştırılması ve bu sistem üzerinden uluslararası standartlarda paydaş kurum kuruluşlara sunulması amacıyla geliştirilmiş açık kaynaklı bir uygulamadır.

2224 Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Türkiye genelinde tapu ve kadastro kayıtlarının tamamı bilgisayar ortamına elektronik veri olarak aktarılmış ve aktarılmaya devam edilmektedir. Ancak, elektronik tapu sicil sisteminin uygulanmasını sağlayacak Türk Medeni Kanunu ve tapu sicil

---

[22] TKMP ile tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritaları tekrar düzenlenecek ve tapu sicilinde gerekli düzeltmeler sağlanması ve böylece geçmiş yıllarda üretilmiş olup bugün değişen ve gelişen sayısal bilgi ihtiyacına cevap veremeyen kadastro haritalarının, sayısal kadastro ve TAKBİS bilgilerini destekleyecek şekilde yenilenmesi, güncellenmesi ve uyumunun sağlanması hedeflenmiştir.

mevzuatında eksikliklerin bulunması yanında, veri hatası eksikliği ve de sistem güvenliği ile ilgili altyapı eksiklikleri, tapu sicilini, ana ve yardımcı unsurları defter tutma usulüne göre devam etmektedir. Tapu sicili sistemimiz henüz elektronik tapu sicili sistemine dönüştürülmemiştir. Elektronik tapu sicili sistemine geçiş aşaması olarak düşüneceğimiz bu dönemde, bilgisayar destekli tapu sicili sistemi uygulanmaya devam ettirilmektedir.

2225 Unutmamak gerekir ki, bilgisayar ortamına aktarılan bilgiler şu anda sadece defter usulüne uygun olarak tutulan klasik tapu sicil sistemini destekleyici ve tamamlayıcı sicil olarak yardımcı fonksiyona haizdir; bilgisayara aktarılan verilerdeki tapu bilgilerinin, defter bilgilerine uygun olmaması durumunda herhangi bir hukuki bağlayıcılığı ve hukuki etkisi bulunmamaktadır. Türk tapu sicil sisteminde, uygulanan bilgisayar destekli tapu sicil sistemi, elektronik tapu sicili için bir altyapı oluşumunu ve ilgili birimlerin yeniden yapılanmasını sağlamıştır. Kadastro ve tapu bilgilerinin elektronik ortama veri olarak aktarılması ve bu verilerin işlenmeye elverişli olması, sonraki elektronik tapu sicili aşaması için zaman, iş yükü ve maliyet avantajı yaratmıştır.

4. Tapu Sicili Tüzüğü'ne Göre Elektronik Tapu Verilerine Erişim

a. Sınırlı Aleniyet (Açıklık) İlkesine Göre Elektronik Tapu Verilerine Erişim

aa. Sınırlı Aleniyet İlkesi

2226 TST'nin 14'üncü maddesiyle, o dönemdeki İsviçre mevzuatındaki açıklık ilkesiyle ilgili o tarihteki gelişmelere benzer düzenlemeler yapılmış, ilgisine göre hangi kişi veya kurumun, hangi tür veriye erişebileceği düzenlenmiştir[2].

[2] *'MADDE 14 – (1) Mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek sağlanabilir. Erişim hakkına sahip kuruluşlar, taşınmaz ile ilgili verileri TAKBİS üzerinden alırlar. (2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilirler. (3) TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede, erişimin türü ve şekli, erişim kontrolü, verilerin kullanım amacı, üçüncü kişilere kullandırılmasına ilişkin sınırlamalar ve amacı dışında kullanımın sonuçları yer alır. (4) Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, düzenlenecek sözleşme şartları dahilinde verilere erişebilirler. (5) Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilir.*

2227 Bu kapsamda belirtmek gerekir ise, TMK'nın 1020'nci maddesi gereğince haklı bir menfaatini inanılır kılan herkesin -öncelikle taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanların- tapu sicili kayıtlarına erişme, öğrenme ve bilgi ve belge alma hakkı bulunmaktadır. İlgisini inanılır kılan kişiler bakımından "sınırsız aleniyet ilkesi" geçerlidir[22]. Bu noktada, tapu sicillerinin TMK m. 7 anlamında resmi sicil olduğunu da belirtmek gerekir.

2228 Elektronik tapu sicili sistemine geçmiş olan ülkelerde, taşınmaz hukukuna hakim aleniyet (açıklık) ilkesinin daha yaygın ve kamuya daha açık ve geniş olarak uygulandığı gözlenmektedir. Örneğin, Hollanda'da ve aşağıda inceleyeceğimiz üzere Avusturya'da "sınırsız aleniyet ilkesi" geçerli olup, isteyen herkes ilgisi ya da yararı olsun olmasın, tapu kayıtlarına erişebilmektedir. İsviçre'de ise, ilgisini inanılır kılan herkes tapu kayıtlarına erişebilmekte ve örnek belge alabilmekte, ayrıca herkes hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın, taşınmazla ilgili bilgileri, malikin kimliğini, mülkiyetin kazanım şekli ve tarihini öğrenme imkanına sahiptir. Hatta, İsviçre'de miras yoluyla edinimler dışında kalan taşınmaz mal edinimleri Kantonlar tarafından belirli aralıklarla yayınlanmaktadır.

2229 Almanya'da ise, hak sahibi olan ve ilgililer bakımından sınırlı aleniyet (açıklık) ilkesi söz konusu olup, bu kişiler elektronik ortamda tapu bilgilerine ilişkin verilere erişebilmektedir. Bunun dışında bazı kurum ve kuruluşlar için sınırsız olarak tapu bilgilerine ulaşım hakkı tanınmıştır. Tapu sicil bilgilerine kimin veya kimlerin erişebileceği; erişime yetkili kılınan kişilerin ulaşım yetkilerinin şart ve sınırları; erişimin hangi protokole kim tarafından bağlanacağı; erişimin doğrudan mı, dolaylı mı olup olmayacağı; tapu verilerine erişimin sadece taşınmazın bulunduğu tapu dairesinden mi, yoksa ülkedeki tüm tapu dairelerinden mi olacağı; dışarıdan, örneğin evden erişime yetki verilip verilmeyeceği; erişim bakımından başka kurum ve kuruluşun, örneğin Noterlerin yetkili olup

(6) Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması hâlinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, TAKBİS'e erişim derhâl durdurulur. (7) TAKBİS verilerine erişime ilişkin döner sermaye katılma payını ve bunun istisnalarını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

[22] **OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR**, Saibe, Eşya Hukuku, 21. Baskı, İstanbul 2018, N.66 vd.; **TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla**, Tekinay Eşya Hukuku, Cilt I, Zilyedlik - Tapu Sicili - Mülkiyet, 5. Bası, İstanbul 1989, s. 242 vd.; **CANSEL, Erol**, Tapu Siciline İtimat Prensibi, Ankara 1964, s. 3 vd.; **AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya**, Eşya Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2018, s. 275 vd.; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 285 vd.; **ERTAŞ, Şeref**, Eşya Hukuku, 13. Baskı, İzmir 2016, s. 134 vd.; **AYBAY, Rona**, Tapu Sicili "Herkese Açık" Mıdır? Çelişkiler Yumağı Bir Madde: Mk 1020, İBD, C. 87, Sa. 2013/2, s. 15 vd.; **BAŞPINAR**, s. 104.

olmadığı; erişimin kapsamı, yani ulaşımın sadece tapu kütüğü bilgileri ile mi, yoksa yardımcı defter bilgileri ile mi sınırlı olup olmadığı; erişilen tapu ve hak sahipliği bilgilerinin hangilerinin, ne kadarına ulaşılabileceği, bu kapsamda kayıt dayanaklarına ulaşılıp ulaşılamayacağı; erişimin ekran üzerinden bilgi alma, veriyi diske indirme; ekran çıktısı alma, suret alma veya örnek alma şeklinde mi olacağı; erişimin kayıt altına alınması ve kontrolü; kötüye kullanımı ve yasaklara aykırı kullanımının engellenmesi, bu konudaki temel sorun ve soruları oluşturmaktadır.

2230 Türk hukuk doktrininde de yasal düzenleme olan sınırlı aleniyet ilkesinin genişletilmesine ilişkin eğilim gözlenmektedir. Bu kapsamda doktrinde savunulan görüşlere bakarsak:

2231 *Oktay-Özdemir*'e göre, tapu sicilinin ayni hakların doğasından kaynaklanan bir ihtiyaç olan aleniyeti sağlama işlevini eksiksiz olarak yerine getirmesi için, üçüncü kişilerin hiçbir sınırlamaya veya kısıtlamaya tabi olmaksızın tapu sicilinde kayıtlı olan ayni hakları öğrenebilmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Yazara göre, tapu sicilinin herkese açık olduğu prensibinin söz konusu olduğu sistemde (TMK m. 1020/1), tapu sicilindeki kayıtları öğrenme ve incelemeyi ayrı esaslara tabi tutarak ilginin inanılır kılınmasının aranması çelişki teşkil etmekte ve bu durum aynı zamanda, tapu sicilinin esas fonksiyonuna da ters düşmektedir[23]. Yazar, tapu sicilinin kamuya aleniyetini, ayni hakların varlığını öğrenme bakımından gerekliliği ile sınırlamaktadır. Örneğin, kütüğün ipotekle ilgili bölümlerinin üçüncü kişilere açılmaması gerektiğini, diğer bilgilerin belirli kayıtlar altında kamuya açılmasına izin verilmesi gerektiğini savunmaktadır[24].

2232 *Başpınar*'a göre, tapu sicilinde taşınmaza ilişkin bilgiler yanında kişinin, özel hayatı ve dolayısıyla kişiliğine ilişkin özel bilgiler de yer aldığından, elektronik ortamdaki kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenleme yapılana kadar, TST'de yapılacak olan değişiklikle, elektronik tapu sicilinde yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilke ve esaslara yer verilmelidir[25].

---

[23] **OKTAY-ÖZDEMİR**, N. 666 vd.

[24] **OKTAY-ÖZDEMİR**, N.666 vd.

[25] **BAŞPINAR**, s. 116.

2233 Yazara göre, malvarlığı kişinin mutlak hakları arasında yer aldığından ve taşınmazlar da kişinin malvarlığı haklarını oluşturduğundan özel hayatın gizliliği ve korunması hakkının bir unsuru olarak ele alınmalıdır. Aksi halde, kişinin sahip olduğu malvarlığına ilişkin tapu sicili kayıtlarının elektronik ortamda herkesin kullanımına açılması, doğrudan kişinin özel hayatına müdahale sonucunu doğuracaktır.

2234 Bu sonucun ise Anayasa'nın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesi[26], özel hayatın gizliliği ilkesini düzenleyen 17. maddesi ve özel hayatın gizliliğine dokunulmama ilkesini düzenleyen 20. maddesine aykırılık teşkil edecektir[27]. Özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik olmak üzere, Tapu Sicili Tüzüğü'nde yer alan kişisel verilerin korunması gereğine uygun olarak ilke ve esasların belirlenmesi gerekir[28]. Bu sebeple Yazar, kişinin özel hayatı kapsamına girmeyen tapu sicil bilgilerinin sınıflandırılarak ve bilgi isteyen kişileri sınırlandırarak erişime açılmasının menfaatler dengesine uygun olacağını ve teknik olarak her türlü izinsiz erişimleri engelleyici güvenlik önlemlerinin de alınması gereklilliğini ifade etmektedir[29].

2235 Bilişim çağı olarak nitelenen günümüzde, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulmasıyla birlikte, hizmetin şeffaflığının sağlanması, verilere olan güvenin artması, başkaca kamu hizmetleriyle ilgili veri bankaları arasında bağlantı kurulması, hizmetin kalitesinin ve hızının artırılması, bürokrasinin azaltılması ve kırtasiyeciliğin önlenmesi bakımından elektronik ortamda tapu verilerine erişim sağlanması yönünde bir eğilim gelişmektedir. Gerçekten, tapu siciline erişimin kolaylaşması ve erişimin kapsamının genişlemesi, işlemlere ve verilere olan kamu güvenin artmasına sebep olmakta ve böylelikle tapu işlem ve kayıtlarının görünür olmasını sağlayarak, aleniyet (kamuya açıklık) ilkesinin gerçeklemesine daha iyi hizmet etmektedir.

2236 Kamu hizmeti dahil, hizmet sunumunun niteliğinin ve şeklinin değişmesi, bilişim alanındaki teknolojik gelişmeler kapsamında, tapu sicilinin açıklığı sağlama ve bilgi verme fonksiyonu ile özel hayatın gizliliği, ticari sır ve toplumun bilgi edinme hakkı birlikte değerlendirilerek bir

---

[26] Kişinin mal durumun özel hayata dahil olduğu ve gizliliğinin korunması gerektiğine ilişkin olarak bkz. AYM. 19.11.1968 T., 1963/336 E. 29 K.

[27] **BAŞPINAR**, s. 113.

[28] **BAŞPINAR**, s. 116. Bu konuda bkz. **ÖZEL, Sibel**. Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, Ankara 2004, s. 158 vd.

[29] **BAŞPINAR**, s. 112 vd., 122.

denge sağlanmalı ve elektronik sicilde veriye ulaşım ve paylaşımın usul ve esasları belirlenmelidir. Sınırsız bir erişim, kişilik haklarını ihlal edeceği gibi, açıklık ilkesinin katı ve dar yorumlanması da aleniyet ilkesini gereksiz ve işlevsiz hale getirir.

2237 Türk Hukukunda, tapu sicilinin elektronik ortamda tutulmasıyla ilgili olarak Türk Medeni Kanunu ve Tapu Sicili Tüzüğü'nde yapılacak en önemli düzenleme, kullanıcıların elektronik tapu sicili verilerine erişim haklarına ilişkin ilke ve esasların belirlenmesidir. Bu sebeple, hangi kişi veya kurumun, hangi tür veriye erişebileceği, nasıl ve hangi kapsamda verilere ulaşabileceğine ilişkin olarak mukayeseli hukuk incelemesini aşağıda yaptıktan sonra, sonuç bölümünde kişisel görüşlerimizi belirteceğiz.

bb. Tapu Bilgilerine İlişkin Bilgi ve Belge İstemi

2238 Türk Medeni Kanunu'nun 1020'nci maddesi; *"Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez."* hükmündedir[32]. TMK'nın 1020'nci maddesi ile düzenlenen aleniyet ilkesi, bir ilginin varlığı ile sınırlandırılmış ve bu ilginin hukuken korunmaya değer bir menfaate dayalı olması gerektiğini vurgulamıştır. Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcıları ile özel kanun hükümleri gereği[33] görevli ve yetkili kişiler, suç araştırma veya soruşturma

---

[32] Görevleri gereği tapu kütüğü ve dayanağı belgelerini incelemeye ihtiyaç duyanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet gereği verilen tapu sicil bilgi ve belgelerinin veriliş esasları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 08.08.2001 tarih ve 2001/11 (1556) sayılı Genelge'de düzenlenmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve/veya Bölge Müdürlükleri ile belediyeler arasında tapu bilgi ve belge örneklerini alma talepleri ile tescile konu harita ve planların kontrol hizmetlerinin yerine getirilmesi 23.02.1993 tarih ve 1993/2 sayılı Genelge'de düzenlenmiştir. Kapsamı büyük ve uzun süreli hizmetler için, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin talep etmesi halinde, imzalanacak tip protokolle kadastral bilgiler ile tapu sicil bilgilerinin verilmesiyle tescile konu harita ve planların kontrol hizmetlerinin yerine getirilmesi 23.02.1993 tarih ve 1993/2 sayılı Genelge'de düzenlenmiştir.

[33] Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 08.08.2001 tarih ve 2001/11 (1556) sayılı Genelge'sinde, 628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca anılan kanun kapsamında soruşturma yapan Cumhuriyet Başsavcıları ile soruşturmayla görevli kılınan müfettişler, kontrolörler, denetmenler ve muhakkikler, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince Vergi Müfettişleri, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5/3(a) maddesi ile 9/2 maddesine göre yürürlüğe konulan Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 13'üncü maddesi gereğince Genel Müdürlük müfettişleri ve müfettiş yardımcıları, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince ön inceleme yapan görevliler, tapu bilgi ve belgesi isteyebilir.

kapsamında bilgi ve belge isteyebilir. Örneğin, mahkemelerin, taşınmaz mal davaları nedeniyle istediği tapu bilgi ve belgelere erişim sağlanmalıdır. Avukatlık Kanunu m. 2/III'e göre[32], kamu görevi ifa eden avukatların vekaletname ibraz etmeden yazılı olarak talepte bulunması koşuluyla, bir tapu memuru huzurunda tapu sicilini inceleyebilmeleri mümkün kılınmıştır. Avukatların tapu sicilinden örnek istemeleri halinde ise, temsil ettiği vekil edenin ilgisini ispat etmek ve örnek talebi sebebiyle tahakkuk eden gerekli harç ve vergilerin ödenmesi kaydıyla, vekaletname ibraz ederek örnek alabilmeleri mümkündür. Doktrinde avukatların bilgi ve belge örneği alma yetkisi, avukatların ifa ettiği kamu hizmetine uygun bir ayrıcalıktır[33].

2239 Sermaye Piyasası Kurulu'nun, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti vermek amacıyla yetki verdiği şirket elemanları, taşınmaza ilişkin bilgi isteminde bulunabilir. Bu kişiler, şirket ile taşınmaz malikinin imzaladığı sözleşmenin ve taşınmaz mala ait tapu senet fotokopisinin ve şirket yetkililerine verilmiş kimlik belgesini ibraz etmeleri halinde, istem belgesi düzenlenmesi koşuluyla taşınmaza ilişkin bilgi isteyebilir.

2240 Bankaların kredi aşamasında, kişilerin taşınmazlarına ait araştırma ve inceleme kapsamında bilgi istemlerinde, banka müdürlüklerince tapu senedi fotokopisi ekli yazılı talepte bulunmalarına bağlıdır[34].

2241 Tapu kayıtlarında yer alan adres bilgisinin, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşımı ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 08.08.2001 tarih ve 2001/11 (1556) sayılı Genelgesi şu şekilde düzenlemiştir: "*Müdürlüklerimizde yapılan işlemler esnasında gerçek ve tüzel kişilerin tapu sicili kayıtlarına yansıtılan adres bilgilerinin, gizlilik kurallarına uyulması ve adres bilgilerinin kullanımından kaynaklanan hukuki sorumluluğun talep eden idare tarafından kabul edilmesi koşuluyla kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşımı mümkündür.*"

---

[32] 4667 sayılı Kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2/III. maddesi: "*Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır*" hükmündedir.

[33] **OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 519, 525; **BAŞPINAR**, s. 106.

[34] Bkz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 08.08.2001 tarih ve 2001/11 (1556) sayılı Genelgesi.

2242 Tapu kayıtlarında yer alan nüfus bilgisinin, kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşımını ise şu şekilde düzenlemiştir: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü maddesinin (1). fıkrasında[35], nüfus kayıt örneğini almaya yetkili olanlar sayılmıştır; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve müdürlükleri bu fıkrada sayılmamıştır. Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülki idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler[36]. Bu madde hükümlerini işletmek üzere, *Kimlik Paylaşımı Sistemi* kurulmuştur.

2243 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 08.08.2001 tarih ve 2001/11 (1556) sayılı Genelge'sinde nüfus sicillerinin aleniyeti ile ilgili getirilen kısıtlama, gerçek kişilerin, şahsi halleriyle ilgili bilgileri içermesi yani, bir kimsenin medeni hali, doğum tarihi, hangi nüfusa kayıtlı olduğu gibi kişilik haklarını ilgilendirebilecek bilgileri içerdiğinden tapu sicilinde mevcut nüfus bilgilerinin, (malikin adı, soyadı ve baba adı dışında) anılan maddede tahdidi olarak sayılan askerlik şubesi, adalet mercileri ve mahallin en büyük idare amirinin onayın: alan daireler (bu dairelerde yazılı olarak istemde bulunmak zorundadır.) dışında hiçbir (sahtecilik olaylarının önlenmesi açısından) özel veya kamu hukuku tüzel kişisine verilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

b. Elektronik Tapu Verilerine Erişim

aa. Türk Tapu Sicillerinin Elektronik Ortamda Tutulması

2244 Türk tapu sicillerinin elektronik ortamda tutulmasını TST m. 12 düzenlemektedir: Tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulması hâlinde,

---

35 *"(1) Nüfus kayıt örneklerini; a) Bakanlık, b) Dış temsilcilikler, c) Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı, ç) Adlî makamlar, d) Adlî işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları, e) Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar, f) Ölüm işlemleri için resmî sağlık kuruluşları, g) Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile ve'i, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler. (3) Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır. (4) Birinci fıkranın (g) bendinde sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar medeni hal bilgisi dışında bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar."*

36 Bkz. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2000 tarih ve B050NÜV0060001-145-1650-10587 sayılı yazısında; *"... 1587 sayılı Nüfus Kanunun 61 inci maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla, Nüfus İdareleri, Askerlik Şubeleri, Adalet Mercileri, Zabıta Makamları (adli işlemler nedeniyle) Evlendirme Memurları (evlendirme işlemleri için), Bakanlık, kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, usul veya fürua yahut bunların resmi vekilleri, ikinci dereceye kadar dan cıvar hısımları nüfus kayıt örneğini almaya yetkilidirler. Bunların dışında kalan resmi daireler ve kurumlara da yazılı olarak başvurmaları üzerine istedikleri nüfus kayıt örnekleri, o yer va'ilik veya kaymakamın emri ile verilir."* şeklinde görüş bildirilmiştir.

ana ve yardımcı siciller TAKBİS içerisinde saklanır ve yönetilir. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nde (TAKBİS) saklanan ve güvenliği sağlanan taşınmaza ilişkin bilgiler, sicilde esas alınır. (TST m. 12 (1)). TAKBİS üzerindeki kayıtlar, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihten sonraki bilgileri gösterir (TST m. 12 (2)).

bb. Resmi Şekle Tabi Olmayan Belge ve Kayıt Örneği Talepleri

2245 Türk tapu sicilinde elektronik ortamda işlem yapılmasına TST m. 13 (1) hükmü imkan sağlamıştır. Genel Müdürlük tarafından belirlenecek resmi şekle tabi olmayan belge ve kayıt örneği verilmesi gibi işlemlerle ilgili elektronik ortamda başvuru yapılabilmesi ve elektronik imza dâhil, diğer kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak işlemlerin tamamlanabilmesi mümkündür.

cc. Elektronik Ortamda Verilere Erişim Hakkı

2246 TAKBİS verilerine erişime ilişkin döner sermaye katılma payını ve bunun istisnalarını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir (TST m.14 (7)). Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek sağlanabilir. Erişim hakkına sahip kuruluşlar, taşınmaz ile ilgili verileri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi: TAKBİS üzerinden alırlar (TST m.14 (1)).

2247 Başka hukuk kurallarında da TAKBİS'e atıf yapılmaktadır. Örneğin, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği m. 57 IV. fıkrasında, "*...Tapu kayıt bilgilerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) bulunması halinde bu bilgilere ilgili idare tarafından TAKBİS üzerinden elektronik ortamda doğrudan erişilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bu konuda gerekli tedbirler alınır. Yapı sahipleri veya vekillerinden ayrıca tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler istenmez. Ancak, bu durumda, yapı sahipleri veya vekillerden, başvuru dilekçelerinde TAKBİS üzerinden parsele ilişkin kayıtlara erişim için gerekli bilgileri beyan etmeleri istenir*" hükmü yer almaktadır.

2248 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilirler (TST m.14 (2)).

2249 TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede, erişimin türü ve şekli, erişim kontrolü, verilerin kullanım amacı, üçüncü kişilere kullandırılmasına ilişkin sınırlamalar ve amacı dışında kullanımın sonuçları yer alır (TST m.14 (3)).

2250 Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, düzenlenecek sözleşme şartları dahilinde verilere erişebilirler (TST m.14 (4)). Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilir (TST m.14 (5)). Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması hâlinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, TAKBİS'e erişim derhal durdurulur (TST m.14 (6)). TAKBİS üzerinden yapılacak her türlü sorgulama ve sorgulayan bilgisi kayıt altına alınır. Bu kayıtlar iki yıl süreyle saklanır (TST m. 15 (1)). TAKBİS üzerindeki verilere erişimi durdurmaya veya kısıtlama yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir (TST m.15 (1)). TAKBİS üzerinde, tapu görevlileri hariç olmak üzere, verilerin ardı ardına sorgulanmasına ilişkin her türlü güvenlik önlemi alınır (TST m. 15 (1)).

c. Veri Paylaşımı Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Tapu ve Kadastro (TAKPAS) Verisinin Paylaşımı

2251 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2'nci maddesi Genel Müdürlüğe "*sicil ve belgelerin arşivlenerek korunmasını sağlamak*" görevini vermiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce üretilen veya arşivlenen verilerin elektronik ortamda veya doküman olarak kişi ve Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (**KAYSİS**) yer alan kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları **Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik**[27] hükümleri ile düzenlenmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatınca üretilen veya arşivlenen verilerin kurumlar ve kişilerle paylaşılmasına imkân sağlayan sistem, **Tapu** ve **K**adastro **P**aylaşım **S**istemi (**TAKPAS**) olarak isimlendirilmiştir.

2252 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 12.05.2015 tarih ve 2015/1 (1763) sayılı Genelge ile önce 21.05.2015 tarihinden itibaren icra-i hacız, kamu haczi, ihtiyati hacız ve bunlara ilişkin şerhlerin salt elektronik ortamda tutulması uygulamasına tüm tapu müdürlüklerinde aynı anda ge-

[27] 07.03.2015 tarih ve 29888 sayılı Yönetmelik (30.04.2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete).

çılmıştır. Haciz işlemleri, TAKBİS üzerinden gerçekleştirilmektedir. 02.07.2015 tarihinden itibaren de Genel Müdürlüğün 23.06.2015 tarih ve 2015/4 (1766) sayılı Genelge ile tapu kütükleri üzerine tescil edilen tüm şerh ve beyanların salt elektronik ortamda tutulması uygulamasına yine tüm tapu müdürlüklerinde aynı anda geçilmiştir. Şerh ve beyanlar da, sadece elektronik ortamda TAKBİS üzerinden yapılmaktadır.

2253 Uygulama değişikliği ile, haciz işlemlerinde ve tüm şerh ve beyan işlemlerinde hak sahipliğinin belirlenmesi sürecinde herhangi bir değişiklğe gidilmeksizin, tapu kütüğü üzerinde şerhler süturu ile beyanlar hanesine yapılan tescillere son verilerek haciz işlemleri ve tüm şerh ve beyanların salt elektronik ortamda tutulmasının sağlanması amaçlanmıştır. Belirtelim ki, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2'nci maddesi ile Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmelik hükümlerinin söz konusu Genelgelere yasal dayanak teşkil ettiğini söylemek zordur. Haciz, Beyan ve şerh işlemlerinin elektronik tapu sicil sistemi içinde tutulması için bunların hukuki altyapısıyla ilgili Tapu Sicili Tüzüğü'nde ve yine maddi yönü için de TMK'nın tapu sicil hükümlerinde özel düzenleme ve değişiklik yapılması gerekir. Türk Medeni Kanun hükümlerinde yasal dayanağı bulunmayan bu Genelgelerin, en kısa zamanda yasal dayanağa kavuşturulması gerekir.

d. Yetki Alanı Dışı Taşınmazla İlgili Tapu İşlemi Yapılması

2254 Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri yayınlanmıştır[38]. Bu yönetmelik kapsamında, yetki ile işlem yapacak (yetki verilen) ve yetki istenen (yetki alan) tapu memurluğu arasındaki tüm yazışmalar ve belge gönderme işlemleri TAKBİS uygulama kılavuzunda gösterildiği şekilde, TAKBİS üzerinden gerçekleştirilecek olup, başka bir ortamda belgeler gönderilememektedir.

e. TAKPAS Verisi Paylaşımı

2255 TAKPAS verileri, elektronik tapu siciline geçilinceye kadar bilgilendirme amaçlı olarak kullanılabilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 5 –

[38] Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra Tapu Dairesi Başkanlığınca 01/08/2011 tarih ve 284-6092 sayılı genel duyuru ile uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla yapılacak işlemlere ilişkin düzenlenmiş 2012/9, 2014/8 ve 2018/1 sayılı ve "Yetki Alanı Dışı Tapu İşlemleri" konulu genelgeler yayımlanmıştır.

(1) C.2). Elektronik tapu siciline geçilene kadar ihtilaf halinde, tapu sicili bilgileri esastır (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik Geçici Madde 1 (1)). TAKPAS'taki veriler, taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içerir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **5** – (1) c.1). Veri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından üretilen veya arşivlenen taşınmazı tanımlayıcı bilgiler dahil, her türlü bilgi ve belgedir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **4** ı). Taşınmazı tanımlayıcı bilgiler, Taşınmazın bulunduğu il, ilçe, mahalle köy, mevkii, ada parsel numarası, nitelığı, yüzölçümü, kat irtifakı veya kat mülkiyeti durumu, varsa blok ve bağımsız bölüm numarası bilgileridir.

2256 Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerindeki kayıtlar, her bir birim için, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihte aktif olan ve bu tarihten sonra oluşan bilgileri içerir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **5** – (1)). TAKBİS öncesi pasif kayıtlara yönelik talepler, kişi ve kurumlar tarafından taşınmazın kaydına ulaşılmasını sağlayacak tanımlayıcı bilgileri belirtilerek tapu sicilinin tutulduğu ve dayanak belgelerin arşivlendiği ilgili birimlere yapılır (Veri Paylaşımı Hk Yönetmelik m. **5** – (2)). Harita verileri, Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği[39] ile Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği[40] esaslarına gore TAKPAS üzerinden paylaşılabilir. (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **13** (1)).

2257 Taşınmazı tanımlayıcı bilgiler, yer kontrol noktaları ve detay koordinatlar TAKPAS üzerinden sözleşme veya protokol düzenlenen kişi veya kurumlar ile paylaşılabilir. (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **14** (1)). Tapu tahrir defterlerine ait kayıtlar elektronik ortamda TAKPAS üzerinden sözleşme veya protokol düzenlenen kişi veya kurumlar ile paylaşılabilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **15** (1)). Tapu ve kadastro verilerini talep eden kurumlar, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile imzalanan protokol, Yönetmelikte "protokol" olarak tanımlanmıştır (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **4** e).

2258 Tapu ve kadastro verilerini talep eden kurumlar, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve taşınmaza

[39] 15.11.1991 tarihli ve 21052 sayılı Resmi Gazete.

[40] 31.08.1994 tarihli ve 22037 sayılı Resmi Gazete.

ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kısaca protokol imzalamaya yetkili olanlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin, elektronik kabul beyanıyla kabul ettikleri metin ya da Genel Müdürlükle imzaladıkları sözleşme, Yönetmelikte "sözleşme" olarak tanımlanmıştır (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **4 f**). Yönetmelikte, protokol imzalananlar dışında kalan taşınmaz malikleri, taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar ile taşınmazın tanımlayıcı bilgilerini talep eden gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda bilgisine sunulan metni kabulüne ilişkin beyanları, "elektronik kabul beyanı" olarak tanımlanmıştır (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **4** b). Alınan veriler kullanım amacı veya sözleşmede protokolde tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka amaçla kullanılamaz (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 7 (4) C.2)). Protokol yapılan kişi ve kurumlarla veri paylaşımı salt elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki kişi ve kurumların elektronik ortam dışındaki veri talepleri karşılanmaz (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 7 (5) C.1). TAKBİS öncesi pasif kayıtlara ilişkin bilgiler ve belge örnekleri ilgili kamu kurumlarının yazılı talebi üzerine verilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 7 (3) C.2).

2259 TAKPAS'ın işletilmesinde, paylaşılmasında ve kullanılmasında T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuatta yer alan; Devlet sırrına, kişisel verilerin korunmasına, özel hayatın ve soruşturmanın gizliliğine, mahkemelerce verilen gizlilik kararlarına, gizli tanıklığa, 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında alınan tedbir kararlarına ilişkin hükümler esas alınır (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 6 – (1)). Kurumlar ve kişiler aldıkları verilerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 7 (4) C.1).

f. TAKPAS Üzerinden Veriye Erişim (Sorgulama) Yetkisi Olanlar

2260 Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek belirlenebilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 10 (2)). Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilirler (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 10 (3)). Tapu Sicili Tüzüğü 14'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, kendi işleriyle sınırlı

olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile imzalanan protokoller kapsamında yapılacak sorgulamalar için Yönetmelik ek-3'te yer alan belgenin ilgililerce doldurulması gerekir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 11 (2)). Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, elektronik kabul beyanı ile oluşturulan sözleşme şartları dahilinde verilere erişebilirler (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 7 (4)). Tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerinde, malike ait T.C. kımlik numarası, ad, soyad, baba adı gibi kimlik bilgilerinin yanında TAKPAS'tan erişilen taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgilerinin de protokol yapılan kurumlarca tapu müdürlüklerine sunulması gerekir. Aksi halde söz konusu talepler ilgili Tapu ve Kadastro müdürlüklerince reddedilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 7 (6)).

2261 Tapu sicilinin açıklığı ilkesi gereğince, taşınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından elektronik kabul beyanı ile oluşturulan sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 7 (5)).

g. TAKPAS Üzerinden Veriye Erişim (Sorgulama) Yöntem ve İlkeleri

2262 Ülke düzeyinde veri talebi veya sorgulama yapılabilmesi için Genel Müdürlük ile protokol veya sözleşme yapılması zorunludur (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 11 (1)). Sözleşme veya protokol yapılmayan kurum ve kişiler TAKPAS'tan yararlanamaz (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 12 (2) C.1). Bu kurum ve kişiler tapu ve kadastro verilerine yönelik sorgulama taleplerini yürürlükteki mevzuat kapsamında taşınmaz kaydının bulunduğu tapu veya kadastro müdürlüklerine iletirler (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 12 (2) c.2). TAKPAS'tan hizmet alanların yapabileceği sorgulamalar, sorgulama sonucu olarak gönderilen bilgiler ve erişilebilecek internet sayfaları kurum veya kullanıcı bazında Genel Müdürlükçe belirlenir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 11 (3) C.1). Hizmet alanların kendilerine verilen yetkiler dışında sorgulama veya işlem yapması ve bilgi alması Genel Müdürlükçe engellenir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 11 (3) C.2). Erişilen ve paylaşılan veriler; Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadıkça, tarafların kendi görev ve faaliyet alanı kapsamında gerçekleştirecekleri işlemler haricinde başka kurum, kuruluş ve diğer kişilere kullandırılamaz ve yayınlanamaz (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. 16 (1)).

h. TAKBİS'te Sorgulama

2263 TAKBİS'teki veriler kişi ya da taşınmaz bilgileri esas alınarak sorgulanabilir. (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **12** (1) C.1) Sorgulama kriterlerini yeniden belirlemeye ve değiştirmeye Genel Müdürlük yetkilidir. Söz konusu değişiklikler hakkında protokol sözleşme yapılan kişi veya kurumlara 30 gün önceden yazılı ya da elektronik ortamda bilgi verilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **12** (3)). TAKPAS'tan alınan verilere ait **çıktı**larda kurum adı, kullanıcı adı, tarih ve saat bilgisi yer alır (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **11** (4)). Sözleşme veya protokol yapılan kurum ve kişilerce TAKBİS'te yer alan verilerin sorgulanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınır (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **12** (1) C.2).

2264 Kişi bilgileri ile sorgulanmasında: 1) Gerçek kişiler için öncelikli olarak T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılması esastır. Ancak, TAKBİS veri tabanında eksik olan malik nüfus bilgileri ve T.C. kimlik numarası entegrasyon işlemleri tamamlanıncaya kadar en az ad, soyad, baba adı kriterleri kullanılarak sorgulama yapılabilir. 2) Tüzel kişiler için sorgulamada öncelikli olarak vergi kimlik numarası ile sorgulama yapılması esastır. Ancak TAKBİS veri tabanında bulunmayan malik unvan bilgileri ile vergi kimlik numarası entegrasyon işlemleri tamamlanıncaya kadar salt unvan bilgisi kullanılarak sorgulama yapılabilir.

2265 Taşınmaz bilgileri ile sorgulanmasında: 1) Taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi köyü, ada ve parsel numarası, 2) Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerin sorgulaması için birinci alt bende ek olarak varsa blok ve bağımsız bölüm numarası, 3) Varsa T.C. taşınmaz numarası, 4) TAKBİS zemin sistem numarası, 5) İmar, kamulaştırma, toplulaştırma ve benzeri uygulamalar sebebiyle toplu olarak taşınmaz bilgilerine erişilmesi için protokolde hüküm bulunması ve sorgulama zaman diliminin Genel Müdürlükçe belirlenerek özel sorgulama yetkisi verilmiş olması gerekir.

i. TAKBİS'ten Örnek Edinme

2266 Yetkili kişi ve kurumların görevleri kapsamındaki bilgi ve belge istemlerinde, kayıtların tutulduğu ilgili birimlerden yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerinin verilmesi mümkündür (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **28** (1)). Taşınmaz malikleri ve taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar ile 4721 sayılı Kanunun 1020'nci maddesi uyarınca ilgisini imanlır kılanlar; kayıtların tutulduğu ilgili birimlerden

yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerini edinebilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **28** (3)).

2267 Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki alanı dışındaki tapu işlemleri hariç olmak üzere tapu siciline yönelik tescil, şerh, beyan, terkin ve TAKPAS'ta yer almayan veri talepleri ile uyumsuz kayıt iddialarına ilişkin taleplerin aslı sicillerinin bulunduğu tapu müdürlüklerine yapılması gerekir. Söz konusu taleplerde taşınmazın tanımlayıcı bilgilerinin bildirilmesi zorunludur. Bunun dışındaki talepler karşılanmaz (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **28** (2)).

2268 TAKPAS'tan herhangi bir nedenle uzun süreli olarak veri alınamaması halinde de bilgi ve belge verilebilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **28** (4)). İlgililerince sorgulama sonucunu gösterir belge tapu kayıt örneğinin istenilmesi durumunda ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince kayıt ve belge örneği verilmesine ilişkin harcın tahsil ettirilmesi gerekmektedir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **28** (6)). Tapu kadastro verileri, çevrimdışı (offline) olarak taşınabilir bellek, CD, DVD ve benzeri ortamlarda paylaşılamaz (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **28** (7)).

ı. Kurum ve Kişilerin Yükümlülükleri

2269 Kurumlar ve kişiler TAKPAS ile kurulan ve standartları Genel Müdürlükçe belirlenen güvenli ağ bağlantısını protokol veya sözleşmede belirlenen amaçlar doğrultusunda diğer bağlı birimlerinde de sağlar. Hizmet alanlar kendine bağlı birimler dışındaki kuruluşları ve kişileri TAKPAS'tan faydalandıramaz (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **20** (3)). Kurumlar ve kişiler, Genel Müdürlükçe belirlenen web servisleri üzerinden, Genel Müdürlüğün belirleyeceği metotlar ile sunulan verilerin kullanılması için gerekli yazılım ve donanımı sağlamakla yükümlüdür (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **20** (1)). TAKPAS'a bağlanmak isteyen kurumlar ve kişilere ait güvenlik kodları kontrol edildikten sonra, hizmet alanların güvenlik duvarları ile sistem güvenlik duvarları arasında özel şifrelenmiş güvenli ağ bağlantısı kurularak iki bağlantı noktası arasında hizmet verilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **20** (2)). TAKPAS'tan yapılan her türlü işlem, işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı, yapılan sorgulama bilgileri izleme bilgisi olarak tutulur ve bu

bilgiler yedeklenir. Tutulan izleme bilgisi sorgu sonucunu içerir. Genel Müdürlük kullanıcıları tarafından izleme bilgileri sorgulanarak TAKPAS'tan yapılan işlemler takip edilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **21** (1)).

j. Veri Paylaşımı İlkelerinin İhlali ve Hukuki Sorumluluk

2270 Veri paylaşımı ilkelerinin ihlali halinde, yaptırım uygulamaya Genel Müdürlük yetkilidir. Genel Müdürlüğün uygulayabileceği idari yaptırımlar şunlardır: **(1). Kısıtlama**: TAKPAS'taki verilere erişimde kısıtlama yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir (Veri Paylaşımı Hakkında Yönetmelik m. **16** (2) C.1). (2). **Durdurma:** Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması halinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sisteme erişim derhal durdurulur (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **16** (2) C.2). **(3). Askıya Alma ve İptal**: Sözleşme protokol hükümleri yerine getirilmediği takdirde kurumların ve kişilerin TAKPAS'tan faydalanması geçici olarak askıya alınır veya iptal edilir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **16** (3)).

2271 Erişilen ve paylaşılan verilerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak kullanılmasından doğan; hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluklar veriyi alan ve veya kullanana aittir (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **16** (4) C.1). TAKPAS kapsamında paylaşılan bilgilerden faydalanan diğer görevliler de bu hükme tabidir. TAKPAS'ın bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de sözleşme protokolde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder (Veri Paylaşımı Hk. Yönetmelik m. **16** (4)).

§ 14. ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ

I. KAVRAM

2272 Elektronik tapu sicili (EDV-Grundbuch, infomatisiertes Grundbuch, computergeführtes Grundbuch, Machinell geführtes Grundbuch) maddi olarak değil, elektronik verilerin bilgisayarla tapu sicili bilgisi olarak girilmesi ve saklanarak tutulması esasına dayanmaktadır[1].

2273 Elektronik tapu sicili sisteminde, tapu sicilinin tutulması ve düzenlenmesi bilgisayar ortamında bileşim araçları ile gerçekleşmekte, bir programa dayanarak bilgisayara işlenen taşınmaz ve hak sahipliğine ilişkin tüm veriler tapu sicil sistemini oluşturmaktadır. Tapu sicili bir bütün olarak ana ve yardımcı sicillerle fikri bir bütünlük modeli oluşturmaktadır[2], tüm siciller, yüklenen aynı verileri tüm sicillerde kullanmaktadır.

2274 Tapu siciline ilişkin aynı defter tapu sicilinde olduğu üzere, tüm kayıt verileri, ilgili taşınmaz sayfasına defter siciline benzer şekilde, bir veri programına elektronik veri olarak işlenerek, veri depolama yerinde saklanır. Tapu sicili verilerinin elektronik ortamda kaydedilmesi ile birlikte bu veriler geri alınamaz ve değiştirilemez şekilde, tapu kütüğüne ve yevmiye defterine ve ilgili diğer yardımcı defterlerin hepsine aynı anda otomatik işlenmiş olur; tüm defter sistemleri birbiriyle ilişki içinde bir bütün olarak çalışır.

2275 Elektronik tapu sicili, kavramsal olarak, taşınmaza ilişkin tüm hukuki, kadastral ve teknik verilerin elektronik ortamda bilgisayara kaydedilerek taşınmazı belirleyen, bu verilerle, birbiriyle uyumlu olarak kendiliğinden tapu kütüğü ve yardımcı tapu sicillerinin elektronik ortamda oluşturulmasını ve tutulmasını sağlayan, tüm tapu işlemlerinin elektronik ortamda yapılarak, bu verilerin sicillere kayıt ve işlenmesi ile taşınmazın hukuki durumunu ve taşınmaz üzerindeki hak durumunu belirleyen ve bu verilerin yönetilmesini, arşivlenmesini, kimlik, adres, coğrafi konumları vb. diğer verilerle ilişkilendirilmesini ifade eder.

---

[1] Genel olarak şu sistemler kullanılmaktadır: Capitastra, ISOV, Terris.

[2] SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N. 382; MÜLLER/SCHMID, s. 147; SCHMID, BSK ZGB Art. 949, N. 6; MÜLLER/SCHMID, s. 145.

2276 Elektronik tapu sicilinin temel mantığı, elektronik veri işlemesi ile tutulan tapu sicili sistemi olmasıdır. Buna karşın defter tapu sicilinin temel mantığı ise madd: varlığı olan defter ve onun sayfasına dayanmaktadır. Elektronik tapu sicilinde kayıt bilgilerine ilişkin bilgilerin bir bilgisayar veri programı aracılığıyla elektronik ortamda verinin işlenmesi; defter tapu sicilinde ise kayıt bilgilerinin defterin ilgili taşınmaz sayfasına elle ya da bilgisayarla yazılması söz konusudur. Elektronik tapu sicilinde sicil kayıt ve bilgilerine, saklandığı bilgi bankasından bir elektronik program üzerinden, tapu idaresince bir araç yardımıyla, örneğin bilgisayar ekranından veya bir yazıcıdan okunabilir tapu bilgilerine ulaşılması söz konusudur. Elektronik tapu sicil bilgilerine, bir defterden değil, bir bilgisayar ekranı üzerinden ulaşılabilir, incelenebilir ve de bir yazıcıdan çıktısı alınabilir.

2277 *Kılıç*, elektronik tapu sicilini, "elektronik veri tabanları kullanılarak tapu sicilinin unsurlarını oluşturan aslî sicîller ile fer'i sicillerin elektronik ortamda tutulduğu ve taşınmazların fiilî ve hukukî durumlarıyla ilgili diğer her türlü verilerin otomatik bir sistem aracılığı ile saklandığı, oluşturulan veri bankaları arasında elektronik bağlantıların kurulduğu, önceden belirlenen kullanıcı gurubu tarafından bu veri bankalarını her şekilde kullanma hakkının tanındığı, kendine özgü yapısı ve tekniği olan başlıca bir sistem" şeklinde tarif etmiştir[3].

II. ELEKTRONİK TAPU SİCİL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Amacı

2278 Tapu sicilinin elektronik olarak tutulması tapu sicilinin otomasyonu anlamına gelmektedir; aşağıda elektronik tapu sicilinin amacını kısaca şu şekilde belirleyebiliriz:

2279 Tapu sicilinin aleniyetini sağlamada elektronik tapu sicili taşınmazı ilgilendiren hakların bir kamuya ulaştırılması aracıdır. Elektronik tapu sicili, aleniyet fonksiyonunu yerine getirme amaca hizmet eden, en verimli ve uygun araçtır.

2280 Tapu sicilinin ilgililer tarafından, gerek tapu idaresinden gerekse başka yetkilendirilmiş kişilerden, örneğin noterden, ilaveten internet üze-

[3] KILIÇ, Tez, s. 65 vd.

rinden ilgilinin doğrudan otomatik veri çağırma işlemi ile tapu bilgilerini sorgulaması, incelemesini, örnek alması gerçekleşmektedir. Tapu sicili işlemlerinin kaydını hızlandırmakta, elektronik işlemler aracılığıyla tapu kaydına imkan tanımaktadır. Taşınmazın bulunduğu tapu idaresine gitmeksizin, hatta yetkilendirilmiş başka bir kuruluşta, örneğin noterde tapu işlemi yapabilme imkanı sağlamaktadır.

2281 Tapu sicili işlemlerinin veri işleme yoluyla tutulması tapu idaresinin çalışmalarını hızlandırmakta, basitleştirmekte, işlemleri hızlandırdığından zaman tasarrufu sağlamakta ve işlem maliyetini ve dolayısıyla da personel maliyetini düşürmektedir. Elektronik ortamda mahkemelerin, kamu kurum ve kuruşlarının ve diğer ilgililerin tapu siciline ulaşımını kolaylaştırmakta ve kurumlar arası, özellikle tapu idareleri arasındaki bilgi alışverişini ve iletişimi hızlandırmakta ve basitleştirmektedir.

B. Olumlu ve Olumsuz Yönleri

2282 Elektronik tapu sicili doktrinde farklı biçimlerde değerlendirilmektedir[4].

1. Olumlu Yönleri

2283 Teknik olarak taşınmazların elektronik kadastro verileri ile belirlenmesi tapu sisteminin elektronik tapu sicil ile bütünlük teşkil etmesi ihtiyacı, elektronik tapu sicilini gerekli kılmaktadır. Tapu sicil sistemi kamu hizmetinin diğer sistemleri ile entregre olmasını kolaylaştırmaktadır. Çok amaçlı arazi bilgi sisteminin kurulmasına da hizmet etmektedir.

2284 Diğer yandan tapu sicilinin aleniyet fonksiyonunu daha iyi sağladığı da söylenebilir. Elektronik tapu siciline olumlu yaklaşanlar, büyük avantaj olarak günümüzdeki donanımların (hardware) büyük kayıt hafızasını göstermektedirler. Diğer bir olumlu nokta da, tapu kütüğü ve yevmiye defteri arasında noksan olan bağlantının çözüme ulaşmasıdır: Yevmiye defterine bir kayıt girildiği zaman, direkt olarak tapu kütüğü ile de bağlantı sağlanmaktadır. Bu da tapu ve kadastro verilerinin elektronik ortamda güncel bir şekilde tutulmasını gerçekleştirir. Elektronik tapu sicili hızlı bir şekilde tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesine hizmet eder. Taşınmazın kayıtlı bulunduğu Tapu Müdürlüğüne gidilmeksizin bilgi sahibi olma ve elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan verir.

[4] MÜLLER/SCHMID, s. 158 ff.

2285 Elektronik tapu sicili, taşınmazların, hak sahiplerinin ve hakların işlevsel olarak sınıflandırılması ve çeşitli arama motorları ile taşınmaz bilgilerinin taranmasına ve bulunmasına hizmet eder. Taşınmazlar hakkında bilgi verme fonksiyonunu en iyi ve amacına en uygun şekilde gerçekleştirir. Personel ve kaynak tasarrufu sağlar[5]. Tapu işlemlerinde insan faktörünü en aza indirerek, olası hataların önlenmesi veya azaltılmasını sağlar. Verilerin elektronik arşivi, yedeklenmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla birlikte fiziki arşiv sisteminin mahzurlarını giderir.

2286 Diğer bir ilave edilecek olumlu yön de, diğer elektronik tapu sicilleri ile ortak bir ağın oluşturulabilmesidir. Böylelikle veri paylaşımını ve diğer kurum verileriyle entegrasyonu sağlar ve gerektiğinde tapu sicil kayıtlarının başka kullanımlar için hazır olması sağlanmaktadır[6]. Son olarak elektronik tapu sicili ile çelişkili ve hatalı girilen kayıtların önlenmesi söz konusudur.

2. Olumsuz Yönleri

2287 Elektronik tapu siciline eleştiriler de mevcuttur: ZGB 949a maddesindeki elektronik tapu sicili düzenlemesine dair yetki normunun sınırlarını aştığı belirtilmektedir[7]. Elektronik tapu siciline geçişte diğer problemler de ortaya çıkmaktadır[8]: Kağıt tapu siciline girilen belirli kayıtların, aktarım sırasında bilgisayar tekniği ile ilgili nedenler yüzünden kısaltılmak zorunda olması söz konusu olabilir. Elektronik tapu sicili kayıtlarının, kağıt tapu sicilindeki gibi içerik olarak olduğu gibi aktarılması gerekse de, kısaltılmaların kullanılmasına izin verilebilir[9].

2288 Açık olmayarsa hangi usul aşamasında bu kısaltmaların gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Her halükarda tapu sicil memuru büyük dikkat ile hareket etmelidir, çünkü güven ilkesi uyarınca lafzın önemli bir anlamı vardır. Diğer bir eleştiri konusu ise, Kantonların sistemi serbestçe seçebilmesidir[10], çünkü bu şekilde bir birlik oluşturulamaz; ayrıca uzun süreli

---

5 HOLZER, Johannes, Das Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz, NJW 1994, s. 483.

6 Art. 111m GBV. Bu konuda karş. SCHMID, BSK ZGB Art. 949, N. 24 ff. Bkz. KARAU, Karsten, L'article 111m ORF et les réglementations cantonales concernant l'accès au registre foncier informatisé, ZBGR 2/2001, s. 65 ff.

7 SCHMID, BSK ZGB, Art. 949, N. 5 ff.

8 Ayrıca bkz. SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N. 391.

9 SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N. 391.

10 SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N. 390.

olarak verilerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili de tatmin edici bir çözüm yoktur[11].

C. Elektronik Tapu Sicil Sisteminin Bütünlüğü

2289 Tapu siciline ilişkin tüm kayıt verileri, ilgili taşınmaza bir veri programı aracılığıyla elektronik veri olarak işlenmekte ve işlenen veriler bir depolama yerinde saklanmaktadır. Tapu sicili verilerinin elektronik ortamda kaydedilmesi ile birlikte, bu veriler geri alınamaz ve değiştirilemez şekilde, tapu kütüğüne ve ilgili diğer yardımcı defterlerin hepsine aynı anda otomatik işlenmiş olur. Tapu sicili kayıtlarına ilişkin girilen veriler, külli olarak bir tapu sisteminde tutulur, tüm defterler birbiriyle ilişki içinde çalışır[12].

2290 Elektronik tapu sicilinde, tapu kütüğündeki ve yevmiye defterindeki kayıtlar aynı sisteme işlenmekte ve birbiri ile ilişkilendirilmektedir (GBV § 8 Abs. 2). Bu yaklaşımda, yevmiye defteri TMK m.1022 II'deki tescilin etkisi fonksiyonunu ve anlamını kaybetmektedir. Ana sicil ve yevmiye defteri kavramları, sadece veya alternatif olarak veyahut sicil bilgilerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak, defter tapu sicili tutulduğu sürece varlığını sürdürecektir. Bu bakımdan, siciller maddi bir kavramdan fikri bir modele dönüşmüştür[13]. Buna karşın uygulaması neredeyse olmayan, fakat kabul edilen bilgisayar destekli tapu sicilinin bazı kısımlarının elektronik veri işlemi (EDV) bünyesinde yürütülmesi, onun tapu sicili olduğu gerçeğini değiştirmez.

D. Elektronik Tapu Siciline Hakim İlkeler

2291 Elektronik tapu sicilinin işleme koyulmasında -özel hükümler dışında- tapu sicilinin tutulmasındaki genel ilkeler geçerlidir[14]. Elektronik tapu sicili, defter tapu sicili gibi **güvenilir ve açık**; defter tapu sicili ile aynı ölçüde doğruluğa sahip olmalıdır[15].

---

[11] **MÜLLER/SCHMID**, s. 161.

[12] Karş. aGBV Art. 111.

[13] EGBA, s. 252, 253.

[14] **PFAMMATTER, Aron**, OFK - Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), ZGB Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Hrsg.: **KREN KOSTKIEWICZ, Jolanta/WOLF, Stephan/AMSTUTZ, Marc/FANKHAUSER, Roland**), 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 949a, N. 7. Bu ilkeler için bkz. **ANTALYA**, EH I, N. 491 vd.

[15] **MÜLLER/SCHMID**, s. 165.

E. Elektronik Tapu Sicilinin Etkisi

2292 Tapu kütüğü ve yevmiye defterinin verileri, tapu müdürlüğünün aygıtlarında gösterilen yazılı ve sayılı şekli ile hukuken hüküm ifade eder. Elektronik tapu sicilinde, tapu sicil müdürlüklerinin elektronik tapu verisinin, yazı ve sayı ile bir taşınmaza ait incelenebilir bilgilerin arşivlendiği yerden çıktısının veya görüntüsünün alındığı andan hukuki etkisi söz konusudur (ZGB 9-2 Abs.4). Ekranda okunan kayıtlar veri bankaları ve programlara girilen tapu kayıtlarına ilişkindir.

2293 Kayıtların kağıda basılması, tapu sicil memurunun imzası olmadığı sürece, kendi başına tapu sicili etkisi oluşturmamaktadır, ancak yine de TMK m. 7 (ZGB Art. 9) uyarınca resmi bir belge yerine geçer[6].

F. Elektronik Tapu Sicil Verilerinin Güvenliği

2294 Elektronik tapu sicili güvenliği, elektronik ortamda yüklenen ve elektronik ortamda saklanarak kaydedilen tapu sicil verilerinin kaybedilemeden ve hasara ve değişikliğe uğramaksızın aynen tekrardan olunabilir şekilde erişiminin sağlanmasını ifade eder.

2295 Elektronik tapu sicili verilerinin güncel haline her an ve hemen ulaşılabilmesi ve bu verilerin güvenliğinin güvence altına alınması gerekir. Bu gerekliliği günümüzün teknik ve teknolojik gelişimlerini karşılayacak şekilde, gelecekteki gelişmeler de dikkate alınarak sağlanması görevi, tapu sicili tutan yetkili tapu idaresinin sorumluluğu altındadır. TMK m. 1006 hükmü tapu idarelerinin kuruluş, işleyiş ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak özel kanun hükümlerine atıfta bulunmuştur.

2296 Elektronik veri güvenliğinin teknik olarak sağlanması, bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin sağladığı imkanlarla gerçekleştirilmelidir. Elektronik tapu sicil verilerinin güvenliğine ilişkin teknik düzenlemelerle ilgili olarak Tapu Kanunu'na veya TMK m. 1003'ten sonra gelmek üzere, TMK m.103a olarak, tapu sicili kayıtlarının tutulmasına dair bir yetki hükmü ile Yönetmelikler ilgili Bakanlıkça düzenlenmelidir. Bu yetki hükmünün düzenlenmesinde mehaz ZGB Art. 949a bazı değişikliklerle

---

[6] Bu konudaki değerlendirmeler için bkz. **SCHMID**, BSK ZGB Art. 949, N. 37 ff.; **PFAMMATTER**, OFK ZGB Art. 949a, N. 3; **TRAUFFER, Bernhard**, Revision der Grundbuchverordnung per 1. April 2005, ZBGR 1/2006, s. 56, 63 ff.; **MULLER/SCHMID**, s. 163 ff.; **ANTALYA, O. Gökhan/TOPUZ, Murat**, Medeni Hukuk (Giriş - Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri), Cilt I (Editör: **ANTALYA, O. Gökhan**), Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul 2019, N. 2253 vd.

temel alınabilir. Elektronik tapu sicil sisteminin maddi hukuktaki yeri bakımından, yine mehaz ZGB Art. 942 Abs. 3'ten esinlenerek, TMK m. 997 hükmüne bir fıkra ilavesi gerekir.

G. Kayıt (Tescil) İşlemlerine Uygunluğun Sağlanması

2297 Kayıt (tescil) işlemlerine ve buna ilişkin maddi hukuk kurallara uygun şekilde, -bunları kayıt giriş sistemi olarak da ifade edebiliriz- girilecek elektronik tapu sicil bilgilerine ilişkin verilerin, veri giriş programına uygun hazırlanıp, kurgulanması gerekir. Verilerin hazırlanması ve kurgulanmaya uygun şekilde, TMK hükümleri ile çelişmeyecek şekilde, Tapu Sicili Tüzüğü'nün elektronik tapu sicil sistemiyle uyuşmayan hükümlerinin değiştirilmesi ve ek maddeler getirilmesi gerekmektedir. Daha da doğrusu tümden Tapu Sicili Tüzüğünün gözden geçirilmesi gerekir.

2298 Bu konuda, TMK m.1015 hükmünün kayıt (tescil) yetkisinin ve sebebinin belirlenmesi, sebebin belgelenmesine ilişkin resmi şekilde ortaya çıkmasına ilişkin kayıt işlemlerinde, tapu memuruna verilen yetkinin, elektronik tapu sicil sisteminde işleyişi ve denetimi özellikle düzenlenmelidir. Kayıt işleminde bir hatanın, kanuna veya gerçeğe aykırı bir kaydın oluşmasının engellenmesine yönelik olarak değişiklik olasılıklarının dikkate alınarak sistemin programlanması gerekir. Programda, kesin veri girişi öncesi **kayıt ön kontrol aşaması** oluşturulmalıdır.

2299 TMK m.1022 hükmü, ayni hakların, yevmiye defterine kaydı esas olmak üzere tapu siciline kayıt tarihini esas almaktadır. Bu düzenleme, özellikle defter esaslı tapu sicil sistemine uygun bir düzenlemedir. Elektronik tapu sicilinde yevmiye defterine kaydın yazımından bahsedilemeyeceği aşikardır. Bu sebeple elektronik tapu sicili kaydının sonuçlarını doğurma anına ilişkin olarak, mehaz ZGB Art. 942 Abs.4 hükmünden yararlanarak, TMK m.997 hükmüne bir fıkra ilavesi gereklidir.

H. Tapu Kütüğündeki Elektronik Kişisel Verilerin Korunması

2300 Elektronik tapu siciline dahil olan kişisel verilerin korunması, özellikle bu verilere ilişkin olarak kişilik hakkının ihlalinin önlenmesi gerekir. Elektronik olarak saklanan kişisel verilere ulaşımın, sadece gerekli olduğu zaman ve ulaşımın gerekliliği ile sınırlı olmalıdır[7]. Bu gereklilik

[7] **MUTTER, Peter**. Persönlichkeitsschutz und Datensicherung. Computer und Recht. Bd. 9. Zürich 1980. s. 353 ff.

uygun amaç ve uygun araçla hizmet etmelidir. Elektronik tapu sicili verilerinin korunması ile tapunun aleniyetinin elektronik tapu sicili aracılığıyla sağlanması arasındaki denge ve ilişki göz ardı edilmemelidir.

III. İSVİÇRE HUKUKUNDA ELEKTRONİK TAPU SİCİL SİSTEMİNİN UYGULANMASI

A. Genel Olarak

2301 İsviçre hukukunda[18] EJPD tarafından 1970'li ve 80'li yıllarda oluşturulan çalışma grupları ve uzmanlar komisyonları, tapu sicilinin otomatik elektronik veri işlenmesi ile de yürütülebileceği sonucuna varmıştır[19]. Ancak o tarihlerde tapu sicilinin teknik olarak hangi elektronik ortamda, hangi programla yürütülmesi gerektiği, verilerin saklanması ve güvenliği, transferi ve uyumu konusunda oldukça teknik sorunlar da söz konusu idi. İsviçre'nin federatif yapısı, yapı ve içerik olarak farklı tapu sicil formlarının teknik özellik bakımından birinden ayrı bağımsız tapu sicil sisteminin çıkmasına imkan verebilecek bir görünüm arz etmekteydi[20]. 1990 yılında ise, İsviçre Medeni Kanunun taşınmaz hukuku ve Borçlar Kanunun taşınmaz satışı hükümlerinin kısmi revizyonu çalışmaları gerçekleşmiştir[21]. Bu kapsamda, elektronik tapu sicili ile bilgisayar destekli tapu sicilinin yasal dayanağı olarak, ZGB Art. 949a Ziff. I hükmü OR ve ZGB'nin taşınmaz hükümlerinin kısmi revizyonuna ilişkin 04.10.1991 tarihli Kanuna alınmıştır; bu kanun 01.01.1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir[22].

2302 ZGB Art. 949a hükmü ilavesi, büyük tartışmalara sebep olmamışsa da, bu değişiklikle birlikte yapılan ZGB Art. 970 hükümlerinde yapılan tapu sicilini inceleme konusu oldukça tartışılmıştır[23].

2303 ZGB Art. 949a hükmü Elektronik İmza Hakkında Federal Kanun'la (ZertES) tekrar revizyona tabi tutulmuştur ve bu hükümde 01.01.2005 ta-

---

[18] Konuya ilişkin Alman ve Avusturya hukukunda elektronik tapu sicil sistemine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. **ANTALYA**, Elektronik Tapu Sicili, s.75 vd.

[19] **MÜLLER/SCHMID**, s. 147 ff.

[20] **SCHMID**, ZBGR 4/1995, s. 262; **MÜLLER**, s. 348 ff.; **MÜLLER/SCHMID**, s. 146 ff.; **SCHMID**, BSK ZGB, Art. 949a, N. 5.

[21] **SCHMID**, BSK ZGB, Art. 949a, N. 3.

[22] AS 1993 1404, BBl 19889 III 953. Bu değişikliğe paralel olarak da GBV Art. 111 ff. hükümleri getirilmişti.

[23] **SCHMID**, ZBGR 4/1995, s. 261; **SCHMID**, BSK ZGB Art. 949a, N. 7 ff.

rihinde madde değişikliğe uğramıştır[24]. ZGB Art. 949a hükmü ile birlikte tapu sicilinin aleniyetini düzenleyen ZGB Art. 970 hükmü de değiştirilmiş ve 970a hükmü ilave edilmiştir[25]. ZGB Art. 949a hükmü, ZGB Art. 942 II ve Art. 970, 970a ile birlikte - bilgisayar destekli veya elektronik sicil sistemi çerçevesinde tapu sicilinin yürütülmesinin yasal dayanağını oluşturmaktadır. ZGB Art. 949a Abs.1 hükmünde, Kantonların tapu sicilinin sadece kağıt (defter) tapu sicili olarak değil, elektronik araçlarla da tutulabileceğini düzenlemiştir. Kantonlar, tapu sicil sisteminin ne şekilde tutulacağına ilişkin sistemi seçmede serbesttir[26]. İlaveten, ZGB Art. 942 Abs. 3 hükmündeki açıklama ile de tapu sicilinin kağıt (defter) şekli yanında, elektronik araçlarla tutulabileceği konusunda netlik kazandırılmıştır. ZGB Art. 942 Abs.4 hükmü, elektronik tapu siciline yapılan kayıtların (tescilin), sayısal ve yazı şeklinde okunabilir çıktısının, depolandığı elektronik arşivden alındığı anda hukuki etkisini –sonuçlarını- doğuracağını düzenlemiştir.

2304 23.10.2011 tarihli GBV Art. 3 hükmü, tapu sicilinin tutulma şekilleri olan kağıt (defter) şekli ile elektronik şeklin aynı değerde olduğunu, yani her ikisinin de aynı hüküm ve sonuçları doğurduğu ifade edilmiştir. ZGB'de getirilen elektronik tapu siciline uygun olarak, GBV Art. 8, 14 ff. ve 159 ff. hükümleri getirilmiştir. Aşağıda bu hükümler üzerinde durulacaktır.

2305 GBV düzenlenmesinde iki temel ilke söz konusudur[27]: İlk olarak, elektronik tapu sicili, bilgisayar destekli tapu sicilinde olduğu üzere sadece bilgilendirme ve işlemleri basitleştirme ve hızlandırma fonksiyonlu değil, maddi anlamda (olumlu veya olumsuz) hukuki sonuç doğurucu fonksiyonlu düzenlenmiştir. İkinci olarak, elektronik tapu sicili, tapu sicilinin maddi hükümlerini düzenleyen ZGB'nın genel ilkelerine uygun olarak, teknik farklılıklar gerektirmedikçe, defter tapu sicili sistemine paralel bir sistemle tutulması ilkesi benimsenmiştir.

2306 GBV Art. 8 I elektronik araçlarla tutulan tapu sicilinde, tapu kütüğü ve yevmiye defteri verilerinin aynı sistemde birbiriyle ilişki içinde çalışa-

[24] AS 2004 5085; BBl 2001 5704 ff.

[25] SCHMID, ZBGR 4/1995, s. 262 ff.; SCHMID, BSK ZGB, Art. 949a, N. 3a.

[26] SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N. 387.

[27] SCHMID, BSK ZGB, Art. 949a, N. 5.

cağı ifade edilmiştir[24]. Söz konusu verilerin taşınmazın bilgilerinin diğer arama tanımlamalarına, örneğin kişi adı, taşınmaz adresi vb. göre ulaşılabilir olması gerektiği belirtilmiştir.

2307 Tapu sicilinin teknik anlamda farklı şekillerde yürütülebilir olması, taşınmaz eşya hukukunun bir tapu sicili sistemine dayandığı gerçeğini değiştirmemektedir. Yapı ve içerik bakımından farklı tapu sicil şekilleri, teknik düzenleme haricinde aynıdır[25]. ZGB Art. 949a II'de, Federal Konseyin yetki normunu düzenlenmiş ve Kantonlara devredilen düzenleme yetkisi kapsamında Federal otoritenin düzenleme getirmekte yetkili olduğu hususlar yedi bent halinde detaylı ve açık bir şekilde sayılmıştır. Bu kapsamda özellikle ZGB Art. 949 II 3 hükmü, tapu sicil müdürlüğü ile yapılan işlemlerde elektronik işlemlere izin verilip verilmeyeceği ve bunların koşullarını düzenleme yetkisini Federal Konsey kendisinde tutmuştur. Yine Federal Konsey, ZGB Art. 949a II hükmü kapsamında el imzasının elektronik imza yerine geçip geçemeyeceğini ve bunun şartlarını belirleme yetkisine haizdir[26]. Bunlara ek olarak 3. fıkra ile de, yetki verilen kamu kurumlarınca tapu sicili ve resmi ölçüm modelleri için müşterek bir arayüz tayin edilmesi hususu düzenlenmiştir.

B. Elektronik Tapu Sicilinin Tutulması[27]

1. Elektronik Tapu Sicilinin Tutulması

a. Kayıt (Tescil) Verilerinin İşlenmesi (Tetkik Usulü)

2308 Yeni kayıt sistemi tapu sicilinin elektronik ortamda tutulması ZGB Art. 949a Abs.2 Ziff. 2 hükmüne dayanılarak çıkarılan yeni GBV hükümlerinde düzenlenmiştir. Yeni GBV düzenlemesinde defter usulü ile tapu sicilinin tutulması temel alınmıştır[28]. Elektronik tapu sicilinin temel (ana) defteri, yine tapu kütüğüdür[29]. Elektronik tapu kütüğü, her taşınmaz için

---

24 **PFAMMATTER**, OFK ZGB, Art. 949a, N. 2; **SCHMID**, BSK ZGB, Art. 949a, N. 5a.

25 **SCHMID**, ZBGR 4/1995, s. 262; **SCHMID**, BSK ZGB, Art. 949a, N. 5; **MÜLLER/SCHMID**, s. 146. Bu konuda bkz. **MÜLLER**, ZBGR 6/2001, s. 348 ff.

26 **MÜLLER/SCHMID**, s. 162 ff.

27 Bu konuda bkz. **PFAMMATER**, OFK ZGB, Art. 949a, N. 1 ff.; **DEILLON-SCHEGG, Bettina**, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (Hrsg. **BREITSCHMID, Peter/RUMO-JUNGO, Alexandra**), Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2016, Art. 949a, N. 6-7; **SCHMID**, BSK ZGB, Art. 949a, N. 6 ff.

28 **SCHMID**, BSK ZGB, Art. 949a, N. 9.

29 **MÜLLER/SCHMID**, s. 155; **SCHMID**, BSK ZGB, Art. 949a, N. 10.

elektronik tapu kütüğünde ayrı bir sayfa açılacak şekilde ve bu sayfaya taşınmaz bilgileri ve taşınmaz üzerindeki kaydı gereken haklar veri olarak işlenecek şekilde elektronik ortamda oluşturulur.

2309 Elektronik tapu sicili tutulmasında, tescil işlemleri ve diğer kayıt işlemleri elektronik veri olarak tapu kütüğüne işlenir. Tapu kütüğüne tapu bilgileri elektronik ortama veri olarak girilir. Bu işlemi, **veri işleme işlemleri veya usulü (tetkik usulü)** olarak adlandırabiliriz. Veri işleme işlemlerini de dar anlamada *tescil işleme işlemleri (usulü)* ve geniş anlamda *kayıt işleme işlemleri (usulü)* olarak ikiye ayırabiliriz.

2310 Tapu kütüğüne verilerin işlenmesini amaçlayan kayıtlar (tesciller), yine elektronik ortamda tutulan yevmiye defterine yapılan kayıt ile başlar (GBV Art. 91 I). Yevmiye defteri de tapu sicilinin temel defteri olma özelliğini devam ettirmektedir. Tapu kütüğü ile diğer gerekli yardımcı siciller ve ilgili yevmiye defteri kayıtlarıyla irtibat ve ilgi kurulur. Elektronik tapu sicil sistemi, yevmiye defterine kayıt sebebiyle tapu kütüğüne ait verilerin daha tetkik safhasında olduğundan, tapu kütüğünde hukuki geçerli verilerin varlığına terkin veya düzeltme şeklinde etki olmamalıdır (GBV Art. 91 II).

2311 Yevmiye defterine kaydın etkisi, tetkik usulünün tamamlanması sonrasında, tapu sicil memurunun girilen ya da değiştirilen tescil ile ilgili kayıtların hukuki hüküm ve sonuç yaratacak şekilde onaylamasına bağlı olmalıdır (GBV Art. 91 III). Tapu sicil memuru, kayıt tetkik safhasında kayda geçen, tadil ya da terkin edilen verileri bir onay komutu ile hukuken geçerli hale getirir; aynı şekilde yevmiye defterine girilen tescil taleplerini reddedebilir, geri alabilir ya da yanlış olarak girilen kaydın geçersiz sayarak reddetmesi de söz konusu olabilir[34].

b. Tapu Sicil Müdürlüğü ile Yapılan Elektronik Hukuki İşlemler

2312 Tapu Sicil Müdürlüğü katılımı veya ona talepler yapılacak elektronik hukuki işlemlerle ilgili olarak ZGB Art. 949a Abs.2 Ziff.3 hükmündeki yetki ile yeni GBV hükümleri düzenlenmiştir. Tapu sicil memurluğunda yapılan elektronik işlemlerin, bir kısmı tapu sicilne ilişkin *bilgilendirme işlemleri*dir; diğerleri ise elektronik ortamda yapılan hukuki işlemlerdir. Tapu memurunun tapu sicili üzerinde taşınmaza ve taşınmaza ilişkin ka-

[34] **SCHMID**, BSK ZGB, Art. 949a, N. 14; **DEILLON-SCHEGG**, CHK ZGB, Art 949a, N. 9.

yıtlı haklar konusunda bilgilendirilmesi, tapu memurluğunda ya da memurluklarında veya başka bir kamu kurumunda, örneğin noterde, veyahut başka bir elektronik ortamda -web sitesine veya portala ulaşımla- inceleme, sorgulama ve örnek alma olarak karşımıza çıkar.

2313 Elektronik ortamda yapılan işlemler ise tapu sicili hukuki işlemi olarak tapu kütüğünde kayıtlı taşınmaz üzerindeki haklar üzerinde etkili, güvenilir elektronik imza ile de yapılabilen işlemlerdir (sözleşmelerdir). Elektronik ortamda yapılan işlemler (sözleşmeler) konusunda, güvenli elektronik imza ile tapu işlemlerinin yapılabilmesine ilişkin teknik yapı oluşturulması yanında, elektronik tapu işlem (sözleşmeleri) verilerinin ve bu verilerin tapu kaydı verisi olarak işlenmesinin usul ve esaslarının belirlenmesi gerekir. Güvenilir elektronik imza ile tapu sicil müdürlüğüne elektronik ortamda tapu işlemeleri için başvurulabilir (GBV Art. 44). GBV, bu kapsamda elektronik işlemler için yeknesak bir platformda, diğer veri sistemleri ile uyumlu bir sistemin oluşturmuş (GBV Art. 39) ve güvenli elektronik imza ile yapılabilecek tüm işlemler ve sözleşmeler ile ilgili olarak, veri formatında EJPD tarafından yasal örnek işlemler hazırlanarak ve veri formatları EGBA tarafından elektronik ortamda kullanılmak üzere kamuyla paylaşılmıştır (GBV Art. 41)[28].

2314 Aynı şekilde tapu sicil memurları da tüm işlemlerini elektronik yolla yapabilme imkanına sahiptir. Kantonların, hangi tapu işlemlerinin elektronik ortamda, hangisinin yazı ya da hangilerinin karma şekilde yapılacağını belirleme yetkisi bulunmaktadır (GBV Art. 42). Elektronik işlem için Tapu sicilline müracaat (varış) tarihi olarak da güvenilir teslim platformundan alınan, varış anını belirten belgede belirtilen alındı tarihi ve saati esas alınır (GBV Art.45) ve bu işlem tapu sicilline kayıt (tescil) olarak işlenmesi gereken işleme ilişkinse bu tarih itibarı ile de yevmiye defterine işlenir.

2315 Tapu sicil memurluğunca ilgililere elektronik ortamda bildirimde bulunulması halinde ise, ilgili tarafın teslim platformuna verinin gönderildiği veya yüklendiği tarih değil, bildirimin, ilgilinin elektronik posta kutusuna varmasından sonraki yedinci günde bildirimin yapıldığı kabul edilir (GBV Art. 45). İsviçre uygulamasında "SIX-Group" olarak anılan hakim ticari işletmeler, bankalar, sigorta, sosyal güvenlik kurumu, kadastro ve büyük ticari işletmeler bir tarafta, diğer tarafta ncter ve tapu memurluğu,

[28] SCHMID, BSK ZGB, Art. 949a, N. 18.

hatta tapu sicil memurluğu da dahil olacak şekilde, tapu siciline ilişkin verilerin ulaşım ve hizmetleri ve işlemleri, özellikle taşınmaz rehni (ipotek) ve tapu işlemlerini (sözleşmelerini) "Terraxis" isimli platform üzerinden gerçekleştirmektedir[36].

2316 İsviçre hukukunda, tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasıyla ilgili kanun değişikliğinden sonra, "aleniyet"i düzenleyen ZGB Art. 970'inci maddesi iki kere değiştirilmiştir. İsviçre Medeni Kanunu'nda yapılan bu değişiklikler öncesi, tapu sicilinin aleniyet ilkesi, ilgilinin haklı ve korunmaya değer yararı ile sınırlı idi[37]. Aynı maddede, 2003 yılında yapılıp 01.01.2005 yılında yürürlüğe giren değişiklik ile eskisi gibi, tapu sicilinin aleniliği, ilgilinin korunmaya değer yararına bağlı olarak, ilgisini inanılır kılma şartına bağlanmış; ancak ikinci fıkrada, taşınmaz ve taşınmazla ilgili bilgiler, malikin ismi ve kimliği, mülkiyetin iktisap şekli ve edinme tarihi olarak üç bent halinde sayılan taşınmaz bilgilerine herhangi bir sınırlama olmaksızın ve yararı ispat şartı olmaksızın, herkesin tapu verilerine ulaşması imkanı getirilmiştir. Benzer bir düzenleme, GBV Art.26 Abs.1 Ziff. a hükmünde yer almaktadır[38].

2317 İsviçre hukukunda, bu son düzenlemelerle, biraz daha genişletilmiş şekliyle sınırlı aleniyet ilkesine tekrar geri dönülmüştür. Böylelikle ZGB Art. 970 I'de tapu siciline erişim, ilgilinin korunmaya değer yararını inanılır kılınmasına bağlanmıştır. ZGB Art.970 II hükmü ise, tapu siciline ilişkin olarak saydığı bilgilere ulaşımda yararını ortaya koymaksızın ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın herkesin ulaşımına imkan tanımıştır. Bu yarar sadece hukuki değil, maddi bir yarar olmalıdır.

---

36 **SCHMID**, BSK ZGB, Art. 949a, N. 20a.

37 Bu konuda bkz. **MEIER-HAYOZ, Arthur**, Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum: 1. Teilband, Systematischer Teil und Allgemeine Bestimmungen, Art. 641-654 ZGB, 5. Aufl., Bern 1981, N. 100 ff.; **HOMBERGER, Arthur**, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band IV/3, Das Sachenrecht, Art. 919-977 ZGB, Besitz und Grundbuch, 2. Aufl., Zürich 1938, Art. 970, N. 4 ff.; **DESCHENAUX, Henri**, Das Grundbuch, Schweizerisches Privatrecht (Hrsg.: **MEIER-HAYOZ, Arthur**), Bd. V/3, II, Basel 1989, s. 159; **WIEGAND, Wolfgang**, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II (Hrsg.: **HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter/GEISER, Thomas**), Art. 457-977 ZGB und Art. 1-61 SchlT ZGB, 5. Aufl., Basel 2015, BSK ZGB vor Art. 641, N.53 ff.; **SCHMID**, BSK ZGB Art. 970, N. 2, 4 ff.; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 63 ff.; **ARNET, Ruth/BELSER, Eva Maria**, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (Hrsg.: **BREITSCHMID, Peter/RUMO-JUNGO, Alexandra**), Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2012, Art. 641, N. 22; **DEILLON-SCHEGG**, CHK ZGB Art. 970, N. 2 ff.; **REY, Heinz**, Zur Öffentlichkeit des Grundbuchs, ZBGR 2/1984, s. 80 ff.; **OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 100 vd.; **BAŞPINAR**, s. 100 vd.; **KILIÇ, Mehmet**, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Tapu Sicili Hukukunda Getirdiği Yenilikler, Prof. Dr. Fikret Eren'e Armağan, Ankara 2006, s. 627 vd.

38 Tapu bilgilerine ulaşma yetkili olanlar için bkz. GBV Art. 28.

2318 İsviçre Hukuku ZGB Art. 970 ve GBV Art. 26 1a hükmüyle sayılan bilgiler için "sınırsız kamuya açıklık", bu bilgiler haricindeki tapu kayıtlarının öğrenilmesi içinse, ilgisini inanılır kılma şartı getirilerek "sınırlı kamuya açıklık" ilkesi benimsenmiştir.

2319 ZGB Art. 970a ile de Kantonlara, tapu sicilinde yapılan işlemlerle ilgili, taşınmaz parsel numaraları, alanı, niteliği, yeri ve taşınmaz üzerindeki yapı türü; taşınmazı devreden ve devralan kişilerin ad ve yerleşim yerlerini veya adreslerini; taşınmazın kazanıldığı tarihi; müşterek mülkiyet veya kat mülkiyeti söz konusu ise payına ilişkin tapu bilgileri yayınlama yetkisi vermiştir.

c. Tapu Sicil Verilerine Erişim

2320 GBV Art. 26 I hükmünde tapu sicili verilerine serbestçe giriş düzenlenmiştir. Bu hükme göre: herhangi bir kişi, tapu sicil memurundan herhangi bir yararının varlığını inanılır kılmadan, aşağıdaki geçerli olan tapu verileri hakkında, bilgi veya örnek talep edebilir: a. ZGB Art. 979 II hükmünde yer aldığı üzere taşınmaz ve taşınmazla ilgili bilgiler, hak sahibinin (malikin) kimliği, mülkiyeti iktisap şekli ve edinme tarihi, b. İrtifak ve taşınmaz yükü, c. Bazı istisnalarla (örneğin GBV Art. 55 Abs. 1 ve 56 düzenlenen tapu tasarruf sınırları) beyanlar. Bu hükme dayanarak verilecek bilgi veya örnek sadece belirli bir taşınmaz için verilebilir (GBV Art. 26 II).

2321 Kantonlarca belirli kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak tapu kütüğü, yevmiye defteri ve yardımcı sicillere somut olaya ilişkin yararının haklı olduğunu ispat etmeksizin ulaşmasına imkan verebilmesi GBV Art. 28 ve devamı hükümlerde düzenlenmiştir[25]. Belirli meslek gruplarının tapu ve kadastro memurları, yetkili kadastro mühendisleri, vergi memurları ve diğer yasal görev verilmiş mercilerin memurları, görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi verilerine ulaşılmasını sağlamakla sınırlı olmak üzere, tapu kütüğüne ve diğer veri kayıtlarının elektronik erişimine Kantonlar tarafından izin verilebilir (GBV Art.28 I Ziff.a, Art. 30 I). Verilere erişimin kapsamının sınırı, yetki verilen kişinin yerine getirmesi gereken görevin kapsamına göre belirlenir.

2322 Aynı şekilde, tapu verilerine erişim imkanı Banka, PTT, sosyal sigorta kurumu, emekli sandıkları, sigorta şirketleri ve kanunla belirlenen di-

[25] SCHMID, BSK ZGB Art. 949, N. 22, Art. 970, N. 4a

ger kişiler veya bunların örgütlerinin, rehin işlemi için gerekli olan tapu verileri ile sınırlı olmak üzere tapu verilerine erişim hakkı bulunmaktadır (GBV Art.28 I Ziff.b). Yine baro siciline kayıtlı avukatların, üstlendikleri avukatlık hizmeti kapsamındaki görev ve yetkileri sınırları içinde tapu sicili verilerine erişim hakkı bulunmaktadır (GBV Art.28 I Ziff. b). Yapılan erişimler sistem tarafından otomatik olarak kaydedilir ve bir protokole bağlanır. İlgili protokoller iki sene süresince saklanır (GBV Art. 30 II).

§ 15. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA TAPU SİCİLİ

I. TAPU SİCİLİ KAVRAMI

2323 Tapu sicili, taşınmaz eşyaların gerek geometrik gerekse hukukî durumlarını ortaya koymak için devletin yetkili organlarınca ve yine devletin denetim, kontrol ve sorumluluğu altında tutulan siciller, defterler ve belgelerin tümüne birden verilen isimdir. Tapu siciline ilişkin olarak TMK m. 997'de, "*Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur (f.1) Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile planlardan oluşur (f.2). Sicilin örneği, nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirlenir (f.3).*" düzenlemesine yer verilmiştir. Tapu Sicil Tüzüğü m. 5'te, "*Tapu sicili, Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.*" şeklinde tanıma yer vermiştir.

2324 Zilyetliğe ilişkin açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi, zilyetlik; taşınır eşyalarda ayni haklarda aleniyeti sağlamakla birlikte aynı görevi taşınmazlar bakımından aynı şekli ile gerçekleştiremez. Bir taşınır eşyaya zilyet olan kimse TMK gereği onun malikı sayılır. Fakat aynı sonuca taşınmaz eşyalar bakımından varılamayacaktır. Çünkü bir taşınmaza zilyet olan kimsenin aynı zamanda o taşınmazın malikı olduğu sonucuna varmak mümkün gözükmemektedir[1]. Taşınmaz eşyalar üzerindeki zilyetliğin aynî haklar bakımından aleniyet sağlamada yetersiz kalması ve taşınmazların büyük ekonomik değere sahip olmasının bir sonucu olarak sadece taşınmazlara özgü bir sistemin hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır[2].

2325 *Tapu sicili sisteminin,* taşınmazların gerek geometrik gerekse hukukî durumlarını bütün ayrıntılarıyla ortaya koyarak bunları aleni hale getiren

---

[1] Ayrıntılı bilgi için bkz. **GÜRSOY / EREN / CANSEL**, s. 169; **TEKİNAY / AKMAN / BURCUOĞLU / ALTOP**, s. 241-242. Belirtelim ki, taşınmaz eşyalar üzerinde ayni hak tesis edebilmek için zilyetliğin devri şart değildir. Buna bağlı olarak, bir taşınmaza zilyet olan kişi o taşınmazın maliki olabileceği gibi, kiracısı veya intifa hakkı sahibi de olabilir. Hatta söz konusu taşınmazı haksız bir şekilde işgal eden kişinin konumunda da olabilir.

[2] Söz konusu amacı gerçekleştirmek için 'kayıt ve tespit sistemi', 'tasdik sistemi' ve 'torrens sistemi' gibi çeşitli sistemler geliştirilmiştir. 'Tapu sicili sistemi' de taşınmaz eşyalar üzerindeki yer alan ayni hakları, bu hakların kapsamını ve hak sahiplerini aleni hale getiren bir sistem olarak ortaya konulmuş bir sistemdir. Bkz. **OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 117.

bir vasıta olarak karşımıza çıktığını yukarıda belirtmiştik. Aşağıda da açıklayacağımız üzere tapu sicili sistemi içerisinde taşınmazların gerek geometrik gerekse hukukî durumlarını bütün ayrıntılarıyla ortaya koyma görevini yerine getiren tek bir defter veya belge bulunmaz. Başta tapu kütüğü adı verilen ana kütük olmak üzere yevmiye defteri, plân ve diğer resmî belgelerin tümü bu görevi görürler. Buna bağlı olarak doktrinde, tapu sicili ifadesinden *ana kütük (tapu kütüğü) ve yardımcı unsurlardan oluşan bir bütünün* anlaşılması gerektiği dile getirilmiştir[3].

2326 Tapu sicili sisteminde, taşınmazların kaydı yapılırken diğer bir ifadeyle mevcut bir taşınmaz tapu siciline işlenirken nasıl ki, doğan her insana nüfus cüzdanı çıkarılır ise aynı şekilde her taşınmaz için de tapu sicilinde bağımsız bir sayfa açılır. Taşınmaz için açılan bu sayfada o taşınmazın tüm özellikleri, yüzölçümü, sınırları, maliki, taşınmaz üzerinde mevcut sınırlı aynî haklar yazılır. Taşınmazlar üzerinde aynî hak kazanılması, devri ve ortadan kaldırılması, kural olarak tapu siciline yapılacak bir tescil işlemi ile gerçekleştirilir.

II. TAPU SİCİLİNİN BAŞLICA FONKSİYONLARI

2327 Tapu sicilinin birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Söz konusu fonksiyonlar sadece ayni haklar ile de sınırlı bulunmamaktadır. İlerleyen bölümlerde tapu sicilinin her türlü fonksiyonunu ilgili başlıklar altında inceleyeceğiz. Biz burada tapu sicilinin birkaç önemli fonksiyonu üzerinde duracağız.

A. Yapısı İtibariyle Taşınmaz Olan Şeylere Hukuki Olarak Taşınmaz Niteliği Kazandırması

2328 Bir nesnenin eşya hukuku bakımından taşınmaz muamelesi görmesi ve taşınmaz eşyaların hukuki rejimine tabi olabilmesi için tapu siciline kaydedilmesi gerekmektedir. Taşınmaz mülkiyeti anlatılırken de üzerinde durulacağı üzere tapu siciline kaydedilmemiş ancak özü itibariyle taşınmaz olan şeyler TMK kapsamında taşınmazların hukuki rejimine tabi olmayacakları gibi eşya olarak da taşınmaz eşya olarak kabul edilmeyeceklerdir. Bu nedenle özü itibariyle taşınmaz olan şeylerin hukuki olarak da

[3] Ayrıntılı bilgi için bkz. NOMER/ERGÜNE, s. 97 vd.; TEKİNAY / AKMAN / BURCUOĞLU / ALTOP, s. 318; OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR, s. 121; GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 177.

taşınmaz olarak kabul edilebilmesi tapu siciline kaydedilmeleri ile mümkündür.

B. Taşınmazlar Üzerindeki Hakları Kamuya Açık Hale Getirmesi

2329 Ayni haklar ve ayni haklara hakim olan ilkeler ile zilyetlik anlatılırken de üzerinde durulduğu gibi ayni haklar alenidir yani kamuya açıktır. Bu sayede bir eşya üzerinde ayni hak varsa bunun herkes tarafından bilinmiyor en azından kolaylıkla bilinebilir olması gerekir. Aksi durumda ayni hakka herkesin riayet etmesi ve ayni hakkın ihlali durumunda herkese karşı ileri sürülebilmesi mümkün olmazdı.

2330 Hiç kimse tarafından bilinmeyen veya kolaylıkla bilinme imkanı olmayan haklara herkesin riayet etmesi düşünülemez. Bu bakımdan taşınır eşyalar üzerinde mevcut olan zilyetlik o eşya üzerinde bir ayni hakkın varlığının göstergesi olarak kabul edilir. Zira taşınır eşya üzerinde zilyetlik en önemli ayrı hak olan mülkiyet hakkına karine teşkil etmektedir. Diğer taraftan taşınmaz eşyalar üzerinde zilyetlik kişinin o eşya üzerinde bir ayni hak sahibi olduğu konusunda kanuni açıdan bir karine oluşturmamaktadır. Buna bağlı olarak bir taşınmaz üzerinde bir ayni hak söz konusu ise bu hakkı aleni hale getiren diğer bir ifadeyle kamuya açık hale getiren ve taşınırlardaki zilyetliğin fonksiyonunu gören şey tapu sicilidir (TMK m. 997 f.1).

C. Ayni Hakların Kazanılması, Devredilmesi veya Ortadan Kaldırılmasını Sağlama

2331 Belirtelim ki, kural olarak bir ayni hakkın kazanılması, devredilmesi veya sona erdirilmesinde tapu sicili belirleyici rol oynamaktadır. Örneğin; taşınmaz bir eşya üzerinde ayni bir hakkın kazanılması kural olarak tescil ile mümkündür. O halde tapuya kaydedilmiş bir taşınmaz üzerinde bir ayni hak tesis edilmek, ayni hakkı devretmek ve ayni hakkı sonlandırmak isteniyorsa tapu sicilinde ilgili işlemin gerçekleştirilmesi gerekir.

III. TAPU SİCİLİNİ MEYDANA GETİREN UNSURLAR

A. Genel Olarak

2332 Tapu sicilinin fonksiyonlarını icra edebilmesi için TMK ile diğer mevzuata uygun bir şekilde devletin denetim ve kontrolünde bir tapu sicili si-

teminin kurulması gerekir[4]. Burada üzerinde önemle durmak gereken en önemli husus tapu sicili sisteminin tüm unsurları ile beraber kurulabilmesi için de tüm taşınmazların tapulama işleminin yani kadastrosunun yapılmış olması gerekir[5]. Yine önemle belirtmek gerekir ki, Türkiye'de tüm taşınmazların tapulama işlemleri henüz tamamlanmış değildir. Bazı taşınmazlar halihazırda ya tapusuz ya da eski tapu kayıtları ile işlem görmektedir.

2333 Tüm bu açıklamalar ışığında doktrinde tapu sicili sitemi ve unsurları incelenirken tapulaması yapılmış olan taşınmazlar için mevcut tapu sicili unsurları ile henüz tapulaması yapılmamış yerler açısından ikili bir ayrım yapılması gerektiği belirtilmiştir[6]. Biz tapulaması yapılmış taşınmazlar bakımından tapu sicilinin unsurlarını inceleyip, tapulaması yapılmamış yerler bakımından ise yeri geldikçe kısaca değineceğiz[7].

---

[4] Ayrıntılı bilgi için bkz. **AYİTER**, s. 38 vd.; **OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 117 vd.; Belirtelim ki, tapu sicilinin elektronik ortamda tutulması da mümkündür. Tapu Sicil Tüzüğü'nün "*Tapu Sicilinin Elektronik Ortamda Tutulması*" başlığını taşıyan üçüncü bölümünde söz konusu husus 4 madde halinde düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler nazara alındığında ortaya çıkan başlıca hususlar şunlardır: TST m.12'de, "*(1) Tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulması hâlinde, ana ve yardımcı siciller TAKBİS içerisinde saklanır ve yönetilir. TAKBİS'te saklanan ve güvenliği sağlanan taşınmaza ilişkin bilgiler, sicilde esas alınır. (2) TAKBİS üzerindeki kayıtlar, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihten sonraki bilgileri gösterir.*" düzelmesine yer verilmiştir. Bu sistemde elektronik ortamda işlem yapılması ise TST m.13'te, "*(1) Genel Müdürlük tarafından belirlenecek resmî şekle tabî olmayan belge ve kayıt örneği verilmesi gibi işlemler, elektronik ortamda başvuru yapılarak ve elektronik imza dâhil diğer kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak tamamlanabilir.*" şeklinde düzenlenmiştir. Elektronik ortamda verilere erişim hakkı ise TST m.14'te, "*(1) Mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek sağlanabilir. Erişim hakkına sahip kuruluşlar, taşınmaz ile ilgili verileri TAKBİS üzerinden alırlar. (2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilirler. (3) TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede, erişimin türü ve şekli, erişim kontrolü, verilerin kullanım amacı, üçüncü kişilere kullandırılmasına ilişkin sınırlamalar ve amacı dışında kullanımın sonuçları yer alır. (4) Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, düzenlenecek sözleşme şartları dahilinde verilere erişebilirler. (5) Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilir. (6) Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması hâlinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, TAKBİS'e erişim derhâl durdurulur. (7) TAKBİS verilerine erişime ilişkin döner sermaye katılma payını ve bunun istisnalarını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.*" Şeklinde düzenleme altına alınmıştır. Son olarak ise, erişim ve bilgi güvenliği TST m.15'te, "*(1) TAKBİS üzerinden yapılacak her türlü sorgulama ve sorgulayan bilgisi kayıt altına alınır. Bu kayıtlar iki yıl süreyle saklanır. (2) TAKBİS üzerindeki verilere erişimi durdurmaya veya kısıtlama yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. (3) TAKBİS üzerinde, tapu görevlileri hariç olmak üzere, verilerin ardı ardına sorgulanmasına ilişkin her türlü güvenlik önlemi alınır.*" şeklinde düzenlenmiştir. Elektronik ortamda tapu sicilinin tutulması ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 250 vd.; **ŞENGÜL**, s. 53 vd.

[5] **OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 119-120.

[6] **REİSOĞLU**, s. 123.

[7] Henüz kadastronun yapılmadığı yerlerde tutulan siciller ise şunlardan oluşmaktadır: 1. Zabıt (kayıt) defteri. Bunlar kadastronun yapılmadığı yerlerde tutulan temel defterlerdir. Örneğin he-

2334 *Tapu sicilinin unsurlarını gerek TMK gerekse Tapu Sicil Tüzüğü ortaya koymuştur. TMK m. 997'de, "Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulur (f.1). Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur (f.2). Sicilin örneği, nasıl tutulacağı ve yardımcı siciller tüzükle belirlenir (f.3)." düzenlemesine yer verilmiştir.*

2335 *TMK m.1000 vd. hükümlerinde de tapu sicilinin unsurları aynı şekilde belirtilmiştir.* Tapu Sicili Tüzüğü m. 7'de ise tapu sicilinin unsurları ikili bir ayırım yapılarak düzenlenmiştir. Tüzüğün 7. maddesine göre, tapu sicilinin unsurları ana siciller ve yardımcı siciller olarak tasnif edilmiştir. Ana siciller, tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri, resmî belgeler (resmi senet, mahkeme kararı ve diğerleri) ve plânlar olarak ifade edilmiş, yardımcı siciller ise, azîller sicili, düzeltmeler sicili, kamu orta malları sicili, tapu envanter defteri şeklinde belirtilmiştir.

2336 Belirtelim ki, bizde bundan sonraki anlatımlarımızda TST'nin yapmış olduğu ana siciller ve yardımcı siciller ayırımını esas alacağız. Şimdi öncelikle ana sicîller üzerinde duralım:

2337 Ana siciller, ilerleyen bölümlerde ayrıntısı ile üzerinde duracağımız gibi, tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde ayni hakkın doğumunu, el değiştirmesini ve sona ermesini sağlayan tescil, terkin, şerh, beyan, düzeltme gibi tapu sicili işlemlerin gerçekleştirildiği sicillerdir[4].

---

nüz kadastro görmemiş yerlerde malik sıfatıyla taşınmaza zilyet olan kimsenin TMK m. 713 uyarınca açacağı dava neticesinde (davasız, aralıksız, malik sıfatıyla yirmi yıl zilyet olma koşulu ile) taşınmazın kaydedileceği yer, zabıt defteridir. Tapu sicili ile zabıt defteri arasındaki farklar şu şekilde ifade edilebilir. - Tapu sicilinde her bir taşınmaza tapuda ayrı bir sayfa açılmasına rağmen (aynî sistem), zabıt defterlerinde taşınmazlara ayrı bir sayfa açılmamakta; taşınmazlara ait işlemler tarihlerine göre aynı sayfalarda yer almaktadır. Ancak sayfalar arasında 'geldiği defter' ve 'gittiği defter' şeklinde işaretleme yapılarak ayrıca bağlantı sağlanmaktadır. - Tapu sicilinden farklı olarak zabıt defterleri köy veya mahalle esasına göre değil, bölgeler (ilçeler) esas alınarak tutulmaktadır. - Zabıt defterlerinin tapu sicilinden ayrılan bir diğer yönü de ipoteklerin, zabıt defterinden ayrı olarak ipotek kayıt defterine tescil edilmesidir. 2. Kat mülkiyeti zabıt (kayıt) defteri: Henüz kadastronun yapılmadığı yerlerde kat mülkiyeti sicili yerine kat mülkiyeti zabıt defterleri tutulmaktadır. 3. İpotek zabıt (kayıt) defteri: Zabıt defterinin tutulduğu yerlerde taşınmazlara ilişkin mülkiyet, sınırlı ayni hak, şerh ve beyanlar sütunu bulunmasına ve bu kapsamdaki kayıtlar zabıt defterine yazılabilmesine rağmen ipotekler sütunu zabıt cefterlerinde yer almamaktadır. İpotekler, zabıt defterinden ayrı olarak tutulan ipotek zabıt defterine tescil edilmekte, fakat aynı zamanda bu tescil zabıt defterinde de gösterilerek bağlantı sağlanmaktadır. 4. Fihrist defteri: Zabıt defterinin tutulduğu yerlerde, tapu sicilindeki 'mal sahipleri sicili' yerine köy ve mahalle esasına göre tutulan defterlerdir. 5. Diğer defterler: Zabıt defterinin tutulduğu yerlerde de tapu sicilinin bulunduğu yerlerde olduğu gibi yevmiye defteri ve aziller sicili tutulmaktadır.

[4] NOMER/ERGÜNE, s. 99 vd.

B. Tapu Kütüğü (Ana Kütük)

2338 Tapu Kütüğü (ana kütük), tapu siciline kaydı gereken bütün taşınmazlarla bu taşınmazlar üzerindeki ayni hakların yazıldığı sicildir. Tapu kütüğü tapu sicilinin en önemli kısmını, deyim yerindeyse temelini bel kemiğini oluşturur[3]. Bu nedenle, tapu kütüğüne *"esas sicil"* adı da verilmektedir[4]. Tapu kütüğünün tutulmasında belediye sınırları içinde mahalle, belediye sınırları dışında köyler baz alınır. Her taşınmaza, diğer taşınmazlarınkinden ayrı ve tamamen bağımsız bir sayfa özgülenir. Buna, tapu kütüğünün tutulmasında taşınmazın malikinden değil de taşınmazın bizzat kendisinden hareket edildiği için *"ayni yöntem (sistem)"* denir[5].

2339 Tapu kütüğü, MK'nin 997 ve Tapu Sicil Tüzüğü'nün 6. maddesi gereğince ana sicillerden olup taşınmaz malların, taşınmaz mal niteliğindeki müstakil ve daimî hakların ada, parsel, miktarı, vasfı gibi nitelikleri ile sahiplerinin mülkiyet hanesine yazıldığı, bu mülkiyet hakları üzerinde tesis edilen veya yetkili mercilerce resen istenilen diğer hak ve takyitlerinde durumuna göre şerhler, irtifak hakları, beyanlar, rehinler, düşünceler ve nevi hanelerine yazılan, ilçe bazında ve kent belediye sınırlar içinde mahalle birimine, köylerde köy birimine göre düzenlenen ve takriben 34x47 cm boyutlarında, sayfa numarası birden başlayarak sıra ile devam eden ve her sayfaya bir parselin (taşınmaz mal veya müstakil ve daimî hakkın) kaydedildiği genellikle 99 sayfadan ibaret ciltler hâlinde olan defterlerdir.

C. Kat Mülkiyeti Kütüğü

2340 Kat mülkiyeti kütüğü, kat mülkiyeti kurulmuş bir binanın bağımsız bölümleri için tutulan kütüktür. Belirtelim ki, kat mülkiyeti kütüğünde her bir bağımsız bölüm için ayrı sayfa açılır ve tapu kütüğü ile irtibat kurularak ana taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfası işlemelere kapatılır. Özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, bu kütükte yapılacak işlemler hakkında tapu kütüğüne ilişkin hükümler uygulanır.

2341 Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli olanları (bağımsız bölümleri) üzerinde, o gayrimenkulün maliki

---

[3] AYBAY /HATEMİ, s. 72 vd.; OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR, s. 122.

[4] GÜRSOY / EREN / CANSEL, s. 178.

[5] AYİTER, s. 37, 43; OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR, s. 122.

veya ortak malikleri tarafından (Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerince) kurulan mülkiyet haklarının yazılı olduğu kütüklerdir.

2342 Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir. Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup yapı tamamlandıktan sonra, arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı yazılı bir istem üzerine, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki şartlar uyarınca kat mülkiyetine çevrilir[2].

2343 Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz. Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya mahkeme hükmü ile yapılır. Kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğü'ne göre tutulacak kat mülkiyeti kütüğüne tescil olunur. Kanunda aksine hüküm olmadıkça tescille ilgili genel hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır. Kat irtifaklarının tescili kat mülkiyeti kütüğüne yapılmaz, kanunda yazılı ilgili hükümler gözetilmek şartıyla, irtifak haklarının tesciline ait genel hükümlere göre yapılır. Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğü'ndeki formüle göre, ayrıca tutulacak kat mülkiyeti zabıt defteri ne tescil olunur. Tümü kâgir olmayan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz.

---

[2] Kat Mülkiyeti ile ilgili başlıca kavramlar şunlardır: Ana gayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünüdür. Ana yapı: Esas yapı kısmına denir. Bağımsız bölüm: Ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri. Eklenti: Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerler. Kat maliki: Bağımsız bölümlere sahip olanlara denir. Ortak yerler: Ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerdir. Kullanma hakkı: Kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarıdır. Ayni haklar: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır (örnek mülkiyet hakkı). İrtifak hakkı: Sahibine hakkın konusu taşınmaz mal üzerinde kullanma ve yararlanma yetkisi veren sınırlı ayni hakların genel adıdır. Bir arazi lehine kurulursa arazi irtifak hakkı, bir şahıs yararına kurulursa şahsi irtifak hakkı denir. Başkalarına devri mümkün olarak ve yirmi yıldan fazla süreli kurulursa daimi ve bağımsız irtifak hakkı şeklinde tescil edilebilir. Medeni Kanun'da irtifak hakları: intifa hakkı, oturma hakkı, geçit hakkı, kaynak hakkı, üst hakkı ve diğer irtifak hakları olarak gösterilmiştir. Kat irtifakı: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından 634 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır. Arsa payı: Arsanın, bu kanunda (Kat Mülkiyeti Kanunu) yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarıdır. Sözleşme: Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmî senettir.

D. Yevmiye Defteri

2344 Yevmiye defteri, TMK m. 1002'de, "*Tapu kütüğüne tescil istemleri, isteyenin kimliği ve istemin konusu belirtilerek istem sırasına göre derhal yevmiye defterine yazılır (f.1). Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler, özenle sıraya konulur ve saklanır.*" şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, yevmiye defteri, tapu memurluğuna yapılacak başvuruların talep sırasına göre ilk olarak yazıldığı defterdir denilebilir.

2345 Tapu memuru, tapuya kayıtlı bir taşınmaz üzerinde yeni bir aynî hak kurulması veya mevcut bir aynî hakkın kapsamının değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması amacına yönelik talepleri hemen o anda tapu kütüğüne işlemez. Yapılan talepler önce yevmiye defterine yazılır. TST m. 23'te yevmiye defterine kayıtların nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiştir[3]. Yevmiye defterine tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını gerektiren veya reddedilen istemler kaydedilir. Tapu kütüğüne tescil istemleri, isteyenin kimliği ve istemin konusu belirtilerek istem sırasına göre derhal yevmiye defterine yazılır. Bir ayni hak, tapu kütüğüne tescil ile doğmakla birlikte, hakkın doğuş anı, yevmiye defterine kayıt anıdır. Tapu sicilinde akit, tescil, düzeltme, değişiklik ve terkini gerektiren tüm talepler yevmiye defterine kaydedilir. Müdürlüğe gelen istemler, akitli işlemlerde, usulüne uygun resmî senet düzenlenerek taraflarca imzalanmasından, resmî kurumların akitsiz işlemlerine akit yazılarının alınmasından sonra yevmiye defterine kaydedilir.

2346 Yevmiye defterine her sene başında, birden başlayan sıra numarası verilir. Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş günü sonunda kapatılarak imzalanır. Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz. Yevmiye defterine kayıtlar siyah veya ma-

---

[3] TST m. 23'te, "*(1) Yevmiye defterine, tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını gerektiren veya reddedilen istemler kaydedilir. Tapu sicili üzerinde kayıtlı hakların birbirlerine üstünlüğü, bu deftere yazım tarih ve sıra numarasına göre belirlenir. (2) Müdürlüğe gelen istemler; a) Sözleşme düzenlenmesi gereken işlemlerde usulüne uygun resmî senet düzenlenerek taraflarca imzalanmasından, b) Sözleşme düzenlenmesi gerekmeyen işlemlerde istem belgesinin imzalanmasından, c) Resmî kurumlara ait yazıların alınmasından sonra yevmiye defterine kaydedilir. (3) Yevmiye defterine; işlemin yevmiye numarası, saat ve dakikası, istemde bulunanın adı ve soyadı, istemin niteliği, isteme konu taşınmazın köy veya mahalle adı, cilt ve sayfa numaraları ile işlemi hazırlayan, kontrol eden ve onaylayanın adı ve soyadı yazılır. (4) Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş günü sonunda kapatılarak imzalanır. Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz. (5) Yevmiye defterine her sene başında, birden başlayan sıra numarası verilir. (6) Müdür, müdürlük dışına çıkarken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden ayrılırken yetki verdiği memuru yevmiye defterine yazar ve imza eder. Müdür göreve dönünce, göreve başladığını yine yevmiye defterine yazar ve imza eder.*' düzenlemesine yer verilmiştir.

ve mürekkepli kalemle yazılır (TST m.22). Yevmiye defterine: istemin niteliği, ilgili kütüğün sahife numarası, tarihi, saat ve dakikası, istemde bulunanın adı, soyadı ve adresi yazılır.

2347 Üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biri de yevmiye defterine kaydın aynı haklar bakımından gösterdiği etkidir. TMK m. 1022'de, "*Ayni haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır (f.1). Tescilin etkisi, kanunen öngörülen belgeler isteme eklenmiş veya geçici tescil halinde belgelerin uygun zamanda tamamlanmış olması koşuluyla yevmiye defterine yapılan kayıt tarihinden başlar (f.2). Bir hakkın içeriği, tescilin sınırları içinde, dayandığı belgelere göre veya diğer herhangi bir yolla belirlenir (f.3).*" düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre, *aynî haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır*. Fakat belirtelim ki, kural olarak hak ancak tescil işleminin yapılmasıyla birlikte doğarsa da aynî hak yevmiye defterine yazım işleminin yapıldığı anda doğmuş sayılır. Dolayısıyla, aynî haklar sıralarını da yevmiye defterine yapılmış olan bu yazılış tarihine göre alırlar[4].

E. Tapu Planı

2348 Tapu planı, taşınmazın geometrik ve hukuki durumunun belirlenmesi için önceden belirlenmiş esaslara göre yetkili kamu görevlileri tarafından çizilen haritalardır. Bir tapu sicilinin oluşturulabilmesi için taşınmazların tapu plânlarının hazırlanması zorunludur. Tapu planı, kural olarak sadece taşınmazın kadastrosunun yapılması hâlinde hazırlanabilir. Henüz kadastrosu yapılmamış taşınmazlarda tapu sicilinin esaslı unsuru sayılabilecek nitelikte plânlar yer almaz.

2349 Bir taşınmaz tapu kütüğüne kaydedilmeden önce onun bir planı yapılır (TST m.4). Plan, tapuya kaydedilecek taşınmazın yer yüzeyi üzerindeki geometrik konumunu yani taşınmazın bulunduğu yöreyi, taşınmazın sınırlarını, çevresindeki taşınmazları, yüz ölçümünü ve varsa üzerindeki yapıları gösteren resmî bir makamca yapılmış bir belgedir. Kadastronun temel amacı da bütün taşınmazları bir plana bağlamaktır.

---

[4] Yarg. 12. HD. T. 22.12.2014. E. 2014/31441. K. 2014/31064: "*...Tescilin etkisi yasa hükmü uyarınca satışın yevmiye defterine kayıt tarihinde başlayacağından taşınmazın hissesinin mülkiyeti şikayetçi üçüncü kişiye satışın yevmiye defterine işlendiği tarihte geçmiştir...*" Benzer nitelikte başka bir karar için bkz; Yarg. 12. HD. T. 17.3.2014. E. 2014/4551. K. 2014/7561

F. Resmi Belgeler

2350 Resmi belgeler, tapu planları dışında kalan resmi senet, istem talep belgesi, mahkeme kararı ve diğer belgelerdir. Tapu kütüğünde yapılan işlemlerin dayanağı olan belgelerin özenle sıraya konulması ve saklanması gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Belirtelim ki, resmi belgeler, taşınmaz üzerindeki ayni hakların geçerli bir şekilde kurulmuş olup olmadığına ilişkin anlaşmazlıklar ile aynî hakkın kapsamına ilişkin anlaşmazlıkların çözümlenmesinde büyük öneme sahiptirler. Zira, ayni haklarla ilgili kapsamlı bilgilere bu belgeler sayesinde ulaşılabilir. Belgeler bakımından da her taşınmaz için özel bir dosya açılır. Bu belgeler, yevmiye defterine kayıt ve tapu kütüğüne tescil edilen hakların dayanıkları belgelerdir. Satış, bağış, trampa sözleşmeleri (akitleri), irtifak hakkı kurulmasına ilişkin sözleşmeler, ipotek sözleşmeleri, yargı kararları, veraset (mirasçılık) belgeleri, mirası bölüşme sözleşmeleri, vekâletnameler, ilgililerin tescil istekleri, vergi değer belgeleri ve ödemeye ilişkin belgeler, kamulaştırma kararları vb.dir. Tamamlayıcı nitelikteki bu belgeler, aldıkları sıra numarasına göre, özel dosyalarda saklanır (TST m.29). Tapu kütüğü ile bu dosyaların bağıntısını kurabilmek için, dosyalara kütük sayfa numarası yazılır.

2351 Kanıtlayıcı belgeler hem tescilin dayandığı edinme nedenini hem de tescil edilen haklara ilişkin ayrıntıları gösterdiği için önemli belgelerdir ve süresiz korunur. Kütük sayfalarındaki sütunlar, kayıtları çok kısa biçimde yazmaya elverişlidir. O sütunlarda kaydedilmiş bir hak için açıklama ya da ayrıntı gerektiğinde, kanıtlayıcı belgelere başvurulması zorunludur. Örneğin bir ipoteğin ne gibi koşullarda kurulmuş olduğunu öğrenmek için kütük sayfasında inceleme yapmak yeterli olmaz, bunları öğrenmek için kanıtlayıcı belgelere bakmak gerekir. Biz burada sadece resmi senet üzerinde duracağız.

2352 Resmi belgelerin başında resmi senet gelir. Satış, mal değişimi sözleşmesi veya bağışlama gibi sözleşmelerde resmi senet düzenlenir. Resmi senetlerin nasıl düzenleneceği "*Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik*" ile belirlenmiştir.

2353 Bu yönetmelik esas alındığında bazı noktalar şu şekilde tespit edilebilir: Resmi senette yer alan irade beyanlarından tarafların karşılıklı ve birbirine uygun olmasını sağlamak için taraflara açıklayıcı bilgiler verilir.

Sözleşmenin türüne göre bütün esaslı noktalar resmi senette ortaya konulur. Tapuda taşınmazı sınırlayan hak ve yükümlülükler varsa, bunlar hakkında taraflara bilgi verilir ve mevcut sınırlama ve yükümlülüklerin varlığı kabul edilerek işlem yapılmasının istenip istenmediği sorulur. Mevcut sınırlama ve yükümlülüklerin varlığı kabul edilerek işlemin sonuçlandırılması talep ediliyorsa, taşınmazı sınırlayan hak ve yükümlülükler resmî senede doğru ve tam olarak yazılarak, bunların kabul edildiğine dair beyan alınır.

2354 Tapu sicilinin en önemli unsuru kabul edilen ana sicilleri kısaca bu şekilde değerlendirdiğimize göre, şimdi yine tapu sicilinin bir diğer unsuru olan yardımcı sicilleri açıklamaya başlayabiliriz.

G. Yardımcı Siciller

2355 *Yukarıda da belirttiğimiz gibi yardımcı siciller;* aziller sicili, düzeltmeler sicili, kamu orta malları sicili, tapu envanter defteridir. Belirtelim ki, bu sicil ve defterler taşınmaz üzerinde aynî hakkın kurulması, kapsamının değiştirilmesi ve sona erdirilmesi bakımından doğrudan doğruya etkili olmayan, fakat tapu kütüğünün sağlıklı bir şekilde tutulmasını kolaylaştıran sicillerdir.

2356 Tapu sicilleri, tapu birimleri dışına çıkarılamaz. Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde onaylı örnekleri verilir. Ancak, mahkemeler veya yetkili resmî merciler tarafından sicil veya belgelerin aslı istenildiği takdirde, örnekleri müdür tarafından tasdik edilip, iade edilmek üzere imza karşılığında asılları verilir. Onaylı örnek belgeler, asılları iade edilene kadar özenle saklanır (TST. m. 84).

1. Aziller Sicili

2357 Bir kimse vekilini azletmişse bunu tapu sicili müdürlüğüne bildirmesi gerekir. Eğer vekalet veren vekilini azlettiğini bildirmez ise vekil taşınmaz ile ilgili tapuda işlem yapmaya devam edebilecektir. Bu da taşınmaz üzerinde hak sahibi olanların istemediği ve talep de etmediği işlemlerin muhatabı haline getirebilecektir. Bir olayda vekilin azledilmiş olup olmadığı hususu aziller siciline bakılarak belirlenir. Böylece, yetkisiz kişilerin taşınmaz üzerindeki aynî hakkı etkilemeleri önlenmiş olur. Azil belgesi geldiği zaman, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi tarafından üzerine alındığı tarih, saat ve dakika hemen yazılarak aziller sicili-

ne kaydedilir. Bu durum TST m. 77'de, *"(1) Vekâletten azliler, vekâlet verenlerin adının baş harfleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre, her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır. (2) Azil belgesi geldiğinde, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi tarafından üzerine alındığı tarih, saat ve dakika hemen yazılarak, azliler siciline kaydedilir."* şeklinde düzenleme alanı bulmuştur.

2. Düzeltmeler (Tashih) Sicili

2358 Düzeltmeler sicili, tapu sicilinde veya kat mülkiyeti sicilinde yapılan yanlış yazımların düzeltilmesi durumu ortaya çıktığında birtakım esaslara göre bu düzeltmelerin yapıldığı, düzeltilen her yanlışlığın da sebebi gösterilerek kaydedildiği sicildir. Düzeltmeler sicili ile tapu kütüğünde yapılmış düzeltmelere ilişkin olarak daha sonra ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi kolaylaştırılmış olur.

3. Kamu Orta Malları Sicili

2359 Kamu orta malları sicili ise, mera, yaylak, kışlak gibi kamu orta mallarının bu sicile yazılarak hangi köy veya belediyeye tahsisli olduğu gösterilir[5]. Kamu malları kavramı ile, kamu hizmetine veya kamunun ortak kullanımına tahsis edilmiş mallar kastedilmektedir. Ayrıca devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kamu malları ile devletin mülkiyetinde bulunan özel mallar ayrımı yapılmaktadır.

2360 Bu ayrıma göre kamuya ait bazı mallar üzerinde, devlet Medenî Hukuk anlamında mülkiyet hakkına sahiptir. Onun için bu tür mallara devletin özel malları denilmektedir. Kamunun özel malları, özel hukuk hükümlerine tabidirler. Bu mallar, diğer özel kişilere ait mallar gibi gayrimenkul iseler, hazine veya ilgili kamu tüzel kişiliği adına tapuya; keza motorlu taşıt araçları gibi bir yere kaydı gereken menkul iseler, ilgili kamu tüzel kişileri adına sicillerine kaydolunurlar.

2361 Özel mallar üzerinde malikin sahip olduğu hak ve yetkiler burada da aynen geçerli olup, bu hak ve yetkiler ya devlete ya da ilgili kamu tüzel kişiliklerine aittir. Ancak devlet ve kamu tüzel kişilerinin bu mallar üze-

[5] Kamu malı olma statüsüne bağlanmış bazı hukukî sonuçlar vardır. Bunların başlıcalarını şöyle-ce sıralamak mümkündür: Kamu malları, özel mülkiyete geçirilemez, zamanaşımıyla iktisap edilemez, tescile tabi değildirler, haczedilemezler, rehin konusu olamazlar, kamulaştırma konusu olmazlar, yararlanma yönünden tahsis, izin, ruhsat, imtiyaz gibi özel usullere tabidirler, ancak kamu yararı bulunan irtifaklarla takyit olunurlar, harç, resim ve vergiden muaftırlar.

rinde sahip oldukları idare, kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkileri kamu hukukuna ilişkin bazı sınırlamalara tabidir. Bundan çıkan sonuca göre, söz konusu mallarla ilgili olarak idarenin üçüncü kişilerle kurduğu ilişkiler özel hukuk hükümlerine tabi olduğu halde; bu mallarla ilgili işlemlerin ifasında ve iradesinin oluşmasında kamu hukuku kurallarına tabidir.

2362 Kamunun özel malları, kamu hizmetine tahsis edilmemiş olduğundan kişiler bu mallardan doğrudan doğruya ve diledikleri gibi yararlanamazlar; keza, bu konuda onların ileri sürebilecekleri herhangi bir hakları da mevcut değildir. Ancak kişiler bu mallardan dolaylı bir şekilde yararlanabilirler. Bu yararlanma kamunun özel mallarından elde edilen gelirlerin devlet bütçesi içinde yer alması ve bu gelirlerin kamu harcamalarında kullanılması yoluyla olur. Bunun dışında kamunun özel mülkiyetindeki mallardan kişiler, ancak özel hukuk hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma, irtifak tesis etme ve bunlara benzer diğer yollarla bedelini ödeyerek yararlanabilir.

2363 Tüm bu açıklamalar göstermektedir ki, devletin mülkiyet hakkı bulunan mallara kamuda "özel mallar" denilmektedir. Bunlar kural olarak özel hukuk hükümlerine tabidirler. Buna karşılık, kamuya ait bazı mallar üzerinde de devletin hüküm ve tasarrufu söz konusudur. Bu son duruma giren kamu malları da kendi içinde orta malı, hizmet malı ve sahipsiz mallar olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. İşte orta malı, hizmet malı ve sahipsiz malların tümüne birden kamu malları denilmektedir. Buna göre, geniş anlamdaki kamu malları kendi içinde önce özel mallar ve kamu malları olmak üzere ikiye; sonra da, kamu malları kendi içinde orta malı, hizmet malı ve sahipsiz mallar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu son anlamda "kamu malları" deyimi, idarenin görevlerini yerine getirirken kamu hizmetine devamlı surette tahsis edilen veya doğrudan doğruya kamunun kullanımına açık olan malları ifade etmektedir[4].

[4] Kamu malları bakımından şu ayırımlar yapılabilir. **1. Orta malları**: Bu tür mallar halkın, önceden izin almadan ücretli veya ücretsiz olarak, doğrudan doğruya yararlanmasına tahsis edilmiş mallardır. Bu tür malların bir kısmı tahsis yoluyla, bir kısmı ise geleneksel yollarla kamunun kullanımına sunulmuştur. TMK m. 715'te 'yararı kamuya ait mallar' olarak adlandırılmıştır. Örneğin, mera, yaylak, kışlak, otak, harman, pazar ve panayır yerleri, cadde, sokak ve yollar, keza köprüler, baltalıklar, parklar, meydanlar, çocuk bahçeleri, mezarlıklar, eski eserler vs. bu tür mallardandır. Bir malın bu vasfı devam ettiği sürece genel yararlanma söz konusu olur ve ayrıca bu yararlanma hiçbir suretle sona erdirilemez. **2. Hizmet malları**: Kamu malları ise, kamu hizmetlerine o hizmetin bir unsurunu teşkil edecek şekilde tahsis edilmiş mallardır. Bir malın hizmet malı, dolayısıyla kamu malı sayılabilmesi için o malın bir kamu hizmetine tahsis edilmiş olması ve o hizmete göre uyarlanmış ve düzenlenmiş bulunması gerekir. Örneğin, iskele ve limanlar, askeri

4. Tapu Envanter Defteri

2364 Tapu envanter defterine ise müdürlükte bulunan bütün kütük, zabıt defteri, yevmiye defteri ve resmî senet ciltleri ile yardımcı siciller kaydedilir.

tesisler, müzeler ile içlerinde sergilenen eşya ve eserler, kütüphaneler, hizmete özel binalar, okullar, hastaneler, kara, deniz ve hava ulaşım tesisleri bu anlamda birer hizmet malıdır. **3. Sahipsiz mallar:** Başta TMK. m. 715 olmak üzere çeşitli kanunlarca "sahipsiz mallar" terimi kullanılmaktadır. TMK. m. 715'te geçen "sahipsiz yerler"den kasıt, devlet ile gerek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde olmayan mallardır. Sahipsiz mallar adeta doğal nitelikleri itibariyle bu vasfı kazanmış mallardır. Bu vasıftaki malların ortak özellikleri özel mülkiyete geçirilmeye elverişli olmamalarıdır, ayrıca devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmalarıdır. Onun için "devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mallar" ifadesi ile "sahipsiz mallar" ifadesi çoğu zaman eş anlamda kullanılmaktadır. Bundan dolayı olmalıdır ki, TMK. m. 715'te "sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların, devletin hüküm ve tasarrufu altında" olduğu belirtilmiştir. TMK. m. 715'te, sahipsiz mallar, örnek kabilinden sayılarak "yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar" olarak belirtilmiştir. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, sahipsiz malların alt kategorilerini, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler ve onlardan çıkan kaynaklar, umuma ait sular, denizler, göl ve nehirler, kıyılar, tabiî servet ve kaynaklar, tarih, kültür ve tabiat varlıkları, ormanlar oluşturmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. **ÜNAL/BAŞPINAR**, Orman Hukuku, s. 66 vd.; Yarg. 14. HD. T. 27.09.2013, E. 2013/8630, K. 2013/12294.

§ 16. TAPU SİCİLİNDE GEÇERLİ OLAN TEMEL İLKELER

I. GENEL AÇIKLAMALAR

2365 Tapu sicilinde geçerli olan ilkeleri belirleyebilmek için öncelikle eşya hukukuna hakim olan ilkeleri hatırlamak gerekir[1]. Eşya hukukuna hakim olan genel ilkeler TMK'da tek tek sayılmamıştır. Zira, TMK eşya hukuku kurum ve hükümlerini soyut olarak düzenlemiştir. Buna karşın TMK'nın Eşya Hukuku kitabının hükümleri bir bütün olarak incelendiğinde, eşya hukukuna hakim olan genel ilkelerin belirlenmesi söz konusu olabilmektedir. Eşya hukukuna hakim olan genel ilkeler, TMK m.1 I anlamında, TMK'nın eşya hukuku hükümlerinin özüne dahil olarak ilgili maddenin uygulanmasında, yorumlanmasında rol oynar. Tipiklik ilkesi geçerli olsa da eşya hukuku hükümlerindeki kanun boşluğunun doldurulmasında da eşya hukukunun genel ilkeleri rol oynar[2].

2366 Eşya hukukuna hakim olan genel ilkeleri şu şekilde belirleyebiliriz[3]:

- Mutlaklık ilkesi; bu ilke ayni hakkın mutlak hak olması dolayısıyla söz konusu olan ilkedir. Bir ilkeden ziyade, hakkın niteliği ve bu nitelikten doğan özelliği olarak görmek gerekir.
- Aleniyet ilkesi,
- Tipe bağlılık ilkesi (sınırlı sayı ilkesi),
- Belirlilik ilkesi[4],
- Sebebe bağlılık ilkesi[5],
- Katılma (iltihak) ilkesi[6],

---

1 Geniş bilgi için bkz. **ANTALYA**, EH I, N. 444 vd.

2 **MEIER-HAYOZ**, BK ZGB Art. 1-10. I, N.405 ff. 410.

3 **TUOR/SCHNYDER/SCHMID**, § 87 N. 8 f.; **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.56 ff. **REY**, I. N.270 ff. **SCHMID/HURLIMANN-KAUP**, N.61 ff.; Alman hukuku için bkz. **SCHREIBER**, s.272 ff.; Mukayeseli hukuk için bkz. **STADLER**, JZ 65/2010, s.380 ff.

4 **AYBAY/HATEMİ**, belirli konu – bireysel işlem ilkesi olarak ifade etmiştir (s.22 vd.).

5 *"... Medeni Yasa, ayni hakkın kazanılmasında tescilin haklı ve geçerli bir hukuksal sebebe dayanmasını zorunlu kılmıştır. ..."* (Yarg. 1. HD. T. 09.06.1989., 1989/6084 E., 1989/7468 K.);

6 **AYBAY/HATEMİ**, yan nesnelerin ayni haklar bakımından asla bağımlı olması olarak ifade etmiştir (s.22 vd.).

- Zaman itibarı ile öncelik ilkesi[7].

2367 Eşya hukukunun tamamına hakim olan bu ilkeler yanında, bazı sınırlı ayni haklara özel aşağıdaki genel ilkeler de söz konusudur[8]:

- Taşınmaz ve taşınır rehninde, fer'i hakların bağımlılığı ilkesi[9],
- Taşınır rehninde, rehin sorumluluğunun bölünmezliği ilkesi[10],
- Taşınmaz hukukunda, ayni görünüm ilkesi ve talep ilkesi geçerlidir[11]. Bu ilkeleri tapu sicilinin şekli kamuya açıklığı olarak TMK m.1020 düzenlemiştir. Taşınmazlarda bu ilkeler, belirlilik ilkesine bağlı alt ilkeler olarak değerlendirilebilir.

2368 Tapu siciline hakim olan ilkeler de, zikrettiğimiz bu ilkeler ekseninde değerlendirilmelidir. Şimdi tapu siciline hakim olan ilkelere değinebiliriz:

II. HER TAŞINMAZA AYRI BİR SAYFA AÇILMASI İLKESİ (AYNİLİK İLKESİ)

2369 Yukarıda da ayrıntıları ile belirttiğimiz gibi, hukuken taşınmaz olarak nitelendirilen eşyalar tapu siciline kaydedilir. Taşınmazlar tapu siciline kaydedilirken her taşınmaza tapu kütüğünde bağımsız diğer bir ifadeyle ayrı bir sayfa açılmak zorundadır. Bu yönteme ayni yöntem adı verilir. TMK m. 1000/1'de bu husus, "*Her taşınmaza kütükte bir sayfa ayrılır ve sayfa numaraları birbirini izler*" şeklinde düzenlenmiştir. Taşınmazla ilgili işlemler o taşınmazın kendi tapu sayfası üzerinden yürütülür[12].

2370 TMK'nın benimsediği bu ilke ile taşınmazın hukukî durumunun kolaylıkla belirlenmesi sağlanmaktadır. Örneğin; söz konusu taşınmaz üzerinde bir ayni hak veya şerh edilmiş bir şahsi hak ya da taşınmazla ilgili herhangi bir bilgi yahut kısıtlamayı onun sayfasından görme imkanı mevcuttur[13]. Belirtelim ki, henüz tapulaması tamamlanmamış taşınmazlar bakımından bu ilke geçerli olmayacaktır.

---

[7] **ERTAŞ**, ilaveten 'mutlak olma ilkesi', 'devredebilirlik ilkesi' ve 'mülkilik ilkesi'ni genel ilke olarak saymaktadır (s. 22 vd.).

[8] **REY**, I. N.271.

[9] **RIEMER**, Sachenrecht, II. § 22 N.10, § 31, N.16.

[10] **ZOBL**, Syst. Teil. N.309 ff.

[11] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.100 ff.

[12] Bu ilke için, **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 133; diğer yöntem ise şahsi yöntemdir. Bu yöntemde de taşınmazların maliklerinin adından hareketle tapuya kayıt işlemi yapılır.

[13] **SİRMEN**, s. 114; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 122.

III. TESCİL İLKESİ

2371 *Eşya hukukunun genel teorisinde de ayrıntısıyla açıkladığımız üzere*, tapu sicili sisteminde, usulüne uygun bir tescil işlemi yapılmaksızın tapulu taşınmazlar üzerinde ayni hak kurulması, devri ve ortadan kaldırılması mümkün değildir[4]. TMK m. 1021'de tescile ilişkin, "*Kurulması kanunen tescile tâbi aynî haklar, tescil edilmedikçe varlık kazanamaz.*" düzenlemesine yer verilmiştir. Ayrıca TMK m.1022 f.1'de ise, "Ayni haklar, kütüğe tescil ile doğar; sıralarını ve tarihlerini tescile göre alır." düzenlemesine yer verilmiştir. TST m. 5'te tescil ilkesine ayrıca dikkat çekmiştir. Düzelemeye göre, "*Tapu sicili, Devletin sorumluluğu altında, **tescil ve açıklık ilkelerine** göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.*".

2372 Burada belirtmekte fayda gördüğümüz bir diğer husus tescil ilkesinin de çeşitli istisnalarının bulunduğudur. Örneğin; miras, cebri icra, işgal, kamulaştırma gibi durumlarda ayni hak tapuya tescil edilmeden doğar. Bu durumlarda ise tescil açıklayıcı nitelik taşır.

IV. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ

A. Genel Olarak

2373 Türk-İsviçre eşya hukukunda tüm ayni hakkı konu alan tasarruf işlemlerinin geçerliliği hukuki sebebe bağlıdır. Geçerli bir hukuki tasarruf işlemi ancak ona konu olan ayni hakkı kurabilir, sona erdirebilir veya değiştirebilir. Başka bir deyişle, sebebe bağlılık ilkesi, eşya hukukundaki tasarruf işlemlerinin geçerliliğinin, onun temelini oluşturan borçlandırıcı işlemdeki sebebe bağlı olduğu kuralını (*Kausalitätsprinzip*) ifade eder[5].

---

[4] Belirtelim ki, ayni hakkın kurulması veya devri bakımından tescil gerekli olsa da ayni hakkın sona erdirilmesi için terkin işlemi gerekir. **ANTALYA**, EH I. N. 502, Y. 14. HD. T. 23.06.2011. E. 2011/6284, K. 2011/8250 "*Yasanın 1021. maddesine gore de, "Kurulması kanunen tescile tabi ayni haklar, tescil edilmedikçe varlık kazanamaz." Buna da "tapu siciline tescil ilkesi" adı verilmektedir. Sınırlı bir ayni hak olan taşınmaz rehini de Türk Medeni Kanunu'nun 856. maddesi hükmü gereği, bazı istisnalar dışında tescille kazanılır...*".

[5] Ayrıntılı bilgi için bkz. **ANTALYA**, EH I. N. 600; Yarg. HGK. T. 04.05.2011, E. 2011/1-8, K. 2011/263: "...tapu sicilinin tutulması prensiplerinden biri de geçerli bir hukuki sebebin varlığı koşuludur...". *Y. 14. HD. T. 29.01.2008 T., 2007/12735 E., K. 2008/549* ". *Mülkiyet hakkının davanın kazanılması, kurucu iki şartın, (unsurun) iki ayrı muamelenin varlığını gerektirir. Bunlardan ilki, mülkiyetin devri borcunu doğuran borçlandırıcı bir muamele, yani iktisap sebebidir. Buna, hukuki sebep adı da verilmektedir. İkinci muamele ise, tasarruf muamelesi olan ve tescil ile tamamlanması tescil talebidir. Tescile dayalı devren kazanmada mülkiyet hakkı, tescilin yapıldığı anda geçer. Mülkiyet hakkının geçerli bir şekilde intikal etmesi, bu iki muamelenin birlikte bulunmasına ve özellikle iktisap sebebinin (hukuki sebebin) muteber olmasına bağlıdır. Zira, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, sebebine bağlılık ilkesine tabidir...*"

Örnek verecek olursak, bir ayni hakkın devrinin geçerliliği, onun devri borcunu (tasarrufunu) konu alan borçlandırıcı işlem olan, örneğin satış sözleşmesinin veya bağışlama sözleşmesinin geçerliliğine bağlıdır. Borçlandırıcı işlem, tasarruf işleminin ön aşaması olarak karşımıza çıkmakta, borcun ifası ise tasarruf işlemini ihtiva etmektedir[16].

B. Kazandırma Kavramı ve İşlemler

2374 Konunun anlaşılabilmesi için kazandırma kavramı ve bununla bağlantılı olarak tasarruf işlemi ile tasarruf işlemleri ve borçlandırıcı işlem kavramı ve ilişkileri üzerinde durmamız ve bu kapsamda sebebe bağlılık ilkesini açıklamamız gerekir.

2375 *Kazandırma* (iktisap), bir kişinin malvarlığından diğerinin malvarlığı yararına bir malvarlığı değerinin sağlanması fiilidir. Bu işleme de *kazandırma işlemi* adı verilir. Kazandırma üçüncü kişinin borcunu ödemede, üçüncü kişi lehine sözleşmede olduğu üzere dolaylı ya da taşınmaz mülkiyenin devrinde olduğu üzere doğrudan gerçekleşebilir. Kazandırma ile kazananın malvarlığında bir artış meydana gelir. Artış kazanın aktifinde çoğalma şeklinde olabileceği gibi; pasifinin azalması şeklinde de gerçekleşebilir[17].

2376 Malvarlığındaki değere etkileri açısından hukuki işlemler dörde ayrılır[18]: 1. Kazandırma (iktisap) işlemleri[19], 2. Borçtan kurtarma işlemleri[20], 3. Borçlandırıcı işlemler (borçlanma işlemi), 4. Tasarruf işlemleri.

2377 Borçtan kurtarma işlemleri de aslında borçlandırıcı işlemdir; ancak konu aldığı hakka etkisi yönünden ayrı bir kategori olarak ifade edilmiştir. Diğer yandan borçlandırıcı işlemleri ve tasarruf işlemleri ve ikisi arasındaki ilişki de kazandırmaya olan etkileri yönündendir. Gerek borçlanma işlemleri, gerekse tasarruf işlemleri ile bir kişinin, başkasına ait malvarlığına yeni bir kazandırma fiilinde bulunması halinde kazandırıcı işlemden bahsedilir.

---

16 Bkz. **von TUHR/PETER**, s. 195 vd.

17 **FLUME**, s.152; **FEYZİOĞLU**, I, s 45; **EREN**, BH GH, § 17, I, 1; **KOCAYUSUFPAŞAOĞLU**, BH GH, § 11, III, 1, a; **ANTALYA**, BH GH I, s. 107; **ANTALYA/TOPUZ**, MH, §7, V, C, 3, a.

18 **ANTALYA**, BH GH I, s. 107.

19 Kazandırma işlemleri, kazananın hak kazandırmasını sağlayan, malvarlığının aktifini arttıran işlemlerdir.

20 Borçtan kurtarma işlemleri ise, borcun ifası, ibra, yenileme örneklerinde olduğu üzere bunu yapanın veya karşı tarafın malvarlığının pasifini azaltan işlemlerdir.

2378 Borçlandırıcı işlem ile tasarruf işleminin ortak noktası, her ikisinin de malvarlığında azalmaya sebebiyet vermesidir. Borçlandırıcı işlem, işlemi yapanın malvarlığının pasifini çoğaltırken, tasarruf işlemi aktif kısmını azaltmaktadır. Kazandırma kavramı, hukuki işlemler dışında maddi fiillerle de gerçekleşebilir. Örneğin; TMK. m.755'te işleme halinde işleyen, maddi bir fiille şeyin malikine kazandırmada bulunmuştur[21].

2379 Malvarlığını oluşturan her hakkın devrinde, kural olarak o hakkın devrine ilişkin kurallar uygulanır[22]. Hak, örneğin alacak hakkı ise alacak hakkı, ayni hak ise ayni hak kuralları uygulanacaktır.

C. Eşyanın Devri Sistemleri

2380 Malvarlığı değerleri olarak eşyanın devri konusunda benimsenen iki temel ilke ve bu yaklaşıma bağlı iki sistem söz konusudur[23]: 1. İrade (sözleşme) ilkesi (*Konsensprinzip/Vertragprinzip*), 2. Teslim ve Tescil ilkesi (*Traditionsprinzip/Übergabeprinzip*)

2381 İki ilke (sistem) arasındaki fark, malvarlığı değerinin ne zaman el değiştirdiği noktasındadır. İrade ilkesini kabul eden sistemlerde, devreden ile devralan arasındaki irade uyuşmasıyla, örneğin sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmasıyla birlikte hak devredilmekte; teslim tescil ilkesinde ise, irade uyuşmasına ilaveten eşyanın teslimi ya da ayni hakkın devrinin ya da kurulmasının veyahut sınırlandırılmasının tapu siciline tescilinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin devrinde bir sicile kaydı gereken ayni hakkının devri söz konusu ise, teslim, yerini tapu siciline tescile bırakmaktadır.

2382 Türk Hukuku'nda taşınır mülkiyetinin devri için, zilyetliğin devri (TMK. m. 705 I)[24]; taşınmaz mülkiyetinin devri için, devreden ile devralan arasındaki irade uyuşması (sözleşme) yanında, tasarruf işlemin kurucu unsuru tescil aranmaktadır[25]. Bu yaklaşımla mutlak malvarlığı haklarının, örneğin ayni hakların intikali teslim tescil ilkesine bağlanmıştır. Bu-

---

21 Karışma ve birleşme için bkz. TMK m. 776.

22 **SEROZAN**, Taşınır Eşya, s. 63.

23 İrade sistemi Fransa, İtalya, Belçika, İngiliz ve ABD hukuklarında, teslim ilkesi de Almanya, İsviçre, İspanya, Yunan ve Hollanda hukuklarında benimsenmiştir. **UTKU**, s. 87 dn. 325.

24 Başka bir görüş zilyetliğin nakli ile birlikte tasarruf sözleşmesinin varlığını aramaktadır. Bkz. **KOCAYUSUFPAŞAOĞLU**, § 11, II, 2, a, aa, 1.

25 **UTKU**, s. 88 dn.329'daki yazarlar.

na karşın nisbi hak niteliğindeki alacağın devrince ise irade ilkesi geçerlidir.

D. Hukuki İşlemin Sebebi

2383 Her hukuki işlemin bir sebebi, bunu takip eden her kazandırmanın da bir sebebi vardır. Hukuki sebep (*causa*) taraf veya tarafların kazandırma ile doğrudan doğruya asli olarak istedikleri temel ve kazandırmaya hukuki niteliğini veren amaçtır[26].

2384 Tarafların her birinin ayrı ayrı arzuladıkları amaçları değil, tarafların üzerinde uzlaştıkları, *ortak amaç* dikkate alınır. Ortak amaç, kazandırmanın amacına ilişkin *sebep anlaşmasında* yer alır. Ortak amaç dışında tarafların saikleri de önemli değildir. Hukuki işlemin amacını *saiklerden* (*etken*lerden) ayırmak gerekir[27].

2385 Roma Hukuku'ndan günümüze kadar yapılan ifa sebebi (*causa solvendi*), alacak sebebi (*causa credendi veya acquirendi*), bağışlama sebebi (*causa donandi*) şeklinde yapılan üçlü ayrımın yanında, garanti (teminat) sebebi, yenileme sebebi (*causa novandi*) gibi diğer sebeplerin de varlığını dikkate alarak hukuki sebepler beşli ayrıma tabi tutulmaktadır. Kazandırma birden çok sebebe dayanıyorsa, karma sebep söz konusudur. Örneğin; karma bağışlamalar, hem bağışlama, hem de alacak sebebine dayanır.

E. Kazandırmanın Sebebe Bağlılığı

2386 Taraflarca istenen ortak hukuki sebep (amaç) kazandırıcı işlemi oluşturan işlemin onsuz olmaz bir unsuru haline gelmişse kazandırma *sebebe bağlıdır, illîdir*[28]. Bu kazandırmanın geçerli olarak hukuki sonuçlarını doğurabilmesi için, geçerli bir hukuki işlemin bulunması gerekir.

2387 Buna karşın hukuki sebebin hukuki işlemin olgusunu teşkil etmemesi, kazandırmanın hukuki sebepten soyutlandığı ihtimallerde söz konusu olabilir. Yine hukuki sebebi göstermeyen, ondan ayrılmış hukuki işlem-

---

[26] **ANTALYA**, BH GH. I. s. 109.

[27] Saik, kişinin amacının oluşmasına etken olan, kişiyi bu sebebin bulunduğu hukuki işlemi yapmaya sevk eden kişisel düşünce ve diğer iç ve dış etkenlerdir. Kural olarak hukuk düzeni istisnalar dışında saikleri değil, hukuki sebebi esas almıştır. Saiklerin hukuken dikkate alındığı hukuk kuralları için bkz. **ANTALYA**, BH GH I. s. 110.

[28] **FLUME**, s. 153; **FEYZİOĞLU**, I. s. 43; **EREN**, BH GH. § 17. III; **KOCAYUSUFPAŞAOĞLU**, BH GH. § 11. III,. 2. b aa; **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §7. V. D.

lerle yapılan kazandırmalar da *sebebe bağlı değildir, soyuttur.* Bu tür kazandırmalara (soyut) işlemler denir. Bu durumda hukuki sebep bulunmadan veya geçerli olmadan da kazandırma geçerli olur ve hukuki sonuçlarını doğurur. Unutulmamalıdır ki, kazandırmayı soyut işlemle elde eden kişinin kazandırması bir sebebe dayanmıyorsa "sebepsizdir" ve kazandırmanın sebepsiz zenginleşme kurallarıyla iadesi talep edilebilir.

2388 Borçlandırıcı işlem kural olarak sebebe bağlıdır. Hukuki işlemin zorunlu unsuru olarak kazandırmada belirtilir; taraflar bu unsurda uzlaşır. Borçlandırıcı işlemlerde hukuki sebebin kendisi, hukuki işlemin kendisidir[28]. Kazandırmanın sebebini hukuki işlem oluşturur. Örneğin, alıcının satış bedelini ödeme borcu karşı edim alacağına karşılık alacak sebebi olarak borçlanılmıştır.

2389 Kazandırıcı işlemde ise kural olarak hukuki sebep, borçlandırıcı işlemdir. Tasarruf işlemleri, borçlandırıcı işlemin ifasına hizmet eder. Tescilin hukuki sonuçlarını doğurabilmesi ve tescil işleminden beklenen neticelerin gerçekleşebilmesi için yapılan tescilin muteber olması gerekir. Buna sebebe bağlılık ilkesi denir[29].

2390 Bu kapsamda tescilin geçerli olabilmesi yapılan tescile dayanak teşkil eden hukuki sebebin (hukuki işlemin) geçerli olması gerekir. Söz konusu husus TMK m. 1024'te "*Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise, bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi bu tescile dayanamaz (f.1). Bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan veya hukukî sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur (f.2). Böyle bir tescil yüzünden aynî hakkı zedelenen kimse, tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir (f.3).*" şeklinde düzenlenmiştir. Diğer yandan TMK m.1025'te de, "*Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini*

---

[28] **FLUME**, s.169; **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §7. V. D.

[29] Ayrıntılı bilgi için bkz. **SİRMEN**, s. 115; **GÜRSOY / EREN / CANSEL**, s. 238; **OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 133-134; **ESENER / GÜVEN**, s. 58; Y. 14. HD. T. 29.01.2008 T., 2007/12735 E., K. 2008/549 "... *Mülkiyet hakkının davanın kazanılması, kurucu iki şartın, (unsurun) iki ayrı muamelenin varlığını gerektirir. Bunlardan ilki, mülkiyetin devri borcunu doğuran borçlandırıcı bir muamele, yani iktisap sebebidir. Buna, hukuki sebep adı da verilmektedir. İkinci muamele ise, tasarruf muamelesi olan ve tescil ile tamamlanması tescil talebidir. Tescile dayalı devren kazanmada mülkiyet hakkı, tescilin yapıldığı anda geçer. Mülkiyet hakkının geçerli bir şekilde intikal etmesi, bu iki muamelenin birlikte bulunmasına ve özellikle iktisap sebebinin (hukuki sebebin) muteber olmasına bağlıdır. Zira, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, sebebine bağlılık ilkesine tabidir...*"

dava edebilir (f.1). İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır (f.2)." düzenlemesine yer verilmiştir.

2391 TMK m. 1024-1025 birlikte değerlendirildiğinde tescile esas oluşturacak bir hukukî sebep hiç yoksa veya var olan hukuki sebep geçerli değilse, yetkili memur tarafından usulüne uygun şekilde yapılmasına rağmen tescil de geçersiz olur. Yargıtay bir kararında bu hususu, "*...Türk Medenî Kanunu, aynî hakkın kazanılmasında tescilin haklı ve geçerli bir hukukî sebebe dayanmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, haksız ya da lüzum ifade etmeyen bir işleme dayanılarak yapılan tescil geçersiz bir tescildir. Tescilin geçerli bir hukukî sebebe dayanmaması aynî hakkın doğumunda ve kazanılmasında kurucu unsur olan tescil işlemini temelde sakat duruma getirir...*" şeklinde ortaya koymuştur[31].

2392 Sebebe bağlılık ilkesine göre, talep üzerine devletin yetkili memurları tarafından usulüne uygun bir şekilde yapılsa bile geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan tescil işlemi taşınmaz üzerindeki aynî hakta bir değişiklik meydana getirmez. Buna göre tescil yolsuzdur diğer bir ifade ile geçersizdir ve gerçek hak sahipliği değişmemiştir.

2393 Bu durumu bir örnekle açıklayacak olursak: Ayırt etme gücünden yoksun (A) taşınmazını (B)'ye satıp mülkiyetini tapuda tescil ettirerek onun üzerine geçirmiş olsun. Böyle bir durumda (B) adına yapılan tescil yolsuz tescildir ve geçersizdir. Mülkiyet hakkı halen (A)'dadır. Çünkü ayırt etme gücü bulunmayanların yaptıkları sözleşmeler kesin hükümsüzdür. Kesin hükümsüz bir sözleşmeye dayanarak yapılan tescil de geçersizdir yani yolsuzdur. Verdiğimiz örnekte ayırt etme gücü bulunmayan (A), (B)'ye karşı dava açarak tapunun kendi üzerine geçirilmesini talep edebilecektir. Tabi ki, böyle bir durumda (B)'den aldıklarını da ona iade edecektir[32].

---

[31] Yarg. 1. HD., T. 09.6.1989, E. 1989/6084, K. 1989/7468; Ayrı yönde bkz. Yarg. 1. HD. T. 06.07.2011, E. 2011/2907, K. 2011/7956. "*... Sicilin dayanağının geçerli bir hukukî sebebinin bulunmaması onu yolsuz tescile düşürür.*" Y.1 HD. T. 12.05.2010, T.E. 2010/5029, K.2010/5612 "*Eldeki davada yukarıda açıklanan iddianın içeriği ve ileri sürülüş biçimi itibariyle, davanın, çekişme konusu taşınmaz kaydının davalı taraf adına oluşumunun illetten yoksun olduğu, bu nedenle yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu iddiasına dayalı olduğu açıktır.*". Yarg HGK. T. 30.05.2001, E. 2001/464, K.2001/470. "*Medeni Kanun mülkiyet hakkının doğumunu sebebe (illete) bağlı bir hukuki işlem olarak kabul etmiştir. Medeni Kanun'un sistemine göre, tescilin geçerli olabilmesi ve mülkiyet hakkının doğması için geçerli bir hukuki sebebe dayanması zorunludur. Geçerli bir hukuki sebebe dayanmayan tescil işlemi yolsuz tescil niteliği taşır ve her zaman iptali istenebilir.*".

[32] Belirtelim ki, eğer (B) iyiniyetli olarak bu taşınmazı 10 yıl boyunca davasız ve aralıksız olarak zilyetliğinde bulundurmuş ise artık zamanaşımı yolu ile mülkiyet hakkı (B)'ye geçecektir.

IV. İSTEM (BAŞVURU) İLKESİ

2394 Taşınmazlardaki ayni hak kazanımı, değişimi ve sona ermesi, kural olarak taleple gerçekleşir. TSY m.16 I hükmü "*kanunlarda ve bu Tüzükte belirlenen istisnalar dışında yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamaya*cağını belirtmiştir. Örneğin, bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen değişiklikler, eşlerden birinin istemiyle tapu kütüğüne doğrudan tescil olunur (m.716 III)[33].

2395 Tescil, kural olarak tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılır (TMK m.1013 I). Edinen kimse, kanun hükmüne, kesinleşmiş mahkeme kararına veya buna eşdeğer bir belgeye dayanıyorsa, bu beyana gerek yoktur. Bir aynî hakkı tescilden önce kazanan kimse, gerekli belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir[34].

2396 Bir ayni hakka ilişkin tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı üzerine yapılabilir (TMK m.1014 I). Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukukî sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır (TMK m.1015 I). Hukukî sebebin belgelenmesi, şekil zorunluluğu ilkesi gereği, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur.

2397 Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi için istemde bulunanın, hukukî sebebe ilaveten tasarruf yetkisini de belgelemiş olması gerekir (TMK m.1015 I). İstemde bulunan kimse, kendisinin, aleniyet ilkesi gereği, tapu sicilinde hak sahibi görünen kişi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş olur (TMK m.1015 II).

2398 Tapulu bir taşınmaz üzerindeki ayni hakkı etkileyebilecek herhangi bir tapu sicili işleminin yapılabilmesi için hak sahibinin veya yetkili temsilcisinin yazılı istemde bulunması zorunludur. Bu kapsamda TMK m.1013'te, "*Tescil, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin* ***yazılı beyanı***

---

[33] Ayrıntılı bilgi için bkz. **ANTALYA**, EH I, N. 516.

[34] Bir taşınmazın mülkiyetinin kime ait olduğuna dair uyuşmazlık hakkında taraflar tahkime başvurmuşlarsa hakem, yalnızca mülkiyetin hangi tarafa ait olduğunu tespit edebilir. Yoksa hakem, mahkemelerin görev kapsamına dahil olan tescile karar verme kudretini taşımaz. Hakemin tespiti doğrultusunda ilgili taraf TMK m. 1013/ I çerçevesinde tescil talebinde bulunmalıdır. Aynı yönde bkz. Y. 1. HD. 18.06.2007 T., E. 2007/5642, K. 2007/7012

üzerine yapılır (f.1). Edinen kimse, kanun hükmüne, kesinleşmiş mahkeme kararına veya buna eşdeğer bir belgeye dayanıyorsa, bu beyana gerek yoktur (f.2). Bir aynî hakkı tescilden önce kazanan kimse, gerekli belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir (f.3)." düzenlemesine yer verilmiştir.

2399 Aynı zamanda TMK m.1014'te de, "*Bir tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı üzerine yapılabilir.*" denilmiştir. TST m. 16'da ise söz konusu ilke oldukça ayrıntılı şekilde düzenlenmiş ve "*(1) Kanunlarda veya bu Tüzükte belirlenen istisnalar dışında,* ***yazılı istem olmadıkça*** *tapu sicili üzerinde işlem yapılamaz, (2)* ***İstem, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz****, (3) Müdürlüklere her türlü tapu işlemi için yapılacak istemde,* ***başvuru istem belgesi*** *düzenlenir. (4) Tapu sicilinde yapılacak haciz dahil her türlü kayıt sorgulaması istemlerinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya taşınmazın ada ve parsel numarasının belirtilmesi zorunludur. Aksi hâlde istem reddedilir.*" düzenlemesine yer vermiştir.

2400 TST m. 17'de ise söz konusu ilke çerçevesinde kimlerin istemde bulunabileceği ortaya konulmuştur. Söz konusu hükümde, *"(1) Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler* ***istemde*** *bulunabilir. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler. (2) Aile konutu olarak özgülenen taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair şerhin verilmesini isteyebilir.*"

V. ALENİYET (KAMUYA AÇIKLIK) İLKESİ

2401 Aynî hakların, mutlak hak niteliği gereği, ihlal eden herkese karşı ileri sürülebildiğini ifade etmiştik. Şu hâlde, aynî hakkı ihlal etmemesi istenen kimselere karşı, aynî hukukî durumun dışa yansıtan bir tezahür şekline ihtiyaç vardır[35]. Aleniyet ilkesi (*Publizitätsprinzip, Offenkundigkeit*), eşya üzerinde var olan aynî hakkın herkes tarafından varlığını ve bu hakkın süjesinin kim olduğunun tanınabilir ve bununla birlikte belirlenebilir olmasını ifade eden ilkedir[36].

---

[35] **ANTALYA**, EH I, 450.

[36] Ayrıntılı bilgi için bkz. **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.100 ff.; **WIEGAND**, BSK vor Art 641, N.53 ff.; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 63 ff.; **ANTALYA**, O., G., Eşya Hukukuna Hakim Olan İlkelerden Aleniyet İlkesi, MÜHFD-HAD, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu'na Armağan, Cilt: 23, Sayı: 3, 2017, s.420 vd.

2402 Kamuya açıklığı sağlayacak araçlar (*Publizitatsmittel*), eşya hukukunun temel ayrımı olan taşınır ve taşınmaz ayrımına göre, TMK'da ve özel kanun hükümlerinde düzenlenmiştir[27].

2403 Ayni hakta aleniyetin sağlanabilmesi için kamuya açıklık araçlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ya bir fiili olgu ya da sicil olgusu olabilir. Sicil olgusu taşınmazlarda, fiili olgu olan zilyetlik taşınırlarda aleniyetin kamuya açıklık aracıdır. Kısaca belirtirsek, taşınır eşyalarda ayni hakkı alenileştiren kamuya açıklık aracı zilyetlik olduğu halde, taşınmazlarda tapu sicilidir[28].

2404 Şimdi meseleyi bir örnekle somutlaştıralım: (A)'nın elinde bir cep telefonu vardır ve (A) telefonu kullanmaktadır. Dış görünüş itibarıyla başkaları o cep telefonunun yani cep telefonu üzerindeki mülkiyet hakkının (A)'ya ait olduğunu düşünürler. Mülkiyet hakkı ise en geniş yetkileri sağlayan ayni haktır. Buna göre, bir kimsenin bir taşınır mal üzerinde ayni hak sahibi olduğu hususunu, söz konusu eşyanın o kişinin zilyetliğinde bulunmasından anlarız. Taşınır eşyalar üzerindeki ayni hakları başkaları nazarında alenileştirip bilinebilir hale getiren husus eşyaya zilyet olmaktır. Taşınmazlara geldiğimizde ise, (A)'nın bir arazinin malıki olduğu hususunu ancak tapu sicilinden anlayabiliriz. Zira bir taşınmaz üzerinde ayni hak (örnekte mülkiyet hakkı) tapuya tescil ile kazanılır. Tapu herkese açık olduğu için oradaki kayıtların bilinmediği de ileri sürülemeyecektir.

2405 Aleniyet ilkesi, kamuya açıklığı sağlayan araçlarıyla taraflar arasındaki eşya hukuku ilişkini görünür hale getirir, böylelikle kişi ile eşya arasındaki ilişki ne olduğu, ilişkinin kapsamı, bu ilişkide kimin hak sahibi olduğunu belirler[29].

2406 Zilyetlik taşınır mallarda ayni hakkın varlığı ve sahibi hususunda kural olarak yeterli aleniyeti sağlamakta ise de, taşınmazlar bakımından aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira bir çalışma masasında ve çantasında taşıdığı bilgisayar kişinin malıki olduğunu ortaya koyabilirken, bir evde oturan ya da bir araziyi işleyen kimse her durumda onun malıki sayılmayabilir. Bu nedenle taşınmaz mallarda ayni hakkın varlığını kamuya açıklamaya yarayan vasıta, o hakkın tapu siciline tescil edilmiş olmasıdır.

---

[27] Geniş bilgi için bkz. **ŞENGÜL**, s.7; **HEDDINGER**, s.41 ff.

[28] **AKİPEK/AKINTÜRK**, s.20; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 65; **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.56 ff.; **REY**, I, N.270 ff.; **SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP**, N. 63.

[29] **WIEGAND**, BSK ZGB vor Art 641 ff. N. 55.

Zira taşınmazları konu alan tüm ayni haklar kural olarak tapu siciline tescil ile kurulur (TMK m.1021). Tescil varsa ayni hak kazanılmıştır, tescil yoksa ayni hak kazanılmamıştır. Ayrıca tapu sicili herkese açıktır. Kimse tapudaki kaydı bilmediğini ileri süremez (TMK m. 1020).

2407 Tapu sicili veya kat mülkiyeti sicili, ayni hakların, eşyaya bağlı borçlar da dahil olmak üzere, kamuya açıklık araçlarıdır[40]. Tapu sicilinin etkisi, taşınmazlar üzerinde ayni hak kazanımı için kural olarak ayni hakkın tapu siciline kaydının (tescili, şerhi) şart olduğunu ifade eder. Başka bir ifadeyle taşınmazlar üzerinde bir ayni hakkın kazanımı, değişimi için tescil şarttır. Tapu siciline tescille ayni hak doğar (TMK m.1022 I).

2408 Ayni hakkın devrini konu alan tasarruf işlemi yapılsa da, tescil yapılmadıkça ayni hak kazanılmaz. Tasarruf işlemi tamamlayıcı olgu olan tescille tamamlanır. Tescilin bu olumsuz etkisi, TMK m.1020'de genel kural olarak ifade edilmekle yetinilmemiş; mülkiyet (TMK m.705 I) ve sınırlı ayni hak kazanımı için (TMK m.780 I, 795, 840 I, 856 I) kanunda özel olarak düzenlenmiştir. Bu hallerde, tescilin *kurucu* etkisi söz konusudur. Bu etkiye *tescilin olumsuz hükmü* ismi de verilmektedir.

2409 Tescilsiz ayni hak kazanımı sonrasında yapılan tescilde ise, *açıklayıcı* etki söz konusudur. Tescilsiz ayni hak kazanımında yine o hakkın tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır (TMK m.705 II c.2; m.780 II). Tasarruf yetkisi eksikliğine rağmen, yapılan tasarruf işlemi sonucunda iyiniyetli üçüncü kişinin ayni hak kazanımının korunması tapu sicilinin olumlu maddi etkisidir. Bu etkiye tescilin (maddi) olumlu etkisi hükmü ismi de denilmektedir. TMK m.1023 hükmü gereğince, tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur[41].

2410 Aleniyet ilkesinin kamuya açıklığı sağlayan, taşınmazlarda tapu sicili, taşınırlarda zilyetlik araçlarıyla, taraflar arasındaki eşya hukuku ilişkisindeki hakkın ne olduğu, hakkın kapsamı ve bu ilişkide kimin hak sahibi olduğunu belirlenir[42].

---

40 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.58; **HAAB**, ZK Einl. N.63.

41 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.57; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 27 vd.; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 94 vd.; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 66.

42 **WIEGAND**, BSK vor Art.641 ff., ZGB, N. 55. Aleniyetin ayni hakkı görünür hale getirerek belirleme etkisi, zilyetlikte tam olarak ortaya konulamazsa da, kanun koyucu zilyedin, zilyetliğinde bulundurduğu taşınır üzerinde iddia ettiği hakkın varlığına karine teşkil ettiğini düzenlemiştir. TMK m.985 hükmü taşınırın zilyedi onun maliki sayılır. Zilyetliğin hak karinesi özelliği taşınmaz-

2411 Tapu sicilinin olumlu etkisi yanında, olumsuz etkisi de söz konusudur. Tapu sicilinin ve zilyetliğin hak karinesi olması hukuk yargılamasında ispat yükünü tersine çevirir[42].

2412 Tapu sicilinin aleniyeti ilkesi, TMK m.1020'de, *"Tapu sicili herkese açıktır (f.1). İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir (f.2). Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez (3)."* denilmek suretiyle ortaya konulmuştur. Aynı şekilde TST m.5'te *"(1) Tapu sicili, Devletin sorumluluğu altında, tescil ve **açıklık ilkelerine** göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir."* denilmektedir.

2413 Eşya hukukunun genel teorisi kısımlarında da ayrıntısı ile açıklandığı üzere ayni haklar mutlak haklardandır ve herkese karşı ileri sürülebilme imkanı vardır. Belirtelim ki, kişilerin ayni hakka riayet edebilmeleri bu hakkın varlığından ve kapsamından haberdar olmalarına bağlıdır. Bunun içinse, ayni hakkın herkesçe bilinmiyor veya en azından kolaylıkla bilinebilir yani kamuya açık olması gerekir. Söz konusu aleniyeti, taşınır eşyalarda zilyetlik, taşınmaz eşyalarda tapu sicili sağlamaktadır. Taşınmaz eşyalar üzerinde mevcut ayni hakları herkesçe bilinir bilinebilir hâle ancak tapu sicili getirir[43].

2414 Tapu sicilinin aleni olması mutlak bir ilke olmayıp bazı noktalarda sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede gerek TMK gerekse TST düzenlemeleri nazara alındığında söz konusu ilkenin iki bakımdan sınırlandırıldığını görmekteyiz. Bu sınırlamanın ilki incelemeye yetkili kişiler bakımındandır. İkincisi ise söz konusu incelemelerin yapılabileceği tapu sicili unsurları bakımındandır.

2415 Birinci sınırlamayı açıklayacak olursak, malikin açıkça izin verdiği haller dışında bir kimsenin tapuyu inceleyebilmesi için bu kişinin hukuken korunmaya değer bir ilgisi veya bir menfaati olmalıdır. Bunun dışın-

---

larda BGB § 891 aksine düzenlenmemesine karşın, TMK'nın m.1020 ile 1024 hükümleri incelendiğinde, tapu siciline kayıtlı taşınmazlar bakımından, -tapu sicilinin olumlu etkisi olarak – söz konusu hak karinesinin tapu siciline kayıtlı haklar bakımından olduğunu söyleyebiliriz. TMK m.7 resmi sicil olan tapu sicilinin belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturduğuna ilişkin karineyi düzenlemiştir. Karş. **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.59; **HAAB**, ZK Einl. N.62; **REY**, I. N.287; **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §13. VI.

[42] **ANTALYA/TOPUZ**, MH. §13. VI. D.

[43] Ayrıntılı açıklamalar için bkz. **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 205; **EREN/BAŞPINAR**, s. 208; **OKTAY-ÖZDEMİR**, s.503 vd.; **ŞENGÜL**, s. 7 vd.

da sırf bilgi edinmek için veya başka saikler tapu sicili inceleme hakkı vermemektedir. Örneğin; bir kimse taşınmaz satın alacaksa tabi ki o taşınmaza ilişkin olarak tapuyu inceleyebilir veya bir banka müşterisine konut kredisi verecekse banka, o kredi ile satın alınacak taşınmazla ilgili tapu sicilini inceleyebilir. Fakat bir sanatçının malvarlığını öğrenmek için meraklı bir gazeteci veya televizyoncunun tapuya gidip inceleme yapması ise söz konusu değildir.

2416 Burada belirtmekte fayda gördüğümüz bir diğer önemli husus tapu sicilini inceleyecek olan kişinin TMK m.1020 kapsamında ilgisini inanılır kılması gerektiğinden tapu müdürlüğü nezdinde bu durumu ispat etmesi gerekecektir. Buradaki ispat ölçüsü kanaatimizce tam ispat değil yaklaşık ispattır. Diğer bir ifadeyle talepte bulunulan kişi tapuda görevli memur nezdinde olumlu bir kanaat uyandırması yeterlidir.

2417 Uygulamada genelde malikten tapu senedinin fotokopisini almak suretiyle ilgili kişiler tapu sicilini rahatlıkla inceleyebilmektedirler. Belirtelim ki, TMK m. 1020 f.2'ye göre, ilgili kişiler incelediği unsurların birer örneğinin kendisine verilmesini talep edebilir. TST m. 85 f.2'de, *"İlgilisinin istemi hâlinde, tapu sicilini oluşturan diğer bilgi ve belgelerin örneği verilir." düzenlemesi de söz konusu hususa dikkat çekmektedir.*

2418 İkinci sınırlama ise kişiler tarafından incelenebilecek unsurlardır. Buna göre *açıklık ilkesi, kural olarak sadece ana siciller unsurlar (tapu kütüğü, yevmiye defteri, plân ve diğer resmî belgeler) için geçerlidir*[45]. O halde yardımcı siciller için aleniyet ilkesi işlemeyecektir. Buna göre yardımcı sicillerde bulunan bir kaydın veya bilginin bilinememesi normaldir. Bir kimse yardımcı sicillerde yer alan bir bilgiyi bilmediğini iddia edebilir. Ama ana sicillerdeki bilgileri bilmediğini ileri süremez.

2419 Tapu sicilinin aleni olması yukarıda da belirttiğimiz gibi tapu sicilinde yer alan kayıtlara ilişkin olarak bilgisizlik iddiasında bulunulamama sonucunu doğuracaktır. Buna göre, herkesin tapu kayıtlarını bildiği varsayılır. Bu *varsayım kesin kanuni bir karine olduğundan aksi iddia ve ispat edilemeyecektir.* Bir kimse gerçekten de bir taşınmaza ilişkin bilgileri bilmiyor olabilir. Örneğin; uygulamada genelde taşınmaz satın alacak kişi malikin kendisine gösterdiği tapu senedine güvenerek işlem yapar ve tapu kütüğünü incelemez. Halbuki tapu senedi taşınmaza ilişkin bazı bilgiler

[45] HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s. 417

içerse de birçok bilgiyi içermez. Bu nedenle tapu sicilinin ana unsurlarında mevcut bilgiler hususunda bilgisiz olunduğu belirtilerek iyiniyet iddiasında bulunulamaz.

2420 Tapu sicilinin herkese açıklığı sınırsız değildir[46]. Herkesten kast edilen her üçüncü kişi değil, tapudaki kayıtla ilgisini inanılır kılan üçüncü kişiler, sadece tapu sicilinin ilgisi olduğu kaydı inceleyebilir.

2421 Tapu sicilinde ayni veya eşyaya bağlı hak sahibi olan veya hakkın yükümlüsü olanların inceleme ve örnek alma hakkı olduğu tabiidir. Tapu sicilleri, Tapu Müdürlüğü dışına çıkarılamaz; ancak, mahkemeler veya yetkili resmî merciiler tarafından sicil veya belgelerin aslı istenildiği takdirde, örnekleri müdür tarafından tasdik edilip, iade edilmek üzere imza karşılığında asılları verilir. Onaylı örnek belgeler, asılları iade edilene kadar özenle saklanır (TST m.84).

2422 TMK m.1020 II'e paralel olarak, ama daha dar olarak TST m.84/2 hükmü, kamu tüzel kişisine (Devlete), özel hukuk kişilerine bir hizmetin görülmesi, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde, tapu kayıtlarının onaylı örneğinin verileceğini düzenlemiştir.

2423 Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcıları ile özel kanunları ve tüzükleri gereği görevli ve yetkili kişilerin suç araştırma veya soruşturma kapsamında yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerinin verilmesi mümkündür. Tapu işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen istem belgesi, resmi senet, tapu senedi ve ipotek belgelerinin birer örneği Tapu Müdürlükleri tarafından hak sahiplerine verilir (TST m. 85/1). İlgilisinin istemi halinde, tapu sicilini oluşturan diğer bilgi ve belgelerin örneği verilir (TST m. 85/2).

2424 Tapu sicili kayıtlarının incelenmesi ve örnek alınması, bir ilginin varlığı ile sınırlandırılmıştır; bu ilginin hukuken korunmaya değer bir menfaate dayalı olması gerekir. Ancak, korunmaya değer menfaati daha az olan bazı durumlarda örneğin; hangi taşınmazda, hangi tarihten itibaren, hangi hukuki sebebe dayanarak, kimin ayni hak sahibi olduğu, hak sahipliğinin mülkiyet mi yoksa başka bir sınırlı ayni hak olduğunu öğrenmekte ilgisi var olduğu kabul edilmelidir[47].

---

[46] REY, ZBGR 1984, s.73 f.; HAUSHEER, ZBGR 1988, s.1 ff.

[47] ZGB Art. 790 (2).

2425 Kamu düzeni ve tapu siciline güvenin gereği olarak gerek özel hukuk tüzel kişilerinin gerekse kamu hukuku tüzel kişilerinin münferit isteklerinde de ilginin varlığının ispatı aranmalıdır. Örneğin, uygulamada; bankaların kredi aşamasında, kişilerin taşınmazlarına ait araştırma ve inceleme kapsamında bilgi istemlerinde, banka müdürlüklerince yazılı talepte bulunmaları halinde, incelenmesi talep edilen taşınmazın tapu senedi fotokopisinin ibrazı ile ilgisi ispatlanması istenmekte, belge örneği istemlerinde ise malikin veya yetkili vekilinin yazılı talebi aranmaktadır.

2426 Tapu sicilindeki kaydın süjesine ilişkin kişilik değeri oluşturan kişisel verilerin korunması için de tapu müdürlükleri özen göstermekle yükümlüdür. Nüfus kimlik bilgileri ile yerleşim paylaşımında, talep edenin kamu ve özel ayrımı yapmaksızın kayıtla ilgisinin varlığına dikkat etmelidir. Tapu kayıtlarının elektronik ortamda tutulması halinde, ana ve yardımcı siciller TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) içerisinde saklanır ve yönetilir (TST m. 12/1).

2427 Mahkemeler, Cumhuriyet başsavcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek sağlanabilir (TST m. 14/1). Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilirler (TST m.14/2).

2428 Protokolde, TAKBİS üzerinden sorgulama yapılabilmesi için, erişimin türü ve şekli, erişim kontrolü, verilerin kullanım amacı, üçüncü kişilere kullandırılmasına ilişkin sınırlamalar ve amacı dışında kullanımın sonuçları yer alır (TST m.14/3). Erişim hakkına sahip kuruluşlar, taşınmaz ile ilgili verileri TAKBİS üzerinden alırlar. Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, düzenlenecek sözleşme şartları dahilinde verilere erişebilirler (TST m.14/4). Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilir (TST m.14 (5)).

2429 Kaydın herkes tarafından bilindiği olgusunun fiksiyon olduğu; bu sebeple aksinin ispat edilemediği kabul edilmektedir. Bu olgu tapu sicilinin (tescilin) olumlu etkisi yani tapuya güven ilkesi ile yakından ilgilidir[48].

[48] SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, N 459 ff; REY, I, N 296a; ZOBL, Grundbuchrecht, N 106 ff.

Tapu sicilindeki kayıtlar, tapu sicili kaydının yani kayıttaki hak sahipliğinin, hakların ve hakların niteliğinin ve kapsamının doğru olduğuna kanıt teşkil eder (TMK m. 7).

VI. TAPUYA GÜVEN (İTİMAT) İLKESİ

2430 Tapu sicilline güven ilkesi, tapu siciline güvenilerek yapılan iyiniyetli kazanımların korunmasını ifade eder (TMK m.1023)[45]. Başka bir deyişle, kamusal tapu sicilinde ayni hakkın aleniyet bulmuş maddi olgularına güvenerek üçüncü kişilerin iyiniyetli kazanımları istisnasız korunur[46].

2431 TMK m.3 II'e göre durumun gereklerine göre kendinden beklenen özeni göstermeyen kişi iyiniyet iddiasında bulunamaz[47]. Burada tapu sicilinin ortaya koyduğu hukuki görünüme olan güven korunur[48]. Doktrinde *tescilin olumlu hükmü* olarak da incelenen tapuya güven ilkesi aynı zamanda *tapu sicilinin olumlu etkisini* de ortaya koymaktadır. Bu ilkeye maddi aleniyet ilkesi ismi de verilmektedir[49].

2432 İyiniyetli hak kazanımlarının korunması ilkesi, aleniyet ilkesinin yansıması olan aleniyeti sağlayan araçların (tapu sicilinin, zilyetliğin) olumsuz etkisi olarak bu araçların maddi olgusunun hukuki sonuçlarıyla da yakından bağlantılıdır. Ayni hakların aleniyeti, taşınırlarda zilyetlik ve taşınmazlarda tapuya tescil ile temin edilmektedir. Şu halde doğal olan, bir taşınırı devralırken zilyedinin, taşınmazı devralırken de taşınmaz tapuda adına tescil edilmiş kimsenin ayni hak sahibi olduğunun kabul edilmesidir.

2433 İfade ettiğimiz hususlar gerçeği yansıtmakta ise sorun yoktur. Ancak taşınırı devreden kimse zilyet olsa dahi gerçekte aynı hak sahibi olmayan ya da devir yetkisi bulunmayan bir kimse, örneğin bir hırsız olabilir. Aynı şekilde, taşınmazı devraldığımız kimsenin de tapuda adına tescil bulunsa dahi gerçekte mülkiyet hakkı olmayabilir. Acaba taşınırlarda fiili duruma,

---

45 BGE 109 II 102 E.2; 93 II 290, 298. Konuya ilişkin Mahkeme kararları için bkz. YİBK., T. 27.12.1939, E. 1939/11, K. 1939/60. YİBK., T. 03.02.1943, E. 1942/7, K. 1943/8. YİBK., T. 08.11.1991, E. 1990/4, K. 1991/3. YİBK., T. 02.04.2004, E. 2003/1, K. 2004/1. YHGK., T. 17.01.2017, E. 2017/1231, K. 2018/35. YHGK., T. 28.06.1995, E. 1995/1-464, K. 1995/676.

46 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.60, 64. **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 94 vd., **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 66. Bu konuda bkz. **CANSEL, E.**, Tapu Siciline İtimat Prensibi, Ankara, 1964.

47 BGer 5C.301/2005 vom 17.02.2005. **ANTALYA/TOPUZ**, MH, §10, V, B.

48 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.65; **REY**, I, N.291.

49 **REY**, I, s.291.

taşınmazlarda ise tapu sicilindeki mevcut tescile güvenen kimsenin bu *iyiniyeti* korunacak mıdır? Türk Medeni Kanunu taşınmazlarda iyiniyeti mutlak olarak korumuş (TMK m.1023), taşınırlarda ise elden rıza dışı veya rıza ile çıkma bakımından bir ayrım yaparak iyiniyetin korunmasında sınırlı bir koruma kabul etmiştir (TMK m.988-990).

2434 Sonuç olarak bir ayni hakkın kazanılmasında, hakkın kazanılmasına engel olacak hukuki sakatlık veya eksikliği bilmeyen kişinin iyiniyeti bazı koşullarda korunur. Böylece ayni hak iyiniyet sayesinde hukuken kazanılmış olur. O halde ayni hakların kazanılmasında iyiniyet önemli bir role sahiptir.

2435 Kamusal nitelikteki tapu sicilinde ayni hakkın aleniyet bulmuş maddi olgularına güvenen üçüncü kişilerin iyiniyetli kazanımları istisnasız korunur (TMK m.1023)[54]. TMK m.3 II'e göre durumun gereklerine göre kendinden beklenen özeni göstermeyen kişi iyiniyet iddiasında bulunamaz[55]. Burada tapu sicilinin ortaya koyduğu hukuki görünüme olan güven korunur[56].

2436 TMK'nın "*Resmî belgelerle ispat*" başlığını taşıyan 7. maddesinde, "*Resmî sicil ve senetler, belgelediklerî olguların doğruluğuna kanıt oluşturur (f.1). Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, herhangi bir şekle bağlı değildir (f.2).*" düzenlemesine yer verilmiştir. Ayrıca TST m.5'te, "*Tapu sicili, Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.*" denilmektedir.

2437 Söz konusu bu düzenlemelere göre, tapu sicili, devletin yetkili organları tarafından ve yine devletin denetim, gözetim ve sorumluluğu altında tutulan resmî sicillerdendir. Buna bağlı olarak bu sicillerdeki bilgilerin yanlışlıkları ispat edilinceye kadar doğru ve tam oldukları kabul edilir[57].

2438 Belirtelim ki, devlet tarafından tutulan tapu sicilinde yer alan bilgilerin doğru olduğunu düşünmek ve buna göre işlem yapmak hayatın nor-

---

[54] BGE 109 II 102 E.2; 93 II 290, 298.

[55] BGer 5C.301/2005 vom 17.02.2005. Bkz. **ANTALYA/TOPUZ**, MH, §10, V.

[56] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.65; **LIVER**, SPR V/1, s. 311; **REY**, I, N.291; Üçüncü kişinin iyiniyeti sadece tapu kütüğündeki tescil yönünden korunmakta olup, sicil dışı unsurlar bu maddenin koruma kapsamı dışındadır (Y. 1. HD., 24.02.2009 T., 11502 E., 2327 K.).

[57] **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 242.

mal akışı içerisinde olduğu gibi ticari hayatta da olağan karşılanmaktadır. Fakat belirtelim ki, uygulamada daima tapu bilgilerinin doğru olduğu gerçek hak durumunu yansıttığı söylenemeyecektir. Burada ortaya çıkan en önemli sorun, gerçek hak durumunu yansıtmayan tapu sicilindeki bilgilere "*bu sicil devlet tarafından tutuluyor, resmi sicilde yazan bilgiler de doğrudur*" inancıyla işlem yapan kişilerin durumunun ne olacağıdır. Uygulamadan kaynaklanan sorunlar, tapu sicilindeki kaydın doğruluğuna güvenerek işlem yapan iyiniyetli kişilerin korunması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Aksi yönde getirilecek bir çözüm tarzı devletin yetkili organları tarafından tutulmakta olan sicillerin güvenilirliğini sarsar, bundan da iktisadi hayat ağır sarsıntılara maruz kalırdı[55].

2439 Tüm bu nedenlerle "*tapuya güven ilkesi*" kabul edilmiştir. Bu ilke, tapu sicilinde yer alan bir kayda iyiniyetle güvenerek ayni hak kazanan kişilerin, bu kayıt gerçek hak durumuna aykırı olsa dahi bu kazanımlarının korunmasıdır.

2440 TMK m. 1023 tapuya güven ilkesini "*Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.*" şeklinde ortaya koymuştur. Belirtelim ki, yukarıda da açıkladığımız gibi, bir ayni hakkın kazanılabilmesi için tapu siciline tescil şarttır. Tescilin ayni hakkı kazandırabilmesi için de geçerli olması zorunludur. Tescile dayanak teşkil eden hukuki sebebin (örneğin satış işleminin) geçersiz olması tescili yolsuz yapar ve yolsuz tescile dayanarak hak elde edilemez. Fakat TMK m. 1023, tapu sicilindeki yolsuz kayda güvenerek iyiniyetle ayni hak kazanan üçüncü kişiler bakımından önemli bir istisna kabul etmiştir. Bu tapu siciline güven ilkesinin bir sonucudur.

2441 Tapu siciline güven ilkesi mutlak bir ilke olmayıp bazı bakımlardan sınırlandırılmıştır. Buna göre, ilk sınırlandırma bu ilkenin hangi taşınmazlar bakımından geçerli olduğu, ikinci sınırlandırma, söz konusu ilkenin tüm tapu sicil unsurlarını kapsayıp kapsamadığı ile ilgilidir. Üçüncü sınırlandırma ise güven ilkesinin koruma altına aldığı hakkın türü bakımındandır.

2442 Birinci sınırlandırmaya göre tapu siciline güven ilkesi kamuya ait taşınmazları kapsamamakta sadece özel mülkiyete konu olabilen taşınmaz-

[55] Ayrıntılı bilgi için bkz. **ÖZÇELİK**, s. 32 vd.; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 348.

lar bakımından geçerli olmaktadır. Bunun anlamı devlete ait bir taşınmaza ilişkin tapudaki kayda dayanarak iyiniyetle hak kazanımı mümkün değildir. Örneğin; devlete ait bir orman arazisi özel bir şahıs üzerine bir şekilde tescil edilse bu tescil yolsuzdur. Üçüncü bir kişi o araziyi satın alıp mülkiyetine geçirse TMK m.1023 hükmünden yararlanamaz. Yani tapuya güvenerek hak kazandım iddiasında bulunamaz[59].

2443 İkinci sınırlandırma tapuya güvenin hangi unsurlar için geçerli olduğudur. Belirtelim ki, tapu sicilinin ana unsurlar ve yardımcı unsurlardan oluştuğunu yukarıda açıklamıştık. Buna göre güven ilkesi yardımcı unsurlar bakımından işlemez. Güven ilkesi kanaatimizce tapu sicilinin ana unsurları bakımından yani ana siciller bakımından uygulama alanı bulur. Fakat ana sicillerin tamamı bakımından da uygulama alanı bulmamalıdır.

2444 Düşüncemize göre, TMK m.1023 güven ilkesini ortaya koyarken tapudaki tescile güvenden bahsetmiş ayrıca ayni hak kazanımlarından söz etmiştir. Buna göre, tapuda işlem yapan kişiye tescil ve ayni haklar hususunda tam bir bilgi veren ve güvenin oluşmasını sağlayan siciller bakımından bu ilke geçerli olmalıdır. Bu hususta ön plana çıkan en önemli sicil tapu kütüğü ile kat mülkiyeti kütüğüdür. Bu iki sicil haricindeki unsurlar ayni haklar ve tescil bakımından yeterince açıklığı sağlamazlar. Bu nedenle tapu siciline güven sadece bu iki sicil bakımından kabul edilmelidir. Örneğin; bir kimse yevmiye defterine güvenerek TMK m. 1023 kapsamında ayni hak kazanamayacaktır[60].

---

[59] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 202; **UMAR**, s. 35 vd.

[60] Çifte tapu halinde güven ilkesinin uygulama alanı bulup bulmayacağı hususu ise doktrinde yoğun tartışmalara neden olmuştur. Çift tapu, bir taşınmazın mülkiyetinin aynı anda birden fazla kişi üzerine tescil edilmiş olması durumudur. Örneğin köydeki bir arazinin kadastrosu yapılırken önce A adına tapulama işlemi yapılmış, söz konusu arazi için tapuda ayrı bir sayfa açılmış, bir müddet sonra bir yanlışlık sebebiyle aynı yer B adına kaydedilmiş ve daha önceki tapu sayfasının kapatılarak iptal edilme işlemi yapılmamışsa söz konusu arazi hakkında iki farklı kişiye ait iki ayrı tapu sayfası ortaya çıkmış demektir. Ayrıntılı bilgi için bkz. **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s.204. Çifte tapu durumunda güven ilkesinin uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin beş görüş ortaya atılmıştır. Bir görüşe göre, iyiniyetli üçüncü kişi tapu kütüğünde her taşınmaz için tek kayıt bulunacağını kabul etmekte haklıdır. Buna göre, bir taşınmazla ilgili başkaca kayıt bulunup bulunmadığını araştırma zorunluluğu yoktur. Buna bağlı olarak hangi tapu kaydına güvenerek kazanım sağladıysa o kazanım korunur. İkinci görüşe göre, çift tapu durumunda TMK m.1023'e dayanmak mümkün değildir. Çünkü tapu sicili herkese açık olup kimse gerçek maliki gösteren sayfayı görmediğini iddia edemeyecektir. Üçüncü görüşe göre, çifte tapuya rağmen gerçek hak sahibinden yapılan kazanma geçerli sayılmalıdır. Çünkü aynı taşınmaz tapuda ayrı sayfalarda ayrı kişiler adına çift olarak kaydedilmişse, kayıt sahiplerinden hiçbiri güven ilkesinden yararlanamaz. Bu takdirde maddî hukuka göre gerçek hak sahibinden iktisap edilen ayni hak geçerli olur. Dördüncü görüşe göre, Dördüncü görüşe göre, yolsuz olan ikinci tapu kaydına dayanan iktisaplar korunmaz. Buna karşılık, kayıtlardan ikisi de doğru temele dayanıyor gözüküyorsa eski tarihli kayıt tercih edilir. Beşinci görüşe göre, çift tapu durumunda aynî hakkı dev-

2445 Üçüncü sınırlandırma ise, güven ilkesinin sadece aynî hakları koruma altına almasıdır. TMK m.1023 bu durumu açıkça ortaya koymuştur. O halde tapu sicilindeki kayıtlara iyiniyetle güvenerek bir nisbî hak kazanılması mümkün değildir.

2446 TMK m.1023 gereği, bir kimsenin tapu siciline iyiniyetle güvenerek aynî hak elde edebilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir[61]. Şöyle ki:

- *Tapu siciline güven sadece üçüncü kişiler için geçerlidir.* Güven ilkesi çerçevesinde *sadece üçüncü kişiler* aynî hak kazanabilirler. Buna göre, kazanımın korunması için, tapu sicilindeki yolsuz tescile güvenerek tesis edilmiş veya devredilmiş aynî hakkı kazanmış olan kimseler (örneğin taşınmazı satın alan kişiler) üçüncü kişi niteliği taşımalıdır[62]. Tescile dayanak teşkil eden sözleşmenin karşı tarafı veya onun küllî halefleri açısından güven ilkesi geçerli olmayacaktır[63].

Örneğin, ayırt etme gücünden yoksun olan A, taşınmazını B'ye satıp devretmiş olsa, B adına yapılan tescil yolsuzdur çünkü satış işlemi kesin hükümsüzdür. Böyle bir durumda B tapu sicilindeki kayda güvendiğini A'nın tapuda malik olarak gözüktüğünü, bu nedenle taşınmazın mülkiyetini kazandığını, tescilin geçerli olduğunu ileri süremez (B ölmüş olsa ve

---

reden kayıt sahibi aynı zamanda taşınmaza da zilyet bulunuyorsa, TMK m. 989/f.2 de yer alan, "*Bu taşınır, açık artırmadan veya pazardan ya da benzeri eşya satanlardan iyiniyetle edinilmiş ise; iyiniyetli birinci ve sonraki edinenlere karşı taşınır davası, ancak ödenen bedelin geri verilmesi koşuluyla açılabilir*" hükmünden hareket edilerek çözüme ulaşmak gerekir. Bu takdirde de gerçek ve mutebar tapu sahibinin, taşınmazını üçüncü şahıstan düzeltme davası yoluyla geri alabilmesi mümkün olacaktır. Böylece üçüncü şahsın ödediği satış bedelinin kendisine ödenmesi gerekecektir. Yargıtay ise, önceleri ikinci görüşü kabul etmiştir. Son kararlarına göre ise, kayıtların her ikisi de doğru olduğu takdirde "gerçek (doğru) temele dayanan eski (önceki) tarihli kayıt" tercih edilmeli ve sonraki tarihli kayda dayanan iktisaplar korunmaması gerektiğini düşünmektedir. Ayrıntılı bilgi ve tartışmalar için bkz. **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 377-378; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 206; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 270. Çifte tapu halinde ilk tapunun işlevini koruduğu ikinci tapuya değer verilmeyeceği hakkında bkz. Yarg. HGK., 06.06.1984, E. 1982/14-519, K. 1984/662; Yarg. 16. HD., 13.05.2004, E. 2004/5241, K. 2004/7286; Yarg. 16. HD. 18.05.2006, E. 2006/1014, K. 2006/3708; Yarg 17. HD. 07.11.2006, E. 2006/4576, K. 2006/8147; Yarg. 7. HD. 13.06.2007, E. 2007/1577, K. 2007/2210.

61 Ayrıntılı bilgi için bkz. **ÖZÇELİK**, s. 107 vd.; **YILDIRIM**, s. 87 vd.

62 **ESENER/GÜVEN**, s. 137-138.

63 **ANTALYA / SAĞLAM**, 53-54; **OĞUZMAN / SELİÇİ / OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 196-197; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 271; Bkz. Yarg. HGK 04.05.2011, E. 2011/1-8, K. 2011/263; Yarg. HGK. 26.1.1994, E.1993/1-792 K.1994/9; Yarg. 1. HD. 21.11.2008, E. 2008/7719, K. 2008/12192; Yarg. 1. HD. 24.02.2009, E. 2008/11502, K. 2009/2327: "*...davalının ise, ilk el olduğundan Türk Medeni Kanununun 1023 maddesinde öngörülen sicilin aleniliğinden (güvenildiğinden) istifade ederek iyiniyetli kişinin edinimlerinin korunacağı ilkesinden yararlanamayacağı tartışmasızdır.*".

taşınmaz mirasçıları adına tescil edilse bile aynı durum geçerlidir). Taşınmazın gerçek malikı halen A'dır. Fakat B adına yapılan tescilden sonra -ki bu tescil yolsuzdur- B taşınmazı C'ye satıp devretse daha sonra A bu taşınmazın kendi adına tekrar tescil edilmesini C'den talep edemeyecektir. Çünkü C, B adına yapılmış yolsuz tescile güvenerek taşınmazı satın almıştır. Tapu sicilini incelediğinde B'yi malik olarak görmüştür. Belirtelim ki, verilen bu örnekte B taşınmazı C'ye satmasaydı şartları varsa olağan (MK. m.712) zamanaşımı (10 yıl) ile taşınmazın mülkiyetini kazanabilir.

- *Koruma sadece tapu sicil kaydına dayanan kazanımlarda geçerlidir.* Üçüncü kişilerin sadece tapu kütüğündeki tescile ilişkin kayıtlara dayanması yeterlidir[64]. Tapuya güven ile ayni hak kazanılabilmesi için öncelikle tapuda yolsuz bir tescilin bulunması gerekir. Üçüncü kişinin şeklen var olan ama gerçek hak durumunu yansıtmayan tescile diğer bir ifadeyle yolsuz tescile dayanması gerekir. TMK m. 1024 f.2'de yolsuz tescil, "*Bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan veya hukukî sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur.*" şeklinde taraf edilmiştir. Bu nedenle üçüncü kişinin, sahte kimlik, sahte vekaletname veya sahte mirasçılık belgesi gibi sicil dışı unsurlara güvenmesi tapuya güven anlamına gelmeyecektir[65].

- *Koruma sadece ayni haklar için geçerlidir.* Üçüncü kişilerin sicildeki yolsuz tescile dayanan kazanımlarından sadece ayni haklar, yani mülkiyet, irtifak, taşınmaz yükü ve rehin haklarına dair kazanımları iyiniyet sayesinde korunur. Şerh verilmiş olsa dahi, sicil kaydına dayanarak kişisel hak kazanılması iyiniyet kapsamında korunmamaktadır[66].

---

[64] **ERTAŞ**. s. 192; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**. s. 190.

[65] Y. HGK. 04.05.2011 T., E. 2011/1-8, K. 2011/263: "*... Bu oluşuma göre, davalı tapu sicillerinin güvenilirliği ve aleniyetinden istifade ederek sicilden edinen kişi değil, sicilin dayanağı belgeden edinen kişi olup, ilk el konumundadır. Öyleyse davalının Türk Medeni Kanunu'nun 1023 maddesinin koruyuculuğundan yararlanma imkanı bulunmadığı da şüphesizdir.*". Y. 1. HD. 21.11.2008 T., E. 2008/7719, K. 2008/12192: "*... Davalılar taşınmazları tapu sicilinin aleniyet ve güvenilirlik ilkesinden değil, sicilin illetini teşkil eden geçersiz vekaletnameye dayanarak edinmişlerdir. Bu nedenle edinimleri yolsuz tescil hükmündedir. İyiniyet kuralından da yararlanamazlar.*". Y. 1. HD. 18.2.2014 T., E. 2013/20419, K. 2014/3473: "*... Öncelikle önceki kayıt maliklerinin davada yer almasının sağlanması, davalılar adına oluşan sicilin dayanağını teşkil eden belgelerin sahteliği konusunda hükme yeterli araştırma ve inceleme yapılması, mahkemece yapılacak araştırma neticesinde gerçekten davalılar adına oluşan sicil kaydının dayanağını teşkil eden belgelerin sahte olduğunun saptanması halinde, ilk el konumunda bulunanların TMK'nın 1023 maddesinin koruyuculuğundan yararlanamayacağının gözetilmesi ...*".

[66] Ayrıntılı bilgi için bkz. **ÖZÇELİK**. s. 107 vd.; **YILDIRIM**. s. 87 vd.; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**. s. 191.

Örneğin, gerçekte malik olmayan, sadece tapuda malik olarak görünen yolsuz tescil sahibi kimse ile kira, onalım, alım veya geri alım sözleşmesi yapılsa ve bu tapuya şerh edilmiş olsa dahi, söz konusu kişisel haklar gerçek malike karşı ileri sürülemez.

- *Ayni hakkı kazanan üçüncü kişi iyiniyetli olmalıdır.* TMK m.1024'te ayni hak kazanımının iyiniyetli olması gerektiği belirtilmiştir. TMK m.1024'te, "*Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş ise,* ***bunu bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi*** *bu tescile dayanamaz (f.1). Bağlayıcı olmayan bir hukukî işleme dayanan veya hukukî sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur (f.2). Böyle bir tescil yüzünden aynî hakkı zedelenen kimse,* ***tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya ileri sürebilir*** *(f.3).*

Ayni hakkı kazanacak üçüncü kişinin tapudaki tescilin yolsuz olduğunu bilmemesi ve bilebilecek durumda olmaması gerekmektedir (TMK m. 3)[67]. Önemle belirtelim ki, burada aranan iyiniyet *tescil anındaki*, diğer bir ifadeyle tescil talebinin yevmiye defterine kaydı esnasındaki iyiniyettir[68]. Dolayısıyla üçüncü kişi tescil anında iyiniyetli ise, mevcut tescilin yolsuz olduğunu sonradan öğrenmesi ayni hakkı kazanmasına engel değildir[69].

- *Üçüncü kişinin ayni hakkı kazanması için gerekli diğer geçerlilik şartlarının da var olması gerekir.* Şayet üçüncü kişi adına yapılan tescilin hukuki sebebi geçerli değilse ya da tescil talebinde bulunan kişinin ayırt

---

[67] Uygulamada, hakkı kazanacak olan kişinin karı - koca, kardeş, ana baba - çocuk, aynı mahalle veya köyde oturma, davacının kiracısı olma gibi taraflarla belirli bir yakınlık içinde bulunması kötü niyetine karine sayılmaktadır. Yargıtay'a göre, davalı ile akrabalık ilişkisinin bulunması veya tarafların aynı yerde oturmaları (ikamet etmeleri) yanında, taşınmazın el değiştirmesindeki çabukluk veya değerinin çok altında bir bedelle satılması da kötüniyetin ispatı açısından fiili karine teşkil eder. Bkz. Y. 7. HD. 16.9.1991 T., E.1991/12641 K.1991/11489; Y. 7. HD. 13.2.1998 T., E.1997/6325 K.1998/477; Y. 8. HD. 22.6.1998, E.1998/679 K.1998/7266 (www.kazanci.com.tr); Durumun gereklerine göre beklenen özeni göstermeyen kimsenin de iyiniyet iddiasında bulunamayacağı yönünde bkz. Y. HGK. T. 21.10.2015 T., E. 2015/2-247, K. 2015/2323. "... *Yükleniciden henüz inşaat halinde bulunan ve tamamlanmamış bağımsız bölüm satın alan üçüncü kişilerin yüklenicinin halefi sıfatıyla hareket ettikleri, dolayısıyla üçüncü kişilerin inşaatın tamamlanamaması durumunda yükleniciden satın aldıkları arsa paylarının iade edilebileceğini öngörmelerinin gerektiği ve bu sebeplerle üçüncü kişiler için TMK md 1023 hükmünün uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin* bkz. **ÇAVDAR**, s 415.

[68] **ERTAŞ**, s. 193; **ESENER/GÜVEN**, s. 136; *Y.23. HD., 29.5.2017 T., E. 2016/7256, K. 2017/1588.* "... *Buna göre, kendisinden beklenen özeni göstermeyen, tescilin yolsuz olduğunu bilen veya bilebilecek durumda olan üçüncü kişiler iyiniyet iddiasında bulunamazlar. Burada aranan iyiniyet, tescil isteminin yevmiye defterine kaydı esnasında mevcut olmalıdır...*". *Y. 23. HD. 23.11.2016 T., E. 2015/783, K. 2016/5155* "... *Burada aranan iyiniyet, tescil isteminin yevmiye defterine kaydı esnasında mevcut olmalıdır...*".

[69] Ayrıntılı bilgi için bkz. **ÖZÇELİK**, s. 107 vd.; **YILDIRIM**, s. 87 vd.; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 199.

etme gücü yoksa, üçüncü kişi adına yapılan tescil de yolsuz olacağından, üçüncü kişinin ayni hakkı kazanması iyiniyetli olsa bile mümkün değildir[70]. Diğer bir ifadeyle, tapu siciline iyiniyetle güvenen kişi lehine yapılmış olan tescilin ve bu tescile esas teşkil eden hukukî sebebin geçersizliğine yol açabilecek herhangi bir eksiklik bulunmamalıdır. Aksi takdirde, ikinci tescil de yolsuz olacağından, artık güven ilkesinin etkisini göstermesi beklenemez[71]. Örneğin: ayırt etme gücünden yoksun A taşınmazını B'ye satıp devretmiş, B adına tescil gerçekleşmiş, B de taşınmazı C'ye satıp devretmiştir. C'nin ayni hakkı kazanabilmesi için B ile yaptığı satış sözleşmesinin yani adına yapılan tescile dayanak teşkil eden hukuki sebebin geçerli olması gerekir. Örneğin, B taşınmazı mirasçılarından mal kaçırmak için gerçekte bağışladığı halde satış göstermişse muvazaa nedeniyle devir işlemi hükümsüz olacaktır[72]. Böyle bir durumda C, TMK m.1023'ten yararlanamayacaktır. Çünkü üçüncü kişinin (C'nin) kendi işlemi geçerli değildir.

2447 Şimdi tapu siciline güven ile bir ayni hakkın kazanılmasını son bir örnekle açıklayalım: (S) büyük bir site kurmak için geniş bir araziye ihtiyaç duyduğu için A'nın arazisini almak istemekte fakat A satışa yanaşmamaktadır. S, bir gün A'yı arayarak araziyi devretmez ise kızının yüzüne asit dökerek hayatını karartacağını söyler. Kendisine yöneltilen tehditlerden korkan A taşınmazı S'ye satıp devreder. Yapılan devir işlemi tehdit nedeniyle hükümsüzdür. S adına yapılan tescil de yolsuzdur. S, inşaata başlamak için ihtiyaç duyduğu parayı bankadan kredi çekerek karşılığında arazisini bankaya ipotek eder. A bir müddet sonra cesaretini toplayarak polise gider durumu anlatır ve taşınmazın tekrar kendi adına tescilini mahkemeden talep eder. Aynı zamanda da bankaya da dava açarak ipoteğin kaldırılmasını talep eder. Belirtelim ki, mahkeme arazinin mülkiyetini tekrar A adına tescilline yönelik karar verebilecektir. Fakat banka lehine kurulan ipcteğin kaldırılmasına karar veremeyecektir. Çünkü banka kredi verirken yaptığı tapu incelemesinde malik olarak S'yi göreceği için tapuya güvenerek lehine ipotek kurulmasını sağlayabilecektir[73].

---

[70] Ayrıntılı bilgi için bkz. **ÖZÇELİK**, s. 107 vd.; **YILDIRIM**, s. 87 vd.

[71] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 200; Ayrıntılı bilgi için bkz. **ÖZÇELİK**, s. 107 vd.; **YILDIRIM**, s. 87 vd.

[72] Mirastan mal kaçırma, muris muvazaası ve buna emare teşkil eden olgular hakkında bkz. **TOPUZ, M.**, Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaasının Varlığını Gösteren Emareler, Prof. Dr. İlhan ULUSAN'a Armağan, Cilt II, İstanbul 2016, s. 710 vd.

[73] Tapu sicilindeki yolsuz tescile güvenerek ayni hak kazanımına ilişkin başka uygulama örnekleri de verilebilir. Örneğin, ayni hak tapu dışı yolla kazanılmış olmasına rağmen hak sahibinin açık-

VII. TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLU OLMASI İLKESİ

A. Genel Açıklamalar

2448 Tapu sicilinin devletin denetim, kontrol ve sorumluluğu altında tutulduğunu daha önce belirtmiştik. Bu nedenle tapu sicilinin hukuka aykırı tutulmasından dolayı ortaya çıkan zararlardan da devlet sorumludur. TMK m.1007'de devletin sorumluluğu, "*Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur (f.1). Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder (f.2). Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür (f.3)*" şeklinde ortaya konulmuştur[74].

---

layıcı tescili yaptırmamış olmasına bağlı kazanımlar da söz konusu olabilir. Örneğin, taşınmaz maliki S ile alıcı A arasında yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi sonrası A'nın satım parasını ödemesine rağmen S tescilden kaçınırsa A'nın tescile zorlama davası açması mümkündür. Bu durumda mahkemenin A lehine vereceği karar taşınmaz mülkiyetinin mahkeme kararı ile ve tescilsiz olarak ona geçmesini sağlar (TMK m. 716) ve artık S tapuda yolsuz tescil sahibi durumundadır. İşte A adına verilmiş bir mahkeme ilamı olmasına rağmen, açıklayıcı tescil yapılmamış ve iyiniyetli Ü taşınmazı S'den devralmışsa, Ü'nün bu kazanımı korunur. Bir diğer örnek ise, sahte belgeye dayalı oluşan yolsuz tescile güvenen iyiniyetli üçüncü kişilerin kazanımı hallerinde gündeme gelebilir. Örneğin, bir taşınmazın sahte nüfus kaydı kullanılarak elde edilen sahte mirasçılık belgesine (veraset ilamı) dayanarak veya sahte vekaletname çerçevesinde devredilmesi durumunda devralanın tapuya güvendiğinden ve aynî hakkı kazandığından söz edilemez. Bu durumda taşınmazı devralan ya da lehine aynî hak tesis edilen kişi yolsuz tescil sahibidir. Fakat bu hâllerde adına yolsuz tescil bulunan kimseden iyiniyetle aynî hak kazanımı yine TMK m. 1023 çerçevesinde korunur. Bir başka uygulama örneği ise, hatalı idarî işleme dayalı oluşan yolsuz tescile güvenen iyiniyetli üçüncü kişilerin kazanımı hallerinde söz konusu olur. Örneğin, S'nin maliki olduğu taşınmaz yanlışlıkla A'nın bir başkasına olan borcu için ve A'nın taşınmazıdır diye cebrî icra vasıtasıyla satılmışsa, taşınmazı ihâle sonucu satın alan B'nin bu kazanımı korunmaz, o yolsuz tescil sahibidir. Fakat B'nin taşınmazı Ü'ye devretmesi ihtimalinde iyiniyetli Ü'nün bu kazanımı TMK m. 1023 kapsamında korunur. Yolsuz tescil bulunan taşınmazı tapu dışı yolla kazanan üçüncü kişilerin kazanımı hallerinde de kazanımlar korunabilmektedir. Örneğin, bir taşınmazda S'nin adı yazılı olmasına rağmen S geçerli bir hukukî sebep bulunmadığı için tapuda yolsuz tescil sahibi olsun. Şayet S bu taşınmazı A'ya satmayı vaad etmiş olmasına rağmen sonradan tescilden kaçınmışsa ve A ona karşı tescile zorlama davası açmış ve kazanmışsa, iyiniyetli olması koşulu ile A mahkeme ilamı ile mülkiyeti kazanır. Zira bu durumda mahkemenin kararı da tapu sicilindeki S adına mevcut kayda dayanmaktadır. Yolsuz olarak terkin sonrası iyiniyetli üçüncü kişilerin aynî hak kazanımı hallerinde de güven ilkesi işleyebilmektedir. Tapu sicilindeki kayıt mevcut tescille gerçeğe uymayabileceği gibi, tapuda yazılı bir aynî hakkın terkini de gerçeğe uymayabilir. Örneğin, S'nin maliki olduğu taşınmaz üzerinde R bankası lehine bir ipotek varsa ve bu ipotek yanlışlıkla terkin edilmişse, söz konusu terkin yolsuzdur. İşte S'nin bu hâliyle taşınmazı Ü'ye satıp devretmesi durumunda iyiniyetli Ü mülkiyet hakkını ipotek olmaksızın devralmıştır. Bu durumda Ü'nün kazanımı yine TMK m. 1023 kapsamındadır. Örnek ve açıklamalar için bkz. **ÖZÇELİK**, s. 107 vd.; **YILDIRIM**, s. 88 vd.

[74] Ayrıntılı bilgi için bkz. **SİRMEN**, Sorumluluk, s. 10 vd.; **ERTAŞ**, Sorumluluk, s. 45 vd.; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 447; **GÖRGEÇ**, s. 1185 vd. Y. HGK., 21.11.2012 T., E. 2012/5-512, K. 2012/822 "... *Tapu kütüğünün oluşumu aşamasındaki imar işlemleri ile tapu işlemleri bir bütün oluşturduğundan, bu kayıtlarda yapılan hatalardan Devletin sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Davacının, Devletin kusursuz sorumluluğundan kaynaklanan bir zararlarının oluştuğu ve bu zararın tazminini Devletten isteyebileceği, Devletin imar işlemleri sırasında elemanların ihmalinden kaynaklanan sorumluluğunun da TMK'nın 1007. maddesi kapsamında*

2449 Belirtelim ki, tapu sicilinin hukuka aykırı tutulması özellikler taşınmazlar üzerindeki ayni hak sahipleri bakımından büyük mağduriyetler oluşturabilmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tapudaki yolsuz tescile iyiniyetli olarak güvenen üçüncü kişiler ayni hak sahibi olabilmektedirler. Bu durumda gerçek hak sahipleri çoğu zaman mülkiyet haklarını yitirmekte veya sınırlı ayni haklar ile kayıtlanmaktadırlar.

2450 Ortaya çıkacak mağduriyeti bir örnekle açıklayalım: Emin ve Emine babalarından kalan iki daireyi kendi adlarına tescil ettirmek istemektedirler. Emine, kardeşine vekalet vererek söz konusu işlemleri yürütmesini istemiştir. Diyelim ki, tapu memuru dikkatsizliği sonucu iki daireyi de Emin adına tescil etmiş bulunsun. Durumun farkında olan Emin de taşınmazların ikisini de Ali'ye satıp devretmiş olsun. Böyle bir durumda Emine taşınmazın mülkiyetini kaybetmiş olacaktır. Emine tabi ki kardeşine karşı tazminat davası açabilecektir. Fakat taşınmazı geri alması mümkün olmayacaktır. Böyle durumlarda çoğu zaman kusurun kimde bulunduğu da tespit edilemeyecektir. İşte TMK m.1007 hükmü tapu sicilinin yanlış hukuka aykırı tutulmasından dolayı sorumlu olması en makul çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

B. Sorumluluğun Niteliği

2451 Tapu sicilinin hukuka aykırı tutulmasından dolayı devletin sorumluluğu kusursuz sorumluluk halidir. Belirtelim ki, devlet sadece ana sicillerin değil, yardımcı sicillerin hukuka aykırı tutulmasından doğan zararlardan da sorumludur. Bu sorumluluk zabıt (kayıt) defterinin tutulduğu yerler bakımından da geçerlidir. Ancak böyle bir sorumluluk için şu hususların varlığı gerekir:

C. Sorumluluk Koşulları

1. Tapu Sicili Hukuka Aykırı Olarak Tutulmuş Olmalı

2452 Devletin sorumlu tutulabilmesi için tapu sicil işlemlerinin yapılması ve yürütülmesine ilişkin kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık

---

olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu durumda, yerel mahkemenin bunu amaçlayan direnme kararı doğrudur...". Y. HGK., 08.10.2008 T., E. 2008/4-591, K. 2008/609 "... Dava, Medeni Kanun'un 1007. maddesi gereği Devlet'in tapu sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğuna yönelik tazminat istemine ilişkindir. Hukuksal dayanağını kusursuz sorumluluktan alan davada Devletin sorumluluğunun bir tehlike sorumluluğu olduğunun benimsenmiş olmasına; bilhassa tapu sicil müdürlüğü görevlilerinin kusurlu olup olmadığının araştırılmasına ya da kusurun varlığının ispatına gerek olmadığı gibi, esasen Devletin sorumluluğu için bu kusurun varlığı da şart olmayıp, tapu sicil müdürlüğünün hukuka aykırı eylem ve işlemleri ile zarar arasında illiyet bağı bulunduğundan bu zarardan Devletin sorumlu olduğu ilkesi kabul edildiğine göre: Yerel Mahkemenin, tapu sicilinin tutulmasıyla ilgili dava konusu işlemden doğan davacı zararından, davalı Hazinenin sorumlu bulunduğu yönündeki direnme kararı usul ve yasaya uygundur...".

bulunmalıdır[75]. Diğer bir ifadeyle, kasten veya bir ihmal sonucu yapılması gereken kaydın hiç yapılmamış olması ya da yanlış yapılması hâllerinde hukuka aykırı bir tapu sicili işlemi var demektir[76].

2453 Aynı şekilde, geçerli bir hukukî sebep mevcut olmadığı hâlde veya talep olmadan tescil yapılması, hak sahibi olmayan bir kişinin talebi üzerine aynî hakkın terkin edilmesi, yevmiye defterinde talebin kayıt tarihinin gösterilmemiş olması yüzünden aynî hakkın yanlış sıra alması, rehin hakkının zamanında tescil edilmemesi, ihtiyatî tedbir kararı tapu kütüğüne işlenmediği için taşınmazın devrine sebep olunması, vekilin azledildiğine ilişkin bildirimin azil sicilline işlenmemesi, taşınmazın vasıflarının yanlış gösterilmesi, paydaşların (müşterek maliklerin) isim ve hisse miktarlarının gösterilmemesi, tescilin sebebini oluşturan hukukî işlemlerin veya diğer resmî belgelerin özenli biçimde kontrol etmediği için, örneğin nüfus cüzdanının, vekâletnamenin veya mirasçılık belgesinin sahte olduğunu fark edememişse neden olduğu yolsuz tescillerden kaynaklanan zararlar açısından da devlet sorumlu olacaktır.

2. Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması Sonucu Bir Zarar Doğmalı

2454 Tapu sicilinin hukuka aykırı tutulması sonucu bir zarar doğmalıdır. Herhangi bir zarar bulunmadıkça tapu sicilinin yanlış tutulmasından Devlet sorumlu tutulamaz. Zararın varlığını ve miktarını davacının ispat etmesi gerekir[77]. Zarara uğrayanın birlikte kusuru tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınır. Şayet zarar, memurun kusurundan ileri gelmişse Devlet ödediği tazminat için o memura rücu imkânına sahiptir (TMK m. 1007 II). Belirtelim ki, fiilen gerçekleşmiş bir zarar yoksa sorumluluk

---

[75] ESENER/GÜVEN, s. 110.

[76] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 131; Y. 1. HD. 07.05.2002 T., E. 2002/3549, K. 2002/5807; Yarg. 4. HD. 28.10.2010, E. 2010/10142, K. 2010/10973; Orman kadastrosu gereğince orman sayılan yerler hakkında tapu kaydı oluşturmanın hukuka aykırı olduğu ve devletin sorumluluğu altında olduğu yönünde bkz. Y. 13. HD. 02.02.2010 T., E. 2009/3120, K. 2010/1096; Kadastronun gerçeğe aykırı yapılmasının hukuka aykırı olduğu yönünde bkz. Y. HGK. 16.06.2010 T., E. 2010/4-349, K. 2010/318; Yarg. 5. HD. 01.04.2014 T., E. 2013/24348, K. 2014/9133; Y. T. 5. HD. E. 22.12.2014, E. 2014/20879, K. 2014/31094. Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenen resmi senette taşınmazın tamamının davacıya satıldığı yer almaktayken, tapudaki tescilin taşınmazın yarısını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesinin hukuka aykırıda olduğu yönünde bkz. Y. 5. HD. 03.12.2013 T., E. 2013/12004, K. 2013/21500; Kaldırılmış bulunan vakıf şerhinin, sonraki zamanda yeniden şerh edilmesinin hukuka aykırı olduğu yönünde bkz. Y. 4. HD. 28.04.2005 T., E. 2004/10144, K. 2005/4534.

[77] ESENER/GÜVEN, s. 111.

da yok demektir[78]. Zarara uğrama tehlikesi mevcut olmakla birlikte bunu önleme imkânı varsa, yine devletin sorumluluğundan söz edilemez. Meselâ, açılacak bir tapu sicilini düzeltme (tapu iptali ve tescil) davasıyla (MK. m. 1025) hukuka aykırı tapu sicili işleminin ortadan kaldırılması[79] veya asıl borçlu aleyhine takip yapılması imkânı bulundukça devletin sorumluluğu yoluna gidilemez[80].

3. Zarar, Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğmuş Olmalı (İlliyet Bağı)

2455 Doğan zarar tapu sicilinin hukuka aykırı tutulmasından kaynaklanmıyorsa Devletin sorumluluğundan da söz edilemez[81]. Aynı şekilde sicilin tutulması hukuka uygun olmakla birlikte, sicildeki kaydın sonradan gerçekleşen bir nedenle (örneğin sicildeki kaydın toprak kayması, sel gibi nedenlerle tapuda yazılı vasıflara uymaması gibi) gerçeğe uymamasından bir zarar doğmuşsa, burada da Devletin sorumluluğuna gidilemez[82].

---

[78] **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 209; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 129; Y. 5. HD. 26.06.2012 T., E. 2012/5944, K. 2012/14076: Zararın bulunup bulunmadığı noktasında emsal taşınmazların piyasa değeri karşılaştırılması yapılması hususunda bkz. Y. 5. HD. 01.12.2014 T., E. 2014/14842, K. 2014/27931: zarar görenin gerçek zararının esas alınması gerektiği yönünde bkz. Y. 3. HD. 11.02.2013 T., E. 2012/18637, K. 2013/1877: Zararın içeriğine faizin de dahil edilmesi gerektiği yönünde bkz. Y. 4. HD. 09.02.2010 T., E. 2009/7135, K. 2010/1031.

[79] **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 452; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 209-210; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 129.

[80] **TEKİNAY / AKMAN / BURCUOĞLU / ALTOP**, s. 455.

[81] Y. HGK., 11.07.2007 T., E. 2007/4-422, K. 2007/536: "*Tapu müdür ya da memurunun, gerçek tapu maliki olmayıp, "ilgili" sıfatı taşımayan başvuru sahibinin imzasını taşıyan yazılı başvuru belgesini almadan ve sicildeki resimle bu kişinin ibraz ettiği sahte nüfus cüzdanındaki resmi ve kayıtları karşılaştırmadan, kayıp nedeniyle yeniden tapu senedi düzenleyip bu kişiye vermesi resmi senette soyismin yanlış yazılması ve ardından da temin edilen sahte vekaletnameye dayalı olarak sicile yolsuz tescil işlemini gerçekleştirmiş olması hukuka aykırıdır. Bu hukuka aykırı davranışla zarar arasında illiyet bağının varlığı belirgin olup; devlet bundan doğan zarardan sorumludur...*"

[82] **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 210; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 129-130. Devletin sorumluluğuna ilişkin bazı özel halleri ele almakta yarar vardır: Kadastroya dayanan tespitler sonucu tutulan tapu sicili sonucu sınır ve yüzölçümü eksikliği bulunmakta ise Devlet doğan zarardan sorumludur. Fakat zabıt defterine kayıtlı taşınmazlar kadastroya dayanmaksızın tahmini beyanlar sonucu teşekkül ettiğinden, bu konudaki tespitlerin hatalı olmasından Devlet sorumlu tutulamaz. **ERTAŞ**, Sorumluluk, s. 138-139. Ormanlar, meralar, yaylak ve kışlaklar gibi kamu malı niteliğindeki taşınmazlar özel mülkiyete konu olamazlar. Bunlar için kanuna aykırı olarak oluşturulan yolsuz tapu kayıtları konusunda, TMK m. 1023 çerçevesinde iyiniyetli üçüncü kişilerin iyiniyeti dahi korunmaz. Ancak bu kayıtlar nedeniyle zarar gören kimselerin uğradıkların zararın TMK m. 1007 uyarınca Devlet tarafından tazmini gerekir. Çifte tapu kaydının bulunması ihtimalinde TMK m. 1023 hükmü uygulanmadığından, gerçek hak sahibinin zarara uğramasından söz edilemez. Buna karşılık çifte kayda güvenen iyiniyetli üçüncü kişilerin uğradıkları zararın yine TMK m. 1007 hükmünce tazmini gerekir. TBK m. 504/II uyarınca taşınmazlar üzerinde tasarrufi işlemlerde bulunacak vekilin özel temsil yetkisinin varlığı aranır. Şayet tapu memuru böyle bir vekaletname bulunmaksızın genel vekaletnameye dayanarak bir işlem yapmışsa bu

2456 Belirtelim ki, devlete karşı davanın açılabilmesi tapu memurunun kusurlu olmasına bağlı değildir[23]. Devlet, tapu memurunun kusursuz olduğunu ispatlayarak sorumluluktan kurtulamayacağı gibi, kurtuluş kanıtı da getiremez[24]. Buna karşılık tapu memurunun kusuru, ilgilinin zararını tazmin eden devletin kendisine rücu etmesi bakımından önem taşır. Zira, *devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder*. Devletin sorumluluğu, hukukî niteliği bakımından bir *haksız fiil sorumluluğudur* ve mahiyetine uygun düştüğü ölçüde TBK 49 vd. maddeleri uygulanır. Devlet aleyhine açılacak tazminat davası bakımından da *genel haksız*

---

sebeple meydana gelecek zararlardan Devlet sorumludur. Bir kişinin kullandığı sahte vekaletname veya sahte veraset senedine dayanarak tapu memurunun yaptığı işlemden doğan zararlardan Devletin sorumlu tutulup tutulamayacağı tartışmalıdır. Hâkim görüşe göre bu nitelikteki bir belge sonucu tutulan tapu kayıtlarından doğan zararlardan Devlet sorumludur. Zira Devletin sorumluluğu kusursuz sorumluluk olup, kayıtların yanlış tutulmasına sebebiyet veren üçüncü kişilerin sahte belge ibraz etmeleri de tapu sicilinin yanlış tutulmasıyla zarar arasındaki illiyet bağını kesecek nitelikte değildir. Ayrıntılı bilgi için bkz. **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 279-280; Diğer bir görüşe göre ise böyle bir zarar tapu sicilinin hukuka aykırı tutulmasından ileri gelmemektedir. Meğer ki, sahteliği belli bir vekaletname veya veraset senedi kullanılmış olmasına rağmen tapu memuru bu konuda gerekli incelemeyi yapmayı ihmal etmiş olsun. **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 129; Yargıtay ise sahte vekaletname veya nüfus cüzdanının esas alınarak tescilin gerçekleştirilmesi durumunda, zarar ile tapuda yapılan hukuka aykırı işlem arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kararlar vermektedir. Bu yönde sahte vekaetname ile ilgili bkz. Y. HGK 11.07.2007 T., E. 2007/4-422; K. 2007/536; Y. 20. HD. 12.01.2016 T., E. 2015/11315, K. 2016/177; sahte nüfus cüzdanı ile ilgili bkz. Y. 4. HD. 26.02.2009 T., E. 2009/1913, K. 2009/2811; Y. 4. HD. 25.11.2010 T., E. 2010/12873, K. 2010/12062.

[23] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, 129, 131; Ayrıca bkz. Y. 5. HD., 01.12.2014 T., E.2014/14842 K.2014/27931; Y. 1. HD., 01.03.2012 T., E. 2012/1785, K. 2012/2199: "*... Yasanın bu açık hükmünün kaynak olduğu devletin sorumluluğu tapu sicilinin tutulması sırasında, sicil memurunun hukuka aykırı işlemi ile sonuç arasında nedensellik bağının varlığı gerekli ise de eylem ya da işlemin kusura dayanması gerekmez.*"; Y. HGK., 08.10.2008 T., E. 2008/4-591; K. 2008/609: "*... Devletin sorumluluğu için bu kusurun varlığı da şart olmayıp, tapu sicil müdürlüğünün hukuka aykırı eylem ve işlemleri ile zarar arasında illiyet bağı bulunduğundan bu zarardan Devletin sorumlu olduğu ilkesi kabul edildiğine göre; Yerel Mahkemenin, tapu sicilinin tutulmasıyla ilgili dava konusu işlemden doğan davacı zararından, davalı Hazinenin sorumlu bulunduğu yönündeki direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, yerindedir.*"; Y. HGK., 09.05.2007 T., E. 2007/4-212; K. 2007/261: "*... Devletin tapu sicilini çok düzgün tutması ve taşınmazların durumunu tespit ve tescil bakımından gerekli düzenlemelerin yapılarak açık hale getirilmesi konusuna büyük önem verilmiş, bu sicillerin devlet memurlarınca tutulmasından ileri gelecek bütün zararlardan dolayı vatandaşlara karşı feri değil, aynen İsviçre'de olduğu gibi asli bir sorumluluk yüklenmiştir...*"; Y. HGK., 11.07.2007 T., E. 2007/4-422, K. 2007/536: "*... Tapu sicil müdürlüğü görevlilerinin kusurlu olup olmadığının araştırılmasına ya da kusurun varlığının ispatına gerek olmadığı gibi, Devletin "tapu sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğuna" ilişkin olarak, kusursuz sorumluluk/ağırlaştırılmış sebep/ağırlaştırılmış objektif sorumluluk/tehlike sorumluluğuna ilişkin kurallar uygulanır...*"; Y. HGK., T.11.07.2007 T., E. 2007/4-422, K. 2007/536: "*... Tapu sicil müdür ya da memurunun kusuru olsun olmasın, tapu sicilinin tutulmasında kişilerin mameleki çıkarlarını koruyan hukuk kurallarına aykırı davranılmış olması yeterlidir. Kusurun varlığı ya da yokluğu Devletin sorumluluğu için önem taşımamakta, sadece Devletin memuruna rücuu halinde iç ilişkide etkisi söz konusu olmaktadır. Tapu sicilinin tutulmasında kişi çıkarlarının korunması bakımından uyulması gereken kurallar tapu mevzuatı ile sınırlı olmayıp, bu mevzuat dışındaki hukuk kurallarına ve hukukun genel ilkelerine de uyulması gerekmektedir...*"

[24] **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 458.

fiil sorumluluğuna ilişkin TBK. m.72'deki *zamanaşımı süresi* uygulanır[2458]. Yani, tazminat davasının *iki* ve *on* yıllık süreler içinde açılması gerekir.

2457 Devletin memuruna yapacağı rücu bakımından Tapu Kanunu'nda yeni bir düzenleme getirilmiştir. Tapu K.'nun "Rücu istemi" başlıklı Ek Madde 2'de, "(Ek: 10/9/2014-6552/84 md.) *Tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili olarak, Devletin kusursuz sorumluluğu sebebiyle yapılan ödemeler dolayısıyla, ikmali bulunan personel aleyhine başlatılacak rücu istemleri, ödeme tarihinden itibaren iki yıl, her hâlde zarara yol açan işlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ağır kusura dayalı sorumluluğu bulunan personel için 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 73'üncü maddesi hükümleri saklıdır.*" düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme ile rücu edilecek memurun kusurunun ağırlığına göre zamanaşımının farklılık arzettiği belirtilebilecektir.

2458 TBK m. 73'te ise, "*Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar (f.1). Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere bildirmek zorundadır. Aksi takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlar (f.2).*" düzenlemesine yer verilmiştir. Tapu Kanunu'ndaki düzenleme dikkate alındığında, ağır kusuru bulunan memurlar bakımından rücu isteminin tabi olduğu zamanaşımı daha aleyhe hükümler içermektedir.

[2458] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 132; GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 211; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOGLU/ALTOP, s. 460; Ayrıca bkz. Yarg. HGK., T. 21.4.1999, E.1999/1-222, K.1999/226.

§ 17. TAPU SİCİLİNDE YAPILAN TEMEL İŞLEMLERİ

I. KAYIT

A. Genel Açıklamalar

2459 Bir taşınmazın eşya hukuku kapsamında taşınmaz vasfı kazanabilmesi için kayıt işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Taşınmazların kaydedilmesi ana başlığını taşıyan TMK m. 998'e göre, "*Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir: 1. Arazi, 2. Taşınmazlar üzerindeki bağımsız ve sürekli haklar, 3. Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler (f.1). Arazinin tapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir (f.2). Bağımsız ve sürekli hakların kaydedilmesi için gerekli koşullar ve usul tüzükle belirlenir. Süreklilik koşulunun gerçekleşmesi için hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli olması gerekir (f.3). Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir (f.4).*".

2460 TMK m. 999'da ise, "Kaydedilmeyecek taşınmazlar" şu şekilde ortaya konulmuştur "*Özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescil: gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz (f.1). Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır (f.2).*".

2461 TMK'nın bu hükmünden de anlaşıldığı üzere tapulamanın konusunu taşınmaz oluşturur. Belirtelim ki, taşınmaz kavramı ile taşınmaz eşya kavramı farklı anlamlara gelmektedir. Şöyle ki, taşınmaz eşya ne kendi gücü ne de dışarıdan uygulanacak başka bir güç ile sınır ve özüne zarar gelmeden bir yerden başka bir yere taşınabilir. Taşınmaz kavramı ise,

---

TST m. 8/f.2'ye gore, özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması soz konusu olmadıkça kütüğe kaydolunmaz. Bunlar kendi özel sicillerine (kamu orta malları siciline) yazılırlar. Bu tür bir taşınmazın bir şekilde tapu kütüğüne kaydedilmesi, onun kamu mal olma niteliğine zarar vermez. Uygulamada en çok karşılaşılan durum, hukuk vasfı orman olan yerin bir kişi üzerine kaydedilmesidir. Belirtelim ki, boyle bir durum orayı orman olmaktan çıkarmaz. İdare, dava açarak kişi üzerine çıkarılmış tapuyu iptal ettirebilir. İlk başta ozel mülkiyet konusu olduğu için tapu kütüğüne kaydedilmiş bir taşınmaz daha sonra kamu malı niteliği kazanırsa, örneğin yola tahsis edilirse, onun da tapu kütüğündeki kaydının silmesi gerekir. Devlet veya kamu kuruluşlarının ozel malları niteliğindeki taşınmazları özel mülkiyete tabi olduğundan tapu siciline kaydedilirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 258-260.

hukuk düzeni tarafından tapu veya kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilmiş şey olarak ifade edilmektedir. Buna göre, tapu kütüğüne kaydedilmemiş arazi maddi niteliği itibariyle taşınmaz eşya olduğu halde, hukuki anlamda taşınmaz değildir[1].

2462 *Kayıt*, taşınmazların tapu kütüğünün bağımsız bir sayfasına yazılmasıdır. Diğer bir ifadeyle her taşınmaza diğerlerinden bağımsız bir tapu kütüğü sayfası tahsis edilmesine *kayıt* adı verilir. Belirtelim ki, nitelik olarak taşınmaz olan bir eşyanın hukuken de taşınmaz sayılması ve taşınmazlara ilişkin hükümlere tabi olması ancak o taşınmazın kaydı ile mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus *kanunun açıkça öngördüğü şeyler dışındaki bir hususun tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilmesi mümkün değildir*. Diğer bir ifadeyle tapuya taşınmaz olarak kaydedilecek şeyler sınırlı sayıdadır[2].

2463 Bağımsız ve süreklı haklar, kat mülkiyeti kurulması ve olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılması gibi istisnalar bir tarafa bırakılırsa, taşınmaz malların tapu kütüğüne kaydı (yazımı) "*kadastro (tapulama)*" neticesinde gerçekleşir. "*Kadastro*", taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarının devletin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından bilimsel esaslara uygun olarak plânlar içinde gösterilmesidir[3].

2464 Kayıt veya tapulama kelimelerinin biri geniş, diğeri dar olmak üzere iki anlamı vardır. Buna göre, geniş anlamda tapulama, bir taşınmazın geometrik, fiili ve hukuki durumunun gerek arazide gerek kağıt üzerinde belirlenmesi ile başlayan ve o taşınmazın tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına kaydına kadar devam eden ve kadastroyu da içine alan bir seri tapu işlem ve faaliyetler bütününü ifade eder.

2465 Örneğin, tapuya kaydı yapılacak taşınmazların belirlenmesi, bunlardan tapusuz olanlarının tapuya geçirilmesi, tapulu olanlarının tapularının yenilenmesi, tapulu olsun veya olmasın sınır, tür, yüzölçümleri ile geometrik şekillerinin tespiti, bunların plân ve haritalara işlenmesi ve nihayet bu şekilde tespit ve sınırlamaları yapılan taşınmazların tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına kaydedilmesi bu anlamda birer tapulama işlem ve faaliyetidir.

2

2466 Bu anlamda tapulama kelimesi kadastro kelimesi ile eş anlamlıdır. Dar anlamdaki tapulama ise, tapulama faaliyetleri sonunda bir taşınmazın tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına kaydı anlamında kullanılmaktadır. Bu anlamdaki tapulamada "kayıt" sözcüğü ile eşanlamlıdır[5]. Sonuç olarak, kayıt işlemi tapulama (kadastro) faaliyetinin finalize edilmesidir.

B. Tapuya Taşınmaz Olarak Kaydedilecek Şeyler

1. Genel Açıklamalar

2467 Tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilebilecek[6] şeyleri açıklamaya başlamadan önce kısaca taşınmaz kavramı üzerinde durmak, taşınırdan farkına dikkat çekmek ve kamuya ait mallar üzerinde durmak gerekir[7]:

---

5 ÜNAL/BAŞPINAR, s. 309.

6 Belirtelim ki, her taşınmaz tapu kütüğüne kaydedilemezler. Buna göre, Türk Medeni Kanunu 999 hükmüne göre özel mülkiyete tâbi olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazların, bunlara ilişkin tescili gerekli bir aynî hakkın kurulması söz konusu olmadıkça tapu siciline kaydedilmeleri mümkün değildir. Burada kastedilen özel mülkiyete tâbi olmayan kamu malı niteliğindeki taşınmazlardır. Bu konuda temel düzenleme olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 16, kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere ilişkin tesptin ne şekilde yapılacağını düzenleme konusu yapmaktadır. Tapuya kaydedilemeyecek taşınmazlar şu şekilde açıklanabilir: **1. Kamu hizmet malları**: Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmî bina ve tesisler (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgah, cami, genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur. **2. Kamu orta malları**: Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmaz mallar sınırlandırılır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmaz mallar özel siciline yazılır. Fakat bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu şekilde belirlenen taşınmaz mallar, özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete konu teşkil etmezler. Yol, meydan, köprü gibi orta malları ise haritasında gösterilmekle yetinilir. **3. Sahipsiz mallar**: Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescile tâbi değildir. **4. Ormanlar**: Kadastro Kanunu 16/D hükmüne göre özel kanun hükümlerince tescili öngörülen ormanların tapuya kayıt esasları 6831 sayılı Orman Kanunu ile belirlenmiştir. Ayrıca ormanlar, orman kadastrosu sonucu oluşturulan haritalarda gösterilir.

Türkiye'de ormanlara ilişkin ilk düzenleme 1274 (1858) tarihli Arazi Kanunnamesi, kısaca Arazi Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanuna göre ülke toprakları beş kısma ayrılmıştır. **1- Mülk arazi**: Üzerinde şahıslar lehine mülkiyet hakkı kurulmuş olan arazilerdir. Bu arazilerin malikleri taşınmazın hem kendisine hem de menfaat mülkiyetine sahiptirler; bir başka deyişle arazinin gerek kuru mülkiyeti gerek menfaat mülkiyeti malike aittir. **2. Miri arazi:** Ülke topraklarının ikinci türünü oluşturmaktadır. Bu tür toprakların kuru mülkiyeti devlete ait olup menfaat mülkiyeti fertlere bırakılmıştır. **3. Sahih vakıf arazileri**: Sahih vakıf araziler Osmanlı arazi türlerinin üçüncüsünü oluşturur. Bu tür arazi, bir kimsenin mülkiyeti kendisine ait bir araziyi vakfa tahsis ederek onu tedavülden kaldırmasıyla, yani onun serbest piyasada alım-satımını yasaklamasıyla meydana gelmektedir. **4. Terkedilmiş arazi:** Bu tür arazi Devlet tarafından kamunun kullanımına ve yararına bırakılmış olan arazidir. **5. Ölü arazi:** Ölü arazi ekime ve dikime elverişli olmayan ve üzerinde

2468 Özel hukuka tabi tüm eşyalar, toplumsal yaşam ilişkilerine konu olabilir. Başka bir deyişle özel eşya hakkın konusu (objesi) olabilir; özel hukuk işlemine konu olabilir ve üzerinde tasarruf edilebilir. Kamu mülkiyetine tabi eşyalar ise, üzerinde ya hiç toplumsal yaşam ilişkilerine konu olmaz ya da sınırlı olarak bu türden ilişkilere konu olur.

2469 TMK m. 715 I hükmü, "*...yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.*" düzenlemesi ile TMK m. 715 II hükmü ise, "*Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, özel hukuk kişisinin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz.*" düzenlemesi ile genel mallarla ilgili karine yer vermektedir.

2470 TMK m.715 III ise, yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tabi olduğu ifade etmiştir.

2471 Kamu malları, kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal amaçlarının yerine getirilmesine hizmet eden ya da kamunun kamusal ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan maddi varlıklardır[5].

2472 Bir malın kamu malı olup olmadığı, mülkiyet ilişkisine, özellikle ilişkinin tarafına bakarak belirlenmez; maddi varlığın amacının belirlenmesiyle tespit edilir[6].

2473 Maddi varlık kamusal bir amacının yerine getirilmesine, kamusal bir fonksiyonun veya görevin yerine getirilmesine hizmet ediyorsa, kamu

---

nebat bulunmayan ve yetişmeyen arazilerdir. Ancak bu tür araziler ihya edilerek üzerinde ağaç ve bitki yetiştirilerek fertler tarafından temellük edilebilir ve bu suretle nitelik değiştirerek mülk arazi haline getirilebilir. Halen yürürlükte bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu m. 4'e göre ormanlar, mülkiyet ve idare yönünden 3 kısma ayrılmaktadır. Bunlar, devlet ormanları, kamu tüzelkişilerine ait ormanlar ve özel ormanlardır. Bkz. **ÜNAL, M./BAŞPINAR, V.,** Orman Hukuku, Güncellenmiş ev Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2017, s. 8-9, 38.

Belirtelim ki, mülga Medeni Kanun döneminde tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilen şeylerden biri de madenler idi. Madenlerin taşınmaz olarak tapuya kaydını öngören hüküm Medeni Kanundan çıkarılmıştır. Böylece, madenler Medeni Kanun anlamında artık taşınmaz olma niteliğini kaybetmişlerdir. 3213 sayılı Maden Kanunu tapu sicilinden ayrı, fakat ona benzer bir maden sicilinin de tutulmasını öngörmüş bulunmaktadır (Mad. K. m. 38). Maden sicili, madenler ile ilgili işletme ruhsatları ve ilgili hakların (buluculuk hakları arama ve bunlara ait işletme izinleri vs.) ve bu hakların devir ve intikali, sona ermesi, haczi, rehin ve ipotek edilmesi gibi hallerin kaydedildiği özel bir sicildir.

[4] Ayrıntılı bilgi için bkz. **ANTALYA,** EH I, N. 155 vd.

[5] **MEIER-HAYOZ,** BK Syst. Teil N.177 f., **WIEGAND,** BSK ZGB Vorb. Art 641 N.39.

[6] **RENTCH,** ZBGR 1980, s.339.

malı niteliği söz konusudur[11]. Dar anlamıyla kamu malları ikiye ayrılır: idarenin kamusal malları ve idarenin genel malları[12]. Geniş anlamıyla kamu malları içine bu ikisine ilaveten kamu finans malları da ilave edilmektedir[13].

2474 Bu kapsamda örneğin, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik[14] çıkarılmıştır.

2475 Kamu malları üzerindeki tasarruf, kamu hukuku kurallarına tabidir. Kamu malları, kamu hukukuna dair mülkiyet kurallarına tabidir. Kamu hukuku kuralları, malı kullanma yetkisini ve kullanma amacını belirler. Ancak kamu malları tasarrufu konusunda bir kamu kuralı bulunmaması durumunda, özel hukuk kuralları, özellikle TMK'nın eşya hukuku kuralları, niteliğine uygun olduğu ölçüde kıyasen uygulanır.

2476 Kamu mallarının mülkiyetinin kapsamı da kamu kuralları tarafından belirlenir. Bu kurallar, kamu malının hizmet ettiği amacın ve kamu ödevinin yerine getirmesi kapsamına göre kamu mallarının kapsamını belirler; ve yine bu kurallar şekilde yorumlanır[15].

2477 İdarenin özel mülkiyete tabi eşyası da söz konusu olabilir. İdarenin kamu malı dışındaki eşyaları özel hukuk hükümlerine tabidir. Buna ilaveten kamu malı maliki olan idare, malik sıfatıyla TMK m. 730 hükmü uyarınca sorumludur; TBK m. 69 OR Art. 58 uyarınca yapı malıki olarak so-

---

[11] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.178.

[12] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.1177 f.; İsviçre hukukunda kamu mallarının düalist yapısı için Bkz. **HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN**, N. 1847 ff.

[13] 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Taşınır ve Taşınmaz Satışı" başlıklı 46'ncı maddesinde "*Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir...*" hükmü yer almaktadır. Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması amacıyla tahsisin kaldırılması ve satışı, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la düzenlenmiştir. Özel kanunlarla verilen yetkiler dışında, kamu (Hazine) malları konusunda genel yetkili kuruluş Milli Emlak Genel Müdürlüğü'dür.

[14] R.G. 19.06.2007.

[15] **LIVER**, SPR V/1, s.131

rumludur[16]. Özel hukuka tabi bir taşınmazın kamulaştırma ile kazanımı (TMK m.705) veya kamu taşınmazı üzerindeki bir hakkın tapuda devri sözleşmesi de özel hukuk şekil kurallarına tabidir (TMK m.706)[17].

2478 İdarenin yani kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş ve hizmet amacının yerine getirilmesine hizmet eden kamu mallarıdır. Bunlara 'kamu yönetim malları' da denmektedir. Kamu mallarına taşınmaz eşya örneği olarak: valilik gibi yönetim binaları, hastane binaları, okul gibi hizmet binaları veya taşınır eşya örneği olarak araç, büro masası, ameliyat malzemesi veya ilaç, sıra ya da kitap olabilir. Bu kamu mallarının kullanım kapsamı da amaçları ve amaçta belirlenen ödevleri yerine getirmeyle sınırlıdır. Kamu malları, kamu finans mallarından farklı olarak, özel hukuka konu olamaz. Örneğin kamu malları rehin edilemez; üzerlerinde inşaatçı ipoteği kurulamaz[18].

2479 Dini yerlerden idarenin ibadete tahsis ettiği yerlerden örneğin cami, şadırvan, abdesthane, mescit vb. idarenin kamu mallarıdır. Buna karşın dini vakıfların, özel hukuk kişilerinin ibadete tahsis ettiği yerler ise, özel hukuk hükümlerine tabidir.

2480 Genel mallar kamu amaçlı olarak herkesin kullanımına ve yararlanmasına açık olan mallardır. Kamunun yararlanması, yararlananın onun maddesel varlığına müdahale hakkı vermez. Bu yararlanma, kamusal yararlanma kapsamından ve onun belirlediği sınırlar içinde gerçekleşir. Genel maldan herkesin yararlanması kamu idaresinin rıza veya iznine bağlı olmadığı gibi, bedelsizdir[19]. Özel ve genel nitelikli ortak mal kullanımı idare tarafından ücretlendirilebilir[20].

2481 Genel malların bir kısmında, kamuda herkesin kullanımı söz konusudur. Örneğin caddeler, köprüler, meydanların herkes tarafından kullanılması gibi. Diğer kısmı ise *tabiat varlıklarıdır*; örneğin dağ, tepe ova, plato, orman, buzullar, bunlardan çıkan kaynaklar vb. veya *kamu sularıdır*, örneğin göller, nehirler, akarsular, dereler, yeraltı suları vb.[21]. Genel mal-

---

16 **ANTALYA**, BH GH II, s. 307 vd.

17 **MEIER-HAYOZ**, BK ZGB Art.644, N.83; **HAAB**, ZK ZGB Art.664, N.27.

18 BGE 108 II 305 ff; 124 III 337 f.

19 **HAAB**, ZK ZGB Art.664, N.7; **HEBERLEIN/BREITSCHMID/BELSER/RIEDER**, CHK ZGB Art.664, N.8.

20 **HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN**, N.2392.

21 **REY**, BSK ZGB Art.664, N.11 f.

lar mülkiyet konusu olmasa da tabiat varlığı olan araziden tarıma elverişli olan yerlerin mülkiyete konu olması mümkündür[22]. TMK m.715 II hükmü tarıma elverişli olmayı, arazilerin mülkiyete konu olabilmesi noktasında bir istisna olarak düzenlemiştir.

2482 Kamu malları içinde değerlendirilen kamu finans malları ise sermaye değeri veya onun getirisi olarak kamusal amacın yerine getirilmesine hizmet eden kamu mallarıdır. Kamu finans malları sermaye, değişim getirisi olarak umuma açık olan ve doğrudan kamusal amaç ve bu amaçta belirtilen ödevin yerine getirilmesine hizmet etmeyen mallardır. Devlet tahvilleri, hazine bonoları, tasarruf bonoları, gelir ortaklığı senetleri gibi kamu menkul değerleri, kamu finans mallarına örnek olarak gösterilebilir. Bu kamu finans malları dış ilişkide, özel hukuk hükümlerine tabidir[23].

2483 Bu mallar üzerinde sınırsız olarak tasarruf edilebilir[24]. Buna karşın idarenin özel hukuk alanındaki faaliyetleri, örneğin bankacılık faaliyetleri, kanunla kurulsa veya ondan kaynaklansa da doğrudan kamusal bir ödeve ve amaca hizmet etmediğinden özel hukuk hükümlerine tabidir. Mülkiyeti özel hukuk tüzel kişisinde olan bir eşya, kamusal amaçlı olarak bir kamusal ödevin ifasında kullanılsa bile, örneğin üniversite vakıflarının malları, dini vakfın malları, özel hukuk hükümlerine tabidir.

2484 Kamu yararı amacıyla bir eşyanın üzerindeki tasarruf ya da yararlanma, sınırlanabilir veya kaldırılabilir[25]. Bu sınırlama savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi olağanüstü kamu düzeni sebeplerine dayanabilir; askeri savunma ve güvenlik amaçlı olabilir. Yine ormanların, meraların, çevrenin, kültür ve tabiat varlıkları vb. korunması amacına yönelik olabilir. İmar, inşaat ve şehircilik amaçlı olabilir. Yabancıların, özellikle ülke sınırları içinde taşınmaz devralması sınırlandırılmıştır[26].

2485 Bir eşya, taşınmaz mülkiyeti konusuna girmiyorsa ve bulunduğu arazi ile sıkı surette bağımlı bulunmuyorsa, konusu ve nitelikleri bakımından

---

22 Bkz. **MEIER-HAYOZ**, BK ZGB Art.664, N.148 f.

23 Ayrıntılı bilgi için bkz. **HEBERLEIN/BREITSCHMID/BELSER/RIEDER**, CHK ZGB Art.664, N.7. Ayrıca bkz. **HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN**, N.1843.

24 **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil N.83; **REY**, Syst. Teil, N.207.

25 **REY**, I, N.194 ff.

26 2012 yılı Bakanlar Kurulu kararına göre, sit alanlarında, sit alarını belirleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüğünden izin alınması gerekir. Adalardaki taşınmazlarda, çişleri Bakanlığından izin alınması için talep yazı

özüne zarar gelmeden başka bir yere nakledilebiliyorsa veya hukuk kurallarınca taşınır olarak belirlenmişse bu eşya, taşınır eşyadır. TMK m.762'de taşınırın konusunu belirleyen hükmünde taşınır kavramını tanımlamıştır. Taşınmaz mülkiyetinin konusu ise TMK m.704 hükmünde tek tek sayılmıştır. Ayrıca TMK m.998 taşınmaz mülkiyeti konusu olabilen taşınmaz eşyaları, tapu kütüğüne kaydedilebilecek taşınmaz olarak tekrar saymıştır: Arazi, Kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya kaydedilebilen bağımsız ve sürekli haklar, Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.

2486 Yukarıda sayılanlar arasında arazi, taşınmazın tipik konusunu oluşturur[27].

2487 Taşınmaz eşya olarak sayılan eşyalardan hareketle, taşınmaz eşya ise, konusu ve nitelikleri bakımından özüne zarar gelmeden başka bir yere nakledilemeyen, hukuk kurallarının taşınmaz olarak belirlediği eşyalardır.

2488 Taşınır ile taşınmaz ayrımının temelini, eşyanın bir yerden diğer bir yere taşınması (nakledilmesi) oluşturmaktadır. Taşınır eşyanın bir yerden başka yere naklı, onun doğal niteliği sonucu gerçekleşebileceği gibi bir dış güç marifetiyle de gerçekleşebilir; bu farklılık taşınır-taşınmaz ayrımı yönünden önemli değildir. Bazı taşınırlar da taşınmazla olan ilişkileri sebebiyle taşınmaz hükümlerine tabi kılınmıştır[28]. Örneğin araziye sahip olan o şeyin bütünleyici parçası olan taşınırlarında malikı olur (TMK m.684). Aynı şekilde, TMK 685 III'e göre doğal ürünler asıl şeyden ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçasıdır. Eşyanın nakledilmesi veya nakledilememesi temel kriteri yanında, örneğin TMK m.762, edinmeye elverişli şeyleri örneğin, doğal güç ve enerjiyi de taşınır olarak belirlemiştir. Aynı şekilde TMK m.704 daimi ve sürekli hakkı tapu kütüğüne kaydedildiğinde taşınmaz olarak kabul etmiştir. Yine niteliği tartışmalı olan kat mülkiyetine kayıtlı bağımsız bölüm, taşınmaz olarak kabul edilmiştir. Öyleyse, nakledilebilme kriteri yanında eşyaya, onun fonksiyonuna uygun olarak, kanun koyucunun yüklediği nitelik de önemlidir. Kanun koyucunun nitelemesi de eşyanın nitelik ve özeliğine en yakın veya kapsam itibarıyla da düzenlemenin temel -taşınır veya taşınmaz- ayrımına uygun nitelemedir. Bu niteleme toplumsal ilişkilerin sosyal ve ekonomik dinamiğine de uygundur.

---

[27] MEIER-HAYOZ, BK Syst. Teil N.170.

[28] HAAB, ZK Einl., N.27.

2489 Diğer özel kanunlarda da, örneğin İİK m.23 ve 136 hükmünde niteliği taşınır olan gemiyi, taşınmaz hükmüne tabi tutmuşken, 6103 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası İİK m.23 son fıkrasında gemi bu kanun yönünden taşınır hükümlerini tabi tutmuştur. TTK m.954 ve devamında gemiler taşınmaz hükümlerine benzer (örneğin özel bir gemi sicilinin varlığı) şekilde düzerlemiştir.

2490 Şimdi tapuya taşınmaz olarak kaydedilecek şeylere geçelim:

2. Arazi

2491 Tapuya taşınmaz olarak kaydedilebilecek şeylerin başında araziler gelir. TST m. 9'da, *"(1) Arazi, sınırları hukukî ve geometrik yöntemlerle belirlenmiş yeryüzü parçasıdır. Arazinin tapu siciline kaydı, özel kanun hükümlerine tâbidir."* düzenlemesi yer almaktadır. Sınırları belirlenip tapu kütüğünün bağımsız bir sayfasına kaydedilmiş (yazılmış) arazi parçası ise "*parsel*" adını alır[25].

2492 Belirtmek gerekir ki, arazi sadece bir zeminden yani eni ve boyu olan bir yeryüzü parçasından, bir alandan ibaret değilcir. Onun yerin altına ve üstüne doğru devam eden bir de derinliği, yani dikey boyutu vardır. Bu boyut malikin faydalanabileceği yerin altına ve üstüne kadar devam eder. Buna göre arazi kavramı sadece eni ve boyu olan yatay bir alanı değil, aynı zamanda derinliği ve yüksekliği de bulunan üç boyutlu bir hacmi ifade etmektedir[26].

3. Kat Mülkiyetine Tabi Bağımsız Bölümler

2493 Tamamlanmış bir yapının ayrı ayrı kullanılmaya elverişli bölümleri üzerinde bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir (KMK m.1). Bütünleyici parça (mütemmim cüz) kuralının istisnası olarak, bağımsız bölümler üzerinde kurulan bu mülkiyete "*kat mülkiyeti*" adı verilir.

2494 Üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş olan ana taşınmazın tapu kütüğündeki kaydı bu durum belirtilerek kapatılır. Kat mülkiyetine konu bağım-

---

[25] **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s.192, 194-195; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 245. Arazinin bütünleyici parçası durumundaki şeyler, örneğin arazinin üstünde veya altında inşa edilmiş yapılar taşınmaz niteliğinde olsalar bile ayrı bir sayfa açılmaz. Bilindiği üzere, bütünleyici parça asıl eşyanın hukukî geleceğine tâbidir olup asıl şeye malik olan bunlara da malik olur. Söz konusu şeyler, sadece arazinin kayıtlı olduğu tapu kütüğü sayfasının "taşınmazın nitelikleri (vasıfları)" kısmında belirtilirler.

[26] **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 312-313.

sız bölüm ise, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına veya kat mülkiyeti zabıt defterine o bölüme ait arsa payı da gösterilmek suretiyle kaydedilir[2]. Böylece, kütüğe kaydedilen her bölüm bağımsız bir taşınmaz niteliği kazanır ve ayn ayrı aynî haklara konu oluşturabilir (KMK. m. 13).

2495 Kat mülkiyetine konu bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kaydı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine tâbidir (TMK m. 998 son). Buna göre kat mülkiyeti resmî senetle ve tapu siciline tescil ile doğar (KMK m. 10 I).

2496 Kat mülkiyeti kurulan taşınmazlarda, kat mülkiyeti konusu olan her bağımsız bölüm için kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfa açılır. Kat mülkiyeti kurulduktan sonra parselin kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine "Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir" ibaresi yazılarak, sayfa parselin leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılır. Ayrıca kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve parselin kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir. Bu durumda parselin kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır (KMK m. 13 II).

2497 Kat mülkiyetine çevrilmiş parsel sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, irtifak hakları hariç, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir. Kat mülkiyetine çevirme işleminden sonra, parselin leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları da o parsel tapu kütüğü sayfasına tescil edilir ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde de ayrıca belirtilir (KMK m. 13 III).

2498 Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir taşınmaz niteliğini kazanır ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alır (KMK m. 13 IV). Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir (KMK m. 10 III). Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu

[2] GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 203.

Sicili Tüzüğündeki formüle göre, ayrıca tutulacak Kat Mülkiyeti Zabıt Defterine tescil olunur (KMK m. 11 II).

4. Bağımsız ve Sürekli Haklar

2499 Bağımsız ve sürekli haklar taşınmaz üzerinde kurulmuş bazı irtifak haklarıdır[22]. Ancak, bir irtifak hakkının tapu sicilinde taşınmaz olarak kaydedilebilmesi için hakkın bağımsız ve sürekli nitelikte olması gerekir. Hakkın bağımsız olması demek, irtifak hakkının el değiştirmesi mümkün olacak şekilde belirli bir kişi lehine kurulmuş bulunmasını ifade eder. İrtifak hakkı bir taşınmaz lehine veya el değiştirmesi mümkün olmayacak şekilde belirli bir kişi lehine kurulmuşsa, artık hakların bağımsızlığından söz edilemez. Dolayısıyla, tapu sicilinde taşınmaz olarak kaydı da yapılamaz. Örneğin taşınmaz lehine kurulan bir irtifak ile kişi lehine kurulabilen intifa ve oturma hakları bağımsız olmadığından tapu sicilinde ayrı bir sayfaya kaydedilmezler[23].

2500 Hakkın *sürekli olması ise* hakkın süresiz veya en az otuz yıl süreli olması gerekliliğini ifade eder.

2501 TST m. 10'da, *"(1) Süresiz veya en az otuz yıl süreli olan ve tasarrufları kısıtlanmayan ve izne tâbi kılınmayan bağımsız ve sürekli irtifak hakları, hak sahibinin yazılı istemi üzerine tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına taşınmaz olarak tescil edilir. (2) Tapu kütüğüne taşınmaz olarak tescil edilen bağımsız ve sürekli haklar, üçüncü kişilere devredilebilir, mirasçılara geçebilir ve üzerinde her türlü aynî veya kişisel hak kurulabilir." şeklinde düzenleme mevcuttur.*

2502 Tapu sicilinde kayıt işleminin yapılmasıyla birlikte, artık söz konusu irtifak hakları bağımsız birer taşınmaz niteliğini kazanırlar. Teknik anlamda taşınmazlara ilişkin kurallar kıyasen bunlara da uygulanırlar. Dolayısıyla bunlar, ilişkili bulundukları taşınmazın mülkiyetinden bağımsız olarak hukukî işlemlere konu yapılabilirler. Sağlararası veya ölüme bağlı tasarruflarla başkalarına devredilebilecekleri gibi, miras yoluyla da intikal ederler. Üzerlerinde mahiyetlerine aykırı düşmeyen sınırlı aynî haklar ve alacak hakları kurulabilir. Taşınmazlar gibi icra işlemlerine konu yapılabilir.

---

[22] HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s. 374-375.

[23] TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP s. 246; HATEMİ/SEROZAN/ARPACI s. 374.

2503 Örneğin üst hakkı söz konusu ise, arazinin altına ya da üstüne yapılmış olan inşaat araziden bağımsız olarak üst hakkı sahibinin mülkiyetine girer ve sanki bağımsız bir taşınmaz gibi taahhüt ve tasarruf işlemleri yapabilir.

2504 TMK m. 838 hükmünde düzenlenen diğer irtifaklar kural olarak devredilmeleri ve mirasçılara intikali mümkün olmayan irtifaklardandır. Fakat sözleşme ile bunun da aksinin kararlaştırılması mümkündür. Şu hâlde, sözleşme ile bu hakların devri imkânı kabul edilmişse, hak bağımsız nitelik kazanacağından, diğer şartların da varlığı hâlinde bunların tapuda ayrı sayfaya kaydedilmeleri mümkündür.

2505 İrtifak hakkı bağımsız ve sürekli özellik taşısa dahi re'sen ayrı sayfaya kaydı mümkün değildir. Tapuda ayrı sayfaya yapılacak kayıt için irtifak hakkı sahibinin yazılı talepte bulunması gerekmektedir. Belirtelim ki hak sahibinin ayrı sayfaya kayıt talebi yeterli olup, irtifak hakkının yükletildiği taşınmaz malikinin veya bu taşınmazdaki diğer hak sahiplerinin rızalarına gerek yoktur. Zira bu kimselerin, irtifaka tapuda ayrı sayfa açılmasıyla engellenen bir menfaatleri bulunmamaktadır.

C. Kaydın Yapılış Şekli

2506 TMK m. 1004'e göre, "*Taşınmazlar, bulundukları bölgenin tapu siciline kaydedilir.*". Birden çok bölge varsa TMK m.1005'e göre, "*Birden çok bölgede bulunan taşınmaz, diğer bölge sicillerine kayıtlı olduğu belirtilmek suretiyle her bölgedeki sicile ayrı ayrı kaydedilir (f.1). Böyle bir taşınmaza ilişkin tescil istemleri ve tescil işlemleri taşınmazın büyük kısmının bulunduğu bölgede yapılır ve yapılan tescil kütüğe işlenmek üzere diğer bölgelerdeki tapu idarelerine bildirilir (f.2)*". Bölgeden maksat, her ilçenin idarî sınırlarıdır.

2507 Belirtelim ki, taşınmazların bölünmesi ve birleşmeleri durumunda da bir kayıt işlemi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu 1000. maddesi bir taşınmazın bölünmesine ya da birden fazla taşınmazın birleştirilmesine ilişkin usul ve esasların Tapu Sicil Tüzüğüne gcre belirleneceğini ifade etmektedir.

2508 Taşınmazın bölünmesi ile kastedilen, tapuda tek sayfada kayıtlı taşınmazın birden fazla parsel ya da arsa niteliğinde taşınmazlara ayrılmasıdır. Bu ya ilgili ya da ilgililerin talebi ile ya da İmar mevzuatı hükümleri çerçevesinde re'sen gerçekleştirilir. Taşınmazın bölünmesiyle her yeni

parsel veya arsa için bir kütük sayfası açılır ve önceki sayfalardaki kayıtlar yeni sayfalara nakledilerek eski sayfa kapatılır (TST m. 65).

2509 Taşınmazların birleştirilmesinde ise tapuda birden fazla sayfada kayıtlı parsel ya da arsalar tek bir taşınmaz hâline getirilmektedir. Böyle bir işlem için birleştirilen taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak bulunmaması veya böyle haklar varsa da hak sahiplerinin birleşmeye muvafakat etmeleri ya da irtifaklar bakımından birleşmenin bu hak sahiplerinin durumunu ihlal etmemesi gerekmektedir. Birleştirilecek taşınmazların malikî aynı olabileceği gibi farklı malıklere ait taşınmazların birleştirilmesi de mümkündür. Birden çok taşınmazın birleştirilmesi ile oluşan taşınmaza yeni bir numara altında tapuda ayrı bir sayfa açılır ve eski taşınmazlara ait sayfalar kapatılır. Birleştirilen taşınmazların üzerindeki hak ve yükümlülüklerin tamamı yeni taşınmazın sayfasına aynen geçirilir. Bununla birlikte geçirilen hak ve yükümlülüklerin paydaşlardan hangisine ait olduğu da ayrıca belirtilir.

D. Tapulamanın (Kadastronun) Yapılışı

1. Genel Olarak

2510 Taşınmazların tapu siciline kaydı, Medenî Kanunun öngördüğü tapu kütüklerinin tutulmasına bağlıdır. Bundan dolayı gerçek manada tapulamanın yapılabilmesi için arazi kadastrosunun öncelikle tamamlanmış olması gerekir. Kadastro demek, taşınmazların geometrik şekillerinin, sınır ve miktarları ile hukukî ve fiilî durumlarının teknik ve matematiksel esaslara göre belirlenmesidir. Yani, kadastro taşınmazlara ferdiyet, yani belirlilik, dolayısıyla eşya olma niteliği kazandıran teknik çalışmaları ile hukukî işlemlerin adıdır.

2511 Medenî Kanun'un taşınmaz mülkiyetine ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için öncelikle arazinin hukukî ve matematiksel durumunu tespit eden kadastro çalışmalarının tamamlanması gerekir. Ülkemizde ise, arazinin önemli bir kısmının kadastrosu tamamlanmıştır.

2512 Kadastro Kanununun asıl amacı, tapusuz taşınmazların, yeni teknik imkânlardan da yararlanarak kadastrolarının yapılmasını ve tapuya geçirilmesini sağlamak, gerçek hak durumu yansıtmayan, bu yüzden hukukî geçerliliğini kaybetmiş tapu kayıtlarını tasfiye ederek, fiilî ve gerçek durumları hukukileştirmek, geçerli, fakat eski tapu kayıtlarını yenileyerek mevcut durumu hakkıyla aleniyete kavuşturacak hale getirmek, ayrıca

bütün taşınmazların tapuya veya bu maksatla tutulan özel sicillere kayıtlarını sağlayarak mümkün mertebe ülke çapında kayıt dışı taşınmaz bırakmamak, bu suretle Medenî Kanunun öngördüğü taşınmazlara ilişkin hükümlerin tam olarak uygulanabilmesi için gerekli olan tapu sicili sisteminin bütün unsurlarıyla oluşmasını sağlamaktır[34].

2513 Kadastrosu tamamlanmış olan taşınmazlar tapuda kayıtlı ise, adına kayıtlı oldukları kimseler veya mirasçıları zilyet ise onlar adına; ölmüşler ise öldükleri belirtilerek gene onlar adına; adına kayıtlı olduğu kişi ve mirasçılarından başkaları zilyet iseler, adına kayıtlı olduğu kimselerin veya onların mirasçılarının rızaları alınarak veya zilyetleri tapu dışı bir yolla iktisap ettiklerini ispatlarlarsa rızaları alınmadan zilyetleri adına; kayıt sahibi 20 yıl önce ölmüş veya gaipliğine karar verilmişse zilyetleri adına kayıt edilir (Kad. K. m. 13).

2514 Devletin hüküm ve tasarrufunda olmakla birlikte masraf ve emek sarfı ile imar veya ihya edilen yerler Kadastro Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen şartlar gerçekleştiği takdirde, imar ve ihya edenler veya halefleri adına tespit edilir. Yeter ki, böyle yerler orman, kamu hizmetine mahsus veya imar planına dâhil yerlerden olmasın (Kad. K. m. 18)[35]. Özel mülkiyete ve tapu siciline tâbi olan, fakat herhangi bir kimse adına kaydı mümkün olmayan taşınmazlar devlet adına kaydedilir (Kad. K. m. 18). Sahipsiz olduğu düşüncesiyle devlet adına tespit ve tescil edilen taşınmazın sahipleri 10 yıllık süre içinde hazineye karşı dava açabilecektir[36].

2515 Tapulu taşınmazların bölünmesi (ifrazı) veya birleştirilmesi (şuyulandırılması) de pekala mümkündür. TMK. m. 1001 II'ye göre "***bir***

---

[34] **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 323 vd.; bu nedenlerden ötürü kadastro işleminin gerçek hak sahibi lehine yapılması gerektiği yönünde bkz. Yarg. 16. HD. 26.12.2002, E. 2002/12908, K. 2002/13049.

[35] Ayrıntılı bilgi için bkz. **BAŞPINAR**, s. 29 vd.

[36] Kadastro tutanakları, süresi içinde itiraza uğramadığı veya dava açılmadığı takdirde kesinleşir. Bu suretle kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları, kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç üç ay içinde tapu kütüğüne kaydedilir (Kad. K. 12/II). Böylece yapılan tesciller, aksi hükmen sabit oluncaya kadar geçerlidir. Artık kadastro komisyonları kesinleşmiş kararlarını değiştiremez. Bu durumda, gerçek hak sahipleri ancak dava açarak kaydın tashihini isteyebilirler. Yeter ki, haklara sınırlandırma ve tespitlere ilişkin tutanakların kesinleşmesinden itibaren 10 yıl geçmiş olmasın. Zira Kad. K. m. 12/III, bu dava için 10 yıllık bir hak düşürücü süre öngörmüştür. O yüzden bu süre geçtikten sonra kadastrodan önceki sebeplere dayanılarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. Böylece 766 sayılı kanunda da mevcut olan bu esas, Kadastro Kanunu'nun bir tasfiye kanunu olduğunu gösterir. Ayrıca 10 yıllık süre içinde tapuda mevcut (yolsuz) kayda dayanarak yapılan ayni hak iktisapları da korunur (TMK. m. 1023).

taşınmazın bölünmesi veya birden çok taşınmazın birleştirilmesi halinde uyulacak usul tüzükle belirlenir". Tapu Sicili Tüzüğü, bir arazinin bölünmesi (taksimi) ile ondan bir parçanın ayrılmasını ifade eden **ifraz**ını aynı esaslara tabi tutulmuştur (TST. m. 65). Oysa taksim halinde, bölünen taşınmazın sayfası kapatılır (TST. m. 67), ondan ayrılan her parça için tapu kütüğünde ayrı bir yeni sayfa açılır. Buna karşılık, arazıden bir parçanın ayrılması anlamına gelen ifrazında ise, bundan farklı olarak eski sayfa yüzölçümü düzeltilerek aynen muhafaza edilir; ayrılan her parça için ise tapu kütüğünde yeni bir sayfa açılır.

2516 Aynı şahsa veya değişik şahıslara ait birbiriyle bitişik birden çok taşınmazların yeni bir numara altında tek bir taşınmaz olarak bir araya getirilmesine birleştirme denir (TST. m. 66/1). Bu halde, birleştirilen taşınmazların tapu kütüğündeki sayfaları kapatılır, kapatılan sayfaların yerine yeni bir sahife açılır (TST. m. 67/1). Bu işleme eski ifadesiyle ***"tevhit"*** de denilmektedir. Bu tür birleştirme (tevhit) bir taşınmaza bir parsel eklenerek yüzölçümünün artırılmasını ifade eden "**şuyulandırma**"dan farklıdır (TSN. m. 101).

2517 İlâve (şuyulandırma) halinde sadece ilave edilen parselin sayfası kapatılır, buna karşılık kendisine ilave edilen ve bu suretle yüzölçümü büyüyen taşınmazın sahifesinde yazılı yüzölçümde ise, gerekli değişiklik ve düzeltme yapılır. Tapu Sicili Tüzüğünde "şuyulandırma" ile ilgili de bir hüküm bulunmamaktadır. Taksim ve birleştirme yanyana bulunan taşınmazlar için söz konusu olur[37].

2518 Şimdi yukarıda kısaca bahsettiğimiz kadastro işlemlerinin yapılışını daha ayrıntılı ele alalım.

2. Kadastronun Amacı ve Yapılışı

a. Kadastronun Amacı

2519 TMK'nın tapu sicil sisteminin uygulanabilmesi için Ülke bütününde yapılacak kadastro teknik çalışmalarla taşınmazların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirlenmesi gereklidir.

2520 Kadastro faaliyetinin teknik yönü tek bir sistem içinde, Ülke bütününde üretilecek haritaların ülke nirengi ve nivelman ağına Böylelikle ül-

[37] Bkz. ÜNAL/BAŞPINAR s. 332-333.

kenin memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritası oluşturulmaktadır. Bunun içinde öncelikle kadastro çalışmalarında ihtiyaç durulan kadastral veya topoğrafik haritalarda üretilmesi gerekir.

2521 Bu haritalarla birlikte çağdaş imar ve şehircilik anlayışına uygun harita üretilebilmesi ve kadastro sonucu elde edilen verilerin haritacılık ile ilgili tüm alanlarda kullanılabilmesine imkan sağlayan mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmakta gereklidir.

2522 Ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritası yapılırken, aynı zamanda bu planlarda yer alan taşınmazların malikleri belirlenmesi, varsa üzerinde hakların saptanması, eski tapuların yenilenmesi ve tapusuz yerlerin tapuya bağlanması suretiyle TMK'nın öngördüğü tapu sicilinin oluşturur. Böylece, TMK'dan önce ve sonraki dönemlerde taşınmazlar üzerinde meydan gelen eylemli durum ile hukuki durum arasındaki farklılıklarda giderilebilir.

b. Kadastro Bölgesinin ve Çalışma Alanın Belirlenmesi

aa. Kadastro Bölgelerinin Belirlenmesi ve İlanı

2523 Kadastro çalışmalarına, her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgeleri, ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir (KK m.2/I, II).

2524 Kadastrosuna başlanacak bölgeler en az bir ay önceden Resmi Gazete, Radyo veya Televizyonda, bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde, varsa yerel gazetede ilan olunur ve ayrıca alışılmış vasıtalarla duyurulur (KK m.2/ son f.).

bb. Kadastro Ekibi ve Komisyonun Kuruluşu

2525 Kadastro ekibi; en az ikı kadastro teknisyeni[38], mahalle veya köy muhtarı[39] ile üç bilirkişiden[40] oluşur (KK m.3/I). Belediyesi olan yerlerde

---

[38] Kadastronun fennî işlerinin ihale yoluyla yaptırılması halinde, kadastro ekibinde iki kadastro teknisyeni, iki teknisyenin temin edilememesi durumunda yerine bir kadastro teknisyeni görevlendirilebilir. Ekipteki kadastro teknisyeni yerine kontrol memuru da görevlendirilebilir (KK m.3/II).

[39] Muhtarın diğer bir kadastro ekibi ile çalışması veya herhangi bir sebeple hazır bulunmaması halinde, yerine kanuni vekili katılır (KK m.3/III).

[40] Kadastro ekibinde görev alacak bilirkişilerin; a) Türk Vatandaşı olması, b) 40 yaşını bitirmiş olması, c) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, d) En az 10 yıldan beri o mahalle

belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir (KK m.3 IV)[41]. Seçilen bilirkişiler, Kadastro mahkemesinde, mahkeme kurulmamışsa sulh mahkemesinde yemin verirler[42].

c. Kadastro Komisyonu

aa. Genel Olarak

2526 Kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın mahiyetine göre kontrol mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması halinde yerine fen kontrol memuru katılır (KK m.3 IX).

bb. Kadastro Çalışma Alanında Ormanın Bulunması

2527 Çalışma alanında orman bulunması ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre, orman kadastrosuna başlanılmamış olması halinde, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti kadastro ekibi tarafından yapılır. Ancak, bu çalışmalarda kadastro ekibine, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisinin bildirimden itibaren yedi gün içe-

---

veya köyde ikamet etmesi. *(Mülki amir tarafından seçilecek bilirkişilerde bu şart aranmaz.)* e) Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması. f) Türkçe okuma- yazma bilmesi gerekmektedir. Köy muhtarı veya belediye başkanı tarafından o köy veya mahallede bilirkişi seçilme niteliklerine haiz yeter sayıda okur-yazar kişi bulunmadığının yazılı olarak kadastro müdürlüğüne bildirilmesi koşuluyla okur-yazar olmayan kişiler arasından da bilirkişi seçilebilir. Okuma-yazma bilmeyen bilirkişilerin Kadastro Kanunu'na göre düzenlenecek belgelere sol elinin başparmağını, bu parmak yoksa öteki herhangi bir parmağını basması imza yerine geçer. Kadastro tutanağı, okuma yazma bilmeyen bilirkişilere okunur ve beyanlarına uygun olduğunun belirtilmesi halinde tutanağa parmak izi bastırılır. Bu durumda, kadastro tutanağının okuma yazma bilmeyen bilirkişi "..... ....." a okunduğu, tespitin kendi beyanına uygun olduğunu belirterek parmak izini bastığı ve parmak izinin bilirkişinin hangi elinin hangi parmağına ait olduğu hususu tutanağın edinme sebebi sütunundaki boş kısma yazılarak kadastro teknisyenleri ve muhtar tarafından birlikte imzalanır. Seçilen bilirkişiler kadastro ekibinin çalışması sırasında, kendisine, eşine, usul ve füruuna, kardeşine, kardeşinin çocuklarına ve eşinin usul ve füruuna ait tespitler ile bunların hak iddia ettiği tespitlerde ve ayrıca hak iddia edenlerden biri ile kendisi veya usul ve füruu arasında davası bulunanlara ait tespitlerde de bilirkişi olarak dinlenemezler (KK m.3/VII). Bilirkişiliğe mani yukarıdaki haller, kadastro teknisyeni, muhtar ve diğer görevliler ile bunların yerine kaim olanlar hakkında da uygulanır (KK m.3/VIII).

[41] Bilirkişilerin zamanında seçilememesi veya bilirkişiliklerine mani hallerin bulunması halinde, bölgenin mülki amiri tarafından aynı sayıda bilirkişi belirlenir (KK m.3/VI).

[42] Mahkemece düzenlenen yemin tutanağı Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Yemin tutanağının aslı müdürlük dosyasında bir örneği de ekip dosyasında saklanır.

ısında iştirak ettirilmesi zorunludur. Bu çalışmalara muhtar ve bilirkişilerin katılmaması halinde çalışmalar re'sen devam ettirilir (KK m.4 III).

2528 Ormanla ilgili yapılan itirazların incelenmesinde kadastro komisyonuna da itiraza konu tespitlerde görev almayan Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtınca görevlendirilecek bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi iştirak ettirilmesi zorunludur (KK m.4 VI).

2529 Çalışma alanındaki ormanların bu ekipçe sınırlandırma ve tespitleri yapılarak otuz günlük kısmî ilâna alınır. Bu alanlarda orman kadastrosu yapılmış sayılır.

2530 Orman kadastrosu kesinleşmiş yerlerde bu sınırlara aynen uyulur (KK m.4 V).

cc. Kadastro Çalışma Alanında Kamu Orta Malı Bulunması

2531 Kamu orta mallarının sınırlandırması ve bunlara yapılacak itirazların incelenmesi; 4342 sayılı Mera Kanununun 7'nci maddesinin son fıkrası uyarınca kamu orta mallarının sınırlandırma yetkisi kadastro komisyonuna geçtiğinde; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 26'ncı maddesi hükmü nedeniyle kadastro komisyonuna konu uzmanı Ziraat Mühendisinin dâhil edilmesi zorunludur.

2532 Bu nedenle, kamu orta malı nitelikli taşınmazların kadastro komisyonunca sınırlandırılmasında veya bunların sınırlandırma ve tespitine yapılacak itirazların incelenmesinde, *Kadastro Komisyonu*; kadastro müdürü veya müdür yardımcısının başkanlığında, kadastro üyesi ve kontrol mühendisi ile tarım müdürlüğünce görevlendirilecek ziraat mühendisinden oluşturulur.

d. Kadastro Çalışma Alanı, İlan ve İtiraz

aa. Genel Olarak

2533 Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder (KK m.4 I)[43].

[43] Kadastro ekibi, kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde il ve ilçelerin belediye sınırları ile köy sınırlarını dikkate alır. Bu sınırlar mahalle, belediye, köy idarî sınırları sayılmaz (KK m. 4/VI). Sınır tespitlerinde, komşu mahalle veya köyün bilgi ve belgelerinden istifade edilir.

2534 Kadastro müdürü, kadastrosuna başlanacak mahalleyi veya köyü en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir (KK m.4/II).

2535 Kadastro teknisyenlerince tespit edilen sınıra yedi gün içerisinde kadastro müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir. Kadastro müdürü, bu itirazı inceleyerek yedi gün içerisinde karara bağlar. İlgililer hazırsa tefhim, değilse derhal tebliğ edilen bu karara karşı yedi gün içerisinde kadastro mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, duruşmasız ve gerektiğinde mahallinde inceleme yapılarak, onbeş gün içinde kesin karara bağlanır. Ancak; tespit edilen bu sınıra karşı kesinleşmiş mahkeme kararı var ise aynı konuda itirazda bulunulamaz (KK m.4/VIII).

2536 Kadastro teknisyenleri, sınırlama ve tespit işlerini yapacağı kadastrosuna başlayacakları mevki veya adaları en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir. Çalışmalara üç aydan fazla ara verilmesi halinde ilan yenilenir (KK m.6).

bb. Dava Listesi ve Diğer Belgelerin Alınması

2537 Kadastro müdürü çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli hukuk mahkemesinde, bu alandaki taşınmaz mallar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge örnekleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine verir (KK m.5/I)[44]

aaa. Dava Listelerinin Alınması

2538 Kadastro çalışmalarına başlanmadan önce mahalli sulh ve asliye hukuk mahkemelerine yazılacak yazı ile, kadastrosuna başlanacak çalışma alanı sınırı (Köy veya mahalle sınırı) içinde bulunan taşınmazlardan, mahkemelerinde davası devam eden veya karara bağlanmış olmakla bir-

---

Tespit edilen sınır harita veya ölçü krokisinde gösterilir (KK m. 4/VII). Kadastro çalışma alanı içinde, ilk parsel için kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra idari teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik başlanan kadastroyu durdurmaz (KK m.4/IX).

[44] Listenin müdür tarafından alınmasından sonra o çalışma alanında bulunan taşınmaz mallar hakkında mahalli hukuk mahkemelerine açılan davalar, derhal kadastro müdürüne bildirilir. Bu halde de kadastro müdürü, yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca işlem yapar (KK m.5/II). Kadastro müdürü, bu listedeki davalı taşınmaz malların tespiti yapıldıktan sonra, bunlarla ilgili tutanakları bir hafta içinde kadastro mahkemesine gönderir ve durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi haberdar eder (KK m.5/III).

likte henüz kesinleşmemiş olan davalar varsa, bunlardan kadastro mahkemesinin görevi içine girenlerin listesi istenir. Dava listelerinde davanın esas numarası, davacı ve davalının adı-soyadı, adresleri, davanın konusu, dava konusu taşınmazın mevkii ve hudutları, varsa davaya dayanak belgelerin cinsi, tarih ve numarası belirtilir.

2539 Kadastro müdürü, mahkemelerden alınan dava listelerini kontrol edip kadastro mahkemesinin görevine girmeyen dava bulunmadığını tespit ettikten sonra kadastro teknisyenlerine imza karşılığında teslim eder.

2540 3402 sayılı Kadastro Kanununun 25'inci maddesinde, taşınmaz mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına ilişkin kadastroyu ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara konu taşınmazların davalı sayılacağı belirtilmiştir.

bbb. Tapu Kayıt Örneklerinin Çıkarılması

2541 Tapu kayıtları ve haritalarının çıkarılması ve bunların kadastro çalışmaları sırasında uygulanması 01.08.1991 tarihli ve 1509 sayılı genelge ile açıklanmıştır:

2542 Kadastro müdürü tarafından görevlendirilecek bir ekip tarafından, tapu müdürlüğündeki zabıt kayıtları taranıp, kadastrosuna başlanacak çalışma alanı sınırı içerisinde bulunan taşınmazlara ait tapu kayıtlarının örnekleri tarih sırasına göre çalışma alanı kayıt defterine (zabıt defterinin boşuna) çıkarılır. Örneği alınan kayıtların düşünceler sütununa kırmızı mürekkepli kalemle ***"KADASTRO"*** ibaresi yazılır. Örneği çıkarılan kayıt hisseli ise hisseleri tamamlanır. Kayıtlar üzerinde mevcut hak ve mükellefiyetler, ihtiyati tedbir, haciz, ipotek ve vakıf ilişiği gibi tüm ayni ve şahsi haklar ile takyidatlar örnekleri üzerine aynen işlenir. Kayıtlar haritaya bağlı ise bu haritalarında birer örnekleri alınır ve üzerlerine ait oldukları tapu kaydının tarih ve numarası, çalışma alanı kayıt defterine örneği alınan tapu kaydının yüzölçümü sütununa da haritası var anlamına gelen **(H)** harfi yazılarak aralarında irtibat kurulur.

2543 Tapu kayıtları örneklerinin çıkarılma işlemi tamamlandıktan sonra yeniden kontrol edilir ve çalışma alanı kayıt defterine çıkarılan kayıtların doğruluğu ve başkaca çıkarılması gereken kayıt bulunmadığı hususu yazılarak, kaydı çıkaranlar ve kontrol edenler tarafından imzalanır.

2544 Tapu kayıtlarının örneklerinin çıkarılmasından sonra, taşınmazın tapu müdürlüğünde intikal ve satış gibi nedenlerle tedavül veya tapu kaydı üzerinde aynı veya şahsi hak tesisi için talepte bulunulması durumunda, tapu müdürlüğünce kadastro müdürlüğünden tespit örneği istenmek suretiyle talep karşılanır. Talep karşılandıktan sonra, tedavül sonucu düzenlenen tapu kaydının veya ipotek belgesinin birer örneği kadastro müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. İhtiyati tedbir veya haciz talepleri ise öncelikle zabıt kaydı üzerinde karşılanır ve sonucundan kadastro müdürlüğüne bilgi verilir.

2545 Çalışma alanına ait olup mahallinde hisse tamamlaması yapılamayan veya eski yazı okuyan bulunmaması nedeniyle çıkarılamayan kayıtlar, köy ve mahalle adı, tesis tarihi (ay ve yıl olarak) ve sıra numaraları bildirilmek suretiyle TKGM Merkez Arşivi'nden (Arşiv Dairesi Başkanlığı) temin edilir.

ccc. Vergi Kayıtlarının Çıkarılması

2546 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 14'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında: 31 Aralık 1981 tarihinde veya daha önceki tarihlerde düzenlenmiş olan vergi kayıtları zilyetliği tevsik edici belge olarak kabul edilmiştir.

ddd. Zilyetliği Tevsik Edici Vergi Kayıtları

2547 Zilyetliği tevsik eden vergi kayıtları,

- 31/Aralık/1971 tarihine kadar, 2901 Sayılı Arazi Tahrir Kanununa göre tesis edilmiş özel idare tahrir kayıtları,

- 1/Ocak/1972 tarihinden 31/Aralık/1981 tarihine kadar 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve değişikliklerine istinaden taşınmazların zilyetlerince vergi dairelerine verilen emlak vergisi beyannameleri olmak üzere ikiye ayrılır.

2548 Ayrıca, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 36'ncı maddesinin 5'inci fıkrasında, *"Kadastrosu yapılan taşınmazlara, emlak vergisi son beyan dönemi esas alınarak 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifede gösterilen oranlarda, kadastro harcı tahakkuk ettirilir."* hükmü yer almaktadır.

2549 Bu nedenle, 31 Aralık 1971 tarihine kadar olan özel idare tahrir kayıtlarının örnekleri özel idare müdürlüklerinden, devredilmiş ise Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden, 1981 yılına ait emlak vergisi beyanna-

meleri örnekleri, vergi dairelerinden, devredilmiş ise belediyelerden, en son beyan dönemine ait emlak vergisi beyannamesi örnekleri ise belediyelerden alınır.

2550 Bunlardan, özel idare tahrir kayıtları ile 1981 yılına ait emlak vergisi beyan kayıtları 3402 sayılı Kanunun 14'üncü maddesi uyarınca yapılacak sınırlandırma ve tespitlerde, en son beyan dönemine ait emlak vergisi beyannameleri ise kadastro harçlarının tahakkukunda değerlendirilir. Belediye sınırları içerisinde bulunan taşınmazlara ait emlak vergisine esas değerler, belediyelerce her yıla ait yeniden değerlendirme oranları esas alınmak suretiyle yeniden belirlendiğinden, belediye sınırları içerisindeki taşınmazlar için belediyelerden o yıla ait emlak vergisine esas matrahın alınması yeterlidir

eee. Diğer Kuruluşlarca Yaptırılmış Haritaların Alınması

2551 Sınırlandırma ve tespitlerde değerlendirilmek üzere, Belediyeler, Karayolları, DSİ, TEK, BOTAŞ ve Orman İdaresi gibi kuruluşlarca yaptırılmış olan harita ve belgelerinin birer örnekleri bu kuruluşlardan alınır.

cc. Kadastro Tespit Tutanağı ve Tutanağa İtiraz

aaa. Kadastro İncelemesi, Tespitler ve Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi

2552 Kadastro teknisyenleri hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda, varsa harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceler ve mahalline uygular[45]. Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak 3402 sayılı Kadastro Kanun hükümlerine göre taşınmaz malı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder. Sınırlandırma, kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde gösterilir; ihtilaflı sınırlar ayrıca belirtilir (KK m.7/II).

2553 Kadastro teknisyenleri, sınırlandırma ve tespitini yapacakları taşınmazlarla ilgili olarak muhtar ve bilirkişilerden aldıkları bilgi ve beyanlar ile bir sonuca varamazlarsa, nedeni kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklamak suretiyle tahkikatı genişleterek o taşınmaza sınır

[45] Bu çalışmalara, istedikleri takdirde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri de gözlemci olarak katılabilirler (KK m.7/V).

bulunan diğer taşınmazların malikleri ile hazır bulunan diğer kimselerin bilgi ve beyanlarına başvurarak, varacakları kanaat doğrultusunda taşınmazın sınırlarını ve gerçek hak sahibini tespit etmekle yükümlüdürler (KK m.7 II).

2554 Muhtar ve bilirkişilerin bilgi ve beyanlarına aykırı olarak yapılacak tespitlerin mutlaka bir kayıt veya belgeye dayandırılması gerekmektedir.

2555 Muhtar ve bilirkişiler, kendi bilgi ve beyanları dışında yapılan tespitlere muhalif kalırlarsa, muhalif kalma nedenleri kadastro tutanağının edinme sebebi bölümünde etraflıca açıklanır. Şayet, bilgi ve beyanları dışında yapılan tespit nedeniyle kadastro tutanağını imzalamaktan kaçınırlarsa, kadastro teknisyenlerince bu husus tutanağın edinme sebebi sütununun uygun bir yerine yazılarak tespit sırasında hazır bulunan diğer kişilerle birlikte imzalanır. Bu durumda da tutanak tekemmül etmiş sayılır.

2556 Ancak, edinme sebebi ile tutanağa sonradan verilecek şerh arasında çelişki doğmaması için, tespit öncesinde, değerlendirmeye alınacak belgelerin uygunluğu ile mülkiyet bilgileri muhtar ve bilirkişilerle birlikte değerlendirilerek onların tespite ilişkin görüşleri alınmalıdır. Ayrıca, muhtar ve bilirkişilerin sonradan görüş değiştirilmelerinin ve bu nedenle de kadastro tutanaklarını imzalamaktan kaçınmalarının önlenmesi amacıyla, her adadak: çalışmalar tamamlandığında kadastro tutanakları düzenlenmeli, düzenlendikten sonra da hemen imzalatılmalıdır[45].

2557 Kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı olduğu veya tarafların dayandıkları kayıt ve belgeler aynı kuvvet ve mahiyette görüldüğü takdirde taşınmaza ait tutanak gerekçesi ile birlikte çözümlenmek üzere kadastro komisyonuna gönderilir.

2558 Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğindeki taşınmaz mallar ile dışında toplu olarak bulunan taşınmaz mallardan kadastro tutanağı düzenlenmeyen yerlerin kadastroya tabi olması yolunda iddia vaki olursa, KK gereğince tahdit ve tespiti yapılarak tutanak düzenlenir ve iddia sebepleri açıklanarak kadastro komisyonuna tevdi edilir (KK m.7 IV).

2559 5304 sayılı Kanunla değişik 3402 sayılı KK'nın 4'üncü maddesinde, Ormanla ilgili çalışmalara muhtar ve bilirkişilerin katılmamaları halinde, çalışmalara bunların yokluklarında resen devam edileceği hükmü yer al-

[45] 3402 sayılı KK m.7, Yönetmelik m. 47/D; Bkz. TKGM 10.10.2006 tarihli 2006/18 no.lu genelgesi

maktadır. Bu nedenle, muhtar ve bilirkişilerin çalışmalara katılmamaları halinde, çalışmalara katılmadıkları ve varsa nedeni, orman parsellerine ait kadastro tutanağının edinme sebebinde belirtilir. Kadastro tutanağının ve ilgili diğer belgelerin imza sütunlarında ise isimlerinin karşısına *"Çalışmalara Katılmadı"* ibaresi yazılır[47].

2560 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ile kadastrosu yapılacak taşınmazların sınırlarını ve hukuki durumunu tespit etme görevi kadastro teknisyenlerine verilmiştir. Ancak, 5304 sayılı Kanunla değişik 3402 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi hükmü nedeniyle ormanların sınırlandırma ve tespitinde kadastro ekibine orman ve ziraat yüksek mühendisi mühendisi iştirak ettirilir[48].

2561 4342 sayılı Mera Kanununun 7'nci maddesi hükmü nedeniyle kamu orta malı niteliklı taşınmazların sınırlandırılması mera komisyonlarınca, Mera Kanununda öngörülen 4 aylık sürenin geçmesi durumunda ise kadastro komisyonunca yapılır[49].

2562 Kadastro ekibinde görevli kadastro teknisyenleri; ada ilanında belirtilen gün ve saatte, muhtar ve bilirkişilerle birlikte sınırlandırma ve tespit çalışmalarına başlayacakları adaya giderek, burada taşınmazı tasarrufunda bulunduran kişiler ile, aynı taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan başkaca kişiler varsa bunların iddialarını dinleyip, ibraz edecekleri belgeler ile tapu ve vergi kayıtlarını, muhtar ve bilirkişilerin ve gerekiyorsa hazır bulunan diğer kişilerin bilgilerinden de istifade etmek suretiyle zemine uygulayıp taşınmazların sınırlarını belirlerler.

2563 Uygulanan kayıt ve belgeler haritaya bağlı ve harita fenni sıhhate haiz ise, taşınmazın sınırları bu haritaya göre belirlenir.

2564 Birbirine bitişik (Hudut) taşınmazlarda sınır ihtilafı varsa ve malikleri de aynı sınır nokta ları üzerinde anlaşma sağlayamıyorlarsa, anlaşmazlık bulunan *(Davalı taşınmazlar hariç)* sınırlar, tapu ve vergi kayıtları ile varsa tapu haritaları zemine uygulanmak ve bilirkişilerle hazır bulunan diğer kişilerin bilgi ve beyanlarından istifade edilmek suretiyle kadastro teknisyenlerince belirlenir.

---

[47] 3402 sayılı KK m. 4. Yönetmelik m. 47/D.

[48] TKGM 2014/4 no.lu genelgesi.

[49] TKGM 2004/16 no.lu genelgesi.

2565 Şayet, sınır ihtilafı nedeniyle mahallî hukuk mahkemelerinde dava açılmışsa davalı olan sınırlar paftasında mürekkeplenmeyip kurşun kalemli olarak bırakılır ve ayrıca, zeminde halen mevcut olan sınırlar ile tarafların hak iddiasında bulundukları sınırları gösteren ayrı bir kroki düzenlenerek kadastro tutanağına eklenir.

2566 Tapuda ifraz görerek parçalara ayrılmış bulunan taşınmazların sınırları belirlenirken, her hangi bir hataya ve parsel kaybına sebebiyet verdirilmemesi için ifraz krokileri ile ifraz sonrası oluşturulan tapu kayıtları birlikte değerlendirilir.

2567 Sınırları belirlenen taşınmazlar için, **sınırlandırma ve ölçü krokisi** düzenlenir[55].

2568 Kadastro teknisyenleri, sınırlandırmasını yaptıkları taşınmazların, muhtar ve bilirkişiler ile hazır bulunan ilgililerinden (Taşınmazı tasarrufunda bulunduran kişiler ile, aynı taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişiler) ve varsa tanıklığına başvurdukları kişilerden alacakları bilgileri değerlendirmek suretiyle hukuksal durumlarını belirlerler. Bu bilgileri ve kendi düşüncelerini her taşınmaz için ayrı ayrı düzenleyecekleri kadastro tutanağının edinme sebebi sütununa yazarlar.

2569 Uygulaması yapılan tapu kayıtları üzerinde, vakıf ilişiği, ipotek, haciz, ihtiyatî tedbir ve irtifak hakkı gibi aynî ve şahsî haklar ve şerhler varsa, bunlar da kadastro tutanağının ilgili sütunlarına yazılır.

2570 Düzenlenen kadastro tutanakları, muhtar ve bilirkişilerle birlikte, varsa bilgi ve tanıklığına başvurulan kimseler ve kadastro teknisyenlerince imzalanır. Ayrıca, edinme sebebi sütununda yapılan açıklamanın bittiği yere tarih konur ve boş satır bırakılmaksızın muhtar ve bilirkişiler tarafından kendi el yazılarıyla okudum ibaresi yazılarak imzalanır.

2571 Taşınmazların sınırlarının ve mülkiyetinin belirlenmesinde kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı çıkarsa, anlaşmazlığın nedeni kadastro tutanağında açıklanır. Ayrıca anlaşmazlık sınıra yönelik ise anlaşmazlık bulunan sınırlar paftasında mürekkeplenmez ve yüzölçümü hesaplanmaz, anlaşmazlık mülkiyete yönelik ise taşınmazın maliki tayin edilmez ve anlaşmazlığın kadastro komisyonunda çözümlenmesi için kadastro tutanağı tanzim edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir.

---

[55] TKGM 2010/11 no lu Genelgesi.

2572 Taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan kişilerce ibraz edilen kayıt ve belgelerin aynı kuvvet ve mahiyette olması halinde, kayıt ve belgelerin zemine uygunluğu ve zilyetlik durumu tutanakta açıklanmak suretiyle malik tayini yapılmaz ve tutanak komisyonda görüşülmek üzere 7 gün içinde kadastro müdürüne teslim edilir.

2573 Çalışma alanı sınırı içinde veya bitişiğinde ya da dışında toplu olarak bulunan taşınmazlardan kadastro tutanağı düzenlenmeyerek kadastro harici (tespit harici) bırakılan yerler için kadastroya tabi tutulması yönünde bir iddia vaki olursa, öncelikle, kadastro teknisyenlerince iddia konusu yerin bir başka çalışma alanı sınırı içerisinde veya kesinleşmiş orman tahdit sınırı içerisinde kalıp kalmadığı hususu araştırılır. Yapılacak araştırma sonucunda, taşınmazın bir başka çalışma alanı ya da kesinleşmiş orman tahdit sınırı veya mera sınırı içerisinde kalmadığı anlaşılırsa sınırlandırılması yapılır ve ibraz edilen belgeler, muhtar ve bilirkişi beyanlarından da istifade edilmek suretiyle değerlendirilerek tespiti yapılır.

2574 Bu şekilde yapılan tespite karşı ilgililerince itiraz edilmese dahi düzenlenen kadastro tutanağı ve eki belgeler kadastro komisyonunda incelenmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.

2575 Ancak, hak iddiasında bulunulan yer sınırlandırma ve tespiti yapılan bir başka parselin hudutları içerisinde kalıyorsa, kadastro teknisyenlerince bu parselin sınırlarında değişiklik yapmak suretiyle içinde yeni bir parsel oluşturulması mümkün olmadığından, hak iddiasında bulunan kişinin kadastro komisyonuna itirazı sağlanır.

bbb. Kat İrtifakına Konu Taşınmazların Tespiti

2576 Zabıt kaydı üzerinde kat irtifakı tesis edilmiş taşınmazların tespiti yapılırken, o taşınmaza ait zabıt kaydı ve evrakı müspiteleri incelenip, kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda maliklerin mülkiyet hisseleri ile hangi bağımsız bölümün kimlere ait olduğu ve bunlara ayrılan arsa paylarının neler olduğu açıklanır. Ayrıca, kadastro tutanağının *"İrtifak hakları ve Gayrimenkul Mükelleftyetleri"* sütununda kat irtifakına konu bağımsız bölümlerin kimlere ait olduğu ve arsa payları yazılır. Tutanağın mülkiyet sütununda ise arsa payları belirtilmeksizin sadece maliklerin mülkiyet payları yazılır.

2577 Askı ilanı sonucu tespit kesinleştiğinde, o parsele ait tapu kütük sayfasına tescil yapıldıktan sonra, TKGM'nin 3 Eylül 1997 tarih 1997/10

(1536) sayılı genelgesi uyarınca kat irtifakının "***Kat Mülkiyeti Kütüğüne***" taşınması gerekmektedir.

ccc. Kat Mülkiyetine Konu Taşınmazların Tespiti

2578 Ana gayrimenkul için kadastro tutanağı düzenlenerek bu tutanakta hangi bağımsız bölümlerin kimlere ait olduğu, bunların arsa payları ile mülkiyet paylarının neler olduğu ve edinme şekilleri açıklandıktan sonra her bağımsız bölüm için ayrıca birer kadastro tutanağı düzenlenir. Bu tutanakların ada ve parsel numaralarının yazıldığı sütunlarda, ada numarası aynen, parsel numarası ise bağımsız bölüm numarası ile taksimli olarak yazılır. *(Örnek: ana gayrimenkul 114 ada 5 parsel ise, 114 ada 5/1, 2, 3, ...14 parsel şeklinde)* Bağımsız bölümler için düzenlenen kadastro tutanağında sadece o bağımsız bölüme ilişkin bilgiler yazılır ve bağımsız bölümlere ilişkin tutanaklar ana gayrimenkul için düzenlenen kadastro tutanağına eklenir.

2579 Askı ilanında, kat mülkiyetine konu bağımsız bölümler ayrı ayrı yazılarak ilana alınır. Tescil aşamasında öncelikle ana gayrimenkulün tapu kütüğüne tescili yapılır ve bu sayfa usulünce kapatılarak bağımsız bölümler kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilir. Ana gayrimenkule ait kütük sayfası ile bağımsız bölümlere ait kat mülkiyeti kütük sayfaları arasında irtibat kurulur.

ddd. Davalı Taşınmazların Sınırlandırma ve Tespiti ile Tutanakların Mahkemeye Devri

2580 Kadastro tutanağı düzenlenmeden önce dava listeleri kontrol edilerek taşınmazın davalı olup olmadığı araştırılır. Dava listelerinde yer almamakla birlikte, hak iddiasında bulunan kişilerce veya bilirkişilerce taşınmazın davalı olduğu beyan edilirse bu husus araştırılır.

- ***Dava mülkiyete yönelik ise,*** taşınmazın sınırlandırma, ölçü ve tersimatı yapılarak yüzölçümü hesaplanır. Tarafların iddiaları ve ibraz ettikleri belgeler değerlendirilerek sonuçları kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklanır. Ancak, malik tayini yapılmaz.
- ***Dava sınır ve yüzölçümüne yönelik ise,*** tarafların iddiaları ve belgeleri değerlendirilerek taşınmazın malikı tayin edilir. Ancak, İhtilaflı sınırlar paftasında mürekkeplenmez ve yüzölçümü hesaplanmaz.
- ***Dava hem mülkiyete, hem de sınır ve yüzölçümüne yönelik ise,*** malik tayini yapılmaz, ihtilaflı sınırlar paftasında mürekkeplenmez ve yüzölçümü hesaplanmaz.

- ***Dava sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek haklara yönelik ise;*** taşınmazın sınırları belirlenip, malikı tayin edilir.

2581 Davanın konusu, dosya numarası ve mahkemenin adı kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda açıklanır. Ayrıca, Davalı olan tutanakların üst sağ köşesine kırmızı kalemle ve dikkati çekecek şekilde (davalıdır) sözcüğü yazıldıktan sonra, tutanağın dava dosyası ile kolayca birleşmesini sağlamak için mahkemenin adı ve esas numarası yazılır.

2582 Davalı taşınmazların kadastro tutanakları düzenlendiğinde, bu tutanaklar pafta örnekleri ile birlikte 7 gün içinde Kadastro Mahkemesine gönderilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.

2583 Kadastro teknisyenlerince kadastro müdürüne teslim edilen davalı taşınmazlara ait kadastro tutanakları ile eklerinin fotokopisi veya örnekleri çıkarılarak, asılları 7 gün içinde kadastro Mahkemesine gönderilir, ayrıca davanın görülmekte olduğu mahalli Hukuk Mahkemesine de dava konusu taşınmazın tespitinin yapılarak kadastro tutanağının kadastro mahkemesine gönderildiği hususunda bilgi verilir. Kadastro mahkemesine gönderilen davalı taşınmazlara ait kadastro tutanaklarının örneği, kadastro müdürü tarafından aslına uygunluğu tasdik edilerek ayrı bir dosyada saklanır. Çalışmaların tamamlanmasından sonra, bu dosya diğer evrakı müspiteleri ile birlikte tapu müdürlüğüne devredilir.

2584 ***Dava Listeleri Kadastro Müdürlüğüne Gönderildikten Sonra Mahalli Hukuk Mahkemelerinde Açılan Davalar Hakkında Yapılacak İşler:***

— ***Dava konusu taşınmaza ait kadastro tutanağı henüz düzenlenmemiş ise;*** Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda taşınmazın sınırlandırma ve tespiti yapılır.

— ***Dava, kadastro tutanağının düzenlenmesinden önce açılmış olmakla birlikte, tutanak düzenlendikten sonra kadastro müdürlüğüne bildirilmiş ise;*** kadastro teknisyenlerince malik sütunu kırmızı kalemle çizilir ve tutanağın uygun bir yerine şerh verilmek suretiyle tespit davalı hale getirilir.

— ***Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra dava açılmış ise;*** tutanağın düzenlendiği tarihte kadastro mahkemesinin görevi başladığından, kadastro tutanağı üzerinde herhangi bir işlem yapılmaz ve

davanın açıldığı hukuk mahkemesine açıklayıcı bir yazı ile kadastro tutanağının düzenlendiği hususunda ayrıntılı bilgi verilir.

— ***Askı ilanı süresi içinde dava açılmış ise;*** askı ilan süresi içinde Kadastro Mahkemesinde dava açılabileceğinden, kadastro tutanağı üzerinde herhangi bir işlem yapılmaz ve dava konusu taşınmazın tespitinin yapılarak Kadastro Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca askı ilanına alındığı hususunda davanın açıldığı hukuk mahkemesine ayrıntılı bilgi verilir.

— ***Kadastro tespitinden önce davalı olduğu halde, tespit davasız olarak yapılmış ve askı ilanı sonucu da kadastro tutanağı kesinleştirilmiş ise;***

Taşınmazın henüz tapu kütüğüne tescili yapılmamış ise tutanak davalı hale getirilir. Tapu kütüğüne tescil edilmiş ise tapu kütüğünün beyanlar hanesine, tespitin davalı olması nedeniyle kesinleşmediği yazılarak davalı hale getirilir. Taşınmaz tapu kütüğüne tescilini müteakip el değiştirmiş ise hiçbir işlem yapılmadan ilgililerine mahkemeye başvurmaları gerektiği hususu tebliğ edilir.

— ***Davalı Taşınmazların İhtilafsız Kısmının Ayrılması:*** Kadastro Mahkemesince sınır uyuşmazlığı nedeniyle açılmış davalarda, ilgililerin talebi üzerine dava konusu taşınmazın ihtilaf dışında kalan kısmının 3402 sayılı Kanunun 30'uncu maddesi gereğince mahkemece ayrılabilir. Mahkeme, ayırma işlemini yapmak üzere kadastro müdürlüğünden talepte bulunur.

2585 Kadastro Müdürlüğü bu ayırma işleminin imara uygunluğunu yetkili mercilerden (il idare kurulu veya belediye encümeni) sağladıktan sonra (Şayet mahkemece bu husus yetkili mercilerden sorulmuş ve imara uygunluğu bildirilmiş ise, kadastro müdürlüğünce ayrıca yazışma yapılmasına gerek yoktur.) ayırımı yapar ve sonucunu mahkemeye iletir. Mahkemenin bildirisi üzerine ihtilafsız kısma son parsel numarası verilerek tescili yapılır. Şayet, taşınmazın bulunduğu yere göre İl İdare Kurulu veya Belediye Encümenince ayırma işleminin imara uygun olmadığı yolunda karar verilirse ayırma yapılmaz ve sonucundan Kadastro Mahkemesine bilgi verilir.

2586 Diğer taraftan, ayırma işlemine konu yer tarım arazisi ise; 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun" 8'inci maddesine gö-

re[5], *asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan altında ifraz suretiyle parsel oluşturulması mümkün değildir. Bu nedenle, ihtilafsız kısım ile ihtilaflı kısmın ayrılmasında bölünemez büyüklük olan bu miktarların altında parsel oluşuyorsa, öncelikle* Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden (*Mahkemenin müzekkeresi de belirtilmek suretiyle*) soru konusu edilir. Alınacak cevap olumlu ise talep yukarıda açıklandığı gibi karşılanır.

2587 Aksi takdirde, talep karşılanmaz ve sonucundan, 5403 sayılı Kanunun 8'inci maddesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden alınan yazı açıklanmak suretiyle Mahkemeye bilgi verilir.

eee. Kadastro Tutanağının Kontrolü

2588 Kadastro çalışmaları esnasında, kadastro müdürü veya görevlendireceği kontrol elemanları tarafından kadastro tutanağı ve bunları tamamlayan belgeler üzerinde ve gerektiğinde arazide inceleme yapılır. İnceleme sonucu tespit edilecek teknik, idari ve hukuki noksan ve yanlışlıklar, kadastro ekibine tamamlattırılır veya düzelttirilir. Yapılan işlem ilgililerin haklarını etkilemekte veya kontrol elemanları ile kadastro teknisyenleri arasında görüş ayrılığı bulunmakta ise, kadastro tutanağı ekleriyle birlikte kadastro komisyonuna gönderilir (KK M.8 I).

fff. Kadastro Komisyonlarının Görevleri

2589 Kadastro komisyonun görevlerini şu şekilde belirleyebiliriz: İtirazların İncelenmesi, orman parsellerine; kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar, orman parselleri dışında kalan taşınmazlara; kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten kadastro ekibinin çalışma alanında işinin bittiğini gösteren tutanağın düzenlendiği tarihe kadar, yapılacak itirazları; aşınmazların sınırlandırma ve tespiti sırasında, ekip görevlisi kadastro teknisyenleri arasında, ormanla ilgili sınırlandır-

[5] Ayrıntılı bilgi için bkz. **YAVUZ, C./TOPUZ, M.**, Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Türk Medeni Kanunu'nun Miras Hukukuna İlişkin Hükümlerinde Yaptığı Değişiklikler. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 21 (2), 663 vd.

ma ve tespitler sırasında ise kadastro teknisyenleri ile kadastro ekibinde görev alan orman veya ziraat yüksek mühendisi mühendisi arasında ya da orman mühendisi ile ziraat mühendisi arasında görüş ayrılığı çıkması nedeniyle gönderilecek kadastro tutanaklarını, Kadastro teknisyenleri ile kontrol elamanları arasında görüş ayrılığı çıkması veya kontrol elamanlarınca yapılması istenen değişikliğin taşınmazın mülkiyetinde, tespit maliklerinin paylarında veya taşınmazın sınır ve yüzölçümünde değişiklik gerektirmesi nedeniyle gönderilecek kadastro tutanaklarını, Kadastroya tabi tutulmayan yerler üzerinde hak iddiasında bulunulması nedeniyle, 3402 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince sınırlandırması ve tespiti yapılan taşınmazlarla ilgili gönderilecek kadastro tutanaklarını, Taraflaın dayandıkları kayıt ve belgelerin aynı kuvvet ve mahiyette olması neceniyle malik tayini yapılmayan ve çözümlenmek üzere kadastro komisyonuna gönderilen taşınmazlara ait kadastro tutanaklarını, inceleyerek, gerçek hak sahibini belirler. Kadastro komisyonları bu inceleme sonucunda, kadastro tutanağının yerine geçmek üzere kadastro komisyon tutanağı düzenlerler. Emlak vergisi beyan değeri bulunmayan taşınmazların, kadastro harcına ve yargılama giderine esas olacak matrahını tespit etmek görevi kadastro komisyonlarına aittir

2590 Mera komisyonlarınca, 4342 sayılı Kanun hükümlerine göre, bu yasada öngörülen 4 aylık süre içerisinde mera, yaylak ve kışlak gibi orta malı taşınmazların sınırlarını belirleyerek belgelerini göndermemesi durumunda, bu yerlerin sınırlarını belirlemek görevi kadastro komisyonlarına aittir.

ggg. Kadastro Tespitine İtiraz

2591 Orman parsellerine, kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar; Orman parselleri dışında kalan taşınmazlara, kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten kadastro ekibince çalışma alanında sınırlandırma ve tespit işlerinin bitirildiğine ve ölçülecek taşınmaz kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar; itiraz edilebilir (KK m.9 I).

2592 Kadastro ekibinin çalışma alanında sınırlandırma ve tespit işini bitirdiği tarih, *Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin* 24'üncü maddesinde öngörülen "*Bitim*" tutanağının düzenlendiği tarihtir. İtiraz, kadastro müdürlüğüne veya kadastro

teknisyenliğine (ilgilisince bizzat veya kanuni vekil, veli, vasi veya kayyımları aracılığıyla) verilen bir dilekçe ile yapılabileceği gibi, kadastro tutanağına yazdırılmak suretiyle de yapılabilir.

2593 Bilgilendirme İlanı. Gerçek ve tüzel kişilerin kadastro ekibince yapılan sınırlandırma ve tespitleri incelemeleri ve varsa itirazlarını yapabilmeleri için, çalışma alanında sınırlandırma ve tespit çalışmaları ile kadastro tutanaklarının ekip görevlilerince imza işlemleri tamamlandıktan sonra, (bitim tutanağı düzenlenmeden önce) askı ilanı formatında ve "***Bilgilendirme İlanı***" adı altında bir ilan hazırlanır[62]. Bu ilan, pafta örnekleri ile birlikte *Kadastro Müdürlüğünde, Muhtarlıkta ve belediye teşkilatı olan yerlerde Belediyede* 15 gün süre ile *(hafta sonu ve bayram tatilleri dahil)* ilan edilir.

2594 İlan süresi içerisinde yapılacak itirazlar, kadastro komisyonunca en geç ilanın bitimini takip eden 15 günlük süre içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. 3402 sayılı Kanunun 9'uncu maddesi ***"Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir."*** hükmünde olduğundan, bilgilendirme ilanının yapılmış olması, kadastro ekibince, çalışma alanında işinin bittiğine dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar itiraz yapılmasına engel teşkil etmez. Bu nedenle, bilgilendirme ilanının bitim tarihinden kadastro ekibinin çalışma alanında işinin bittiğini gösteren tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen süre içerisinde, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak itirazların da kadastro komisyonunca incelenmesi zorunludur.

2595 Taşınmaz Malların Sınırlandırma, *Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 24'üncü maddesinde öngörülen "Uygulanmayan ve uygulanamayan kayıtlar listesi ile bitim tutanağı"*, 3402 sayılı Kanunun 7, 8 maddelerine göre kadastro komisyonuna intikal ettirilen işler ile Kanunun 9'uncu maddesine göre yapılan tüm itirazlar, kadastro komisyonunca sonuçlandırıldıktan sonra düzenlenir.

2596 Kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılan itirazlarda, itiraza konu taşınmaza ait kadastro tutanağı ekleriyle birlikte en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilmek üzere kadastro

---

[62] Bilgilendirme ilanının yapılma şekli, TKGM'nin 14.01.2013 tarihli ve 2013/4 no.lu genelgesinde açıklanmış ve ilanın format örneği genelgeye eklenmiştir. Bilgilendirme ilanı öncesinde ***"Uygulanmayan ve uygulanamayan kayıtlar listesi ile bitim tutanağı"*** düzenlenmez. Kısmi kadastro sonucu yapılacak askı ilanı öncesinde bilgilendirme ilanı yapılmaz.

müdürlüğüne teslim edilir. İtirazlı tutanaklar geliş sırasına göre itiraz defterine kaydedilir. İtirazla ilgili yapılan işlem bu defter üzerinde gösterilir.

2597 Bir belgeye dayanmayan itirazların komisyonca incelenmesi mümkün olmadığından, kadastro müdürü tarafından belgeye dayanmayan itirazlı tutanaklar komisyona intikal ettirilmez ve bu husus itirazda bulunan kişilere yazılı olarak duyurulur. Bu duyuruda askı ilanı süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açma haklarının bulunduğu da belirtilir. İtiraz, kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir (KK m.9 II). İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerlilığı hakkında yapılabilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır (KK m.9 III).

hhh. Kadastro Komisyonu İncelemesi

2598 Kadastro komisyonu kendisine intikal eden işlerle itirazlı tutanakları, intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar incelemek zorundadır (KK m.10 I). Bu incelemeler sonucunda eski tutanağın yerine kaim olmak üzere hak sahibini belirleyici yeni bir tutanak düzenlenir. Gerektiğinde bilirkişilerin ve muhtarın bilgilerinden yararlanılabilir (KK m.10 I). Belgeye karşı şahit dinlenmez. Komisyon, tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğu ile tespit yapar, sonuç askı ilanı ile ilgililere duyurur (KK m.10 III).

2599 Aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konular, kadastro komisyonu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak ve ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir (KK m.10 IV).

iii. Kadastro Sonuçlarının İlanı

2600 Kadastro müdürü, kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitlere dayanarak, askı cetvellerini düzenler; bu cetvelleri ve pafta örneklerini, müdüriyette ve ayrıca muhtarın çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirir; itirazı olanların ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabileceklerini belirtir. Bu ilanda kadastro harçları da gösterilir (KK m.11 I).

2601 Kadastro müdürü bu işlemleri, kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde yapmak zorundadır (KK m.11 II). Müdür, Genel Müdürlüğün iznini alarak, kadastrosu henüz

tamamlanmayan çalışma alanlarında mahalle bucak merkezi ve köyde, bir ada veya mevkiden daha küçük olmamak üzere kadastro çalışmaları sonuçlanan taşınmaz mallara ait kısmi ilanı yukarıdaki esaslara göre yapabilir (KK m.11/III). Bu Kanun gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzelkişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır (KK m.11/IV).

dd. Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve Hak Düşürücü Süre

2602 Kadastro tutanaklarının arka sayfasındaki ilgili sütunun boş bırakılan tarih kısmına askı ilanının başlama ve bitim tarihleri, askı ilan süresi içinde dava açılıp açılmadığı hususu, bu sütunun altındaki boş kısma ise askı ilanının bitimini takip eden günün tarihi yazılır. İlan süresi içerisinde sınırlandırma ve tespitlerine dava açılmayan kadastro tutanakları kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleştirilir. *(47/D Madde: 25)*[53].

2603 Kadastro tutanağının 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir (KK m.12/I).

2604 Tescil, kesinleşmiş bulunan kadastro tutanakları ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları, o çalışma alanı için düzenlenecek tapu kütüklerine kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle 3 ay içerisinde tescil edilir. Tescil ada ve parsel numarası sırasına göre yapılır[54].

2605 Kadastroda önce davalı olması veya askı ilanı sırasında dava açılması nedeniyle, kadastro tutanakları kadastro mahkemesine gönderilmiş bulunan taşınmazlara ait tapu kütük sayfaları boş bırakılır. Davanın görüldüğü mahkemenin ismi ile dava dosya numarası tapu kütük sayfasının beyanlar hanesine yazılır. (47/D madde: 26)

2606 3402 sayılı Kanunun 16/B maddesinde sayılan Mera, yaylak, kışlak, kamuya ait otlak ve çayırlar, harman ve panayır yerleri gibi *"ORTA MALI"* taşınmazlar tescile tabi olmadığından, bunlar kadastroları kesinleştiğinde "Özel Siciline" *(Kamu Orta Malları Sicili)* kaydedilirler.

---

[53] Örnek: 3402 sayılı Kanunun 11'inci maddesine göre .../.../2018 ila .../.../2018 tarihleri arasında yapılan 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesine dava açılmadığından kesinleşmiştir.
Açıldığından kesinleşmemiştir.
.../.../2018 *Kadastro Müdürü*

[54] TKGM'nin 2005/10 no lu genelgesi

2607 Askı ilanı süresi içerisinde sınırlandırma ve tespitlerine dava açılan taşınmazlara ait kadastro tutanaklarının örnekleri çıkarılıp aslına uygunluğu kadastro müdürü tarafından tasdik edilerek müdürlükte bir dosya içerisinde saklanır. Asılları ise, pafta örnekleri ile birlikte dava dosyasına eklenmek üzere kadastro mahkemesine gönderilir.

2608 Kesinleşerek tescilleri yapılan kadastro tutanakları ile kadastro mahkemesine gönderilmesi nedeniyle suretleri alıkonulan davalı taşınmazlara ait kadastro tutanakları (ada ve parsel sırasına göre bir klasör içerisine konularak) ve tapu kütükleri bir cetvele bağlı olarak tapu müdürlüğüne devredilir. Tapu kütükleri ile paftalarının ikinci nüshaları, arşiv kurulan yerlerde bölge müdürlüklerine, aksi takdirde Genel Müdürlüğe gönderilir.

2609 **Kadastro Müdürlüğünce yapılan tescillerde;** askı ilanı sonucu yapılacak tescillerde, tapu kütüğünün "Edinme Sebebi" sütununa "Kadastro" ibaresi, "Kayıt Tarihi" sütununa da "Tespitin Kesinleşme Tarihi" yazılır. Kadastro müdürlüklerinde yevmiye defteri tutulmadığından tapu kütüğünün yevmiye numarası yazımına ilişkin sütun boş bırakılır.

2610 **Tapu Müdürlüğünce yapılan tescillerde,** tapu kütüklerinin tapu müdürlüğüne devrinden sonra, kadastro mahkemelerince karara bağlanarak kesinleştirilen taşınmaz mallara ait dava dosyaları, mahkemece tescil için tapu müdürlüklerine imza karşılığı teslim edilmektedir. Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir (KK m.12/II).

2611 Kadastro mahkemesince verilen karar, aynı zamanda ayırma (ifraz) veya birleştirme (tevhit) işlemini de gerektiriyorsa, karar ve eki krokı öncelikle bir yazı ekinde kadastro müdürlüğüne gönderilerek, karar uyarınca tescil bildirimi düzenlenmesi istenir ve bu yazının sonucu takip edilir.

2612 **Kadastro mahkemesince verilen kararın tescilinde,** tapu kütüğünün "Edinme Sebebi" sütununa "Hükmen" ibaresi, "Kayıt Tarihi" sütununa kadastro mahkemesince verilen "Kararın Kesinleştiği Tarih", "Yevmiye Numarası" sütununa ise "Yevmiye Defterinden Alınan Numara ile Yevmiyeye Kaydedildiği Yıl Taksimli Olarak" (Örneğin; 2014/21) yazılır.

2613 Kesinleşen sınırlandırma ve tespitlere karşı kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde genel hükümlere göre ma-

hallı hukuk mahkemelerinde dava açılabilir. Bu süre geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanılarak dava açma hakkı ortadan kalkar.

2614 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'na 5304 Sayılı Kanun ile eklenen "Sayısallaştırma" başlıklı Ek Madde 1'in 2'nci fıkrası ile *"Tapu kayıtlarında icareteyn veya mukataalı olduğuna dair vakıf şerhi bulunan taşınmazlarda 12'nci maddenin 3'üncü fıkra hükümleri uygulanmaz."* şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

2615 Bu nedenle, tapu kayıtlarında icareteyn veya mukataalı olduğuna dair vakıf şerhi bulunan taşınmazlar için 12'nci madde de yer alan hak düşürücü süre hükümleri uygulanmaz. Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz (KK m.12 III)[55].

2616 Kadastrosu tamamlanan çalışma alanı içerisinde kalan eski tapu kayıtları, işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bu kayıtlara dayanılarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapılamaz (KK m.12 IV).

2617 Kesinleşmemiş tutanaklar herhangi bir nedenle tapuya tescil edilmişse, iddia ve taşınmazın niteliğine bakılmaksızın, taşınmazı tescil tarihinden itibaren 20 yıl müddetle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduranlar ile bunların akdi ve kanuni halefleri açılmış ve açılacak olan davalarda medeni kanunun tapuya itimat prensibinden yararlanırlar (KK m.12 V).

ee. Kadastro Başladıktan Sonraki Akit ve Tescil İşlemleri

2618 Çalışma alanlarında, kadastroya başladıktan sonra her türlü akit ve tescil işlemleri taşınmaz malların o andaki kadastro tespit durumu, kadastro müdüründen sorularak alınacak cevaba göre tapu sicil müdürlükleri tarafından yapılır ve kayıt örnekleri derhal kadastro müdürlüğüne gönderilir (KK m.40 I).

2619 Kadastro tespiti kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası adına yapılmış ve kesinleşmemiş ise, kadastro sonucunu beklemeleri, ilgililere tebliğ olunur; ancak ilgililer kadastro sonunda hasıl olacak kesin durumu kabul edeceklerin: noterde düzenlenmiş bir belge ile veya tapu sicil mü-

[55] Bu fıkraya 25/2/2009- 5841/2 m. ile eklenen ek cümle Anayasa Mahkemesi'nin 12/5/2011 tarihli ve E.: 2009/31, K.: 2011/77 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

dürü huzurunda tespit olunacak ifadeleri ile beyan ederek, aktın veya tescilin yapılmasını isterlerse, bu işlemler tapu sicil müdürlüğünde yapılır ve keyfiyet derhal kadastro müdürlüğüne, dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir (KK m.40 II).

2620 İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve benzeri kararlarla ilgili talepler tapu sicil müdürlüğünce derhal tapu siciline işlenmekle birlikte kadastro tutanağına da geçirilmek üzere resen kadastro müdürlüğüne veya dava açılmış ise kadastro mahkemesine bildirilir (KK m.40 III).

2621 Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce re'sen düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden başlayan otuz gün içinde düzeltmeye itiraza edilmezse kesinleşir (KK m.41 I)[56].

2622 Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle kesinleşmiş olan taşınmazlarda, değişiklik işlemleri sırasında ortaya çıkan yüzölçümü farklılıklarından, kadastronun dayandığı teknik kurallarda belirtilen hata sınırları içinde kalanların re'sen düzeltilmesine kadastro müdürlükleri yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında, 12'nci maddede belirtilen hak düşürücü süre aranmaz (KK m.41 II).

ff. Kadastro Kanunun Uygulanacağı Diğer Haller

2623 Kadastro işlemlerinin bir bölgede tamamlanmasından sonra veya iş hacmi itibariyle kadastro mahkemesinin devamına ihtiyaç kalmadığının anlaşılması halinde, Adalet Bakanlığı o bölgede kadastro mahkemesini kaldırmaya ve görülmekte olan dava dosyalarını taşınmaz malların bulunduğu mahalli asliye hukuk mahkemesine devretmeye yetkilidir. Bu mahkemede davaya bu Kanunda yazılı usul ve esasa göre, kaldığı noktadan devam olunur (KK m.33 I).

2624 Devredilen bu davalar ile kesinleşmemiş kadastro tespitleri aleyhine sonradan mahalli mahkemelerde açılacak davalarda, dördüncü bölüm hükümleri uygulanır (KK m.33 II).

---

[56] Tapu sicili üzerinde yapılmış hataların düzeltilmesine ilişkin olarak 1495 no.lu genelge gereğince işlem yapılmakta iken, Tapu Sicili Tüzüğü ile getirilen yeni uygulamalar nedeniyle TKGM'ce 20.05.2014 tarihli ve 2014/3 no.lu genelge düzenlenmiştir.

2625 KK'nın zilyede tanıdığı haklar, kadastrosuna başlanan bölgede zilyedin leh ve aleyhine açılan davalarda iddia ve def: olarak ileri sürülebilir. Bu hükümler henüz kesinleşmemiş davalarda da uygulanır (KK m.40/IIII).

e. Kadastro Uyuşmazlıkların Kadastro Mahkemesinde Çözümlenmesi

aa. Görev ve Yetki

2626 Genel mahkemelere ait olup da bu Kanunun uygulanması ile ilgili dava ve işlere belirlenen usul ve esaslara göre bakmak üzere her kadastro bölgesinde tek hakimli ve Asliye Mahkemesi sıfatını haiz yeter sayıda kadastro mahkemesi kurulur (KK m.24/I). Kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlerde görevlidir (KK m.25/I c.2)[57].

2627 KK m.26 ve 40 hükümleri saklı kalmak üzere, kadastro tutanağının düzenlenmesi gününden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmiş ise, o günden sonra doğan haklara dair istekler, taksim şuyuun giderilmesi veya muhdesata bağlı olarak taşınmaz malı iktisap, muhdesatın yıkılıp kaldırılması ve benzeri nitelikte olan ve mahkemeden yenilik doğurucu hüküm almayı gerektiren dava ile ilgili isteklerin incelenmesi, kadastro mahkemesinin görevi dışındadır (KK m.25/ son f.)[58]. Kadastro Mahkemesi KK m.25/I hükmünde sayılan, A) 10'uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davaları, B) 11'inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davaları, C) Mahalli hukuk Mah-

---

[57] Kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi, istek üzerine veraset belgesi de verebilir (KK m.25/I c.2). KK m.25/II hükmüne göre, Kadastro mahkemesi, yalnız kadastro işlerine münhasır olmak üzere: A) Velisi veya vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara kayyım tayin eder. Bunların menfaatlerini korumak amacıyla Türk Medeni Kanununun hakimin iznini şart kıldığı hallerde bu izni verir. B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 465 ve bunu takip eden maddeleri gereğince adli yardım taleplerini inceleyerek kabul edebilir. C) Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu kararı hemen o yerin kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir. Tedbir kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün öngördüğü süre içinde kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz kalır.

[58] Geçici Madde 1'e göre, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş tapulama mahkemeleri, kadastro mahkemesi adını alır ve açılmış davaları, bu Kanundaki hükümlere göre yürütür. Asliye hukuk mahkemelerinde bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre açılan veya müracaata bırakılan davalara, kadastro mahkemelerinde bu Kanundaki hükümler doğrultusunda bakılmaya devam olunur.

kemelerinden 27'nci madde uyarınca Kadastro Mahkemesine devredilen dava ve dosyaları; D) Kadastro Mahkemelerine dava açıldıktan sonra, tespitten önceki haklara dayanarak, asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları, inceler ve karara bağlar[55].

2628 Mahallî hukuk mahkemelerinde görülmekte olan kadastro ile ilgili ve henüz kesinleşmemiş bulunan taşınmaz mala ilişkin davalar hakkında o taşınmaz mal için kadastro tutanağı düzenlendiği tarihte bu mahkemelerin görevi sona erer ve davalara ait dosyalar mahkemesine resen devrolunur (KK m.27/I)[60]. Tapulama ve kadastro mahkemelerince bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kesin hükme bağlanmış uyuşmazlıklara bu Kanun uygulanmaz. Tapulama mahkemeleri ile kadastro mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye mahkemelerinde halen görülmekte olan davalar ile 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılacak davalara bu Kanun hükümleri uygulanır (KK Geçici Madde 4/I)[61,62].

2629 Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. Bu yetkiyi bölgenin idarî sınırları belli eder. Yeni ilçe kurulup, teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç, idarî kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklar, kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlanır (KK m.25/ son f). Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal, 40'ıncı madde uyarınca başkasına devredildiği takdirde, davaya devralan devam eder (KK m.25/III).

---

[55] Kadastro mahkemelerinde görülen davalarda, 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz (KK m.25/II).

[60] Ayrıca müracaata kalmış davaların yenilenmesi halinde de KK m.27/I hükmü uygulanır (KK m.27/II). Kadastro hakimi, devredilen bu dava dosyaları ile KK m.5 gereğince müdür tarafından gönderilen kadastro tutanaklarını birleştirerek KK m.11'de yazılı şekle uygun olarak askı ilanını yaptırır. İlan süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz kesinleşmemiş olan davalara, kaldıkları noktadan bu Kanunda öngörülen esas ve usul dairesince devam olunur (KK m.27/III). Kadastro komisyonları tarafından KK m.10 uyarınca gönderilen tutanaklar için de hemen askı ilanı yaptırılarak, KK m.28/I hükmü uyarınca işlem yapılır (KK m.27/IV). Hakim, usul ve şekle ilişkin eksiklikler sebebiyle tutanakları kadastro müdürlüğüne iade edemez (KK m.27/V).

[61] 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile diğer kanunlar gereğince özel kadastrosu yapılan ve tutanakları kesinleşmiş bulunan taşınmazlar için 10 yıllık hak düşürücü süre geçmiş ise, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde hak sahipleri dava açabilirler.

[62] Bu Kanunun yürürlüğünden önce düzenlenmiş tapulama tutanakları ve kadastro beyannameleri ile verilmiş bulunan komisyon kararları geçerliliklerini korurlar. Bunlara süresi içinde itiraz durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.

bb. Kadastro Davalarında Yargılama

2630 Kadastro hakimi, askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerinden devredilen işler hakkında dava dosyası açar. İlgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ilgili dairelerden getirtir. Hakim, duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen tebliğ eder (KK m.28 I).

2631 Davacı gerçek ve tüzelkişiler, dava sebep ve delillerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır[81]. Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise, hakim gönderilecek davetiye ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder. Davacı, ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmez ise, hakim, davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. KK m.30 hükmü saklıdır. (KK m.28 II)

2632 Davacı, tespit sırasında yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir (KK m.28 IV). Davanın açılmamış sayılması halinde davacının hak düşürücü süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde yeniden dava açma hakkı saklıdır (KK m.28 IV).

cc. Yargılama Usulü

2633 Kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz. Hakim, toplanması mümkün olan delilleri inceler ve KK m. 30 hükmünce işi karara bağlar (KK m.29 I).

2634 Bir mirasçı diğerlerinin muvafakati olmadan dava açabilir ve yalnız başına davaya devam edebilir. Mirasçılarının tayin edilememesi sebebiyle ölü olduğu belirtilerek kayıt sahibi adına tespiti yapılan taşınmaz mallar hakkında, ölünün ismi açıklanarak mirasçıları denilmek suretiyle mi-

---

[81] HMK'nın tanıdığı imkanlar saklı kalmak ve davada menfaatleri zıt olmamak şartıyla, kadastro işlerinde karı ve koca birbirlerini vekil tayin edebilirler. Kadastro veya sulh hakimi tarafından tasdik edilmiş vekaletnameler de geçerlidir (KK m.31/I). Kamu kurum ve kuruluşları, taraf olduğu işlerde; avukatlarıyla, avukatları bulunmadığı takdirde, daire amiri veya daire amirinin yetkili kılacağı memurlarca temsil edilir (KK m.31/II). Avukat veya dava vekili ile takip edilen davalarda vekalet ücreti; davanın önemi, vekilin sarf ettiği emek, tarafların davada iyi niyetle hareket edip etmediği, hak ve eşitlik kuralları göz önünde tutularak maktuan takdir ve tayin olunur. Şu kadar ki, takdir edilecek vekalet ücretinin miktarı keşif yapılmışsa, taşınmaz malın değerine göre avukatlık ücret tarifesinin tayin ettiği nispi vekalet ücreti sınırlarının üstünde olamaz (KK m.32/III).

rasçılar aleyhinde dava açılabilir. Dava sırasında davalının davadan önce öldüğünün anlaşılması halinde davaya mirasçıları aleyhine devam edilir (KK m.29 II). KK'nın tatbikinde ayrıca açıklık bulunmayan hallerde basit yargılama usulü uygulanır. Kadastro mahkemeleri adlî tatile tabi değildir (KK m.29 III).

dd. Deliller ve Hakimin Takdiri

2635 Kadastro tutanaklarında beyanlarına başvurulan kişiler, bu beyanlarına gerekçe göstererek itiraz edilmedikçe, yeniden dinlenmezler. Ancak hakim, kadastro tutanağındaki beyanla, duruşma sırasında topladığı deliller arasında çelişki görürse, bunu gidermek için tutanakta beyanlarına başvurulan kimseleri tanık sıfatıyla yeniden dinleyebilir (KK m.20 I).

2636 Kadastro komisyonlarından gönderilen tutanaklar ile mahallî mahkemelerden devredilen dosyaların muhtevasından malik tespiti yapılamadığı veya dava açan mirasçının dışında başka mirasçıların da bulunduğu anlaşıldığı takdirde, hakim resen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayarak taşınmaz malın kimin adına tescil edileceğine karar vermekle yükümlüdür. Taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğu anlaşılır ve mirasçıları da tespit edilemezse, ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahsın adına tescil kararı verilir. (KK m.20 II)

2637 Kadastro mahkemesinde açılmış davalarda, ihtilaf taşınmaz malın muayyen bir kısmına münhasır kalıyorsa, ilgililerin talebi üzerine ve imar mevzuatı da engel teşkil etmediği takdirde ihtilaflı olmayan kısım ifraz edilerek davaya ihtilaflı kısım üzerinde devam edilir. (KK m.20 III)

ee. Karar ve Kararın Yerine Getirilmesi

2638 Kadastro mahkemesi kararları[64], Tebligat Kanunu hükümlerine göre resen taraflara tebliğ olunur (KK m.32 I). Bu kararlara karşı kanun yolla-

[64] Yargılama giderleri, kadastro harcı ve tahakkuku hususunda KK m. 36'ya göre, taraflardan her biri dava harcını, dinlenmesini talep ettiği tanık ve bilirkişi ücretini ve diğer yargılama giderlerini karşılamak zorundadır. Davacı hakim tarafından belirlenecek süre içinde gerekli giderleri mahkeme veznesine yatırmadığı takdirde, onunla ilgili delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılır. Bu Kanun gereğince reser yapılması gereken soruşturma ve tebliçat işlemleri için zaruri giderler, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere bütçeye konulan ödenekten karşılanır. Kadastro hakimi, dava harcı, yargılama giderlerinin tespit ve hesaplanmasında ilgili taşınmaz mala ait son beyan dönemi emlak vergisi değerini esas alır. Hakim, hükmün kesinleşmesinden itibaren onbeş gün içinde giderin miktarı ile mükellefin kimliği ve en son ikametgahını bir yazı ile maliyeye bildirir. Bu yazıda belirtilen giderler maliye tarafından yapılacak tebligattan başlayarak iki ay içinde ödenir. Süresi içinde ödenmeyen giderler için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kadastrosu yapılan taşınmaz mallara, emlak vergisi son beyan dö-

rına asliye mahkemelerindeki usule uygun olarak başvurulabilir. Mahkeme, kesinleşen ilamları dayanakları olan dava dosyaları ile birlikte tescil edilmek üzere ilgili kadastro veya tapu sicil müdürlüğüne devreder (KK m.32 II). Mahkeme kararı kadastro haritasında değişikliği gerektiriyorsa, bu değişikliği gösteren ve mahkemece tasdiki gereken harita, ilama eklenir (KK m.32 III).

ff. Kararın Kesinliği

2639 Kadastro mahkemeleri kararları, davada taraf olanlar ile taraflar dışında hak iddia ederek davaya müdahil sıfatıyla katılanların leh ve aleyhinde kesin hüküm teşkil eder. Taraf olmadığı halde lehine karar verilen şahıs hakkında mahkemece tesis edilen hüküm yukarıda sözü edilenleri de bağlar (KK m.34).

f. Kadastro Uyuşmazlıklarına Uygulanacak Maddi Hukuk Kuralları

aa. Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar

aaa. Kayıt Sahibi veya Mirasçıları Zilyet Bulunuyorsa

2640 Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespitine ilişkin esasları düzenleyen KK m. 13 I hükmüne göre: *"Tapuda kayıtlı taşınmaz mal, A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa;*

a) Kayıt sahibi adına,

b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına,

c) Mirasçılar tayin olunamazsa, ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına," tespit edilir.

Kayıt maliki sağ ve taşınmazı tasarrufunda bulunduruyorsa kayıt maliki adına tespit yapılır[66].

---

nemi esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifede gösterilen oranlarda kadastro harcı tahakkuk ettirilir. Kadastrosu yapılan yerlerde, emlak vergisi değeri belli olmayan taşınmaz mallara, kadastro ve dava harcı ile yargılama giderlerine esas olmak üzere kadastro komisyonunca kıymet takdir edilir.

Kamu tarafından açılan davalarda yargılama giderleri hususunda KK m.36 /A'ya göre, kadastro işlemi ile oluşan tespit ve kayıtların iptali için Devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı kadastro mahkemeleri ile genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekâlet ücreti dâhil, yargılama giderine hükmolunmaz.

[66] Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile mübadil (***değiştirilen***), mütegayyip (***kayboları***), mufarakat (***terkeden***) ve firari (***kaçak***) kişilerin taşınmaz malları ile ilgili olarak ne yönde işlem yapılması

2641 Tapu kaydı maliki ölü ve taşınmaz mirasçılarının tasarrufunda bulunuyorsa mirasçıları adına tespit yapılır. Mirasçılar; veraset belgesi ibraz edilmesi halinde veraset belgesindeki bilgilere göre belirlenir. Veraset belgesi yoksa, kadastro ekibinde görevli muhtar ve bilirkişilerin beyanları ile köy nüfus defterindeki veya nüfus idaresinden alınacak vukuatlı nüfus kaydı örneğindeki bilgiler karşılaştırılarak nüfus kayıtları ile bilirkişi beyanları arasında mutabakat sağlanması halinde bu bilgilere göre mirasçılar belirlenmelidir. Şayet, muhtar ve bilirkişilerce ölen kişinin mirasçıları hakkında kesin bilgi verilmez veya bilgi verilmekle beraber nüfus kayıtlarındaki bilgiler ile bilirkişi beyanları arasında mutabakat sağlanamaz ise, taşınmaz kayıt maliki adına tespit edilir. Malikin ölü olduğu ve mirasçılarının belirlenememe nedeni tutanağın edinme sebebi sütununda açıklanıp, beyanlar hanesinde de malikin ölü olduğu hususunda belirtme yapılır.

2642 Tüm mirasçıların yazılı talebini içeren, noterlikçe tanzim edilmiş veya haricen düzenlenerek köy ya da mahalle muhtarlıklarınca tasdik edilmiş bir belgenin ibraz edilmesi veya tüm mirasçıların bir arada kadastro teknisyenleri huzurunda beyanda bulunmalar halinde, paylı (müşterek) mülkiyet olarak, aksi takdirde elbirliği mülkiyeti (iştirak halinde mülkiyet) olarak tespitin yapılması gerekir.

2643 Ancak, taşınmazın tüm mirasçıların katılımı ile aralarında haricen taksime konu edilmesi veya üçüncü kişilere satılması suretiyle birlikte kullanıma son verilmesi hallerinde, muhtar ve bilirkişi beyanları ile elbirliği mülkiyetinin (*iştirak halindeki mülkiyetin*) paylı (*müşterek*) mülkiyete dönüştürülmesinde bir sakınca bulunmamaktadır[65]. Veraset belgelerinde mirasçıların hisselerinin belirtilmesi, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için yeterli olmayıp, ayrıca, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürüldüğü hakkında bir hükmün de yer alması gerekmektedir.

---

gerektiği TKGM 29.06.2001 tarihli ve 2001/7 no.lu genelgede açıklanmıştır. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerine ilişkin talepleri, 18.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanunla değişik 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 ve 36'ncı maddeleri hükümlerine açıklama getiren TKGM'nin ***2012/12, 2012/13, 2013/14 ve 2013/15 no.lu*** genelgeleri esaslarına gore değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin tapu ve kadastro işlemlerinde kullanılacak belgeleri ise TKGM'nin ***2013/13*** no.lu genelgesi esaslarına gore belirlenir.

[65] TKGM'nin 1508 sayılı çenelgesi" ve "Tarım arazilerinde ise TKGM Kadastro Dairesi Başkanlığı çıkışlı 19.11.2014 tarihli ve 76617 sayılı duyuru.

bbb. Kayıt Sahibi veya Mirasçılarından Başkası Zilyet Bulunuyorsa

2644 KK m.13 I, tapuda kayıtlı taşınmazlarla ilgili olarak, "*B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa; a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları*[67] *halinde zilyet adına, b) Zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya mirasçılarından veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına, c) Kayıt sahibinin yirmi yıl önce gaipliğine hüküm verilmiş veya tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur.*" hükmünü getirmiştir.

2645 Bu düzenlemeye göre, tapuda kayıtlı taşınmaz:, tapu kaydı maliki veya mirasçıları dışında zilyet ve tasarrufunda bulunduran kişi veya kişiler, taşınmazı çalışma alanı ilan tarihinden önce kayıt malikinden, kayıt maliki ölü ise mirasçılarından veya bunların kanuni mümessillerinden tapu dışı sözleşmelerle satın aldıklarını, satışı yapan kişilerin beyanı (*Bu durumda, beyanda bulunan kişilerin beyanları kadastro tutanağına yazılarak imzaları alınır)* veya noterlikçe ya da köy veya mahalle muhtarlıklarınca tasdik edilmiş bir belge ile veya bilirkişi ya da şahit sözleriyle ispat etmeleri ve satış tarihiyle tespitinin yapıldığı tarih arasında taşınmazı en az on yıl müddetle nizasız, fasılasız olarak ve malik sıfatı ile zilyet ve tasarrufunda bulundurmaları halinde, taşınmazın bu kişiler adına tespiti yapılır.

2646 Tespitin yapıldığı tarihte, haricen satın alan kişinin taşınmaz üzerindeki zilyetliği on yılı doldurmamışsa, kayıt malikinin, malik ölü ise mirasçılarının ya da bunların yasal temsilcisinin muvafakatleri aranır. Bu kişiler kadastro teknisyenleri huzurunda taşınmazın haricen satın alan kişi veya kişiler adına tespitine muvafakat ederlerse haricen satın alan kişi adına, muvafakat edilmez ise kayıt malıkı, kayıt malıkı ölü ise mirasçıları adına tespit yapılır. Kayıt malıkı veya mirasçılarınca, taşınmazın tapu dışı sözleşme ile satın alan kişi adına tespitinin yapılmasına muvafakat edildiğini gösterir noterlikçe düzenlenmiş bir belgenin teknisyenliğe ibraz edilmesi halinde ayrıca huzurda muvafakat aranmaz.

---

[67] Noter tarafından tespit ve tevsik edilen muvafakat beyanı veya düzenlenen satış vaadi senedi teknisyen huzurunda yapılmış muvafakat sayılır (KK m.13/II).

2647 Tapuda kayıtlı taşınmazın çalışma alanı ilanından önce noterde satış vaadi sözleşmesi düzenlenmek suretiyle haricen satılması halinde, on yıllık zilyetlik süresi dolmasa dahi muvafakat aranmadan satın alan kişi adına tespiti yapılır. Ancak, satış vaadi sözleşmesinde bir yükümlülük varsa bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olduğunun belgelenmesi gerekmektedir. Taşınmazı tapu dışı sözleşmeyle satın alan kişi, bu tutanaklara şerh vermek suretiyle 10 yıllık zilyetlik süresini doldurmadan bir başka kişiye satması halinde, önceki zilyedin zilyetlik süresi yeni zilyedin zilyetlik süresine eklenir.

2648 Kadastro çalışmalarına başlama tarihi olarak kabul edilen çalışma alanı ilanının yapıldığı günden sonraki tarihi taşıyan harici devir ve temliklerde, muvafakat sağlansa dahi harici satış kabul edilmez ve tespit kayıt maliki adına yapılır. Elbirliği mülkiyeti olarak tasarruf edilen taşınmazlarda, iştirakçilerden bir veya bir kaçı hisselerini diğer bir iştirakçilere devir ve temlik etmesi mümkündür. Bu durumda, kadastro tutanağının edinme sebebi sütununda gerekli açıklama yapılarak, mülkiyet sütununda elbirliği hali çözülmeden hissesini devreden iştirakçinin ismi yerine bu hisseyi devralan iştirakçinin ismi tekrar yazılır.

ccc. Tapuda Kayıtlı Taşınmazın Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Zilyet Bulunan Kişi Adına Tespiti

(1) Kayıt Malikinin Ölmüş Hallerde

2649 Kayıt maliki ölmüş ve taşınmazı mirasçı sıfatını taşımayan üçüncü bir kişinin 20 yıl müddetle, nizasız ve fasılasız olarak malik sıfatı ile zilyet ve tasarrufunda bulundurması halinde, taşınmaz zilyet bulunan kişi adına tespiti yapılmakta iken; bu hüküm, 3.5.2012-6302 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi ile iptal edilmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendi (*"c) Kayıt sahibinin yirmi yıl önce gaipliğine hüküm verilmiş veya tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur."* şeklinde değiştirilmiştir. Zilyet kayıt malikinin mirasçısı durumunda ise, mirasçılar arasında da kazandırıcı zamanaşımı yoluyla taşınmazın iktisabı mümkün olmadığından tespit bilinmiyorsa tüm mirasçılar adına, aksi takdirde kayıt maliki adına yapılarak, malikin ölü olduğu tutanağın beyanlar hanesinde gösterilir.

(2) Kayıt Malikinin Gaipliğine Karar Verildiği Hallerde

2650 Tapu kaydı malikinin gaipliği taşınmazı kazandırıcı zamanaşımı yolu ile mülk edinilmeye elverişli duruma sokar. Zilyedin bu hükümden yararlanabilmesi için mahkemece tapu kaydı malikinin gaipliğine karar verilmiş olması ve verilen bu kararın kesinleşme tarihinden itibaren mirasçı durumunda olmayan üçüncü bir kişinin taşınmazı nizasız ve fasılasız olarak malik sıfatı ile, ve en az 20 yıl müddetle zilyet ve tasarrufunda bulundurması, bu süre içerisinde kayıt malikinin mirasçıları tarafından tapuda intikal işleminin yaptırılmamış veya zilyedin men ettirilmemiş olması gerekmektedir.

(3) Tapu Kaydında Yazılı Malikin Kim Olduğunun Tespit Edilemediği Hallerde

2651 Tapu kaydında yazılı malikin kim olduğu tespit edilemiyorsa, Medeni Kanunun yürürlük tarihinden önce tesis edilmiş ve bu güne kadar tedavül görmemiş tapu kayıtlarından bazılarında malikin lakabı ve baba adı (açık kimliği) yazılı olmadığından malikinin kim olduğunu anlamak güçtür. Yapılacak araştırmalara rağmen sicilindeki bu yetersizlik nedeniyle malikinin kim olduğu tespit edilemeyen taşınmaz, 20 yıl müddetle nizasız ve fasılasız olarak malik sıfatı ile zilyet ve tasarrufunda bulunduran kişi adına tespit edilir.

2652 Ancak, her üç halde de zilyet edilen taşınmazlar, kanunları uyarınca Devlete intikal eden kişilere ait ise, bu gibi yerler 3402 Sayılı Kanunun 18'inci maddesinin son fıkrası hükmü nedeniyle zilyetlikle iktisap edilemeyeceğinden zilyetlik şartları tahakkuk etmiş olsa dahi Maliye Hazinesi adına tespit edilir *(KK m: 13, Yönetmelik m. 9)*.

bb. Haricen Satışın Dikkate Alınamayacağı Durumlar

2653 Tapu dışı sözleşmelerle yapılan satışların kabul edilmeyeceği hallerden bazıları aşağıda belirtilmiştir; bu durumlarda harici satışa ilişkin talepler kabul edilmeyerek taşınmaz kayıt malikı adına tespit edilir.

2654 Tapuda kayıtlı taşınmazın çalışma alanı ilan tarihinden sonraki bir tarihte harici satışa konu edilmesi, harici satışa konu edilen taşınmaza ait tapu kaydı üzerinde ihtiyati tedbir veya kamu alacağından dolayı konmuş haciz varsa, tapu kaydı üzerinde üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş olan hakların ve şerhlerin (*Haciz, ipotek, geçit hakkı gibi*) haricen satın alan kişi veya kişilerce kabul edilmemesi, askeri Yasak Bölge ve Güvenlik

Bölgeleri Kanunu uyarınca birinci ve ikinci derece askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri sınırları içinde bulunan taşınmazlar yabancı uyruklu gerçek bir kişiye haricen satılmışsa *(29.12.2005 tarihli ve 5444 sayılı Kanunla değişik 2644 sayılı Tapu Kanunu Madde 35)*, uygulama imar planı veya mevzii imar planı bulunmayan alanlardaki taşınmazlar yabancı uyruklu gerçek bir kişiye haricen satılmışsa, harici satışa konu edilen taşınmaza ait tapu kaydı üzerinde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 31/b maddesine göre verilmiş kamulaştırma şerhi varsa, 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uygulama alanı içerisinde kalan taşınmazın, uygulama alanı ilan tarihinden sonra harici satışa konu edilmesi.

cc. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti

2655 Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların tespit şekli, 3402 Sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle düzenlenmiştir. Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir (KK m.14/I).

2656 KK m.14 hükmünde hangi nitelikteki taşınmazların kazandırıcı zaman aşımı yoluyla zilyedi adına tespit edilebileceği hususunda bir açıklık bulunmamakla beraber, Kanunun 18'inci maddesinin 2'nci fıkrası ile, ***"orta malları, hizmet malları, ormanlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ve özel kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmazlar"*** tapuda kayıtlı olsun veya olmasın kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisap edilemeyeceği hükmü getirilmiş ve Kanunun 16'ncı maddesinde de hizmet malları ile orta malı taşınmazların neler olduğu açıklanmıştır.

2657 Ayrıca, *kıyı kenar çizgisi (3621 sayılı Kanun) içerisinde kalan taşınmazların, vakıf taşınmazların ve 5226 sayılı Kanunla değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 11'inci maddesi gereğince de, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca birinci grup olarak tescil ve ilan edilen kültür varlıklarının bulunduğu taşınmazlar ile birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarındaki taşınmazların* zilyetlik yoluyla iktisabı mümkün değildir.

2658 Sulu veya kuru arazi ayrımı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine göre yapılır (KK m.14 II)[65].

2659 Buna göre; kadastroya açılan çalışma alanlarında sulu tarım arazisi tanımına giren yerlerin bulunup bulunmadığı varsa bunların hangi sınırlar içinde kaldığı hususunun, kadastro müdürü tarafından çalışmalara başlanmadan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yazılacak bir yazı ile, sorularak, alınacak cevaba göre 40 veya 100 dönümlük normların değerlendirilmesi gerekmektedir.

2660 Aynı çalışma alanı sınırı içinde bir kişi adına belgesizden toplam olarak sulu toprakta 40 veya kuru toprakta 100 dönüm tespit yapılması mümkündür. Bir kişinin, çalışma alanında hem sulu, hem de kuru toprak tanımına giren belgesiz taşınmazlarının bulunması halinde, *(40 dönüm sulu toprak=100 dönüm kuru toprak)* ilkesinden hareket edilerek *(100/40 yani 1 dönüm sulu toprak = 2,5 dönüm kuru toprak)* orantısı kurulur. Böylece, sulu veya kuru topraktaki 40 veya 100 dönümlük normları geçip geçmediği araştırılır. Yapılan araştırmada belgesizden edinilebilecek normları geçtiği anlaşılırsa, fazla gelen kısım zilyedin tercihine göre ifrazen ayrılıp Hazine adına tespiti yapılır.

2661 4342 sayılı Mera Kanununun 7'nci maddesinin üçüncü fıkrası gereği 3402 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde Kadastro Komisyonlarına konu uzmanı Ziraat Mühendisi dâhil edilir (KK m.14 III).

2662 Taşınmaz malın, yukarıdaki fıkranın kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için, birinci fıkra gereğince delillendirilen zilyetliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır (KK m.14 IV).

---

[65] 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 3'üncü maddesinin (j) bendinde ise *"Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilen"* olarak tanımlanmıştır. Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında ise, "Tarımı yapılan bitkilerin çeşidine göre büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli olduğu, su kaynağının yeterli sulamaya uygun olduğu ve yeterli miktarda su olduğu, kontrollü bir şekilde sulama ihtiyacının karşılandığı hususları ilgili tarım müdürlüklerince tespit edilmiş alanlardaki araziler sulu tarım arazisi, bu alanlar dışındaki araziler ise, kuru tarım arazisi olarak değerlendirilecektir. Kadastro müdürü; çalışmalara başlanmadan önce, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden çalışma alanında sulu tarım arazisi tanımına giren yerler varsa bunların hangi sınırlar içinde kaldığının bildirilmesini bir yazı ile ister." hükmü yer almaktadır.

dd. Harici Taksimin Kabul Edilmeyeceği Haller

2663 Harici taksim olarak kabul edilmeyen haller şunlardır:

- Tapu kaydı üzerinde ihtiyati tedbir veya kamu alacağından dolayı haciz bulunan taşınmazlar harici taksime konu edilmişse,
- Tapu kaydı üzerinde üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş olan hakların ifrazen taksim sonucu oluşan taşınmazlar üzerine işlenmesine muvafakat edilmiyorsa,
- Tapu kaydı üzerinde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 31/b maddesi uyarınca verilmiş kamulaştırma şerhi varsa,
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 11'inci maddesi gereğince, ***kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca birinci grup olarak tescil ve ilan edilen kültür varlıklarının bulunduğu taşınmazlar ile birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanları*** içinde kalan taşınmazlar Kültür ve Turizm Bakanlığının izni alınmadan ifraza konu edilmişse,
- Yaşı küçük çocuğun velisi ile birlikte hissedar oldukları taşınmazın harici taksiminde veli ve çocuk aynı taşınmazdan hisse almamışsa,
- Hazinenin de hissedar bulunduğu taşınmaz, maliye kuruluşunun izni alınmadan taksime konu edilmişse,
- 3083 Sayılı Kanun uyarınca dağıtılan taşınmazlar harici ifraz ve taksime konu edilmişse,
- Tarım arazilerinde 19.07.2005 tarihinden sonra yapılmış ifrazen taksimlerde, ifraz sonucu oluşan parsel büyüklükleri, 5403 sayılı Kanunun 8'inci maddesine göre belirlenmiş tarımsal arazi yeter büyüklüklerinin altında ise,
- Kesinleşmiş imar planı bulunan yerlerde, belediye encümeni veya il idare kurulunca imara uygun olmadığı belirtilen ifrazen taksimler,

2664 Harici taksimin kabul edilmeyeceği hallerden uygulamada en çok rastlananlar yukarıda sayılmıştır. Bu gibi hallerde harici taksime ilişkin talepler kabul edilmez.

ee. Taksim ve Kısmi İktisap Hali

2665 Tapuda kayıtlı taşınmaz malların malikleri veya bunların mirasçıları arasında, tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların ise KK'nın m.14 ge-

reğince belirlenen zilyetleri arasında taksim edildikleri belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanları ile sabit olduğu takdirde bu mallar taksim gereğince zilyetleri adına tespit olunur (KK m.15 I).

2666 Taşınmaz mal tapuda kayıtlı olsun veya olmasın, onun ayrılması mümkün bir kısmının veya belirli bir payının, bu Kanunda zilyet lehine kabul edilen sebeplerle iktisabı caizdir (KK m.15 II).

2667 İştirak halinde mülkiyet hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde, iştirakçilerinden biri veya birkaçının belirli bir taşınmaz maldaki hissesinin diğer iştirakçilere devir ve temliki; tapulu taşınmaz mallarda yazılı, tapusuzlarda ise her türlü delille ispat edilebilir (KK m.15 III).

2668 Kadastrodan önce hissedarlar veya mirasçılar arasında ayırma veya birleştirme suretiyle taksime konu edilmiş ve sınırları doğal veya yapay işaret ya da tesislerle belirlenmiş taşınmaz malların, imar planı bulunmayan yerlerde zeminde fiilen oluşmuş sınırlarına göre tespiti yapılır (KK m.15 IV).

2669 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8'inci maddesinde ise *"Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir."* hükümlerini içermektedir.

2670 Söz konusu hükümler nedeniyle, hissedarlar, mirasçılar veya 14'üncü madde gereğince belirlenen zilyetler arasında yapılan taksim aynı zamanda ifrazı da içeriyorsa, öncelikle ifraz sonucu oluşan taşınmazların sınırlarının zeminde doğal veya yapay işaretlerle belirlenmiş olması ve ayrıca aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

2671 İmar planı bulunmayan yerlerde, belediye encümeni veya il idare kurulunun kararı aranmadan, zeminde fiilen oluşmuş sınırlarına göre sınırlandırma ve tespitleri yapılır.

2672 İmar planı bulunmayan yerlerde, 1- Ayırma veya birleştirme işleminin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan nazım imar planı veya uygulama imar planının kesinleşme tarihinden önce yapıldığının anlaşılması halinde, belediye encümeni veya il idare kurulu kararı aranmadan, 2- Ayırma veya birleştirme işleminin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan nazım imar planı veya uygulama imar planının kesinleşme tarihinden sonra yapıldığının anlaşılması halinde ise, belediye encümeni veya il idare kurulunun olumlu kararı alınmak suretiyle,

2673 Fiili zemin durumuna göre sınırlandırma ve tespiti yapılır. Bu amaçla, kadastro çalışmalarına başlanılmadan önce, kadastro müdürlüğünce, belediye teşkilatı olan yerlerde belediye başkanlığına, köylerde ise bayındırlık ve iskan il müdürlüğüne yazılacak birer yazı ile çalışma alanı sınırı içinde nazım imar planı veya uygulama imar planı kesinleşmiş alanların mevcut olup olmadığı ve varsa, bu planların hangi tarihlerde kesinleştiği hususları sorularak haritalarının gönderilmesi ve kesinleşme tarihlerinin bildirilmesi istenilir.

2674 Taşınmazların harici ayırma veya birleştirilmesiyle ilgili olarak belediye encümeni veya il idare kurullarınca çalışma alanının tamamını veya bir kısmını kapsayacak şekilde verilen kararların kabul edilmeyerek, ilgililerinden, ifrazdan önceki harici ayırma veya birleştirmeye konu olan her taşınmaz için belediye encümeni veya il idare kurulu kararı getirmeleri istenir.

2675 Ancak, 3290 ve 3366 Sayılı Kanunlarla değişik 2981 Sayılı Kanunun 10 b maddesi uyarınca yapılan kadastro çalışmaları sırasında ayırma ve birleştirmeye konu edilmiş taşınmazlar için belediye encümeni veya il idare kurulu kararı aranmaz.

ff. Tarım Arazilerinde

2676 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 30.4.2014 tarihli ve 6537 sayılı ***"Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un*** 2'nci maddesi ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası *"Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarım-*

sal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir" hükmü yer aldığından;

2677 ***Kadastro çalışmalarında***, 5403 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ***19.07.2005 tarihinden sonra*** tarım arazilerinde, miras yoluyla intikal edilenler hariç hissedarları arasında haricen yapılmış olan ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerin yüzölçümlerinin bölünmez büyüklük olarak kabul edilen bu miktarların altında olması durumunda ifrazen taksim talebi il ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan karşılanmayacaktır. Miras yoluyla intikal edilenlerde ise il ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden alınacak cevaba göre işleme yön verilecektir. ***19.07.2005 tarihinden önce*** yapıldığı tespit edilen ifrazen taksimlerde ise parsel yeter büyüklüğü aranmayacaktır.

2678 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ***15.05.2014 tarihinden sonra*** tarım arazilerinin intikalleri, tüm mirasçıların birlikte talepleri olsa dahi elbirliği halinde mülkiyet şeklinde (iştirak halinde mülkiyet verasette iştirak olarak) yapılacağından il ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan müşterek mülkiyete dönüştürülmeyecek ve ifrazen taksimlere yönelik talepler karşılanmayacaktır. ***15.05.2014 tarihinden önceki*** ölümlere dayalı olarak yapılacak intikallerde ise paylı mülkiyet olarak tasarruf edilen tarım arazilerinin paylı mülkiyet olarak tespiti mümkündür.

2679 Cinsi tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlar için, valilik belediyelere, imar planı (nazım, mevzi, uygulama imar planı gibi) kapsamında kalıp kalmadığı, kalmakta ise planda kullanım amacının tarım dışı olup olmadığının yazılı olarak sorularak alınacak cevabi yazılarda, taşınmazın imar planı (nazım, mevzi, uygulama imar planı gibi) kapsamında kaldığı ve planda kullanım amacının tarım dışı olduğunun bildirilmesi halinde bu Kanun hükmü uygulanmayacaktır.

gg. Miktar Fazlasının İfrazı

2680 Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir (KK m.21 I).

2681 Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir (KK m.21 II).

2682 Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır (KK m.21 III).

hh. Takyitler, Sınırlı Ayni Haklar ve Muhdesat

2683 Tapuda kayıtlı taşınmaz malın zilyet lehine tespitinde, mevcut ve her türlü takyid ile sınırlı ayni haklar saklı tutulur. Eski tapu kayıtlarındaki bu tür hak ve mükellefiyetler, kadastro tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir (KK m.19 I).

2684 Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise bunun sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir (KK m.19 II).

2685 Tarafların muvafakatı halinde kadastro teknisyenleri veya kadastro komisyonu ikili kullanmayı anlaşmaları çerçevesinde tek mülkiyete dönüştürebilir (KK m.19 III).

ii. Kayıt ve Belgelerin Kapsamını Tayin

2686 KK m. 20 hükmü tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayinine ilişkin hükümde: A) Kayıt ve belgeler, harita, plan ve krokiye dayanmakta ve bunların yerlerine uygulanması mümkün bulunmakta ise, harita, plan ve krokideki sınırlara itibar olunur. B) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar mahalline uygulanabiliyor ve bu sınırlar içinde kalan yer hak sahibi tarafından kullanılıyor ise, kayıt ve belgelerde gösterilen sınırlar esas alınarak tespit yapılır. C) Harita, plan ve krokiye dayanmayan kayıt ve belgelerde belirtilen sınırlar, değişebilir ve genişletilmeye elverişli nitelikte ise, bunlarda gösterilen miktara itibar olunur. Ancak değişebilir ve genişletilmeye elverişli sınırlardaki taşınmaz malların kayıtları, fizik yapıları ve konumları itibariyle belli

bir yeri kapsıyorsa, tespit o sınır esas alınarak yapılır. D) Hazinece, özel kanunlar hükümlerine göre değişmez ve genişlemeye müsait olmayan sınırlarla miktar üzerinden satılan, tefviz veya tahsis veya parasız dağıtılan taşınmaz mallarda çıkan fazlalık, taşınmaz malla birlikte satış, tefviz, tahsis ve dağıtım tarihinden itibaren on yıl geçmiş ise, miktarına bakılmaksızın kayıt sahibi adına tespit edilir.

2687 KK m.20'de yazılı taşınmaz mallarda meydana gelen fazlalıklar hakkında şartlar uygun bulunduğu takdirde, 14 üncü ve 17'nci madde hükümleri uygulanır.

jj. Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerler

2688 Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz (KK m.20 I c.1). Bu gibi yerler ikinci defa kadastroya tâbi tutulmuşsa, ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medenî Kanununun 1026'ncı maddesine göre işlem yapılır. Süresinde dava açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadastro, tapu sicil müdürlüğünce re'sen iptal edilir (KK m.20 I c.2). Ancak aşağıdaki hallerde yukarıdaki kural uygulanmaz:

2689 a) Tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde[65],

2690 b) Daha önce sadece tapu tahriri yapılan veya 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre yenileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine tâbi yerlerde.

---

[65] KK m.22/II'ye göre, "(a) bendinin uygulanacağı alanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün onayı ile belirlenir ve çalışmalara başlanmadan en az onbeş gün önce çalışma alanında, bölge merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, ayrıca varsa yerel gazete ile ilân edilir. Yapılacak çalışmalarda 2, 4, 14, 17, 19 ve 21'inci maddeler ile 13 üncü maddenin (B) ve 20'nci maddenin (B), (C) ve (D) bentleri hükümleri uygulanmaz".

2691 Tapulama ve kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tescili yapılır. Tapuya tescil edilmiş ormanlardan, haritaları teknik mevzuata uygun olanlar aynen, diğerleri ise teknik mevzuata uygun hale getirildikten sonra tapu kütüğüne aktarılır (KK m.22/IV).

kk. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi

2692 Kadastro Kanunu Ek Madde 3 (Ek: 15.1.2009-5831/8 md.)'e göre, bir mirasçı, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde tapu sicil müdürü, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Tebligat masrafları ilgilisince karşılanır. Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilir.

g. Ormanın Kadastrosu

2693 Kadastro Kanunu Ek Madde 5'e göre kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışma alanlarında, orman kadastrosu ya da tahdidi yapılmamış ormanlar, 4 üncü ve 39'uncu maddelerde yer alan esaslar çerçevesinde kadastroya tabi tutulur[c].

2694 6831 sayılı Orman Kanununun 20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2'nci maddesi ile 23.9.1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5.6.1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2'nci maddesinin (B) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, bu Kanunun 11'inci maddesinde belirtilen askı ilanı hariç diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir (Ek Madde 4[ç]). Bu maddeye göre yapılacak kadastro çalışmaları ikinci kadastro sayılmaz.

---

[c] KK Geçici Madde 7'ye göre, "*Bu Kanuna göre yapılacak çalışmalardan önce 6831 sayılı Orman Kanununa göre başlanan orman kadastrosu, bu Kanunun 4 üncü maddesine göre sonuçlandırılır*".

[ç] Beşinci fıkra Anayasa Mahkemesi'nin 12/5/2011 tarihli ve E. 2009/24, K. 2011/75 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

2695 Ek Madde 4 göre, yapılacak kadastro sırasında orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle orman işletme müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin iştirak ettirildiği kadastro ekibince zemine aplike edilir. Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde, yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. Bu çalışmalara kadastro kontrol mühendisi de iştirak ettirilir. Çalışma sonucunda bir zabıt düzenlenir ve bu zabıt ekip görevlileri ile kontrol mühendisi tarafından birlikte imzalanır. Düzeltme işlemleri, orman mevzuatı ile tapu ve kadastro mevzuatına göre yapılmış ve bu Kanuna göre yapılacak askı ilanı ile de ilan ve tebliğ edilmiş sayılır.

2696 Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle ifraz ve veya tevhit de yapılabilir. Bu işlemler sırasında, orman ve kadastro haritalarında tespit edilen fenni hatalar, yukarıdaki üçüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslara göre düzeltilir.

2697 Kadastro çalışmalarına başlanılmadan önce, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin içerisinde özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gereken alanlar bulunup bulunmadığı kadastro müdürlüğünce ilgili kurum ve kuruluşlarına yazı ile sorulur. İlgili idarelerce 15 gün içerisinde kadastro müdürlüğüne bilgi verilir. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde, söz konusu alanların bulunmadığı yönünde cevap verilmiş sayılır. Bu bilgilere veya ilgili idarelerce zeminde gösterilen sınırlara göre bu yerler içindeki bu alanların sınırları ölçülerek krokisinde gösterilir ve beyanlar hanesinde belirtilir.

b. İhya Edilen Taşınmaz Mallar

2698 Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar için KK 14 üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde hazine adına tespit edilir (KK m.17/I).

2699 İl, ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygulanmaz (KK m.17/II).

i. Hazine Adına Tespit ve Kazandırıcı Zamanaşımı Kazanım Yasağı

2700 KK hükümleri dışında kalan ve tescile tabi bulunan taşınmaz mallar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler Hazine adına tespit olunur (KK m.18 I). Orta malları, hizmet malları, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz mallar, tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez (KK m.18 II).

j. Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Haller

2701 KK'nda aksine hüküm bulunmayan hallerde, Türk Medeni Kanunu ile diğer kanunların iktisap ve tescile ilişkin hükümler uygulanır (KK m.23).

II. TESCİL

A. Genel Açıklamalar

2702 Yukarıda da sıklıkla belirttiğimiz gibi ayni hakların kurulması tescil işlemi ile gerçekleşir. Fakat belirtelim ki tescil ayni hakların sadece kurulması değil mevcut bir ayni hakkın kapsamının değiştirilmesi, devri veya ortadan kaldırılması işlevine de sahiptir. Tescil kavramı bazı hallerde sadece ayni hakkın tapu siciline yazılmasını anlamında kullanılırken bazı hallerde terkin ve düzeltme işlemini kapsayacak biçimde de kullanılmaktadır.

2703 Tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde ayni hak kazanılması, ayni hakkın kapsamının değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması için tescilin yapılması zorunludur. Fakat belirtelim ki, ayni hakların kazanılması tescil olmadan da bazı istisnai hallerde mümkündür. Belirtelim ki, bir tescil ayni hakkın doğumunu sağlıyorsa kurucu tescilden bahsedilirken, bir tescil elde edilen bir ayni hakkı sadece açıklıyorsa buna da açıklayıcı tescil denir[2].

---

[2] GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 250. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 327 vd.: Açıklayıcı nitelik taşıyan tescil ayni hakkı doğrudan doğruya etkilemez. Dolayısıyla onun tasarruf işlemi sayılması da mümkün olmaz. Buna karşılık, kurucu nitelik taşıyan tescilin aynı zamanda bir tasarruf işlemi sayılıp sayılamayacağı hususu tartışmalıdır. Bir görüşe göre, kurucu nitelik taşıyan tescil, her ne kadar ayni hak tescilin yapılmasıyla birlikte doğarsa da teknik an-

2704 Aynî hakkın tapu dışı bir yolla kazanıldığı hâllerde (kamulaştırma, cebri icra, mahkeme kararı, miras, olağanüstü zamanaşımı ile iktisap, işgal) hak sahibi adına tapuda yapılacak tescil, açıklayıcı mahiyettedir. Söz konusu tescilsiz kazanım durumlarında tescili talep yetkisi de prensip itibariyle **aynî hakkı tapu dışı yolla iktisap etmiş** (kazanmış) olan kimseye aittir.

2705 Tescil, lehine tescil yapılan kişi bakımından kazandırıcı bir işlem niteliğindedir. Tescil işleminin ayni hakkın kurulmasını sağladığı durumlarda ise mevcut hukukî durumda yenilik meydana getirdiği için yenilik doğurucu bir işlem niteliğinde olduğu kabul edilmelidir. Bunun bir sonucu olarak, tescilin şarta bağlanamayacağı belirtilebilecektir. Ayrıca tescil işlemi yukarıda da belirttiğimiz gibi sebebe bağlı bir hukukî işlem mahiyetindedir.

2706 TMK m. 1008'de, "*Taşınmaza ilişkin aşağıdaki haklar, tapu kütüğüne tescil edilir: 1. Mülkiyet, 2. İrtifak hakları ve taşınmaz yükleri, 3. Rehin hakları.*" düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre tescil işleminin konusunu ayni haklar oluşturmaktadır. Fakat belirtelim ki, ayni hakkın tesciline dayanak teşkil eden hukukî sebep de tescil edilmektedir[3].

2707 TST m. 27'de tescilin şekli açıklanmıştır. Buna göre, "*(1) İstem, yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı tarih ve yevmiye numarası ile kütüğe tescil edilir. Tescil, siyah veya mavi mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde yazılır. Kütük üzerinde kazıntı, silinti ve çıkıntı yapılamaz.*".

2708 Mülkiyet hakkının tescilini düzenleyen TST m. 28'e göre, "*(1) Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı, baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazı-*

---

lamda bir tasarruf işlemi sayılamaz. O, sadece usulî bir işlemdir. Aynî hak üzerinde tasarruf niteliğini taşıyan işlem tescil talebidir (istemidir). İkinci görüşe göre ise, tescil bir tasarruf işlemidir. Zira, bu işlem aynî hakka doğrudan doğruya etki eder. Son aşamada bir kamu görevlisi tarafından icra edilmesi bu sonucu değiştirmez. Üçüncü görüşe göre, tasarruf işleminin tescil talebi (istemi) ve tescilden meydana gelmektedir. Bu görüşü savunan *Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop*'a göre, taşınmazın mülkiyetinin devrine yönelen tasarruf işlemi birinci aşamada her iki tarafça yapılan ve resmî memurun katılımını zorunlu kılan bir sözleşme ikinci aşamada sadece malikin yetkili memura yapacağı yazılı talep ve üçüncü aşamada tapu sicili memurunun kütüğe düşüreceği tescil unsurlarını içine alır. Buna göre, tescil, taşınmaz mülkiyetinin geçmesini sağlayan tasarruf işleminin unsurlarından biri, fakat sonuncusudur **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 329.

[3] **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 324; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 241.

lır. Malik sütununun ilk beş satırına yeni malikin adı, soyadı ve baba adı, edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası yazılır.". Bu düzenlemede hukuki sebebin de tescil edileceği belirtilmektedir.

2709 Tescil ilkesinin mutlak tescil ilkesi ve nispi tescil ilkesi olarak ikiye ayırarak incelememiz gerekir:

2710 Mutlak tescil ilkesi, tescilin *kurucu (indasi) hukuki etkisini* (*konstituve, rechtsbegründende Wirkung*) ifade eder. Bu kuralın birinci istisnası, TMK m.727 III'te düzenlenen dışarıdan görülebilen mecra irtifakının tescille değil, noterde düzenlenen sözleşmeye dayanılarak mecranın yapılmasıyla doğmasıdır. Bu durumda aleniyet doğal olarak sağlanmıştır; yani *doğal aleniyet* söz konusudur. Diğer bir istisnası da, mecra geçirme hakkının, hak sahibinin istemi üzerine giderleri karşılandığında tapu kütüğüne tescil edilmesidir.

2711 Nispi tescil ilkesi (*relative Eintragungsprinzip*) ise, ayni hakkın sadece hukuki işleme (sözleşmeye) dayalı tescil olgusuyla değil, kanunda özel olarak düzenlenmiş diğer ayni hak kazandırıcı –tescilsiz iktisap- olguların gerçekleşmesi ile, örneğin, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma, mirasın intikali gibi olguların gerçekleşmesi ile tescil olgusu olmaksızın kazanılabileceğini ifade etmektedir.

2712 TMK m. 705 II'de sayılan bu haller *tescilsiz kurucu olgular*dır. Tescilsiz ayni hak kazanım olguları ile kişi taşınmaz üzerinde olgunun gerçekleşmesiyle ayni hak sahibi olsa da, hak sahibinin ayni hak üzerinde tasarruf edebilmesi, mülkiyetin tapu siciline tescil edilmiş olmasına bağlıdır. Buradaki tescil ayni hakkı kurucu değil, *açıklayıcı tescil*dir.

B. Tescilin Yapılabilmesinin Şartları

1. Geçerli Bir Hukuki Sebebin Bulunması

2713 Tapu sicilindeki kayıtların hüküm doğurması sebebe bağlıdır. Türk borçlar ve eşya hukuku işlemlerde birlik değil, ayrılma sistemini benimseyerek, borçlandırıcı işlemle tasarruf işleminin birbirinden ayrı olarak düzenlediği halde, her iki işlemin birbirine sebebe bağlılık ilkesi ile ilişkilendirmiştir[74].

[74] Alman hukukunda hakim olan soyutluk ilkesi (Abstraktionsprinzip), BGB'nin benimsediği ayrılık prensibinin/sisteminin (Trennungsprinzip) sonucudur bkz. **STADLER**, Soergel Einl. SachenR. Rn. 28; Tescil ilkesine ilişkin olarak ayrıntılı bilgi için bkz. **ANTALYA**, EH I. N. 616.

2714 Tasarruf işlemin geçerliliği, borçlandırıcı işleminin varlığına ve onun geçerliliğine bağlıdır. Bu bağlılık *sebebe bağlılık ilkesi* olarak ifade edilmektedir. Her iki işlemin tek işlemde birleştiği veya bütünleştiği haller de (Geschäftseinheit) pek ayrıştırılamazsa da, mevcuttur. Geçersizlik, olgu eksikliği aynılığı her iki sözleşmeyi ayrı ayrı etkiler.

2715 Borçlandırıcı (sebep) işlemin geçersizliğine sebep oluyorsa, geçersizlik tasarruf işlemine de sirayet ederek, onu geçersiz kılar; tam tersine, tasarruf işleminin geçersizliği borçlandırıcı işlemin geçersizliğine geçersizlik sebebinde ayniyet (Fehleridentität) söz konusu ise, örneğin ayırt etme gücü olmaması sebebiyle ehliyetsizlik, borçlandırıcı işlemi etkiler[75].

2716 Sağlar arası işlemlerde, tescilin hukuki sebebi esas itibarı ile taşınmazı devrini konu alan borçlandırıcı işlemlerdir. Konusu yönünden taşınmaz mülkiyetini devreden borçlandırıcı sözleşmeler; örneğin satış sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi hukuki sebebi oluşturur.

2717 Ölüme bağlı tasarruflar da, örneğin, vasiyetname, miras sözleşmesi taşınmaz devrinin sebebini oluşturabilirler. Hukuki sebebin belgelenmesi de, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur (TMK m.1015 III). Bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur (TMK m.1024 II).

2718 Bir ayni hak tapu siciline yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir (TMK m.1025 I). İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemleri korunur (TMK m.1023).

2719 Taşınmazlarda şekil zorunluluğu önemli bir rol oynar. Taşınmazdaki bir ayni hak kazanımı, değişimi ve terkininin belirli bir şekil zorunluluğu içinde gerçekleşmesi, aleniyetin doğrudan sonuçlarından biridir. Aynı haklar tescille değdukları an itibarı ile sıralarını ve tarihlerini alırlar (TMK m.1022 I). Önce yapılan tescil veya şerh kaydı, sonrakilere nazaran önceliklidir. Öncelik bakımından yevmiye defterine kayıt tarihi esas alınır (TMK m.2022 II; TST m.23 II c.2).

---

[75] Malikin ehliyetsiz olduğu zaman zarfında düzenlediği vekaletname ile satış işlemini gerçekleştirilmiş olmasının tapudaki tescili yolsuz hale getireceği yönünde bkz. Yarg. 1. HD. 06.02.2006, E. 2005/13101, K. 2006/680.

2720 Tapu sicilinde kayıtlı olan ayni hakkın niteliği, içeriği, kapsamı ve sınırları yine tapu sicilindeki kayıtla anlaşılır. Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi için, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini de belgelemiş olması gerekir (TMK m.1015 I). İstemde bulunan kimse, kendisinin aleniyet ilkesi gereği, tapu sicilinde hak sahibi görünen kişi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş olur (TMK m.1015 II).

2721 Tapu sicilinde kayıtlı ayni hakkın içeriğini belirlemesi, tapu sicilinin kendisinde kayıtlı hakkın herkesçe bilindiği ilkesi ve tapu sicilindeki kayıtların doğruluğuna kanıt oluşturduğu ilkesi ile ilişkilidir.

2722 TMK m. 1015'e göre, "*Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukukî sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır (1). İstemde bulunan kimse, kendisinin, sicilde hak sahibi görünen kişi veya bu kişinin temsilcisi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş olur (2). Hukukî sebebin belgelenmesi, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur (3).*". *Belirtelim ki*, tescile esas teşkil edecek bir hukukî sebep hiç yoksa veya var fakat geçerli değilse, yapılan tescil de geçersiz olur[76].

2723 *Tescilin dayanağını oluşturan hukuki sebep*, genelde ayni hakkın devrini veya ortadan kaldırılmasını isteme hususunda ilgililere hak ve yükümlülükler getiren bir *hukukî işlemdir*[77]. Bu, satış, bağışlama, mal değişimi, miras sözleşmesi, mirası paylaşma sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi iki taraflı bir hukukî işlem olabileceği gibi, belirli mal bırakma vasiyeti şeklinde tek taraflı bir hukuki işlem de olabilir[78].

2724 Şayet tescil talebinde bulunan, tasarruf yetkisini ve buna esas teşkil eden hukukî sebebi belgeleyemezse, tapu memuru tescil talebini reddedecektir (TMK m. 1016). Fakat hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam olmasına rağmen tasarruf yetkisi belgelenememişse malikin muvafakatı veya mahkeme kararı ile geçici tescilin şerhi tapu kütüğüne yazılabilir (TMK

---

[76] GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 244-245.

[77] GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 243.

[78] Hukukî işlemler dışındaki bir durum da tescile dayanak teşkil edebilir. Örneğin miras, işgal, olağanüstü zamanaşımı, kanuni rehin hakkı, mahkeme ilâmı, cebrî icra, kamulaştırma. Tescilden önce kazanımlarda iktisaba sebebiyet veren hukukî olay veya hukukî işlemin mevcut olması gerekir. Buna göre açıklayıcı tescilin de hukuki sebebi bulunmadıkça kendinden beklenen sonuçları doğurması beklenemeyecektir.

m. 1011). Eksik belgeler sonradan tamamlandığında, aynî hak, geçici şerhin yevmiye defterine yazımı anından itibaren hüküm ifade eder (TMK m. 1022).

2725 Belirtelim ki, tescile dayanak teşkil eden hukukî sebep geçerli olmadıkça kendinden beklenen sonuçları doğurmayacaktır. Hukukî işlem, ehliyetsizlik, imkânsızlık, genel ahlâk ve adaba aykırılık, muvazaa, şekil şartına riayet edilmemesi, aşırı yararlanma[79], irade bozukluğu gibi herhangi bir sebep yüzünden baştan geçersiz veya sonradan iptal edilmiş ise, buna dayalı olarak yapılan tescil de geçersiz olur ve düzeltilmesi istenebilir (TMK. m. 1025)[80].

2. Tescil Talebinin Yetkili Kişi Tarafından Yapılması

2726 TMK m. 1013'e göre, "*Tescil, tasarrufa konu olan taşınmaz malikinin yazılı beyanı üzerine yapılır (1). Edinen kimse, kanun hükmüne, kesinleşmiş mahkeme kararına veya buna eşdeğer bir belgeye dayanıyorsa, bu beyana gerek yoktur (2). Bir aynî hakkı tescilden önce kazanan kimse, gerekli belgeleri ibraz ederek tescili isteyebilir (3).*"

2727 Belirtelim ki, ilgililerce talep edilmedikçe tapu memurunun kendiliğinden tescil işlemini yapması mümkün değildir[81]. TST m. 16/1'e göre, "*Kanunlarda veya bu Tüzükte belirlenen istisnalar dışında, yazılı istem olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamaz.*". Tescil talebi, kural olarak, taşınmazın kayıtlı olduğu bölge tapu sicil müdürlüğüne yapılır.

2728 Tescil talebinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı olmayan bir talebe dayanılarak yapılan tescil hukuka aykırıdır. Tescil talebi, yapıldığı tarih, saat ve dakika ile yapanın kimliği, yerleşim yeri, talebin niteliği ve kapsamı, talebe konu taşınmazın köy veya mahalle adı, cilt ve sayfa numaraları ile işlemi hazırlayan, kontrol eden ve onaylayanın adı ve soyadı gösterilmek suretiyle önce yevmiye defterine yazılır (TST. m. 23).

2729 TST m. 17'de talepte bulunabilecekler, "*(1) Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler. (2) Aile konutu olarak özgülenen taşınma-*

---

[79] TOPUZ, M., "Yargıtay Kararları Işığında Türk Borçlar ve Ticaret Hukukunda Gabin (Aşırı Yararlanma). MÜHF-HAD. Doç. Dr. Mehmet Somer'in Anısına Armağan. 743 vd.

[80] Yarg. 1. HD. 06.02.2006. E. 2005/13101. K. 2006/680.

[81] GÜRSOY/EREN/CANSEL. s. 246.

zın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair şerhin verilmesini isteyebilir." şeklinde düzenlenmiştir[82].

2730 Tescil işlemirin yapılabilmesi için hem hukuki sebebın hem de tescil talebinde bulunma yetkisinin belgelenmesi lâzımdır[83]. Zıra, TMK m.1015'e göre, tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukukî sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır.

2731 Ayrıca belirtelim kı, tapu memurunun söz konusu hususları inceleme yükümlülüğü de mevcuttur. Tapu memuru tescil işlemini yapmadan önce, talep edenin bu işlemi yapmaya yetkili olup olmadığını, tescili istenen hususun buna elverişliliğini, tescil talebinde bulunan kişi veya kişilerın tasarruf yetkisini ve nihayet geçerli bir hukukî sebebin bulunup bulunmadığını özenle araştırmak zorundadır.

2732 Malik yanında, onun bir başkasına veya bizzat aynî hakkı kazanacak kişiye vereceği temsil yetkisi de o kimselerin tescil talebinde bulunabilmesini sağlar. Ancak önemle belirtelim, burada temsille kullanılacak tescil talebı için, bu yetkinin temsil yetkisinde özel olarak gösterilmiş olması şarttır[84]. Bunun yanında temsil yetkisinin kanundan doğduğu hâllerde ka-

---

[82] Tescil talebinin geri alınıp alınamayacağı hususu tartışmalıdır. Bir görüşe gore, tescil talebi bir kere yapıldıktan sonra artık geri alınamaz. İkinci görüşe gore, tescil talebinin, tapu memuru tarafından tescil işlemi yapılıncaya kadar geri alınması mümkündür. Tescil talebi gibi, dönme beyanının da yazılı olması şarttır. Beyan, tescil talebinde bulunma yetkisine sahip kimse veya yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir. Hattâ hak sahibinin tescilden önce ölmesi, hukukî işlem ehliyetini kaybetmesi gibi durumlarda, henüz tescil yapılmamış olması kaydıyla mirasçıları veya kanunî temsilcisi tarafından da dönme beyanında bulunulabilir. Tapu memurunun tescili yapmasından sonra ise, artık tek yönlü bir dönüş mümkün değildir. Somut olayın özelliklerine göre ya tarafların anlaşmaları ya da şartları varsa tapu sicilini düzeltme davasının (MK. m. 1025) açılması gerekir.

[83] **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 337; TST m. 22'de ise tescil talebine yönelik belgenin nasıl düzenleneceğine yer verilmiştir. Buna göre, "*Sözleşme düzenlenmesini gerektirmeyen işlemlerde, istem sahibinin kimlik bilgileri ile merkezi nüfus idaresi sisteminden alınan yerleşim yeri bilgilerini içeren istem belgesi düzenlenir. (2) Müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi, istem belgesinin imzalanmasından önce işlemle ilgili tüm belgeleri kontrol eder. İşlemi hazırlama ve kontrol etme görevleri aynı kişide birleşemez. Bu hüküm tek personel bulunan müdürlüklerde uygulanmaz. (3) İşlemde eksiklik ve yanlışlık bulunmuyorsa, kontrol görevini yapan, istem belgesinin 'işlem kontrolü yapıldı' sütununa adını ve soyadını yazarak imzalar. İşlemde eksiklik veya yanlışlık tespit edilmiş ise, bunlar giderilmeden imza aşamasına geçilmez. (4) İstem sahibi belgeyi 'okudum' ibaresini yazarak imzalar. İstem belgesi, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi ile belgeyi düzenleyen tapu görevlisi tarafından imzalanarak müdürlük mührü ile onanır. (5) İstem belgesinde silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz*". Satış yetkisi bulunmayan kişi aracılığıyla gerçekleştirilen tescil işleminin sicili yolsuz hale getireceği hususunda bkz. Yarg. 1. HD. 20.10.2011, E. 2011/8806, K. 2011/10610.

[84] TST m. 13/III hükmü, temsilcinin tescili talep edebilmesi bakımından, Noterlik Kanunu'na gore düzenlenmiş ve talebe konu işleri yapabilmeye ilişkin yetki verildiğini içerir bir vekaletnamenin

nunî temsilcilerin (veli ya da vasinin), vasiyeti tenfiz memurunun ve ihtiyari açık arttırma memurunun da tescil talebi bulunmaktadır[45].

2733 TST m. 18/1'e göre, "*İstem, müdür veya görevlendireceği tapu görevlisi tarafından incelenir ve istemin hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı belirlenir.*".

2734 TST m. 19'da, "*İstemde bulunanların fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı araştırılır. (2) Müdürlük, istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşerse resmî veya özel sağlık kuruluşundan ilgilinin ayırt etme gücüne sahip olup olmadığı hakkında fotoğraflı sağlık raporu ister. Raporun tarihi ve numarası resmî senet veya istem belgesi içeriğinde belirtilir ve raporun asli işlem dosyasında saklanır*".

C. Tescilin Gerçekleştirilmesi

2735 Buna karşılık yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik bulunmadığı kanaatine ulaşan tapu memuru, yevmiye defterindeki tarihe (kayıt sırasına) göre derhâl tescili gerçekleştirir. Kazanılması söz konusu olan aynî hak da yevmiye defterine yazılış tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Ayrıca, istemeleri durumunda ilgililere tapu kaydının onaylı bir sureti verilir.

D. Tescilin Hükümleri

1. Tescilin Olumsuz Hükmü

2736 *Tescilin olumsuz hükmü,* tapulu taşınmazlar üzerinde aynî hakkın doğumu veya mevcut bir aynî hakkın el değiştirmesi ya da sona ermesi için usulüne uygun bir tescilin zorunlu olmasıdır[46]. Tescil yapılmadığı sürece, aynî hak kurma amacına yönelik hukuki işlemler sadece taraflar arasında hüküm ifade eder. TMK m. 1021'de *kurulması kanunen tescile tâbi aynî*

---

ibrazını aramaktadır. Bu ise rızai temsil yetkisinin (vekaletname) resmî şekle tâbi olup olmadığı konusunda öğretide farklı görüşlerin ileri sürülmesine neden olmuştur. Ancak bu konudaki hâkim görüş tescili talep yetkisini içeren iradi temsilin resmî şekle tâbi olduğu yönündedir. Bu konudaki tartışmalar için ayrıca bkz. **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 164, dn. 553; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 334 vd.; **ERTAŞ**, s. 185, 186.

[45] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 164; Ayrıntılı bilgi için bkz. **ERTAŞ**, s. 183-184.

[46] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil, N.57; **HAAB**, ZK Einl. ZGB, N.62; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 94 vd.; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 66; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 194; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 343.

haklar, tescil edilmedikçe varlık kazanamaz denilmektedir. Diğer bir ifadeyle tescil yoksa ayni hak da yoktur[21].

2737 Belirtelim ki, ayni hakkın tescilden önce kazanıldığı hallerde tescilin olumsuz hükmü geçerli değildir. Çünkü, söz konusu hâllerde ayni hak tescilin yapılmasından önce doğmuştur. Yani, tescil kurucu değil açıklayıcıdır. Ancak, söz konusu hâllerde her ne kadar aynî hak tescilin yapılmasından önce kazanılmış ise de kazanılmış olan bu aynî hakkın herkese karşı ileri sürülebilmesi ve üzerinde tasarruflarda bulunulabilmesi için tescil şarttır (TMK. m. 705).

2. Tescilin Olumlu Hükmü

2738 *Tescilin olumlu hükmü*, tapu kütüğüne yapılmış olan her tescilin belirli bir aynî hakkı karşılamasıdır. Herkes, tapu kütüğündeki tescillerin taşınmaz üzerindeki ayni hakka uygun (doğru) olduğunu kabul etmekte haklıdır. Yani, tescil, ilişkin olduğu aynî hakkın varlığına karinedir (MK. m. 992). Ancak bu karinenin aksi iddia ve ispat edilebilir (TMK. m. 1025). İspat yükü aksini iddia eden tarafa düşer. Aksi iddia ve ispat edilinceye kadar doğru oldukları kabul edildiği için de *tapu siciline güven ilkesi* getirilmiştir (TMK. m. 1023). Bu nedenle, tescilin olumlu hükmü, "iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması ilkesi" olarak da nitelendirilebilir[22].

---

[21] Kural olarak aynî hakların tesisi veya doğumu için tapu siciline tescil şart ise de Kanun bazı hâllerde aynî hakkın tescilden önce kazanılabilmesine de imkân tanımıştır. Bir önceki başlıkta ifade edildiği üzere, şayet aynî hakkın varlığı için tescil şart ise bu durumda tescil kurucu mahiyettedir. Buna karşılık, aşağıda değineceğimiz hâllerden birinin varlığı durumunda aynî hak tapu dışı bir yolla iktisap edilmişse, bu hâlde yapılacak tescil sadece açıklayıcı bir fonksiyona sahiptir. Fakat aynî hakkın tescilsiz olarak kazanıldığı bu hâllerde dahi, aynî hak sahibinin tasarrufta bulunabilmesi için söz konusu açıklayıcı tescilin yapılması bir zorunluluktur. Örneğin taşınmaz mülkiyetini mahkeme kararı ile kazanan kişinin mülkiyetten doğan haklarını kısmen ya da tamamen bir başkasına devredebilmesi için tapuda adına tescilin yapılması şarttır. Aynî hakların tescilsiz kazanılma hâllerini şu şekilde özetlemek mümkündür. Aynî hakkın miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma yollarından biriyle kazanılması (TMK m. 705), özel mülkiyete tâbi olmayan sahipsiz yerlerde, arazinin kayması veya kamuya ait suların yer değiştirmesi suretiyle oluşan yararlanmaya elverişli arazilerin Hazinece kazanılması (TMK m. 708), taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kazanılması (TMK m. 713), şahsiyeti sona eren tüzel kişilerin sahip olduğu taşınmazların mülkiyetinin ilgili kamu kuruluşuna intikali (TMK m. 54, Dernekler Kanunu m. 55), bir vakfa tahsis edilen taşınmaz mülkiyetinin vakfın sicile tescil edilmesiyle kazanılması (TMK m. 105), Evlilik sözleşmesi ile mal ortaklığı rejiminin kabul edilmesi hâlinde (TMK m. 256), evlilik sözleşmesinin notere tescil ve ilanıyla birlikte eşlerin ortaklığa giren taşınmazlar üzerinde elbirliği hâlinde mülkiyeti kazanması (TMK m. 716), iki şirketin birleşmesi hâlinde, şirketlere ait taşınmazların mülkiyetinin yeni şirkete intikali (TTK m. 151), 775 sayılı Gecekondu Kanunu m. 3 ve 3091 sayılı İmar Kanunu m. 11 çerçevesinde, belediyelerin imar sahaları içinde kalan, daha önceden bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş Hazineye ait taşınmazların mülkiyetinin kendiliğinden belediyelere intikali.

[22] **MEIER-HAYOZ**, BK Syst. Teil. N.57 f.; **HAAB**, ZK Einl. ZGB. N.62 f.; **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 94 vd.; **ÜNAL/BAŞPINAR**, s. 66; **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 196.

III. TERKİN

A. Genel Açıklamalar

2739 Terkin, bir tescilin üzerinin çizilerek hükümsüz hale getirilmesini ifade eden tapu sicili işlemidir[89]. Diğer bir ifadeyle *terkin*, tapulu bir taşınmaz üzerinde bulunan bir aynî hakkı sona erdirmek için yapılan çizim işlemidir[90]. Ancak belirtelim ki, terkin işlemi sadece ayni hakların tapu sicilinden üzeri çizilerek ortadan kaldırılmasını değil, tapu sicilindeki diğer kayıtların da koşulları oluştuğunda silinmesini de ifade etmektedir[91].

2740 Tapu müdürlüğüne yapılan diğer bütün talepler gibi terkin talebi de önce yevmiye defterine yazılır. Daha sonra gerekli diğer unsurlar tamamlanır ve terkin işlemi icra edilir.

2741 Tescil gibi, dar anlamda terkinin konusunu da aynî hak oluşturur. Bu açıdan mülkiyet ile mülkiyet dışındaki (sınırlı) aynî haklar arasında fark yoktur. Geniş anlamda ele alındığı zaman ise, şerh veya beyan edilmiş bir husus da terkine konu teşkil edebilecektir. Terkin ayni hakka doğrudan etki ettiği için yenilik doğuran bir tasarruf işlemidir[92].

2742 Terkin tek taraflı hukuki işlem olup sebebe bağlıdır. Terkin talebinin koşula (şarta) veya vadeye bağlanması mümkün değildir. Tescil talebinde olduğu gibi, terkin talebi de terkin işlemi icra edilinceye kadar geri alınabilir. *Terkin işlemi yapıldıktan sonra ise dönülemez.*

2743 Terkin işleminin yapılış şeklini düzenleyen TST m. 70'e göre, *"(1) Tapu sicili üzerinde yapılacak terkinler, terkin edilecek hakla ilgili kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilmesi ve altındaki satıra yine*

---

89 OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 178.

90 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 342.

91 TST m. 69'a göre, *"(1) Tapu sicilinde terkin, tescilin kendisine hak sağladığı kimsenin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılır. (2) Kayıtların terkininde, tescil istemleriyle ilgili hükümler uygulanır. (3) Kanunda açıkça gösterilen hâller ile şerhedilmiş kişisel haklarda ve tescil edilmiş taşınmaz lehine veya kişisel irtifak hakkında belli bir süre söz konusu ise, bu sürenin dolması hâlinde taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin işlemi yapılır. (4) Bir aynî hakkın veya şerhedilmiş kişisel hakkın diğer sebeplere dayalı olarak sona ermesiyle kayıt hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir. Müdürlük, bu istemi yerine getirirse her ilgili, bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir. . ."*

92 GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 314; Terkinin yapılmasından önce ayni hakkın sona erdiği haller de vardır (Örneğin TMK. m. 705, 783, 843, 883). Söz konusu hallerde açıklayıcı terkinin varlığından bahsedilir. Böyle durumlarda ayni hak ortadan kalmıştır fakat tapuda şekli olarak mevcut olan tescilin tapudan terkin edilmesi gerekir.

kırmızı mürekkepli kalemle "terkin edildi" ibaresi ile tarih ve yevmiye numarasının yazılması ve müdürün veya görevlendireceği tapu görevlisinin imzalamasıyla olur...".

B. Terkinin Yapılabilmesinin Şartları

2744 Terkinin yapılabilmesi için tescil de olduğu gibi terkine dayanak teşkil edecek geçerli bir hukukî sebebin mevcut olması[53] ve yetkili kişinin terkin talebinde bulunması gerekir[54]. Diğer bir ifadeyle, terkinden etkilenecek aynî hakkın sahibi veya temsilcisi ya da yetkili makam tarafından terkin talebinde bulunulmuş olmalıdır[55].

2745 TMK m. 1014'e göre, "*Bir tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi, ancak bu kaydın kendilerine hak sağladığı kimselerin yazılı beyanı üzerine yapılabilir.*". Ayrıca TMK m. 1015'e göre de, "*Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukukî sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır (1). İstemde bulunan kimse, kendisinin, sicilde hak sahibi görünen kişi veya bu kişinin temsilcisi olduğunu ispat etmek suretiyle tasarruf yetkisini belgelemiş olur (2). Hukukî sebebin belgelenmesi, bu sebebin geçerliliği için gerekli şekle uyulduğunun ispatı suretiyle olur (3)*".

2746 Belirtelim ki, terkinin yapılabilmesi için talepte bulunanın hem terkine dayanak teşkil eden hukukî sebebi hem de tasarruf yetkisine sahip olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. TMK m. 1016'ya göre, "*Tasarruf yetkisine ve hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam değilse istem reddedilir. Bununla birlikte, hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam olmasına rağmen, tasarruf yetkisini belirten belgenin tamamlanması gereken hâllerde, malikin rızası veya hâkimin kararıyla geçici tescil şerhi verilebilir.*"

2747 Kanunun aradığı koşullar gerçekleşmediği halde yapılan terkin geçersiz yani yolsuz terkin niteliğindedir. Bu nedenle yolsuz terkinin düzeltilmesi gerekir. Yolsuz terkine rağmen taşınmaz üzerindeki aynî hak ortadan kalkmış olmaz. Gerçek hak sahibi açacağı bir tapu sicilinin düzel-

---

53 GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 316-317.

54 Y. 19. HD., 14.11.2005 T., E. 2005/283 K., 2005/11073: "*İpoteğin terkini malik tarafından istenebilir. Bir tescilin terkin edilmesi veya değiştirilmesi kendilerine hak sağlayan kişilerin beyanıyla yapılabilir. Terkine rıza gösterilmemesi halinde malik tapu kaydının düzeltilmesini dava etmek zorundadır. Mahkeme kararı üzerine terkini malik talep edebilecektir.*"

55 HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 454-455; GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 317.

tılmesi davası ile (TMK. m. 1025) ile yolsuz olan bu terkini düzelttirebilir.

C. Terkinin Hükmü

2748 *Terkinin hükmü söz konusu terkinin niteliğine göre farklılık arz edecektir. Kurucu nitelik taşıyan terkinlerde,* tapu memurunun terkin işlemini yapmasıyla birlikte konusunu oluşturan ayni hak sona erer. Terkinin konusu şerh edilmiş bir husus ise, şerh etkisini yitirir. Ancak, terkinin amacına uygun sonuçları yaratabilmesi için geçerli bir hukukî sebebe dayanması ve yetkili kişinin usulüne uygun şekilde dile getirdiği bir istem (talep) olması zorunludur. Aksi takdirde terkin yolsuz olur ve tapu sicilinin düzeltılmesi davası ile düzeltirilebilir (MK. m. 1025). *Açıklayıcı nitelik taşıyan terkinlerde* (MK. m. 705/1, 716/1, 883, 796-797, 1019, 1026) ise gerçek hak sahipliği etkilenmez. Zira, hak terkinin yapılmasından önce zaten sona ermiştir (TST. m. 69).

IV. ŞERH

A. Genel Açıklamalar

2749 Hukuk düzeninin sınırlı bir şekilde ortaya koyduğu bazı hususların tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılmasına şerh adı verilir. Şerhin başlıca amacı şerhi mümkün alacak haklarının taşınmaz üzerinde daha sonra hak kazanan kişilere karşı ileri sürme olanağını oluşturmak ve üçüncü kişilerin iyiniyet iddiasında bulunmasına engel olmaktır.

2750 TMK m. 1009, 1010, 1011 ile TST m. 47, 48 ve 49 nazara alındığında şerhin konusunu oluşturabilecek bazı hususlar ön plana çıkmaktadır. Bu hükümlere göre, bazı kişisel haklar (*MK. m. 1009; TST m.47*), taşınmaz malikinin tasarruf yetkisini kısıtlayan işlemler (*MK. m. 1010; TST m. 48*), tasarruf hakkını yasaklayan şerhler (*TST. m. 49*), geçici tescil *şerhi (MK. m. 1011; TST m. 50)*[86] *mevcuttur.*

[86] Ancak, tapu kütüğüne şerh edilebilecek hususlar sadece Medenî Kanunun 1009-1011'inci maddeleri ile Tapu Sicili Tüzüğünde sayılanlardan ibaret değildir. Hem Medenî Kanunun diğer hükümlerinde (MK. m. 254, 695/II, 698/II, 731/II, 733/II, 830, 871/III), hem de Borçlar Kanunu (292, 312), Tapu Kanunu (m. 26/V), Tapu Kayıtlarından Hukukî Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun (m. 2), Kat Mülkiyeti Kanunu (m. 24), 3081 sayılı Tarım Reformu Kanunu (m. 6, 7, 11), İmar Kanunu (m. 11), 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (m. 15/11), 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (m. 7/III, 16) gibi Medenî Kanun dışındaki bir kısım özel kanunlarda da şerh edilebilecek hususlar gösterilmiştir. Bkz. **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 398-400, 403-404.

2751 Kanunda sayılanlar dışındaki bir hususun tapu kütüğüne şerh edilmesi ise mümkün değildir. Belirtelim ki, şerh edilebilecek hususlar açısından *sınırlı sayı esası (numerus clauses)* geçerlidir[57].

2752 Kanunun öngörmediği hususlar şerh işlemine konu oluşturamazlar. Yargıtay bir kararında, hukukî bir dayanağı bulunmadığı için zılyetlik şerhının yok hükmünde olduğu, hiçbir hüküm ve sonuç doğurmayacağı, böyle bir şerhin silinmesinin istenebileceğine karar vermiştir[58].

B. Tapu Siciline Şerh Edilebilecek Hususlar

1. Kişisel Haklar

2753 TMK m. 1009'da tapuya şerh edilebilecek kişisel (nisbi) haklara ilişkin, "*Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerhedilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerhedilebilir (1) Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir (2).*" düzenlemesi mevcuttur[59].

---

[57] **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 273; **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 378.

[58] Yarg. 14. HD. 9.11.2015, E.2014/14305 K.2015/10079 (www.kazanci.com.tr); Yargıtay bir kararında "... *devre tatil sözleşmesinin geçerliği resmi şekle tabi olmayıp, Türk Medeni Kanunu'nun 1009. maddesinde tapu siciline şerh verilecek haklar tek tek sayılmış olup devre tatil hakkı yer almadığından tapu sicilne şerh bile edilemez ...*" sonucuna varmıştır. Yarg. 12. HD. 24.4.2014, E.2014/9207 K.2014/12090 (www.kazanci.com.tr).

[59] Bu konuda yazılmış önemli bir eser olarak bkz. **SUNGURBEY, İ.**, Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul 1963. Y. HGK. 02.11.2016 T., E. 2015/14-12, K. 2016/1005 "... *Kişisel haklar sadece sözleşmenin tarafları arasında hüküm ve sonuçlarını doğurur. Fakat hukukumuzda bazı kişisel hakların üçüncü kişiler bakımından da etkili olabilmesi için kabul edilen haller de vardır. Bunların başında zilyetlik gelmektedir. Ne var ki taşınmazlarda kamuya açıklık ve hak karinesi 'şeye zilyet' olmakla değil hakkın sicile kayıt edilmesine bağlandığı için taşınmazlar ile ilgili kişisel hak sahibi olanların hakkını korumada zilyetlik yeterli değildir. Kanun koyucu tarafından bu sakıncaları gidermek ve şahsi hak sahibinin güçlendirilmesi amacıyla taşınmazlarla ilgili bulunan bazı kişisel hakları tapu siciline şerh verdirerek, bunları taşınmaz üzerinde sonradan hak kazanan üçüncü kişilere karşı da öne sürmek olanaklı kılınmıştır... Kişisel (nispi) hakkın şerhinin, hak üzerinde yapacağı etki doktrinde tartışmalı olmakla birlikte çoğunluğun kabulüne göre şerhin iki etkisi vardır. Birincisi: şerh verilen kişisel hakkın konusunda borç doğuncaya kadar etkisidir ki bu şerh verilen hakla ilgili borcu "eşyaya bağlı borç" durumuna sokar. Buna göre, şerhten sonra taşınmazın her maliki kendi mülkiyeti esnasında doğacak borçla yükümlü olur. Şerhin ikinci etkisi: şerhten sonra taşınmazda hak kazanmış olanlardan, doğmuş borcun ifasında alacaklıya zarar verenlerin haklarının bertaraf edilmesini sağlamasıdır. Buna şerhin munzam etkisi denir. Şerhin birinci etkisi ancak borcun doğumuna kadardır. Borcun doğumundan sonra rolü yoktur. Doğan borç, hangi malik zamanında doğarsa onun borcudur. Borç doğduktan sonra taşınmaz el değiştirirse borç yeni malike geçmez. İkinci yanı munzam etki ise ancak borç doğduktan sonra söz konusu olur. Borç doğmadıkça bir rolü yoktur. Her iki etki bakımından da şerh kurucu bir nitelik taşır. Diğer bir ifade ile ancak şerhin yapılması ile kişisel hak sözü geçen etkilen kazanır.*".

2754 Belirtelim ki, söz konusu hükmün sözünden anlaşıldığı kadarıyla tapuya şerh edilebilecek kişisel haklar sadece TMK'da zikredilenler ibaret olmayıp başka kanunlarda düzenlenen kişisel hakların da tapuya şerh edilebileceği açıktır.

a. Tapuya Şerh Edilebilecek Başlıca Kişisel Haklar

2755 Nisbi hakların sadece taraflar arasında hüküm ve sonuç doğurması; sadece belirli kişi veya kişilere karşı ileri sürülebilmesi, üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesini ifade etmektedir. Ancak bununla beraber, kanunun öngördüğü bazı hallerde, kanunun belirlediği bir işlemin gerçekleştirilmesiyle borç ilişkisinden doğan nisbi hakların ileri sürülebilecekleri kişilerin kapsamının genişletilmesi ve etkisinin güçlendirilmesi mümkündür. Bir başka deyişle, kanun tarafından tanınan "şerh" müessesiyle, nisbi hakların bazılarının ileri sürülebileceği çevreyi genişletmek suretiyle hakların etkisinin kuvvetlendirilmesi yolu açılmıştır. Buna göre, kanunun öngördüğü bazı nisbi haklar, tapu sicilinde, şerh adı verilen bir kayıtla üçüncü kişilere karşı da iddia edilebilir hale getirilmiştir. Bu haklara "şerh edilebilir şahsi haklar" da denilmektedir[100].

2756 Taşınmazları konu edinen bir hak tapuya şerh verildiğinde söz konusu hak tapu sicilinin "şerhler sütunu"na yazılır. Tapu sicili aleni olduğundan ve orada yazan kayıtların bilinmediği hiç kimse tarafından ileri sürülemeyeceğinden artık şerh edilmiş nisbi hak, bu hakkı ihlal edenlere karşı ileri sürülebilir hale gelmektedir. Çünkü şerh ile birlikte nisbi hak aleni hale gelmekte, kimse şerhi bilmediğini iddia ve ispat edememektedir.

---

[100] Ayrıntılı bilgi için bkz. **CAUCH/SCHLEUP/SCHMID**, §2, Nr. 64a, §2, Nr.86; **LARENZ/WOLF**, § 15, Nr. 52 vd.; **ÖZTAN**, s. 77; **SEROZAN**, s. 252; **HATEMİ/SEROZAN/ARPACI**, s. 23; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 9. Alacak hakkının sadece borçluya karşı ileri sürülmesi kural olmakla birlikte, üçüncü şahıslara karşı da ileri sürülebildiği durumların mevcut olduğunu belirttik. Bu tür durumlarda alacak hakkının ileri sürülebileceği çevre genişlemektedir. Ancak bu durum alacak hakkının ayni hak haline geldiğini göstermemektedir. Alacak hakkı çeşitli biçimlerde güçlendirilebilir. Alacak hakkının güçlendiği ilk durum eşyaya bağlı borç durumudur. Eşyaya bağlı borç, bir kimseyi bir mala malik olduğu için yükümlülük altına sokan borçtur. Eşyaya bağlı borç, bir sözleşmenin ancak taraflarını borç altına sokabileceği prensibine istisna teşkil eder. Eşyaya bağlı borçlarda kişi, borçlanma yönünde herhangi bir irade açıklamasında bulunmasa da sırf o eşyaya malik olduğu için borçlu durumuna girer. Yani, eşyaya bağlı borçtan söz edilen durumlarda borçlu sıfatının bir eşyanın mülkiyetine bağımlı olarak belirlendiği, borç ilişkisi ile bağımlı bulunan eşyanın mülkiyeti kime geçerse, borçlu sıfatının da ona geçtiği kabul edilmektedir. Böylece alacaklı, başlangıçta borç ilişkisinin tarafı olmayan bir kişiye (yeni malike) karşı da alacak hakkını ileri sürebilme olanağına kavuşmuş olur. Eşyaya bağlı borçlara klasik örnek olarak, geçit irtifakı ile yükümlü taşınmaz malikinin geçidin bakımını da üstlenmesi gösterilir. Böyle bir durumda, geçit irtifakı ile yükümlü taşınmaz el değiştirirse, taşınmazın yeni maliki de geçidin bakımını yapmak mecburiyetinde kalır. Başka bir ifadeyle, yararlanan (hâkim) taşınmazın maliki, geçidin bakımını yapmasını yükümlü taşınmazın yeni malikinden de talep edebilir.

Kanunda şerhine izin verilen başlıca nisbi haklar şunlardır[61]:

aa. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Alıcının Hakkı

2757 Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan alıcının hakkı tapuya şerh verilebilir (TMK m. 1009/1; Tapu K. 26). Taşınmaz satış vaadi, taraflardan birine veya her ikisine bir taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasını istemek hakkını sağlayan bir ön sözleşmedir ve TBK m. 29/II uyarınca bu sözleşmenin noterde yapılmış olması gerekir. İşte geçerlilik şekline uygun olarak yapılan taşınmaz satış vaadinin tapu siciline şerh edilmesi, nispi (kişisel) hakkın üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilmesini sağlar[62]. Örneğin, (A), noterde gerekli şekle uyarak taşınmazını (B)'ye satma vaadinde bulunduğunda, bu vaat sadece kendisini bağlar. (B) ancak ondan, taşınmazı kendisine satmasını talep edebilir. (A) taşınmazını (B)'ye satıp ona devredecek yerde, onu (Ü)'ye devrederse, o takdirde (B), (Ü)'den herhangi bir talepte bulunamaz. Kural bu olmakla birlikte, eğer taşınmaz satış vaadi tapuya şerh verilmiş ise, o takdirde (B) satış vaadinin kendisine tanıdığı nispi hakkı taşınmazı sonradan iktisap eden (Ü)'ye karşı kullanabilir, yani taşınmazı kendisine satıp devretmesini (Ü)'den isteyebilir.

bb. Sözleşmeden Doğan Önalım (Şufa) Hakkı (TMK m. 1009/1; TMK m. 735)

2758 Ön alım hakkı, bir kimsenin taşınmazını üçüncü bir kişiye satması hâlinde onalım hakkı sahibine tek taraflı irade beyanı ile taşınmazın alıcısı olabilme yetkisini veren yenilik doğuran bir haktır. Adi yazılı şekilde yapılabilen onalım hakkı, şerh edilmediği sürece sadece o sözleşmenin tarafı olan taşınmaz malikine karşı ileri sürülebildiği hâlde, şerh edilmişse taşınmazın satılması durumunda satın alan üçüncü kişiye karşı da kullanılabilecektir[63].

---

[61] Ayrıntılı bilgi ve örnekler için bkz. NOMER, s. 9 vd.

[62] Taşınmaz satış vaadinin tapuya şerh edilmesinin altında yatan amacın, yaratılan hukuki durumun resmi kayda yansıtılarak, sonradan aynı hak sahibi olanlara karşı da ileri sürülebilmesi ve hukuki duruma aleniyet kazandırmasıdır. Bu yönde bkz. Y. HGK., 10.07.2013 T., E. 2013/14-474, K. 2013/1050; Y. 14. HD., 05.06.2014 T., E. 2014/2957, K. 2014/7487. Tapu Kanunu m. 26/V uyarınca, tapuya şerh edilen satış vaadi sözleşmesi uyarınca yapılan şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz ise şerh, tapu sicil müdürlüğü tarafından re'sen terkin edilir. Tapu Kanunu'nun açık hüküm karşısında terkinin malikin istemi üzerine yapılacağı yönünde bkz. Y. 14. HD., 05.06.2014 T., E. 2014/2957, K. 2014/7487.

[63] Y. 6. HD., 17.01.2012 T., E. 2011/13040, K. 2012/160: "*Sözleşmeden doğan onalım hakkı şahsi bir haktır. Sözleşmenin tarafı olanlar için hüküm ifade eder. Ayni bir hak olmadığı gibi ayni*

2759 Örneğin, evini (A)'ya kiralayan (B), kira sözleşmesinde (A)'ya onalım hakkı tanımıştır. Bu durumda, (B) taşınmazı üçüncü bir kişiye satmak istediğinde, (A)'nın taşınmazı öncelikle satın alma hakkı vardır. Önalım hakkının tapu siciline şerh verilmesi halinde, (A) bu hakkını taşınmazı satın alan üçüncü kişiye karşı da ileri sürebilir. (B), taşınmazı (C)'ye satar ve malik olarak da (C)'nin adı tapu siciline tescil edilirse, o takdirde (A) onalım hakkını, şerh sayesinde (C)'ye karşı kullanabilir. Bu hakkın kullanılmasıyla (A) ile (C) arasında bir satış ilişkisi kurulur; çünkü bu hak nispi hak olmasının yanında ayrıca kurucu yenilik doğuran haklardandır. Koşullar kütükte belirtilmemişse, o takdirde (B) ile (C) arasında kararlaştırılan koşullar, (A) ile (C) arasındaki ilişki için de geçerlidir (TMK 735/1). Kurulan bu satış ilişkisine rağmen, (C) taşınmazı (A)'ya değil de (D)'ye devrederse, o takdirde şerh sayesinde (A), taşınmazın kendine devrini (D)'den isteyebilir.

cc. Alım (İştira) Hakkı

2760 Alım (iştira) hakkı tapuya şerh verilebilir (TMK m. 1009/1; TMK m. 736). Resmî şekilde yapılması zorunlu olan alım hakkı, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanıyla bir taşınmazın alıcısı olabilme yetkisi veren yenilik doğuran bir haktır. Alım hakkı resmî şekilde yapılmış olmasına rağmen tapu siciline şerh edilmemişse sadece sözleşmenin tarafı olan taşınmaz malikine ve onun külli haleflerine karşı ileri sürülebildiği hâlde, şerh edilmesi durumunda şerhte belirtilen süre içerisinde her malike karşı ileri sürülebilir.

2761 Örneğin, (A), resmi şekilde yapılan bir anlaşmayla, (B) lehine alım hakkı tanımıştır. Buna rağmen, (A), alım hakkına konu olan taşınmazını (C)'ye devretmiştir. Alım hakkının şerh verilmiş olması halinde, (B) alım hakkını (C)'ye karşı kullanabilir. Alım hakkının kullanılması ile birlikte (B) ile (C) arasında bir satış ilişkisi kurulur; çünkü bu hak nispi hak olmasının yanında ayrıca kurucu yenilik doğuran haklardandır. Kurulan bu satış ilişkisine rağmen, (C) taşınmazı (B)'ye değil de (D)'ye devrederse, o takdirde şerh sayesinde (B), taşınmazın kendine devrini (D)'den isleyebilir.

---

zamanda nispi bir haktır. Önalım sözleşmesinin tapuya şerh edilmiş olması şahsi nitelik taşıyan hakka aynı hak vasfını kazandırır. Şerh bu hakkı güçlendirir ve herkese karşı ileri sürülebilir hale getirir. Hakkın tapuya şerh edilmesi mal sahibinin taşınmazını satmasını engellemez. Önalım sözleşmesi tapu siciline tescil edildikten sonra mal sahibi taşınmazını üçüncü kişiye satarsa o takdirde alacaklı üçüncü kişi hakkında da önalım hakkını kullanabilir.

dd. Geri Alım (Vefa) Hakkı (TMK m. 1009/1; TMK m.736)

2762 Resmî şekilde yapılması zorunlu olan geri alım hakkı, taşınmazını bir başka kimseye devretmiş kişiye, tek taraflı irade beyanı ile geri alabilme yetkisi sağlayan bir yenilik doğuran haktır. Geri alım hakkı tanımak üzere taşınmazı elinden çıkarmak zorunda kalan kişi ile yeni malik arasında yapılan sözleşme geri alım sözleşmesidir. İşte bu sözleşmeden doğan nispi (kişisel) hak, ancak şerh edilmesi durumunda taşınmazı devralan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir[1264].

2763 Örneğin, (A), taşınmazını (B)'ye satar. Satış sözleşmesinde (B), (A)'ya geri alım hakkı tanır. Daha sonra (B) taşınmazını (C)'ye devreder. Geri alım hakkının şerh verilmiş olması halinde, (A) bu hakkını (C)'ye karşı kullanabilir. Geri alım hakkının kullanılması ile birlikte (A) ile (C) arasında bir satış ilişkisi kurulur; çünkü bu hak da nispi hak olmasının yanında ayrıca kurucu yenilik doğuran haklardandır. Kurulan bu satış ilişkisine rağmen, (C) taşınmazı (A)'ya değil de (D)'ye devrederse, o takdirde şerh sayesinde (A), taşınmazın kendine devrini (D)'den isteyebilir.

ee. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Haklar

2764 Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan haklar tapuya şerh verilebilir (TMK m. 1009/1; Tapu K. 26/VII; TST m. 55/c): Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafları, müteahhit ve arsa sahibidir. Resmî şekilde yapılması gerekli olan bu sözleşme ile arsa sahibi yeterli maddî imkânlara sahip olmadığı için binanın yapım masrafı olarak arsasının tamamını veya belli bir payını müteahhide satmayı, müteahhit ise taşınmaz üzerinde bağımsız bölümler yapmayı ve arsa sahibinin hakkı olanları ona devretmeyi taahhüt eder. Ancak, resmî şekilde yapılmasına rağmen tapuya şerh edilmemiş böyle bir sözleşme, sadece arsa sahibini ve müteahhidi bağlar. Diğer bir ifadeyle, şayet arsa payı inşaat sözleşmesi tapuya şerh edilmemişse malikin taşınmazı bir başkasına devri durumunda, müteahhidin yeni malikten taşınmazın adına tescilini isteme hakkı yoktur. Buna karşılık sözleşme şerh edilmiş olsaydı müteahhidin sonraki devirlerde her yeni malike karşı devri istemesi mümkün olacaktı.

[1264] Y. 14. HD. 07/12/2016 T., E. 2015/15856, K. 2016/10198: "... *Vefa hakkı (geri alım hakkı) bir kimsenin satmış olduğu bir gayrimenkulü bedeli karşılığında tek taraflı bir irade açıklaması ile satın alma imkanını veren kurucu yenilik doğuran şahsi bir haktır. Tapu siciline şerh verildiği takdirde bu şahsi hak ayni bir nitelik kazanır. Konusu gayrimenkuldür ...*"

2765 Örneğin (A), arsası üzerinde inşaat yapması hususunda yüklenici (müteahhit) (M) ile anlaşır. (A), karşılık olarak arsasının 1/2 hissesini (M)'ye devretmeyi vaat eder. Taraflar noterde yaptıkları anlaşmayı tapuya şerh verdirirler. (A) taahhüdüne rağmen, arsanın tamamını (B)'ye temlik eder. (M), şerh sayesinde, arsanın 1/2 hissesinin kendisine devrini (B)'den isteyebilir.

ff. Kiracının Alacak Hakkı

2766 Kiracının alacak hakkı tapuya şerh verilebilir (TMK m. 1009/1; TBK m. 312). 818 sayılı (eski) Borçlar Kanunu'na göre, taşınmaz kiralarında, yeni malik kiracıyı mülkiyet hakkına dayanarak taşınmazdan çıkartabilmekteydi (Eski BK 254, 276). Kiracı, kira sözleşmesine dayanan nispi hakkını yeni malike karşı ileri süremezdi.

2767 Buna karşılık kiracı, kira sözleşmesi tapuya şerh verilmiş ise, kira sözleşmesinden doğan hakkını yeni malike karşı da ileri sürebilmekteydi. Bu takdirde yeni malik kiracıyı taşınmazdan çıkartamamaktaydı. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, "*Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur*" (TBK m. 310/1). Bunun yanı sıra, kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhine de imkân tanınmıştır (TBK m. 312).

2768 Bu düzenleme, konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin 351. madde ile birlikte bir anlam taşır. TBK m. 351/1 hükmü, yeni malike gereksinimi sebebiyle kira sözleşmesini sözleşme süresinin bitiminden önce sona erdirme imkânı tanımıştır. Şerh varsa, yeni malik kiracının kira sözleşmesine uygun olarak taşınmazı kullanmasına izin vermek zorundadır. İşte şerhin varlığı halinde yeni malik, m.351'de kendisine tanınmış olan edinim sebebine dayalı tahliye davasını kiracıya karşı açamayacaktır[725].

---

[725] Kişisel hakların tapu kütüğüne şerh ettirilmesinin amacı, hakkın yeni müktesiplere karşı da ileri sürülebilmesine imkân yaratmaktır. Oysa, 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu'nun 310'uncu maddesine göre, ***"Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur. Kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır."*** Borçlar Kanununun 311'inci maddesine göre de, ***"Sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü bir kişi, kiralanan üzerinde kiracının hakkını etkileyen bir ayni hak sahibi olursa, kiralananın el değiştirmesiyle ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır"***. Görüldüğü gibi, söz konusu düzenlemeler, kira sözleşmesinden doğan alacak hakkının yeni malike veya kiracının hakkıyla çelişen bir sınırlı ayni hak kazanmış üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilmesi için şerh edilmesine ihtiyaç bırakmamıştır. Buna karşılık, Medenî Kanun ve Tapu Sicili Tüzüğü kira sözleşmesinin şerhine imkân tanıdığı gibi, Borçlar Kanunu'nun 312'nci maddesine göre de, ***"taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhi kararlaştırılabilir"***. 818 sayılı eski Borçlar Kanununun ***"Satım ile kiranın infisahı"*** başlıklı 254'üncü maddesinin ***"Kiranın akdinden sonra, kiralanan kiralayan tarafından ahara temlik yahut icraen takibat veya***

gg. Tapuya Şerh Edilebilen Diğer Nispi Haklar

aaa. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlamalarda, Bağışlayanın Hakkı (TBK m. 292)

2769 Bağışlayana dönme (rücu) koşullu bağışlama sözleşmesinde, bağışlananın bağışlayandan önce ölmesi halinde, bağışlanan şeyin bağışlayana geri dönmesi söz konusudur. Bu hak şerh sayesinde, sonradan taşınmazda hak iktisap eden malike karşı ileri sürülebilir.

bbb. Taşınmaz Rehninde Sonraki Sırada Yer Alan Rehinli Alacaklının Boşalan Dereceye Geçme Hakkı (TMK m. 871/III)

2770 Taşınmaz rehninde sabit dereceler sistemi geçerlidir. Boş dereceye ilerlemek için rehin veren ve rehin alanın boş dereceye ilerleme sözleşmesi yapmaları gerekir. Örneğin (A), taşınmazı üzerinde (B) lehine birinci sırada, (C) lehine ikinci sırada rehin hakkı kurmuştur. (B) lehine kurulan rehin hakkının terkin edilmesi halinde, (A), bir başkası lehine birinci sırada rehin hakkı kurabilir; (C), bu halde kendisine ait rehin hakkının birinci sıraya geçirilmesini talep edemez (TMK m. 871). (C)'nin (A)'dan bunu talep edebilmesi, (A)'nın önceden bir sözleşme ile kendisine boşalan dereceye geçme hakkı tanımış olmasına bağlıdır. Resmi şekilde yapılan bu sözleşmenin tapuya şerh verilmesi halinde, (C), sözleşmeden doğan hakkını taşınmazda sonradan ayni hak kazananlara, özellikle boşalan derecede lehine rehin hakkı kurulan kimseye karşı da ileri sürebilir. Böy-

---

iflas tariki ile kendisinden nezedildiği takdirde; kiracı kiralananın ahiren maliki olan üçüncü şahıstan ancak kabulü şartı ile kiranın devamını ve kiralayandan akdi icra yahut tazminat ita etmesini isteyebilir." hükmü karşısında anlam taşıyan 312'nci maddenin 310 ve 311'inci maddeler karşısında nasıl bir anlam taşıyacağı hususu ilginçtir. 310 ve 311'inci maddenin sadece taşınmaz kiralarına değil, aynı zamanda taşınır kiralarına da uygulanacağı düşünülürse, kiracının yeni malik karşısında bu ölçüde korunmasının hakkaniyete uygun düşüp düşmediği hususu da tartışmaya açık bir görünüm arz etmektedir. Uygulama açısından bkz. Y. 6. HD. 18.11.2014 T., E.2014/2092 K.2014/12561. "kiralananın üçüncü kişiye satılmasının kira sözleşmesine etkisi TBK'nın 310. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse yeni malik sozleşmenin tarafı olur. Yasa hükmü uyarınca yeni malik satımla birlikte sozleşmenin tarafı haline gelirken, eski malik ile kiracı arasındaki akdi ilişki de sona erecektir. Sona eren akdi ilişkinin satım tarihi itibariyle tasfiyesi gerekir ..." kararlar için bkz. www.kazanci.com.tr. TBK'nın 310/I ve TBK'nın 312. Maddesi birlikte değerlendirildiğinde kira sozleşmelerinde şerhin önemini yitirdiği sonucuna ulaşılması isabetli bir yaklaşım olmayacaktır. Zira bu iki hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin 351. madde ile birlikte düşünüldüğünde önemli bir anlam kazanmaktadır. TBK'nın 351. madde hükmüne gore, yeni malik söz konusu kiralanana gereksinim duyuyorsa kira sozleşmesini sozleşme süresinin bitiminden once sona erdirebilmektedir. Şerh varsa, TEK 351 hükmünün uygulanması mümkün olamayacaktır. Şerhe rağmen taşınmazı satın alan yeni malik gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdiremeyecek ve kiracının taşınmazı kullanmasına izin vermek zorunda kalacaktır. Burada şerh yeni malikin tahliye davasının önünde geçmiş olacaktır.

lelikle ona ait hakkın terkin edilmesini ve boşalan dereceye kendisinin geçmesini sağlayabilir.

ccc. Paylaşmalı Mal Ayrılığında, Evliliğin İptali veya Boşanma Durumunda, Eşit Olarak Paylaşma Konusu Olan Aile Konutunda Kalma Hakkı (TMK m. 254/I-II)

2771 Örneğin (A) ile (B), evlenmeden kısa bir süre önce yaptıkları mal rejimi sözleşmesi ile "paylaşmalı mal ayrılığı" rejimini seçerler. (A) evlendikten sonra çalışarak edindiği para ile bir ev satın alır. Eşler, aile konutu olarak bu evi kullanırlar. Birkaç yıl geçtikten sonra eşler boşanır ve aile konutu eşler arasında eşit olarak paylaşılır (TMK m. 250/1). Taraflar boşanmadan sonra aile konutunda (B)'nin kalması hususunda anlaşırlar ve (B)'nin bu hakkı tapu kütüğüne şerh verdirilir. Bir süre sonra (A), payını (C)'ye devreder. (B), şerh sayesinde konutta kalma hakkını (C)'ye karşı da ileri sürebilir. Tarafların anlaşamaması halinde, boşanma hâkimi, konutta kimin kalmaya devam edeceği hususunda karar verebilir ve kararını, tapu kütüğüne şerh verilmesi için tapu memuruna bildirebilir (TMK m. 254). Hâkim, konutta kalma hakkını (B)'ye tanımış olsa, o takdirde (A)'nın sonradan payını (C)'ye devretmesi halinde, (B) şerh sayesinde bu hakkını (C)'ye karşı da ileri sürebilir.

ddd. Üst Hakkı Sona Erdiğinde, Üst Hakkı Sahibine Ödenmesi Kararlaştırılan Bedele İlişkin Anlaşmadan Doğan Haklar (TMK m. 830)

2772 Örneğin (A), sahibi olduğu arazi üzerinde (B) lehine üst hakkı kurar. (B), bu hakka dayanarak arazi üzerinde bir alışveriş merkezi inşa edecek ve 30 yıl boyunca bunu işletecektir. 30 yılın sonunda üst hakkı sona erecek ve (B)'nin inşa ettiği binalar (A)'ya kalacaktır (TMK m. 828/1). (A), kendisine kalan yapılar için uygun bir bedel ödemeyi kabul etmiş ve buna ilişkin anlaşma üst hakkının kurulması için gerekli olan resmi şekilde yapılmış ve tapuya şerh verilmiştir. (A), üst hakkı sona ermeden önce taşınmazı (C)'ye temlik ettiği takdirde, şerh sayesinde (B) bedel alacağını (C)'den isteyebilecektir.

b. Kişisel Hakların Şerhinin Gerçekleştirilmesi

2773 Kişisel hakkın geçerli biçimde şerh edilebilmesi için söz konusu hakkın tapuya şerhi mümkün haklardan olması ve şerhe dayanak teşkil eden hukukî işlemin de muteber olması gerekir. Şerhe dayanak teşkil

rine karşı ileri sürülebilir (f.2)." düzenlemesine yer verilerek tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler sayılmıştır"[6].

2778 TMK m. 1010 ile TST m. 48/c hükümlerinde yer alan husus daha ziyade taşınmaz üzerinde ayni hak kurulması veya devrini amaçlayan taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkan ihtilâflara ilişkin şerhlerdir"[7]. Yani taşınmaz üzerinde ayni hak değişikliğini gerektirecek uyuşmazlık konusu kişisel hakların, malikin tasarruflarına karşı resmî mercilerce ve özellikle mahkemelerce korunmasıdır.

2779 TST m. 48'de tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler için aranacak belgeler *"(1) Tasarruf yetkisini kısıtlayan şerhler için; a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmî yazısı, b) Devretmekle yükümlü önmirasçı atama hâlinde vasiyetnamenin onaylı bir örneği ve şerhi içeren mahkeme yazısı, c) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin hâllerde mahkeme kararı, ç) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen belgeler, aranır."* şeklinde düzenlenir.

2780 TST m. 49'da ise tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgeler, *"(1) Tasarruf hakkını yasaklayan şerhler için; a) İhtiyatî tedbir için mahkeme kararı veya yazısı, b) Kamu haczi, iflas veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin resmî yazısı, c) Aile konutu şerhi için merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medenî hâli gösterir nüfus kayıt örneği, ç) Aile yurdu kurulması hâlinde mahkeme kararı veya yazısı, d) Eşlerden birinin taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması hâlinde mahkeme kararı, e) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü diğer hâllerde kanunda belirtilen belgeler, aranır."* şeklinde düzenlenmiştir"[8].

---

[6] Ayrıntılı bilgi için bkz. **DOĞAN**, s. 33 vd. *Y. 14. HD., 12.2.2008 T., E. 2007/13090, K. 2008/1540* "*... Haciz, kesinleşmiş icra takibinin konusu olan bir alacağı ödemesini teminen borçluya ait ve haczi kabil bulunan mallara bir anlamda takibi yapan icra müdürlüğünün el koyması işlemidir. İİK. m.91 hükmünce gayrimenkulun haczi ile takip konusu borç ve eşya arasında ilişki kurulur ve malikin tasarruf yetkisi de Türk Medeni Kanununun 1010. maddesi anlamında kısıtlanmış olur. Tasarruf yetkisi kısıtlamaları da tıpkı ipotek şerhi gibi tapu kütüğüne şerh verilince taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir.*"

[7] **HATEMİ/SEROZAN/ARPACI**, s. 429.

[8] Belirtelim ki, ehliyetsizlik veya yasal onalım hakkı gibi doğrudan doğruya bir kanun hükmü ile getirilen sınırlamaların tapu kütüğüne şerh edilmeleri gerekmez. Zaten bunlar ister iyiniyetli ister kötüniyetli olsunlar, bütün sonraki müktesiplere karşı ileri sürülebilirler. **AÇIKGÖZ, O.**, Tarım Arazilerinde Yasal Önalım Hakkı (Tarımsal Önalım Hakkı), İstanbul 2018, s. 11 vd.

tiğinde mahkemeye başvurulması için bir süre verilir." şeklinde ortaya konulmuştur[123].

2789 TST m. 50'de, "*(1) İddia edilen bir aynî hakkın güvence altına alınmasının gerektiği veya tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki eksikliklerin sonradan tamamlanmasına kanunun olanak tanıdığı hâllerde, bütün ilgililerin istemi veya hâkim kararı ile geçici tescil şerhi verilebilir.*" denilmektedir.

2790 Belirtelim ki, TMK 1011'de belirtilen hallerde, TMK m. 1010'da belirtilen çekişmeli hakların tapu kütüğüne şerh edilmesinden farklı olarak, burada, *kazanılmış bir aynî hakkın güvence altına alınması (korunması)* söz konusudur[124].

2791 Miras, olağanüstü zamanaşımı, cebrî icra gibi bir sebeple sicil dışı kazanılmış aynî hakların tapu kütüğünde açık hâle getirilmesi amacına yönelik davalarda, davacı, mahkemeden kendisi lehine geçici tescilin şerh ettirilmesini isteyebilir. Aynı şekilde, yolsuz tescillerin düzeltilmesi için açılmış davalarda da geçici tescilin şerhi yoluna gidilebilir[125]. Amaç, üçüncü kişilerin henüz dava devam ederken iyiniyetle aynî hak kazanmalarını engellemektir[126].

---

[123] Bu hususta yazılmış önemli bir eser için bkz. **AYBAY, A.**, Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, İstanbul 1962. Y. 14. HD., 08.04.2011 T., E. 2011/3033, K. 2011/4659: "... *Tescilin tasarrufa konu taşınmaz malikinin yazılı beyanı ile yapılacağı, tescil için de tasarruf yetkisinin ve hukuki sebebin belgelenmiş olması gerektiği Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş, Tapu Sicil Tüzüğünde de açıkça belirtilmiştir. Tasarruf yetkisine ve hukuki sebebe ilişkin belgeler tamam değil ise tescil istemi reddedilecektir. Ancak, hukuki sebebe ilişkin belgeler tamam olmasına rağmen, tasarruf yetkisini belirten belgenin tamamlanması gereken hallerde malikin onayı veya hakim kararıyla geçici tescil şerhi verilebilmektedir. Türk Medeni Kanunu'nun 10:6. maddesinde tanınan bu hak yukarda değinilen 1011/2 kapsamında geçici tescil şerhi verilmesine olanak sağlamaktadır. Eldeki davada da hükmen geçici tescil şerhi kararı verilmesi talep edilmektedir.*"

[124] **OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR**, s. 185.

[125] **AYBAY**, s. 29 vd.; **GÜRSOY / EREN / CANSEL**, s. 289; **TEKİNAY / AKMAN / BURCUOĞLU / ALTOP**, s. 396; **HATEMİ / SEROZAN / ARPACI**, s. 431.

[126] **AYBAY**, s. 13-15; **TEKİNAY / AKMAN / BURCUOĞLU / ALTOP**, s. 396; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 288: Örneğin, zihinsel engelli (A) ile (B) arasında yapılacak bir satış sözleşmesi, resmî şekil şartı yerine getirilmiş olsa bile kesin hükümsüzdür. Dolayısıyla, tescil de yolsuz tescil olacağı için, tapu kütüğündeki tescile rağmen mülkiyet alıcıya geçmemiştir. Malik hâlâ (A)'dır. (A) veya onun ölümü hâlinde mirasçıları, (B) veya ölmüşse onun mirasçıları aleyhine tapu sicilini düzeltme davası açarak yolsuz kaydı düzelttirebilirler (TMK. m. 1025). Ancak, böyle bir davanın açılması kendiliğinden (B)'nin taşınmaza ilişkin tasarruf işlemleri yapmasını engellemez. Bu durum, iyiniyetli üçüncü kişilerin tapu siciline güven ilkesi (TMK. m. 1023) çerçevesinde taşınmazın mülkiyetini veya taşınmaza ilişkin diğer bir sınırlı aynî hakkı kazanmaları sakıncasını yaratır. İşte, yolsuz tescilin düzeltilmesi için dava açan (A) veya mirasçıları, dava ile birlikte geçici tescilin şerhi talebinde bulunurlar ve bu şerh gerçekleştirilirse, artık söz konusu sakınca ortadan kalkar. Şüphesiz, şerhe rağmen (B) yine tasarruf işlemleri yapabilir. Ama bu işlemler, mahkemenin olumlu yöndeki kararına istinaden yolsuz tapu kaydını kendi adına düzelttiren gerçek malik (A) tarafından terkin ettirilebilirler.

2792 Geçici tescilin şerh ettirilebileceği ikinci hâl, *"tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanlıkların tamamlanmasına kanunun izin vermesi"*dir. TMK m.1016 f.2'ye göre, "... *hukukî sebebe ilişkin belgeler tamam olmasına rağmen, tasarruf yetkisini belirten belgelerin tamamlanması gereken*[27] *hâllerde, malikin rızası veya hâkimin kararıyla geçici tescil şerhi verilebilir*".

2793 Örneğin, vekilin soyadının vekâletnameye yanlış yazılmış olması veya tescil talebinde bulunan kişinin nüfus hüviyet cüzdanındaki resminin çok fazla yıpranmış olması gibi durumlarda da geçici tescilin şerhi yoluna gidilebilir[28].

2794 Geçici tescilin şerh ettirilebileceği üçüncü durum ise, tartışmalı olmakla birlikte, *ait yüklenici veya zanaatkârların (yapı müteahhit ve işçilerinin) kanuni rehin istemek hususundaki haklarının sağlanmasıdır* (TMK. m. 893, 895).

b. Geçici Tescil Şerhinin Yapılması ve Etkisi

2795 Geçici tescilin şerhi, ya mal sahibi ve bütün ilgililerin talebi üzerine ya da bir mahkeme kararı ile gerçekleştirilir. İlgililerin talebi üzerine şerh, daha ziyade eksik olan belgelerin tamamlanmasında söz konusu olur[29]. Talebin yazılı olması gerekir. Böyle bir durumda şerhin süresini tapu memuru belirler (TST m. 83/1). Buna karşılık, taraflar geçici tescilin şerhi konusunda anlaşamazlarsa, şerhın yapılıp yapılmayacağına hâkim (mahkeme) karar verir. Geçici tescilin şerhi asıl dava ile birlikte istenebileceği gibi, ondan bağımsız olarak da istenebilir.

2796 Mahkeme seri muhakeme usulüne göre hareket eder ve iddia edilen hakkın varolduğu kanaatine ulaşırsa geçici tescilin şerhine hükmeder. Kararda şerhin süresi ve hükümleri de belirlenir[30]. Ayrıca, hâl ve şartlar gerektiriyorsa davacıya iddiasını ispat etmesi için ayrı bir süre de verilebilir (MK. m. 1011/III, c. 2). Belgelerin tamamlanması amacıyla yapılacak şerhlerde ise, süre, tapu memurunca belirlenir (TSN. m. 82).

2797 Hangi şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin, geçici tescilin şerhi (tescil ile ilgili geçici şerh) yapılırken "*(G.Ş.)*" kısaltmasıyla açıklama yapılır

[27] Ayrıntılı bilgi için bkz. **HATEMİ/SEROZAN/ARPACI**, s. 432.

[28] **TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP**, s. 397.

[29] **AYBAY**, s. 59.

[30] **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 290.

(TST. m. 51 II, c. 1). Kesin tescil, terkin olunacak geçici tescil şerhinin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır (TST. m. 51 1, c. 2).

2798 Şerhin malikin tasarruf yetkisini etkilemeyeceği yönündeki esas, geçici (muvakkat) tescilin şerhi bakımından da geçerlidir. Yani, şerhe rağmen malikin tasarruf yetkisi devam eder. Şerhle birlikte tapu kütüğü işlemlere kapatılmış olmaz. Geçici tescilin şerhi, sadece tapu sicilindeki kayıtlara iyiniyetle güvenerek aynî hak kazanılmasını (TMK. m. 712, 1023) engeller[31]. Buna karşılık, hak kesinleşirse, böyle bir durumda geçici tescilin şerh edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder[32].

V. BEYAN

A. Genel Açıklamalar

2799 *Beyan,* çoğunlukla taşınmazın fiilî ve hukukî durumuna ilişkin olup fakat aynî hak sahipliğini doğrudan etkilemeyen bazı hususların aleni hale getirmek için tapu kütüğüne yazılmasıdır. Bu yazım işlemi beyanlar sütununa yapılır. Beyan işlemi, beyanlar sütununda yazan hususlar bakımından üçüncü kişilerin iyiniyet iddiasında bulunmalarını önleyecektir. Beyan işlemi bir tasarruf işlemi değildir[33]. Belirtelim ki, beyanlar sütununa sadece mevzuatta belirtilen hususlar yazılabilir.

2800 TST m. 52'ye göre, *"(1) Kütüğün beyanlar sütununa, mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar tarih ve yevmiye numarası belirtilerek yazılır. (2) Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukukî veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti hâlinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda re'sen belirtilir".*

B. Beyanlar Sütununa Yazılacak Hususlar

2801 Yukarıda da belirttiğimiz gibi beyanlar sütununa yazılması mevzuatta öngörülen hususlar yazılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

1. Heyelân Bölgesi

2802 TMK m. 710'a göre, arazi kaymasının sınır değişikliğine yol açmayacağı ilkesi, yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yöre-

---

[31] GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 290-291.

[32] TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 402; AYBAY, s. 78.

[33] TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 404.

lerde uygulanmaz. Bu yörelerin belirlenmesi sırasında yöredeki arazinin yapısı göz önünde tutulur. Bir taşınmazın böyle bir yörede bulunduğu, ilgililere uygun biçimde bildirilir ve tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazılır.

2. Kanundan Kaynaklanan Geçit Hakları

2803 TMK m.748'e göre, taşınmaz malikinin taşınmazını işletme veya iyileştirme ya da taşınmazı üzerinde yapı yapma amacıyla komşu taşınmaza geçici olarak girme hakkı ile tarla yolu, hayvan sulama yolu, kış geçidi, tomruk kaydırma yolu ve oluğu ve bunlara benzer diğer geçitler özel kanun hükümlerine tâbidir. Özel kanun hükmü yoksa yerel âdet uygulanır. Doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit hakları, tapu kütüğüne tescil edilmeksizin doğar. Ancak, bunlardan sürekli nitelikte olanlar beyanlar sütununda gösterilir.

3. Toprağın İyileştirilmesi

2804 TMK m.755'e göre, su yollarını düzeltme, sulama, bataklık yerlerini kurutma, yol açma, orman yetiştirme, arazileri toplulaştırma gibi iyileştirme işleri, ancak ilgili maliklerin ortak girişimleriyle yapılabilecekse, arazinin yarısından fazlasına sahip bulunmak koşuluyla maliklerin üçte ikisinin bu yolda karar vermeleri gerekir. Diğer malikler de bu karara uymak zorundadır. Alınan karar, tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilir.

4. Eklentiler

2805 TMK m. 1012'ye göre, bir taşınmazın eklentileri, malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa yazılır. Bu kaydın terkini, kütükte hak sahibi görünen bütün ilgililerin rızasına bağlıdır. Taşınmaz mülkiyetine ilişkin kamu hukuku kısıtlamalarının beyanlar sütununa yazılması ve bu sütuna yazılabilecek diğer hususlar tüzükle belirlenir. Yine TMK m.862'ye göre, rehin, taşınmazı bütünleyici parçaları ve eklentileri ile birlikte yükümlü kılar. Rehnin kuruluşu sırasında makine, otel döşeme eşyası gibi açıkça eklenti olarak gösterilen ve tapu kütüğünde beyanlar sütununa yazılan şeyler, kanuna göre bu nitelikte olamayacakları ispat edilmedikçe eklenti sayılır. Üçüncü kişilerin eklentiler üzerindeki hakları saklıdır. TMK m. 1000'e göre, eklentiler, malikin isteği üzerine beyanlar sütununa kaydedilir. TST m.53'e göre, eklentiler mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine, kütüğün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye

numarası ile yazılır. İstem sahibinin dilekçesinde eklentinin adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir. (3) 23.6.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun eklentiye dair hükümleri saklıdır.

5. Kurulmaları Artık Mümkün Olmayan Ayni Hakların Yazımı

2806 TST m.54'e göre, 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmaları artık mümkün olmayan aynî haklar, ilgili taşınmaz kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. Bu hakların tasarruf işlemleri, bağımsız ve süreklı hakların kayıt usulüne tâbidir.

6. Vesayet Kararlarının Yazımı

2807 TST m.55'e göre, müdürlüğün, hak sahibinin vesayet altına alındığına veya vesayetin kaldırıldığına dair mahkeme kararlarından yazılı olarak bilgisi olursa, bu durum taşınmazın kütüğünün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile yazılır[34].

7. Zanaatkârlar veya Yüklenicilerin İşe Başlama Tarihinin Yazımı

2808 TST m.56'ya göre, işe başlama tarihi, hak sahibi, zanaatkâr veya yüklenicinin bildirimi üzerine beyanlar sütununa yazılır.

8. Yararlanan ve Yüklü Taşınmazın Bölünmesi

2809 TST m.63'e göre, yararlanan ve yüklü taşınmazın bölünmesinde kütük sayfasında mevcut hak ve yükler, oluşan yeni taşınmazların kütük sayfalarına aynen nakledilir ve beyanlar sütununda aralarındaki bağlantı gösterilir.

9. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili

2810 TST m.29'a göre, sosyal tesis, ticarî mahal, yüzme havuzu, tenis kortu gibi taşınmaz veya bağımsız bölümler ortaklaşa kullanıma ayrılmış ise, malik sütununa yararlanan taşınmazların ada ve parsel veya bağımsız bölüm numaraları yazılır. Ortaklaşa kullanılan yerler, yararlanan taşınmazlarla aynı ada ve parsel içerisinde olabileceği gibi, ortak sınırı olmaksızın ayrı ada ve parsellerde de bulunabilir. Yararlanan taşınmaz-

[34] İsviçre Medeni Kanunundan vesayet hükümleri çıkarılmış onun yerine Yetişkinleri koruma adı altında düzenlemelere yerverilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. **YAVUZ, C./ERLÜLE. F./TOPUZ. M.**, Yeni vesayet hukukuna doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku(İsviçre örneği), İstanbul 2017, s. 1 vd.

ların kütük sayfasının beyanlar sütununa, ortaklaşa kullanılan taşınmazın, hangi ada ve parsel veya bağımsız bölümle ortak olduğu belirtilir. Ortaklaşa kullanılan yerler, kanuni istisnalar dışında, yararlanan bütün taşınmaz maliklerinin birlikte istemleri olmadan paylı mülkiyete dönüştürülemez.

2811 Belirtelim ki beyanlar sütununa yazılacak olan hususlar bu saydıklarımızla sınırlı olmayıp başkaca hususlar da mevcuttur[25].

C. Beyanın Yapılması

2812 Beyan işlemi, kural olarak, malikin veya diğer bir ilgilinin yazılı talebi üzerine gerçekleştirilir (TST. 16/1). Bu yapılırken tarih ve yevmiye numarası da belirtilir (TST. m. 52/1). Beyanın yapılması konusunda, beyan edilecek hususlara ilişkin olarak da Tapu Sicili Tüzüğünde getirilmiş özel hükümler vardır. Örneğin eklentiler, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine, kütüğün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile yazılır (TST. m. 53/1). Tapu memurunun beyan işlemini kendiliğinden yapmak zorunda olduğu hâllerle de karşılaşılabilir. Örneğin, Tapu Sicili Tüzüğünün 52'nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukuki veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti hâlinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda re'sen belirtilir.

D. Beyanın Hukuki Etkisi

2813 Beyan, sadece konusunu oluşturan husus bakımından **açıklayıcı nitelik** taşır[26]. Buna karşılık, **ayni haklar üzerinde herhangi bir etki yapmayacağı gibi, kişisel hakları (alacak haklarını) güçlendirmesi de söz konusu değildir**. Burada ulaşılmak istenen amaç, hukuk düzeninin ön-

[25] Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde eklentiler, kat irtfakı kurma taahhüdü, yönetim planı ve onda daha sonra yapılan değişiklikler (KMK. m. 28); harab olan kata düşen arsa payının devri (KMK. m. 47/II), devre mülk kurulmasına ilişkin sözleşme (KMK. m. 47/11. 60, 61) beyanlar sütununa yazılabilir. Aynı şekilde, 3402 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, taşınmaz üzerinde bulunup da malik dışındaki bir kişiye ait olan muhdesat; kadastro tespitlerine karşı otuz günlük askı ilânı içinde açılan davaların esas numarası; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 7'nci maddesine göre taşınmazın korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olduğu hususu; 3194 sayılı İmar Kanununun 11'inci maddesine göre, belirli istisnalar dışında hazine ve özel idareye ait arsalardan belediyeye ve özel idareye bırakılan arsaların satılamayacağı ve başka amaçla kullanılamayacağı hususu da beyanlar sütununa yazılır. Bkz. OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 217; ÜNAL/BAŞPINAR, s. 207-208; Y. 7. HD. 12.12.2012 T., E. 2012/7247, K. 2012/9185.

[26] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 216.

gördüğü bir kısım hususlara açıklık (aleniyet) kazandırmak ve bu sayede üçüncü kişilerin iyiniyet iddialarını ortadan kaldırmaktır[37].

2814 **Beyan, tapu kütüğüne yazılan hususların eklenti sayılacağı hususunda da adi bir karine yaratır** (TMK. m. 862). Ancak, bunun için eklenti olarak yazdırılan taşınırların asıl şeyin mahiyetine yabancı olmaması gerekir. Aksi takdirde, sadece beyanlar sütununa bir yazımın yapılması taşınıra eklenti niteliği kazandırmaz ve onu eklentiye ilişkin hükümlere (TMK. m. 862) tabi kılmaz. Bu konuda ispat yükü, anlaşmazlık konusu şeyin eklenti niteliği taşımadığını iddia eden tarafa düşer. Beyan, zanaatkârlar ve yüklenicilerin işe başladıkları tarih bakımından ise, bu tarihten yapının bitimini izleyen üç aylık sürenin sonuna kadar taşınmaz üzerinde ipotekten başka bir rehin hakkı kurulmasını önler (TMK. m. 897).

2815 ***Beyanlar açısından tapu siciline güven ilkesi (TMK. m. 1023) uygulanmaz.*** Yani, tapu kütüğünün beyanlar sütununa yapılmış bir kaydın doğruluğuna **güvenerek iyiniyetle ayni hak kazanılamaz**[38].

VI. DÜZELTME

A. Genel Açıklamalar

2816 *Düzeltme gerçek hak durumuna uygun düşmeyen başta tescil ve terkin işlemleri olmak üzere* gerçeğe aykırı her türlü tapu kaydının gerçeğe uygun hâle getirilmesidir. Söz konusu düzeltme işlemi ile birlikte tapu sicili gerçek hak durumunu yansıtacak hale gelmektedir[39]. Tapu sicilinin gerçek hak durumunu yansıtmaması farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Örneğin tapu sicili işlemleri yapılırken bir yanlışlık yapılmış olabileceği gibi sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle de yanlışlıklar ortaya çıkabilir[40].

2817 Tapuda gerçek hak durumunu göstermeyen yanlış kayıtların bulunması telafisi oldukça zor malvarlığı zararlarına neden olabilir. Çünkü iyiniyetli üçüncü kişilerin kazanımları sonucu gerçek hak sahibi haklarını

---

[37] GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 298.

[38] HATEMİ/SEROZAN/ARPACI, s. 447; GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 298-299; ESENER/GÜVEN, s. 90.

[39] Düzeltme işlemi, gerçek hak sahipliği üzerinde herhangi bir etki yapmadığı için tasarruf işlemi niteliği taşımaz. Düzeltmenin amacı gerçeğe aykırı tapu sicili kayıtlarının yeniden gerçek hak durumuna uygun hâle getirilmesidir.

[40] TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 411-412; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 218.

kaybedebilir. Diğer yandan tapu kayıtları gerçek hak durumunu yansıtmıyorsa gerçek hak sahibinin hakları üzerinde tasarruf yetkisini kullanması da mümkün olmayacaktır[141]. İşte, bütün bu sakıncaları ortadan kaldırabilmek için, kişilere, belirli şartlar altında tapu kayıtlarının düzeltilmesini isteme imkânı tanınmıştır[142].

B. Tapu Sicilini Düzeltme Yöntemleri

1. İstem Üzerine Düzeltme

2818 TMK m. 1026'da, "*Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir (f.1). Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir (f.2).*

2819 *Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir (f.3).*" şeklindeki düzenleme tapu sicilinin düzeltilmesi için bir düzenleme getirmiştir.

2820 TMK m.1027'de, "*İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir (f.1). Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir (f.2). Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir (f.3).*" tapu sicilinin düzeltilmesi için düzenleme getirmiştir.

2821 Söz konusu düzenlemeler nazara alındığında istem üzerine tapu sicilinin düzeltilmesi için taraflardan birinin talebi üzerine veya tarafların anlaşması ile mümkün olduğu görülmektedir. Belirli hallerde tapu memurunun ilgili tarafları düzeltme için çağırması da mümkündür.

2822 Eğer taraflardan sadece biri tapu sicilinin düzeltilmesini talep ediyorsa kural olarak aynî hakkın sona erdiğinin tapu kayıtlarından açıkça anlaşılması gerekmektedir. Tapu Sicil Tüzüğü m. 69'da, "*(1) Tapu sicilinde terkin, tescilin kendisine hak sağladığı kimsenin istemine ya da yetkili makam veya mahkeme kararına istinaden yapılır. (2) Kayıtların terkinin-*

---

[141] Bkz. ÜNAL/BAŞPINAR, s.211; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.218; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 413-414.

[142] Bu hususla ilgili yazılmış önemli bir eser olarak bkz. KURT, E., Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, İstanbul 2004.

de, tescil istemleriyle ilgili hükümler uygulanır. (3) Kanunda açıkça gösterilen hâller ile şerhedilmiş kişisel haklarda ve tescil edilmiş taşınmaz lehine veya kişisel irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise, bu sürenin dolması hâlinde taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin işlemi yapılır." düzenlemesiyle bu duruma dikkat çekmiştir[43].

2823 TST m. 74 III'e göre, ana veya yardımcı siciller üzerinde yapılmış hata veya eksikliklerin, ilgililerce sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerden kaynaklanması hâlinde, *ilgililerin gerçek durumu kanıtlayıcı belgelere dayalı başvuruları üzerine,* istem yevmiye defterine kaydedilerek gerekli düzeltme yapılır. Gerekli düzeltmeyi yapan tapu memuru ilgilileri durumdan haberdar eder (TMK. m. 1019).

2824 Tapu sicilinin düzeltilmesinin bir diğer yolu tarafların anlaşmasıdır. Bu anlaşmaya göre yolsuz tapu kaydının düzeltilmesi istenebilir. Kanaatimizce söz konusu anlaşmanın yazılı yapılması yeterlidir.

2825 Tapu sicilini düzeltmenin bir diğer yolu, tapu memurunun, tarafları gerçekte sona ermiş aynî hak için terkin talebinde bulunmaya çağırmasıdır. Böyle bir durumda, kendilerine çağrı yapılan ilgililer yazılı olur verirlerse, memur bu olur çerçevesinde gerekli düzeltmeyi yapar. O, çağrıda bulunmaya gerek görmezse veya taraflar yapılan çağrıya icabet etmezlerse, doğrudan mahkemeden terkin yönünde karar vermesini de isteyebilir.

2. Re'sen Düzeltme

2826 TMK m. 1027 f.3'e göre, *tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir.* TST m. 74 1'e göre ise, *kütük,*

[43] İrtifak hakkının süresinin dolması, intifa veya oturma hakkı sahibinin ölmesi, tüzel kişiliğin ortadan kalkması veya tüzel kişi lehine kurulmuş intifa hakkında yüz yıllık sürenin geçmesi gibi hâllerde ayni hakkın sona ermiş olduğu tapu kayıtlarının incelenmesinden kolayca tespit edilebilir. Dolayısıyla, bu tip olaylarda, yüklü taşınmazın maliki tek başına gerekli düzeltmenin yapılması için talepte bulunabilir. Tapu Sicili Tüzüğü, kadastro çalışmaları sonucunda ortaya çıkan yanlışlıkların düzeltilmesini özel olarak düzenlemiştir. Buna göre, kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine; senetsizden tespitlerde, nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber, kayda dayalı tespitlerde, dayanağı kayıt ve belgeler, incelenmek ve gerektiğinde tanık ve varsa tespit bilirkişileri dinlemek ve zeminde inceleme yapmak suretiyle istemin gerçek hak sahibinden geldiği belirlenirse, istem yevmiye defterine kaydedilerek düzeltilir (TST. m. 75/I). Zeminde inceleme, kadastro müdürlüğü teknik personeli ile birlikte yapılır ve inceleme neticesinde teknik rapor düzenlenir. Zeminde incelemede, komşu parsel malikleri, muhtar ve diğer ilgililer dinlenir, vergi kaydı ve diğer her türlü bilgi ve belgeden yararlanılır (TST. m. 75/II). Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesinde de yukarıdaki fıkralar uygulanır (TST. m. 75/III). Bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılması zorunludur (TST. m. 75/IV).

yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde, belgelere aykırı basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır. Basit yazım hatasından maksat, ilişkin olduğu hakkı olumsuz yönde etkilemeyen, hakkın nitelik ve değerini veya hakkın varlığı ve içeriği ile ilgili olamayan yanlışlardır[44]. Örneğin fındık bahçesi olarak yazılması gereken bir arazi çay bahçesi olarak yazılmışsa bu yanlışlık tapu memurluğunca düzeltilebilir[45].

2827 Şüphesiz, aynî hak niteliği taşımayan bir hak tapu kütüğüne tescil edilmiş ise, böyle bir tescil de tapu memuru tarafından re'sen düzeltilebilecektir. Zira, daha önce de işaret edildiği üzere, sadece aynî haklar tescil işlemine konu teşkil edebilir. Tescil, usulüne uygun şekilde yapılmış olsa bile, aynî hak niteliğine sahip olmayan bir hakka aynî hak niteliği kazandıramaz.

3. Mahkeme Kararı ile Düzeltme

2828 TMK m. 1025'e göre, "*Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir (f.1). İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır (f.2)*". Bu hükümde tapu sicilinin düzeltilmesi davası düzenlenmiştir. Bu davaya uygulamada tapu iptali ve tescil davası adı verilmektedir[46]. Uygulamada yerleşmiş adı ise "tapu iptali ve tescili davası" dır.

2829 Tapu sicilinde yer alan yolsuz kayıtların düzeltilmesi gerekir. Hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın, yolsuz tapu sicili kayıtlarının en kısa zamanda düzeltilmesinde ve tapunun gerçek hak durumunu yansıtmasının temin edilmesi hem kamusal hem de hak sahibince büyük öneme sahiptir. Çünkü *yolsuz tescil devam ettiği sürece gerçek hak sahibinin hakkı üzerinde tasarruf etmesi mümkün olmaz.* Ayrıca gerçek hak sahibi tapu sicilinin yarattığı hak karinelerinden yararlanamaz. Üçüncü kişiler tapu sicilindeki kayıtlara iyiniyetle güvenerek mülkiyet veya sınırlı aynî

---

[44] OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 222.

[45] Söz konusu durumlarda gerekli düzeltmeyi yapan tapu memurunun ilgilileri durumdan haberdar etmesi gerekir (TMK m. 1019). Düzeltme işlemi yüzünden aynî hakkı zarar gören veya zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişiler "otuz gün içinde" bu düzeltmeye karşı mahkemeye itiraz edebilirler (TMK m. 1026/II).

[46] Bu hususta bkz. ÜSTÜNDAĞ, S., Tapu Kütüğünün Düzeltilmesi Davası, İstanbul 1959.

hak kazanabilirler. Tapudaki tescilin yolsuz olduğunu bilmeyen iyiniyetli sicil zilyedinin olağan zamanaşımı ile taşınmazın mülkiyetini veya lehine tescil edilmiş görünen sınırlı aynî hakkı kazanması ihtimali vardır

2830 Kanunun öngördüğü istisnalar dışında, mahkeme tarafından verilmiş bir karar mevcut olmadıkça tapu sicili kayıtlarında düzeltme yapılması mümkün değildir. Bu duruma TMK m. 1027 f.1, *ilgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir şeklinde düzenlemiştir.*

2831 *Tapu sicilini düzeltme davası*, kural olarak mülkiyet veya bir sınırlı aynî haktan kaynaklandığı için *ayni nitelik taşır*[47]. Dolayısıyla, herhangi bir *hak düşürücü veya zamanaşımı süresine tabi değildir*. Bu davanın nitelik olarak da bir tespit davası olduğu belirtilmektedir.

2832 Tapu sicilinin düzeltilmesi davası esas itibarıyle tescil ve terkin işlemleri için açılsa da taşınmaz üzerindeki ayni hak sahipliğini doğrudan veya dolaylı etkiledikleri oranda şerh ve beyan işlemleri için de açılabilecektir.

2833 Tapu sicilini düzeltme davasını *gerçek hak sahibi açabilir*. Bunlar yolsuz tescil dolayısıyla zarara uğrama tehlikesine maruz malik veya sınırlı aynî hak sahibidir. *Paylı mülkiyette*, her paydaş kendi payı için bağımsız olarak bu davayı açabilir. *Elbirliği mülkiyetinde*, tapu sicilini düzeltme davasını maliklerin birlikte açmaları zorunludur. *Aynî hakları dolaylı bir şekilde ihlâl edilmiş kişilerin* de bu davayı açabilecekleri kabul edilmektedir[48]. Örneğin, rehin hakkı sahibi, hâkim taşınmaz lehine mevcut olup da yolsuz bir şekilde terkin edilmiş geçit veya kaynak irtifakının düzeltilmesini isteyebilir. Buna karşılık, *satı alacak hakkı sahibi olan kişiler* bu davayı açamazlar[49].

2834 Tapu sicilinin düzeltilmesi davası gerçek hak sahibi olmadığı halde tapuda hak sahibi görünen veya yolsuz; terkinden yararlanan kişiye karşı açılır[50]. Bu açıdan, onun iyi veya kötüniyetli olması önem taşımaz. Davalı ölmüşse mirasçıları aleyhine dava açılır. Lehine yolsuz tescil yapılmış kişiden hakkı devralan üçüncü kişi aleyhine de, kötüniyetli olması kay-

[47] GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 303; ÜSTÜNDAĞ, s. 30.

[48] GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 309.

[49] TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU / ALTOP, s. 421.

[50] ÜSTÜNDAĞ, s. 94; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s. 220.

dıyla, tapu sicilini düzeltme davası açılabilir (TMK. m. 1023, 1024 III). Buna karşılık, devralan iyiniyetli ise, artık ona karşı tapu sicilini düzeltme davası açılamaz (TMK. m. 1023). Böyle bir durumda, sadece malik olmadığı halde taşınmazı devreden veya üzerinde sınırlı aynî hak kuran kişiye karşı, koşulları olmuşsa haksız fiile dayalı olarak tazminat davası açılabilir veya sebepsiz zenginleşmeye dayanan taleplerini ileri sürebilir. Şerhlerde, dava lehine yolsuz olarak şerh yapılmış kişi aleyhine açılır. Haksız olarak terkin edilmiş bir şerh için dava açılacaksa, davalı malıktır. Beyanlarda da aynı esas geçerlidir[51].

2835 Gerçek hak sahibinin adının veya soyadının yanlış yazıldığı hâllerde de tapu kütüğünün düzeltilmesi gerekir. Uygulamada, bu tip isim ve soyadı düzeltilmesine ilişkin davalar için tapu müdürlüğüne husumet yöneltilmektedir. Yargıtay'a göre, bu tip davalarda tapu müdürlüğü ilgili sıfatıyla yasal hasım durumunda olduğu için yargılama giderlerinden ve yargılama giderlerinden olan vekâlet ücretinden sorumlu tutulmamalıdır[52].

2836 Tapu sicilini düzeltme davası sonucunda sicildeki kaydın gerçeğe uygun düşmediği tespit edilmiş olur. Mahkemenin kararı kurucu olmayıp bildiricidir[53]. Davacı, mahkemenin kararına dayanarak tapu kütüğünü düzeltttirebilir. Bunun için mahkeme tarafından ayrıca talimat verilmesine gerek yoktur[54].

2837 İster ilgililerin talebi üzerine, ister tapu memurunca re'sen, isterse mahkeme kararıyla olsun, düzeltme (tashih), yanlış kayıtların okunacak şekilde kırmızı mürekkeple çizilmesi ve ilk boş sütuna doğrusunun yazılması suretiyle gerçekleştirilir (TST. m. 76 I). Kazıntı, silinti, satır aralarına veya sayfa kenarına çıkıntı veya kayda ek yapılmak suretiyle düzeltme yapılamaz (TST. m. 76 II). Yevmiye defterine kaydedilerek yapılar. düzeltmelerde tarih ve yevmiye numarası, düzeltmeler siciline kaydedilerek yapılanlarda ise bu sicilin numarası düzel-

---

[51] TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 422.

[52] Gerçek hak sahibinin adının veya soyadının yanlış yazıldığı hâllerde de tapu kütüğünün düzeltilmesi gerekir. Uygulamada, bu tip isim ve soyadı düzeltilmesine ilişkin davalar için tapu müdürlüğüne husumet yöneltilmektedir. Yargıtay'a göre, bu tip davalarda tapu müdürlüğü ilgili sıfatıyla yasal hasım durumunda olduğu için yargılama giderlerinden ve yargılama giderlerinden olan vekâlet ücretinden sorumlu tutulmamalıdır. Y. 1. HD. 25.9.2013 T., E.2013/9518 K.2013/13423 (www.kazanci.com).

[53] Y. 1. HD. 12.2.1993 T., E.1993/1407 K.1993/1598 (www.kazanci.com).

[54] ÜSTÜNDAĞ, s. 131-132; GÜRSOY/EREN/CANSEL, s. 313.

tilen işlemin üzerine "D.S." şeklinde başlayarak yazılır. Ayrıca, düzeltme ile ilgili belgeler taşınmaz mala ait dosyada saklanır (TST. m. 76/III)[55].

2838 Tapu sicilinin düzeltilmesi davası uygulamada bazı davalarla karıştırılmaktadır. Bu davaların başında tescile zorlama davası (TMK m. 716) gelmektedir. Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukuki sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda bir alacak hakkına sahip olan kimse, malikin kaçınması halinde hakimden, mülkiyetin kendi adına geçirilmesini talep edebilir. TMK m. 716 f.1'e göre, "Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukuki sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse, malikin kaçınması hâlinde hâkimden, mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir.". Söz konusu hüküm, borçlandırıcı bir işlem sonucu bir taşınmazın mülkiyetini devir yükümlülüğü altına giren borçlunun, haklı bir neden bulunmamasına rağmen, bu borcunu yerine getirmemesi yani tapu memuru önünde tescil bildirimine yanaşmaması durumunda başvurulur, alacaklının, ayni bir hakka dayalı gerçek hak sahibi olmaması nedeniyle tapu sicilinin düzeltilmesi davasını açması söz konusu değildir. Malikin, tescili talepten kaçınmasını gerektiren haklı nedenlerin bulunması durumunda dava reddedilir[56].

2839 Tescile zorlama davası bir eda davasıdır ancak bu dava sonucunda elde edilen hüküm bir eda ilamı olmayıp, yenilik doğuran bir karar niteliği taşır. Karar içeriğinde, mülkiyetin davacıya geçirildiği hususu açıkça belirtilmelidir; bunun dışında kararda ayrıca tapu memuruna yöneltilmiş bir tescil emrinin yer almasına gerek yoktur. Bu hüküm, mülkiyetin tescilden önce kazanıldığı hallere de bir örnek teşkil etmektedir. Mülkiyetin kazanılması anı, kararın kesinleştiği tarihtir. Tapu sicilinin düzeltilmesi davası bir tespit davası niteliği taşımaktadır. Tescile zorlama davasının

---

[55] Düzeltme (tashih), hangi şekilde yapılırsa yapılsın, kurucu olmayıp açıklayıcı nitelik taşıdığı için taşınmaz üzerindeki ayni hak sahipliğini etkilemez. Sadece, düzeltmenin yapılmasıyla birlikte maddî hukuk bakımından mevcut olduğu hâlde şekilen tapu kütüğünde görünmeyen haklar tapu kütüğünde de görünmeye başlarlar. Başka bir ifadeyle, gerçek hak durumuna uygun düşmeyen tapu sicili kayıtları düzeltmenin yapılmasıyla birlikte gerçek hak durumuna uygun hâle gelirler. Düzeltme, hakkın tapu kütüğünde görünmemesinden kaynaklanan sakıncaları ortadan kaldıracağı gibi, hak sahibine de hakkı üzerinde tasarruf etme imkânını yeniden kazandırır. Tapu sicilini düzeltme davası sonucunda gerçekleştirilmiş bir düzeltmeye rağmen, düzeltmenin yapılmasına kadar geçen süre içinde iyiniyetle sınırlı ayni hak kazanmış kişilerin kazanmaları korunur.

[56] Ayrıntılı bilgi için bkz. **AKİPEK/AKINTÜRK**, s. 96-97; **KURT**, s. 177.

temelini, aralarındaki borç ilişkisi nedeniyle tescil borçlusu malikin tescil talebinde bulunma yükümlüğü oluşturmaktadır. Bu nedenle, tescile zorlama davasının, hukuki sebebini oluşturan temel ilişkideki zamanaşımına tabi olacağı açıktır. Oysa aynı bir dava niteliği taşıyan düzeltme davası herhangi bir zamanaşımına tabi olması söz konusu değildir[57].

[57] Ayrıntılı bilgi için bkz. **ÜSTÜNDAĞ**, s. 32; **GÜRSOY/EREN/CANSEL**, s. 502; **TEKİNAY/ AKMAN/ BURCUOĞLU/ ALTOP**, s. 716; **KURT**, s. 177.

Kaynakça

ACAR, F., Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 2015 (Rehin).

ACAR, F., Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, Tıpkı 2. Basım, İtanbul 2017.

AÇIKGÖZ, O., Tarım Arazilerinde Yasal Onalım Hakkı (Tarımsal Onalım Hakkı), İstanbul 2018.

ACEMOĞLU, K., Türk Hukukunda Tapu Kütüğüne Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Hukukı Durumu, İstanbul, 1965.

AKBIYIK, C., Miras Sebebiyle İstihkak Davası, İstanbul 2003.

AKÇURA KARAMAN, T., Gemi ve Hava Aracı İpoteği ve Motorlu Taşıt Rehni, İstanbul 2019.

AKINCI, Ş., Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ-Doku) Naklı Kavramı ve Bundan Doğan Hukukı Sonuçlar, Ankara 1996.

AKİPEK, J., "Mülkiyet Kavramı Üzerine Bir İnceleme", BATIDER, C.V. S.1, Şubat 1969.

AKİPEK, J. G./AKINTÜRK, T., Eşya Hukuku, İstanbul 2009.

AKİPEK, J. G./AKINTÜRK, T., Eşya Hukuku, İstanbul 2009.

AKİPEK, J., Medeni Hukuk I. Cilt, I. Cüz, Ankara 1973.

AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Eşya Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2018.

AKSOY DURSUN, S., Eşya Kavramı, İstanbul 2012.

ANTALYA, O. G., Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I. İstanbul 2016 (Kısaltma: **ANTALYA**, BH GH I).

ANTALYA, O. G., Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II. İstanbul 2016 (Kısaltma: **ANTALYA**, BH GH II).

ANTALYA, O. G., Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt III, İstanbul 2016 (Kısaltma: **ANTALYA**, BH GH III).

ANTALYA, O. G., Elektronik Tapu Sicili, Ankara, 2019. (Kısaltma: **ANTALYA**, Elektronik Tapu Sicili)

ANTALYA, O. G., Eşya Hukuku Cilt I, Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2017. (Kısaltma: **ANTALYA**, EH I)

ANTALYA, O. G., Eşya Hukuku Cilt II, Zilyetlik İstanbul 2017. (Kısaltma: **ANTALYA**, EH II)

ANTALYA, O. G./TOPUZ, M., Eşya Hukuku, Cilt III (Tapu Sicili), İstanbul 2018 (Kısaltma: **ANTALYA/ TOPUZ**, EH III).

ANTALYA, O. G., Eşya Hukukuna Hakim Olan İlkelerden Aleniyet İlkesi, MÜHFD-HAD, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu'na Armağan, Cilt: 23, Sayı: 3, 2017. (Kısaltma: **ANTALYA**, Aleniyet İlkesi)

ANTALYA, O. G., Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması, İstanbul 2017 (Kısaltma: **ANTALYA**, Manevi Tazminat).

ANTALYA, O. G./ACAR, F., Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, İstanbul 2017. (Kısaltma: **ANTALYA/ACAR**, Taşınır Rehni)

ANTALYA, O. G./SAĞLAM, İ., Miras Hukuku, İstanbul 2015. (Kısaltma: **ANTALYA/ SAĞLAM**, Miras)

ANTALYA, O. G./TOPUZ, M., Medeni Hukuk (Giriş, Temel Kavramlar, Başlangıç Hükümleri), İstanbul 2016. (Kısaltma: **ANTALYA/ TOPUZ**, Medeni)

ANTALYA, O. G./TOPUZ, M., Medeni Hukuk (Giriş - Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri), Marmara Hukuk Yorumu, Cilt I (Editör: **ANTALYA, O. G.**), Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul 2019. (Kısaltma: **ANTALYA/ TOPUZ**, MHY I: Medeni)

ANTALYA, O.G., Gelecekteki Hakta Tasarruf, Prof. Dr. Fahiman Tekil'e Armağan, İstanbul 2003, s. 545 vd (Kısaltma: **ANTALYA,** Gelecekteki Hakta Tasarruf).

ARMUTCUOĞLU, C. Y., "Aile Konutuna Sağlanan Koruma ve Aile Konutu Şerhinin Hukuki Niteliği" MÜHF-HAD, C. 17, S. 1-2.

ARNET, R./BELSER, E. M., CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht Art. 641-977 ZGB, Zürich - Basel - Genf 2012.

ARNET, R./BELSER, E. M., Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht (Art. 641–977 ZGB), Zürich 2012.

ARNET, R./BELSER, E. M., CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (Hrsg.: **BREITSCHMID, Peter/RUMO-JUNGO, Alexandra**), Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, 2. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2012.

ATAR, E. A., Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkı ve Korunması, İstanbul, 2017.

AVCI, M. Ö., Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması, İstanbul 2014.

AYAN, M., Eşya Hukuku – I (Zilyetlik ve Tapu Sicili), Ankara 2016.

AYAN, M., Eşya Hukuku – III (Sınırlı Ayni Haklar), Ankara 2017 (Sınırlı Ayni Haklar).

AYBAY, A., Tapu Sicilinde Muvakkat Tescil, İstanbul 1962.

AYBAY, A./HATEMİ, H., Eşya Hukuku, İstanbul 2010.

AYBAY, Rona. Tapu Sicili "Herkese Açık" Mıdır? Çelişkiler Yumağı Bir Madde: Mk 1020, İBD, C. 87, Sa. 2013/2, s. 15 vd.

AYİTER, K., Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri. Ankara 1953.

AYİTER, N., Mamelek Kavramı Üzerinde İnceleme, Ankara 1968.

BÄNZIGER-COMPAGNONI, D., Die Öffentlichkeit des Grundbuchs – de lege lata – rechtsvergleichend – de lege ferenda, Diss. Zürich 1993.

BASSENGE, P., Palandt Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, 73. Aufl., München 2013.

BAŞPINAR, V., "Sınırlı Ayni Hakların Sırası", Türkiye Noterler Birliği Dergisi, Sayı 78, Yıl 1993, s. 50-60.

BAŞPINAR, V., Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Müdahaleler, Ankara 2009.

BAŞPINAR, V., Türk Toprak Hukukunda İhya, Ankara 2000.

BAŞPINAR, V., Elektronik Tapu Sicili Düzenlenirken, Tapu Sicilinin Aleniyeti ve Diğer Alanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler. AÜHFD. C. 57. S. 3. 2008. s. 97 vd.

BAUR, F./BAUR, J.F./STÜRNER, R., Sachenrecht, 18. Aufl., München 2009.

BENGEL, M./SIMMERDING, F., Grundbuch, Grundstück, Grenze, 5. Aufl., Neuwied 2000.

BERGER, Der Besitz von Rechten, Zürich 1915.

BESSON, C., Non, l'art. 949a CC et la modification de l'ordonnance sur le registre foncier du 23 novembre 1994 ne sont pas des absurdités. ZBGR 2 1996, s. 140 ff.

BIGLER-EGGENBERGER, M., Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, Art. 1– 456 ZGB, Honsell Heinrich Vogt Nedim Peter Geiser Thomas (Hrsg.), 3. Aufl., Basel Genf München 2006.

BÖHRINGER, W., Änderungen der Rechtsquellen des Grundbuchrechts, BWNotZ 1996, s. 25 ff. (Kısaltma: **BÖHRINGER**, BWNotZ 1996).

BÖHRINGER, W., Auswirkungen des Register erfahrenbeschleunigungsgesetzes auf den Grundstücksverkehr in den neuen Bundeslandern. DtZ 1994, s. 50 ff. (Kısaltma: **BÖHRINGER**, DtZ 1994).

BÖHRINGER, W., Informationelles Selbstbestimmungsrecht kontra Publizitätsprinzip bei § 12 GBO. Rpfleger 1987, s. 181 ff. (Kısaltma: **BÖHRINGER**, Rpfleger 1987).

BÖHRINGER, W., Isolierte Grundbucheinsicht durch Notar fur Dritte, DNotZ 2014, s. 16 ff. (Kısaltma: **BÖHRINGER**, DNotZ 2014).

BÖTTCHER, R., Grundbuchordnung: GBO Kommentar (Hrsg.: **MEIKEL, Georg**), 11. Aufl., Köln-München 2015.

BREDL, Walther, SOLUM-STAR - Das maschinell geführte Grundbuch, MittBayNot 1997, s. 72 ff.

BREHM, W./BERGER, C., Sachenrecht. 2. Aufl., Tübingen 2006.

BURCUOĞLU, H., "Taşınır Mülkiyetinin Devrinde Sebebe Bağlılık ve Sebebpten Soyutluk Kavramları ve Bu Kavramlar Kapsamında Sebepsiz Zenginleşme", İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 4, S. 1, İstanbul 2018 (Sebebe Bağlılık).

BURCUOĞLU, H., Paranın Başkasının Parası ile Kaçırılması Üstüne Bir Deneme, Prof. Dr. Faruk Erem'e Armağan, TBB Yayını, Ankara 1994, s. 94 vd.

BÜTTNER, W./FROHN, M., Elektronischer Rechtsverkehr in Grundbuchsachen, DNotZ-Sonderheft 2016, s. 157 ff.

BYDLINSKI, P., Grundzüge der juristischen Methodenlehre, 2. Aufl., Wien 2005.

CANSEL, E., Menkul Mülkiyetinin Geçişinin İlliliği Mese-lesi ve Ayni Sözleşme Kavramı, İmran Ökcem'e Armağan, Ankara 1970.

CANSEL, Erol, Tapu Siciline İtimat Prensibi, Ankara 1954.

COİNG, H., Europäische Privatrecht, Band 1, 1989.

ÇAVDAR, P., Anayasa Mahkemesi'nin 2014/12321 Başvuru Numaralı ve 20.07.2017 Tarihli Kararı'nın Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Cilt 24, Sayı 1, Haziran 2018.

ÇEVİK, İ., Alman Hukukunda Elektronik Tapu Sicilinin Gelişimi ve Oluşumu, MÜHF-HAD, C. 24, S. 2, 2018, s. 1086 vd.

ÇOLAK, U., Türk Marka Hukuku, İstanbul 2016.

DEDE, İ., Ürün Kiras: Sözleşmesinde Kiracının Haksız Zilyetlikte İade Sorumluluğu Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, I. Cilt, MÜHF-HAD Özel Sayı, C. 22, S. 3, 2016, s. 857 – 877.

DEILLON-SCHEGG, B., CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (Hrsg.: **BREITSCHMID, P./RUMO-JUNGO, A.**), Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, 3. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2016.

DEMHARTER, J., Beck'sche Kurz-Kommentare, Grundbuchordnung, 31. Aufl., München 2018.

DESCHENAUX, H., Das Grundbuch, Schweizerisches Privatrecht (Hrsg.: **MEIER-HAYOZ, A.**), Bd. V/3, II, Basel 1989.

DOĞANAY, İ., Türk Hususi Hukukunda Zilyetliğin Himayesi, AD (1959) 50-4.

DOMEJ, T., Kurzkommentar ZPO, Hrsg: Oberhammer Paul Domej Tanja Haas Ulrich, 2. Aufl., Basel 2013 (Kurzkommentar).

DRESSLER, Alexander, Grundbuchordnung: GBO Kommentar (Hrsg.: **MEIKEL, Georg**), 11. Aufl., Köln-München 2015.

DURAL, M./SARI, S., Türk Özel Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2017.

DÜRR, D., Zürcher Kommentar, Art. 793-804 ZGB und Systematischer Teil. Das Grundpfand, 2. Aufl., Zürich 2009.

EDİS, S., Menkullerde Mülkiyetin İntikali Meselesi Hususiyle İlliyet Meselesi, AÜHF Dergisi, Cilt 14, Sayı: 1- 4, 1957.

EITEL P./ ARNET R., CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, Zürich - Basel - Genf 2012.

EITEL, P., Bricht Kauf Miete und Leihe bei Fahrnis? Festschrift für Eugen BUCHER zum 80. Geburstag, Bern 2009.

ENGEL, Thomas, GBV - Grundbuchverfügung mit WGV und GGV Kommentar (Hrsg.: **MEIKEL, Georg**), 11. Aufl., Köln-München 2019.

ERBER-FALLER, Sigrun, KEHE Grundbuchrecht Kommentar, NotarKommentar (Hrsg.: **KELLER, Ulrich/MUNZIG, Jörg**), 5. Aufl., Berlin 1999.

ERDEM, M., Özel Hukukta Zamanaşımı, İstanbul 2010.

EREL, Ş. Gayrımenkul Rehninde Sıra, Ankara, 1974.

EREL, Ş., Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1982.

EREN, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2017 (BH GH).

EREN, F., Mülkiyet Hukuku, Ankara 2016.

EREN, F., Mülkiyet Kavramı", Recai Seçkin'e Armağan, Ankara 1974.

EREN, F./BAŞPINAR V., Toprak Hukuku, Ankara 2014.

ERLÜLE, F., Gen Teknolojisinden Doğan Hukuki Sorunlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2015.

ERNST, W., Possessorischer Besitzschutz und eidgenössicher Zivilprozess recht 2011.

ERNST, W., Eigenbesitz und Mobiliarerwerb, Tübingen, 1992.

ERTAŞ, Ş., "Mülkiyet Hakkının Yeni Boyutu ve Bu Hakka Getirilen Daraltımların Anayasa ve İnsan Haklarına Uygunluğu", Türk Medeni Kanununun Yürürlüğe Girişinin 80. Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Sempozyum, Ankara 2007.

ERTAŞ, Ş., Pratik Eşya Hukuku, İzmir 1995.

ERTAŞ, Ş., Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğan Zararlardan Hazinenin Sorumluluğu, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce'ye Armağan, İzmir 2001, s.45 vd.;

ERTAŞ, Ş., Eşya Hukuku, 13. Baskı, İzmir 2016.

ESENER, T./GÜVEN, K., Eşya Hukuku, 2012.

FEIL, E./MARENT, K.H./PREISL, G., Grundbuchsrecht Kommentar, 2. Aufl., Wien 2010.

FERID, M./SONNENBERGER, H. J., Das Französische Zivilrecht, 4 Bde., 2. Aufl., Heidelberg 1986.

FEYZİOĞLU, F. N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, İstanbul 1977.

FLUME, W., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. 2: Das Rechtsgeschaft, 4. Aufl., Berlin Heidelberg New York 1992.

FRENZ, N., Ein Jahrhundert-Gesetz fur die Freiwillige Gerichtsbarkeit, DNotZ 1994, s. 153 ff. (Kısaltma: **FRENZ**, DNotZ 1994).

FRENZ, N., Zur Neufassung der Grundstücksverkehrsordnung, DtZ 1994, s. 56 ff. (Kısaltma: **FRENZ**, DtZ 1994).

FRIEDRICH, H. P., Datenverarbeitung und Grundbuch ZBGR 4 1974, s. 193 ff. (Kısaltma: **FRIEDRICH**, ZBGR 4 1974).

FRIEDRICH, H. P., Rechtliche Voraussetzungen und Probleme einer EDV-Grundbuchführung in der Schweiz, ZBGR 2 1981, s. 78 ff. (Kısaltma: **FRIEDRICH**, ZBGR 2 1981).

FURTER, R., Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II (Art. 530 – 1186 OR), Hrsg: Honsell H./Vogt Nedim Watter, 3. Aufl., Basel Genf München 2008.

GAUCH, P./SCHLUEP, W. R./SCHMID, J./REY, H./EMMENEGGER, S., Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, Band I, 9. Aufl., Zürich Basel Genf 2008.

GENÇ ARIDEMİR, A., Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, Istanbul 2008.

GIGER, H., Berner Kommentar; Das Obligationenrecht, 2. Abteilung, Die einzelnen Vertragsverhaltnisse, 1. Teilband, Kauf und Tausch - Die Schenkung, 1. Abschnitt, Allgemeine Bestimmungen - Der Fahrniskauf, Art. 184-215 OR, 2. A., Bern 1979.

GÖRGEÇ B., Devletin Tapu Sicilinden Doğan Sorumluluğu, Rücu Hakkı ve Tabi Olduğu Zamanaşımı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, C. III, MÜHFD-HAD, C. 22, S. 3, 2016.

GÖTTLINGER, F., Projekt Grundbuchautomation in der Bundesrepublik Deutschland, ZBGR 2 1981, s. 65 ff.

GSCHNITZER, F., Lehrbuch des österreichischen bürgerlichen Rechts, Sachenrecht, Wien New York 1968.

GÜLLER, W., Unfreiwilliger Besitzverlust und gutgläubiger Erwerb, Zürich 1924.

GÜRSOY, K. T./EREN, F./CANSEL, E., Türk Eşya Hukuku, Ankara 1984.

HAAB, R., Zürcher Kommentar: Das Sachenrecht, Erste Abteilung, Das Eigentum, Art. 641-729, Lieferung 1-6, 2. A., Zürich 1929 bis 1938.

HAEGELE, K./SCHÖNER, H./STÖBER, K., Grundbuchrecht, 10. Aufl., München 1993.

HÄFELIN, U./MÜLLER, G./UHLMANN, F., Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2006.

HATEMİ, H., Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 2013.

HATEMİ, H./SEROZAN, R./ARPACI, A., Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

HAUSHEER, H., Öffentlichkeit des Grundbuches Anmerkungen zu Art. 970 ZGB und BGE 112 II 422 ff. = ZBGR 69 S. 27 ff., ZBGR 69 1988, s. 1 ff.

HAUSHEER, H., Öffentlichkeit des Grundbuches Anmerkungen zu Art. 970 ZGB und BGE 112 II 422 ff. = ZBGR 69 S. 27 ff., ZBGR 69 1988.

HEBERLEIN, A./BREITSCHMID, P./BELSER, E. M./RIEDER, C., CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, 2. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2012.

HEDINGER, M., Über Publizitätsdenken im Sachenrecht, Bern 1987.

HEINEMANN, J., Aufgabenübertragung auf Notare, FGPrax 2013, s. 139 ff.

HEINRICHS, H., Palandt Bürgerliches Gesetzbuch: BGB. 73. Aufl., München 2013.

HELVACI S./ATAR E. A., Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Üç Aşamalı Test, Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, II. Cilt. MÜHF-HAD Özel Sayı. C. 22, S. 3, 2016, s. 1289 – 1303.

HINDERLING, H., Der Besitz, in: Schweizerisches Privatrecht Bd. V/I, hg. von Meier-Hayoz Arthur, Basel Stuttgart 1977 (SPR V/I).

HIZIR, S./TURAEV, A., Türk Hukuku'nda Hava Araçları Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi, AÜHFD, 2008.

HOLZER, J., Das Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz, NJW 1994, s. 481 ff.

HOLZER, J./KRAMER, A., Grundbuchrecht, 2. Aufl., München 2004.

HOMBERGER, A., Zürcher Kommentar, Art. 919-977 ZGB, Besitz und Grundbuch, Band IV 3 - Das Sachenrecht, 2. Aufl., Zürich 1938.

HOMBERGER, A., Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band IV 3. Das Sachenrecht, Art. 919-977 ZGB, Besitz und Grundbuch, 2. Aufl., Zürich 1938.

HONSELL, H., Tradion und Zession –kausal oder abstrakt- Festschrift für Wolfgang Wiegand zum 65. Geburstag, Bern 2005.

HUBER, Die Bedeutung der Gewere im deutschen Sachenrecht, Berner Festschrift für Halle, 1894.

HUBER, E., System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechtes, Dritter Band, Basel 1889 (SGPR III).

HUBER, E., System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechtes, Vierter Band, Basel 1893 (SGPR IV).

IŞIK, E., Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı, İstanbul 2017.

İMRE, Z., Ayni Hak Mefhumu Üzerine Düşünceler, A. Samim Gönensay'a Armağan, İstanbul 1955.

JÄGGI, P., Rechtsnatur der Zession, Privatrecht und Staat, Zürich, 1976.

JENNY, K. DerBesitzbegriff nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch; Zürich 1915.

JICKELI, J., J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB - Buch 1: Allgemeiner Teil§§ 90 - 124; §§ 130 - 133 (Allgemeiner Teil 3), München 2012.

JOOST, D., Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 6: Sachenrecht (§§ 854-1296), WEG, ErbbauRG, 6. Aufl., München 2013.

KAISER, Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht, Köln Graz, 1956.

KÄLIN, O. Der Sachbegriff im schweizerischen ZGB, Diss. Zürich 2002.

KARAGÖZ, H., Zilyetliğin İktisabı ve Devrine Dair D.41.2'nin Latinceden Çevirisi ve Şerhi, Tunçomağ'a Armağan, İstanbul 1997.

KARAN, H./KILIÇ, M., Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004.

KARAU, K., L'article 111m ORF e les réglementations cantonales concernantl'accès au registre foncier informatisé, ZBGR 2/2001, s. 65 ff.

KAYA, A., Marka Hukuku, İstanbul 2006.

KEIM, C., Ein Bericht über den Probebetrieb für das EDV-Grundbuch im Jahre 1982 bei dem Grundbuchamt München, DNotZ 1984, s. 724 ff.

KIKINIS, Benutzungsrechte an Sachen, Zürich 1996.

KILIÇ, M., 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun Tapu Sicili Hukukunda Getirdiği Yenilikler, Prof. Dr. Fikret Eren'e Armağan, Ankara 2006, s. 627 vd. (Kısaltma: **KILIÇ**, Yenilikler)

KILIÇ, M., Türk Özel Hukukunda Elektronik Tapu Sicili, Yayımlanmamış Doktora Tezi, AÜSBE, Ankara 2005 (Kısaltma: **KILIÇ**, Tez).

KOCABAŞ, G., Sözleşmeden Doğan Geçit Hakkı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2011.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N. (KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N./HATEMİ, H./SEROZAN, R./ARPACI, A.), Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, İstanbul 2014.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N., Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi, İstanbul 1959.

KÖPRÜLÜ, B./KANETİ, S., Sınırlı Ayni Haklar, İstanbul 1982-1983.

KRAMER. E. A., Berner Kommentar; Das Obligationenrecht, 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen: 1. Teilband, Lieferung 1, Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1 und 2 OR (1980), Lieferung 4, Kommentar zu Art. 18 OR (1985), Bern 1986.

KUHLMEY, René/WITTMER, Gerhard, Neues Grundbuch- und Registerrecht, Berlin 1915.

KURT, E., Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, Istanbul 2004.

KÜHL, K./REICHOLD, H./RONELLENFITSCH, M., Einführung in die Rechtswissenschaft, 2. Aufl., München 2015.

LARENZ, K., Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 14. Aufl., München 1987.

LARENZ, K./CANARIS, C., Lehrbuch des Schuldrechts, Band II, Besonderer Teil, 2. Halbbd., 13. Aufl., München 1994.

LARENZ, K./WOLF, M., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Ein Lehrbuch, 9. Aufl., München 2004.

LARENZ, K./WOLF, M., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Ein Lehrbuch, 9. Aufl., München 2004.

LEIPOLD, Grundlagen des einsweiliger Rechtsschutz, 1971.

LIVER, P., Das Eigentum, in: Schweizerisches Privatrecht Bd. V/1, hg. von Meier-Hayoz Arthur, Basel Stuttgart 1977 (SPR V/1).

MAKARACI BAŞAK, A., Taşınır Rehni Sözleşmesi, Istanbul 2014.

MAURER, S./KERSTING, D., Ist der Leichnam eine Sache? Ein Dialog zwischen Rechtswissenschaft und Philosophie, Jusletter vom 29. August 2011, s. 1 ff.

MEIER-HAYOZ, A., Berner Kommentar; Einleitung, Art. 1-10 ZGB, Bern 1962 (BK ZGB).

MEIER-HAYOZ, A., Das Sachenrecht; Band IV des Berner Kommentars zum schweiz. Privatrecht; I. Abt., 1. Teilband (System. Teil und Art. 641-654), 5. Aufl., Bern 1981 (BK Syst. Teil).

MEIER-HAYOZ, A., Vom Wesen des Eigentums, Festgabe fur Karl Oftinger, 1969.

MEIER-HAYOZ, A./SCHLUEP, W. R./OTT, W., Zur Typologie im schweizerischen Gesellschaftsrecht, ZSR 90, 1971, s. 293 ff.

MEIER-HAYOZ, A., Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Das Sachenrecht, 1. Abteilung, Das Eigentum: 1. Teilband, Systematischer Teil und Allgemeine Bestimmungen, Art. 641-654 ZGB, 5. Aufl., Bern 1981.

MEIKEL, G., Grundbuchordnung: GBO Kommentar (Hrsg.: **MEIKEL, Georg**), 11. Aufl., Köln-München 2015.

MEIKEL, G./BÖHRINGER, W., Grundbuchrecht, 7. Aufl., Berlin 1993.

MERZ, H., Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, SPR VI/1, Basel 1984.

MÜTTER, P., Persönlichkeitsschutz und Datensicherung, Computer und Recht, Bd. 9, Zürich 1980.

MÜLLER, M., Aus cem Tagebuch des Eidgenössischen Amtes für Grundbuch- und Bodenrech, ZBGR 6 2001, s. 337 ff.

MÜLLER, M./SCHMID, C., Aspekte der EDV-Grundbuchführung, ZBGR 3 1998, s. 145 ff. (Festschrift 50 Jahre Verband Schweizerischer Grundbuchverwalter Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht, Wadenswil 1998, s. 61 ff.)

NIGGLI, Der Besitz – ein ungeklärter Grundbegriff des schweizerischen Sachenrecht, Zürich 1993.

NOMER, H. N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6093 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Hazırlanmış, Gözden Geçirilmiş Onbirinci Bası, İstanbul 2012.

NOMER, H.N./ERGÜNE, M.S., Eşya Hukuku, Zilyetlik-Tapu Sicili-Rehin Hakları, Gözden geçirilmiş 4. Bası, İstanbul 2017.

OFTINGER, K./BÄR, R., Zürcher Kommentar; Das Sachenrecht, Zweite Abteilung, Die beschränkten dinglichen Rechte. Das Fahrnispfand. Art. 884-918 ZGB, 3. Aufl., Zürich 1981.

OGRIS, W., Gewere, HRG I, Berlin 1971.

OĞUZMAN, M. K., Eşyaya Bağlı Borçlara Hakim Olan Esaslar, İÜ Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, 50. Yıl Sempozyumu, İstanbul 1978.

OĞUZMAN, M. K., Eşyaya Bağlı Haklar ve Borçlar, İÜHFM, C. 31, Sa. 1-4 (1965).

OĞUZMAN, M. K./BARLAS, N., Medeni Hukuk (Giriş - Kaynaklar - Temel Kavramlar), İstanbul 2017.

OĞUZMAN, M. K./SELİÇİ, Ö./OKTAY-ÖZDEMİR, S., Eşya Hukuku, İstanbul 2017.

OĞUZMAN, M. K./SELİÇİ, Ö./OKTAY-ÖZDEMİR, S., Eşya Hukuku, 21. Baskı, İstanbul 2018.

OKTAY-ÖZDEMİR, S., "Fikri Nitelikteki Sınai Değerler Üzerindeki Haklar ile Bunlara İlişkin Verilen Lisansın Hukuki Niteliği", Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan, İstanbul 2004.

OKTAY-ÖZDEMİR, S., Kişilik Hakları ve Bilgi Alma Hakkı Çerçevesinde Tapu Sicilinin Aleniliği (Kamuya Açıklığı) İlkesi, Prof. Dr. Özer Seliçi'ye Armağan, Ankara 2006, s. 503 vd.

OSTERTAG, F., Berner Kommentar: Besitz und Grundbuch. Art. 919–977 ZGB, 2. Aufl., Bern 1917.

ÖRÜCÜ, E., Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı, İstanbul 1976.

ÖZ T., Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, İstanbul 1990.

ÖZEL, S., Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması, Ankara 2004.

ÖZEN, B., Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 2008 (İntifa).

ÖZTRAK İ., Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara, 1977.

PFÄFFLI, R., Zur Revision der Grundbuchverordnung, BN 1995, s. 45 ff.

PFAMMATTER, A., OFK - Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), ZGB Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Hrsg.: **KREN KOSTKIEWICZ, J./WOLF, S./AMSTUTZ, M./FANKHAUSER, R.**), 3 Aufl., Zürich 2016.

PFISTER, H.R. Der Schutz des offenlichen Glaubens im schweizerichen Sachenrecht, Zürich 1986.

PFITZER, W., Der Ersizung nach schweizerichen Recht, Zürich, 1931.

PIOTET, P., Dienstbarkeiten und Grundlasten, in: Schweizerisches Privatrecht Bd. V/1, hg. von Meier-Hayoz Arthur, Basel Stuttgart 1977 (SPR V/1).

PORTMANN, R., Der Besizteschutz des schweizerischen Zivşilgesetzbuchs, mit Kurzdarstellung des Besitzschutzverfahren nach der Zivilprozessordung des Kantons Luzewrn, Zürich, 1997.

POSTACIOĞLU, İ., Gayrımenkullerin Ferağına Müteallik Akitlerde Şekle Riayet Mecburuiye-ti, İstanbul 1945.

PÜLS, J., Die Grundbucheinsicht durch Notare im Lichte der Aufgabenübertragung, NotBZ 2013, s. 329 ff.

RAAPE, Besizterwerb ohne Willen, 1901.

RENTSCH, M., Öffentliche Sachen, ZBGR 61/1980.

REY, H., Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Band IV, Das Sachenrecht, 2. Abteilung, Die beschränkten dinglichen Rechte, Die Dienstbarkeiten und Grunclasten, 1. Teilband, Die Grunddienstbarkeiten, Lieferung 1, Systematischer Teil und Art. 730 und 731 ZGB, 2. Aufl., Bern 1981 (BK Syst. Teil).

REY, H., Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum; Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Bd. I, Bern 1991 (I).

REY, H., Zur Öffentlichkeit des Grundbuchs (Schriftliche Fassung des vor der Gesellschaft der Notar-Stellvertreter des Kantons Zürich am 16. November 1983 gehaltenen Referats), ZBGR 65/1984, s. 73 ff.

REY, H., Zur Öffentlichkeit des Grundbuchs (Schriftliche Fassung des vor der Gesellschaft der Notar-Stellvertreter des Kantons Zürich am 16. November 1983 gehaltenen Referats), ZBGR 65/1984.

REY, H./STREBEL, L., Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch II (Art. 457 – 977 ZGB, Art. 1 – 61 SchlT ZGB), Hrsg: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Geiser Thomas, 4. Aufl., Basel Genf/München 2011.

REY, Heinz, Zur Öffentlichkeit des Grundbuchs, ZBGR 2/1984, s. 73 ff.

RIEMER, H. M., Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Bd II, Die beschränkten dinglichen Rechte – Dienstbarkeiten, Grund- und Fahrnispfandrechte, Grundlasten, 2. Aufl., Bern 2000.

RITTER, H., Einfuhrung in Speichermedien und Datentechnik, Ludwigshafen 1988.

SARI, S., Alıkoyma Hakkı, İstanbul 1997.

SAYMEN, F. H./ELBİR, H. K., Türk Eşya Hukuku, İstanbul 1954.

SCHLUEP, W., "Wirksamer Wettbewerb" - Schlüsselbegriff des neuen schweizerischen Wettbewerbsrechts, Bern Stuttgart Toronto 1987.

SCHMID, J./HÜRLIMANN-KAUP, B., Sachenrecht, 4 Aufl., Zürich Basel Genf 2012.

SCHMID, J./HÜRLIMANN-KAUP, B., Sachenrecht, 5. Aufl., Zürich 2017.

SCHMID, J., Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II (Hrsg.: **HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter/GEISER, Thomas**), Art. 457-977 ZGB und Art. 1-61 SchlT ZGB, 5. Aufl., Basel 2015.

SCHMID, J., Ungereimtes in Art. 949a ZGB in der Änderung 1994 der eidgenössischen Grundbuchverordnung, ZBGR 4/1995, s. 261 ff.

SCHMIDT-RÄNTSCH, J., Das EDV-Grundbuch, VIZ 1997, s. 83 ff. (Kısaltma: **SCHMIDT-RÄNTSCH**, VIZ 1997).

SCHMIDT-RÄNTSCH, J., Das neue Grundbuchrecht, Köln 1994 (Kısaltma: **SCHMIDT-RÄNTSCH**, Grundbuchrecht).

SCHNEIDER, W., Quo vadis - Grundbuch?, ZfIR 2013, s. 81 ff. (Kısaltma: **SCHNEIDER**, ZfIR 2013).

SCHNEIDER, W., Verwalter und Grundbuch, ZWE 2014, s. 349 ff. (Kısaltma: **SCHNEIDER**, ZWE 2014)

SCHÖBI, F., Der Besitzesschutz (Art.926-929 ZGB). Bemerkungen zu einer gesetzgeberischen Fehlleistung, Bern, 1987.

SCHREIBER, K., Die Grundprinzipien des Sachenrechts, Jura 32/2010.

SCHREIBER, K., Die Grundprinzipien des Sachenrechts, Jura 32/2010.

SCHWAB, P.,, Vom Papier- zum EDV-Grundbuch, Jubilaumsschrift: 75 Jahre Verband solothurnischer Notare, Solothurn 1997, s. 63 ff.

SCHWARZ, A. B., Medeni Hukuka Giriş (Çev.: H. Veldet), İstanbul 1946.

SEILER, H. H., J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB - Buch 3: Sachenrecht Einleitung zum Sachenrecht; §§ 854-882 (Allgemeines Liegenschaftsrecht 1), Berlin 2012.

SEROZAN, R., Medeni Hukuk (Genel Bölüm Kişiler Hukuku), İstanbul 2017

SEROZAN, R., Taşınır Eşya Hukuku, İstanbul 2007.

SIMONIUS, P./SUTTER, T., Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Bd I, Grundlagen, Grundbuch und Grundeigentum, Basel Frankfurt aM 1995.

SİRMEN, L., Eşya Hukuku, 3. Bası, Ankara 2015.

SİRMEN, L., Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devlet'in Sorumluluğu, Ankara 1976.

SOERGEL, H. T., Bürgerliches Gesetzbuch, Sachenrecht 1 (§§ 854-984 BGB), hg. von Siebert Wolfgang Baur Jürgen F., 13. Aufl., Stuttgart 2002.

STADLER, A., Die Vorschläge des Gemeinsamen Referenzrahmens für ein europaisches Sachenrecht - Grundprinzipien und Eigentumserwerb, JZ 65 2010.

STADLER, A., Soergel BGB, Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: BGB Band 15 1: Sachenrecht 2 1 §§ 985 - 1017 BGB, ErbbauVO, 13. Aufl., Konstanz 2007.

STARK, E. W., Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 3. Abteilung, Besitz und Grundbuch, 1. Teilband, Der Besitz, Art 919-941 ZGB, 3. Aufl., Bern 2001.

STEINAUER, P., Les droits réels, Bd I, 4. Aufl., Bern 2007.

STEINAUER, P., Les droits réels, Bd I, 5. Aufl., Bern 2012.

STEINAUER, P.H., Les droits réels, Bd. I, 5. Aufl., Bern 2012.

STINTZING, W., Besitz, Gewere, Rechschein, Ac9, 109.

STROBEL, W., Der Regierungsentwurf zum Registerverfahrenbeschleunigungsgesetz - ein Überblick, DStR 1993, s. 950 ff.

SUNGURBEY, İ., Hayvan Hakları, Istanbul 1999.

SUNGURBEY, İ., Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstanbul 1963.

ŞENGÜL, M., Tapu Sicilinin Aleniliği, Ankara 2013.

TEKİNALP Ü., Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2012.

TEKİNAY, S. S., Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Haklar (Eşya Hukuku II 3), İstanbul 1994.

TEKİNAY, S.S./AKMAN, S./BURCUOĞLU, H./ALTOP, A., Tekinay Eşya Hukuku, Cilt I, Zilyedlik - Tapu Sicili - Mülkiyet, 5. Bası, İstanbul 1989.

TRAUFFER, B., Revision der Grundbuchverordnung per 1. April 2005, ZBGR 1 2006, s. 56 ff.

TROLLER, A., Immaterialgüterrecht, I, Basel 1983.

TOPUZ, M., "Yargıtay Kararları Işığında Türk Borçlar ve Ticaret Hukukunda Gabin (Aşırı Yarar-lanma), MÜHF-HAD, Doç. Dr. Mehmet Somer'in Anısına Armağan, İstanbul 2006, s.743 vd.

TOPUZ, M., İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddi Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi, İstanbul 2011, s. 133 vd.

TOPUZ, M., 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Genel İşlem Koşullarında Kapsam (Yürürlük) Denetimi, Prof.Dr. Mustafa DURAL'a Armağan, İstanbul 2013, s. 1138 vd.

TOPUZ, M., Ticari İşletmenin Devrinde Tasarruf İşlemlerine İlişkin Şekil Sorunu (İsviçre Bir-leşme Kanunu (Fusionsgesetz: FusG) ve Alman Hukuku Perspektifinde), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 18 (2), 19 vd.

TOPUZ, M., Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaasının Varlığını Gösteren Emareler, Prof. Dr. İlhan ULUSAN'a Armağan, Cilt II, İstanbul 2016, s. 710 vd.

TOPUZ, M., Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, İstanbul 2017, s. 261 vd.

TUOR, P./SCHNYDER, B./SCHMID, J., Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Zürich 1995.

TUOR, P./SCHNYDER, B./SCHMID, J., Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Zürich 1995.

TUOR, P./SCHNYDER, B./SCHMID, J./RUMO-JUNGO, A., Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14. Aufl., Zürich 2015.

TÜREL, E., "Roma Hukukundan Günümüze Hukuki Sebep ve Sınallagma İlişkisi", Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu'na Armağan, MÜHF-HAD, C. 23, S. 3, İstanbul 2017.

TÜRKMEN, A., Bağışlamanın Geri Alınması, Ankara 2019.

UMAR, B., MK. m. 931 Devlete Karşı da Geçerlidir, İzmir Barosu Dergisi C.4, S.3, 1985.

UTKU, D., Sınai Hakların Rehni, İstanbul 2009.

ÜNAL, M./BAŞPINAR, V., Şekli Eşya Hukuku, Ankara 2016.

ÜNAL, M./BAŞPINAR, V., Şekli Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara 2017.

von TUHR, A., Die Eigentumsübertragung nach Schwizerichem Recht ZSR. NF 4047.

von TUHR, A./PETER, H., Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, 3. Aufl., Zürich 1974/79.

WACKE, A., Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Band 6: Sachenrecht (§§ 854-1296), WEG, ErbbauRG, 4. Aufl., München 2004.

WALDNER, W., Grundbuchordnung Kommentar (Hrsg.: **BAUER, Hans-Joachim/OEFELE, Helmut Freiherr von**), 3. Aufl., München 2013.

WEBER, D., Das Publizitätsprinzip im schweşizerischen Recht dert beweglichen Sachen, Basel 1963

WEBER, F., Die Besitesschutzklagen, inbsbesondere ihre Abgrenzung von den petitorischen Klagen, Freiburg, 1975.

WESTERMANN, H., Sachenrecht, 5. Aufl., Karlsruhe 1966.

WIEGAND, W., Akzessorietät und Spezialität – Zum Verhältnis zwischen Forderung und Sicherungsgegenstand, in: Probleme der Kreditsicherung, Berner Tage für die juristische Praxis, Bern, 1982, (Akzessorietät).

WIEGAND, W., Akzessorietät und Spezialität – Zum Verhältnis zwischen Forderung und Sicherungsgegenstand, in: Probleme der Kreditsicherung, Berner Tage für die juristische Praxis, Bern, 1982. (Akzessorietät).

WIEGAND, W., Doppelverkauf und Eigentumserwerb – Wer zuerst kommt, mahlt zuerst? Festgabe für Hans Marti, Bern 1985, s. 11 ff. (Eigentumserwerb).

WIEGAND, W., Numerus clausus der dinglichen Rechte. Zur Entstehung und Bedeutung eines zentralen zivilistischen Dogmas, in: Festschrift Kroeschell, Frankfurt New York 1987, S. 623 ff (Numerus Clausus).

WIEGAND, W., Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II (Hrsg.: **HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter/GEISER, Thomas**), Art. 457-977 ZGB und Art. 1-61 SchIT ZGB, 5. Aufl., Basel 2015.

WIELAND (Çev. KARAFAKİ. İ.H.), Kanunu Medenide Ayni Haklar, Ankara 1946.

WIELAND (Çev. KARAFAKİ, İ.H.), Kanunu Medenide Ayni Haklar, Ankara 1946.

WIGGERS, F., Das Gesetz zur Einfuhrung eines Datenbankgrundbuchs und seine Auswirkungen für die Praxis, FGPrax 2013, s. 235 ff.

WILSCH, H., Beck'scher Online-Kommentar Grundbuchordnung (Hrsg.: HÜGEL, Stefan), 35. Ed., München 2019.

WINDSC WOLFF/RAISER HEID, B./KIPP, T., Lehrbuch des Pandektenrechts, Band 1, 9. Aufl., Aalen 1963.

WINKLER, R., Rechtsvermutungen aud dem Besitz, Zürich 1969.

WOLFF, M./RAISER, L., Sachenrecht, 10. Aufl., Tübingen 1957.

WUDARSKI, A., Furktionswandel des elektronischen Grundbuchsystems in Polen, WiRO 2015, s. 33 ff.

YARSUVAT D., Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Haklar:, İstanbul, 1984.

YASAMAN, H., Marka Hukuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, Cilt I, İstanbul 2004.

YAVUZ, C./TOPUZ, M., Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Türk Medeni Kanunu'nun Miras Hukuku-

na İlişkin Hükümlerinde Yaptığı Değişiklikler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 21 (2),İstanbul 2015, 663 vd.

YAVUZ, C./ERLÜLE, F./TOPUZ, M., Yeni vesayet hukukuna doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku:(İsviçre örneği), İstanbul 2017.

YILMAZ C., "Türk ve İsviçre Borçlar Kanunlarına Göre Yayın (Neşir) Sözleşmesi", Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2007.

ZOBL, D., Das Sachenrecht, Band IV des Berner Kommentars zum Schweiz. Privatrecht. 2. Abt., 5. Teilband. 1. Unterteilband (Systematischer Teil und Art. 884-887), Bern 1982.

ZOBL, D., Grundbuchrecht, 2. Aufl., Zürich Basel Genf 2004 (Grundbuchrecht).

ZOBL, Dieter, Grundbuchrecht, 2. Aufl., Zürich 2004.

ZWAHLEN, M., Zilyetliğin Havalesi, Kubalı'ya Armağan, İstanbul 1974.

Kavramlar Dizini

A

Açık Zilyetlik · 257

Açıklık Aracı · 183, 184

Aile Konutu · 207, 235, 361

Aile Konutunda Kalma Hakkı · 670

Alacağa Bağlı Ayni Haklar · 129

Alacak Hakkı · 64, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 119, 120, 161, 164

Alacak Sebebi (Causa Crederdi veya Acquirendi) · 162

Aleniyet · 509, 547

Aleniyet (Kamuya Açıklık) Araçları · 133

Aleniyet (Kamuya Açıklık) İlkesi · 131, 132, 133, 139, 143, 145, 148, 149, 153, 157, 166, 522, 547, 574

Aleniyet Fonksiyonu · 496, 514, 536

Aleniyet Kazanmamış Veri · 492

Aleniyet Kazanmış Veri · 492

Aleniyeti Sağlama Fonksiyonu · 215

Alıkoyma Hakkı · 457

Alıkoymak · 461

Alım (İştira) Hakkı · 666

Alma Yetkisi · 524

Amaçsal Olgu · 91, 92, 93, 94, 109

Ana Kütük · 511, 512, 513, 556

Animus · 188, 198, 199, 225

Animus Domini · 188, 198, 199, 225

Animus Possession · 199

Araçların Teslimi · 239, 246, 247, 248, 297

Arazi · 191, 201, 303, 342, 344, 348, 446, 452, 468, 603

Arazi Bilgi Sistemi · 517, 537

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi · 667

Art Mirasçı · 228

Aslen Kazanma · 238, 240, 242, 243, 373

Aslen Kazanma (Hâkimiyet) İradesi · 241

Asli Hak · 108

Asli Sicil · 510, 533, 536

Asli Zilyet · 222, 225, 308

Avukatların Bilgi · 524

Avukatların Tapu Sicilinden Örnek İstemeleri · 524

Ayni (Reel) Olgu · 101

Ayni (Tasarruf) Sözleşme · 164

Ayni Etki · 94, 103, 173

Ayni Görünüm İlkesi · 511

Ayni Hak · 56, 81, 83, 90, 119, 123, 126, 127, 128, 129, 134, 137, 138, 141, 143, 144, 146, 149, 150, 153, 154, 155, 157, 158, 161, 167, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 202, 203, 205, 216, 222, 225, 227, 228, 229, 231, 244, 259, 261, 273, 277, 280, 284, 285, 286, 291, 292, 293, 300, 311, 321, 329, 330, 355, 356, 365, 368, 369, 376, 378, 380, 385, 391, 398, 402, 403, 405, 406, 412, 413, 416, 417, 418, 425, 426, 428, 429, 460, 473, 492, 493, 509

Ayni Hak (Malik) Sahibi Sıfatıyla Zilyet · 229

Ayni Hak Görüşü · 192

Ayni İşlem · 90, 91

Ayni Kayıt İlkesi · 494

Ayni Sözleşme · 91, 167, 171, 243, 244, 245, 253, 263

Ayni Tasarruf İşlemi · 164

Ayni Teminat (Paraya Çevirme) Hakkı · 126, 127

Ayni Teminat Hakkı · 127, 152

Ayni Uyuşma · 244

Aynilik İlkesi · 566

Ayrılık İlkesi · 166, 167, 168

Aziller Sicili · 513, 561

B

Bağımsız Bölüm · 55, 69, 84, 85, 142, 176, 234, 603
Bağımsız ve Sürekli Hak · 69, 84
Bağımsız ve Sürekli Haklar · 605
Bağışlama Sebebi (Causa Donandi) · 162
Bağışlananın Zilyetliği · 250
Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama · 669
Bağlanma İlişkisi · 175
Banka · 493, 524, 548
Banka Kasa Sözleşmesi · 212
Basit (Yalın) Zilyetlik · 221
Basit Eşya · 71, 72, 74, 76
Basit Zilyetlik · 221
Başka Sıfatla Zilyet · 229
Başkası Adına Zilyet · 226, 246
Başkası İçin Zilyet · 209, 226, 229
Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi · 157
Belirlilik İlkesi · 71, 132, 143, 157, 158, 175, 191
Beyan · 289, 290, 409, 531, 533, 548, 678
Bilgi Edinme Hakkı · 522
Bilgi ve Belge İstemi · 523
Bilgi Verme Fonksiyonu · 522, 538
Bilgisayar Destekli Defter · 511
Bilgisayar Destekli Defter Tapu Sicili · 512
Bilgisayar Destekli Kağıt (Defter) Sicil Sistemi · 513
Bilgisayar Destekli Tapu Sicili · 511, 512, 513, 514, 515, 519, 539, 543
Birleşik Eşya · 71, 72, 76
Birlik İlkesi · 166, 167
Birlikte Eşya · 64, 71, 72, 462
Birlikte Zilyet · 191, 218, 224, 225, 227, 234, 256, 304, 307, 310, 381
Borç Sözleşmesi · 171
Borçlandırıcı İşlem · 111, 145, 146, 147, 155, 159, 160, 163, 164, 169, 172, 173, 255, 272, 414, 453
Borçlandırıcı işlemler (Borçlanma İşlemi) · 160
Borçtan Kurtarma İşlemleri · 160
Boş Dereceye İlerleme Hakkı · 106
Boşalan Dereceye Geçme Hakkı · 669
Boşluk · 288, 326, 428, 429, 466
Bölünebilen Eşya · 89
Bölünemeyen Eşya · 89
Bölünme Görüşü · 109
Brevi Manu Traditio Bkz. Kısa Elden Teslim · 256, 264
Bulunan Eşya · 242
Bütün Zilyet · 229, 306
Bütünleyici Parça · 72, 85, 123, 124, 158, 174, 175, 176, 191, 230, 379, 446, 455
Bütünlük İlkesi · 73

C

Coğrafi Bilgi Sistemi · 516, 517, 518
Condictio Possesionis · 363, 387, 391
Condictio Possidentis · 363, 387
Corpus · 188, 195
Cumhuriyet Başsavcılıkları · 526
Cüzi Halef · 318, 335, 393, 395

Ç

Çeşit (Cins) Eşya · 87

D

Dava Süresi · 391
Deed Kayıt Sistemi · 484
Define · 242
Defter (Kağıt) Tapu Sicili · 511
Defter (Klasik) Tapu Sicili · 511
Defter Tapu Sicili · 509, 511, 535, 536, 539, 543
Derece Sistemi · 180
Devletin Sorumlu Olması İlkesi · 589
Devletin Sorumluluğu · 517

Devren Kazanma · 238, 239, 242
Dışa Soyutluk · 169
Doğal Aleniyet · 144
Doğal Güçler · 68, 191, 379
Doğal İrade · 199, 200, 297, 409, 411
Doğal Ürünler · 442
Doğrudan Temsilci · 254
Doğrudan Zilyet · 201, 204, 218, 219, 220, 223, 253, 254, 276, 364, 429, 430
Dolaylı Etki · 482
Dolaylı Temsilci · 254
Dolaylı Zilyet · 219, 309
Dolaysız Zilyet · 218, 219, 220, 281, 283, 284, 309
Döner Sermaye Katılma Payı · 526
Durum Borcu · 101
Düşen ve Sürüklenen Şeyler · 242
Düzeltme · 545, 682
Düzeltmeler (Tashih) Sicili · 562
Düzeltmeler Sicili · 513
Düzenleme Görüşü · 92
Düzenli Kişiye Bağlı İrtifaklar · 129
Düzensiz Kişiye Bağlı İrtifaklar · 129

E

Ecrimisil · 435, 437, 465, 466, 467
E-Devlet · 490, 514, 516
E-Devlet Sistemi · 514
Edim Hukuku · 52
Edinmeye Elverişlilik · 57, 68, 75, 85
Eğitim Dokümanı · 517
Eklenti · 60, 72, 74, 175, 176, 191, 455
Eklentiler · 679
Ekonomik Bütünlük · 74
Ekonomik Değerlilik · 47, 57, 58, 72, 74, 75, 89
Ekonomik Eşya Birliği · 74
El Atma · 301, 302, 305
El Değiştirmeyen Kişiye Bağlı İrtifaklar · 129
Elbirliği (İştirak Halinde) Zilyetlik · 234
Elbirliği İle Zilyet · 233, 234, 310, 335, 381
Elbirliği Mülkiyeti · 363, 649
Elbirliğiyle Zilyet · 233, 235, 410
Elde Edilen Ürün · 461
Elden Bağışlama · 273
Elden Çıkarma · 439
Elektronik Arşiv · 543
Elektronik Hukuki İşlemler · 545
Elektronik Kabul Beyanı · 530, 531
Elektronik Ortam · 510
Elektronik Ortamda Verilere Erişim Hakkı · 142
Elektronik Ortamda Yapılan İşlemler · 546
Elektronik Posta Kutusu · 546
Elektronik Sicil · 495
Elektronik Tapu İşlem · 546
Elektronik Tapu Sicil Sistemi · 536
Elektronik Tapu Sicili · 509, 535
Elektronik Tapu Sicilinin Unsurları · 510
Elektronik Tapu Verilerine Erişim · 525
Elektronik Ver · 510, 545
Elinden Alınması · 303
Elinden Alma Hakkı · 320
Embriyo · 60
Emekli Sandıkları · 548
Emin Sıfatıyla Zilyet · 212, 236, 381, 389, 397, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 417
Emtia Senetleri · 288
Emtiayı Temsil Eden Evrakların Teslimi · 287
Emtiayı Temsil Eden Kıymetli Evrak · 288, 289, 290
Enerji · 68
Erişim Hakkına Sahip Kuruluşlar · 526
Erişimi Durdurma · 527
Erişiminin Elektronik Ortamda Sağlanması · 510
Erteleyici Şart · 423
Eşya Bağlı Sözleşme · 106

Eşya Birlikteliği · 191
Eşya Topluluğu · 58, 72, 76
Eşya Zilyetliği · 190, 194, 202, 203, 204
Eşyanın Araçlarının Teslimi · 246
Eşyanın İadesi · 373
Eşyanın Niteliği · 196, 295
Eşyanın Teslimi · 245, 247
Eşyaya Bağlı Ayni Haklar · 128
Eşyaya Bağlı Borç · 100, 101, 102, 103, 104, 106, 177
Eşyaya Bağlı Hak · 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 126, 127
Eşyaya Bağlı İrtifak · 114, 117, 118
Eşyaya Bağlı İrtifaklar · 117
E-Tapu · 512
E-Tapu Sicili · 509

F

Falsus Procurator · 255
Farazi İrade · 201, 468
Faydalı Gider · 454
Fer'i Hak · 120, 123, 132
Fer'i Sicil · 510, 536
Fer'i Zilyet · 225, 269, 308, 356
Fiili Eşya Birliği · 72, 74
Fiili Etki · 183, 185, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 221, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 249, 251, 252, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 274, 277, 278, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 305, 309, 314, 316, 317, 319, 321, 323, 324, 331, 332, 333, 338, 339, 340, 343, 355, 356, 360, 361, 369, 370, 400, 405, 426, 427, 431, 434, 446, 451, 476
Fiili Hakimiyet · 185, 189, 190, 192, 194, 195, 197, 200, 201, 203, 204, 206, 209, 211, 213, 219, 221, 226, 227, 228, 231, 235, 238, 247, 262, 294, 343, 361, 476
Fiili Hakimiyet'in Geçici Kaybı · 183, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 212, 213, 214, 224, 230, 233, 235, 239, 247, 251, 254, 294, 296, 324, 390
Fiili Hakimiyet'in Sürekli Kaybı · 190, 196, 247, 294, 295, 296, 303, 304, 305, 324, 335, 431
Fiili Sözleşme İlişkisi · 431
Fikri Hak · 58, 35, 66, 67, 72
Fikri Mülkiyet Hakkı · 65
Fikri Ürünler · 65
Fiksiyon · 204, 227, 233, 359
Fiksiyon Zilyet · 227
Fiktif Zilyetlik · 190, 204
Fuzuli İşgal · 344

G

Garanti (Teminat) Sebebi · 162
Gasp · 184, 212, 213, 231, 240, 248, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 311, 312, 313, 316, 318, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 331, 332, 334, 339, 340, 341, 342, 368, 369, 371, 380, 387, 398, 400, 401, 428
Gayri Misli Eşya · 290
Geçici Kesilme · 295
Geçici Tescil Şerhi · 675
Geçit Hakkı · 334, 679
Gemi · 258, 295, 379, 413
Gemi Sicili · 136
Genel İrade · 200
Genel Mallar · 75, 76, 77, 79
Genetik Fonksiyonu · 53
Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme · 437, 461, 465
Geri Alım Hakkı · 106, 361, 667
Geri Alma Davası · 323
Geri Verme (Alma) Davası · 323
Gider · 444
Görünüşte Hükmen Teslimden · 270
Güven (Maddi Aleniyet) İlkesi · 148

Güven İlkesi · 538
Güvenilir Elektronik İmza · 491
Güvenin Korunması Etkisi · 216
Güvenli Elektronik İmza · 510, 546

H

Hak Düşürücü Süre · 299, 313, 339, 340, 379, 391, 402, 404
Hak Görüşü · 192
Hak Karinesi · 139, 140, 372
Hak Ziyetliği · 190, 201, 202, 203
Hâkimiyet Görüşü · 91
Hakimiyet Hukuku · 52
Hakimiyet İradesi · 198, 199, 204, 205, 238, 239, 241, 249, 253
Hakka Dayanan Zilyet · 228, 230, 458
Hakkı Kurma Etkisi · 216
Hakkı Zamanaşımı ile Kazancırma Etkisi · 216
Haksız Zilyedin Varlığına İnandığı Hak · 443
Haksız Zilyet · 231, 307, 317, 398, 419, 420, 422, 424, 428, 434, 435, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 468, 469
Haksız Zilyetlik Kazanımı · 373
Halihazır Zilyet · 237, 265, 327, 362, 364, 372, 373, 375, 376, 383, 387, 392, 394
Hapis Hakkı · 123, 124, 125, 286, 292, 293, 395, 413, 457
Harici Taksim · 643
Hayvan · 63
Hayvan Bulunduran · 206
Hayvan Rehni Sicili · 135
Hazır Olmayanlar Arasında (Temsilciye Teslim) · 246
Hazine Adına Tespit · 651
Heyelan Bölgesi · 678
Hisse Senetleri Portföyü · 153
Hizmet Zilyeti · 195, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 218, 229, 246, 252, 253, 254, 259, 271, 278, 301, 317, 318, 381, 410
Hukuka Uygurluk · 305
Hukuki Durum Görüşü · 193
Hukuki Eşya Birliği · 72
Hukuki Koruma Fonksiyonu · 215
Hukuki Sebep · 161, 162, 163, 256, 273, 305, 306, 408, 414, 416, 419, 446
Hukuki Sonuç Doğurucu Fonksiyon · 543
Hukuki Tasarruf · 220, 416
Hukuki Ürün · 439, 444, 452
Huzur Fonksiyonu · 213
Huzur Teorisi · 214
Hükmen Teslim · 218, 239, 244, 245, 246, 256, 260, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 297, 410, 411, 412
Hükmen Teslim Sözleşmesi · 271

İ

İade Sorumluluğu · 438
İbra Sözleşmesi · 164
İcra ve İflas Müdürlükleri · 526
İçerikte Soyutluk · 169
İdarenin Kamu Malları · 78
İdari Koruma · 300, 341, 342, 343, 345, 350, 351, 446, 464, 465
İdari Makam · 345
İdari Yönden Koruma · 300, 341
İfa Sebebi · 167
İfa Sebebi (Causa Solvendi) · 162
İfa Sözleşmesi · 244
İhlali Defetme · 319
İhya Edilen Taşınmaz Mallar · 650
İkili Kademe · 225
İlgisini İnanılır Kılma · 520, 532, 547
İn Iure Cessio · 478
İnançlı İşlem · 210, 270, 275
İnceleme Hakkı · 492
İnceleme ve Örnek Alma Hakkı · 140
İnfaz · 351
İnsan Cesedi · 59

İntifa Hakkı · 88, 112, 114, 115, 136, 147, 179, 202, 223, 224, 243, 268, 366, 380, 442, 443, 458
İpotek · 119, 120, 121, 447, 547
İpotekli Borç Senedi · 119, 121, 128
İpso İura · 233, 409
İrade (Sözleşme) İlkesi · 161
İrade İlkesi · 161, 166
İrade Sakatlıkları · 411
İradi Temsili · 258
İrat Senedi · 119, 122, 128
İrtifak · 184, 190, 201, 202, 203, 308, 342, 361, 369
İrtifak Hakları · 112, 171, 177
İstem (Başvuru) İlkesi · 573
İstem Belgesi · 524
İstem Üzerine Düzeltme · 683
İstihkak Davası · 231, 237, 319, 322, 327, 339, 375, 378, 387, 391, 392, 401, 402, 403
İstihkak Hakkı · 256, 278, 279
İşgal · 184, 242, 343, 344, 438
İşleten · 206
İyi Niyetli Haksız Zilyet · 366, 404
İyiniyetle Kazanım · 383
İyiniyetli Hak Kazanımı · 417
İyiniyetli Haksız Zilyet · 232, 438
İyiniyetli Kazanımların Korunması İlkesi · 150
İyiniyetli Malik Sıfatı · 365
İyiniyetli Zilyet · 204, 365, 393, 395, 404, 405, 416, 435, 441

K

Kadastro · 184, 607
Kadastro Davaları · 634
Kadastro Ekibi · 610
Kadastro Komisyonu · 611, 624, 627
Kadastro Mahkemesi · 632
Kadastro Mühendisleri · 548
Kadastro Tespit Tutanağı · 626
Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi · 628
Kadastro Veri Konsolidasyonu · 518
Kadastro Verileri · 514, 515, 518, 528, 529, 531, 533, 537
Kademeli Zilyetlik · 204, 217, 221, 222, 254, 269, 271, 275, 292, 308
Kamu Finans Malları · 79
Kamu Hizmeti · 522, 524, 537
Kamu Hizmeti Tedarikçileri · 493
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Paylaşım · 524
Kamu Malları · 76, 77, 78, 191
Kamu Orta Malları Sicili · 513, 562
Kamuya Açıklık · 183
Kamuya Açıklık İlkesi · 133
Kanun Atfı · 68
Kararın Uygulanması · 351
Karışma · 424
Karine Etkisi · 216
Karine Olgusu · 362
Karine Sonucu · 363
Kat İrtifakı · 529
Kat Mülkiyeti · 512, 529, 532, 548
Kat Mülkiyeti Kütüğü · 512, 513, 556
Kat Mülkiyeti Yöneticileri · 493
Katılım İlişkisi · 223
Katılma (İltihak) İlkesi · 132
Katılma İlişkisi · 174
Kaybedilen Eşya · 221
Kaydın Herkesçe Bilindiği İlkesi · 142
Kaydın İçeriğinin Doğru Olduğuna Kanıt Oluşturması İlkesi · 142
Kayıt · 595
Kayıt (Tescil) Verilerinin İşlenmesi · 544
Kayıt İşleme İşlemleri · 545
Kayıt Örneğin · 533
Kayıt/Tespit Sistemi · 479
Kaynak Hakkı · 112, 113, 179
KAYSİS · 527
Kazandırma · 159, 161, 162

Kazandırma (İktisap) İşlemleri · 160
Kazandırma İlkesi (Sistemi) · 161
Kazandırma İşlemi · 159, 164
Kazanma Yolları · 238
Kendisi İçin Zilyet · 226, 228, 229, 241
Kısa Elden Teslim · 239, 246, 264, 265, 411
Kısa Elden Zilyetliğin Devri · 264
Kısıtlama · 527
Kısıtlayan veya Yasaklayan Şerh · 672
Kısmi Zilyetlik · 191, 229
Kimlik Paylaşımı Sistemi · 525
Kiracının Alacak Hakkı · 668
Kişi Görünüm İlkesi · 512
Kişici (Şahısçı) <erga omnes> Görüş · 91
Kişilik Dışılık · 58
Kişinin Bedeni · 58
Kişisel Hak · 198, 226, 284, 355, 413, 663
Kişisel Veri · 496, 521
Kişisel Verilerin Korunması · 522, 530, 541
Kişiye Bağlı Ayni Haklar · 128
Kişiye Bağlı İrtifak · 114, 128
Konşimento · 289
Korunmaya Değer Yarar · 547
Kovma · 312, 315, 319
Kovma Hakkı · 319
Kötüniyetli Haksız Zilyed · 459
Kötüniyetli Haksız Zilyet · 232, 420, 435, 460, 462, 464, 465, 468
Kötüniyetli Kazanım · 383
Kötüniyetli Zilyet · 307, 317, 396, 404, 436, 459, 468, 469
Kullanım Yararı · 465
Kullanma Yetkisi · 53, 56, 110, 112
Kuvvet Kullanarak Zilyetliği Geri Alma · 319
Kuvvet Kullanarak Zilyetliğin Korunması · 312
Kuvvet Kullanma · 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316
Kuvvet Kullanma Hakkı · 313
Külli Halef · 327, 335, 400
Kütük · 511, 512
KVK · 518

L

Longa Manu Traditio · 248, 250, 256, 260
Lüks Gider · 447, 451, 455

M

Maddi Mekânsal Fiili İlişki · 186, 188, 189, 190, 193, 195, 196, 200, 208, 209, 210, 213, 214, 217, 218, 224, 230, 233, 239, 241, 244, 247, 249, 250, 251, 252, 257, 259, 262, 265, 267, 274, 280, 297, 303, 304, 306, 311, 321, 331, 333, 350, 356, 358, 363, 371, 372, 378, 379, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 409, 411, 412, 448, 460, 476
Maddi Şey · 57, 64
Maddi Varlık · 64, 70, 76, 77
Maden Sicili · 137
Mahkeme Kararı ile Düzeltme · 685
Makbuz · 288, 289
Makbuz Senedi · 289
Makbuzun Cirosu · 290
Mal Ortaklığı · 227, 256
Mala Hakimiyet · 52
Malın Değişimi · 52
Malik Olma İradesi · 199, 220, 365
Malvarlığı · 52, 64, 67, 72, 73, 107, 108, 114, 121, 122, 158, 159, 161, 165
Mancipatio · 478
MEGSİS · 518
Mekansal Fiili (Maddi) İlişki · 195
Mekansal Fiili İlişki · 196
Mekansal Gayrimenkul Sistemi · 518
Menkul Davası Bkz. Taşınır Davası · 357, 376, 398
Meşru Müdafaa · 306, 311, 313, 318, 319
Miras · 204, 233, 238, 269, 322, 361, 402, 414, 418, 423, 428, 429, 436

Miras Yoluyla Zilyetliğin Kazanılması · 238
Mirasçıların Zilyetliği · 204
Misli Eşya · 86, 87, 290
Misli Olmayan Eşya · 86, 87, 88
Motorlu Araç · 206, 385
Mutlak Hak · 59, 70, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 108, 131, 132
Mutlak Tescil İlkesi · 143
Mutlaklık İlkesi · 95, 131
Muvazaa · 434
Mülkiyet · 495, 522, 548
Mülkiyet Hakkı · 47, 54, 55, 65, 98, 109, 115, 134, 150, 163, 172, 176, 177, 227, 229, 322, 362, 363, 364, 369, 402, 403, 418, 427, 439, 442, 462
Mülkiyet Karinesi · 359, 361, 362, 363, 364, 365, 407
Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydıyla Devir Sözleşmesi Sicili · 135
Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi · 228, 270
Mülkiyetin Devri · 243
Münhasır Zilyetlik · 232
Müşterek Mülkiyet · 548
Mütekabiliyet (Karşılıklılık) Şartı · 80

N

Nisbi Haklar · 664, 665
Nispi Etki · 94, 152, 157
Nispi Hak Görüşü · 192
Nispi Hak Karinesi · 367
Nispi Tescil İlkesi · 143, 144
Nispilik İlkesi · 102
Normatif Olgu · 94
Noter · 496, 665, 668
Numerus Clausus · 511
Nüfus Sicillerinin Aleniyeti · 525

O

Olağan Gider · 447
Olağan Kullanım · 460
Olağanüstü Zamanaşımı · 242
Olumlu (Maddi) Etkisi · 149
Olumlu Davranış · 302
Olumlu İrtifak · 93, 113
Olumsuz (Kurucu) Etkisi · 149
Olumsuz Davranış · 302
Olumsuz İrtifaklar · 93, 113, 199
Onay Komutu · 545
Onaylama · 545
Orantısız Kuvvet Kullanma · 315
Organın Zilyetliği · 211
Orman · 342
Ormanın Kadastrosu · 649
Oturma Hakkı · 112, 114, 115, 179, 202

Ö

Ölçüm Modelleri · 544
Ön Kontrol Aşaması · 541
Ön Mirasçı · 238
Önalım (Şufa) Hakkı · 665
Önalım Hakkı · 106, 361
Önceki Zilyedin Hak Karinesi · 360, 372
Önceki Zilyedin İradesi · 243
Önceki Zilyedin Rızası · 245, 261, 263
Önceki Zilyedin Üstün Hak Karinesi · 376
Öncelik İlkesi · 148
Örnek Edinme · 532
Örnek İşlemler · 546
Özel Hayatın Gizliliği · 522
Özel Malvarlığı · 73
Özenli Bir Yönetimin · 465

P

Para ve Hamile Yazılı Senetler · 393
Paraya Çevirme Yetkisi · 56, 119, 127
Parça Eşya · 87, 270
Paylı (Müşterek) Zilyetlik · 234
Paylı Zilyet · 233, 234, 235, 236, 310, 335, 382, 388, 410, 436
Probatio Daibolica · 356
Prossesorium · 321
Protez · 60

R

Re'sen Düzeltme · 684
Rehin · 183, 210, 218, 230, 243, 264, 270, 274, 275, 277, 283, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 308, 325, 361, 365, 369, 375, 378, 417, 444, 458
Rehin Hakkı · 49, 70, 99, 111, 119, 123, 124, 127, 135, 171, 172, 177, 178, 179
Rehinde Belirlilik İlkesi · 158
Rehinli Taşınır Sicili · 135
Rei Vindicatio Bkz. İstih-Kak Davası · 279
Resmi Belgeler · 560
Resmi Sicil · 520
Rıza Dışı Elden Çıkma · 248, 389, 390, 401

S

Sahiplenme · 242
Sahiplik İlkesi · 73
Sahipsiz · 220, 240, 242, 295, 342, 345
Sahipsiz Eşya · 90
Sahipsiz Taşınır Sahiplenme · 242
Saldırgan · 318
Saldırı · 184, 212, 220, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 324, 329, 331, 333, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 368, 369, 371
Sanal Zilyetlik · 204
Savunma Hakkı · 215, 299, 300, 307, 313, 314, 315, 316, 317
Savunma Yetkisi · 316, 318
Sayısallaştırma · 517
Sebebe Bağlılık · 170, 273
Sebebe Bağlılık İlkesi · 132, 145, 159, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 567
Sebep Anlaşması · 162
Sebep Fonksiyonu · 53
Sebep İşlemden Soyutluğu · 259
Sebepsiz Zenginleşme · 421
Sermaye Piyasası · 524
Sınırlı Açıklık İlkesi · 140
Sınırlı Aleniyet İlkesi · 519, 521, 547
Sınırlı Ayni Hak · 202, 222, 225, 227, 284, 285, 286, 356, 365, 368, 406, 412, 417, 418
Sınırlı Ayni Hak Karinesi · 367
Sınırlı Kamuya Açıklık · 492, 548
Sınırlı Sayı İlkesi · 98, 152
Sınırsız Aleniyet İlkesi · 520
Sınırsız Kamuya Açıklık · 548
Sicil Zilyetliği · 191
Sigorta Şirketi · 493, 548
Software · 490
Sorgulama · 532
Sorgulama Hakkı · 527
Sorgulanma · 496
Soruşturma · 346, 348
Soruşturmacı · 346
Sosyal Sigorta Kurumu · 548
Soyut Hukuki İşlem · 168
Söküp Alma Hakkı · 468
Sözleşme · 530
Sübjektif Ayni Hak · 100
Sübjektif Hak · 90
Sürekililik Teorisi · 214

Ş

Şahit · 348

Şerh · 369, 531, 533, 662, 664, 665, 669

T

Tabiat Varlıkları · 79

TAKBİS · 514, 515, 516, 517, 526, 527, 528, 529, 530, 532

TAKPAS · 527, 528, 530, 531, 533, 534

Taleplerin Yarışması · 422

Tanımlanabilirlik · 70

Tapu Envanter Defteri · 513, 564

Tapu Kaydı · 330

Tapu Kütüğü · 543, 544, 556

Tapu Planı · 559

Tapu Sicil Verilerine Erişim · 548

Tapu Sicili · 183, 185, 186, 190, 191, 368, 415, 473, 476

Tapu Sicili Sistemi · 488

Tapu Sicili Tüzüğü · 509, 516 519, 528, 541

Tapu Sicili Veri Bankası · 489

Tapu Siciline Güven İlkesi · 148

Tapu Siciline Kayıt İlkesi · 142

Tapu Sicilini İnceme · 524

Tapu Sicilinin Aleniyet Fonksiyonu · 537

Tapu Sicilinin Aleniyeti · 543

Tapu Sicilinin Düzeltilmesini · 172

Tapu Sicilinin Olumlu Etkisi · 138, 139, 149

Tapu Sicilinin Olumsuz Etkisi · 138, 143

Tapu Verilerine Erişim · 519

Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz · 641

Tapulama · 607

Tapusuz Taşınmaz · 370, 371, 379

Tapuya Güven (İtimat) İlkesi · 581

Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmaz · 320, 370, 379, 403

Tapuya Kayıtlı Taşınmaz · 369, 370, 428

Tarım Arazileri · 645

Tasarruf İşlemi · 136, 138, 145, 146, 151, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 173

Tasarruf İşlemleri · 160

Tasarruf Yetkisi · 53, 110, 122, 123, 136, 138, 145, 148, 165, 166, 169

Tasdik Sistemi · 486

Tasfiye İlişkisi · 173

Taşıma Senedi · 289

Taşıma Senedi Bkz. Konşimento · 289

Taşınır Davası · 215, 237, 322, 327, 334, 339, 359, 360, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 428, 447

Taşınır Eşya · 54, 78, 84, 161, 175, 379, 407, 427

Taşınır Mülkiyeti · 84, 110, 111, 146, 149, 161, 168, 170, 171

Taşınır Rehni · 122, 218, 219, 261, 264, 274, 282, 283, 286, 385, 417

Taşınmaz Eşya · 68, 78, 84, 85, 111

Taşınmaz Mülkiyeti · 55, 82, 83, 84, 98, 110, 143, 146, 147, 161, 167, 170, 176, 183, 216, 231

Taşınmaz Rehni · 84, 119, 123, 177, 369, 669

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi · 665

Taşınmaz Veri Bankası · 495

Taşınmaz Yöneticileri · 496

Taşınmaz Yükü · 106, 108, 111, 126, 127, 128, 143, 153, 157, 177

Taşınmaz Zilyedi · 307, 336

Taşınmazı İşgal · 242

Taşınmazlarda Karine Etkisi · 496

Taşınmazlarda Kurucu Etki · 496

Taşıyıcıya ya da Ardiyeciye veya Umumi Mağazaya Bırakılmış Olmalı · 288

Tecavüz · 213, 300, 303, 319, 333, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353

Teferruat · 72, 88, 158, 175

Tek Başına Zilyet · 228, 230, 232, 233, 363, 376

Temsil Evrakı · 289
Temsilci · 195, 201, 211, 212, 239, 246, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 270, 309, 317, 345, 347, 348, 384, 388, 409, 410, 414, 415
Temsilciye Teslim · 250
Tercihe Şayan Hak · 398
Tereke Malı · 89
Terkin · 197, 297, 473, 495, 516, 531, 533, 545, 660
Terraxis · 547
Tescil · 202, 342, 368, 369, 370, 394, 428, 436, 473, 511, 516, 528, 531, 533, 539, 541, 543, 545, 546, 653
Tescil İlkesi · 567
Tescil İşleme İşlemleri · 545
Tescili İlkesi · 143
Tescille Kazanım İlkesi · 143
Tescilsiz Kurucu Olgu · 144
Tesisen Kazanma · 238
Teslim (Tradio) · 478
Teslim İlkesi · 149, 150, 161
Teslim Platformu · 546
Teslim Şartlı Rehin · 274
Teslim ve Tescil İlkesi · 161
Teslime Bağlı Rehin · 123, 183, 458
Teslimsiz Devir · 185, 245, 260
Teslimsiz Kazanılma · 239, 255, 277
Teslimsiz Zilyetliğin Devri · 251, 257, 259, 412
Tetkik Usulü · 544, 545
Ticari İşlem · 394
Ticari İşletmelerde Taşınır Rehni Sicili · 135
Ticari Sır · 522
Tipe Bağlılık · 55, 94, 108, 152, 153, 154
Tipe Bağlılık İlkesi · 55, 132, 153, 511
Tipin Kapsamının Belirliliği · 55, 152, 154, 156
Tipin Kapsamının Belirliliği İlkesi · 155
Title Kayıt Sistemi · 485
Toprağın İyileştirilmesi · 679
Tutanağa İtiraz · 616
Tüketilebilen Eşya · 87, 88
Tüketilemez Eşya · 87

U

Uçak · 333, 413
Uçak Sicili · 137
Uluslararası Yersel Referans Koordinat Sistemi · 518
Umumî Mağaza · 287, 288, 289, 291, 292
Usulî Resmî Bir İşlem · 167
Uyuşma Sistemi · 482
Uzak Elden Teslim · 260, 261

Ü

Üreme Hücreleri · 60
Ürün · 443
Ürün Kirası · 107
Ürün Sözleşmesi · 107
Ürünler · 439, 441, 442, 443, 444, 452, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 466
Ürünlerin Mahsubu · 456
Üst Hakkı · 81, 105, 112, 113, 114, 115, 116, 127, 129, 156, 176, 342, 670

V

Varant · 288, 289
Varsayım · 204, 227, 406
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlileri · 496
Vekalet · 187, 207, 219, 255, 361, 395, 421, 460, 465, 468
Vekaletsiz İşgörenin Temsili · 255
Vergi Kayıtları · 615
Vergi Memurları · 548
Veri Bankaları · 495, 510, 522, 536, 540
Veri Bankası · 510
Veri Formatları · 546
Veri Giriş Formları · 517

Veri Girişi · 517
Veri Güvenliği · 510
Veri İşleme İşlemleri · 545
Veri Paylaşımı İlkeleri · 534
Veri Transferi/Nakli · 495
Verilere Erişim Hakkının Kötüye Kullanılması · 527
Verisi Paylaşımı · 528
Veriye Erişim · 531
Veriye Erişim (Sorgulama) Yetkisi Olanlar · 530
Vesayet Kararlarının Yazımı · 680

Y

Yan Zilyet · 225, 231, 233, 235, 241
Yararlanan (veya Hakim) Taşınmaz · 128
Yararlanan Taşınmaz · 55, 106, 117, 128
Yararlanma Hakları · 126
Yararlanma Yetkisi · 53, 56, 110, 112, 113, 114, 115, 118
Yararlı Gider · 438, 447, 449, 450, 451, 452, 455
Yardımcı Kütük · 513
Yardımcı Siciller · 512, 561
Yenileme Sebebi · 162
Yenileme Sebebi (Causa Novandi) · 162
Yenilik Doğuran Haklar · 666, 667
Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlar · 528
Yetki Normu · 538, 544
Yetkisiz Zilyet Temsilcisi · 255
Yevmiye Defteri · 509, 511, 512, 513, 535, 537, 539, 540, 541, 543, 545, 546, 548, 558
Yolsuz Tescil · 170, 172, 473
Yönetim ve Yararlanma Hakkı · 55
Yönetme Yetkisi · 56
Yükleme Görüşü · 109
Yüklü (veya Hadim) Taşınmaz · 128
Yüklü Taşınmaz · 55, 105, 105, 117, 118, 122, 128

Z

Zaman İtibarı İle Öncelik İlkesi · 132
Zaman İtibarı İle Öncelik İlkesi · 176, 177, 179, 180
Zamanaşımı · 183, 184, 185, 220, 229, 231, 237, 239, 242, 295, 340, 391, 392, 402, 404, 424, 436, 437, 438, 454
Zanaatkârlar veya Yüklenicilerin İşe Başlama Tarihi · 680
Zilyedin Rızası · 306
Zilyet Olma İradesi · 199, 220, 364, 365
Zilyet Temsilcisi · 251, 252, 253, 254
Zilyet Yardımcısı · 207, 211, 278, 307, 309, 310
Zilyetliğe Açık Durumdaki Eşyanın Devri · 246
Zilyetliğe Bağlanan Karine · 359
Zilyetliğe Katılım İradesi · 223
Zilyetliğe Saldırı · 301, 302, 303, 312, 318, 332, 334, 336
Zilyetliğe Yasak El Atma · 302
Zilyetliği İhlal · 301, 302, 304, 318, 322
Zilyetliğin Devri · 123, 146, 149, 161, 171, 243
Zilyetliğin Devri Anlaşması · 244
Zilyetliğin Gaspı · 303, 312, 313, 320, 323, 324, 325, 330, 428
Zilyetliğin Havalesi · 239, 245, 246, 256, 257, 260, 266, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 293, 297, 411
Zilyetliğin Havalesi Sözleşmesi · 279
Zilyetliğin İdari Yönden Korunması · 341
Zilyetliğin Kaybedilmesi · 293
Zilyetliğin Kaybı · 298, 328, 395
Zilyetliğin Kazanılması · 200, 237, 238, 239, 259, 294, 297, 435
Zilyetliğin Rıza Dışı Çıkmış Olması · 388
Zilyetliğin Teslimle Devrinde Anlaşma · 248
Zilyetliğine Tecavüz · 343
Zilyetlik · 54, 84, 101, 107, 111, 123, 125, 133, 134, 139, 149, 150, 165, 170

Zilyetlik Anlaşması · 200, 235, 244, 245, 247, 251, 252, 264, 272, 391

Zilyetlik Davaları · 307, 311, 312, 315, 318, 320, 322, 323, 329

Zilyetlik Karinesi · 359, 427

Zilyetlik Kavramının İzafiliği · 188

Zilyetlik Olgusu · 371

Zilyetlik Sözleşmesi · 237, 239, 245, 250, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 271, 272, 276, 279, 294, 297, 408

Zorunlu Gider · 448, 449, 450, 452, 459, 463, 468

Zorunluluk Hali · 197, 306

Zorunluluk İlkesi · 73